OBJECTIF
BARREAU

CRFPA 2026

LIBERTÉS PUBLIQUES ET DROITS FONDAMENTAUX

SOMMAIRE

PARTIE I – ÉLÉMENTS INTRODUCTIFS 4
FICHE N°1 - LES NOTIONS 5
Fiche nº 2 - LES ORIGINES PHILOSOPHIQUES ET RELIGIEUSES 17
Fiche nº 3 - LES ORIGINES TEXTUELLES 28
Fiche nº 4 - LES CLASSIFICATIONS 37
Fiche nº 5 - LES PRINCIPES DIRECTEURS 46
Fiche nº 6 - LES RÉGIMES 56
Fiche nº 7 - LIMITATIONS ET ÉTATS D'EXCEPTION 63
Fiche nº 8 - LA CRISE DES DROITS HUMAINS ET L'ÉTAT DE DROIT 74
PARTIE II. LES SOURCES INTERNES 82
Fiche nº 9 - LES SOURCES CONSTITUTIONNELLES 83
Fiche nº 10 - LE BLOC DE LÉGALITÉ 94
Fiche nº 11- LE RÈGLEMENT ET LES LIBERTÉS 104
PARTIE III. LES SOURCES EXTERNES 115
Fiche nº 12 - L'INTERNATIONALISATION DU DROIT DES LIBERTÉS 116
Fiche nº 13 - LE DROIT ONUSIEN 125
Fiche nº 14 - LE CONSEIL DE L'EUROPE ET LA CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME 133
Fiche nº 15 - LE DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE 144
PARTIE IV. LES MÉCANISMES INTERNES DE PROTECTION 153
Fiche nº 16 - LA PROTECTION PAR LE JUGE CONSTITUTIONNEL 154
Fiche nº 17 – LA PROTECTION PAR LE JUGE JUDICIAIRE 164
Fiche nº 18 – LA PROTECTION PAR LE JUGE ADMINISTRATIF 177
Fiche nº 19 - LES DÉROGATIONS AU PRINCIPE DE SÉPARATION DES AUTORITÉS 188
Fiche nº 20 - LA PROTECTION ADMINISTRATIVE 197
PARTIE V. LES MÉCANISMES INTERNATIONAUX ET EUROPÉENS DE PROTECTION 208
Fiche nº 21 - LES COMITÉS ONUSIENS 209
Fiche nº 22 – LA COUR EUROPÉNNE DES DROITS DE L'HOMME 217
Fiche nº 23 - LA COUR DE JUSTICE DE L'UNION EUROPÉENNE 227
Fiche nº 24 - LES AUTRES JURIDICTIONS RÉGIONALES 237
Fiche nº 25 - LA PROTECTION POLITIQUE ET ADMINISTRATIVE INTERNATIONALE 245
PARTIE VI. LES DROITS CIVILS ET POLITIQUES 254
Fiche nº 26 - LE DROIT À LA VIE 256
Fiche nº 27 – LE DROIT À L'INTÉGRITÉ DE LA PERSONNE 267

Fiche nº 28 - L'INTERDICTION DE LA TORTURE ET DES PEINES OU TRAITEMENTS INHUMAINS OU DÉGRADANTS 279
Fiche nº 29 – L'INTERDICTION DE L'ESCLAVAGE, DE LA TRAITE, DE LA SERVITUDE ET DU TRAVAIL FORCÉ 288
Fiche nº 30 - LE DROIT À LA LIBERTÉ ET À LA SÛRETÉ 298
Fiche nº 31 - LE DROIT À UN PROCÈS ÉQUITABLE ET LE DROIT À UN RECOURS EFFECTIF 308
Fiche nº 32 - LES GARANTIES FONDAMENTALES EN DROIT PÉNAL 321
Fiche nº 33 - LE DROIT À LA VIE PRIVÉE 331
Fiche nº 34 - LE DROIT À LA VIE FAMILIALE 343
Fiche nº 35 - LE DROIT À LA PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL 355
Fiche nº 36 - LA LIBERTÉ DE PENSER, DE CONSCIENCE ET DE RELIGION 369
Fiche nº 37 - LA LIBERTÉ D'EXPRESSION 381
Fiche nº 38 - LA LIBERTÉ DE RÉUNION ET DE MANIFESTATION PACIFIQUE 395
Fiche nº 39 - LA LIBERTÉ D'ASSOCIATION 404
Fiche nº 40 - LA LIBERTÉ D'ALLER ET VENIR 416
Fiche nº 41 - LA LIBERTÉ D'ENSEIGNEMENT 428
Fiche nº 42 - LE DROIT À DES ÉLECTIONS LIBRES 436
Fiche nº 43 - LES PROTECTIONS FONDAMENTALES EN CAS D'ÉLOIGNEMENT, D'EXPULSION ET D'EXTRADITION 445
Fiche nº 44 - LE DROIT DES PEUPLES À DISPOSER D'EUX-MÊMES 456
PARTIE VII. LES DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS 467
Fiche nº 45 - LA LIBERTÉ DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE 468
Fiche nº 46 – LE DROIT DE PROPRIÉTÉ 475
Fiche nº 47 - LE DROIT À L'ÉDUCATION ET À LA FORMATION 481
Fiche nº 48 - LE DROIT À LA SANTÉ ET À LA PROTECTION SOCIALE 490
Fiche nº 49 - LE DROIT À UN ENVIRONNEMENT SAIN 500
Fiche nº 50 - LE DROIT AU TRAVAIL 509
Fiche nº 51 - LE DROIT AU LOGEMENT 518
Fiche nº 52 - LE DROIT À LA CULTURE 526
Fiche nº 53 - LE DROIT D'ASILE 536
PARTIE VIII. L'ÉGALITÉ ET LA NON-DISCRIMINATION 546
Fiche nº 54 - L'INTERDICTION DE LA DISCRIMINATION 547
Fiche nº 55- LA PRISE EN COMPTE DES VULNÉRABILITÉS 559
Fiche nº 56 - LES MESURES D'INÉGALITÉ COMPENSATOIRE 571
TABLES DES MATIÈRES 581

PARTIE I – ÉLÉMENTS INTRODUCTIFS

Fiche n°1

Les notions

Fiche n°2

Les origines philosophiques et religieuses

Fiche n°3

Les origines textuelles

Fiche n°4

Les classifications

Fiche n°5

Les principes directeurs

Fiche n°6

Les régimes

Fiche n°7

Limitations et états d'exception

Fiche n°8

La crise des droits humains et l'état de droit

FICHE N°1 - LES NOTIONS

POINTS CLÉS

- *Des notions imprécises et une terminologie variée à l'origine du droit des libertés.*
- *Des libertés publiques définies dans la Constitution et le droit international.*
- *Consécration dans des instruments nationaux, régionaux et internationaux.*
- *Rôle du législateur et des juges administratif et judiciaire dans le droit des libertés.*
- *Les évolutions attachées aux droits et libertés fondamentaux.*
- *La question du titulaire des droits et libertés : la personne humaine.*
- *L'obsolescence et l'insuffisance de l'expression « droits de l'homme ».*
- *L'approche dynamique des droits humains pour une universalité effective.*

PRINCIPALES RÉFÉRENCES

- *Cons. const., déc. n° 71-44 DC, 16 juillet 1971.*
- *Loi constitutionnelle n° 74-904 du 29 octobre 1974.*
- *Cons. const., déc. n° 74-54 DC, 15 janvier 1975.*
- *CE, Assemblée, 30 octobre 1998, Sarran et Levacher.*
- *Cour de cassation, Assemblée plénière, 2 juin 2000.*
- *Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008.*
- *Cons. const., décision n° 2017-750 DC, 23 mars 2017.*

1.
Prolégomènes historiques

Quoique peu enclin aux spéculations abstraites de la scolastique, le juriste praticien n'ignore pas que les droits et libertés, attributs essentiels de la personne, procèdent d'une tradition philosophique pluriséculaire et se déploient au gré des inflexions du langage.

Sans ambition d'en dresser la généalogie exhaustive, il importe de reconnaître que le système juridique contemporain repose sur le paradigme des droits et libertés, dont la richesse des formulations – droits de l'homme, droits et libertés fondamentaux, libertés publiques, droits humains… – témoigne moins d'une confusion conceptuelle que de l'évolution d'un champ en permanente reconfiguration.

La pluralité des usages des notions rend illusoire toute tentative d'en cerner les contours par un simple inventaire de leurs occurrences dans les textes de droit positif ou dans les jurisprudences. Toute définition suppose en effet des choix préalables :

- L'approche formelle consiste à délimiter la catégorie des droits et libertés en se référant aux textes à valeur supra-législative qui les consacrent – Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, Préambule de la Constitution de 1946, Constitution de 1958, Charte de l'environnement, ainsi que les instruments internationaux ratifiés par la France, comme la Convention européenne des droits de l'homme, les deux Pactes des Nations unies du 16 décembre 1966, ou la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

- L'approche substantielle vise à dépasser les limites de la démarche formelle en considérant que certains droits peuvent être qualifiés de fondamentaux indépendamment de leur ancrage dans un texte de portée supérieure. Elle repose sur une hiérarchisation des droits et libertés selon un ordre de valeurs, qui transcende la stricte hiérarchie des normes.

1.1. Les notions de liberté et de dignité au fondement des droits de la personne humaine : la subjectivisation des rapports juridiques

La liberté, notion ayant donné lieu à des emplois abusifs, ne saurait se définir comme l'absence totale de contraintes, une telle conception étant inconciliable avec la vie en société. Elle désigne plutôt l'absence de contraintes jugées illégitimes, anormales ou immorales (A. Lalande, *Vocabulaire technique et critique de la philosophie*).

L'adjectif « publique » n'oppose pas ces libertés aux libertés privées, mais désigne la source de la contrainte susceptible de s'exercer sur l'individu. Cette approche permet de définir le cadre conceptuel dans lequel s'inscrivent leurs possibles restrictions.

La notion de dignité est également un concept fondateur des droits et libertés attachés à la personne humaine. Pour René Cassin, l'objet de « la science des droits de l'homme » est *« d'étudier les rapports entre les hommes en fonction de la dignité humaine, en déterminant les droits et les facultés dont l'ensemble est nécessaire à l'épanouissement de la personnalité de chaque être humain »* (R. Cassin, *Science des droits de l'homme : méthodologie et enseignement*).

Dès lors, ce n'est pas l'autorité de l'État, mais bien la dignité de la personne humaine qui constitue, avant tout, le socle indéfectible des droits fondamentaux.

Les notions conceptuellement mouvantes de liberté et de dignité, qui ont contribué à l'essor de l'individualisme moderne, se traduisent plus concrètement, depuis une cinquantaine d'années, par un mouvement de subjectivisation des rapports juridiques.

Cette évolution du langage juridique reflète une transformation profonde de la conception du droit : celui-ci tend désormais à être envisagé comme un système d'allocation de droits subjectifs aux individus, plutôt qu'à travers le prisme d'un droit objectif, structurant les situations juridiques selon des statuts et des institutions – approche qui prévalait dans la tradition classique.

Notion essentielle. – Pourquoi la dignité constitue-t-elle un principe matriciel, fondateur des droits et libertés ?

La dignité est qualifiée de principe matriciel en ce qu'elle ne protège pas seulement une prérogative déterminée, mais constitue le soubassement à partir duquel peuvent être rattachés ou dégagés différents droits fondamentaux. Un principe matriciel est ainsi un principe majeur dont découlent d'autres droits ou principes qui en constituent les prolongements. La dignité vise fondamentalement à empêcher la réification de la personne humaine, c'est-à-dire son traitement comme un objet ou un simple moyen, plutôt que comme un sujet de droit. Elle présente en outre un caractère objectif et inconditionné : attachée à la seule qualité d'être humain, elle peut protéger l'individu indépendamment de son propre consentement. Cette conception explique que la dignité puisse exceptionnellement justifier une restriction apportée à l'exercice d'une liberté.

Cette fonction apparaît particulièrement en droit administratif. Depuis le célèbre arrêt *Commune de Morsang-sur-Orge*, le respect de la dignité de la personne humaine constitue une composante de l'ordre public, permettant à l'autorité de police d'interdire une activité portant, par son objet même, atteinte à la dignité, même en l'absence de circonstances locales particulières et malgré le consentement de la personne concernée. Dans cette affaire, la réification résultait précisément de l'utilisation d'une personne comme un « projectile ». La dignité présente donc une singularité essentielle : elle constitue à la fois le fondement de droits attachés à la personne et, dans certaines circonstances, un fondement de leur limitation, sous le contrôle du juge et dans le respect du principe de proportionnalité (CE, Ass., 27 octobre 1995, *Commune de Morsang-sur-Orge*, n° 136727).

POUR ALLER PLUS LOIN

Les notions de droits et libertés soulèvent inévitablement la question du titulaire. Elles renvoient à la personne, entendue dans son acception juridique et dans sa dimension humaine. En droit, la personne est avant tout une entité dotée de la personnalité juridique, ayant la capacité à être titulaire de droits et d'obligations. Cette qualité n'est pas réservée aux seuls individus : elle s'étend à des entités telles que les sociétés ou les associations. Toutefois, la notion de personne humaine demeure centrale dans l'appréhension des droits et libertés fondamentaux. Bien que leur reconnaissance soit intrinsèquement liée à la qualité d'être humain, il convient de ne pas sous-estimer le rôle de la personnalité juridique, certains droits – comme celui d'ester en justice – en dépendant directement. Récemment, le débat s'est élargi à la question de la « personne non humaine ». Sensibles à l'argument, éthique et scientifique, de la proximité génétique des animaux humains et non humains, une partie de la doctrine mobilise cette notion pour promouvoir la reconnaissance de droits fondamentaux à des espèces non humaines, notamment les grands singes. Il s'agirait de leur garantir des droits tels que le droit à la vie ou la protection contre la torture. Dans cette perspective, la reconnaissance d'un statut de personne non humaine pourrait, à terme, fonder l'attribution de certains droits fondamentaux aux animaux. Cette évolution conceptuelle connaît déjà des traductions concrètes dans plusieurs pays, comme l'Inde ou l'Argentine, où les juridictions ont reconnu des droits à des dauphins ou à des orangs-outans, sur la base de cette approche.

1.2. L'École moderne du droit naturel et les doctrines du contrat social à l'origine de la conception moderne des droits de l'homme

La vision contemporaine des droits et libertés s'inscrit dans l'héritage d'un certain nombre de constructions philosophiques de l'Occident, qu'il est utile d'évoquer succinctement.

1.2.1. Le Jusnaturalisme

À la différence du droit naturel classique, enraciné dans la nature des choses selon la tradition antique et médiévale d'Aristote et de Thomas d'Aquin, les théoriciens modernes du droit naturel, tels que Grotius et Pufendorf, fondent le droit sur la nature propre de l'homme.

Rompant avec l'idée aristotélo-thomiste d'une société naturelle, les modernes conçoivent la fiction – inconcevable pour la pensée classique – d'un état de nature dans lequel l'individu jouit d'une liberté affranchie de toute contrainte sociale. La société politique naît lorsque les individus décident de quitter l'état de nature.

Cette conception ne relève toutefois pas seulement d'une construction théorique. Elle trouve aujourd'hui des assises textuelles dans le droit positif, notamment dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Son article 2 affirme ainsi que *« le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'Homme* » et identifie parmi eux « *la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression* ». Cette filiation jusnaturaliste demeure également perceptible dans le Préambule de la Constitution de 1946, dès son premier alinéa, selon lequel « *tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède <u>des droits inaliénables et sacrés</u>* ». La référence à un droit attaché à l'homme indépendamment de l'intervention de l'État conserve ainsi une traduction explicite au sein du bloc de constitutionnalité.

POUR ALLER PLUS LOIN

Certains historiens du droit, à l'instar de Michel Villey, n'ont pas hésité à critiquer la notion de droits subjectifs, perçue comme une invention moderne. L'idée selon laquelle l'individu pourrait revendiquer des droits en vertu de sa seule appartenance à l'humanité incarnerait, selon eux, une forme d'individualisme ayant contribué à la perte du sens véritable du droit, entendu comme ordre objectif. Cette dérive trouverait, selon ces auteurs, ses racines dans le nominalisme médiéval – notamment celui de Guillaume d'Occam, en rupture avec l'aristotélisme de Thomas d'Aquin – et, surtout, dans la pensée des jusnaturalistes modernes, qui ont fait émerger une figure nouvelle : celle du sujet de droit, détenteur de droits individuels fondés sur une nature humaine universelle. Ce que la modernité aurait sacrifié c'est la conception classique d'un droit envisagé comme une réalité extérieure ordonnant les rapports entre les personnes et les choses.

1.2.2. Le Contrat social

Les théories du contrat social cherchent à résoudre la tension entre l'autorité nécessaire de l'État et la préservation des libertés originelles, héritées de l'état de nature. Les institutions y sont conçues comme des créations artificielles, à l'instar du Léviathan de Hobbes, fruit d'un pacte fondateur.

Les réponses des théoriciens du contrat social divergent quant aux modalités du transfert des libertés au souverain : chez Locke, les individus ne cèdent qu'une partie de leur liberté, les droits naturels, antérieurs à l'État, peuvent dès lors lui être opposés. Rousseau, au contraire, postule un abandon total des libertés à la volonté générale, mais celle-ci, toujours orientée vers le bien de tous (l'intérêt général), garantit aux citoyens la conservation effective de leur liberté.

Ces deux conceptions se traduisent dans les traditions juridiques modernes : la pensée de Locke irrigue la vision américaine des *human rights*, tandis que l'influence de Rousseau se retrouve dans la conception française des droits de l'homme.

1.3. Les enjeux juridiques de l'invisibilisation linguistique des femmes

L'expression « droits de l'homme » illustre une conception du droit imprégnée d'un héritage patriarcal. Ces droits revêtent un caractère sexiste, tant par leur terminologie que par leur contenu, puisqu'ils ont été faits par des hommes pour des hommes (M.-L. Basilien-Gainche, Y. Lécuyer, *Les droits humains : pour un principe d'universalité*).

L'homonymie entre « homme », en tant que genre, et « homme », en tant que catégorie générique des êtres humains, reflète une convergence entre l'évolution de la langue et celle du droit, tous deux élaborés dans un contexte où les instances de pouvoir étaient sous hégémonie masculine.

Ce croisement entre langage et normativité traduit une vision du monde structurée selon une rationalité patriarcale, dont les effets continuent de se faire sentir de nos jours. L'usage d'une majuscule à « Homme » pour en neutraliser la connotation genrée, est une tentative grammaticalement contestable et symboliquement arbitraire, en plus d'être inaudible à l'oral. À l'inverse, l'expression « droits humains » offrent une formulation claire et inclusive. C'est la voie préconisée à ceux qui sont soucieux de promouvoir un langage juridique non sexiste.

2. La fondamentalisation des droits et libertés : l'importance croissante des sources supra-législatives

Parallèlement au mouvement de subjectivisation précédemment mentionné, le droit connaît depuis plusieurs décennies un phénomène de fondamentalisation, révélant l'affirmation croissante des normes supra-législatives, qu'elles soient d'ordre constitutionnel ou conventionnel. Un nouveau modèle d'élaboration et de mise en œuvre du droit émerge, porté par la valorisation croissante des libertés et des droits fondamentaux.

2.2. Les sources constitutionnelles

En 1971, pour la première fois, une loi est empêchée de promulgation en raison de l'atteinte portée à une liberté reconnue par la Constitution – en l'occurrence, la liberté d'association. La révision constitutionnelle de 1974, en permettant à l'opposition parlementaire de saisir le Conseil constitutionnel, a considérablement enrichi sa jurisprudence.

→ Cons. const., déc. n° 71-44 DC, 16 juillet 1971, *Liberté d'association.*

→ Révision constitutionnelle du 29 octobre 1974.

En instituant la question prioritaire de constitutionnalité, la révision de 2008 a, quant à elle, ouvert la voie à une remise en cause des lois promulguées en subordonnant l'accès à la QPC à l'existence d'une atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit.

→ Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions.

→ Art. 61-1 de la Constitution.

Notion essentielle. – Pourquoi la décision Liberté d'association est-elle fondamentale pour la protection des droits et libertés ?

À l'origine, le Conseil constitutionnel n'a pas été conçu comme un juge des libertés. Institué en 1958 dans le cadre de la rationalisation du parlementarisme, il devait avant tout veiller au respect de la répartition des compétences entre le Parlement et le pouvoir réglementaire (art. 34 et 38 C., 1858). C'est d'ailleurs pour cela que Michel Debré le qualifiant de « *chien de garde de l'exécutif* ». Son contrôle demeurait en outre limité : il intervenait avant la promulgation de la loi et ne pouvait être saisi que par le Président de la République, le Premier ministre et les présidents des deux assemblées. Surtout, le corps même de la Constitution de 1958 contient relativement peu de dispositions consacrant directement des droits et libertés.

La décision *Liberté d'association* constitue un changement majeur (Cons. const., déc. n° 71-44 DC, 16 juillet 1971, Liberté d'association) faisant évoluer la nature même du Conseil constitutionnel d'un organe politique en véritable organe juridictionnel. Saisi d'une loi qui entendait soumettre certaines associations à un contrôle préalable, le Conseil constitutionnel reconnaît la liberté d'association comme un principe fondamental reconnu par les lois de la République (PFRLR) et censure, pour la première fois, une disposition législative en raison de l'atteinte qu'elle porte à une liberté garantie par le Préambule de la Constitution.

La portée de cette décision dépasse largement la seule liberté d'association. En visant la Constitution « *et notamment son Préambule* », le Conseil donne pleine portée constitutionnelle au renvoi opéré par le Préambule de 1958 vers la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et vers le Préambule de la Constitution de 1946. Il ouvre ainsi une véritable « chaîne de juridicité », à partir de laquelle se constitue ce que la doctrine désignera comme le bloc de constitutionnalité. La Déclaration de 1789 sera ensuite expressément mobilisée comme norme de contrôle dans la décision *Taxation d'office* (Cons. const., déc. n° 73-51 DC, 27 décembre 1973). Le Conseil dispose dès lors d'un ensemble beaucoup plus vaste de normes lui permettant de contrôler la loi au regard des droits et libertés constitutionnels.

La décision de 1971 révèle également l'importance des PFRLR. Ceux-ci sont mentionnés par le Préambule de 1946 sans y être énumérés. Il appartient donc au Conseil constitutionnel d'identifier, à partir de la tradition législative républicaine, certains principes auxquels il reconnaît une valeur constitutionnelle. La liberté d'association constitue le premier exemple emblématique de cette technique, qui permettra ensuite la reconnaissance d'autres principes constitutionnels.

Deux réformes ont achevé cette transformation.

D'une part, la révision constitutionnelle du 29 octobre 1974 a ouvert la saisine du Conseil constitutionnel à soixante députés ou soixante sénateurs. L'opposition parlementaire peut ainsi provoquer le contrôle d'une loi avant sa promulgation, ce qui a considérablement développé le contentieux constitutionnel des libertés.

La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 a franchi une nouvelle étape avec la création de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC). Depuis l'entrée en vigueur de l'article 61-1 de la Constitution, un justiciable peut, à l'occasion d'un litige, soutenir qu'une disposition législative déjà en vigueur porte atteinte « aux droits et libertés que la Constitution garantit ». Le contrôle de constitutionnalité n'est donc plus seulement préventif et

réservé aux autorités politiques : il devient également un instrument de protection des droits susceptible d'être mobilisé à l'occasion d'un procès.

À retenir : 1971 transforme les normes de référence du contrôle en faisant pleinement entrer les droits et libertés dans le contrôle de constitutionnalité ; 1974 élargit les autorités pouvant déclencher ce contrôle ; 2008 permet, enfin, au justiciable d'être à l'origine de la contestation d'une loi déjà promulguée. C'est cette triple évolution qui explique le passage du Conseil constitutionnel, initialement conçu comme un organe de régulation des pouvoirs publics, à un véritable juge constitutionnel des droits et libertés.

2.1. La fascination de la doctrine française pour le modèle allemand

En France, les libertés publiques regroupent à la fois celles énoncées par la Constitution et celles garanties par le droit international, sans oublier les libertés définies par le législateur national, le juge administratif et le juge judiciaire, qui en assurent la protection quotidienne.

Si les expressions « droits de l'homme » et « libertés publiques » sont courantes, elles ne sont pas exclusives. L'usage croissant de la notion de « libertés fondamentales » traduit l'influence grandissante de la jurisprudence constitutionnelle dans la définition des libertés.

Grâce au développement du contrôle de constitutionnalité, complété par celui de conventionnalité, la France offre désormais, à l'instar de ses voisins européens, une protection effective des libertés qualifiées de « fondamentales » – une terminologie empruntée à la Loi fondamentale allemande, reprise par la doctrine française.

Cette transposition reste toutefois sujette à débat, dans la mesure où la France ne reconnaît pas à ses libertés un statut juridique équivalent à celui des droits consacrés aux articles 1 à 19 de la constitution allemande.

2.1.1. La construction incertaine du droit positif français

Les notions de « libertés et de droits fondamentaux » relèvent du droit positif, mais leur développement se fait toutefois selon des modalités pour le moins désordonnées.

Bien qu'elles soient désormais consacrées par de nombreux textes législatifs et codifiés – notamment le Code civil –, elles n'ont pas encore reçu la consécration constitutionnelle qui distingue les « droits de l'homme » (Déclaration de 1789) et les « libertés publiques » (art. 34 de la Constitution).

→ Art. 415 du Code civil.

En outre, les juridictions françaises adoptent à leur égard des approches variées, aboutissant à une jurisprudence éclatée. En pratique, les contours de cette catégorie dépendent des fonctions que le droit positif leur attribue.

Dans certains cas, elles servent d'appui argumentatif dans le raisonnement judiciaire, au risque d'un usage approximatif. Dans d'autres, elles participent à la détermination du champ d'application d'un régime juridique ou d'une voie juridictionnelle, et sont alors maniées avec davantage de rigueur par les juges.

2.1.2. Les droits fondamentaux sous l'angle de l'Union européenne

Devenue juridiquement contraignante avec l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, la Charte des droits fondamentaux s'inscrit dans la volonté de l'Union européenne de garantir le respect de ces droits qui font partie du droit de l'Union en tant que principes généraux. Ce texte unificateur regroupe diverses sources, telles que la Convention européenne des droits de l'homme ou la Charte sociale européenne.

→ Art. 6 du traité sur l'Union européenne.

La Charte s'applique non seulement aux institutions, mais aussi aux États membres lorsqu'ils appliquent le droit de l'Union, dans le respect du principe de subsidiarité. Si l'expression « droits fondamentaux » s'est imposée dans la jurisprudence de la Cour de justice, il reste que pour le juge européen, l'expression « libertés fondamentales » conserve un sens distinct, renvoyant aux quatre libertés de circulation qui constituent les fondements du marché intérieur : celles des marchandises, des services, des capitaux et des personnes.

Notion essentielle. – Quelle est la place de la Charte des droits fondamentaux dans la protection européenne des droits ?

La Charte des droits fondamentaux constitue aujourd'hui le principal instrument de protection des droits fondamentaux propre à l'Union européenne. Elle rassemble dans un même instrument des droits civils, politiques, économiques et sociaux auparavant issus de sources dispersées.

Son champ d'application demeure toutefois limité. En vertu de l'article 51 de la Charte, celle-ci s'impose aux institutions, organes et organismes de l'Union ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. Elle ne constitue donc pas un catalogue général de droits fondamentaux applicable à toute situation relevant du droit interne.

La Charte entretient néanmoins des rapports étroits avec la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (CESDH). Le §3 de l'article 52 prévoit que lorsqu'un droit garanti par la Charte correspond à un droit protégé par la Convention, son sens et sa portée sont les mêmes que ceux que lui confère la CESDH, sans empêcher le droit de l'Union d'assurer une protection plus étendue. La Convention constitue ainsi un standard essentiel d'interprétation des droits fondamentaux de l'Union. Cette articulation favorise un véritable dialogue des juges entre la Cour de justice de l'Union européenne et la Cour européenne des droits de l'homme, même si les deux systèmes juridiques demeurent autonomes.

Cette articulation ne signifie toutefois pas qu'un État membre puisse toujours appliquer son propre standard constitutionnel lorsqu'il offre une protection plus élevée. Dans l'arrêt *Melloni*, la Cour de justice de l'UE a jugé que l'article 53 de la Charte ne permet pas à un État membre d'écarter une règle du droit de l'Union pleinement conforme à la Charte au seul motif que sa Constitution nationale offrirait une protection supérieure. Une telle possibilité compromettrait la primauté, l'unité et l'effectivité du droit de l'Union. Les standards constitutionnels nationaux peuvent donc être mobilisés lorsque le droit de l'Union laisse une marge d'appréciation aux États, mais ils ne peuvent remettre en cause le niveau de protection fixé de manière uniforme par le droit de l'Union (CJUE, Gde ch., 26 février 2013, *Melloni*, C-399/11).

À retenir : la Charte constitue une source autonome de protection des droits fondamentaux dans l'ordre juridique de l'Union, mais elle s'inscrit dans un système à plusieurs niveaux. La CEDH constitue un standard d'interprétation important, les constitutions nationales peuvent compléter la protection lorsqu'une marge nationale subsiste, tandis que la Cour de justice garantit que cette pluralité des sources ne porte pas atteinte à la primauté et à l'unité du droit de l'Union.

2.3. Les sources conventionnelles

En France, la Constitution n'est pas l'unique fondement des droits humains, comme en témoignent les nombreux traités internationaux ratifiés ainsi que l'européanisation progressive du droit national. La question de la source – qu'elle soit constitutionnelle ou conventionnelle – revêt une importance juridique certaine, dans la mesure où l'origine de la norme qui fonde une liberté conditionne son invocabilité devant le juge.

Ainsi, le Conseil constitutionnel s'est abstenu de contrôler la conformité de la loi avec le droit à la vie consacré à l'article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, estimant qu'il ne lui appartenait pas de contrôler une loi au regard d'une convention internationale.

→ Cons. const., déc. n° 74-54 DC, 5 janvier 1975, *Loi relative à l'interruption volontaire de grossesse.*

De la même manière, le Conseil d'État et la Cour de cassation ont refusé de contrôler la compatibilité d'une norme de valeur constitutionnelle avec une norme internationale.

→ CE, ass., 30 octobre 1998, *Sarran et Levacher*, n° 200286 200287.

→ Cass. ass. plén., 2 juin 2000, *Fraisse*, n° 99-60.274.

3. Les débats contemporains autour de la notion de droits humains

Les droits humains, loin d'être une notion figée, se transforment au rythme des mutations sociales, politiques, éthiques et technologiques.

De nombreux axes cristallisent les enjeux de cette évolution : l'adoption du terme « droits humains », plus inclusif que « droits de l'homme », reflète une sensibilité accrue aux spécificités et à la diversité des situations humaines.

Le débat sur l'extension des droits à des entités non humaines, qu'il s'agisse des animaux ou des systèmes d'intelligence artificielle, interroge les frontières traditionnelles de la subjectivité juridique. En outre, la révolution numérique impose de nouvelles protections, notamment à travers la réflexion contemporaine sur les *neurodroits*, à l'intersection de la liberté individuelle et des nouvelles technologies.

3.1. Glissements terminologiques et évolution sémantique : vers une universalité inclusive

Les expressions « droits humains » ou « droits de l'humain » contribuent à remettre en question les déterminismes porteurs de discriminations, notamment à l'égard des femmes et des personnes marginalisées. Le choix des mots n'est jamais neutre.

Préférer l'expression « droits humains » à celle de « droits de l'homme », c'est affirmer la nécessité d'une approche des droits orientée vers l'effectivité, attentive aux besoins spécifiques et aux vulnérabilités, et ouverte à l'enrichissement progressif d'un héritage en constante évolution.

Le principe d'universalité ne doit pas se limiter à affirmer un champ des droits à l'échelle de l'humanité tout entière, mais inviter à repenser leur champ à partir de leur indivisibilité, en dépassant la distinction entre droits civils et politiques dits de première génération, et droits économiques, sociaux et culturels dits de deuxième génération.

L'enjeu est de souligner que l'effectivité des droits fondamentaux suppose à la fois la prise en compte des vulnérabilités propres à chaque individu, et la défense d'une solidarité réelle, face à une conception strictement individualiste du sujet de droit.

POUR ALLER PLUS LOIN

Parmi les menaces que l'intelligence artificielle fait peser sur les libertés individuelles, la reconnaissance faciale et les systèmes prédictifs déployés dans la justice et la police comptent parmi les plus préoccupantes. Le règlement européen sur l'IA vise à encadrer ces technologies jugées à haut risque au regard des droits fondamentaux. Par ailleurs, et sur un tout autre plan, l'IA bouleverse en profondeur les notions de liberté, de dignité et de responsabilité humaines, constitutives du socle des droits fondamentaux. L'ère algorithmique substitue le déterminisme à la liberté comme horizon d'existence pour l'individu du XXIe siècle, refermant la parenthèse historique de l'individualisme. Ce glissement bouleverse notre civilisation : comment maintenir un droit fondé sur la responsabilité, si l'individu est partiellement piloté par les algorithmes ? Une société d'humains assistés ou dirigés par l'intelligence artificielle appelle une refonte de nos cadres éthiques et juridiques. En effet, le libre arbitre, jadis ancré dans le religieux puis dans le politique, cède progressivement la place à une vision techniciste où l'être humain est déterminé par nature et programmable par la machine. (proposition : où l'être humain, déterminé par nature, devient programmable par la machine.) Le déterminisme spinoziste l'emporte sur l'autonomie kantienne (M. Bertolucci, L'homme diminué par l'IA).

Le transhumanisme semble, à première vue, prolonger l'idéal libéral en offrant aux individus des outils pour élargir leur autonomie et optimiser leur quête du bonheur. Mais cette promesse de liberté masque une ambiguïté : plus la liberté d'action s'accroît, plus le libre arbitre s'efface. En niant l'existence d'une nature humaine, le transhumanisme réduit l'homme à une machine gouvernée par les lois de la matière. Porté par une vision cybernétique, il conçoit le vivant comme un ensemble de processus logiques, modélisables et manipulables – rendant ainsi possibles les synergies entre le cerveau humain et l'ordinateur (J. Gobin, L'individu, fin de parcours).

3.2. Les libertés de la personne humaine à l'ère du numérique : vers des neurodroits humains

Le marché des neurotechnologies, fort de plusieurs milliards de dollars, et l'essor rapide des interfaces cerveau-machine inquiètent les défenseurs des droits humains à travers le monde. Face à ces risques, certains appellent à l'instauration de « neurodroits ».

Le Chili a ouvert la voie en 2021 en les inscrivant dans sa Constitution, mais aucun autre pays ne l'a, pour l'heure, imité. Des organisations comme la *NeuroRights Foundation* militent pourtant depuis des années pour protéger des droits fondamentaux tels que la « vie privée mentale », l'identité personnelle, le libre arbitre, l'accès équitable à l'augmentation cognitive ou encore à la protection contre les biais algorithmiques.

Des avancées législatives émergent : en Californie, une loi de 2024 interdit l'exploitation abusive des données cérébrales. En avril 2024, un rapport d'experts mandatés par l'Unesco soulignait les risques liés à la convergence des progrès de l'IA et des neurotechnologies, évoquant la manipulation, le profilage, la neuro-amélioration aux effets potentiellement délétères sur le système nerveux, et la menace d'un accroissement des inégalités biologiques et technologiques mettant ainsi en péril le concept même d'humanité.

Cependant, l'enjeu dépasse les « neurodroits ». Certains plaident pour la reconnaissance du droit à la liberté cognitive et à l'autodétermination mentale, estimant qu'il est insensé de consacrer des droits à certaines parties du corps, comme le cerveau, et qu'il convient plutôt de parler de droits humains (N. Farahany, *The Battle for your Brain*, 2023).

3.3. L'élargissement potentiel du cercle des bénéficiaires : la prise en compte juridique des « non-humains »

L'expression « droits humains », par son inclusivité, pourrait enrichir les réflexions actuelles, tant en éthique qu'en droit, sur les droits fondamentaux des non-humains – qu'il s'agisse des animaux ou des entités artificielles, telles que les systèmes d'IA incorporés dans des dispositifs robotiques ou les agents conversationnels (chatbots).

Elle permettrait de clarifier la distinction entre les droits propres aux êtres humains et ceux susceptibles d'être reconnus à d'autres formes d'existence. Elle ouvre ainsi un champ fécond de recherche visant à définir les critères d'attribution de droits aux non-humains.

POUR ALLER PLUS LOIN

Si le droit répugne aux révolutions – fussent-elles mentales –, l'irruption de l'intelligence artificielle nous oblige néanmoins à repenser nos certitudes. La question centrale devient alors : comment habiter une « humanité élargie » (J.-M. Besnier, Demain les posthumains), une communauté qui engloberait les animaux et les machines ? L'avènement du post-humain ouvre un terrain fertile à la philosophie, et les juristes n'ont pas tardé à s'emparer de cette question pour interroger l'évolution du droit et la redéfinition du sujet de droit à l'ère des legal tech. De nombreux colloques voient émerger des propositions doctrinales visant à intégrer le non-humain – et même le non-vivant – dans le champ juridique, qu'il s'agisse d'êtres animaux ou de créations technologiques. Parmi ces pistes, certaines explorent l'évolution du statut du non-humain sous l'angle de l'intériorité et de la complexité (Humain / Non-Humain : repenser l'intériorité du sujet de droit, dir. G. Aïdan, D. Bourcier).

POUR S'ENTRAÎNER

Argumentation juridique : *Soutenez* que la controverse grammaticale autour de la notion de « droits humains » est, en réalité, de nature juridique et politique.

Il faut définir les termes et les expressions du sujet :

- ***Droits humains*** *: e*nsemble des droits fondamentaux reconnus à toute personne du seul fait de son appartenance à l'humanité. L'expression est synonyme, sur le fond, de la formule classique des *droits de l'homme*, mais en propose une formulation plus inclusive.
- ***Controverse*** *: discussion argumentée, contestation sur une opinion ou ensemble des éléments divergents ou contradictoires du débat.*
- ***Grammaticale*** *: simple débat d'ordre linguistique ou terminologique, sans réelle portée :*
    - ***Juridique*** *: débat d'interprétation portant sur une règle de droit, sa portée, sa légitimité ou son application. D*épassant la question du vocabulaire, la controverse devient juridique lorsqu'elle interroge la portée des textes, leur interprétation et leur application afin d'engager le droit lui-même, son langage, sa normativité et ses effets concrets.
    - ***Politique*** *: débat d'idées opposant différentes visions de la société, souvent ancrées dans des idéologies ou des rapports de pouvoir et impliquant des valeurs, des intérêts et des représentations collectives.*

Il faut soutenir que la controverse autour de la notion de droits humain est de nature politico-juridique, quand bien même ses détracteurs invoquent la prétendue neutralité du masculin générique ou les traditions lexicales du droit français.

Il faut indiquer également les bases juridiques dans lesquelles l'expression « droits humains » a été reprise en droit positif.

- *Loi n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre.*

Il faut rappeler qu'il existe une controverse en France autour de la notion des droits humains, laquelle dépasse la sphère doctrinale et académique pour revêtir une dimension institutionnelle :

- Commission nationale consultative des droits de l'homme, Avis du 19 novembre 1998 : *« L'expression Droits Humains est d'une telle généralité qu'elle conduit à englober des domaines qui ne concernent pas les droits fondamentaux définis par les instruments internationaux. »*
- Cons. const., déc. n° 2017-750 DC du 23 mars 2017 : *« Le caractère large et indéterminé de la mention des droits humains. »*

Il faut montrer le caractère national(iste) du débat dans la mesure où une telle controverse n'existe pas, ou plus, dans d'autres pays qui ont choisi d'adopter la formule équivalente des droits humains, précisément choisie pour s'affranchir de l'ambiguïté sémantique, historiquement associée à la figure de l'individu masculin.

- Pays anglophones : *rights of man* versus *human rights.*
- Pays hispanophones : *derechos del hombre* versus *derechos humanos.*

- Autres pays francophones : au Québec, « droits de la personne humaine » (*rights of the human person*).

Il faut indiquer que le retard de la France puise ses racines dans la fierté patriotique suscitée par la Déclaration de 1789 : un tel patriotisme est-il souhaitable s'il repose sur un héritage intrinsèquement patriarcal ?

- La déclaration des droits de l'homme et du citoyen, bien qu'érigée en texte universel, excluait de fait les femmes : celles-ci n'ont joué aucun rôle dans son élaboration et n'ont été ni représentées ni prises en compte par la Constituante.
- La tentative d'Olympe de Gouges de pallier cette invisibilisation par sa Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne lui vaut la peine de mort.

Il faut démontrer que les arguments avancés par les tenants du conservatisme linguistique ne sont pas convaincants.

- L'argument de l'anglicisme : un regard comparatif sur les langues autres que l'anglais révèle que l'expression « droits humains » est répandue : les hispanophones parlent de *derechos humanos*, les Italiens de *diritti umani*, et de nombreux francophones privilégient également cette formulation.
- L'argument du réductionnisme et de la rigueur grammaticale : si l'on considère « humain » comme un adjectif *classifiant,* droits humains signifie exactement la même chose que *droits des humains*. C'est une tournure plus concise pour dire qu'il s'agit des droits de tous les êtres humains.
- Pour justifier le maintien de l'expression « droits de l'homme », capitaliser le mot *Homme*, pour en élargir le sens à l'ensemble de l'humanité n'est pas une solution. Cette pirouette typographique et artificielle constitue une entorse à la grammaire, et reste, en outre, imperceptible à l'oral.

Il faut soutenir que le langage, loin de se limiter à refléter une réalité objective, agit comme un instrument normatif qui structure et oriente la pensée. Dans une perspective juridique, il est crucial de reconnaître que la langue n'est ni neutre ni descriptive en ce qu'elle participe activement à la formation des normes sociales et politiques. En désignant les droits universels sous un terme implicitement masculin, on forge une vision du monde dans laquelle l'homme, à l'exclusion de la femme, est érigé en référence universelle.

Il faut montrer qu'en tant que vecteur de l'égalité et de la justice, le droit a la responsabilité de rectifier les biais présents dans le langage qui, sous couvert de neutralité, peuvent perpétuer des inégalités.

- *Si le droit des libertés promeut l'égalité entre les individus, il doit en toute logique veiller à l'équité des termes qu'il utilise et promouvoir un langage non discriminatoire.*
- *L'expression « droits humains » permet d'éliminer le biais sexiste inhérent à la formule « droits de l'homme ».*
- *Cette correction lexicale vise à reconnaître l'universalité des droits, affranchie des codes de genre, et à garantir que les droits humains sont attribués à l'ensemble des êtres humains, sans distinction ni exclusion.*
- *Au-delà d'une simple évolution linguistique, il s'agit d'un geste juridique exprimant un langage qui reflète véritablement l'égalité des sexes.*

Il faut démontrer, pour finir, que ceux qui critiquent la formule « droits humains », sous-couvert d'en rejeter le militantisme, négligent de prendre en compte l'aspect profondément politique du maintien d'une terminologie excluante :

- *L'argument selon lequel « droits humains » serait une politisation excessive, issue des idéologues et des milieux féministes, dissimule souvent un rejet du changement, porté par une peur de l'effritement du modèle patriarcal traditionnel.*
- *La défense de l'expression « droits de l'homme » peut être une stratégie pour maintenir un ordre symbolique où l'homme continue de dominer les représentations politiques et sociales*

***En conclusion**, en refusant de reconnaître l'égalité des sexes jusque dans les termes employés pour désigner l'universalité des droits, les détracteurs de l'évolution langagière sont ceux qui politisent réellement la question.*

Fiche nº 2 - LES ORIGINES PHILOSOPHIQUES ET RELIGIEUSES

POINTS CLÉS

- L'évolution des origines philosophiques et religieuses des libertés n'est pas linéaire.
- Il est difficile de dater précisément les origines des libertés publiques.
- Chaque période doit faire face aux menaces permanentes des libertés.

PRINCIPALES RÉFÉRENCES

- Article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

1. La difficile recherche des origines antiques

L'origine de l'idée des droits humains est difficile à trouver. Il faut préciser à titre liminaire que cette question est discutée et est sujette à controverse dans la mesure où elle n'est pas l'apanage d'une région du globe, d'une culture particulière ni même d'un moment de l'Histoire.

La recherche de traces de textes relatifs aux droits humains dans l'Antiquité dépend essentiellement de deux éléments : la technique de conservation des supports et de l'interprétation qui en est faite.

Aussi, certains font remonter les sources des droits humains dans le Code d'Hammurabi ou encore chez Cyrus le Grand.

1.1. Le Code d'Hammourabi

Le Code d'Hammurabi (autour de 1750 avant notre ère) est le symbole de la législation mésopotamienne en ce qu'il est l'un des premiers codes juridiques de l'histoire. À ce titre, il fixe plusieurs règles qui intéressent directement ou indirectement la protection des droits. Par exemple, il sanctionne le viol et l'adultère et protège le propriétaire contre le vol de ses biens.

En ce sens, certains y voient le premier écrit concernant les droits humains, mais cette affirmation semble pouvoir être écartée pour plusieurs raisons.

Tout d'abord, ce Code ne dispose pas d'un degré suffisant d'universalité. Du point de vue de la forme, ses lois sont casuistiques, rédigées sous forme de cas concrets, sans formulation abstraite. Elles révèlent plutôt une forme de droit pénal reprise de l'activité judiciaire du roi Hammourabi.

> *« Si le feu a éclaté dans la maison d'un homme et si quelqu'un y est allé pour éteindre, et si, levant les yeux sur le bien du maître de la maison, il a pris le bien du maître de la maison, celui-là sera jeté dans le même feu »* (§ 25 du Code).

De plus, sur le fond, le Code révèle un droit profondément inégalitaire, établissant des distinctions selon le statut social. L'esclave dispose ainsi d'un statut et d'une protection inférieure.

> *« S'il a crevé l'œil d'un esclave d'homme libre ou brisé un membre d'un esclave d'homme libre, il payera la moitié de son prix »* (§ 199 du Code).

Ce code est davantage un rassemblement de législations civiles et pénales qui sont fondées sur la loi du Talion, qu'un véritable texte de protection des droits humains. Même si ces derniers sont indirectement protégés, comme le droit de propriété, il ne le proclame pas.

1.2. Le cylindre de Cyrus

Le cylindre de Cyrus, également appelée Charte de Cyrus, du nom du roi Perse Cyrus le Grand (autour de 549 avant notre ère), contient des dispositions sur les droits humains. Selon certains, il s'agirait d'une déclaration de droits proclamée à la suite de la conquête de la ville de Babylone en 539 avant notre ère. Il aurait libéré l'ensemble des esclaves en les renvoyant chez eux.

Ce texte présenterait les mesures préconisées par Cyrus le Grand. Parmi elles, on retrouve la liberté de religion et l'interdiction de l'esclavage. Ses formulations sont générales et traduisent une quête du bien-être.

> *« J'ai recherché le bien-être de la cité de Babylone et de tous ses centres sacrés. Pour ce qui est des citoyens de Babylone, auxquels* [Nabonide] *avait imposé une corvée n'étant pas le souhait des dieux et ne* […] *convenant guère* [aux citoyens]*, je soulageai leur lassitude et les libérai de leur service »* (trad. française réalisée par le British Museum).

En 1971, l'Organisation des Nations unies l'a fait traduire dans toutes ses langues officielles et l'a érigé en première proclamation des droits humains.

La qualification de ce texte de Déclaration des droits humains, aussi séduisante soit-elle, doit être nuancée. Ce texte est une propagande royale illustrant l'attachement de Cyrus à ses nouveaux sujets.

2. La philosophie grecque classique des libertés publiques

La philosophie grecque classique a d'abord pensé les libertés publiques autour de la cité puis le stoïcisme a introduit l'idée d'individualisme.

2.1. La pensée grecque classique : liberté et citoyenneté

La liberté sous la Grèce Antique est directement rattachée à l'exercice de la démocratie : la vie humaine s'inscrit dans le cadre de la cité.

Les libertés sont politiques et s'exercent dans le cadre de la citoyenneté qui n'est l'apanage que de quelques-uns : la liberté individuelle fondée sur le primat de l'individu n'existe pas. L'homme n'a d'existence juridique que parce qu'il est membre de la cité.

> *« La personne humaine comptait pour bien peu de chose vis-à-vis de cette autorité sainte et presque divine qu'on appelait la patrie ou l'État »* (Fustel de Coulanges, *La Cité antique*, 1864).

En dehors de la cité, les hommes ne sont pas protégés. Par conséquent, les étrangers et ceux qui ne disposent pas de la qualité de citoyens n'ont pas de droits (les enfants, les femmes, les esclaves).

La qualité d'être humain n'est pas une fin en soi, il faut être apte à la citoyenneté. La tradition philosophique grecque voulait que l'homme fût un animal parmi les autres. Ce qui le différencie des autres est sa capacité à penser et à dire. Cette faculté de penser rationnellement, le *logos*, en fait un être supérieur en dignité.

Par exemple, Aristote a une conception restrictive de la notion de liberté. Selon lui, l'homme est *« un animal politique »* dont la vraie nature consiste à vivre dans la société. La liberté n'est pas inhérente à la nature, mais s'inscrit pleinement dans le fonctionnement de la cité. Tous les hommes ne possèdent pas le même *logos.*

Dans la démocratie grecque, la liberté est citoyenne et non humaine. Elle est réservée aux citoyens afin que ces derniers participent aux affaires de la cité : cette liberté publique repose sur l'égalité devant la loi ou sur le droit de prendre la parole lors des assemblées, mais n'est pas un instrument de protection face à l'État.

2.2. La pensée stoïcienne : l'émancipation de l'individu de la Cité

La pensée stoïcienne constitue un premier essor de la notion d'individualisme. Il s'agit d'un nouveau rapport de l'individu avec lui-même et avec les autres, avec un accent mis sur les notions de dignité et d'universalité. On retrouve une illustration de ce principe avec Socrate :

> *« Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux*. »

Les stoïciens considèrent que les hommes participent d'une communauté d'existence qui transcende toute différence.

Pour certains, cette faculté de penser rationnellement est intrinsèque à tout humain, y compris aux esclaves. Sénèque affirmait d'ailleurs que les esclaves conservent une âme libre dans son *Traité des bienfaits.*

> *« L'âme est et reste émancipée. Tout ce qui vient d'elle est libre ; car nous ne pouvons donner des ordres illimités, et nos esclaves ne sont pas tenus de nous obéir en tout »* (Sénèque, *Traité des bienfaits*, Livre III, § 20).

La distinction entre la qualité d'homme et de citoyen s'atténue et perd de son importance. Désormais, les Grecs reconnaissent l'existence de lois naturelles, non écrites et non formulées, limitant le pouvoir de la Cité et supérieures aux lois de celle-ci.

L'illustration de cette distinction entre lois naturelles et lois écrites se révèle quand Antigone refuse d'obéir à son oncle Créon.

> *« Ce n'est pas la Justice assise aux côtés des dieux infernaux ; non, ce ne sont pas là les lois qu'ils n'ont jamais fixées aux hommes, et je ne pensais pas que tes défenses à toi fussent assez puissantes pour permettre à un mortel de passer outre à d'autres lois, aux lois non écrites, inébranlables, des dieux ! Elles ne datent, celles-là, ni d'aujourd'hui ni d'hier, et nul ne sait le jour où elles ont paru »* (Sophocle, Antigone).

L'émergence de la loi naturelle entendue comme juste, conforme à la nature, à l'universalité et à l'éternité doit protéger du mal. Les stoïciens introduisent donc une notion de dignité qui devient une nouvelle source de distinction des individus.

Cependant, le christianisme va donner naissance à une nouvelle loi naturelle : la loi divine.

3. La philosophie chrétienne : une nouvelle conception de l'humain

La philosophie chrétienne poursuit l'émergence des notions de dignité de la personne humaine et d'égalité, toutes deux désormais appréhendées sous le prisme de Dieu.

Cette conception demeure structurante dans la doctrine sociale contemporaine de l'Église. Le Compendium de la doctrine sociale de l'Église rattache ainsi la dignité inaliénable de toute personne humaine à sa création « à l'image et à la ressemblance de Dieu ». Il en fait surtout le principe premier sur lequel reposent les autres principes permanents de la doctrine sociale de l'Église : le bien commun, la subsidiarité et la solidarité. Cette conception rejoint l'idée, développée à propos du caractère matriciel de la dignité, selon laquelle la personne doit toujours être reconnue comme un sujet et ne saurait être réduite à un objet ou à un simple moyen.

Le principe de subsidiarité prolonge cette primauté accordée à la personne : l'autorité ou le groupement supérieur doit soutenir les personnes, les familles et les corps intermédiaires lorsqu'ils ne peuvent agir seuls, sans toutefois se substituer inutilement à leur initiative, à leur liberté et à leur responsabilité. Il traduit ainsi une conception de l'organisation sociale dans laquelle les institutions demeurent ordonnées à la personne humaine et au bien commun.

Pour autant, le christianisme a constitué un blocage au développement d'autres notions.

3.1. Les apports du christianisme : le renforcement de l'individualisme

Les libertés publiques trouvent une partie de leur origine dans les traditions religieuses chrétiennes. Les textes bibliques constituent une référence, accentuée par le rôle joué par les premiers penseurs chrétiens qui ont jeté les bases d'une réflexion sur la place de l'individu dans la société.

L'Ancien testament comme le Nouveau ont permis l'émergence de certaines notions relatives aux libertés publiques en singularisant l'individu autour de la notion d'égalité et de séparation du spirituel et du temporel.

3.1.1. L'égalité dans la pensée chrétienne

Par exemple, l'Ancien Testament pose le principe selon lequel chaque humain est transcendé par des valeurs uniques et universelles. La dignité de l'être humain est intrinsèque et conditionne l'existence individuelle. La pensée chrétienne reconnaît à l'individu une dignité particulière en raison de sa relation filiale à Dieu.

La dignité humaine n'a de raison d'être que parce qu'elle est un don de Dieu. Cette dignité doit impliquer un respect de l'être humain et l'Homme a une valeur en soi, car il est fait à l'image de Dieu. Il existe une égalité de tous dans la soumission à Dieu.

> *« Maîtres, accordez à vos esclaves ce qui est juste et équitable, sachant que vous aussi vous avez un maître dans les cieux »* (Colossiens, 4 :1).

De même, la notion de dignité fait naître celle de l'égalité. Il ne s'agit nullement d'une égalité absolue, mais elle ne se comprend qu'à l'aune de l'égalité spirituelle, sans considération du statut social. Les êtres humains se transcendent grâce à Dieu et au christianisme.

> *« Il n'y a plus ni Juif ni Grec : il n'y a plus ni esclave ni homme libre ; il n'y a plus ni homme ni femme : car vous n'êtes tous qu'une personne dans le Christ Jésus »* (Saint Paul, *Épître aux Galates*, III, 28).

3.1.2. La séparation du spirituel et du temporel

Enfin et surtout, le christianisme tente de concilier ces principes avec un troisième principe : la séparation entre le temporel et le spirituel. Il y a l'affirmation progressive d'une séparation entre deux pouvoirs avec des légitimités distinctes : le pouvoir temporel de l'État et le pouvoir spirituel religieux. Cette séparation du religieux et de l'État s'illustre dans la célèbre affirmation :

> *« Il faut rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu »* (Matthieu 22 : 21).

Cette séparation affirme l'indépendance de la sphère religieuse par rapport à l'État. Dans le cas où l'État interviendrait dans le domaine spirituel, l'individu pourrait résister légitimement à toute forme d'oppression de l'État.

Outre les textes bibliques, les penseurs chrétiens ont également contribué à développer ces principes qui sont au cœur du développement de la pensée universelle des droits humains.

3.2. Les obstacles du christianisme au développement des libertés publiques

La religion chrétienne a joué un rôle important dans la construction de l'individualisme humain grâce à l'émergence de la notion d'égalité et de dignité. Pourtant, elle a parfois porté atteinte à des principes, mettant en lumière les paradoxes de l'apport du christianisme à la construction des libertés.

Le christianisme n'implique pas d'égalité absolue. Par exemple, les textes bibliques considèrent la femme dans un rôle subordonné et cette vision a influencé pendant plusieurs siècles les sociétés chrétiennes. Par exemple, il est écrit :

> *« Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur »* (Éphésiens, 5 : 22-23).
>
> *« Que vos femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis de parler ; mais qu'elles soient soumises, comme le dit aussi la loi »* (Corinthiens 14 : 34).

Enfin, les dogmes religieux sont régulièrement entrés en contradiction avec des libertés de l'individu. En ce sens, la religion a parfois été en tension avec le droit à la vie privée, notamment en matière de sexualité, de mariage ou de procréation.

Les interdictions liées à l'avortement ont souvent été justifiées par des contraintes religieuses. De même, les textes bibliques n'ont pas remis en cause l'esclavage.

4. La limitation du pouvoir de l'État (XVIe et XVIIe siècles)

La limitation du pouvoir permettant de jouir des droits humains a été progressivement permise par la référence à un droit supérieur, qu'il s'agisse de la nature, de Dieu ou encore de la Raison.

4.1. Le droit naturel : un droit intrinsèque à l'individu

Historiquement, c'est vers Dieu que se sont portées les références au droit naturel. Grâce à l'œuvre de Saint Thomas d'Aquin (1225-1274), une réflexion sur le droit naturel s'est faite par opposition au droit positif, tout en étant rattachée à Dieu.

De même, les théologiens de l'École de Salamanque (XVIe siècle) défendent l'idée d'un droit naturel d'origine divine permettant une limite au pouvoir de l'État.

> ***POUR ALLER PLUS LOIN***
>
> *La controverse de Valladolid (1550-1551) a opposé Bartolomé de las Casas et Juan Gïnes de Sepulveda. De nombreux théologiens soutenaient que les Indiens pouvaient être privés de leurs terres et réduits en esclavage parce qu'ils n'étaient pas chrétiens. Le Pape de l'époque soutenait que cela était faux et qu'ils ne sauraient être privés de leur liberté ni de leurs biens. Sepulveda soutient l'inverse en retenant l'infériorité des Indiens. Pour trancher la controverse, un débat a lieu et Las Calas soutient l'absence d'une humanité hiérarchisée en raison de la religion grâce à des lois naturelles pour tous les humains.*

À la suite de l'École de Salamanque, le droit naturel, comme reflet de la loi divine, va se transformer au profit d'un droit rationnel fondé sur la Raison. Alors que la loi naturelle divine était verticale et descendante, de Dieu vers l'humain, la Raison vient de l'Homme lui-même.

L'œuvre de Grotius est importante en la matière puisqu'elle constitue un mouvement de sécularisation du droit naturel. Il définit le droit naturel comme :

> *« Les principes de la droite raison qui nous font connaître qu'une action est moralement honnête ou déshonnête selon la convenance ou la disconvenance nécessaire qu'elle a avec une nature raisonnable ou sociable »* (Grotius, *De jure belli ac pacis*, 1625).

La thèse de Grotius est confirmée par Pufendorf qui empruntera des éléments de réflexion à l'état de nature et à la notion de contrat social. À partir de là, le droit naturel se définit comme la liberté que possède chaque homme de veiller à sa propre conservation.

Enfin, l'essor de l'individualisme a été parachevé avec la pensée cartésienne. Avec son célèbre *cogito ergo sum* soit « je pense donc je suis », Descartes s'inscrit dans l'émancipation de l'individu. Désormais, le « je » devient le centre de gravité de la représentation du monde dans lequel l'individu occupe toute sa place. Le doute cartésien est un fondement de connaissance et, par conséquent, permet la résistance de l'individu et son autodétermination.

Cette émancipation de l'individu trouve un prolongement radical dans la pensée de Friedrich Nietzsche. La célèbre formule « Dieu est mort », exposée notamment dans *Le Gai Savoir*, ne doit pas être comprise comme la simple affirmation de l'inexistence de Dieu. Elle traduit plus profondément l'effondrement des fondements religieux et métaphysiques traditionnels sur lesquels reposaient jusque-là la morale, les valeurs et la représentation de l'homme. Dès lors que les valeurs ne peuvent plus être reçues d'un ordre transcendant, l'individu est conduit à interroger leur origine et à participer lui-même à leur création. La pensée nietzschéenne pousse ainsi à son terme le mouvement de subjectivisation et d'autonomisation de l'individu, tout en faisant apparaître une difficulté nouvelle : la liberté acquise à l'égard des valeurs traditionnelles suppose désormais de déterminer sur quels fondements peuvent reposer les normes communes.

4.2. Les théories du contrat social

À partir du XVIIe siècle, les théories du droit naturel moderne s'affirment. L'idée est désormais que l'individu ne dépend plus uniquement de la société, mais il dispose de droits qui lui sont opposables. Au cœur de l'idée de droits humains figure, outre le fait que les individus aient des droits inhérents à leur nature humaine, le fait que ces droits constituent des limitations du pouvoir de la puissance publique.

En parallèle, l'idée que Dieu légitime ces droits opposables disparaît au profit d'une sécularisation du droit naturel. Les théories contractualistes, c'est-à-dire portant sur le contrat social, commencent à s'affirmer.

Ces théories reposent sur l'idée qu'un état précédant le pacte social existait : il s'agit de l'état de nature. Cet état est réputé inorganisé, car il se caractérise par une soustraction à toute autorité et de la jouissance d'une pleine liberté.

Pour Hobbes, par exemple, l'état de nature ou le droit de nature est un état de liberté d'user de ses pouvoirs propres, il s'agit d'un état d'autodétermination. En sortant de l'état de nature par le contrat social, l'individu renonce à son état de liberté pour transférer ses pouvoirs à un État protecteur.

À l'inverse d'Hobbes, qui voit dans l'état de nature un état de guerre, Locke y voit un état de paix et de bonnes volontés tout en disposant d'une liberté de disposer de lui-même. Pourtant, les individus vont se détacher de cet état de liberté pour se regrouper en société.

En effet, cet état de pleine liberté est précaire et les hommes doivent progressivement en sortir. Ils doivent en sortir, car leur sécurité est menacée par un état de guerre perpétuelle, soit un état de guerre de tous contre tous pour Hobbes dans le *Léviathan*, ou pour protéger leur propriété pour Locke dans le *Second Traité du Gouvernement civil* de 1690.

Le contrat social marque alors la sortie de l'état de nature au profit d'une société collectivement organisée. Aussi, le pacte social est un accord par lequel les hommes décident de mettre fin à leur état de nature primitif par l'instauration d'un pouvoir politique et d'un souverain, tous deux destinés à garantir leurs libertés. Jean-Jacques Rousseau écrivait que le contrat social servait à :

> *« Trouver une forme d'association qui défende et protège de toute la force commune la personne et les biens de chaque associé, et par laquelle, chacun, s'unissant à tous, n'obéisse pourtant qu'à lui-même, et reste aussi libre qu'auparavant »* (J.-J. Rousseau, *Du Contrat social*, 1762).

Le pacte social réside donc dans la volonté de se détacher de certaines libertés confiées au souverain et d'exercer collectivement dans la société pour en préserver d'autres. Par le contrat social, chacun aliène la totalité de sa liberté et l'homme devient un citoyen, soumis aux lois qui sont l'expression de la volonté générale.

Ainsi, après avoir affirmé que le citoyen s'abandonne tout entier au souverain pour jouir des droits et libertés qu'il lui assure exclusivement, Rousseau fait place à un droit naturel attaché à la qualité d'homme.

5. La philosophie des Lumières, l'essor des libertés (XVIIIe siècle)

La période des Lumières, dont l'apogée est au XVIIIe siècle, est un courant de pensée visant à l'affirmation de nombreux droits politiques dont certains guideront les révolutionnaires français et seront consacrés dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

5.1. La pensée des Lumières, prémices de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen

Dans un État français qui est devenu absolutiste de droit divin, des voix, celles des philosophes des Lumières, s'élèvent pour contester cet absolutisme et pour que soit reconnues certaines libertés.

Montesquieu consacre le principe de séparation des pouvoirs entre le législatif, l'exécutif et le judiciaire afin de garantir la liberté individuelle et en empêchant un pouvoir absolu et tyrannique. Un pouvoir doit être limité par un autre pouvoir pour garantir la liberté de l'individu :

> *« Pour qu'on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. Une constitution peut être telle, que personne ne sera contraint de faire les choses auxquelles la loi ne l'oblige pas, et à ne point faire celles que la loi lui permet »* (Montesquieu, *De l'Esprit des lois*, 1748).

Ce principe sera consacré dans l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

> *« Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution »* (art. 16 DDHC).

Dans son *Traité sur la tolérance* de 1763, Voltaire défend la notion de tolérance religieuse. Ce dernier est connu pour son combat contre l'intolérance religieuse.

Ce principe a été repris dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en son article 10.

> *« Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la Loi »* (art. 10 DDHC).

5.2. La philosophie révolutionnaire et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen

La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen a été proclamée le 26 août 1789, après que les représentants des trois ordres (Noblesse, Clergé, Tiers-État) se furent proclamés Assemblée Nationale et eurent aboli les privilèges.

La Déclaration est marquée par plusieurs principes philosophiques tirés des périodes antérieures. Il s'agit d'une synthèse des périodes précédentes.

Le principe jusnaturaliste : la Déclaration se rattache à la philosophie du droit naturel en déclarant des droits préexistants et inhérents à l'humain, sans les créer.

Le principe individualiste : la Déclaration ne reconnaît que des individus et non des groupes. Il s'agit de replacer l'individu au centre de la pensée, excluant *de facto* les libertés collectives.

Le principe libéral : dans la Déclaration, l'accent est mis sur la protection de la liberté individuelle vis-à-vis du pouvoir politique. Il s'agit de préserver la sphère privée de l'individu de toute immixtion de l'État. En conséquence, les droits qui impliqueraient une action positive de l'État ne sont pas proclamés.

6. Le renouveau philosophique des libertés (XIXe et XXe siècle)

Tout d'abord, la Déclaration de 1789 a fait l'objet de critiques, notamment de la part de Karl Marx qui y voyait un instrument bourgeois. En parallèle, la conception négative des libertés publiques, entendue comme l'absence d'intervention de l'État dans la sphère individuelle, ne suffisait plus à protéger l'individu.

6.1. La critique marxiste des droits révolutionnaires

Pour Marx, l'universalité et l'égalité proclamées dans la Déclaration de 1789 sont des principes fictifs. En effet, la liberté est conçue sur un modèle bourgeois : elle s'arrête où commence celle d'autrui sans appréhender l'individu dans le collectif.

Marx considère que les droits de 1789 sont fallacieux pour deux raisons : d'une part, ils sont déconnectés des enjeux et des affrontements réels de la société qui sont économiques : l'homme ne jouit pas de ses libertés tant qu'il n'est pas en mesure d'assurer sa propre survie.

Surtout, ils sont proclamés sans prendre en considération leur exercice, ce qui rend leur effectivité illusoire. Il en résulte que ce sont des libertés formelles auxquelles Marx veut opposer des libertés réelles garanties par la mise à disposition de moyens matériels de les exercer.

6.2. La pensée socialiste et l'intervention de l'État

Il est apparu nécessaire de compléter les droits abstraits de 1789 par des droits tenant compte des conditions réelles d'existence de l'humain. Aux libertés individuelles de la Déclaration, fondées sur l'abstention de l'État, sont venus s'ajouter des « droits-créances » à caractère collectif qui supposent l'obtention d'interventions positives de l'État.

L'État ne se contente plus de préserver la sphère individuelle, il doit désormais agir pour la protéger.

Une des raisons de la chute de la monarchie en 1848 est très certainement son indifférence à la question sociale. Alors que le prolétariat, qui était apparu avec la révolution industrielle, était largement exploité et usé, des insurrections ouvrières éclataient et étaient réprimées dans le sang.

Il existait déjà des textes précurseurs, représentatifs de cette pensée socialiste : la Constitution de 1793 propose déjà une déclaration avec une préoccupation sociale indéniable. Ce texte est la première manifestation de droits collectifs perçus en opposition avec les droits de l'individu.

> *« La société doit la subsistance aux citoyens malheureux, soit en leur procurant du travail, soit en assurant les moyens d'exister à ceux qui sont hors d'état de travailler »* (art. 21).

7. L'émergence de nouvelles philosophies des libertés (XXe siècle).

L'émergence de nouvelles philosophies des libertés publiques s'explique par la volonté de se voir reconnaître de nouveaux droits, sous l'influence notamment de la transformation des mœurs.

7.1. Les théories féministes et la critique féministe

Initialement, les différentes philosophies des droits humains se sont déclinées au masculin. Si certains auteurs s'accordent pour reconnaître dans le droit naturel une égalité parfaite entre les femmes et les hommes, il n'en demeure pas moins que la pratique s'est révélée bien inférieure à la théorie.

Les théories féministes sont récentes. Pour autant, elles trouvent des échos anciens et présents dans l'histoire des droits humains. En 1791, Olympe de Gouges, femme de lettres et révolutionnaire française, rédigea une Déclaration des droits de la Femme et de la Citoyenne dont l'article 1er affirmait :

> *« La femme naît libre et demeure égale à l'homme en droits »* (art. 1er, Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne).

Son engagement politique en faveur des femmes, mais aussi pour l'abolition de l'esclavage, lui valurent d'être guillotinée en 1793. Les courants philosophiques, jusqu'au XVIIIe siècle, ne concevaient les droits naturels qu'au prisme du genre masculin et non du genre humain.

7.2. La protection du vivant face aux technologies

Aujourd'hui, le droit doit s'adapter au développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication (NTIC) ou au développement des biotechnologies touchant l'humain. Les libertés publiques sont désormais interrogées au prisme de l'amélioration de l'humain.

Par exemple, la question du transhumanisme menace les fondements les plus essentiels de la protection du corps. Les différentes lois « bioéthiques » sont l'occasion de modifier des pans entiers du droit sur des sujets délicats en ce qu'ils touchent au corps humain. On pense par exemple aux questions de clonage, à la procréation médicalement assistée, à la fin de vie. De même, l'arrivée de l'intelligence artificielle interroge sur la relation à l'humain. Les craintes sont celles d'une utilisation trop attentatoire aux droits fondamentaux comme le *scoring social* ou encore l'identification de masse.

POUR ALLER PLUS LOIN

L'expression « scoring social » désigne le fait d'attribuer une note ou un score à un individu en fonction de ses relations sociales. Ce « scoring social » peut avoir des conséquences sur la vie quotidienne en ce qu'il pourrait déterminer l'attribution de logement, de prêt ou encore l'emploi ou les services.

L'identification de masse désigne le fait de recourir à surveillance par des logiciels d'intelligence artificielle destinés à contrôler ou identifier des comportements suspects.

Actualité. - Le scoring social des bénéficiaires de prestations sociales en France

Cette problématique ne demeure pas théorique. En France, la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) utilise depuis plusieurs années des techniques de datamining permettant d'attribuer aux dossiers des allocataires un score de risque d'indu, utilisé afin de cibler prioritairement certains contrôles. Cette pratique a suscité d'importantes interrogations relatives à la protection des données personnelles et au risque de discriminations indirectes, certains critères retenus par les précédents modèles étant susceptibles de conduire à un contrôle plus fréquent des personnes se trouvant dans des situations de précarité.

Le règlement européen sur l'intelligence artificielle (*IA Act*) apporte désormais un encadrement supplémentaire. Il interdit certaines pratiques de notation sociale lorsqu'elles conduisent à un traitement défavorable injustifié ou disproportionné et classe parmi les systèmes d'IA à haut risque ceux utilisés par les autorités publiques pour déterminer l'accès à des prestations sociales essentielles, leur réduction, leur retrait ou leur récupération. Ces dispositifs sont en effet susceptibles d'affecter notamment le droit à la protection sociale, le principe de non-discrimination, la dignité humaine et le droit à un recours effectif.

→ Règlement (UE) 2024/1689 du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l'intelligence artificielle, art. 5 et annexe III.

Une actualité française est intéressante à ajouter, à ce stade : à la suite des critiques formulées à l'encontre de son précédent système, la CNAF a déployé en janvier 2026 un nouveau modèle, le « DMDE 2026 ». La CNAF indique que celui-ci sert uniquement d'aide au ciblage des contrôles, sans décision automatisée, et qu'il exclut notamment la nationalité, le genre, l'adresse et le lieu de résidence des variables utilisées.

POUR S'ENTRAÎNER

Dissertation : Les libertés chez les penseurs du contrat social.

À travers leur théorie du passage de l'état de nature à la société politique, les trois philosophes que sont Thomas Hobbes, John Locke et Jean-Jacques Rousseau nous plongent au cœur de la doctrine des droits naturels de l'homme et des libertés.

À partir du XVIIe siècle, différentes théories laïques de la fondation du pouvoir vont voir le jour, même si elles demeurent parfois empreintes de religiosité. Pour ces théories, les libertés ne résultent plus d'un don divin, elles ne sont pas une création ou une volonté de Dieu. Elles trouvent leur explication dans l'œuvre fondatrice des hommes et résulte, en somme, de leurs volontés. Hobbes, Rousseau et Locke figurent parmi les principaux théoriciens du contrat même si d'autres les ont précédés en la matière.

Le point de départ de leur réflexion est que les hommes vivaient initialement dans l'état de nature avant de fonder la société politique, c'est-à-dire de fonder le pouvoir politique qui n'est autre que la puissance collective. Ils détenaient des droits naturels, c'est-à-dire des droits attachés à leur qualité d'hommes : ils étaient naturellement libres et égaux en ce sens que les hommes sont capables des mêmes choses.

Problématique et annonce du plan : il faut expliquer pourquoi les hommes ont voulu sortir de l'état de nature et fonder la société politique et quelle est l'incidence de ce passage sur la protection des libertés.

I. La nécessité de sortir de l'état de nature pour garantir la liberté

A. L'homme en danger dans l'état de nature

Les auteurs n'ont pas la même perception de l'état de nature, mais ils se rejoignent pour considérer que les hommes y sont en danger.

Dans l'état de nature, les hommes sont tous égaux dans la mesure où ils peuvent choses égales, et notamment s'enlever la vie

Chacun, étant totalement libre, peut faire ce qu'il veut. On comprend que cet état de nature se caractérise par un état de guerre perpétuelle entre tous et un rapport de domination des plus forts.

Pour John Locke, si les hommes y disposent d'une parfaite liberté, chacun doit rester dans les bornes de la loi de la nature. Selon cette loi, l'homme n'a pas le droit de se détruire ni de faire tort à une autre personne.

Pour lui, comme pour Hobbes, les hommes sont égaux, car ils disposent des mêmes facultés. Mais la liberté et l'égalité sont menacées par la volonté réciproque des hommes de se nuire.

S'agissant de Rousseau, les hommes naissent libres et égaux. Au départ, dans l'état de nature, les hommes vivent seuls et ne cherchent qu'à satisfaire leurs besoins primordiaux, c'est-à-dire à demeurer vivants.

B. La garantie des libertés par la société politique

La même idée est partagée par ces trois auteurs : c'est en fondant la société politique que les hommes vont pouvoir assurer leur conservation et protéger les droits qu'ils possèdent dans l'état de nature.

Pour Locke, les hommes ont cherché à composer un corps pour la conservation mutuelle de leurs vies, de leurs libertés et de leurs biens. Il s'agit en fait de mettre en place ce qui manque dans l'état de nature

Rousseau explique que les possédants, pour éviter d'être tués ou dépossédés, ont réussi à faire admettre la nécessité de protéger chacun et les biens de chacun en instituant ensemble un pouvoir protecteur. En ce sens, Rousseau explique que la propriété est à l'origine de la société.

II. Le pacte au fondement de la protection des libertés

A. Les « termes » du contrat

Hobbes comme Rousseau considèrent que, par le pacte, les hommes abandonnent leurs droits naturels et se soumettent sans réserve au pouvoir né du contrat

Le Léviathan, ce monstre aquatique de la mythologie phénicienne, est un être monstrueux qui symbolise le pouvoir que les hommes ont créé.

Il a été envoyé par dieu pour sauvegarder la vie, les droits et les biens des citoyens, mais les hommes n'ont pas la possibilité ni le droit de se rebeller contre le souverain, même s'il est injuste.

Rousseau rejoint Hobbes, car la clause fondamentale du contrat social est l'aliénation totale de l'individu envers tous (par chacun, de tous ses droits, à toute la communauté). Rousseau veut dire que chacun doit renoncer à un libre exercice de ses droits naturels et se soumettre entièrement, sans limite, à la volonté générale (la loi).

Pour Rousseau, l'abandon total des droits naturels est la meilleure façon de garantir une réelle égalité et une réelle liberté. D'une part, l'égalité est assurée, car tous les hommes participent à la formation de la volonté générale et la loi est applicable à tous.

Pour Locke, enfin, qui incarne la conception libérale du pouvoir, le contrat ne conduit pas à un abandon des droits naturels, mais seulement à leur limitation. Les hommes remettent l'égalité, la liberté et le pouvoir qu'ils avaient dans l'état de nature à la société, c'est-à-dire qu'ils renoncent à les exercer comme ils le veulent.

B. Le détenteur du pouvoir

Pour Hobbes, les hommes peuvent choisir comme souverain un homme seul et en ce cas, il s'agit d'une monarchie, ou de confier le pouvoir à plusieurs et il s'agit alors d'une aristocratie, mais la monarchie a sa préférence.

Rousseau défend une conception démocratique du pouvoir. Locke défend quant à lui une représentation du peuple par une élite cultivée, raisonnable, à laquelle le pouvoir est délégué et qui prend les décisions à la

majorité. L'objectif est de parvenir à mettre en place un pouvoir modéré en empruntant à la monarchie, à l'aristocratie et à la démocratie.

En conclusion, les hommes ont voulu sortir de l'état de nature pour fuir le danger et garantir leur liberté politique en fondant un pacte, un contrat social et en remettant leurs libertés aux mains d'un souverain.

Fiche nº 3 - LES ORIGINES TEXTUELLES

POINTS CLÉS

- Origine anglaise des textes fondateurs.
- Indépendance américaine et proclamation des droits.
- Révolution française et abolition de la monarchie.
- Rédaction de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

PRINCIPALES RÉFÉRENCES

- La Grande Charte anglaise (1215).
- Le *Bill of Rights* anglais (1689).
- La Déclaration d'Indépendance des États-Unis (1776).
- La Constitution américaine du 17 septembre 1787.
- La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.
- Stéphane Rials (présenté par), *La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen*, Paris, Hachette, coll. « Pluriel », 1988.
- Alexis de Tocqueville, *De la démocratie en Amérique I (1835)*, Paris, Gallimard, coll. Bibliothèque de la Pléiade, 1992.
- Frédéric Rouvillon, *Les Déclarations des droits de l'Homme*, Flammarion, 2009.

1. Les premiers textes anglais

Les premiers textes concernant les droits et libertés fondamentaux ont été rédigés en Angleterre. Tous ces textes sont issus de périodes de crise dans lesquelles la bourgeoisie et la noblesse se dressent contre l'absolutisme anglais et cherchent à limiter son pouvoir.

Ces différents textes, courts et pragmatiques, visent à protéger les intérêts des Anglais face au monarque. Ils ont pour vocation de protéger des prérogatives concrètes, pensées tout d'abord dans un cadre impersonnel avant d'être appliquées personnellement aux Hommes libres.

1.1. La Grande Charte (1215)

La Grande Charte ou *Magna Carta*, a été accordée par le Roi Jean en 1215. Elle est issue d'un contexte de troubles et de défiances à l'encontre du Roi Jean qui était le Régent du Roi Richard Cœur de Lion lors de ses croisades.

Cette Charte, composée de 66 articles dont l'article 39, reconnaît pour la première fois une protection contre les atteintes à la liberté individuelle :

> *« Aucun homme libre ne sera arrêté ni emprisonné, ou dépossédé de ses biens, ou déclaré hors-la-loi, ou exilé, ou exécuté de quelque manière que ce soit, et nous n'agirons pas contre lui et nous n'enverrons personne contre lui sans un jugement légal de ses pairs et conformément à la loi du pays. »*

Ce texte énumère aussi les droits et libertés de l'Église d'Angleterre, dont la liberté des élections ainsi que divers principes concernant les impôts et la procédure pénale.

Ce premier texte fondateur connaît un grand prestige au sein de l'Europe et Outre-Atlantique.

1.2. La Pétition des droits (1628)

Ce texte a été rédigé par Sir Edward Coke, John Pym et John Selden.

La Pétition des droits accordée par Charles I[er] en 1628 rappelle des droits figurant dans la *Magna Carta* et réaffirme la volonté des nobles de faire respecter leurs prérogatives fiscales telles que le consentement à l'impôt et l'interdiction de prêter au roi contre la volonté du débiteur.

Le monarque ne peut plus agir de manière arbitraire dans certains domaines : propriété, décret de la loi martiale, levée des impôts (accord du Parlement nécessaire), emprunts, logement des troupes chez l'habitant.

1.3. L'Habeas Corpus Act (1679)

L'Habeas Corpus a été adopté par Charles II en 1679 après avoir été voté par le Parlement à l'initiative de Lord Shaftesbury.

Il traite de la procédure d'emprisonnement avec un rôle central du juge, du paiement des cautions, de la compétence des juridictions et des délais de procédure.

Désormais, pour éviter les détentions arbitraires, c'est le juge pour faire suite à un mandat d'arrêt qui délivre une ordonnance d'Habeas Corpus afin que la personne se présente devant lui pour étudier les charges retenues contre cette dernière. Si ces dernières sont insuffisantes ou en absence de délit, la personne doit être libérée, *a contrario* une caution raisonnable est fixée ainsi qu'un lieu de détention en Angleterre.

1.4. Le Bill of rights (1689)

Le *Bill of rights* de 1689 est une loi du Parlement d'Angleterre intitulée *Acte déclarant les droits et les libertés du sujet* et mettant en place la succession de la couronne.

Ce texte a été proclamé à la fin de la *Glorious Revolution* en 1688 afin d'instaurer la première monarchie parlementaire. Le pouvoir royal est une fois de plus limité avec l'affirmation de la supériorité de l'autorité de la loi sur celle du roi.

> *« Debet rex esse sub lege. »*

Les droits proclamés sont pragmatiques et concrétisés par des procédures écrites :

- Art. 3 : consentement à l'impôt.
- Art. 5 : droit de pétition.
- Art. 6 : autorisation du Parlement pour la levée et l'entretien d'une armée en temps de paix.
- Art. 7 : droit pour les sujets protestants de posséder des armes conformes à leur condition.
- Art. 8 : liberté d'expression au sein du Parlement.
- Art. 9 : droit à des élections parlementaires libres.
- Art. 10 : Habeas corpus.

POUR ALLER PLUS LOIN

Au cœur du Bill of rights, on trouve l'ancêtre de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme : « Qu'il ne peut être exigé de cautions, ni imposé d'amendes excessives, ni infligé de peines cruelles ou inusitées. »

2. Les textes américains

La Révolution américaine trouve sa source dans un conflit entre la couronne anglaise et les colons américains. Ces derniers n'étant pas représentés au Parlement britannique estimaient qu'ils ne pouvaient pas être taxés sans leur consentement selon le principe *« No taxation without representation »*.

Les treize colonies américaines se sont réunies, à l'initiative de Benjamin Franklin, en septembre 1774 à Philadelphie lors d'un premier Congrès et la guerre d'Indépendance américaine débuta le 17 juin 1775. Après 8 ans de guerre, l'indépendance américaine a été officiellement reconnue par la Grande-Bretagne le 3 septembre 1783 avec la signature du traité de Paris et du traité de Versailles. John Adams, John Jay et Benjamin Franklin étaient les signataires de ce traité pour les États-Unis.

2.1. La Constitution de l'État de Virginie (12 juin 1776)

Au sens moderne, il s'agit de la première déclaration des droits, rédigée par George Mason. Elle inspirera de nombreux textes tels que la Déclaration d'Indépendance des États-Unis et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

Court texte composé de 16 articles, la Constitution de l'État de Virginie proclame de nombreux droit et libertés fondamentaux :

- Art. 1er : *« Que tous les hommes sont nés également libres et indépendants, et qu'ils ont certains droits inhérents dont ils ne peuvent, lorsqu'ils entrent dans l'état de société, priver ni dépouiller par aucun contrat leur postérité : à savoir le droit de jouir de la vie et de la liberté, avec les moyens d'acquérir et de posséder des biens et de chercher à obtenir le bonheur et la sûreté. »*
- Art. 2 : dévolution du pouvoir au peuple.
- Art. 3 : gouvernement institué pour l'avantage commun, pour la protection et la sécurité du peuple, de la nation ou de la communauté.
- Art. 5 : séparation des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire.
- Art. 6 : droit à des élections libres.
- Art. 8 : garanties procédurales et droit à un jury impartial.
- Art. 12 : liberté de la presse.
- Art. 16 : liberté de religion.

D'autres colonies notamment le Massachusetts et la Pennsylvanie adopteront aussi une constitution précédée d'une déclaration des droits. Ces textes seront traduits en français par le Duc de la Rochefoucauld.

Avec ces déclarations des États, le peuple fixe des limites à son propre pouvoir puis confie ce pouvoir aux gouvernants en l'encadrant par la Constitution. Les droits deviennent ainsi des principes constitutionnels.

Ces différents droits sont issus du droit naturel, on y retrouve la liberté de religion, le consentement à l'impôt des représentants, la sûreté, le droit à un jury populaire en matière pénale, la liberté de la presse, la non-rétroactivité des lois pénales…

POUR ALLER PLUS LOIN

Le Virginia Statute for Religious Freedom, rédigé par Thomas Jefferson d'après un mémoire de James Madison, a été adopté le 16 janvier 1786 par l'Assemblée de Virginie : premier texte américain à instaurer la liberté de conscience.

2.2. La Déclaration d'Indépendance des États-Unis d'Amérique (4 juillet 1776)

Texte majeur rédigé par Thomas Jefferson et John Adams, il marque le triomphe des idées libérales, des théories du *self-government* et de la doctrine du droit naturel.

Ce texte ne se contente pas de proclamer une nouvelle nation, mais aussi un corps électoral élargi et une séparation stricte des pouvoirs afin de garantir les droits et libertés.

> *« Tous les hommes sont créés égaux ; ils sont dotés par le créateur de certains droits inaliénables ; parmi ces droits se trouvent la vie, la liberté et la recherche du bonheur. Les gouvernements sont établis parmi les hommes pour garantir ces droits, et leur juste pouvoir émane du consentement des gouvernés. »*

Si les gouvernements s'écartent de ce but, la Déclaration d'Indépendance consacre un droit de résistance à l'oppression.

« Toutes les fois qu'une forme de gouvernement devient destructive de ce but, le peuple a le droit de la changer ou de l'abolir et d'établir un nouveau gouvernement, en le fondant sur les principes et en l'organisant en la forme qui lui paraîtront les plus propres à lui donner la sûreté et le bonheur. »

Cependant, tous ne disposent pas de ces droits : la question de l'esclavage dans certains États empêche la conciliation de ces droits avec la réalité sociale. Afin d'obtenir une union avec les États du Sud, les passages sur l'esclavage et la traite ont été supprimés.

2.3. La Constitution américaine du 17 septembre 1787

Texte et acte fondateur des États-Unis d'Amérique rédigé par 55 personnalités dont les plus illustres rédacteurs sont Benjamin Franklin, Georges Washington, Alexandre Hamilton et James Madison. Cette Constitution a été approuvée en 17 septembre 1787 par 39 des 55 membres de la convention.

Cette constitution est entrée en vigueur le 4 mars 1789 et elle est encore en vigueur de nos jours. Elle définit et met en place un régime présidentiel, une séparation stricte des pouvoirs.

Le pouvoir exécutif est confié au président des États-Unis, le pouvoir législatif repose sur deux chambres élues : Sénat et Chambre des représentants. Le pouvoir judiciaire est représenté par la Cour suprême.

POUR ALLER PLUS LOIN

Préambule de la Constitution des États-Unis : « Nous, Peuple des États-Unis, en vue de former une Union plus parfaite, d'établir la justice, de faire régner la paix intérieure, de pourvoir à la défense commune, de développer le bien-être général et d'assurer les bienfaits de la liberté à nous-mêmes et à notre postérité, nous décrétons et établissons cette constitution pour les États-Unis d'Amérique. »

Cette constitution est complétée le 15 décembre 1791 par dix amendements constituant le *Bill of rights* américain :

- 1er am. : liberté d'expression, de religion et de la presse.
- 2e am. : droit de porter des armes.
- 3e am. : droit de propriété.
- 4e am. : l'interdiction des perquisitions et des saisies déraisonnables.
- 5e et 6e am. : règles procédurales et droit à un procès équitable.
- 7e am. : droit à un procès par jury.
- 8e am. : interdiction des amendes ou cautionnement excessifs et des peines cruelles et inhabituelles.
- 9e am. : liste des droits décrits précédemment non exhaustive.
- 10e am. : compétence de principe des États fédérés et compétence d'attribution de l'État fédéral.

Depuis, d'autres amendements ont successivement élargi la liste des droits :

- 1804 : droits relatifs au pouvoir judiciaire.
- 1865 : abolition de l'esclavage.
- 1868, 1960, 1962, 1971 : absence de discrimination dans le droit de vote, procédure de vote.
- 1913 : impôt sur le revenu.
- 1919 : droit de vote des femmes.

- 1933 : prohibition de l'alcool.

POUR ALLER PLUS LOIN

XIVe amendement ratifié le 9 juillet 1868 : « Toute personne née ou naturalisée aux États-Unis, et soumise à leur juridiction, est citoyen des États-Unis et de l'État dans lequel elle réside. Aucun État ne fera ou n'appliquera de lois qui restreindraient les privilèges ou les immunités des citoyens des États-Unis ; ne privera une personne de sa vie, de sa liberté ou de ses biens sans procédure légale régulière ; ni ne refusera à quiconque relève de sa juridiction l'égale protection des lois. »

L'adoption de ces différents amendements correspond et répond à des besoins très spécifiques du peuple américain épris de libertés. En France, les Révolutionnaires souhaiteront surtout consacrer l'égalité entre les hommes.

3. La Déclaration des droits de l'homme et du Citoyen de 1789

3.1. Le contexte de la Déclaration de 1789

Les Révolutionnaires français souhaitaient rompre avec l'absolutisme monarchique de droit divin. La société française était alors composée de trois ordres : clergé, noblesse et tiers-état. Seuls les deux premiers ordres bénéficiaient de nombreux privilèges. L'abolition des privilèges et la proclamation de l'égalité entre les hommes étaient une priorité.

L'idée d'une Déclaration des Droits a été soufflée par Lafayette, celui-ci étant inspiré des textes américains et il proposa d'ailleurs un texte corédigé avec Jefferson. Cependant, cette version ne sera pas retenue.

C'est un texte rédigé en neuf jours par Mirabeau, Jean-Jacques Desmeunier, César Guillaume de la Luzerne, François Tronchet et Claude Redon qui sera finalement adopté le 26 août 1789 par l'Assemblée nationale constituante et promulgué en tête de la Constitution française du 3 septembre 1791.

La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen est composée de 17 articles qui proclament des droits généraux sans préciser leur finalité, leurs conditions d'application ou leurs garanties juridiques, le but affiché et recherché est celui du bonheur de l'homme.

3.2. Le contenu de la Déclaration de 1789

Au travers des 17 articles qui la composent, la Déclaration énonce des valeurs, des principes et des droits.

Concernant les valeurs :

- Article 1er : les hommes sont libres et égaux.
- Article 2 : ils jouissent de droits naturels et imprescriptibles.

Concernant les libertés individuelles :

- Article 6 : égalité devant la loi.
- Article 7 : non détention arbitraire.
- Article 9 : présomption d'innocence.
- Article 10 : liberté d'opinion.
- Article 11 : liberté d'expression.
- Article 17 : propriété privée.

Concernant les principes :

- Article 3 : souveraineté nationale.
- Article 4 : seule la loi peut limiter cette liberté.

- Article 7 et 8 : seule la loi fixe les délits et les peines.
- Article 16 : principe de la séparation des pouvoirs.
- Article 13 : principe d'une contribution commune pour l'entretien de la force publique et les dépenses de l'Administration.
- Article 14 : principe du consentement à l'impôt.

On remarque une primauté de la liberté, cette dernière suppose une autonomie individuelle vis-à-vis de l'État. Selon Montesquieu, *« la liberté politique consiste dans la sûreté ou du moins dans l'opinion que l'on a de sa sûreté »*. La Déclaration s'intéresse donc au droit pénal et à la procédure pénale afin de garantir cette sûreté. Cette dernière est aussi garantie par la légalité des délits et des peines, la présomption d'innocence et l'échelle des peines.

POUR ALLER PLUS LOIN

Relativité du principe d'égalité consacré dans la Déclaration : il ne s'agit que d'une égalité juridique et non d'une égalité de citoyen. Elle ne s'applique pas aux femmes, ni aux Juifs, ni aux esclaves des colonies qui restent soumis au Code noir de Colbert.

De plus le suffrage était censitaire : seuls les plus riches possédaient le droit de vote.

Actualité. - Vers l'abrogation formelle du « Code noir »

Si l'esclavage a été définitivement aboli en France par le décret du 27 avril 1848, le « Code noir » n'avait jamais fait l'objet d'une abrogation expresse. Il était généralement regardé comme ayant perdu toute portée juridique du fait de l'abolition de l'esclavage, autrement dit comme ayant été tacitement abrogé, mais cette absence d'abrogation formelle conservait une forte portée symbolique et mémorielle.

Une proposition de loi déposée en septembre 2025 entend précisément mettre fin à cette situation. Le 28 mai 2026, l'Assemblée nationale a adopté à l'unanimité, en première lecture, un texte prévoyant l'abrogation expresse de l'ordonnance de mars 1685 dite « Code noir », ainsi que de l'ensemble des dispositions prises pour son application, son adaptation ou son extension dans les différentes colonies françaises. Le texte vise notamment les législations de 1723 et 1724 qui avaient étendu ce régime à d'autres territoires.

La proposition comporte également une dimension mémorielle : elle rattache expressément ces textes au crime contre l'humanité constitué par la traite et l'esclavage, déjà reconnu par la loi du 21 mai 2001 dite « loi Taubira ». Elle prévoit en outre un recensement des dispositions issues du droit colonial qui demeureraient encore en vigueur dans les territoires ultramarins.

3.3. Les caractères de la Déclaration de 1789

Les droits consacrés par la déclaration sont des droits individuels : aucun groupe, aucune communauté ne sont mentionnés dans la Déclaration. Cette logique s'inscrit dans le rejet par les Révolutionnaires du corporatisme de l'Ancien régime. Le décret d'Allarde des 2 et 17 mars 1791 abolira par la suite les corporations.

Puis les droits consacrés sont absolus : par principe, ils ne peuvent pas être limités. Il est défendu à l'État de s'immiscer dans la sphère privée. On qualifie ainsi les droits de 1789 comme des « libertés-barrières » ou des « libertés-résistance » face au pouvoir.

Enfin, il s'agit de droits privatifs : ces droits reposent sur la liberté civile de laquelle découle des droits politiques. La liberté est donc placée au-dessus de la loi qui est la seule à pouvoir la limiter. Cette importance de la loi dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen contribuera à la mise en place du légicentrisme en France.

3.4. Les critiques à l'encontre de la Déclaration de 1789

3.4.1. La critique contre-révolutionnaire

La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen a été immédiatement critiquée par les contre-révolutionnaires, Joseph de Maistre, Louis de Bonald et Edmond Burke, notamment pour son caractère trop abstrait et son universalisme.

Edmond Burke dénonce l'artificialité des droits civils qui ne correspondent pas aux droits naturels ainsi qu'une éventuelle subversion des gouvernements.

3.4.2. La critique féministe

L'intitulé Déclaration des droits de l'homme et du citoyen n'exclut pas explicitement les femmes dans sa rédaction, mais les habitudes politiques et juridiques de l'époque en font un usage exclusivement masculin.

En réaction, Olympe de Gouges écrira sa Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne en 1791 pour que ces droits s'appliquent aussi aux femmes en vertu de l'égalité des sexes.

Cela lui valut d'être guillotinée en 1793 pour avoir voulu « être un homme d'État ».

POUR ALLER PLUS LOIN

Article 10 de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions mêmes fondamentales ; la femme a le droit de monter sur l'échafaud, elle doit également avoir celui de monter sur à la tribune, pourvu que ses manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. »

3.4.3. La critique socialiste et marxiste

Les critiques socialiste et marxiste ont mis l'accent sur les carences de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, notamment l'absence de droits économiques et sociaux.

In fine, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen sépare d'un côté le citoyen qui interagit dans la vie politique avec certains droits et de l'autre, l'homme qui interagit dans la société civile avec des droits de l'homme qui sont essentiellement des droits du propriétaire.

Pour Karl Marx, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen fonde la liberté sur le modèle de la propriété bourgeoise avec la sacralisation du droit de propriété et l'absence de droit de solidarité. Elle laisse donc prospérer les inégalités sociales tout en les aggravant.

POUR S'ENTRAÎNER

Commentaire de texte : Article 1er Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 1789 : *« Les Hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. »*

Un vent de liberté et de révolte souffle en France lors de l'Assemblée Constituante, nourrit par l'expérience américaine. Les rédacteurs de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ont consacré une place d'honneur au principe d'égalité. L'égalité et la liberté sont donc instaurées et proclamées dès l'article 1er de la Déclaration comme des droits naturels et imprescriptibles.

Le texte de la Déclaration a une vocation universelle et il est à noter qu'il est toujours opératoire de nos jours. Ce texte est une source de droit ayant la même valeur que la Constitution.

La liberté et l'égalité entre les citoyens est une condition *sine qua none* permettant aux Révolutionnaires de s'émanciper de l'absolutisme royal et de venir construire un nouvel ordre constitutionnel.

La Déclaration des droits de l'homme s'inspire du précédent américain tout en ayant ses propres caractéristiques, elle proclame des droits individuels, absolus et privatifs. L'accent est mis sur l'égalité de tous permettant la réalisation de la liberté de chacun.

Problématique et annonce du plan : Il s'agira donc de s'interroger sur les moyens mis en œuvre pour proclamer ces principes. À travers la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, les Révolutionnaires ont consacré une liberté et une égalité entre tous les citoyens **(I)**, tout en prévoyant de possibles limitations à ces deux principes **(II)**.

I. La proclamation révolutionnaire de l'égalité et de la liberté

A. L'abolition nécessaire des privilèges

L'abolition des privilèges et des droits féodaux durant la nuit du 4 août 1789 constitue le préalable nécessaire et obligatoire pour pouvoir proclamer un nouvel ordre humain.

Les anciens droits féodaux « sont sacrifiés sur l'autel du bien public ».

L'abolition de la qualité de serf, de la mainmorte, des juridictions seigneuriales, du droit exclusif de la chasse, des privilèges et immunités pécuniaires, de la vénalité des offices, l'égalité de l'impôt et l'admission de tous les citoyens aux emplois civils et militaires permettent d'inscrire dans la Déclaration les principes de liberté et d'égalité.

B. La consécration de la liberté et l'égalité en droits

La plupart des droits et libertés dont nous sommes titulaires découlent de la liberté et de l'égalité prévues dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

Le principe d'égalité irrigue ainsi le suffrage universel, l'égalité des sexes, l'égalité devant la loi, la justice, la non-discrimination à l'emploi.

La liberté, quant à elle, est très générale et irrigue de nombreux domaines : la liberté d'aller et de venir, la liberté d'opinion, d'expression, de réunion, de religion, la liberté syndicale, le droit de grève, la liberté sexuelle… Bien qu'il s'agisse d'une Déclaration promulguée il y a plus de 200 ans, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen résonne toujours de nos jours.

Cependant, il convient d'encadrer et restreindre ces deux grands principes pour les concilier avec d'autres.

II. La relativité de la liberté et de l'égalité entre les citoyens

A. Les possibles restrictions de la liberté

L'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen définit et limite la liberté : *« La liberté consiste à faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi. »*

Il appartiendra donc au législateur de fixer les limites et de restreindre la liberté au nom de l'intérêt général.

Ici sont semées les graines du légicentrisme auquel il sera finalement mis fin deux siècles plus tard avec l'instauration du Conseil constitutionnel sous la Ve république.

Critique marxiste : liberté fondée sur le modèle de la propriété bourgeoise.

B. Les aménagements de l'égalité

L'application rigoureuse du principe d'égalité peut paradoxalement engendrer des situations inégalitaires. Le législateur peut donc instaurer « des distinctions sociales » fondées une fois de plus sur l'intérêt général.

L'égalité civile est affirmée avec force par les Révolutionnaires, mais elle n'est pas un droit naturel et imprescriptible. Le principe d'égalité a un statut supérieur, les Révolutionnaires estiment qu'il s'agit du fondement de tout droit naturel.

Critique féministe : cette égalité ne s'appliquera pas à tous et exclura les femmes pendant de nombreux siècles.

En conclusion, les Révolutionnaires ont porté aux nues les principes d'égalité et de liberté, mais ces dernières ne sont pas absolues.

Fiche nº 4 - LES CLASSIFICATIONS

POINTS CLÉS

- Il existe deux grandes méthodes de classification : la méthode doctrinale et la méthode prétorienne.
- Chaque classification a sa propre démarche et sa propre raison d'être.
- Les classifications sont réalisées en fonction d'un critère déterminé : les titulaires des libertés, l'histoire ou encore leur contenu.

PRINCIPALES RÉFÉRENCES

- Articles 7, 10 et 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
- Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.
- CE, avis, 13 août 1947.
- Cons. const., décision nº 84-181 DC du 11 octobre 1984, *Loi visant à limiter la concentration et à assurer la transparence financière et le pluralisme des entreprises de presse.*

Plusieurs tentatives de catégorisation des droits et libertés fondamentaux peuvent être mises en lumière. La difficulté réside dans le fait que chaque catégorie tente d'appréhender les droits sous un prisme différent, parfois de façon subjective. Toute classification comporte une part d'arbitraire.

Une autre difficulté est celle de l'absence de catégorisation reflétant une vérité absolue, cela explique d'ailleurs le foisonnement de tentatives. Aucune tentative de classification des libertés fondamentales ne peut prétendre à l'exhaustivité. Leur utilité ne se comprend qu'à l'aune d'une meilleure compréhension de la notion, les classifications ont une visée didactique.

Établir une classification permet de présenter les droits et libertés de manière organisée et cohérente, en les appréhendant à travers différents prismes : la chronologie, l'utilisation, l'objet ou encore la fonction.

À cet égard, il est proposé de retenir comme *summa divisio*, c'est-à-dire comme distinction majeure, les classifications doctrinales et les classifications prétoriennes.

1. Les classifications doctrinales

Ces classifications sont qualifiées de doctrinales en ce qu'elles n'ont pas été dégagées par les juges. Plusieurs sont possibles à envisager, qu'elles soient appréhendées en fonction de leur objet ou de leur chronologie, par exemple. Il faut retenir que beaucoup de libertés ne peuvent pas être rattachées à une catégorie. Cela montre la grande relativité des méthodes de classification.

1.1. La classification chronologique ou diachronique : les générations de droit

Traditionnellement, la doctrine s'accorde à reconnaître qu'il existe plusieurs générations de droits et libertés.

1.1.1. Les droits de première génération (XVIIIe siècle)

La première génération de droits correspond aux droits et libertés classiques à caractère individuel. Ce sont des droits et libertés de tradition libérale et hérités du droit naturel, théorie selon laquelle ils sont inhérents à la nature humaine, imprescriptibles et inaliénables. On parle alors de « droit de » l'individu.

Ce sont des droits civils et politiques qui ne nécessitent pas l'intervention de l'État. Au contraire, il s'agit uniquement de les concevoir comme une sphère de protection contre son empiètement : l'État ne doit pas les entraver ni les remettre en cause.

On pense par exemple à l'égalité, la liberté de croyance et de conscience, la liberté d'expression et la liberté d'aller et venir.

→ Articles 7, 10, 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789.

→ Article 10 et 11 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966.

1.1.2. Les droits de deuxième génération (XIXe siècle)

Les droits de deuxième génération sont l'expression d'une tradition moins libérale, mais plus sociale. En effet, ce sont des droits économiques et sociaux exercés par des groupes et non par des individus : ces droits ne se rattachent pas à l'individu isolé, mais plutôt à l'individu placé dans un groupe social. Ils résultent d'une longue évolution historique.

POUR ALLER PLUS LOIN

Les droits économiques et sociaux, dits de deuxième génération, résultent d'un processus ancien qui a débuté en 1793. La Constitution du 24 juin 1793 reconnaissait de nombreux droits aux citoyens impliquant une intervention positive de l'État. Il en va ainsi de la consécration du droit aux secours publics reconnus comme une « dette sacrée » pour les « citoyens malheureux » (art. 21) ou encore le droit à l'instruction qui est un besoin pour tous (art. 22). Avant, les révolutionnaires de 1789 avaient déjà envisagé des droits économiques et sociaux. Sieyès envisageait dans son second projet un droit à l'assistance pour ceux qui n'avaient pas de travail.

Historiquement, c'est le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 qui a affirmé officiellement ces principes économiques et sociaux particulièrement nécessaires à notre temps. Cette consécration correspond à l'émergence d'un État-providence.

Ces droits sociaux sont des droits-créances qui sont en opposition aux droits-libertés en ce qu'ils nécessitent l'intervention de l'État pour garantir leur effectivité : en consacrant de tels droits, l'État devient interventionniste, il doit agir pour permettre leur exercice. On parle alors ici de « droit à ».

On pense par exemple au droit de grève, au droit syndical, au droit à la santé, au droit à l'éducation ou encore au droit aux loisirs.

On observe ici une première contradiction dans la classification de ces libertés. En effet, le droit à la paresse théorisé par Paul Lafargue entre en contradiction avec le droit au travail.

→ Articles 5, 6 et 7 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.

→ Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966.

1.1.3. Les droits de troisième génération

Les droits de troisième génération sont des droits collectifs et de solidarité. Ils se différencient des droits de deuxième génération en ce qu'ils dépassent un exercice dans un groupe, mais sont inhérents à l'humanité tout entière, ils sont d'inspiration tiers-mondiste. Ils s'inscrivent dans une dynamique intergénérationnelle et dépassent le cadre d'intervention de l'État.

En d'autres termes, l'État devient lui-même incapable d'œuvrer à la consécration de ces droits en ce qu'ils dépassent le cadre des frontières : il en résulte une internationalisation des droits.

Il en va ainsi du droit à un environnement sain, du droit au développement ou encore du droit au logement.

Une critique peut être adressée à cette catégorie de droits : ils ne sont pas toujours opposables aux personnes, ce qui les rend parfois peu effectifs. Si les droits en matière environnementaux se développent, il n'en demeure pas moins que d'autres droits souffrent encore de lacunes.

→ Charte de l'environnement de 2004.

→ Cons. const., déc. n° 2022-843 DC du 12 août 2022, *Loi portant mesure d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat.*

En matière environnementale, le Conseil d'État a reconnu :

> *« Le droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, tel que proclamé par l'article premier de la Charte de l'environnement, présente le caractère d'une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du Code de justice administrative »* (CE, ord., 20 sept. 2022, n° 451129).

1.1.4. Les droits de quatrième génération

Ce sont des droits apparus du fait de l'évolution technique, technologique et scientifique. Ils relèvent d'une protection de l'individu contre toute manipulation de son corps (clonage, protection de l'embryon) ou de ses données (protection des données personnelles par voie d'information ou encore la vidéosurveillance).

Actualité. - Des droits désormais confrontés à l'intelligence artificielle et aux nouvelles biotechnologies

Les droits dits de quatrième génération ont progressivement acquis une véritable consistance juridique. En matière de bioéthique, la loi du 2 août 2021 a notamment renouvelé l'encadrement de l'assistance médicale à la procréation, de l'accès aux origines, de la recherche sur l'embryon et des techniques génétiques. Elle illustre la recherche permanente d'un équilibre entre les progrès scientifiques, l'autonomie individuelle et la protection de la dignité humaine.

Cette évolution est particulièrement importante dans le domaine numérique. La protection des données personnelles, garantie notamment par le RGPD et par les articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, est désormais confrontée au développement des traitements algorithmiques. Dans l'arrêt SCHUFA, la Cour de justice a ainsi considéré qu'un système de scoring automatisé susceptible de jouer un rôle déterminant dans l'octroi d'un crédit peut constituer une décision individuelle automatisée soumise aux garanties renforcées de l'article 22 du RGPD (CJUE, 7 décembre 2023, *SCHUFA Holding*, C-634/21).

Le règlement européen sur l'intelligence artificielle précitée marque une nouvelle étape. Adopté en 2024, il organise un encadrement des systèmes d'IA en fonction des risques qu'ils font peser notamment sur les droits fondamentaux. Certaines pratiques sont interdites, tandis que les systèmes considérés comme « à haut risque » sont soumis à des obligations renforcées de contrôle, de transparence et de supervision humaine.

⟶ Loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique.

⟶ Règl. (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des données personnelles.

⟶ Règl. (UE) 2024/1689 du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l'intelligence artificielle.

1.1.5. Une classification soumise à critique

La classification selon la génération des droits est une approche historique qui contient des lacunes et des failles. En effet, l'évolution des droits n'est pas linéaire. Il serait erroné de considérer qu'il n'y avait pas de droits sociaux et économiques avant 1946. De même, des droits civils et politiques ont été reconnus – notamment par des textes internationaux – après 1789. Ainsi, chaque génération n'efface pas la précédente, elles coexistent entre elles.

De même, cette classification ne prend pas en compte les diversités géographiques, culturelles et politiques. La reconnaissance de droits de quatrième génération, aussi importante soit-elle, n'intéresse que très peu les pays en développement dans lesquels les citoyens n'ont accès ni aux ressources nécessaires pour vivre ni, *a fortiori*, aux technologies ou encore dans les pays en proie à un régime autoritaire dans lesquels les autres libertés peinent elles-mêmes à être consacrées et protégées.

En conclusion, cette classification sert surtout de paravent à un clivage politique très européanocentré entre libéralisme et socialisme.

1.2. Les classifications en fonction de l'objet

Les classifications en fonction de l'objet sont extrêmement nombreuses, mais ne parviennent pas à englober l'ensemble des droits en raison de leur diversité. Pour cette raison, il est permis ici d'en retenir trois essentielles.

1.2.1. La distinction entre droit substantiel/droit procédural

Cette première classification permet de distinguer les droits dits substantiels et les droits qualifiés de procéduraux.

Les droits substantiels s'attachent à la matière quand les droits procéduraux regroupent les aspects procéduraux.

La particularité de cette division est qu'elle permet de mettre en lumière l'importance des droits procéduraux. En effet, ces derniers sont extrêmement importants en ce qu'ils permettent d'assurer l'effectivité de la protection des seconds : les droits substantiels nécessitent l'intervention d'un juge, le droit à un procès équitable est donc une garantie essentielle.

La Cour européenne des droits de l'homme a affirmé que :

> *« La Cour a déjà déclaré à maintes reprises que le droit à un procès équitable, garanti par l'article 6 § 1 de la Convention* […] *qui exige que soit assurée une voie judiciaire effective permettant à chaque justiciable de revendiquer ses droits civils »* (CEDH, 12 février 2003, *Bêles et a. c. République Tchèque*, n° 47273/99).

POUR ALLER PLUS LOIN

Selon un célèbre adage de Rudolf von Jhering, « ennemi juré de l'arbitraire, la forme est la sœur jumelle de la liberté ». Cette citation s'applique aisément au droit des libertés en ce que la forme, et donc la procédure, est une garantie des libertés. Supprimer toute liberté procédurale empêche le justiciable de faire valoir ses droits substantiels.

1.2.2. La distinction entre liberté physique, intellectuelle et relationnelle

Les libertés physiques sont celles qui s'attachent à la sauvegarde de la personne humaine et de son corps. Il est possible de citer notamment le droit de disposer de son corps, le droit à l'intégrité physique, le droit à la sûreté…

Les libertés intellectuelles concernent les libertés dont l'individu jouit dans l'exercice de ses activités intellectuelles ou dans son for intérieur. On retrouve entre autres la liberté d'opinion, la liberté d'expression ou encore la liberté religieuse, la liberté d'enseignement.

POUR ALLER PLUS LOIN

Dans sa décision du 20 janvier 1984, le Conseil constitutionnel a qualifié de principe fondamental reconnu par les lois de la République le principe d'indépendance des enseignants-chercheurs dans l'exercice de leurs fonctions d'enseignement et de leurs activités de recherche permettant une liberté dans l'enseignement.

Enfin, les libertés relationnelles, parfois qualifiées de libertés de l'action collective ou de l'expression collective, concernent essentiellement des libertés devant être exercées en groupe telles que la liberté d'association et la liberté de réunion.

1.3. La classification fondée sur le rôle de l'État

La classification fondée sur le rôle de l'État résulte de deux distinctions opérées par deux idéologies : celle de Jellinek et celle de Marx.

1.3.1. La distinction opérée par G. Jellinek

Jellinek expose les relations possibles entre l'État et l'individu et décrit les différents statuts, c'est-à-dire les différentes positions de l'individu face à l'État. Pour lui, les droits fondamentaux, en tant que droits subjectifs, produisent des effets différents selon la catégorie de droits considérés.

Il distingue trois types de rapports de l'individu à l'État auxquels correspondent trois fonctions des libertés :

Le caractère défensif des libertés (*status negativus*) : l'individu est fondamentalement libre d'agir et défense est faite à la puissance publique et à l'État de s'immiscer dans sa sphère de liberté. En effet, les libertés sont d'abord des droits de défense du citoyen contre l'État, cela implique une non-action de celui-ci.

Le caractère prestataire des libertés (*status positivus)* : au-delà de l'abstention, il y a des cas où l'efficacité de la garantie des droits exige une action positive de l'État. Les droits fondamentaux qui en résultent revêtent un caractère prestataire et sont qualifiés de « *droit à* » ou droit-créances.

Enfin, le *status activus* correspond aux situations dans lesquelles, l'individu doit pouvoir exercer son activité dans et pour l'État. Il doit participer à la formation de la volonté générale. Il s'agit de la mise en œuvre de la liberté de participation qui s'exprime notamment à travers les droits d'électorat et d'éligibilité.

Le succès de la typologie de G. Jellinek tient à ce qu'elle met en relief le fait que les droits fondamentaux sont d'abord des droits subjectifs opposables à l'État. Cependant, cette distinction n'est que très peu originale et correspond, à quelques exceptions près, à la distinction générationnelle.

1.3.2. La distinction opérée par K. Marx

Dans *La question juive* de 1844, texte portant sur l'émancipation des juifs dans l'Allemagne du XIXe siècle, Marx s'est livré à une critique des droits de l'Homme de 1789. Il oppose les libertés formelles aux libertés réelles.

Les droits et libertés de 1789 sont analysés par Marx comme des libertés formelles, c'est-à-dire des libertés illusoires. Il s'agit de libertés dont la consécration juridique ne s'accompagne d'aucune effectivité dès lors que ceux qui subissent l'aliénation économique ne peuvent concrètement en avoir l'usage. Par exemple, la liberté de la presse est considérée comme un non-sens pour celui qui n'a pas les moyens de faire fonctionner un organe de presse. La liberté d'opinion est secondaire pour des gens dans le besoin.

Marx oppose les libertés illusoires, formelles aux libertés réelles qui regroupent largement les droits économiques, sociaux ou les droits-créances. Selon lui, la conception des libertés formelles est la conception libérale et bourgeoise. Il ne s'agit que de proclamations de valeurs sans réels moyens d'en assurer la protection.

1.4. La distinction fondée sur le régime d'exercice

Parce que la France est un État libéral, la liberté est la règle et sa limitation l'exception.

→ Art. 5 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen

Dans ces conditions, le régime des libertés doit refléter au maximum cette conception libérale. Une classification peut être proposée en fonction du régime d'exercice des libertés, distinguant entre le régime le moins attentatoire aux libertés, le régime répressif, et celui qui est le plus contraignant à savoir le régime préventif.

1.4.1. Le régime répressif

Contrairement à ce que son nom laisse entendre, le régime répressif est le plus respectueux des libertés et il laisse l'individu agir à sa convenance. Ce régime n'intervient que pour sanctionner le franchissement de limites préalablement établies et supposées connues, conformément au principe de légalité des délits et des peines.

Dans ce cas, l'exercice d'une liberté est immédiat, sans formalité préalable, la seule limite étant le respect de la loi pénale. Lorsqu'il n'est pas observé, les juridictions répressives de droit commun peuvent sanctionner les auteurs de toute infraction définitivement constatée.

Le régime répressif est celui qui laisse l'individu exercer sa liberté tout en lui assignant des limites dont la transgression entraîne une sanction pénale prononcée par une juridiction répressive. Par la place faite au principe de liberté, le régime répressif a toujours eu la préférence des libéraux.

Le régime répressif permet une sanction *a posteriori* en raison de la violation d'une règle.

1.4.2. Le régime de la déclaration préalable

Dans ce type de régime, l'autorité administrative exige de l'individu qu'il l'informe de certaines de ces activités. L'administration est en mesure d'exercer un contrôle éclairé sur différents comportements afin de déterminer le plus efficacement possible leur compatibilité avec les exigences de l'ordre public.

Dans ce régime, l'exercice de la liberté est subordonné à une démarche à effectuer auprès de l'autorité publique qui ne dispose d'aucun pouvoir discrétionnaire ni d'aucune marge de manœuvre dans l'appréciation de la situation. La déclaration préalable n'a qu'une fonction d'information. La liberté d'association permet de bien comprendre la frontière entre régime déclaratif et régime préventif. Une association peut se constituer librement sans autorisation préalable. La déclaration prévue par la loi du 1er juillet 1901 est notamment nécessaire lorsqu'elle entend bénéficier de la capacité juridique attachée à sa publicité.

On retrouve l'exercice du régime de déclaration préalable concernant le droit associatif ou l'exercice de la liberté de manifestation. Le droit de manifester est soumis à une déclaration préalable en préfecture.

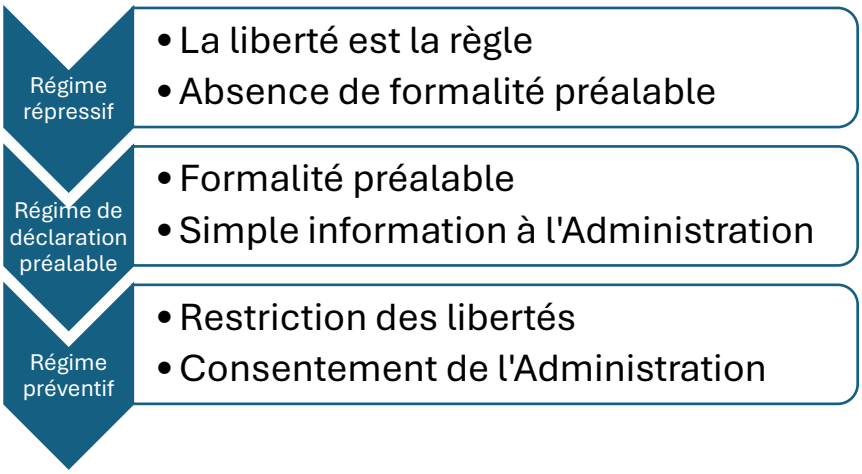
→ Art. L. 211-1 et suiv. du Code de la sécurité intérieure.

1.4.3. Le régime préventif

Avec le régime préventif, la logique est inversée par rapport au régime répressif. Pour prévenir tout dommage irréparable, il prévoit qu'une liberté ne peut être exercée que par une personne qui a requis et obtenu le consentement préalable de l'autorité publique avertie de l'action envisagée.

L'exercice de la liberté n'est plus la règle, c'est désormais sa restriction qui l'est puisque le principe est l'interdiction sauf autorisation de l'autorité administrative. Seule la loi peut prévoir un tel régime.

→ CE, ass., 22 juin 1951, *Daudignac*, n° 00590, Lebon. p. 651.



2. Les classifications prétoriennes

Ces classifications sont qualifiées de prétoriennes en ce qu'elles sont soit créées par le juge soit celui-ci va s'y référer directement. Il convient de distinguer selon qu'une classification émane du Conseil d'État ou du Conseil constitutionnel.

2.1. La classification retenue par le Conseil d'État : libertés individuelles/libertés collectives

À l'occasion d'un avis rendu le 13 août 1947, le Conseil d'État s'est livré à une classification des libertés. Il distingue ainsi deux groupes de libertés : les libertés individuelles et les libertés collectives.

Selon le Conseil d'État, les libertés fondamentales peuvent être distinguées en deux catégories. D'une part, les libertés qui sont celles dont la personne humaine peut jouir individuellement et isolément comme la liberté d'aller et venir ou la liberté individuelle. Il est question notamment du droit à la vie, du droit à la sûreté, du droit à la vie privée, de la liberté d'aller et venir, de la liberté d'opinion, du droit de propriété.

D'autre part, il fait référence à une autre catégorie, celle des libertés collectives soit :

> *« Les grandes libertés qui n'étant pas limitées à l'individu seul se manifestent en dehors et comportent l'action des coparticipants ou l'appel au public »* (CE, avis, 13 août 1947).

Dans cet avis, le Conseil d'État énumère sept exemples, à savoir la liberté de réunion, la liberté d'association, la liberté syndicale, la liberté de la presse, la liberté d'expression, la liberté religieuse, la liberté de l'enseignement.

Cette distinction a le mérite de la binarité, ce qui la rend aisée à comprendre.

2.2. La classification retenue par le Conseil constitutionnel : libertés fondamentales/libertés publiques

Dans sa décision des 10 et 11 octobre 1984, le Conseil constitutionnel introduit une nouvelle distinction. Il distingue à cette occasion les libertés publiques et les libertés fondamentales.

> → Cons. const., déc. n° 84-181 DC du 11 octobre 1984, *Loi visant à limiter la concentration et à assurer la transparence financière et le pluralisme des entreprises de presse*.

Selon cette distinction, les libertés fondamentales sont considérées comme plus importantes et bénéficient d'un régime de protection plus important en ce qu'elles permettent l'exercice des autres libertés. Le Conseil constitutionnel soumet la restriction de ces libertés fondamentales à trois conditions :

- Il est interdit de les soumettre à un régime d'autorisation préalable.
- La loi ne peut en aucun cas en restreindre l'exercice.
- Elles doivent être appliquées de manière uniforme sur l'ensemble du territoire.

Ont ainsi été reconnues comme des libertés fondamentales la liberté d'association, la liberté d'enseignement, la liberté de la presse, la liberté d'aller et venir.

> → Cons. const., déc. n° 71-44 DC du 16 juillet 1971, *Loi complétant les dispositions des articles 5 et 7 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.*

POUR S'ENTRAÎNER

Argumentation juridique : La classification des libertés fondamentales est-elle impossible ?

Dans leurs tentatives de comprendre le droit, les juristes tentent sans cesse de conceptualiser des notions. Une des tentatives de conceptualisation consiste à classifier et à distinguer. Cette méthode innerve le droit dans son ensemble : le droit est traditionnellement présenté autour de la distinction droit privé et droit public.

Classer les libertés consiste à tenter d'en organiser la diversité selon des critères juridiques, historiques ou philosophiques. Mais cette entreprise se heurte à plusieurs obstacles : évolution constante des droits, pluralité des sources, diversité des objets. Faut-il en conclure que toute tentative de classification serait vaine, voire impossible ? Ou peut-on, malgré tout, en dégager des catégories pertinentes et utiles à la compréhension du droit des libertés ?

Le droit des libertés fondamentales, entendues comme un ensemble de prérogatives personnelles qu'une société donnée estime être fondamentales (Cons. const., décision n° 84-181 DC du 11 octobre 1984), n'échappe pas à cette tendance classificatrice.

- La première raison est que le développement de l'État libéral a impliqué un accroissement du nombre de libertés reconnues et une évolution de leur philosophie. Dans un souci de comprendre le régime juridique applicable, le besoin de les classifier s'est fait ressentir.
- La seconde raison s'explique par la concurrence des notions. En effet, la classification a permis d'apporter une alternative à la distinction entre les notions de « libertés publiques », « libertés fondamentales » et « droits fondamentaux ».

Problématique et annonce du plan : La classification des libertés publiques est-elle vouée à l'échec en raison de la complexité et de la variété des libertés, ou peut-elle au contraire constituer un outil pertinent d'analyse juridique ? Si les classifications restent possibles et utiles à certains égards **(I)** elles se heurtent à de réels obstacles **(II)**.

I. L'utilité concrète de certaines classifications

Les classifications possèdent un double intérêt. Elles sont un instrument didactique de compréhension et d'analyse **(A)** et elles sont opératoires en droit positif **(B)**.

A. L'intérêt didactique des classifications

Les classifications n'ont pas vocation à être exhaustive. Il ne s'agit que d'une méthode de penser la matière.

Elles peuvent avoir une utilité dans la détermination de leur régime juridique, mais il s'agit avant tout d'un instrument de compréhension et de témoignage des évolutions.

Elles sont une grille de lecture pertinente pour l'analyse de la matière et pour refléter une vue d'ensemble de la diversité.

B. Les classifications opératoires en droit positif

Les classifications sont opératoires quand elles sont reconnues et dégagées par le juge. Elles intègrent le droit positif et favorisent leur protection.

Le juge administratif va recourir à certaines classifications (notamment celle entre liberté publique et liberté fondamentale) depuis la mise en œuvre du référé-liberté (art. 521-2 du CJA) qui organise un recours visant à la protection d'une « liberté fondamentale ».

La CEDH retient également des distinctions implicites en séparant les droits absolus (comme les articles 2 et 3 de la Convention) des droits relatifs pouvant faire l'objet d'une certaine ingérence (comme l'article 8). (CEDH, F.G. c. Suède, 23 mars 2016, n° 43611/11).

La classification permet d'identifier les régimes de contrôle, les intensités de protection, et parfois les organes compétents.

II. Les lacunes certaines des classifications des libertés fondamentales

Les classifications des libertés fondamentales ont des lacunes et à ce titre, elles peuvent être critiquées. En effet, soit elles ne parviennent pas à refléter la diversité des libertés **(A),** soit elles sont empreintes d'un dogme empêchant toute distinction objective **(B)**.

A. L'impuissance à refléter la diversité des libertés

Les classifications peinent à refléter la diversité des libertés puisqu'il s'agit d'un mécanisme de conceptualisation qui n'est pas dynamique : elles appréhendent les libertés à un moment donné.

Les sources évoluent et se diversifient, notamment sous l'influence du droit européen et international. La multiplicité des origines rend complexe une représentation concrète des libertés.

Le contenu des libertés est en constante évolution. Souvent, le juge fait évoluer leur contenu ou leur reconnaît un nouveau statut (Cons. const., décision n° 71-44 DC du 16 juillet 1971 dite « Liberté d'association »). Le juge évite d'adopter des classifications trop rigides qui le contraindraient ultérieurement et qui limiteraient son pouvoir créateur.

Enfin, il existe de nombreuses interactions entre les libertés et les classifications peuvent semer de la confusion : la liberté individuelle peut s'opposer à la liberté collective, mais elle peut être aussi la protection contre la détention arbitraire.

B. Derrière les classifications empreintes, les dogmes

La plupart des classifications ne sont pas objectives.

Elles sont le fruit d'une influence géographique et culturelle : les libertés de troisième et quatrième génération n'ont que peu d'importance dans des pays mal développés tandis que leur influence est croissante dans des États développés.

Les classifications doctrinales des libertés tentent de refléter la conception d'une société. Pour Karl Marx, la théorie des libertés ne peut entrer en contradiction avec sa conception de la société bourgeoise et capitaliste.

En conclusion, les classifications sont artificielles et floues. Leur utilité ne saurait être contestée, mais leurs limites sont flagrantes. Il convient de les aborder avec du recul pour ne pas perdre de vue qu'il ne s'agit que d'une méthode et non d'une fin en soi.

Fiche nº 5 - LES PRINCIPES DIRECTEURS

POINTS CLÉS

- Il existe de nombreux principes directeurs, c'est-à-dire des principes ayant une force suffisamment générale pour qu'ils puissent s'imposer à tout individu et à tout État.
- Parmi ces principes, on retrouve l'inaliénabilité des droits, la dignité, l'indivisibilité et l'universalité.
- Bien qu'ils soient consacrés par plusieurs textes, ces principes souffrent souvent de lacunes.
- Ces lacunes impliquent qu'ils soient parfois remis en question et que la protection des droits soit parfois moins importante.

PRINCIPALES RÉFÉRENCES

- Préambule de la Déclaration universelle des droits de l'homme.
- Article 20 de la Charte africaine des droits de l'homme.
- Article 5 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
- Article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme.

1. L'inaliénabilité des droits humains

L'inaliénabilité d'un droit signifie qu'il ne peut être cédé. Certains droits, comme les droits humains, sont inaliénables, c'est-à-dire que les individus ne peuvent pas y renoncer d'eux-mêmes.

Cette notion renvoie donc expressément à la renonciation de ses droits. Celle-ci peut être contrainte, mais parfois volontaire.

Il était possible de retrouver cette notion d'inaliénabilité dans les théories de l'état de nature puisque dans cet état, les hommes étaient libres. En raison de leur qualité d'êtres humains, les individus disposaient de droits subjectifs, universels et inaliénables, auxquels ils ne sauraient renoncer.

L'inaliénabilité des droits humains a été consacrée dans une multitude de textes de droit positif. Cependant, le sujet de la renonciation par l'individu lui-même mérite d'être questionné.

1.1. Les fondements textuels de l'inaliénabilité

Le caractère inaliénable des droits humains a été proclamé dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. En effet, le préambule dispose que :

> *« Les représentants du peuple français, constitués en Assemblée nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer, dans une déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme »* (Préambule DDHC).

Par la suite, ce principe a été consacré par le préambule de la Constitution de 1946 dont le premier alinéa prévoyait :

> *« Au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d'asservir et de dégrader la personne humaine, le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés »* (Préambule de la Constitution de 1946).

Les textes internationaux n'ont pas ignoré ce principe directeur. En effet, la Déclaration universelle des droits de l'homme, se situant dans la lignée de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, proclame également dans son préambule la protection de droits égaux et inaliénables.

De même, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples prévoit dans son article 20, une référence au caractère inaliénable des droits humains.

Il est possible de remarquer que les différentes consécrations du caractère inaliénable des droits humains interviennent en réaction à des événements passés. Le préambule de 1946, comme la Déclaration universelle des droits de l'homme, proclame l'inaliénabilité des droits en réponse aux violations massives des droits durant la Second Guerre mondiale.

L'article 20 alinéa 1er de la Charte africaine dispose que :

> *« Tout peuple a droit à l'existence. Tout peuple a un droit imprescriptible et inaliénable à l'autodétermination. »*

Il s'agit d'une réponse aux violations des droits commises par les puissances coloniales.

La consécration de ce principe d'inaliénabilité des droits humains a pour conséquence que nulle personne ne peut confisquer volontairement les droits d'une autre. Cependant, la question du renoncement volontairement interroge. Il s'agit du cas précis dans lequel l'individu choisit de renoncer ou aliéner certains de ces droits proclamés.

1.2. La question de la renonciation volontaire

Deux exemples peuvent illustrer la question de l'alinéation volontaire, par l'individu lui-même, de ses droits. Il s'agit de la question du droit à la fin de vie et de celle du droit de se faire mal en recourant à des pratiques sadomasochistes.

1.2.1. L'inaliénabilité et la fin de vie

Le droit à la vie est reconnu comme attaché à la personne humaine. À ce titre, l'article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme dispose que :

> *« Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. »*

Le droit à la vie est donc le droit le plus élémentaire des droits humains, car sans une protection stricte, la proclamation des autres droits ne sert à rien.

La Cour européenne des droits de l'homme a reconnu au droit à la fin de vie un caractère inaliénable en estimant que le droit à la vie est :

> *« Un attribut inaliénable de la personne humaine* […] *une valeur suprême dans l'échelle des droits de l'homme sur le plan international »* (CEDH, *G.C. Streletz, Kessler et Krenz c. Allemagne*, 22 mars 2001, n° 34044/96).

Cependant, ce caractère inaliénable se heurte à certaines législations telle que celle sur la fin de vie. Le rapport à la mort a évolué sous l'influence des progrès de la médecine, mais également en raison d'un changement dans la représentation sociale de la mort.

La volonté de « bien mourir », entendue comme la mort décidée par la personne elle-même en raison de souffrances ou de dégradations irréversibles de l'état de santé, est devenue une revendication sociale.

La question de la fin de vie se heurte cependant à une conception objective du droit à la vie et de la dignité humaine. Cette dimension objective transcende l'individu et fait du corps humain un objet « sacré » qui n'est pas à la disposition de l'individu.

POUR ALLER PLUS LOIN

La conception objective domine encore aujourd'hui malgré plusieurs évolutions médicales et sociales. Le Code civil dispose encore que « le corps humain est inviolable » en son article 16-1 al. 2. Cela signifie que le corps humain est inaliénable en ce qu'il insusceptible de faire l'objet d'une patrimonialisation. En découle l'interdiction de recourir à la gestation pour autrui (art. 16-7) ou de proposer son corps pour des expérimentations sur le corps ou les organes (art. 16-6).

L'approche objective revêt une dimension ontologique à partir du moment où elle défend la dignité de la nature humaine comme valeur sacrée et inaliénable tandis que l'approche subjective défend une posture individualiste en faisant de la dignité non plus un instrument de défense, mais un attribut de sa propre liberté : chaque individu s'érige en seul juge de la qualité de sa vie ou de sa mort.

1.2.2. L'inaliénabilité et le droit de se faire mal

L'inaliénabilité renvoie à la renonciation de ses droits. Il est donc question ici de la renonciation volontaire au droit à l'intégrité physique ou au droit à la vie privée.

Le droit de se faire mal renvoie à la question de savoir si l'état démocratique libéral est fondé à protéger l'individu contre ce qu'il estime être un mauvais usage par l'individu lui-même de sa propre liberté.

Classiquement, la liberté consiste à faire ce qui ne nuit pas à autrui (art. 4 DDHC). De même, l'article 5 du même texte prévoit que :

> *« La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société »* (art. 5 DDHC).

Pour vérifier si la répression des pratiques sadomasochistes constitue ou non une atteinte à la vie privée, la Cour européenne des droits de l'homme prend en compte deux principes en mettant en balance la protection de l'intégrité physique et la garantie de l'autonomie personnelle par la renonciation volontaire à certains droits.

D'une part, le principe de l'autonomie personnelle renvoie à la libre disposition de soi. D'autre part, le principe du consentement prévoit que chacun a le droit d'entretenir des relations sexuelles.

Dans son arrêt *KA et AD c. Belgique* de 2005, la Cour européenne indique que la faculté pour chacun de mener sa vie comme il l'entend peut également inclure la possibilité de s'adonner à des activités comme étant d'une nature physiquement ou moralement dommageable ou dangereuse pour sa personne.

Néanmoins, si une personne peut revendiquer le droit d'exercer des pratiques sexuelles le plus librement possible, c'est dans le respect de la volonté de la victime de ses pratiques dont le propre droit au libre choix quant aux modalités d'exercice de sa sexualité doit aussi être garanti. Ceci implique que les pratiques se déroulent dans des conditions qui permettent un tel respect du consentement de la victime.

> → CEDH, *KA et AD c. Belgique*, 17 février 2005, n° 42758/98 et n° 45558/99.

2. L'universalité des droits humains

L'universalité des droits humains est l'un des principes directeurs codifié dans le droit international à partir du XXe siècle. Elle constitue l'idée centrale, comme son nom l'indique, de la Déclaration universelle des droits de l'homme.

L'universalité signifie que tous les êtres humains jouissent des mêmes droits fondamentaux du seul fait de leur humanité, où qu'ils vivent et qui qu'ils soient, indépendamment de leur statut ou de toute caractéristique particulière.

Le principe d'universalité est présent dans de nombreux textes. Par exemple, la Déclaration universelle des droits de l'homme précise dans son préambule que :

> *« Considérant que les États Membres se sont engagés à assurer, en coopération avec l'Organisation des Nations unies, le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »*

De même, sans prétendre directement et expressément à une application universelle, la Convention européenne des droits de l'homme renvoie à la Déclaration universelle pour permettre :

> *« La reconnaissance et l'application universelles et effectives des droits qui y sont proclamés. »*

Enfin, la Charte africaine prévoit dans son article 60 que la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples s'inspire de la Déclaration universelle des droits de l'homme.

Bien que de nombreux textes tentent de consacrer ce principe d'universalité, on remarque que, en pratique, ce principe souffre de lacunes. Il est possible d'en citer deux parmi lesquelles on trouve des lacunes terminologiques et géographiques.

2.1. La limite terminologique de l'universalité : droits de l'homme ou droits humains ?

La notion de droit de l'homme est très proche de celle de liberté fondamentale. Il s'agit d'une notion marquée par une série de représentations. Ce terme et très marqué par la période révolutionnaire et par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Il s'agit d'une conception *jus naturaliste* des droits, c'est l'idée qu'ils sont inhérents à la nature humaine est transcendante et existe en dehors de l'existence d'un quelconque texte juridique.

Par exemple, le préambule de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen évoque *« les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme »*. On remarque que l'utilisation de ces termes dans des textes juridiques internationaux est justifiée par un idéal commun dans la nature humaine qui transcende les frontières, il y a une dimension philosophique commune.

Pourtant aujourd'hui, l'expression reflète peu cet universalisme. Le terme « homme » ne saurait englober l'ensemble des individus. Il s'agit d'une limite terminologique à l'universalisme des droits.

C'est pourquoi, l'expression « droits humains » possède cette dimension philosophique universaliste en ce qu'elle permet, par un changement étymologique, de ne pas privilégier un genre ou induire une bivalence entre les sexes.

Il s'agit d'une expression utilisée au nom de l'universalité. Le recours à l'expression « droit de l'homme » impliquerait que cela ne concerne pas les femmes qui seraient placées dans une situation d'infériorité (droit de vote, incapacité étendue, inégalité). Sur le plan linguistique, la référence aux droits de l'homme pour désigner les deux sexes serait le produit historique d'une volonté de hiérarchiser. L'expression droits humains tend à pallier ce problème par une notion nouvelle et neutre.

Si cette notion demeure essentiellement absente du droit français, on la retrouve par exemple dans le Code de commerce à l'article L. 225-102-4 qui dispose que :

> *« Le plan* [de vigilance] *comporte les mesures de vigilance raisonnable propres à identifier les risques et à prévenir les atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi que l'environnement, résultant des activités de la société. »*

2.2. La limite géographique de l'universalité : protection régionale ou universelle ?

Le développement du droit international des droits de l'homme ne doit pas laisser croire à une adhésion universelle et inconditionnelle à la conception moderne des libertés.

2.2.1. La difficile universalité au niveau mondial

Un lien est souvent établi entre l'hégémonie économique, politique et culturelle du monde occidental et la vision et le discours des droits humains. La conception moderne des libertés fondamentales traduit une philosophie de l'individu et de sa place dans la société qui s'est développée avec les sociétés occidentales.

On remarque ainsi que cette philosophie occidentale cohabite souvent mal avec d'autres systèmes de pensée qui valorisent notamment la collectivité aux dépens de l'individu, notamment sous l'influence de la religion.

Par exemple, la Charte africaine des droits de l'homme a une forte dimension collective notamment en incluant dans son nom le terme « Peuples » et en disposant dans son préambule que :

> *« Tenant compte des vertus de leurs traditions historiques et des valeurs de civilisation africaine qui doivent inspirer et caractériser leurs réflexions sur la conception des droits de l'homme et des peuples. »*

La conception africaine des droits de l'homme s'exprime essentiellement par l'affirmation de devoirs de l'homme à l'égard de sa famille et de la communauté nationale.

De même, dans la culture arabo-musulmane, certains textes énumèrent des droits et libertés humains tout en rappelant la supériorité de la loi islamique.

Par exemple, l'article 3 de la Charte arabe des droits de l'homme adoptée en 1994 précise que :

> *« L'homme et la femme sont égaux sur le plan de la dignité humaine, des droits et des devoirs dans le cadre de la discrimination positive instituée au profit de la femme par la charia islamique et les autres lois divines et par les législations et les instruments internationaux »* (art. 3 de la Charte arabe des droits de l'homme de 1994).

L'article 24 de la Déclaration du Caire sur les droits de l'homme en Islam affirme que :

> *« Tous les droits et libertés énoncés dans* […] *la Déclaration sont soumis aux dispositions de la Charia. »*

C'est pour tenir compte de ces diversités culturelles et géographiques que les instruments universels de protection des droits humains peinent à être véritablement contraignants. Même si certains de ces textes régionaux visent la Déclaration universelle des droits de l'homme, cette dernière n'en demeure pas moins qu'une résolution des Nations unies aux effets non contraignants.

2.2.2. La difficile universalité au niveau régional et étatique

C'est également pour prendre en compte l'absence d'universalité réelle à l'intérieure même d'un système de protection régional que la Cour européenne des droits de l'homme a une jurisprudence prudente sur certains sujets, en s'en remettant à la « marge nationale d'appréciation » de l'État.

Elle considère, en effet, que les autorités nationales se trouvent souvent mieux placées pour apprécier toute l'ampleur d'un problème et y apporter des solutions les plus adaptées. La Cour laisse donc les États choisir les mesures qui leur paraissent les plus appropriées pour s'acquitter de leurs obligations.

Par exemple, concernant l'homosexualité, la Cour reconnaît que malgré certaines avancées, il y a une absence de consensus et d'universalité entre les États sur le sujet. Elle retient donc que :

> *« Néanmoins, la Cour a seulement admis dans sa jurisprudence que la relation affective et sexuelle qui unit un couple homosexuel relève de la "vie privée", mais non qu'elle se rapporte au domaine de la "vie familiale", même lorsqu'est en jeu une relation entre deux personnes vivant ensemble. Elle est parvenue à cette conclusion après avoir observé que, malgré l'évolution constatée dans plusieurs États européens tendant à la reconnaissance légale et juridique des unions de fait stables entre homosexuels, il s'agit là d'un domaine dans lequel les États contractants, en l'absence d'un dénominateur commun amplement partagé, jouissent encore d'une grande marge d'appréciation »* (CEDH, 24 juin 2010, *Schalk et Kopf c. Autriche*, n° 30141/04).

Enfin, l'universalité est aussi interrogée à l'intérieur de l'État et notamment en France. Ce débat sur l'universalité des droits humains se cristallise largement avec le fait religieux. Il n'est pas sans lien avec la question de la place qu'il convient d'accorder à certaines expressions et pratiques religieuses dans l'espace public.

3. L'unité ou l'indivisibilité des droits humains

POUR ALLER PLUS LOIN

À plusieurs reprises, les juridictions françaises ont été amenées à se prononcer sur de telles questions. La Cour de cassation a approuvé le refus d'une cour d'appel de reconnaître en France une répudiation prononcée au Maroc au motif que cette répudiation était contraire au principe d'égalité des époux (Cass., 1re civ, 4 novembre 2009). De même, le Conseil d'État a estimé que le gouvernement pouvait refuser l'acquisition de la nationalité française pour défaut d'assimilation d'une femme qui avait une pratique religieuse radicale et incompatible avec le principe d'égalité des sexes.

L'unité (ou l'indivisibilité, car les termes seront employés de manière indifférente) des droits humains signifient qu'ils ne constituent qu'un tout. L'indivisibilité des droits humains est un principe fondamental selon lequel ces derniers sont liés entre eux, interdépendants et doivent être considérés comme un tout cohérent.

Cela signifie qu'on ne peut pas hiérarchiser ou fragmenter les droits humains en estimant que certains seraient plus importants ou prioritaires que d'autres.

C'est pourquoi, la Déclaration de Vienne de 1993 précise en son point n° 5 que :

> *« Tous les droits de l'homme sont universels, indissociables, interdépendants et intimement liés. La communauté internationale doit traiter des droits de l'homme globalement, de manière équitable et équilibrée, sur un pied d'égalité et en leur accordant la même importance. S'il convient de ne pas perdre de vue l'importance des particularismes nationaux et régionaux et la diversité historique, culturelle et religieuse, il est du devoir des États, quel qu'en soit le système politique, économique et culturel, de promouvoir et de protéger tous les droits de l'homme et toutes les libertés fondamentales. »*

Pour autant, l'introduction de classifications aux visées pédagogiques ou pratiques induit nécessairement une classification des droits humains mettant en cause leur indivisibilité. La division essentielle qui porte atteinte à l'unité des droits est celle entre droits civils et politiques et droits économiques, sociaux et culturels.

L'étude des instruments de protection illustre parfaitement cette dichotomie entre les droits. Dans le cadre onusien, ce sont deux pactes différents, pourtant conclus la même année, qui s'appliquent : d'un côté le pacte international relatif aux droits civils et politiques et de l'autre, le pacte international relatifs aux droits économiques, sociaux et culturels. Cette dichotomie implique une hiérarchisation des droits. Il s'agit d'une opposition entre les conceptions libérales et socialistes des droits.

Pourtant, l'indivisibilité des droits est une condition nécessaire pour préserver l'universalité, car la garantie des droits économiques, sociaux, culturels, voire environnementaux est aussi nécessaire que celle des droits civils et politiques pour protéger les individus. De même, tous les droits ont une dimension économique, sociale, culturelle impliquant des devoirs pour les États et les individus, et qui seuls en permettent l'effectivité.

Pour transcender cette opposition, la Déclaration universelle fonde l'indivisibilité des droits sur la dignité et l'unité de l'homme. Aux termes de la résolution 421 de l'Assemblée générale des Nations unies :

> *« La Déclaration universelle des droits de l'homme envisage l'homme comme une personne à laquelle appartiennent indubitablement des libertés civiques et politiques, ainsi que des droits économiques, sociaux et culturels. »*

C'est précisément à partir de l'idée d'unité des droits garantis que la Cour européenne a consacré la dimension économique et sociale de certains droits civils et politiques qui étaient absents du texte de la Convention, à partir des années 1970.

Par exemple, dans un arrêt de 1979, la Cour énonce la nécessité de prendre en compte la situation économique de la requérante pour apprécier l'effectivité de son droit au recours. Elle affirme dans son arrêt *Airey c. Irlande* que :

> *« Nulle cloison étanche ne sépare la sphère des droits économiques et sociaux du domaine de la Convention* […]. *La Convention a pour but de protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs »* (CEDH, *Airey c. Irlande*, 9 octobre 1979, n° 6289/73).

4. Le principe matriciel : la dignité humaine

4.1. La définition de la dignité de la personne humaine

La dignité de la personne humaine désigne la valeur inaliénable attachée à tout être humain, indépendamment de ses caractéristiques sociales, physiques, morales ou juridiques. Elle implique que nul ne peut être traité comme un simple moyen ou objet, et commande le respect de l'intégrité, de l'autonomie et de l'égalité de chacun.

Elle est souvent qualifiée de « source » ou de « principe directeur » des droits de l'homme, car elle constitue leur fondement éthique et juridique commun.

La dignité est affirmée dans de nombreux textes de protection des droits humains.

Avant d'être une notion juridique, la dignité de la personne est une notion théologique et philosophique. Dans les discours théologiques de la fin du Moyen Âge, la dignité est synonyme de liberté, de libre arbitre : elle renvoie alors à l'autonomie de la personne.

Dans la pensée Thomiste (pensée de Thomas d'Aquin) :

> *« L'homme est digne en ce qu'il participe de façon déterminée à un univers voulu et organisé par Dieu. »*

Sur le plan philosophique, la dignité est la capacité de l'homme à penser. Selon Pascal :

> *« Toute la dignité de l'homme consiste en la pensée. »*

Kant marque la dernière évolution philosophique importante du concept de dignité dans son œuvre *Fondement de la pensée métaphasique des mœurs* dans laquelle il estime que :

> *« La dignité est l'antithèse du prix marchand* […] *ce qui a un prix peut être aussi bien remplacé par quelque chose d'autre* […] *au contraire ce qui est supérieur à tout prix et par suite n'admet pas d'équivalent, c'est ce qui a une dignité. »*

4.2. Les consécrations de la dignité de la personne humaine

Ainsi, le préambule de la Charte des Nations unies dispose que :

> *« Nous, peuple des Nations unies, résolus à préserver les générations futures du fléau de la guerre qui deux fois en l'espace d'une vie humaine a infligé à l'humanité d'indicibles souffrances, à proclamer à nouveau notre foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine* […]. *»*

De même, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne précise dans un chapitre 1er intitulé « la dignité » et dans son article 1er relatif à la dignité humaine que :

> *« La dignité humaine est inviolable. Elle doit être respectée et protégée. »*

Il en est de même pour la Déclaration universelle des droits de l'homme qui, en son article 1er, consacre également un tel principe.

Placée au frontispice de ces textes internationaux, la dignité est un principe directeur en ce qu'elle reflète et conditionne la nature humaine.

En France, le Conseil constitutionnel a dégagé de l'interprétation du Préambule de la Constitution de 1946 que :

> *« La sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme d'asservissement et de dégradation est un principe à valeur constitutionnelle »* (Cons. const., décision n° 94-343/344 DC du 27 juillet 1994, *Loi relative au respect du corps humain et loi relative au don et à l'utilisation des éléments et produits du corps humain, à l'assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal*).

La dignité est consacrée dans presque toutes les Constitutions des États européens ainsi, par exemple, l'article 1er de la première partie de la loi fondamentale allemande de 1949 prévoit que la dignité de l'homme est intangible. L'article 1er de la Constitution portugaise de 1976 indique que le Portugal est une République souveraine fondée sur la dignité de la personne humaine.

Le bloc de constitutionnalité comporte une seule occurrence de la dignité à l'article 6 de la Déclaration de 1789, mais elle désigne alors la charge ou la fonction :

> *« Tous les citoyens sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics selon leur capacité et sans autre distinction que celle de leur vertu et de leur talent. »*

La dignité entendue comme la qualité de la personne humaine est en revanche absente du bloc de constitutionnalité.

POUR ALLER PLUS LOIN

La question de la consécration constitutionnelle explicite du respect de la dignité s'est posée dernièrement à l'occasion de la révision constitutionnelle de 2008. Le rapport du comité Balladur a toutefois renoncé à faire une proposition en ce sens en raison « des délicates questions de principe plus idéologiques que proprement juridiques », que pose la dignité.

4.3. La portée du principe de dignité

Dans sa décision de 2010, *M. Daniel W*, le Conseil constitutionnel a jugé que la dignité de la personne figure au nombre des droits et libertés que la Constitution prévoit et peut être invoquée à l'appui d'une QPC.

→ Cons. const., déc. n° 2010-14/22 QPC, 30 juillet 2010, *Daniel W et autres.*

Pour le juge administratif, la dignité n'est pas un droit, mais une composante de l'ordre public, elle constitue donc une limite à la liberté. Dans ses arrêts *Commune de Morsang-sur-Orge* et *Ville d'Aix en Province de 1995*, le Conseil d'État juge que :

> *« Il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police municipale de prendre toutes mesures pour prévenir une atteinte à l'ordre public ; que le respect de la dignité de la personne humaine est une des composantes de l'ordre public ; que l'autorité investie du pouvoir de police municipale peut même en l'absence de circonstance locale particulière, interdire une attraction qui porte atteinte au respect de la dignité de la personne humaine »* (CE, ass., 27 octobre 1995, *Commune de Morsang-sur-Orge,* n° 136727).

4.4. Les droits couverts par le principe de dignité

La dignité est protégée sous de nombreux aspects en particulier. Elle peut renvoyer au principe de non-discrimination.

Dans une résolution sur la discrimination dont sont victimes les personnes transsexuelles, adoptée en 1989, le Parlement européen affirme que la dignité de l'homme implique nécessairement le droit de mener une vie conforme à son identité sexuelle. La CJCE s'est inscrite dans une telle approche puisque dans un arrêt de 1996 rendu à propos du licenciement d'un transsexuel, elle a jugé que le droit de ne pas être discriminé en raison de son sexe s'applique aux discriminations qui trouvent leur origine dans la conversion sexuelle d'un individu.

→ CJCE, n° C-13/94, Arrêt de la Cour, *P contre S et Cornwall County Council*, 30 avril 1996.

La dignité peut également être rattachée à l'interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants.

Selon la Cour européenne des droits de l'homme, l'un des principaux buts de l'article 3 de la Convention est de respecter la dignité et l'intégrité physique de la personne. Toutefois, pour la Cour, un traitement inhumain et dégradant n'est constitutif d'une violation de la dignité que s'il atteint un minimum de gravité, lequel est apprécié en fonction des circonstances.

→ CEDH, *Irlande c. Royaume-Uni*, 18 janvier 1978, n° 5310/71.

Enfin, la dignité peut être rattachée à la protection du droit à la vie. Dans sa décision de 2001, le Conseil constitutionnel a jugé qu'en portant de 10 à 12 semaines le délai pendant lequel peut être pratiquée une IVG lorsque la femme enceinte se trouve du fait de son état dans une situation de détresse, la loi n'a pas :

> *« En l'état des connaissances et des techniques, rompu l'équilibre entre la sauvegarde de la dignité de la personne humaine et la liberté de la femme »* (Cons. const., déc., n° 2001-446 DC, 27 juin 2001, *Loi relative à l'IVG et à la contraception*).

Ici, le conseil contrôle l'équilibre trouvé par le législateur entre la liberté de la femme d'avorter et le respect de la dignité d'une personne humaine en projet.

POUR S'ENTRAÎNER

Argumentation juridique : Soutenez que l'universalité des droits humains est impossible.

L'universalité des droits humains constitue l'un des fondements proclamés du droit international contemporain, en particulier depuis la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Ce principe postule que tous les êtres humains, partout et toujours, doivent jouir des mêmes droits fondamentaux, indépendamment de leur origine, culture, religion, ou régime politique.

Mais cette prétention à l'universalité fait aujourd'hui l'objet de nombreuses remises en cause. Loin d'être un consensus, elle apparaît pour certains comme une construction idéologique occidentale, inadaptée à la diversité des cultures et des traditions. En d'autres termes, il se pourrait que l'universalité des droits humains soit, dans les faits comme en droit, impossible à réaliser.

Problématique : L'universalité des droits humains est-elle une réalité juridique et philosophique, ou bien une fiction incompatible avec la diversité des conceptions humaines du bien, du juste, et du droit ?

Nous soutiendrons ici que l'universalité des droits humains est impossible, tant en raison de l'ancrage culturel des normes **(I)**, que du manque de consensus sur leur mise en œuvre concrète dans les systèmes juridiques **(II)**.

I. L'universalité des droits humains est impossible en raison du relativisme culturel et des conflits de valeurs

A. Les droits humains comme produit d'une culture particulière

L'idée même de droits « naturels », puis « universels », est née dans le contexte européen moderne, avec les Lumières, la Révolution française et la Déclaration de 1789.

Les critiques postcoloniales soulignent que les droits humains reflètent une certaine vision individualiste et sécularisée de la personne humaine, étrangère à d'autres traditions : confucianisme, islam, cultures communautaires africaines…

Jack Donnelly parle de « droits humains à saveur occidentale » : leur prétention à l'universalité est perçue comme une forme d'impérialisme moral.

B. Le relativisme culturel et les contestations politiques de l'universalité

De nombreux États invoquent leur souveraineté ou leur spécificité culturelle pour rejeter certaines obligations : par exemple, refus de reconnaître les droits des minorités sexuelles, restrictions à la liberté de religion…

La Charte africaine des droits de l'homme (1981) insiste sur les devoirs envers la communauté et les valeurs africaines, s'éloignant du modèle libéral occidental.

Le « consensus de Bangkok » (1993) exprime le refus de voir imposer des standards universels perçus comme occidentaux.

II. L'universalité des droits humains est impossible en raison des divergences dans leur interprétation et leur effectivité

A. L'absence de consensus sur le contenu et la hiérarchie des droits

La Déclaration universelle des droits de l'homme énumère un catalogue de droits civils, politiques, économiques et sociaux, mais leur hiérarchisation et leur interprétation varient fortement.

Les pays occidentaux mettent l'accent sur les libertés individuelles, tandis que d'autres (pays en développement notamment) insistent sur les droits collectifs, le développement, ou la sécurité.

Des droits nouveaux (droit à un environnement sain, droit à la paix) divisent encore plus la communauté internationale.

B. Des systèmes juridiques qui traduisent inégalement ces droits

Les traités internationaux sont souvent signés, mais non ratifiés ou appliqués de manière sélective.

Même au sein de l'Europe, des différences importantes existent dans l'interprétation de droits fondamentaux : l'interdiction du voile intégral, par exemple, oppose la France à d'autres États membres du Conseil de l'Europe.

La Cour européenne des droits de l'homme reconnaît elle-même une « marge d'appréciation nationale », ce qui revient à relativiser l'universalité.

En conclusion, l'universalisme des droits humains demeure une idéalisation utile, mais intrinsèquement contradictoire avec la diversité culturelle, politique et juridique du monde contemporain. Sous couvert d'universalité, les droits humains sont souvent perçus comme le vecteur d'une vision particulière du monde, historiquement située. Le principe reste davantage un horizon normatif dont l'effectivité est profondément conditionnée par les rapports de force et les contextes culturels qu'une réalité juridique.

Fiche nº 6 - LES RÉGIMES

POINTS CLÉS

- Régime répressif.
- Régime préventif.
- Régime déclaratif.
- Ordre public.
- Test de proportionnalité.
- Pouvoir de police.

PRINCIPALES RÉFÉRENCES

- Art. 34 de la Constitution.
- Art. 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
- Cons. const., déc. nº 82-141 DC, 27 juillet 1982, *Loi sur la communication audiovisuelle*.
- Art. L. 211-1 du Code de la sécurité intérieure.

1. Une nécessité de conciliation des libertés avec d'autres impératifs

1.1. Les principes généraux

La protection des droits et libertés doit nécessairement se concilier avec les exigences de sécurité et de maintien de l'ordre public. Il s'agit d'une compétence du législateur selon l'article 34 de la Constitution et faisant intervenir d'autres acteurs en fonction des règles de conciliation.

→ Cons const., déc. nº 2003-467 DC, 13 mars 2003, *Loi pour la sécurité intérieure.*

Dans ce cadre, le législateur peut opter entre plusieurs approches relatives à la conciliation de ces deux notions :

- Le régime répressif.
- Le régime préventif.

À noter : de nombreux auteurs développent leur approche des régimes selon cette binarité des régimes répressif / préventif. Il faut cependant mentionner un autre type de régime dit « déclaratif ». Il est souvent inclus directement dans la réflexion sur le régime préventif en ce qu'il nécessite également une action avant l'exercice de la liberté, mais en diffère, car il n'impose aucune autorisation. Il s'agit d'une information ou d'une déclaration d'exercice (voir *infra*).

Dans le cadre de ces régimes et de la conciliation des libertés publiques avec la notion d'ordre public, trois conditions ont par la suite été développées, sous l'impulsion de la Cour européenne des droits de l'homme et appelées par le Conseil d'État le « triple test de proportionnalité », pour encadrer la légalité d'une mesure de police par un contrôle « entier » :

- La nécessité d'une telle mesure pour la préservation de l'ordre public.
- Le caractère adapté de la mesure.
- La proportionnalité de la mesure pour atteindre cet objectif.

→ CE, ass., 26 octobre 2011, *Association pour la promotion de l'image et autres*, nº 317827.

1.2. La notion d'ordre public

La notion d'ordre public, avec laquelle doivent se concilier les droits et libertés, connaît une définition particulièrement large. Elle correspond aux considérations sociales essentielles et à des valeurs fondamentales de la société.

L'ordre public est de plus une notion particulièrement malléable, correspondant à la fois à des notions concrètes et abstraites, qui peut être subdivisée en un ordre public matériel et immatériel.

L'ordre public matériel correspond au triptyque classique :

- Sécurité.
- Salubrité.
- Tranquillité.

À titre d'exemple, voir notamment :

→ CE, CHR, 15 novembre 2017, *Ligue française pour la défense des droits de l'homme et du citoyen*, n° 403275.

→ CE, 6 février 1903, *Terrier*, n° 07496.

L'ordre public a également évolué uniquement dans la jurisprudence administrative vers une acception « immatérielle » incluant les notions :

- Dignité.
- Morale.

→ CE, sect., 18 décembre 1959, *Société Les films Lutetia*, n° 36385 et 36428.

→ CE, ass., 27 octobre 1995, *Commune de Morsang-sur-Orge et Ville d'Aix-en-Provence*, n° 43835/11.

À noter, le professeur Maurice Hauriou considérait à l'origine comme inconcevable l'extension de la notion d'ordre public en dehors de son acception « matérielle », rejetant l'idée d'un ordre public pouvant être un « ordre moral ».

→ Maurice Hauriou, *Précis de droit administratif et de droit public*, 1933, rééd. 2002, Dalloz, p. 58.

La protection de l'ordre public (dans le cas d'atteintes graves, de péril imminent) permet également le déclenchement de l'état d'urgence permettant des atteintes exceptionnellement admises à la protection des droits humains, de même que l'état d'urgence sanitaire (créée par la loi du 23 mars 2020).

Le Conseil constitutionnel a consacré uniquement le volet matériel de l'ordre public, à savoir le bon ordre, la sécurité, la salubrité et la tranquillité publique, qui est considéré comme un objectif à valeur constitutionnelle. L'ordre public immatériel se réfère néanmoins à d'autres fondements constitutionnel (à l'instar de la dignité).

→ Cons. const., déc. n° 82-141 DC, 27 juillet 1982, *Loi sur la communication audiovisuelle.*

POUR ALLER PLUS LOIN

Le développement de l'ordre public immatériel peut faire l'objet de nombreuses critiques, notamment par l'absence de définition claire de ses composantes et leur caractère particulièrement subjectif à l'instar de la morale. Néanmoins, l'ordre public est également et paradoxalement lié aux libertés en ce qu'il permet la réunion des éléments essentiels de leur exercice sans abus.

Notion essentielle. - L'ordre public immatériel peut également revêtir une dimension sociétale. Bien qu'aucun texte ni décision de justice n'en fait expressément mention, les travaux parlementaires relatifs à la loi du 11 octobre 2010 *interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public* ont ainsi expressément développé la notion d'un « *ordre public immatériel ou sociétal* », reposant sur un socle minimal d'exigences nécessaires à la vie en société. La dignité de la personne humaine avait été envisagée au cours des débats, mais elle n'a finalement pas été retenue comme fondement autonome permettant de justifier une interdiction générale de la dissimulation du visage.

Le Conseil constitutionnel a néanmoins validé cette interdiction en relevant que le législateur avait estimé que la dissimulation du visage pouvait méconnaître les « *exigences minimales de la vie en société* » et placer certaines femmes dans une situation d'exclusion et d'infériorité incompatible avec les principes constitutionnels de liberté et d'égalité.

→ Cons. const., déc. n° 2010-613 DC, 7 octobre 2010*, Loi interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public*.

À retenir. - Sans consacrer expressément une catégorie générale d' « ordre public immatériel », cette décision illustre une conception de l'ordre public dépassant la seule sécurité, salubrité et tranquillité publiques pour intégrer certaines exigences fondamentales de la vie collective.

2. Les types de régimes

2.1. Le régime répressif

Le régime répressif est le régime le plus protecteur pour les droits et libertés comme en témoigne les conclusions du Commissaire du Gouvernement Corneille dans l'arrêt Baldy rendu par le Conseil d'État le 10 août 1917 dont on retient généralement la formule suivante : « La liberté est la règle et la restriction de police l'exception. »

La règle est ainsi normalement une restriction des libertés strictement nécessaire à l'objectif recherché. Cette idée est notamment exprimée à travers l'arrêt Benjamin du 19 mai 1933 qui considère que les mesures de police doivent opérer une conciliation entre le maintien de l'ordre public et l'exercice des libertés publiques.

→ CE, 19 mai 1933, *Benjamin*, n° 17413 et 17520.

Le régime répressif met en place une sanction par le juge *a posteriori* de l'action illicite réalisée dans le cas d'un abus de la liberté par un individu. Dès lors, elle laisse une plus grande liberté à l'individu pouvant exercer ses droits dans la limite de la commission d'une infraction pénale et permet donc un exercice plus libre des libertés publiques. Son essence libérale est résumée par l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen :

> *« La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi. »*

Cet article met en lumière l'existence de limites aux libertés et la possibilité d'abus, mais également que l'exercice des libertés n'est *a priori* soumis à aucune déclaration ou autorisation préalable. Les sanctions appliquées *a posteriori* doivent nécessairement être conformes au principe de légalité des délits et des peines permettant aux individus de réguler en avance leur comportement.

La liberté d'expression constitue pour l'essentiel un bon exemple du régime répressif, les abus de cette liberté (diffamation, atteinte à la vie privée…), étant sanctionnés après leur commission.

2.2. Le régime préventif

Le régime préventif implique un contrôle *a priori* par l'administration afin d'empêcher préventivement l'abus d'une liberté fondamentale pour préserver l'ordre public. L'exercice de la liberté est donc soumis et dépendant de la délivrance d'une autorisation à cette fin.

Ce régime est ainsi le plus strict avec l'exercice des libertés puisque le contrôle se concentre sur un risque de troubles à l'ordre public pour interdire l'exercice de ces libertés.

Ces appréciations sont donc soumises à une appréciation locale et casuistique, risquant nécessairement des divergences d'interprétation.

Ce régime est généralement mis en place pour contrôler plus étroitement l'exercice de certaines libertés, mais doit rester un régime exceptionnel sous peine de dérives autoritaires, bien que l'utilisation de ce type de régime puisse être justifié au titre d'une volonté politique de disparition du « risque » dans la société.

> → Cons. const, déc. n° 71-44 DC, 16 juillet 1971, *Loi complétant les dispositions des articles 5 et 7 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.*

Seule la loi permet la mise en place d'un régime préventif via des autorisations :

> → CE, ass., 22 juin 1951, *Daudignac*, n° 290 et 2251.

À titre d'exemple, la diffusion d'un film à des fins commerciales nécessite obligatoirement un visa d'exploitation (art. L. 211-1 du Code du cinéma et de l'image animée).

2.3. Le régime déclaratif

Un troisième type de régime, le régime déclaratif, permet de déclarer l'exercice préalable d'une liberté publique aux autorités compétentes. Il s'agit dès lors d'un simple enregistrement de l'activité, à titre informatif et ne donne pas à l'administration de pouvoir d'appréciation sur l'exercice de cette liberté, même si cet enregistrement peut être obligatoire.

L'exercice des libertés publiques est moins contraint que dans le cas du régime préventif, mais moins libre que dans le cas du régime répressif.

Ce régime s'applique notamment à la liberté d'association qui implique un enregistrement préalable ainsi que le mentionne l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 (modifié par l'ordonnance du 23 juillet 2015). Ce régime est également utilisé dans le cadre de la déclaration de manifestation à l'instar de l'article L. 211-1 du Code de la sécurité intérieure rendant obligatoire toute déclaration d'une manifestation publique. L'autorité administrative peut tout de même édicter un arrêté d'interdiction s'il existe des risques réels et sérieux de trouble à l'ordre public, interdiction alors notifiée aux organisateurs de la manifestation (art. 211-4 du Code de la sécurité intérieure).

Actualité jurisprudentielle. - L'interdiction d'une manifestation déclarée demeure une mesure de dernier recours

Le Conseil d'État rappelle que l'autorité de police saisie d'une déclaration de manifestation doit concilier la liberté de manifestation et la liberté d'expression avec la sauvegarde de l'ordre public. Une interdiction ne peut être prononcée qu'en dernier recours et à la condition d'être adaptée, nécessaire et proportionnée aux circonstances, en tenant compte notamment des moyens humains, matériels et juridiques dont dispose l'administration. Elle peut toutefois être justifiée non seulement par un risque de violences ou de dégradations, mais également par la nécessité de prévenir la commission suffisamment certaine et imminente d'infractions susceptibles de mettre en cause l'ordre public, même en l'absence de troubles matériels déjà constatés.

En l'espèce, le juge des référés a admis l'interdiction d'une manifestation de soutien au peuple iranien organisée à Paris en raison des risques précis de violences dirigées contre le rassemblement et de la forte mobilisation concomitante des forces de l'ordre, résultant notamment du plan Vigipirate.

⟶ CE, ord., 20 juin 2026, *Association nouveaux droits de l'Homme*, n° 516908.

À retenir. - Le régime déclaratif ne se transforme pas en régime d'autorisation : l'administration ne dispose pas d'un pouvoir discrétionnaire pour autoriser ou refuser la manifestation. Elle peut néanmoins l'interdire lorsqu'un risque suffisamment établi pour l'ordre public ne peut être prévenu par des mesures moins attentatoires aux libertés.

POUR S'ENTRAÎNER

Commentaire de texte : article 211-1 du Code de la sécurité intérieure (Ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012) : *« Sont soumis à l'obligation d'une déclaration préalable tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d'une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique. Toutefois, sont dispensées de cette déclaration les sorties sur la voie publique conformes aux usages locaux* […]. *»*

Le droit de manifestation et de réunion est un droit fondamental, mais non absolu et il revient normalement au pouvoir législatif d'en réglementer ses aspects.

Le texte dont il est question correspond aux deux premiers alinéas d'un article du Code de la sécurité intérieure, créé par l'ordonnance du 12 mars 2012 (l'ordonnance permettant au pouvoir réglementaire d'agir dans le champ de compétence du pouvoir législatif selon l'article 38 de la Constitution). C'est alors la loi du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure qui habilite le gouvernement à légiférer par ordonnance pour la création d'un Code de la sécurité intérieure.

Ce texte met en place la règle générale relative au droit de réunion et de manifestation à savoir son conditionnement à une déclaration auprès des autorités publiques.

Cet article démontre une certaine volonté de contrôle de l'exercice des réunions et des manifestations et l'existence d'une tension intrinsèque entre sécurité (comme composante de l'ordre public) et exercice des libertés publiques.

Problématique et annonce du plan : Cet article est un parfait exemple du régime déclaratif, cherchant à opérer des conciliations entre les différents intérêts et la liberté de manifestation **(I)**, bien que ce régime soit propice aux droits et libertés il peut dériver vers un régime moins protecteur **(II)**.

I. Une déclaration en vue d'une conciliation

A. La création d'un régime déclaratif pour les manifestations

L'article indique une « obligation d'une déclaration préalable » de toute réunion ou manifestation sur la voie publique.

L'article prévoit donc un régime déclaratif, à savoir un régime d'enregistrement de l'activité. Il se distingue des régimes répressifs (plus libéraux) et des régimes préventifs (plus sécuritaires) par une approche intermédiaire qui postule le caractère licite *a priori* de la manifestation, mais soumise à déclaration.

Dans ce cadre, l'article respecte le précepte énoncé dans les conclusions du commissaire du Gouvernement Corneille dans l'arrêt Baldy rendu par le Conseil d'État le 10 août 1917 à savoir que « la liberté est la règle et la restriction de police l'exception ».

L'obligation énoncée dans l'article a également un corolaire : ne pas s'y conformer est puni par l'article 431-9 du Code pénal.

B. Une obligation sous-jacente de protection de l'ordre public

L'obligation énoncée dans l'article permet de protéger l'ordre public notamment :

- La tranquillité et la sûreté notamment lorsqu'il est lu en parallèle de l'article L. 211-4 du Code de la sécurité intérieure.
- Toute interdiction de la manifestation peut légitimement faire l'objet d'un recours en référé-liberté devant le juge administratif.

Cet article démontre l'existence d'une forme de conciliation :

- La préservation de l'ordre public qui est un objectif à valeur constitutionnelle (Cons. const., déc. n° 94-352 DC, 18 janvier 1995, *Loi d'orientation et de programmation relative à la sécurité*).
- Le droit de réunion et de manifestation, possédant des liens importants avec la liberté d'expression et donc fondamentale dans une société démocratique, possédant une valeur constitutionnelle indirecte (Cons. const., déc. n° 93-345 DC, 29 juillet 1994, *Loi relative à l'emploi de la langue française* et déc. n° 2019-780 DC, 4 avril 2019, *Loi visant à renforcer et garantir le maintien de l'ordre public lors des manifestations*, par référence à l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen) et possédant une valeur conventionnelle largement reconnue dans les instruments normatifs internationaux (art. 10 et 11 de la Convention européenne des droits de l'homme, et articles 11 et 12 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne).

L'interdiction ne peut avoir lieu qu'en cas de risque de troubles à l'ordre public (en cas de danger réel), selon l'article 211-4 du Code de la sécurité intérieure, cela devant rester exceptionnel.

Le régime permet également de prévoir toute possibilité de débordement et donc d'abus de cette liberté en prévoyant des dispositifs de sécurité (d'où la nécessité informative) et l'obligation qui en est même faite et constitue un juste milieu dans la conciliation des intérêts.

II. Les limites du régime déclaratif du droit de manifester

A. Les limites traditionnelles

La notion d'« usages locaux » correspond à des règles non écrites à savoir des coutumes locales s'appliquant à tous ou des usages propres s'adressant à certaines catégories (agriculteurs, particuliers…) et fait référence ici à des manifestations traditionnelles. Leur caractère coutumier et traditionnel fait de ces manifestations des événements bien installés dans le paysage social, ce qui prévient en théorie tout risque à l'ordre public. La manifestation est coutumière donc connue (ce qui rend superflue sa déclaration à titre informatif aux autorités), mais également acceptée tacitement et ne troublant pas outre mesure la tranquillité publique, voire participant aux valeurs nationales et à l'état de paix sociale.

Cependant, certaines conditions peuvent tout de même conduire à interdire préventivement certains usages locaux à l'instar de l'arrêté préfectoral du 20 juin 2023 de la Préfète de la Région Grand-Est interdisant entre autres les feux de la St Jean pour risques environnementaux, montrant que ce régime n'est pas absolu.

Les « usages locaux » n'étant cependant pas définis clairement, ils peuvent faire l'objet d'une interprétation par les autorités.

Pour ces usages, il s'agit d'un régime répressif, permettant une protection plus étendue et faisant une distinction dans les protections entre manifestations traditionnelles (davantage protégées par le système répressif) et manifestations autres concernant des revendications (soumises à un régime plus contraignant), ce qui peut questionner la légitimité de cette distinction.

B. Le risque du basculement vers un régime préventif

Malgré ce que présente cet article, à savoir une appréhension non restrictive du droit de réunion et de manifestation, cette « règle » générale a pu devenir résiduelle et se transformer en régime préventif lors de l'état d'urgence sanitaire :

- Art. L. 3131-15 Code de la santé publique.
- Le décret du 20 mai 2020, finalement abrogé par le décret du 10 juillet 2020, transformait le régime énoncé dans l'article 211-1 du Code de la sécurité intérieure en régime préventif : ce qui a été sanctionné par le juge administratif, grâce à un contrôle entier, considérant qu'il ne s'agissait pas d'une mesure « adaptée, proportionnée et nécessaire » (CE, ord., 13 juin 2020, *Ligue des droits de l'homme, CGT-Travail et autres*, n° 440846, 440856, 441015).

Le juge permet alors de protéger la liberté de manifester en empêchant son changement de régime, pouvant s'apparenter à une mesure liberticide et ainsi préserver cet article comme étant la règle générale.

Malgré cela, d'autres mesures cherchent à contrôler les manifestations notamment la loi du 10 avril 2019 visant à renforcer et garantir le maintien de l'ordre public lors des manifestations et autorisant les forces de l'ordre à effectuer divers contrôles, ou les règles relatives à la dissimulation du visage dans l'espace public (art. 431-9-1 et R645-14 du Code pénal), démontrant une certaine méfiance des autorités publiques à l'égard des manifestations et donc une nécessité de contrôle renforcé du juge.

En conclusion, le régime déclaratif concernant l'autorisation des manifestations est un régime protecteur des libertés grâce à l'équilibre trouvé avec la protection de l'ordre public.

Fiche nº 7 - LIMITATIONS ET ÉTATS D'EXCEPTION

POINTS CLÉS

- Pouvoirs exceptionnels du président de la République.
- État de siège.
- État d'urgence.
- État d'urgence sanitaire.
- Théorie des circonstances exceptionnelles.
- Limitation des droits humains en période d'exception.
- Droits humains indérogeables même en période d'exception.

PRINCIPALES RÉFÉRENCES

- Article 16 de la Constitution.
- CE, ass., 2 mars 1962, *Rubin de Servens*, nº 55049.
- Article 36 de la Constitution.
- Loi nº 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence.
- Cons. const., déc. nº 85-187 DC du 25 janvier 1985, *Loi relative à l'état d'urgence en Nouvelle-Calédonie.*
- CE, ord., 14 novembre 2005, *Rolin,* nº 286835.
- Loi nº 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19.
- Article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
- Article 15 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

1. Les régimes d'exception prévus par la Constitution

Deux états d'exception sont reconnus par la Constitution du 4 octobre 1958. L'un, inscrit à l'article 16, confère au président de la République des pouvoirs extraordinaires. L'autre, inséré à l'article 36, prévoit l'état de siège qui élargit les pouvoirs de l'autorité militaire.

1.1 Les pouvoirs exceptionnels du chef de l'État prévus à l'article 16 de la Constitution

L'introduction de l'article 16 de la Constitution traduit la volonté du général de Gaulle de prévenir la survenance d'événements similaires à ceux de 1940.

1.1.1. Les conditions de sa mise en œuvre

L'article 16 précise les conditions cumulatives de sa mise en œuvre, dont les contours ne sont pas précis. Il est applicable :

> *« Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la Nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacés d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu. »*

La décision du président de la République de le déclencher n'est pas soumise à contreseing, mais requiert une consultation préalable pour avis du Premier ministre, des présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, ainsi que du Conseil constitutionnel, sans que la décision du président de la République soit liée par cette consultation.

En 1962, le Conseil d'État affirme que cette décision est un acte de gouvernement, elle ne peut dès lors pas faire l'objet d'un contrôle juridictionnel.

→ CE, ass., 2 mars 1962, *Rubin de Servens*, n° 55049.

1.1.2. Les pouvoirs exceptionnels du chef de l'État

Le déclenchement de l'article 16 de la Constitution constitue une entorse licite au principe de la séparation des pouvoirs. En effet, lorsqu'il est déclenché, le président de la République peut temporairement exercer les compétences du Parlement et du Gouvernement, sans que ces derniers soient totalement dessaisis.

L'article 16 fait figure d'exception au sein des démocraties libérales, dont les textes constitutionnels ne connaissent pas de dispositions analogues.

Lorsque l'article 16 est déclenché, le chef de l'État ne peut pas dissoudre l'Assemblée nationale. De plus, l'alinéa 4 de l'article 89 de la Constitution ne permet pas la révision constitutionnelle « *lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire* ».

1.1.3. Le contrôle des décisions prises sur le fondement de l'article 16

Si la décision de recourir à l'article 16 de la Constitution constitue un acte de gouvernement, les décisions prises sur son fondement peuvent, selon leur nature, faire l'objet d'un contrôle juridictionnel. Le juge administratif contrôle les actes qui relèvent normalement du pouvoir réglementaire, mais pas ceux qui relèvent du domaine de la loi.

1.1.4. La modification de l'article 16 par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008

L'existence de telles dispositions dans la Constitution est significativement contestée, mais l'article 16 a survécu à toutes les révisions constitutionnelles. Toutefois, celle du 23 juillet 2008 a conduit à des modifications tenant à sa prolongation :

> *« Après trente jours d'exercice des pouvoirs exceptionnels, le Conseil constitutionnel peut être saisi par le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, soixante députés ou soixante sénateurs, aux fins d'examiner si les conditions énoncées au premier alinéa demeurent réunies. Il se prononce dans les délais les plus brefs par un avis public. Il procède de plein droit à cet examen et se prononce dans les mêmes conditions au terme de soixante jours d'exercice des pouvoirs exceptionnels et à tout moment au-delà de cette durée. »*

Cette modification demeure d'une portée modeste, car l'avis rendu par le Conseil constitutionnel n'a pas de force contraignante.

1.1.5. L'unique application de l'article 16

L'article 16 a été utilisé une seule fois en 1961 par le général de Gaulle en réaction au putsch des généraux pendant la guerre d'Algérie. Malgré l'échéance de la menace à la fin du mois d'avril, ces dispositions sont restées en vigueur jusqu'au 29 septembre 1961.

POUR ALLER PLUS LOIN

Lorsque le général de Gaulle a mis en œuvre l'article 16 de la Constitution, il a, par exemple, adopté une décision relative à la garde à vue le 24 avril 1961, puis institué un Haut Tribunal militaire par une décision du 27 avril 1961. Ces mesures relèvent en principe du domaine de la loi en vertu de l'article 34 de la Constitution, qui inclut notamment « la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procédure pénale ».

1.2. L'état de siège prévu à l'article 36 de la Constitution

L'état de siège, qui n'a jamais été appliqué sous la Ve République, trouve ses origines dans les lois du 9 août 1849 et du 3 avril 1878. Il est prévu à l'article 36 de la Constitution, dont les termes laconiques se bornent à indiquer que l'état de siège « est décrété en Conseil des ministres » et que « sa prorogation au-delà de douze jours ne peut être autorisée que par le Parlement ».

1.2.1. Les conditions de mise en œuvre de l'article 36

Le Code de la défense précise les conditions de sa mise en œuvre. L'état de siège ne peut être déclaré :

> *« Qu'en cas de péril imminent résultant d'une guerre étrangère ou d'une insurrection armée »* (art. L. 2121-1).

1.2.2. L'accroissement des compétences de l'autorité militaire

Le Code précité prévoit le transfert du maintien de l'ordre et de la police à l'autorité militaire en laissant à l'autorité civile l'exercice des autres attributions (art. L. 2121-2) et le transfert de compétences qui relèvent normalement de la juridiction judiciaire à des tribunaux militaires (art. L. 2121-4).

1.2.3. Les limitations aux droits humains sous l'état de siège

Ce même Code prévoit également les limitations possibles aux droits humains par l'autorité militaire. Elle peut faire des perquisitions domiciliaires de jour comme de nuit, éloigner des personnes condamnées pénalement qui n'ont pas leur domicile dans les lieux soumis à l'état de siège, ordonner la remise d'armes et de munitions, et interdire les publications et les réunions que l'autorité militaire considèrerait comme une menace à l'ordre public (art. L 2121-7).

2. L'état d'urgence prévu par le législateur

L'état d'urgence est prévu par la loi du 3 avril 1955. Toutefois, la loi du 23 mars 2020 a été adoptée afin de répondre aux spécificités de l'urgence liée à l'épidémie du coronavirus. On distingue par conséquent désormais l'état d'urgence dit « sécuritaire » et l'état d'urgence dit « sanitaire ».

2.1. La loi du 3 avril 1955 classiquement appliquée sous la Ve République

La loi du 3 avril 1955 a été rédigée lors de la guerre d'Algérie et a fait l'objet de plusieurs modifications par l'ordonnance du 15 avril 1960, la loi du 17 mai 2011 ainsi que sous l'état d'urgence déclaré en 2015 à la suite des attentats du 13 novembre 2015.

Malgré sa rédaction antérieure à la Constitution de la Ve République, le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État ont considéré qu'elle n'avait pas été implicitement abrogée.

> → Cons. const., déc. n° 85-187 DC, 25 janvier 1985, *Loi relative à l'état d'urgence en Nouvelle-Calédonie.*
>
> → CE, ord., 21 novembre 2005, *Boisvert*, n° 287217.

2.1.1. Les conditions de la mise en œuvre et de la prolongation

L'article premier de la loi du 3 avril 1955 prévoit que l'état d'urgence peut être déclaré sur l'ensemble du territoire ou sur une partie de celui-ci, y compris dans les départements et collectivités d'outre-mer. Ce même article dispose qu'il peut être mis en œuvre :

> *« Soit en cas de péril imminent résultant d'atteintes graves à l'ordre public, soit en cas d'événements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique. »*

L'état d'urgence est décrété en Conseil des ministres et sa prolongation au-delà de douze jours doit faire l'objet d'une autorisation législative. En cas de prolongation, la loi détermine la durée de l'état d'urgence.

2.1.2. Le contrôle juridictionnel de la mise en œuvre et de la prolongation

La décision de le mettre en œuvre peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Cependant, les dispositions législatives qui prévoient la prolongation de l'état d'urgence ne peuvent pas être contrôlées par le juge administratif, mais être contestées au moyen d'une question prioritaire de constitutionnalité.

→ CE, ord., 14 novembre 2005, *Rolin*, n° 286835.

→ CE, 27 janvier 2016, *Ligue des droits de l'homme,* n° 396220.

2.1.3. Les limitations aux droits humains prévues par la loi du 3 avril 1955

Afin de répondre aux impératifs liés à la sécurité et l'ordre publics, la loi du 3 avril 1955 prévoit les mesures que le ministre de l'Intérieur peut prendre (assignation à résidence) ainsi que les pouvoirs accordés au préfet (interdiction de circulation, interdiction de séjour sur tout ou partie du département).

Le ministre de l'Intérieur ainsi que le préfet sont autorisés à ordonner la fermeture provisoire de *« salles de spectacles, débits de boissons et lieux de réunion de toute nature »*, à ordonner la remise des armes et munitions, à ordonner des perquisitions en tout lieu y compris un domicile *« sauf dans un lieu affecté à l'exercice d'un mandat parlementaire ou à l'activité professionnelle des avocats, des magistrats ou des journalistes »*.

En outre, des associations ou groupements de fait peuvent être dissous par décret en conseil des ministres.

En 2017, le Conseil constitutionnel a déclaré inconstitutionnelles les dispositions de la loi du 3 avril 1955 qui prévoyaient que le préfet peut ordonner des contrôles d'identité, des inspections visuelles, des fouilles de bagages et la visite de véhicules. Il a jugé que la pratique généralisée et discrétionnaire, sans qu'elle soit nécessairement justifiée, de ces opérations serait incompatible avec la liberté d'aller et venir et le droit au respect de la vie privée.

→ Cons. const. déc. n° 2017-677 QPC, 1er décembre 2017, *Ligue des droits de l'Homme.*

2.1.4. Le contrôle des mesures prises sur le fondement de la loi du 3 avril 1955

L'article 14-1 de cette même loi prévoit explicitement que les mesures prises sur son fondement peuvent faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Initialement, le juge administratif opérait un contrôle restreint des mesures prises au titre de l'état d'urgence.

En 2015, le Conseil constitutionnel a affirmé que le juge administratif est chargé de contrôler que la mesure est *« adaptée, nécessaire et proportionnée à la finalité qu'elle poursuit »*.

→ Cons. const., déc. n° 2015-527 QPC, 22 décembre 2015, *M. Cédric D*.

La régularité d'une perquisition administrative ou d'une assignation à résidence à l'issue de laquelle une procédure pénale est conduite est toutefois contrôlée par le juge pénal.

→ Cass. crim., 28 mars 2017, n° 16-85.072, n° 16.85.073.

→ Cass. crim., 3 mai 2017, n° 16-86.155.

2.1.5. Les applications de la loi du 3 avril 1955 sous la Ve République

Sur le fondement de la loi de 1955, l'état d'urgence a été déployé à sept reprises sous la Ve République, parfois sur l'ensemble du territoire, d'autres sur une partie seulement. Les déploiements les plus récents concernent l'état d'urgence de 2015 ainsi que l'état d'urgence de 2024.

Du 15 au 28 mai 2024, l'état d'urgence a été déclaré par décret sur l'ensemble du territoire de la Nouvelle-Calédonie en réaction à des émeutes qui résultaient du projet de loi constitutionnelle portant modification du

corps électoral pour les élections au congrès et aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, qui prévoit l'élargissement du corps électoral calédonien, restreint depuis l'Accord de Nouméa de 1998.

Sur le fondement du décret du 15 mai 2024 relatif à l'application de la loi de 1955, plusieurs mesures de restriction et de suspension des droits humains ont été prises, comme des assignations à résidence, l'interdiction de rassemblements, l'interdiction du port et du transport d'armes, l'interdiction de vente d'alcool sur l'ensemble du territoire de la Nouvelle-Calédonie, notamment.

2.2. L'épidémie de Covid-19 et la loi du 23 mars 2020

La loi du 9 août 2004 prévoit un régime de police spéciale en cas de menaces sanitaires qui donne des pouvoirs importants au ministre de la Santé. Cependant, face à l'épidémie de la maladie Covid-19, une nouvelle loi a été adoptée pour instaurer un état d'urgence sanitaire. Il s'agit d'un régime d'exception *ad hoc*, qui est aujourd'hui abrogé.

→ Loi n° 2022-1089 du 30 juillet 2022 mettant fin aux régimes d'exception.

Le Conseil constitutionnel a jugé que la création d'un régime d'état d'urgence sanitaire n'est pas contraire à la Constitution.

→ Cons. const., déc. n° 2020-800 DC, 11 mai 2020, *Loi prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions.*

L'état d'urgence sanitaire a été déclaré le 23 mars 2020 et prolongé jusqu'au 10 juillet 2020, puis il a été redéclaré le 14 octobre 2020 et prolongé à deux reprises jusqu'au 16 février 2021 avant de laisser place à un régime transitoire jusqu'au 31 décembre 2021.

Lorsque le juge administratif a contrôlé les mesures prises sous l'état d'urgence sanitaire, il a opéré un contrôle de proportionnalité de ces dernières.

→ CE, 22 mars 2020, *Syndicat des jeunes médecins*, n° 439674.

POUR ALLER PLUS LOIN

La crise sanitaire a particulièrement affecté les droits humains des personnes vulnérables. Par exemple, le ministère de l'intérieur et l'Office français de l'immigration et de l'intégration avaient interrompu les procédures d'enregistrement des demandes d'asile en Île-de-France. Par une ordonnance du 30 avril 2020, le Conseil d'État a affirmé que cette décision portait gravement atteinte au droit d'asile. De plus, le Conseil d'État a rappelé aux autorités pénitentiaires qu'elles doivent protéger la santé des personnes incarcérées. Il a ordonné à plusieurs prisons, celle de Ducos, de Martinique et de Toulouse-Seysses, la fourniture de masques aux personnes incarcérées lors de leurs contacts extérieurs.

Tableau récapitulatif des états d'exception mis en œuvre sous la Ve République

États d'exception	Fondement	Raison de la mise en œuvre	Durée
Pouvoirs exceptionnels du président de la République en 1961	Article 16 de la Constitution	Putsch des généraux d'Alger.	Du 22 avril au 29 septembre 1961
État d'urgence en 1961 sur le territoire métropolitain	Loi du 3 avril 1955	Putsch des généraux d'Alger.	Du 22 avril 1961 au 31 mai 1963
État d'urgence en 1985 sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie	Loi du 3 avril 1955	Violents affrontements dans le cadre de revendications d'indépendance de la Nouvelle-Calédonie.	Du 12 janvier 1985 au 30 juin 1985
État d'urgence sur le territoire de Wallis et Futuna en 1986	Loi du 3 avril 1955	Raison peu documentée ; il s'agit d'un état d'urgence qui n'a duré qu'un seul jour.	Du 29 octobre au 30 octobre 1986
État d'urgence sur le territoire de la Polynésie en 1987	Loi du 3 avril 1955	Violences urbaines à la suite d'une grève ; affrontements entre des personnes qui faisaient grève et les forces de l'ordre.	Du 24 octobre au 5 novembre 1987
État d'urgence en 2005 applicable dans certains départements	Loi du 3 avril 1955	Violences urbaines à la suite du décès de deux adolescents qui échappaient à un contrôle de police, ce qui a mené à des affrontements entre plusieurs centaines de personnes et les forces de l'ordre.	Du 8 novembre 2005 au 4 janvier 2006
État d'urgence en 2015	Loi du 3 avril 1955	Attentat terroriste revendiqué par l'État islamique du 13 novembre 2015 qui fait 130 morts et plus de 400 blessés.	Du 14 novembre 2015 au 30 octobre 2017
État d'urgence en 2020	Loi du 23 mars 2020	Épidémie de la maladie Covid-19.	Du 23 mars 2020 au 10 juillet 2020 ; puis du 14 octobre 2020 au 16 février 2021.
État d'urgence sur l'ensemble du territoire de la Nouvelle-Calédonie en 2024	Loi du 3 avril 1955	Émeutes en Nouvelle-Calédonie en réaction au projet de loi constitutionnelle portant modification du corps électoral pour les élections au congrès et aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie.	Du 15 au 28 mai 2024

3. La création prétorienne de la théorie des circonstances exceptionnelles

La théorie des circonstances exceptionnelles émane du juge administratif. Elle permet à l'administration de prendre des décisions, en l'absence de texte, qu'elle ne pourrait pas prendre en période normale.

En 1918, le Conseil d'État applique la théorie des circonstances exceptionnelles du fait de la guerre et de la nécessité que les services publics fonctionnent. L'année suivante, il affirme que :

> *« Il appartient au juge, sous le contrôle duquel s'exercent ces pouvoirs de police, de tenir compte, dans son appréciation, des nécessités provenant de l'état de guerre, selon les circonstances de temps et de lieu, la catégorie des individus visés et la nature des périls qu'il importe de prévenir. »*
>
> → CE, 28 juin 1918, *Heyriès*, n° 63412.
>
> → CE, 28 février 1919, *Dame Dol et Laurent*, n° 61593.

Avant l'entrée en vigueur de la loi du 23 mars 2020, les mesures de limitation des droits humains prises sous l'état d'urgence sanitaire ont d'abord été prises par un arrêté du ministre des Solidarités et de la Santé du 14 mars 2020 ainsi que par décret du Premier ministre du 16 mars 2020.

L'arrêté du 14 mars 2020 prévoyait notamment la fermeture de nombreux établissements, l'interdiction de rassemblements de plus de cent personnes, l'interdiction de faire des escales pour des navires de croisière et de navires de passagers transportant plus de cent personnes. Le Conseil d'État reconnaît le caractère exceptionnel des circonstances qui justifient l'édiction d'un premier confinement de la population par le décret du 16 mars 2020, même sans texte.

> → CE, 22 décembre 2020, n° 439800.

POUR ALLER PLUS LOIN

Du 14 au 29 mai 2024, le réseau social « TikTok » a été bloqué en Nouvelle-Calédonie sur décision du 14 mai 2024 du Premier ministre, sur le fondement de circonstances exceptionnelles, à cause de la diffusion de contenus d'incitation à la violence. Le Conseil d'État a été saisi d'un recours pour excès de pouvoir contre cette décision. Par un arrêt du 1er avril 2025, le Conseil d'État a précisé les conditions dans lesquelles une autorité administrative peut interrompre provisoirement l'accès à un réseau social. Cette interruption provisoire ne peut être prononcée, d'une part, que si elle est nécessaire dans le cadre d'événements d'une particulière gravité, d'autre part, que s'il n'existe aucun moyen qui ne permette de prendre des mesures alternatives moins attentatoires aux droits et libertés. Enfin, cette mesure doit être prise pour une durée limitée nécessaire à la recherche de mesures alternatives. Le Conseil d'État a considéré que les conditions n'étaient pas réunies et annule la décision qui a « porté une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression, à la liberté de communication des idées et opinions et à la liberté d'accès à l'information ».

Actualité. – La création d'un nouvel état d'alerte de sécurité nationale

La loi n° 2026-791 du 16 août 2026 a créé un nouveau régime d'exception, dénommé « état d'alerte de sécurité nationale », inscrit aux articles L. 2143-1 et suivants du Code de la défense. Présenté au cours des travaux parlementaires comme un régime intermédiaire entre le droit commun et les régimes d'exception classiques, il vise principalement à permettre une mobilisation rapide des moyens civils, industriels, logistiques et militaires en présence d'une menace grave pour la sécurité nationale.

L'état d'alerte peut être déclaré, sur tout ou partie du territoire national, par décret en conseil des ministres en présence d'une menace « grave et actuelle » pesant sur la sécurité nationale, justifiant la mise en œuvre des engagements internationaux de la France en matière de défense ou nécessitant le déploiement à bref délai de forces françaises ou alliées sur le territoire national.

Son déclenchement permet notamment de protéger certains sites stratégiques, de soumettre l'accès à certaines installations à une enquête administrative, d'adapter les règles de la commande publique, de prendre certaines mesures relatives au fonctionnement du système de santé et de déroger temporairement à des normes réglementaires dans des domaines tels que l'urbanisme, l'environnement, les transports, les communications électroniques ou, dans certaines hypothèses, le droit du travail. Des procédures dérogatoires sont également prévues pour accélérer la réalisation d'infrastructures nécessaires aux forces armées.

→ Loi n° 2026-791 du 16 août 2026 *actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030*, art. 35 ; Code de la défense, art. L. 2143-1 et s.

Un régime d'exception demeure soumis au contrôle de proportionnalité. Le Conseil constitutionnel a jugé que la Constitution n'interdit pas au législateur d'instituer un tel régime. Celui-ci doit néanmoins assurer une conciliation entre les exigences constitutionnelles tenant à la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation et le respect des droits et libertés.

Le Conseil constitutionnel précise notamment qu'une « menace grave et actuelle » doit être établie à partir d'éléments matériels suffisamment caractérisés. Le décret déclarant l'état d'alerte peut en outre être contesté devant le Conseil d'État. Les mesures prises pendant cette période restent elles-mêmes soumises au contrôle du juge, notamment quant à leur nécessité et leur proportionnalité.

Enfin, l'état d'alerte ne peut être prorogé au-delà de deux mois que par la loi. L'Assemblée nationale et le Sénat doivent être informés sans délai de sa déclaration et des mesures adoptées sur son fondement.

→ Cons. const., déc. 2026-907 DC, 6 août 2026, *Loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense*.

À retenir. - Le droit français connaît désormais un nouvel échelon dans la gestion juridique des crises. Contrairement à la théorie des circonstances exceptionnelles, qui permet au juge d'admettre exceptionnellement certaines dérogations au droit commun en l'absence de texte, l'état d'alerte de sécurité nationale organise directement par la loi les pouvoirs susceptibles d'être exercés par l'administration face à certaines menaces graves. Sa déclaration ne constitue toutefois pas, par elle-même, une dérogation à la Convention européenne au sens de son article 15 : les mesures adoptées demeurent soumises au respect des engagements internationaux de la France.

4. La reconnaissance conventionnelle de la dérogation aux droits humains

Le droit international et européen des droits humains n'exclut pas la possibilité pour les États de déroger temporairement à des dispositions protectrices des droits humains, tout en reconnaissant que certaines d'entre elles sont indérogeables.

4.1. L'article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques

L'article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques dispose que les États parties peuvent prendre des mesures dérogeant aux obligations prévues dans le Pacte, *« dans le cas où un danger public exceptionnel menace l'existence de la nation et est proclamé par un acte officiel »*. Ces mesures ne doivent pas être *« incompatibles avec les autres obligations que leur impose le droit international et qu'elles n'entraînent pas une discrimination fondée uniquement sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou l'origine sociale »*.

Les États souhaitant appliquer le droit de dérogation doivent informer le Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies des obligations auxquelles ils ont dérogé ainsi que les motifs de ces dérogations, en vertu du troisième paragraphe de l'article 4.

4.2. L'article 15 de la Convention européenne et son interprétation prétorienne

L'article 15 de la Convention européenne prévoit la possibilité pour les États parties à la Convention de déroger exceptionnellement aux obligations qui découlent de la Convention. Cet article indique explicitement qu'il est applicable *« en cas de guerre ou en cas d'autre danger public menaçant la vie de la nation »* et *« dans la stricte mesure où la situation l'exige et à la condition que ces mesures ne soient pas en contradiction avec les autres obligations découlant du droit international »*.

Les États parties doivent informer le Secrétaire général du Conseil de l'Europe *« des mesures prises et des motifs qui les ont inspirées »* pour l'application de l'article 15.

En 2008, le président arménien a déclaré l'état d'urgence en réaction à des manifestations massives à la suite des résultats de l'élection présidentielle, cadre dans lequel les médias ont été concernés par des restrictions. La Cour

européenne des droits de l'homme a jugé que les manifestations ne justifiaient pas la dérogation, puisqu'elles ne constituent pas une menace pour la vie de la nation.

→ CEDH, 21 septembre 2021, *Dareskizb Itd c. Arménie*, n° 61737/08.

Les États disposent d'une large marge d'appréciation sans pour autant jouir d'un pouvoir illimité. La Cour vérifie si cela excède la « stricte mesure » des exigences de la crise. La Cour contrôle également la proportionnalité des mesures prises en application de l'article.

→ CEDH, 18 janvier 1978, *Irlande c. Royaume-Uni*, n° 5310/71.

→ CEDH, 19 février 2009, *A et a. c. Royaume-Uni*, n° 3455/05.

Enfin, l'application de l'article 15 implique l'observation d'exigences de forme. En 1983, la Cour affirme qu'en l'absence d'un acte formel et public de dérogation, la Turquie ne pouvait pas appliquer l'article 15 de la Convention.

→ CEDH, 4 octobre 1983, *Chypre c. Turquie*, n° 25781/94.

POUR ALLER PLUS LOIN

Lors de la ratification de la Convention, le gouvernement français a émis une réserve relative au premier paragraphe de l'article 15. Cette réserve consiste à assurer que les circonstances contenues dans l'article 16 de la Constitution, les dispositions législatives relatives à l'état de siège ainsi que l'article 1er de la loi du 3 avril 1955 correspondent aux exigences de l'article 15.

4.3. Les droits indérogeables en période d'exception

Les deux articles susmentionnés indiquent que certaines dispositions conventionnelles ne peuvent pas faire l'objet de dérogation.

4.3.1. Les droits indérogeables selon le Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Le deuxième paragraphe de l'article 4 prévoit que le droit à la vie, l'interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, l'interdiction de l'esclavage et la traite des esclaves ainsi que l'interdiction de la servitude, l'interdiction d'emprisonnement pour impossibilité d'exécuter une obligation contractuelle, le principe de légalité des peines, le droit à la reconnaissance de la personnalité juridique ainsi que le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion sont des dispositions indérogeables.

4.3.2. Les droits indérogeables selon la Convention européenne des droits de l'homme

Article 15 de la Convention de 1950	**Article 4 du Protocole n° 7 de 1984**	**Article 2 du Protocole n° 13 de 2002**
• **Le droit à la vie (sauf en cas de décès résultant d'actes licites de guerre).** • **L'interdiction de la torture et des traitements ou peines inhumains ou dégradants.** • **L'interdiction de l'esclavage et de la servitude.** • **Le principe de la légalité des peines.**	• Le droit à ne pas être jugé ou puni deux fois.	• L'interdiction de la peine de mort (en période de paix et en période de guerre).

POUR S'ENTRAÎNER

Dissertation : Les limitations des droits humains en période d'exception constituent-elles réellement des exceptions ?

L'article L100-2 du Code des relations entre le public et l'administration prévoit expressément que l'administration « respecte le principe de légalité ». Certaines situations conduisent à la mise en œuvre d'une légalité de crise, impliquant des limitations à l'exercice de certains droits humains.

Les régimes d'exception accroissent les prérogatives des autorités publiques sur le fondement d'une législation spécifique, dérogeant au droit commun en temps normal. Le droit français contient une diversité de régimes d'exception reposant sur des fondements juridiques pluraux.

Ces régimes ont vocation à s'étendre sur une durée déterminée. Or, le XXIe siècle est marqué par la succession de plusieurs états d'urgence, ce qui interroge leur caractère exceptionnel. En outre, un certain nombre de dispositions exceptionnelles ont été intégrées dans le droit commun, ce qui accentue cette interrogation.

Problématique et annonce du plan : Si des limitations de droits humains apparaissent nécessaires en période d'exception **(I)**, force est de constater que ces limitations tendent à se normaliser **(II)**.

I. La nécessité de limiter temporairement des droits humains en période d'exception

A. Des limitations aux droits justifiées par des situations exceptionnelles

Certaines situations sont marquées d'une telle gravité qu'il est difficile d'appliquer le droit commun et nécessitent la mise en œuvre d'un droit exceptionnel. Par exemple, la protection de la santé constitue un objectif de valeur constitutionnelle qui découle du onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946. En cas d'épidémie, il apparaît justifié que des mesures suspendent ou restreignent des droits humains. Par un arrêt rendu le 29 août 2024, *Pasquinelli et a. contre San Marin*, la Cour européenne a affirmé que l'obligation vaccinale de tous les professionnels de santé n'était pas contraire à l'article 8 de la Convention, car elle poursuivait le but légitime de protection de la santé de la population en général.

B. L'existence de droits humains indérogeables même en période d'exception

Les limitations aux droits humains en période d'exception ne signifie pas que tous les droits puissent faire l'objet de dérogations. Certains droits ne peuvent souffrir d'aucune limitation. C'est ce que prévoient l'article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et l'article 15 de la Convention européenne (droit à la vie, sauf en cas d'actes licites de guerre, interdiction de la torture et des traitements ou peines inhumains ou dégradants, interdiction de l'esclavage et de la servitude, principe de la légalité des peines), ainsi que l'article 4 du Protocole n° 7 (droit à ne pas être puni ou jugé deux fois) et l'article 2 du Protocole n° 13 (interdiction de la peine de mort) de cette même convention.

II. La normalisation des limitations aux droits humains

A. La multiplication des périodes d'exception au XXIe siècle

Le principe de légalité, pierre angulaire de l'État de droit, a été de nombreuses fois confronté à une légalité d'exception depuis le début du XXIe siècle en France. Entre 2005 et 2024, l'état d'urgence a été décrété à quatre

reprises. L'état d'urgence déclenché à la suite des attentats terroristes du 13 novembre 2015 a duré près de deux ans. À l'aune de l'imprévisibilité des attaques, cette durée a suscité des critiques et des interrogations quant à la nécessité de maintenir aussi longtemps l'état d'urgence.

B. L'intégration de dispositions exceptionnelles dans le droit commun

L'amoindrissement de ce caractère temporaire réside également dans l'ancrage de dispositions exceptionnelles dans le droit commun alors que l'état d'urgence doit permettre de revenir à une situation normale à son issue.

Plusieurs dispositions prises lors de l'état d'urgence de 2015 sont restées dans le droit commun. Par exemple, la loi du 21 juillet 2016 de prolongation de l'état d'urgence a créé un cadre légal de vidéosurveillance en détention dans le cadre de la répression du terrorisme. En outre, la loi du 30 octobre 2017 prévoit de nouveaux régimes de mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance. Qui plus est, alors que l'état d'urgence en Nouvelle-Calédonie a pris fin le 28 mai 2024, le couvre-feu décidé en mai a continué de s'appliquer jusqu'en décembre 2024 et a été réappliqué pour le nouvel an.

Dans ses conclusions de l'arrêt *Baldy* de 1917, le commissaire du gouvernement Corneille avait employé la formule suivante : *« La liberté est la règle et la restriction de police l'exception. »* Un principe dont l'application s'amenuise du fait de la succession des états d'exception et de leurs conséquences durables sur l'exercice des droits humains.

Fiche nº 8 - LA CRISE DES DROITS HUMAINS ET L'ÉTAT DE DROIT

POINTS CLÉS

- Commission pour la démocratie par le droit du Conseil de l'Europe.
- Contestation de la légitimité des juges.
- Contestation du droit supranational.
- Crise des droits humains.
- Fragilisation des droits de l'opposition.
- Liberté académique en crise.
- Remise en cause des droits des femmes.
- Réticence à l'égard des droits des personnes migrantes.

PRINCIPALES RÉFÉRENCES

- Article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
- Article 2 du Traité sur l'Union européenne.
- Article 7 du Traité sur l'Union européenne.
- Article 258 du Traité sur le fonctionnement de l'Union.
- CJUE, 15 juillet 1964, *Costa contre Enel*, nº C-6/64.
- CJUE, 2 avril 2020, *Commission contre Pologne, Hongrie et République Tchèque*, aff. C-715/17, C-718/17, C719/17.
- CEDH, 3 septembre 2024, *Shlosberg contre Russie*, nº 32648/22.
- CEDH, 7 janvier 2025, *A.R.E. contre Grèce*, nº 15783/21.
- Tribunal constitutionnel polonais, 22 octobre 2020.
- Cour suprême américaine, 24 juin 2022, *Dobbs v. Jackson Wowen's Health Organization.*

1. La définition de l'État de droit

Sous l'impulsion du constitutionnalisme moderne et du droit international et européen des droits humains, les contours de l'État de droit ont été retracés au XXe siècle. En effet, l'État de droit ne se borne plus à un aspect purement formel, il contient désormais une dimension matérielle, également dite substantielle.

En d'autres termes, l'État de droit ne se limite pas seulement au respect du droit par l'État et ses organes, le droit qu'il respecte contient des droits humains et des libertés fondamentales reconnus aux individus.

Parfois considéré comme tautologique, il s'inscrit au cœur des enjeux de l'exercice du pouvoir. Concept cardinal de la lutte contre l'arbitraire, il est la traduction d'une conception libérale du pouvoir.

1.1. L'absence de définition normative univoque

Le droit français ne comporte aucune disposition qui définit clairement le contenu de l'État de droit.

S'il apparaît en filigrane dans le corps de la Déclaration de 1789, il n'est pas explicitement inscrit dans le marbre constitutionnel et n'apparaît pas dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel.

> → Article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen : *« Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution. »*

1.2. L'État de droit dans des textes constitutionnels et conventionnels

L'État de droit apparaît à plusieurs reprises dans la Loi fondamentale allemande de 1949, dans le préambule et à l'article 1er de la Constitution espagnole de 1978, ainsi que dans les constitutions de la Hongrie et de la Fédération de Russie, pour n'exposer que quelques exemples.

Il est explicitement mentionné dans le Traité sur l'Union européenne ; dans son préambule, à l'article 2 parmi les valeurs fondatrices de l'organisation et à l'article 21 qui dispose quant à lui que l'action de l'Union sur la scène internationale repose sur plusieurs principes, dont l'État de droit.

La notion de prééminence du droit, notion voisine si ce n'est jumelle de l'État de droit, est inscrite dans le préambule de la Convention européenne et irrigue la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme.

La Cour européenne des droits de l'homme affirme que la prééminence du droit est *« une notion inhérente à l'ensemble des articles de la Convention ».*

> → CEDH, 28 mai 2002, *Stafford contre Royaume-Uni*, no 46295/99.

1.3. La définition de l'État de droit selon la Commission de Venise

La Commission européenne pour la démocratie par le droit, connue sous le nom de Commission de Venise, est un organe du Conseil de l'Europe.

Son activité consiste à partager les valeurs qui structurent les activités du Conseil de l'Europe, à savoir, la démocratie, les droits humains et la prééminence du droit, en rendant des avis visant à apporter une aide juridique aux États ainsi qu'en publiant des études et rapports relatifs aux domaines susmentionnés.

La Commission de Venise peut être saisie par des États, des organes du Conseil d'Europe ainsi que des organisations internationales.

Elle a dressé une liste des critères de l'État de droit qui sont les suivants : la légalité, la sécurité juridique, la prévention contre l'abus de pouvoir, l'égalité devant la loi et la non-discrimination, ainsi que l'accès à la justice.

> → Commission européenne pour la démocratie par le droit, « Liste des critères de l'État de droit », adoptée par la Commission de Venise à sa 106e session plénière, Venise, 11-12 mars 2016.

Selon ces critères de l'État de droit, la légalité comprend la primauté du droit, le respect du droit, le rapport entre le droit international et le droit interne, la répartition des compétences entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, ainsi que les modalités de mise en œuvre du droit d'exception.

À cet égard, la Commission souligne que des gouvernements autoritaires ont pu instrumentaliser le droit d'exception :

> *« pour se maintenir au pouvoir, museler l'opposition, et restreindre les droits de l'homme en général ».*

Le principe de sécurité juridique comporte quant à lui les exigences d'accessibilité et de prévisibilité de la loi, la stabilité et la cohérence du droit, les attentes légitimes, un cadre circonscrit de rétroactivité du droit, ainsi que le principe *nullum crimen, nulla poena sine lege* (pas d'infraction ni de sanction sans loi).

Le principe d'égalité et de non-discrimination renvoie à l'égalité dans la loi ainsi qu'à l'égalité devant la loi.

L'accès à la justice exposé dans cette liste englobe plusieurs principes cardinaux. Ces principes résident dans l'indépendance et l'impartialité des juges et du barreau, ainsi que les garanties tenant au procès équitable, comprenant un accès effectif à la justice, la garantie des droits de la défense, dont la présomption d'innocence.

Dans ce même document, la Commission de Venise affirme que :

> *« Il existe des interconnexions entre l'État de droit et les droits de l'homme. L'État de droit serait une coquille vide sans la protection des droits de l'homme. Inversement, la protection et la promotion des droits de l'homme ne sont réalisées que par le respect de l'État de droit : une solide garantie de l'État de droit est vitale pour la protection des droits de l'homme. »*

POUR ALLER PLUS LOIN

Parmi ses activités récentes, la Commission de Venise a rendu en 2023, à propos de la France, un avis relatif à l'article 49 alinéa 3 de la Constitution ainsi qu'un avis conjoint avec la Direction générale des droits humains et de l'État de droit un avis sur le Conseil supérieur de la magistrature et sur le statut de la magistrature en ce qui concerne les nominations, mutations, promotions et procédures disciplinaires.

Parmi les domaines à propos desquels elle rend des avis, se trouvent, par exemple, la liberté de religion, la liberté de réunion pacifique, la liberté d'expression et liberté de recevoir et de diffuser des informations, les droits des minorités, ainsi que la prévention et la protection contre la discrimination.

Actualité. – La Commission de Venise actualise les critères de l'État de droit

La Commission de Venise a adopté, en décembre 2025, une nouvelle version de sa liste des critères de l'État de droit afin de tenir compte des évolutions intervenues depuis 2016. Sans remettre en cause les critères classiques tenant notamment à la légalité, à la sécurité juridique, à la prévention de l'abus de pouvoir, à l'égalité et à l'accès à la justice, elle consacre désormais les mécanismes de freins et contrepoids ainsi que le contrôle de constitutionnalité comme critères spécifiques de l'État de droit.

La nouvelle grille prend également en compte les menaces contemporaines liées au recul de l'État de droit, aux évolutions technologiques et à l'intelligence artificielle ainsi qu'à l'influence croissante d'acteurs privés sur l'exercice des droits et le fonctionnement démocratique.

→ Commission de Venise, *Liste actualisée des critères de l'État de droit*, CDL-AD(2025)002, adoptée les 12 et 13 décembre 2025.

2. La remise en cause protéiforme de l'État de droit

La substance de l'État de droit s'effrite à mesure que se multiplient les dissonances entre sa reconnaissance et les pratiques des gouvernants à travers le monde, y compris en Europe. Plusieurs formulations sont utilisées pour qualifier la nature des modèles antilibéraux telles que « démocratie illibérale », « démocrature », « autocratie électorale », « populisme », « autoritarisme », sans qu'il existe un consensus sur la qualification à employer pour désigner ces modèles parfois hybrides.

Les atteintes à l'État de droit ne connaissent ni la même fréquence ni la même intensité d'un pays à un autre. Elles sont généralement la combinaison d'une contestation de la légitimité des juges, de la contestation du droit supranational, et d'une crise des droits humains.

2.1. La contestation de la légitimité des juges

La contestation de la légitimité des juges fait partie intégrante de cette remise en cause, une critique dite du « gouvernement des juges ».

Elle concerne non seulement les juges ordinaires, mais aussi les juges européens et constitutionnel. Parfois, elle va même jusqu'à l'instrumentalisation de la justice à des fins illibérales, une instrumentalisation intimement liée aux procédures de nomination des juges.

POUR ALLER PLUS LOIN

Plusieurs États sont concernés par des restrictions à l'indépendance des juges. En 2011, une révision constitutionnelle en Hongrie a limité les compétences de la Cour constitutionnelle. En outre, en Pologne, des attaques répétées ont été dirigées contre la Cour suprême, le Conseil national de la magistrature et les juridictions ordinaires. Enfin, en Israël, une réforme de la justice, initiée par le gouvernement de Benjamin Netanyahou en 2023, vise à réduire les pouvoirs de la Cour Suprême.

Actualité jurisprudentielle. - La Cour de justice face à la remise en cause de l'État de droit

La crise de l'État de droit a donné lieu à une nouvelle décision majeure de la Cour de justice. Celle-ci a jugé qu'un État membre ne peut, par l'intermédiaire de sa juridiction constitutionnelle, soustraire son ordre juridique aux exigences découlant des articles 2 et 19 du traité sur l'Union européenne, ni remettre en cause la primauté, l'autonomie et l'effectivité du droit de l'Union. La Cour condamne ainsi la Pologne pour les positions adoptées par son Tribunal constitutionnel contestant la force obligatoire de certaines décisions de la Cour de justice et la possibilité pour les juridictions nationales d'en assurer l'exécution (CJUE, Gde ch., 18 décembre 2025, *Commission c. Pologne*, C-448/23).

À retenir. - L'État de droit n'est plus seulement une valeur politique proclamée à l'article 2 TUE : il produit des obligations juridiques dont la Cour de justice peut assurer le respect à l'égard des États membres.

2.2. La contestation du droit supranational

La Cour européenne des droits de l'homme est souvent l'objet d'une rhétorique hostile en raison de la menace perçue pour la souveraineté des États qu'elle représenterait.

Le refus de certains États condamnés d'appliquer les décisions de la Cour dans certains domaines et les critiques récurrentes concernant l'interprétation par la Cour des dispositions de la Convention phare du Conseil de l'Europe témoignent d'une contestation du droit supranational.

Le droit de l'Union européenne fait également l'objet de contestations, en particulier en ce qui concerne le principe de primauté de ce dernier.

→ CJUE, 15 juillet 1964, *Costa contre Enel*, n° C-6/64.

Le rejet de la primauté du droit de l'Union européenne s'est notamment manifesté par une décision du Tribunal constitutionnel polonais du 7 octobre 2021.

2.3. La crise des droits humains

Les droits humains sont parfois perçus comme un obstacle à l'exercice du pouvoir. Ainsi, la crise des droits humains prend diverses formes, telles que, de façon non-exhaustive, la fragilisation des droits de l'opposition, la crise de la liberté académique, la remise en cause des droits des femmes ainsi que la réticence à l'égard des droits des personnes migrantes.

2.3.1 La fragilisation des droits de l'opposition

La restriction des droits de l'opposition, qu'elle soit parlementaire ou extra-parlementaire, constitue un indicateur de l'illibéralisme. Plusieurs États sont concernés par un affaiblissement de ces droits, affectant non seulement les organisations non gouvernementales, mais aussi les médias.

La répression politique est particulièrement marquée en Turquie. L'incarcération d'opposants au gouvernement, militants, journalistes et avocats s'élève, selon *Prison Insider,* à 10 % de la population carcérale.

POUR ALLER PLUS LOIN

La Cour européenne continue de rendre des décisions sur les affaires pendantes concernant la Russie et son exclusion du Conseil de l'Europe en 2022, en vertu de l'article 8 du Statut du Conseil de l'Europe, en réaction à l'agression militaire en Ukraine.

En 2024, dans l'affaire Shlosberg contre Russie, la Cour a jugé que la décision d'inéligibilité d'un candidat à la Douma en raison de sa participation à une manifestation pacifique de soutien à Alexeï Navalny était contraire à l'article 3 du Protocole n° 1 relatif au droit à des élections libres.

2.3.2. La liberté académique en crise

La liberté académique est menacée dans plusieurs pays européens, notamment en Hongrie, où le gouvernement de Viktor Orban a pris des mesures portant atteintes à la liberté des universitaires et l'autonomie des universités.

La réélection de Donald Trump à la présidence des États-Unis d'Amérique a marqué un tournant important en termes de liberté académique par une succession de mesures préoccupantes à l'encontre de la recherche. Ces atteintes à la science se manifestent, entre autres, par l'interdiction de publications dans un nombre élevé de domaines, dont plusieurs liés aux droits humains.

2.3.3. La remise en cause des droits des femmes

Le 8 mars 2024, une révision constitutionnelle a intégré à l'article 34 de la Constitution la liberté des femmes de recourir à une interruption volontaire de grossesse. Inédite dans l'histoire, cette révision s'inscrit dans un contexte de restriction et/ou d'interdiction croissantes, notamment aux États-Unis.

> → Loi constitutionnelle n° 2024-200 du 8 mars 2024 relative à la liberté de recourir à l'interruption volontaire de grossesse.

Plusieurs États sont concernés par cette remise en cause, dont la Pologne. En 2020, le Tribunal constitutionnel polonais affirme l'interdiction de recourir à une interruption volontaire de grossesse en cas d'anomalie du fœtus.

Cette régression concerne également les États-Unis avec la décision rendue par la Cour Suprême en 2022 qui renverse sa jurisprudence *Roe v. Wade* de 1973, laissant ainsi aux entités fédérées un pouvoir discrétionnaire en la matière.

> → Tribunal constitutionnel polonais, 22 octobre 2020.

> → Cour Suprême américaine, 24 juin 2022, *Dobbs c. Jackson Women's Health Organization.*

Jusqu'en 2023, Malte était le dernier État membre de l'Union européenne à interdire en toute circonstance l'interruption volontaire de grossesse. En juin 2023, une loi a été votée pour l'autoriser, dans des conditions toutefois restrictives.

2.3.4. La réticence à l'égard des droits des personnes migrantes

La matière migratoire est particulièrement touchée par la crise des droits humains.

Plusieurs États européens ont fait l'objet d'une condamnation par la Cour de justice de l'Union européenne pour avoir relocalisé des demandeurs de protection internationale.

> → CJUE, 2 avril 2020, *Commission contre Pologne, Hongrie et République Tchèque*, aff. C-715/17, C-718/17, C-719/17.

Qui plus est, en 2024, le gouvernement de Giorgia Meloni a conclu un accord avec l'Albanie visant à externaliser la présence de personnes migrantes vers des centres de rétention administrative albanais, l'Albanie ne faisait pas partie de l'Union européenne.

En 2025, la Cour européenne des droits de l'homme a reconnu une pratique systématique de refoulements des demandeurs d'asile depuis la Grèce vers la Turquie.

> → CEDH, 7 janvier 2025*, A.R.E. contre Grèce*, n° 15783/21.

POUR ALLER PLUS LOIN

Dans son rapport annuel d'activité de 2023, la Défenseure des droits a livré un bilan critique de la situation des droits humains en France. L'État de droit y est présenté comme « menacé par l'érosion des droits fondamentaux ».

Le rapport soulève plusieurs fragilités de l'État de droit, au nombre desquelles se trouvent les critiques portées à l'autorité et au rôle du juge, la non-exécution de décisions de la Cour européenne des droits de l'homme, la multiplication des restrictions des libertés d'expression, de manifestation et d'association. Ce même document met tout de même en lumière plusieurs avancées majeures de l'année 2023, telle que la gratuité du numéro 31 41 permettant aux personnes détenues de faire valoir leurs droits sans écoute ni enregistrement.

POUR S'ENTRAÎNER

Commentaire de texte : Article 2 du Traité sur l'Union européenne : *« L'Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d'égalité, de l'État de droit, ainsi que de respect des droits de l'homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités. Ces valeurs sont communes aux États membres dans une société caractérisée par le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l'égalité entre les femmes et les hommes. »*

Signé en 1992 et entré en vigueur en 1993, le Traité sur l'Union européenne (Traité de Maastricht) fait partie du droit primaire de l'Union européenne. Il établit les principes politiques et les valeurs fondatrices de l'Union. Révisé à plusieurs reprises (par les Traités d'Amsterdam, de Nice, et de Lisbonne), il encadre la répartition des compétences entre l'Union et ses États membres, comporte des dispositions relatives aux institutions de l'organisation et fixe des règles de coopération dans certains domaines. L'article 6 de la version initiale comportait des dispositions similaires, mais moins détaillées, aux dispositions de l'actuel article 2. Ce contenu était d'ores et déjà en germe dans l'Acte unique européen de 1986. Les valeurs exposées s'inscrivent dans le sillage des standards matriciels du Conseil de l'Europe.

La portée juridique ainsi que la justiciabilité de ces valeurs interpellent à l'aune des atteintes répétées par des États européens aux valeurs que cet article contient.

Problématique et annonce de plan : Malgré la reconnaissance textuelle de valeurs libérales gravées dans le marbre du Traité sur l'Union européenne **(I)**, le respect de ces valeurs tend vers un affaiblissement croissant **(II)**.

I. Une reconnaissance textuelle des valeurs fondatrices de l'Union européenne

A. Une manifestation des valeurs libérales de l'Union européenne

Définir précisément le libéralisme peut être complexe en raison des diverses interprétations possibles.

Le libéralisme se caractérise par la protection des libertés individuelles face à la puissance publique, dans un cadre juridique qui garantit les droits humains. Si ces libertés peuvent être limitées pour des raisons d'intérêt général ou d'ordre public, de telles restrictions doivent rester l'exception.

Les valeurs énoncées à l'article 2 reflètent la dimension libérale de l'organisation, des valeurs qui irriguent l'ensemble de la politique de l'Union. Elles trouvent un écho dans le Préambule de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qui réitère ces valeurs en affirmant notamment que l'Union *« repose sur le principe de la démocratie et le principe de l'État de droit »*.

B. Une reconnaissance assortie de mécanismes de garantie

L'article 7 du Traité sur l'Union européenne établit un mécanisme non-juridictionnel de prévention et de sanction visant à constater *« un risque clair de violation grave par un État membre des valeurs visées à l'article 2 »*.

Cette procédure a été activée à l'encontre de la Pologne en 2017 ainsi qu'à l'encontre de la Hongrie en 2018. La faible effectivité de cette procédure a mené au renforcement du cadre de garanties des valeurs de l'Union.

L'article 258 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prévoit une procédure en manquement.

Un règlement sur la conditionnalité de fonds européens a été adopté le 16 décembre 2020 afin d'exercer une pression financière sur les États qui ne respectent pas les valeurs de l'Union.

Des mécanismes juridictionnels visent à assurer implicitement le respect de ces valeurs, tel que le recours en manquement.

II. Un affaiblissement croissant du respect des valeurs de l'Union européenne

A. La crise des valeurs au sein des États membres de l'Union européenne

L'article commenté consacre le pluralisme parmi les valeurs fondamentales de l'Union. Toutefois, le respect de ce pluralisme est en péril dans plusieurs États, notamment en Hongrie avec un fort contrôle gouvernemental sur les médias mis en place.

Le rapport sur l'Etat de droit dans l'Union européenne de 2024 expose des inquiétudes relatives à la transparence en matière de propriété des médias en France ainsi qu'aux menaces et agressions, notamment lors de manifestations de journalistes.

Une incarnation tragique de la crise de la liberté de presse se traduit par le meurtre en 2017 de la journaliste Daphne Caruana Galizia qui enquêtait sur la corruption à Malte.

B. Le relâchement des valeurs au sein de l'Union européenne

Dans la liste des critères de l'État de droit précitée, la Commission de Venise expose parmi les exemples de défis spécifiques à l'État de droit la corruption et les conflits d'intérêts. Selon ses termes, la corruption *« débouche sur l'arbitraire et l'abus de pouvoir, car les décisions ne sont pas prises conformément au droit, et mine ainsi les fondements mêmes de l'État de droit »*.

Les récentes affaires du « Qatargate » et du « Marocgate » contribuent à l'affaiblissement de la crédibilité des valeurs promues par l'Union européenne, y compris à l'échelle internationale, alors que le respect des droits humains constitue une condition d'adhésion et de maintien dans l'Union européenne et que ces valeurs sont promues par l'Union.

En conclusion, la **montée de l'illibéralisme** soulève des interrogations sur l'avenir de la préservation de celles-ci et des mécanismes garantissant leur respect. Dans sa liste des critères de l'État de droit, la Commission de Venise affirme que, parallèlement à la dimension juridique, l'État de droit doit être, au sein d'une société, accompagné d'une culture politique et juridique.

PARTIE II. LES SOURCES INTERNES

Fiche n°9

Les sources constitutionnelles

Fiche n°10

Le bloc de légalité

Fiche n°11

Le règlement et les libertés

Fiche n° 9 - LES SOURCES CONSTITUTIONNELLES

POINTS CLÉS

- Évolution du rôle du Conseil constitutionnel.
- Création prétorienne du bloc de constitutionnalité.
- Diversité des composants du bloc de constitutionnalité.
- Le Conseil constitutionnel garant des droits et libertés fondamentaux.

PRINCIPALES RÉFÉRENCES

- Cons. const., n° 71-44 DC, 16 juillet 1971, *Loi complétant les dispositions des articles 5 et 7 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.*
- Pierre Avril, Jean Gicquel, *Le Conseil constitutionnel*, Montchrestien, 6e éd., 2011.
- Louis Favoreu et al. *Les grandes décisions du Conseil constitutionnel*, Dalloz, 20e éd., 2022.
- E. Picard, « L'émergence des droits fondamentaux en France », *AJDA*, 1998. 6, n° spécial juillet-août.
- « Le Conseil constitutionnel », *Pouvoirs*, 2003, n° 105.
- « Les catégories de normes constitutionnelles », *Titre VII*, n° 8, 2022.
- *Redécouvrir le Préambule de la Constitution* – Rapport du comité présidé par Simone Veil, La Documentation française, 2008.

1. Le bloc de constitutionnalité

La Ve République marque un point de rupture avec les régimes précédents par l'instauration du Conseil constitutionnel. Initialement imaginé comme soutien du pouvoir exécutif dans le cadre de la rationalisation du parlementarisme, le Conseil constitutionnel est progressivement devenu gardien des droits fondamentaux constitutionnels grâce à la création du « bloc de constitutionnalité ».

1.1. Avant la Constitution de 1958

POUR ALLER PLUS LOIN

Cette expression initialement créée par Claude Emeri, par opposition au bloc de légalité, lequel contenait les libertés adoptées par voie législative lors de la IIIe République, a été popularisée et développée par Louis Favoreu. À ce vocable est parfois préféré celui de normes de référence du contrôle de constitutionnalité. Il s'agit toujours de désigner les normes qui ont une valeur constitutionnelle que le juge constitutionnel peut utiliser dans son contrôle de constitutionnalité des lois et des traités internationaux.

Il n'y avait pas de consécration constitutionnelle des libertés dans les constitutions du XIXe siècle, ou alors exceptionnellement, comme dans la Constitution de 1848. La Constitution de 1875, en particulier, ne s'intéressait absolument pas aux droits et libertés. Face à ce silence, il y a eu des débats sur la valeur de la Déclaration de 1789.

Deux thèses s'affrontent sur la question de la valeur de la déclaration de 1789 :

- D'un côté, la première thèse soutient l'idée d'une valeur juridique des déclarations des droits en droit positif et, même, d'une valeur supérieure aux autres normes juridiques. Il y aurait une valeur supra-constitutionnelle de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, celle-ci aurait possédé une valeur antérieurement à son rattachement à la Constitution de 1791 et la conserve. La Déclaration ne ferait que retranscrire des droits « naturels » qui lui préexistent. Cette thèse se fonde sur deux raisons principales : les principes de droit naturel sont supérieurs à toute règle juridique et il y aurait une nature intrinsèquement supérieure de ces principes.
- De l'autre côté, la deuxième thèse défend l'idée d'une simple valeur philosophique et morale de la Déclaration de 1789. Deux raisons principales sont avancées :
    - Les principes de 1789 sont trop généraux et vagues.
    - La Constitution de 1791 contient un titre I sur la garantie du droit, la Constitution de 1848 un chapitre II sur les droits des citoyens garantis par la Constitution.

Il n'y a jamais eu de solution sur la valeur réelle de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ou même du Préambule de 1946. La question n'a jamais été réglée avant la Ve République.

1.2. Après la Constitution de 1958

Avec la Constitution de la Ve République, une multiplicité de normes va pouvoir être utilisée par le Conseil constitutionnel lors de son contrôle de constitutionnalité des lois en se basant sur le préambule de la Constitution :

> *« Le peuple français proclame solennellement son attachement aux droits de l'homme et aux principes de la souveraineté nationale, tels qu'ils sont définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le Préambule de la Constitution de 1946. »*

Le Conseil constitutionnel a eu un rôle actif dans la reconnaissance et la consécration constitutionnelle de ces différentes sources formant le bloc de constitutionnalité.

2. Le contenu du bloc de constitutionnalité

Le bloc de constitutionnalité est composé d'un ensemble de normes regroupant : la Constitution du 4 octobre 1958 et son préambule, le préambule de la Constitution de 1946, de la Déclaration de 1789, de la Charte de l'environnement de 2004, des principes à valeur constitutionnelle et des objectifs à valeur constitutionnelle.

2.1. La Constitution de 1958 et son préambule

Le corps de la Constitution de 1958 contient peu de droit et libertés. Certains articles y font tout de même référence :

- Art. 1 : égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion, et l'égalité entre les sexes dans les fonctions électives professionnelles et sociales.
- Art. 2 : forme démocratique du régime et devise « *Liberté, Égalité, Fraternité* ».
- Art. 3 : suffrage universel, égal et secret.
- Art. 4 : pluralisme et liberté des partis politiques.
- Art. 16 : pouvoirs du président de la République en cas de circonstances exceptionnelles.
- Art. 34 : détermination du domaine de la loi.
- Art. 53-2 : possibilité de reconnaître la juridiction de la Cour pénale internationale.
- Art. 61 : contrôle *a priori* de constitutionnalité des lois.
- Art. 61-1 : contrôle *a posteriori* de constitutionnalité des lois.
- Art. 64 : indépendance des magistrats.
- Art. 66 : *« Nul ne peut être arbitrairement détenu. L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi. »*
- Art. 66-1 : *« Nul ne peut être condamné à la peine de mort. »*

Le Préambule de la Constitution de 1958 fait référence à de nombreux textes sur lesquels le Conseil constitutionnel va pouvoir s'appuyer comme normes de référence pour effectuer son contrôle de constitutionnalité des lois.

> *« Le peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l'homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946, ainsi qu'aux droits et devoirs définis dans la Charte de l'environnement de 2004. »*

2.2. Le préambule de la Constitution de 1946

Au sein du préambule de la Constitution de 1946 se trouvent les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République et les principes particulièrement nécessaires à notre temps.

2.2.1. Les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République

Le Conseil constitutionnel a consacré pour la première fois le principe de la liberté d'association en 1971 en tant que principe fondamental reconnu par les lois de la République ce qui était incompatible avec la volonté du législateur de mettre en place un régime d'autorisation préalable.

> → Cons. const., déc. n° 71-44 DC, 16 juillet 1971, *Loi complétant les dispositions des articles 5 et 7 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.*

Dans le cadre de ces principes, le juge constitutionnel a un rôle actif dans la reconnaissance et la proclamation de ces principes.

Il va puiser et s'inspirer des lois des républiques précédentes pour dégager ces différents principes en suivant différentes règles.

Le Conseil constitutionnel reconnaît un principe fondamental reconnu par les lois de la République selon trois critères cumulatifs :

- Le principe doit être une règle suffisamment importante, avoir un degré suffisant de généralité et intéresser des domaines essentiels de la vie de la nation comme les libertés fondamentales, la souveraineté nationale ou l'organisation des pouvoirs publics.

  > → Cons. const., déc. n° 98-407 DC, 14 janvier 1999, *Loi relative au mode d'élection des conseillers régionaux et des conseillers à l'Assemblée de Corse et au fonctionnement des Conseils régionaux.*

- Le principe doit trouver une base textuelle dans une ou plusieurs lois républicaines antérieures à 1946

  > → Cons. const., déc. n° 86-224 DC, 23 janvier 1987, *Loi transférant à la juridiction judiciaire le contentieux des décisions du Conseil de la concurrence*.

- Le principe doit avoir fait l'objet d'une application continue. Aucune dérogation à ce principe par une loi antérieure à la Constitution de 1946 n'est acceptée.

  > → Cons. const., déc. n° 88-224 DC, 20 juillet 1988, *Loi portant amnistie.*

Le Conseil constitutionnel a pu être critiqué sur le fait que ces critères restent vagues et qu'il possède ainsi un fort pouvoir créateur.

Plusieurs principes ont été reconnus par le Conseil constitutionnel :

- La liberté d'association.

  > → Cons. const., déc. n° 71-44 DC, 16 juillet 1971, *Loi complétant les dispositions des articles 5 et 7 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.*

- Le respect des droits de la défense.

  > → Cons. const., déc. n° 76-70 DC, 2 décembre 1976, *Loi relative au développement de la prévention des accidents du travail.*

- La liberté individuelle.

  → Cons. const., déc. n° 76-75 DC, 12 janvier 1977, *Loi autorisant la visite des véhicules en vue de la recherche et de la prévention des accidents du travail.*

- La liberté de conscience et la liberté d'enseignement.

  → Cons. const., déc. n° 77-87 DC, 23 novembre 1977, *Loi complémentaire à la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée par la loi n° 71-400 du 1er juin 1971 et relative à la liberté de l'enseignement.*

- L'indépendance de la juridiction administrative.

  → Cons. const., déc. n° 80-119 DC, 22 juillet 1980, *Loi portant validation d'actes administratifs.*

- La garantie de l'indépendance des professeurs d'université.

  → Cons. const., déc. n° 83-165 DC, 20 janvier 1984, *Loi relative à l'enseignement supérieur.*

- La compétence exclusive de la juridiction administrative pour l'annulation des actes de la puissance publique.

  → Cons. const., déc. n° 86-224 DC, 23 janvier 1987, *Loi transférant à la juridiction judiciaire le contentieux des décisions du Conseil de la concurrence*.

- La compétence de l'autorité judiciaire en matière de protection de la propriété immobilière privée.

  → Cons. const., déc. n° 89-256 DC, 25 juillet 1989, *Loi portant dispositions diverses en matière d'urbanisme et d'agglomérations nouvelles.*

- La recherche du relèvement éducatif et moral des enfants délinquants par des mesures adaptées.

  → Cons. const., déc. n° 2002-461 DC, 29 août 2002, *Loi d'orientation et de programmation pour la justice.*

- Le maintien de la législation des départements d'Alsace et de Moselle tant qu'elle n'est pas remplacée.

  → Cons. const., déc. n° 2011-157 QPC, 5 août 2011, *Société SOMODIA [Interdiction du travail le dimanche en Alsace-Moselle].*

Quelques principes fondamentaux reconnus par les lois de la République ont aussi été reconnus par la Cour de cassation et le Conseil d'État :

- Refus d'extradition dans un but politique.

  → CE, déc. n° 169219, 3 juillet 1996, *Koné.*

- La laïcité.

  → CE, déc. n° 219379, 6 avril 2001, *Syndicat national des enseignants du second degré*.

Afin de limiter les critiques concernant leur reconnaissance, le Conseil constitutionnel n'intervient pas dans les questions sociétales et considère que cela relève du domaine d'appréciation du législateur.

→ Cons. const., déc. n° 2013-669 DC, 17 mai 2013, *Loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe.*

Actualité jurisprudentielle. - Le PFRLR relatif à la justice pénale des mineurs demeure une norme de contrôle pleinement applicable

Le Conseil constitutionnel a précisé en 2025 les exigences qui découlent du principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice pénale des mineurs. Celui-ci impose notamment de rechercher le relèvement éducatif et moral des mineurs par des mesures adaptées à leur âge et à leur personnalité, mises en œuvre par une juridiction spécialisée ou selon des procédures appropriées.

Saisi du régime permettant le maintien en détention provisoire d'un mineur d'au moins seize ans après sa mise en accusation devant la cour d'assises des mineurs, le Conseil constitutionnel rappelle que la détention d'un mineur doit rester exceptionnelle et entourée de garanties particulières. Il censure les dispositions qui permettaient son maintien selon des règles insuffisamment adaptées à la spécificité de la justice des mineurs.

→ Cons. const., déc. n° 2025-1143 QPC, 27 juin 2025, *M. Mohamed Z.* [Durée de la détention provisoire d'un mineur après sa mise en accusation devant la cour d'assises].

À retenir. - Les PFRLR ne constituent pas seulement des principes dégagés à partir de lois anciennes : ils peuvent encore conduire à la censure de dispositifs législatifs contemporains lorsqu'ils ne respectent pas les garanties constitutionnelles qui en découlent.

2.2.2. Les principes particulièrement nécessaires à notre temps

Le Préambule de la Constitution de 1946 proclame comme particulièrement nécessaires à notre temps des principes politiques, économiques et sociaux limitativement énumérés.

Il est possible de classer les principes particulièrement nécessaires à notre temps en deux catégories :

- La première génération des droits humains : ce sont des droits et libertés qui supposent l'abstention de l'État.
- La seconde génération des droits humains : ce sont des « droits-créances » qui supposent une intervention de l'État pour la réalisation de ces droits.

Il existe de nombreux principes particulièrement nécessaires à notre temps :

- L'égalité entre les sexes.
- Le droit d'asile pour tout homme *« persécuté en raison de son action en faveur de la liberté »*.
- Le droit au travail et à l'emploi.
- Le droit à la non-discrimination dans le travail.
- Le droit à l'action syndicale.
- Le droit de grève.
- Le droit à la participation à la détermination collective des conditions de travail.
- La possibilité des expropriations pour cause d'utilité publique.
- Le droit à obtenir de la collectivité les moyens nécessaires au développement de l'individu et de la famille.
- Le droit à la protection de la santé, à la solidarité pour ceux qui ne peuvent pas travailler.
- Le principe de solidarité devant les catastrophes naturelles.
- Le droit à l'instruction, à la formation professionnelle et à la culture.
- Le principe du respect du droit international, et de l'abstention de l'usage agressif de la force.
- Le principe d'égalité des droits et des devoirs, sans distinction de race ni de religion.

2.3. La Déclaration de 1789

Le Conseil constitutionnel a reconnu expressément la valeur constitutionnelle de la Déclaration de 1789 en 1973.

> → Cons. const., déc. n° 73-51 DC, 27 décembre 1973, *Loi de finances pour 1974 « Taxation d'office »* : *« Considérant, toutefois, que la dernière disposition de l'alinéa ajouté à l'article 180 du code général des impôts par l'article 62 de la loi de finances pour 1974, tend à instituer une discrimination entre les citoyens au regard de la possibilité d'apporter une preuve contraire à une décision de taxation d'office de l'administration les concernant ; qu'ainsi ladite disposition porte atteinte au principe de l'égalité devant la loi contenu dans la Déclaration des droits de l'homme de 1789 et solennellement réaffirmé par le préambule de la Constitution. »*

Le Conseil constitutionnel accepte ainsi tous les moyens tirés de la violation d'un article de la Déclaration pour effectuer le contrôle de constitutionnalité des lois.

2.4. La Charte de l'environnement

La Charte de l'environnement de 2004 a été intégrée dans le préambule de la Constitution avec la révision constitutionnelle du 1er mars 2005.

Le législateur doit donc respecter les différents droits et devoirs de la Charte de l'environnement.

- Art. 1 : droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé.
- Art. 2 : obligation de chacun de participer à la préservation et à l'amélioration de l'environnement.
- Art. 3 : chacun doit prévenir ou limiter les conséquences des atteintes qu'il peut porter à l'environnement…
- Art. 4 : … et contribuer à leur réparation.
- Art. 5 : principe de précaution - *« Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en œuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage. »*
- Art. 6 : le développement durable est un objectif des politiques publiques.
- Art. 7 : toute personne a le droit d'accéder aux informations sur l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant des conséquences sur l'environnement. Le législateur est compétent pour fixer les modalités de cette participation citoyenne et cette dernière doit permettre aux citoyens de connaître les incidences directes et significatives de ces décisions sur l'environnement.

  → Cons. const., déc. n° 2016-595 QPC, 18 novembre 2016.

  → Cons. const., déc. n° 2020-843 QPC, 28 mai 2020.

- Art. 9 : la recherche et l'innovation doivent apporter leur concours à la préservation et à la mise en valeur de l'environnement.

La valeur constitutionnelle de la Charte de l'environnement a été reconnue explicitement par le Conseil constitutionnel.

→ Cons. const., déc. n° 2005-514 DC, *Loi relative à la création du registre international français*.

À l'exception de l'article 6 de la Charte de l'environnement qui n'institue pas un droit ou une liberté que la Constitution garantit.

→ Cons. const., déc. n° 2012-283 QPC, *M. Antoine de M. [Classement et déclassement de sites].*

POUR ALLER PLUS LOIN

Le choix du pouvoir constituant dérivé d'intégrer la Charte de l'environnement dans le préambule de la Constitution de 1958 vient légitimer toute la démarche prétorienne du Conseil constitutionnel afférent à la création du bloc de constitutionnalité.

En effet, la volonté était de donner une valeur constitutionnelle à cette Charte, son intégration dans le préambule vient donc reconnaître implicitement la valeur constitutionnelle de ce dernier.

2.5. Les principes à valeur constitutionnelle

Le Conseil constitutionnel au fil de sa jurisprudence consacre différents principes comme des principes à valeur constitutionnelle. Pour créer et dégager ces différents principes à valeur constitutionnelle, le Conseil constitutionnel s'appuie sur le premier alinéa du préambule de la Constitution de 1946.

> *« Au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d'asservir et de dégrader la personne humaine, le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés. Il réaffirme*

solennellement les droits et libertés de l'homme et du citoyen consacrés par la Déclaration des droits de 1789 et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. »

Le Conseil constitutionnel a alors considéré que *«* la sauvegarde de la dignité de la personne contre toute forme d'asservissement et de dégradation est au nombre de ces droits et constitue un principe à valeur constitutionnelle *».*

→ Cons. const., déc. n° 94-343/344 DC, 27 juillet 1994, *Loi relative au respect du corps humain et loi relative au don et à l'utilisation des éléments et produits du corps humain, à l'assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal.*

→ Cons. const., déc. n° 2017-632 QPC, 2 juin 2017, *Union nationale des associations de familles de traumatisés crâniens et de cérébrolésés [Procédure collégiale préalable à la décision de limitation ou d'arrêt des traitements d'une personne hors d'état d'exprimer sa volonté].*

Parmi les principes à valeur constitutionnelle, on trouve :

- La continuité de l'État et du service public.

  → Cons. const., déc. n° 79-105 DC, 25 juillet 1979, *Loi modifiant les dispositions de la loi n° 74-696 du 7 août 1974 relatives à la continuité du service public de la radio et de la télévision en cas de cessation concertée du travail.*

- La liberté d'entreprendre.

  → Cons. const., déc. n° 81-132 DC, 16 janvier 1982, *Loi de nationalisation.*

- La liberté d'aller et de venir.

  → Cons. const., déc. n° 79-107 DC, 12 juillet 1979, *Loi relative à certains ouvrages reliant les voies nationales ou départementales.*

- La liberté personnelle du salarié.

  → Cons. const., déc. n° 89-257 DC, 25 juillet 1989, *Loi modifiant le Code du travail et relative à la prévention du licenciement économique et au droit à la conversion*.

- La sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme d'asservissement et de dégradation.

  → Cons. const., déc. n° 94-34/344 DC, 27 juillet 1994, *Loi relative au respect du corps humain et loi relative au don et à l'utilisation des éléments et produits du corps humain, à l'assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal.*

- L'inamovibilité des magistrats du siège.

  → Cons. const., déc. n° 70-40 DC, 9 juillet 1970, déc. n° 70-40 DC, *Loi organique relative au statut des magistrats.*

- Le principe du pollueur-payeur.

  → Cons. const., déc. n° 99-424 DC, 29 décembre 1999, *Loi de finances pour 2000.*

- Le principe de fraternité.

  → Cons. const., déc. n° 2018-717/718 QPC, 6 juillet 2018, *M. Cédric H. et autre [Délit d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger].*

- La publicité des audiences devant les juridictions civiles et administratives.

  → Cons. const., déc. n° 2019-778 DC, 21 mars 2019, *Loi de programmation 2018-2022 et de réforme de la Justice.*

2.6. Les objectifs à valeur constitutionnelle

La première consécration des objectifs de valeur constitutionnelle par le Conseil constitutionnel a été faite en 1982.

→ Cons. const., déc. n° 82-141, 27 juillet 1982, *Loi sur la communication audiovisuelle* : *« Il appartient au législateur de concilier* […] *l'exercice de la liberté de communication telle qu'elle résulte de l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme, avec* […] *les objectifs de valeur constitutionnelle que sont la sauvegarde de l'ordre public, le respect de la liberté d'autrui et la préservation du caractère pluraliste des courants d'expression socioculturels. »*

Comme son appellation l'indique, il s'agit d'objectifs, c'est-à-dire d'orientations. Les objectifs de valeur constitutionnelle n'ont donc pas de portée normative. Pour cette raison, le Conseil constitutionnel considère qu'ils ne constituent pas en eux-mêmes des droits et libertés au sens de l'article 61-1 de la Constitution, permettant de fonder une question prioritaire de constitutionnalité.

Certains objectifs limitent les droits et libertés (bonne administration de la justice, protection des deniers publics, préservation de l'ordre public), et d'autres les rendent plus effectifs (parité entre les hommes et les femmes). Il s'agit d'orientations générales à destination du législateur.

Parfois le Conseil constitutionnel rattache ces objectifs à des dispositions constitutionnelles, mais ce n'est pas toujours le cas.

Ont été consacrés comme objectifs à valeur constitutionnelle :

- Le maintien de l'ordre public.

  → Cons. const., déc. n° 82-141 DC, 27 juillet 1982, *Loi sur la communication audiovisuelle.*

- La recherche des auteurs d'infractions.

  → Cons. const., déc. n° 96-377 DC, 16 juillet 1996, *Loi tendant à renforcer la répression du terrorisme et des atteintes aux personnes dépositaires de l'autorité publique ou chargées d'une mission de service public et comportant des dispositions relatives à la police judiciaire*.

Concernant ces deux objectifs : le législateur effectue une conciliation entre celui de sauvegarde de l'ordre public et de prévention des infractions avec l'exercice des libertés constitutionnellement garanties, notamment la liberté personnelle.

→ Cons. const., déc. n° 2018-761 QPC, 1er février 2019.

- La possibilité pour toute personne de disposer d'un logement décent.

  → Cons. const., déc. n° 94-359 DC, 19 janvier 1995, *Loi relative à la diversité de l'habitat.*

- L'accessibilité et l'intelligibilité du droit.

  → Cons. const., déc. n° 99-421 DC, 16 décembre 1999, *Loi portant habilitation du Gouvernement à procéder, par ordonnances, à l'adoption de la partie législative de certains codes.*

- La lutte contre la fraude fiscale.

  → Cons. const., déc. n° 99-424 DC, 29 décembre 1999, *Loi de finances pour 2000.*

- Égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives.

  → Cons. const., déc. n° 2000-429 DC, 30 mai 2000, *Loi tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives*.

- L'équilibre financier de la sécurité sociale.

  → Cons. const., déc. n° 2001-453 DC, 18 décembre 2001, *LFSS pour 2002.*

- Le bon usage ou le bon emploi des deniers publics.

  → Cons. const., déc. n° 2003-473 DC, 26 juin 2003, *Loi habilitant le Gouvernement à simplifier le droit.*

- Le pluralisme des courants d'expression socioculturel.

  → Cons. const., déc. n° 93-333 DC, 21 janvier 1994, *Loi modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.*

- Le pluralisme et l'indépendance des médias

  → Cons. const., déc. n° 2009-577 DC, 3 mars 2009, *Loi relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision.*

- La bonne administration de la justice.

  → Cons. const., déc. n° 2009-595 DC, 3 décembre 2009, *Loi organique relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution.*

- La protection de la santé.

  → Cons. const., déc. n° 2012-248 QPC, 16 mai 2012, *M. Mathieu E. [Accès aux origines personnelles].*

- Lutte contre la fraude en matière sociale.

  → Cons. const., déc. n° 2019-798 QPC, 14 juin 2019, *Mme Hanen S.*

- Protection de l'environnement, patrimoine commun des êtres humains.

  → Cons. const., déc. n° 2019-823 QPC, 31 janvier 2020, *Union des industries de la protection des plantes.*

- Sauvegarde de la propriété intellectuelle.

  → Cons. const., déc. n° 2020-841 QPC, 20 mai 2020, *La quadrature du net et autres.*

Les objectifs de valeur constitutionnelle représentent aussi une forme de garantie pour les droits fondamentaux dans la mesure où ils assurent l'équilibre du système social et juridique. Ils révèlent l'importance particulière de la conciliation entre les principes propres aux libertés fondamentales.

Les objectifs sont donc des guides pour la conciliation de ces principes.

3. La supériorité du bloc de constitutionnalité

La Constitution est définie comme la norme la plus haute dans la hiérarchie des normes. Elle est supérieure et donc suprême. La Constitution est un ensemble de normes suprêmes fondant l'autorité étatique et attribuant des compétences à ses institutions.

La Constitution détermine les modalités de production des normes qui lui sont inférieures, idem pour la loi, idem pour le règlement… La suprématie de la Constitution signifie alors que c'est la norme limite d'un système. C'est d'elle que résultent toutes les autres normes. Cela implique que les divers actes juridiques doivent lui être conformes.

Cette théorie a été développée par Kelsen avec la hiérarchie des normes :

- Existence d'une norme supérieure (selon l'ordre de production) N ;
- Cette norme N définit les conditions de production de la norme qui lui est directement inférieure N-1 ;
- Cette norme N-1 définira les conditions de production d'une norme N-2 et ainsi de suite ;
- Il se peut toutefois que la norme N-2 ne respecte pas toutes les conditions nécessaires à sa production.

C'est cette suprématie de la norme supérieure N, la Constitution et le bloc de constitutionnalité, qui justifie notamment le contrôle de la constitutionnalité des lois, c'est-à-dire la vérification de la conformité d'une loi à la Constitution.

POUR S'ENTRAÎNER

Commentaire de décision : Cons. const., n° 71-44 DC, 16 juillet 1971, Loi complétant les dispositions des articles 5 et 7 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.

Cette célèbre décision du Conseil constitutionnel vient fixer les contours du contrôle de constitutionnalité des lois effectué par ce dernier. Elle illustre la capacité du Conseil constitutionnel à se donner ses propres normes de référence pour exercer ce contrôle de constitutionnalité des lois.

Cette décision phare a aussi permis au préambule de la Constitution de 1958 d'être consacré comme constitutionnel.

Initialement, pour exercer son contrôle de constitutionnalité des lois, le Conseil constitutionnel était limité aux dispositions des articles 1er à 89 de la Constitution de 1958. Dans cette décision de 1971, les juges constitutionnels ont de manière prétorienne décidé de censurer une loi en se référant à une catégorie de normes mentionnée dans le préambule de la Constitution de 1958 : les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République.

Cette décision de 1971 n'est pas la première dans laquelle le Conseil constitutionnel mentionne le préambule de la Constitution de 1958 (Cons. const., n° 70-39 DC, 19 juin 1970), mais il s'agit de la première qui censure explicitement sur le fondement du préambule de la Constitution de 1958.

Problématique et annonce du plan : Le conseil constitutionnel fonde désormais son contrôle sur les libertés fondamentales en s'appuyant sur le préambule de la Constitution **(I)** pour protéger constitutionnellement la liberté d'association **(II)**.

I. Le contrôle de constitutionnalité désormais fondé sur les libertés

A. Toute la Constitution, rien que la Constitution

Initialement, le Conseil constitutionnel pour effectuer son contrôle de constitutionnalité des lois ne pouvait se référer qu'aux articles 1er à 89 de la Constitution. Le corps de la Constitution de 1958 contient peu de droit et libertés même si certains articles y font tout de même référence.

(Exemples : Article 1 : égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion, et l'égalité entre les sexes dans les fonctions électives professionnelles et sociales. Article 2 : forme démocratique du régime et devise « Liberté, égalité, fraternité ». Article 3 : suffrage universel, égal et secret. Article 4 : pluralisme et liberté des partis politiques.

Cette limitation au corps même de la Constitution restreignait le champ des normes applicables par le Conseil constitutionnel lors de son contrôle.

B. La création prétorienne du bloc de constitutionnalité

Nécessité pour le Conseil constitutionnel d'utiliser le préambule de la Constitution de 1958 qui fait référence à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, au préambule de 1946 (la Charte de l'environnement de 2004 sera rajoutée en 2005 par une révision constitutionnelle).

Et par ricochet, utilisation des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République présents dans le préambule de 1946.

II. La consécration constitutionnelle de la liberté d'association

A. Une tentative législative de restriction de la liberté d'association

La loi soumise au Conseil constitutionnel avait pour objet de modifier la loi du 1er juillet 1901 qui consacrait la liberté d'association. Elle avait pour objet de rendre cette dernière plus restrictive en permettant au préfet de saisir le juge judiciaire pour contrôler l'objet de l'association avant la remise du récépissé de déclaration permettant à l'association d'exister.

In fine, cela revenait à mettre en place un régime d'autorisation et non plus de simple déclaration pour permettre la constitution d'une association.

En l'espèce, il s'agissait de s'opposer à l'association « Les amis de la cause du peuple » fondée par Simone de Beauvoir et M. Leyris.

B. La valeur de la liberté d'association

Depuis la loi de 1901, la liberté d'association n'a pas été consacrée constitutionnellement. Le Conseil d'État l'avait déjà reconnue comme principe fondamental reconnu par les lois de la République (CE, ass., 11 juillet 1956, *Amicale des annamites de Paris*).

Confirmation dans la décision du Conseil constitutionnel qui la consacre et nourrit une nouvelle catégorie de normes constitutionnelles.

Liberté d'association : concentre tous les aspects de la reconnaissance du droit à l'action collective.

Volet négatif de la liberté d'association : liberté pour l'individu de ne pas être contraint par la loi ou la puissance publique à s'associer.

Nombreux droits reconnus aux associations : principe d'égalité entre les associations, droit d'ester en justice.

En conclusion, le Conseil constitutionnel est ainsi devenu acteur et maître du contrôle de constitutionnalité des lois en élargissant les normes de référence pour exercer son contrôle de constitutionnalité des lois en garantissant le plus largement possible les différents droits et libertés fondamentaux.

Fiche nº 10 - LE BLOC DE LÉGALITÉ

POINTS CLÉS

- En raison du légicentrisme, la loi était considérée comme omnipotente, mais cette conception a disparu.
- La loi n'est pas une norme uniforme, car il en existe plusieurs types. Tous ces types n'ont pas la même valeur : on préfèrera parler de bloc de légalité.
- Ce bloc de légalité est hétérogène : il existe plusieurs types de lois intéressant les libertés, progressivement concurrencés par les principes généraux du droit.
- Désormais, la Constitution donne compétence au législateur pour organiser les droits et les libertés tout en encadrant cette possibilité.
- La loi connaît des limites en raison de contrôles juridictionnels, de critiques ou encore de la faculté d'y désobéir.

PRINCIPALES RÉFÉRENCES

- Articles 5 et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.
- Article 34 de la Constitution de 1958
- CE, 26 octobre 1945, *Aramu,* nº 77726….

1. Les origines de la consécration législative des libertés

Dans les théories de Jean-Jacques Rousseau, la loi ne peut mal faire puisqu'elle est l'émanation de la volonté populaire qui est elle-même infaillible. À l'époque, cette conception vise à remplacer la coercition d'une norme arbitraire imposée par le Roi à une norme dont l'émanation est l'ensemble du peuple : il s'agit de la théorie de la souveraineté populaire.

Cette logique triomphe dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Dans de nombreux articles, ce texte insiste sur l'importance de la loi, qui apparaît comme la source principale du droit.

> *« La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas »* (art. 5 DDHC).
>
> *« La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse* […] *»* (art. 6 DDHC).

La loi va connaître un véritable regain avec la IIIe République. Cela s'explique, d'une part, par le renoncement du pouvoir exécutif à recourir à ses prérogatives reconnues par les lois constitutionnelles de 1875, permettant au législateur d'œuvrer plus facilement et d'autre part, par la promulgation de grandes lois protectrices des libertés :

POUR ALLER PLUS LOIN

Dans son discours d'investiture en tant que nouveau président de la République en février 1849, Grévy va renoncer à utiliser certains pouvoirs constitutionnellement prévus comme le droit de dissolution. Cette déclaration, ultérieurement appelée « Constitution Grévy », impliquait un déséquilibre dans la séparation des pouvoirs bénéficiant au pouvoir législatif.

la liberté de la presse (loi de 1881) ; la liberté syndicale (loi de 1884) ; la liberté d'association (loi de 1901) ou encore la liberté de conscience (loi de 1905).

Aujourd'hui, la place de la loi dans la protection des libertés fondamentales est limitée et ambiguë. Désormais le domaine d'action du législateur est limitativement énuméré dans l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 et le développement du contrôle de constitutionnalité a contribué à limiter le prestige de la loi.

En ce sens, rompant avec la tradition rousseauiste de la loi, le Conseil constitutionnel a affirmé que la loi ne pouvait être l'expression de la volonté générale qu'à la condition qu'elle respecte la Constitution.

→ Cons. const., déc. n° 85-197 DC, 23 août 1985, *Loi sur l'évolution de la Nouvelle-Calédonie.*

Le mouvement de constitutionnalisation des libertés ne doit pas cacher que nombre d'entre elles sont issues de la loi.

2. La définition du bloc de légalité

Le bloc de légalité peut être appréhendé à travers deux approches : la première est traditionnelle et s'attache à la loi en tant que norme faisant intervenir le législateur. La seconde est une approche élargie intégrant les principes généraux du droit.

2.1. Le bloc de légalité « traditionnel » : la norme législative

La définition du bloc de légalité peut être appréhendée à travers une définition formelle impliquant de la comprendre à travers sa place dans la hiérarchie des normes, mais également à travers une définition matérielle tenant compte de son contenu.

2.1.1. La définition formelle : la hiérarchie des normes

Le bloc de légalité fait référence directement à la norme législative. En vertu du principe de hiérarchie des normes, la norme règlementaire est inférieure à la loi et doit donc en respecter les dispositions. Le bloc de légalité sert donc de référence aux juridictions administratives pour examiner la conformité des actes administratifs à la loi. Tout acte administratif contraire à l'une des normes du bloc de légalité peut être annulé pour illégalité : c'est le contrôle de légalité.

Le bloc de légalité occupe une position intermédiaire dans la hiérarchie des normes puisqu'il sert de norme de référence au contrôle de légalité des actes administratifs, mais il est aussi la norme inférieure à la Constitution : il subit alors lui-même un contrôle de constitutionnalité et de conventionnalité.

2.1.2. La définition matérielle : le contenu du bloc de légalité

L'expression « bloc de légalité » s'entend de la réunion de plusieurs normes différentes.

Tout d'abord, les lois organiques sont, dans la hiérarchie des normes, supérieures aux lois ordinaires. Elles sont adoptées par le Parlement et fixent les règles propres à l'organisation des pouvoirs publics. Les lois qui modifient ou complètent la Constitution sont des lois organiques et elles ne peuvent intervenir que dans des domaines énumérés par la Constitution elle-même. Elles sont soumises à une procédure d'adoption particulière prévue à l'article 46 de la Constitution.

Les lois ordinaires sont votées par le Parlement selon une procédure législative classique prévue aux articles 39 et suivants de la Constitution. Le domaine dans lequel les lois ordinaires peuvent intervenir est prévu à l'article 34 de la Constitution.

Les lois référendaires sont l'expression directe de la souveraineté nationale. En vertu de l'article 11 de la Constitution, le Gouvernement ou les assemblées parlementaires conjointement peuvent décider de soumettre à un référendum un projet de loi portant sur certaines matières énumérées par ledit article (sur l'organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent ou sur la ratification d'un traité dont les stipulations auraient des incidences sur le fonctionnement des institutions).

Entrent également dans le champ des lois référendaires, les propositions de lois référendaires adoptées en vertu du référendum d'initiative partagée prévu depuis la révision constitutionnelle de 2008. Cette procédure est initiée

par un cinquième des membres du Parlement et soutenue par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales.

POUR ALLER PLUS LOIN

Traditionnellement, le Conseil constitutionnel se refuse à procéder à un contrôle de conventionnalité des lois référendaires adoptées en vertu de l'article 11 de la Constitution en ce qu'elles sont l'expression directe de la souveraineté nationale (décision n° 62-20 DC du 6 novembre 1962 relative à l'élection du président du suffrage universel direct). L'article 11 ne permet d'adopter que des lois référendaires, mais ne permet pas en théorie de modifier la Constitution (art. 89 de la Constitution). Cependant, à deux reprises le Général de Gaulle s'est affranchi de cette procédure en 1962 et en 1969 et a révisé la Constitution par la voie de l'article 11 de la Constitution.

Enfin, sont intégrées au bloc de légalité les ordonnances prises en vertu de l'article 38 de la Constitution. En principe, tant qu'elle n'est pas ratifiée, une ordonnance prise sur le fondement de l'article 38 de la Constitution a valeur d'acte réglementaire.

Pourtant, par une décision QPC de 2020, le Conseil constitutionnel considère qu'à l'expiration du délai d'habilitation, les dispositions de l'ordonnance ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif. Cela signifie qu'une ordonnance acquiert automatiquement valeur législative dès lors qu'un projet de loi de ratification a été déposé dans le délai d'habilitation, sans qu'il y ait besoin d'une ratification expresse. En conséquence, une fois le délai de transposition échu, l'ordonnance valant loi, seul le Conseil constitutionnel serait compétent pour censurer une telle ordonnance.

→ Cons. const., décision n° 2020-843 QPC, 28 mai 2020, *Force 5.*

POUR ALLER PLUS LOIN

La question de la valeur juridique des ordonnances non ratifiées a fait l'objet d'un dialogue entre le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel. À la suite de la décision du Conseil constitutionnel du 28 mai 2020, le Conseil d'État a examiné au fond un recours contre cette ordonnance non ratifiée. Il a ainsi implicitement jugé être compétent pour connaître d'un recours pour excès de pouvoir contre une ordonnance prise sur le fondement de l'article 38 de la Constitution et n'ayant pas été ratifiée, même après l'expiration du délai d'habilitation (CE, 1er juillet 2020, Conseil national de l'Ordre des architectes).

Deux jours plus tard, par une décision n° 2020-851/852 QPC du 3 juillet 2020, M. Sofiane A. et autre, le Conseil constitutionnel a rappelé qu'en vertu du dernier alinéa de l'article 38 de la Constitution, à l'expiration du délai de l'habilitation fixé par la loi, les dispositions d'une ordonnance prise sur son fondement ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif. Il semble réaffirmer sa compétence pour connaître des ordonnances non ratifiées après l'expiration du délai d'habilitation, en opposition avec la décision implicite du Conseil d'État. Cependant, il précise que la compétence du Conseil constitutionnel est circonscrite aux cas dans lesquels sont invoqués des moyens relatifs aux droits et libertés. Dans un tel cas, le Conseil constitutionnel doit être saisi par le biais d'une QPC. En dehors de ces cas, le Conseil d'État demeurerait compétent pour examiner les autres motifs d'illégalités de ces ordonnances.

Enfin, le Conseil d'État, dans un arrêt du 16 décembre 2020, Fédération CFDT des finances et autres, a repris à son compte l'analyse du Conseil constitutionnel quant à la valeur législative des ordonnances prises sur le fondement de l'article 38 de la Constitution non ratifiées après l'expiration du délai d'habilitation, il retient également que la contestation des dispositions relevant du domaine de la loi de telles ordonnances ne peut s'opérer qu'à travers une QPC ***transmise au Conseil constitutionnel***

Actualité jurisprudentielle. - Le Conseil d'État précise à nouveau le statut des ordonnances non ratifiées

Le Conseil d'État a rappelé en 2025 qu'une ordonnance prise sur le fondement de l'article 38 de la Constitution conserve, aussi longtemps qu'elle n'a pas été expressément ratifiée par le Parlement, le caractère d'un acte administratif. Une particularité existe toutefois après l'expiration du délai d'habilitation. Les dispositions de l'ordonnance qui relèvent du domaine de la loi ne peuvent alors plus être modifiées ou abrogées par le pouvoir réglementaire. Seul le législateur, ou le Gouvernement bénéficiant d'une nouvelle habilitation, peut intervenir. Cette règle s'applique même lorsque les dispositions concernées seraient entachées d'illégalité.

→ CE, 20 mars 2025, *Association pour la défense du droit au recours*, n° 494158.

À retenir. - Une ordonnance non ratifiée demeure un acte administratif, y compris après l'expiration du délai d'habilitation. Toutefois, les dispositions relevant du domaine législatif acquièrent alors un régime particulier : leur conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution relève de la QPC (art. 61-1 C.) et elles ne peuvent plus être modifiées ou abrogées par le simple pouvoir réglementaire.

2.2. Le bloc de légalité « élargi » : l'intégration des principes généraux du droit

Le bloc de légalité élargi intègre des principes généraux du droit, ce qui interroge sur leur valeur dans la hiérarchie des normes.

2.2.1. La notion de principe général du droit

Les principes généraux du droit sont des principes dégagés par le juge en l'absence de textes. Ces derniers sont particulièrement importants et nombreux en droit administratif.

Les principes généraux ne doivent pas être confondus avec les principes à valeur constitutionnelle ainsi qu'avec les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République (PFRLR) qui sont des principes dégagés par le Conseil constitutionnel. Les principes généraux du droit sont des règles jurisprudentielles qui ont été dégagées par le juge administratif pour répondre à des enjeux et besoins spécifiques et qui ne sont pas prévus par divers textes.

En 1945 et pour la première fois, le juge administratif va recourir à l'expression de *principe général du droit* dans l'arrêt *Aramu*. Dans cette décision, le Conseil d'État reconnaît l'existence de *principes généraux du droit applicables même sans texte*.

→ CE, 26 octobre 1945, *Aramu,* n° 77726

Aujourd'hui, de nombreux principes ont été dégagés par le juge. On peut citer, par exemple, le droit de la défense en matière administrative (CE, Sect., 5 mai 1944, *Dame Veuve Trompier Gravier*, n° 69751), la possibilité d'exercer un recours pour excès de pouvoir même sans texte (CE, Ass, 17 février 1950, *Ministre de l'Agriculture c. Dame Lamotte,* n° 86949*),* l'interdiction d'extrader un réfugié politique (CE, Ass. 1er avril 1988, *Bereciartua-Echarri*, n° 85234*),* le droit au regroupement familial (CE, Ass., 8 décembre 1978, *Gisti et autres*, n° 10676 et 10679*)* ou encore la liberté d'aller et venir (CE, 20 décembre 1995, *Madame Vedel*, n° 132183).

2.2.2. L'incertitude de la valeur des principes généraux du droit

Bien qu'ils soient dégagés par le juge, ces principes généraux du droit ont une valeur particulière.

Selon le Conseil constitutionnel, seul le législateur est compétent pour mettre en cause ces principes généraux du droit, ce qui pourrait laisser penser, d'un point de vue du parallélisme des formes, que ces principes ont au moins une valeur législative.

Dans une décision de 1969, le Conseil constitutionnel décide expressément :

> *« Considérant que d'après un principe général de notre droit le silence gardé par l'administration vaut décision de rejet et, qu'en l'espèce, il ne peut y être dérogé que par une décision législative »* (Cons. const., déc. n° 91-167 L du 19 décembre 1991, *Nature juridique des dispositions des articles 48, 48 bis et 60, pour partie, de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée et concernant l'organisation des concours d'internat en médecine et en pharmacie*).

En outre, le professeur René Chapus considérait que si le Conseil d'État est soumis à la loi, il peut en revanche censurer les actes administratifs comme les décrets. Les principes généraux du droit ont donc une valeur infralégislative, mais supra-décrétale puisque le juge administratif est serviteur de la loi, mais censeur des décrets.

Il est donc possible d'intégrer dans un bloc de légalité « élargi » les principes généraux du droit.

3. Une protection législative des droits et libertés

La loi exerce une réelle influence sur la protection et la garantie des droits et des libertés en ce qu'elle est désormais le fondement légal de certains d'eux, mais également en ce qu'elle est à la fois un instrument de conciliation, mais aussi d'encadrement des droits.

3.1. Une protection législative prévue par la Constitution

Si la Constitution est venue consacrer une compétence du législateur en matière de protection des droits, il n'en demeure pas moins que cette norme a connu un encadrement.

La Constitution de 1958 réserve au législateur une compétence expresse et de principe en matière de libertés puisque son article 34 confère à la loi le soin de :

> *« La fixation des règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques. »*

Cet article garantit également les droits et les libertés de manière indirecte puisqu'il revient à la loi de déterminer notamment les droits civiques (droit de vote et d'éligibilité), la détermination des crimes, des délits et des peines qui leur sont applicables, le régime de la propriété, le droit syndical et le droit du travail… Dans tous ces domaines, la mise en œuvre des droits relève d'un régime légal.

Dès lors, en l'absence de loi, le principe est celui de la permission : tout ce qui n'est pas prohibé par la loi est donc possible. Par exemple, en l'absence de loi interdisant l'exercice de la prostitution, celle-ci n'est pas formellement interdite. Seul l'achat de services sexuels, c'est-à-dire du point de vue du « client », est prohibé.

> → Loi n° 2016-444 du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées.

Si l'article 34 de la Constitution de 1958 prévoit que la loi fixe les règles concernant l'exercice des libertés, cela signifie qu'elle peut les autoriser ou les prohiber.

Par exemple, le législateur est venu adopter des lois spécifiques dans des domaines très divers comme l'interruption volontaire de grossesse, l'égalité des sexes, le droit des étrangers ou encore le droit des citoyens face à l'administrations.

- Le législateur a renforcé les modalités du droit d'interrompre une grossesse par la loi Veil du 17 janvier 1975 qui a dépénalisé l'avortement puis par les différentes lois qui ont succédé.
- Le législateur a tenté d'organiser la question de l'égalité des sexes dans le monde professionnel avec les lois du 13 juillet 1983 pour le Code du travail et la fonction publique ou encore avec une loi plus globale du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté.
- La loi a également prévu des dispositions concernant les droits des étrangers et qui ont été intégrées dans le Code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : on peut citer des dispositions sur le droit de vote et d'éligibilité par les citoyens de l'Union européenne.
- Enfin, de nombreuses lois sont venues organiser les relations entre le citoyen et l'administration notamment quant à l'accès aux documents administratifs, à l'amélioration de la qualité du droit ou à l'allégement des démarches administratives.

Plusieurs autres domaines sont concernés par des lois visant à protéger les droits des citoyens comme la police ou encore la justice.

3.2. Une intervention du législateur indispensable en pratique

De plus, l'intervention du législateur pour définir le cadre légal des droits de l'Homme ne répond pas seulement à un fondement constitutionnel, mais également à un besoin pratique puisque la loi agit alors comme une mesure d'effectivité des textes supra-législatifs : la loi devient une traduction juridique de droits consacrés dans d'autres textes afin de les rendre effectifs.

Par exemple, la consécration de la liberté d'association ne saurait être effective sans une traduction dans la loi des règles de création ou de fonctionnement. De même, la consécration du droit de vote implique de déterminer des règles d'éligibilité ou d'organisation des consultations électorales.

3.3. Un outil de conciliation entre les droits

En marquant la limite de chaque droit, la loi organise une conciliation entre chacun d'eux. La loi n'est qu'un instrument servant de frontière ou de délimitation des droits entre eux pour un même individu, mais également entre les individus.

En ce sens, l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 prévoit que la loi détermine les bornes à l'exercice des droits naturels afin d'assurer aux autres membres de la société que leurs propres droits puissent être exercés.

> *« La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi. »*

La loi est donc un instrument de résolution de conflits entre les droits, devenus probables en raison de leur développement important. Les cas de conflits entre les droits ne sont pas hypothétiques et ne relèvent pas de cas d'école : le droit au respect de la vie privée peut être en conflit avec la liberté de la presse ou la liberté d'expression ; le droit de grève et le droit de manifester peuvent entrer en conflit avec certains droits économiques comme la liberté d'entreprendre.

Le législateur et le juge doivent donc procéder à un arbitrage et à une mise en balance entre ces droits afin de concilier leur exercice parfois contradictoire. Par exemple, le législateur a dû concilier la liberté d'entreprendre et les droits du travail, précisément ceux du salarié, à propos de l'exercice du travail de nuit.

> → Cons. const., déc. n° 2014-373 QPC, 4 avril 2014, *Société Sephora.*

L'exemple topique de la conciliation entre les libertés est celui de la protection de l'ordre public, entendue ici comme la protection de la sécurité au sens général. Par exemple, le Conseil constitutionnel a estimé qu'il appartient au législateur :

> *« D'assurer la conciliation entre, d'une part, la prévention des atteintes à l'ordre public et la recherche des auteurs d'infractions, toutes deux nécessaires à la sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelle, et, d'autre part, l'exercice des libertés constitutionnellement garanties »* (Cons. const., déc. n° 2003-467 DC, 19 mars 2003, *Sécurité intérieure*).

En l'espèce, le Conseil constitutionnel retient qu'il revient au législateur d'assurer une conciliation entre la protection des libertés et la prévention des atteintes à l'ordre public, mais que la sauvegarde de l'ordre public est consubstantielle à la protection des libertés : il n'y a pas de libertés individuelles sans sécurité. Cette approche favorise le développement des discours sécuritaires.

C'est précisément en ce sens que la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence a été rédigée puis utilisée à plusieurs reprises dans le cadre des attentats en France ou encore qu'a été promulguée la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 instituant un régime d'état d'urgence sanitaire pour lutter contre l'épidémie de Covid19. Ces lois contenaient des dispositions attentatoires aux libertés en vue de protéger l'ordre public (sécuritaire ou sanitaire). Le législateur a dû procéder à cette occasion à une mise en balance des droits puisqu'il s'agit de mesures d'aggravation des atteintes aux libertés.

Concernant l'état d'urgence sanitaire, le législateur a pu porter atteinte au respect du droit à la vie privée concernant la mise en place de la vaccination obligatoire. Il peut ainsi imposer des obligations vaccinales contre des maladies très graves ou contagieuses et insusceptibles d'être éradiquées. Le fait de porter de trois à onze le nombre de vaccinations obligatoires constitue une atteinte au droit au respect de la vie privée justifiée par l'objectif d'amélioration de la couverture vaccinale.

→ Cons. const., n° 2015-458 QPC ,20 mars 2015, *Époux L.*

→ CE, 6 mai 2019, *Ligue nationale pour la liberté des vaccinations*, n° 419242.

4. Les limites de la loi : la protection des droits contre la loi

Si le recours à la loi s'avère nécessaire pour protéger les droits et les libertés, celle-ci n'est plus omnipotente. Elle est l'objet d'un contrôle et de critiques. De plus, dans certains cas, il sera possible pour le citoyen de ne pas respecter la loi.

4.1. Le contrôle juridictionnel de la loi

Désormais, si la loi peut limiter les libertés, ce pouvoir n'est plus absolu. En d'autres termes, la loi ne peut pas porter atteinte à des droits de valeur constitutionnelle, mais seulement les mettre en œuvre de façon à les rendre plus effectifs.

Le Conseil constitutionnel est venu permettre au législateur de modifier ou d'abroger des dispositions antérieures à la seule condition qu'il ne prive pas de garanties légales les dispositions constitutionnelles. Appliquée aux libertés, cette décision empêche, en vertu de la hiérarchie des normes, le législateur de modifier ou supprimer des dispositions législatives traduisant et rendant effectives des libertés constitutionnellement garanties.

→ Cons. const., déc. n° 86-217 DC, 18 septembre 1986, *Liberté de communication.*

Ce contrôle s'est accentué avec la possibilité reconnue au juge ordinaire de procéder à un contrôle de conventionnalité des lois. La non-conformité de la loi aux dispositions de droit international ou européen et notamment aux dispositions relatives à la protection des droits peut désormais être censurée par le juge ordinaire, y compris à l'occasion d'une audience de référé.

→ CE, ass., 20 octobre 1989, *Nicolo,* n° 108243.

→ Cass., 24 mai 1975, *Jacques Vabre,* n° 73-13.556.

→ CE, ass., 31 mai 2016, *Gonzales Gomez,* n° 396848.

4.2. La critique de la loi

La loi est aussi soumise à certaines critiques notamment en raison de l'inflation normative. La loi est devenue un instrument de réponse à une demande politique et sociale croissante et les droits et libertés n'y échappent pas.

→ CE, Rapport public pour l'année 1991, *Simplification et qualité du droit.*

Cependant, l'inflation normative dévalorise la valeur de la loi ainsi que sa qualité. C'est pourquoi le Conseil constitutionnel veille à la clarté, à l'intelligibilité et à l'accessibilité de la loi, qu'il a élevées au rang d'objectifs à valeur constitutionnelle.

→ Cons. const., déc. n° 2005-530 DC, 29 déc. 2005, *Loi de Finances pour 2006.*

POUR ALLER PLUS LOIN

L'expression « inflation normative » désigne un accroissement massif du nombre de lois, mais surtout de leur contenu. Plusieurs rapports publics du Conseil d'État a fait le constat de cette augmentation. Dans son rapport de 1991, il estimait que « quand la loi bavarde, le citoyen ne l'écoute plus que d'une oreille indiscrète ». En matière de protection des libertés, cette inflation est inquiétante puisqu'elle risque d'affaiblir l'effectivité de la protection.

4.3. La désobéissance à la loi

Théorisée sous la plume de Henry David Thoreau, la désobéissance civile à la loi est un instrument de revendication et de protestation. À tire d'exemple, certains maires ont refusé de marier des couples homosexuels après l'entrée en vigueur de la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de même sexe. De même, un maire a refusé de marier une personne ayant une obligation de quitter le territoire français en méconnaissance de nombreuses dispositions du Code civil et du code général des collectivités territoriales.

Tandis que la résistance à l'oppression remet en cause le pouvoir lui-même, en raison de sa nature autoritaire, la désobéissance civile vise à contester une mesure adoptée par le pouvoir. Il s'agit d'un acte contraire à la loi destiné à induire un changement dans celle-ci ou dans la politique menée.

La désobéissance à la loi est en principe prohibée. Cependant, il existe des cas prévus par celle-ci.

C'est notamment le cas de la clause de conscience. Aujourd'hui, la clause de conscience permet aux médecins et professionnels de santé de refuser de pratiquer une interruption volontaire de grossesse (CSP, art. 2212-8) ou une stérilisation chirurgicale (CSP, art. 2123-1) ou encore aux chercheurs de participer à des recherches sur les embryons humains (CSP, art. 2151-7-1).

La possibilité de désobéir est également reconnue, de façon limitée, aux fonctionnaires. En principe, le fonctionnaire ne peut pas désobéir aux ordres de son supérieur. Une exception est toutefois acceptée dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public.

Actualité. - Une nouvelle clause de conscience en matière d'aide à mourir

La loi du 18 août 2026 relative au droit à l'aide à mourir a créé une nouvelle clause de conscience à l'article L. 1111-12-12 du Code de la santé publique. Les professionnels de santé directement appelés à participer à la procédure, notamment le médecin saisi de la demande, les professionnels de santé participant au collège pluriprofessionnel ainsi que le médecin ou l'infirmier chargé d'accompagner l'administration de la substance létale, ne peuvent être contraints d'y participer.

L'exercice de cette clause est toutefois concilié avec l'effectivité du droit à l'aide à mourir. Le professionnel qui refuse de participer doit en informer sans délai la personne ou le professionnel qui le sollicite et lui communiquer le nom de professionnels disposés à participer à la procédure. Les professionnels volontaires se déclarent auprès de la commission de contrôle et d'évaluation instituée par la loi.

→ Loi n° 2026-794 du 18 août 2026 *relative au droit à l'aide à mourir*, art. 14 ; CSP, art. L. 1111-12-12. *La loi, définitivement adoptée en juillet 2026 puis promulguée le 18 août 2026, est entrée en vigueur sur ce point le 20 août 2026.*

POUR S'ENTRAÎNER

Commentaire de texte : Loi constitutionnelle n° 2024-200 du 8 mars 2024 relative à la liberté de recourir à l'interruption volontaire de grossesse : Article unique : *« Après le dix-septième alinéa de l'article 34 de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : "La loi détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la liberté garantie à la femme d'avoir recours à une interruption volontaire de grossesse". La présente loi sera exécutée comme loi de l'État. »*

Face à un risque de recul des droits des femmes et notamment de la liberté de recourir à l'avortement, le 8 mai 2024, la France est devenue le premier état à faire entrer dans sa Constitution une telle liberté.

L'objectif affiché d'une telle démarche était d'empêcher pour l'avenir toute remise en cause de cette liberté par la loi.

En effet, jusque-là, ce droit n'avait aucune valeur constitutionnelle, le Conseil constitutionnel s'étant refusé de lui conférer une telle valeur. En d'autres termes, la liberté de la femme de recourir à l'avortement était une affaire du législateur : la loi Veil de 1975 relative à l'interruption volontaire de grossesse a permis de dépénaliser le recours à l'avortement puis une autre loi de 1979 a permis de rendre définitives les dispositions de la loi de 1975. D'autres lois sont venues apporter quelques précisions notamment en supprimant la notion « situation de détresse » ou encore afin d'allonger le délai légal de recours de 12 à 14 semaines par une loi du 2 mars 2022.

Cependant, ce que la loi pouvait faire, elle pouvait le défaire à défaut d'ancrage constitutionnel. L'IVG était donc à la merci d'un changement de majorité au Parlement.

C'est à cette difficulté que tend à répondre la loi constitutionnelle du 8 mars 2024 destinée à modifier l'article 34 de la Constitution. Aux termes de plusieurs débats au sein de chaque assemblée parlementaire, le Parlement réuni en congrès a approuvé le projet avec 780 pour et 72 contre.

Par cette loi constitutionnelle, l'article 34 de la Constitution prévoit désormais que le législateur dispose d'une compétence pour déterminer les conditions d'exercice de la liberté de recourir à l'IVG.

Il convient de comprendre les incidences de la loi sur l'exercice de cette liberté.

Problématique et annonce du plan : Dans quelle mesure cette loi constitutionnelle est venue bouleverser la conception traditionnelle du droit de recourir à l'interruption volontaire de grossesse ? Cette modification de l'article 34 de la Constitution permet une reconnaissance constitutionnelle de cette liberté **(I)** tout en encadrant la possibilité pour le législateur d'y porter atteinte **(II)**.

I. Une reconnaissance constitutionnelle de la liberté d'avorter

A. Une inscription dans un contexte troublé

Cette réforme intervient dans un contexte où plusieurs pays, notamment les États-Unis depuis l'arrêt *Dobbs v. Jackson Women's Health Organization* (2022) de la Cour suprême, ont restreint voire ont supprimé l'accès à l'avortement. En réponse, le constituant français entend **prévenir une régression** du droit à l'IVG en élevant sa protection au niveau constitutionnel.

Les avancées sociales majeures aux États-Unis sont le fruit de la Cour suprême (mariage des couples de même sexe, IVG, déségrégation) tandis qu'en France, c'est le législateur qui se saisit souvent de ces questions (loi Veil de 1975, loi Taubira de 2013).

Cette compétence du législateur s'explique par l'ancienne tradition légicentriste, mais aussi par la compétence constitutionnelle du Parlement en matière de détermination des droits et libertés.

B. La consécration au sein de l'article 34 de la Constitution

Un nouvel alinéa est introduit dans l'article 34 de la Constitution relatif au domaine de la loi.

Ce choix témoigne d'une volonté de constitutionnaliser non pas un droit fondamental *stricto sensu*, mais une « liberté garantie », dont l'exercice relève du législateur.

Il s'agit d'un équilibre entre affirmation de principe et encadrement parlementaire.

L'insertion dans la Constitution empêche toute remise en cause totale par la loi de cette liberté et réserve le soin au législateur de déterminer les conditions d'exercice.

Cette modification permet de contrebalancer l'absence de protection supra-législative de cette liberté : le Conseil constitutionnel refusait de consacrer un principe constitutionnel et la CEDH reste prudente sur cette question en renvoyant à la marge d'appréciation des États.

II. Les implications juridiques de la constitutionnalisation

A. Une nouvelle norme de référence du contrôle de la loi

La terminologie choisie – « liberté garantie » – confère à l'IVG un statut supérieur dans la hiérarchie des normes. Toute loi future portant atteinte à cette liberté pourrait faire l'objet d'une censure par le Conseil constitutionnel.

Le contrôle de constitutionnalité (y compris par voie de QPC) pourrait donc devenir un outil de protection renforcée contre d'éventuelles atteintes.

La mention explicite du fait que *« la loi détermine les conditions »* d'exercice de cette liberté souligne que le législateur garde la main sur l'encadrement du recours à l'IVG : délais, modalités, obligations d'information ou d'accompagnement…

Ainsi, la liberté d'avorter est protégée, mais non absolutisée : son exercice pourra continuer à faire l'objet de régulations raisonnables, pourvu qu'elles ne portent pas atteinte à son essence.

B. L'absence d'empiètement sur d'autres droits

La consécration de cette liberté ne remet pas en cause l'exercice d'autres libertés, notamment la liberté de conscience des médecins et des sage-femmes qui leur permet de ne pas pratiquer l'IVG si cet acte est contraire à leurs convictions.

Concernant la clause de conscience, elle est reconnue et préservée. Si cette clause doit être maintenue, elle peut, dans certains cas, notamment en l'absence de nombre suffisant de praticiens exerçant l'intervention ou encore en cas d'information défaillante des femmes concernées, constituer un obstacle à l'IVG.

En conclusion, cette révision constitutionnelle a permis de pérenniser le droit de recourir à l'IVG tout en assurant un juste équilibre avec les autres droits. Désormais, le législateur peut adapter le principe sans le remettre en cause.

Fiche nº 11- LE RÈGLEMENT ET LES LIBERTÉS

POINTS CLÉS

- La Constitution de 1958 donne au pouvoir règlementaire un domaine de compétence étendu.
- S'il revient au législateur de connaître des garanties relatives aux libertés publiques, le pouvoir règlementaire dispose d'une compétence certaine en la matière.
- Le pouvoir règlementaire intervient, dans le cadre de l'article 37 de la Constitution, pour interpréter les lois, mais aussi par des décrets autonomes.
- Il intervient enfin pour restreindre les libertés afin de maintenir l'ordre public, dans le cadre de la police administrative.
- Cette mise en balance des libertés publiques avec la protection de l'ordre public se fait sous le contrôle du juge administratif.

PRINCIPALES RÉFÉRENCES

- Articles 21 et 37 de la Constitution.
- CE, 7 février 1936, *Jamart,* nº 43321.
- CE, 28 juin 1919, *Heyriès*, nº 63412.
- CE, 19 mai 1933, *Benjamin,* nº 17413.

1. La définition du pouvoir règlementaire

Au préalable, une définition générale peut être donnée : le pouvoir règlementaire est le pouvoir dont dispose des autorités pour prendre unilatéralement (sans l'accord du destinataire) des actes exécutoires comprenant des dispositions générales et impersonnelles.

Pour définir ce qu'est le pouvoir règlementaire, il faut identifier qui est titulaire de la faculté d'édicter de telles normes et quelles sont les différentes manifestations de ce pouvoir.

1.1. Les autorités chargées du pouvoir règlementaire

Aux termes de l'article 21 de la Constitution de la Ve République, le Premier ministre détient la compétence d'exercer le pouvoir règlementaire.

Au sein du Gouvernement, le Premier ministre est le seul à détenir le pouvoir règlementaire qui peut revêtir deux formes : le pouvoir règlementaire d'exécution des lois et le pouvoir règlementaire autonome. Les autres ministres ne disposent pas du pouvoir règlementaire, mais seulement d'un pouvoir d'organisation et d'administration de leur service.

→ CE, 7 février 1936, *Jamart,* nº 43321.

Le pouvoir règlementaire autonome est prévu à l'article 37 de la Constitution. Il peut être défini de manière négative puisque tout ce qui ne relève pas du domaine de la loi, c'est-à-dire toutes les matières qui ne sont pas limitativement énumérées à l'article 34 de la Constitution, relève de la compétence du pouvoir règlementaire.

Parfois, le pouvoir règlementaire va être partagé entre le Premier ministre et le président de la République pour les décrets délibérés en conseil des ministres. Quant aux décrets signés par le président de la République, mais non délibérés en conseil des ministres, c'est la seule signature du Premier ministre qui leur donne une pleine validité.

→ CE, 27 avril 1962, *Sicard*, nº 50032.

Dans le cas où un décret a été signé par le président de la République, y compris lorsque cela n'était pas nécessaire, celui-ci ne peut être modifié que par un autre décret pris selon les mêmes formes.

→ CE, 27 avril 1994, *Allamigeon et Pageaux,* n° 147203.

Si, en principe, le règlement est un acte émanant du pouvoir exécutif, soit un décret ou un arrêté, l'article 72 de la Constitution prévoit l'exercice d'un pouvoir règlementaire local exercé par les exécutifs des collectivités territoriales : maire, président du conseil départemental :

> *« Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s'administrent librement par des conseils élus et disposent d'un pouvoir règlementaire pour l'exercice de leurs compétences. »*

POUR ALLER PLUS LOIN

Dans une décision de 1965, le Conseil d'État a reconnu aux collectivités territoriales la possibilité de prendre des mesures liées à l'organisation de leur service public par voie règlementaire en l'absence de disposition législative (CE, 9 juillet 1965, Pouzenc, n° 58778). À partir de 2002, avec une décision sur la loi relative à la Corse, le Conseil constitutionnel a considéré que le pouvoir règlementaire des collectivités territoriales n'avait pas pour fondement le pouvoir règlementaire national des articles 13 et 21 de la Constitution, mais leur libre administration contenue dans l'article 72, alinéa 2 (Cons. const., 17 janvier 2002, n° 2001-454 DC, loi relative à la Corse).

1.2. La classification des normes règlementaires

Il existe une hiérarchie au sein des normes règlementaires : toutes n'ont pas la même valeur. Par exemple, les décrets s'imposent aux autres actes règlementaires émanant des autorités de l'État ou des autres autorités décentralisées.

À ce titre, on distingue trois types de décrets :

- Les décrets en Conseil des ministres sont signés par le président de la République en vertu de l'article 13 de la Constitution.
- Les décrets en Conseil d'État sont signés par le Premier ministre après avis du Conseil d'État.
- Les décrets simples ne font l'objet d'aucune formalité particulière et sont signés par le Premier ministre uniquement.

À côté de ces décrets se trouvent des arrêtés. Ce sont des actes administratifs unilatéraux pris par les ministres, les préfets ou les maires. Dans la hiérarchie des normes, les arrêtés sont inférieurs aux décrets et doivent donc en respecter les dispositions.

2. La détermination des droits et des libertés par le pouvoir règlementaire

L'intervention du pouvoir règlementaire en matière de protection des droits et libertés se justifie à travers deux compétences distinctes : une compétence constitutionnelle et une compétence autonome.

2.1. Le pouvoir règlementaire pour suppléer la loi

En vertu de l'article 37 de la Constitution, toutes les autres matières que celles réservées au législateur relèvent du pouvoir règlementaire. Bien que le législateur dispose d'une compétence pour définir les garanties fondamentales concernant l'exercice des libertés, le pouvoir règlementaire peut déterminer les modalités concrètes, notamment dans le cadre de son pouvoir d'exécution des lois.

Au-delà de la compétence du législateur déterminée à l'article 34 de la Constitution, le gouvernement est appelé à intervenir, car la loi renvoie souvent à des décrets d'application. Il est très rare que la loi soit autosuffisante.

Des mesures complémentaires ou des précisions sont apportées par le pouvoir règlementaire dans de nombreuses hypothèses et notamment pour garantir la bonne effectivité des droits-créances.

Avant 1958, le Conseil d'État avait progressivement dressé les contours d'un pouvoir règlementaire de police administrative en permettant déjà au chef de l'Exécutif de prendre des mesures règlementaires de police administrative même sans délégation de la loi, mais en vertu de ses pouvoirs propres.

> → CE, 8 août 1919, *Labonne*, n° 56377.

En l'espèce, le pouvoir règlementaire peut intervenir dans le silence de la loi pour réglementer les libertés : le pouvoir règlementaire, en l'occurrence le président de la République, se voit reconnaître une compétence qu'il ne tient pas du législateur, une compétence propre. Cette compétence propre s'épanouit dans le domaine particulier de la police administrative, car sa seule justification est la nécessité d'assurer l'ordre public.

Par exemple, dans une décision du 8 janvier 1991, le Conseil constitutionnel a rappelé qu'il appartenait au législateur de déterminer les cas dans lesquels la publicité pour les boissons alcooliques pouvait être autorisée. En effet, en vertu de l'article 34 de la Constitution selon lequel la loi fixe les garanties accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques, il revient au législateur d'apporter des restrictions à la propagande en faveur des boissons alcooliques.

Cependant, le Conseil constitutionnel précise dans sa décision que :

> *« Il revient cependant au pouvoir règlementaire de mettre en œuvre, s'il y a lieu, les dispositions de la loi à la condition de ne pas en altérer la portée »* (Cons. const., déc. n° 90-283, 8 janvier 1991, *Loi relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme*).

On observe ainsi que le pouvoir règlementaire dispose d'une compétence limitée à des fins de précision et d'application de la loi puisqu'il ne peut tenter d'en modifier les effets, notamment en prévoyant des dispositions qui aggraveraient la restriction des libertés.

L'articulation entre les pouvoirs législatif et règlementaire se fait sous le contrôle du Conseil constitutionnel qui veille à ce que le pouvoir règlementaire n'outrepasse pas ses prérogatives en modifiant les effets de la norme déterminée par le législateur.

Le Conseil constitutionnel a encadré les possibilités d'action du pouvoir règlementaire en prévoyant que s'il lui appartient d'assurer la mise en œuvre de la loi, celle-ci doit être faite conformément aux objectifs de la loi et de manière proportionnées à ces objectifs.

Il estime ainsi dans sa décision susvisée que :

> *« Il incombera par suite au pouvoir règlementaire d'assurer la mise en œuvre de la loi compte tenu de cet objectif ; qu'il lui appartiendra dès lors, dans la détermination des catégories de radios et des tranches horaires, de prendre en considération, en priorité, le nombre des jeunes effectivement touchés par les émissions des radios concernées* […]*. Qu'il appartiendra au pouvoir règlementaire, agissant par décret en Conseil d'État, d'assurer la mise en œuvre de la loi en fonction de données objectives applicables à l'ensemble des boissons alcooliques »* (Cons. const., déc. n° 90-283, 8 janvier 1991, *Loi relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme*).

Le pouvoir règlementaire doit évidemment respecter les dispositions législatives qu'il applique, mais il doit également veiller au respect des garanties constitutionnelles. En d'autres termes, le règlement d'application ne saurait méconnaître la loi au titre de laquelle il intervient, mais plus généralement toutes les garanties prévues dans la Constitution, telles que le droit de la défense par exemple.

> → Cons. const., déc. n° 98-401 DC, 10 juin 1998, *Loi d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail.*

Actualité jurisprudentielle. - Un ministre peut préciser l'exercice d'une liberté sans se substituer au législateur

Si les ministres ne disposent pas, en principe, d'un pouvoir réglementaire général, la loi ou le règlement peuvent leur attribuer une compétence réglementaire dans un domaine déterminé. Le Conseil d'État en a donné une illustration en 2025 à propos du programme d'éducation à la vie affective, relationnelle et à la sexualité.

Le Code de l'éducation confie à l'État la fixation des programmes nationaux et prévoit que le contenu des formations est déterminé par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Celui-ci était donc compétent pour fixer le contenu du programme d'éducation à la sexualité applicable à compter de l'année scolaire 2025-2026. Le Conseil d'État vérifie ensuite que l'exercice de cette compétence respecte les droits et libertés en cause, notamment l'autorité parentale, la vie privée des élèves, leur droit à l'éducation ainsi que le principe de neutralité du service public. Il relève notamment que les notions enseignées doivent être présentées de manière neutre et objective, en fonction de l'âge des élèves et sans les inciter à adopter un comportement déterminé.

→ CE, 27 juin 2025, *Association Juristes pour l'enfance et autres*, nos 501820 et 503152.

À retenir. - Les ministres ne disposent pas d'un pouvoir réglementaire général comparable à celui du Premier ministre. Ils peuvent toutefois exercer un pouvoir réglementaire spécial lorsqu'un texte leur attribue expressément cette compétence.

2.2. Le pouvoir règlementaire et les situations de crise

Les différents pouvoirs lors de différentes crises sont des mécanismes destinés à faire face à des situations exceptionnelles qui se traduisent par un assouplissement ou une mise à l'écart pour une durée plus ou moins longue de la légalité ordinaire et du fonctionnement normal des institutions.

Le règlement est une norme essentielle dans la mise en œuvre des régimes de crise et la question concernant ces régimes est celle de leur portée vis-à-vis de la garantie effective des libertés. En effet, pendant ces situations spécifiques, il peut s'avérer nécessaire de mettre en œuvre un régime moins favorable aux libertés publiques.

Ainsi, le Conseil d'État a dégagé une théorie des circonstances exceptionnelles permettant à l'autorité administrative de se substituer temporairement au Parlement.

→ CE, 28 juin 1919, *Heyriès*, n° 63412.

Il n'est pas question d'envisager ici le régime juridique de chacun de ces mécanismes dans des situations de crise, mais plutôt de comprendre l'utilité du pouvoir règlementaire pendant ces périodes.

Concernant l'article 16 de la Constitution, il faut qu'il y ait une interruption des pouvoirs publics constitutionnels et qu'il y ait aussi un autre élément, comme l'atteinte aux institutions, l'atteinte à la souveraineté de la nation, ou l'atteinte à l'intégrité du territoire. Cet article précise uniquement que le président de la République prend les mesures exigées par les circonstances.

Pour ce faire, le président de la République peut prendre des mesures relevant du pouvoir règlementaire, mais aussi empiéter sur l'exercice du pouvoir législatif.

En vertu de ses pouvoirs, le président de la République a donc la possibilité de restreindre ou de suspendre l'exercice ou la garantie des droits fondamentaux.

On pourrait craindre une restriction de l'exercice des libertés par le pouvoir règlementaire au détriment de la compétence législative. Cependant, les décisions du président de la République qui définissent les mesures exceptionnelles peuvent faire l'objet d'un contrôle juridictionnel : si le président peut empiéter sur le pouvoir législatif, il n'y a pas de confusion entre les normes, la loi ne devient pas un règlement.

C'est pourquoi, le Conseil d'État a reconnu sa compétence pour contrôler les actes relevant du domaine du pouvoir règlementaire et adoptés par le président de la République.

→ CE, 19 octobre 1962, *Canal*, n° 58502.

Le règlement est également une norme essentielle dans la mise en œuvre du régime de crise. Par exemple, conformément à l'article 36 de la Constitution, l'état de siège est décrété en Conseil des ministres : l'état de siège est donc établi par un décret et il s'agit d'une manifestation du pouvoir règlementaire, sous le contrôle du juge administratif.

→ CE, 23 octobre 1953, *Huckel*, n° 91261.

La déclaration de l'état de siège a pour conséquence l'attribution à l'autorité militaire de certains pouvoirs exorbitants : perquisition à domicile de jour comme de nuit, éloignement des condamnés par la justice, interdiction de certaines publications et réunions susceptibles d'exciter ou d'entretenir le désordre. Les mesures individuelles adoptées par les autorités militaires sur le fondement de l'état de siège sont soumises au régime juridique des décisions administratives et s'exercent par la voie règlementaire.

Dans l'état de siège, la norme règlementaire devient donc un instrument de restriction massive des libertés individuelles.

Enfin, l'état d'urgence institué par la loi du 3 avril 1955 peut également l'être par une norme règlementaire puisqu'il est déclaré par le président de la République par décret en Conseil des ministres. Surtout, ce régime accroît considérablement le pouvoir de certaines autorités administratives comme les préfets qui pourront donc exercer un pouvoir règlementaire de police bien plus important et restreindre davantage les libertés.

POUR ALLER PLUS LOIN

Le décret n° 2015-1475 du 14 novembre 2015 portant application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 a déclaré l'état d'urgence à compter du 14 novembre 2015. Ce décret, délibéré en conseil des ministres, a été pris à la suite des attentats terroristes qui ont frappé notre pays dans la soirée du 13 novembre.

2.3. Le pouvoir règlementaire et la police administrative

Aux côtés d'une compétence constitutionnelle, le pouvoir règlementaire exerce également une compétence liée à l'exercice du pouvoir de police. Ce pouvoir de police est une compétence autonome destinée à règlementer l'exercice des droits et libertés.

> *« Considérant, d'une part, qu'en donnant compétence au législateur pour fixer "les règles concernant… les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques", l'article 34 de la constitution n'a pas retiré au chef du gouvernement les attributions de police générale qu'il exerçait antérieurement ;* ***qu'il appartient dès lors au Premier ministre de pourvoir, par des précautions convenables, à la sécurité des usagers des voies publiques sur l'ensemble du territoire*** *»* (CE, 17 février 1978, *Association Comité pour léguer l'esprit de la Résistance*, n° 02633).

Ainsi, l'exercice des pouvoirs de police n'est pas fondé sur l'article 37 de la Constitution : il n'est donc pas question de faire respecter la répartition de compétences avec l'article 34. Ce pouvoir de police administratif général peut viser n'importe quel droit ou liberté consacré au niveau législatif, mais également constitutionnel ou supranational.

La police administrative est une activité qui tend à protéger l'ordre public sans prétendre à la recherche d'une infraction déjà commise ou à l'arrestation de son auteur. Le pouvoir de police est donc un pouvoir normatif qui permet à son détenteur d'édicter des mesures règlementaires.

L'ordre public constitue une limite objective aux libertés. La notion d'ordre public est indispensable dans un système juridique. Il est possible de la saisir au travers notamment de la liberté d'autrui. En effet, notre liberté s'arrête où commence celle d'autrui. Dans un espace social, il est nécessaire de préserver l'égale liberté d'autrui et cela est notamment possible en vertu de l'ordre public.

En pratique, la distinction entre police administrative qui vise à la prévention des infractions et au maintien de l'ordre public et la police judiciaire qui tend à la répression est importante puisqu'elle entraîne la compétence contentieuse de juges différents : le juge administratif est compétent pour la police administrative et l'autorité judiciaire pour la police judiciaire.

Surtout, cela s'explique par des compétences normatives bien différentes : les mesures de police administrative sont décidées par l'autorité ayant en charge le pouvoir règlementaire (le Premier ministre, le maire ou encore le préfet) tandis que la police judiciaire, qui vise la répression des infractions, relève de l'autorité judiciaire.

De plus, la distinction est précieuse concernant l'exercice de certaines libertés pour lesquelles il est difficile de définir clairement le domaine d'action des deux polices. En effet, une seule et même autorité peut intervenir, selon les types d'opérations menées, en matière de police administrative et/ou de police judiciaire.

Ainsi, un fonctionnaire de police ou un gendarme peut faire aussi bien de la police administrative que de la police judiciaire : par exemple, le contrôle d'identité permet aussi bien la prévention d'une infraction que sa répression.

Une autre distinction intéresse directement la protection des droits et libertés, celle séparant la police administrative générale de la police administrative spéciale. La première tend à encadrer l'exercice des libertés ainsi que toutes activités afin de maintenir l'ordre public tandis que la seconde concerne uniquement certaines activités dans des domaines précis : la liberté de déplacement est limitée par la police spéciale de la circulation et du stationnement, la liberté de communication est limitée notamment par la police de l'audiovisuel et de la cinématographie, etc.

Toute mesure de maintien de l'ordre public implique nécessairement des restrictions aux libertés.

Ainsi, le Conseil d'État a estimé qu'il revenait au pouvoir règlementaire et précisément au Premier ministre de prendre des mesures en cas d'atteinte à l'ordre public et précisément à la sécurité intérieure. Il a ainsi jugé que la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures de l'espace Schengen relève de la compétence règlementaire malgré qu'elle impacte à l'évidence la liberté de circulation.

> → CE, 28 décembre 2017, *Association nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers*, n° 415291.

POUR ALLER PLUS LOIN

La période liée à l'état d'urgence sanitaire en raison du Covid-19 a vu l'émergence de nombreux décrets destinés à protéger l'ordre public, mais qui ont porté une atteinte sans précédent aux libertés. Par exemple, le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 portant règlementation des déplacements interdisait tout déplacement hors de son domicile et portait une atteinte à la liberté d'aller et venir.

De même, le décret 2020-293 du 23 mars 2020 prohibait certains rassemblements, réunions ou activités et portait ainsi atteinte à la liberté de réunion.

De même, les différentes jurisprudences du Conseil d'État sont très parlantes sur la nécessaire mise en balance entre protection de l'ordre public par le pouvoir règlementaire et la protection des libertés. À titre d'exemple, la protection de la dignité comme composante de l'ordre public prime sur la liberté de travail et sur la liberté de commerce et d'industrie ou encore sur la liberté d'expression et de réunion.

→ CE, Ass., 27 octobre 1995, *Commune de Morsang sur Orge*, n° 136727.

→ CE, ord., 9 janvier 2014, *Dieudonné M'Bala Bala et les productions de la plume*, *n° 374508.*

2.4. Le pouvoir règlementaire contraventionnel du Premier ministre

Le pouvoir règlementaire contraventionnel attribué au Premier ministre lui permet d'édicter des incriminations (des interdictions) et de déterminer les peines qui en sanctionnent la réalisation, au détriment parfois de l'exercice de certaines libertés.

L'actualité politique et juridique est foisonnante en la matière puisque plusieurs décrets contraventionnels ont incriminé de nouvelles infractions comme l'outrage au drapeau ou encore la dissimulation du visage à l'occasion de manifestations.

Concernant l'infraction d'outrage au drapeau, une association a contesté le décret incriminant cette nouvelle infraction en invoquant l'incompétence du pouvoir règlementaire pour y procéder au motif qu'il appartient au législateur de fixer *« les règles relatives aux garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques »* conformément à l'article 34 de la Constitution.

→ CE, 19 juillet 2011, *Ligue des droits de l'Homme,* n° 343430.

Face à cet argument, le Conseil d'État va raisonner en deux temps. Tout d'abord, si l'article 34 de la Constitution donne compétence au législateur pour déterminer les crimes et les délits ainsi que leurs peines, le pouvoir règlementaire est compétent en matière contraventionnelle. Il avait déjà jugé en 1995 que :

> *« Considérant que, d'après l'article 37, alinéa 1er, de la Constitution, "les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère règlementaire" ; que, si l'article 34 réserve à la loi le soin de fixer "les règles concernant la détermination des crimes et délits, ainsi que les peines qui leur sont applicables", cet article ne mentionne pas les règles concernant la détermination des infractions punies de peines de police ;* […] *dès lors, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que le gouvernement n'était pas compétent pour assortir d'une peine d'amende »* (CE, 13 septembre 1995, *Association Collectif pour la défense du droit et des libertés*, n° 139446).

Dans un deuxième temps, le Conseil d'État va estimer que, dès lors qu'il ne s'agit pas de règlementer l'exercice d'une liberté, mais d'y apporter des limitations pour la sauvegarde de l'ordre public, la création d'une incrimination n'appartient pas au pouvoir législatif.

> *« La circonstance que l'incrimination d'un acte a pour effet de limiter l'exercice d'une liberté publique garantie par des dispositions constitutionnelles ne saurait, par elle-même, avoir pour conséquence de réserver au pouvoir législatif la compétence pour édicter ces contraventions »* (CE, 19 juillet 2011, *Ligue des droits de l'homme*, n° 343430).

La compétence pour édicter une contravention est aussi justifiée par une distinction intéressante entre la norme visant à la règlementation (compétence du législateur) et la norme de limitation visant à protéger l'ordre public (compétence du pouvoir règlementaire).

Cette distinction est utilisée par le Conseil d'État à plusieurs reprises et notamment dans un arrêt de 2011 à propos de la dissimulation du visage lors de manifestation. Dans cet arrêt, le Conseil d'État précise que :

> *« Dans la mesure d'une part où le décret attaqué n'avait pas pour objet de règlementer la liberté de manifestation, et notamment pas d'interdire de manifester en dissimulant son visage, ni d'autre part, pour effet d'y porter atteinte, dès lors que ses dispositions ne peuvent régir le comportement des manifestants participant dans le respect de l'ordre public à une manifestation »* (CE, 23 février 2011, *Syndicat national des enseignants du second degré*, n° 329477).

En d'autres termes, le décret n'a pas pour objet de réglementer la liberté de manifester ni d'y porter atteinte, mais uniquement de maintenir l'ordre public. Aussi, il ne constitue pas un empiétement sur la compétence du législateur pour fixer les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques.

Le Conseil d'État distingue donc l'objet de la norme règlementaire (assurer l'ordre public) et l'effet de la mesure mobilisée (restreindre une certaine liberté).

2.5. Le contrôle du juge sur l'exercice du pouvoir règlementaire

Si les autorités investies du pouvoir règlementaire de police administrative doivent veiller au maintien de l'ordre public en réglementant l'exercice des libertés, elles doivent le faire en le conciliant dans la mesure du possible, avec l'exercice des libertés publiques.

Elles le font sous le contrôle du juge administratif qui va tenter d'apprécier la nécessité de la mesure de police et son adéquation au but recherché.

Selon les conclusions du commissaire du Gouvernement dans l'arrêt *Baldy* :

> *« La liberté est la règle, la restriction de police l'exception »* (Corneille, concl. sur CE, 10 août 1917, *Baldy*, n° 59855).

Le juge doit donc concilier les exigences contradictoires de protection des libertés et de maintien de l'ordre public en tenant compte de circonstances de lieu, de temps et des conditions sociales dans laquelle s'inscrit la norme règlementaire.

À l'occasion de la mise en balance de la liberté de réunion avec la protection de l'ordre public, le Conseil d'État a précisé que l'interdiction d'une conférence devait être nécessaire, adaptée et proportionnée au but recherché. Il a estimé que :

> *« Considérant que, s'il incombe au maire, en vertu de l'article 97 de la loi du 5 avril 1884, de prendre les mesures qu'exige le maintien de l'ordre, il doit concilier l'exercice de ses pouvoirs avec le respect de la liberté de réunion garantie par les lois des 30 juin 1881 et 28 mars 1907 »* (CE, 19 mai 1933, *Benjamin*, n° 17413).

Une telle solution a également été dégagée à l'occasion de la règlementation du stationnement et de la circulation en ville des personnes nomades. La liberté de circulation peut être restreinte pour des motifs d'ordre public, notamment liée à la sécurité ou à la tranquillité publique, mais elle ne saurait justifier une interdiction totale de circuler.

> → CE, 2 décembre 1983, *Ville de Lille c. Ackermann,* n° 13205.

Actualité jurisprudentielle. - Le pouvoir réglementaire peut restreindre une liberté pour protéger la santé publique

Le Conseil d'État a examiné en juillet 2026 le décret interdisant en France les produits à usage oral contenant de la nicotine. Pris sur le fondement de l'article L. 5132-8 du Code de la santé publique, ce texte interdit notamment leur offre, leur cession, leur acquisition et leur utilisation.

Le Conseil d'État rappelle que les mesures prises par le pouvoir réglementaire doivent être justifiées par l'objectif de santé publique poursuivi et proportionnées aux risques constatés. En l'espèce, compte tenu notamment du caractère addictif de la nicotine, des risques particuliers pour les jeunes et de l'augmentation des intoxications, il considère que l'interdiction de la commercialisation et de l'utilisation de ces produits sur le territoire national est propre à atteindre l'objectif poursuivi et n'excède pas ce qui est nécessaire. L'atteinte portée à la liberté d'entreprendre, à la liberté du commerce et de l'industrie et, à supposer qu'elle soit en cause, à la vie privée est donc admise (puisque proportionnée).

Le Conseil d'État a toutefois saisi la Cour de justice de l'Union européenne afin de déterminer si l'interdiction pouvait également s'étendre, au regard des libertés de circulation garanties par le droit de l'Union, à la production, au transport ou à l'exportation de produits destinés exclusivement à être commercialisés dans un autre État membre.

→ CE, 13 juillet 2026, *Société Dean et Simmons France et autre*, n° 509446

À retenir. - La compétence du pouvoir réglementaire ne dispense jamais d'un contrôle de proportionnalité. Une interdiction générale peut être admise lorsqu'elle repose sur un risque suffisamment établi et qu'aucune mesure moins restrictive ne permet d'assurer avec la même efficacité l'objectif poursuivi.

POUR S'ENTRAÎNER

Dissertation : Le pouvoir règlementaire est-il gardien des libertés ?

En France, le pouvoir règlementaire, défini comme la compétence de prendre des actes de portée générale et impersonnelle en dehors du champ de la loi, est un attribut essentiel du pouvoir exécutif. Il est exercé principalement par le Premier ministre (art. 21 de la Constitution) et le président de la République (art. 13), mais aussi par les autorités déconcentrées et décentralisées. Traditionnellement perçu comme un simple outil d'exécution des lois, le pouvoir règlementaire joue néanmoins un rôle non négligeable dans la définition et l'encadrement des libertés publiques, qu'il contribue à organiser, mais aussi parfois à restreindre.

Dans un État de droit démocratique, les libertés publiques constituent un socle fondamental, c'est pourquoi la Constitution de 1958 réserve au législateur le soin d'en déterminer les modalités d'exercice. Cependant, progressivement, le pouvoir règlementaire a été doté d'un arsenal juridique lui permettant de connaître des questions intéressant les libertés.

Problématique/fil directeur : Dans quelle mesure le pouvoir règlementaire, bien qu'issu de l'exécutif, peut-il être perçu comme un garant des libertés fondamentales, alors même qu'il détient un pouvoir normatif susceptible de les restreindre ?

Ce sujet invite à s'interroger sur le paradoxe du pouvoir règlementaire : instrument de mise en œuvre des libertés publiques, il en est aussi le limiteur, voire l'adversaire s'il n'est pas strictement encadré.

Nous verrons ainsi que le pouvoir règlementaire peut être un outil nécessaire à la garantie concrète des libertés publiques **(I)**, mais qu'il comporte aussi un risque d'atteinte à ces libertés si son usage échappe à un contrôle rigoureux **(II)**.

I. Le pouvoir règlementaire : un instrument de protection des libertés

A. Une compétence normative encadrée qui peut garantir les droits

Le pouvoir règlementaire est juridiquement subordonné à la loi (art. 34 et 37 de la Constitution), mais il dispose d'une autonomie dans le domaine règlementaire propre (CE, *Labonne*, 1919).

Dans ce cadre, il peut poser des règles nécessaires à l'exercice des libertés : fixer les modalités de leur mise en œuvre (ex. : décrets d'application de lois garantissant l'exercice de certaines libertés).

Le Conseil d'État reconnaît que le pouvoir règlementaire est tenu de respecter les droits et libertés constitutionnellement garantis (CE, *Amicale des Annamites de Paris*, 1956 ; *Koné*, 1996).

B. Une action administrative au service de la conciliation des libertés

Le pouvoir règlementaire est aussi le support des règlements de police générale, qui visent à prévenir les troubles à l'ordre public, condition nécessaire à l'exercice des libertés.

La jurisprudence impose une conciliation entre libertés publiques et ordre public (CE, *Benjamin*, 1933), exigeant une proportionnalité dans les restrictions imposées.

Certaines autorités administratives indépendantes dotées d'un pouvoir règlementaire (ex. : CNIL, ARCOM) ont précisément pour mission de protéger des libertés spécifiques, comme le droit à la vie privée ou la liberté de communication.

II. Un pouvoir susceptible de porter atteinte aux libertés fondamentales

A. Un pouvoir exercé par l'exécutif, historiquement suspect

Le pouvoir règlementaire, exercé par le gouvernement, est historiquement associé à l'arbitraire, en particulier sous l'Ancien Régime.

La tradition libérale place la loi, expression de la volonté générale, comme seule source légitime des restrictions aux libertés : article 34 de la Constitution, mais aussi article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen**.**

L'exécutif peut être tenté d'utiliser le pouvoir règlementaire pour restreindre abusivement les libertés, notamment en période de crise (ex. : état d'urgence, pandémie de Covid-19).

Le pouvoir exécutif est le vecteur normatif des régimes de crise. Historiquement, il revient au pouvoir exécutif de mettre en place des régimes restrictifs des libertés (état d'urgence, état de siège).

B. Une garantie des libertés qui repose davantage sur le juge que sur le pouvoir règlementaire

Le juge administratif contrôle la conformité des actes règlementaires aux droits fondamentaux. C'est davantage par ce contrôle que les libertés sont garanties, que par l'initiative du pouvoir règlementaire lui-même.

Le pouvoir règlementaire peut être suspendu ou annulé s'il méconnaît une liberté fondamentale, notamment par la voie du référé-liberté (CE, ord., 9 janvier 2014, *Dieudonné M'Bala Bala et les productions de la plume,* n° 374508).

La confiance dans le pouvoir règlementaire comme gardien des libertés suppose donc un encadrement juridictionnel fort, ce qui témoigne de sa fragilité dans ce rôle.

En conclusion, le pouvoir règlementaire occupe un rôle important dans la détermination des modalités d'exercice des libertés publiques. Soumis à la loi sous le contrôle du juge, il ne saurait altérer la portée de la loi pour en modifier les effets. Son pouvoir étendu, notamment en matière de police, ne doit pas être un prétexte pour porter atteinte aux libertés.

PARTIE III. LES SOURCES EXTERNES

Fiche n°9 –

Les sources constitutionnelles

Fiche n°10 –

Le bloc de légalité

Fiche n°11 –

Le règlement et les libertés

Fiche nº 12 - L'INTERNATIONALISATION DU DROIT DES LIBERTÉS

POINTS CLÉS

- Conflits mondiaux et impulsion de l'internationalisation des droits.
- Déclaration universelle de 1948 et nouveaux droits sociaux.
- Mutation de la figure du titulaire des droits.
- Multiplication des systèmes de protection régionaux.
- Articulation complexe entre normes nationales et internationales.
- Coopération et confrontation entre ordres juridiques européens et nationaux.
- Accès des individus aux juridictions supranationales.

PRINCIPALES RÉFÉRENCES

- Charte des Nations unies du 26 juin 1945.
- Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen de 1948.
- Pacte international relatif aux droits civils et politiques et Pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966.
- Convention européenne des droits de l'homme et du citoyen.
- Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
- CJUE, 11 décembre 2007, *Viking*, C-438/05.
- *CJUE, 3 septembre 2008, Kadi c. Conseil et Commission.*
- *CEDH,12 septembre 2012, Nada c. Suisse, nº 10593/08.*

1. Le contexte général de l'internationalisation du droit des libertés en France

En l'espace de quelques décennies, le droit des libertés a été profondément transformé par deux dynamiques complémentaires :

- Sur le plan interne : la constitutionnalisation.
- Sur le plan externe : l'internationalisation

Ces deux phénomènes relèvent d'un même mouvement de fondamentalisation des droits, en tant qu'il s'agit de sources supra-législatives.

1.1. Les conflits du xxe siècle, traumatisme fondateur de l'internationalisation des droits humains

L'internationalisation des droits a reçu une impulsion décisive à la suite des deux conflits mondiaux, bien qu'on en décèle les prémices dès le XIXe siècle, avec l'émergence d'une protection internationale embryonnaire des droits humains, illustrée par la lutte contre l'esclavage et par la Convention de Genève de 1864, consacrant le droit humanitaire.

Au lendemain de la Première Guerre mondiale, le traité de Versailles institue en 1919 la Société des Nations, mettant en place des mécanismes encore rudimentaires de garantie des droits, et crée l'Organisation internationale du travail, destinée à encadrer la protection des droits sociaux.

Après la Seconde Guerre mondiale, la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 marque un tournant majeur, bientôt renforcée par l'adoption en 1966 de deux instruments complémentaires : le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

Ce mouvement d'internationalisation s'amplifiera par la suite à travers une série de traités spécifiques, tant par leur objet (lutte contre la torture, traitements inhumains…) que par les catégories de bénéficiaires visées (femmes, enfants, personnes en situation de handicap).

1.2. Un vecteur d'universalisation en phase avec l'idéal des Lumières

De façon plus abstraite, il convient de souligner que l'internationalisation prolonge l'universalisme propre à la conception moderne du droit des libertés, tel qu'il s'exprime dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, davantage que dans les déclarations américaines marquées par le pragmatisme anglo-saxon.

1.2.1. Une filiation avec l'universalisme de 1789 au-delà de l'État

Pour les révolutionnaires, l'universalité des droits de l'homme était une nécessité avant tout d'ordre philosophique. Aujourd'hui, l'universalité des droits humains est devenue une réalité, non pas dans le sens où ils seraient désormais universellement reconnus et respectés, mais dans celui où la revendication de ces droits s'est étendue à l'ensemble de la planète.

Un long processus de transformation s'est néanmoins avéré nécessaire pour faire émerger les droits et libertés au-delà du cadre étatique, bouleversant leur conception en les affranchissant de la référence à l'État et en affirmant leur dimension internationale, indépendante de toute citoyenneté. Portés par la dynamique d'internationalisation, les droits et libertés ont progressivement été reconnus comme un bien commun de l'humanité.

L'internationalisation des droits de l'homme représente à la fois un signe et un moteur de leur universalisation, mais cette avancée soulève la question de la signification de cette universalité dans un monde façonné par la diversité des cultures.

POUR ALLER PLUS LOIN

La Charte des Nations unies, signée à San Francisco le 26 juin 1945, marque véritablement l'entrée des droits humains dans l'ordre juridique international. Elle établit un lien étroit entre le maintien de la paix et la promotion des droits humains, comme en témoigne son article 1er, qui assigne à l Organisation la mission de développer et d encourager le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion. Dans un premier temps, cependant, l effectivité de ces droits demeure incertaine : la Déclaration universelle, adoptée par l Assemblée générale le 10 décembre 1948, n'a pas de valeur juridiquement contraignante pour les États. Certes, des mécanismes de contrôle commencent à voir le jour au sein de l Organisation, mais leur efficacité reste tributaire des compromis politiques. Il faudra attendre 1966 pour que l Assemblée générale adopte deux Pactes distincts, reflet des clivages idéologiques de l'époque : l Union soviétique et ses alliés mettant l accent sur les droits économiques, tandis que le bloc occidental privilégiait les droits civils et politiques, rendant impossible l adoption d un instrument unique. En outre, le Pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels n'impose aux États qu'une obligation de moyens, tandis que le Pacte relatif aux droits civils et politiques leur impose une obligation de résultat, engageant leur responsabilité quant au respect effectif des droits reconnus, sans discrimination. Un Comité des droits de l homme est également institué pour veiller à l application de ces engagements.

1.2.2. La Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 : les droits d'un être humain situé

Si les droits proclamés en 1789 traduisaient avant tout les valeurs et les intérêts de la bourgeoisie du XVIIIe siècle, la Déclaration universelle de 1948 reflète, quant à elle, l'essor des idées socialistes, nourri par l'entrée des classes laborieuses dans la vie politique et l'universalisation du suffrage.

Il est ainsi souvent question de droits sociaux, en particulier du droit au travail, de la liberté syndicale, du droit de grève, du droit à l'éducation et du droit à la protection sociale. L'idéal n'est plus celui du citoyen abstrait de 1789 – derrière lequel se profilait la figure de l'homme blanc –, mais celui de l'être humain concret, envisagé dans sa condition économique et sociale.

1.2.3. Les mécanismes de plaintes au cœur de la protection internationale des droits humains

L'internationalisation du droit des libertés s'accompagne de la mise en place de mécanismes de plainte, de nature juridictionnelle ou administrative, destinés à garantir le respect des engagements par les États signataires. La construction progressive de l'ordre juridique international se manifeste donc par le développement d'instruments et d'institutions juridiques qui, au-delà des systèmes juridiques nationaux, ont pour mission de garantir le respect et la protection des droits fondamentaux.

Cette évolution traduit la volonté d'assurer une universalité plus effective des droits humains en dépassant le cadre strictement étatique. Désormais, les individus eux-mêmes – et non plus seulement les États – peuvent saisir des instances internationales, via des mécanismes juridictionnels, comme dans le cadre de la Convention européenne des droits de l'homme, ou des procédures prévues par les Pactes internationaux relatifs aux droits civils et politiques d'une part, et aux droits économiques, sociaux et culturels d'autre part.

La protection des libertés fondamentales ne repose donc plus exclusivement sur la bonne volonté des États : elle s'inscrit dans des dispositifs supranationaux aptes à sanctionner les manquements étatiques. Ce mouvement contribue à dépasser la conception traditionnelle de la souveraineté étatique.

1.3. Reconfiguration juridique de l'ordre interne : hiérarchie des normes

Selon la théorie de la hiérarchie des normes de Kelsen, dans l'ordre juridique interne, la Constitution occupe une place suprême. Toutefois, la situation se complexifie dès lors que l'on prend en compte l'ordre juridique international, auquel il convient d'assimiler, pour l'essentiel, le droit de l'Union européenne. Il devient alors nécessaire de déterminer comment ces normes internationales s'articulent avec celles de l'ordre interne.

La réponse diffère selon que l'on adopte le point de vue de l'un ou de l'autre ordre.

Du point de vue du droit international et de ses juridictions, les normes internes, même constitutionnelles, sont considérées comme subordonnées. Cette position a été affirmée dès 1932 par la Cour permanente de justice internationale et reprise par les Cours européennes de Strasbourg et de Luxembourg.

→ CPJI, 4 février 1932, *affaire du traitement des nationaux polonais à Dantzig*.

→ CJUE, 15 juillet 1964, *Costa c. ENEL*, aff. 6/64.

→ CEDH, 30 janvier 1998, *Parti communiste unifié de Turquie c. Turquie*., 19392/92.

À l'inverse, du point de vue du droit interne, notamment des juridictions nationales, la primauté de la Constitution est affirmée avec force : le droit international ne saurait lui être supérieur. Le Conseil d'État a ainsi précisé que la suprématie conférée par l'article 55 de la Constitution aux engagements internationaux ne s'étend pas aux dispositions constitutionnelles, position reprise par la Cour de cassation en assemblée plénière.

→ CE, 30 octobre 1998, *M. Sarran, M. Levacher et autres.*

→ Cass., ass. plén., 2 juin 2000, *Melle Fraisse.*

En pratique, les interactions entre les juridictions nationales et internationales se sont multipliées au cours des dernières décennies. Ce développement est alimenté par les nombreux recoupements entre le contrôle de constitutionnalité et le contrôle de conventionnalité, renforcés par les emprunts réciproques de jurisprudence et par le dialogue permanent entre juges nationaux et européens.

Toutefois, cet enchevêtrement des normes internationales et constitutionnelles engendre des configurations complexes et mouvantes, difficilement réductibles à des schémas simplificateurs ou rigides.

POUR ALLER PLUS LOIN

La prolifération des instruments internationaux engendre parfois des conflits de normes dont la résolution peut s'avérer délicate dans la mesure où chaque régime conventionnel tend à affirmer la primauté de l'ordre juridique qu'il instaure sur les obligations émanant d'autres systèmes concurrents. Ainsi, la Cour de justice de l'Union européenne s'est reconnue compétente pour apprécier la légalité d'un règlement européen pris en application d'une résolution du Conseil de sécurité des Nations unies, et a jugé ce règlement contraire aux droits fondamentaux, en raison d'une atteinte disproportionnée. (CJUE, 3 septembre 2008, Kadi c/ Conseil et Commission).

De son côté, la Cour européenne des droits de l'homme a jugé que la Suisse avait violé le droit au respect de la vie privée en maintenant à tort une personne sur une liste de suspects liés à Al-Qaïda. Elle a rappelé que la spécificité de la Convention européenne, en tant que « traité de garantie collective des droits de l'homme et des libertés fondamentales », interdisait aux États membres de s'abriter derrière le caractère contraignant des résolutions du Conseil de sécurité (CEDH, arrêt Nada c. Suisse, 12 septembre 2012).

Les juridictions nationales sont elles aussi confrontées à cette nécessité d'arbitrage entre traités internationaux concurrents. Ainsi, le juge administratif français, saisi d'une contestation fondée sur une incompatibilité entre la Convention européenne et d'autres engagements internationaux, a affirmé sa préférence pour la Convention de Strasbourg (CE, 22 mai 1992, Larachi)

2. Une internationalisation à géographie variable

Si, à l'échelle internationale, les Nations unies ont élaboré de nombreuses conventions relatives aux droits humains, proposées à la ratification des États, c'est dans le cadre régional que la protection internationale des droits de l'homme a pris son essor véritable. Ce phénomène est à l'œuvre depuis un peu plus d'un demi-siècle.

2.1. L'européanisation du droit des libertés

L'Europe joue un rôle déterminant dans l'affirmation et la protection des droits et libertés fondamentaux, à travers deux dynamiques complémentaires, mais distinctes : celle du Conseil de l'Europe et celle de l'Union européenne.

Le Conseil de l'Europe a très tôt inscrit la défense des droits humains au cœur de son projet, notamment par l'adoption de la Convention européenne des droits de l'homme et la mise en place d'un système juridictionnel novateur.

Parallèlement, l'Union européenne, bien que née d'une ambition économique, a progressivement intégré les droits fondamentaux dans son ordre juridique, sous l'impulsion d'une jurisprudence audacieuse de la Cour de justice et de l'adoption d'instruments propres, au point de jouer aujourd'hui un rôle central dans leur garantie.

Ces deux cadres institutionnels ont contribué, chacun à leur manière, à façonner une européanisation du droit des libertés, marquée par la pluralité des sources, la complémentarité des protections, mais aussi par certains défis de cohérence.

2.1.1. Le Conseil de l'Europe

Le Conseil de l'Europe, fondé en 1949, a pour vocation de rassembler les démocraties libérales du continent et de favoriser leur coopération en matière de droits humains. Dès ses débuts, il s'est doté de la Convention européenne des droits de l'homme, un texte de grande précision quant à l'étendue des libertés qu'il consacre.

La Convention distingue ainsi entre des droits intangibles, des libertés ne pouvant être restreintes qu'en cas de guerre ou de danger public menaçant la vie de la nation, et d'autres droits susceptibles de limitations, même en temps normal, selon des conditions strictement encadrées.

L'innovation majeure par rapport au droit international classique réside dans la possibilité offerte à tout particulier de saisir une instance internationale – généralement contre son propre État –, laquelle statue par un arrêt doté de l'autorité de la chose jugée.

Avec l'entrée en vigueur du 11e Protocole en 1998, le système connaît une transformation décisive : la Cour européenne des droits de l'homme devient une juridiction permanente, dont la compétence est désormais obligatoire pour les États membres.

2.1.2. L'Union européenne

Le droit de l'Union européenne se distingue par son évolution singulière, marquée par une histoire complexe faite de paradoxes et de lacunes. Ce droit conjuguait historiquement une portée à la fois large et limitée, privilégiant les libertés économiques – essentielles à l'édification du marché commun – parfois au détriment d'autres droits fondamentaux, notamment sociaux et politiques.

Toutefois, en tant que droit d'intégration, le droit de l'Union s'est rapidement révélé plus vaste que les autres instruments internationaux, y compris la Convention européenne, tant par l'ampleur de son champ d'application que par l'intensité de ses effets. L'impact profond du droit de l'Union sur les libertés a ainsi conduit les États membres à doter l'ordre juridique européen de mécanismes propres à assurer la garantie des droits fondamentaux.

Bien que l'orientation initiale de l'Union ait suscité des critiques, son droit a considérablement évolué, notamment avec l'adoption de la Charte des droits fondamentaux le 7 décembre 2000, à laquelle le traité de Lisbonne attribue la même valeur juridique que les traités.

Il faut souligner le rôle de la Cour de justice, qui, par une interprétation dynamique du droit originaire et dérivé, s'est affirmée comme un garant de la protection des droits humains. C'est dans sa jurisprudence qu'a été posé le principe selon lequel l'applicabilité du droit de l'Union implique celle des droits fondamentaux garantis par la Charte.

→ CJUE, 26 février 2013, *Aklagaren c. Hans Akerberg Fransson*, aff. C-617/10.

2.1.3. L'européanisation à l'épreuve de la souveraineté démocratique

L'objection démocratique est souvent opposée aux décisions de justice fondées sur la primauté des droits européens. Depuis près d'un demi-siècle, le processus d'européanisation a transformé les systèmes juridiques des États européens, notamment à travers l'interprétation européenne des principes d'égalité et de l'organisation de la justice.

Cette européanisation s'accompagne de la diffusion de valeurs véhiculées par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et de la Cour de justice de l'Union. Le droit européen porte l'empreinte d'un libéralisme d'inspiration anglo-saxonne, qui irrigue les domaines des mœurs, des relations sociales et de l'économie.

La Cour de Strasbourg a notamment consacré la notion d'autonomie personnelle, affirmant pour chacun la liberté de « mener sa vie comme il l'entend », au risque de heurter certaines conceptions nationales de la morale.

→ CEDH, 17 février 2005, *K. A. c. Belgique.*

De son côté, l'Union européenne est régulièrement accusée de promouvoir un libéralisme économique parfois préjudiciable aux droits fondamentaux, et tout particulièrement aux droits sociaux. La Cour de justice a ainsi considéré que l'action syndicale, en ce compris le droit de grève et d'action collective, pouvait constituer une entrave à une liberté économique.

→ CJUE, 11 décembre 2007, *Viking*, C-438/05.

Actualité jurisprudentielle. - Les compétences nationales sont de plus en plus saisies par le droit européen

La nationalité demeure en principe une compétence des États. Pourtant, lorsque son exercice produit des effets sur le statut de citoyen de l'Union, il doit respecter le droit de l'Union. La Cour de justice a ainsi jugé contraire au droit de l'Union le programme maltais permettant l'acquisition de la nationalité en contrepartie d'investissements prédéterminés. Selon elle, la commercialisation de l'accès à la citoyenneté européenne méconnaît la nature particulière du lien de solidarité et de loyauté qui doit unir un État à ses ressortissants (CJUE, Gde ch., 29 avril 2025, *Commission c. Malte*, C-181/23).

À retenir. - L'internationalisation et l'européanisation des droits réduisent la possibilité pour les États d'exercer de manière totalement autonome des compétences pourtant traditionnellement regardées comme régaliennes.

2.2. La situation des autres régions dans le monde

L'universalité n'implique pas l'homogénéité puisque la protection supranationale des droits humains se manifeste de manière diverse à travers les régions du monde, offrant ainsi l'opportunité de prendre en compte les spécificités de chaque culture juridique.

2.2.1. L'Amérique

L'organisation des États américains a suivi une trajectoire similaire à celle du Conseil de l'Europe, en adoptant, le 22 novembre 1969, la Convention américaine relative aux droits de l'homme. Celle-ci se rapproche de la Convention européenne, tant par le contenu des droits qu'elle garantit que par l'efficacité des mécanismes de protection instaurés.

De surcroît, la Cour interaméricaine des droits de l'homme dispose d'une compétence consultative.

2.2.2. L'Afrique

Le continent africain a adopté, en 1981, la Charte des droits de l'homme et des peuples dans le cadre de l'Organisation de l'Unité africaine, désormais connue sous le nom d'Union africaine. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a produit une jurisprudence en constante expansion, qui reprend en grande partie les principes établis au niveau international tout en les adaptant aux réalités des sociétés africaines, notamment en ce qui concerne les libertés religieuses.

→ *Commission africaine des droits de l'homme et des peuples c. Kenya*, 26 mai 2017.

2.2.3. L'Asie

Contrairement à l'Europe, à l'Afrique et à l'Amérique, l'Asie ne dispose ni d'une véritable charte des droits humains, ni d'une institution régionale chargée d'en garantir le respect. L'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN), principalement orientée vers les questions économiques et politiques, s'est révélée à plusieurs reprises incapable de faire face aux crises régionales en matière de droits humains. La Charte de l'organisation, adoptée en 2007, affirme la promotion des droits humains, mais en subordonne néanmoins la protection au respect de la souveraineté des États membres.

Si de graves violations des droits fondamentaux persistent dans plusieurs pays, un régionalisme asiatique en matière de droits humains commence néanmoins à émerger. Malgré la grande diversité des contextes nationaux, la majorité des États asiatiques reconnaissent désormais formellement les droits fondamentaux.

Cette reconnaissance se traduit notamment par des proclamations constitutionnelles, la mise en place d'institutions nationales des droits humains, ainsi qu'une participation active des États aux mécanismes onusiens, comme l'examen périodique universel (EPU). Parallèlement, on observe un intérêt croissant pour les droits humains au sein des organisations régionales à vocation économique – en particulier l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est, dont l'influence ne cesse de s'étendre – ainsi qu'une intensification des mobilisations transnationales issues de la société civile.

2.2.4. Le monde arabo-musulman

Le monde arabo-musulman a vu l'émergence de plusieurs textes relatifs aux droits humains, tels que la Charte arabe des droits de l'homme, adoptée en 1994 dans le cadre de la Ligue arabe (profondément révisée en 2004), ou la Déclaration islamique universelle des droits de l'homme de 1981. Toutefois, ces documents soulignent la primauté de la loi islamique sur les droits et libertés qu'ils énoncent.

La Charte arabe des droits de l'homme met l'accent sur les droits collectifs, notamment le droit des nations à disposer d'elles-mêmes, et rejette fermement le sionisme, l'occupation et la domination étrangères, considérés comme des violations des droits humains et des menaces pour la paix et la sécurité internationales.

Concernant les droits individuels, et notamment l'égalité entre hommes et femmes, la version de 2004 marque un progrès sensible par rapport à celle de 1994. Elle affirme l'égalité des sexes, interdit la discrimination, et reconnaît même des mesures positives en faveur des femmes.

Cependant, la mise en œuvre reste incertaine en raison des contraintes culturelles, religieuses et sociales. Le combat pour l'égalité des femmes dans le monde arabe reste difficile et dépendra du soutien des États et de la communauté internationale.

3. L'internationalisation des droits humains face au relativisme culturel

La diversité des conceptions des droits humains, partout dans le monde, ne saurait laisser croire à une adhésion universelle et uniforme à la conception moderne des droits et libertés attachés à la personne humaine.

3.1. L'hégémonisme politique et culturel de l'Occident

La conception moderne des libertés fondamentales repose sur une philosophie de l'individu et de sa place dans la société, née au sein des sociétés occidentales et diffusée par le biais de l'internationalisation du droit des libertés. Ce modèle présente plusieurs limites : d'une part, il est lié au développement économique des États qui le promeuvent, et d'autre part, il met en tension la diversité culturelle et l'hégémonie politique de l'Occident.

Il est vrai que ce dernier argument sert parfois à justifier le maintien de systèmes oppressifs ou à favoriser les régimes illibéraux, y compris en Europe.

Mais ce modèle occidental, accusé de présenter un biais culturel, ne peut prétendre s'imposer à l'échelle mondiale sans prendre en considération les particularités et vulnérabilités de l'individu situé dans son environnement, c'est-à-dire ancré dans des conditions sociales, économiques et culturelles concrètes. Il doit également promouvoir une véritable solidarité, face à la tentation de privilégier la seule autonomie individuelle.

3.2. La cohabitation des droits humains avec des systèmes de pensée valorisant la collectivité

Dans plusieurs régions du monde, l'engouement pour les droits humains reste modéré.

Plusieurs États musulmans ont, par exemple, émis des réserves concernant certains instruments internationaux, permettant à ces pays de ne pas être liés par des dispositions jugées incompatibles avec la Charia, comme cela a été le cas pour l'Arabie Saoudite avec la Convention internationale des droits de l'enfant. Sur la compatibilité de la Charia avec la Convention européenne des droits de l'homme, la Cour de Strasbourg a affirmé qu'il est difficile de se déclarer respectueux des droits de l'homme et de soutenir un régime fondé sur la loi islamique qui se démarque nettement des valeurs de la Convention.

→ CEDH, 13 février 2003, *Refah Partisi c. Turquie*, n° 41340/98.

POUR S'ENTRAÎNER

Dissertation : Internationalisation du droit des libertés et souveraineté des États

De même qu'il existe une affirmation interne des libertés publiques (constitutionnelle, législative), une affirmation similaire se déploie à l'échelle internationale (Déclaration Universelle des droits de l'homme et Convention de sauvegarde des droits de l'homme).

Présentation de l'internationalisation des droits humains à travers la Charte des Nations unies, la Déclaration universelle des droits de l'homme et les Pactes de 1966.

Évocation du paradigme de Westphalie, qui place la souveraineté étatique au cœur du droit international classique, ambiguïté de la position des Nations unies face à la souveraineté étatique.

Définition des termes/expressions :

- **Internationalisation du droit des libertés** : processus par lequel les droits fondamentaux, initialement consacrés dans les ordres juridiques internes, sont progressivement affirmés, protégés et garantis à l'échelle internationale et régionale.
- **Souveraineté** :
    - Étatique (souveraineté externe) : autonomie d'un État dans la conduite de ses affaires intérieures et extérieures, à l'abri de toute ingérence. Logique de liberté.
    - Démocratique (souveraineté interne) : source du pouvoir dans le peuple, qui l'exerce directement, ou par l'intermédiaire de représentants élus. La souveraineté démocratique suppose l'existence d'un État de droit garantissant protection des libertés publiques et droits fondamentaux. Logique de pouvoir (compétence de la compétence).

Problématique et annonce du plan : L'universalisation des droits fondamentaux portée par le droit international vient-il heurter le principe de souveraineté étatique, pilier du droit international classique ? L'internationalisation du droit des libertés, perçue comme un frein à la souveraineté étatique **(I)**, favorise, en réalité, la souveraineté démocratique et les droits fondamentaux, tant sur la scène interne qu'internationale **(II)**.

I. Limitation de la souveraineté classique des États au profit des droits humains

A. Le tournant de 1948 : la mise en cause des États et reconnaissance des droits humains

Désormais « l'humanité a des droits sur l'État ». Après les atrocités des guerres mondiales, les États, responsables des violations massives des droits humains, sont sommés de se soumettre à de nouvelles normes internationales. Les Nations unies, tout en affirmant le respect de la souveraineté des États, promeut des valeurs universelles qu'elle peine parfois à imposer. Néanmoins, des mécanismes de contrôle (commissions, comités) et des possibilités de sanction apparaissent.

Rôle des traités internationaux (discrimination envers les femmes ou sur l'origine, protection des enfants…) qui complètent les Pactes des Nations unies. Ces traités largement ratifiés contribuent à l'internationalisation des droits humains. Mais leur efficacité dépend du respect par les États des obligations sans les réserves qui en altèrent la substance. Des organes de contrôle se prononcent sur la validité des réserves comme l'illustrent les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme et de la Cour interaméricaine (*CEDH, arrêt Belilos c Suisse, 1988*). Plusieurs Comités d'experts suivent cette approche, bien que certains États y résistent

B. L'européanisation et la remise en cause de la souveraineté étatique

L'édification progressive de l'ordre international se traduit par le développement d'instruments juridiques destinés, au-delà des systèmes juridiques nationaux, à garantir les droits fondamentaux. La Convention européenne des droits de l'homme illustre cette internationalisation effective des droits fondamentaux en Europe, grâce à la création d'institutions juridiques dotées du pouvoir de contrôle. L'européanisation des droits fondamentaux est l'un des aspects les plus significatifs de la transformation juridique des systèmes nationaux. À côté de la Convention, le rôle de l'Union européenne doit être souligné, même si l'intégration européenne a suscité des réticences. L'atteinte à la souveraineté des États était d'autant plus vive que les Communauté manquaient de légitimité démocratique et ne consacraient pas les droits fondamentaux. L'européanisation s'est manifestée d'abord par la reconnaissance des principes généraux du droit issus des traditions constitutionnelles, puis par l'alignement sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Elle a trouvé son aboutissement dans la Charte des droits fondamentaux devenue contraignante en 2009 avec le traité de Lisbonne.

II. Renforcer la démocratie et les droits humains à l'échelle nationale et internationale

A. Protéger la démocratie et l'État de droit sur la scène interne

En Europe, l'Union européenne, longtemps perçue comme un projet anti-démocratique, s'affirme désormais comme un acteur clé dans la protection des droits fondamentaux, en diffusant les valeurs de démocratie, de dignité humaine et d'État de droit. L'Union s'est ainsi distinguée dans la défense des droits humains en Pologne, face aux dérives constatées en 2015. En réponse aux réformes menaçant l'indépendance judiciaire, la Commission a activé l'article 7 du Traité, ouvrant la voie à des sanctions. Elle a également initié des recours devant la Cour de justice, qui a condamné la Pologne à plusieurs reprises (*Commission c Pologne, 15 juillet 2021, aff. C-791-19*). Par ailleurs, elle a activé les leviers financiers via le mécanisme de conditionnalité budgétaire. Par ces actions diversifiées, les institutions de l'Union ont affirmé leur engagement en faveur des principes démocratiques et consolidé leur rôle de gardiennes actives de ces valeurs.

B. Un droit à la démocratie : internationalisation et démocratisation

Dans le cadre mondial, plusieurs résolutions de l'Assemblée générale et de la Commission des droits de l'homme des Nations unies ont encouragé l'émergence d'un droit à la démocratie, un droit à être gouverné de manière démocratique. La légitimité démocratique inscrite dans la Déclaration universelle des droits de l'homme a été redécouverte, mettant en valeur le rôle du peuple par rapport à l'État, avec un accent sur les droits des citoyens.

Cercle vertueux entre démocratisation au niveau national et renforcement du droit international. L'internationalisation du droit des libertés s'est accélérée avec les vagues de démocratisation. La fin des régimes autoritaires et les processus démocratiques ont favorisé l'adhésion des États aux traités internationaux et la reconnaissance d'un contrôle international sur le respect des droits humains à l'échelle nationale.

En conclusion, l'internationalisation des droits humains, qui s'est intensifiée au milieu du siècle dernier, s'enrichit des apports culturels divers, notamment en ce qui concerne l'indivisibilité des droits fondamentaux, les droits de solidarité ainsi que les droits des minorités et peuples autochtones.

Ce processus incite à intégrer une éthique humaine universelle, favorisant démocratie et coopération, au niveau interne et international.

L'essor des organisations internationales non gouvernementales et de la société civile mondiale renforce cette dynamique. Le droit international des droits humains, avec ses institutions, procédures et jurisprudence, vise ainsi à bâtir un ordre mondial accepté par toutes les cultures, comme une maison commune pour la famille humaine.

Fiche nº 13 - LE DROIT ONUSIEN

POINTS CLÉS

- Universalité, interdépendance et indivisibilité des droits humains.
- Inspiration libérale.
- Idéal commun de protection universelle.
- Valeur juridique.
- Droit de dérogation.
- Obligations positives et négatives.

PRINCIPALES RÉFÉRENCES

- Art. 1er – 30 de la Déclaration universelle des droits de l'homme.
- Art. 1er– 27 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
- Art. 1er– 15 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.
- Art. 1er – 16 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
- Art. 1er – 7 de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale.
- Art. 1er – 16 de la Convention sur l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes.
- Art. 1er – 41 de la Convention relative aux droits de l'enfant.
- Art. 1er – 71 de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.
- Art. 1er– 33 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées.
- Art. 1er – 25 de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.

Après la Seconde guerre mondiale, la création de l'Organisation des Nations unies par la Charte des Nations unies signée à San Francisco le 26 juin 1945 annonce l'avènement d'une ère d'intensification normative sur le plan international. Les atrocités commises pendant la guerre incitent les États à créer des instruments contraignants protégeant les droits humains, considérant même au troisième point de l'article 1er de la Charte des Nations unies que l'un des objectifs des Nations unies est de :

> *« Réaliser la coopération internationale en résolvant les problèmes internationaux d'ordre économique, social, intellectuel ou humanitaire, en développant et en encourageant le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion. »*

Le système normatif des Nations unies au regard de la protection des droits humains est particulièrement complexe et comprend de nombreux instruments normatifs, généraux ou spécialisés, ainsi que de nombreux organes compétent pour influer sur l'interprétation et l'application de ces droits. Au regard du fonctionnement du droit international, le caractère contraignant ou l'opposabilité de ces dispositions est soumis au consentement étatique par la procédure de signature puis de ratification de chaque instrument.

Le droit international des droits de l'homme est ainsi caractérisé par un vaste ensemble de conventions adoptées sous l'égide du système onusien.

1. La Charte internationale des droits de l'homme

La Charte internationale des droits de l'homme fait référence à trois textes internationaux, tous adoptés par l'Assemblée générale des Nations unies et qui forment la clé de voûte de la protection onusienne des droits humains à savoir :

- La Déclaration universelle des droits de l'homme.
- Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
- Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

Les deux Pactes internationaux ont été adoptés le même jour et sont conçus en miroir l'un de l'autre, protégeant deux « générations » différentes, mais interdépendantes et complémentaires des droits humains. Cette séparation n'empêche pas les Comités de manifester une interprétation des dispositions conformes aux principes d'universalité, d'indivisibilité et d'interdépendance des droits humains (voir *infra* Fiche 21).

Le regroupement de ces textes sous l'appellation de Charte internationale des droits de l'homme tend à appuyer l'idée d'une aspiration à un idéal commun de protection.

Cependant, la Déclaration et les deux Pactes ne sont pas rédigés selon les mêmes philosophies, ni dans les mêmes contextes et leur forme diffèrent.

En effet, le nombre d'États membres des Nations unies a plus que doublé entre l'adoption de la Déclaration en 1948 et l'adoption des Pactes en 1966 grâce au processus de décolonisation. Le contexte géopolitique d'élaboration est également sensiblement différent, conciliant dans la Déclaration les aspirations libérales et marxistes et les opposant dans les Pactes de 1966.

1.1. La Déclaration universelle des droits de l'homme

La Déclaration universelle des droits de l'homme a été adoptée le 10 décembre 1948 au Palais Chaillot à Paris, par la Résolution 217 (III) A de l'Assemblée générale des Nations unies avec l'abstention de l'URSS, des États de l'Est et de certains États du Sud, dû à sa forte inspiration libérale.

Elle constitue le premier instrument universel de protection des droits humains et s'adresse directement à l'individu pour lui conférer des droits essentiels, ainsi qu'à l'État pour l'engager vers la concrétisation de ceux-ci afin de réaliser l'universalité des droits humains ainsi affirmée.

De nombreux principes essentiels au droit international des droits humains y sont affirmés à savoir l'universalité, l'interdépendance et l'indivisibilité des droits, l'inaliénabilité de la personne humaine et le caractère central de la dignité humaine.

La Déclaration énonce solennellement une liste de droits permettant de protéger les individus des autorités nationales afin d'empêcher « la tyrannie et l'oppression » et est directement inspirée de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ainsi que de la *Bill of Rights* américaine de la même année même si de nombreux droits sont nouvellement inclus ou davantage développés.

Les droits et libertés listés correspondent à l'essence des libertés individuelles et recouvrent de manière générale le principe d'égalité, la protection de l'intégrité physique et psychique, les droits procéduraux, les libertés politiques essentielles, ainsi que certains droits économiques et sociaux (leur nombre étant limité).

La Déclaration limite la référence aux devoirs de l'individu à l'égard de la société, lui conférant un esprit individualiste souvent critiqué.

Elle n'a pas la même valeur juridique que les traités et conventions internationales puisqu'il ne s'agit pas d'un instrument juridiquement contraignant à proprement parler, mais d'une proclamation de droits. Dès lors, elle ne contraint pas les États à respecter les droits énoncés, ne prévoit aucune sanction en cas de violation, ni aucun mécanisme de contrôle du respect de ses dispositions.

Cette réalité juridique fonde la critique de l'absence d'effectivité des droits humains comme critique récurrente du système de droit international des droits humains.

La Déclaration n'est pas pour autant dénuée de tout effet juridique, et les États peuvent décider de lui accorder un caractère contraignant en incluant les engagements qu'elle énonce directement dans leur ordre juridique

interne, à l'instar de la Constitution espagnole qui impose dans son article 10.2 que les libertés publiques internes soient interprétées en conformité avec la Déclaration.

Bénéficiant d'une portée universelle, la Déclaration possède une force symbolique et morale et constitue un engagement général au respect des droits humains.

Exceptionnellement par rapport aux autres systèmes, elle est utilisée comme instrument contraignant par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui a le pouvoir d'interpréter et d'appliquer tous les instruments relatifs aux droits humains, dont la Déclaration, et peut ainsi examiner les violations de celle-ci :

> → Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, 22 mars 2018, *Ochieng Anudo c. République-Unie de Tanzanie*, n° 012/2015.

De même, la Cour internationale de Justice s'y est référée explicitement comme source autonome des droits humains :

> → CIJ, 24 mai 1980, *États-Unis c. Iran (Affaire relative au personnel diplomatique et consulaire des États-Unis à Téhéran)*, C.I.J. Recueil 1980, p. 3.

La Déclaration a également été une source d'inspiration très importante pour l'élaboration du système onusien, mais également pour la construction des systèmes régionaux de protection des droits humains. La plupart des textes régionaux y font référence dans leur préambule. On constate également une utilisation croissante dans les jurisprudences régionales.

> → CIDH, 28 novembre 2012, *Artavia Murillo et a. c. Costa Rica*, Series C n° 257.
>
> → CEDH [GC], 8 novembre 2016, *Magyar Helsinki Bizottság c. Hongrie*, n° 18030/11.

Cependant, sur le plan interne, la Déclaration ne bénéficie pas d'un rayonnement aussi important. Le Conseil d'État considère en effet que la Déclaration universelle des droits de l'homme n'a pas d'effet juridique contraignant, ce qui l'empêche d'en contrôler l'application dès 1951 :

> → CE, 18 avril 1951, *Élections de Nolay*, n° 94.389.

POUR ALLER PLUS LOIN

Le Comité de rédaction de la Déclaration universelle des droits de l'homme a été présidé par Eleanor Roosevelt, connue pour son engagement pour le droit des femmes. Parmi les rédacteurs se trouvaient également René Cassin, rapporteur du projet de Déclaration, qui sera désigné prix Nobel de la paix en 1968 et premier juge français à la Cour européenne des droits de l'homme de 1959 à 1976 dont il fut également le président de 1965 à 1968.

1.2. Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Rédigé par la Commission des droits de l'homme, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques a été adopté le 16 décembre 1966 par la résolution 2200A (XXI) de l'Assemblée générale des Nations unies, entré en vigueur le 23 mars 1976 après le dépôt du 35e instrument de ratification et ratifié par la France le 4 novembre 1980.

Le Pacte s'adresse aux États et aux individus et possède une valeur juridique contraignante et un effet direct permettant aux individus d'invoquer la violation de ses dispositions devant les juridictions internes françaises.

Il est composé de deux types de dispositions :

- Des dispositions substantielles protégeant les droits civils et politiques de l'être humain.
- Des dispositions organiques instituant le Comité des droits de l'homme (voir Fiche 21).

La première catégorie correspond à une liste de droits et libertés reconnus comme inhérents à la personne ainsi que des obligations (positives et négatives) incombant à l'État pour leur protection.

Parmi ces libertés civiles et politiques se trouvent le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, l'interdiction de la discrimination, les différentes libertés physiques (le droit à la vie, le droit à ne pas subir de torture ou de

traitement inhumain ou dégradant, le droit de ne pas être réduit en esclavage, le droit à la liberté et la sûreté, l'interdiction de l'emprisonnement pour dette), les droits procéduraux (droit à un procès équitable, l'interdiction de la rétroactivité des délits et des peines), le droit à la reconnaissance de la personnalité juridique, le droit au respect de la vie privée et familiale, la liberté de pensée, de conscience et de religion, la liberté d'expression, le droit de réunion et d'association, le droit au mariage, la protection de l'enfant, le droit de participation politique, l'égalité devant la loi, le droit des minorités, etc.

À noter, le Pacte possède deux articles qui ne font pas partie de cette liste de droits. L'article 4 met en place un processus de dérogation, qui permet aux États de notifier l'existence d'un danger public exceptionnel menaçant l'existence de la nation au Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies, et lui permet ainsi de déroger aux dispositions du Pacte dans la stricte mesure du nécessaire. Les États doivent également mentionner au Secrétaire général les dispositions du Pacte auxquelles ils dérogeront, tout en considérant que certaines dispositions ne peuvent jamais faire l'objet de dérogation : le droit à la vie, l'interdiction des tortures et autres traitements inhumains et dégradants, l'interdiction de l'esclavage et de la servitude, l'emprisonnement pour dette, le principe de non-rétroactivité pénale, le droit à la personnalité juridique, le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion.

Il est également notifié au Secrétaire général la levée des dérogations.

L'article 46 du Pacte met en place une clause de compatibilité institutionnelle selon laquelle aucune des dispositions du Pacte ne porte atteinte au droit de la Charte des Nations unies.

Le Pacte est complété par deux protocoles facultatifs :

- Le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté par l'Assemblée générale des Nations unies dans sa résolution 2200A (XXI) du 16 décembre 1966, qui concerne la création d'un mécanisme de communications individuelles de particuliers alléguant être victimes de violations des dispositions du Pacte et qui habilite le Comité des droits de l'homme à recevoir et examiner les plaintes et auquel la France a adhéré le 17 février 1984.
- Le Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, adopté par l'Assemblée générale des Nations unies dans sa résolution 44/128 et auquel la France a adhéré le 2 octobre 2007 (voir Fiche 26).

POUR ALLER PLUS LOIN

Comme tout traité international, l'État peut émettre des réserves au moment de la ratification des conventions onusiennes. Cela a été le cas notamment pour l'État français qui a émis une réserve à l'article 27 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, sur le droit des minorités, considérant que cette disposition s'inscrivait en opposition avec l'article 2 de la Constitution de 1958, reconnaissant uniquement le français comme langue nationale. En effet, la France ne reconnaît pas l'existence de minorités sur son territoire, ce qui a également motivé son refus d'adhérer à la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires.

Le système des réserves peut être un réel frein à la mise en œuvre des conventions de protection des droits humains, à l'instar des réserves de nombreux États islamiques à la Convention pour l'élimination de toutes les formes de discriminations à l'égard des femmes, la rendant grandement inopérante et pouvant expliquer l'interdiction des réserves dans le Protocole facultatif attaché à cette convention. Néanmoins, la possibilité d'émettre des réserves n'est pas illimitée et celles-ci doivent être compatibles avec l'objet et le but du traité en question et peuvent être éventuellement requalifiées par les organes de contrôle.

1.3. Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels

Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels a été adopté le 16 décembre 1966 par la résolution 2200A (XXI) de l'Assemblée générale des Nations unies, entré en vigueur le 3 janvier 1976 et ratifié par la France le 4 novembre 1980.

Le Pacte s'adresse directement aux États membres pour protéger les droits dits de « deuxième génération ». Il possède une valeur juridique contraignante et un effet direct permettant aux individus d'invoquer la violation de ses dispositions devant les juridictions internes françaises.

Il protège notamment le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes (dans un article 1er identique au Pacte sur les droits civils et politiques), l'interdiction de la discrimination, le droit au travail dans des conditions dignes, le droit de former un syndicat, le droit à la sécurité sociale, la protection et l'assistance aux familles, le droit à un niveau de vie suffisant et à être à l'abri de la faim, le droit à la santé, l'éducation…

Les droits de deuxième génération sont parfois qualifiés de « droits programmatoires » en ce qu'ils nécessitent l'adoption par l'État de politiques publiques spécifiques et sont ainsi des droits « à développer ». Dans ce cadre, l'effectivité de ces droits dépend également du contexte économique dans lequel se trouve l'État membre qui peut prendre de nombreux types de mesures (voir Fiche 21).

Le Pacte a été complété par le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, adopté le 10 décembre 2008 et ratifié par la France le 13 novembre 2014, qui institue un Comité des droits économiques et sociaux pouvant connaître de plaintes individuelles de particuliers alléguant être victimes de violations du Pacte.

À noter : l'existence de deux Pactes protégeant chacun une « génération » de droits humains correspondant également à deux visions de la protection humaine (les droits civils et politiques représentant davantage l'idéal libéral occidental ; les droits économiques, sociaux et culturels se rapprochant davantage des idéaux du bloc soviétique), pourrait faire penser à un cloisonnement des droits humains ou à une fragmentation, contraire à l'idéal de la Déclaration d'interdépendance de ces droits. Cependant, le travail des Comités (voir Fiche 21) ne conforte pas ce point de vue et permet d'aller au-delà de cette impression, que ce soit dans leurs observations générales ou dans leur fonction quasi-contentieuse en consacrant par exemple le volet économique et social du droit à la vie dans le cadre des droits civils et politiques :

→ CDH, 20 septembre 2019, *Cáceres c. Paraguay*, n° 2751/2016.

2. Les traités spécialisés

Le système onusien a été complété par de nombreux instruments spécialisés de protection des droits humains sur des sujets plus restreints qui offrent une protection catégorielle. Il existe 7 autres conventions onusiennes principales dont la mise en œuvre est contrôlée par des comités (voir Fiche 21).

- La Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, 21 décembre 1965, cherchant à développer et encourager le respect universel et effectif des droits humains et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de langue ou de religion.
- La Convention sur l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, 18 décembre 1979, dont les dispositions imposent à l'État de promouvoir l'égalité entre les sexes et d'éliminer toute forme de discriminations qui contribuent à secondariser les femmes dans la société.
- La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, 10 décembre 1984, qui incite l'État à prendre toutes les mesures législatives, administratives, judiciaires ou autres pour empêcher la commission de tels actes sous la juridiction de l'État partie.
- La Convention relative aux droits de l'enfant, 20 décembre 1989, qui met en avant les droits généraux et spéciaux accordés aux enfants selon quatre principes directeurs : la non-discrimination, l'intérêt supérieur de l'enfant, le droit de vivre, de survivre et de se développer et le respect des opinions de l'enfant (cette convention bénéficie par ailleurs d'une ratification universelle, à l'exception des États-Unis).
- La Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, 18 décembre 1990, qui protège les travailleurs contre les discriminations en fonction de différentes situations.
- La Convention relative aux droits des personnes handicapées, 12 décembre 2006, qui impose à l'État signataire d'assurer l'exercice sans discrimination des droits humains aux personnes en situation de handicap ainsi qu'une assistance adéquate.
- La Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, 20 décembre 2006, reconnaissant la pratique comme une violation grave des droits humains appelant les États à prendre des mesures concrètes pour protéger les individus.

Il existe d'autres conventions spécialisées adoptées sous l'égide des Nations unies, mais non dotées d'un comité d'experts (parmi lesquelles se trouvent la Convention relative au Statut des apatrides (28 septembre 1954), la Convention pour l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité (26 novembre 1968), …).

Toutes ces différentes dispositions du droit international des droits humains onusiens, qu'elles émanent des dispositions générales des textes de la Charte internationale des droits de l'homme ou des conventions thématiques spécialisées, ont tendance à se rejoindre et se renforcer mutuellement.

Actualité. -Vers une convention internationale sur les droits des personnes âgées

Le système conventionnel des Nations unies pourrait prochainement être complété par un nouvel instrument spécialisé. Le 3 avril 2025, le Conseil des droits de l'homme a créé un groupe de travail intergouvernemental chargé d'élaborer un instrument international juridiquement contraignant relatif aux droits humains des personnes âgées.

Cette initiative répond au constat que les conventions existantes ne permettent pas toujours de prendre suffisamment en compte les difficultés propres au vieillissement, notamment les discriminations fondées sur l'âge, les atteintes à l'autonomie, l'accès aux soins et à la protection sociale, les violences ou encore l'exclusion numérique. Les travaux se poursuivent en 2026 en vue de déterminer le contenu du futur instrument.

→ Conseil des droits de l'homme des Nations unies, Résolution 58/13, 3 avril 2025, Groupe de travail intergouvernemental sur les droits de l'homme des personnes agées, A/HRC/RES/58/13.

À retenir. - Il n'existe pas encore de convention universelle spécifiquement consacrée aux personnes âgées. La résolution de 2025 marque toutefois le passage d'une réflexion sur l'opportunité d'un nouvel instrument à un processus formel d'élaboration d'un traité juridiquement contraignant.

POUR S'ENTRAÎNER

Argumentation juridique : Soutenez que la Déclaration universelle des droits de l'homme contribue à la protection des droits humains malgré son caractère non contraignant.

La Déclaration universelle des droits de l'homme constitue le fondement du système onusien de protection des droits humains. Il s'agit de la première déclaration solennelle internationale sous forme d'énonciation de droits fondamentaux, adoptée le 10 décembre 1948 à Paris par l'Assemblée générale des Nations unies. Les droits listés recouvrent une grande partie du système classique de protection qu'est le droit international des droits de l'homme, protégeant à la fois des droits civils, politiques, économiques et sociaux.

Malgré ce caractère universel et le fait qu'elle soit au fondement du développement des droits humains onusiens, elle ne possède pas de caractère contraignant, s'agissant d'une déclaration et non d'une convention.

Problématique et annonce du plan : La Déclaration semble alors ne pas avoir de réelle valeur juridique et ainsi être seulement une déclaration d'intention de la part de la communauté internationale. Or, la Déclaration constitue le socle de tout le droit onusien de la protection des droits humains **(I)** et sa portée dépasse son simple statut de déclaration non contraignante **(II)**.

I. Un fondement de la protection internationale des droits humains

A. Une source d'inspiration

Une déclaration inspirée d'un texte contraignant : la Déclaration universelle a été inspirée en partie de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen française qui a valeur constitutionnelle dans l'ordre interne français.

Une déclaration inspirant le droit international des droits humains : au-delà du système onusien, la Déclaration a été une source d'inspiration importante pour la rédaction des autres instruments de protection des droits humains au niveau international comme en témoignent la Convention européenne des droits de l'homme, la Convention américaine des droits de l'homme et la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples qui mentionnent la Déclaration dans leurs préambules respectifs.

Un rôle de promotion des droits humains : le caractère non contraignant du texte permet aussi aux États de s'y référer sans le caractère dissuasif d'une répression internationale et est ainsi un instrument d'application souple.

B. La clé de voûte du système onusien de protection

La Charte du droit international des droits de l'homme comme structure de la protection onusienne :

- Le projet de la Déclaration prévoyait qu'elle serait accompagnée d'un ou plusieurs autres textes rendant les principes qui y sont énoncés contraignants (au travers des Pactes de 1966), rendant ces textes intrinsèquement liés.
- Les dispositions de la Déclaration sont majoritairement reprises dans les Pactes (mise à part le droit de propriété et l'article 28 ne trouvant pas d'équivalent), bien qu'elles soient parfois formulées différemment, ce qui permet de rendre substantiellement la Déclaration effective par le biais des Pactes et au-delà, par les autres systèmes s'en inspirant.
- La Déclaration incite par ailleurs les États à prendre des mesures pour la reconnaissance des droits énoncés en s'adressant directement à eux dans son préambule.

II. Une absence de caractère contraignant discutable

A. Un caractère contraignant selon les systèmes

Sur le plan interne :

- La Déclaration est certes non contraignante sur le plan international ou dans les systèmes monistes (c'est le cas de la France, CE, 18 avril 1951, *Élections de Nolay*, n° 94.389), en revanche, les États peuvent intégrer directement ses dispositions dans leur ordre interne.
- Certaines constitutions mentionnent directement la Déclaration comme source d'obligations : la Constitution espagnole en son article 10.2, mais également l'article 16 de la Constitution portugaise de 1976, l'article 20 de la Constitution roumaine de 1991 : toutes imposent d'interpréter les droits fondamentaux de l'ordre interne en conformité avec la Déclaration. La Constitution d'Andorre considère en son article 5 que *« la Déclaration universelle des droits de l'homme est en vigueur en Andorre »*, lui conférant directement un caractère contraignant.

Les juridictions régionales de protection des droits humains y font également référence en tant que source d'inspiration pour l'interprétation de leur convention : (CEDH, 8 novembre 2016, *Magyar Helsinki Bizottság c. Hongrie*, n° 18030/11).

Dans certains systèmes, elle peut être considérée comme un instrument contraignant à part entière (Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, 22 mars 2018, *Ochieng Anudo c. République-Unie de Tanzanie*, n° 012/2015).

B. La Déclaration, une valeur symbolique

La Déclaration a également une valeur symbolique en tant qu'instrument conférant directement des droits à tous les individus, et constitue un tournant dans la création du droit international qui n'est alors plus uniquement centré sur les États, devant désormais également protéger les individus.

Elle constitue une inspiration morale, symbolique et permet la détermination des principes directeurs des droits humains. Elle véhicule un idéal libéral ainsi que des principes fondamentaux tels que l'universalité, l'interdépendance des droits, le principe de dignité humaine…

En conclusion, malgré son caractère non contraignant, la Déclaration universelle des droits de l'homme n'est pas dépourvue d'effet et constitue un instrument déterminant pour la protection des droits humains.

Fiche nº 14 - LE CONSEIL DE L'EUROPE ET LA CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME

POINTS CLÉS

- Une organisation régionale comprenant 46 États membres.
- Une organisation ayant pour mission la promotion, la défense et la protection des droits humains, de l'État de droit et de la démocratie.
- Près de 200 traités et protocoles additionnels sur des thématiques diverses en lien avec les buts de l'organisation ont été adoptés.
- Une organisation ayant élaboré la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (Conv. EDH).
- La Convention EDH est un instrument vivant et central dans la protection des droits humains au sein du continent européen.

PRINCIPALES RÉFÉRENCES

- CEDH, déc., 11 janvier 1961, *Autriche c. Italie*, nº 788/60.
- CEDH, GC., 23 mars 1995, *Loizidou c. Turquie* (exceptions préliminaires), nº 15318/89.
- CEDH, 8 juillet 2004, *Ilascu c. Moldavie et Russie*, nº 48787/99.
- Cass. crim, 3 juin 1975, *Respino*, nº 75-90.687.

1. Le Conseil de l'Europe

À l'issue de la Seconde Guerre mondiale, et dans un contexte de Guerre froide, de nombreux politiques et juristes (à l'image de W. Churchill dans le cadre du discours de Zürich le 19 septembre 1946, ou de R. Schuman dans le cadre de son discours tenu au Quai d'Orsay le 9 mai 1950) ont souligné la nécessité d'assurer le maintien des démocraties libérales et de la paix par le biais d'une coopération des États européens.

Motivés par cet élan humaniste, divers mouvements politiques ayant pour point commun de souhaiter une coopération européenne se réunissent afin de former le Comité international de coordination des mouvements pour l'unité européenne (CICME).

Ce sera notamment sous l'impulsion du CICME que le Congrès pour l'Europe sera organisé. Ce dernier s'est tenu du 7 au 10 mai 1948 à La Haye dans le but d'évoquer les pistes d'une future coopération régionale.

À la suite de ce congrès, une résolution est adoptée appelant à la création d'une Assemblée européenne, d'une union politique et économique, l'institution d'une Cour suprême européenne et l'adoption d'une Charte des droits humains.

Des négociations sont menées à la suite de ce congrès visant à la concrétisation des statuts du futur Conseil de l'Europe et aboutissent à un compromis entre les visions fédéralistes et unionistes. Les statuts (sous forme de traité international) du Conseil de l'Europe ont ainsi été signés à Londres le 5 mai 1949.

Située à Strasbourg, cette organisation régionale a pour but de défendre et de promouvoir les droits humains, la démocratie, l'État de droit et de *« réaliser une union plus étroite entre ses membres »* (Préambule des statuts du Conseil de l'Europe).

Initialement composé de 12 membres, le Conseil de l'Europe a connu par la suite une croissance importante du nombre de ses membres, ces derniers ne se limitant désormais plus au seul périmètre de l'Europe occidentale. Il dispose désormais de 46 États parties depuis le départ effectif de la Confédération de Russie en septembre 2022.

1.1. Les organes politiques du Conseil de l'Europe

Le Conseil de l'Europe est composé de plusieurs organes politiques ayant pour mission de remplir les objectifs poursuivis par l'institution :

- Le Secrétaire général : Élu pour 5 ans par l'Assemblée parlementaire, il est chargé de la planification stratégique, de l'orientation du programme d'activité et du budget du Conseil de l'Europe. Il a également pour mission de représenter l'organisation.
- Le Comité des ministres : Composé des ministres des affaires étrangères des 46 États membres du Conseil de l'Europe, il a notamment pour mission d'orienter la politique de l'institution, de valider le budget. Il a également pour mission de contrôler l'exécution par les États membres des arrêts rendus par la Cour européenne des droits de l'homme.
- L'Assemblée parlementaire : Organe délibérant du Conseil de l'Europe composée de 306 membres issus des 46 États membres. L'Assemblée adopte des recommandations à destination du Comité des ministres et peut, sur demande de ce dernier, émettre des avis sur des thématiques en lien avec les compétences du Conseil de l'Europe. Elle procède à l'élection du Secrétaire général et du Secrétaire général adjoint, du Commissaire aux droits de l'homme ainsi que des juges à la Cour européenne des droits de l'homme.
- Le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux : Composé de 306 membres élus pour 5 ans, ils sont issus des 46 États membres du Conseil de l'Europe. Le Congrès a pour mission de représenter les pouvoirs locaux et régionaux et de promouvoir la démocratie locale et régionale.
- Le Commissaire aux droits de l'Homme : Organe indépendant et non judiciaire, le Commissaire a été institué par le Comité des ministres le 7 mai 1999. Il peut réaliser des visites au sein des États afin de surveiller le respect des droits humains et d'initier un dialogue avec le gouvernement et la société civile. Il mène également des activités de sensibilisation et de prévention, publie des avis et des conseils à l'intention des États. Il peut également participer à une affaire auprès de la Cour européenne des droits de l'homme en tant que tiers intervenant (art. 36 de la Convention EDH).

1.2. La diversité des normes adoptées au sein du Conseil de l'Europe

En 2025, 226 traités internationaux et accords (ce qui comprend les traités, protocoles ainsi que les révisions des traités) ont été élaborés et adoptés sous l'égide du Conseil de l'Europe. Ce dernier adopte fréquemment de nouveaux traités, à l'image de la Convention sur la protection du métier d'avocat ouverte à la signature depuis le 13 mai 2025.

Les activités de cette organisation ne se limitent toutefois pas à l'adoption de normes juridiquement obligatoires pour les États signataires.

1.2.1. L'activité normative du Comité des ministres

Le Comité des ministres peut adopter des normes contraignantes pour les États qui les signeront. Elles prendront alors la forme de conventions ou d'accords.

Le Comité peut également adopter des normes non contraignantes sous forme de recommandations, de déclarations, par voie de résolutions, sur des thématiques en lien avec les compétences du Conseil de l'Europe.

> → Art. 15, Statut du Conseil de l'Europe.
>
> → La Charte européenne du Sport adoptée par la Recommandation CM/Rec(2021)5 du Comité des ministres le 13 octobre 2021.

1.2.2. Les principaux traités autres que la Convention européenne des droits de l'homme

Outre l'adoption de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, texte phare du Conseil de l'Europe, ce dernier a pareillement adopté d'autres traités principalement à destination de ses États membres, et à la portée contraignante plus ou moins forte.

Chaque État membre du Conseil de l'Europe demeure libre d'adhérer aux autres traités que la Convention EDH adoptés par ce dernier.

Si ces textes ont tous pour point commun de se rattacher en toile de fond aux missions du Conseil de l'Europe, notamment à la défense et à la protection des droits humains, ils portent néanmoins sur des thématiques extrêmement diverses.

Ces dernières peuvent aussi bien concerner des droits civils et politiques, des droits sociaux et économiques (la Charte sociale européenne), que porter sur des thématiques spécifiques telle que l'interdiction de la torture, la protection des données personnelles, l'intelligence artificielle ou l'interdiction du dopage dans les compétitions sportives.

a. La Charte européenne des droits sociaux

Adoptée à Turin le 18 octobre 1961, la Charte sociale européenne est entrée en vigueur le 26 février 1965 et a fait l'objet d'une révision en profondeur le 3 mai 1996 (entrée en vigueur en 1999). Elle fait actuellement l'objet de 46 signatures.

Cette Charte constitue le pendant des droits économiques et sociaux de la Conv. EDH, mais son fonctionnement et son contenu diffèrent grandement de cette dernière.

Les États parties sont toutefois libres de choisir les stipulations leur étant obligatoires. Il s'agit d'un système de ratification à la « carte ».

Les États doivent néanmoins ratifier un nombre minimal de stipulations selon la Partie III article A 1) de la Charte révisée.

Les Parties contractantes ont l'obligation de formuler biannuellement des rapports sur leur mise en œuvre de la Charte.

Ce rapport sera ensuite examiné par le Comité de suivi institué pour ce texte, le Comité européen des droits sociaux. En cas de non-conformité, le Comité des ministres pourra alors adopter une recommandation.

Ce mécanisme de rapport a été complété en 1995 par un protocole d'amendement prévoyant la mise en place d'un système de réclamations collectives pour les États l'ayant accepté.

b. La Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel

Le Conseil de l'Europe dispose également d'une Convention relative à la protection des données. Entrée en vigueur en 1985, elle constitue le premier texte international en la matière.

La Convention ne dispose pas d'organe juridictionnel permanent, mais d'un Comité consultatif. Il a pour mission d'interpréter le texte de la Convention et d'en assurer le suivi.

Ce texte est également mobilisé de manière fréquente par la Cour européenne des droits de l'homme à titre de droit international pertinent.

→ CEDH, GC., 4 mai 2000, *Rotaru c. Roumanie*, n° 28341/95

Un Protocole d'amendement a été ouvert à la signature en 2018 afin de moderniser la Convention.

c. Les accords partiels

Les accords partiels ne sont pas des traités internationaux. Ils permettent à des États membres du Conseil de l'Europe de s'abstenir de participer à des plans d'actions préconisés par d'autres États membres ou de s'associer à des États tiers pour mener à bien des activités communes.

Ils doivent être autorisés préalablement par le Comité des ministres et faire l'objet d'une résolution de ce dernier. L'accord partiel doit comporter *a minima* un tiers des États membres du Conseil de l'Europe.

→ Résolution statutaire du Comité des ministres 93(28) du 14 mai 1993 et résolution 96(36) du 17 octobre 1996

Ces accords permettent également la participation à des États non-membres du Conseil de l'Europe, assurant de la sorte la réalisation conjointe d'une action intergouvernementale.

L'accord sera partiel s'il est mené par une partie des États membres, élargi s'il fait l'objet d'une association de tous les États membres et d'États tiers, et sera enfin qualifié d'accord partiel élargi s'il fait l'objet d'une association d'une partie des membres du Conseil de l'Europe avec des États tiers.

À titre d'exemple, le Comité des ministres a institué par sa Résolution CM/Res(2007)8 du 11 mai 2007 l'accord partiel élargi sur le sport (APES). Il s'agit d'une plateforme de coopération entre les gouvernements, les organisations sportives et les autres parties prenantes du sport. L'APES a également pour mission d'élaborer des normes et d'en assurer le suivi à l'aune de celles adoptées sous l'égide du Conseil de l'Europe.

Actualité. - La première convention internationale contraignante consacrée à l'intelligence artificielle

Ouverte à la signature le 5 septembre 2024, la Convention-cadre du Conseil de l'Europe sur l'intelligence artificielle et les droits de l'homme, la démocratie et l'État de droit constitue le premier traité international (à l'exception des textes européens) juridiquement contraignant spécialement consacré à l'intelligence artificielle. Elle vise à garantir que les activités menées au cours du cycle de vie des systèmes d'intelligence artificielle demeurent compatibles avec les droits humains, la démocratie et l'État de droit.

Elle impose notamment la prise en compte des risques et des incidences des systèmes d'intelligence artificielle sur les droits fondamentaux et prévoit des exigences de transparence, de responsabilité ainsi que des mécanismes de prévention et d'atténuation des risques. Elle permet également aux États d'envisager l'interdiction ou le moratoire de certaines utilisations particulièrement dangereuses.

L'Union européenne a ratifié cette Convention le 15 mai 2026 et a précisé que, pour les acteurs privés, elle mettrait notamment en œuvre ses obligations par l'intermédiaire du règlement européen sur l'intelligence artificielle. Au mois d'août 2026, la Convention n'est toutefois pas encore entrée en vigueur.

⟶ Convention-cadre du Conseil de l'Europe sur l'intelligence artificielle et les droits de l'homme, la démocratie et l'État de droit, STCE n° 225, 5 septembre 2024 ; ratification par l'Union européenne le 15 mai 2026.

À retenir. - La protection européenne des droits fondamentaux face à l'intelligence artificielle ne repose plus seulement sur le droit de l'Union européenne. Le Conseil de l'Europe développe également un cadre conventionnel susceptible d'avoir une portée géographique plus large.

2. La Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Signée le 4 novembre 1950 par 12 États parties à Rome, la Convention est entrée en vigueur le 3 septembre 1953. Il s'agit de l'instrument central du Conseil de l'Europe en tant qu'*« instrument constitutionnel de l'ordre public européen »*.

→ CEDH, GC., 23 mars 1995, *Loizidou c. Turquie* (exceptions préliminaires), n° 15318/89.

Sa ratification par la France n'est toutefois intervenue que le 3 mai 1974.

La Cour européenne des droits de l'homme est chargée depuis 1959 d'assurer le respect des droits énoncés par la Convention. Organe juridictionnel permanent, la Cour est en mesure de traiter des requêtes interétatiques

ainsi que, depuis l'entrée en vigueur du Protocole n° 11 en novembre 1998, d'avoir à connaître des requêtes individuelles formulées par des particuliers.

La Convention a connu depuis sa version de 1950 de substantielles modifications textuelles puisqu'elle a fait l'objet à ce jour de 16 protocoles. Ces derniers constituent de véritables traités et peuvent être de deux ordres.

Ils peuvent prendre la forme de protocoles additionnels lorsque de nouveaux droits seront ajoutés à la Convention, leur entrée en vigueur ne sera alors pas conditionnée par la ratification de l'ensemble des parties contractantes, mais par un nombre prédéterminé.

Ces protocoles ne produiront d'effet qu'à l'égard des États les ayant ratifiés.

- Le protocole additionnel n° 16 prévoit la possibilité pour les États signataires de saisir la Cour européenne des droits de l'homme pour avis consultatif. Ce protocole est entré en vigueur le 1er août 2018 à la suite de sa ratification par la France.
- Le protocole additionnel n° 13 sur l'abolition de la peine de mort est entré en vigueur le 1er juillet 2003.
- Le protocole additionnel n° 12 entré en vigueur le 1er avril 2005, qui comporte dans son article 1er une interdiction autonome et générale de la discrimination, n'a par exemple pas encore été signé par la France. Seuls vingt États l'ont à ce jour ratifié.

Les protocoles d'amendements quant à eux modifient le texte initial de la Convention et requièrent dès lors une ratification par l'intégralité des Hautes Parties contractantes. Pour illustration, le quinzième protocole d'amendement adopté le 24 juin 2013 n'est ainsi entré en vigueur que le 1er août 2021.

2.1. Un mécanisme subsidiaire de protection des droits de l'Homme doté d'un plein effet direct

2.1.1. La primauté de la Convention sur le droit interne

En tant que traité international, la Convention oblige en premier lieu les États signataires. Ce mécanisme va toutefois au-delà puisqu'il consacre des droits objectifs dont les États sont tenus de garantir le respect.

Les États ne peuvent donc pas invoquer le principe de réciprocité pour se libérer de leurs obligations tel qu'ils pourraient le faire en vertu d'autres traités.

> → Art. 1, Convention européenne des droits de l'homme.
>
> → CEDH, déc., 11 janvier 1961, *Autriche c. Italie*, n° 788/60.

La Convention jouit selon la Cour européenne des droits de l'homme d'une primauté sur l'ensemble du droit interne des États parties et ce, qu'il s'agisse de dispositions législatives ou constitutionnelles.

> → CEDH, GC., 30 janvier 1998, *Parti communiste unifié de Turquie et a. c. Turquie*, n° 19392/92.
>
> → CEDH, 28 octobre 1999, *Zielinski et Pradal et Gonzalez et a. c. France*, nos 24846/94 et 34165/96 à 34173/96.

En droit français, la primauté est assurée concrètement par le juge lors de la mise en œuvre du contrôle de conventionnalité.

Ce procédé permet au juge interne de contrôler la compatibilité d'une norme de droit interne de rang législatif ou inférieur avec la norme issue du traité applicable à la cause. Lorsque la première s'avère être contraire ou incompatible avec la seconde, le juge doit alors l'écarter au profit de la norme issue du traité.

> → Cass. ch. Mixte, 24 mai 1975, *Société des Cafés Jacques Vabre*, n° 73-13.556.
>
> → CE, Ass., 20 octobre 1989, *Nicolo*, n° 108243.

2.1.2. Une Convention dotée d'un plein effet direct en droit interne

La Convention européenne des droits de l'homme dispose d'un plein effet direct en droit interne français. Ses stipulations sont directement invocables par les requérants auprès des juridictions internes sans qu'il n'y ait préalablement eu besoin de mesure de transposition.

Le juge français a effectivement reconnu à cette Convention un effet direct non seulement dans le cadre de litiges opposant un particulier à l'État, mais également au sein de relations interindividuelles.

→ Cass. crim, 3 juin 1975, *Respino*, n° 75-90.687.

Pour une application horizontale directe dans le cadre de relations contractuelles : Cass. civ. 3e, 6 mars 1996, *Mel Yedei*, n° 93-11.113.

→ Par exemple : Cass. soc., 14 janvier 2014, n° 12-27.284.

2.1.3. Un mécanisme de protection des droits humains reposant sur le principe de subsidiarité

La Convention repose sur le principe de subsidiarité reconnu pour la première fois par le juge strasbourgeois.

→ CEDH, 23 juillet 1968, *Affaire relative à certains aspects du régime linguistique de l'enseignement en Belgique c. Belgique*, n° 1474/62, 1677/62, 1691/62, 1769/63, 1994/63 et 2126/64

Ce principe a par la suite été formellement intégré à la Convention par le biais du protocole additionnel n° 15 adopté en 2013 et entré en vigueur le 1er août 2021. Il s'agit d'un « principe modérateur » en ce qu'il permet de laisser une plus ample marge de manœuvre aux États.

Le protocole additionnel n° 15 a également consacré textuellement la marge nationale d'appréciation en l'introduisant dans le préambule de la Convention.

Le principe de subsidiarité s'applique aussi bien en amont auprès du juge national, premier juge de la Convention EDH, qu'ultérieurement lors de la saisine de la Cour européenne des droits de l'homme.

Selon ce principe, les juges nationaux ne sont pas contraints d'appliquer les stipulations de la Convention pour autant qu'il existe en droit interne des dispositions similaires ou équivalentes ou que le droit national soit interprété de manière à assurer le respect des droits garantis par la Convention.

→ CEDH, GC., 1er déc. 2020, *Guðmundur Andri Ástráðsson c. Islande*, n° 26374/18.

Si l'invocation en substance des stipulations de la Convention au plan interne s'avère importante puisqu'elle conditionne par la suite la recevabilité des recours auprès de la Cour européenne des droits de l'homme, ce principe est néanmoins apprécié avec tempérance. Les requérants peuvent tout à fait invoquer des dispositions du droit interne similaires ou équivalentes.

→ Art. 35 § 1, Convention EDH.

→ CEDH, GC., 1er juin 2010, *Gäfgen c. Allemagne*, n° 22978/05.

2.1.4. Une Convention vivante garantissant des droits non pas théoriques et illusoires, mais concrets et effectifs

a. La consécration d'une hiérarchie fonctionnelle des droits garantis

La Convention contient tout d'abord des droits absolus ou intangibles. Il s'agit de droits ne pouvant faire l'objet de restrictions ou de dérogations. Les États ne peuvent donc commettre d'ingérences ou apposer de limitations à ces droits sous peine de violer la Convention.

→ Les articles 2 sur le droit à la vie, 3 sur l'interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains et dégradants, 4 sur l'interdiction de l'esclavage et du travail forcé, l'interdiction de la peine de mort, 7 concernant la non-rétroactivité de la loi pénale et l'article 4 du protocole n° 2 concernant la règle *non bis in idem*.

Ces droits peuvent toutefois prévoir des clauses d'exclusion permettant de considérer que certains évènements ne relèveront pas du champ de ces articles.

→ L'article 4 § 3, par exemple, prévoit des hypothèses ne pouvant relever du champ des notions de travail forcé ou obligatoire.

La Convention contient également des droits relatifs ou conditionnels. Elle énonce dans un premier temps ces droits, avant de prévoir ensuite des restrictions spécifiques limitativement énumérées (voir par exemple l'article 5 relatif au droit à la sûreté) ou générales, telles que le respect de l'ordre public.

Lorsqu'une atteinte à un droit relatif est portée à un individu, l'État ne sera pas nécessairement condamné. Il faut en effet qu'il ait commis une atteinte injustifiée.

En cas d'exceptions limitativement énoncées, l'atteinte sera injustifiée si l'ingérence ne répond pas aux conditions prévues par le texte. En présence d'une clause de restriction générale (par exemple l'article 8), l'atteinte sera injustifiée si elle n'est pas proportionnée :

- L'atteinte doit être prévue par la loi, ce qui englobe non-seulement les dispositions législatives, mais également le droit non écrit et donc la jurisprudence. Cette « loi » doit en outre être accessible, précise et prévisible.
- Elle doit viser un but légitime (la protection de la santé, le respect de l'ordre public, la protection des droits d'autrui…).
- Elle doit enfin être nécessaire au sein d'une société démocratique. Ce critère permet à la Cour de contrôler l'adéquation, l'équilibre entre les moyens utilisés pour remplir le but légitime visé et l'atteinte portée aux droits de la Convention.

POUR ALLER PLUS LOIN

Outre les restrictions spéciales et générales, les États peuvent également se prévaloir de l'article 15 de la Convention en cas de circonstances exceptionnelles afin de déroger temporairement à certains droits prévus par le texte après en avoir notifié le Secrétaire général du Conseil de l'Europe. La validité de l'exercice de ce droit de dérogation est toutefois appréciée strictement par la Cour selon les trois critères de l'article 15 § 1 :

Un cas de guerre ou de danger menaçant la vie de la nation (CEDH, 1er juillet 1961, Lawless c. Irlande (nº 3), nº 332/57) ;

Si les États disposent d'une large marge nationale d'appréciation, ils ne doivent toutefois pas prendre de mesures n'étant pas strictement exigées par la situation (CEDH, 16 mai 2024, Domenjoud c. France, nº 34749/16 79607/17) ;

Les mesures doivent être compatibles avec les autres obligations internationales de l'État.

Les articles 2, 3, 4 § 1, 4 § 3 du protocole nº 7, 3 du protocole nº 6 sur l'abolition de la peine de mort en temps de paix et de l'article 2 du protocole nº 13 sur l'abolition complète de la peine de mort de la Convention ne peuvent cependant pas faire l'objet de dérogations.

L'État est également soumis à des obligations positives qui ne requièrent pas qu'une simple abstention de sa part pour éviter un constat de violation.

→ CEDH, GC., 9 décembre 1994, *Lopez Ostra c. Espagne*, nº 16798/90.

Le contrôle du respect des obligations positives de l'État varie de celui opéré afin de contrôler les ingérences qu'il aurait pu causer aux droits garantis par la Convention.

En cas d'abstention de la part de l'État, la Cour apprécie tout d'abord les motifs avancés par l'État pour justifier sa passivité.

En présence de mesures prises par le gouvernement, la Cour appréciera alors le caractère adéquat des mesures adoptées au regard d'une multiplicité de critères et notamment selon le droit en cause, ou la marge d'appréciation à disposition des autorités nationales en la matière.

b. L'extension du champ d'application de la Convention

Les droits consacrés par la Convention EDH ont fait l'objet d'une interprétation constructive par la Cour. Cette dernière a ainsi largement étendu le champ d'application initial des stipulations conventionnelles.

La Convention a fait l'objet d'une interprétation extensive de son champ d'application puisqu'elle protège toute personne relevant de la juridiction des Hautes Parties contractantes.

→ Art. 1 Conv. EDH.

Cette notion de juridiction est en principe conçue territorialement.

→ CEDH, 8 juillet 2004, *Ilascu c. Moldavie et Russie*, n° 48787/99.

Mais le critère de la juridiction peut transcender les notions de nationalité voire de territoire national. La Convention peut alors s'appliquer à des situations s'étant déroulées à l'étranger ou concernant des nationaux d'États tiers au Conseil de l'Europe dès lors qu'un lien de rattachement avec la juridiction d'un État membre *a minima* pourra être établi.

La Convention s'applique dès lors qu'un État partie exerce des prérogatives de puissance publique sur un territoire étranger par le biais d'agents publics fût-ce temporairement.

→ CEDH, GC., 7 juillet 2011, *Al Skeini et a. c. Royaume-Uni*, n° 55721/07.

c. La conception extensive des droits garantis

La conception extensive de la Convention se retrouve également d'un point de vue matériel, car les droits qu'elle consacre ont été considérablement enrichis par la Cour européenne des droits de l'homme.

Cette interprétation dynamique se rencontre tout particulièrement pour l'article 8 de la Convention garantissant le droit à la protection de la vie privée et familiale. La Cour retient en effet une acception extrêmement large de la notion de vie privée et familiale, car cet article englobe également selon elle les notions de domicile, de correspondances, mais aussi d'intégrité physique et morale.

→ CEDH, 16 décembre 1992, *Niemietz c. Allemagne*, n° 13710/88 : la vie privée peut alors englober un volet social et protéger le droit de nouer et de développer des relations avec ses semblables au travail.

→ CEDH, GC., 9 avril 2024, *Verein klimaseniorinnen schweiz et a. c. Suisse*, n° 53600/20 : le droit à la vie privée comprend également le droit de *« bénéficier de la protection effective des autorités de l'État contre les effets négatifs graves sur leur vie, leur santé, leur bien-être et leur qualité de vie qui résultent des conséquences et risques néfastes liés au changement climatique »*.

Cette extension se retrouve également au niveau des obligations à la charge des États puisque la Cour leur impose non seulement des obligations négatives, mais également des obligations positives.

2.2. La dénonciation des traités du Conseil de l'Europe

Les États parties disposent du droit de dénoncer leur adhésion au Conseil de l'Europe et à la Convention. L'article 7 des statuts du Conseil de l'Europe ainsi que l'article 58 de la Convention prévoient une telle faculté de dénonciation.

POUR ALLER PLUS LOIN

La Russie a cessé d'être membre du Conseil de l'Europe le 16 mars 2022 et a cessé d'être partie à la Convention EDH le 16 septembre 2022. La Russie demeurait toutefois liée par les obligations issues de la Convention entre ces deux dates. La Cour estime ainsi demeurer compétente pour traiter des allégations de violations survenues jusqu'à la date de cessation effective de la qualité de partie à la Convention de la Russie. (CEDH, GC., 17 janvier 2023, Fedotova et a. c. Russie, n^{os}40792/10 et 2 autres).

Pour les allégations de violations survenues avant la cessation de la qualité de Haute Partie contractante, mais se prolongeant au-delà, la Cour prendra en considération la date de survenance des faits à l'origine de la violation alléguée (CEDH, GC., 8 mars 2006, Blecic c. Croatie, n° 59532/00) (CEDH, déc., 6 juin 2023, Pivkina et a. c. Russie, n^{os}2134/23, 2156/23, 4556/23).

Actualité jurisprudentielle. - Le retrait d'un État de la Convention n'efface pas sa responsabilité pour les violations antérieures

La cessation de la qualité de partie à la Convention n'empêche pas la Cour européenne des droits de l'homme de statuer sur les violations imputables à un État pour des faits relevant encore temporellement de sa juridiction.

La Grande Chambre l'a illustré de manière particulièrement importante en 2025 dans l'affaire Ukraine et Pays-Bas c. Russie. Malgré la cessation de la qualité de partie de la Russie à la Convention le 16 septembre 2022, la Cour a statué sur les violations commises dans le cadre du conflit en Ukraine depuis 2014 et jusqu'à cette date. Elle a notamment déclaré la Russie responsable de violations graves et généralisées de plusieurs droits garantis par la Convention ainsi que de la destruction du vol MH17.

→ CEDH, G.C., 9 juillet 2025, *Ukraine et Pays-Bas c. Russie,* nos 8019/16, 43800/14, 28525/20 et 11055/22.

À retenir. - La dénonciation de la Convention produit des effets pour l'avenir. Elle ne permet pas à un État d'échapper à la compétence de la Cour pour les actes accomplis alors qu'il demeurait lié par la Convention.

;

POUR S'ENTRAÎNER

Dissertation : Existe-t-il un gouvernement des juges de la Cour européenne des droits de l'homme ?

La Cour européenne des droits de l'homme est l'interprète exclusif de la Convention EDH depuis 1959 en vertu de l'article 32 de ce texte. Elle assure ainsi la protection des droits de toute personne relevant de la juridiction des Hautes Parties contractantes que ce soit dans le cadre de recours interétatiques ou de recours individuels depuis 1998. Pour ce faire, cette juridiction internationale a joué un rôle fondamental au niveau européen dans la protection des droits humains, notamment en développant une interprétation dynamique et évolutive. Ce faisant, la Cour a considérablement enrichi la Convention. Cette œuvre jurisprudentielle a cependant fait l'objet de nombreuses et vives critiques lui reprochant notamment d'avoir imposé aux États des obligations qu'ils n'auraient pas consenti lors de leur signature du traité. Le 22 mai 2025, 9 chefs de gouvernement d'États du Conseil de l'Europe ont ainsi ouvertement critiqué la jurisprudence de la Cour en matière d'immigration estimant que celle-ci les empêchait de protéger leurs sociétés démocratiques.

Si la Cour a certes considérablement enrichi la protection des droits humains offerte par le texte initial de la Convention, on ne saurait pour autant évoquer un quelconque gouvernement des juges strasbourgeois.

Problématique et annonce du plan : La Cour demeure en effet non-seulement liée par les méthodes d'interprétation classiques des traités issues du droit international **(I)**, mais ce mécanisme de protection des droits repose également sur le principe de subsidiarité **(II)**.

I. Une interprétation dynamique de la Convention freinée par des méthodes d'interprétation issues du droit international

A. L'interprétation téléologique de la Convention

La Cour n'interprète pas de manière arbitraire les droits issus de la Convention. La Cour doit en effet fonder son interprétation de ce texte sur des méthodes issues des articles 31 à 33 de la Convention de Vienne de 1969 sur l'interprétation des traités. Elle peut ainsi avoir recours aux travaux préparatoires de la Convention (CEDH, GC., 18 novembre 2020, *Slovénie c. Croatie*, déc., n° 54155/16), mais également opérer une comparaison entre les différentes versions linguistiques afin de déterminer le sens du texte.

La Cour mène une interprétation téléologique de la Convention la conduisant à lire cette dernière à la lumière de ses buts et de ceux de l'organisation internationale au sein de laquelle elle s'insère (CEDH, 27 juin 1968, *Wemhoff c. Allemagne*, n° 2122/64).

La Cour ne crée donc pas de toutes pièces des droits sans que ces derniers ne puissent être rattachés à une stipulation de la Convention. Le droit à un environnement sain n'est ainsi protégé que dans la mesure où l'atteinte environnementale porterait atteinte à un droit garanti par la Convention.

Le système de la Convention n'évolue pas en vase clos. La Convention peut en effet entretenir des liens plus ou moins étroits avec divers textes internationaux. La prise en compte du droit international pertinent se justifie donc également pour éviter les contradictions entre les différents engagements de l'État.

B. La prise en considération de la souveraineté étatique dans l'application des garanties de la Convention

Les États ayant signé la Convention conservent la possibilité de formuler des réserves dans la mesure où elles n'ont pas pour effet de contredire leur engagement conventionnel. Ils conservent par ailleurs de la faculté de déroger temporairement aux garanties de la Convention en cas de circonstances exceptionnelles (CEDH, 1er juillet 1961, *Lawless c. Irlande* (n° 3), n° 332/57).

En outre, les protocoles dont a fait l'objet la Convention EDH ne peuvent être opposables aux États que dans la mesure où ceux-ci l'ont ratifié. La Cour est ainsi liée dans ce cas par la souveraineté étatique (voir par exemple l'interdiction générale et autonome de la discrimination issue du Protocole n° 12).

II. Une interprétation dynamique freinée par le rôle subsidiaire du système conventionnel

A. La prise en compte de la subsidiarité dans la construction du mécanisme de protection des droits

Le principe de subsidiarité est omniprésent au sein du système conventionnel depuis qu'il a été consacré par la jurisprudence (CEDH, 23 juillet 1968, *Affaire relative à certains aspects du régime linguistique de l'enseignement en Belgique*). Il a par la suite fait l'objet d'une consécration textuelle au sein du préambule de la Convention après l'entrée en vigueur du protocole n° 15.

Avant d'introduire une requête auprès de la Cour, les requérants doivent avoir préalablement épuisé les voies de recours internes (art. 35 § 1). L'État doit donc avoir eu l'opportunité de redresser une violation de la Convention avant que la Cour européenne des droits de l'homme ne soit saisie.

Tous les États disposent d'un juge appelé à siéger notamment dans les affaires qui concerneraient leur pays dans le cadre des arrêts de section ou de grande chambre.

Les États disposent surtout de moyens afin d'éviter un potentiel arrêt de condamnation prononcé par la cour : par le biais d'un règlement amiable (Conv. EDH, art. 39 ; art. 62 du règlement de procédure), mais également par des demandes d'avis formulées par les hautes autorités juridictionnelles (protocole n° 16).

B. La prise en compte de la subsidiarité dans le contrôle du respect des droits

La Cour n'est pas un quatrième degré de juridiction et ne peut donc en principe se substituer aux constats dressés par les juridictions nationales (CEDH, 24 novembre 1994, *Kemmache c. France* (n° 3), n° 17621/91).

Selon le principe de subsidiarité, les États disposent d'une marge d'appréciation plus ou moins étendue dans le choix des mesures et la manière de les exécuter afin de se conformer aux obligations conventionnelles (protocole n° 15).

Les États disposent donc d'une certaine liberté dans la mise en œuvre de la Convention. Dans le cadre de l'examen de la nécessité des ingérences la Cour prend par ailleurs en considération les particularités nationales afin de ne pas imposer un fardeau excessif à l'État.

Cette liberté se retrouve également lorsque l'État a été reconnu responsable d'une violation. Si la Cour peut parfois proposer des mesures permettant à l'État de se conformer à ses obligations au titre de la Convention, elle ne lui impose toutefois rien. C'est à ce dernier de déterminer les mesures adéquates afin de mettre fin à la violation (CEDH, AP., 29 avril 1988, *Belilos c. Suisse*, n° 10328/83).

Loin de s'avérer arbitraire, l'interprétation des obligations étatiques par la Cour repose donc sur la souveraineté des États qui disposent, conformément au principe de subsidiarité, du premier et du dernier mot sur la mise en œuvre de leurs obligations découlant de la Convention.

Fiche nº 15 - LE DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE

POINTS CLÉS

- Un droit initialement conçu comme un instrument d'intégration économique.
- L'intégration des droits fondamentaux comme processus lent mais constant.
- L'incomplétude des premiers traités comblée par la jurisprudence.
- Le rôle historique des Cours constitutionnelles nationales.
- Le rôle dynamique de la Cour de justice dans la consécration des droits humains.
- L'importance secondaire du droit dérivé dans la protection des droits humains.
- Une recherche d'harmonie avec le droit issu de la Convention européenne.
- L'instrumentalisation des droits humains au service de l'intégration européenne.
- Des critiques persistantes sous l'angle des droits sociaux.

PRINCIPALES RÉFÉRENCES

- CJCE, *15 juillet 1964, Costa c/ Enel, aff.6/64.*
- *CJCE, 17 décembre 1970, Internationale Handelsgesellschaft, aff.11/70.*
- Tribunal constitutionnel de Karlsruhe, 29 mai 1974, *So lange I.*
- CJCE, 21 septembre 1989, *Hoechst / Commission, C-46/87.*
- CJCE, 29 mai 1997, *Kremzow, C-299/95.*
- CJCE, 14 octobre 2004, *Omega, C-36/02.*
- CJCE, 11 décembre 200, *Viking, C-438-05.*
- CJUE, 6 mars 2014, *Cruciano Siragusa, C-206/13.*
- CJUE, 26 février 2013, *Stefano Melloni, C-399/11.*

1. Les sources des droits fondamentaux dans l'Union européenne

L'orientation tracée par les textes fondateurs de l'Union est claire : elle vise à édifier une union sans cesse plus étroite entre les peuples d'Europe, à instaurer un marché unique sans frontières intérieures, et à construire un espace de liberté, tant politique qu'économique.

Cependant, l'intégration des droits fondamentaux dans le droit de l'Union européenne, à l'initiative de la Cour de justice de l'Union européenne (anciennement Cour de justice des Communautés européennes), s'est réalisée de manière progressive, mais constante, soutenue et renforcée par les traités et le droit dérivé.

1.1. L'influence historique et persistance de la jurisprudence

À l'origine, les traités communautaires (CEE, CECA) comportaient peu de dispositions relatives aux libertés et droits fondamentaux, leur vocation étant principalement économique. Certes, le droit primaire consacrait le principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, mais son champ d'application restait limité.

→ Art. 119 CE initial (devenu article 157 TFUE).

1.1.1. La résistance des Cours constitutionnelles nationales face aux lacunes des premiers traités

L'absence d'un catalogue des droits humains dans les traités fondateurs a poussé les juges internes à se référer aux Constitutions des États membres, remettant en cause le monopole de la Cour de justice sur le contrôle du

droit communautaire et la primauté de ce dernier. Cette primauté consacrée de façon prétorienne leur semblait d'autant plus contestable que les traités originels ne mentionnaient pas explicitement les droits fondamentaux.

En outre, la primauté du droit de l'Union avait vocation à s'appliquer même vis-à-vis des droits fondamentaux garantis par les constitutions nationales, ce qui revenait, en pratique, à faire primer des dispositions de nature économique… sur les droits humains.

→ CJCE, 15 juillet 1964, *Costa c. Enel.*

→ CJCE, 9 mars 1978, *Simmenthal.*

La Cour de justice avait ainsi estimé que l'invocation d'atteintes portées soit aux droits fondamentaux tels qu'ils sont formulés par la constitution d'un État membre, soit aux principes d'une structure constitutionnelle, ne saurait affecter la validité d'un acte de l'Union.

En 1974, le Tribunal constitutionnel allemand a affirmé sa compétence pour juger de la validité des actes communautaires au regard des droits fondamentaux inscrits dans la constitution allemande, en réponse à la position de la Cour de justice selon laquelle le droit communautaire devait prévaloir même sur les normes constitutionnelles nationales.

→ Tribunal constitutionnel de Karlsruhe, 29 mai 1974, *So lange I.*

Dès lors que la primauté du droit communautaire était conditionnée par le juge constitutionnel allemand au respect des bases constitutionnelles de l'Allemagne, et notamment à la garantie des droits fondamentaux, il fallait que l'ordre juridique communautaire garantisse une protection des droits équivalente à celle assurée par la Constitution nationale pour que la saisine de la Cour de Karlsruhe n'ait plus lieu d'être : *« aussi longtemps que »* cette condition ne serait pas remplie, des recours contre une disposition de droit communautaire invoquant la violation d'un droit fondamental reconnu par la Constitution allemande seraient recevables.

1.1.2. La consécration prétorienne des principes généraux du droit

Dans un premier temps, la Cour de justice s'était initialement opposée à l'introduction des droits fondamentaux dans l'ordre juridique communautaire.

→ CJCE, 15 juillet 1960, *Ruhrkohlen-Verkaufsgesellschaft.*

Mais sous la pression des Cours constitutionnelles allemandes et italiennes, la Cour a reconnu, en 1970, que les droits fondamentaux font partie intégrante des principes généraux du droit des Communautés.

→ CJCE, 17 décembre 1970, *Internationale Handelsgesellschaft.*

Cette préoccupation jurisprudentielle à l'égard des principes généraux s'est poursuivie par un rapprochement avec les instruments internationaux de protection des droits humains auxquels les États membres ont adhéré, en plus des traditions constitutionnelles communes. À cet égard, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a pu revêtir pour la Cour de Luxembourg « une signification particulière ».

→ CJCE, 21 septembre 1989, *Hoechst c. Commission.*

1.2. Le droit primaire : une incomplétude dépassée au fil des traités

Le droit primaire de l'Union européenne s'est enrichi au fil des révisions des traités, comblant les lacunes concernant les droits fondamentaux et la citoyenneté européenne. En effet, dans les premiers traités, le droit communautaire privilégiait avant tout la figure du travailleur et de l'agent économique, essentiel à la construction du marché, plutôt que celle du citoyen.

1.2.1. Le tournant Maastricht : couverture conventionnelle et citoyenneté de l'Union

Le traité de Maastricht a donné une couverture conventionnelle à la jurisprudence de la Cour en consacrant dans le droit primaire le principe selon lequel les droits fondamentaux font partie du droit de l'Union en tant que principes généraux du droit.

En outre, c'est avec le traité de Maastricht qu'est instituée une citoyenneté de l'Union européenne. Cette « citoyenneté commune » est définie comme un instrument de renforcement des droits des ressortissants des États membres.

Les ressortissants des États membres ont vu leurs droits politiques consacrés par les traités : droit de vote et d'éligibilité au Parlement européen, droit de pétition, droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales dans l'État de résidence. Par ailleurs, le traité établit expressément un droit de circulation et de séjour sur le territoire des États membres, consolidant ainsi les libertés fondamentales des citoyens de l'Union.

→ Art. 18 TUE.

1.2.2. L'apport de Lisbonne : Charte des droits fondamentaux et adhésion à la Convention européenne des droits de l'homme

Le Traité sur l'Union européenne, issu de la révision de Lisbonne, précise que l'Union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés dans la Charte des droits fondamentaux du 7 décembre 2000, telle qu'adaptée le 12 décembre 2007, laquelle a la même valeur juridique que les traités.

→ Art. 6.1 TUE.

De plus, l'Union adhère à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette adhésion ne modifie pas les compétences de l'Union telles qu'elles sont définies dans les traités.

→ Art. 6.2 TUE.

1.3. Le droit dérivé : une importance secondaire

Le droit dérivé, destiné à mettre en œuvre les objectifs de l'Union, n'a pas vocation à constituer une source principale des libertés et droits fondamentaux. Toutefois, il présente deux particularités : il bénéficie, à l'instar des traités, du principe de primauté, ce qui lui permet de prévaloir sur le droit national ; et, dans certains cas, il sert de cadre central à l'affirmation des droits fondamentaux.

En l'absence de dispositions explicites dans les traités, plusieurs directives et règlements ont joué un rôle déterminant dans la reconnaissance et la protection de droits fondamentaux, notamment en matière d'égalité de traitement et de non-discrimination, ou dans la régulation du traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée.

→ Règlement n° 2016/679 du 27 avril 2016 (RGPD).

2. La protection des droits fondamentaux : enjeu de fédéralisation pour l'Union

Le mutisme originel des traités, largement comblé depuis, ne peut plus servir de prétexte aux juges nationaux pour mettre en cause les actes des institutions de l'Union au motif d'une atteinte aux droits fondamentaux consacrés par les Constitutions nationales. En intégrant les droits fondamentaux dans les sources de droit de l'Union, la Cour de justice a fait du traité l'équivalent d'un « pacte fédératif » et engagé, d'une certaine façon, un double phénomène de « constitutionnalisation » et de « fédéralisation » de l'Union européenne.

POUR ALLER PLUS LOIN

La garantie des droits fondamentaux revêt une grande importance dans la plupart des États fédéraux dans le monde. Aux États-Unis, où le fédéralisme est né, les droits des individus et le respect des compétences étatiques sont intimement liés, le Xe Amendement de la Constitution prévoit : « The powers not delegated to the United States by the Constitution, nor prohibited by it to the States, are reserved to the States respectively, or to the people. »

Cette analyse épouse pleinement la double nature d'une fédération, conçue à la fois comme une union d'États et une union de peuples, où les droits fondamentaux des États viennent enrichir et compléter ceux reconnus aux individus. Toutefois, en raison des particularités inhérentes au droit d'intégration et des contingences historiques ayant marqué son évolution, l'Union européenne ne peut être regardée comme une véritable Fédération.

2.1. La spécificité des droits fondamentaux en droit de l'Union

Le régime des droits et libertés consacrés par l'Union européenne présente une spécificité qui le distingue des autres instruments de protection des droits fondamentaux. Consacrés tant par la Cour de justice que par les traités, ces droits s'imposent aux institutions européennes, mais ne lient les États membres que dans la mesure où ils mettent en œuvre le droit de l'Union ou lorsqu'une situation relève de ce droit.

→ CJCE, 29 mai 1997, *Kremzow.*

Cette exigence, déjà reconnue pour les principes généraux du droit, a été consacrée par la Charte des droits fondamentaux.

→ Art. 51 § 1 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

Selon la Cour de justice, la notion de « mise en œuvre du droit de l'Union » suppose un lien de rattachement suffisant, dépassant le simple voisinage des matières ou leurs effets indirects.

→ CJUE, 6 mars 2014, *Cruciano Siragusa.*

Ainsi, les juridictions françaises ont écarté l'application de la Charte dans des domaines relevant de la compétence exclusive des États membres, comme l'aménagement du système de sécurité sociale.

→ Cass. civ. 2e, 6 octobre 2016.

Cette limitation inhérente aux spécificités du droit de l'Union contribue à reléguer la Charte des droits fondamentaux à un rôle secondaire dans la protection des droits fondamentaux, malgré son statut de texte international le plus récent et le plus complet en la matière.

POUR ALLER PLUS LOIN

Outre les recours juridictionnels, les particuliers disposent de mécanismes non judiciaires leur permettant de protéger leurs droits fondamentaux face aux violations imputables aussi bien aux institutions de l'Union européenne qu'aux États membres lorsqu'ils agissent dans le champ d'application du droit de l'Union. Ainsi, le droit de s'adresser au Médiateur européen, reconnu comme un droit fondamental par l'article 44 de la Charte des droits fondamentaux, permet aux citoyens de l'Union et aux personnes résidant sur son territoire de dénoncer les cas de mauvaise administration commis par les institutions, organes et organismes de l'Union, à l'exception toutefois de la Cour de justice dans l'exercice de ses fonctions juridictionnelles.

De même, toute personne estimant que ses droits en matière de protection des données ont été violés par une institution, un organe ou un organisme de l'Union peut saisir le Contrôleur européen de la protection des données au moyen d'une plainte formelle. Lorsqu'une violation des droits fondamentaux est imputable aux autorités nationales agissant dans le cadre du droit de l'Union, une plainte peut être déposée auprès de la Commission européenne. En outre, le droit de pétition auprès du Parlement européen – également garanti par l'article 44 de la Charte – permet aux citoyens et résidents de l'Union d'attirer l'attention du Parlement sur toute question relevant de ses compétences et les affectant directement.

2.2. Constitutionnalisation, fédéralisation ou instrumentalisation ?

En élevant les droits fondamentaux au rang de principes généraux, la Cour de justice a largement contribué à la constitutionnalisation matérielle des traités, dans la lignée des Constitutions nationales qui intègrent un catalogue des droits et libertés. Si cette consécration prétorienne se justifiait par la nécessité de combler une lacune des traités, afin de soumettre les actes des institutions au respect des droits reconnus aux ressortissants

nationaux, la Cour a rapidement adopté une approche plus ambitieuse : elle a étendu sa compétence au contrôle des mesures nationales.

Une partie de la doctrine y voit une instrumentalisation de la protection des droits fondamentaux au service d'un renforcement de l'influence de l'Union sur celui des États membres. En effet, même lorsqu'elle veille au respect des droits fondamentaux, la Cour poursuit l'objectif premier d'approfondir l'intégration européenne.

La jurisprudence de la Cour de justice n'a pas échappé aux critiques qui dénoncent une interprétation biaisée en faveur des intérêts du marché, opérant au détriment de la protection d'intérêts non marchands. C'est en vain que les États membres ont tenté d'opposer leurs propres standards constitutionnels de protection des droits fondamentaux à l'empire des libertés économiques garanties par l'Union.

→ CJCE, 11 décembre 2007, *Viking.*

Au-delà du marché unique, l'espace de liberté, de sécurité et de justice témoigne d'une forte tension entre protection des droits fondamentaux et l'exigence d'uniformité du droit de l'Union. À la question de savoir si la conception nationale du droit à un procès équitable pouvait primer sur celle de la Charte pour justifier une dérogation à l'exécution d'un mandat d'arrêt européen, la Cour de justice a répondu négativement : une mesure nationale mettant en œuvre le droit de l'Union ne peut pas prévoir un niveau de protection plus élevé que celui de la Charte, si cela compromet le niveau de protection garanti par cette dernière, la primauté ou l'effectivité du droit de l'Union.

→ CJCE, 26 février 2013, *Stefano Melloni.*

2.3. Droits fondamentaux des individus et « droits fondamentaux » des États

Dans une perspective fédérale ou quasi-fédérale, la protection de l'autonomie des États contre les ingérences de l'Union (ou de la Fédération) peut théoriquement être envisagée comme un « droit fondamental » des États *(States' rights)*, calqué sur le modèle des droits fondamentaux reconnus aux individus. Dans une fédération, ces deux dimensions – respect des compétences étatiques et garantie des droits et libertés individuelles – sont appelées à coexister harmonieusement.

De manière analogue, au sein de l'Union européenne, un conflit normatif entre le droit de l'Union et le droit constitutionnel d'un État membre soulève des questions de subsidiarité, mettant en lumière l'articulation entre protection des droits fondamentaux et préservation de l'identité nationale. Reconnaître une place accrue à l'identité nationale ou constitutionnelle d'un État membre peut ainsi apparaître comme une modalité indirecte de protection des droits des ressortissants nationaux.

La jurisprudence illustre parfois cette complémentarité entre autonomie étatique et sauvegarde des droits individuels : ainsi, la prise en compte de l'identité constitutionnelle d'un État membre (le respect de la dignité humaine étant un droit constitutionnel indérogeable en Allemagne) a permis de faire primer la dignité humaine sur les exigences des libertés marchandes consacrées par le droit de l'Union (libre prestation de service).

→ CJCE, 14 octobre 2004, *Omega.*

3. Les rapports ambivalents entre droit de l'Union et droit de la Convention

Les rapports entre ces systèmes juridiques supranationaux demeurent complexes sous l'angle de la protection des droits fondamentaux. La Convention européenne et la Charte des droits fondamentaux de l'Union permettent, toutes deux, aux États membres de maintenir des standards de protection plus élevés que ceux garantis par ces textes.

→ Art. 53 de la Convention européenne des droits de l'homme.

→ Art. 53 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

Cependant, la Cour de justice a précisé que la primauté et l'effectivité du droit de l'Union restreignent cette faculté, empêchant les États d'invoquer des standards plus protecteurs lorsque cela compromet l'application uniforme du droit de l'Union. Une coordination rigoureuse s'impose dès lors dans la mise en œuvre des garanties fondamentales, notamment en cas de conflit entre les niveaux de protection.

En outre, la Cour européenne des droits de l'homme exige, dans certains cas, que les États contrôlent le respect des droits fondamentaux par d'autres États, dans le cadre de mécanismes de coopération ou de reconnaissance mutuelle. Inversement, la Cour de justice affirme que le niveau de protection des droits fondamentaux prévu par le droit interne ne saurait excéder celui fixé par le droit de l'Union, afin de préserver la cohérence et l'unité de l'ordre juridique européen.

L'adhésion de l'Union à la Convention vise à permettre aux particuliers d'intenter un recours contre l'Union devant une juridiction internationale indépendante, à savoir la Cour de Strasbourg. En vertu de cette adhésion, l'Union serait tenue de réparer toute violation des droits fondamentaux constatée par la Cour de Strasbourg, renforçant ainsi la protection effective des droits humains à l'échelle continentale.

Cette démarche favoriserait par ailleurs une meilleure cohérence jurisprudentielle entre la Cour européenne des droits de l'homme et la Cour de justice.

3.1. Une recherche de cohérence entre les deux ordres juridiques européens

La Charte organise un mécanisme de coordination entre le droit de l'Union et la Convention. Elle prévoit que, dans la mesure où la Charte contient des droits correspondant à ceux garantis par la Convention, leur sens et leur portée sont identiques, sans préjudice pour l'Union de prévoir une protection plus étendue.

→ Art. 52.3 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

Les jurisprudences respectives de la Cour de Luxembourg et de la Cour de Strasbourg témoignent de l'essor continu de la judiciarisation des sociétés européennes et de la place croissante reconnue aux droits fondamentaux. Ces derniers participent désormais pleinement à la définition de l'identité européenne.

L'adhésion de l'Union à la Convention viendra parachever ce processus en soumettant l'Union à un contrôle externe, renforçant ainsi la promotion et la protection des droits fondamentaux sur le continent. Il convient toutefois de ne pas occulter un risque politique : celui qu'un État membre instrumentalise une éventuelle condamnation de l'Union par la Cour européenne des droits de l'homme à des fins de contestation de l'ordre juridique européen.

3.2. Adhésion de l'Union à la Convention : enjeux juridiques et politiques

L'adhésion de l'Union à la Convention revêt une dimension, à la fois politique et juridique :

- Sur le plan politique, elle manifeste l'engagement en faveur de la protection des droits fondamentaux et assurer une meilleure cohérence entre l'Union et le Conseil de l'Europe.
- Sur le plan juridique, l'adhésion offrirait aux individus une protection juridictionnelle accrue des droits fondamentaux dans l'ordre juridique de l'Union. Les citoyens européens et les ressortissants d'États tiers, pourraient, en cas de violation alléguée de la Convention par l'Union, saisir la Cour de Strasbourg dans les mêmes conditions que les États membres.

L'Union européenne se trouvera dans une situation comparable à celle des États membres, qui disposent pour la plupart de leur propre catalogue de droits fondamentaux tout en étant liés par la Convention européenne des droits de l'homme. L'adhésion comblera ainsi les lacunes actuelles en assurant aux citoyens européens une protection effective vis-à-vis des actes de l'Union, analogue à celle dont ils bénéficient à l'égard des États membres.

Par ailleurs, l'adhésion contribuera à instaurer une uniformité dans le contrôle de la protection des droits fondamentaux à travers l'ensemble des ordres juridiques européens, renforçant ainsi la confiance des citoyens.

3.3. Des obstacles persistants

L'adhésion de l'Union à la Convention se heurte encore à des obstacles majeurs. Un premier coup d'arrêt avait été donné par la Cour de justice dans un avis de 1996, où elle avait estimé que la Communauté ne disposait pas de la compétence nécessaire pour adhérer à la Convention.

→ CJUE, avis du 28 mars 1996.

Plus récemment, la Cour de justice a considéré que le dernier projet d'accord d'adhésion était incompatible avec le droit de l'Union. L'avis de la Cour contrastait avec les conclusions de l'Avocat général qui avait estimé que le projet était compatible avec les traités, sous réserve de certaines interprétations.

→ CJUE, avis 2/13 du 18 décembre 2014.

La Cour a identifié sept motifs d'incompatibilité du projet d'accord avec le droit de l'Union, invoquant à une vingtaine de reprises la nécessité de préserver l'autonomie de l'ordre juridique de l'Union, jugée gravement menacée par l'accord proposé. Cet avis a brutalement interrompu un processus d'adhésion engagé depuis cinq ans.

La position de la Cour de justice est d'autant plus discutable que le traité de Lisbonne avait précisément introduit des dispositions destinées à permettre l'adhésion, conformément aux exigences formulées par la même Cour dans son avis de 1996.

Actualité. - Une nouvelle étape vers l'adhésion de l'Union à la Convention européenne des droits de l'homme

Le rejet du projet d'adhésion par l'avis 2/13 n'a pas mis fin au processus. Les négociations ont repris en 2020 entre l'Union européenne et les États membres du Conseil de l'Europe et ont abouti, en mars 2023, à un accord provisoire sur un projet révisé destiné à répondre aux objections formulées par la Cour de justice.

Une difficulté particulière demeurait toutefois concernant le contrôle juridictionnel des actes relevant de la politique étrangère et de sécurité commune. La jurisprudence de la Cour de justice rendue en 2024 a précisé que l'exclusion de sa compétence en matière de PESC doit être interprétée strictement et qu'elle peut contrôler les actes et omissions qui ne sont pas directement liés à des choix politiques ou stratégiques.

Une nouvelle étape a été franchie le 21 novembre 2025 : la Commission européenne a saisi la Cour de justice, sur le fondement de l'article 218 § 11 TFUE, afin qu'elle se prononce sur la compatibilité du projet révisé d'accord d'adhésion avec les traités.

⟶ CJUE, demande d'avis 1/25, Adhésion de l'Union à la CEDH ‑ II, introduite le 21 novembre 2025.

Au mois d'août 2026, cette procédure demeure pendante. L'Union européenne n'est donc toujours pas partie à la Convention européenne des droits de l'homme.

À retenir. - L'adhésion de l'Union à la Convention constitue une obligation inscrite à l'article 6 § 2 TUE, mais elle n'est toujours pas réalisée. L'avis 1/25 constitue une étape décisive : la Cour de justice doit déterminer si le nouveau projet préserve suffisamment l'autonomie de l'ordre juridique de l'Union tout en permettant son contrôle externe par la Cour européenne des droits de l'homme.

POUR S'ENTRAÎNER

Argumentation juridique : Soutenez qu'il existe un décalage entre le discours actuel de l'Union européenne sur les droits humains et la réalité observée en matière de politique migratoire, de lutte contre les discriminations et de protection de l'État de droit.

Il faut définir les termes du sujet

- **Politique migratoire** : ensemble des règles et mesures adoptées au niveau de l'Union européenne pour encadrer l'entrée et le séjour des ressortissants de pays tiers.
- **Lutte contre les discriminations** : recouvre les politiques et instruments visant à garantir l'égalité de traitement entre les individus, indépendamment de l'origine ethnique, religion, sexe, l'orientation sexuelle, handicap ou âge.
- **Protection de l'Etat de droit** : renvoie au respect des principes fondamentaux d'une démocratie (primauté du droit, indépendance de la justice, séparation des pouvoirs, contrôle de la légalité de l'action publique).

Il faut commencer par rappeler que l'Union dispose, depuis 2000, d'une charte des droits fondamentaux (entrée en vigueur en 2009 avec le traité de Lisbonne) dont le préambule annonce que l'Union repose sur le principe de l'État de droit et qu'elle place la personne au cœur de son action, notamment en créant un espace de liberté, de sécurité et de justice.

Il faut savoir que l'Union se définit elle-même comme une « Union de droit » (*CJUE, Gde ch., 29 juin 2010, E et F, aff. C-550/09, point 44*)

Il faut indiquer que lesdites politiques entrent dans le champ du droit de l'Union et donner la base juridique de ces domaines :

- Politique d'immigration : article 79 et 89 du traité sur le fonctionnement de l'Union.
- Lutte contre les discriminations et protection de l'État de droit : article 2 du traité sur l'Union européenne aux termes duquel *« l'Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de démocratie, d'égalité, de l'État de droit, ainsi que de respect des droits de l'homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités. Ces valeurs sont communes aux États membres dans une société caractérisée par la non-discrimination* […] *et l'égalité entre les femmes et les hommes ».*

Il faut démontrer que l'Union, qui se pense comme un espace de droit, est une forteresse où le droit s'efface lorsque l'urgence politique s'impose. La question migratoire en témoigne : en 2024, la politique migratoire de l'Union a pris un tournant préoccupant, illustrant une stratégie de dissuasion brutale. Sous couvert de gestion des flux migratoires, le Pacte sur la migration et l'asile restreint l'accès à la protection internationale, facilite les décisions expéditives et accroît la détention aux frontières. Des notions juridiquement floues comme « afflux massif » permettent désormais de contourner le droit d'asile, au mépris des garanties fondamentales.

Il faut savoir que l'Union européenne externalise, par ailleurs, sa politique migratoire, déléguant à des pays tiers – Égypte, Mauritanie, Tunisie – le contrôle des frontières, au prix d'un silence coupable face aux violations graves et systématiques des droits humains dans ces zones.

Il faut rappeler les statistiques : plus de 2 000 personnes ont péri en mer en 2024. Face à cette hécatombe, la complaisance institutionnelle de l'Union interroge son engagement envers ses propres valeurs. L'Agence des droits fondamentaux et la Médiatrice européenne appellent à des mécanismes de contrôle plus robustes.

Il faut montrer que l'Europe a vu une progression de l'intolérance, alimentée par la montée de l'extrême droite et la banalisation de discours racistes et xénophobes : des rapports de l'Agence des droits fondamentaux montrent l'ampleur de l'antisémitisme et des discriminations subies par les musulmans, y compris des violences policières.

Il faut aussi insister sur l'augmentation, parmi les États membres, de la discrimination envers les personnes d'origine africaine, les migrants et les personnes LGBT, alimentée par la désinformation sur les réseaux sociaux (fake news). Sur le plan législatif, l'Union a adopté une directive sur la violence contre les femmes, sans toutefois inclure de définition du viol fondée sur le consentement ni interdire la stérilisation forcée, pourtant légale dans plusieurs États membres.

Il faut indiquer que la stratégie de la Commission pour 2024-2029 relègue les questions d'égalité à un portefeuille de gestion des crises, marquant un recul institutionnel majeur, d'autant plus qu'un rapport de la Commission en 2024 a révélé l'écart persistant entre les pensions de retraite des hommes et des femmes en 2022.

Il faut rappeler que malgré la création, en 2004, d'un poste de Commissaire à la démocratie, à la justice et à l'État de droit, les actions concrètes de l'Union demeurent insuffisantes : la Hongrie, toujours sous examen de l'article 7 pour des violations graves de l'État de droit, n'a, à l'heure actuelle, fait l'objet d'aucune sanction ; en Pologne, alors que les réformes nécessaires n'ont pas été mises en œuvre, la Commission a mis fin à la procédure de l'article 7.

Il faut souligner que, bien que le règlement sur l'IA adopté en juin 2024 constitue un progrès – avec l'interdiction de la notation sociale et les restrictions sur la surveillance biométrique –, l'Union a cédé aux pressions des entreprises en retirant son projet de directive sur la responsabilité, au moment même où les atteintes de l'IA aux droits fondamentaux (vie privée, protection des données, biais, discriminations) n'ont jamais été aussi préoccupantes.

En conclusion, il existe un puissant paradoxe. D'une part, l'Union européenne érige les droits fondamentaux en socle de légitimité. D'autre part, elle tolère, voire génère, des logiques sécuritaires, économiques ou politiques qui les érodent de l'intérieur. Ce décalage entre les principes proclamés et les réalités constatées (replis identitaires, dérives autoritaires et nouvelles technologies) entame la crédibilité du projet européen. L'Union doit, pour rester fidèle à ses valeurs, cesser de faire des droits humains une variable d'ajustement.

PARTIE IV. LES MÉCANISMES INTERNES DE PROTECTION

Fiche n°16

La protection par le juge constitutionnel

Fiche n°17

La protection par le juge judiciaire

Fiche n°18

La protection par le juge administratif

Fiche n°19

Les dérogations au principe de séparation des autorités

Fiche n°20

La protection administrative

Fiche nº 16 - LA PROTECTION PAR LE JUGE CONSTITUTIONNEL

POINTS CLÉS

- Contrôle de constitutionnalité des lois *a priori.*
- Contrôle de constitutionnalité des lois *a posteriori.*
- Réserves d'interprétation.
- Modulation des effets dans le temps.
- Retrait, abrogation.

PRINCIPALES RÉFÉRENCES

- Mathieu Disant, L'autorité de la chose interprétée par le Conseil constitutionnel, LGDJ, 2010.
- Louis Favoreu, *Le Conseil constitutionnel*, PUF, Que sais-je ?, 7e éd., 2005
- Karine Foucher (dir.), L'apport de la QPC à la protection des droits et libertés, Dalloz, 2010.
- Pierre Esplugas-Labatut, *Le Conseil constitutionnel*, Dalloz, 10e éd., 2023.
- Marc Guillaume, « Question prioritaire de constitutionnalité », Dalloz, Répertoire de contentieux administratif, avril 2022.
- *Le Conseil constitutionnel et le Parlement*, Les Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel, nº 38, janvier 2013.

1. L'instauration du Conseil constitutionnel

1.1. Les timides débuts du Conseil constitutionnel

L'instauration du Conseil constitutionnel français est l'aboutissement d'un long processus historique durant lequel la force de la tradition légicentriste a progressivement perdu en importance. Selon la tradition révolutionnaire et la théorie de Rousseau, la loi expression de la volonté générale ne peut pas mal faire.

Cette conception interdisait donc de soumettre la loi à un contrôle juridictionnel.

Lors des débats révolutionnaires, Sieyès avait proposé la mise en place d'un jury constitutionnaire. Cependant, cette proposition n'a jamais été adoptée.

Sous le Consulat et l'Empire, ce contrôle de constitutionnalité des lois était confié au Sénat et au Sénat conservateur. Néanmoins, du fait de la concentration des pouvoirs entre les mains des empereurs Napoléon puis Napoléon III, ce contrôle n'a jamais été effectif.

Les lois de la IIIe République ne mentionnent pas de contrôle de constitutionnalité des lois. Un Comité constitutionnel sera instauré sous la IVe République pour vérifier la conformité des lois à la Constitution. Cependant, le légicentrisme étant encore très ancré, en cas de non-conformité d'une loi à la Constitution, c'est cette dernière qui était révisée. Le Comité constitutionnel avait donc un rôle très restreint en la matière.

Le Conseil constitutionnel est instauré en 1958, sous la Ve République.

→ Titre VII de la Constitution de 1958 : « Le Conseil constitutionnel » (art. 56 à 63).

La volonté du constituant était de limiter et d'encadrer la place du Parlement français pour éviter les dérives parlementaires des IIIe et IVe Républiques.

Le contrôle de constitutionnalité mis en place en 1958 avait essentiellement pour but de s'assurer que le Parlement reste dans le domaine législatif prévu par l'article 34 de la Constitution sans venir empiéter sur le domaine réglementaire de l'article 37 de la Constitution.

Le Conseil constitutionnel n'a donc pas été instauré initialement dans le but de défendre et de faire respecter les droits et libertés du citoyen.

1.2. L'affirmation du rôle de garant des droits et libertés fondamentaux du Conseil

Le Conseil constitutionnel s'émancipera progressivement du rôle de « chien de garde de l'exécutif » pour devenir le garant des droits et libertés fondamentaux.

Cette affirmation prend notamment appui sur la décision liberté d'association dans laquelle le Conseil s'adosse au Préambule de la Constitution de 1946 et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République pour censurer une loi.

> → Cons. const., déc. n° 71-44 DC, 16 juillet 1971, *Loi complétant les dispositions des articles 5 et 7 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.*

Il en est de même avec la décision « Taxation d'office » confortant l'élargissement du bloc de constitutionnalité à la Déclaration des droits de l'homme et du Citoyen et donc à l'ensemble du préambule de la Constitution de 1958.

> → Cons. const., déc. n° 73-51 DC, 27 décembre 1973, *Taxation d'office.*

L'élargissement des autorités de saisine avec la révision constitutionnelle permettant à l'opposition parlementaire de déférer une loi au Conseil constitutionnel dans le cadre du contrôle *a priori* des lois a permis une augmentation du nombre de saisine et le développement de la jurisprudence constitutionnelle.

> → Loi constitutionnelle n° 74-904, promulguée le 29 octobre 1974.

La révision constitutionnelle de 2008 instaurant la QPC viendra parachever cette mutation.

> → Loi constitutionnelle n° 2008-724, 23 juillet 2008, *Loi de modernisation des institutions de la Ve République.*

POUR ALLER PLUS LOIN

Insuffisances du contrôle de constitutionnalité dans certains domaines :

- Refus de se prononcer sur le fait de savoir si une motion de censure déposée durant la période des pleins pouvoirs en application de l'article 16 de la Constitution était recevable.
- Refus de se prononcer sur la constitutionnalité des lois adoptées par référendum.
- Refus d'examiner la constitutionnalité d'une loi proposée à référendum.
- Refus de se prononcer sur les lois constitutionnelles adoptées par le Congrès.

1.3. Les compétences du Conseil constitutionnel

Les compétences du Conseil constitutionnel peuvent être regroupées en deux grandes catégories : les compétences consultatives et les compétences juridictionnelles.

1.3.1. Les compétences consultatives

Les compétences consultatives concernent principalement celles mises en œuvre sur le fondement de l'article 16 de la Constitution.

Le Gouvernement peut aussi consulter le Conseil constitutionnel pour l'organisation des élections du président de la République et lors de référendum.

Le Conseil constitutionnel peut proposer des mesures pour améliorer les élections parlementaires et présidentielles.

1.3.2. Les compétences juridictionnelles

a. Le contentieux électoral et référendaire

Pour les élections présidentielles, le Conseil peut être saisi des irrégularités lors des élections, il proclame les résultats et annonce le nouveau président.

→ Art. 59 de la Constitution.

Pour les élections des parlementaires, le Conseil constitutionnel est saisi des irrégularités et des fraudes et il peut invalider les élections de certains députés ou sénateurs.

→ Art. 59 de la Constitution.

Pour les référendums législatifs, le Conseil constitutionnel contrôle le projet de loi référendaire avant qu'il ne soit soumis au peuple.

→ Art. 11 de la Constitution.

→ Cons. const., déc. n° 2013-681 DC, 5 décembre 2013, *Loi portant application de l'article 11 de la Constitution.*

Pour les référendums constituants : refus du Conseil constitutionnel de contrôler le contenu de la loi référendaire révisant la Constitution. Le Conseil considère qu'il s'agit de l'expression directe de la volonté du peuple souverain. Il veille cependant à la régularité des opérations et proclame les résultats.

→ Art. 60 de la Constitution.

b. Le contentieux normatif

Le Conseil constitutionnel est l'unique organe en France chargé de contrôler la constitutionnalité des lois. Le contrôle est donc concentré.

→ Art. 61 et 61-1 de la Constitution.

2. Le contrôle de constitutionnalité des lois

2.1. Le contrôle a priori de constitutionnalité des lois

Le contrôle *a priori* des lois est prévu à l'article 61 de la Constitution :

- Saisine <u>obligatoire</u> : pour les lois organiques, les lois référendaires et les règlements des assemblées parlementaires.
- Saisine <u>facultative</u> : pour les lois ordinaires, les engagements internationaux, les lois du Pays adoptées par le congrès de la Nouvelle-Calédonie.

Le contrôle *a priori* des lois se fait sur saisine du Conseil constitutionnel par : le président de la République, le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, 60 députés ou 60 sénateurs depuis 1974.

→ Loi constitutionnelle n° 74-904, 29 octobre 1974.

2.2. Le contrôle a posteriori de constitutionnalité des lois

La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 a introduit la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) à l'article 61-1 de la Constitution :

« Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé […]. *»*

La question prioritaire reconnaît le droit à toute personne qui est partie à un procès de soutenir qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit.

La question peut être posée à tout moment de la procédure tant en première instance, qu'en appel ou en cassation. En matière criminelle, la question ne peut être posée que durant la phase d'instruction.

La question prioritaire de constitutionnalité est recevable devant toutes les juridictions de l'ordre administratif et de l'ordre judiciaire. Il y a une exception : on ne peut pas la poser de devant une cour d'assises.

Les conditions de forme : la question doit être soulevée par écrit. L'écrit doit être motivé et distinct des autres conclusions.

Les conditions de fond : la question doit remplir trois conditions cumulatives :

- L'applicabilité de la loi au litige : la disposition législative doit être applicable au litige ou à la procédure ou constituer le fondement des poursuites ;
- L'absence de déclaration préalable de conformité : la disposition législative ne doit pas avoir déjà été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel, que ce soit dans les motifs ou le dispositif d'une de ses décisions. Seul un changement de circonstances peut permettre de poser une QPC sur une disposition qui a déjà été déclarée conforme à la Constitution.
- Le caractère sérieux ou nouveau de la question : le juge de première instance ou d'appel examine si la question n'est pas dépourvue de caractère sérieux. Le mémoire de la QPC doit donc motiver en quoi la disposition législative méconnaît les droits ou libertés garantis par la Constitution, ou en quoi la question est nouvelle.

Quand le juge de première instance ou d'appel reçoit une QPC, il doit statuer sans délai. Si les conditions sont réunies, la QPC est transmise au Conseil d'État ou à la Cour de cassation.

Lorsqu'une QPC est posée devant la Cour de cassation ou le Conseil d'État, l'examen doit se faire dans un délai de 3 mois.

Si les conditions de la QPC sont réunies : elle est transmise au Conseil constitutionnel qui doit rendre sa décision dans un délai de 3 mois.

Les parties peuvent présenter des observations écrites et les avocats peuvent formuler des observations orales le jour de l'audience. La décision du Conseil constitutionnel est rendue publiquement soit :

- Le Conseil constitutionnel déclare la loi conforme à la Constitution : elle est maintenue, elle continue de s'appliquer. Toutefois, le Conseil constitutionnel peut apporter des précisions sur la façon d'appliquer la loi. L'affaire initiale peut reprendre son cours.
- Le Conseil constitutionnel déclare la loi contraire à la Constitution : la loi est abrogée. La suppression peut être immédiate ou reportée à une date ultérieure fixée par le Conseil constitutionnel. L'affaire initiale peut reprendre son cours, mais la loi déclarée contraire à la Constitution ne peut plus être appliquée.

Il est impossible de faire appel d'une décision du Conseil constitutionnel.

Caractères de la question prioritaire de constitutionnalité :

- La priorité s'envisage par rapport au contrôle de conventionnalité. Quand une juridiction est saisie de moyens contestant la conformité d'une disposition législative *« d'une part aux droits et libertés garantis par la Constitution et d'autre part aux engagements internationaux de la France,* [elle doit] *se prononcer par priorité sur la transmission de la question de constitutionnalité au Conseil d'État ou à la Cour de cassation ».*
- La publicité : L'article 8 du règlement intérieur sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel consacre le caractère public des audiences.
- Le respect du contradictoire : L'article 3 du règlement intérieur prévoit que les parties peuvent présenter des mémoires en réplique par voie électronique.

- L'impartialité de la procédure. Ce caractère impartial est inspiré de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. L'article 4 du règlement intérieur énonce ainsi que les membres du Conseil peuvent s'abstenir de siéger et que les parties peuvent demander la récusation d'un membre du Conseil.

Actualité jurisprudentielle. - La protection des mineurs ne justifie pas une interdiction générale d'accès aux réseaux sociaux

Le Conseil constitutionnel a censuré en août 2026 la disposition législative qui interdisait l'accès aux réseaux sociaux à l'ensemble des mineurs de moins de quinze ans.

Il reconnaît que la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant ainsi que la prévention des atteintes à l'ordre public peuvent justifier des restrictions à la liberté d'expression et de communication des mineurs. Ces restrictions doivent toutefois demeurer adaptées, nécessaires et proportionnées.

En l'espèce, l'interdiction concernait de manière générale un nombre très important de services de communication en ligne, sans distinction selon leurs fonctionnalités, leurs contenus ou les risques qu'ils présentent effectivement pour les mineurs. Elle s'appliquait également indistinctement à tous les mineurs de moins de quinze ans, sans tenir compte de leur âge, de leur degré de maturité, de leur situation familiale ou de la possibilité pour les titulaires de l'autorité parentale d'autoriser certains usages.

Le Conseil constitutionnel considère donc que cette interdiction générale portait une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression et de communication. Il relève également que le dispositif impliquait nécessairement un contrôle de l'âge de l'ensemble des utilisateurs, y compris majeurs, affectant ainsi le droit au respect de la vie privée.

→ Cons. const., déc. n° 2026-911 DC, 14 août 2026, *Loi visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux*.

À retenir. - La protection de l'enfance peut justifier une restriction importante de l'accès aux réseaux sociaux, mais le législateur doit prévoir un dispositif suffisamment ciblé et individualisé. Une interdiction générale et indifférenciée ne satisfait pas au contrôle de proportionnalité.

3. Les techniques de contrôle du Conseil constitutionnel

3.1. L'économie et la stratégie du contrôle

Malgré sa fonction de contrôle, le Conseil constitutionnel rappelle qu'il ne saurait se substituer au législateur et qu'il ne peut donc pas juger de l'opportunité politique d'une loi.

> → Cons. const., déc. n° 74-54, 15 janvier 1975, *Loi relative à l'interruption volontaire de grossesse* : *« Il ne dispose pas d'un pouvoir général d'appréciation et de décision identique à celui du Parlement. »*

Le Conseil constitutionnel se limite donc à un contrôle restreint, en particulier pour les domaines politiquement ou socialement sensibles. Il rappelle souvent qu'il ne lui appartient pas de rechercher si l'objectif poursuivi par le législateur aurait pu être atteint par d'autres voies que les dispositions de la loi soumise à son contrôle, tant que ces dernières ne sont pas manifestement disproportionnées à l'objectif visé.

Le Parlement dispose donc d'une liberté politique qui est encadrée et soumise au respect de la Constitution et de ses règles.

3.2. Les réserves d'interprétation

La technique des réserves d'interprétation permet au Conseil constitutionnel de faire œuvre de pédagogie auprès du législateur tout en évitant la confrontation avec celui-ci.

Tout comme les Cours allemande, italienne et espagnole, le Conseil constitutionnel utilise les réserves d'interprétations pour éviter de censurer les lois soumises à son contrôle.

Le Conseil constitutionnel estime que certaines dispositions sont conformes à la Constitution tout en les assortissant de réserves concernant l'interprétation et l'application qui en seront faites par les autorités publiques. Les dispositions de la loi sont donc conformes à la Constitution à la condition qu'elles soient appliquées de la manière précisée par le juge constitutionnel.

La loi est donc supposée constitutionnelle, et ce n'est qu'en cas de réelle contrariété avec la Constitution que le texte est censuré. Cette technique a été utilisée dès l'instauration du contrôle de constitutionnalité des lois en 1959.

> → Cons. const., n° 59-2 DC, 24 juin 1959, *Règlement de l'Assemblée nationale.*
>
> → Cons. const., n° 84-181 DC, 11 octobre 1984, *Loi visant à limiter la concentration et à assurer la transparence financière et le pluralisme des entreprises de presse.*
>
> → Cons. const., n° 2022-835 DC, 21 janvier 2022, *Loi renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le Code de la santé publique.*

Il existe différents types de réserves d'interprétation : le juge constitutionnel utilise différents types de réserves d'interprétation en fonction de l'objectif qu'il poursuit vis-à-vis du législateur et des autorités publiques :

- Réserves « neutralisantes » : il s'agit de priver d'effets juridiques les dispositions législatives litigieuses ou d'exclure les interprétations de la loi qui la rendraient contraires à la Constitution.
- Réserves « constructives » : il s'agit d'ajouter une interprétation pour que le texte soit conforme à la Constitution ou produise un certain effet juridique.
- Réserves « directives » : le juge précise et impose les modalités d'application de la loi pour que cette dernière soit constitutionnelle. Dans cette dernière hypothèse, la Cour de cassation et le Conseil d'État vont s'assurer que la loi est appliquée conformément à la réserve du Conseil constitutionnel.

3.3. Les décisions de non-conformité et de conformité partielle

Les interprétations données par le Conseil constitutionnel lui permettent tout de même de déclarer certaines dispositions contraires à la Constitution quand celle-ci est flagrante.

Désormais, le législateur étant sensibilisé au contrôle de constitutionnalité des lois, il existe peu de cas de censure totale d'une loi. Ces censures concernent de graves vices de procédure ou de graves motifs d'inconstitutionnalité.

Les décisions de non-conformité partielle sont plus nombreuses : il s'agit des cas où des mots ou des phrases de la loi sont considérés comme contraires ou non conformes à la Constitution. Le juge doit alors statuer sur la séparabilité ou non de ces dispositions avec l'ensemble de la loi en utilisant deux critères :

- Le juge évalue si la loi demeure applicable en ayant supprimé les dispositions invalidées.
- Le juge examine les débats législatifs afin de mesurer l'importance de ces dispositions, à savoir si sans ces dispositions la loi aurait tout de même été adoptée. Le juge apprécie ici l'intention du législateur et les conséquences politiques de sa décision et n'entre pas entièrement en conflit avec le législateur.

3.4. L'effet cliquet

Il s'agit d'une technique de contrôle du Conseil constitutionnel qui permet de sanctionner les modifications législatives qui remettraient en cause des acquis juridiques.

Deux conséquences principales :

- Cela entrave les revirements jurisprudentiels : pas de retour en arrière jurisprudentiel.
- Pas d'abrogation ou de modification par le législateur des dispositions législatives mettant en cause des droits fondamentaux : pas de retour en arrière législatif.

La première interdiction de retour en arrière législatif a été affirmée en 1984.

> → Cons. const., déc. n° 83-165 DC, 20 janvier 1984, *Loi relative à l'enseignement supérieur.*

Cette décision concernait les franchises universitaires et l'abrogation de la loi « Edgar Faure ». Le Conseil constitutionnel a jugé que l'abrogation de cette loi n'était pas conforme à la Constitution, car certaines dispositions de la précédente loi n'étaient pas remplacées par des garanties équivalentes dans la nouvelle loi.

Ainsi, une loi modifiant le régime juridique d'une liberté fondamentale ne peut le faire que de manière plus favorable.

> → Cons. const., déc. n° 93-325 DC, 13 août 1993, *Loi relative à la maîtrise de l'immigration et aux conditions d'entrée, d'accueil et de séjour des étrangers en France* : *« S'agissant d'un droit fondamental* […]*, la loi ne peut en réglementer les conditions qu'en vue de le rendre plus effectif ou de le concilier avec d'autres règles de principe de valeur constitutionnelle. »*

Cette technique a été confirmée et utilisée plusieurs fois pour la liberté de la presse et le droit à un logement décent.

> → Cons. const., déc. n° 86-210 DC, 29 juillet 1986, *Loi portant réforme juridique du régime de la presse.*
>
> → Cons. const., déc. n° 94-359 DC, *Loi relative à la diversité de l'habitat.*

Cependant, on considère désormais que cette technique a été abandonnée au cours des années 1990, le Conseil constitutionnel s'en étant lui-même délesté afin de ne pas ériger un mur constitutionnel infranchissable.

3.5. Les moyens et conclusions soulevés d'office

Les moyens et conclusions soulevés d'office sont deux techniques juridictionnelles utilisées par le Conseil constitutionnel très controversées qui lui permettent d'élargir son contrôle en matière de libertés et droits fondamentaux.

Les moyens soulevés d'office

Le juge constitutionnel requalifie un argument utilisé par le requérant ou il en découvre un totalement nouveau, de sa propre initiative.

> → Cons. const., déc. n° 84-181, 11 octobre 1984, *Loi visant à limiter la concentration et à assurer la transparence financière et le pluralisme des entreprises de presse* : il rejette le moyen fondé sur l'article 66 de la Constitution et la séparation des pouvoirs pour soulever le moyen tiré de l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen pour statuer sur la non-conformité de la loi.

Les conclusions soulevées d'office

Le Conseil relève une disposition de la loi déférée devant lui qui n'avait pas été soulevée par les requérants.

> → Cons. const., déc. n° 86-216, 3 septembre 1986, *Loi relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France* : la saisine portait sur l'article 5 de la loi et le Conseil a censuré l'article 15-11.

Pour aller plus loin – Le bloc de constitutionnalité est-il encore en construction ?

La construction du bloc de constitutionnalité ne s'est pas achevée avec la décision *Liberté d'association* de 1971. La jurisprudence contemporaine montre au contraire que le Conseil constitutionnel continue de dégager de nouvelles exigences constitutionnelles à partir des textes composant ce bloc.

Deux décisions permettent particulièrement de mesurer la technicité de cette construction prétorienne : la consécration du principe de fraternité dans la décision *Cédric H.* et l'identification, dans la décision *Société Air France*, du premier principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France.

Dans la décision Cédric H., le Conseil constitutionnel était saisi des dispositions réprimant l'aide apportée à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger. De façon inédite, il fonde sur l'article 2 de la Constitution, selon lequel la devise de la République est « *Liberté, Égalité, Fraternité* », ainsi que sur le Préambule et l'article 72-3 de la Constitution, pour reconnaître pour la première fois la fraternité comme principe à valeur

constitutionnelle. Il en déduit une nouvelle liberté : la liberté d'aider autrui, dans un but humanitaire, sans considération de la régularité de son séjour sur le territoire national (Cons. const., déc. n° 2018-717/718 QPC, 6 juillet 2018, *M. Cédric H. et autre*).

Cette décision illustre ainsi la capacité du Conseil à conférer une portée normative nouvelle à des dispositions constitutionnelles anciennes. La décision est particulièrement révélatrice de la construction jurisprudentielle des droits fondamentaux. Le Conseil constitutionnel ne crée pas un principe sans fondement textuel : il s'appuie sur plusieurs dispositions de la Constitution pour faire émerger une norme qui n'avait jamais été expressément consacrée comme telle. Le bloc de constitutionnalité apparaît ainsi comme un ensemble de normes dont la portée continue d'être précisée et enrichie par l'interprétation du juge constitutionnel.

Une autre évolution contemporaine concerne les rapports entre la Constitution et le droit de l'Union européenne. Le Conseil constitutionnel considère qu'il ne lui appartient, en principe, pas de contrôler la conformité à la Constitution de dispositions législatives qui se bornent à tirer les conséquences nécessaires de dispositions européennes précises et inconditionnelles. Cette limite connaît toutefois une exception lorsqu'est en cause une règle ou un principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France. Cette notion a reçu une première concrétisation dans la décision *Société Air France* : était en cause l'obligation imposée aux entreprises de transport aérien de réacheminer les étrangers auxquels l'entrée sur le territoire français avait été refusée. Le Conseil constitutionnel reconnaît alors, pour la première fois, comme principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France l'interdiction de déléguer à des personnes privées des compétences de police administrative générale inhérentes à l'exercice de la force publique (Cons. const., déc. n° 2021-940 QPC, 15 octobre 2021, *Société Air France*). Le Conseil juge néanmoins que ce principe n'est pas méconnu. Les compagnies aériennes sont seulement tenues de prendre en charge et de transporter les personnes concernées : elles ne disposent d'aucun pouvoir de surveillance ou de contrainte sur celles-ci.

La décision est néanmoins fondamentale puisqu'elle donne, pour la première fois, un contenu concret à la notion de principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France.

À retenir : Ces deux jurisprudences montrent que le bloc de constitutionnalité demeure un ensemble vivant. Dans la décision *Cédric H.*, le Conseil constitutionnel dégage de la devise républicaine le principe constitutionnel de fraternité, dont il déduit une liberté d'aide humanitaire. Dans la décision *Société Air France*, il identifie pour la première fois un principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France, susceptible d'être opposé à la mise en œuvre du droit de l'Union. Le Conseil constitutionnel ne se contente donc pas d'appliquer les droits expressément consacrés par les textes : il continue d'en préciser la portée et d'en dégager de nouvelles exigences pour répondre aux problématiques juridiques contemporaines

POUR S'ENTRAÎNER

Commentaire de texte : commentez les articles 61 et 61-1 de la Constitution de 1958.

L'une des majeures innovations de la Constitution de 1958 est de mettre en place le Conseil constitutionnel et un contrôle de constitutionnalité des lois. En effet, pendant très longtemps en France, le légicentrisme régnait en maître. La loi ne pouvant mal faire. Dès lors, tout contrôle de constitutionnalité était exclu. Quelques tentatives sont restées vaines, telles que le jury constitutionnaire de Sieyès ou le Comité constitutionnel de la IVe République.

Il faudra donc attendre 1958 et la Ve République pour qu'un réel juge constitutionnel soit instauré ainsi qu'un contrôle de constitutionnalité des lois en France. Nonobstant, il faudra attendre quelques décennies pour que le Conseil constitutionnel endosse son rôle de gardien des droits et libertés :

- Ce contrôle de constitutionnalité des lois était initialement pensé comme un garde-fou face au pouvoir législatif afin que ce dernier respecte son domaine d'attribution.
- Grâce à une jurisprudence audacieuse, le Conseil constitutionnel s'est érigé progressivement comme garant des droits et libertés que la Constitution garantit (Cons. const., déc. n° 71-44 DC, 16 juillet 1971, Liberté d'association : référence au Préambule de la Constitution de 1946 et aux principes fondamentaux reconnus par les lois de la République pour censurer la loi / *déc. n° 73-51 DC, 27 décembre 1973, Taxation d'office* : référence à la Déclaration des droits de l'homme).

Problématique : Tirant les enseignements des dérives des IIIe et IVe République, la nécessité d'instaurer un contrôle de constitutionnalité des lois s'est imposé sous la Ve République **(I)**, contrôle renforcé avec l'instauration de la question prioritaire de constitutionnalité **(II)**.

I. La reconnaissance d'un nécessaire contrôle de constitutionnalité des lois

A. La mise en place d'un contrôle *a priori* des lois

Article 56 de la Constitution : instauration du Conseil constitutionnel : neuf membres pour un mandat de 9 ans avec trois autorités de nomination (président de la République, président de l'Assemblée national et président du Sénat) avec un renouvellement par tiers tous les 3 ans.

Article 61 de la Constitution : création du contrôle *a priori* des lois, examen par le Conseil constitutionnel de la conformité des lois à la Constitution : saisine obligatoire du Conseil constitutionnel pour : les lois organiques, les lois référendaires et les règlements des assemblées parlementaires / saisine facultative : pour toutes les lois ordinaires.

Initialement : contrôle de constitutionnalité fait uniquement au regard du corps de la Constitution puis point de bascule avec la décision liberté d'association de 1971 et la création prétorienne du bloc de constitutionnalité permettant au Conseil constitutionnel d'élargir ses normes de référence lors de son contrôle.

B. L'élargissement des autorités de saisine

Initialement, seuls le président de la République, le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat pouvaient saisir le Conseil constitutionnel dans le cadre du contrôle a priori des lois.

Cette saisine restreinte par ces quatre autorités souvent du même parti ou bord politique pouvait conduire à ce que certaines lois issues de la majorité ne soient pas déférées devant le Conseil constitutionnel.

La loi constitutionnelle n° 74-904, promulguée le 29 octobre 1974, révise l'article 61 de la Constitution afin de permettre à l'opposition parlementaire, 60 députés ou 60 sénateurs de déférer une loi votée par le Parlement au Conseil constitutionnel avant sa promulgation par le président de la République.

Cependant, le caractère facultatif du contrôle des lois ordinaires permet à certaines lois inconstitutionnelles d'être promulguées.

II. Le renforcement du contrôle de constitutionnalité avec la question prioritaire de constitutionnalité

A. Les marques procédurales de la question prioritaire

Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République : article 61-1 de la Constitution.

Lors d'un procès, un citoyen peut contester une loi s'il estime qu'elle porte atteinte aux droits et libertés garanties par la Constitution, en posant une question prioritaire de constitutionnalité (QPC). Avant cette réforme, il n'était pas possible de contester la conformité constitutionnelle d'une loi déjà entrée en vigueur.

Loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution : fixe les règles procédurales de la QPC.

Trois conditions de fond de la QPC : l'applicabilité de la loi au litige, l'absence de déclaration préalable de conformité, le caractère sérieux ou nouveau de la question.

Double filtre : juge du fond puis saisine du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui transmettent (ou pas) au Conseil constitutionnel.

B. Les effets du contrôle de constitutionnalité des lois

Examen de la loi ou de la disposition de loi par le Conseil constitution au regard du bloc de constitutionnalité.

Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61 ne peut être promulguée ni mise en application. Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause. Possible modulation des effets dans le temps des décisions du Conseil constitutionnel.

Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.

En conclusion, le Conseil constitutionnel a indubitablement dépassé pleinement le carcan initial de « chien de garde de l'exécutif » pour s'ériger en protecteur des droits et libertés fondamentaux en s'appropriant pleinement le contrôle de constitutionnalité des lois au regard du bloc de constitutionnalité.

Fiche n° 17 – LA PROTECTION PAR LE JUGE JUDICIAIRE

POINTS CLÉS

- Un juge garant des libertés individuelles.
- Une exclusivité de compétence en matière de litiges interindividuels.
- La reconnaissance du plein effet direct des droits de la Convention EDH en droit interne.
- Un juge compétent pour la réalisation des contrôles de conventionnalité des lois au regard du droit international.

PRINCIPALES RÉFÉRENCES

- Cass. ass. plén., 15 avril 2011, n°s 10-17.049, 10-30.242, 10-30.313 et 10-30.316.
- Cass. mixte, 24 mai 1975, *Société des cafés Jacques Vabre*, n° 73-13.556.
- Cass. civ. 3e, 6 mars 1996, *Mel Yedei*, n° 93-11.113.
- Cass. civ. 1re, 4 décembre 2013, n° 12-26.066.

1. Le juge judiciaire, garant de la protection des droits humains sur le plan interne

En France, la protection des droits humains est assurée conjointement par le juge judiciaire et le juge administratif. Cette dualité des ordres de juridiction entraîne de fait une répartition des domaines de compétences entre eux.

La compétence du juge judiciaire se dédouble, car il peut être à la fois compétent pour traiter de litiges interindividuels, dits horizontaux, et de litiges verticaux mettant aux prises l'État et des particuliers.

S'il dispose d'une compétence exclusive pour traiter des litiges interindividuels au sein desquels seraient invoquées des atteintes aux droits humains commises par d'autres particuliers, sa compétence est partagée avec le juge administratif en cas de litiges verticaux.

L'autorité judiciaire est conçue au niveau national de manière large comme incluant les juges professionnels, qu'ils relèvent du siège ou du parquet.

> → Cons. const., déc. n° 2019-778 DC, 21 mars 2019, *Loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.*

Cette qualification est toutefois rejetée par la Cour européenne des droits de l'homme. Selon cette dernière, la qualité d'autorité judiciaire au sens de l'article 5 § 3 de la Convention exclut en effet que le magistrat *« puisse agir par la suite contre le requérant dans la procédure pénale, à l'instar du ministère public »*.

> → CEDH, GC., 29 mars 2010, *Medvedyev et a. c. France*, n° 3394/03.
>
> → CEDH, 23 novembre 2010, *Moulin c. France*, n° 37104/06.

1.1. La protection des libertés individuelles et du droit de propriété face à l'administration

Le juge judiciaire dispose d'une double compétence en cas de litige opposant des particuliers à l'administration. Il est en effet non seulement compétent pour assurer la protection des libertés individuelles, mais également pour assurer celle du droit de propriété.

1.1.1. La protection de la liberté individuelle

a. L'autorité judiciaire, garante de la protection de la liberté individuelle

L'article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958 prévoit que le juge judiciaire est le gardien exclusif des libertés individuelles.

> → Cons. const., déc., n° 76-75 DC,12 janvier 1977, *Loi autorisant la visite des véhicules en vue de la recherche et de la prévention des infractions pénales.*

Cet article permet donc de répartir les compétences des juridictions judiciaires et administratives.

La notion de liberté individuelle a cependant fait l'objet d'une appréciation changeante de la part du Conseil constitutionnel. Initialement, elle était envisagée de manière extensive par les Sages de la rue de Montpensier. La liberté individuelle comprenait alors le droit au respect de la vie privée et à l'inviolabilité du domicile.

> → Cons. const., déc., n° 76-75 DC,12 janvier 1977, *Loi autorisant la visite des véhicules en vue de la recherche et de la prévention des infractions pénales.*
>
> → Cons. const., déc. n° 83-164 DC, 29 décembre 1983, *Loi de finances pour 1984.*

Le juge constitutionnel a toutefois restreint de manière conséquente cette notion, devenant par conséquent synonyme de droit à la sûreté.

> → Cons. const., déc. n° 2005-532 DC, 19 janvier 2006, *Loi relative à la lutte contre le terrorisme.*

Le Conseil constitutionnel semble désormais estimer qu'une atteinte à la liberté individuelle pouvait survenir sans qu'il n'y ait nécessairement eu privation de liberté (par exemple en cas d'actes d'enquêtes), rendant de fait l'autorité judiciaire compétente afin d'en contrôler la légalité.

> → R. Parisot, *La jurisprudence constitutionnelle sur l'autorité judiciaire gardienne de la liberté individuelle*, Titre VII, n° 7, « La liberté individuelle », octobre 2021.

b. Une autorité de contrôle et de direction de la police judiciaire

L'article 66 de la Constitution, en tant que clause d'habeas corpus, rend compétente l'autorité judiciaire afin d'autoriser et de contrôler les arrestations et les actes d'enquête.

L'autorité judiciaire a ainsi pour mission de diriger, contrôler et surveiller les officiers et agents de police judiciaire et la légalité des actes pris par ces derniers. Seule la police judiciaire est cependant placée sous l'autorité directe du juge judiciaire, excluant de fait la police administrative, et les agents municipaux.

> → Cons. const., déc. n° 2021-817 DC, 20 mai 2021, *Loi pour une sécurité globale préservant les libertés*.

Si le pouvoir de direction est principalement exercé par le procureur de la République et exceptionnellement par le juge d'instruction (en cas d'information judiciaire), les pouvoirs de surveillance et de contrôle sont respectivement exercés par le procureur général et la chambre de l'instruction.

Le pouvoir de direction du procureur de la République permet à ce dernier de donner tous les ordres ou instructions aux officiers de police judiciaire afin que soient réalisés les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite d'infractions pénales (art. 41 du Code de procédure pénale).

Le pouvoir de surveillance s'exerce par le biais du pouvoir d'habilitation des officiers dont dispose le procureur général. Celui-ci pouvant intervenir avant l'habilitation et après celle-ci afin de la suspendre ou d'en décider le retrait.

Le contrôle de la police judiciaire est exercé quant à lui par la chambre de l'instruction (art. 13 du Code de procédure pénale) qui peut engager des poursuites à l'encontre d'un officier ou agent détenant les pouvoirs de police judiciaire en cas de faute de sa part.

c. Une autorité dotée d'une compétence exclusive pour le prononcé et le contrôle des peines privatives de liberté

L'article 66 de la Constitution confère *a fortiori* aux autorités judiciaires une compétence exclusive s'agissant des peines privatives de liberté. Cette dernière s'applique en cas de privation de liberté antérieure au jugement définitif.

→ L'article 133 du Code de procédure pénale prévoit par exemple l'obligation en cas de détention provisoire de présentation de l'individu à un magistrat dans les 24 heures suivant son arrestation.

→ Cons. const., déc. n° 2019-778 DC, 21 mars 2019, *Loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.*

Mais également sur le prononcé de la peine, et le contrôle de leur exécution. Ainsi, une loi qui ôterait au juge judiciaire le pouvoir de contrôler des mesures privatives de liberté, notamment sur sa faculté d'apprécier la justification de la remise en liberté, doit être censurée.

→ Cons. const., déc. n° 2008-562 DC, 21 février 2008, *Loi relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.*

Cette compétence exclusive se retrouve pour ce qui concerne les mandats de recherche, de comparution, d'amener, d'arrêt et de dépôt.

Les mandats étant des mesures de contrainte personnelle, ils ne peuvent être délivrés que par les autorités judiciaires (art. 122 et suiv. du Code de procédure pénale). Ces dernières disposent également d'une plénitude de compétence s'agissant du contrôle de leur légalité en vertu de l'article 136 du Code de procédure pénale.

Les mesures d'hospitalisation sans consentement et de rétention des étrangers constituent également des atteintes aux libertés individuelles placées sous le contrôle du juge judiciaire.

Ainsi, en cas de privation de liberté pour raison sanitaire, l'intervention d'un juge doit donc se faire dans le plus court délai possible.

→ Cons. const., déc. n° 2020-844 QPC, 19 juin 2020, *M. Éric G., Loi sur le contrôle des mesures d'isolement ou de contention dans le cadre des soins psychiatriques sans consentement.*

Le juge judiciaire, en l'occurrence le juge de la liberté et de la détention, demeure ainsi compétent de manière exclusive pour statuer sur la régularité de l'admission en soin psychiatrique sans consentement, mais également pour prononcer la mainlevée de la mesure ou son maintien (art. 3216-1 Code de la santé publique).

Le partage de compétence entre le juge judiciaire et le juge administratif se retrouve toutefois selon les griefs invoqués.

Les personnes détenues par l'effet d'une décision de l'autorité judiciaire, mais qui contesteraient leurs conditions de détention, pourront ainsi relever de la compétence du juge administratif à ce que le litige porte sur des actes ou agissements non détachables des services judiciaires.

→ Le juge administratif est cependant compétent lorsque la contestation ne porte pas sur la fonction juridictionnelle, mais sur l'organisation de la justice (T. confl., 27 novembre 1952, *préfet de la Guyane*, n° 01420).

1.1.2. La protection en cas de voie de fait

La notion de voie de fait a été développée par le juge face au constat que les procédures administratives étaient inadaptées afin de traiter rapidement les atteintes ou les risques d'atteintes aux droits humains. Comparativement, la compétence du juge judiciaire présentait de nombreux atouts lui permettant d'agir promptement contre de telles atteintes (la célérité de la procédure de référé judiciaire ainsi que la compétence de ce juge pour prononcer des mesures d'injonction, d'astreinte et de réparation du préjudice).

→ T. confl., 8 avril 1935, *Action française*, n° 00822.

La voie de fait a ainsi été conçue comme conférant un titre de compétence au juge judiciaire. L'acception retenue par les juridictions de cette notion a toutefois connu une évolution importante.

La voie de fait était initialement caractérisée par deux versants. Le premier visait l'atteinte grave au droit de propriété ou à une liberté fondamentale causée par l'exécution forcée irrégulière d'une décision régulière de l'administration, tandis que le second concernait les décisions prises par cette dernière alors qu'elles étaient manifestement insusceptibles de relever d'un pouvoir de l'autorité administrative.

La création du référé-liberté par la loi du 30 juin 2000 a toutefois considérablement réduit l'utilité du recours au juge judiciaire. Cette procédure permet désormais au juge administratif, sous condition d'urgence, d'ordonner toute mesure nécessaire à la sauvegarde d'une liberté fondamentale.

La compétence du juge judiciaire n'a eu de cesse de se restreindre en matière de voie de fait. D'abord par l'interprétation restrictive des conditions posées en 1935 par le tribunal des conflits, puis par la redéfinition des critères de la voie de fait.

Le juge judiciaire n'est désormais plus compétent qu'en cas d'atteinte à la liberté individuelle (et non plus en cas d'atteinte à un droit fondamental comme auparavant) ou en cas d'extinction du droit de propriété (et non plus d'atteinte grave).

→ T. confl., 17 juin 2013, *Bergoend c. Société ERDF Annecy Léman*, n° C3911.

→ Cass. civ. 1re, 5 février 2020, n° 19-11.864.

→ Cass. ass. plén., 28 juin 2019, n° 19-17.330.

1.1.3. La protection contre les atteintes au droit de propriété portées par l'administration

Le juge judiciaire de première instance est compétent pour traiter des expropriations pour cause d'utilité publique. Il opère le transfert de la propriété du bien du propriétaire à l'autorité publique par l'ordonnance d'expropriation et fixe ensuite le montant de l'indemnisation à verser ou à consigner en cas d'absence d'accord amiable des parties.

S'agissant de l'emprise, le juge judiciaire n'avait compétence que pour l'indemnisation de l'emprise préalablement reconnue comme étant irrégulière par le juge administratif (une atteinte irrégulière à la propriété immobilière imputable à l'administration entraînant une dépossession).

Cette notion qui vise la dépossession irrégulière par une personne publique d'une propriété immobilière privée a également fait l'objet d'un rétrécissement du domaine de compétence alloué au juge judiciaire. Celui-ci n'est désormais plus compétent que pour octroyer une indemnisation en cas d'extinction du droit de propriété.

→ T. confl., 9 décembre 2013, *M. et Mme Panizzon c. Commune de Saint-Palais*, n° 3931.

1.2. La protection des droits humains par le juge judiciaire dans le cadre de litiges interindividuels

1.2.1. La protection des droits humains par l'application des normes afférant

Le juge judiciaire dispose d'une exclusivité de compétence dans le cadre de litiges interindividuels. Il est ainsi amené à trancher des litiges portant sur, ou ayant un lien, avec les droits humains.

Pour ce faire, le juge peut mobiliser une multiplicité de normes, qu'elles soient de rang constitutionnel ou législatif. Plusieurs séries de dispositions du Code civil permettent, par exemple, au juge judiciaire de protéger les droits humains, tels que le droit au respect de la vie privée (art. 9 du Code civil), ou des articles 16 et suivants du Code civil relatifs à la dignité de la personne et au respect du corps humain.

→ Cass. soc., 8 juillet 2009, *Okaïdi*, n° 09-60.011, 09-60.031 et 09-60.032 : L'adhésion d'un salarié à un syndicat relève de sa vie personnelle et ne peut être révélée sans son accord. La Cour mobilise au sein des visas de l'arrêt, l'alinéa 6 du préambule de la Constitution de 1946, l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme, et l'article 9 du Code civil.

Le juge judiciaire est donc amené à protéger les droits humains des requérants au sein d'un très grand nombre de domaines, que ce soit dans le cadre de litiges prud'homaux, en matière de responsabilité délictuelle ou encore dans le cadre de relations contractuelles.

Plusieurs dispositions lui permettent ainsi concrètement de protéger les droits humains des parties au litige sans pour autant qu'elles ne portent explicitement sur ces derniers.

Parmi ces dernières, l'ordre public demeure une notion centrale en ce qu'elle peut s'appliquer à tous les domaines juridiques. Cette notion vise des dispositions obligatoires auxquelles il n'est pas possible de déroger même par voie de convention.

L'ordre public contractuel a été renforcé en matière de protection des droits humains. Cette notion a été en effet largement influencée par les traités internationaux en matière de droits humains, au point de sembler désormais les sous-entendre.

L'article 6 du Code civil ainsi que les articles 1102 et 1162 du Code civil relatifs à l'ordre public en matière contractuelle ne mentionnent pas la notion de droits humains, mais ces derniers ne semblent cependant pas être sans effets sur le contrat. Les clauses contractuelles causant des atteintes injustifiées à ces droits peuvent être neutralisées par le juge.

→ Cass. civ. 3e, 22 mars 2006, no 04-19.349.

Leur régime respectif est toutefois différent. L'atteinte à l'ordre public entraîne par principe la disparition de la convention contraire, alors que l'atteinte aux droits fondamentaux n'entraîne une telle sanction qu'en cas d'atteinte injustifiée.

La méconnaissance de l'ordre public et ou d'atteintes illégales aux droits de la personne auront cependant des conséquences similaires.

Cette influence croissante des droits humains sur l'ordre public se retrouve tout particulièrement pour ce qui concerne la notion d'ordre public international dans le cadre de litiges en droit international privé.

L'utilisation de l'ordre public international permet au juge du for d'écarter la loi ayant été désignée par la règle de conflit, car son résultat serait inconciliable avec les normes fondamentales de l'ordre juridique du for. Cette notion, dans le cadre d'une demande d'exequatur, permet également au juge du for de ne pas conférer de force exécutoire à une décision étrangère qui porterait gravement atteintes aux normes fondamentales de son ordre juridique.

Bien que cette notion d'ordre public international soit plus restreinte que celle de l'ordre public de l'article 6 du Code civil, elle comprend néanmoins en son sein les stipulations de la Convention européenne. L'application de l'ordre public international permet donc au juge de confronter la solution notamment au regard de la Convention européenne des droits de l'homme et donc d'assurer une protection des droits des parties au litige.

→ Cass. civ. 1re, 14 novembre 2024, no 23-50.016.

→ Ainsi, le juge de l'exequatur doit vérifier d'office que la décision étrangère ne contrevient pas à l'ordre public international français qui comprend notamment les stipulations de la Convention EDH : Cass. civ. 1re, 15 janvier 2020, no 18-24.261.

→ Cass. civ. 1re, 2 octobre 2024, no 22-20.883 : concernant la demande d'exéquatur d'un jugement étranger établissant la filiation d'un enfant né de GPA à l'étranger avec la mère d'intention, la Cour cite la Convention européenne des droits de l'homme et le paragraphe 9 de Convention de New York de 1989.

1.2.2. La transposition du contrôle de proportionnalité

Le contrôle de proportionnalité permet également au juge d'assurer la protection des droits humains. Ce contrôle dispose d'une dualité de sources.

Il peut tout d'abord être exigé par la loi. Le juge a alors l'obligation de réaliser ce contrôle en cas d'applicabilité de la disposition le prévoyant.

L'article L. 1121-1 du Code du travail (anciennement L. 120-2) impose par exemple qu'un rapport de proportionnalité soit établi dans les limites apportées aux droits des salariés et qu'elles poursuivent un but légitime. Lorsque le juge applique cette disposition il doit alors mettre en balance les intérêts de l'employeur et du salarié.

→ Cass. soc., 25 septembre 2024, n° 23-13.992 : L'utilisation par l'employeur d'une clé USB personnelle appartenant au salarié, non-branchée à son ordinateur professionnel, pour y consulter des fichiers constitue une atteinte à sa vie privée, mais doit être mise en balance avec un droit concurrent, le droit à la preuve de l'employeur.

→ Cass. ass. plén., 25 juin 2014, *Baby-Loup*, n° 13-28.369 : Le licenciement d'une salariée pour avoir refusé de se conformer aux demandes de son employeur lui demandant de ne pas porter de voile au travail n'emporte pas d'atteinte disproportionnée à sa liberté religieuse.

Depuis 2013, la Cour de cassation peut également réaliser un contrôle de proportionnalité *in concreto* et ce, sans que la loi ne lui ait imposé de le faire. Ce dernier a ainsi conduit la Cour à refuser d'appliquer une loi au motif que son application aurait eu pour effet de causer une ingérence injustifiée dans les droits de l'une des parties au litige au sens de l'article 8 de la Convention européenne.

→ Cass. civ. 1re, 4 décembre 2013, n° 12-26.066.

Ce contrôle est également qualifié de contrôle de conventionnalité *in concreto* puisqu'il permet au juge, après avoir examiné les particularités de la cause, d'écarter l'application de la loi nationale qui serait conforme aux droits humains, mais qui concrètement y porterait atteinte.

La réalisation de ce contrôle par la Cour n'a pas été exempte de critiques. Certains observateurs ont pu craindre un risque d'insécurité juridique puisque la mise à l'écart d'une disposition législative demeurerait imprévisible, car largement conditionnée par les faits de l'espèce.

En effet, si dans le cadre d'un contrôle classique de conventionnalité *in abstracto* la loi est en soi déclarée comme non conforme au droit international, entraînant généralement son abrogation par la suite par le législateur. Il en va différemment s'agissant du contrôle *in concreto*.

L'application de ce principe peut conduire à la mise à l'écart de l'application de la loi nationale dans certaines espèces et son application dans d'autres, la loi étant conforme au droit international. L'intensité du contrôle sera en outre susceptible de varier en fonction des droits en cause. Celui-ci pourra être étendu ou restreint.

Actualité jurisprudentielle. - Le juge judiciaire, arbitre des droits fondamentaux concurrents

La jurisprudence récente confirme la place croissante du contrôle de proportionnalité dans l'office du juge judiciaire. Il ne s'agit plus seulement de déterminer si un droit fondamental a été méconnu, mais de rechercher comment assurer la conciliation de plusieurs droits ou intérêts protégés qui entrent en concurrence.

Cette évolution apparaît particulièrement en matière de droit à la preuve. Dans un arrêt du 3 octobre 2024, la Cour de cassation a précisé les conditions dans lesquelles un salarié invoquant une discrimination peut obtenir la communication de documents concernant d'autres salariés, alors même que ceux-ci contiennent des données à caractère personnel. La protection de la vie privée et des données personnelles ne fait donc pas nécessairement obstacle au droit à la preuve. Le juge doit rechercher si la communication demandée est indispensable à l'exercice de ce droit et proportionnée au but poursuivi, puis limiter, si nécessaire, les informations communiquées conformément au principe de minimisation des données résultant du RGPD (Cass. 2e civ., 3 octobre 2024, n° 21-20.979).

Cette construction a été confirmée et précisée par la chambre sociale dans une décision du 18 juin 2025. Une salariée qui estimait subir une discrimination liée à son sexe et à ses origines sollicitait la communication des contrats, avenants, bulletins de salaire et éléments de carrière de plusieurs salariés auxquels elle entendait comparer sa situation. La Cour de cassation admet une telle communication dès lors qu'elle est nécessaire au droit à la preuve et proportionnée au but poursuivi. Elle impose toutefois au juge de cantonner, au besoin d'office, le périmètre des pièces communiquées et d'occulter toutes les données personnelles qui ne sont pas indispensables à la comparaison. Les parties doivent en outre être tenues de n'utiliser ces informations qu'aux seules fins de l'action en discrimination (Cass. soc., 18 juin 2025, n° 23-23.471).

Le contrôle de proportionnalité prend ainsi une dimension particulièrement concrète. Le juge ne choisit pas nécessairement entre le droit à la preuve et le droit au respect de la vie privée : il recherche les modalités permettant de préserver simultanément l'effectivité de chacun de ces droits, notamment par la limitation du nombre de documents communiqués, l'occultation des informations inutiles ou la restriction de leur utilisation.

À retenir : Le contrôle de proportionnalité transforme progressivement l'office du juge judiciaire. Face à deux droits fondamentaux concurrents, celui-ci ne raisonne plus nécessairement selon une logique d'exclusion de l'un au profit de l'autre. Il recherche une conciliation concrète permettant de préserver autant que possible l'effectivité de chacun d'eux

2. L'internationalisation des fondements de la protection des droits humains utilisés par le juge judiciaire

2.1. La primauté du droit international des droits humains

Certains traités de droit international prévoient un principe de primauté, tels que le droit de l'Union européenne ou la Convention EDH, selon lequel en cas de normes contradictoires, la norme supérieure devra être appliquée à la place de celle de rang inférieur.

En France, l'article 55 de la Constitution prévoit que la primauté des traités et conventions internationales leur confère une autorité supra-législative, mais infra-constitutionnelle.

L'effectivité de ce principe de primauté est ainsi assurée non seulement par la réalisation d'un contrôle de conventionnalité, qu'il soit concret ou abstrait, et par l'effet direct des normes internationales.

2.1.1. Le contrôle de conventionnalité des lois et des dispositions internes

Le juge ordinaire s'est longtemps refusé à contrôler la conformité du droit interne aux traités et Conventions internationaux. Le point de bascule s'est toutefois opéré en 1975 après que le Conseil constitutionnel se soit reconnu incompétent pour contrôler la conformité des dispositions internes au droit international.

→ Cons. const., déc. n° 74-54 DC, 15 janvier 1975, *Loi relative à l'interruption volontaire de la grossesse*.

En réaction, et ce dès 1975, le juge judiciaire va alors affirmer sa compétence pour réaliser un contrôle de conventionnalité aboutissant à la mise à l'écart d'une disposition législative contraire au droit international adoptée postérieurement à la ratification du traité.

→ Cass. mixte, 24 mai 1975, *Société des cafés Jacques Vabre*, n° 73-13.556.

Le Conseil constitutionnel a par la suite souligné son incompétence en la matière et a, *a contrario*, réaffirmé la compétence du juge ordinaire.

→ Cons. const., déc. n° 86-216 DC, 3 septembre 1986, *Loi relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France*.

La mise en œuvre de ce contrôle abstrait de conventionnalité a pour effet d'assurer en droit interne l'application du principe de primauté du droit international. Toute disposition applicable à un litige, adoptée antérieurement ou postérieurement à la ratification d'un traité international et contraire à celui-ci doit être écartée par le juge ordinaire.

Ce mécanisme permet d'assurer la protection effective des droits humains au plan interne notamment lorsque la disposition interne s'avère contraire à une norme issue d'un traité international portant sur la protection de ces droits.

Le juge judiciaire ne restreint pas son contrôle de conventionnalité aux seules règles formelles du droit international, il prend également en considération l'interprétation donnée par les interprètes officiels de ces textes.

→ Cass. ass. plén., 15 avril 2011, n °s10-17.049, 10-30.242, 10-30.313 et 10-30.316.

2.1.2. Le plein effet direct des normes de droit international en droit interne

La tradition moniste de l'ordre juridique français (art. 55 de la Constitution) permet au juge national d'appliquer directement, mais sous certaines conditions, des stipulations issues du droit international.

L'effet direct comporte deux aspects. L'effet direct vertical permet tout d'abord aux justiciables d'invoquer une norme issue du droit international dans le cadre de litiges les opposant à l'État, tandis que l'effet direct horizontal, ou plein effet direct, permet également d'invoquer ces normes dans le cadre de litiges interindividuels.

Pour que les normes internationales en matière de droits humains jouissent d'un tel effet, il est cependant nécessaire qu'elles soient claires, qu'elles prévoient des droits inconditionnels et qu'elles ne requièrent pas de transposition en droit interne.

Le juge français a ainsi reconnu un effet direct à la Convention européenne des droits de l'homme, non seulement dans le cadre de litiges opposant un particulier à l'État, mais également au sein de relations interindividuelles.

> → Cass. crim, 3 juin 1975, *Respino*, n° 75-90.687.
>
> → Pour une application horizontale directe dans le cadre de relations contractuelles voir Cass. civ. 3e, 6 mars 1996, *Mel Yedei*, n° 93-11.113. Voir également Cass. soc., 14 janvier 2014, n° 12-27.284.

Le juge judiciaire peut également soulever d'office un moyen tiré de ce texte sans que les parties au litige ne l'aient invoqué.

> → Cass. civ. 1re, 9 juin 2017, n° 16-12.457.

2.2. La prise en compte de normes issues du droit international

Toutes les normes de droit international ne sont pas pourvues d'effet direct.

> → Concernant l'absence d'effet direct des recommandations du Comité des ministres du Conseil de l'Europe, voir Cass. civ. 1re, 21 décembre 1987, n° 86-12.888.

Si la norme issue du droit international n'est pas pourvue d'effet direct, cela ne la prive pas pour autant de produire des effets sur l'issue du litige. Le juge judiciaire peut en effet prendre en considération cette norme en tant qu'élément de fait de nature à influencer sa décision.

> → Cass. civ. 1re, 26 avril 2006, n° 02-17.344.

Un traité international portant sur les droits humains peut également disposer de normes qui sont dotées d'effet direct en droit interne et d'autres qui en sont dépourvues.

> → Sur la Convention internationale des droits de l'enfant : Cass. civ. 1re, 17 mars 2010, n° 08-14.619.

En outre, avant que les arrêts de l'Assemblée plénière du 15 avril 2011 n'affirment la force interprétative des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme, la Cour de cassation avait déjà pris en considération les jurisprudences de la Cour européenne des droits de l'homme au sein d'arrêts visant d'autres États signataires que la France.

> → Avec une référence à l'arrêt *Le Compte, van Leuven de Meyere c. Belgique* : Cass. civ. 1re, 10 janvier 1984, *Renneman*, n° 82-16.968.

3. Le rôle de filtre dans la transmission de questions en rapport avec les droits humains auprès d'organes juridictionnels tiers

3.1. La transmission de questions prioritaires de constitutionnalité au Conseil constitutionnel

La réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008 a introduit, en plus du contrôle a priori, un contrôle de constitutionnalité a posteriori au sein de l'article 61-1 de la Constitution. Ces contrôles sont primordiaux en ce qu'ils permettent de s'assurer du respect par la loi des droits et libertés contenus dans la Constitution.

Ce contrôle est intéressant du point de vue des droits humains puisqu'il permet à des requérants d'invoquer la contrariété à la constitution d'une disposition applicable à leur litige. La question transmise à la Cour de cassation ou formée devant elle doit cependant être renvoyée par cette dernière au Conseil constitutionnel.

Cette dernière dispose donc d'un pouvoir de filtrage sur les questions prioritaires de constitutionnalité qui lui sont adressées. Elle semble toutefois dépasser ce seul rôle d'intermédiaire avant la saisine du Conseil constitutionnel.

Afin d'exercer cette mission, la Cour va ainsi analyser si les trois critères cumulatifs exigés pour qu'une question soit transmise au Conseil des sages sont remplis :

- La question est applicable au litige en cause ;
- Le caractère nouveau de la question (la Cour peut prendre en compte un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme afin d'estimer que le caractère nouveau causé par un changement de circonstance est rempli : Cass. crim., 20 août 2014, n° 14-80-394).
- Le caractère sérieux de la question. La Cour dispose d'une véritable marge d'appréciation dans l'interprétation de ce dernier critère. Elle ne reste pas neutre et ne se contente pas de simplement transmettre la question au Conseil constitutionnel. Elle opère généralement une interprétation de la Constitution afin de déterminer l'intérêt de la question et la vraisemblance de l'atteinte aux droits et libertés garantis. Le juge judiciaire va ainsi motiver sa décision sur la constitutionnalité de la loi afin de déterminer le sérieux de la question posée.

  → Cass. crim., 20 août 2014, n° 14-80.394 et Cass. crim., 27 mars 2018, n° 17-84.509 (absence de caractère sérieux).

Ce faisant, la Cour de cassation a parfois pu apparaître comme un *« juge constitutionnel de droit commun »*

→ J. Bonnet et A. Roblot-Troizier, Les juges ordinaires, juges constitutionnels de droit commun ?, in *La QPC, vers une reconfiguration de l'architecture juridictionnelle*, PUAM, 2020, p. 15.

De même, afin de refuser le renvoi d'une question, la Cour de cassation met parfois en avant l'interprétation qu'elle retient d'une loi afin de justifier de l'absence d'atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution.

→ Cass. civ. 2e, 27 avril 2017, n° 17-40.027.

Le contrôle exercé sur le sérieux de la question l'a également conduit parfois à modifier sa jurisprudence afin de se conformer aux droits et libertés contenus au sein de la constitution.

→ Cass. civ. 3e, 13 février 2014, n° 13-22.383.

POUR ALLER PLUS LOIN

La Cour de cassation exerce une réelle mission de filtrage dans la transmission des questions au Conseil constitutionnel. Sur la période 2019-2023, la Cour a enregistré une moyenne 16,3 % de questions transmises (rapport annuel 2023 de la Cour de cassation).

3.2. La procédure d'avis consultatif auprès de la Cour européenne des droits de l'homme

L'entrée en vigueur du Protocole 16 le 1er aout 2018 à la suite de la ratification du protocole par la France a introduit le mécanisme d'avis consultatif auprès de la Cour européenne des droits de l'homme.

Cette procédure permet aux hautes juridictions des États contractants d'adresser une question pour avis à la Cour européenne des droits de l'homme à propos de questions de principes sur l'interprétation ou l'application des droits garantis par la Convention.

La France, par le biais de la Cour de cassation, a été le premier État du Conseil de l'Europe à avoir recours à cette procédure le 5 octobre 2018 en posant une question relative à la transcription d'actes de naissance en cas de gestation pour autrui.

→ Cass. ass. plén., 5 octobre 2018, n° 10-19.053.

La Cour de cassation n'est pas liée par les demandes d'avis formulées par les parties. Elle peut ainsi tout à fait rejeter cette demande et avoir à la place recours à un contrôle de proportionnalité *in concreto* conduisant à la mise à l'écart de la disposition interne litigieuse.

→ Cass. civ. 1re, 27 janvier 2021, n° 19-15.921.

Cette procédure permet de renforcer le dialogue entre les juges strasbourgeois et les juges de la Cour de cassation qui vont surseoir à statuer le temps que l'avis soit rendu par la Cour européenne des droits de l'homme. Ces avis

ne sont certes pas contraignants, mais ils peuvent cependant être mobilisés par le juge judiciaire afin de renforcer l'autorité de sa décision en citant l'avis consultatif au sein de ses visas ou de ses motifs.

→ Cass. ass. plén., 4 octobre 2019, n°s 10-19.053 et 12-30.138.

→ Cass. civ. 1re, 14 novembre 2024, n° 23-50.016.

POUR S'ENTRAÎNER

Argumentaire juridique : Soutenez que les contrôles de conventionnalité sont nécessaires afin d'assurer le respect des droits humains.

Les traités et conventions internationales disposent, en vertu de l'article 55 de la Constitution, d'une valeur infra-constitutionnelle, mais supra-législative. Les textes internationaux disposent également en vertu de ce texte d'un principe de primauté selon lequel en cas de norme contraire inférieure au texte de droit international, celle de rang inférieur devrait être écartée.

Ces principes répondent tout à la fois à un souci de cohérence des ordres juridiques nationaux internationaux et d'effectivité des normes internationales. L'un des principaux moyens pour que la Convention EDH soit appliquée au niveau national est, en effet, que le juge interne se fonde directement sur cette norme dans le cadre des litiges qu'il a à trancher.

Selon le principe de subsidiarité, il revient en premier lieu aux États parties d'appliquer la Convention. Le juge européen n'interviendra ainsi qu'en ultime recours lorsque les juridictions nationales n'auront pas été en mesure d'assurer le respect de la Convention.

Afin d'assurer la primauté du droit international, plusieurs notions peuvent être utilisées par le juge : l'effet direct du droit international et le contrôle de conventionnalité. Pour que le principe de primauté s'applique, les normes doivent cependant avoir le même champ d'application matériel. Cela suppose en outre qu'un juge soit en mesure d'analyser la conformité des premières aux secondes. En France, les juges ordinaires exercent ces missions depuis que le Conseil constitutionnel a expressément exclu sa compétence (Cons. const., déc., n° 74-54 DC, 15 janvier 1975, *Loi relative à l'interruption volontaire de la grossesse*). Son incompétence en la matière a laissé le champ libre aux juridictions administrative ou judiciaire. Ainsi, toutes les juridictions ordinaires sont compétentes pour mener ce contrôle de conventionnalité (Cass. com., 20 octobre 1998, n° 96-19.277).

Le contrôle de conventionnalité a progressivement évolué, il vise désormais une dualité de contrôle, un contrôle concret de conventionnalité dit « contrôle de proportionnalité », venant compléter le contrôle abstrait de conventionnalité réalisé depuis 1975.

Problématique et annonce du plan : Le contrôle de conventionnalité permet tout à la fois de mettre à l'écart une loi nationale contraire au droit international par le biais d'un contrôle abstrait **(I)**, qu'une loi conforme à ce texte, mais dont l'application aurait concrètement pour effet d'y porter atteinte **(II)**.

I. La mise à l'écart d'une loi contraire à la Convention par le contrôle abstrait de conventionnalité

A. L'appréciation abstraite d'une situation de non-conformité

Le juge judiciaire accepte depuis 1975 de contrôler la conformité d'une disposition nationale au droit international et ce, qu'elle soit antérieure ou postérieure à la signature du traité (Cass. mixte, 24 mai 1975, *Société des cafés Jacques Vabre*, n° 73-13.556).

La mise en œuvre du contrôle de conventionnalité abstrait conduit le juge interne à comparer la norme nationale à celle issue du droit international et d'apprécier si la première offre des garanties conformes à la seconde. Lorsque la norme interne de rang inférieur s'avère être non conforme à celle issue de l'ordre international, il devra alors appliquer la seconde.

La réalisation de ce contrôle suppose donc que les normes internationales soient dotées d'effet direct en droit interne, ce qui n'est pas le cas de l'article 24 de la Charte sociale européenne. (Cass. ass. plén., avis, 17 juillet 2019, n° 19-70.010).

Le contrôle est possible même lorsque la loi contrôlée a déjà été déclarée conforme à la Constitution.

Les juges du fond peuvent également avoir recours à la procédure d'avis auprès de la Cour de cassation pour avoir sa position à propos de la conventionnalité d'une disposition applicable à un litige en cours au regard du droit international (Cass. ass. plén., avis, 17 juillet 2019, n° 19-70.010).

Afin d'apprécier la conventionnalité d'une norme interne, le juge doit également prendre en considération la portée de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (Cass. ass. plén., 15 avril 2011, n°s 10-17.049, 10-30.242, 10-30.313 et 10-30.316).

B. La mise à l'écart de la norme non-conforme

En cas de constat de non-conformité au regard du droit international, plusieurs solutions seront possibles afin d'assurer la primauté du droit international. Le juge pourra ainsi opter pour un revirement de jurisprudence si la non-conformité était causée par l'interprétation de la norme interne. La disposition en cause pourra alors être maintenue au sein de l'ordre juridique.

Au contraire, lorsque la non-conformité est issue du texte, la disposition sera écartée par le juge pour les litiges au sein desquels elle aurait été normalement applicable dans le but d'assurer le respect du droit international.

Lorsque le contrôle de conventionnalité aboutit à un constat de non-conformité, la norme ne disparaît toutefois pas de plein droit de l'ordre juridique, elle sera déclarée inapplicable par les juges. En pratique, ce constat va entraîner son abrogation par le législateur.

II. La mise à l'écart d'une loi conforme à la Convention par le contrôle concret de conventionnalité

A. L'appréciation concrète de la conformité à la Convention

Depuis 2013 (Cass. civ. 1re, 4 décembre 2013, n° 12-26.066), la Cour de cassation admet la mise en œuvre d'un autre type de contrôle de conventionnalité : le contrôle concret, dit de « proportionnalité ».

La mise en œuvre du contrôle de proportionnalité n'est pas nouvelle, cette méthode était déjà utilisée par la Cour de cassation, notamment en cas de conflit de droits.

Ce contrôle est toutefois innovant, car la Cour mène un contrôle concret de conformité de la solution obtenue par l'application de la loi interne au droit international.

Ce contrôle, qui avait initialement été utilisé dans le domaine du droit de la famille (Cass. civ 1re, 14 novembre 2024, n° 23-50.016), semble désormais avoir été étendu à d'autres domaines juridiques, tels que le droit du travail (Cass. soc., 11 mai 2022, 21-14.490).

Lorsque le juge met en œuvre ce contrôle, il prend en considération les conséquences concrètes que pourraient avoir l'application de la disposition interne au regard des parties au litige et non de manière abstraite le seul texte de la loi.

Dès lors, une norme ayant d'ores et déjà été jugée comme conforme au droit international peut tout à fait par la suite faire l'objet d'un tel contrôle de proportionnalité.

Bien que la Cour de cassation ait estimé que l'article L. 1253-3 du Code du travail était conforme à l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT, elle a tout de même apprécié si son application dans l'affaire pendante n'avait pas pour effet d'engendrer une atteinte injustifiée aux droits consacrés par ce texte.

B. Le maintien de la norme conforme à la Convention

Ce contrôle de proportionnalité est sans incidence sur l'application de la loi pour les litiges au sein desquelles elle serait normalement applicable.

En cas de non-conformité, la loi dont l'application a été écartée au cas d'espèce demeure théoriquement parfaitement conforme au droit international (cette loi ayant pu *a fortiori* avoir été préalablement déclarée conforme à la Constitution ou au droit international).

Contrairement au contrôle abstrait de conventionnalité, la réalisation du contrôle de proportionnalité permet au juge d'éviter l'application de la loi au litige sans pour autant qu'elle ne disparaisse par la suite.

Ce contrôle concret permet d'approfondir la question de la conformité du droit interne au regard du droit international puisqu'il permet l'éviction, pour un litige particulier, d'une loi nationale portant en apparence une atteinte proportionnée à un droit, mais qui en réalité aurait pour effet d'y porter une atteinte trop vigoureuse.

En conclusion, l'internationalisation de la protection des droits humains a rendu indispensable la réalisation d'un contrôle de conformité du droit interne à ces garanties internationales afin de s'assurer du respect des engagements étatiques. Celui-ci ne peut cependant être efficace qu'en prenant la forme d'un double contrôle de conventionnalité, abstrait et concret, se rapprochant de la sorte des contrôles réalisés par les juridictions internationales de protection des droits humains.

Fiche nº 18 – LA PROTECTION PAR LE JUGE ADMINISTRATIF

POINTS CLÉS

- Traditionnellement, la protection des libertés est confiée à l'autorité judiciaire par application extensive de l'article 66 de la Constitution.
- Cependant, le juge administratif a développé son office autour de la protection des libertés.
- Grâce à différentes lois, il s'est doté de pouvoirs destinés à rendre plus effectif le contrôle : injonction, référé.
- Par sa jurisprudence, il a développé son contrôle afin de garantir davantage de libertés et de droits.

PRINCIPALES RÉFÉRENCES

- Loi des 16-24 août 1790
- Article 66 de la Constitution de 1958
- Cons. const., décision nº 80-119 DC, 22 juillet 1980, *Loi portant validation d'actes administratifs*
- CE, 17 février 1950, *ministre de l'Agriculture c/ Dame Lamotte*, nº 86949
- Loi nº 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives

À plusieurs reprises, l'ancien premier président de la Cour de cassation Bertrand Louvel a remis en cause la pertinence d'un maintien de la dualité juridictionnelle. S'il retient que personne ne discute plus sérieusement que la compétence du juge administratif en matière de défense des droits fondamentaux est aussi protectrice de l'individu face à l'intérêt général que celle offerte par le juge judiciaire, il n'en demeure pas moins que les magistrats judiciaires s'inquiètent d'une certaine mise à l'écart de l'autorité judiciaire au profit du juge administratif dans la protection des droits et libertés.

À titre d'exemple, le premier président, Bertrand Louvel, a été très critique à l'encontre de la compétence du Conseil d'État pour connaître de la prolongation des assignations à résidence dans le cadre de l'État d'urgence. Il estimait que le législateur avait dérogé à la compétence de l'autorité judiciaire, constitutionnellement garantie à l'article 66 de la Constitution, en refusant de se tourner, en certaines matières, vers le juge judiciaire.

Ces critiques doivent être mise en parallèle avec ses déclarations dans une interview accordée au journal *Le Point en 2016 :*

> *« Alors que la logique voudrait que plus il y a de restrictions aux libertés,* ***plus le juge naturel des libertés devrait être mobilisé****. Or, depuis une vingtaine d'années, on a ôté au juge judiciaire le contrôle des libertés que le constituant de 1958 lui avait confiées : la liberté d'aller et de venir, l'intimité de la vie privée, le secret des correspondances, l'inviolabilité du domicile* […] ***le juge administratif était celui de l'intérêt général. Ce primat s'est estompé et il est devenu aussi un juge des libertés*** *: il prend en compte comme un impératif très fort cette défense des intérêts des citoyens. Dès lors, la dualité des compétences n'est plus très lisible. »*

1. L'intérêt de la dualité juridictionnelle pour la protection des libertés

Le système juridictionnel français est caractérisé par deux ensembles hiérarchisés et autonomes de juridictions.

L'ordre juridictionnel administratif est chapeauté par le Conseil d'État et réunit toutes les juridictions administratives, dont les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel. La Cour de cassation est, quant à elle, la Cour suprême dans l'ordre judiciaire.

La distance entre ces deux ordres juridictionnels a longtemps été affirmée. L'adoption de la loi des 16 et 24 août 1790 était déjà un signe de la différence de conception entre ce qui relève du privé ou ce qui relève du public, et de l'existence d'un périmètre d'intervention propre au juge judiciaire. La création du Conseil d'État par la Constitution du 22 frimaire an VIII et la consécration de l'existence d'un droit administratif par le Tribunal des conflits en 1873 dans l'arrêt *Blanco* en sont d'autres illustrations.

→ Trib. Conflits, 8 février 1873, *Blanco,* n° 00012.

POUR ALLER PLUS LOIN

En estimant dans son article 13 que « les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives. Les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler, de quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions », la loi des 16-24 août 1790 a déterminé la séparation de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif.

Elle s'explique par une profonde méfiance des révolutionnaires quant aux institutions juridictionnelles de l'Ancien Régime. Cela implique une conception française de la séparation des pouvoirs, où, dès la Révolution, il n'était pas possible pour les juges judiciaires de s'immiscer dans les affaires de l'administration, laquelle est au service du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif. Autrement dit, il s'agit ici d'empêcher une prise des juges judiciaires sur les procédures politico-administratives francaises.

Contrairement au juge judiciaire qui voit son office consacré à l'article 66 de la Constitution en matière de protection des libertés, le juge administratif a progressivement vu sa compétence étendue sous l'influence des jurisprudences et des lois successives.

> *« L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi »* (art. 66 de la Constitution).

Le juge administratif a vu son existence et son champ de compétence propre dotés d'une assise constitutionnelle par le Conseil constitutionnel.

→ Cons. const., déc. n° 80-119 DC, 22 juillet 1980, *Loi portant validation d'actes administratifs.*

→ Cons. const., déc. n° 86-224 DC, 23 janvier 1987*, Loi transférant à la juridiction judiciaire le contentieux des décisions du Conseil de la concurrence.*

S'interroger sur la défense des droits et libertés fondamentaux par le juge administratif est une remise en cause de la spécificité du juge judiciaire, car ces deux juges ne seraient finalement pas si différents.

Jusqu'à la fin des années 1990, le Conseil constitutionnel retenait une conception très extensive de la notion de « liberté individuelle » au sens de l'article 66 de la Constitution. Par exemple, il avait rattaché à cette notion la protection de la vie privée (décision du 18 janvier 1995, Loi relative à la sécurité) ou encore l'inviolabilité du domicile (décision du 19-20 janvier 1981, Loi relative à la sécurité et à la liberté), ce qui justifiait une compétence étendue du juge judiciaire.

À partir de la décision du 29 juillet 1998 (*Loi d'orientation et de programmation relative à la sécurité*), le Conseil constitutionnel est revenu sur cette conception en renouant avec l'esprit du Constituant : il a retenu une conception restrictive de la liberté individuelle, entendue comme le seul droit de ne pas être arbitrairement détenu. En conséquence, de nombreux droits qui avaient été rattachés auparavant à la liberté individuelle — comme le respect de la vie privée ou l'inviolabilité du domicile — en ont été détachés, ce qui a ouvert la voie à une compétence accrue du juge administratif.

2. Les instruments du juge administratif pour protéger les libertés

Au préalable, il faut rappeler que depuis plusieurs décennies, le législateur a conféré de nombreuses attributions au juge administratif pour veiller à la protection des libertés dans le périmètre des compétences qui lui étaient assignées. Le juge administratif a été, dans son domaine de compétences, doté d'outils de contrôle et de procédures plus performants comme des pouvoirs d'astreinte (loi du 16 juillet 1980), des pouvoirs d'injonction (loi du 8 février 1995) ou encore le pouvoir de statuer dans l'urgence par un référé (loi du 30 juin 2000).

Conformément à ce qu'a décidé le Conseil constitutionnel, le juge administratif est le seul à pouvoir annuler une décision administrative illégale, notamment lorsqu'elle porte atteinte à une liberté légalement reconnue quand bien même le juge judiciaire peut apprécier la légalité de certaines décisions administratives à l'occasion d'un litige.

> *« Conformément à la conception française de la séparation des pouvoirs, figure au nombre des "principes fondamentaux reconnus par les lois de la République" celui selon lequel, à l'exception des matières réservées par nature à l'autorité judiciaire,* ***relève en dernier ressort de la compétence de la juridiction administrative l'annulation ou la réformation des décisions prises, dans l'exercice des prérogatives de puissance publique,*** *par les autorités exerçant le pouvoir exécutif, leurs agents, les collectivités territoriales de la République ou les organismes publics placés sous leur autorité ou leur contrôle »* (Cons. const., décision n° 86-224 DC, 23 janvier 1987, *Loi transférant à la juridiction judiciaire le contentieux des décisions du Conseil de la concurrence*).

À l'occasion de divers litiges tendant à l'annulation de décisions administratives, le juge administratif a façonné des outils et des règles destinés à mieux protéger les droits et les libertés. Il a, par exemple, dégagé de nombreux principes généraux du droit à partir des sources législatives, constitutionnelles ou conventionnelles.

C'est surtout par la voie procédurale que le juge administratif opère un contrôle approfondi du respect des droits et libertés des citoyens par l'administration. En effet, sans voie de droit efficace, la protection des libertés ne l'est pas davantage.

C'est pourquoi, trois voies de droit peuvent être appréhendées en ce qu'elles permettent de protéger les droits et libertés des citoyens. On peut citer le recours pour excès de pouvoir, le recours aux procédures d'urgence et enfin le contrôle de conventionnalité permettant d'intégrer les normes supranationales dans le raisonnement du juge.

2.1. Le recours pour excès de pouvoir

Le recours pour excès de pouvoir (REP) est la voie de recours principale devant le juge administratif. Il s'agit d'un instrument essentiel afin de garantir une voie de recours effective puisque ce recours est ouvert même sans texte contre tout acte administratif et il a pour effet d'assurer, conformément aux principes généraux du droit, le respect de la légalité.

> → CE, 17 février 1950, *Ministre de l'Agriculture c. Dame Lamotte*, n° 86949.

Le recours pour excès de pouvoir a connu une formidable évolution : initialement conçu comme un instrument destiné au respect de la légalité, il tend désormais à prendre en compte la situation du requérant pour protéger ses droits subjectifs : c'est la subjectivisation du recours pour excès de pouvoir.

2.1.1. Un recours objectif : la protection de la légalité

Selon Edouard Laferrière, le recours pour excès de pouvoir est un recours objectif qui amène le juge à décider du sort de l'acte attaqué au regard de la seule légalité. Le REP a ainsi pour fonction première d'obtenir de l'administration le respect de la légalité : selon Gaston Jèze, il s'agit d'un procès fait à un acte.

Le recours pour excès de pouvoir n'est pas un recours destiné à servir les droits du requérant. Ce dernier, en faisant un recours pour un litige personnel, va aussi servir la collectivité et l'intérêt général en soumettant l'acte au contrôle de légalité.

Le recours pour excès de pouvoir doit, en général, être introduit dans un délai de deux mois à compter de la publication ou de la notification de l'acte. L'acte contesté doit être un acte administratif faisant grief, c'est-à-dire qu'il doit modifier l'ordonnancement juridique. En d'autres termes, il doit modifier de façon considérable la situation du citoyen.

Le requérant doit avoir la capacité d'ester en justice et démontrer un intérêt à agir ce qui signifie que l'acte attaqué doit affecter ses intérêts de façon suffisamment direct. Pouvant facilement saisir le juge administratif, les requérants peuvent voir dans le REP un moyen de défense aisé de leurs droits.

Plus le recours est ouvert, plus il y aura de chances qu'il y ait des recours exercés et donc de chances de corriger les irrégularités et les illégalités, même si cela n'a jamais débouché sur une action populaire. La conséquence est que l'intérêt à agir n'est pas défini en fonction d'un droit subjectif, mais il est plus large : il suffit qu'un acte administratif porte atteinte à certains intérêts même indirects.

En cas d'annulation de l'acte, pour un motif de légalité externe (compétence, règles de forme ou de procédure) ou de légalité interne (erreur de fait, erreur de droit, détournement de pouvoir), il sera réputé ne jamais avoir existé. Autrement dit, l'acte disparaît rétroactivement de l'ordonnancement juridique.

2.1.2. Un recours devenu subjectif : l'intégration des droits

Ce recours a connu une transformation appelée subjectivisation du recours pour excès de pouvoir.

Ce contentieux va être de moins en moins centré sur l'acte attaqué, mais un peu plus sur la situation du requérant ou plus généralement des parties au litige. Cette évolution du REP conduit à ce qu'il ne soit plus uniquement centré sur l'acte administratif, mais sur une situation juridique triangulaire (l'administration, le juge et le justiciable) et tend à faire en sorte que la solution que va apporter le juge de l'excès de pouvoir ne se résume pas à sanctionner une illégalité, mais qu'elle vise à apporter une solution définitive à une situation concrète.

Pour comprendre ce mouvement, il faut avoir en tête l'idée d'un droit subjectif. On peut le définir comme étant le reflet de l'obligation d'autrui dont on bénéficie comme titulaire d'une telle obligation : l'administration doit appliquer la règle de droit et désormais, l'individu a un droit à ce que l'administration applique cette règle de droit à son avantage.

Plusieurs exemples concrets illustrent ce mouvement de subjectivisation du recours pour excès de pouvoir, mais nous n'en retiendront que deux.

Le premier concerne les effets de l'annulation contentieuse. Dans la mesure où celle-ci est rétroactive, elle est susceptible d'affecter la sécurité juridique pour le requérant et l'administration.

Au travers de sa jurisprudence *Association AC !* de 2004, le Conseil d'État a reconnu la possibilité de moduler dans le temps les effets d'une annulation et de décider que cette dernière ne prendra effet qu'à partir d'une certaine date. Cette modulation permet au juge administratif de prendre davantage en compte les conséquences réelles de sa décision.

Dans cette perspective, la politique jurisprudentielle du juge administratif se subjectivise : elle prend davantage en compte les situations subjectives des parties qui se présentent devant le juge administratif. En cela, elle est en mesure d'être plus protectrice de leurs droits.

→ CE, 11 mai 2004, *Association AC !*, n° 255886.

Deuxièmement, le juge administratif est désormais doté d'un pouvoir d'injonction.

Si l'arrêt *Benjamin* de 1933 est connu en ce qu'il consacre des règles de contrôle des mesures de police administrative, il marque aussi l'absence d'effectivité du recours pour excès de pouvoir certaines fois. En l'espèce,

la décision administrative interdisait une conférence et limitait donc la liberté de réunion. Or, au bout de cinq ans de procédure, si la décision a été annulée par le Conseil d'État, car elle était illégale, la réunion n'a jamais eu lieu : la décision de justice a été inefficace pour la protection des droits.

Techniquement, le pouvoir d'injonction créé par la loi de 1995 conduit le juge de l'excès de pouvoir à se prononcer sur la légalité d'un acte administratif, qui peut être le refus de prendre une décision. Le juge, si cette décision est illégale, va l'annuler, mais va aussi pouvoir enjoindre à l'administration de prendre la décision demandée par le requérant.

Le juge ne substitue pas sa décision, mais fait pression : il va contraindre l'administration à agir dans un sens déterminé pour se mettre en conformité avec la légalité.

2.2. Les référés

Deux référés peuvent être appréhendés ici en ce qu'ils ont une conséquence considérable sur la protection des libertés. Il s'agit du référé-liberté et du référé-suspension.

Les référés ont été créés par la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives. Ils ont été intégrés dans les dispositions du Code de justice administrative.

2.2.1. Le référé-liberté

La loi du 30 juin 2000 a introduit un article L. 521-2 dans le Code de justice administrative. Il dispose que :

> *« Saisi d'une demande en ce sens justifiée par **l'urgence**, le juge des référés peut ordonner **toutes mesures nécessaires** à la **sauvegarde d'une liberté fondamentale** à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, **une atteinte grave et manifestement illégale**. Le juge des référés se prononce dans un délai de **quarante-huit heures.** »*

Tout d'abord, le référé-liberté peut être utilisé par un justiciable si une décision prise à son encontre par une administration porte une atteinte grave et manifestement illégale à l'une de ses libertés fondamentales.

Il a été mobilisé dans la plupart des affaires emblématiques dont a eu à connaître le juge administratif ces dernières années comme l'affaire Dieudonnée, Lambert, les arrêtés anti-burkinis, sur les mesures prises dans le cadre de l'état d'urgence notamment en matière d'assignation à résidence ou encore dans le cadre des mesures prises contre le Covid-19.

Le référé-liberté est une procédure d'urgence dont l'objectif est de faire cesser de manière immédiate une atteinte en cours à une liberté fondamentale imputable à l'administration. L'effet de ce référé-liberté est que la décision litigieuse portant atteinte aux libertés sera suspendue.

À ce titre, le juge dispose d'un délai de 48 heures pour se prononcer.

Trois conditions essentielles doivent être réunies pour suspendre une décision administrative portant atteinte aux libertés :

- Il faut une atteinte grave à une liberté fondamentale **:** la plupart des libertés et droits fondamentaux proclamés en droit constitutionnel et dans la CEDH sont des libertés fondamentales au sens de ce recours.
- Il faut aussi une illégalité manifeste et le Conseil d'État estime que :

  > *« Le caractère manifestement illégal de l'atteinte à la liberté fondamentale en cause doit s'apprécier en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente »* (CE, ord., 30 juillet 2015, *Section française de l'OIP*, n° 392043).

- Enfin, il faut une urgence rendant nécessaire l'intervention à très brève échéance d'une décision destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. L'appréciation de l'urgence dépend de la gravité de l'atteinte et de la liberté en cause.

Notion essentielle. – Qu'est-ce qu'une « liberté fondamentale » au sens du référé-liberté ?

La notion de « liberté fondamentale » au sens de l'article L. 521-2 du Code de justice administrative (CJA) constitue une catégorie autonome définie par le juge administratif. Il ne suffit donc pas qu'un droit bénéficie d'une protection constitutionnelle, conventionnelle ou législative pour qu'il puisse automatiquement être invoqué à l'appui d'un référé-liberté.

Cette autonomie apparaît notamment dans l'affaire *Commune de Dannemarie*. Une association contestait l'installation par une commune de représentations féminines qu'elle estimait sexistes et attentatoires à la dignité et au principe d'égalité entre les femmes et les hommes. Le Conseil d'État refuse toutefois de considérer que la seule méconnaissance du principe d'égalité caractérise, par elle-même, une atteinte à une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 (CE, ord., 1er septembre 2017, *Commune de Dannemarie*, n° 413607). Cette solution illustre la distinction entre l'importance juridique d'un principe et son invocabilité propre dans le cadre particulier du référé-liberté.

À l'inverse, la liste des libertés susceptibles d'être protégées n'est pas figée. Le Conseil d'État peut reconnaître de nouvelles libertés fondamentales en fonction de l'évolution du droit et des situations dont il est saisi. Il a ainsi expressément reconnu comme telles la liberté de création artistique et la liberté d'accès aux œuvres culturelles, à l'occasion du contentieux relatif à la fermeture des cinémas, théâtres et salles de spectacle pendant la crise sanitaire (CE, ord., 23 décembre 2020, *Moreau et autres*, n° 447698 et autres).

Cette qualification demeure également susceptible de porter sur certaines composantes d'un droit sans englober nécessairement celui-ci dans son ensemble. Ainsi, le droit à la protection de la santé ne constitue pas, par lui-même, une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2, alors que certaines prérogatives liées à la protection de l'intégrité de la personne ou aux soins peuvent bénéficier de cette protection dans des circonstances déterminées. C'est ainsi que, dans le domaine médical, seul le droit de ne pas subir une obstination déraisonnable et le droit au respect de la vie ont été considérées comme des libertés fondamentales (CE, ord., 14 févr. 2014, *Lambert*, n° 375081, 375090, 375091 ; CE, 8 mars 2017, *Assistance Publique – Hôpitaux de Marseille*, n°408146)

À retenir : Il ne faut donc jamais déduire automatiquement la qualité de liberté fondamentale au sens du référé-liberté de la seule valeur constitutionnelle ou conventionnelle d'un droit. Il convient de rechercher si le Conseil d'État lui a reconnu cette qualité ou si la prérogative invoquée peut être rattachée à une liberté fondamentale déjà identifiée

Jurisprudences à retenir. - Le référé-liberté au cœur des grandes affaires contemporaines

Depuis sa création en 2000, le référé-liberté est devenu l'une des principales voies de protection juridictionnelle des libertés face à l'administration. Plusieurs affaires importantes permettent de mesurer l'étendue de l'office du juge des référés.

Dans l'affaire *Dieudonné*, le juge des référés du Conseil d'État a admis qu'une mesure d'interdiction d'un spectacle pouvait être justifiée par la nécessité de prévenir des atteintes graves à l'ordre public, notamment au respect de la dignité de la personne humaine, tout en rappelant l'importance particulière de la liberté d'expression. Le référé-liberté devient ainsi le cadre d'une mise en balance immédiate entre les nécessités de l'ordre public et l'exercice d'une liberté fondamentale (CE, ord., 9 janvier 2014, *Ministre de l'Intérieur c. Société Les Productions de la Plume et M. Dieudonné M'Bala M'Bala*, n° 374508).

L'affaire *Gonzalez-Gomez* a encore renforcé cet office. Saisi en référé-liberté du refus d'autoriser le transfert vers l'Espagne des gamètes du mari décédé de la requérante, le Conseil d'État a accepté d'apprécier concrètement les conséquences de l'application de la législation française au regard de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Il a finalement ordonné à l'administration de permettre leur exportation (CE, Ass., 31 mai 2016, *Mme Gonzalez-Gomez*, n° 396848). Le juge du référé-liberté peut ainsi assurer directement la protection d'une liberté fondamentale garantie par une convention internationale lorsque les conditions de l'article L. 521-2 sont réunies.

Plus récemment, l'affaire du blocage de *TikTok* en Nouvelle-Calédonie rappelle que l'existence d'une atteinte particulièrement importante à une liberté ne dispense jamais le requérant de démontrer l'urgence propre au référé-liberté. En mai 2024, le juge des référés a refusé de suspendre le blocage du réseau social, les requérants n'ayant pas suffisamment établi les conséquences immédiates et concrètes de la mesure sur leur situation au regard du contexte de troubles particulièrement graves (CE, ord., 23 mai 2024, n° 494320).

L'affaire présente un intérêt pédagogique supplémentaire : saisi ensuite au fond, le Conseil d'État a finalement annulé, le 1er avril 2025, la décision d'interruption totale de TikTok, en estimant que les circonstances exceptionnelles pouvaient permettre une telle mesure seulement si elle était indispensable et strictement proportionnée, notamment dans sa durée, en l'absence de mesure alternative moins attentatoire aux libertés (CE, 1er avril 2025, *Ligue des droits de l'homme et autres*, nos 494511, 494583 et 495174).

À retenir : Le référé-liberté constitue un instrument particulièrement puissant, mais son efficacité dépend de la réunion de chacune de ses conditions. Une mesure peut porter une atteinte très importante à une liberté et ne pas être suspendue en urgence, puis être ultérieurement annulée par le juge du fond. L'affaire *TikTok* en offre une illustration particulièrement actuelle.

POUR ALLER PLUS LOIN

Figurent parmi les libertés fondamentales invoquées à l'appui d'un référé-liberté :

- Le droit à la sûreté : CE, ord., 20 juillet 2001, *Commune de Mandelieu-La Napoule,* n° 236196.
- La liberté d'opinion : CE, 28 février 2001, *Casanovas*, n° 229163.
- La liberté d'aller et venir : CE, réf., 9 janvier 2001, *Deperthes*, n° 228928.
- Le droit au recours : CE, ord., 13 mars 2006, *Bayrou et association de défense des usagers des autoroutes publiques de France*, n° 291118.
- Le droit de grève : CE, 9 décembre 2003*, Aguillon,* n° 282186.

Pour consulter toutes les libertés fondamentales, au sens de l'article L. 521-2 du CJA, par le juge administratif, v. : LANTERO (Caroline), « Les libertés fondamentales au sens de l'article L. 521-2 du Code de justice administrative », *Le blog de Droit administratif*, 3 septembre 2018.

2.2.2. Le référé-suspension

Le référé-suspension est une procédure qui s'est substituée au sursis à exécution par l'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives. Son régime juridique est prévu à l'article L. 521-1 du Code de justice administrative.

En vertu du principe du privilège du préalable, les décisions de l'administration sont immédiatement exécutoires. Elles commencent donc à produire des effets et les destinataires doivent s'y soumettre même en cas d'illégalité.

Ainsi, le référé-suspension permet d'obtenir du juge administratif la suspension provisoire de l'exécution d'une décision administrative, même de rejet, faisant l'objet d'une requête au fond, à condition que deux conditions soient réunies : il faut que l'urgence le justifie et qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ladite décision.

POUR ALLER PLUS LOIN

Contrairement au référé-liberté pour lequel il n'est pas nécessaire de présenter une requête au fond en parallèle, le référé-suspension n'est recevable qu'à la condition qu'il ait été présenté en même temps qu'une requête en annulation (au fond).

Le juge statue en premier et dernier ressort sur la demande de suspension. L'ordonnance peut uniquement faire l'objet d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État.

Dans la mesure où dans la procédure administrative contentieuse les recours n'ont pas d'effet suspensif, l'introduction du référé-suspension a été une grande avancée en matière de défense des droits et libertés fondamentaux.

2.3. Le contrôle de conventionnalité

Le juge administratif a progressivement intégré les droits et libertés consacrés dans des normes supranationales grâce au contrôle de conventionnalité des lois.

Ce contrôle permet d'écarter une loi qui serait contraire à un traité, à une convention ou à toute norme supranationale. Dans ce cas de figure, la légalité du décret sera appréhendée à travers les droits et libertés consacrés dans la norme supranationale.

Le juge administratif s'est reconnu tardivement compétent pour procéder à un tel contrôle de conventionnalité des lois.

> → CE, 20 octobre 1989, *Nicolo,* n° 108243.

Enfin, le juge administratif est allé encore plus loin dans l'appréciation des droits et libertés consacrés dans les textes supranationaux puisqu'il s'est reconnu compétent pour les apprécier à l'occasion des procédures d'urgence.

> *« Eu égard à son office, qui consiste à assurer la sauvegarde des libertés fondamentales, il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du Code de justice administrative, de prendre, en cas d'urgence, toutes les mesures qui sont de nature à remédier aux effets résultant d'une atteinte grave et manifestement illégale portée, par une autorité administrative, à une liberté fondamentale, y compris lorsque cette atteinte résulte de l'application de dispositions législatives qui sont manifestement incompatibles avec les engagements européens ou internationaux de la France, ou dont la mise en œuvre entraînerait des conséquences manifestement contraires aux exigences nées de ces engagements. »*

Dans son ordonnance de 2016, le Conseil d'État rappelle qu'il appartient au juge des référés d'assurer la sauvegarde des libertés fondamentales. Il doit donc, pour apprécier l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté, veiller au respect des textes européens ou internationaux.

En l'espèce, le Conseil d'État a estimé qu'il y avait une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté au regard des dispositions de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.

> → CE, ord., 31 mai 2016, *Gonzalez Gomes c. Agence de biomédecine*, n° 396848.

3. L'évolution de la protection : la meilleure justiciabilité des actes

Le juge administratif a progressivement ouvert les portes de son prétoire en rendant justiciable devant lui des actes qui, jusque-là, bénéficiaient d'une forme d'immunité juridictionnelle en ce qu'ils ne pouvaient pas être contestés à raison de leur nature.

Cela a notamment été le cas d'actes qui avaient été pris au regard de considérations purement politiques.

> → CE, 19 février 1875, *Prince Napoléon*, n° 46707.

Désormais, ces actes peuvent désormais être contestés en ce qu'ils ont des conséquences manifestes sur les libertés de l'individu. On peut citer les mesures d'ordre intérieur et les actes de droit souple.

3.1. Les mesures d'ordre intérieur

Les mesures d'ordre intérieur forment une catégorie d'actes composée de décisions prises par l'administration dans le cadre de l'organisation et du fonctionnement de ses services qui, bien que pouvant avoir un effet sur la situation de l'administré ou d'un agent public et notamment sur ses droits, sont insusceptibles de recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif.

Ce choix de placer ces actes hors du recours juridictionnel s'explique par la volonté de ne pas encombrer le prétoire d'actes de faible portée ou peu contraignants.

Ces mesures d'ordre intérieur concernent pourtant des domaines dans lesquels les droits et libertés méritent une attention particulière : les hôpitaux, les services pénitentiaires, l'éducation, par exemple.

De manière globale, le juge administratif tend à réduire progressivement la catégorie des mesures d'ordre intérieur afin de rendre justiciables plus d'actes administratifs.

Particulièrement en matière pénitentiaire, le Conseil d'État a réduit considérablement cette catégorie en tenant compte des effets de cette mesure sur la liberté de l'individu en retenant que :

> *« Tant par ses effets directs sur la liberté d'aller et venir du militaire, en dehors du service, que par ses conséquences sur l'avancement ou le renouvellement des contrats d'engagement, la punition des arrêts constitue une mesure faisant grief, susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir »* (CE, 17 février 1995, *Hardouin et Marie*, n° 107766).

Le Conseil d'État prend également en compte les droits et libertés des fonctionnaires en veillant à ce que les décisions prises à leur encontre ne constituent pas de la discrimination ou ne violent pas leurs droits et leurs libertés découlant de leur statut.

> *« Considérant que les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours ; qu'il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent perte de responsabilités ou de rémunération ; que le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination, est irrecevable »* (CE, 25 septembre 2015, *Bourjolly*, n° 372624).

3.2. Les actes de droit souple

La notion de « droit souple » recouvre une diversité d'actes de dénominations variables qui ne se présentent pas formellement comme des actes décisoires (qui modifient la situation juridique et qui font grief), mais qui ne sont pas sans influence concrète sur leurs destinataires.

En principe, ces actes n'étaient pas susceptibles de recours, mais le Conseil d'État a fait évoluer cette règle afin de rendre justiciable des actes qui entraîneraient des conséquences sur leur destinataire.

Dans deux arrêts de 2016, le Conseil d'État a estimé que désormais, les actes de droit souple comme les avis, recommandations, mises en garde et prises de position adoptés par les autorités de régulation dans l'exercice des missions peuvent être contestés :

- S'ils revêtent le caractère de dispositions générales et impératives.
- S'ils énoncent des prescriptions individuelles dont ces autorités pourraient ultérieurement censurer la méconnaissance.
- S'ils sont de nature à produire des effets notables, notamment de nature économique, ou ont pour objet d'influer de manière significative sur les comportements des personnes auxquelles ils s'adressent.

  → CE, 21 mars 2016, *Société Fairvesta international GMBH*, n° 368082.

  → CE, ass., 21 mars 2016, *Société NC Numericable*, n° 390023.

POUR ALLER PLUS LOIN

Le Conseil d'État a poursuivi l'ouverture de son prétoire aux actes de droit souple dans un arrêt GISTI du 12 juin 2020, n° 418142. Dans cette décision, il retient que « peuvent être déférés au juge de l'excès de pouvoir lorsqu'ils sont susceptibles d'avoir des effets notables sur les droits ou la situation d'autres personnes que les agents ».

Cet arrêt conclut que l'ensemble des documents de portée générale émanant d'autorités publiques susceptibles d'avoir des effets notables sur les droits ou la situation d'autres personne peuvent faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

POUR S'ENTRAÎNER

Commentaire de décision : CE, ord., 12 janvier 2001, *Hyacinthe*, n° 229039.

En matière de référé administratif, l'urgence et le sérieux des moyens invoqués sont au cœur du contrôle du juge. En effet, le référé-liberté est une voie de droit créée par la loi du 30 juin 2000 relative aux procédures d'urgence devant le juge administratif. Il permet au requérant de saisir le juge administratif de toute atteinte de l'administration à ses droits ou libertés garantis.

En l'espèce, une ressortissante haïtienne est arrivée en France pour rejoindre son compagnon alors qu'elle était enceinte. Cette dernière a été emprisonnée en raison d'une condamnation pour entrée et séjour irrégulier en France et usage de faux documents. La requérante a été mise dans l'impossibilité par les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis de présenter une demande d'admission au titre de l'asile.

Quant à la procédure, la requérante a saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise en vue d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'admission au séjour et de lui délivrer un titre de séjour provisoire. Le TA l'a déboutée et elle saisit le juge des référés du Conseil d'État pour faire annuler l'ordonnance du TA et pour enjoindre au Préfet de satisfaire sa demande initiale.

Problématique : le droit d'asile est-il une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du Code de justice administrative justifiant l'exercice d'un référé-liberté ?

I. L'atteinte à une liberté fondamentale consacrée par la Constitution

A. La reconnaissance d'un droit subsidiaire : le droit d'asile

Le Conseil d'État rappelle que les ressortissants étrangers ne peuvent pas invoquer, à la différence des nationaux, la liberté d'entrée sur le territoire.

Cela ne signifie pas que le Conseil d'État refuse d'apprécier cette liberté dans le cadre d'un référé-liberté, mais précisément que la requérante ne peut pas s'en prévaloir (CE, ord., 9 janvier 2001 *Desperthes*, n° 228928).

B. Le droit constitutionnel d'asile invocable subsidiairement

Le Conseil d'État commence par rappeler que, si les étrangers ne disposent pas d'un droit général d'accès au territoire français, ils peuvent toutefois revendiquer le droit d'asile. Ce droit est présenté comme fondamental, car il trouve son origine dans la Constitution française et constitue une condition pour l'exercice des autres libertés fondamentales.

Le Conseil d'État se livre donc à une appréciation des libertés consacrées dans la Constitution pour opérer son contrôle. Il s'agit d'un droit subsidiaire

Ainsi, même dans le cadre d'une régulation stricte des flux migratoires, le droit de solliciter l'asile bénéficie d'une protection renforcée**,** au même titre que d'autres libertés fondamentales telles que le droit à la vie ou à la sûreté. Cela avait déjà été le cas avec le droit de demeurer en France le temps de l'examen de la demande (CE, ord., 2 mai 2001, *Dziri*, n° 232997).

II. La reconnaissance d'une illégalité manifeste

A. L'examen de conditions cumulatives

Le Conseil d'État rappelle ici que la condition de l'illégalité manifeste prévue à l'article L. 521-2 du CJA est cumulative avec l'atteinte à une liberté fondamentale. Il faut que la seconde découle de la première.

À ce propos, le Conseil d'État avait rappelé que *« le caractère manifestement illégal de l'atteinte à la liberté fondamentale en cause doit s'apprécier en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente »*, (CE, ord., 30 juillet 2015, *Section française de l'OIP*, n° 392043).

En l'espèce, sans se limiter à la constatation de la violation d'une liberté, le Conseil d'État retient également une illégalité manifeste de la décision prise.

B. L'examen concret de la situation du requérant

Le Conseil d'État va procéder à un contrôle *in concreto* de la situation du requérant pour apprécier l'illégalité manifeste.

Sans préjuger du fond de la légalité, il va se reposer sur un faisceau d'indice pour tenter de rechercher si la décision paraît illégale.

En l'espèce, il retient que l'antériorité de la demande de statut de réfugié du compagnon de l'intéressé ne saurait constituer une volonté de faire échec à une mesure d'éloignement.

Enfin, le contrôle est concret en ce que le juge va se placer à la date du jugement pour vérifier s'il y a eu des changements de circonstance justifiant d'enjoindre ou non à l'administration de s'exécuter.

En conclusion, le Conseil d'État va développer son office en matière de référé en adoptant une position de plus en plus protectrice des individus et de leurs droits. Le référé est devenu une voie de droit offerte au plus grand nombre afin de rétablir des situations potentiellement illégales.

Fiche nº 19 - LES DÉROGATIONS AU PRINCIPE DE SÉPARATION DES AUTORITÉS

POINTS CLÉS

- Tribunal des conflits.
- Expropriation pour cause d'utilité publique.
- Voie de fait.
- Emprise irrégulière.
- Juge judiciaire et actes administratifs.
- Contentieux de reconduite des étrangers à la frontière.

PRINCIPALES RÉFÉRENCES

- Article 66 de la Constitution.
- Article 2, 17 Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
- Loi des 16 et 24 août 1790 sur l'organisation judiciaire.
- T. confl., 16 juin 1923, *Septfonds*, nº 00732.
- Loi nº 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives.
- T. confl., 17 octobre 2011, *SCEA du Chéneau c. INAPORC, M. Cherel et a. c. CNIEL*, nº C3828-3829.
- T. confl., 17 juin 2013, *Bergoend c. Société ERDF Annecy Léman*, nº C3911.
- T. confl., 9 décembre 2013*, Pannizon c. commune de Saint-Palais-sur-Mer,* nº C3931.
- Cons. const., déc. nº 89-256 DC, 25 juillet 1989, *Loi portant dispositions diverses en matière d'urbanisme et d'agglomérations nouvelles.*
- Cons. const., déc. nº 89-261 DC, 28 juillet 1989, *Loi relative aux conditions de séjour et d'entrée des étrangers en France.*

1. Les fondements du dualisme juridictionnel

La loi des 16 et 24 août 1790 sur l'organisation judiciaire constitue le fondement de la séparation des autorités administratives et judiciaires, séparation réaffirmée par la loi du 16 fructidor an III de 1795 qui comporte un article unique :

> *« Défenses itératives sont faites aux tribunaux de connaître des actes d'administration, de quelque espèce qu'ils soient, aux peines de droit. »*

Cette séparation des autorités résulte du principe de la séparation des pouvoirs inscrit à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789.

Le principe selon lequel, dans le cadre de l'exercice des prérogatives de puissance publique, les décisions prises par les autorités exerçant le pouvoir exécutif relèvent de la compétence du juge administratif pour leur annulation et leur réformation, a été érigé au rang de principe fondamental reconnu par les lois de la République. Le Conseil constitutionnel a affirmé qu'à l'exception :

> *« Des matières réservées par nature à l'autorité judiciaire, relève en dernier ressort de la compétence de la juridiction administrative l'annulation ou la réformation des décisions prises, dans l'exercice des prérogatives de puissance publique, par les autorités exerçant le pouvoir exécutif, leurs agents, les collectivités territoriales de la République ou les organismes publics placés sous leur autorité ou leur contrôle »* (Cons. const., déc. nº 86-224 DC, 23 janvier 1987, *Conseil de la concurrence*).

Qui plus est, dans une décision de 1947, le Tribunal des conflits avait affirmé que :

> *« La sauvegarde de la liberté individuelle et la protection de la propriété privée rentrent essentiellement dans les attributions de l'autorité judiciaire »* (T. confl., 18 décembre 1947, *Hilaire*).

La rigidité apparente du dualisme s'est atténuée, laissant place à des dérogations au principe de séparation des autorités en vue d'assurer la bonne administration de la justice.

La bonne administration de la justice constitue un objectif de valeur constitutionnelle reconnu par le Conseil constitutionnel par une lecture croisée des articles 12, 15 et 16 de la Déclaration de 1789.

> → Cons. const., déc. n° 2009-595 DC, 3 décembre 2009, *Loi organique relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution.*

Le Conseil d'État se réfère également à la bonne administration de la justice.

> → CE, 25 avril 2001, *Association choisir la vie et Association pour l'objection de conscience à l'avortement*, n° 216521.

Les dérogations au principe de séparation des autorités sont nombreuses, parmi lesquelles se trouvent la compétence du juge judiciaire en cas de responsabilité de l'administration pour les dommages causés par ses véhicules, la compétence du juge judiciaire en cas de contestation en matière douanière, la compétence du juge judiciaire en matière de contrat de service civique.

> → Loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 attribuant compétence aux tribunaux judiciaires pour statuer sur les actions en responsabilité des dommages causés par tout véhicule et dirigés contre une personne de droit public.
>
> → Art. 357 *bis* du Code des douanes.
>
> → Loi n° 2010-241 du 10 mars 2010 relative au service civique.

Ainsi, si en principe le juge administratif est compétent lorsque sont en cause des atteintes aux droits humains commises par des autorités administratives, il existe toutefois des exceptions. La jurisprudence du Tribunal des conflits a eu un apport majeur dans la délimitation de ces dérogations.

2. Le rôle du Tribunal des conflits en cas de situations conflictuelles de compétences

Le Code de justice administratif prévoit qu'en cas de conflit de compétence entre la juridiction administrative et la juridiction judiciaire, c'est au Tribunal des conflits qu'il revient de le régler (art. R771-1 CJA).

Une loi de 1872, encore en vigueur et qui a fait l'objet de modifications, prévoit la composition du Tribunal des conflits, les règles de délibération en son sein, le caractère obligatoire de ses décisions et ses compétences. Avant 2015, le Tribunal des conflits était présidé par le garde des Sceaux, ce qui a été modifié par une réforme de 2015 ; la présidence du Tribunal des conflits est assurée par un de ses membres désigné pour trois ans.

> → Loi du 24 mai 1872 relative au Tribunal des conflits.
>
> → Loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures.
>
> → Décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles.

Compétences du Tribunal des conflits	
Conflit positif	Le préfet saisit le Tribunal des conflits pour qu'il détermine le juge compétent pour un litige ; litige que le préfet considère comme ne relevant pas de la compétence du juge judiciaire.
Conflit sur renvoi	Le conflit sur renvoi intervient lorsqu'une juridiction a décliné sa compétence pour un litige par une décision qui ne peut pas faire l'objet d'un recours, qu'une partie au litige saisit ensuite une juridiction de l'autre ordre, et que cette juridiction saisit le Tribunal des conflits pour statuer sur la compétence. Le conflit sur renvoi consiste aussi, à l'occasion d'un litige, à renvoyer au Tribunal des conflits une question de compétence soulevée qui concerne la séparation des deux ordres de juridiction.
Conflit négatif	Le juge administratif et le juge judiciaire ont tous deux décliné leur compétence pour un même litige sans renvoyer le litige devant le Tribunal des conflits : une partie au litige peut le saisir pour qu'il détermine la juridiction compétente.
Conflit de décisions	Deux décisions concernant un même litige ont été rendues par le juge administratif et par le juge judiciaire qui entrent en contradiction.
Durée excessive des procédures	Dans le cas où des procédures relatives au même litige, devant le juge administratif et devant le juge judiciaire, ont donné lieu à durée totale excessive de procédures du fait des règles de compétence, une partie au litige peut effectuer une action en indemnisation devant le Tribunal des conflits.

POUR ALLER PLUS LOIN

Dans sa décision Préfet de Guyane rendue en 1952, le Tribunal des conflits délimite les compétences entre le juge administratif et le juge judiciaire pour le contrôle des actes du service public de la justice.

Le juge judiciaire est compétent pour connaître des actes relatifs à l'exercice de la fonction juridictionnelle et des actes relatifs au fonctionnement du service public de la justice.

Le juge administratif est compétent pour connaître des actes relatifs à l'organisation même du service public.

3. L'autorité judiciaire gardienne de la propriété privée immobilière et de la liberté individuelle

Selon l'article 66 de la Constitution, l'autorité judiciaire est la gardienne de la liberté individuelle.

L'article 136 du Code de procédure pénale prévoit que :

« Dans tous les cas d'atteinte à la liberté individuelle, le conflit ne peut jamais être élevé par l'autorité administrative et les tribunaux de l'ordre judiciaire sont toujours exclusivement compétents. »

La liberté individuelle a fait l'objet d'une conception large, incluant plusieurs libertés, jusqu'à ce qu'elle soit délimitée au droit de ne pas être arrêté ou enfermé arbitrairement, dont des développements ultérieurs y sont consacrés plus amplement (*Fiche n° 30 – Le droit à la liberté et à la sûreté*).

En outre, figure au nombre des droits « naturels et imprescriptibles de l'homme », pour reprendre l'article 2 de la Déclaration de 1789, la propriété.

Le droit de propriété est également inscrit à l'article 17 de la Déclaration de 1789, qui prévoit que :

« La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité. »

L'article 34 de la Constitution prévoit que les règles relatives au régime de la propriété relèvent du domaine de la loi. De plus, le Conseil constitutionnel a affirmé que :

« Les atteintes portées à ce droit doivent être justifiées par un motif d'intérêt général et proportionnées à l'objectif poursuivi » (Cons. const., déc. n° 2011-212 QPC, 20 janvier 2012, *Mme Khadija A., épouse M.*).

L'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme de 1952 garantit le droit de propriété, qui implique *« le droit au respect des biens »*.

→ CEDH, 13 juin 1979, *Marckx c. Belgique*, n° 6833/74.

L'article 17 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne est consacré au droit de propriété, et précise qu'il est possible d'y porter atteinte pour cause d'utilité publique, dans les conditions prévues par la loi, avec une juste indemnité, pour l'intérêt général.

Le droit de propriété est également inscrit à l'article 544 du Code civil qui prévoit que :

« La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. »

Enfin, en 1989, le Conseil constitutionnel a affirmé le principe fondamental reconnu par les lois de la République selon lequel l'autorité judiciaire est garante de la protection de la propriété immobilière.

→ Cons. const., déc. n° 89-256 DC, 25 juillet 1989, *Loi portant dispositions diverses en matière d'urbanisme et d'agglomérations nouvelles.*

Actualité jurisprudentielle. - Isolement et contention psychiatriques : une compétence étendue du juge judiciaire

Le Tribunal des conflits a précisé que les mesures d'isolement et de contention constituent, en toutes circonstances, des privations de liberté. En application de l'article 66 de la Constitution, le juge judiciaire est donc compétent pour contrôler leurs conditions de mise en œuvre, ordonner leur mainlevée et connaître des actions en indemnisation résultant de leur mise en œuvre irrégulière.

→ T. confl., 8 décembre 2025, *M. G. c/ Assistance Publique - Hôpitaux de Paris*, n° C4361.

Cette compétence a été précisée en 2026. Une patiente hospitalisée sans consentement était décédée après avoir été placée à l'isolement et avoir fait l'objet d'une contention chimique. Ses proches invoquaient également des fautes médicales liées au traitement administré et à l'insuffisance de la surveillance. Alors que la responsabilité d'un établissement public hospitalier relève normalement du juge administratif, le Tribunal des conflits juge que, lorsque les actes médicaux se rattachent à une mesure d'isolement ou de contention, notamment chimique, le contentieux indemnitaire relève dans son entier du juge judiciaire.

→ T. confl., 8 juin 2026, *Centre hospitalier de Lannemezan*, n° C4374.

À retenir : La compétence judiciaire attachée à la protection de la liberté individuelle peut englober des actes qui, pris isolément, relèveraient normalement de l'activité médicale d'un établissement public. Dès lors qu'ils se rattachent à une mesure d'isolement ou de contention constitutive d'une privation de liberté, leur contentieux indemnitaire relève entièrement du juge judiciaire.

3.1. Les compétences juridictionnelles dans le cadre du contentieux de l'expropriation pour cause d'utilité publique

L'expropriation pour cause d'utilité publique consiste en une procédure visant l'acquisition de biens immobiliers appartenant à une personne privée, moyennant une indemnité, afin de répondre à un objectif d'intérêt général, à une utilité publique.

Ainsi, cette procédure permet à l'État de porter atteinte au droit de propriété privée.

La Cour européenne des droits de l'homme reconnaît que les pouvoirs publics peuvent recourir à une procédure d'expropriation si celle-ci est reconnue par la loi, qu'elle est d'intérêt général, et que cette ingérence dans le droit de propriété est proportionnée.

L'article 545 du Code civil dispose que :

> *« Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. »*

L'utilité publique est susceptible de se manifester pour plusieurs raisons, par exemple en cas de :

- Risque technologique (art. L. 515-16 du Code de l'environnement).
- Risques naturels majeurs (art. L. 561-1 et suivants du Code de l'environnement).
- Insalubrité et risque pour la santé des occupants d'un immeuble (art. L. 512-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique).

Dès une loi du 8 mars 1810, l'expropriation pour cause d'utilité publique comporte deux phases : une phase administrative et une phase judiciaire.

Phase administrative	**Phase judiciaire**
Les déclarations d'utilité publique et les arrêtés de cessibilité	Le prononcé du transfert de propriété (ordonnance) et l'indemnisation du propriétaire (jugement)
Contrôle par le juge administratif	Compétence du juge judiciaire
- Contrôle des règles de compétence et de procédure : il contrôle par exemple le but poursuivi pour s'assurer qu'il est d'utilité publique ; il opère une mise en balance des avantages et des inconvénients par la théorie dite « théorie du bilan ».	- En l'absence de cession amiable, le transfert de propriété doit être prononcé par le juge judiciaire (art. L. 220-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique).

3.2. La compétence juridictionnelle en cas de voie de fait

La compétence du juge judiciaire en cas de voie de fait est une expression de la compétence du juge judiciaire pour connaître des atteintes aux droits humains par l'administration.

Avant 2013, la voie de fait permettait de déroger à la compétence du juge administratif au profit du juge judiciaire en cas d'atteinte à une liberté fondamentale ou à l'extinction d'un droit de propriété émanant d'une autorité administrative, dont la décision était manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir de l'administration. En outre, la voie de fait pouvait se caractériser par une exécution forcée dans des conditions irrégulières portant atteinte à une liberté ou un droit de propriété. Dans cette situation, l'action perd sa qualification d'acte administratif.

> → T. confl., 23 octobre 2000, *Préfet de police c. M. Boussadar*, n° 03227.

En matière de voie de fait, le juge judiciaire peut enjoindre l'administration de mettre fin à l'atteinte aux droits humains, et assurer la réparation des préjudices subis à cause de l'autorité administrative.

L'étendue du champ d'application de la voie de fait a été restreint par une décision du Tribunal des conflits de 2013.

Désormais, la voie de fait se caractérise :

- Soit par une exécution forcée irrégulièrement prise ou une décision portant atteinte à la liberté individuelle ou qui éteint un droit de propriété. (*Passage d'une atteinte grave à une liberté fondamentale à une atteinte grave à la liberté individuelle, ce qui resserre son champ d'application*.)
- Soit par une décision qui a les mêmes effets et qui n'est manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir de l'administration.

→ T. confl., 17 juin 2013, Bergoend c. Société ERDF Annecy Léman, n° C3911.

Ainsi, en 2019, la Cour de cassation a affirmé :

> *« En l'absence de voie de fait, il n'appartient pas au juge judiciaire d'enjoindre à l'administration de déclasser un bien ayant fait par erreur l'objet d'une décision de classement dans la voirie communale, et qu'un tel classement, bien qu'illégal, n'est constitutif d'une voie de fait que s'il procède d'un acte manifestement insusceptible de se rattacher à l'un des pouvoirs de l'administration »* (Cass. civ. 3e, 16 mai 2019, n° 17-26.210).

Ce rétrécissement de l'étendue de la voie de fait emporte donc plusieurs conséquences :

- La voie de fait ne concerne plus toute liberté fondamentale, mais seulement la liberté individuelle et à l'extinction du droit de propriété.
- La voie de fait réduit le champ de compétence du juge judiciaire en redonnant compétence au juge administratif pour connaître des autres atteintes aux libertés fondamentales à une autorité administrative.

Ce rétrécissement de l'étendue de la voie de fait a pour justification la création en 2000 de référés devant le juge administratif, dont le référé-liberté qui permet la sauvegarde d'une liberté fondamentale en cas d'atteinte manifestement grave et illégale.

→ Loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives.

3.3. L'emprise irrégulière

Une emprise est irrégulière lorsque l'administration porte une atteinte irrégulière au droit de propriété immobilière par la prise de possession temporaire ou définitive.

S'agissant de la répartition des compétences juridictionnelles pour connaître des demandes d'indemnisation du préjudice résultant d'une emprise irrégulière, le Tribunal des conflits a affirmé que :

> *« Dans le cas d'une décision administrative portant atteinte à la propriété privée, le juge administratif, compétent pour statuer sur le recours en annulation d'une telle décision et, le cas échéant, pour adresser des injonctions à l'administration, l'est également pour connaître de conclusions tendant à la réparation des conséquences dommageables de cette décision administrative, hormis le cas où elle aurait pour effet l'extinction du droit de propriété »* (T. confl., 9 décembre 2013, *Pannizon c. commune de Saint-Palais-sur-Mer*, n° C3931).

3.4. Le contentieux de la reconduite des étrangers à la frontière

Si le juge judiciaire est le gardien de la liberté individuelle, il demeure une exception concernant le contentieux de la reconduite des étrangers à la frontière.

En effet, par une décision de 1989, le juge constitutionnel a affirmé que *« conformément à la conception française de la séparation des pouvoirs »*, les recours exercés contre des arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ne doivent pas relever de la compétence du juge judiciaire, mais de la compétence du juge administratif, avec les termes suivants :

« À l'exception des matières réservées par nature à l'autorité judiciaire, relève en dernier ressort de la compétence de la juridiction administrative l'annulation ou la réformation des décisions prises, dans l'exercice des prérogatives

de puissance publique, par les autorités exerçant le pouvoir exécutif, leurs agents, les collectivités territoriales de la République ou les organismes publics placés sous leur autorité ou leur contrôle. »

→ Cons. const., déc. n° 89-261 DC, 28 juillet 1989, *Loi relative aux conditions de séjour et d'entrée des étrangers en France.*

POUR ALLER PLUS LOIN

Par un arrêt du 13 décembre 2012, De Souza Ribeiro contre France, la Cour européenne des droits de l'homme a condamné la France dans le cadre d'une affaire portant sur la reconduite d'une personne étrangère à la frontière. Dans cette affaire, une décision de reconduite à la frontière a été exécutée dans l'heure qui a suivi l'exercice de son recours, ce qui a rendu son recours inopérant. La Cour a dès lors constaté une violation combinée de l'article 13 (droit à un recours effectif) et de l'article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des droits de l'homme.

4. Le juge judiciaire et les actes administratifs

En 1923, le Tribunal des conflits rend une décision importante relative à l'interprétation d'actes administratifs par le juge judiciaire. Il rappelle que le juge judiciaire ne peut pas contrôler la légalité d'un acte administratif réglementaire, mais qu'il peut en interpréter un. En revanche, il ne peut pas interpréter les actes administratifs individuels, sauf s'il est parfaitement clair Si l'acte administratif individuel n'est pas parfaitement clair, le juge judiciaire doit poser une question préjudicielle au juge administratif.

→ T. confl., 16 juin 1923, *Septfonds*, n° 00732.

Sans que le contrôle de légalité des actes administratifs par le juge administratif ne soit remis en cause, une décision de 2011 apporte une exception à ce principe.

Le Tribunal des conflits a affirmé la compétence du juge judiciaire non répressif en cas de contestation visant à écarter la validité d'un acte administratif afin d'assurer l'effectivité du droit communautaire, sans avoir à poser une question préjudicielle au juge administratif.

→ T. confl., 17 octobre 2011, *SCEA du Chéneau c. INAPORC, M. Cherel et a. c. CNIEL*, n° C3828-3829.

La portée de cette décision s'est rapidement manifestée par une décision rendue deux mois plus tard par le Tribunal des conflits. Ce dernier affirme que le juge judiciaire, au regard du principe de non-rétroactivité des actes administratifs, est compétent pour trancher ce type de contestations.

→ T. confl., 12 décembre 2011, *Société Green Yellow et a. c. Electricité de France*, n° C3841.

De plus, s'agissant de l'interprétation d'actes administratifs par le juge judiciaire répressif par voie d'exception, le Code pénal prévoit une dérogation au principe de séparation des autorités en son article 111-5 que :

« Les juridictions pénales sont compétentes pour interpréter les actes administratifs, réglementaires ou individuels et pour en apprécier la légalité lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis. »

POUR S'ENTRAÎNER

Dissertation : L'autorité judiciaire est-elle la gardienne de la propriété privée immobilière ?

Lors de la Révolution française, le droit de propriété apparaît en rupture avec le système féodal de l'Ancien Régime, dans la perspective d'éviter les expropriations arbitraires.

Il est reconnu par plusieurs socles textuels : art. 2 et 17 de la Déclaration de 1789 ; art. 1er du protocole nº 1 additionnel à la Convention européenne ; art. 17 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; art. 544 du Code civil. Il n'apparaît pas dans les pactes de 1966.

Pour des raisons d'intérêt général, l'autorité administrative peut légalement porter atteinte au droit de propriété immobilière (expropriation d'utilité publique). Il arrive que l'autorité administrative y porte illégalement atteinte (voie de fait, emprise irrégulière).

Le Titre VIII de la Constitution est consacré à l'autorité judiciaire (art. 64 à 66-1).

L'arrêt Blanco rendu par le Tribunal des conflits en 1873 semblait apporté une solution claire : en cas de dommage causé dans le cadre du fonctionnement du service public, les règles applicables sont dérogatoires de celles inscrites dans le Code civil, des règles exorbitantes du droit commun.

La répartition des compétences entre l'autorité judiciaire et l'autorité administrative n'est pas si limpide, il existe des dérogations.

Problématique et annonce du plan : L'autorité judiciaire assure en principe la protection de la propriété immobilière **(I)**, l'évolution de la répartition des compétences juridictionnelles en la matière tend à atténuer ce principe **(II)**.

I. L'affirmation du principe de la protection de la propriété immobilière par l'autorité judiciaire

A. La protection de la propriété immobilière par le juge judiciaire

T. confl., 18 décembre 1947, *Hilaire : « La sauvegarde de la liberté individuelle et la protection de la propriété privée rentrent essentiellement dans les attributions de l'autorité judiciaire. »*

Cons. const., nº 89-256 DC, 25 juillet 1989 : *« En tout état de cause, n'est pas méconnue l'importance des attributions conférées à l'autorité judiciaire en matière de protection de la propriété immobilière par les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. »*

B. Une dérogation au principe de séparation des autorités

Séparation des autorités administratives et judiciaires : loi des 16 et 24 août 1790 et loi du 16 fructidor an III de 1795 → justification par la séparation des pouvoirs.

Le juge judiciaire a longtemps été seul compétent pour connaître des voies de fait (dont le champ d'application était plus étendu avant 2013), ce qui constitue une dérogation au principe de séparation des autorités.

II. Les atténuations du principe de la protection de la propriété immobilière par l'autorité judiciaire

A. Les mutations jurisprudentielles de cette protection juridictionnelle

Deux décisions du Tribunal des conflits rendues la même année ont atténué le principe :

La décision *Bergoend c. Société ERDF Annecy Léman*, du 17 juin 2013 : relative à une redéfinition plus enserrée de la voie de fait. (Le domaine d'application de la voie de fait a diminué depuis ce rétrécissement.)

La décision *Pannizon c. commune de Saint-Palais-sur-Mer*, du 9 décembre 2013 : relative à l'emprise irrégulière. (Le juge judiciaire ne dispose d'une compétence résiduelle qu'en cas d'extinction d'un droit de propriété.)

B. Le droit de propriété dans le prétoire du juge administratif

Depuis la loi du 30 juin 2000, des procédures de référé existent devant le juge administratif.

Par une ordonnance du 31 mai 2001, *Commune d'Hyères-les-Palmiers*, le Conseil d'État a affirmé que le droit de propriété *« a le caractère d'une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 précité du Code de justice administrative »*.

Par un arrêt du 2 février 2004, *Abdallah*, le Conseil d'État a reconnu l'atteinte au droit de propriété du fait de la reprise d'un terrain cédé à un particulier fondée sur un texte abrogé *« la collectivité départementale de Mayotte doit être regardée comme ayant porté au droit de propriété de M. et Mme X une atteinte grave et manifestement illégale »*.

En 2013, le Conseil d'État a affirmé dans une ordonnance qu'il appartient au juge administratif des référés *« d'enjoindre à l'administration de faire cesser une atteinte grave et manifestement illégale au droit de propriété, lequel a le caractère d'une liberté fondamentale, quand bien même cette atteinte aurait le caractère d'une voie de fait ».*

En conclusion, si l'autorité judiciaire était auparavant la gardienne de la propriété privée immobilière, des évolutions législatives et jurisprudentielles ont atténué cette compétence, laissant au juge administratif une place dans la protection de ce droit.

Fiche nº 20 - LA PROTECTION ADMINISTRATIVE

POINTS CLÉS

- Il revient traditionnellement au juge de régler les différends et de protéger les libertés.
- Cependant, face à certaines défaillances, mais aussi en raison d'une évolution de la mentalité face au contentieux, des voies de règlement extra-juridictionnels des litiges ont émergé.
- Ce sont des moyens offerts par l'administration elle-même, on parle de protection administrative.
- Cette protection émerge soit à l'intérieur de l'administration, notamment par des voies de recours administratifs.
- Surtout, cette protection est réalisée par des organes dédiés : les autorités administratives indépendantes.

PRINCIPALES RÉFÉRENCES

- Article 71-1 de la Constitution de 1958
- Cons. const., décision nº 84-173 DC du 26 juillet 1984, *Loi relative à l'exploitation des services de radio-télévision mis à la disposition du public sur un réseau câblé*

1. L'effectivité des droits sans le juge ?

De plus en plus, une distinction est opérée entre accès au juge et accès au droit. En effet, le recours à la justice n'est plus le seul mode de protection des droits humains.

Depuis plusieurs décennies, d'autres modes de garanties des droits et des libertés se sont développés, mais toujours sous la tutelle de l'autorité étatique. En cela, la protection extra-juridictionnelle s'oppose à des moyens non organisés de défense comme la résistance à l'oppression.

On trouve par exemple la création des autorités administratives indépendantes françaises (AAI) sur le modèle des *agencies* anglo-américaines comme les agences fédérales des États-Unis (on peut citer la CIA, la NASA, …).

Le développement de solutions alternatives au juge s'explique par certaines insuffisances de la justice : coûts de frais de justice, formalisme judiciaire, lenteur des procédures contentieuses sont autant d'arguments qui peuvent détourner le citoyen du juge.

POUR ALLER PLUS LOIN

Le récent et célèbre DOGE (Department of Government Efficiency) aux États-Unis, anciennement dirigé par Elon Musk daepuis sa création par Donald Trump, a notamment pour objectif de réduire considérablement les moyens financiers et humains de ces différentes agences fédérales. Il a également pour mission de « moderniser » les techniques de gouvernance de l'administration fédérale. En France, la proposition de suppression de certaines AAI dans un souci d'économie revient souvent dans les débats.

Hors de tout contentieux, de tout conflit traduit en termes de droit, les droits fondamentaux se voient protégés par des principes politiques et des aménagements institutionnels (à commencer indirectement par la séparation des pouvoirs elle-même). L'encadrement de l'action administrative par certaines procédures et certains pouvoirs constitués permet à l'administration, à son tour, de prendre en compte la protection des libertés dans son action.

Cette double dimension a d'ailleurs été première dans nos systèmes libéraux et n'a cessé d'évoluer et de se complexifier.

Il est parfois paradoxal d'évoquer une protection administrative des libertés lorsqu'on considère que le pouvoir politique ne peut être qu'un pouvoir liberticide.

Ces solutions administratives sont néanmoins apparues comme un moyen de favoriser une nouvelle manière de penser l'administration et ses relations avec les citoyens en permettant une réflexion entre l'administration et des personnalités qualifiées sur des sujets de société (c'est le cas, par exemple, de la Commission consultative des droits de l'homme ou encore de la Commission d'accès aux documents administratifs), ou en matière économique (comme en matière d'énergie par la Commission de régulation de l'énergie).

Il s'agit d'une démarche destinée à rapprocher la fonction administrative du citoyen et à progressivement désengorger le prétoire du juge.

En toute hypothèse, les autorités administratives indépendantes sont un des signes des mutations contemporaines de la notion même de légitimité démocratique : à côté de l'efficacité de la parole judiciaire, la régulation qu'elles offrent autorise une approche plus experte et moins contentieuse.

Cependant, leur légitimité est parfois remise en question. Tantôt opposées au législateur, tantôt au juge, ces autorités souffrent souvent de la critique soulignant leur proximité avec le pouvoir exécutif et donc de leur manque d'impartialité. La critique de son immixtion dans un domaine réservé au pouvoir politique est récurrente.

Aujourd'hui, il existe même des recours préalables obligatoires devant certaines administrations ordinaires.

2. La protection au sein des administrations elles-mêmes

Les personnes qui considèrent que leurs droits et leurs libertés ont été atteintes peuvent utiliser des moyens non juridictionnels pour faire entendre leurs revendications par le biais du recours préalable. De plus, des acteurs particuliers de l'administration jouent un rôle particulier en matière de protection des libertés.

2.1. Les voies de recours consacrées : le recours administratif préalable

Il existe des voies de recours non juridictionnelles destinées à remettre en cause les décisions prises par l'administration. Les recours n'appelant pas l'intervention du juge sont le recours administratif et le recours hiérarchique.

Le premier recours administratif est le recours gracieux. Il s'agit de présenter un recours à l'autorité qui a pris la décision contestée en précisant pourquoi elle doit réexaminer la décision en question.

L'objectif pour le demandeur est d'obtenir une révision de la décision initiale en motivant sa demande sur des motifs de fait, de droit ou d'opportunité.

Le second recours administratif est le recours hiérarchique. Il ne s'agit nullement de s'adresser directement à l'autorité qui a pris la décision, mais de saisir son supérieur hiérarchique afin de lui demander de revenir sur l'acte de son subordonné.

Dans ces deux cas, le recours administratif préalable est fondé sur la discussion et la conciliation plutôt que sur la coercition du juge. Il s'agit d'un moyen intéressant de défendre les droits et les libertés sans avoir obligatoirement recours au juge administratif.

À cet effet, le Conseil d'État estime à propos de ces recours que :

« Il s'agit de rechercher, en droit et en opportunité comme en équité, une solution qui satisfasse à la fois les intérêts de l'administration et ceux de l'administré » (Étude du Conseil d'État, Régler autrement les conflits : conciliation, transaction, arbitrage en matière administrative, 1993.)

POUR ALLER PLUS LOIN

Dans de nombreux domaines touchant aux droits et aux libertés, les recours administratifs préalables comme le recours gracieux ou hiérarchique sont obligatoires avant toute saisine du juge. On parle alors de recours administratif préalable obligatoire (RAPO).

Par exemple, le justiciable doit saisir l'administration à l'origine de la décision contestée avant de saisir le juge pour exercer son droit à la communication des documents administratifs (art. L. 342-1 du CRPA). De même, un RAPO doit être exercé dans le cadre des contentieux sociaux (personnes handicapées pour la MPDH).

Cependant, l'efficacité de cette procédure doit être nuancée, car le réexamen par l'administration est souvent superficiel voire pas réalisé du tout. Cela s'explique par un manque de temps de l'administration pour procéder à un réexamen complet de la situation, mais aussi par une méconnaissance de l'utilité du recours administratif qui s'inscrit comme un droit des administrés à voir leur demande traitée de manière effective.

2.2. Un agent de l'administration protecteur : l'inspecteur du travail

L'inspecteur du travail assure une compétence fondamentale en matière de protection des droits et des libertés du salarié.

À ce titre, il dispose de pouvoirs importants comme le fait d'exiger le retrait ou la modification d'une disposition du règlement intérieur de l'entreprise qui apporterait des restrictions aux droits et libertés des salariés non justifiées par la nature des tâches à accomplir.

→ Art. L. 1322-1 du Code du travail.

Il peut également prendre toute mesure utile pour préserver la santé ou la sécurité du salarié en le soustrayant d'une situation de danger grave et imminent, notamment en prescrivant l'arrêt de l'activité. Il peut aussi constater des infractions dans la relation de travail.

→ Art. L. 8112-1 du Code du travail.

3. La Commission nationale consultative des droits de l'homme (CNCDH)

Le choix est fait de placer la CNCDH en dehors des autorités administratives indépendantes en raison de sa proximité historique et particulière avec le Gouvernement.

En effet, le Gouvernement dispose d'un organe de conseil et de proposition en matière de droits humains à savoir la Commission nationale consultative des droits de l'Homme dont l'existence est consacrée par la loi n° 2007-292 du 5 mars 2007.

Il s'agit d'une institution de protection et de promotion des droits humains en France. Elle exerce sa mission en toute indépendance puisque la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 précise que la Commission ne reçoit ni ne sollicite d'instruction d'aucune autorité administrative ou gouvernementale.

Elle a pour mission d'assister le Premier ministre et les ministres intéressés par ses avis sur toutes les questions de portée générale relevant des droits et libertés tant sur le plan national qu'international. Elle peut, de sa propre initiative, appeler publiquement l'attention du Parlement et du Gouvernement sur les mesures qui lui paraissent de nature à favoriser la protection et la promotion des droits de l'Homme.

À titre d'exemple, la Commission a rendu certains avis concernant l'état d'urgence, la situation des familles françaises de djihadistes en Syrie, la toxicomanie, le droit de vote des personnes en situation de handicap, l'université…

4. La protection par des autorités administratives indépendantes

Avant d'envisager la protection par les AAI, il convient de tenter d'apporter une définition à celle-ci. Cette définition est compliquée du fait de la multiplicité d'AAI, mais une distinction majeure peut être retenue entre le Défenseur des droits, seule AAI constitutionnellement prévue, et les autres AAI dont l'apport à la protection des libertés est plus sectoriel.

Dans un rapport rédigé au nom d'une commission d'enquête du Sénat, les sénateurs Dosière et Vanneste ont mis en lumière la grande hétérogénéité des AAI et l'absence de définition et de cadre juridique communs : ils estiment que les contours de la notion sont entachés d'un défaut de précision.

4.1. L'ébauche d'une définition générale de la protection administrative

Il n'existe pas de définition unique de la notion de protection administrative tant il existe une multiplicité d'organes chargés d'y veiller. Dans un rapport de 2001, le Conseil d'État recensait 34 autorités administratives indépendantes différentes tout en mettant en exergue l'hétérogénéité de leurs pouvoirs et de leurs statuts.

Cependant, il est possible de dégager des traits communs entre ces organes afin d'en donner une définition globale.

La notion d'autorité administrative indépendante répond à trois conditions cumulatives.

- Il s'agit d'une autorité. À ce titre, elle dispose de pouvoirs comme celui d'infliger des sanctions ou de faire des recommandations.
- Il s'agit d'une autorité administrative. Elle agit de ce fait au nom de l'État et dans le cadre des règles fixées par celui-ci.
- C'est une autorité administrative indépendante. Par conséquent, elle doit être placée hors de l'appareil administratif c'est-à-dire qu'elle ne doit pas être soumise à l'autorité hiérarchique du pouvoir exécutif.

Enfin et surtout, si les règles de fonctionnement et leur statut sont flous, il est possible de s'accorder sur le fait que seul le législateur est compétent pour les créer, notamment lorsqu'elles exercent une attribution qui constitue une garantie fondamentale pour l'exercice d'une liberté publique.

> *« Considérant que la désignation d'une autorité administrative indépendante du Gouvernement pour exercer une attribution aussi importante au regard de la liberté de communication que celle d'autoriser l'exploitation du service radio-télévision mis à la disposition du public sur un réseau câblé constitue une garantie fondamentale pour l'exercice d'une liberté publique et relève de la compétence exclusive du législateur »* (Cons. const., déc. n° 84-173 DC, 6 juillet 1984, *Loi relative à l'exploitation des services de radio-télévision mis à la disposition du public sur un réseau câblé*).

Il convient d'écarter ici les autorités n'ayant pas pour mission principale la garantie des libertés publiques, notamment celles intervenant en matière économique.

Si l'on s'en tient uniquement aux autorités intervenant dans le champ des libertés, il est possible de retenir celles ayant un statut constitutionnel et d'autres plus sectorielles.

4.2. Le Défenseur des droits, autorité constitutionnelle et générale

Avant d'évoquer en détail le statut actuel du Défenseur des droits, il est important de rappeler que cette nouvelle institution n'est pas nouvelle et qu'elle succède au Médiateur pour la République.

4.2.1. L'ancêtre du Défenseur des droits, le Médiateur pour la République

Le Défenseur des droits regroupe les missions autrefois dévolues à plusieurs autorités : le Médiateur pour la République, le Défenseur des enfants, la Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l'Egalité (HALDE) et la commission Nationale de Déontologie de la Sécurité (CNDS).

Le Médiateur pour la République avait une compétence très large puisqu'il recevait les réclamations concernant, dans les relations avec les administrés, le fonctionnement des administrations de l'État, des collectivités

territoriales ou de tout organisme, public ou privé, chargé d'une mission de service public. En résumé, il disposait d'une compétence pour traiter les maux des administrations et leurs dysfonctionnements.

Il disposait d'une grande autorité morale, à ce titre, il pouvait faire des recommandations et des propositions afin de régler les difficultés et les différends, mais ces mesures ne disposaient pas d'une réelle force juridique contraignante.

4.2.2. La consécration constitutionnelle d'une autorité indépendante

La révision de la Constitution de 2008 a inséré un nouvel article 71-1 dans la Constitution de 1985 afin de donner naissance à une institution qualifiée d'autorité constitutionnelle indépendante, le Défenseur des droits.

Le régime juridique de cette nouvelle autorité est déterminé par la loi organique modifiée n° 2011-333 du 29 mars 2011 et la loi n° 2011-334 du même jour.

Cette création s'appuie sur les réflexions menées par le Comité Balladur sur la Constitution de la Vème République. Ce dernier suggérait de remettre de l'ordre dans les institutions chargées d'une mission de défense des droits fondamentaux afin de renforcer la lisibilité de leur action, leur cohérence et leur efficacité.

Le Défenseur des droits est nommé par le président de la République, selon la procédure de nomination des hauts fonctionnaires désormais prévue à l'article 13 alinéa 5 de la Constitution, c'est-à-dire après une audition par les commissions permanentes respectives des assemblées parlementaires.

POUR ALLER PLUS LOIN

L'article 13 alinéa 5 de la Constitution prévoit une nouvelle procédure de nomination par le président de la République à certaines fonctions en raison de l'importance de celles-ci sur les libertés et les droits garantis ou sur la vie économique et sociale de la Nation. Cette procédure est semblable aux auditions sénatoriales aux États-Unis, notamment pour les nominations à la Cour suprême.

La nomination ne peut intervenir qu'après une audition et un vote des commissions permanentes du Sénat et de l'Assemblée nationale. La nomination est bloquée si 3/5 des suffrages exprimés s'opposent à celle-ci.

À titre d'exemple, les membres du Conseil constitutionnel sont auditionnés par les commissions des lois des deux assemblées parlementaires. Il en est de même pour le Défenseur des droits ou encore pour le PDG d'EDF.

Le mandat du Défenseur des droits est irrévocable, non renouvelable et long (6 ans) afin de lui garantir la plus grande indépendance. Il est soumis aux règles de non-cumul des fonctions et, à ce titre, il ne saurait être membre du Gouvernement ou parlementaire.

> → Loi n° 2011-333 du 29 mars 2011, art. 2 : *« Le Défenseur des droits, autorité administrative indépendante, ne reçoit, dans l'exercice de ses attributions, aucune instruction. »*

Cependant, les autorités administratives indépendantes ne sont pas indépendantes à l'égard de la loi puisque le législateur est compétent, en vertu de l'article 34 de la Constitution, pour fixer les règles relatives aux garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés.

En dépit de sa consécration dans le texte constitutionnel, le statut financier du Défenseur des droits ne diffère pas sur ce plan de celui des autres AAI. Ainsi, son autonomie financière n'est pas constitutionnellement protégée et le législateur reste donc libre de modifier les crédits qui lui sont affectés dans les lois de finances votées chaque année, ce qui peut avoir une incidence considérable sur son fonctionnement et son autonomie.

Quant aux missions assurées par le Défenseur des droits, elles sont consacrées par le texte de la Constitution à l'article 71-1 alinéa 1er.

> *« Le Défenseur des droits veille au respect des droits et libertés par les administrations de l'État, les collectivités territoriales, les établissements publics, ainsi que par tout organisme investi d'une mission de service public, ou à l'égard duquel la loi organique lui attribue des compétences. »*

Le défenseur des droits ne dispose pas d'une compétence générale dans le domaine de la défense des droits et libertés. Toutefois, ses compétences sont assez larges : relation entre les administrés et l'administration impliquant l'exercice de libertés, la lutte contre les discriminations, la protection des droits de l'enfant, la déontologie…

Il n'a pas de pouvoir de sanction, mais peut émettre des recommandations à l'égard de l'autorité concernée. Il peut également engager une procédure de médiation ou proposer une transaction aux parties pour régler en équité les litiges.

Il peut être saisi de manière assez large et notamment par des personnes privées, morales et par des associations afin de couvrir un grand nombre de situations possibles au regard des atteintes aux droits.

Si la saisine du défenseur des droits par les parlementaires est possible comme c'était le cas pour le médiateur, toute personne dont les droits ou libertés sont en cause ainsi que ses ayants-droits peuvent saisir directement le Défenseur des droits. Des saisines sont également offertes à d'autres personnes ou organismes : pour le droit des enfants, il s'agit des membres de la famille ou des services médico-sociaux.

La saisine est gratuite et n'interrompt ni ne suspend par elle-même les délais de prescription pénale, civile ou administrative. Le Défenseur des droits apprécie si les faits qui font l'objet d'une réclamation ou qui lui sont signalés appellent une intervention de sa part. Les suites données à une réclamation sont insusceptibles de recours.

> *« Il résulte de ces dispositions que lorsqu'il émet des recommandations, sans faire usage de la faculté dont il dispose de la rendre publique, le Défenseur des droits n'énonce pas des règles qui s'imposeraient aux personnes privées ou aux autorités publiques, mais recommande aux personnes concernées les mesures qui lui semblent de nature à remédier à tout fait ou à toute pratique qu'il estime être discriminatoire, ou à en prévenir le renouvellement. Par suite, ces recommandations, alors même qu'elles auraient une portée générale, ne constituent pas des décisions administratives susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Il en est de même du refus de faire usage des pouvoirs que le Défenseur des droits tient de ces dispositions »* (CE, 22 mai 2019, n° 414410).

Actualité. - Le Défenseur des droits, acteur du contentieux des discriminations

L'action du Défenseur des droits ne se limite pas au traitement extrajuridictionnel des réclamations. Il peut également présenter des observations devant les juridictions afin d'éclairer le juge sur les atteintes aux droits et libertés relevant de ses compétences.

L'affaire *Seydi et autres c. France* en fournit une illustration importante. Saisi de contrôles d'identité dénoncés comme discriminatoires, le Défenseur des droits avait présenté des observations devant la cour d'appel de Paris, puis devant la Cour de cassation et enfin devant la Cour européenne des droits de l'homme. En 2025, celle-ci a considéré que l'un des six requérants avait subi un contrôle d'identité discriminatoire en raison de son origine, en violation de l'article 14 combiné avec l'article 8 de la Convention.

→ CEDH, 26 juin 2025, *Seydi et autres c. France*, n° 35844/17.

À retenir : La protection administrative et la protection juridictionnelle ne sont pas étanches. Sans se substituer au juge, le Défenseur des droits peut contribuer à l'établissement et à la qualification d'une atteinte aux droits fondamentaux par ses enquêtes, ses décisions et les observations qu'il présente devant les juridictions nationales ou européennes.

4.3. La protection par des autorités administratives indépendantes sectorielles

Sur le fondement du dernier alinéa de l'article 34 de la Constitution, le législateur organique a réservé au législateur ordinaire la compétence pour instituer les AAI et pour fixer des règles relatives à la composition et aux attributions ainsi que les principes fondamentaux relatifs à l'organisation et au fonctionnement des AAI et API.

On peut envisager trois autorités sectorielles très actives dans le domaine des libertés. On pense ainsi au contrôleur général des lieux de privation de libertés, à la Commission nationale de l'informatique et des libertés et au Conseil supérieur de l'audiovisuel.

4.3.1. Le Contrôleur général des lieux de privation de libertés

Le Contrôleur général des lieux de privation de libertés est une AII instituée par la loi du 30 octobre 2007 pour assurer la mise en œuvre du protocole additionnel à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En vertu de ce dernier, les États ont l'obligation de prévoir un mécanisme indépendant chargé d'examiner régulièrement la situation des personnes privées de liberté se trouvant dans des lieux de détention.

Le Contrôleur a pour mission de contrôler les conditions de prise en charge et de transfèrement des personnes privées de liberté afin d'assurer le respect de leurs droits fondamentaux. Son champ d'intervention concerne l'ensemble des lieux de privation de liberté dont les établissements pénitentiaires, mais également les locaux de garde à vue, les centres éducatifs fermés et les établissements de santé.

Il dispose d'un droit de visite et peut se voir transmettre toute pièce ou information utile à sa mission. Au terme de chaque visite, il établit un rapport et formule des observations.

4.3.2. La Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL)

Créée par la loi du 17 juillet 1978, la Commission nationale de l'informatique et des libertés joue un rôle central dans la protection des personnes et en particulier de leur vie privée face aux dispositifs de traitement informatique des données.

Il s'agit d'une institution collégiale composée de 18 membres désignés pour 5 ans parmi des magistrats, des parlementaires et des personnes qualifiées pour leur connaissance du numérique.

Les missions sont très diversifiées : il est à la fois question d'information, de sensibilisation, de certification, d'avis, de règlementation et de sanction. La principale mission de la CNIL est de veiller à ce que les traitements de données personnelles soient opérés selon les normes en vigueur et notamment conformément au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD).

L'article 4 § 2 du règlement général de protection des données définit les traitements comme :

> *« Toute opération ou tout ensemble d'opérations effectuées ou non à l'aide de procédés automatisés et appliquées à des données ou des ensembles de données à caractère personnel, telles que la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la structuration, la conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, la limitation, l'effacement ou la destruction. »*

La Commission possède une compétence effective en matière de protection des droits et des libertés, notamment concernant le respect du droit à la vie privée. Sa mission est particulièrement nécessaire dans des domaines sensibles comme la protection des fichiers relatifs aux mineurs, aux données biométriques, génétiques ou de santé.

4.3.3. L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM)

L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique est née de la fusion du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de l'HADOPI le 1er janvier 2022. Elle est composée de neuf membres : le président est nommé par le président de la République, trois membres par le président du Sénat, trois par le président de l'Assemblée

nationale, un membre par le vice-président du Conseil d'État et un membre par le premier président de la Cour de cassation.

Il lui incombe de garantir l'exercice de la liberté de communication audiovisuelle, de contribuer aux actions en faveur de la lutte contre les discriminations dans le domaine de l'audiovisuel ou encore d'assurer le respect des droits des femmes ou de veiller au respect de l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion dans les programmes des services de radio et de télévision.

L'Autorité dispose de pouvoirs plus étendus que l'ancien Conseil supérieur de l'audiovisuel puisqu'il peut mener des procédures de conciliation. Elle dispose de pouvoirs d'enquête et de sanctions financières. Elle peut prononcer la suspension de la diffusion d'une certaine catégorie de programme ou d'une ou plusieurs séquences publicitaires pour un mois au plus ou une sanction pécuniaire voire le retrait de l'autorisation d'émettre.

POUR ALLER PLUS LOIN

Récemment, l'actualité a mis en lumière l'action de l'ARCOM, notamment dans la fermeture des chaînes C8 et NRJ12. L'ARCOM a infligé une sanction de 200 000 euros à CNews à raison des propos tenus par Éric Zemmour au sujet des mineurs étrangers isolés (CSA, décision n° 2021-218 du 17 mars 2021). De même, dans une décision du 29 mai 2024, la chaine C8 a été condamnée à une sanction pécuniaire de 50 000 euros du fait d'une atteinte à la vie privée.

Surtout, l'ARCOM a décidé de ne pas renouveler les fréquences attribuées aux chaines C8 et NRJ12 ce qui a valu leur fermeture en 2025. Après plusieurs recours, le Conseil d'État « dans ces conditions, au vu de l'ensemble des caractéristiques des projets qui lui ont été présentés et compte tenu des différents impératifs et critères énoncés par la loi, l'Arcom a pu légalement estimer que les candidatures de C8 et NRJ 12 étaient moins à même que les onze projets qu'elle a retenus, notamment ceux des chaînes CMI TV, OFTV, TFX, TMC et W9, seuls contestés par les sociétés requérantes, de contribuer au pluralisme des courants d'expression socio-culturels et de répondre à l'intérêt du public » (CE, 19 février 2025, NRJ12 et C8, n° 499823).

POUR S'ENTRAÎNER

Dissertation : La protection des libertés par les autorités administratives indépendantes

L'État de droit repose sur un équilibre subtil entre l'efficacité de l'action publique et la garantie des droits fondamentaux. Traditionnellement, cet équilibre repose sur la séparation des pouvoirs prévue à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et sur la soumission de l'administration au contrôle du juge en vertu de la hiérarchie des normes.

Cependant, progressivement, des moyens non juridictionnels de règlement des litiges et de protection des libertés se sont mis en place au sein de l'appareil étatique. Dans ce contexte, les autorités administratives indépendantes constituent une catégorie originale d'institutions administratives : ni gouvernementales ni juridictionnelles, elles incarnent un modèle de régulation autonome, souvent à la frontière du pouvoir exécutif et des exigences d'impartialité.

En effet, nombre d'entre elles œuvrent à la protection des droits du citoyen. D'ailleurs, il revient au législateur, selon l'article 34 de la Constitution, de créer des autorités voire d'en modifier le régime et le statut.

Leur développement s'est accéléré depuis les années 1980, sous l'effet de la montée des exigences démocratiques, de la complexité croissante des régulations sectorielles (communications, finances, concurrence…), et d'une défiance relative à l'égard des pouvoirs traditionnels. Les libertés publiques – liberté d'expression, de communication, de concurrence, droit à la vie privée… – se trouvent au cœur de leur champ d'action.

Toutes les autorités administratives indépendantes n'œuvrent pas à la protection des libertés et certaines sont uniquement des organes de régulation économique ou administrative. Il convient de les écarter de l'étude. D'autres autorités connaissant des libertés sont plus sectorielles, mais leur apport n'en est pas moins fondamental.

Problématique / fil directeur : Dès lors, dans quelle mesure les autorités administratives indépendantes contribuent-elles à la garantie des libertés fondamentales, sans elles-mêmes constituer une menace pour ces libertés du fait de leur statut original et de leurs pouvoirs parfois considérables ?

Annonce du plan : Si les autorités administratives indépendantes ont été conçues comme des instruments garantissant les libertés, leur intervention soulève néanmoins des questions de légitimité démocratique et de respect des principes de l'État de droit.

I. Les autorités administratives indépendantes comme instruments de protection et de promotion des libertés

A. Une mission de régulation protectrice des droits malgré une hétérogénéité

Les autorités administratives indépendantes ont souvent pour une mission plus ou moins explicite de protection des libertés fondamentales malgré le fait qu'elles soient hétérogènes. D'ailleurs, il est prévu qu'il revienne à la loi, en vertu de l'article 34 de la Constitution, le soin d'en déterminer le régime lorsqu'elles

garantissent les libertés (Cons. const., décision n° 84-173 DC, 26 juillet 1984, *Loi relative à l'exploitation des services de radio-télévision mis à la disposition du public sur un réseau câblé*).

On pense alors à :

- La **Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL)**, chargée depuis 1978 de protéger la vie privée face aux traitements automatisés de données à caractère personnel. Elle veille aujourd'hui à l'application du RGPD.
- Le **Défenseur des droits**, né de la révision constitutionnelle de 2008 et institué par la loi organique de 2011, qui veille au respect des droits des administrés, y compris dans des domaines sensibles comme la déontologie de la sécurité ou de lutte contre les discriminations.
- Le **Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA)** devenu **ARCOM** (Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique), garantissant la liberté de communication audiovisuelle et la pluralité des opinions.

Ces autorités s'inscrivent dans une logique de contre-pouvoir administratif, au service des libertés individuelles et collectives.

B. Une indépendance au service de l'impartialité et de la neutralité

L'indépendance organique des AAI par rapport au pouvoir exécutif – garantie par des règles de nomination spécifiques et des conditions de révocation strictes – vise à renforcer leur crédibilité dans la protection des libertés.

Leur indépendance permet une distance critique vis-à-vis des intérêts politiques ou économiques. Cela renforce la confiance des citoyens dans les mécanismes de régulation et de protection de leurs droits. Par exemple, les décisions de la CNIL, même si elles ne sont pas juridictionnelles, peuvent avoir des effets comparables à ceux d'une sanction judiciaire.

Par exemple, le mandat du Défenseur des droits est irrévocable, non renouvelable et long (6 ans) afin de lui garantir la plus grande indépendance. Il est soumis aux règles de non-cumul des fonctions et à ce titre, il ne saurait être membre du Gouvernement ou parlementaire.

II. Une protection des libertés parfois ambiguë

A. Des pouvoirs croissants pouvant restreindre les libertés

Les autorités administratives indépendantes disposent souvent de pouvoirs normatifs, de contrôle, et de sanction significative, ce qui peut conduire à des atteintes aux libertés fondamentales si ces pouvoirs ne sont pas encadrés. C'est notamment pour cela que le Conseil d'État a accepté de contrôler les actes de droit souple de ces autorités (CE, 2016, *Fairvesta et Numéricable*) :

- L'ARCOM peut, par exemple, ordonner le blocage de sites internet, avec des conséquences importantes sur la liberté d'expression. Cela a notamment été l'objet de débat lors de la fermeture de la chaîne de télévision C8 (CE, 19 février 2025, *NRJ12 et C8,* n° 499823).
- L'Autorité de la concurrence peut infliger des amendes très lourdes à des entreprises, ce qui interroge la régularité de ces sanctions au regard du respect des droits de la défense.

Ainsi, bien qu'indépendantes, les autorités exercent parfois des prérogatives de puissance publique**,** y compris en matière répressive, sans disposer de toutes les garanties associées à une juridiction (principe du contradictoire, impartialité…).

B. Une légitimité démocratique et un contrôle juridictionnel parfois insuffisants

Le déficit démocratique des autorités administratives indépendantes est souvent critiqué : leurs membres ne sont pas élus, et leur légitimité repose principalement sur leur expertise. Cette situation peut susciter des tensions dans un régime fondé sur la souveraineté populaire.

Le Conseil constitutionnel a encadré à plusieurs reprises les pouvoirs des AAI, notamment dans la décision n° 89-260 DC du 28 juillet 1989, posant des exigences sur la séparation des fonctions et le respect des principes constitutionnels (droit à un recours juridictionnel effectif, droits de la défense…). Il a jugé que l'exercice du pouvoir de sanction doit être encadré et qu'il revient à la loi d'en déterminer les modalités.

Le contrôle juridictionnel exercé par les juges est essentiel, mais parfois complexe, car les autorités administratives indépendantes échappent à la classification traditionnelle des autorités publiques. Le Conseil d'État a dû adapter sa jurisprudence à cette forme particulière d'administration.

En conclusion, les AAI se sont affirmées comme des institutions fondamentales de la protection des droits en raison du développement de leurs missions. Cependant, des clarifications sur leur rôle vis-à-vis du pouvoir exécutif et du juge méritent d'être réalisées.

PARTIE V. LES MÉCANISMES INTERNATIONAUX ET EUROPÉENS DE PROTECTION

FICHE N° 21

Les Comités onusiens

FICHE N° 22

La Cour européenne des droits de l'homme

FICHE N° 23

La Cour de justice de l'Union européenne

FICHE N° 24

Les autres juridictions régionales

FICHE N° 25

La protection politique et administrative internationale

Fiche nº 21 - LES COMITÉS ONUSIENS

POINTS CLÉS

- Contrôle de l'application des traités.
- Observations générales.
- Rapports périodiques.
- Communications individuelles et fonction quasi-juridictionnelle.
- Communications interétatiques.
- Mesures provisoires.
- Procédure d'enquête.

PRINCIPALES RÉFÉRENCES

- Art. 28-45 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
- Art. 1er- 15 du Protocole facultatif au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.
- Art. 8-16 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale.
- Art. 1er-12 du Protocole facultatif à la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes.
- Art. 17-24 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
- Art. 43-45 de la Convention internationale des droits de l'enfant.
- Art. 72-77 de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.
- Art. 34-39 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées.
- Art. 26-36 de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.

Les comités onusiens (qu'on appelle aussi en anglais les « *treaty bodies* » ou « organes de traité »), sont les organes chargés de surveiller la bonne mise en œuvre par les États parties des neuf principales conventions onusiennes de protection des droits humains (voir Fiche 13).

Ces organes sont institués soit directement par ces conventions après l'énumération des droits qu'elles visent à protéger, soit par le biais d'un protocole facultatif adopté *a posteriori*. Chaque État est alors libre de ratifier ce protocole ou d'émettre une réserve (lorsque permise) aux dispositions conférant certaines compétences à ces comités.

La France a ratifié les 18 conventions onusiennes dont les protocoles reconnaissant la compétence de chaque comité pour exercer certaines fonctions, notamment la possibilité de connaître de communications individuelles.

Plusieurs fonctions sont attribuées à ces comités, prenant principalement appui sur les fonctions reconnues au premier d'entre eux : le Comité des droits de l'homme surveillant la mise en œuvre du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Parmi ces fonctions se trouvent classiquement :

- L'obligation pour les États de remettre un rapport périodique sur la mise en œuvre de la Convention.
- La réception de « communications » interétatiques pour alerter sur des manquements d'autres États.

- La réception de « communications » individuelles pour que les particuliers ou groupes de particuliers puissent formuler une plainte.
- La rédaction d'observations générales (ou recommandations générales) détaillant et expliquant les dispositions de la Convention dont ils contrôlent l'application.

Chaque Comité réalise un rapport annuel de ses activités consultables en ligne.

Malgré la réception de communications individuelles relatives à des atteintes alléguées aux droits des particuliers par les États parties, ces comités ne sont pas des juridictions, mais ont une fonction quasi-juridictionnelle. L'État s'engage de bonne foi à protéger les droits énoncés dans les conventions et à respecter les recommandations et observations du Comité, mais il n'est prévu aucun mécanisme de sanction en cas de non-respect.

1. La multiplication des comités

1.1. Fondements normatifs

Le Comité des droits de l'homme est l'organe chargé de surveiller l'application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques par les États parties, et est institué à l'article 28 de celui-ci, complété par le Protocole facultatif relatif au Pacte.

Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels est l'organe institué par le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et contrôle la bonne application par les États parties des dispositions du Pacte.

Le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale est le comité chargé de contrôler la bonne mise en œuvre de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale et est directement institué par l'article 8 de cette convention.

Le Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes surveille l'application de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Il est institué par l'article 17 de cette Convention et ses fonctions sont complétées par un Protocole facultatif.

Le Comité contre la torture surveille la mise en œuvre de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et est créé par l'article 17 de celle-ci. Le Protocole facultatif y étant relatif complète ses missions par l'élaboration d'un sous-comité.

Le Comité des droits de l'enfant est institué par l'article 43 de la Convention internationale des droits de l'enfant, complété par le troisième Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant établissant une procédure de présentation de communications, adopté le 19 décembre 2011, et contrôle la bonne application de ces dispositions ainsi que de celles des deux autres Protocoles facultatifs à la Convention à savoir le Protocole facultatif à la Convention, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (2000) et le Protocole facultatif à la Convention qui appréhende l'implication d'enfants dans les conflits armés (2000). Le Comité promeut l'application de la Convention dans le respect du principe de l'intérêt supérieur de l'enfant et du respect de ses droits (notamment de son opinion).

Le Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille est créé à l'article 72 de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille qui ne possède pas de protocole facultatif.

Le Comité des droits des personnes handicapées est institué à l'article 34 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Ses fonctions sont précisées par le Protocole facultatif qui complète cette dernière.

Le Comité des disparitions forcées rattaché à la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées est institué par son article 26.

POUR ALLER PLUS LOIN

Attention à ne pas confondre le Comité des droits de l'homme et le Conseil des droits de l'homme. Le Conseil des droits de l'homme est un organe politique et diplomatique réunissant les États membres des Nations unies qui analysent les uns après les autres les progrès et manquements des autres États à la protection internationale des droits humains (Examen Périodique Universel). Cet organe était auparavant appelé Commission des droits de l'homme et a vu son nom et certaines fonctions transformés lorsqu'elle est devenue le Conseil des droits de l'homme dans une réforme de 2006 cherchant à rendre les procédures de l'organe moins opaques et moins politisées.

1.2. La composition des comités

Le Comité contre la torture ainsi que le Comité pour les droits des enfants et le Comité contre les disparitions forcées sont composés de 10 experts.

Le Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes est composé de 23 membres et le Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille est composé de 14 experts.

Les autres comités sont composés de 18 membres.

Ces membres doivent être des ressortissants des États parties à la convention qu'ils protègent et sont élus pour quatre ans. Ils doivent être des « personnalités de haute moralité » et possédant des compétences particulières dans le domaine de la convention et une expérience juridique pertinente. La Convention relative aux droits des personnes handicapées ajoute qu'il est tenu compte de la participation d'experts handicapés.

Ils sont élus par les États parties à chaque instrument, siègent à titre individuel (c'est-à-dire qu'ils ne représentent pas l'État duquel ils sont ressortissants et sont des experts indépendants) et agissent sous le sceau de l'impartialité. Lors de leur élection, il est tenu compte d'une répartition géographique équitable, de la représentation des diverses formes de civilisation ainsi que des principaux systèmes juridiques et d'une répartition équilibrée entre les hommes et les femmes.

À noter : La professeure française Hélène Tigroudja a été élue pour deux mandats successifs au Comité des droits de l'homme (2019-2022 et 2023-2026) et occupe aujourd'hui la fonction de vice-présidente du Comité.

2. L'hétérogénéité fonctionnelle des comités

2.1. Les rapports périodiques

Chaque État partie doit soumettre aux différents comités un « rapport » périodique selon un cycle de plusieurs années ou dès que les comités lui en font la demande, sur *« les mesures qu'ils auront arrêtées et qui donnent effet aux droits reconnus »* dans les différentes conventions, qu'elles soient d'ordre législatif, judiciaire, administratif ou autre, et *« sur les progrès réalisés dans la jouissance de ces droits »* (art. 40-1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques).

Ces rapports, spécifiques à chacune de ces conventions, sont examinés par les Comités, qui peuvent demander aux États parties des informations complémentaires avant de proposer à leur tour à l'État des observations et recommandations concernant la situation des droits humains (appelées observations finales).

Certains comités, notamment le Comité des droits des personnes handicapées et le Comité des droits de l'enfant, peuvent également demander des rapports sur la mise en œuvre des dispositions de leur convention aux institutions spécialisées ainsi que transmettre les demandes d'assistance des États aux organismes compétents.

2.2. Les communications interétatiques

Toutes les conventions prévoient un mécanisme de communications interétatiques qui permettent le signalement d'une situation d'atteinte aux droits protégés par un autre État partie, soumis à une reconnaissance de cette compétence par les États parties.

La communication est adressée au Comité puis transmise à l'État défendeur qui doit alors fournir des explications et éclaircissements sur la situation en cause à l'État partie, auteur de la communication. Le Comité intervient alors dans le cas où la situation n'est pas réglée par ce dialogue interétatique.

Dans ce cas, il rédige un rapport dans lequel il inclut des observations et recommandations concernant le respect des dispositions de protection des droits humains le cas échéant. Un suivi de la situation est organisé par les Comités.

2.3. Les communications individuelles

La faculté de recevoir des communications individuelles constitue la fonction quasi-contentieuse des comités. Si cette fonction n'est pas mentionnée directement dans la Convention, elle fait l'objet d'un Protocole facultatif se rapportant à celle-ci et soumise à l'acceptation des États.

Cette compétence comprend la réception et l'examen de communications émanant de particuliers ou de groupes de particuliers qui se prétendent victimes d'une violation des dispositions protégées par la convention de rattachement, et relevant de la juridiction d'un État y ayant adhéré.

Plusieurs critères de recevabilité sont mentionnés :

- La requête n'est pas anonyme.
- La requête ne constitue pas un abus de droit ou n'est pas incompatibles avec les dispositions de la convention.
- Il n'y a pas de situation de litispendance devant un autre organe international.
- Les voies de recours internes sont épuisées (sauf en cas de délais excessifs de traitement de l'affaire).
- Les faits doivent être postérieurs à l'acceptation de la compétence du comité par l'État.

D'autres critères sont ajoutés par certains comités, mais sont généralement admis par tous :

- La communication doit être faite dans un délai d'un an après l'épuisement des voies de recours internes (pour le Comité des droits économiques, sociaux et culturels et le Comité des droits de l'enfant).
- L'atteinte doit faire naître un « désavantage notable » (pour le Comité des droits économiques, sociaux et culturels).
- La requête doit être présentée par écrit (spécifié par le Comité des droits de l'enfant).
- La requête ne doit pas être manifestement mal fondée ou insuffisamment motivée (pour le Comité des droits des personnes handicapées).

Les Comités peuvent également demander à l'État partie la mise en place de mesures provisoires *« dans des circonstances exceptionnelles pour éviter qu'un éventuel préjudice irréparable ne soit causé à la victime ou aux victimes de la violation présumée »*. Elles ne préjugent en rien de l'issue de l'affaire en cause.

Une fois la communication reçue, le Comité transmet la notification à l'État défendeur qui doit fournir des explications ou déclarations éclaircissant la question et indiquant, le cas échéant, les mesures qu'il pourrait prendre pour remédier à la situation. Dans le cas où le règlement amiable n'est pas atteint, le Comité procède à l'examen de la requête et rend des « constatations » à l'État partie et aux personnes requérantes, accompagnées de ses observations et recommandations. Voir à titre d'exemple la constatation dans laquelle la France a été condamnée sur le fondement d'une violation de la liberté de religion et sur le fondement d'une discrimination croisée à la fois sur le genre et la religion :

→ CDH, 22 octobre 2018*, S. Yaker c. France*, n° 2747/2016.

Un suivi de la bonne prise en compte de ces observations par l'État est assuré par le Comité.

À noter, cependant, les mesures que peuvent prendre les États pour le respect des dispositions à teneur économique et sociale, en ce qu'elles sont des droits « programmatoires », sont nombreuses et nécessitent la mise en place de mesures parfois coûteuses, individuelles ou générales. Elles offrent des degrés de protection

diverses, nécessitant un examen souple de la part des Comités qui se bornent à constater le caractère suffisant et adéquat des mesures tout en tenant compte du contexte. Cependant et selon les Principes de Limburg, les États parties doivent nécessairement assurer un minimum de protection de ces droits économiques et sociaux, peu importe leur niveau économique, la réalisation pleine et entière des dispositions du Pacte étant progressive.

> → *« The Limburg Principles on the Implementation of the International covenant on economic, social and cultural rights »*, *HRQ*, 1987, vol. 9, pp. 122–135.

Cette compétence quasi-juridictionnelle des comités connaît cependant un engouement moins important des États. À titre d'exemple, on note seulement une soixantaine d'États ayant accepté la clause facultative à l'article 14 de la Convention pour l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, reconnaissant la compétence du Comité pour connaître de communications individuelles.

2.4. Les Observations générales

L'une des compétences des comités onusiens est également la possibilité de formuler des Observations générales (ou « Recommandations générales » pour le Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes), analysant et détaillant le contenu de leur convention de référence afin de clarifier et développer les obligations des États. Elles fournissent un éclairage essentiel sur la manière d'interpréter les dispositions.

Le Comité des droits de l'homme a été le premier à formuler de telles observations à partir des années 1980, mais celles-ci se sont particulièrement développées à partir des années 1990. À titre d'exemple, voir notamment :

> → CDH, Observation générale n° 36 sur l'article 6 : *Droit à la vie*, 3 septembre 2019, CCPR/C.GC.36.
>
> → CDH, Observation générale n° 37 sur l'article 21 : *Droit de réunion pacifique*, 17 septembre 2020, CCPR/C.GC.37.

Concernant le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, voir par exemple :

> → CDESC, Observation générale n° 25 sur l'article 15 : *La science et les droits économiques, sociaux et culturels*, 30 avril 2020, E/C.12/GC.25.
>
> → CDESC, Observation générale n° 24 sur les obligations des États en vertu du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels dans le contexte des activités des entreprises, 10 août 2017, E/C.12/GC.24.

2.5. Les autres fonctions

2.5.1. Les procédures d'enquête

Certains comités possèdent un pouvoir d'enquête, expressément soumis au consentement de l'État, dans le cas où il existe des informations et renseignements crédibles selon lesquels l'État porte une atteinte grave ou systématique à l'un des droits protégés.

Le Comité peut ainsi charger un ou plusieurs de ses membres d'effectuer une enquête et de lui rendre compte d'urgence des résultats. Cette enquête peut impliquer, lorsque cela se justifie et avec l'accord de l'État partie, une visite sur le territoire de cet État.

L'État partie est ensuite informé des résultats de l'enquête et des observations et recommandations du Comité.

Cette compétence est proposée par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, le Comité contre la torture, le Comité des disparitions forcées, le Comité des droits des personnes handicapées, le Comité des droits des enfants, ainsi que par le Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes qui peut aussi lancer des enquêtes confidentielles sur des violations graves ou systématiques des droits des femmes dans un pays et qui travaille également avec d'autres organes des Nations unies et partenaires pour promouvoir l'égalité des sexes au niveau mondial.

De plus, concernant le Comité des disparitions forcées, dans le cas où celui-ci *« reçoit des informations qui lui semblent contenir des indications fondées selon lesquelles la disparition forcée est pratiquée de manière généralisée ou systématique sur le territoire relevant de la juridiction d'un État partie, et après avoir recherché auprès de l'État partie concerné toute information pertinente sur cette situation, il peut porter la question, en*

urgence, à l'attention de l'Assemblée générale des Nations unies, par l'intermédiaire du Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies » (art. 34 de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées).

De même, le Comité sur les disparitions forcées peut être saisi, en urgence, par les proches d'une personne disparue, leurs représentants légaux, leurs avocats ou toute personne mandatée par eux, ainsi que toute autre personne ayant un intérêt légitime, d'une demande visant à chercher et retrouver une personne disparue.

2.5.2. Le Sous-comité de prévention

Une autre compétence particulière est reconnue au Comité contre la torture. En effet, le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adopté le 18 décembre 2002 établit un Sous-comité de prévention au sein du Comité contre la torture tendant à *« l'établissement d'un système de visites régulières, effectuées par des organismes internationaux et nationaux indépendants, sur les lieux où se trouvent des personnes privées de liberté, afin de prévenir la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants »* (art. 1er).

Ce Sous-comité de la prévention est composé de 10 membres élus pour 4 ans, *« de haute moralité ayant une expérience professionnelle reconnue dans le domaine de l'administration de la justice, en particulier en matière de droit pénal et d'administration pénitentiaire ou policière, ou dans les divers domaines ayant un rapport avec le traitement des personnes privées de liberté »*. Ses fonctions sont énumérées à l'article 11 :

- Concernant les États membres, il effectue des visites et des recommandations concernant la protection des personnes privées de liberté.
- Concernant les mécanismes nationaux de prévention : il formule des avis pour évaluer les moyens nécessaires à la protection des personnes, propose une assistance aux États parties pour la mise en place de mécanisme de prévention et entretient des liens directs avec ces mécanismes nationaux.
- Concernant les autres institutions : il coopère avec tous les organes et organismes compétents au niveau international, régional et national.

Il communique ses observations à l'État partie et aux mécanismes nationaux de prévention.

3. Les controverses sur la valeur juridique des décisions des comités ?

Les Comités n'étant ni des juridictions, ni des organes interétatiques, il persiste un flou sur la valeur juridique précise à accorder aux constatations ou aux observations générales puisque celles-ci sont l'œuvre d'experts et non de juges et ne bénéficient pas de l'autorité de la chose jugée. Cependant, en s'engageant à respecter ces dispositions et en reconnaissant la compétence du Comité, les États doivent respecter leurs engagements internationaux de bonne foi et donc coopérer avec les comités.

→ Julie FERRERO, « Faut-il prendre les Comités conventionnels au sérieux ? », no 10, *RDLF*, 2022.

La question est cependant plus délicate dans le cas d'un conflit avec un autre organe international comme une cour régionale. Dans ce cadre, il peut exister un conflit d'obligation pour l'État. L'exemple le plus souvent mentionné est le suivant :

→ CEDH, 1er juillet 2014*, S.A.S. c. France* [GC], no 43835/11.

→ CDH, 22 octobre 2018*, S. Yaker c. France*, no 2747/2016.

Ces décisions concernaient l'interdiction de la dissimulation du visage dans l'espace public, portée par la loi 10 octobre 2010 et l'existence d'une atteinte à la liberté de manifester sa religion, la loi impliquant implicitement l'interdiction du port du *niqab* par les femmes musulmanes. La Cour européenne des droits de l'homme considère en 2014 que l'atteinte à cette liberté est justifiée par la notion de « vivre ensemble ». À l'inverse, le Comité des droits de l'homme saisi de la question en 2018 trouve une violation du droit de manifester sa religion, mais également une discrimination croisée basée à la fois sur la religion et la condition féminine. Par conséquent, l'État français n'a pas suivi la constatation du Comité des droits de l'homme.

POUR S'ENTRAÎNER

Dissertation : Les comités onusiens de protection des droits humains : garants d'une justice universelle ou simples organes consultatifs ?

La structure onusienne joue un rôle central dans la protection des droits humains dès la sortie de la Seconde Guerre mondiale et par la suite avec une forte activité normative dans ce domaine par la création de nombreuses conventions internationales. Neuf de ces conventions principales mettent en place des comités surveillant la bonne mise en œuvre de ces conventions.

Cependant, si ces comités sont les seuls organes ayant une prétention universaliste dans la protection des droits humains (en ce qu'il n'existe que des juridictions régionales de protection des droits humains et pas de cour mondiale), ces mécanismes de contrôle ont une portée limitée, bien que réelle.

Problématique et annonce du plan : Si leur nature quasi-juridictionnelle créé une ébauche de justice universelle **(I)**, leur manque de pouvoir coercitif et leur dépendance aux coopérations étatiques soulèvent des interrogations sur leur efficacité réelle **(II)**.

I. Une architecture juridique au service d'une justice universelle

A. Une compétence normative et interprétative importante

Les comités ont diverses fonctions qui en font des mécanismes de développement incontournable du droit international des droits humains, notamment par l'adoption d'observations générales interprétant les textes conventionnels qui constituent une part importante du développement d'une vision universelle des droits humains.

À titre d'exemple, voir l'Observation générale n° 34 du Comité des droits de l'homme qui donne des indications claires pour la protection des différentes formes d'expression par les États (CDH, 29 juillet 2011, Observation générale n° 34 sur l'article 19 : *Liberté d'opinion et liberté d'expression*, CCPR/C.GC.34).

Les observations finales sur les rapports périodiques jouent aussi un rôle important ainsi que par certains pouvoirs comme les enquêtes qui permettent de renforcer la protection des droits humains au niveau universel et structurel dans chaque État (sans pour autant parler de « justice » à proprement parler).

B. Des mécanismes quasi-juridictionnels universels

L'examen des communications individuelles (si l'État reconnaît cette compétence) se rapproche d'une fonction juridictionnelle :

- Par un système de plaintes individuelles avec des critères de recevabilité.
- Par l'intervention des Comités en cas d'échec du règlement amiable, qui tranche l'existence d'une violation des dispositions de la convention, à titre d'exemple voir :

CDH, 23 novembre 2005, *Faure c. Australie*, n° 1036/2001.

Les requêtes sont traitées selon le principe d'universalité des droits humains et de manière égalitaire entre les différents États.

Le caractère spécialisé des comités peut leur permettre de connaître de certaines affaires échappant aux juridictions régionales.

Enfin, l'existence de mécanisme de suivi se rapproche à bien des égards des mécanismes juridictionnels internationaux.

II. Les limites structurelles au pouvoir des comités

A. Une fonction judiciaire entravée

L'élément principal empêchant de considérer les comités comme garants d'une « justice » universelle est leur absence de caractère juridictionnel :

- Par la nature non contraignante des constatations et recommandations.
- Par leur composition (des experts et non des juges, bien que la compétence juridique soit un des critères pour le choix des membres du comité).

Cela implique de privilégier d'autres sources en cas de conflit (Cass. rév., 10 décembre 2015, n° 14REV017).

La mise en œuvre des constatations et des observations dépend uniquement de la volonté et de la coopération des États parties (sans sanction en cas d'irrespect). Dans ce cadre, le dialogue est privilégié à la procédure contentieuse.

B. L'influence croissante des comités

Il faut reconnaître une complémentarité avec d'autres mécanismes internationaux ou régionaux.

Il existe une référence croissante du travail des comités par les juges régionaux et donc une certaine influence des raisonnements des comités pour les juridictions internationales (CEDH, 7 juillet 2011, *Bayatyan c. Arménie,* n° 23459/03) ainsi que pour les juges nationaux (Cass. crim., 5 octobre 2021, 21-81.062).

Certains auteurs ont par ailleurs fait un parallèle entre les comités et l'existence d'une Cour mondiale, considérant que ces comités pourraient évoluer dans cette direction ou pourraient travailler en collaboration avec une cour mondiale pour rendre plus efficients les droits humains protégés (Olivier de Frouville, « Pourquoi nous avons besoin d'une Cour des droits de l'Homme des Nations unies ? », in *Les droits humains comparés, à la recherche de l'universalité des droits humains* (dir. N. Aloupi, D.P. Fernández Arroyo, C. Kleiner, L.-A. Sicilianos et S. Touzé), Paris, Pedone, 2019, pp. 129-161.)

En conclusion, les comités contribuent d'une manière certes souple, mais significative au développement du droit international des droits humains et leur fonction se rapproche de celle d'une juridiction internationale, mais en manque les attributs essentiels ce qui limite leurs effets.

Fiche nº 22 – LA COUR EUROPÉNNE DES DROITS DE L'HOMME

POINTS CLÉS

- Une juridiction internationale permanente de protection des droits de l'Homme.
- L'interprète authentique de la Convention EDH.
- Une interprétation dynamique et évolutive de la Convention.

PRINCIPALES RÉFÉRENCES

- CEDH, 23 juillet 1968, *Affaire relative à certains aspects du régime linguistique de l'enseignement en Belgique c. Belgique*, nº 1474/62 et a.
- CEDH, AP., 21 février 1975, *Golder c. Royaume-Uni*, nº 4451/70.
- CEDH, 9 octobre 1979, *Airey c. Irlande*, nº 6289/73.
- CEDH, GC., 6 avril 2000, *Thlimmenos c. Grèce*, nº 34369/97.
- CEDH, GC., 22 juin 2004, *Broniowski c. Pologne*, nº 31443/96.

1. Le fonctionnement institutionnel de la Cour

Créée en 1959, la Cour constitue l'organe juridictionnel permanent chargé de contrôler le respect de la Convention européenne des droits de l'homme.

L'institution de cet organe permanent fait du système de la Convention un système particulièrement innovant. Les États ne sont en effet pas seulement astreints par les obligations contenues au sein du texte de la Convention, ils peuvent également être condamnés pour ne pas les avoir respectés.

1.1. La hiérarchisation des formations de jugement

La Cour a fait l'objet d'une modification profonde de son organisation en 2010 avec l'adoption du quatorzième protocole :

- La formation à juge unique permet de traiter rapidement une requête manifestement irrecevable.
- Création du Comité de trois juges : Il statue à l'unanimité s'agissant des décisions d'irrecevabilité ou d'affaires au sein desquelles la jurisprudence de la Cour est bien établie.
- La formation ordinaire est la chambre de 7 juges. Elle peut à la fois se prononcer sur la recevabilité et le fond de la requête.
- Création de la Grande chambre. Formation la plus solennelle, elle est composée de 17 juges. Elle a compétence en cas de dessaisissement de la formation de jugement en raison d'une question majeure ou problématique. Elle est également la formation de renvoi et peut donc être saisie en tant que voie de recours dans le délai de 3 mois par l'une des parties au litige. Elle est également compétente pour traiter des demandes d'avis consultatifs formulés par les juridictions nationales (art. 47 Conv. EDH).

1.2. Les différents types de recours

Ce mécanisme prévoyait initialement une procédure de recours interétatiques permettant à un État de saisir la Commission des droits de l'homme en cas de violation de la Convention par un autre État membre. Ce type de contentieux représente toutefois une infime partie des affaires traitées par la Cour par rapport à celui des requêtes individuelles qui a connu quant à lui un franc succès.

Un autre type de recours, cette fois-ci individuel, prévoyait également, pour les États l'ayant accepté, la faculté des individus relevant de leur juridiction de saisir la Commission. La France a ainsi accepté ce droit de requête individuelle le 2 octobre 1981.

Ce n'est que par l'entrée en vigueur du protocole n° 11 en 1998 que la compétence de la Cour est devenue obligatoire pour l'intégralité des Hautes Parties contractantes. L'adoption de ce protocole a entraîné par la même occasion la disparition de la Commission des droits de l'homme (auparavant chargée d'apprécier la recevabilité des requêtes).

La Cour peut donc désormais être saisie par les individus (art. 34 Conv. EDH) et par les États (art. 33 Conv. EDH).

1.3. Les différentes étapes de la procédure contentieuse

Lorsqu'une requête est introduite auprès de la Cour, la première étape de la procédure consistera pour cette dernière à évaluer sa recevabilité en fonction des conditions énoncées par la Convention. La Cour va alors rendre une décision de recevabilité ou d'irrecevabilité et dans ce cas la requête ne sera pas traitée sur le fond.

Une fois passé ce filtre, la requête pourra être transmise à l'une des formations de jugement en fonction de l'importance, ou de la particularité de la requête pour que la Cour rende un arrêt.

Un arrêt rendu par le Comité de trois juges ou un arrêt de section ne sera définitif qu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de sa publication. Dans le cadre de ce délai, les parties disposent ainsi de la possibilité de demander un renvoi de l'affaire vers la Grande chambre afin que la Cour se prononce à nouveau dans sa formation la plus solennelle.

Avant qu'un arrêt sur le fond ne soit rendu par l'une de ces formations de jugement, il est possible pour les parties au litige de convenir d'un accord amiable.

En vertu de l'article 39 du règlement de la Cour, les juges sont en mesure « d'indiquer aux parties toute mesure provisoire » de manière exceptionnelle lorsqu'il existe des risques de violation imminente et irréparable.

> → CEDH, GC., 4 février 2005, *Mamatkulov et Askarov c. Turquie*, n^{os}46827/99 et 46951/99.

S'il s'agit de mesures obligatoires pour les États, cette procédure présente toutefois des limites notamment lorsque l'État visé refuse de s'y conformer puisqu'elles n'ont pas d'effet direct au sein des ordres juridiques étatiques.

> → Voir la seconde mesure provisoire prononcée par la Cour n° 063 (2021), du 17 février 2021 concernant Aleksey Navalny.

Une fois l'arrêt devenu définitif, il sera notifié à l'État et en cas de condamnation de celui-ci sera tenu de l'exécuter. Il devra ainsi faire état des mesures générales ou individuelles adoptées afin de redresser la violation au Comité des ministres qui examinera si l'arrêt a été correctement exécuté par l'État.

2. L'interprétation de la Convention

La Cour a exercé au cours de son activité juridictionnelle le rôle d'interprète de la Convention (art. 32 Conv. EDH). Son activité a toutefois évolué puisqu'elle n'interprète plus seulement ce texte dans le cadre de son activité contentieuse, mais également dans le cadre de sa mission d'avis consultatif.

2.1. L'activité juridictionnelle de la Cour

L'activité juridictionnelle de la Cour européenne des droits de l'homme a produit une double influence sur le texte de la Convention. La Cour a à la fois développé des concepts de nature à enrichir la portée des garanties de cette dernière et à en limiter l'essor.

2.1.1. L'enrichissement de la Convention par l'interprétation dynamique de la Cour

Le droit de la Convention a grandement évolué depuis son adoption en 1950. L'activité juridictionnelle de la Cour a en effet considérablement enrichi les droits initialement consacrés au sein de la Convention.

La Cour peut ainsi prendre en considération les travaux préparatoires de la Convention afin de la guider dans son interprétation.

→ CEDH, GC., 18 novembre 2020, *Slovénie c. Croatie*, déc., n° 54155/16.

La Cour retient une interprétation finaliste qui prend appuis sur différents concepts employés et développés par elle tout en ayant en vue les objectifs du Conseil de l'Europe : la démocratie, la prééminence du droit, et la protection effective des droits humains.

→ CEDH, 27 juin 1968, *Wemhoff c. Allemagne*, n° 2122/64.

Ces concepts ne sont pas exclusifs les uns des autres et plusieurs d'entre eux sont fréquemment mobilisés au sein d'un même arrêt de la Cour.

a. La définition et l'élaboration de notions autonomes

Dans le cadre de ses arrêt la Cour donne un sens à certains termes qu'elle utilise pour l'intégralité des Hautes Parties contractantes. Ce procédé est double.

La Cour a élaboré une définition à des notions employées par la Convention, mais aussi à des termes non expressément mentionnés par cette dernière, mais découlant de l'interprétation du texte. Cette découverte a eu pour effet d'étendre de manière conséquente le champ d'application matériel des stipulations de la Convention sur le fondement desquelles elles ont été dégagées.

> → Sur le fondement de l'article 8, la Cour a par exemple dégagé la notion de droit à un environnement sain alors qu'aucune stipulation de la Convention ne le prévoyait initialement (CEDH, GC., 9 décembre 1994, *Lopez Ostra c. Espagne*, n° 16798/90).

Les notions autonomes présentent un triple intérêt. Elles permettent à la Cour de s'assurer d'une définition uniforme au sein des États parties et de préciser le sens des termes de la Convention et donc d'éviter que les Hautes Parties contractantes ne retiennent des définitions potentiellement contradictoires.

Cette autonomie des définitions est également une garantie pour l'effectivité de la Convention. Cela permet à la Cour de gommer les risques de divergences de législations et donc d'assurer l'application des notions indépendamment des acceptions internes de ces dernières.

> → La notion de vie privée a ainsi fait l'objet d'une définition autonome dont les contours sont extrêmement larges. Au sens de la Cour, cette notion englobe aussi bien la vie privée prise sous son sens commun (l'intimité de l'individu) qu'un volet social (CEDH, *Niemietz c. Allemagne*, 16 décembre 1992, n° 13710/88).

Certaines notions autonomes dites « originales » ont progressivement gagné en importance au point de pouvoir transcender le seul cadre de l'article au sein duquel elles ont été révélées.

La notion d'autonomie personnelle a ainsi été dégagée par la jurisprudence de la Cour dans le sillage de l'application de l'article 8 relatif à la vie privée et familiale alors même qu'elle était initialement absente du texte de la Convention.

Cette notion confère aux individus la liberté d'opérer des choix concernant leur propre personne y compris ceux de nature à y porter atteinte.

> → CEDH, 29 avril 2002, *Pretty c. Royaume-Uni*, n° 2346/02.
>
> → CEDH, GC., 11 juillet 2002, *Christine Goodwin c. Royaume-Uni*, n° 28957/95.
>
> → CEDH, GC., 17 février 2005, *KA. Et AD. c. Belgique*, n°s42758/98 et 45558/99.

b. La combinaison des articles de la Convention

La Cour étend également le champ des garanties offertes aux individus lorsqu'elle procède à la combinaison de deux articles de la Convention.

Ce procédé est le plus souvent réalisé sur le fondement de l'article 14 relatif au droit à la non-discrimination. Ce droit n'étant ni indépendant ni autonome il doit être combiné à un autre article de la Convention pour s'appliquer.

→ CEDH, GC., 6 avril 2000, *Thlimmenos c. Grèce*, n° 34369/97.

Ce procédé est également mobilisé par la Cour avec d'autres articles de la Convention.

→ Pour une combinaison des articles 8 et 3 (CEDH, 4 décembre 2003, *M.C. c. Bulgarie*, n° 39272/98).

→ Concernant la combinaison des articles 1er du protocole n° 1 et 13 de la Convention (CEDH, 13 novembre 2007, *Driza c. Albanie*, n° 33771/02).

c. La prise en considération du droit international pertinent

Les droits humains sont en théorie universels, et interdépendants. Dès lors, leur protection sous l'égide de la Cour européenne des droits de l'homme ne saurait évoluer en vase clos. Cette protection régionale doit prendre en considération l'état du droit international afin de déterminer l'étendue des protections des droits.

Le droit international pertinent peut ainsi être pris en considération afin d'apprécier la portée des obligations à la charge de l'État défendeur découlant de la Convention.

La Cour va apprécier l'état du droit international pertinent seulement afin de faire évoluer les obligations à la charge des États découlant de la Convention. Elle ne sanctionne donc pas les manquements aux obligations au titre d'autres traités.

→ CEDH, GC., 9 avril 2024*, Verein klimaseniorinnen schweiz et a. c. Suisse*, n° 53600/20

Cette prise en compte ne requiert pas nécessairement que l'État défendeur ait signé les textes de droit international sondés par le juge strasbourgeois.

→ CEDH, GC., 12 novembre 2008, *Demir et Baykara c. Turquie*, n° 34503/97

d. L'interprétation évolutive et finaliste de la Convention

Les droits garantis par la Convention ne sont pas figés dans le temps. Ils évoluent sous l'interprétation de la Cour en suivant l'évolution de la société.

« *La Convention est un instrument vivant à interpréter à la lumière des conditions de vies actuelles* » (CEDH, 13 juin 1979, *Marckx c. Belgique*, n° 6833/74).

La Cour a parfois pu par son interprétation téléologique du texte de la Convention dégager de nouveaux droits non expressément prévus.

→ CEDH, 21 février 1975, *Golder c. Royaume-Uni*, n° 4451/70.

Cette interprétation évolutive suppose donc d'apprécier concrètement la situation des États, leur législation et leurs finances afin de déterminer la portée des droits garantis par la Convention.

La Cour ne doit pas en effet faire peser sur les États un « fardeau excessif » en leur imposant des obligations matériellement irréalisables ou en contradiction profonde avec leurs traditions juridiques nationales.

→ CEDH, 28 octobre 1998, *Osman c. Royaume-Uni*, n° 23452/94.

La Cour a ainsi souvent recours à la notion de consensus européen en plus de celle de droit international pertinent afin de dégager de potentielles visions communes concernant une question donnée.

→ CEDH, GC., 15 mars 2018, *Nait-Liman c. Suisse*, n° 51357/07.

La portée des droits garantis par la Convention est donc susceptible d'évoluer à la hausse. Cette interprétation évolutive peut ainsi justifier des revirements de jurisprudence.

→ Puisque la Cour n'est pas liée en principe par sa jurisprudence antérieure (CEDH, 27 septembre 1990, *Cossey c. Royaume-Uni*, n° 10843/84).

→ Pour un exemple de revirement (CEDH, 11 juillet 2002, *Christine Goodwin c. Royaume-Uni*, n° 28957/95).

La prise en compte de cet état du droit et du caractère évolutif peut toutefois justifier une appréciation à la baisse des garanties offertes par la Convention. Elle peut donc entraîner des atteintes plus importantes aux droits garantis par la Convention.

→ CEDH, 18 janvier 2018, *FNASS et a. c. France*, nos 48151/11 et 77769/13

e. Le développement des obligations positives

La Cour impose différents types d'obligations aux États. Ces derniers doivent classiquement s'abstenir de commettre des ingérences injustifiées dans les droits des personnes relevant de leur juridiction, il s'agit d'obligations négatives.

La Convention fait cependant l'objet d'une appréciation concrète de la part de la Cour. Les droits qu'elle garantit ne doivent pas être théoriques ni illusoires, mais « concrets et effectifs ».

→ CEDH, 9 octobre 1979, *Airey c. Irlande*, n° 6289/73.

Cette interprétation accroît considérablement les obligations à la charge de l'État. Une abstention de ce dernier peut tout autant être considérée comme constitutive d'une violation qu'une ingérence de sa part.

L'État ne doit donc pas uniquement s'abstenir de commettre des ingérences, il doit parfois également garantir que les droits consacrés par la Convention et ses protocoles soient effectifs : il s'agira alors d'obligations positives.

→ CEDH, 26 mars 1985, *X. et Y. c. Pays-Bas*, n° 8978/80.

→ CEDH, 9 décembre 1994, *Lopez Ostra c. Espagne*, n° 16798/90.

POUR ALLER PLUS LOIN

Les obligations positives font produire un effet horizontal indirect à la Convention. L'État pourra être poursuivi pour des allégations de violation dans le cadre de relations interindividuelles en raison de son abstention dans l'adoption de mesures concrètes permettant d'éviter que les droits ne soient violés dans au sein de telles relations. La Cour a ainsi estimé que la Suisse avait manqué à ses obligations positives issues de l'article 6 concernant le droit à un recours effectif en ne s'assurant pas qu'une audience publique ait pu se tenir dans le cadre de litiges arbitraux entre personnes privées (CEDH, 2 octobre 2019, Mutu et Pechstein c. Suisse, n°s40575/10 et 67474/10).

Ces obligations positives peuvent être de deux ordres. Il peut s'agir d'obligations positives procédurales ou d'obligations positives matérielles. Les premières contraignent l'État à mener des enquêtes effectives afin de faire la lumière sur une atteinte potentiellement illégale aux droits des personnes relevant de sa juridiction. Tandis que les obligations positives matérielles peuvent exiger de la part de l'État l'adoption de moyens concrets permettant de garantir l'effectivité d'un droit telle que la mise en place d'une aide juridictionnelle pour garantir le droit d'accès au tribunal (CEDH, 9 octobre 1979, Airey c. Irlande) ou l'obligation d'adoption de dispositions sanctionnant effectivement le viol (CEDH, 4 déc. 2003, M.C. c. Bulgarie, n° 39272/98).

Actualité jurisprudentielle. - La Cour adapte ses obligations positives aux nouvelles menaces démocratiques

Dans l'arrêt *Bradshaw*, la Cour a examiné pour la première fois la question d'une ingérence systématique d'un État étranger (en l'espèce, la Russie) dans des processus électoraux au moyen notamment de campagnes de désinformation, de cyberattaques et de réseaux sociaux. Elle admet que l'article 3 du Protocole n° 1 peut imposer aux États des obligations positives afin de protéger l'intégrité du processus électoral contre de telles menaces. Elle conclut toutefois à l'absence de violation compte tenu des mesures finalement prises par les autorités britanniques (CEDH, 22 juillet 2025, *Bradshaw et autres c. Royaume-Uni*, n° 15653/22).

À retenir. - La jurisprudence européenne est évolutive : les obligations positives permettent à la Cour d'adapter la Convention à des menaces nouvelles qui n'étaient pas envisagées lors de sa rédaction.

2.1.2. La découverte de concepts modérateurs de la Convention

Le système conventionnel repose sur le concept de subsidiarité, principe qui présente une double facette, un versant textuel et juridictionnel.

En effet, la Cour n'est pas un quatrième ordre de juridiction. Elle ne peut donc se substituer aux juridictions nationales.

Elle a ainsi rapidement développé au sein de sa jurisprudence la notion de subsidiarité avant qu'elle ne soit consacrée dans le préambule de la Convention par la suite.

> → CEDH, 23 juillet 1968, *Affaire relative à certains aspects du régime linguistique de l'enseignement en Belgique c. Belgique*, n°s 1474/62 ; 1677/62 ; 1691/62 ; 1769/63 ; 1994/63 ; 2126/64.

Ce principe transparaît des exigences de recevabilité de l'article 35 de la Convention et notamment de l'exigence d'épuisement des voies de recours internes. Les requérants doivent effectivement avoir épuisé toutes les voies de recours internes utiles, nécessaires et adéquates afin d'exposer leurs allégations de violations avant de saisir la Cour européenne.

L'État doit avoir eu la possibilité de remédier à la violation avant toute saisine de la Cour.

> → CEDH, GC., 16 décembre 2010, *A., B. et C. c. Irlande*, n° 25579/05.

Une autre notion découle également de ce principe de subsidiarité : la marge nationale d'appréciation.

Les obligations de la Convention ne prescrivent pas d'uniformisation des ordres juridiques des États parties ni de comportements spécifiques de leur part. Ils disposent ainsi d'une multiplicité de solutions afin de se conformer à leurs obligations conventionnelles.

La marge nationale d'appréciation permet à la Cour de déterminer l'applicabilité de certaines dispositions de la Convention et constitue surtout un outil de contrôle de la proportionnalité de l'ingérence étatique.

Dans cette deuxième hypothèse, l'intensité de la marge nationale d'appréciation permet à la Cour de déterminer la marge de liberté à disposition des États dans un domaine précis, et donc d'adapter l'intensité de son contrôle.

Plus cette marge d'appréciation sera restreinte, moins les États disposeront d'une liberté de choix et de mise en œuvre de mesures afin de se conformer à la Convention.

Attention, en présence d'un consensus international ou d'une disposition importante de la Convention la marge nationale d'appréciation des États sera par exemple considérablement réduite.

2.2. La procédure d'avis de la Cour

Depuis l'entrée en vigueur du protocole 16, le 1er août 2018, la Cour peut être saisie pour avis par les Hautes Cours désignées par les États parties.

Cette procédure permet à la Cour européenne des droits de l'homme d'exprimer un avis motivé quant à des questions de principe relatives à l'interprétation ou à l'application des droits et libertés de la Convention et de ses protocoles.

La procédure doit être motivée par la Cour interne ayant formulé la demande d'avis et ne peut concerner que les affaires pendantes auprès des juridictions nationales.

Un collège de 5 juges de la Grande chambre se prononce alors sur la recevabilité de la demande d'avis. En cas de recevabilité ce sera cette dernière formation qui formulera l'avis consultatif.

La première procédure d'avis a ainsi été initiée par la France dans le cadre des réminiscences de l'affaire *Mennesson c. France*.

> → CEDH, 10 avril 2019, avis relatif à la reconnaissance en droit interne d'un lien de filiation entre un enfant né d'une gestation pour autrui pratiquée à l'étranger et la mère d'intention, n° P16-2018-001.

La Cour peut d'ailleurs tout à fait déclarer irrecevable une telle demande d'avis.

> → CEDH, 26 juin 2024, décision relative à une demande d'avis consultatif présentée en vertu du Protocole n° 16 et concernant l'interprétation ou l'application de l'article 6 de la Convention et de l'article 1 du Protocole n° 1, n° P16-2024-001.

Ces avis sont en outre dépourvus de force obligatoire, il est donc en théorie tout à fait possible pour les États d'aller à l'encontre de l'avis sollicité (art. 5 P16).

La France semble avoir, par l'intermédiaire du juge judiciaire, pris bonne note du premier avis consultatif, car elle l'a mobilisé afin de motiver la mise en œuvre de son contrôle concret de conventionnalité : Cass. civ. 1re, 14 novembre 2024, no 23-50.016.

Les avis rendus par la Cour devraient en outre jouir d'une autorité de la chose jugée au même titre que sa jurisprudence au regard de leur utilisation par le juge strasbourgeois.

→ CEDH, 16 juillet 2020, *D. c. France*, no 11288/18.

3. La portée des arrêts de la Cour

3.1. L'absence de force exécutoire automatique en droit interne

La Cour ne condamne pas les individus, elle n'a vocation qu'à se prononcer sur le comportement des États. Ses arrêts sont ainsi obligatoires à l'égard des États parties au litige (art. 46 § 1 Conv. EDH).

Lorsque le litige prend sa source d'une relation interindividuelle, la Cour n'a pas le pouvoir de condamner l'une des parties concernées par le litige au plan interne. Ce n'est donc pas le comportement d'un individu qui entraîne à la violation de la Convention, mais bien l'incapacité de l'État à s'assurer que la Convention soit respectée par ce dernier.

3.2. La force obligatoire des arrêts de condamnation à l'égard des États condamnés

3.2.1. La force obligatoire des arrêts de la Cour

Selon l'article 46 § 1, les États parties au litige sont obligés d'exécuter l'arrêt les concernant. Un arrêt de condamnation n'a toutefois aucune incidence directe sur la victime.

Les arrêts de la Cour sont effectivement dépourvus d'effet exécutoire en droit interne. Afin de se conformer à l'arrêt, l'État devra donc prendre des mesures internes permettant de se conformer à ses obligations et d'effacer autant que faire se peut la violation.

Les arrêts de condamnation ne sont toutefois pas sans incidence sur la victime. L'État doit ainsi adopter des mesures individuelles permettant de mettre fin à la violation et à ses incidences négatives sur la victime.

La Cour peut ainsi condamner l'État à verser à la victime une somme d'argent au titre de satisfaction équitable (art. 41) ou le contraindre, pour autant que cela soit possible et non disproportionné, à rétablir le *statu quo ante* pour la victime en supprimant les sources de la violation au titre de la *restitutio in integrum*.

→ CEDH, 31 octobre 1995, *Papamichalopoulos et a. c. Grèce* (art. 50), no 14556/89.

L'État dispose en principe d'une liberté dans le choix et la mise en œuvre des mesures adéquates afin de remédier à cette violation de la Convention. Exceptionnellement, la Cour peut néanmoins indiquer à l'État les mesures idoines afin de mettre un terme à la violation.

3.2.2. La procédure des arrêts pilotes

La procédure des arrêts pilotes a été initiée à la suite de la situation d'engorgement critique au début des années 2000 (en 2011 la Cour comptait plus de 150 000 requêtes pendantes).

Une grande partie des requêtes provenait cependant d'un nombre réduit d'États, certaines d'entre elles étant en outre répétitives, car relevant de problématiques similaires.

Ce constat a poussé la Cour à élaborer jurisprudentiellement une méthode plus qu'une procédure à l'origine afin de faire face à cette situation inédite. En effet, il s'agit tout d'abord d'identifier la source d'une violation structurelle ou systémique afin de proposer ensuite à l'État défendeur des mesures adéquates afin d'y remédier.

→ CEDH, GC., 22 juin 2004, *Broniowski c. Pologne*, n° 31443/96

Cette procédure permet ainsi à la Cour de traiter au sein d'un seul arrêt les lacunes d'un ordre juridique pouvant faire l'objet de nombreuses requêtes « répétitives ». Toutes les requêtes similaires seront alors gelées le temps que des mesures adéquates soient adoptées par l'État défendeur pour mettre fin à la violation.

Cette procédure dite des arrêts pilotes a été codifiée en 2011 au sein de l'article 61 du règlement de la Cour.

3.3. L'existence d'une autorité de la chose interprétée à l'égard des autres États du Conseil de l'Europe

La portée normative des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme ne se limite pas uniquement aux États parties au procès. La Convention étant un instrument constitutionnel de l'ordre public européen, les autres États non parties au litige doivent également se conformer aux arrêts rendus à l'encontre de leurs homologues.

La Convention est ainsi dotée d'une autorité de la chose interprétée. Les États ne doivent pas attendre d'être condamnés par la Cour pour mettre en conformité leur droit interne à la Convention.

→ CEDH, 6 mars 2007, *Scordino c. Italie* (n° 3), n° 43662/98.

Cette autorité de la chose interprétée est toutefois variable selon les circonstances, la thématique et les États concernés. Le juge, voire le législateur national, peuvent ainsi se fonder sur un arrêt de condamnation de la Cour à l'égard d'un État tiers afin d'écarter l'application d'une disposition interne au sein d'un litige ou de modifier l'ordre juridique.

→ *Cass*, ass. plén., 15 avril 2011, n°s 10-17.049, 10-30.242, 10-30.313 et 10-30.316.

POUR S'ENTRAÎNER

Dissertation : L'exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme

En tant qu'organe juridictionnel international chargé d'interpréter la Convention (art. 32 de la Convention), la Cour peut rendre des arrêts. Ces derniers n'ont pas pour objet de condamner des particuliers, mais bien les États parties à la Convention pour une ou plusieurs violations des droits qu'elle garantit.

L'arrêt devient définitif à l'expiration d'un délai de 3 mois suivant sa publication, ou en cas d'arrêt de la Grande chambre, dès sa publication. Ce mécanisme de protection des droits humains repose sur le principe de subsidiarité. Consacré depuis le 1er août 2021 au sein du préambule de la Convention, il s'applique également à la phase d'exécution des arrêts. Selon ce principe, il revient donc en premier lieu aux États de garantir l'effectivité des droits issus de ce texte en prenant des mesures de nature à supprimer la violation.

Problématique et annonce du plan : Si les arrêts de la Cour sont en principe dotés d'une force normative à l'égard des États **(I)**, leur effectivité au plan national demeure toutefois largement dépendante du bon vouloir de ces derniers **(II)**.

I. Une force normative conséquente des arrêts à l'égard des États parties

A. La force obligatoire des arrêts à l'encontre de l'État défendeur à l'instance

Une fois l'arrêt devenu définitif (3 mois après sa publication), l'État condamné doit exécuter l'arrêt. S'ouvre alors un processus de surveillance sous le contrôle du Comité des ministres.

Les arrêts de la Cour disposent d'une force obligatoire à l'égard des États défendeurs (art. 46). Les États condamnés sont donc tenus de se conformer à l'arrêt de condamnation (CEDH, GC., 30 juin 2009, *Verein Gegen Tierfabriken Schweiz (vgt) c. Suisse* (n° 2), n° 32772).

Pour ce faire, la Cour liste parfois des mesures individuelles ou générales permettant de supprimer la violation.

Toutefois, les États en vertu du principe de subsidiarité demeurent libres d'adopter des mesures adéquates différentes (CEDH, AP., 29 avril 1988, *Belilos c. Suisse*, n° 10328/83).

L'État dispose de trois mois pour s'acquitter de la satisfaction équitable et de 6 mois pour préparer et soumettre des plans d'actions comprenant les mesures envisagées ou adoptées pour se conformer à l'arrêt.

Il doit ensuite communiquer au Comité des ministres un bilan des actions menées qui sera analysé.

Si les mesures sont satisfaisantes, ce dernier adoptera alors une résolution finale clôturant ce processus.

B. L'autorité interprétative des arrêts à l'encontre des États non-défendeurs

Les arrêts de la Cour ne disposent pas par principe d'effet *erga omnes*. Ils ne disposent ainsi que d'une portée individuelle limitée aux seules parties à l'affaire.

Cependant, la Cour a déjà eu l'occasion d'affirmer que l'État ne devait pas attendre d'être condamné pour modifier son droit interne (CEDH, 6 mars 2007, *Scordino c. Italie* (n° 3), n° 43662/98).

La Convention est un élément constitutif de l'ordre public européen. Dès lors, les arrêts de la Cour qui font partie intégrante de ce texte obligent en théorie les autres États parties.

II. Une effectivité dépendante du bon vouloir des Hautes Parties contractantes

A. L'absence de force exécutoire des arrêts en droit interne

Une fois devenu définitif, l'arrêt ne produira aucun effet en droit interne automatiquement.

L'État doit donc se faire le relais de la Cour et adopter des mesures permettant d'exécuter l'arrêt.

Cette absence de force exécutoire peut être de nature à enrayer la protection effective des droits de la Convention puisque l'État peut rencontrer des difficultés dans l'exécution de cette décision.

Plus insidieusement, l'État pourra volontairement retarder l'exécution de l'arrêt pendant des mois ou années.

Or, certains arrêts requièrent une exécution rapide afin d'effacer la violation constatée.

Les mécanismes institutionnels permettant de contrôler l'exécution des arrêts présentent donc des limites.

La création du recours en manquement (art. 46 § 4) permet de manière exceptionnelle au Comité des ministres de saisir la Cour en cas de manquement grave de l'État dans l'exécution de l'arrêt.

Ce recours sera toutefois confronté aux mêmes obstacles que ceux rencontrés par le premier arrêt. Il prévoit en effet la possibilité pour la Cour de se saisir en cas d'inexécution afin de rendre un arrêt en manquement qui devra lui aussi être exécuté par l'État.

B. Le risque de défiance des États à l'égard de la jurisprudence de la Cour

Le mécanisme institutionnel révèle enfin ses limites lorsqu'il doit faire face à des États refusant d'exécuter les arrêts de la Cour.

Certains États ont ainsi temporairement pu faire preuve de défiance à l'égard de la Cour en refusant de se conformer à ses arrêts.

Le Royaume-Uni a ainsi longtemps refusé d'exécuter les arrêts condamnant son interdiction du droit de vote des détenus (CEDH, 6 octobre 2005, *Hirst c. Royaume-Uni* (n° 2), n° 74025/01).

Cette inexécution a ultérieurement fait l'objet d'un arrêt pilote constatant une violation de la Convention en raison de l'inexécution de l'arrêt Hirst (CEDH, *Greens et M.T. c. Royaume-Uni*, 23 novembre 2010, n°s 60041/08 et 60054/08). D'autres arrêts ont par la suite constaté des violations en raison de cette inexécution (par exemple : CEDH, 11 avril 2019, *Miller et a. c. Royaume-Uni*, n°s 70571/14 et a.).

L'absence d'exécution n'est pas sans risques pour le système conventionnel. Outre le fait que la légitimité de la Cour s'en trouve atteinte, cette défiance risque *in fine* de se répercuter sur la Cour en faisant peser sur elle un afflux massif de requêtes répétitives (CEDH, GC., *Burmych et a. c. Ukraine*, n° 46852/13 et a.).

La Russie a, quant à elle, cessé d'échanger avec le Comité des ministres alors même qu'elle reste tenue d'exécuter les arrêts rendus à son encontre. Cette dernière a adopté de plus des dispositions législatives permettant d'entraver l'exécution des arrêts de la Cour.

L'absence de pouvoir d'astreinte, contrairement à la Cour de justice de l'Union européenne en cas de procédures en manquement lorsqu'une institution de l'Union est en défense, contribue à l'essor de ces problématiques d'exécution des arrêts (sur la confirmation de l'astreinte prononcée à l'encontre de la Pologne : Trib. UE, 5 février 2025, aff. T-830/22 et T-156/23, Pologne c. Commission et aff. T-1033/23, Pologne c. Commission).

En conclusion, l'exécution des arrêts demeure ainsi tributaire des pressions politiques et diplomatiques résultant de la condamnation de l'État.

Fiche nº 23 - LA COUR DE JUSTICE DE L'UNION EUROPÉENNE

POINTS CLÉS

- Fonctions contentieuse, régulatrice et consultative.
- Contrôle de la légalité des actes de l'Union européenne.
- Requérants non privilégiés : accès difficile des particuliers à la Cour de justice.
- Collaboration avec les juridictions nationales : subsidiarité juridictionnelle.
- Interprétation uniforme du droit de l'Union européenne.
- Rôle du juge national dans la protection des justiciables.
- Droit au juge et protection juridictionnelle effective.

PRINCIPALES RÉFÉRENCES

- Article 19 du Traité sur l'Union européenne.
- Article 47 de la Charte des droits fondamentaux.
- Article 2*63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.*
- Article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
- *CJCE,* 15 juillet 1963, *Plaumann, aff.25/62.*
- CJUE, 8 avril 2014, *Digital Rights Ireland, C-293/12.*
- CJCE, 9 mars 1978, *Simmenthal, aff.106/77.*
- CJCE, 15 mai 1986, *Johnston, aff.222/84.*
- CJCE,13 mars 2007, *Unibet, C-432/05.*
- CJUE, 27 octobre 2021, *Commission contre Pologne, C-204/21.*

1. L'institution, ses missions et son fonctionnement

La Cour de justice de l'Union européenne, dont le siège est à Luxembourg, comprend deux juridictions : la Cour de justice, créée en 1952, et le Tribunal, créé en 1988. La mission de la Cour de justice consiste à assurer le respect du droit dans l'interprétation et l'application des traités, y compris les droits fondamentaux garantis par le droit de l'Union européenne.

Dans ce cadre, elle contrôle la légalité des actes des institutions européennes, veille au respect par les États membres des obligations qui découlent des traités, et interprète le droit de l'Union à la demande des juges nationaux. Elle constitue l'autorité judiciaire de l'Union européenne et veille, en collaboration avec les juridictions des États membres, à l'application et à l'interprétation uniforme du droit de l'Union.

Le régime linguistique de la Cour de justice est singulier en ce que chacune des langues officielles de l'Union peut être une langue de procédure. Le respect d'un multilinguisme intégral découle de la nécessité de communiquer avec les parties dans la langue du procès et d'assurer la diffusion de la jurisprudence de la Cour dans l'ensemble des États membres.

POUR ALLER PLUS LOIN

On distingue généralement trois fonctions de la Cour de justice de l'Union européenne, la fonction contentieuse, régulatrice et consultative. La première revêt une importance certaine, car son objet est de contrôler, à titre principal et exclusif, l'action des institutions de l'Union et subsidiairement, l'action des États membres. S'agissant du contrôle de l'action des institutions de l'Union, la Cour dispose d'importants moyens pour se prononcer sur des questions de légalité – via les recours en annulation, en carence et l'exception d'illégalité – et des questions d'indemnité. À cet égard, les juges nationaux sont incompétents pour contrôler les actes et agissements des institutions européennes. S'agissant, en revanche, du contrôle de l'action des États membres, la Cour dispose de moyens limités.

1.1. Les voies de recours à disposition des particuliers en cas de violation de leurs droits par le droit de l'Union

Il existe principalement deux moyens pour accéder aux juridictions de l'Union européenne :

- Le recours en annulation qui est une voie directe.
- La question préjudicielle qui constitue une voie indirecte.

Ces moyens ne sont pas interchangeables, car ils sont soumis à des règles de procédure différentes.

1.1.1. Le recours en annulation devant le Tribunal

Le recours en annulation qui consiste en un contrôle de la légalité des actes européens peut être exercé par des particuliers dans un délai de deux mois à compter, suivant le cas, de la publication de l'acte, de sa notification ou du jour où celui-ci en a eu connaissance.

En tant qu'ils appartiennent à la catégorie des requérants « non-privilégiés » les particuliers doivent démontrer un intérêt à agir pour demander l'annulation d'un acte européen : l'acte contesté doit être à destination du requérant ou le concerner directement et individuellement.

→ Art. 263 TFUE.

Ainsi, dans l'affaire Kadi, en désaccord avec le Tribunal initialement saisi, la Cour de justice a annulé un règlement européen gelant les fonds d'un requérant pour violation des droits de la défense et du principe de protection juridictionnelle effective.

→ CJCE, 3 septembre 2008, *Kadi c. Conseil et Commission.*

1.1.2. La question préjudicielle posée à la Cour de justice

La Cour de justice est compétente pour statuer à titre préjudiciel sur la validité des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l'Union. Aucun délai n'est prescrit pour former un renvoi préjudiciel, mais cette possibilité de saisir la Cour de justice est exclusivement réservée aux juridictions nationales.

Il ne s'agit donc pas, à proprement parler, d'un recours à disposition des particuliers, mais d'un dialogue des juges.

Il est nécessaire qu'une procédure judiciaire soit en cours au niveau national, qui mette en cause un acte de l'Union ou une mesure nationale de mise en œuvre du droit de l'Union prétendument contraire aux droits fondamentaux de l'Union européenne. Les particuliers peuvent demander à la juridiction nationale de saisir la Cour de justice d'une question préjudicielle, mais la décision finale appartient au juge national lui-même qui peut aussi saisir la Cour de sa propre initiative.

→ Art. 267 TFUE.

Dans l'affaire *Digital Rights*, la Cour de justice a, par exemple, jugé que la directive 2006/24/CE sur la conservation de données traitées dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques était invalide en ce qu'elle comportait une ingérence disproportionnée dans le droit au respect de la vie privée et le droit à la protection des données, consacrés aux articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux.

→ CJUE, 8 avril 2014, *Digital Rights Ireland.*

Actualité européenne. - Le Tribunal peut désormais statuer à titre préjudiciel

Depuis le 1er octobre 2024, la compétence préjudicielle n'appartient plus exclusivement à la Cour de justice. Une partie des renvois formés sur le fondement de l'article 267 TFUE peut désormais être examinée par le Tribunal lorsque la question relève exclusivement de l'une des six matières énumérées par le statut de la Cour : TVA, droits d'accise, Code des douanes, classement tarifaire des marchandises, indemnisation et assistance des passagers ainsi que système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre.

Toutes les demandes de décision préjudicielle demeurent néanmoins adressées à la Cour de justice, qui détermine si elles doivent être transférées au Tribunal. La Cour conserve notamment sa compétence lorsqu'une demande soulève une question autonome relative au droit primaire, au droit international public, aux principes généraux du droit de l'Union ou à la Charte des droits fondamentaux.

→ Règl. (UE, Euratom) 2024/2019 du 11 avril 2024 modifiant le protocole n° 3 sur le statut de la Cour de justice de l'Union européenne ; art. 50 *ter* du statut.

Le Tribunal a rendu ses premiers arrêts préjudiciels en 2025, consacrant ainsi la mise en œuvre effective de cette nouvelle répartition des compétences.

→ Trib. UE, 9 juillet 2025, *Gotek*, aff. T-534/24.

À retenir. - Le renvoi préjudiciel n'est plus une compétence exclusivement exercée par la Cour de justice. Le Tribunal peut désormais statuer dans certaines matières techniques précisément délimitées, tandis que la Cour conserve notamment les questions relatives aux droits fondamentaux et aux principes structurants de l'ordre juridique de l'Union.

1.2. L'accès limité des particuliers à la Cour de justice

Malgré l'existence de ces mécanismes, l'accès des particuliers à la justice de l'Union européenne reste, aujourd'hui encore, très difficile pour contester une mesure de l'Union de portée générale. Dans la mesure où il s'agit du cas de figure le plus fréquent, la critique doctrinale est particulièrement vive.

1.2.1. Les conditions strictes de la jurisprudence Plaumann

Le recours en annulation visé à l'article 263 du Traité permet de contester la légalité d'un acte de l'Union dès lors qu'il a été adopté par une institution ou un organe de l'Union et que cet acte fait grief. La disposition réserve aux particuliers l'accès à ce recours à la condition qu'il soit « directement et individuellement » concerné par l'acte.

Ces deux conditions ont été interprétées de manière très stricte par la Cour de justice : dans sa jurisprudence dite « Plaumann », la Cour a jugé que les particuliers sont individuellement concernés s'ils sont atteints *« en raison de certaines qualités qui leur sont particulières ou d'une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne et de ce fait les individualise d'une manière analogue à celle du destinataire »*.

→ CJCE, 15 juillet 1963, *Plaumann.*

1.2.2. Le droit à un recours effectif consacré par la Charte

La Cour de justice a, malgré les critiques, conservé son interprétation stricte de l'article 263, exigeant que le requérant soit individuellement concerné pour que le recours en annulation soit recevable contre un acte de portée générale adopté par les institutions de l'Union.

Si le droit à un recours effectif est consacré par la Charte des droits fondamentaux, cette disposition n'impose pas, selon une jurisprudence constante de la Cour, la possibilité d'intenter de manière inconditionnelle un recours en annulation devant le juge de Luxembourg.

→ Art. 47 CDFUE.

La compatibilité de cette approche avec l'article 47 de la Charte est assurée aux yeux de la Cour du fait de la capacité des requérants à pouvoir contester la légalité d'un acte de portée générale par d'autres voies de recours, notamment le renvoi préjudiciel en validité.

→ CJCE, 3 octobre 2013, *Inuit Tapiriit Kanatami.*

La Cour de justice justifie cette approche par la complétude du système juridictionnel de l'Union, qui repose non seulement sur les voies de droit de l'Union, mais également sur celles des États membres, garantissant un contrôle effectif de légalité des actes de l'Union. Dès lors, l'accès au recours en annulation n'est pas indispensable, étant donné qu'il ne prive pas le particulier d'une véritable protection juridictionnelle.

Si la Charte n'a pas eu d'incidence sur la jurisprudence de la Cour, qui considère que le système actuel apporte les garanties suffisantes en matière de droit au recours effectif, il sera intéressant de constater, une fois l'adhésion à la Convention effective, si la Cour européenne des droits de l'homme a la même approche du système juridictionnel de l'Union.

1.3. Les recours en manquement en cas de violation des droits fondamentaux par un État

Un recours en manquement, dirigé contre un État membre qui a manqué à ses obligations découlant du droit de l'Union, peut être formé par la Commission ou par un autre État. Lorsque le manquement est constaté par la Cour de justice, l'État membre concerné doit se conformer à l'arrêt dans les meilleurs délais.

Lorsque la Commission estime que l'État ne s'est pas conformé à l'arrêt, elle peut introduire un nouveau recours demandant des sanctions pécuniaires. Si le recours en manquement n'est pas une voie ouverte aux particuliers, il permet néanmoins à la Commission et à la Cour de justice de constater des violations des droits fondamentaux.

À la suite de l'adoption par la Pologne en 2019, d'une loi modifiant les règles relatives à l'organisation des juridictions de droit commun et de la Cour suprême, la Commission a introduit des recours en manquement, demandant à la Cour de déclarer que le régime mis en place par cette loi méconnaissait le droit de l'Union.

La Cour de justice a jugé que les dispositions nationales obligeant les juges polonais à indiquer par écrit leur appartenance à une association ou à un parti politique, et prévoyant la mise en ligne de ces informations, violaient les droits fondamentaux de ces juges à la protection des données à caractère personnel et au respect de la vie privée.

→ CJCE, 27 octobre 2021, *Commission c. Pologne.*

2. Protection des droits fondamentaux sous l'angle de la subsidiarité juridictionnelle

L'article 19 du Traité sur l'Union européenne prévoit que les États membres établissent les voies de recours nécessaires pour assurer une protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l'Union.

En plus de contrôler la bonne application du droit de l'Union, le juge national doit, en tant qu'arbitre naturel des conflits mettant en cause les droits individuels, assurer la protection des droits et libertés des individus qui découlent de ce droit.

2.1. La compétence première des juridictions nationales

Les juridictions nationales sont la clé de voûte du système juridictionnel de l'Union. Les juges internes disposent ainsi d'une compétence de principe dans le contrôle de la compatibilité du droit national avec le droit de l'Union, d'une part, et dans la protection juridictionnelle des particuliers, d'autre part.

Dès le début des Communautés, le juge national agissait en tant que juge communautaire de droit commun dans la mesure où il était tenu *« d'appliquer intégralement le droit communautaire et de protéger les droits que celui-ci confère aux particuliers, en laissant inappliquée toute disposition nationale contraire au droit communautaire »*.

→ CJCE, 9 mars 1978, *Simmenthal.*

La protection directe et effective des droits que les particuliers tirent du droit de l'Union dépend du juge national. Le rôle capital du juge interne dans la mise en œuvre du droit communautaire s'est traduit, pour les justiciables, par la reconnaissance d'un droit au juge, un tel droit se trouvant à la base des traditions constitutionnelles communes aux États membres.

Le caractère subsidiaire des compétences juridictionnelles de la Cour de justice, par rapport aux compétences de principe des juridictions nationales, ressort de la fonction contentieuse limitée de celle-ci et s'explique par le fait que la Cour de Luxembourg ne constitue pas une véritable Cour Suprême au sommet de la hiérarchie judiciaire.

POUR ALLER PLUS LOIN

Les juridictions nationales disposent, dès l'origine, d'une compétence de droit commun dans le contrôle du respect du droit de l'Union par les États membres. En vertu du principe d'administration indirecte, l'exécution, y compris juridictionnelle, des normes européennes est largement décentralisée. L article 19.1 TUE indique que « les États membres établissent les voies de recours nécessaires pour assurer une protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l Union ». À la différence du principe de subsidiarité consacré à l'article 5.3 TUE, la subsidiarité juridictionnelle se présente comme un principe de répartition des compétences entre les juges nationaux et la Cour de justice, et non comme un principe de régulation de leur exercice, dans la mesure où elle implique une séparation étanche entre les sphères de compétences juridictionnelles. Si la Cour de justice est compétente pour interpréter le droit de l'Union, et contrôler la légalité du droit dérivé par rapport au droit primaire, les juges nationaux sont compétents pour interpréter le droit interne et en sanctionner la non-conformité au droit de l'Union, tel qu'interprété par la Cour de justice. Une telle distribution paraît naturelle, le juge national étant mieux placé que le juge européen pour se prononcer sur le droit interne.

2.2. La complémentarité des voies de droit de l'Union et des États membres

L'article 19 du Traité sur l'Union rappelle la particularité du système juridictionnel de l'Union qui ne dépend pas uniquement des voies de droit devant la Cour de justice. Aux yeux de la Cour de justice, si les États membres disposent d'une autonomie procédurale, ils doivent garantir l'accès au juge et ouvrir les voies de droit interne à la protection des droits que les justiciables tirent du droit de l'Union.

→ Art. 19 TUE.

→ CJCE, 25 juillet 2002, *Unión de Pequeños Agricultores.*

Cependant, cette obligation n'implique pas que les États membres ouvrent une voie de droit spécifique permettant de contester à titre principal un acte de l'Union de portée générale. La Charte n'a pas eu d'incidence sur la jurisprudence de la Cour, qui considère que le système actuel apporte les garanties suffisantes en matière de droit au recours effectif.

POUR ALLER PLUS LOIN

Les limites de la subsidiarité juridictionnelle ont été mises en lumière lors de la controverse relative à la question de l'irrecevabilité des recours en annulation introduits, devant le juge européen, par les particuliers, personnes physiques ou morales, contre des actes européens de portée générale ne les concernant pas individuellement. Afin de garantir la complétude des voies de recours, le Tribunal, par son arrêt Jégo-Quéré, et l'Avocat général, dans ses conclusions relatives à l'affaire UPA, avaient estimé que le droit à un recours effectif exigeait une évolution de la jurisprudence sur la notion de personne individuellement concernée. À cet égard, l'arrêt UPA offre une illustration de la façon dont la Cour de justice a pu user de la subsidiarité juridictionnelle (CJCE, 25 juillet 2002, Unión de Pequeños Agricultores). Dans la mesure où la notion d'affectation individuelle était prévue par le droit primaire, la Cour a considéré que seule une révision du traité permettait un assouplissement des conditions de recevabilité. La Cour a néanmoins pris soin de renvoyer aux juridictions nationales la tâche d'assurer la protection complète du justiciable dans la mesure où il leur revenait d'assurer, au premier chef, la protection des droits des particuliers. La Cour fut accusée de se retrancher derrière la subsidiarité juridictionnelle dans le but d'éviter un encombrement de son prétoire. On lui a également reproché d'imposer aux autorités nationales une obligation de compléter les voies de recours de l'Union, au risque de faire varier la protection des particuliers en fonction des États membres. La modification de l article 263 TFUE par le traité de Lisbonne n a pas permis de combler les lacunes dans la protection juridictionnelle des justiciables. Si le nouvel article 263 TFUE a modifié l ex-article 230 TCE, la Cour de justice a maintenu sa lecture rigoriste. Cette caractéristique s explique par le fait que la Cour de justice n est pas, contrairement à ce qui existe dans le fédéralisme allemand ou suisse, une juridiction suprême compétente pour réformer les jugements des tribunaux des États

3. La Cour de justice et les autres juridictions protectrices des libertés : concurrence ou synergie ?

Dans l'architecture complexe de la protection des droits fondamentaux en Europe, la Cour de justice n'agit pas seule. Face à elle, les juridictions nationales, mais aussi la Cour européenne des droits de l'homme, revendiquent chacune un rôle déterminant.

Entre rivalité et complémentarité, concurrence et recherche d'harmonie, les rapports entre ces juridictions traduisent une dynamique à la fois coopérative et conflictuelle. Dans ce jeu d'influences croisées, se pose la question de savoir si la pluralité des juges protecteurs des libertés concourt à un enrichissement mutuel ou révèle, au contraire, une compétition larvée entre ordres juridiques.

3.1. Les rapports de la Cour de justice avec les juridictions des États membres

L'organisation judiciaire de l'Union européenne, fondée sur un mécanisme de subsidiarité juridictionnelle, exclut toute hiérarchie entre la Cour de justice et les juridictions nationales, la Cour n'étant pas une Cour suprême fédérale. Contrairement aux modèles fédéraux traditionnels, elle ne dispose ni d'un pouvoir d'appel, ni d'un pouvoir de cassation pour réformer les décisions internes.

3.1.1. Le renvoi préjudiciel en interprétation : une coopération indispensable des juges

Pour assurer l'unité d'interprétation et d'application du droit de l'Union sans instaurer de lien de subordination entre les juges, les rédacteurs des traités ont institué le mécanisme original du renvoi préjudiciel. Celui-ci, pierre

angulaire de l'effectivité du droit de l'Union, permet à la Cour de justice, par un art subtil de la reformulation des questions, d'apporter aux juridictions nationales des réponses suffisamment précises pour guider leur jugement.

Si, en principe, la Cour ne statue pas sur la validité du droit national, le renvoi préjudiciel en interprétation du droit de l'Union lui offre, en pratique, une capacité d'influence notable, restreignant la marge d'appréciation des juges nationaux.

Ainsi, la subsidiarité juridictionnelle, pensée comme une garantie d'une protection de proximité pour les justiciables, sert aussi à affirmer l'autorité du droit de l'Union.

3.1.2. Protection juridictionnelle effective : protection du justiciable ou de la norme européenne

La répartition des compétences juridictionnelles paraît, en théorie, simple : le juge national, arbitre naturel des litiges individuels, assure la protection des justiciables, et ce n'est qu'exceptionnellement, en cas de défaillance, que le juge de l'Union est appelé à intervenir. Le critère déterminant est celui de la protection effective des droits individuels.

Cependant, cette logique est infléchie par la jurisprudence de la Cour, qui, dans les années 1980, a érigé en principe général le droit à un recours juridictionnel effectif. Cette décision marque un tournant : non seulement elle renforce la protection des droits fondamentaux, mais elle permet également à la Cour de circonscrire l'autonomie procédurale des États membres au travers des exigences d'effectivité et d'équivalence.

→ CJCE, 15 mai 1986, *Johnston.*

La reconnaissance prétorienne de ce droit a permis, ponctuellement, de limiter l'autonomie nationale en matière procédurale. Dans cette perspective, la protection juridictionnelle effective apparaît moins comme une fin en soi que comme un instrument destiné à garantir la pleine effectivité du droit de l'Union.

Ainsi, le « droit au juge » devient un levier au service de la sauvegarde de l'intégrité du droit de l'Union, sans pour autant nier totalement la dimension protectrice à l'égard des particuliers. La jurisprudence ultérieure semble confirmer que la protection juridictionnelle effective est davantage conçue comme un moyen d'assurer l'applicabilité uniforme du droit de l'Union que comme une fin autonome.

→ CJCE,13 mars 2007, *Unibet.*

3.2. Les rapports de la Cour de justice avec la Cour européenne des droits de l'homme

L'idée d'une rivalité persistante entre les deux Cours ne correspond plus aujourd'hui qu'à une réalité résiduelle : d'une part, les relations entre la Cour de Luxembourg et la Cour de Strasbourg, sont empreintes de courtoisie et de coopération ; d'autre part, les échanges institutionnels sont réguliers, et les magistrats des deux Cours suivent de près leurs jurisprudences respectives.

Toutefois, la Cour de justice reste indéniablement attachée à préserver l'autonomie du droit de l'Union, au point que son « obsession du contrôle » est souvent dénoncée. Les critiques ont été nombreuses à la suite de la publication de l'avis de 2014 par lequel la Cour de justice a temporairement mis fin au processus d'adhésion à la Convention.

→ CJUE, avis 2/13 du 18 décembre 2014.

Derrière la série de griefs formulés par la Cour contre le projet d'adhésion de l'Union à la Convention, beaucoup de commentateurs ont vu l'expression d'une méfiance viscérale à l'idée de partager, même partiellement, sa souveraineté juridictionnelle. On lui a ainsi reproché un manque d'audace dans sa défiance tant à l'égard des juridictions suprêmes nationales qu'à l'égard de la Cour de Strasbourg pour intégrer les spécificités du système juridictionnel de l'Union.

Cependant, d'autres analyses soulignent la cohérence d'ensemble de l'argumentation de la Cour de justice, reflet d'une vision structurée et globale de l'ordre juridique de l'Union.

Loin d'une logique brutale de confrontation, les deux Cours s'inscrivent dans une recherche constante de complémentarité et de convergence, au service d'une protection renforcée des droits fondamentaux en Europe.

POUR S'ENTRAÎNER

Dissertation : Commentaire de texte.

« Article 19.1 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : La Cour de justice de l'Union européenne comprend la Cour de justice, le Tribunal et des tribunaux spécialisés. Elle assure le respect du droit dans l'interprétation et l'application des traités. Les États membres établissent les voies de recours nécessaires pour assurer une protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l'Union […]. *»*

« Article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne - Droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial : Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l'Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter […]. *»*

Les extraits issus de l'article 19 § 1 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux définissent les garanties juridictionnelles dans l'ordre juridique de l'Union.

Le premier établit le rôle central de la Cour de justice dans l'interprétation et l'application du droit de l'Union et impose aux États membres d'assurer une protection juridictionnelle effective. Le second consacre, comme droit fondamental, l'accès à un tribunal impartial et à un recours effectif. Cette protection repose cependant sur un équilibre complexe entre l'exigence d'unité dans l'application et l'interprétation du droit de l'Union, d'une part, et l'autonomie procédurale des États membres, d'autre part.

Problématique. La subsidiarité juridictionnelle contribue-t-elle à renforcer la protection juridictionnelle des justiciables, ou ne sert-elle qu'à dissimuler les lacunes du système juridictionnel de l'Union européenne ?

Bien que la consécration implicite de la subsidiarité juridictionnelle à travers l'article 19 du Traité sur le fonctionnement de l'Union entretienne des rapports ambigus avec l'effectivité du droit au recours garanti par l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux **(I)**, la Cour n'hésite pas à s'adosser à ces textes afin d'imposer aux États l'obligation de garantir, dans leur ordre juridique interne, l'accès à un tribunal indépendant et impartial **(II)**.

I. La subsidiarité juridictionnelle : entre consécration implicite et mise en œuvre ambiguë

A. L'article 19 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, garant de l'autonomie procédurale des États membres

Si le principe de subsidiarité juridictionnelle n'a jamais été formellement consacré dans les traités, il semble néanmoins trouver une reconnaissance implicite à travers l'article 19 TUE, introduit par le traité de Lisbonne, qui impose aux États membres d'établir les voies de recours nécessaires pour assurer une protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l'Union.

Cela s'articule étroitement avec l'autonomie procédurale des États membres et le rôle central des juridictions nationales, placées en première ligne pour garantir l'effectivité du droit de l'Union. Mais cette logique de proximité, qui devrait renforcer la protection juridictionnelle des justiciables, apparaît ambivalente à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice.

B. Une subsidiarité révélatrice des limites de l'accès direct au juge de l'Union

Dans l'arrêt *Inuit*, la Cour de justice rappelle que les États conservent la compétence pour organiser les recours internes, dans le respect des principes d'équivalence et d'effectivité (CJUE, 3 octobre 2013, *Inuit Tapiriit Kanatami c. Parlement et Conseil*). Ce raisonnement, consolidé par les références répétées à l'article 19 TUE, fait peser sur les juridictions nationales la responsabilité d'assurer une protection juridictionnelle effective, reléguant le juge de l'Union à un rôle subsidiaire.

En refusant d'élargir l'accès direct des particuliers à ses prétoires, comme dans la jurisprudence *Plaumann* (CJCE, 15 juillet 1963, *Plaumann*), la Cour se décharge de ses propres exigences découlant de l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union.

Cela reflète moins une volonté de proximité avec le justiciable qu'une stratégie de gestion des carences structurelles du système juridictionnel. Loin de garantir le droit au recours, la subsidiarité juridictionnelle masque un renoncement jurisprudentiel à assurer une protection juridictionnelle intégrale à l'échelle de l'Union.

II. La combinaison de l'article 47 de la Charte et de l'article 19 du Traité afin d'approfondir les exigences envers les États membres

A. L'équivalence entre l'article 47 de la Charte et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme

Le droit des personnes à voir leur cause entendue dans un délai raisonnable constitue un principe général du droit de l'Union qui a été consacré à l'article 6.1 de la CEDH et à l'article 47 CDF pour ce qui concerne la procédure juridictionnelle.

L'article 47 de la Charte consacrant le droit à un recours effectif et l'accès à un tribunal impartial prévoit que toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l'Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal. Aux termes de cette disposition, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable et doit avoir la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter. La Cour veille à ce que l'interprétation qu'elle effectue de l'article 47 assure un niveau de protection qui ne méconnaît pas celui garanti à l'article 6 de la CEDH, tel qu'interprété par la Cour européenne des droits de l'homme (CJUE, 29 juillet 2019, *Gambino et Hyka, C-38/18*).

B. L'article 19 du Traité, fondement d'un contrôle de la Cour de justice des réformes juridictionnelles nationales

L'exigence d'indépendance découlant de l'article 19.1 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne à laquelle doivent satisfaire les juridictions nationales susceptibles d'interpréter et appliquer le droit de l'Union, impose que les règles gouvernant le régime disciplinaire prévoient l'intervention d'instances satisfaisant elles-mêmes aux garanties inhérentes à une protection juridictionnelle effective conformément à une procédure conforme à l'article 47 de la Charte (CJUE, *Commission c Pologne, affaire C-791/19*).

Fiche nº 24 - LES AUTRES JURIDICTIONS RÉGIONALES

POINTS CLÉS

- Cour interaméricaine des droits de l'homme.
- Commission interaméricaine des droits de l'homme.
- Cour africaine des droits de l'homme et des peuples.
- Cour arabe des droits de l'homme.
- Universalisme des droits humains.
- Relativisme culturel.

PRINCIPALES RÉFÉRENCES

- Déclaration américaine des droits et devoirs de l'homme 1948.
- Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948.
- Convention américaine relative aux droits de l'homme de 1969.
- Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 1981.
- Protocole relatif à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples portant création d'une Cour africaine des droits de l'homme et des peuples de 1998.
- Nouveau règlement intérieur de la Cour africaine de 2020.
- Charte arabe des droits de l'homme de 2004.
- Résolution nº 7790 portant Statut de la Cour arabe des droits de l'homme de 2014.

1. La Cour interaméricaine des droits de l'homme

1.1. L'entrée en vigueur de la Cour interaméricaine et la reconnaissance de sa compétence

La Déclaration américaine des droits et devoirs de l'homme a été adoptée en 1948 à Bogota, en Colombie, par les États membres de l'Organisation des États américains qui comporte 35 États membres. Le Secrétaire général de l'Organisation des États américains est Luis Almagro (Uruguay).

En 1969 est adoptée à San José, au Costa Rica, la Convention américaine relative aux droits de l'homme, qui est entrée en vigueur en 1978. 22 États ont reconnu la compétence de la Cour interaméricaine. Les États-Unis ainsi que le Canada ne sont pas parties à la Convention.

Cette Convention prévoit deux organes compétents pour la protection des dispositions de la Charte : la Commission interaméricaine des droits de l'homme et la Cour interaméricaine des droits de l'homme. La création de la Commission remonte à la Déclaration américaine des droits et devoirs de l'homme.

1.2. Les compétences de la Commission et de la Cour

La Commission interaméricaine des droits de l'homme (organe non juridictionnel) :

- Composition : 7 membres élus par l'Assemblée générale de l'Organisation des États américains pour un mandat de quatre ans renouvelable une fois.
- Siège : à Washington aux États-Unis.
- Compétence : examen des requêtes des États parties à la Convention avant transmission à la Cour et examen des plaintes et pétitions soumises par une personne ou un groupe de personne + règlement à l'amiable + enquête + rapports et recommandations relatifs aux droits humains dans les États membres.

- Conditions de recevabilité : épuisement des voies de recours internes (sauf absence de procédure ou refus d'accès aux voies de recours ou retard injustifié de la décision) + délai de six mois après connaissance du requérant de la décision définitive + affaire non examinée antérieurement.

La Cour interaméricaine des droits de l'homme (organe juridictionnel) :

- Composition : 7 juges élus par l'Assemblée générale de l'Organisation des États américains pour un mandat de six ans renouvelable une fois.
- Siège : à San José au Costa Rica.
- Compétence consultative : avis sur l'interprétation de la Convention américaine ou des traités relatifs aux droits humains en Amérique à la demande d'un organe de l'Organisation ou d'un État membre de l'Organisation.
- Compétence contentieuse : saisine par un État membre de l'Organisation ou par la Commission, pas de recours individuel direct + statuer sur la violation d'un droit ou d'une liberté enfreint par un État + prononcer des mesures provisoires.
- Procédure contentieuse : en cas d'échec de la procédure devant la Commission et de non-respect des recommandations de la Commission par un État.

1.3. Exemples de rapports adoptés par la Commission interaméricaine

- Rapport de 2023 relatif aux femmes privées de liberté dans les Amériques.
- Rapport de 2023 relatif à la criminalité organisée et les droits des enfants, des adolescents et des jeunes : défis actuels et actions des États.
- Rapport de 2023 relatif à la situation des défenseurs de l'environnement en Amérique centrale et du Nord.
- Rapport de 2023 relatif aux personnes réfugiées et migrantes arrivées du Venezuela.

1.4. Exemples de décisions rendues par la Cour interaméricaine

En 1988, les disparitions forcées commencent à faire l'objet d'un traitement juridictionnel par la Cour interaméricaine avec l'arrêt *Velasquez Rodriguez contre Honduras.* En 2010, par l'arrêt *Chitay Nech et a. c. Guatemala*, la Cour a condamné le Guatemala à cause de la disparition forcée du maire d'une commune en considérant que celle-ci violait concomitamment les droits politiques du maire et de sa communauté dont il était un représentant.

Pour la première fois, dans l'arrêt *Atala Riffo et filles c. Chili* de 2012, la Cour interaméricaine condamne un État pour discrimination fondée sur l'orientation sexuelle.

La matière pénitentiaire fait également l'objet d'une jurisprudence de la Cour. Par exemple, elle a condamné en 2020 le Venezuela du fait de l'usage disproportionné de la force à l'égard de détenus dans l'arrêt *Olivarez Muñoz y otros c. Venezuela.*

POUR ALLER PLUS LOIN

Il existe des conventions interaméricaines traitant de thèmes spécifiques : la Convention interaméricaine pour la prévention et la répression de la torture ; le Protocole additionnel à la Convention américaine traitant des droits économiques, sociaux et culturels ; le Protocole à la Convention américaine traitant de l'abolition de la peine de mort ; la Convention interaméricaine sur la prévention, la sanction et l'élimination de la violence contre la femme ; la Convention interaméricaine sur la disparition forcée des personnes ; la Convention interaméricaine pour l'élimination de toutes les formes de discrimination contre les personnes handicapées ; la Convention interaméricaine contre toutes les formes de discrimination.

2. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples

2.1. Entrée en vigueur et ratifications

Initialement, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, adoptée en 1981, ne prévoit pas de juridiction visant à garantir les dispositions de la Convention. Une Commission africaine des droits de l'homme et des peuples fut créée en 1987 qui, en vertu de l'article 45 de la Charte, promeut les droits humains et des peuples, les protège, et interprète la Charte.

Le Protocole de 1998 à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples a institué à l'article premier une Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, protocole adopté par les États parties à l'Organisation de l'Union africaine (anciennement Unité africaine) à Ouagadougou. Il est entré en vigueur en 2004.

La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples est située à Arusha, en Tanzanie. Sur les 55 États membres de l'Union africaine, 34 États ont ratifié le protocole.

2.2. Composition de la Cour africaine

La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples est composée de onze juges élus ressortissants d'États membres de l'Union africaine. Ils disposent d'un mandat de six ans qui peut être renouvelé une fois.

L'actuelle présidente de la Cour africaine est une femme, la juge Imani Daud Aboub (Tanzanie), le vice-président est le juge Sacko Modibo (Mali). Ils composent tous deux le Bureau de la Cour, élus pour une période de deux ans, leur mandat est renouvelable une fois.

2.3. Les compétences de la Cour africaine

Le règlement intérieur de la Cour africaine, modifié en 2010 puis en 2020, prévoit le double volet de compétences de la Cour à la règle 29.

2.3.1. La compétence contentieuse de la Cour africaine

La règle 29 du règlement intérieur prévoit la compétence contentieuse de la Cour qui se décline de la façon suivante :

- *« Connaître de toutes les affaires et de tous les différends dont elle est saisie concernant l'interprétation et l'application de la Charte, du Protocole et de tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l'homme et ratifié par les États concernés. »*
- *« Tenter de régler à l'amiable les affaires qui lui sont soumises conformément aux dispositions de la Charte et du Protocole. »*
- *« Interpréter une décision qu'elle a rendue. »*
- *« Réviser sa décision. »*

La Cour africaine peut être saisie, en vertu de l'article 39 du règlement intérieur par : la Commission, l'État partie à la Commission, l'État partie contre lequel une plainte a été introduite devant la Commission, l'État partie dont le ressortissant est victime d'une violation des droits de l'homme, les organisations intergouvernementales africaines, et un individu ou une organisation non gouvernementale.

Dans le cadre de situation *« d'extrême gravité ou d'urgence et lorsqu'il s'avère nécessaire d'éviter des dommages irréparables à des personnes »*, des mesures provisoires peuvent également être ordonnées par la Cour africaine (art. 59).

L'art. 72 indique le caractère obligatoire et exécutoire des décisions de la Cour pour les parties.

Sur les 34 États qui ont ratifié le protocole, seuls quelques États ont reconnu la compétence de la Cour pour le traitement des requêtes émanant des individus et des organisations non gouvernementales.

2.3.2. La compétence consultative de la Cour africaine

L'article 29 du règlement intérieur prévoit que la Cour peut rendre des avis relatifs à des questions juridiques tenant à la Charte ou à d'autres textes relatifs aux droits de l'homme. La Cour peut être saisie pour avis consultatif par un État membre, l'Union africaine, et les organes de l'Union africaine.

POUR ALLER PLUS LOIN

Selon le rapport d'activité de la Cour africaine de 2024, depuis qu'elle est opérationnelle (2006) la Cour a reçu 366 requêtes dans le cadre de sa compétence contentieuse ainsi que 16 demandes d'avis consultatifs ; le rapport indique que la Cour a statué sur 253 requêtes, 16 demandes d'avis consultatifs. Plus de 110 requêtes sont actuellement pendantes.

À titre d'exemples d'avis rendus par la Cour africaine :

- Avis consultatif du 28 septembre 2017 sur les obligations des États en vertu du protocole à la Charte relatif aux droits des femmes en Afrique (*demande introduite par plusieurs demandeurs*).
- Avis consultatif du 4 décembre 2020 sur la compatibilité des lois sur le vagabondage avec la charte africaine des droits de l'homme et des peuples et avec les autres instruments des droits de l'homme applicables en Afrique (*demande introduite par l'Union panafricaine des avocats*).
- Avis consultatif du 16 juillet 2021 sur le droit de participer à la direction des affaires publiques dans un contexte d'une élection tenue lors d'une urgence de santé publique ou d'une pandémie telle que la crise de la Covid-19 (*demande introduite par l'Union panafricaine des avocats*).

En 2024, une demande d'avis consultatif a été introduite par l'Union panafricaine des avocats à propos de la compatibilité de la peine de mort avec la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples.

2.3.3. Le partage de compétence avec la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples

Le chapitre II du règlement intérieur est consacré à la « Complémentarité entre la Cour et la Commission » et détaille les modalités de saisine de la Cour par la Commission et précise que la Cour ne peut pas traiter une requête ou une demande d'avis si l'affaire est pendante devant la Commission.

3. La Cour arabe des droits de l'homme

3.1. L'adoption du Statut portant création de la Cour arabe

Sous l'égide de la Ligue arabe, la Charte arabe des droits de l'homme, adoptée à Tunis en 2004, a institué par son article 45 un Comité arabe des droits de l'homme composé de sept membres élus par les États parties à la Charte pour un mandat de quatre ans. Le Conseil de la Ligue arabe a adopté une résolution en 2014 pour créer la Cour arabe des droits de l'homme, dont le siège est fixé à Manama, au Bahreïn.

3.2. La composition de la Cour arabe

L'article 5 du Statut prévoit que la Cour est composée de sept juges, un nombre qui peut s'élever à onze juges, l'article 6 prévoit qu'ils sont élus par l'Assemblée créée par ce même statut. Les juges sont élus pour un mandat de quatre ans, renouvelable une fois ; en vertu de l'article 11 du Statut, le président et le vice-président sont élus parmi les membres de la Cour pour une durée de deux ans, et sont rééligibles une fois.

3.3. Les compétences de la Cour arabe

L'article 16 du Statut prévoit la compétence de la Cour :

« Dans tous les procès et litiges découlant de l'application et de l'interprétation de la Charte arabe des droits de l'homme ou de toute autre convention arabe dans le domaine des droits de l'homme dont les États litigieux en font partie.

La Cour statue sur des litiges soulevés à l'égard de sa compétence à propos des procès, des requêtes ou des affaires qu'elle étudie. »

Le recours individuel devant la Cour arabe n'est pas reconnu par le Statut portant sa création, de plus, le recours des organisations non gouvernementales est subordonné à l'autorisation des États. La Cour arabe dispose également d'une compétence consultative à la demande d'un organe de la Ligue Arabe.

3.4. La portée limitée de la Cour arabe

La portée de la Cour arabe est particulièrement limitée dans la mesure où cette dernière **n'est pas entrée en vigueur**, et n'a dès lors jamais rendu de décisions.

POUR ALLER PLUS LOIN

Dans une note du Secrétaire général des Nations unies du 27 août 2024, « Promotion et protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la lutte contre le terrorisme », il est indiqué que le projet de Cour arabe des droits de l'homme demeure « au point mort ».

4. Tableau comparatif des différentes juridictions régionales :

	Cour européenne des droits de l'homme	Cour interaméricaine des droits de l'homme	Cour africaine des droits de l'homme et des peuples	Cour arabe des droits de l'homme
Socle conventionnel	Convention européenne des droits de l'homme de 1950	Convention américaine relative aux droits de l'homme de 1969	Protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 1998	Statut de la Cour arabe des droits de l'homme de 2014
Entrée en vigueur	1959	1979	2004	Pas entrée en vigueur
Nombre d'États reconnaissant la compétence de la Cour	46 États	22 États	34 États	1 État a ratifié le Statut de la Cour (Arabie Saoudite)
Composition	46 juges	7 juges	11 juges	7 juges
Compétence	Contentieuse Recours individuel Recours interétatique Consultative Juridictions des États parties	Contentieuse États et Commission Consultative États membres et organes de l'Organisation des États américains	Contentieuse États, Commission Recours individuel (reconnu par quelques États) Consultative États membres et organes de l'Union africaine	Contentieuse États membres, et ONG avec l'autorisation des États membres Consultative Ligue arabe et ses organes

POUR S'ENTRAÎNER

Dissertation : Les juridictions régionales et l'universalisation des droits humains

Le terme « universel » renvoie à ce qui est commun à tous les êtres humains, qui s'étend à l'échelle mondiale.

La Déclaration universelle des droits de l'homme a été votée par cinquante pays en 1948 ; certains ne l'ont pas votée, comme l'Afrique du Sud (en raison de l'Apartheid) et l'Arabie saoudite (à cause du rejet de l'égalité entre les hommes et les femmes).

La Déclaration évoque deux aspects de l'universalisme des droits humains :

- Les droits humains sont universels, car chaque être humain en est bénéficiaire au nom de sa dignité.
- Les droits humains sont universels, car ils doivent être respectés par l'ensemble de la société internationale.

La conférence de Vienne sur les droits de l'homme de 1993 a été l'occasion de réaffirmer cet universalisme qui apparaît comme un principe directeur des droits humains au même titre que l'interdépendance, l'indivisibilité et l'inaliénabilité de ces droits. En dépit de cette réaffirmation, une fragmentation régionale de la protection des droits humains peut être observée.

Lors de cette conférence, il a également été dit : *« S'il convient de ne pas perdre de vue l'importance des particularismes nationaux et régionaux et la diversité historique, culturelle et religieuse, il est du devoir des États, quel qu'en soit le système politique, économique et culturel, de promouvoir et de protéger tous les droits de l'homme et toutes les libertés fondamentales. »*

Problématique et annonce du plan : L'universalité des droits humains a pu être concrétisée au moyen de mécanismes de protection régionaux des droits humains **(I)**. Cette concrétisation de l'universalité des droits humains demeure toutefois confrontée à des difficultés structurelles **(II)**.

I. Une universalisation concrétisée par des instruments et mécanismes régionaux

A. L'absence de juridiction internationale de protection des droits humains

La Déclaration universelle des droits de l'homme est une résolution sans force contraignante (même si certains États lui ont reconnu une portée normative) ; le Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966 l'ont concrétisée. Plusieurs conventions onusiennes portent sur des thèmes spécifiques (Exemples : Convention sur l'élimination de toutes formes de discrimination à l'égard des femmes, Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, Convention relative aux droits de l'enfant, Convention relative aux droits des personnes handicapées…).

L'ensemble de ces textes n'a pas donné lieu à une juridiction internationale de protection des droits humains, seulement à la création de comités onusiens dont les décisions n'ont pas de valeur contraignante (Exemples : Comité des droits de l'homme, Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, Comité contre la torture, Comité des droits de l'enfant, Comité des travailleurs migrants, Comité des droits des personnes handicapées…).

La Cour internationale de justice, organe judiciaire principal des Nations unies, n'a pas vocation à régler des litiges relatifs aux violations des droits humains : saisine que par des États dans le cadre de sa compétence contentieuse ; dans le cadre de sa compétence consultative, elle peut être saisie par des organes ou institutions onusiens.

B. Une concrétisation réalisée à l'échelle régionale

Plusieurs textes adoptés à des échelles régionales prévoient des juridictions compétentes à une échelle déterminée pour connaître des violations des droits humains et libertés fondamentales (*Cour européenne des droits de l'homme, Cour interaméricaine des droits de l'homme, Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, Cour arabe des droits de l'homme*).

II. Une universalisation confrontée à des obstacles structurels

A. Une universalisation confrontée à l'efficacité variable des cours régionales

Dans un communiqué de l'Union africaine relatif à la « Conférence sur la mise en œuvre et l'impact des décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples » du 3 novembre 2021, il est relevé pour l'année 2020 :

- Exécution intégrale à 7 % ;
- Exécution partielle à 18 % ;
- Non-exécution totale 75 % ; exécution des mesures provisoires de 10%.

Dans ce même document, il est indiqué parmi les défis *« la difficulté pour les systèmes nationaux de cerner les décisions de la Cour africaine qui ne tiennent pas compte de principes tels que la subsidiarité, la contextualisation des valeurs universelles »*.

Il est difficile d'évoquer l'exécution de la mise en œuvre des décisions de la Cour arabe des droits de l'homme dans la mesure où celle-ci n'est pas en vigueur. Par ailleurs, il n'existe pas de juridiction régionale de protection des droits humains en Asie.

B. Une universalisation limitée par le relativisme culturel

La Cour européenne des droits de l'homme, soucieuse de l'universalisme des droits humains, laisse toutefois une large marge d'appréciation aux États parties à la Convention européenne sur des questions pour des raisons culturelles, notamment religieuses (interruption volontaire de grossesse, légalisation du mariage entre personnes de même sexe, fin de vie).

La Charte arabe des droits de l'homme fait, dès son préambule plusieurs références à la religion ; l'article 3 prévoit *« la discrimination positive instituée au profit de la femme par la charia islamique et les autres lois divines et par les législations et les instruments internationaux »*. L'article 6 de la Charte prévoit la possibilité de prononcer la peine de mort dans certains cas, l'article 7 prévoit qu'elle peut être prononcée à l'encontre de personnes de moins de dix-huit ans dans certains cas ; l'article 33 prévoit que la famille est *« fondée sur le mariage entre l'homme et la femme »*. Le préambule du Statut de la Cour arabe des droits de l'homme fait également référence à Dieu.

Enfin, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples prévoit des devoirs de l'être humain envers sa communauté (art. 27, 28, 29) et fait référence à des traditions.

En conclusion, malgré les efforts déployés, l'universalisation demeure fragmentée et confrontée à des obstacles structurels d'ordre institutionnel, culturel ou politique. Il persiste une tension entre l'unité des principes universels et la diversité des contextes régionaux.

Fiche nº 25 - LA PROTECTION POLITIQUE ET ADMINISTRATIVE INTERNATIONALE

POINTS CLÉS

- Conseil des droits de l'homme des Nations unies.
- Haut-Commissariat aux droits de l'homme des Nations unies.
- Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe.
- Commission européenne pour la démocratie par le droit.
- Médiateur européen.
- Agence des droits fondamentaux.
- Contrôleur européen de la protection des données.

PRINCIPALES RÉFÉRENCES

- Art. 1er de la Charte des Nations unies.
- Art. 43 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
- Art. de la Convention européenne des droits de l'homme.
- Art. 228 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
- AGNU, Résolution 48/141 Haut-Commissaire chargé de promouvoir et de protéger tous les droits de l'homme, 20 décembre 1993.
- Comité des ministres, Résolution (99)50 sur le Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, 7 mai 1999.
- Comité des ministres, Résolution (90)6 relative à un Accord partiel portant création de la Commission européenne pour la démocratie par le droit, 10 mai 1999.
- Conseil, Règlement nº 168/2007 portant création d'une Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne, 15 février 2007.
- AGNU, Résolution 60/251 Conseil des droits de l'homme, 15 mars 2006.
- Art. 58 du règlement nº 2018/1725 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l'Union et à la libre circulation de ces données.

1. La protection administrative et politique par les organes des Nations unies

La Charte des Nations unies expose explicitement les buts poursuivis par les Nations unies, irrigués par le maintien de la paix et de la sécurité internationales. Son premier article précise que ces buts se réalisent notamment par le développement et l'encouragement des droits humains et libertés fondamentales.

Toutefois, il n'existe pas de juridiction internationale rattachée à l'Organisation des Nations unies chargée de veiller au respect des instruments internationaux relatifs aux droits humains.

Les Nations unies ont développé un système de protection politique et administrative des droits humains, comportant plusieurs organes en dehors des Comités conventionnels, parmi lesquels figurent le Conseil des droits de l'homme ainsi que le Haut-Commissariat aux droits de l'homme.

1.1. Le Conseil des droits de l'homme

Le Conseil des droits de l'homme est un organe intergouvernemental, héritier de la Commission des droits de l'homme (créée par une résolution en 1946), chargé de la promotion et de la protection des droits humains.

1.1.1 La création du Conseil des droits de l'homme

Créé en 2006 par la résolution 60/251 de l'Assemblée générale des Nations unies, il siège à Genève.

> → AGNU, Résolution 60/251 Conseil des droits de l'homme, 15 mars 2006.

Son prédécesseur institutionnel, la Commission des droits de l'homme, a fait l'objet de vives critiques tant en raison de sa composition que de l'orientation politique de ses prises de positions.

1.1.2. La composition du Conseil des droits de l'homme

Le Conseil se compose de 47 membres élus par l'Assemblée générale des Nations unies pour un mandat de trois ans, en tenant compte de la représentativité des zones géographiques. Le tiers des sièges est renouvelé chaque année.

Son président actuel est le diplomate Omar Zniber (Maroc) depuis 2024.

1.1.3. Les missions du Conseil des droits de l'homme

La résolution précitée lui confère des missions de promotion et de défense des droits humains. Il peut examiner des violations de ces derniers et formuler des recommandations à l'Assemblée générale des Nations unies.

Parmi ses missions se trouve la conduite de l'examen périodique universel afin de dresser un bilan des droits humains à travers le monde. Qui plus est, des experts indépendants peuvent mener des procédures spéciales qui consistent à dresser un rapport sur la situation des droits humains dans un pays ou sur un thème spécifique.

En 2007, une procédure de requête a été instaurée afin de permettre le signalement de graves violations des droits humains.

> → Conseil des droits de l'homme, Résolution 5/1 relative à la mise en place des institutions du Conseil des droits de l'homme, 18 juin 2007.

Les divers actes émis par le Conseil des droits de l'homme n'ont pas de valeur contraignante pour les États.

POUR ALLER PLUS LOIN

Le 3 avril 2025, le Conseil des droits de l'homme a adopté une résolution dont l'objet est de créer un groupe de travail intergouvernementale afin d'élaborer une convention contraignante relative aux droits humains des personnes âgées.

1.1.4. Les récents retraits d'États du Conseil des droits de l'homme

L'année 2025 a été marquée par le retrait de plusieurs États du Conseil des droits de l'homme des Nations unies. En effet, les États-Unis, Israël ainsi que le Nicaragua ont annoncé leur retrait. Concernant les États-Unis et le Nicaragua, il s'agit de leur deuxième retrait (respectivement en 2018 et 2022).

1.2. Le Haut-Commissariat aux droits de l'homme

Le Haut-Commissariat aux droits de l'homme a été créé par une résolution adoptée en 1993.

> → AGNU, Résolution 48/141 Haut-Commissaire chargé de promouvoir et de protéger tous les droits de l'homme, 20 décembre 1993.

1.2.1. La composition du Haut-Commissariat aux droits de l'homme

Le Haut-Commissaire est nommé par le Secrétaire général des Nations unies, la durée de son mandat est de quatre ans, ce mandat est renouvelable une fois. Depuis 2022, le Haut-Commissaire est Volker Türk (Autriche).

1.2.3. Le rôle du Haut-Commissariat aux droits de l'homme

Il est chargé de la coordination de la promotion des droits humains au sein des Nations unies. Bien que ses actions n'aient pas de force juridiquement contraignante, il exerce une influence politique importante.

2. La protection politique et administrative par des organes du Conseil de l'Europe

Lorsque le Conseil de l'Europe est mentionné, c'est généralement la Cour européenne des droits de l'homme qui fait l'objet d'observations et de commentaires.

Cependant, le Conseil de l'Europe comporte d'autres organes moins connus, dont des organes de protection politique et administrative, qui sont le Commissaire aux droits de l'homme et la Commission pour la démocratie par le droit.

2.1. Le Commissaire aux droits de l'homme

Le Commissaire aux droits de l'homme est un organe clé au sein du Conseil de l'Europe en ce qu'il entretient des dialogues avec les États membres relatifs au respect des droits humains.

2.1.1. La création du Commissaire aux droits de l'homme

Par une résolution de 1999, le Conseil des ministres a créé le Commissaire aux droits de l'homme. Son article 9 prévoit qu'il est élu par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, son article 11 prévoit que son mandat, non renouvelable, dure six ans.

→ CM, Rés. (99)50 sur le Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, 7 mai 1999.

L'actuel Commissaire est l'avocat Michael O'Flaherty (Irlande) depuis 2024.

2.1.2. Les compétences du Commissaire aux droits de l'homme

En vertu de l'article 3 de cette même résolution, ses missions résident dans la promotion des droits humains auprès des États membres du Conseil de l'Europe ainsi que dans des conseils et informations apportés dans ce domaine.

Il réalise des visites au sein de ces États, conduit des travaux thématiques et des activités de sensibilisation, et il émet des recommandations, avis et rapports (art. 8).

Il convient de préciser que le Commissaire aux droits de l'homme ne peut pas être saisi par requête individuelle.

Cependant, l'article 36 de la Convention européenne des droits de l'homme dispose que le Commissaire aux droits de l'homme peut présenter des observations écrites et prendre part aux audiences devant la Cour européenne des droits de l'homme.

POUR ALLER PLUS LOIN

En 2025, le Commissaire aux droits de l'homme a alerté sur le recul des droits humains en appelant les États membres du Conseil de l'Europe à les reprendre en considération. Dans son rapport d'activité de 2024, des focus thématiques concernent notamment les droits humains des Roms et gens du voyage, les droits humains des réfugiés, des demandeurs d'asile et des migrants, l'intelligence artificielle et les droits humains, ainsi que les droits humains des personnes LGBTI.

S'agissant des droits humains des Roms et gens du voyage, il a affirmé qu'il s'agissait d'une partie importante de son programme, et a effectué des visites spécifiques dans plusieurs États membres du Conseil de l'Europe. De plus, il a exposé des violations systématiques des droits humains aux frontières ainsi qu'une instrumentalisation de la matière migratoire, la nécessité d'une surveillance humaine efficace de l'intelligence artificielle, et a également mis en exergue les violations multiformes dont sont victimes des personnes transgenres.

Par des déclarations, en 2025, le Commissaire a appelé au renforcement des droits humains en Géorgie, notamment en ce qui concerne les droits des manifestants et des journalistes, mais aussi ceux des personnes LGBTI. Il a également appelé la Hongrie à ne pas voter le projet de loi anti-Organisations non gouvernementales.

2.2. La Commission pour la démocratie par le droit

Plus souvent appelée Commission de Venise, la Commission pour la démocratie par le droit est un organe consultatif du Conseil de l'Europe dans le domaine de la démocratie, des droits humains et de l'État de droit.

2.2.1. La création de la Commission de Venise

La Commission a été créée en 1990 par une résolution du Comité des ministres du Conseil de l'Europe.

> → CM, Rés. (90)6 relative à un Accord partiel portant création de la Commission européenne pour la démocratie par le droit, 10 mai 1999.

2.2.1. La composition de la Commission de Venise

Aux 46 États membres du Conseil de l'Europe s'ajoutent 15 autres États, parmi lesquels se trouvent notamment le Canada, le Chili, le Costa Rica, les États-Unis, Israël, le Maroc.

La Commission est composée d'un membre titulaire et d'un membre suppléant pour chaque État, ainsi que de membres de pays observateurs (Argentine, Saint-Siège, Japon, Uruguay).

L'actuelle présidente de la Commission de Venise est Claire Bazy Malaurie (France), autrefois membre du Conseil constitutionnel.

2.2.2. Les compétences de la Commission de Venise

La Commission fournit des conseils juridiques à la demande des États désireux de faire évoluer leur droit conformément aux principes qui irriguent les textes et l'action du Conseil de l'Europe. Elle peut émettre des avis et des recommandations, ainsi que des avis sur les suites données.

En plus de cela, la Commission publie des études (telle que sa liste des critères de l'État de droit), des rapports (comme celui relatif aux mesures au sein de l'Union européennes prises lors de la crise sanitaire du Covid-19) et des lignes directrices (comme celle relative à la réglementation des partis politiques) relatifs à la matière constitutionnelle et aux droits humains.

En outre, la Commission peut déposer des mémoires *amicus curiae* auprès de juridictions à leur demande. Par exemple, en 2025, elle a déposé un mémoire auprès de la Cour constitutionnelle ukrainienne.

3. La protection politique et administrative par des organes de l'Union européenne

La protection politique et administrative qui émane de l'Union européenne se caractérise par l'existence du Médiateur européen, de l'Agence des droits fondamentaux ainsi que du contrôleur européen de la protection des données.

3.1. Le médiateur européen

S'il fallait opérer une analogie avec le droit français, le médiateur européen s'apparente en quelque sorte au Défenseur des droits de l'Union européenne dans la mesure où celui-ci veille au respect des droits des citoyens et personnes morales européens dans le cadre de leur relation avec l'administration à l'échelle de l'Union européenne.

Il a été institué en 1992 par le Traité de Maastricht (voir art. 228 TFUE).

De plus, l'article 43 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union est consacré au médiateur.

3.1.1. L'élection du médiateur européen

En vertu de l'article 228 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, il est élu par le Parlement européen pour la durée de sa législature, soit cinq ans. La médiatrice actuelle est une juriste universitaire, Terese Anjinho (Portugal), depuis le 27 février 2025.

3.1.2. Les compétences d'enquête du médiateur européen

Les compétences du médiateur européen, énumérées à l'article précité, se manifestent en deux volets : en cas de plaintes des citoyens européens ainsi que de personnes morales en vue d'enquêter sur d'éventuels dysfonctionnements des différents institutions et organes de l'Union européenne, il peut également enquêter de sa propre initiative.

Cependant, il n'examine pas les plaintes lorsqu'il s'agit de la Cour de justice de l'Union européenne. En outre, sa compétence d'enquête ne trouve pas à s'appliquer lorsque les faits en cause font l'objet d'une procédure juridictionnelle selon ces mêmes dispositions.

Parmi les cas justifiant une enquête du médiateur européen se trouvent les défaillances dans les bonnes pratiques administratives ainsi que la méconnaissance des droits humains par des organes et institutions de l'Union européenne.

3.1.3. La portée de l'action du médiateur européen

Dans le cas où la demande d'enquête fait l'objet d'un examen, il formule des propositions et suggère des solutions que l'organe peut accepter ou non. Dans le cas contraire, il se borne à formuler des suggestions d'amélioration sans que celles-ci ne soient obligatoires pour l'organe concerné.

Malgré cette absence de caractère obligatoire, les propositions du médiateur européen sont généralement suivies par les entités concernées.

POUR ALLER PLUS LOIN

Selon les chiffres du médiateur européen, celui-ci traite environ 350 enquêtes annuelles.

En 2024, le médiateur européen a par exemple mené des enquêtes en matière de droits humains des personnes migrantes. En effet, il a mené une enquête sur la garantie de ces droits par la Commission européenne dans le cadre du protocole d'accord avec la Tunisie. De plus, il a mené une enquête relative à l'action de l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes s'agissant de ses activités de recherche et de sauvetage ; à l'issue de cette enquête, il a relevé les défaillances en la matière.

En 2025, le médiateur européen a notamment mené une enquête relative à la transparence des relations entre le Parlement européen et le lobbying du tabac et a souligné des lacunes en termes de transparence.

3.2. L'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne

3.2.1. La création de l'Agence des droits fondamentaux

Un règlement du Conseil de 2007 constitue le fondement légal de l'existence de l'Agence des droits fondamentaux.

> → Conseil, Règlement n° 168/2007 portant création d'une Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne, 15 février 2007.

Elle succède à l'Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes.

Disposant de son siège à Vienne, elle est dirigée par la Sirpa Rautio (Finlande) depuis 2024, et est composée d'une centaine de personnes.

3.2.2. Les compétences de l'Agence des droits fondamentaux

Cet organe vise à conseiller, d'une part, les organes de l'Union européenne, d'autre part, les États membres de l'Union européenne dans le domaine des droits humains afin de veiller au respect de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

En 2024, l'Agence a rendu un rapport rendant compte de la croissance des discriminations et du harcèlement (aussi bien dans des relations horizontales que dans des relations verticales) à l'égard des personnes de confession musulmane au sein de l'Union européenne depuis une enquête en date de 2016.

Cette même année, elle a examiné le règlement général de la protection des données, et a également enquêté sur les violences multiples fondées sur le sexe au sein de l'Union européenne.

En 2025, l'Agence a actualisé une base de données relatives à l'incarcération au sein des États membres de l'Union européenne.

3.2.3. La portée limitée de l'action de l'Agence des droits fondamentaux

L'ensemble des avis, rapports et études émanant de l'Agence qui permettent de documenter des violations des droits humains n'ont pas de valeur juridiquement contraignante.

3.3. Le contrôleur européen de la protection des données

3.3.1. La création du contrôleur européen de la protection des données

Dès 2004, l'Union européenne s'est saisi de la question de la protection des données, qui constitue un enjeu grandissant en termes de respect et de protection des droits humains, et a institué un contrôleur européen de la protection des données, siégeant à Bruxelles.

Il se distingue du Comité européen de la protection des données qui a été institué en 2018.

L'actuel contrôleur est l'avocat et universitaire Wojciech Wiewiórowski (Pologne).

3.3.2. La nomination du contrôleur européen de la protection des données

Le contrôleur européen de la protection des données n'est pas élu, mais nommé par une décision rendue conjointement par le Parlement européen ainsi que le Conseil.

3.3.3. Les compétences protéiformes du contrôleur européen des données

Gravées dans un règlement émanant du Parlement européen et du Conseil, les compétences du contrôleur visent à veiller au respect des règles tenant à la protection des données à caractère personnel au sein des organes et institutions de l'Union européenne.

> → Parlement européen, Conseil, règlement n° 2018/1725 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l'Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) n° 45/2001 et la décision n° 1247/2002/CE, 23 octobre 2018.

POUR ALLER PLUS LOIN

Pour rappel, l'article 16 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prévoit le droit de toute personne à la protection des données à caractère personnel le concernant. Ce même article prévoit les modalités d'édiction des règles en la matière. La protection des données à caractère personnel est également consacrée à l'article 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

Plus précisément, l'article 58 de ce règlement énumère ses pouvoirs d'enquête (formes d'audits sur la protection des données, notification aux organismes en cas de violation du règlement, obtention de l'accès de données à caractère personnel pour l'accomplissement de ses missions, obtention de l'accès aux locaux).

Ce même article prévoit que le Contrôleur européen de la protection des données dispose d'un pouvoir d'adopter des mesures coercitives (*avertissements, rappels à l'ordre, limitation temporaire ou définitive voire interdiction de traitement des données, imposition d'amende, suspension de flux de données*).

Enfin, l'article précité prévoit que le Contrôleur dispose de pouvoirs d'autorisation ainsi que de pouvoirs consultatifs (conseil des personnes dans l'exercice de leurs droits, conseiller les responsables de traitement, émission d'avis, autorisation de clauses contractuelles, autorisation d'arrangements administratifs, pouvoir de saisine de la Cour de justice de l'Union européenne dans certains cas).

POUR S'ENTRAÎNER

Argumentation juridique : Soutenez que la protection politique et administrative internationale contribue à la protection des droits humains.

La protection politique et administrative internationale se caractérise par l'existence de plusieurs organes, notamment à l'échelle des Nations unies, du Conseil de l'Europe et de l'Union européenne.

Le XXIe siècle est marqué par la multiplication de ces derniers, dont la plupart sont plutôt méconnus.

La variabilité de l'étendue de leur compétence et de leur activité interroge leur capacité à concourir à la protection des droits humains de manière effective.

Dans le contexte international, y compris européen, de remise en cause des droits humains, l'intérêt d'une telle analyse de l'apport de ces organes à la garantie des droits humains est particulièrement éclairant.

Problématique et annonce du plan : Il s'agira de soutenir que la contribution des organes de protection politique et administrative internationale à la protection des droits humains est tangible **(I)**, même si cette contribution demeure confrontée à des obstacles **(II)**.

I. Une contribution à la protection des droits humains tangible

A. La volonté de renforcer la protection des droits humains en dehors des prétoires

Il existe une diversité d'organes internationaux et européens non juridictionnels dont le but est la protection des droits humains à travers le monde selon des modes d'action variés.

L'indépendance de ces organes au sein d'organisations internationales constitue un élément important pour l'impartialité de leur action et des documents publiés.

Ils permettent de contribuer à la diffusion d'une culture des droits humains (bien que celle-ci fasse régulièrement l'objet de critiques et remises en cause) et permettent de diffuser publiquement des violations de ces droits.

La publication de ces informations est importante pour les citoyens, avocats, organisations non gouvernementales, universitaires, juridictions, gouvernements et contribuent à des évolutions du respect des droits humains

B. Les modalités efficaces de soutien des droits humains

L'efficacité de cette contribution est variable d'un organe à un autre.

Certaines modalités d'action concourent largement à la protection des droits humains :

Les suggestions du médiateur européen sont généralement suivies.

- Le Commissaire au droit de l'homme du Conseil de l'Europe peut, sur le fondement de l'article 36 de la Convention européenne présenter des observations écrites et prendre part à l'audience devant la Cour européenne.
- La Commission de Venise peut déposer des mémoires *amicus curiae*.
- Le Contrôleur européen de la protection des données dispose de pouvoirs étendus.

II. Une contribution à la protection des droits humains existante mais affaiblie

A. Une contribution affaiblie par la valeur juridique variable des actes émanant de ces institutions

Des actes émanant de ces organes ne disposent pas de pouvoirs contraignants à l'égard des États (exemples : actes du Conseil des droits de l'homme des Nations unies, actes du Haut-Commissariat aux droits de l'homme des Nations unies).

Cette absence de pouvoir contraignant implique une absence de sanction.

De plus, il convient de souligner que l'ensemble de ces organes demeure assez peu connu des citoyens qui amoindrit nécessairement la portée de leur action en matière de protection des droits humains.

B. L'affaiblissement consécutif aux critiques du droit international et européen des droits humains

Le droit international et européen des droits de l'homme fait face à un foisonnement de critiques ataviques quant aux ingérences alléguées dans la souveraineté des États, même lorsqu'il s'agit d'avis/déclarations/rapports qui n'ont pas de valeur contraignante.

Ces critiques tiennent également à une perception des droits humains qui seraient une idéologie occidentale et coloniale.

Il arrive souvent que des États manifestent des réactions hostiles en cas de rapports/avis/déclaration de ces organes lorsqu'ils mettent en lumière des violations des droits de l'homme, ce qui implique qu'ils ne soient pas suivis d'effets.

Trois États se sont retirés du Conseil des droits de l'homme des Nations unies en 2025 (États-Unis, Israël, Nicaragua).

La volonté politique des États est un facteur important dans la place de la garantie des droits humains de ces organes.

En conclusion, si les organes de protection politique et administrative à l'échelle européenne et internationale ne concourent pas toujours à une garantie contraignante des droits humains, leur existence contribue tout de même à la protection des droits humains.

PARTIE VI. LES DROITS CIVILS ET POLITIQUES

FICHE N° 26

Le droit à la vie

FICHE N° 27

Le droit à l'intégrité de la personne

FICHE N° 28

L'interdiction de la torture, des peines et des traitements inhumains ou dégradants

FICHE N° 29

Interdiction de l'esclavage, de la traite, de la servitude, et du travail forcé

FICHE N° 30

Le droit à la liberté et à la sûreté

FICHE N° 31

Le droit à un procès équitable et le droit à un recours effectif

FICHE N° 32

Les garanties fondamentales en matière pénale

FICHE N° 33

Le droit à la vie privée

FICHE N° 34

Le droit à la vie familiale

FICHE N° 35

Le droit à la protection des données à caractère personnel

FICHE N° 36

La liberté de penser, de conscience et de religion

FICHE N° 37

La liberté d'expression

FICHE N° 38

La liberté de réunion et de manifestation pacifique

FICHE N° 39

La liberté d'association

FICHE N° 40

La liberté d'aller et venir

FICHE N° 41

La liberté d'enseignement

FICHE N° 42

Le droit à des élections libres

FICHE N° 43

Les protections fondamentales en cas d'éloignement, d'expulsion et d'extradition

FICHE N° 44

Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes

Fiche nº 26 - LE DROIT À LA VIE

POINTS CLÉS

- Valeur suprême et droit indérogeable.
- Début et fin de vie.
- Interdiction de porter atteinte à la vie.
- Peine de mort.
- Opération de puissance publique.
- Situation de conflit armé.
- Obligations positives.
- Effet horizontal.
- Obligations procédurales.

PRINCIPALES RÉFÉRENCES

- Cons. const, déc. nº 94-343/344 DC, 27 juillet 1994, *Loi relative au respect du corps humain et loi relative au don et à l'utilisation des éléments et produits du corps humain, à l'assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal.*
- Art. 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme.
- Art. 2 de la Convention européenne des droits de l'homme.
- Art. 6-1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
- Art. 6 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant.
- Art. 2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
- Art. 122-5 du Code pénal.
- Art. L. 435-1 du Code de la sécurité intérieure.
- Loi nº 2016-87 du 2 février 2016, dite « Claeys-Leonetti ».

1. Principes fondamentaux relatifs à la vie

La protection de la vie est une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques, elle *« constitue un attribut inaliénable de la personne humaine »* et se place en valeur absolue dans l'échelle des droits de l'homme (le Comité des droits de l'Homme qualifie le droit à la vie comme le « droit suprême » de l'être humain).

→ CEDH [GC], 22 mars 2001, *Streletz, Kessler et Krenz c. Allemagne*, nº 34044/96.

→ CDH, 4 avril 1985*, Baboeram c. Suriname*, nº 146/1983, A/40/40.

→ CDH, 3-28 juillet 2017, Observation générale nº 36 sur l'article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Le droit à la vie est un droit indérogeable (au sens où il ne peut faire l'objet de dérogation en temps de troubles internes ou de crises politiques) qui constitue la condition essentielle pour l'exercice de tous les autres droits humains. Il bénéficie d'une place primordiale dans les instruments internationaux de protection des droits humains.

Ce droit est consacré à l'article 3 de la Déclaration Universelle des droits de l'homme qui dispose que *« tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne »*, ainsi qu'à l'article 6-1 du Pacte international relatif aux droits civils et politique dans des termes similaires : *« Le droit à la vie est inhérent à la personne humaine. Ce droit doit être protégé par la loi. Nul ne peut être arbitrairement privé de la vie »* ainsi qu'à l'article 2

de la Charte des droits fondamentaux. La Convention européenne des droits de l'homme formule des exceptions précises au respect absolu du droit à la vie dans son article 2-2.

Dès lors, le droit à la vie, bien que fondamental dans une société démocratique, n'est néanmoins **pas absolu et doit s'articuler avec les nécessités inhérentes à la vie en société démocratique**.

→ CEDH, 17 septembre 1995*, McCann c. Royaume-Uni*, n° 18984/91.

La **Constitution française ne consacre pas un droit suprême à la vie** qui est protégé plus spécifiquement au niveau législatif, contrairement à d'autres constitutions d'États européens. Les juridictions de l'ordre interne ont cependant consacré son caractère fondamental au sens de l'article L. 521-2 du Code de justice administrative :

→ CE, ord., 13 août 2013, *Commune de St Leu*, n° 370902.

POUR ALLER PLUS LOIN

L'article 6-2 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant indique que « les États parties assurent dans toute la mesure possible la survie et le développement de l'enfant ». Le droit à la survie, spécifique à cette convention, est consubstantiel du droit au développement de l'enfant et fait partie de l'un des quatre principes directeurs de l'application de la Convention. Il implique que l'État prenne toutes les mesures nécessaires, positives et négatives, pour permettre le développement et l'épanouissement de l'enfant dans les meilleures conditions. La Déclaration mondiale en faveur de la survie, de la protection et du développement de l'enfant du 18 octobre 1990 (A/45/625) détaille les différentes mesures notamment socio-économiques pour la protection de l'enfant, mais également toutes les menaces concrètes entravant sa survie (famine, conflit armé, catastrophes naturelles, etc.). Ces éléments sont par la suite repris dans les rapports périodiques du Comité des droits de l'enfant et mentionnés dans ses Observations générales spécifiques à l'instar du lien entre la survie de l'enfant et la préservation de l'environnement (Observation générale n° 26 sur les droits de l'enfant et l'environnement avec un accent particulier sur le changement climatique, du 28 août 2023, CRC/C/GC/26, Article 30). Le droit à la survie de l'enfant est une illustration de l'interdépendance des droits humains et des différents volets du droit à la vie.

1.1. Le point de départ de la protection

Le début de la protection de la vie a fait l'objet de débat. Si la Convention européenne des droits de l'homme ne précise pas de début de la protection, outre-Atlantique, la Convention américaine des droits de l'homme, dans son article 4, mentionne : *« 1. Every person has the right to have his life respected. This right shall be protected by law and, in general,* from the moment of conception*. No one shall be arbitrarily deprived of his life. »*

La jurisprudence de la Cour interaméricaine apprécie cependant cette disposition souplement. Elle considère que l'embryon ne peut pas être considéré comme une personne au sens de l'article 4, mais que le droit à la vie peut être protégé de manière graduelle et progressive à partir du moment de « l'implantation » de l'embryon dans l'utérus, bien que cette protection ne constitue pas une obligation absolue et inconditionnelle.

→ CIDE, 28 novembre 2012, *Artavia Murillo et autres (Fécondation in Vitro) c. Costa Rica*, (Exception Préliminaires, Fond, Réparation et coûts), Serie C n° 257.

En Europe, le droit à l'Interruption volontaire de grossesse n'est pas réputé porter atteinte au droit à la vie. Dans la jurisprudence européenne, la Cour a notamment considéré que l'État a une marge d'appréciation sur la détermination du début de la vie. Malgré cette marge nationale d'appréciation, la Cour européenne considère que l'embryon ne peut se prévaloir du droit à la vie :

→ CEDH [GC], 8 juillet 2004, *Vo c. France*, n° 53924/00.

→ CEDH [GC], 10 avril 2007, *Evans c. Royaume-Uni*, n° 6339/05.

En France, le Conseil constitutionnel a décliné la possibilité de connaître de dispositions concernant l'allégation d'une atteinte au droit à la vie protégé par l'article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme dans le cas de l'IVG en restreignant son contrôle aux seules dispositions constitutionnelles :

→ Cons. const., déc. n° 74/54 DC, 15 janvier 1975, *Loi relative à l'interruption volontaire de la grossesse.*

Le Conseil constitutionnel a également refusé de se prononcer sur la question du droit à la vie des embryons, considérant que c'est au législateur de déterminer l'étendue de la protection à attribuer, mais que le droit à la vie est une application, un corollaire du principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité de la personne humaine :

→ Cons. const, déc. n° 94-343/344 DC, 27 juillet 1994, *Loi relative au respect du corps humain et loi relative au don et à l'utilisation des éléments et produits du corps humain, à l'assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal.*

Actualité jurisprudentielle. - GPA réalisée à l'étranger : l'interdiction française cède devant la protection de l'enfant né

La gestation pour autrui demeure interdite en droit français par l'article 16-7 du Code civil. Cette prohibition constitue un principe essentiel de l'ordre juridique français. Elle ne peut cependant conduire à ignorer la situation juridique de l'enfant une fois celui-ci né.

La Cour de cassation, réunie en Assemblée plénière, a ainsi jugé en juillet 2026 qu'une décision étrangère établissant la filiation d'un enfant né d'une gestation pour autrui à l'égard de ses parents d'intention peut être reconnue en France. La seule circonstance que la GPA soit prohibée en droit français ne suffit pas à faire obstacle à cette reconnaissance.

Le juge français doit toutefois vérifier que la décision étrangère présente des garanties suffisantes, notamment quant à l'identification des personnes ayant participé au projet parental et au consentement de la mère porteuse à la convention et à ses conséquences sur ses droits parentaux. L'intérêt supérieur de l'enfant constitue une considération primordiale dans cette appréciation.

Lorsque le jugement étranger est reconnu, la filiation qu'il établit produit en France ses effets en tant que filiation, sans être transformée artificiellement en adoption.

⟶ Cass., Ass. plén., 3 juillet 2026, nos 24-50.028 et 24-50.029.

À retenir : L'interdiction de la GPA protège certaines exigences bioéthiques avant la naissance, mais elle ne permet pas de priver l'enfant déjà né de la reconnaissance de son identité et de sa filiation légalement établies à l'étranger. La protection de l'enfant conduit ainsi à distinguer la licéité du procédé de procréation et les effets juridiques de la naissance.

1.2. L'interdiction d'infliger la mort

L'État a le monopole de la violence légitime, qui doit être limitée dans la mesure du possible par la protection du droit à la vie. Celle-ci implique une obligation pour l'État de s'abstenir d'y porter atteinte, on parle alors d'obligation négative.

1.2.1. La peine de mort

La question de l'interdiction de la peine de mort au nom de la valeur fondamentale du droit à la vie a évolué tant sur le plan interne qu'international vers un consensus au sein des instruments normatifs. Même si l'article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques est rédigé d'une manière suggérant la nécessité d'abolir la peine de mort, il n'interdit pas une telle pratique, mais impose certaines limites (concernant les enfants et les femmes enceintes) de même que des garanties procédurales.

Le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte, adopté le 15 décembre 1989 par l'Assemblée générale et ratifié par la France en 2007, vise alors à amender l'article 6 et propose une abolition de la peine de mort au nom de la dignité humaine et du développement progressif des droits de l'homme.

La Convention européenne des droits de l'homme a également connu une évolution similaire. L'article 2 ne considérait pas la peine capitale contradictoire avec la protection du droit à la vie au moment de sa signature en 1950. Deux Protocoles additionnels ont par la suite modifié cette disposition.

La peine de mort est tout d'abord limitée aux actes commis en période de conflit armé par le Protocole additionnel n° 6 adopté le 28 avril 1983 avant d'être totalement abolie par le Protocole additionnel n° 13 le 3 mai 2002 (seul l'Azerbaïdjan n'a pas ratifié le Protocole n° 13), l'interdiction bénéficiant de la force du consensus européen. Cette interdiction a été renforcée par la jurisprudence de la Cour, considérant qu'il s'agit dès lors d'une forme de sanction inacceptable.

→ CEDH [GC], 12 mai 2005, *Ocalan c. Turquie*, n° 46221/99.

En effet, la protection contre ce traitement est étendue à l'extradition d'un prisonnier vers un État dans lequel il risque la peine de mort :

→ CEDH, 8 novembre 2005, *Bader c. Suède*, n° 13284/04.

L'interdiction de l'extradition se rapporte également à l'article 3 en ce que l'attente dans le couloir de la mort constitue un traitement inhumain et dégradant.

→ CEDH, 7 juillet 1989, *Soering c. Royaume-Uni*, n° 14038/88.

L'interdiction de la peine capitale a également connu des développements au niveau interne à l'initiative de Robert Badinter par la loi du 9 octobre 1981 disposant que *« la peine de mort est abolie »*.

La ratification par la France du deuxième Protocole facultatif au Pacte international relatif aux droits civils et politiques visant à abolir la peine de mort a suscité une réserve de la part du Conseil constitutionnel. Les dispositions ne prévoyaient pas de possibilité de dénonciation de l'engagement et pouvaient dès lors porter atteinte à la souveraineté étatique.

→Cons. const., déc. n° 2005-524/525 DC, 13 octobre 2005, *Engagements internationaux relatifs à l'abolition de la peine de mort.*

Cette décision du Conseil constitutionnel a entraîné une révision constitutionnelle pour intégrer l'article 66-1 dans la Constitution française disposant que *« nul ne peut être condamné à la peine de mort »*.

Le Conseil constitutionnel, saisi d'une QPC sur l'extradition d'un homme vers un État dans lequel il risquait la peine de mort, s'est néanmoins reconnu incompétent pour déterminer la constitutionnalité des dispositions internes appliquant des dispositions inconditionnelles et précises de la directive européenne 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004.

→ Cons. const., déc. n° 2010-79 QPC, 17 décembre 2010, *M. Kamel Douadi.*

1.2.2. Les atteintes résultant des opérations de la puissance publique

Le droit à la vie doit se concilier avec les exigences de la vie démocratique et doit trouver un équilibre avec la protection de l'ordre public par les autorités nationales qui doivent s'abstenir d'infliger arbitrairement la mort ou toute atteinte qui ne serait pas absolument nécessaire.

Pour cela, plusieurs dispositions encadrent l'usage de la force par les agents de l'État, notamment l'article L. 435-1 du Code de la Sécurité intérieure qui dispose que les forces de l'ordre peuvent utiliser leurs armes en cas d'absolue nécessité et de manière strictement proportionnée en cas de légitime défense (outre les cas mentionnés à l'article L. 211-9), en cas de péril imminent pour leur vie ou celle d'autrui, pour arrêter une personne représentant une menace grave pour l'intégrité physique d'autrui et ne pouvant être neutralisée autrement, pour empêcher l'évasion de personnes dangereuses ou violentes, ou s'il s'agit du seul moyen pour défendre un lieu ou des personnes leur étant confiées.

L'article 122-5 du Code pénal concernant le principe de légitime défense s'applique également aux forces de l'ordre et prévoit une irresponsabilité pénale de la personne portant atteinte au droit à la vie en cas d'acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte.

La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme est abondante en la matière. La Cour exerce un contrôle strict pour déterminer si l'usage de la force découlait d'une nécessité absolue et si le recours à la force

était strictement proportionnel à la menace à neutraliser, à l'issue d'un examen minutieux de la situation et d'une planification sérieuse des opérations et après que toutes les précautions utiles aient été prises pour protéger la population civile.

→ CEDH, 17 septembre 1995*, McCann c. Royaume-Uni*, n° 18984/91.

→ CEDH [GC], 24 mars 2011, *Giuliani et Gaggio c. Italie*, n° 23458/02.

→ CEDH [GC], 6 juillet 2005, *Nachova et a. c. Bulgarie*, n° 43577/98.

Dans ce cadre, la France a été condamnée par la Cour à la suite du décès par balle du passager d'un véhicule en fuite dans lequel se trouvait des individus suspectés d'atteinte aux biens, et non aux personnes :

> *« Le but légitime d'effectuer une arrestation régulière ne peut justifier de mettre en danger des vies humaines qu'en cas de nécessité absolue. La Cour rappelle qu'en règle générale il ne peut y avoir pareille nécessité lorsque l'on sait que la personne qui doit être arrêtée ne représente aucune menace pour la vie ou l'intégrité physique de quiconque et n'est pas soupçonnée d'avoir commis une infraction à caractère violent, même s'il peut en résulter une impossibilité d'arrêter le fugitif »* (CEDH, 7 juin 2018, *Toubache c. France*, n° 19510/15. Voir également CEDH, 17 avril 2014, *Guerdner c. France*, n° 68780/10).

La Cour considère cependant que l'acte d'un agent de l'État peut être justifié en cas de conviction honnête de l'existence d'un danger imminent.

Le contrôle strict exercé par la Cour permet d'évaluer l'existence d'une formation adéquate des forces de l'ordre. Elle évalue également la précision des ordres reçus, l'adaptation du type d'arme utilisé en fonction des situations pour minimiser les dommages et leurs conséquences funestes. Malgré l'utilisation d'armes non léthales, le juge interne a également été plusieurs fois saisi de question concernant l'armement en relation avec le droit à la vie comme dans le cas du pistolet à impulsion électrique ou encore les LBD :

→ CE, SSR, 2 septembre 2009, *Association réseau d'alerte et d'intervention pour les droits de l'homme*, n° 318584 et 321715.

→ CE, ord., 1er février 2019, n° 427418.

L'action des forces de l'ordre doit être déterminée par un cadre normatif précis permettant de prévenir les atteintes arbitraires au droit à la vie. La France a par ailleurs été condamnée le 27 février 2025 pour une absence de protection suffisante du droit à la vie dans le cadre d'affrontement entre manifestants et forces de l'ordre, considérant qu'il existait des lacunes dans le contrôle des opérations, mais également dans le cadre juridique et administratif et des défaillances de l'encadrement dans la préparation et la conduite des opérations litigieuses.

→ CEDH, 27 février 2025, *Fraisse et a. c. France*, n° 47626/21.

La Cour européenne prend également en compte l'état de vulnérabilité de la personne retenue par les forces de l'ordre et les circonstances ayant conduit à son décès dans son appréciation.

→ CEDH, 21 juin 2018, *Semache c. France*, n° 36083/16.

1.2.3. L'état de guerre : le privilège du combattant

Bien que le droit à la vie ne soit pas un droit « dérogeable » au sens du déclenchement de l'article 15 de la Convention européenne des droits de l'homme, il ne s'agit pas d'un droit absolu, comme en témoigne son régime dans un contexte de guerre. La protection offerte par le droit européen des droits de l'homme ne cesse pas avec le début des hostilités, mais doit néanmoins s'articuler avec le droit international humanitaire régissant les conflits armés qui constituent la *lex specialis* en la matière :

→ CIJ, AC, 8 juillet 1996, *Licéité de l'usage ou de la menace des armes nucléaires*, CIJ Recueil 1996, p. 126.

La Cour européenne a plusieurs fois rappelé la continuité de l'applicabilité du droit européen des droits de l'homme dans des contextes de conflits armés non internationaux, internationaux, mais aussi dans le cadre d'un conflit extraterritorial :

→ CEDH, 2 mars 2010, *Al-Saadoon et Mufdhi c. Royaume-Uni*, n° 61498/08.

→ CEDH, 24 février 2005, *Issaieva et a. c. Russie*, n° 57950/00.

Dans le contexte d'un conflit armé, il convient d'analyser les violations du droit à la vie « à la lumière » du droit international humanitaire. Le droit humanitaire attribue aux combattants le privilège d'infliger la mort tout en bénéficiant d'une immunité pénale, appelée « privilège de belligérance », codifié implicitement aux articles 4 à 6 de la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre du 12 août 1949, ainsi qu'à l'article 43 du Protocole additionnel I aux Conventions de Genève, du 8 juin 1977.

De même, si le droit humanitaire protège l'individu civil (dont une application peut être tirée de l'article D4122-8 du Code de la Défense), son droit à la vie est à relativiser dans une situation de conflit armé, puisque les atteintes peuvent être justifiées par les opérations de combat dirigées vers des objectifs militaires légitimes. En effet, une attaque respectant les règles du droit humanitaire, mais causant des victimes parmi la population civile ne pourra être qualifiée de violation en ce qu'elle résulte d'un acte licite de guerre. Cependant, le combattant doit respecter des interdictions spécifiques comme s'abstenir d'infliger la mort à un combattant ennemi blessé, hors de combat ou qui se rend (art. D4122-9 du Code de la défense).

Dans ce cadre, la théorie des actes de gouvernement peut être utilisée par le juge administratif pour éviter d'analyser la licéité des décisions militaires considérées comme *« non détachables de la conduite des relations internationales de la France »* :

→ CE, SSR, 5 juillet 2000, *Mégret et Mekhantar*, n° 206303 et 206965.

Les décisions militaires peuvent cependant engager une responsabilité pour crime de guerre en cas de violation des règles du droit des conflits armés (art. 461-1 et suivants du Code pénal), ou devant la Cour pénale internationale (art. 53-2 de la Constitution).

POUR ALLER PLUS LOIN

La Cour européenne ne considère pas que le droit à la vie comporte une dimension négative, à savoir un droit à mourir (CEDH, 29 avril 2002, Pretty c. Royaume-Uni, n° 2346/02). L'autonomie personnelle ne donne ainsi pas à l'individu un droit de « choisir la mort plutôt que la vie ». Le risque serait de créer un effet contraire à celui recherché et induire une pression involontaire sur des personnes vulnérables. Cependant, la Cour reconnaît une large marge nationale d'appréciation aux États concernant la réglementation de la fin de vie (CEDH, 5 juin 2015, Lambert et a. c. France [GC], n° 46043/14). En droit interne, si dans le Code de la santé publique un médecin n'a pas le droit d'infliger délibérément la mort (art. R. 4127-38), l'article L. 1110-5 indique que « toute personne a le droit d'avoir une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance ». Certains actes médicaux ne doivent pas être poursuivis s'ils procèdent d'une « obstination déraisonnable » (art. L. 1110-5-1), à savoir s'ils sont « inutiles, disproportionnés ou lorsqu'ils n'ont d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie ». Ils peuvent alors être arrêtés selon la volonté du patient, ou s'il ne peut exprimer cette dernière, à l'issue d'une procédure collégiale. La loi Clayes-Leonetti du 2 février 2016 visant à créer de nouveaux droits pour les personnes malades et en fin de vie permet une sédation profonde, l'arrêt des traitements dont l'hydratation et la nutrition artificiels ainsi que la mise en place de directives anticipées par le patient. Ces dispositions ont été reconnues comme conforme au principe de dignité humaine et à la liberté personnelle par la décision Cons. const., déc. n° 2017-632 QPC, 2 juin 2017, Union nationale des associations de familles de traumatisés crâniens et de cérébro-lésés. À noter, le débat pour l'autorisation d'une aide active à mourir a repris avec la consultation et le rapport parlementaire du 29 mars 2023, aboutissant à l'adoption le 27 mai 2025 par le Parlement d'un droit à l'aide à mourir permettant d'accompagner le patient vers une aide active à mourir et encadrant cette démarche de critères et de garanties spécifiques.

2. La protection étendue du droit à la vie

2.1. Les garanties procédurales

Le volet procédural est inhérent à l'article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme et distinct des obligations procédurales de la même convention, dû aux spécificités du droit à la vie. Le droit à la vie nécessite l'adoption d'un cadre juridique et administratif adéquates pour une protection effective, qui implique un cadre pénal précis et dissuasif permettant de prévenir et réprimer les atteintes au droit à la vie, et permettant d'encadrer strictement l'usage de la force.

→ CEDH [GC], 30 mars 2016, *Armani da Silva c. Portugal*, n° 5878/08.

En cas d'usage de la force meurtrière par les États ou par des particuliers, les autorités, agissant d'office, doivent pouvoir organiser une enquête prompte, effective et indépendante permettant de contrôler la légalité du recours à la force meurtrière et les circonstances dans lesquelles se sont déroulés les faits.

→ CEDH, 17 septembre 1995, *McCann c. Royaume-Uni*, n° 18984/91.

→ CEDH [GC], 7 juillet 2011, *Al-Skeini c. Royaume-Uni*, n° 55721/07.

Cette obligation a par la suite été étendue à tous les types de situation dans lesquelles un individu subi une atteinte à son droit à la vie, allant des blessures potentiellement mortelles aux cas de disparition forcée. L'enquête doit être particulièrement rigoureuse dans le cas où le décès est survenu lorsque l'individu était sous le contrôle des autorités. Le système judiciaire doit être effectif et indépendant et apte à déterminer les responsabilités des actes résultant de l'atteinte au droit à la vie.

En cas de disparition forcée, l'obligation demeure tant que les circonstances de la disparition et le sort de la personne disparue ne sont pas connus. Dans le cas où les autorités s'abstiennent de diligenter une enquête effective, les obligations procédurales de l'article 2 seront considérées comme une violation continue.

→ CEDH [GC], 18 septembre 2009, *Varnava et a. c. Turquie*, n° 16064/90.

À noter : il s'agit d'une obligation de moyen et non de résultat.

2.2. Les actions positives spécifiques

2.2.1. L'effet « horizontal »

La protection du droit à la vie implique également pour l'État des obligations positives. En effet, l'État a le devoir de protéger la vie de toutes les personnes relevant de sa juridiction en prévenant les atteintes à la vie :

→ CEDH, 9 juin 1998, *L.C.B. c. Royaume-Uni*, n° 23413/94.

L'État peut également être responsable de ne pas avoir pris les mesures pratiques raisonnables contre les atteintes à la vie commises par un individu menaçant la vie d'autrui, étendant le droit à la vie à une protection interindividuelle. Cette nécessité joue lorsque les autorités ont ou auraient dû avoir connaissance de l'existence d'un risque réel et sérieux d'atteinte immédiate à la vie d'un individu, analysé à la lumière de toutes les circonstances et éléments pertinents.

Néanmoins, la protection du droit à la vie doit se concilier avec les difficultés d'exercice de l'autorité publique, les choix opérationnels à faire en termes de priorités et de ressources ainsi que l'imprévisibilité du comportement humain. Le droit à la vie ne doit pas faire peser sur les autorités un fardeau déraisonnable ou excessif et le choix des mesures à prendre relève de la marge nationale d'appréciation.

→ CEDH, 28 octobre 1998, *Osman c. Royaume-Uni*, n° 87/1997/871/1083.

Le droit à la vie joue également dans les cas de négligences des autorités publiques de protéger une victime de violences conjugales, malgré les nombreuses plaintes déposées par la victime avant son décès :

→ CEDH, 22 mars 2022, *Y et a. c. Bulgarie*, n° 9077/18.

2.2.2. La protection contre les aléas

Le droit à la vie impose également de prendre des mesures préventives de protection dans toutes les situations dangereuses, créant dès lors une obligation positive de prévention des risques pour la vie.

→ CEDH, 14 juin 2011, *Ciechońska c. Pologne*, n° 19776/04.

Afin de pallier les risques inhérents à certains activités ou situations, le droit à la vie peut donc jouer au regard de nombreuses situations notamment pour la protection de la santé et des risques sanitaires, dans le cas des personnes vulnérables privées de liberté dans des établissements publics, l'État devant faire preuve d'une diligence particulière lorsque l'individu est sous le contrôle de l'État.

→ À titre d'exemple, CEDH [GC], 17 janvier 2002, *Calvelli et Ciglio c. Italie*, n° 32967/96.

→ CEDH [GC], 17 juillet 2014*, Centre de ressources juridiques au nom de Valentin Câmpeanu c. Roumanie*, n° 47848/08.

Le droit à la vie nécessite également de prendre des mesures de prévention raisonnables pour éviter des accidents, qu'ils soient industriels ou naturels :

→ CE, ord.,13 août 2013, *Commune de St Leu*, n° 370902.

→ CEDH [GC], 30 novembre 2004, *Öneryıldız c. Turquie*, n° 48939/99.

En revanche, le droit à la vie n'implique pas une sécurité absolue, en particulier lorsque la personne a délibérément pris le risque de se mettre en danger.

Actualité jurisprudentielle. - Le droit à la vie face aux pollutions environnementales graves

L'article 2 de la Convention peut imposer à l'État de prendre des mesures concrètes contre une pollution environnementale susceptible de mettre gravement en danger la vie de la population.

La Cour européenne l'a rappelé en 2025 à propos de la « Terre des feux », région de Campanie affectée pendant plusieurs décennies par l'enfouissement, l'abandon et la combustion illégale de déchets dangereux. Alors que les autorités connaissaient depuis longtemps l'ampleur du phénomène et les risques sanitaires qu'il engendrait, elles n'avaient pas adopté avec suffisamment de diligence les mesures nécessaires pour protéger les habitants concernés.

La Cour conclut à une violation de l'article 2 et, compte tenu du caractère structurel de la situation, recourt à la procédure de l'arrêt pilote en demandant à l'Italie de mettre en place des mesures générales permettant de remédier aux défaillances constatées.

⟶ CEDH, 30 janvier 2025, *Cannavacciuolo et autres c. Italie*, nos 51567/14, 39742/14, 74208/14 et 24215/15.

À retenir. - Le droit à la vie ne protège pas seulement contre une atteinte directement infligée par l'État. Il impose également aux pouvoirs publics d'agir lorsqu'ils connaissent l'existence d'un risque environnemental grave et durable pour la population.

Pour rappel, un arrêt pilote est une procédure de la CEDH, utilisée lorsqu'une affaire révèle un problème structurel ou systémique grave dans un pays. La Cour donne à l'État des directives précises et un délai pour modifier sa législation et gèle en parallèle les affaires similaires

POUR ALLER PLUS LOIN

Si le droit à la vie est considéré comme étant un droit civil et politique, de nouvelles acceptions de ce droit se développent notamment sur le volet économique et social. Si la Cour européenne des droits de l'homme reste encore réticente à la consécration d'un tel droit, considérant qu'il n'existe pas de « droit à une certaine qualité de vie » (CEDH, 7 juin 2001, Ivanov c. Lettonie (déc.), n° 55933/00), le Comité des droits de l'homme a pu reconnaître l'existence d'un droit à la vie digne, faisant ainsi le lien entre les droits de première génération (droits civils et politiques) et les droits de la deuxième génération (droits économiques et sociaux) tout d'abord dans son Observation Générale n° 36, ainsi que dans le cas d'une communication individuelle dans Cáceres c. Paraguay (20 septembre 2019, n° 2751/2016), illustrant l'interdépendance des droits humains et une approche décloisonnée du droit à la vie davantage mobilisée par les organes onusiens que par les instruments européens.

POUR S'ENTRAÎNER

Dissertation : La fin de vie

Si des questions naissent concernant le point de départ de la protection du droit à la vie (CEDH, 8 juillet 2004, *Vo c. France* [GC], n° 53924/00), les règles relatives à l'interdiction d'atteinte à la vie semblent à première vue poser moins de difficulté. Cependant, le régime de la fin de vie révèle des difficultés concernant le respect de ce droit, bénéficiant pourtant d'une large protection au niveau national et supranational. De manière générale, la fin de vie fait référence aux situations dans lesquelles une personne se trouve proche du décès, ainsi qu'à tous les mécanismes médicaux et d'accompagnement que cette situation implique. Si le droit à la vie constitue l'une des pierres angulaires des droits fondamentaux, la fin de vie, en ce qu'elle touche à des situations de dépendance aux soins, met en jeu des difficultés d'articulation entre respect strict des droits humains et éthique. En effet, les questions relatives à la fin de vie mettent en perspective l'ambivalence du droit à la vie entre droit fondamental conditionnant l'exercice de tous les autres, et respect du principe de dignité, valeur matricielle des droits humains. La fin de vie met donc en tensions de nombreux éléments de la protection de l'individu. Cette question, particulièrement d'actualité, questionne à la fois l'autonomie personnelle concernant les traitements prolongeant sa vie, les limites du droit à la vie et le pouvoir des tiers.

Problématique et annonce du plan : Bien que le droit à la vie soit une valeur suprême des droits fondamentaux dont toute atteinte nécessite un encadrement strict **(I)**, les dispositions relatives à la fin de vie permettent de ménager un équilibre délicat pour le respect de la dignité humaine **(II)**.

I. Un encadrement strict pour la protection de la vie en toutes circonstances

A. La protection de la vie comme valeur essentielle

De nombreux instruments qualifient la protection de la vie comme une valeur ou un droit suprême (CEDH, 22 mars 2001, *Streletz, Kessler et Krenz c. Allemagne*, n° 34044/96 : le droit à la vie est une valeur suprême ; CDH, 4 avril 1985*, Baboeram c. Suriname*, n° 146/1983, A/40/40 : le droit à la vie est un droit suprême CE, ord.,13 août 2013, *Commune de St Leu*, n° 370902 : reconnaît le droit à la vie comme un droit fondamental).

Cette reconnaissance unanime du caractère fondamental du droit à la vie implique la mise en place d'un cadre législatif protecteur. Cependant, ce droit n'implique pas de double négatif qui permettrait la reconnaissance d'un « droit à mourir », bien que la protection de la vie ne soit pas absolue :

CEDH, 29 avril 2002, *Pretty c. Royaume-Uni*, n° 2346/02 : à l'inverse, la Cour insiste sur l'importance de protéger la vie dans la mesure du possible. L'Observation générale n° 36 du Comité des droits de l'homme mentionne la nécessité de protéger contre les pressions et abus qui pourraient être exercés sur les patients.

Ni la Constitution française ni le Conseil constitutionnel n'ont reconnu de valeur suprême au droit à la vie, consacrant à la place la dignité humaine, relativisant son caractère suprême : Cons. const., déc. n° 94-343/344 DC, 27 juillet 1994, *Loi relative au respect du corps humain et loi relative au don et à l'utilisation des éléments et produits du corps humain, à l'assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal*.

C'est au législateur qu'il revient de réaliser un équilibre délicat entre droit à la vie, à la dignité et protection de l'individu contre les souffrances.

B. La nécessité d'un encadrement strict de la fin de vie

Une des obligations positives découlant de l'article 2 de la Convention européenne est l'établissement d'un cadre législatif adéquat. Il existe des dispositions spéciales interdisant pour le médecin de porter atteinte volontairement à la vie d'un patient : (art. R. 4127-38 du Code de la santé publique) et devant respecter la vie humaine et sa dignité (art. R. 4127-2), ces deux éléments pouvant entrer en conflit.

Plus précisément, plusieurs lois encadrent la fin de vie afin de ménager un équilibre entre ces différents éléments :

La loi du 22 avril 2005, dite « Leonetti », vient introduire pour la première fois des dispositions relatives aux droits des malades et à la fin de vie et consacre l'interdiction de l'obstination déraisonnable. La loi du

2 février 2016, dite « Claeys-Leonetti » considère que la nutrition et l'hydratation artificielles sont des traitements qui peuvent être arrêtés, le patient peut établir des directives anticipées de manière libre et éclairée, ou, dans le cas où la personne serait « hors d'état d'exprimer sa volonté », une procédure collégiale permet de discuter l'opportunité de l'arrêt des traitements (art. L. 1110-5-1 du Code de la santé publique).

La possibilité de saisir le juge en référé est ouverte en cas de litige concernant l'avis du personnel médical et constitue une garantie fondamentale supplémentaire.

II. La protection de la dignité dans la fin de vie

A. Une reconnaissance jurisprudentielle de la dignité dans la fin de vie

Malgré son insistance pour la protection de la vie, la Cour européenne n'interdit pas l'euthanasie face à une absence de consensus européen sur le sujet et laisse une large marge d'appréciation aux États membres (CEDH, 4 octobre 2022, *Mortier c. Belgique*, n° 78017/17), tout en reconnaissant l'autodétermination personnelle (CEDH, 29 avril 2002, *Pretty c. Royaume-Uni*, n° 2346/02). Cette autonomie personnelle ne peut cependant pas faire l'objet d'une présomption de volonté d'arrêt des traitements : Cons. const., déc. n° 2017-632 QPC, 2 juin 2017, *Union nationale des associations de familles de traumatisés crâniens et de cérébro-lésés*.

Le cadre législatif français concernant l'arrêt de l'hydratation et de la nutrition comme traitements maintenant artificiellement en vie un patient dépendant est réputé ne pas violer le droit à la vie : CEDH [GC], 5 juin 2015, *Lambert et a. c. France*, n° 46043/14.

De même, le Comité des droits de l'homme dans son Observation générale n° 36 aux points 9 et 10 abonde dans le sens de la Cour européenne, mais limite son interprétation aux patients adultes, la législation française sur la fin de vie s'appliquant cependant également aux enfants (CE, ord., 24 avril 2023, n° 469669).

B. Un droit à une fin de vie digne ?

Le questionnement de l'étendue des droits des personnes en fin de vie a été relancé par plusieurs éléments.

Une Convention citoyenne sur la fin de vie organisée par le Conseil économique, social et environnemental réunissant 184 citoyennes et citoyens a ainsi été organisée et a rendu son rapport en avril 2023. La Convention constate alors l'insuffisance du cadre législatif actuel et préconise une ouverture de l'aide active à mourir selon des critères médicaux, de discernement et d'âge, illustrant une réelle évolution des mentalités sur le sujet d'une fin de vie digne.

Dans le cadre de cette réflexion, un rapport d'information diligenté par la Commission des affaires sociales du Parlement du 29 mars 2023 réévalue également l'impact de la loi du 2 février 2016 (dite « Claeys-Leonetti »).

Cependant, l'Ordre national des médecins, dans un rapport du 1er avril 2023, marque l'avis défavorable des médecins à l'égard de la possibilité d'une euthanasie ou d'une aide active à mourir, montrant ainsi une dichotomie entre l'avis des experts et l'opinion majoritaire dans la société civile.

La loi du 27 mai 2025 créé un droit à l'aide à mourir qui permet d'accompagner le patient pour l'aider à recourir à un produit létal par lui-même ou par le biais d'un professionnel de santé. Cette révolution dans le parcours des soins palliatifs est cependant encadrée par 5 conditions (être français, majeur, atteint d'une affection grave ou incurable qui engage le pronostic vital et en phase terminale ou avancée, présenter une souffrance physique ou psychologique constante réfractaire aux traitements ou insupportable, et être capable de manifester sa volonté de manière libre et éclairée). Un juste équilibre est atteint en tenant compte du rapport de l'ordre des médecins grâce à une clause de conscience.

Un délit d'entrave à l'aide à mourir est également créé.

En conclusion, la question de la fin de vie implique de réaliser un délicat équilibre entre préservation de la vie et dignité humaine et les développements juridiques récents montrent qu'un tel équilibre peut impliquer une aide active à mourir.

Fiche nº 27 – LE DROIT À L'INTÉGRITÉ DE LA PERSONNE

POINTS CLÉS

- La sacralisation du consentement.
- La consécration de la notion d'autonomie personnelle.
- La protection de l'intégrité physique et de l'intégrité morale.
- L'absence de consécration du droit à mourir.

PRINCIPALES RÉFÉRENCES

- CEDH, 29 avril 2002, *Pretty c. Royaume-Uni*, nº 2346/02.
- CEDH, GC., 25 septembre 2018, *Denisov c. Ukraine*, nº 76639/11.
- CEDH, 24 avril 2025, *L. et a. c. France*, nºs 46949/21 et 2 a.
- CEDH, 23 janvier 2025, *H.W. c. France*, nº 13805/21.
- Cons. const., déc. nº 94-343/344 DC, 27 juillet 1994.
- CE, ass., 27 octobre 1995, *Morsang-sur-Orge*, nº 136727.
- Cons. const., déc. n° 2026-910 DC, 14 août 2026, *Loi relative au droit à l'aide à mourir*.

Le droit à l'intégrité de la personne est protégé tant par le système de la Convention européenne des droits de l'homme qu'en droit français.

Si la notion d'intégrité est absente du texte de la Convention, elle fait néanmoins l'objet d'une protection grâce à l'application de plusieurs de ses articles. La Cour européenne des droits de l'homme protège ainsi essentiellement ce droit sur le fondement des articles 8 et 3 de la Convention, qu'ils soient appliqués isolément ou de manière combinée.

→ CEDH, 26 septembre 2006, *Wainwright c. Royaume-Uni*, nº 12350/04

POUR ALLER PLUS LOIN

Une atteinte à l'intégrité physique sera traitée sur le fondement de l'article 3 si elle dépasse le seuil de gravité requis pour son application en raison des circonstances de la cause notamment de la gravité de l'atteinte. Lorsque le seuil de gravité ne sera pas rempli, la Cour traitera l'atteinte à l'intégrité sur le fondement des articles 8 et 3 combinés ou 8 en cas d'atteinte de moindre gravité.

Le droit à l'intégrité de la personne humaine se dédouble. Il a effectivement vocation à protéger tant l'aspect physique de cette dernière, que son intégrité morale.

→ L'intégrité de la personne humaine découle ainsi du droit au respect de la vie privée protégé par l'article 8 de la Convention (voir par exemple : CEDH, 25 septembre 2018, *Denisov c. Ukraine*, nº 76639/11).

Le Conseil constitutionnel protège également la notion de l'intégrité de la personne humaine. Selon les juges de la rue de Montpensier, cette notion découle du principe à valeur constitutionnelle de la dignité de la personne humaine tiré du préambule de la Constitution de 1946.

→ Cons. const., déc. n° 94-343/344 DC, 27 juillet 1994, *Loi relative au respect du corps humain et loi relative au don et à l'utilisation des éléments et produits du corps humain, à l'assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal.*

1. Le droit à l'intégrité physique de la personne humaine

1.1. Le droit de la personne à disposer librement de son corps

Les individus jouissent du droit de disposer librement de leur corps.

La Cour européenne des droits de l'homme protège ce droit sous l'égide de la notion d'autonomie personnelle tirée par sa jurisprudence de l'article 8 de la Convention EDH.

→ CEDH, 29 avril 2002, *Pretty c. Royaume-Uni*, n° 2346/02.

Selon cette notion, les individus peuvent opérer des choix de nature à potentiellement porter atteinte à leur intégrité physique ou morale dès lors qu'ils y consentent de manière totalement libre et éclairée.

Cela leur permet ainsi d'entretenir des relations sexuelles, y compris des pratiques violentes de type sadomasochistes, dès lors qu'elles sont librement consenties.

→ CEDH, 17 février 2005, *K.A. et A.D. c. Belgique*, n°s 42758/98 et 45558/99.

Cela leur permet également de refuser des traitements médicaux en dépit des conséquences très graves pour leur santé voire pour leur vie que va avoir cette décision.

→ CEDH, GC., 17 septembre 2024, *Pindo Mulla c. Espagne*, n° 15541/20.

Elle offre également la possibilité de demander des rectifications de leur état civil afin de le faire correspondre à leur identité.

Dans un premier temps la Cour de cassation s'opposait toutefois fermement à la rectification du sexe au sein de l'état civil en présence de personne souhaitant faire correspondre leur identité sexuelle à leur sexe légal.

→ Cass. civ. 1re, 21 mai 1990, n° 88-12.829.

L'État a cependant été condamné par la Cour européenne des droits de l'homme pour avoir refusé toute possibilité de rectification du sexe sur les registres d'état civil à une personne née homme.

→ CEDH, AP., 25 mars 1992, *B. c. France*, n° 13343/87.

La Cour de cassation a par la suite opéré un revirement de jurisprudence en admettant la rectification des registres d'état civil. Cette dernière contraignait toutefois les requérants souhaitant opérer une telle rectification à démontrer cinq critères dont le caractère irréversible de la transformation.

→ Cass. ass. plén.,11 décembre 1992, n° 91-11.900.

La Cour européenne des droits de l'homme s'est prononcée une nouvelle fois sur cette procédure et sur l'exigence du caractère irréversible de la transformation. Selon le juge strasbourgeois, une telle obligation méconnaît le droit à l'autonomie personnelle et à l'intégrité physique et constitue dès lors une violation du droit au respect de la vie privée des requérants sur le fondement de l'article 8 de la Convention.

→ CEDH, 6 avril 2017, *Garçon et Nicot c. France*, n°s 79885/12, 52471/13 et 52596/13.

Cette obligation a disparu du droit français depuis la loi du 18 novembre 2016, n° 2016-1547 menant à la création de l'article 61-6 du Code civil. Ce dernier prévoit désormais de manière explicite que le changement de sexe à l'état civil n'est pas subordonné à des traitements médicaux, chirurgicaux ou à une stérilisation.

→ Sur la conformité de l'article 56 de la loi du 18 novembre 2016 instituant ces modifications : Cons. const., déc. n° 2016-739 DC, 17 novembre 2016, *Loi de modernisation de la justice du XXIe siècle*.

Le droit à l'autodétermination n'est toutefois pas absolu. L'État peut donc y apposer des limites sans pour autant commettre de violation de la Convention.

→ Voir par exemple dans le cadre d'un conflit de droits fondamentaux entre l'article 2 et le droit à l'autonomie personnelle issue de l'article 8 : CEDH, GC., 5 juin 2015, *Lambert c. France*, n° 46043/14.

En France, le droit de disposer de son corps n'est pas non plus un droit absolu. Le principe de dignité humaine, conçu de manière objective, peut en effet justifier des atteintes à la notion de dignité humaine.

→ CE, ass., 27 octobre 1995, *Morsang-sur-Orge*, n° 136727.

En droit pénal, le consentement de la victime ne permet pas de rendre légales les atteintes à son intégrité physique. Le seul consentement de la victime ne constitue pas en effet un fait justificatif puisque l'atteinte doit également poursuivre un motif légitime.

En droit civil, le consentement de la victime ne constitue plus une cause d'exonération totale ou partielle pour l'auteur du dommage.

→ Sur la suppression de la notion d'acceptation des risques en matière de responsabilité générale du fait des choses s'agissant d'activités sportives : Cass. civ. 2e, 4 novembre 2010, n° 09-65.947.

Actualités :

1/ Le consentement suffit-il à écarter une atteinte à la dignité ?

La jurisprudence récente illustre particulièrement la tension entre autonomie personnelle et dignité de la personne humaine. En février 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Paris avait suspendu la fermeture de l'établissement « Z Machine », dans lequel étaient organisées des pratiques sexuelles collectives de type « *gang bangs* ». Il avait notamment relevé que les participantes pouvaient déterminer les conditions de déroulement des événements et en demander l'arrêt à tout moment. Le consentement et l'autonomie des participantes conduisaient ainsi le juge à considérer qu'un doute sérieux existait sur la réalité de l'atteinte à leur dignité (TA Paris, ord., *Société Z Machine*, 9 février 2026, n° 2602318).

Le Conseil d'État a toutefois censuré ce raisonnement. Il rappelle que la dignité de la personne humaine constitue une composante de l'ordre public et qu'une activité peut y porter atteinte indépendamment de circonstances locales particulières. Surtout, le seul consentement des personnes concernées ne suffit pas à exclure une telle atteinte. Le juge doit rechercher si, par leur nature et leurs conditions concrètes d'organisation, les pratiques proposées conduisent à un traitement incompatible avec la dignité humaine (CE, 15 juillet 2026, *Société Z Machine*, n° 513080).

En l'espèce, les événements étaient organisés contre paiement autour de scénarios pouvant comporter violences, séquestrations, enlèvements ou agressions sexuelles, les participantes étant présentées comme pouvant être « utilisées » par les participants et réduites à un rôle d'objet sexuel. Le Conseil d'État considère que de telles conditions peuvent, par elles-mêmes, caractériser une atteinte à la dignité, quand bien même la mise en scène aurait été agréée par les participantes. Il prolonge ainsi directement la conception objective retenue dans l'arrêt *Morsang-sur-Orge* : le consentement de la personne ne fait pas nécessairement disparaître sa réification.

L'arrêt comporte également un second apport. Le Conseil d'État se fonde sur la nouvelle rédaction de l'article 222-22 du Code pénal, issue de la loi du 6 novembre 2025, selon laquelle le consentement sexuel doit être libre et éclairé, spécifique, préalable et révocable. Il estime que les conditions d'organisation des événements, notamment l'exercice de contraintes physiques ou sexuelles et l'incitation à la consommation d'alcool, faisaient également apparaître un risque suffisamment sérieux de commission d'infractions pénales pour justifier l'intervention de l'autorité de police.

À retenir : L'arrêt *Société Z Machine* actualise directement la jurisprudence *Morsang-sur-Orge*. Il confirme que la dignité possède une dimension objective : une personne ne peut pas nécessairement faire disparaître, par son seul consentement, une atteinte résultant de sa réification. Le droit français se distingue ici de la logique d'autonomie personnelle développée par la Cour européenne, selon laquelle chacun dispose en principe d'une large liberté pour déterminer les usages de son propre corps.

2/ Le consentement entre désormais expressément dans la définition des agressions sexuelles

La loi du 6 novembre 2025 a profondément modifié l'article 222-22 du Code pénal en définissant désormais l'agression sexuelle comme « *tout acte sexuel non consenti* ». Le consentement doit être libre et éclairé, spécifique, préalable et révocable. Il est apprécié au regard des circonstances et ne peut être déduit du seul silence ou de la seule absence de réaction de la victime. La violence, la contrainte, la menace ou la surprise caractérisent nécessairement une absence de consentement, sans constituer désormais les seuls cas dans lesquels celle-ci peut être établie. Cette évolution inscrit ainsi plus explicitement la protection pénale de l'intégrité sexuelle dans une logique d'autonomie personnelle.

La Cour de cassation a immédiatement précisé la portée de cette réforme. Elle juge que la nouvelle rédaction de l'article 222-22 élargit les éléments constitutifs des agressions sexuelles, dès lors que l'absence de consentement peut être caractérisée indépendamment de la violence, de la contrainte, de la menace ou de la surprise. Les exigences tenant au caractère libre, éclairé, spécifique, préalable et révocable du consentement sont en outre, pour partie, nouvelles. La loi est donc plus sévère et ne peut s'appliquer à des faits commis avant son entrée en vigueur.

→ Loi n° 2025-1057 du 6 novembre 2025 modifiant la définition pénale du viol et des agressions sexuelles.

→ Cass. crim., 1er juillet 2026, n° 26-82.275.

À retenir. - Le consentement devient un élément central et autonome de la définition pénale des agressions sexuelles. La violence, la contrainte, la menace et la surprise demeurent des hypothèses dans lesquelles le consentement est nécessairement exclu, mais l'absence de consentement peut désormais être établie en dehors de ces quatre circonstances. La Cour de cassation considère cette évolution comme une extension de l'incrimination, ce qui interdit son application rétroactive.

1.2. La non-patrimonialité et l'indisponibilité du corps humain

Le législateur en 1994 n'a pas expressément consacré le principe d'indisponibilité du corps humain au sein du Code civil à la différence des principes d'inviolabilité du corps humain (art. 16-3 du Code civil) et de non-patrimonialité (art. 16-5).

Selon ce principe prétorien, toute convention portant sur le corps humain ou ses produits est interdite.

Selon le principe de la non-patrimonialité, le corps humain ne peut faire l'objet d'actes de disposition à titre onéreux. Étant un élément hors du commerce, le corps humain ne peut donc être aliéné contre de l'argent.

Si l'indisponibilité du corps humain est liée à la non-patrimonialité du corps, les deux principes ne sont toutefois pas synonymes.

Le principe de non-patrimonialité n'interdit que les conventions portant sur le corps humain ayant pour effet de conférer une valeur patrimoniale au corps humain (art. 16-5 du Code civil). La cession à titre gratuit de certains éléments, produits ou déchets du corps humain demeure ainsi par exception légale tandis que l'indisponibilité s'étend à tous les actes de disposition qu'ils soient onéreux ou gratuits.

Le principe d'indisponibilité du corps humain et de l'état des personnes avait notamment été mobilisé par la Cour de cassation afin de fonder l'interdiction des conventions de mères porteuses.

→ Cass. ass. plén., 31 mai 1991, n° 90-20105

Cette interdiction a par la suite été consacrée au sein de l'article 16-7 du Code civil par la loi du 29 juillet 1994 n° 94-653.

En présence d'une GPA réalisée légalement à l'étranger, la Cour de cassation admet désormais la transcription du registre d'état civil étranger à l'égard du parent génétique et permet l'établissement d'un lien de filiation à l'égard du parent d'intention par la voie de l'adoption.

Certaines exceptions existent toutefois pour des éléments, produits ou déchets du corps humain détachables du corps humain qui peuvent ainsi faire l'objet d'une convention à titre onéreux (cheveux, ongles, poils…).

Le don d'organe ou de gamète est également permis par l'article L. 1211-8 du Code de la santé publique entre majeurs en cas de lien de parenté direct ou au conjoint en cas d'urgence. Plusieurs conditions sont toutefois exigées.

Le donneur doit avoir pu donner son consentement, le don doit être gratuit et présenter un intérêt thérapeutique pour la personne bénéficiant du don et être anonyme.

S'agissant du prélèvement post-mortem, la loi prévoit désormais une présomption de consentement de la personne décédée.

1.3. Le droit à la protection de la santé

Ni le droit international ni le droit national ne consacrent de droit à la santé. Les textes dotés d'une portée juridique n'assurent en effet que le droit à la protection de la santé.

Ils ont ainsi vocation à protéger l'intégrité physique des individus contre les actes de l'État ou de tiers, non de lui assurer un droit à la bonne santé.

Le droit à la protection de la santé ou à l'intégrité physique de la personne fait l'objet d'une reconnaissance par de nombreux textes internationaux.

→ Art. 25-1 DUDH.

→ Art. 12-1 PIDESC.

→ Art. 11 Charte sociale européenne.

→ Art. 35 CDFUE.

Si ce droit est absent du texte de la Convention EDH, la Cour européenne des droits de l'homme a néanmoins permis de le protéger par le biais de son interprétation dynamique de la Convention.

→ CEDH, GC., 19 décembre 2017, *Lopes de Sousa Fernandes c. Portugal*, n° 56080/13.

Il s'agit donc d'un « droit diffus » au sein de la Convention pouvant être protégé par plusieurs de ses stipulations.

Le droit à la protection de la santé est également consacré en France et découle de l'alinéa 11 du préambule de la Constitution de 1946. Le conseil constitutionnel l'a d'abord qualifié de principe à valeur constitutionnelle avant de le considérer par la suite comme étant un objectif à valeur constitutionnelle.

→ Cons. const., déc. n° 80-117 DC, 22 juillet 1980, *Loi sur la protection et le contrôle des matières nucléaires.*

→ Cons. const., déc. n° 2022-835 DC, 21 janvier 2022, *Loi renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le Code de la santé publique*.

La protection de la santé ne constitue pas un droit directement invocable par les requérants selon le juge administratif, mais seulement un but que doit poursuivre le législateur.

→ Sur l'absence d'effet direct dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir : CE, SJS., 28 juillet 2004, *Préfet de Police c. M. X.*, n° 253927.

→ Le droit à la protection de la santé n'est pas une liberté fondamentale pouvant faire l'objet d'un référé-liberté : CE, ord., 8 sept. 2005, n° 284803.

Le juge judiciaire a toutefois admis l'invocabilité directe du droit à la protection de la santé consacré par l'alinéa 11 du préambule de la Constitution de 1946.

→ Cass. soc., 11 juillet 2012, n° 10-15.905.

1.4. L'inviolabilité du corps humain

1.4.1. La protection de la personne contre les atteintes à la santé

La Cour européenne des droits de l'homme protège les individus contre les atteintes à leur intégrité physique émanant de l'État ou de particuliers.

L'État doit en effet s'abstenir de commettre des ingérences injustifiées dans le droit à l'intégrité physique des personnes relevant de leur juridiction.

> → Telle que la réalisation d'une fouille à corps : CEDH, 26 septembre 2006, *Wainwright c. Royaume-Uni*, n° 12350/04.

L'État fait également l'objet d'obligations positives d'assurer la protection de l'intégrité physique des requérants jusque dans le cadre de relations interindividuelles. Il dispose en ce sens d'une obligation de protection.

> → CEDH, 28 octobre 1998, *Osman c. Royaume-Uni*, n° 23452/94.
>
> → CEDH, 3 décembre 2024*, M.Ș.D. c. Roumanie*, n° 28935/21.

L'État doit ainsi adopter un cadre législatif adéquat et effectif permettant d'éviter et de sanctionner les atteintes à l'intégrité physique. Cette obligation positive contient également une obligation procédurale d'enquêter en cas d'atteinte à l'intégrité physique.

> → CEDH, GC., 12 novembre 2013, *Söderman c. Suède*, n° 5786/08.
>
> → Sur l'obligation de criminalisation du viol sur le fondement des articles 8 et 3 combinés : CEDH, 4 déc. 2003, *M.C. c. Bulgarie*, n° 39272/98.
>
> → L'État commet une violation des articles 3 et 8 de la Convention lorsqu'il n'adopte ni n'applique un régime apte à réprimer les actes sexuels non consentis commis sur des personnes particulièrement vulnérables : CEDH, 24 avril 2025, *L. et a. c. France*, n°s 46949/21 et 2 a.
>
> → CEDH, 30 août 2022, *C. c. Roumanie*, n° 47358/20.

La Cour a également fait peser sur l'État une obligation d'information en présence d'activités dangereuses pour la santé des requérants.

> → En cas d'activité menée par l'État : CEDH, GC., 19 octobre 2005, *Roche c. Royaume-Uni*, n° 32555/96.
>
> → Cette obligation s'applique également aux activités privées menées par des entreprises. La Cour a ainsi considéré que l'État avait manqué à ses obligations positives en ne contraignant pas des employeurs à fournir des informations précontractuelles primordiales afin d'apprécier l'ampleur des risques pour la santé encourus par les salariés dans le cadre d'activités salariées (CEDH, 5 décembre 2013, *Vilnès et a. c. Norvège*, n° 52806/09 et 22703/10).

En France, le principe d'inviolabilité du corps humain est consacré depuis les lois bioéthique du 29 juillet 1994 au sein des articles 16-1 et 16-3 du Code civil. Les atteintes à l'intégrité physique commises par les tiers ne sont toutefois pas totalement proscrites mais encadrées.

Il est en effet nécessaire qu'elles soient consenties librement et de manière éclairée et qu'elles poursuivent une finalité thérapeutique pour la personne visée par l'atteinte ou pour autrui. Ces atteintes peuvent également avoir une finalité de recherche médicale (art. L. 1121-2 du Code de la santé publique).

L'expression du consentement libre et éclairé du patient à l'acte médical est par principe obligatoire. Le patient dispose en effet d'un droit de refuser des traitements (art. L. 1111-4 du Code de la santé publique).

> → L'absence d'information relative aux risques d'un traitement ou d'une intervention délivrée au patient fait naître, en cas de concrétisation du risque pour sa santé, un préjudice autonome du préjudice corporel réparable sur le fondement de l'article 1240 du Code civil : le préjudice d'impréparation (Cass. civ. 1re, 3 juin 2010, n° 09-13.591).
>
> → L'État commet une violation de l'article 8 lorsqu'il ne prend pas en considération le refus de certains traitements médicaux formulé par la mère d'un patient (CEDH, 9 mars 2004, *Glass c. Royaume-Uni*, n° 61827/00).

Les atteintes à l'intégrité physique peuvent également faire l'objet de sanctions pénales (voir les articles du Livre Ier, Titre II du Code pénal). La victime dispose en outre de voies de recours en matière civile afin d'obtenir réparation de son préjudice causé par l'atteinte à l'intégrité physique.

1.4.2. Les exceptions à l'exigence de consentement aux soins médicaux

L'État est également tenu au titre de l'article 2 de la Convention EDH à des obligations de protection de la vie des personnes relevant de sa juridiction. Dès lors, en cas d'urgence vitale et en l'absence de certitude quant aux refus du patient s'agissant du traitement à lui administrer, l'obligation de protection de la vie du patient doit primer.

→ CEDH, GC., 17 septembre 2024, *Pindo Mulla c. Espagne*, n° 15541/20.

Ainsi, l'obligation préalable de recueillir le consentement du patient avant toute intervention médicale s'efface lorsque l'état du patient rend nécessaire une intervention ou des soins pour lesquels il n'est pas en mesure de consentir en raison de son état.

De même, l'existence de vaccinations ou de soins ou traitements obligatoires n'est pas nécessairement contraire à la Convention EDH lorsqu'ils répondent à des objectifs de santé publique.

→ Depuis la loi du 30 décembre 2017, 11 vaccins sont désormais obligatoires en France. Le Conseil d'État a validé l'extension de la liste des obligations vaccinales, car elles visent à lutter contre des maladies infectieuses contagieuses et graves (CE, 6 mai 2019, n° 419242 et 415694).

→ Selon la Cour européenne des droits de l'homme, en matière de santé publique les États jouissent d'une ample marge d'appréciation. Une obligation vaccinale constitue certes une ingérence au droit au respect de la vie privée, mais celle-ci s'avère justifiée et ne dépasse pas cette marge d'appréciation (CEDH, GC., 8 avril 2021, *Vavřička et a. c. République Tchèque*, n°s 47621/13 et 5 autres).

→ L'État ne commet pas de violation de l'article 8 lorsqu'il impose à certains métiers dans le secteur de la santé une obligation vaccinale qui, lorsqu'elle n'est pas respectée, fait obstacle à l'emploi (CEDH, 29 août 2024, *Pasquinelli et a. c. San Marin*, n° 24622/22).

1.4.3. La fin de vie

Le patient ne peut pas exiger de l'État qu'il lui accorde une assistance médicale visant à faciliter son décès. Les États disposent en effet d'une très large marge nationale d'appréciation en matière de fin de vie.

La Convention ne consacre en effet ni de droit à mourir ni à être aidé à mourir.

→ Sur la conventionnalité de l'interdiction de l'aide médicale à mourir (CEDH, 13 juin 2024, *Dániel Karsai c. Hongrie*, n° 32312/23).

Il est nécessaire de distinguer l'euthanasie active, de l'euthanasie passive et du suicide assisté.

En France, l'euthanasie active, c'est-à-dire la réalisation d'un acte ayant pour finalité de donner la mort au patient, est interdite. Les médecins sont toutefois autorisés depuis la loi Léonetti du 22 avril 2005 à limiter ou suspendre les soins (euthanasie passive).

La loi du 2 février 2016 a consacré au sein du Code de la santé publique le droit à la fin de vie digne et la notion d'obstination déraisonnable (art. L. 1110-5). Cela permet ainsi au patient souffrant d'une affection grave et durable de bénéficier d'une sédation profonde et continue jusqu'au décès.

Cette dernière introduit une question de proportionnalité des soins. Lorsqu'ils s'avèrent inutiles et disproportionnés ou qu'ils n'ont pour effet que de maintenir artificiellement en vie le patient, celui-ci peut demander l'arrêt des soins.

L'article L. 1110-5-1 liste ainsi les soins pouvant être stoppés : l'alimentation et l'hydratation artificielle ainsi que la ventilation mécanique.

→ CE, réf., 10 janvier 2024, n° 490403.

Le patient doit toutefois être en mesure d'exprimer sa volonté. Cette volonté peut être exprimée par le patient, par le biais des directives anticipées qui s'imposent désormais au corps médical (art. L. 1111-11 du Code de la

santé publique), mais également à travers la désignation d'une personne de confiance qui sera consultée en cas d'impossibilité de déterminer le choix du patient (art. L. 1111-6).

Le médecin peut toutefois passer outre les directives anticipées lorsqu'elles apparaissent manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale.

> → Le conseil constitutionnel a considéré que cette disposition est conforme à la Constitution : Cons. const., déc. n° 2022-1022 QPC, 10 novembre 2022, *Mme Zohra M. et a*.

Depuis la loi du 22 avril 2005, le Code de la santé publique prévoit la mise en place d'une procédure collégiale lorsque le patient est dans l'incapacité d'exprimer sa volonté, en l'absence de directives anticipées ou lorsqu'elles sont considérées par le médecin comme étant manifestement inappropriées. Cette procédure qui peut mener à une décision d'arrêt des thérapeutiques a été la source de conflits entre le corps médical et la famille de certains patients.

> → Voir notamment l'affaire Lambert : CE, réf., 24 avril 2019, n° 428117.

Le juge des référés peut se prononcer sur la légalité de la décision collégiale d'arrêt de soins.

> → CE, ord., 19 juin 2024, n° 494976.

Le 27 mai 2025, l'Assemblée nationale a adopté deux textes relatifs à la fin de vie, l'un relatif au droit et à l'aide à mourir (proposition de loi n° 122), l'autre se rapportant aux soins palliatifs (n° 121).

Le premier de ces textes prévoit l'ajout de l'article L. 1111-12-1 au Code de la santé publique consacrant un droit à l'aide à mourir. Ce droit permettrait d'autoriser et d'accompagner une personne à recourir à une substance létale lorsqu'elle en a manifesté la volonté, ou de lui administrer lorsqu'elle se trouve en incapacité d'y procéder par elle-même.

Actualité. – La consécration d'un droit à l'aide à mourir

Le processus législatif engagé en 2025 a profondément évolué. Le volet relatif aux soins palliatifs a d'abord abouti à l'adoption de la loi du 26 mai *2026 visant à garantir l'égal accès de tous à l'accompagnement et aux soins palliatifs*.

Le texte relatif à l'aide à mourir a, quant à lui, fait l'objet de profondes divergences entre l'Assemblée nationale et le Sénat, avant d'être définitivement adopté par l'Assemblée nationale le 15 juillet 2026.

Le dispositif adopté consacre un droit à l'aide à mourir, défini comme la possibilité pour une personne qui en a exprimé la demande de recourir à une substance létale afin de se l'administrer elle-même ou, lorsqu'elle n'est pas physiquement en mesure d'y procéder, de se la faire administrer par un médecin ou un infirmier. L'accès à ce dispositif est subordonné à plusieurs conditions cumulatives : être majeur, être de nationalité française ou résider de façon stable et régulière en France, être atteint d'une affection grave et incurable engageant le pronostic vital en phase avancée ou terminale, présenter une souffrance liée à cette affection et être apte à manifester une volonté libre et éclairée.

Cette évolution ne remet pas en cause la jurisprudence européenne selon laquelle la Convention européenne des droits de l'homme ne consacre, en elle-même, aucun droit à mourir ou à bénéficier d'une assistance de l'État pour mourir. Elle illustre plutôt la marge d'appréciation laissée aux États pour déterminer le régime applicable à la fin de vie. Cette articulation était déjà présente dans l'arrêt *Pretty* : l'article 2 de la Convention ne permet pas de déduire un droit à mourir, tandis que l'article 8 protège l'autonomie personnelle et peut couvrir les choix relatifs aux conditions de sa propre fin de vie. La Cour européenne a encore confirmé cette large marge nationale d'appréciation dans l'arrêt *Dániel Karsai c. Hongrie* de 2024.

La réforme française a donné lieu à une première décision inédite du Conseil constitutionnel. Saisi d'une proposition de référendum d'initiative partagée visant à exclure de la notion de soin la « *provocation active de la mort* », il a considéré que les questions éthiques relatives à la fin de vie constituent des questions de société qui ne relèvent pas des objets pouvant être soumis à un référendum d'initiative partagée sur le fondement de l'article 11 de la Constitution. À cette date, il relevait en outre qu'aucune disposition législative n'autorisait encore l'euthanasie, l'assistance au suicide ou une autre forme d'aide active à mourir (Cons. const., déc. n° 2026-7 RIP, 17 juin 2026).

Saisi ensuite de la loi définitivement adoptée, le Conseil constitutionnel a franchi une nouvelle étape le 14 août 2026. Il a déclaré conformes à la Constitution les dispositions qui lui étaient déférées relatives au droit à l'aide à mourir, tout en formulant trois réserves d'interprétation (Cons. const., déc. n° 2026-910 DC, 14 août 2026, *Loi relative au droit à l'aide à mourir*).

La première concerne les majeurs protégés : les observations de la personne chargée de leur protection doivent être effectivement prises en compte par le médecin lorsqu'il se prononce sur la demande. La deuxième résulte de la liberté de conscience et étend aux pharmaciens participant à la préparation ou à la délivrance de la substance létale la possibilité de refuser de participer à la procédure. La troisième concerne les établissements privés : leur responsable peut, dans certaines conditions, refuser que l'aide à mourir soit pratiquée dans l'établissement lorsque cette pratique est incompatible avec ses missions ou son projet, sous réserve que d'autres établissements soient en mesure de répondre aux besoins locaux.

La portée de cette décision doit être précisément comprise. Le Conseil constitutionnel ne consacre pas un droit constitutionnel à mourir. Il valide le choix effectué par le législateur d'organiser un droit légal à l'aide à mourir et vérifie que les conditions et garanties qui l'entourent permettent de satisfaire aux exigences constitutionnelles, notamment au regard de la protection de la personne, de sa liberté et de sa dignité. La décision traduit ainsi la recherche d'un nouvel équilibre entre la dimension objective de la protection de la vie et de la dignité, particulièrement à l'égard des personnes vulnérables, et la dimension subjective tenant à l'autonomie personnelle et à la volonté de l'individu dans la détermination de sa fin de vie.

À retenir : Le droit français connaît ainsi une évolution majeure : alors que la législation Léonetti puis Claeys-Léonetti organisait principalement le refus de l'obstination déraisonnable, l'arrêt des traitements et la sédation profonde et continue jusqu'au décès, le texte définitivement adopté en 2026 reconnaît, sous des conditions strictes, une aide active à mourir. Cette évolution ne signifie ni que la Convention européenne ni que la Constitution consacrent un droit général à mourir : elle résulte d'un choix du législateur, désormais validé par le Conseil constitutionnel sous réserves.

2. Le droit à l'intégrité morale de la personne humaine

2.1. La protection internationale de l'intégrité morale

La Convention européenne des droits de l'homme protège l'intégrité morale des personnes relevant de la juridiction des Hautes Parties contractantes. L'intégrité morale est protégée sur le fondement de l'article 8 (droit au respect de la vie privée).

→ CEDH, 25 février 2025, *Toth et Crișan c. Roumanie*, n° 45430/19.

Les atteintes à l'intégrité morale peuvent consister à la révélation d'éléments rattachés à l'image de l'individu ou à son identité sans son consentement, mais également à des atteintes à sa réputation.

→ CEDH, GC., 7 février 2012, *Axel Springer AG c. Allemagne*, n° 39954/08.

→ CEDH, 29 juin 2004, *Chauvy et a. c. France*, n° 64915/01.

Pour être protégées, de telles atteintes à la vie privée doivent toutefois revêtir un certain nombre de critères.

- L'atteinte doit avoir un certain niveau de gravité et affecter la jouissance personnelle du droit au respect de la vie privée. Elle peut cependant aussi bien affecter la sphère personnelle de l'individu que sa sphère professionnelle.

  → CEDH, GC., 25 septembre 2018, *Denisov c. Ukraine*, n° 76639/11.

  → Les personnes morales ne disposent toutefois pas du même niveau de protection de leur réputation que les personnes physiques : CEDH, 8 octobre 2019, *Margulev c. Russie*, n° 15449/09.

- La personne doit être facilement identifiable ;
- L'individu doit avoir une espérance légitime à la protection de son intégrité morale. Ce critère peut se déduire notamment du comportement adopté par la victime et de sa qualité de personnalité publique.

→ CEDH, GC., 7 février 2012, *Von Hannover c. Allemagne* (n° 2), n° 40660/08 et 60641/08.

L'État dispose d'une obligation positive de protéger l'intégrité morale des individus. Néanmoins, il ne doit pas nécessairement prévoir d'incrimination pénale permettant de sanctionner les atteintes à la réputation, un recours de nature civile peut en effet suffire.

2.2. La protection nationale de l'intégrité morale

La France protège également l'intégrité morale à travers les articles 9 et suiv. du Code civil.

L'alinéa 2 de l'article 9 prévoit ainsi la possibilité de saisir le juge des référés afin de faire cesser une atteinte imminente, à empêcher une atteinte à la vie privée ou à faire cesser un trouble manifestement illicite. Les atteintes doivent toutefois présenter une certaine gravité et aucune autre mesure ne doit être possible afin de protéger ce droit.

Une fois l'atteinte subie, la victime pourra demander réparation de son préjudice sur le fondement des articles 1240 et suivants du Code civil. Si l'atteinte relève cependant du champ d'application des délits de presse prévus par la loi du 29 juillet 1881, la victime ne pourra se fonder sur le droit commun de la responsabilité civile.

→ Cass., ass. plén., 12 juillet 2000, n° 98-10.160.

La protection de l'intégrité morale peut également viser les cas de victimisation secondaire. Les États ont ainsi l'obligation positive de protéger les victimes contre les atteintes à l'image, la dignité et la vie privée au cours de l'enquête, mais également lors du procès.

→ CEDH, 27 mai 2021, *J.L. c. Italie*, n° 5671/16.

→ À propos de la condamnation de la défense pour victimisation secondaire en raison du comportement et des propos tenus par l'avocat du prévenu (Trib. corr., Paris, 10e ch., 13 mai 2025, n° 24057000509).

POUR S'ENTRAÎNER

Argumentation juridique : Soutenez que le devoir conjugal constitue une atteinte grave à l'intégrité des personnes.

Le crime de viol est au centre de vifs débats et questionnements notamment quant à sa définition et à l'opportunité d'intégrer au texte d'incrimination une définition incluant explicitement la délicate notion de consentement.

Les relations sexuelles requièrent l'expression d'un consentement libre, éclairé, non équivoque et rétractable à tout moment et ce indépendamment de la nature de la relation entre les partenaires.

Pour autant, l'article 215 du Code civil prévoit une obligation de communauté de vie pour les couples mariés. La jurisprudence a fait découler de ce texte un devoir conjugal bien qu'il n'en prévoit pas explicitement.

Le refus pour un époux de se conformer à cette obligation a pu justifier par le passé des constats de fautes civiles ayant pu non seulement mener à leur responsabilité civile, mais également au prononcé d'un divorce pour faute.

La prise en compte du consentement des actes sexuels dans le cadre des relations de couples est relativement récente. Elle a été en effet initiée par la jurisprudence en 1984 (Cass., crim., 17 juillet 1984, n° 84-91.288).

Problématique et annonce du plan : Dès lors, le devoir conjugal apparaît comme étant une atteinte grave au droit à l'intégrité des personnes, car il en découle une obligation civile à consentir à des actes sexuels **(I)**, opérant de fait une présomption de consentement des actes sexuels entre époux **(II)**.

I. Le maintien critiquable d'une obligation civile à consentir à des actes sexuels

A. Une atteinte à l'autonomie personnelle

Si le Code civil n'évoque pas explicitement ce droit, à la différence du droit canonique qui faisait d'une telle obligation de lit des époux une condition de validité.

Les principes contemporains d'autonomie personnelle et de dignité humaine rendent archaïque une telle exigence au sein des couples.

Le droit à l'autonomie personnelle permet à l'individu, sur le fondement du droit au respect de la vie privée, de faire des choix le concernant (CEDH, 17 février 2005, *K.A. et A.D. c. Belgique*, n^{os}42758/98 et 45558/99).

En imposant une telle communauté de lit, la jurisprudence porte donc atteinte à ce droit puisqu'en matière de choix aussi intimes que ceux relevant de la sphère des relations charnelles, l'individu ne saurait être contraint de consentir.

B. Le risque d'affaiblissement du consentement

La jurisprudence sur le fondement de l'article 215 du Code civil crée une obligation à la charge des époux. Le fait de ne pas respecter cette dernière permet d'engager la responsabilité délictuelle de l'époux fautif sur le fondement de l'article 1240 du Code civil (CA Aix-en-Provence, 3 mai 2011, n° 09/05752).

Cette jurisprudence a également permis de constater la faute de l'un des époux afin de prononcer le divorce (Cass. Civ. 2e, 17 décembre 1997, n° 96-15.704).

Cette obligation a pour effet de créer un faux dilemme dont chacune des issues aboutit à une violation de la Convention.

Se plier à cette obligation et aller à l'encontre du droit à l'autonomie personnelle, ou ne pas le faire et être potentiellement confronté à une sanction pour l'avoir exercé.

Cette situation est d'autant plus préoccupante qu'elle concerne un des domaines les plus intimes de la personne humaine.

La Cour européenne des droits de l'homme a ainsi estimé que le prononcé d'un divorce aux torts de l'époux n'ayant pas respecté le devoir conjugal constitue une ingérence injustifiée au droit au respect de la vie privée (CEDH, 23 janvier 2025, *H.W. c. France*, n° 13805/21).

II. L'inacceptabilité de la présomption du consentement des époux à des actes sexuels

A. Un devoir conjugal contradictoire avec la pénalisation du viol entre époux

Le devoir conjugal peut donc aboutir pour l'un des époux à accepter sous la pression, faisant dès lors obstacle à son consentement (caractère libre, éclairé et non équivoque).

Cette conception du devoir conjugal consacre implicitement une présomption de consentement du seul fait du mariage. Ce faisant, cette obligation pourrait avoir pour effet de banaliser le viol entre époux et d'aller à l'encontre du caractère librement révocable du consentement.

Ceci est d'ailleurs totalement à contrecourant de la pénalisation de viols entre époux depuis 1984 (Cass., crim., 17 juillet 1984, n° 84-91.288).

Depuis 2010 le législateur a en effet ôté de l'article 222-22 du Code pénal la référence à la présomption de consentement qui existait jusqu'alors.

B. Un devoir conjugal incohérent face à l'obligation de protection contre les atteintes graves à l'intégrité physique

Les États disposent selon la Cour européenne des droits de l'homme d'une obligation d'incrimination pénale du viol en ce que de tels actes portent une atteinte particulièrement grave au droit à l'intégrité des personnes (Voir notamment : CEDH, 24 avril 2025, *L. et a. c. France*, n°s 46949/21 et 2 a.).

La Cour européenne des droits de l'homme juge en outre que le viol entre époux doit être puni pénalement (CEDH, 22 novembre 1995, *S.W. c. Royaume-Uni*, n° 20166/92).

Or, le devoir conjugal brouille la cohérence de l'ordre juridique dans la réponse apportée à la lutte contre de telles infractions.

En conclusion, le devoir conjugal constitue non-seulement une atteinte directe et grave au principe d'autonomie personnelle, puisqu'il touche à un domaine relevant de la sphère intime des individus, mais il a également pour effet, et ce de manière insidieuse, de brouiller la lutte contre le viol entre époux en qualifiant de fautif au sens civil du terme l'expression continuelle du refus d'entretenir des relations intimes avec son conjoint.

Fiche nº 28 - L'INTERDICTION DE LA TORTURE ET DES PEINES OU TRAITEMENTS INHUMAINS OU DÉGRADANTS

POINTS CLÉS

- La torture.
- Les traitements ou peines inhumains.
- Les traitements ou peines dégradants.
- L'autonomie normative de l'interdiction de l'esclavage et du travail forcé.
- Obligations négatives et positives de l'État.
- Conditions indignes de détention.

PRINCIPALES RÉFÉRENCES

- Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
- Article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales.
- Article 5 de la Déclaration universelle des droits de l'homme.
- Article 7 du Pacte relatif aux droits civils et politiques.
- Article 222-1 et suivants du Code pénal.
- Article 2226 du Code civil.
- CE, ord., 22 décembre 2012, *SF-OIP*, nº 364584.
- CEDH, 30 janvier 2020, *J.M.B. et a. c. France*, nº 9671/15.
- Loi nº 2021-403 du 8 avril 2021 tendant à garantir le droit au respect de la dignité humaine en détention.

1. L'interdiction vigoureuse par le droit international et européen des droits humains

Plusieurs socles conventionnels reconnaissent l'interdiction de la torture et des traitements ou peines inhumains ou dégradants. Elle est inscrite à l'article 5 de la Déclaration universelle des droits de l'homme ainsi qu'à l'article 7 du Pacte international des droits civils et politiques qui ajoute qu'il est :

> *« Interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique »*.

L'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme consacre cette interdiction. La Cour européenne des droits de l'homme n'a pas manqué de souligner que les dispositions de l'article 3 ne peuvent pas faire l'objet de dérogation, y compris en cas de recours à l'article 15 relatif à la dérogation en cas d'état d'urgence.

> → CEDH, 18 janvier 1978, *Irlande c. Royaume-Uni*, nº 5310/71.

La Cour se réfère expressément à ces dispositions comme étant une norme de *jus cogens* dans un arrêt de 2001, dans le sillage d'un jugement rendu par le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie en 1998.

> → TPI, 10 décembre 1998, *Procureur c. Furunszija.*

> → CEDH, 21 novembre 2001, *Al-Adsani c. Royaume-Uni*, nº 35763/97.

L'interdiction de la torture et des traitements ou peines inhumains et dégradants est intrinsèquement liée à la dignité humaine. En 2015, la Cour européenne affirme que :

« L'interdiction de la torture et des peines et traitements inhumains ou dégradants est une valeur de civilisation étroitement liée au respect de la dignité humaine » (CEDH, 28 septembre 2015, *Bouyid c. Belgique*, n° 23380/09).

2. L'existence d'instruments conventionnels spécifiques

En 1984, sous l'égide des Nations unies, est adoptée une convention spécifique à cette interdiction, la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Le Comité contre la torture a été institué par cette convention.

L'Assemblée générale des Nations unies a adopté en 2002 un Protocole facultatif se rapportant à cette Convention qui prévoit l'établissement d'un système de visites régulières au sein des lieux où se trouvent des personnes privées de liberté pour prévenir la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Une loi française de 2007 institue une autorité administrative indépendante : le Contrôleur général des lieux de privation de liberté. En 2008, une loi approuve le protocole.

L'actuelle Contrôleur général est madame Dominique Simonnot, nommée pour une durée de six ans par le président de la République en 2020, conformément à l'article 13 de la Constitution, succédant à madame Adeline Hazan.

Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté peut visiter, même de façon inopinée, des établissements pénitentiaires, des établissements de santé dans lesquelles des personnes sont hospitalisées sans consentement, des centres éducatifs fermés, des locaux de garde à vue, des établissements de rétention administrative ainsi que les zones d'attentes et les geôles de tribunaux.

Il peut être saisi par des personnes privées de liberté, mais aussi par leurs proches, des agents publics travaillant dans les établissements privatifs de libertés, le Gouvernement, les parlementaires et d'autres autorités administratives indépendantes.

Le Contrôleur publie des avis, recommandations et rapports thématiques, il ne dispose pas d'un pouvoir réglementaire.

De plus, il existe la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants de 1989 du Conseil de l'Europe, qui a institué (par un protocole) un Comité européen pour la prévention de la torture ou traitements inhumains ou dégradants, un mécanisme de prévention des mauvais traitements dans les lieux de privation de liberté.

En vertu de l'article premier de cette convention, le Comité visite des lieux de privation de liberté, à raison d'environ 18 visites par an.

POUR ALLER PLUS LOIN

En 2024, le Comité a visité plusieurs établissements français particulièrement concernés par la surpopulation carcérale, quatorze établissements de police et de gendarmerie ainsi que les geôles du tribunal judiciaire de Marseille. Dans son 34e rapport général d'activité de 2024, le Comité affirme avoir accordé une attention particulière, notamment, « à la situation des femmes et des enfants dans les prisons et aux conditions de détention dans les établissements des forces de l'ordre ».

Actualité. - Violences en détention et recommandations d'urgence du CGLPL

En juin 2026, la Contrôleure générale des lieux de privation de liberté a adressé des recommandations en urgence au ministre de la Justice concernant le centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe. À la suite d'une visite du quartier de lutte contre la criminalité organisée, elle a constaté des violences commises sur des détenus par certains personnels, ainsi que des fouilles humiliantes ou brutales et des usages disproportionnés de la force. Le CGLPL rappelle à cette occasion que l'administration pénitentiaire est tenue de garantir la sécurité et l'intégrité physique des personnes placées sous sa garde. Ces recommandations ont été publiées au Journal officiel le 9 juillet 2026.

→ **CGLPL, recommandations en urgence du 9 juin 2026 relatives au centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe**.

3. Les contours de la torture

3.1. La définition de la torture

L'article 1er de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants définit la torture de la façon suivante :

> *«* [La torture] *désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte qu'elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d'avoir commis, de l'intimider ou de faire pression sur elle ou d'intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu'elle soit, lorsqu'une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Ce terme ne s'étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles. »*

Pour distinguer la torture des traitements ou peines inhumains ou dégradants, dans l'arrêt de 1978 précité, la Cour se réfère à *« une différence dans l'intensité des souffrances infligées »*.

En 1997, la Cour européenne se réfère à l'infamie spéciale de la torture pour la distinguer des traitements inhumains.

> → CEDH, 25 septembre 1997, *Aydin c. Turquie*, no 23178/94.

La Cour n'exclut pas la possibilité de faire évoluer la qualification d'un acte de traitements inhumains et dégradants à un acte de torture, puisqu'elle considère la Convention comme étant un instrument vivant.

En 1998, la France a fait l'objet d'une condamnation pour des faits de torture à l'encontre d'une personne gardée à vue par des agents de police.

> → CEDH, 28 juillet 1999, *Selmouni contre France*, no 25803/94.

3.2. La torture en droit interne

Sur le plan du droit interne, d'une part, le Code pénal comprend un paragraphe consacré aux tortures et actes de barbaries, inséré dans le chapitre relatif aux atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne. Les articles 222-1 et suivants prévoient les peines encourues en cas de soumission d'une personne à des tortures ou à des actes de barbarie.

D'autre part, l'article 2226 du Code civil dispose d'un délai de prescription de dix ans pour l'action en responsabilité né en raison d'un évènement ayant entraîné un dommage corporel, il est prescrit par vingt ans en cas de préjudice causés par des tortures ou des actes de barbarie.

3. La distinction entre les traitements et peines « inhumains » et « dégradants »

Cette interdiction n'implique pas que tout traitement ou toute peine se heurte à l'article 3 de la Convention. Pour qu'ils impliquent une violation des dispositions de cet article, un seuil de gravité minimum doit être atteint.

3.1. Le caractère « inhumain »

Pour qu'un traitement soit considéré comme « inhumain », la Cour européenne affirme qu'il doit :

> *« Atteindre un minimum de gravité pour tomber sous le coup de l'article 3. L'appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l'ensemble des données de la cause, et notamment de la durée du traitement, de ses effets physiques et mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la victime »* (CEDH, 6 avril 2000, *Labita c. Italie,* n° 26772/95).

3.2. Le caractère « dégradant »

Est qualifié de « dégradant » un traitement :

> *« Comme étant de nature à créer des sentiments de peur, d'angoisse et d'infériorité propres à humilier, avilir et briser éventuellement la résistance physique ou morale de la personne qui en est victime, ou à la conduire à agir contre sa volonté ou sa conscience »* (CEDH, 1er juin 2010, *Gäfgen contre Allemagne*, n° 22978/05).

Par exemple, le fait de placer une personne dans une cage en métal lors de son procès revêt un caractère dégradant.

> → CEDH, 17 juillet 2014, *Svinarenko et Slyadnev c. Russie*, n° 32541/08.

Est considérée « dégradante » une peine à l'aune de l'humiliation découlant de la condamnation ainsi que des modalités de l'exécution de la peine.

> → CEDH, 25 avril 1978, *Tyrer contre Royaume-Uni*, n° 5856/72.

L'incarcération à vie ne constitue pas, en soi, une peine contraire aux dispositions de l'article 3 de la Convention. Cependant, la Cour européenne affirme qu'une incarcération à vie doit pouvoir être compressible, c'est-à-dire qu'il faut que la personne incarcérée puisse disposer d'une possibilité de réexamen.

POUR ALLER PLUS LOIN

Selon les statistiques de la Cour européenne des droits de l'homme relatives aux violations par article et par État pour l'année 2024, il y a eu deux condamnations relatives à l'interdiction de la torture, les deux concernant la Fédération de Russie. S'agissant des traitements inhumains et dégradants, la Cour a prononcé 344 violations sur les 1102 violations prononcées au total. Sur ces 344 violations relatives aux traitements inhumains et dégradants, 30 concernent la Roumanie, 52 concernent l'Ukraine et 195 concernent la Fédération de Russie.

La France a été condamnée à de nombreuses reprises pour violation de l'article 3 en matière pénitentiaire.

Pour quelques illustrations voir :

> → Absence de soins médicaux appropriés à une personne incarcérée anorexique (CEDH, *Raffray Taddei c. France*, n° 36435/07).
>
> → Placement en quartier disciplinaire d'une personne incarcérée 23h/24h dans une cellule incendiée dont l'odeur était « nauséabonde » (CEDH, 10 novembre 2011, *Plathey c. France*, n° 48337/09).
>
> → Fouilles intégrales systématiques (CEDH, 12 juin 2007, *Frérot c. France,* n° 70204/01).
>
> → Conditions de détention (CEDH, 25 avril 2013, *Canali c. France*, n° 40119/09).
>
> → Conditions de détention (CEDH, 30 janvier 2020, *J.M.B. c. France*, n° 9671/15).

La France a également été condamnée sur le fondement de l'article 3 de la Convention européenne dans d'autres domaines, par exemple :

→ Mise à exécution envisagée d'une décision de renvoi du requérant au Maroc qui risquerait d'être soumis à traitements contraires à l'article 3 du fait de son soutien à la cause sahraouie (CEDH, 30 mai 2013, *Rafaa c. France*, n° 25393/10).

→ En matière de violences policières sur une personne vulnérable du fait de sa santé psychiatrique (CEDH, 16 novembre 2017, *Boukrourou et a. c. France,* n° 30059/15).

→ Carence de la prise en charge d'un enfant vivant dans le « bidonville » de Calais (CEDH, 28 février 2019, *Khan c. France*, n° 12267/16).

→ Méconnaissance des obligations positives pour défaut de protection d'un enfant victime de maltraitances par ses parents qui ont conduit à son décès (CEDH, 4 juin 2020, *Association Innocence en Danger et Association Enfance et Partage c. France*).

3.3. Le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants en droit français

Le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du Code de la justice administrative.

→ CE, ord., 22 décembre 2012, *SF-OIP*, n° 364584.

Ce droit apparaît régulièrement dans la jurisprudence administrative. Par une ordonnance de 2015, le Conseil d'État affirme que les autorités publiques doivent veiller à la garantie du droit de toute personne à ne pas être soumise à des traitements inhumains et dégradants et confirme que les conditions de vie des personnes migrantes à Calais portent atteinte à ce droit en relevant la carence des autorités publiques. Le Conseil d'État réitère une solution similaire dans un arrêt de 2017.

→ CE, ord., 23 novembre 2015, n° 394540.

→ CE, 31 juillet 2017, n° 412125.

Ce droit est régulièrement invoqué devant le juge administratif dans le cadre du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers.

→ CE, ord., 23 décembre 2024, n° 499403.

En outre, la Cour de cassation a affirmé qu'au titre de l'interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, les autorités publiques ont :

« une obligation de protection et de prise en charge des mineurs non accompagnés ; que l'article 388 du Code civil permet le recours à des examens radiologiques osseux pour évaluer la minorité d'une personne se présentant comme un mineur isolé étranger lors même qu'il résulte de divers avis d'organismes internes et internationaux que ces examens manquent de fiabilité, de sorte que le recours à ce procédé, qui conduit à l'élaboration d'un rapport ayant force d'expertise judiciaire, présente un risque important que des mineurs isolés, dépourvus de toute protection étatique, soient victimes de traitements inhumains et dégradants et qu'ainsi ne soit pas protégé leur intérêt supérieur ; qu'un juge ne peut dès lors motiver sa décision notamment par ces examens pour déterminer l'âge d'un individu ; qu'en fondant toutefois sa décision sur une expertise osseuse, sur le fondement de l'article 388 du Code civil, la cour d'appel a violé l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales » (Cass, 1re civ., 21 novembre 2019, 19-15.890).

POUR ALLER PLUS LOIN

Par un arrêt du 23 juillet 2024, O.R. contre Grèce, la Cour condamne la Grèce pour ne pas avoir assuré pendant une période de six mois « des conditions de vie propres et adaptées » à « un mineur non

accompagné en situation irrégulière se disant victime d'un passé familial violent et traumatisé, c'est-à-dire un individu relevant de la catégorie des personnes les plus vulnérables de la société ».

4. L'autonomie normative de l'interdiction de l'esclavage et du travail forcé

Si l'esclavage et le travail forcé peuvent *a priori* faire penser qu'ils rentrent dans le champ d'application de l'interdiction de la torture et des traitements ou peines inhumains ou dégradants, l'interdiction de ces actes relève de dispositions normatives distinctes.

En effet, l'article 4 de la Convention européenne est consacré à l'interdiction de l'esclavage et du travail forcé. En outre, l'article 8 du Pacte international des droits civils et politiques prévoit des dispositions qui s'y affèrent, au même titre que l'article 4 de la Déclaration universelle des droits de l'homme.

De surcroît, des conventions traitent spécifiquement de l'esclavage telles que la Convention relative à l'esclavage de 1926 amendée par un protocole de 1953 et la Convention supplémentaire relative à l'abolition de l'esclavage et des institutions et pratiques analogues à l'esclavage de 1956. De plus, il existe la Convention sur le travail forcé de 1930 de l'Organisation internationale du travail.

5. Les obligations négatives et positives de l'État

Découlent des dispositions de l'article 3 de la Convention européenne des obligations aussi bien négatives que positives incombant à l'État. Ces obligations sont essentiellement négatives, pour reprendre les termes de la Cour de Strasbourg.

→ CEDH, 13 novembre 2012, *Hristozov et a. c. Bulgarie*, n° 47039/11.

Un arrêt de 2021 présente une classification tripartite des obligations positives des États, comprenant un volet matériel ainsi qu'un volet procédural. Pour garantir le respect des dispositions de l'article 3 de la Convention, les États doivent établir un cadre normatif, prendre des mesures opérationnelles, ainsi que mener une enquête effective en cas d'allégations portant sur une violation de l'interdiction.

→ CEDH, 2 février 2021, *Affaire X et a. c. Bulgarie*, n° 22457/16.

En 2024, la Cour européenne des droits de l'homme a rendu plusieurs arrêts prononçant la violation de l'article 3 de la Convention pour manquements aux obligations positives en matière de violences faites aux femmes.

Le Danemark a été condamné sur le fondement, notamment, de l'article 3 pour manquement à ses obligations procédurales. La Cour a relevé des défaillances significatives dans la réponse procédurale apportée aux allégations de viols formulées par la requérante.

→ CEDH, 15 octobre 2024, *Daugard Sorensen c. Danemark*, n° 11829/16.

L'Arménie a été condamnée pour violation de l'article 3 pour manquement à ses obligations positives dans une affaire de violences domestiques. Une femme avait subi plusieurs agressions de la part de son ancien conjoint qui a engendré plusieurs blessures graves (commotion cérébrale, nez cassé, traumatisme crânien, hématomes, notamment). L'auteur des faits a été condamné, mais a été dispensé de peine.

Après avoir retenu que le seuil de gravité des faits avait été atteint pour correspondre à l'interdiction prévue à l'article 3, la Cour a notamment retenu que le cadre juridique et législatif arménien en matière de violences domestiques était insuffisant : absence de considération des violences domestiques dans la loi, absence de mesure de protection accordée à la requérante, indigence du traitement malgré les signalements des actes de violence domestiques.

→ CEDH, *Hasmik Khachatryan c. Arménie*, n° 11829/16.

POUR S'ENTRAÎNER

Commentaire d'arrêt : CEDH, 30 janvier 2020, *J.M.B. et a. c. France*, n° 9671/15 [Extrait]

« *220. En définitive, la Cour retient de ce qui précède que les injonctions prononcées par le juge du référé-liberté, dans la mesure où elles concernent des établissements pénitentiaires surpeuplés, ce qui n'est pas contesté par le Gouvernement, s'avèrent en pratique difficiles à mettre en œuvre. La surpopulation des prisons et leur vétusté, a fortiori sur des territoires où n'existent que peu de prisons et où les transferts s'avèrent illusoires, font obstacle à ce que l'utilisation du référé-liberté offre aux personnes détenues la possibilité en pratique de faire cesser pleinement et immédiatement les atteintes graves portées à l'article 3 de la Convention ou d'y apporter une amélioration substantielle.*

Dans ces conditions, il est aisé pour la Cour de concevoir que les autorités pénitentiaires françaises ne sont pas en mesure d'exécuter de manière satisfaisante les mesures prescrites par le juge de l'urgence et en conséquence de garantir aux personnes détenues des conditions de détention conformes à sa jurisprudence. Si le référé-liberté semble offrir un cadre juridique théorique solide pour juger d'atteintes graves aux droits des détenus, il ne peut être considéré comme le recours préventif qu'exige la Cour, pour les raisons qui viennent d'être exposées. La Cour ne voit pas de raison de statuer différemment s'agissant du référé mesures-utiles ; outre son caractère subsidiaire par rapport au référé-liberté et le caractère limité du pouvoir du juge (paragraphes 142 et 144 ci-dessus), il se heurte aux mêmes obstacles pratiques que ce dernier.

221. Eu égard à ce qui précède, la Cour considère qu'il n'a pas été démontré que les voies de recours préventives indiquées par le Gouvernement sont effectives en pratique, c'est-à-dire susceptibles d'empêcher la continuation de la violation alléguée et d'assurer aux requérants une amélioration de leurs conditions matérielles de détention. Dès lors, la Cour considère qu'il y a lieu de rejeter l'exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement et conclut que les requérants, à l'exception de M. Mixtur qui ne s'est pas plaint de la violation de l'article 13 de la Convention, n'ont pas disposé d'un recours effectif en violation de l'article 13 de la Convention. […]

316. Dans ce contexte, la Cour recommande à l'État défendeur d'envisager l'adoption de mesures générales. D'une part, de telles mesures devraient être prises afin de garantir aux détenus des conditions de détention conformes à l'article 3 de la Convention. Cette mise en conformité devrait comporter la résorption définitive de la surpopulation carcérale. Ces mesures pourraient concerner la refonte du mode de calcul de la capacité des établissements pénitentiaires (paragraphes 124 à 126 et 205 ci-dessus) et l'amélioration du respect de cette capacité d'accueil. La Cour note également que la loi de programmation 2018-2022 comporte des dispositions de politique pénale et pénitentiaire qui pourraient avoir un impact positif sur la réduction du nombre de personnes incarcérées. Par ailleurs, devrait être établi un recours préventif permettant aux détenus, de manière effective, en combinaison avec le recours indemnitaire (paragraphe 167 ci-dessus), de redresser la situation dont ils sont victimes et d'empêcher la continuation d'une violation alléguée. […]

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ, […]

Dit qu'il y a eu violation de l'article 13 de la Convention (recours préventif) et rejette l'objection du Gouvernement de non-épuisement des voies de recours internes ;

Dit qu'il y a eu violation de l'article 3 de la Convention du fait des conditions de détention des requérants et des requérantes et rejette l'objection du Gouvernement de non-épuisement des voies de recours internes ; […] »

Dans une décision du 19 novembre 2009, dite *Loi pénitentiaire*, le Conseil constitutionnel a affirmé, en mentionnant le Préambule de la Constitution de 1946, que *« la sauvegarde de la dignité de la personne contre toute forme d'asservissement et de dégradation est au nombre de ces droits et constitue un principe à valeur constitutionnelle »*. Qu'ainsi, en vertu de l'article 34 de la Constitution, le législateur doit notamment déterminer *« les conditions et les modalités d'exécution des peines privatives de liberté dans le respect de la dignité de la personne »*.

Dans une décision QPC du 6 octobre 2023, *Association des avocats pénalistes*, le Conseil constitutionnel a réaffirmé que *« toute mesure privative de liberté doit être mise en œuvre dans le respect de la dignité humaine »*.

Des personnes incarcérées dans plusieurs établissements pénitentiaires français ont saisi la Cour européenne pour violation des article 3 et 13 de la Convention (moins de 3 m^2 d'espace personnel, WC partiellement cloisonnés, intimité insuffisante, insuffisance d'activités, mauvaises conditions sanitaires et hygiénique… + limites des décisions rendues par le juge des référés pour faire cesser les conditions indignes de détention).

Solution de la Cour : le recours préventif est inefficace pour la cessation des conditions indignes de détention à cause de la surpopulation carcérale (violation des articles 3 et 13).

Problématique et annonce du plan : À la suite de la condamnation de la France du 30 janvier 2020, une nouvelle voie de recours en cas de conditions indignes de détention a été adoptée **(I)**, l'effectivité de cette voie de recours demeure toutefois contestée **(II)**.

I. La création d'une nouvelle voie de droit à la suite de l'arrêt *J.M.B et a. contre France*

A. La condamnation de la France pour violation de l'article 3 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme

Selon la Cour, le référé-liberté, au regard de l'office limité du juge des référés, ne suffit pas à la personne incarcérée requérante pour que les conditions indignes de détention cessent.

Dans la lignée de cet arrêt, en 2020, la Cour européenne des droits de l'homme a rendu l'arrêt *Barbotin contre France* par lequel elle condamne la France du fait de l'insuffisance du recours compensatoire en cas de conditions indignes de détention (violation de l'article 3 et 13 également).

B. Une évolution du droit positif à l'issue de l'arrêt *J.M.B. et a. contre France*

Par cet arrêt, la Cour européenne a recommandé à la France de créer une nouvelle voie de recours préventive.

La chambre criminelle de Cour de cassation, le 8 juillet 2020, a pris acte de cet arrêt en affirmant qu'il *« appartient au juge national, chargé d'appliquer la Convention, de tenir compte de ladite décision sans attendre une éventuelle modification des textes législatifs ou réglementaires »* ; affirme que le juge judiciaire doit veiller à ce que la détention provisoire soit *« exempte de tout traitement inhumain et dégradant »*.

Par deux décisions QPC du 2 octobre 2020 et du 16 avril 2021, le Conseil constitutionnel censure des dispositions du Code de procédure pénale, car elles ne permettent pas aux personnes incarcérées (prévenues et condamnées) de contester effectivement (art. 16 de la Déclaration de 1789) les conditions indignes de détention, et dit qu'il incombe au législateur de garantir aux personnes incarcérées de saisir le juge pour que soit mis fin aux conditions indignes.

La loi du 8 avril 2021 tendant à garantir le droit au respect de la dignité humaine en détention a introduit l'article 803-8 dans le Code de procédure pénale une nouvelle voie de recours permettant à une personne incarcérée de saisir le juge judiciaire pour faire constater des conditions de détention indignes : détention provisoire : saisine du juge des libertés et de la détention / condamnation : saisine du juge d'application des peines.

II. La mise en œuvre hésitante de la condamnation de la France du 30 janvier 2020

A. Une effectivité limitée à la nouvelle voie de recours

Dans sa « Déclaration relative à la proposition de loi tendant à garantir le droit au respect de la dignité en détention », la Commission nationale consultative des droits de l'homme considère que le nouveau recours n'est pas compatible avec les exigences de la Cour européenne.

Elle souligne que le transfèrement d'une personne incarcérée, afin qu'il soit mis fin à ses conditions de détention indignes, est incompatible avec le droit au respect de la vie privée et familiale des personnes

concernées ; ainsi, cela pourrait dissuader des personnes d'exercer un recours contre leur conditions indignes de détention puisque cela pourrait mener à être loin de leur famille et donc complexifier les visites.

Dans cette même déclaration, la Commission relève que le délai entre le dépôt de la requête et la décision juridictionnelle est contraire à la dignité humaine puisqu'il est question de conditions indignes de détention.

Enfin, la Commission critique le transfèrement, car il pourrait porter atteinte à un parcours de soin ou encore à un projet d'aménagement de peine.

B. Une effectivité timorée liée à la persistance de la surpopulation carcérale

Dans l'arrêt *J.M.B. et a. contre France*, la Cour européenne recommande à la France, pour assurer des conditions de détention compatibles avec l'article 3, de diminuer sa population carcérale. L'effectivité de cette condamnation se heurte à la surpopulation carcérale.

Le 14 mars 2024, le Comité des ministres du Conseil de l'Europe a exprimé une « profonde préoccupation » à l'aune de l'aggravation de la surpopulation carcérale française.

Au 1er juin 2025 la surpopulation carcérale est à son apogée, le nombre de places en prison est d'environ 62 000 places opérationnelles pour plus de 84 000 personnes incarcérées.

Malgré sa condamnation par la Cour européenne le 30 janvier 2020, la France a fait l'objet de nouvelles condamnations sur le fondement de l'article 3 de la Convention en matière pénitentiaire, dont le 6 juillet 2023 par l'arrêt *B.M. et a. contre France* pour mauvaises conditions de détention, et le 18 avril 2024 par l'arrêt *Leroy contre France* en raison de conditions indignes consécutives à un mouvement social.

Fiche n° 29 – L'INTERDICTION DE L'ESCLAVAGE, DE LA TRAITE, DE LA SERVITUDE ET DU TRAVAIL FORCÉ

POINTS CLÉS

- Esclavage.
- Traite des êtres humains.
- Servitude.
- Travail forcé.
- Obligations positives.
- Obligations procédurales.

PRINCIPALES RÉFÉRENCES

- Art. 4 de la Déclaration universelle des droits de l'homme.
- Convention pour la répression de la traite des êtres humains et l'exploitation de la prostitution d'autrui (1949).
- Art. 4 de la Convention européenne des droits de l'homme.
- Convention relative aux droits de l'enfant (1989) et son Protocole facultatif concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (2000).
- Protocole additionnel à la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (Protocole de Palerme) (2000).
- Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains (2005).
- Directive 2011/36/UE.
- Loi du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées.
- Loi du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre.
- Loi du 21 avril 2021 visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l'inceste.

1. Principes généraux

La protection de l'individu contre les différentes formes d'exploitation qu'elles correspondent à de l'esclavage, du travail forcé ou obligatoire ou de la servitude, ou qu'elles résultent d'un contexte de traite des êtres humains, est l'une des interdictions fondamentales de nombreux textes nationaux et internationaux qui protègent contre toutes les formes les plus sérieuses d'exploitation portant atteinte à la dignité même de l'être humain.

Au niveau européen, l'exploitation de l'individu est interdite par l'article 4 de la Convention européenne des droits de l'homme qui dispose que *« 1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude. 2. Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire* […] *»*, et l'article 5 de la Charte des droits fondamentaux disposant que *« 3. La traite des êtres humains est interdite »*. Au niveau international, l'article 4 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et l'article 8 du Pacte international des droits civils et politiques interdit ces situations dans

des termes similaires. Cette interdiction est considérée comme une valeur fondamentale des sociétés démocratiques.

L'interdiction de l'esclavage et de la servitude ont un caractère absolu, valant également en situation de guerre ou de calamité publique.

→ CEDH, 7 janvier 2010, *Rantsev c. Chypre et Russie*, n° 25965/04.

Il existe par ailleurs un mécanisme de suivi tenant à la surveillance du respect des obligations de l'État en matière de prévention, de protection et de traitement des victimes et des auteurs d'exploitation, grâce au Groupe d'experts sur la lutte contre la traite des êtres humains (communément appelé GRETA) chargé de contrôler le respect de l'application de la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains (2005) en présentant des rapports de mise en œuvre de ces obligations par les États parties selon des cycles d'évaluation.

Dans son quatrième rapport consacré à la France, publié le 25 juin 2026, le GRETA relève une progression du nombre de victimes identifiées de traite et d'exploitation. Le nombre de victimes de traite au sens strict est ainsi passé de 331 en 2021 à 442 en 2024. Le Groupe appelle notamment la France à renforcer l'identification et la prise en charge des victimes, particulièrement des mineurs, des migrants et des personnes en situation de vulnérabilité, ainsi qu'à intensifier les contrôles dans les secteurs particulièrement exposés au travail forcé, tels que l'agriculture, la construction et la restauration. Il souligne également le rôle croissant des technologies numériques dans le recrutement et l'exploitation des victimes.

Parmi la multitude d'instruments nationaux et internationaux traitant de cette question, il existe une convergence des critères concernant les différentes situations d'exploitation.

1.1. L'interdiction de l'esclavage

La définition généralement retenue correspond à celle issue de la Convention relative à l'interdiction de l'esclavage de 1926 dans son article 1er : *« L'esclavage est l'état ou condition d'un individu sur lequel s'exercent les attributs du droit de propriété ou certains d'entre eux »*, également mentionnée dans des termes similaires à l'article 224-1 A, B et C du Code pénal et incriminant également l'exploitation économique ou sexuelle d'une personne dans une situation d'esclavage.

La reconnaissance d'une situation d'esclavage est conditionnée à l'existence de plusieurs critères :

- Une réification de la personne.
- L'annihilation de l'autonomie personnelle.
- Exercice des attributs de propriété sur cette personne.

La négation de la qualité d'être humain de l'individu en constitue un crime contre l'humanité dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique dirigée contre la population civile. L'interdiction de l'esclavage est dès lors considérée comme une règle de *jus cogens*, reconnu par le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie et inscrit dans le Statut de Rome (art. 7-1-c).

→ TPIY, 22 février 2001, Le *Procureur c. Kunarac et a.*, 1re instance, IT-96-23-T& IT-96-23/1-T.

La notion d'esclavage possède une connotation historique importante. En cela, la Cour européenne des droits de l'homme qualifie difficilement une situation d'esclavage, bien que d'autres expressions telles que « esclavage moderne » ou « situations analogues à l'esclavage » aient pu se développer.

→ CEDH, 26 octobre 2005, *Siliadin c. France*, n° 73316/01.

Elle a cependant considéré que le transfert d'argent du fiancé vers le père de la future mariée n'équivalait pas à un transfert des droits de propriété, correspondant plutôt à une pratique, dans certaines cultures, consistant à réaliser des « cadeaux » dans le cadre du mariage.

→ CEDH, 31 juillet 2012, *M. et a. c. Italie et Bulgarie*, n° 40020/03.

1.2. Les formes d'exploitations analogues à l'esclavage

1.2.1 La servitude

La servitude, ou « servage » (art. 1.b. de la Convention supplémentaire relative à l'abolition de l'esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l'esclavage adoptée le 30 avril 1956), est définie comme une forme de travail forcé aggravée. Elle est parfois appelée « esclavage domestique ».

Elle implique que la personne ait été forcée de fournir un service sous l'emprise de la contrainte et constitue une « négation » de la liberté individuelle particulièrement grave. Plusieurs éléments pertinents sont à prendre en compte pour la qualification de servitude selon la Cour européenne :

- L'obligation de fournir un service ou un travail.
- L'existence d'une contrainte (physique, menaces de violence ou de dénonciation aux autorités…) ayant pour but de rendre la victime docile.
- L'obligation de vivre comme « serf » sur la propriété de l'exploiteur.
- Le sentiment profond de l'impossibilité de changer sa condition et de la permanence de la situation.

D'autres éléments peuvent également être pris en compte en fonction du contexte comme une rémunération sans rapport avec le travail fourni, des conditions de vie et de travail indignes, des traitements dégradants, une liberté de circulation réduite etc. L'abus de la vulnérabilité de la victime ou de sa situation de dépendance est notamment mis en avant pour qualifier le caractère aggravé de l'exploitation dans le droit français (art. 225-14-2 du Code pénal).

→ CEDH, 7 mars 2000, *Seguin c. France* (déc.), n° 42400/98.

→ CEDH, 26 octobre 2005, *Siliadin c. France*, n° 73316/01.

→ CEDH, 11 octobre 2012, *C.N. et V. c. France*, n° 67724/09.

Ces arrêts de la Cour européenne des droits de l'hommes ont par ailleurs conduit l'État français à modifier et à adapter son droit pénal pour le mettre en conformité avec le droit du Conseil de l'Europe par la loi du 5 août 2013.

1.2.2 L'interdiction du travail forcé ou obligatoire

L'interdiction du travail forcé ou obligatoire vise à protéger l'individu contre des cas graves d'exploitation par le travail. La Convention de l'Organisation internationale du travail n° 29 du 28 juin 1930 le définit ainsi en son article 2-1 : *«* […] *tout travail ou service exigé d'un individu sous la menace d'une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s'est pas offert de plein gré. »* Il implique dès lors les éléments suivants :

- L'obligation de fournir un travail.
- De manière contraire à la volonté de l'individu.
- Sous la menace d'une peine.
- Sans rétribution ou dans le cas où la rétribution est sans mesure avec le travail accompli.

Le travail exigé doit être compris au sens large, incluant également les services. Cependant, tout travail « exigé » « sous la contrainte d'une menace » ne constitue pas nécessairement une violation des droits humains. Une appréciation concrète de l'activité doit être réalisée afin de déduire si elle constitue ou non un « fardeau disproportionné », en raison de sa nature et de son volume.

→ CEDH, 23 novembre 1983, *Van der Mussele c. Belgique*, n° 8919/80.

De même, la contrainte ne s'entend pas uniquement de l'emploi de la force comme pourrait y faire penser le terme de travail « forcé », mais doit être entendue largement comme pouvant impliquer tout autre type de coercion comme des pressions psychologiques.

De même, un contrat de travail pour lequel l'individu s'est engagé volontairement et le risque d'être licencié en cas de non-accomplissement dudit travail ou des tâches connexes à celui-ci ne saurait être considéré comme une forme de peine.

Il est tenu compte des normes en vigueur afin de déterminer la légitimité du travail requis ainsi que d'une analyse du caractère proportionné de celui-ci. De manière générale, c'est l'ensemble des circonstances qui est analysée

afin d'apprécier le caractère légitime de la contrainte exercée (la rémunération, l'existence d'indemnité, la nature de l'obligation, les conditions matérielles d'exécution du travail, l'existence d'une surveillance…).

Le Code pénal français incrimine également le fait de soumettre un individu à du travail forcé à l'article 225-14-1. De nombreux articles incriminent spécifiquement certains types d'exploitation par le travail d'autrui notamment la prostitution (art. 225-12-1 à 225-12-4), la mendicité (art. 225-12-6 à 225-12-7) ou la vente à la sauvette (art. 225-12-8 à 225-12-10).

Le travail forcé ou obligatoire connaît cependant des exceptions. Ne sont pas considérés comme tels les travaux réalisés dans le cadre des obligations civiques, pendant les détentions ou dans le cadre de travaux d'intérêt généraux, dans la limite fixée par la loi et notamment par les Règles pénitentiaires européennes de 1987 et de 2006 qui appellent à rémunérer les détenus pour le travail accompli pendant leur détention.

→ CEDH, 24 juin 1982, *Van Droogenbroeck c. Belgique*, n° 7906/77.

De même, en cas de force majeure (catastrophe naturelle, guerre, calamités ou crises nationales), le travail obligatoire peut dès lors être justifié dans la limite du raisonnable. Il s'agit du seul type d'exploitation de l'individu qui ne connaît pas de caractère absolu.

1.2.3. La traite des êtres humains

L'article 4 de la Convention européenne des droits de l'homme ne mentionne pas directement l'interdiction de la traite des êtres humains, bien qu'il soit utilisé pour réprimer les violations des droits individuels dans ce contexte grâce à une interprétation du but et de l'objet de l'article (à savoir la protection de l'individu contre toutes les formes d'exploitation).

Par ailleurs, la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, ouverte à la signature le 16 mai 2005 et ratifiée par la France le 1er février 2008, sur laquelle s'appuie la Cour, indique que la traite correspond à une dynamique complexe impliquant plusieurs éléments :

- Un acte (recrutement, transport, hébergement, transfert…).
- Un moyen (par la menace, la menace d'utilisation de la force, la force, de fausses promesses, la coercion, l'enlèvement, la fraude, l'abus de la vulnérabilité d'une personne, le paiement fait à un tiers pour obtenir l'autorisation de l'exploitation de la victime sur laquelle ils ont autorité…).
- Un but d'exploitation (la prostitution ou l'exploitation sexuelle, un travail ou service forcé, l'esclavage ou des pratiques analogues, le trafic d'organes…).

Le consentement de la victime à une situation d'exploitation n'est pas pertinent dès lors que celui-ci a été obtenu par les moyens listés ci-dessus (art. 4 de la Convention anti-traite).

→ CEDH, 7 janvier 2010, *Rantsev c. Chypre et Russie*, n° 25965/04.

Le Code pénal français prévoit des conditions de qualification similaires à l'article 225-4-1. L'utilisation des technologies de la communication ou des réseaux sociaux est également reconnue dans la directive 2011/36/UE et rappelée dans la directive 2024/1712 du 13 juin 2024 comme méthode de recrutement ou de prise de contact avec des cibles potentielles.

Ces directives prévoient l'absence de poursuites pour les victimes de traite ayant été contraintes de réaliser des activités illégales.

En outre, le 6e considérant de la directive 2024/1712 indique que dans le cadre de « *l'augmentation constante du nombre et de l'importance des infractions liées à la traite des êtres humains commises à des fins autres que l'exploitation sexuelle ou l'exploitation de main d'œuvre, il convient d'inclure l'exploitation de la gestation pour*

autrui, du mariage forcé ou de l'adoption illégale dans les formes d'exploitation visées dans ladite directive, dans la mesure où les éléments constitutifs de la traite des êtres humains sont réunis, y compris le critère des moyens ».

POUR ALLER PLUS LOIN

Les mineurs sont l'un des groupes les plus vulnérables ciblés par les réseaux de traite des êtres humains nationaux et transnationaux (Directive 2024/1712), dont le recrutement se fait désormais en grande partie via les réseaux sociaux ou dans le cadre de l'exploitation de la vulnérabilité aggravée des migrants mineurs. Un cadre de protection est mis en place pour le respect des droits humains de l'enfant, commençant tout d'abord avec la Convention internationale pour les droits de l'enfant qui dresse une protection générale, et plus précisément les articles 19, 32 et 36 qui protègent respectivement l'enfant contre les mauvais traitements, l'exploitation par le travail ou tout autre type d'exploitation.

Cette protection est complétée par le Protocole de Palerme au niveau international (Protocole additionnel à la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants) ainsi qu'au niveau européen, par la Convention du Conseil de l'Europe sur la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels (Convention de Lanzarote).

Ces conventions forment la clé de voûte de la protection internationale de l'enfant contre l'exploitation.

Au niveau national, le Code du travail encadre très strictement le travail de l'enfant. Dans le Code pénal, la qualité de mineur aggrave la situation d'exploitation (art. 225-15), sexuelle (art. 225-12-1 et suiv.), de la mendicité (art. 225-12-6) ou de la vente à la sauvette (art. 225-12-9), de même que de manière générale, toute situation de traite commise à l'égard d'un mineur (art. 225-4-1 (II)).

2. Un terrain privilégié des obligations positives

L'interdiction de l'esclavage, de la servitude et du travail forcé ne constitue pas seulement une obligation pour l'État de ne pas se prêter à l'exploitation de l'individu, mais implique également la prise de mesures pour empêcher l'établissement de telles situations entre les particuliers, les prévenir et organiser leur répression.

2.1. L'obligation de prévention

La Convention supplémentaire relative à l'abolition de l'esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l'esclavage adoptée le 30 avril 1956 et entrée en vigueur en France le 26 mai 1964 indique dans son article premier l'obligation de mettre en place toutes les mesures *« législatives et autres, qui seront réalisables et nécessaires* […] *»* pour empêcher et prévenir l'exploitation de l'être humain.

La Cour européenne des droits de l'homme a également poussé les États à instituer des cadres législatifs et administratifs appropriés pour lutter contre ces différentes formes d'exploitation.

→ CEDH, 13 novembre 2012, *C.N. c. Royaume-Uni*, n° 4239/08.

C'est à ce titre que la France a été condamnée en 2005 ainsi qu'en 2012 du fait des lacunes de son système pénal sur l'inadéquation des critères pour la qualification de la servitude dont le défaut de criminalisation et la répression effective ont été pointés.

→ CEDH, 26 octobre 2005, *Siliadin c. France*, n° 73316/01.

→ CEDH, 11 octobre 2012, *C.N. et V. c. France*, n° 67724/09.

Dans le cas particulier de la traite et de sa dynamique complexe, le Protocole de Palerme et la Convention anti-traite du Conseil de l'Europe imposent d'adopter une « approche globale » sous forme de triptyque en adoptant des mesures visant à réprimer les trafiquants (ou toute aide ou tolérance à celle-ci), à prévenir la mise en place de ce trafic et en prévoyant des mesures de protection pour la victime.

De manière générale, cette prévention s'appuie également sur des systèmes plus égalitaires, la majorité des victimes d'exploitation étant des femmes en situation de vulnérabilité et des enfants. Dans ce cadre, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes de 1979 et la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique de 2011 apportent également un éclairage nécessaire sur les mesures particulières que les États doivent prendre pour la protection des victimes.

2.2. Les mesures opérationnelles

Lorsqu'il existe des motifs raisonnables permettant de conclure à une situation d'exploitation, les autorités nationales doivent mettre en place toutes les mesures nécessaires et concrètes pour protéger la victime potentielle ou avérée en la retirant d'une situation dans laquelle elle subissait ou risquait de subir une exploitation. Il existe alors une obligation d'agir pour les autorités dès lors qu'elles savaient ou auraient dû savoir qu'il existait un danger réel et immédiat d'exploitation.

Cela implique la mobilisation de nombreux acteurs à savoir les forces de l'ordre, les magistrats, les services sociaux (art. 12 de la Convention anti-traite du Conseil de l'Europe) devant se coordonner pour offrir une protection complète à la victime et une assistance adéquate. En revanche, cette obligation de prendre des mesures nécessaires et concrètes ne doit pas imposer aux autorités un fardeau insupportable ou excessif.

→ CEDH, 7 janvier 2010, *Rantsev c. Chypre et Russie*, n° 25965/04.

→ CEDH, 30 mars 2017, *Chowdury et a. c. Grèce*, n° 21884/15.

La Convention anti-traite mobilise des obligations supplémentaires pratiques tournées vers la protection de la victime comme une période de réflexion de 30 jours pour la victime lui permettant de décider de son implication ou non dans les poursuites contre l'auteur de l'exploitation, l'obligation de la délivrance d'un visa, l'assistance d'un traducteur, etc. Ces mesures sont analysées à la lumière des circonstances de l'espèce.

2.3. L'obligation d'enquêter

Comme l'exige toute atteinte grave à la dignité de l'individu, la découverte d'une situation d'exploitation implique pour les autorités de diligenter une enquête impartiale et indépendante devant mener à l'identification de l'auteur de l'exploitation ou du réseau de traite et sa traduction en justice. Il s'agit d'une obligation de moyen et non de résultat, valable aussi bien concernant des agents de l'État que des particuliers. Cette obligation n'est pas subordonnée à l'existence d'une plainte de la victime, les autorités devant agir *propio motu* dès que des éléments pouvant indiquer l'existence d'une exploitation leur ont été transmis.

Il existe de plus une exigence de célérité et de diligence raisonnable à apprécier en fonction des circonstances de la cause ainsi que d'une coopération interne des différentes autorités pertinentes. Dans le cas de la traite, il existe également une obligation de coopération internationale (art. 32 de la Convention anti-traite du Conseil de l'Europe, mentionnée également à l'article 5 du Protocole de 2014 relatif à la Convention sur le travail forcé de 1930) dans les cas de réseaux transnationaux.

2.4. L'obligation de réparer

Les victimes d'exploitation ont un droit à réparation pour le préjudice moral et économique subi, reconnu à la fois au niveau national et européen (Convention anti-traite, art. 15 ; Protocole de 2014 relatif la Convention sur le travail forcé de 1930, ratifié par la France le 7 juin 2016, art. 4), ainsi qu'un droit à la réinsertion et réadaptation sociale avec le soutien des services compétents (Protocole de 2014, art. 1).

POUR S'ENTRAÎNER

Commentaire d'arrêt : CEDH, V.*C.L. et A.N. c. Royaume-Uni*, 2021, [extraits] :

« […] *175. La police a découvert le* […] *requérant le 21 avril 2009 à proximité d'une fabrique de cannabis* […]. *L'intéressé ayant initialement indiqué qu'il était né en 1972, ce qui lui aurait donné trente-sept ans, il a été traité comme un adulte* […]. *Eu égard au fait qu'il avait en réalité dix-sept ans, il est difficile de dire dans quelle mesure il était réellement crédible qu'il eût trente-sept ans, mais en toute hypothèse, à supposer que la police n'eût aucune raison de douter qu'il fût un adulte, le récit qu'il a livré lorsqu'elle l'a interrogé pour la première fois aurait dû éveiller des soupçons. En particulier, il a déclaré que la porte était verrouillée de l'extérieur et qu'il pensait que la fabrique était gardée, qu'il n'était pas payé pour son travail, et qu'il risquait d'être tué s'il arrêtait de travailler* […]. *Pourtant, il n'a pas été fait de signalement à une Autorité compétente* [concernant la traite des êtres humains]. *Au contraire, le jeune homme a été accusé de participation à la production d'une substance contrôlée de classe B* […].

176. Le 30 avril 2009, lors d'une audience tenue devant la Magistrates' Court*, le* […] *requérant a déclaré être né en 1992. À partir de ce moment, il a été admis qu'il avait dix-sept ans* […]. *Eu égard à ce que l'on savait de la situation des jeunes vietnamiens travaillant comme jardiniers dans des fabriques de cannabis* […]*, la Cour considère qu'à cette date au plus tard, le CPS* [Crown Prosecution Service] *aurait dû prendre conscience de l'existence de circonstances donnant raisonnablement à penser que le deuxième requérant avait fait l'objet de traite* […]. *Or, alors que le CPS a réexaminé le dossier le 1er juin 2009, et conclu que l'intéressé était entré au Royaume-Uni dans le cadre d'un trafic illicite* […].

177. Entre-temps, le […] *requérant avait plaidé coupable de l'infraction dont il était accusé* […]. *Bien qu'il eût aussi informé son avocat qu'il avait été enfermé dans la fabrique et menacé d'être tué s'il en partait, l'avocat avait estimé que la défense de contrainte n'était pas susceptible d'être retenue, car l'intéressé avait eu l'occasion de s'enfuir et ne l'avait pas saisie – l'Autorité compétente a par la suite considéré que cela pouvait s'expliquer par le fait que le jeune homme se trouvait dans une situation de dépendance et de vulnérabilité.* […].

179. Lorsqu'elle a rejeté l'appel du […] *requérant, la Cour d'appel a dit que les critiques formulées à l'égard de la procédure qui avait abouti à la condamnation de l'intéressé ne tenaient pas compte du fait que les récits qu'il avait lui-même faits donnaient à penser qu'il avait été introduit au Royaume-Uni dans le cadre d'un trafic illicite. Elle a conclu en conséquence que ni la Crown Court, ni le CPS, ni la défense ne disposaient d'éléments permettant de soupçonner qu'il eût été amené au Royaume-Uni dans le cadre de la traite* […].

180. Avec tout le respect qu'elle doit à la Cour d'appel, la Cour juge cette conclusion difficilement conciliable avec les directives publiées par le CPS lui-même en février 2009, où il était indiqué que les enfants soumis à la traite pouvaient être réticents à révéler les circonstances dans lesquelles ils avaient été exploités et qu'en conséquence les procureurs devaient être eux-mêmes attentifs à cette possibilité […]. *La Cour d'appel elle-même a formulé des directives semblables dans l'arrêt qu'elle a rendu dans l'affaire R v. O, où elle a dit clairement que les procureurs devaient connaître les protocoles et que les avocats de la défense devaient mener des investigations lorsqu'il existait des éléments crédibles montrant que leur client avait peut-être été victime de traite* […]. *La conclusion de la Cour d'appel est difficilement conciliable également avec les constats de la NSPCC NCTAIL et de l'Autorité compétente, qui ont conclu l'une et l'autre que le deuxième requérant avait bien été amené au Royaume-Uni dans le cadre de la traite* […].

181. À cet égard, la Cour a déjà dit que, dès le moment où l'on avait découvert le […] *requérant, certains aspects du récit de l'intéressé auraient dû faire soupçonner qu'il s'agissait peut-être d'une victime de traite* […]. *Ces soupçons n'auraient dû que se faire plus présents lorsqu'il est apparu qu'il était mineur* […]. *À partir de ce moment, l'État avait l'obligation positive de prendre des mesures opérationnelles pour le protéger. Au lieu de cela, la procédure pénale a pu suivre son cours, et le deuxième requérant a plaidé coupable sur les conseils de son représentant. Alors que la NSPCC NCTAIL et l'Autorité compétente lui avaient par la suite toutes deux reconnu la qualité de victime de la traite, le CPS a rejeté cette appréciation sans justifier clairement sa décision, qui touchait au cœur des éléments nécessaires pour établir l'existence de la « traite », et la Cour d'appel, s'appuyant sur les mêmes motifs, a conclu que la décision de poursuivre ne constituait pas un abus de procédure.*

182. À la lumière de ce qui précède, la Cour considère que l'on ne peut pas dire que l'État se soit acquitté de l'obligation qui lui incombait au titre de l'article 4 de la Convention de prendre des mesures opérationnelles pour protéger le […] *requérant, que ce soit au début, lorsqu'il devait être considéré comme une victime de traite potentielle, ou par la suite, après que l'Autorité compétente eut reconnu qu'il était effectivement une victime de traite.*

183. Partant, elle conclut qu'il y a eu violation de l'article 4 de la Convention à l'égard du […] *requérant* […]. *»*

Le requérant mineur étranger a été arrêté le 21 avril 2009 à proximité d'une exploitation de cannabis au Royaume-Uni, après avoir été introduit sur le territoire depuis le Vietnam. Il a été accusé de production d'une substance illicite malgré le fait qu'il ait été reconnu comme une victime de traite des êtres humains.

La possibilité que le requérant ait été une victime de traite des êtres humains a été portée à la connaissance des services de l'État pendant la procédure préliminaire. Malgré cela, le requérant a été condamné en première instance et ses appels rejetés sur le fondement qu'il avait participé à des activités illégales. Les demandes d'autorisation de saisie de la Cour suprême ont été rejetées. Le requérant a saisi la Cour européenne des droits de l'homme qui a rendu son arrêt le 10 janvier 2021.

Le requérant indique ne pas avoir été correctement identifié comme victime de traite et de ne pas avoir été protégé en conséquence par l'État défendeur, ayant ainsi failli au respect de ses obligations positives émanant de l'article 4 de la Convention européenne.

La Cour condamne l'État défendeur pour manquement aux obligations émanant de l'article 4 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Problématique et annonce du plan : La Cour européenne des droits de l'homme se penche sur le manquement de l'État concernant les obligations positives de protection de l'individu, se faisant, elle réaffirme les principes de protection classique dans le cadre de la traite **(I)** tout en limitant la marge de manœuvre de l'État pour la protection de cette liberté fondamentale **(II)**.

I. La réaffirmation du cadre protecteur relatif à la traite

A. Un cadre protecteur étendue

La Cour européenne analyse les faits sous l'angle de l'article 4 de la Convention :

L'article 4 possède une structure qui ne mentionne pas la protection contre la traite des êtres humains :

- Cela résulte d'une interprétation à l'aune du but et de l'objet de l'article 4 : protection contre l'exploitation, protection de la dignité inhérente à l'être humain (CEDH [GC], 25 juin 2020, *S.M. c. Croatie*, n° 60561/14)
- Il faut par ailleurs noter une incompétence *Ratione Materiae* de la Cour pour juger les violations des autres conventions

L'utilisation des critères de qualification de la traite fait cependant écho à :

- La convention anti-traite du Conseil de l'Europe en son article 4 : la traite est caractérisée par un acte, un moyen, un but, ici le transport sur le territoire britannique, dans un but d'exploitation.
- Le cas des enfants : la Convention anti-traite du Conseil de l'Europe, Article 4, c) et le Protocole de Palerme ne considèrent pas le critère du « moyen » pertinent dans le cas de l'enfant. Il est remplacé par la « situation de dépendance et de vulnérabilité » inhérente du mineur.

La Cour fait donc une analyse extensive de la notion d'exploitation, et en harmonie avec le droit international.

B. L'existence d'obligations de protection de la victime

Les éléments à la disposition des autorités étaient suffisamment crédibles pour s'engager dans le processus de protection des potentielles victimes de traite.

Les obligations positives émanant de la Convention européenne des droits de l'homme imposent l'obligation de prendre des « mesures opérationnelles » (CEDH, 7 janvier 2010, *Rantsev c. Chypre et Russie*, n° 25965/04) :

- Il y avait des motifs raisonnables de croire que le requérant était une victime avérée ou potentielle de traite (CEDH, 13 novembre 2012, *C.N. c. Royaume-Uni*, n° 4239/08).
- Les faits sont venus à la connaissance des autorités (CEDH, 29 novembre 2011, *V.F. c. France (déc.)*, n° 7196/10).
- La minorité est un élément nécessitant l'adaptation des mesures particulières (CEDH, 1er avril 2021, *A.I. c. Italie*, n° 70896/17 sur l'adaptation des mesures à prendre en fonction des situations).

Le consentement de la victime à l'exploitation n'est pas considéré comme pertinent, en particulier pour les mineurs (CEDH, 20 mars 2017, *Chowdury et a. c. Grèce*, n° 21884/15).

II. La recherche d'un équilibre entre l'action de l'État et la protection de l'individu

A. La criminalisation de la victime de traite

La Cour ne condamne pas l'État sur la base de la criminalisation des victimes de traite, mais sur le non-respect du devoir d'assistance aux victimes :

- L'obligation d'assistance aux victimes possède différentes sources : CEDH,7 janvier 2010, *Rantsev c. Chypre et Russie*, n° 25965/04 ; article 12 de la Convention anti-traite du Conseil de l'Europe.
- Cependant, il existe dans cet arrêt une confrontation entre le respect du devoir d'assistance et la possibilité pour l'État de criminaliser certains comportements.

La marge d'appréciation étatique est réduite considérablement, favorisant un standard de protection élevé pour les mineurs victimes de traite.

Cet arrêt va également dans le sens d'un consensus européen :

- Pour les États membres de l'Union européenne, de la directive 2011/36/EU du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011, réaffirmée par la directive 2024/1712, qui indique dans son article 8 : *« Les États membres prennent, dans le respect des principes fondamentaux de leur système juridique, les mesures nécessaires pour veiller à ce que les autorités nationales compétentes aient le pouvoir de ne pas poursuivre les victimes de la traite des êtres humains et de ne pas leur infliger de sanctions pour avoir pris part à des activités criminelles ou à d'autres activités illicites auxquelles elles ont été contraintes en conséquence directe du fait d'avoir fait l'objet de l'un des actes visés à l'article 2. »*
- En droit international, l'article 26 de la Convention anti-traite du Conseil de l'Europe rejoint cette idée.

B. La critique du refus de coopération entre les organes compétents

La Cour européenne condamne le défaut de coopération des organes internes pour la prise en compte et le traitement des victimes de traite.

Les obligations d'enquête sont remplies, mais c'est la cohérence interne des éléments qui est remise en cause par la juridiction :

- Toutes les circonstances pertinentes n'ont pas été prises en compte : cette obligation peut être tirée du raisonnement de l'arrêt CEDH, *Siliadin c. France*, 26 octobre, n° 73316/01. Ici, il ne s'agissait aucunement d'imposer « un fardeau disproportionné » aux autorités (CEDH,

23 novembre 2011, *G.S. c. Royaume-Uni*, n° 7604/19), mais simplement de prendre en compte les analyses des organes spécialisés, ou de motiver le refus.

- Les obligations d'enquête impliquent une coopération des organisations au niveau national, qui trouve son origine dans l'arrêt CEDH, 20 mars 2017, *Chowdury et a. c. Grèce*, n° 21884/15, mais aussi dans la Convention anti-traite : l'article 10 impose une obligation de formation de corps spécialisés dans la reconnaissance des victimes de traite : cette coopération des instances nationales, en plus de protéger la victime, doit avoir comme but de dissuader la violation des droits de l'individu. La Convention de Lanzarote implique une obligation similaire à l'article 10.
- C'est une obligation qui est également mise en avant par le GRETA.
- La recherche de l'effectivité de la protection (CEDH, *Siliadin c. France*, 26 octobre, n° 73316/01) est un but qui est toujours mis en avant par la CEDH, mais qui, ici, se retrouve de manière plus implicite dans le raisonnement. La condamnation dans cet arrêt est donc avant tout dirigée vers une défaillance du système judiciaire.

En conclusion, cet arrêt illustre les efforts d'harmonisation des obligations internationales et européennes de protection des mineurs contre la traitre.

Fiche nº 30 - LE DROIT À LA LIBERTÉ ET À LA SÛRETÉ

POINTS CLÉS

- Habeas corpus.
- Légalité de l'enfermement.
- Droit au recours effectif.
- Garde à vue.
- Détention provisoire.
- Rétention de sûreté.
- Rétention douanière.
- Zone d'attente.
- Centre de rétention administrative.
- Hospitalisation psychiatrique sans consentement.
- Cellule de dégrisement.

PRINCIPALES RÉFÉRENCES

- Article 66 de la Constitution.
- Articles 2, 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
- Article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme.
- Cons. const., décision nº 92-307 DC, 25 février 1992, *Loi portant modification de l'ordonnance nº 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France.*
- Cons. const., décision nº 2012-253 QPC, 8 juin 2012, *Mickaël D [Ivresse publique].*
- Cons. const., décision nº 2023-1064 QPC, 6 octobre 2023, *Association des avocats pénalistes.*
- CEDH, 26 avril 2007, *Gebremedhin c. France*, nº 25389/05.
- Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes.
- CE, 16 juillet 2012, *Centre hospitalier spécialisé Guillaume Régnier*, nº 360793.

1. Le droit à la liberté individuelle et à la sûreté : le droit de ne pas être enfermé arbitrairement

Sous l'Ancien Régime, des lettres de cachets du roi permettaient l'enfermement arbitraire de personnes. Cette pratique faisait l'objet de vives critiques par les philosophes des Lumières.

L'Habeas corpus vient du latin *habeas corpus ad subjiciendum*, qui signifie « que tu aies ton corps pour le présenter (devant le tribunal) ».

Né au XVIIe siècle en droit anglais, *l'Habeas corpus* a pour objet de protéger la liberté individuelle, en protégeant les personnes contre les décisions d'enfermement arbitraires de la puissance publique au moyen d'une demande adressée au juge pour examiner la légalité de l'enfermement.

Rattachée au droit à la sûreté, elle ne doit pas être confondue avec le droit à la sécurité, dont les tenants ne sont pas les mêmes.

1.1. La reconnaissance constitutionnelle

L'article 66 de la Constitution prévoit que *« nul ne peut être arbitrairement détenu »* et que l'autorité judiciaire est la gardienne de la liberté individuelle. De plus, l'article 2 de la Déclaration de 1789 prévoit que la sûreté fait partie des *« droits naturels et imprescriptibles de l'homme »*.

L'article 7 de la Déclaration de 1789 prévoit que :

> *« Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi, et selon les formes qu'elle a prescrites. »*

Son article 4 prévoit que :

> *« La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. »*

À plusieurs reprises, le Conseil constitutionnel a affirmé que les atteintes portées à la liberté individuelle doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées.

1.2. La reconnaissance conventionnelle

Sa reconnaissance conventionnelle se trouve à l'article 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, à l'article 6 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi qu'à l'article 5 de la Convention européenne dont la longueur témoigne de l'importance particulière de ce droit. L'article 5 de la Convention européenne consacre plusieurs garanties relatives au droit à la liberté et à la sûreté et prévoit une liste de motifs qui justifient des restrictions à la liberté qui, selon la Cour européenne des droits de l'homme, revêt un caractère exhaustif, une interprétation étroite doit en être faite.

→ CEDH, 22 mars 1995, *Quinn c. France*, n° 18580/91.

2. Le contrôle de la légalité de l'enfermement

La liberté individuelle et le droit à la sûreté impliquent un contrôle de la légalité de l'enfermement, il en découle nécessairement un droit à un recours juridictionnel effectif, dont les modalités procédurales diffèrent en fonction du type de privation de liberté. La France a été condamnée pour sa conception selon laquelle cette protection revient concomitamment aux magistrats du siège et aux magistrats du parquet, à l'aune du statut du parquet qui est placé sous l'autorité du garde des Sceaux.

→ CEDH, 23 novembre 2010, *Moulin c. France*, n° 37104/06.

Ainsi, en 2010, la Cour de cassation a affirmé que :

> *« C'est à tort que la chambre de l'instruction a retenu que le ministère public est une autorité judiciaire au sens de l'article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, alors qu'il ne présente pas les garanties d'indépendance et d'impartialité requises par ce texte et qu'il est partie poursuivante »* (Cass. crim., 15 décembre 2010, n° 10-83.674).

Enfin, l'article 432-4 du Code pénal prévoit des sanctions pour les cas où une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ordonne ou accomplit un acte attentatoire à la liberté individuelle. Ces sanctions peuvent aller jusqu'à sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amendes, des peines qui sont plus lourdes lorsque la privation de liberté arbitraire excède une durée de sept jours.

La privation de liberté peut résulter d'une mesure visant la répression pénale ainsi que d'une mesure administrative.

3. La garde à vue

L'article 62-2 du Code de procédure pénale définit la garde à vue :

> *« La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs. »*

Ce même article dresse une liste des objectifs auxquels doit répondre cette mesure de contrainte.

S'agissant de la durée de cette mesure, l'article 63 du Code de procédure pénale prévoit que la garde à vue ne peut excéder vingt-quatre heures, en précisant qu'elle peut être prolongée. Des durées dérogatoires liées à la recherche d'auteurs de certains crimes et délits sont prévues par ce même code.

Cette mesure est prise sous le contrôle du procureur de la République qui peut la prolonger. L'article 706-88 prévoit que pour deux prolongations supplémentaires de vingt-quatre heures, elles peuvent être autorisées :

> *« Par décision écrite et motivée, soit, à la requête du procureur de la République, par le juge des libertés et de la détention, soit par le juge d'instruction. »*

Ce même article dispose qu'en cas d'investigations supplémentaires, la prolongation supplémentaire est décidée par le juge des libertés et de la détention ou par le juge d'instruction.

La personne gardée à vue doit être informée de ses droits (exemple : droit d'être examinée par un médecin, droit d'être assistée par un avocat, droit d'être assistée par un interprète si besoin, droit de se taire…) listés à l'article 63-1 du Code de procédure pénale.

Une décision particulièrement marquante relative à la garde à vue rendue par le Conseil constitutionnel en 2023 doit être retenue.

Sur le fondement du respect de la dignité humaine, consacré à l'alinéa premier du préambule de 1946, le Conseil constitutionnel a affirmé qu'il appartient aux autorités judiciaires de veiller à ce que les locaux de garde à vue soient aménagés et entretenus.

Ainsi, en vertu de l'article 62-3 du Code de procédure pénale, le magistrat compétent doit s'assurer de sa sauvegarde et donc prendre des mesures pour mettre fin aux conditions indignes de garde à vue ou, si cela n'est pas possible, ordonner la mise en liberté de la personne gardée à vue. Si une personne a été gardée à vue dans des conditions indignes, elle peut engager la responsabilité de l'État.

> → Cons. const., déc. n° 2023-1064 QPC, 6 octobre 2023, *Association des avocats pénalistes.*

4. La détention provisoire

La détention provisoire consiste à priver une personne de liberté dans l'attente de son jugement, soit incarcérer une personne présumée innocente. Le Code de procédure pénale prévoit en son article 137 que si les obligations du contrôle judiciaire ou l'assignation à résidence ne sont pas suffisantes, une personne peut être placée en détention provisoire.

L'article 143-1 prévoit que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que si une personne encourt une peine criminelle ou si une personne encourt une peine correctionnelle égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement.

L'article 144 explicite les cas qui justifient qu'une personne puisse être placée en détention provisoire (exemples : conserver les preuves, protéger la personne mise en examen, garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice, mettre fin à l'infraction ou prévenir de son renouvellement…).

Le juge des libertés et de la détention est compétent pour prononcer le placement en détention provisoire d'une personne.

> → Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes.

La détention provisoire en matière correctionnelle peut durer quatre mois, avec prolongations possibles, en matière criminelle la détention provisoire peut durer un an, avec prolongations possibles. Durant la période de sa détention provisoire, une demande de mise en liberté peut être demandée (art. 148-1).

POUR ALLER PLUS LOIN

Lors de la crise sanitaire, une ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 prévoyait la prolongation de plein droit des détentions provisoires pour une durée de deux à six mois. Le 26 mai 2020, la Cour de cassation a jugé que ces dispositions étaient contraires à l'article 5 de la Convention européenne. Le 29 janvier 2021, le Conseil constitutionnel a affirmé le caractère inconstitutionnel de ces dispositions à l'aune de l'article 66 de la Constitution.

5. La rétention de sûreté

Issue d'une loi de 2008, la rétention de sûreté vise à maintenir enfermée une personne dans un centre socio-médico-judiciaire, prévue à l'article 706-53-13 du Code de procédure pénale.

> → Loi n° 2008-174 du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.

Il s'agit d'une mesure administrative qui peut concerner les personnes condamnées à une peine de réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans, pour certains crimes, à l'issue de leur peine d'incarcération :

> *« Pour les crimes, commis sur une victime mineure, d'assassinat ou de meurtre, de torture ou actes de barbarie, de viol, d'enlèvement ou de séquestration. »*

L'article précité expose que des personnes peuvent être placées en rétention de sûreté lorsque :

> *« Elles présentent une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive parce qu'elles souffrent d'un trouble grave de la personnalité. »*

Le placement en rétention de sûreté n'est possible que si la décision de condamnation de la cour d'assises le prévoit. La dangerosité d'une personne est évaluée par une commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté et la décision de placement en rétention de sûreté est prise par la juridiction régionale de la rétention de sûreté.

Le Conseil constitutionnel a affirmé que la rétention de sûreté n'est ni une peine ni une sanction ayant le caractère d'une punition.

> → Cons. const., déc. n° 2008-562 DC, 21 février 2008, *Loi relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.*

Le Code pénitentiaire reconnaît des droits à la personne retenue dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté (art. R 541-11 à R 542-13) : droit au recours, droit de suivre des actions d'éducation et de formation, droit de pratiquer une activité religieuse, droit de correspondance avec les personnes de son choix, droit de visite, notamment.

Actualité. - La création d'une rétention de sûreté terroriste

La loi du 27 juillet 2026 a institué une rétention de sûreté terroriste, susceptible d'être prononcée, à l'issue de leur peine, à l'encontre de certaines personnes condamnées à au moins quinze ans de réclusion pour un crime terroriste et présentant une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive, une adhésion persistante à une idéologie incitant au terrorisme et un trouble grave de la personnalité. La mesure ne peut être prononcée qu'à titre exceptionnel et lorsqu'elle constitue l'unique moyen de prévenir la commission d'un nouveau crime terroriste.

Le Conseil constitutionnel a validé ce dispositif au regard de l'article 66 de la Constitution, compte tenu notamment du contrôle juridictionnel et de l'évaluation régulière de la dangerosité de la personne. Il formule toutefois une réserve importante : eu égard au caractère privatif de liberté de la mesure et à son renouvellement

possible sans limitation prédéterminée, celle-ci ne peut s'appliquer rétroactivement à des personnes condamnées pour des faits antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi (Cons. const., déc. n° 2026-906 DC, 23 juillet 2026).

→ Loi n° 2026-667 du 27 juillet 2026 visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat.

6. La rétention douanière

L'article 323-1 du Code des douanes prévoit la possibilité de placer une personne en rétention douanière :

> *« Qu'en cas de flagrant délit douanier puni d'une peine d'emprisonnement et lorsque cette mesure est justifiée par les nécessités de l'enquête douanière. »*

L'article suivant précise que cette retenue ne peut pas durer plus de vingt-quatre heures, mais une prolongation de vingt-quatre heures est possible sur autorisation du procureur de la République.

Le procureur de la République est chargé de contrôler que les droits de la personne retenue sont assurés au cours de sa rétention douanière.

La personne retenue dispose de droits, tels que celui d'être examinée par un médecin, le droit à l'assistance d'un avocat, notamment. En outre, l'article 323-6 prévoit des garanties accordées à la personne retenue.

7. Le maintien en zone d'attente

La loi du 6 juillet 1992 institue les zones d'attente. Ces zones sont situées dans les aéroports, les ports et les gares ferroviaires et permettent la privation de liberté de personnes étrangères qui n'ont pas reçu de titre de séjour avant leur entrée sur le territoire français et sont prévues par le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (art. L 342-1 à L 342-19).

Le juge administratif est compétent pour statuer sur les requêtes dirigées contre les décisions de refus d'entrée sur le territoire, de placement en zone d'attente, de refoulement.

Le Conseil constitutionnel a rendu en 1992 une décision par laquelle il affirme que le maintien en zone d'attente affecte la liberté individuelle au sens de l'article 66 de la Constitution et que le législateur doit prévoir l'intervention du juge judiciaire.

> → Cons. const., déc. n° 92-307 DC, 25 février 1992, *Loi portant modification de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France.*

L'article L. 342-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit explicitement qu'au-delà de quatre jours, le maintien pour une durée jusqu'à huit jours doit être autorisé par un magistrat du siège ; le juge des libertés et de la détention. Ce même Code prévoit des prolongations exceptionnelles dans des conditions spécifiques (art. L. 342-4).

En vertu de l'article L. 342-5, saisi d'une requête, le magistrat doit statuer dans un délai de vingt-quatre heures ou quarante-huit en cas de nécessités de l'instruction ou :

> *« En cas de placement en zone d'attente simultané d'un nombre important d'étrangers au regard des contraintes du service juridictionnel. »*

Les ordonnances rendues en la matière peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel, et l'appel n'est en principe pas suspensif, mais peut exceptionnellement l'être (art. L. 342-13).

En 2007, la France a été condamnée pour violation combinée de l'article 13 relatif au recours effectif et de l'article 5 de la Convention.

Le recours d'une personne qui demandait l'asile, placée dans une zone d'attente, contre une décision de refus d'accès au territoire français et qui ordonnait son éloignement, n'était pas suspensif ; l'absence d'effet suspensif de plein droit peut faire peser un risque de torture ou de mauvais traitement dans la mesure où cette personne invoquait des persécutions en cas de retour dans son pays d'origine.

> → CEDH, 26 avril 2007, *Gebremedhin c. France*, n° 25389/05.

POUR ALLER PLUS LOIN

En 2025, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté a rendu un rapport de sa deuxième visite de la zone d'attente de l'aéroport de Toulouse-Blagnac de février 2024. Le rapport fait état de plusieurs lacunes en termes de respect des droits humains, tels que l'inaccessibilité aux personnes à mobilité réduite, le défaut de traçabilité des fouilles et des palpations, l'absence d'inventaire des effets des personnes retenues, ainsi que l'absence de confidentialité systématique des soins, notamment.

8. Le placement en centre de rétention administrative

Le placement d'une personne en rétention administrative constitue une privation de liberté qui vise à mettre en œuvre des décisions d'éloignement de personnes étrangères, si ces personnes n'ont pas exécutées elles-mêmes des décisions dans les délais donnés. L'existence légale de la rétention administrative a été instituée par la loi du 29 octobre 1981.

L'article L. 700-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dresse la liste des actes dont la rétention administrative a vocation à mettre en œuvre (*obligation de quitter le territoire français, interdiction de retour sur le territoire français, remises aux autorités d'un autre Etat, décision d'expulsion, peine d'interdiction du territoire français, notamment*).

Le placement en centre de rétention administrative ne doit être prononcé que si l'assignation à résidence n'apparaît pas adaptée à la situation.

L'article L. 741-4 de ce même code relève que le placement en rétention :

> *« Prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »*

La durée d'un placement en centre de rétention administrative est en principe de 48 heures. La prolongation de la durée du placement en centre de rétention administrative fait l'objet d'un contrôle par le juge des libertés et de la détention pour une durée de 28 jours.

Au-delà de 28 jours, le juge des libertés et de la détention peut prononcer plusieurs maintiens en centre de rétention administrative dans la limite totale de 90 jours.

Tout comme pour les personnes placées en zone d'attente, des difficultés dans l'exercice des droits procéduraux peuvent être rencontrées, ainsi dans les deux cas, les personnes étrangères concernées doivent pouvoir disposer de l'assistance d'un interprète ainsi que d'un conseil.

Actualité. - Jusqu'où peut aller la rétention administrative ?

La rétention administrative a connu une évolution majeure en 2026. La loi du 27 juillet 2026 permet désormais, sous certaines conditions, de réitérer plusieurs placements en rétention pour l'exécution d'une même mesure d'éloignement. Un étranger peut ainsi faire l'objet de cinq placements successifs au maximum, pour une durée cumulée qui ne peut en principe excéder 360 jours, portée exceptionnellement à 540 jours pour certaines personnes représentant les menaces les plus graves pour l'ordre public.

Saisi de cette réforme, le Conseil constitutionnel l'a jugée conforme à l'article 66 de la Constitution. Il relève notamment que chaque nouveau placement doit être spécialement motivé, qu'il suppose une menace persistante pour l'ordre public, une soustraction aux mesures de surveillance ou des circonstances nouvelles et qu'une perspective raisonnable d'éloignement doit toujours subsister. Surtout, le magistrat du siège doit contrôler, en tenant compte des périodes de rétention antérieures, que la privation de liberté « *n'excède pas la rigueur nécessaire* » (Cons. const., déc. n° 2026-906 DC, 23 juillet 2026).

→ Loi n° 2026-667 du 27 juillet 2026 visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat.

À retenir : La décision illustre directement la fonction de l'article 66 de la Constitution : même lorsqu'il admet un régime particulièrement restrictif de liberté, le Conseil constitutionnel exige que toute privation de liberté demeure nécessaire, proportionnée et placée sous le contrôle effectif du juge judiciaire.

9. L'hospitalisation psychiatrique sans consentement

Le plus souvent, l'hospitalisation en psychiatrie se déroule à la demande de la personne concernée. Il existe des situations pour lesquelles des personnes sont hospitalisées sans leur consentement, ce qui constitue dès lors une privation de liberté.

Cette hospitalisation peut être décidée d'office, à la demande d'un tiers ou résulter d'un péril imminent pour la santé de la personne.

De surcroît, l'hospitalisation en psychiatrie peut avoir lieu à la suite d'une intervention judiciaire sur le fondement du Code de procédure pénale : en cas de déclaration d'irresponsabilité pénale qui mène au prononcé juridictionnel d'une admission en soins psychiatriques ou lorsque l'état de santé mentale d'une personne incarcérée ne permet pas son maintien en détention et qu'elle doit faire l'objet d'un internement.

Le Conseil d'État a affirmé dans une décision de 2012 que les décisions prises par les médecins lors d'une telle hospitalisation relèvent de la compétence du juge judiciaire puisqu'elles *« participent à la prise en charge de patients faisant l'objet d'une mesure d'admission en soins psychiatriques sans leur consentement »*.

→ CE, 16 juillet 2012, *Centre hospitalier spécialisé Guillaume Régnier*, n° 360793.

L'hospitalisation sans consentement implique l'intervention du contrôle du juge judiciaire s'agissant des demandes de sortie, sa prolongation au-delà de douze jours nécessite également l'intervention du juge des libertés et de la détention.

S'agissant des mesures d'isolement et de contention, qui accentue la privation de liberté, l'article L. 3222-5-1 du Code de santé publique détaille les modalités dans lesquelles elles peuvent avoir lieu ainsi que le contrôle opéré sur ces mesures.

Le Code de santé publique liste à l'article L. 3211-3 un ensemble de droits qui lui sont reconnus (exemples : conseil d'un médecin ou d'un avocat de son choix, émettre et recevoir des courriers, exercice du droit de vote, pratique d'activités religieuses ou philosophiques choisies par le patient).

Actualité. - Une injonction d'examen psychiatrique à finalité antiterroriste

La loi du 27 juillet 2026 précitée institue également une procédure permettant au préfet d'ordonner, sous certaines conditions, à une personne de se soumettre à un examen psychiatrique lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace grave pour l'ordre et la sécurité publics en lien avec une adhésion à des théories incitant ou faisant l'apologie du terrorisme et des agissements susceptibles d'être liés à des troubles mentaux (article 1er de la loi, codifié à l'art. L. 229-7 du code de la sécurité intérieure).

Le Conseil constitutionnel considère que cette injonction porte atteinte à la liberté personnelle, notamment parce qu'elle déroge au principe de libre consentement aux soins, mais la valide au regard des garanties instituées et des objectifs de prévention des atteintes à l'ordre public et de protection de la santé. Si la personne refuse de se soumettre à l'examen, le recours à la force publique et la visite de son domicile sont soumis à l'autorisation d'un magistrat du siège. Surtout, la contrainte ne saurait excéder douze heures, sous peine de devenir une véritable privation de liberté relevant de l'article 66 de la Constitution (Cons. const., déc. n° 2026-906 DC, 23 juillet 2026).

10. Le placement en cellule de dégrisement

Le Code de la santé publique prévoit la possibilité, pour des forces de l'ordre, de placer une personne en état d'ivresse dans les lieux publics dans un local de police nationale ou de gendarmerie jusqu'à ce que la personne concernée « ait retrouvé la raison » (art. L. 3341-1). Ainsi, ce placement peut durer plusieurs heures.

Selon l'article R 3353-1 de ce même code, l'état d'ivresse manifeste dans les lieux publics est sanctionné d'une amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.

Si la personne concernée doit faire par la suite l'objet d'une garde à vue, ses droits lui seront notifiés quand celle-ci sera en état de les comprendre.

La Cour européenne des droits de l'homme a affirmé que le placement en dégrisement constitue une privation de liberté au sens de l'article 5 § 1 de la Convention européenne.

→ CEDH, 4 avril 2000, *Witol Litwa contre Pologne*, n° 26629/95.

Une faute commise par un agent de police ou de gendarmerie dans le placement d'une personne en cellule de dégrisement peut engager la responsabilité de la puissance publique devant le tribunal administratif puisqu'il s'agit d'une opération de police administrative.

→ T. confl., 18 juin 2007, n° C3620.

POUR ALLER PLUS LOIN

Par un arrêt du 31 décembre 2024, le Conseil d'État a reconnu la responsabilité de l'État pour faute de service des services de la gendarmerie, une faute se manifestant par l'abstention d'un placement en cellule de dégrisement d'une personne qui a conduit en motocyclette en état d'ivresse et qui, en circulant à contresens, est décédée.

En 2012, le Conseil constitutionnel a affirmé que les dispositions précitées du Code de santé publique prévoyant la possibilité de placement en cellule de dégrisement des personnes en état d'ivresse dans un lieu public ne sont pas contraires à l'article 66 de la Constitution.

→ Cons. const., déc. n° 2012-253 QPC, 8 juin 2012, *Mickaël D [Ivresse publique].*

Si la durée du placement en cellule de dégrisement est courte, le Conseil d'État n'en a pas moins relevé que :

« Eu égard à la situation particulière des personnes gardées à vue ou retenues dans un local de dégrisement et notamment à leur situation d'entière dépendance, il appartient à l'administration de prendre les mesures propres à assurer le respect de leur dignité. »

→ CE, 10e et 9e ch., 29 décembre 2023, n° 461605.

POUR S'ENTRAÎNER

Argumentation juridique : Soutenez que l'enfermement des mineurs est contraire aux droits humains.

Dans le discours politique contemporain, le souhait de renforcer la justice pénale des mineurs dans le sens d'un durcissement est récurrent. La récente loi Attal *visant à renforcer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants et de leurs parents* (dont le Conseil constitutionnel a prononcé une non-conformité partielle par une décision du 19 juin 2025) en est une manifestation, dans un contexte où, au-delà de l'incarcération, les lieux de privations de liberté où se trouvent des mineurs sont concernés par des violations des droits humains.

La Convention internationale des droits de l'enfant définit un enfant au regard de son âge (art. 1er). L'article 37 prévoit que les enfants privés de libertés doivent l'être en vertu de la loi et doit être traité :

« Avec humanité et avec le respect dû à la dignité de la personne humaine, et d'une manière tenant compte des besoins des personnes de son âge. »

L'enfermement des mineurs répond à des règles dérogatoires à celle de l'enfermement des adultes.

Les lieux de privation de liberté sont des lieux confrontés à des violences multiples, ce qui rend les mineurs particulièrement vulnérables en ces lieux, leurs droits doivent faire l'objet d'une protection accrue.

Problématique et annonce du plan : Malgré un droit international et européen protecteur des droits des enfants privés de liberté **(I)**, le respect des droits humains des mineurs enfermés est souvent lacunaire en France, ce qui rend cet enfermement contraire aux droits humains **(II)**.

I. Le droit international et européen des droits humains protecteur des droits des mineurs enfermés

A. La reconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant

Art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant de 1989 : les autorités publiques doivent considérer l'intérêt supérieur de l'enfant, « une considération primordiale » + les institutions et services en charge de l'enfant doivent assurer sa protection (Convention signée et ratifiée par la France en 1990).

Art. 1er de la Convention européenne sur l'exercice des droits des enfants de 1996 : expose que l'objet de la Convention vise à promouvoir des droits aux enfants dans l'intérêt supérieur des enfants (Convention signée par la France en 1996 et ratifiée en 2007).

L'intérêt de l'enfant peut justifier le recours à son enfermement (exemple : hospitalisation en psychiatrie pour sa protection, ou parfois l'intérêt de la société : incarcération en cas de commission d'infraction d'une particulière gravité).

B. La protection normative contre les mauvais traitements

Selon l'article 37 de la Convention relative aux droits de l'enfant, les États parties doivent veiller à ce que *« nul enfant ne soit soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants »*.

Par un arrêt du 26 mars 2024 *V.I. contre République de Moldova,* la Cour a condamné la Moldavie notamment pour violation de l'article 3 de la Convention (interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants) à l'occasion de l'internement en psychiatrie d'un orphelin ayant fait l'objet de traitements inhumains ou dégradants.

II. Les difficultés du respect des droits humains des mineurs enfermés en France

A. Des difficultés récurrentes en centre de rétention administrative

La France a été condamnée à de nombreuses reprises par la Cour européenne des droits de l'homme pour les conditions matérielles des mineurs en rétention administrative et/ou pour violation de droit procéduraux et/ou de d'autres droits substantiels (CEDH, 19 janvier 2012, Popov contre France ; CEDH, 12 juillet 2016, R.K. et a. contre France ; CEDH, 22 juillet 2021, M.D. et A.D. contre France ; CEDH, 31 mars 2022, N.B. et a. contre France ; CEDH, 4 mai 2023, A.M. et a. contre France)

Dans un communiqué de presse de 2023, le Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF) et des associations appelaient le Gouvernement français à cesser l'enfermement administratif des mineurs.

B. Des difficultés récurrentes en détention

En 2002, le Conseil constitutionnel a reconnu le principe fondamental reconnu par les lois de la République de la spécificité de la justice pénale des mineurs.

L'article 40 de la Convention relative aux droits de l'enfant prévoit que : *« Les États parties reconnaissent à tout enfant suspecté, accusé ou convaincu d'infraction à la loi pénale le droit à un traitement qui soit de nature à favoriser son sens de la dignité et de la valeur personnelle, qui renforce son respect pour les droits de l'homme et les libertés fondamentales d'autrui, et qui tienne compte de son âge ainsi que de la nécessité de faciliter sa réintégration dans la société et de lui faire assumer un rôle constructif au sein de celle-ci. »*

Dans un rapport de 2021 : *« Les droits fondamentaux des mineurs enfermés »*, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté relève que les structures de privation de liberté ne sont pas assez préparées à l'accueil des mineurs + protection inégale des enfants + droit à l'éducation négligé + insuffisance des liens avec la famille.

En conclusion, s'il apparaît parfois nécessaire qu'une personne mineure se voie privée de liberté, l'enfermement des personnes mineurs doit être une mesure exceptionnelle. L'exécution des divers types d'enfermement entre souvent en contradiction avec les droits humains. Ainsi, dans un grand nombre de situations, l'enfermement des mineurs est contraire aux droits humains.

Fiche nº 31 - LE DROIT À UN PROCÈS ÉQUITABLE ET LE DROIT À UN RECOURS EFFECTIF

POINTS CLÉS

- Volet civil.
- Volet pénal.
- Droit à un tribunal.
- Droits de la défense.
- Principe du contradictoire.
- Indépendance.
- Impartialité.
- Restrictions légitimes.

PRINCIPALES RÉFÉRENCES

- Art. 64 de la Constitution.
- Art. 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
- Art. 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme.
- Art. 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
- Art. 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
- Art. 15 et 16 du Code de procédure civile.
- Art. L. 521-1 du Code de justice administrative.

Le droit à un procès équitable et le droit à un recours effectif sont des droits très riches et très largement protégés au niveau national et international. Leur importance est fondamentale dans une société démocratique en ce qu'ils permettent de lutter contre l'arbitraire et de redresser les violations des autres droits humains.

L'article 14-1 du Pacte international relatif aux droits civils et politique prévoit une égalité devant la justice :

> *«* […] T*oute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil.* […]. *»*

L'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne lui est également consacré.

La Déclaration universelle des droits de l'homme protège les droits procéduraux dans deux articles différents, à savoir l'article 8 pour le recours effectif et l'article 10 pour le procès équitable, à l'instar de la Convention européenne des droits de l'homme qui prévoit le droit à un procès équitable dans son article 6-1 :

> *« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle* […]. »

Et dans son article 13, le droit à un recours effectif :

> *« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »*

Ces articles sont complétés par l'article 2 du Protocole additionnel nº 7 à la Convention européenne des droits de l'homme garantissant un double degré de juridiction en matière pénale (voir Fiche nº 32).

Au niveau interne, le droit à un procès équitable et à un recours effectif trouve sa source dans l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui ne le mentionne pourtant pas expressément. C'est le Conseil constitutionnel qui interprète de manière extensive cet article comme suit :

> *« Qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration de 1789 : "Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution" ; que sont garantis par cette disposition le droit des personnes intéressées à exercer un recours juridictionnel effectif, le droit à un procès équitable, ainsi que les droits de la défense lorsqu'est en cause une sanction ayant le caractère d'une punition »* (Cons. const., déc. n° 2006-540 DC, 27 juillet 2006, *Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information*).

La Cour européenne des droits de l'homme, par sa jurisprudence très conséquente sur le sujet (près de 40 % de ses jugements) a grandement contribué à développer et rationnaliser la protection du droit à un procès équitable, notamment en différenciant les volets « civils » et « pénal » de l'article 6 de la Convention, ce qui a conduit à différencier les exigences en fonction des branches du droit.

1. Le droit à un recours effectif

Le droit à un recours effectif est le corollaire du droit à un procès équitable. Il est protégé par l'article 13 de la Convention européenne dont la Cour considère que l'objet *« est de fournir un moyen au travers duquel les justiciables puissent obtenir, au niveau national, le redressement des violations de leurs droits garantis par la Convention, avant d'avoir à mettre en œuvre le mécanisme international de plainte devant la Cour »*. Dans ce cadre, le droit à un recours effectif s'entend, pour ce qui est de la Cour européenne, en harmonie avec les conditions de recevabilité d'une requête telles que présentées à l'article 35 de la Convention.

Ce droit est également protégé par l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux et reconnu comme un principe général du droit par la CJUE :

> → CJUE, 15 mai 1986, *Johnston c. Chief Constable of the Royal Ulster Constabulary*, aff. 222/84.

De manière générale, la Cour européenne considère l'article 6 comme une *lex specialis* lorsque le droit revendiqué par le justiciable est un droit de nature « civile » reconnu en droit interne ou en matière pénale.

> → CEDH [GC], 26 octobre 2000, *Kudla c. Pologne*, n° 30210/96.

L'article 13 de la convention européenne concerne donc des violations alléguées des droits de la Convention, ce qui contribue à l'effectivité de ces derniers en droit interne. Dans ce cadre, l'article 13 n'a pas d'existence propre et doit nécessairement être utilisé en combinaison avec une disposition garantissant l'exercice du droit violé (par exemple peuvent être soulevées des violations de l'article 13 combiné à l'article 2 ou à l'article 8, pour défaut d'effectivité des recours en cas de violation alléguée du droit à la vie ou du respect du droit à la vie privée) devant les juridictions compétentes.

L'applicabilité de l'article 13 s'entend de plusieurs conditions d'applicabilité :

- L'existence d'un grief défendable au sens de la Convention, excluant toute « vengeance privée » ou grief qui ne serait pas fondé sur un droit reconnu.

  > → CEDH [GC], 30 novembre 2004, *Oneryildiz c. Turquie*, n° 48939/99.

- La nécessité de disposer d'un recours en droit interne : ce recours peut être juridictionnel ou non-juridictionnel.
- Le recours doit être effectif, c'est-à-dire apte à se prononcer sur le grief et à redresser le tort et à octroyer une réparation adéquate.

L'effectivité du recours est apprécié *in concreto* et peut nécessiter de s'intéresser aux critères de l'article 6, particulièrement au regard des critères d'accessibilité ou de célérité.

C'est notamment dans le souci de fournir un recours effectif et efficace que se sont développées les procédures en référés (art. L. 521-1 du Code de justice administrative), mais également les jurisprudences étendant le droit de recours de certains actes, à l'instar des circulaires comportant une interprétation impérative à caractère général :

> → CE, sec., 18 décembre 2002, *Duvignères*, n° 233618.

Et les documents de portée générale à effet notable :

→ CE, 12 juin 2020, *GISTI*, n° 418142.

→ Xavier Domino, « Droit au recours et équité du procès devant la justice administrative aujourd'hui », *Les nouveaux cahiers du droit constitutionnel*, n° 44, 2014.

Dans le cadre particulier des problèmes structurels de l'État français au regard de la surpopulation carcérale, le Conseil d'État a considéré que les recours par référés devaient être considérés comme des recours effectifs au sens de l'article 13 de la Convention.

→ CE, SSR, 28 décembre 2012, *Théron*, n° 357494.

2. Le droit à un procès équitable

2.1. Le volet civil du droit à un procès équitable

L'article 6-1 de la Convention européenne, sur son volet civil, protège l'accès à un procès équitable lorsque la demande porte sur des droits à caractère civil. Ses critères d'applicabilité sont les suivants :

- Il doit s'agir d'une contestation réelle et sérieuse dont l'issue est déterminante…
- … portant sur un droit ou une obligation reconnue de manière défendable en droit interne (qu'il soit ou non reconnu par la Convention, et pouvant concernant l'existence d'un droit ou bien même ses modalités d'exercice)…
- … de caractère civil (la notion de « caractère civil » est considérée comme une notion autonome de la Convention, à savoir qu'elle est indépendante de la qualité des parties, de la nature de la loi (civile, administrative, commerciale…) sur laquelle porte la contestation ou même sur le type d'autorité (judiciaire, administratif…).

Ces droits et obligations doivent trouver leur origine dans le droit interne de l'État défendeur (en ce qu'ils doivent être défendables et donc reconnus en droit interne).

→ CEDH [GC], 15 mars 2022, *Grzęda c. Pologne*, n° 43572/18.

Lors d'un recours, il est donc impossible de « créer » un droit matériel n'ayant aucune base légale dans l'État en question :

→ CECH [GC], 3 avril 2012, *Boulois c. Luxembourg*, n° 37575/04.

À noter : l'issue de la contestation doit être directement déterminante pour le requérant, des répercussions trop lointaines ne permettent pas de déclencher l'application de l'article 6-1.

Dans le cas où il est bien question d'une « contestation relative à ses droits et obligations de caractère civil », l'article 6-1 donne le droit à ce que cette contestation soit examinée par un tribunal, formant un « droit à un tribunal ».

En revanche, il existe des limites posées par la jurisprudence de la Cour quant à l'applicabilité de l'article 6. En effet, une réclamation patrimoniale ne suffit pas à déclencher cette applicabilité, de même que les questions fiscales, d'immigration, de droits électoraux. Le Conseil d'État confirme l'absence de « contestation relative à des droits et obligations de caractère civil » au sens de l'article 6 de la Convention européenne en matière de taxation fiscale :

→ CE, SSR, 2 juin 1989, *Bussoz*, n° 62979.

2.2. Le volet pénal du droit à un procès équitable

Le volet pénal de l'article 6-1 fonctionne selon le principal cardinal de l'équité comme principe général du procès pénal, apprécié strictement.

Pour que le volet pénal de l'article 6 soit applicable, plusieurs conditions doivent être réunies :

- L'existence d'une accusation. Celle-ci est décrite comme *« la notification officielle, émanant de l'autorité compétente, du reproche d'avoir accompli une infraction pénale »* :

→ CEDH, 27 février 1980, *Deweer c. Belgique*, n° 6903/75.

L'arrestation, l'inculpation, l'ouverture des enquêtes préliminaires peuvent être considérées comme des accusations au sens de l'article 6-1, puisque ces opérations portent sur une ou plusieurs infractions pénales.

→ CEDH, 27 juin 1968, *Wemhoff c. Allemagne*, n° 2122/64.

- En matière pénale. Ici, trois critères peuvent permettre de déterminer ce qui relève de la matière pénale :
  - La qualification de ce qui relève du droit pénal dans le droit interne de l'État. Ce critère n'a pas une conséquence absolue. Dans le cas où le caractère pénal de l'affaire n'est pas clair, la Cour européenne pourra s'intéresser aux caractéristiques réelles de la procédure.
  - La nature de l'infraction alléguée, pouvant impliquer de prendre en considération des facteurs tels que la portée de la règle, à savoir son objectif et ses destinataires, les intérêts protégés…
  - La sévérité de la sanction encourue (au regard de la sanction maximale prévue dans les textes).

Les deux derniers critères sont alternatifs et non nécessairement cumulatifs :

→ CEDH, 8 juin 1976, *Engel et a. c. Pays-Bas*, n° 5100/71 et suivants.

Il suffit que l'infraction reprochée soit « pénale » au sens de la Convention ou que l'infraction fasse risquer à la personne une sanction qui s'apparente à une sanction pénale par sa nature pour déclencher l'applicabilité de l'article 6-1 sur son volet pénal. La Cour peut cependant adopter une approche cumulative lorsque les critères analysés séparément ne permettent pas d'aboutir à une réponse claire.

→ CEDH, 24 février 1994, *Bendenoun c. France*, n° 12547/86.

2.3. Les particularités du contentieux administratif

Au vu de la diversité des systèmes juridiques des États membres du Conseil de l'Europe, l'article 6 de la Convention européenne ne mentionne pas la matière administrative. La question du respect des règles du procès équitable dans cet ordre juridictionnel a pu questionner, notamment par la dualité de fonction du Conseil d'État en tant que juridiction suprême de l'ordre administratif :

- Il gère les 42 tribunaux administratifs, les 9 cours administratives d'appel et la Cour nationale du droit d'asile ainsi que l'avancée professionnelle de leurs membres.
- Il connaît en dernier ressort des recours contre leurs décisions dans sa fonction contentieuse.

Cette dualité dans l'ordre administratif n'entache cependant pas le respect du droit à un procès équitable ou le principe constitutionnel d'indépendance des juges administratifs selon le Conseil d'État lui-même :

→ CE, SSR., 26 mai 2010, *M. Marc-Antoine et autres*, n° 309503. Confirmé dans :

→ CEDH, 4 juin 2013, déc. *François Marc-Antoine c. France*, n° 54984/09.

Le Conseil d'État a également consacré de longue date le principe général du droit de former un recours pour excès de pouvoir contre toute décision administrative :

→ CE, ass., 17 février 1950, *ministre de l'Agriculture c. Dame Lamotte*, n° 86949.

Le droit d'accès à un tribunal a par ailleurs été consacré comme un principe général par le Conseil d'État reconnaissant le droit de former un recours en cassation contre les décisions des juridictions administratives ou d'autres nature statuant en dernier ressort, même dans le cas où un tel recours est expressément exclu par les textes :

→ CE, ass., 7 février 1947, *D'Aillières*, n° 79128.

2.4. Les particularités du contentieux constitutionnel

Les garanties de l'article 6 de la Convention européenne s'appliquent en principe aux procédures constitutionnelles, la Cour européenne accorde néanmoins une large marge de manœuvre aux États membres pour décider de la forme et surtout du fonctionnement des juridictions constitutionnelles et considère que *« les*

procédures constitutionnelles présentent des caractéristiques propres qui tiennent compte de la spécificité de la norme à appliquer tout comme de l'importance de la décision à rendre pour le système juridique en vigueur ».

Cependant, la Cour européenne a rappelé l'importance de l'application des principes du droit à un procès équitable, en particulier le principe fondamental du contradictoire valable dans tout procès, y compris dans un contentieux constitutionnel :

→ CEDH, 26 juin 1993, *Ruiz-Mateos c. Espagne*, n° 12952/87.

Cependant, les modalités de saisine spécifiques du Conseil constitutionnel lors de son contrôle *a priori* excluent l'existence d'un procès au sens classique du terme et donc l'applicabilité de l'article 6, de même que l'inexistence d'un réel contradictoire, le Secrétariat général du gouvernement produisant les écritures en défense du texte.

L'applicabilité de l'article 6 au contrôle de constitutionnalité *a posteriori* n'est pas encore parfaitement tranchée, notamment au regard des conflits pouvant exister au vu de la hiérarchie des normes. Le Conseil applique cependant certains principes fondamentaux dont celui d'égalité des armes en recevant un mémoire « distinct et motivé » des parties au litige au cours duquel la question prioritaire de constitutionnalité a été soulevée, ainsi qu'en organisant une audience publique, et en considérant de manière générale que la procédure de transmission de la question par le Conseil d'État et la Cour de cassation doit s'exécuter conformément aux exigences du droit à un procès équitable :

→ Cons. const., déc. n° 2009-595 DC, 3 décembre 2009, *Loi organique relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution.*

Le Conseil, tenu de se prononcer dans un délai raisonnable de trois mois, est considéré être indépendant et impartial (bien que sa composition et les procédures relatives aux nominations de ses membres soient régulièrement critiquées), allant dans un sens de juridictionnalisation de la procédure constitutionnelle et participe à l'affirmation du Conseil comme une juridiction depuis 2010.

3. Les garanties du droit à un procès équitable

Le droit à un procès équitable implique des garanties concernant tant l'organisation et la composition du tribunal que la conduite de la procédure. Le tout forme le droit à un procès équitable protégé par l'article 6 § 1 (CEDH, 21 février 1975, *Golder c. Royaume-Uni*, n° 4451/70).

3.1. Le droit à un tribunal

Le droit à un tribunal est une condition essentielle pour pouvoir apprécier le caractère équitable du procès. Il nécessite de pouvoir saisir concrètement un tribunal d'un recours.

→ CEDH, 21 février 1975, *Golder c. Royaume-Uni*, n° 4451/70.

Le terme de « tribunal » est compris comme une notion autonome et a un sens plus large que celle d'un juge ayant une fonction juridictionnelle classique. Elle peut recouvrir tout instrument à même de redresser une violation, et capable, selon la Cour européenne, de *« trancher, sur la base de normes de droit et à l'issue d'une procédure organisée, toute question relevant de sa compétence »*.

→ CEDH, 22 octobre 1984, *Sramek c. Autriche*, n° 8790/79.

Le droit et l'accès à un tribunal ne se contrôle pas uniquement par un accès formel à l'autorité judiciaire, mais également en substance. L'effectivité du droit d'accès implique qu'un requérant ait *« une possibilité claire et concrète de contester un acte constituant une ingérence dans ses droits »*.

→ CEDH, 4 décembre 1995, *Bellet c. France*, n° 23805/94.

Les délais et autres réglementations relatives à la bonne administration de la justice ne sont pas réputés porter atteinte au droit à un tribunal, à moins qu'ils empêchent de manière disproportionnée l'accès à un juge pour le justiciable. La Cour européenne considère que le droit d'accès à un tribunal est atteint dans sa substance quand les restrictions à son accès ne poursuivent plus les buts de la « sécurité juridique » et de la « bonne administration de la justice », mais constituent une sorte de barrière qui empêche le justiciable de voir son litige tranché au fond par la juridiction compétente.

→ CEDH, [GC], 5 avril 2018, *Zubac c. Croatie*, n° 40160/12.

Actualité jurisprudentielle. - L'arbitrage obligatoire doit demeurer soumis à un contrôle juridictionnel effectif

Le recours à l'arbitrage n'est pas, par lui-même, incompatible avec le droit à un procès équitable. Toutefois, lorsque l'arbitrage est imposé à une personne et qu'elle ne dispose d'aucune possibilité réelle de porter son litige devant une juridiction ordinaire, les garanties de l'article 6 § 1 de la Convention doivent être effectivement assurées.

La Cour européenne l'a précisé à propos de l'athlète Caster Semenya, contrainte de saisir le Tribunal arbitral du sport pour contester une réglementation lui imposant de réduire son taux naturel de testostérone afin de participer à certaines compétitions féminines. Le Tribunal fédéral suisse avait ensuite exercé un contrôle très limité de la sentence arbitrale.

La Grande Chambre considère que, lorsque l'arbitrage est obligatoire et que le litige porte sur des droits correspondant à des droits fondamentaux, la juridiction étatique appelée à contrôler la sentence doit procéder à un examen particulièrement rigoureux. Le contrôle insuffisant exercé en l'espèce a donc entraîné une violation de l'article 6 § 1.

→ CEDH, G.C., 10 juillet 2025, *Semenya c. Suisse*, n° 10934/21.

À retenir : L'existence d'un mécanisme d'arbitrage privé ne peut soustraire entièrement un litige mettant en cause des droits fondamentaux au contrôle d'un juge étatique. Plus l'arbitrage est contraint, plus l'exigence d'un contrôle juridictionnel effectif est forte.

3.2. Les exigences procédurales liées au droit à un procès équitable

3.2.1. Les droits de la défense

Le droit à un procès équitable s'analyse à la lumière du respect des exigences procédurales qui en permettent le bon respect à savoir les règles du procès.

→ CEDH, 21 février 1975, *Golder c. Royaume-Uni*, n° 4451/70.

Ainsi, sont inclus dans ces règles les droits de la défense, tels que reconnus également par le Conseil constitutionnel et par les deux ordres de juridiction :

→ Cons. const., déc. n° 2019-801 QPC, 20 septembre 2019, *M. Jean-Claude F.*

→ Cass., ass. plén., 30 juin 1995, n° 94-20.302.

→ CE, 5 mai 1944, *Dame Veuve Trompier Gravier*, n° 69751.

Le Conseil constitutionnel a reconnu le caractère fondamental de ces derniers comme principes fondamentaux reconnus par les lois de la République réaffirmés par le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, et impliquant, notamment en matière pénale, l'existence d'une procédure juste et équitable garantissant l'équilibre des droits des parties.

→ Cons. const., déc. n° 95-360 DC, 2 février 1995, *Loi relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.*

Le Conseil constitutionnel reconnaît également le caractère essentiel de l'équité dans la procédure et en trouve une émanation concrète dans le régime de la preuve, montrant ainsi que ces exigences correspondent à un tout indissociable, comme mentionné dans l'arrêt *Golder* ci-dessus. Cette équité globale peut impliquer que les autorités aient également l'obligation d'enquêter et de réunir des preuves en faveur de l'accusé, particulièrement dans le cas où des éléments de sa situation (en l'espèce une victime du trafic d'êtres humains) sont un « aspect fondamental » de la défense, cette considération ayant une conséquence directe sur l'équité globale du procès.

→ CEDH, 16 février 2021, *V.C.L. et A.N. c. Royaume-Uni*, n° 77587/12.

3.2.2. Le contradictoire

Il s'agit d'une application du principe de l'égalité des armes et qui implique de laisser l'opportunité à toutes les parties de défendre leur cause de manière égale.

Cela implique une égalité de connaissance des documents et preuves présentées par les parties ainsi que l'opportunité de les soumettre au débat (comme le prévoit l'article 15 du Code de procédure civile, par exemple). Le juge a ainsi le devoir de veiller au bon exercice de cette contradiction (art. 16 du Code de procédure civile, mais également reconnu en droit public).

→ CE, 12 mai 1961, *Société La Huta*, n° 40674.

3.2.3. Les exigences tenant au jugement

a. La publicité

Elle permet de créer une transparence de la justice et donc de renforcer la confiance du public dans les juridictions et est appréciée globalement à travers la procédure. Cette publicité s'exprime à la fois par l'organisation d'audiences publiques ainsi qu'une publicité des jugements.

L'audience est considérée comme publique dès lors que le public a accès à la date et au lieu du procès et peut y accéder physiquement. La nécessité d'une audience tient en premier à son organisation en première instance, l'exigence d'organisation de celle-ci est moins stricte concernant l'appel et la cassation. Elle peut également ne pas être nécessaire relativement à la matière traitée.

→ CEDH, 29 octobre 1991, *Jan-Ake Andersson c. Suède*, n° 11274/84.

Le droit à une audience publique n'est cependant pas absolu :

→ Cons. const., déc. n° 88-1113 AN, 8 novembre 1988, *A.N. Saint-Denis (6e circ.).*

Il peut être restreint légitimement dans certains cas :

- Dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique.
- Dans l'intérêt des mineurs.
- Si la protection de la vie privée des parties au procès l'exige.
- Lorsque, dans des circonstances spéciales, la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice, dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal.

→ CEDH, 1er mars 2011, *Welke et Białek c. Pologne*, n° 15924/04.

Le Conseil d'État a également consacré la publicité des débats judiciaire comme un principe général du droit.

Concernant la publicité du jugement, celle-ci permet un contrôle de la régularité de la décision de justice par le public. Elle implique que toute personne peut avoir accès au texte de la décision, généralement satisfait par la publication de la décision au recueil officiel ou par la possibilité d'en demander une copie auprès du greffe du tribunal.

b. Le délai raisonnable

Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable. L'existence de ce critère de délai raisonnable permet à la fois de favoriser la bonne administration de la justice et éviter les dénis de justice, mais également d'éviter le prolongement de l'incertitude due à l'attente, particulièrement pour un individu accusé.

Le point de départ est apprécié, en matière civile, à partir de la saisine de la juridiction. En matière pénale, le délai commence à partir du moment où l'individu est accusé, à savoir à la notification officielle des charges ou à partir d'une arrestation ou d'une mise en examen.

La Cour européenne analyse ce délai selon les circonstances de la cause, mais retient généralement plusieurs éléments pour analyser son caractère raisonnable :

- La complexité de l'affaire : le nombre et la diversité des acteurs, les chefs d'inculpation, la dimension de l'affaire, l'expertise nécessitée pour examiner l'affaire.
- Le comportement du requérant : si celui-ci a demandé des procédures complémentaires ou utilisé de nombreuses voies de recours disponibles.
- Le comportement des autorités compétentes : l'organisation des juridictions doit favoriser un traitement efficace et rapide des affaires, bien que certains retards dus à des réformes structurelles ou un engorgement passager ne sont pas de nature à causer une violation de l'article 6, mais obligent les autorités à prendre des mesures adéquates.
- L'enjeu de l'affaire pour le requérant : ce critère est particulièrement pertinent dans les affaires pénales. Le caractère médiatique de l'affaire ne change néanmoins rien à ce critère.

À noter : le justiciable peut demander des réparations pour un dommage causé par une procédure dont la durée a été excessive.

3.3. Les exigences institutionnelles

Le droit à un procès équitable nécessite que le tribunal soit indépendant, impartial et établi par la loi.

La légalité du tribunal est en général considérée comme la première étape du raisonnement sur les qualités institutionnelles du Tribunal et est une condition découlant de l'État de droit. Concernant les deux autres conditions, c'est-à-dire l'indépendance et l'impartialité du tribunal, il existe des critères distincts pour apprécier leur respect, ces deux notions bénéficiant d'un lien étroit, mais ne devant pas être confondues.

À noter que la Charte européenne sur le statut des juges rédigée dans le cadre des travaux du Conseil de l'Europe, a été adoptée en 1998, ainsi que les travaux de la Commission de Venise sont des références utiles concernant les questions institutionnelles.

3.3.1. L'indépendance du juge

L'indépendance d'un tribunal se mesure par rapport à son degré de liberté vis-à-vis des autres pouvoirs, particulièrement de l'exécutif et du législatif et trouve sa source à la fois dans l'article 6 de la Convention européenne (bien qu'il n'impose aucune forme particulière), mais également dans l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui impose une séparation des pouvoirs, l'article 64 de la Constitution de 1958 reconnaissant ce principe pour le juge judiciaire.

Cependant, les magistrats du siège et du parquet ne bénéficient pas exactement des mêmes prérogatives au regard de leur indépendance.

Le Conseil constitutionnel reconnaît par ailleurs l'indépendance de la juridiction administrative comme étant un Principe fondamental reconnu par les lois de la République :

> *«* [Il] *résulte des dispositions de l'article 64 de la Constitution en ce qui concerne l'autorité judiciaire et des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République en ce qui concerne, depuis la loi du 24 mai 1872, la juridiction administrative, que l'indépendance des juridictions est garantie ainsi que le caractère spécifique de leurs fonctions sur lesquelles ne peuvent empiéter ni le législateur ni le Gouvernement ; qu'ainsi, il n'appartient ni au législateur ni au Gouvernement de censurer les décisions des juridictions, d'adresser à celles-ci des injonctions et de se substituer à elles dans le jugement des litiges relevant de leur compétence »* (Cons. const., déc. n° 80-119 DC, 22 juillet 1980, *Loi portant validation d'actes administratifs*).

Le Conseil d'État s'inscrit dans cette lignée en reconnaissant l'existence d'un principe général du droit inhérent à la fonction de juger :

> → CE, ass., 6 décembre 2002, *Trognon*, n° 240028.

L'indépendance des juges administratifs est en réalité le fruit de l'Histoire qui a fait évoluer et a façonné leur rôle. À noter cependant, les conseillers d'État ne sont pour l'essentiel pas des magistrats, mais des haut-fonctionnaires dont les règles de nomination s'inscrivent dans un débat régulier concernant leur indépendance du pouvoir exécutif.

Plusieurs critères ont été dégagés pour apprécier le degré d'indépendance d'un organe juridictionnel :

- Le mode de désignation de ses membres.
- La durée de leur mandat.
- L'existence d'une protection contre les pressions et les instructions extérieures.
- L'inamovibilité du juge.

  → CEDH [GC], 26 juin 2016, *Baka c. Hongrie*, n° 20261/12.

- L'existence d'une « apparence » d'indépendance aux yeux des justiciables :

  → CEDH [GC], 7 juin 2001, *Kress c. France*, n° 39594/98.

  → CEDH, 4 juin 2013, *François Marc-Antoine c. France*, n° 54984/09.

Le Conseil constitutionnel a ainsi considéré que la présence au sein d'un tribunal de personnels de l'État relevant de l'administration et qui demeurent dépendants de celle-ci, soumis à l'autorité hiérarchique du Gouvernement, ne satisfait pas au principe d'indépendance :

→ Cons. const., déc. n° 2010-10 QPC, 2 juillet 2010, *Consorts C. et a.*

L'indépendance judiciaire est également garantie par l'existence d'un Conseil supérieur de la magistrature agissant de manière indépendante des ordres exécutifs et législatifs et qui constitue ainsi un rempart essentiel contre les influences de l'exécutif :

→ CEDH, 15 mars 2022, *Grzęda c. Pologne*, n° 43572/18.

3.3.2. L'impartialité du juge

L'impartialité, entendue comme l'abolition par le magistrat de tous ses déterminismes et de ses préjugés, est une fiction nécessaire pour assurer l'apparence d'une justice équitable.

Elle implique que le juge doive exercer ses fonctions sans préjugé ou parti pris afin de préserver l'équité et de maintenir la confiance du public dans la fonction juridictionnelle. La Cour européenne s'attache à analyser deux types d'impartialité :

- L'impartialité subjective : il s'agit de l'intérêt personnel d'un juge dans l'exercice de ses fonctions : la Cour considère que *« l'impartialité personnelle d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire »*, bien que cette présomption soit réfragable (quoi qu'il puisse être difficile de prouver une partialité subjective du juge) :

  → CEDH [GC], 15 décembre 2005, *Kyprianou c. Chypre*, n° 73797/01.

- L'impartialité objective : il s'agit d'éléments objectifs permettant de douter de l'impartialité du juge. La Cour s'attache par exemple à apprécier les liens hiérarchiques ou personnels entre les magistrats ou les autres acteurs du procès ou dans le cas où un magistrat aurait déjà connu et jugé la même affaire.

Ainsi, il existe une violation de l'article 6 s'il existe des raisons objectives tendant à penser à un manque d'impartialité, conformément à la théorie des apparences. Un système de récusation du juge peut ainsi préserver l'impartialité objective du tribunal (voir par exemple les articles 341 et suivants du Code de procédure civile et articles 668 et suivants du Code de procédure pénale).

Voir également la saisine QPC du 11 juin 2025 n° 2025-1153 à propos de l'impartialité du Parquet européen.

POUR ALLER PLUS LOIN

Après un suspens né d'un arrêt de la Cour européenne (CEDH, 28 septembre 1995, Procola c. Luxembourg, n° 14570/89), la Cour a considéré que la dualité fonctionnelle du Conseil d'État ne violait pas l'article 6 de la Convention dès lors qu'il ne s'agissait pas des mêmes conseillers d'État participant à ces deux fonctions sur une même affaire (CEDH, 9 novembre 2011, Sacilor Lormines c. France, n° 65411/01). Cette décision a été entérinée par les articles R122-21-1, L131-2 et L231-1-1 du Code de la Justice administrative.

4. Les restrictions au droit à un procès équitable

4.1. Un droit non absolu

Le droit à un procès équitable n'est pas un droit absolu et il peut subir des restrictions eu égard, notamment, à la bonne administration de la justice. Ces restrictions forment en substance les conditions de recevabilité d'un recours.

À ce titre, le droit interne impose des délais relatifs aux recours ou au pourvoi, l'idée étant de satisfaire au principe de sécurité juridique et permet de concéder l'existence de délai de prescription. Ces restrictions ne doivent néanmoins pas restreindre le droit à un procès équitable jusqu'à l'atteindre dans sa substance, à l'instar d'un interprétation excessivement stricte ou formelle d'une règle juridique :

→ CEDH, 26 juillet 2007, *Walchli c. France*, n° 35787/03.

Les tribunaux judiciaires français s'inscrivent dans cet élan qui permet de concilier sécurité juridique, bonne administration de la justice et droit à un procès équitable. En effet, la Cour de cassation a considéré que dans le cadre du délai pour agir en garantie des vices cachés, l'existence d'un délai, même imprécis, mais *« claire dans son objectif et d'application simple selon une jurisprudence constante »*, ne contrevenait pas au droit à un procès équitable qui n'était pas atteint dans sa substance :

→ Cass. civ. 1re, 21 mars 2000, *Le Collinet*, n° 98-11.982.

De même, l'erreur manifeste de pure forme n'est pas de nature à entraîner une irrecevabilité de l'appel, et serait considéré comme entachant le droit d'accès à un tribunal garanti par l'article 6 :

→ Cass. ass. plén., 6 décembre 2004, *Banco di Sicilia*, n° 03-11.053.

4.2. Le cas des immunités de juridiction

L'immunité de juridiction des États étrangers est très largement issue du droit international et participe du principe d'égalité souveraine des États et du principe de souveraineté territoriale. Elle implique dès lors qu'un État ne peut pas être jugé par les tribunaux d'un autre État.

→ CEDH [GC], 21 novembre 2011, *Al-Adsani c. Royaume-Uni*, n° 35763/97.

Pour les organisations internationales, l'immunité permet de favoriser son bon fonctionnement. L'individu doit cependant pouvoir disposer de l'existence d'une autre voie de droit propre à rendre effectif le droit d'accès à un tribunal et permettant d'engager la responsabilité de l'État partie. Dans ce cas, il ne s'agit alors pas d'une restriction considérée comme disproportionnée à ce droit fondamental :

→ Cass. civ. 1re, 25 mai 2016, n° 15-18.646.

Cependant, le principe des immunités n'est pas absolu comme l'a expliqué la Cour de cassation en indiquant que *« les États étrangers et les organisations qui en constituent l'émanation ne bénéficient de l'immunité de juridiction, immunité relative et non absolue, qu'autant que l'acte qui donne lieu au litige ou qui leur est imputé à faute participe, par sa nature et sa finalité, à l'exercice de la souveraineté de ces États et n'est donc pas un acte de gestion »*.

→ Cass. civ. 1re, 9 mars 2011, n° 09-14.743.

De même, l'immunité parlementaire poursuit un but légitime qui est l'indépendance du Parlement et la garantie de mise en œuvre de ses missions sans ingérence ou entrave aux objectifs politiques des députés.

→ CEDH [GC], 3 décembre 2009, *Kart c. Turquie*, n° 8917/05.

Cette immunité se divise en une irresponsabilité qui permet aux députés d'être protégés des poursuites pour des actes effectués dans le cadre de leur mandat (dans les limites du régime disciplinaire du Règlement de l'Assemblée) ; ainsi que l'inviolabilité qui empêche l'exercice des poursuites pénales pour des actes commis à titre privé. À noter, depuis la réforme du 4 août 1995, le député peut faire l'objet de poursuites, mais il ne peut être arrêté ou voir sa liberté restreinte, à l'exception des cas de flagrant délit ou crime ou d'exécution d'une condamnation.

Actualité jurisprudentielle. - Crimes internationaux : la Cour de cassation distingue immunité personnelle et immunité fonctionnelle

Réunie en Assemblée plénière, la Cour de cassation a profondément précisé en juillet 2025 le régime des immunités pénales des représentants d'États étrangers.

D'une part, l'immunité personnelle dont bénéficient les chefs d'État, chefs de gouvernement et ministres des affaires étrangères en exercice demeure particulièrement protectrice. En l'état du droit international coutumier, elle s'oppose aux poursuites devant les juridictions pénales françaises même lorsque sont reprochés des crimes contre l'humanité ou des crimes de guerre. Cette immunité est toutefois temporaire et cesse avec les fonctions.

D'autre part, la Cour reconnaît pour la première fois qu'un agent d'un État étranger ne peut opposer son immunité fonctionnelle lorsqu'il est poursuivi pour génocide, crimes contre l'humanité ou crimes de guerre. Cette solution vaut également pour un ancien chef d'État qui, après la cessation de ses fonctions, ne bénéficie plus que de l'immunité attachée aux actes accomplis dans l'exercice de celles-ci.

→ Cass., Ass. plén., 25 juillet 2025, n° 24-84.393, immunité personnelle du chef d'État en exercice.

→ Cass., Ass. plén., 25 juillet 2025, n° 24-84.071, immunité fonctionnelle des agents de l'État.

À retenir. - Immunité ne signifie pas nécessairement impunité. L'immunité personnelle demeure absolue pendant l'exercice de certaines fonctions internationales, mais l'immunité fonctionnelle recule désormais devant la poursuite des crimes internationaux les plus graves.

POUR S'ENTRAÎNER

Dissertation : Le droit à un procès équitable et à un recours effectif : quelle articulation ?

Les droits procéduraux sont le pilier de l'État de droit et de la justice en ce qu'ils sont l'émanation de la séparation des pouvoirs et de la protection individuelle en permettant à l'individu un accès au tribunal pour faire valoir sa cause. Le droit à un procès équitable et le droit à un recours effectif sont ainsi essentiels pour appréhender la violation des autres droits humains, leurs acceptions peuvent *a priori* sembler proches :

- Le droit au recours effectif recouvre le droit d'accès à une voie de droit.
- Le droit à un procès équitable correspond aux garanties procédurales tenant à l'équité globale du procès (impartialité, délai raisonnable, publicité, contradictoire…).

Ces droits, bien que distincts, bénéficient d'une protection renforcée à différents niveaux. Cette protection accrue a permis d'en développer et préciser les contours et de favoriser l'émergence de régimes procéduraux plus effectifs et des recours plus impartiaux (CEDH [GC], 7 juin 2001, *Kress c. France*, n° 39594/98), grâce également à une réelle prise de conscience que la transparence de la justice et l'apparence d'indépendance et d'impartialité concourent à la confiance du public dans celle-ci.

Problématique et annonce du plan : Le droit à un recours effectif et le droit à un procès équitable sont consubstantiels dans leur finalité **(A)** bien qu'ils se subdivisent néanmoins en des exigences distinctes **(B)**.

I. Deux droits procéduraux consubstantiels

A. Des objectifs communs

Ces deux droits permettent de lutter contre l'arbitraire, de préserver l'équité et d'accéder à une « bonne justice ».

Leur base juridique est souvent commune. Cela témoigne de leur proximité : article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Le principe d'une « protection juridictionnelle effective » est considéré comme étant issu des « traditions constitutionnelles communes des États membres » selon la Cour de justice de l'Union européenne, se référant alors à la fois aux articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme : CJCE, 13 mars 2007, *Unibet*, C-432/05.

En droit interne, le juge constitutionnel fait une interprétation très large de l'article 16 de la Déclaration qui dépasse largement ce qui est textuellement affirmé, mais qui permet d'y trouver un même esprit de protection contre les abus : Cons. const., déc. n° 2006-540 DC, 27 juillet 2006, *Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information.*

L'un suppose donc l'autre dans une relation de consubstantialité, qui est affirmée par les juridictions interne qui citent d'ailleurs régulièrement les deux droits ensemble (à l'instar de CE, SSR., 26 mai 2010, *M. Marc-Antoine et autres*, n° 309503).

B. Entre spécialité et généralité

L'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme est considéré par la Cour européenne comme une *lex specialis* du droit au recours effectif, particulièrement quand il s'agit d'analyser en substance l'équité globale du procès. Les exigences de l'article 6 étant considérées comme plus strictes, elles absorbent la plupart des questions relatives à l'article 13 lorsque les conditions d'applicabilité de l'article 6 sont remplies : CEDH, 25 mars 1983, *Silver et a. c. Royaume-Uni*, n° 5947/72 et autres.

À l'exception des questions regardant le délai raisonnable pour lesquelles il n'y a pas d'absorption (CEDH [GC], 26 octobre 2000, *Kudla c. Pologne*, n° 30210/96).

Malgré sa généralité, l'article 13 n'a néanmoins pas d'existence indépendante : il nécessite d'être utilisé en combinaison avec un droit protégé existant, ce qui souligne le caractère essentiel de ce droit procédural pour la protection des autres violations alléguées des droits humains. L'article 13 n'est pas considéré comme applicable dans le cas où la violation alléguée de la Convention européenne des droits de l'homme s'est produite au cours d'une procédure judiciaire (relevant de l'article 6).

La Cour les utilise donc généralement de manière alternative, mais elle a pu les analyser ensemble assez exceptionnellement dans certaines affaires (CEDH [GC], 19 avril 2007, *Vilho Eskelinen et a. c. Finlande*, n° 63235/00).

II. Des droits aux exigences distinctes

A. Des exigences formelles différentes

Le droit au recours effectif permet de donner accès à une voie de droit effective. Le droit à un procès équitable donne, lui, des garanties procédurales et institutionnelles permettant d'avoir accès au juge et de protéger l'équité du procès.

Il existe donc des exigences institutionnelles concernant l'article 6 relatives à l'indépendance et l'impartialité et des exigences relatives aux procédures (délais, respect des droits de la défense) ainsi qu'aux jugements (à l'instar de la publicité).

L'article 13 nécessite l'existence de voies de recours accessibles en cas de grief défendable.

Le maintien de la différence entre ces deux droits est donc essentiel : le recours peut être effectif sans que le procès soit équitable, et inversement. Ces deux droits permettent de couvrir une très grande majorité des manquements procéduraux.

Leur champ d'action est différent, bien que complémentaire.

B. Des droits fondamentaux dans une société démocratique

Ces deux droits distincts ont permis d'accentuer les garanties procédurales grâce à la précision des interprétations offertes par les organes internationaux, rationalisant ces principes généraux du droit par l'édiction de critères et de conditions précises.

Cela a permis au Conseil constitutionnel, depuis 2010 et l'émergence du contrôle *a posteriori*, de répondre aux critiques structurelles dont il fait l'objet, par une juridictionnalisation de sa fonction grâce au respect de certains droits procéduraux essentiels : Cons. const., déc. n° 2009-595 DC, 3 décembre 2009, *Loi organique relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution*. Ces droits démontrent ainsi un rôle croissant des juges européens dans la transformation du droit et dans la mise en place d'un standard procédural commun.

Dans certains États européens, la montée des populisme cause des questions primordiales sur le respect de ces droits procéduraux essentiels (CEDH [GC], 15 mars 2022, *Grzęda c. Pologne*, n° 43572/18) et d'une manière plus générale sur le respect de l'État de droit par ces États, en faisant de ces droits des garde-fous essentiels.

Cependant, ces règles procédurales peinent à résoudre certains enjeux contemporains à savoir :

- Les risques liés à un formalisme excessif (recevabilité, irrecevabilité, délais…).
- Les problèmes d'accès au juge pour les personnes vulnérables (étrangers, justiciables non représentés…).

En conclusion, ces deux droits forment un socle essentiel de protection des droits procéduraux des individus, renforcé par leur consubstantialité.

Fiche nº 32 - LES GARANTIES FONDAMENTALES EN DROIT PÉNAL

POINTS CLÉS

- Droits de la défense.
- Présomption d'innocence.
- Droit de ne pas s'incriminer.
- Droit à l'assistance d'un avocat.
- Principe de légalité des délits et des peines.
- Principe de nécessité des peines.
- Principe de *non bis in idem.*
- Principe de non-rétroactivité de la loi pénale la plus sévère.
- Principe d'individualisation des peines.
- Responsabilité du fait propre de la personne.
- Irresponsabilité pénale en cas d'abolition du discernement.

PRINCIPALES RÉFÉRENCES

- Art. 34 de la Constitution.
- Art. 8, 9, 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
- Art. 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
- Art. 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.
- CEDH, 17 septembre 2009, *Scoppola c. Italie (nº 2),* nº 10249/03.
- CEDH, 1er juin 2010, *Gäfgen c. Allemagne*, nº 22978/05.
- Art. préliminaire du Code de procédure pénale.
- Loi nº 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue.
- Loi nº 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole.
- Loi nº 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic.

1. La procédure pénale entourée par des garanties fondamentales

L'observation de règles dans le cadre d'une procédure pénale est indispensable à la lutte contre l'arbitraire. Ces règles constituent un bouclier pour l'individu face à la puissance publique lorsqu'elle recherche les personnes soupçonnées d'avoir commis une infraction.

La procédure pénale, intimement liée à l'exercice des droits humains et libertés fondamentales, doit concilier ces impératifs afin d'éviter l'arbitraire tout en protégeant la société, un rôle fondamental de l'État.

L'article préliminaire du Code de procédure pénale, modifié à plusieurs reprises, expose cet équilibre dès la première ligne :

> *« La procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties. »*

Ce même article liste un ensemble de garanties qui entourent la procédure pénale. La longueur des dispositions de cet article atteste de l'importance des règles en la matière.

En vertu de l'article 34 de la Constitution, la loi doit fixer les règles relatives à :

> *« La détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procédure pénale ; l'amnistie ; la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats. »*

L'exigence de normes écrites préétablies ne suffit pas à la procédure pénale : ces normes ne portent pas n'importe quel contenu.

Les droits de la défense recouvrent un ensemble de garanties accordées à l'accusé en matière pénale. La reconnaissance constitutionnelle des droits de la défense résulte de l'article 16 de la Déclaration de 1789 selon une lecture prétorienne du Conseil constitutionnel.

L'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques prévoit un ensemble de garanties visant à ce qu'une personne accusée puisse assurer sa défense, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne emploie explicitement le vocable de droits de la défense en son article 48. De plus, l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme prévoit un ensemble de dispositions visant à assurer les droits de la défense.

POUR ALLER PLUS LOIN

En matière de procédure pénale, il existe des exceptions au principe d'égalité devant la loi qui s'expliquent par le principe de la séparation des pouvoirs. S'agissant des parlementaires, l'article 26 de la Constitution prévoit qu'ils ne peuvent pas faire l'objet d'une arrestation ou d'une mesure de privation ou de restriction de liberté sans l'accord du bureau de l'assemblée dont ils font partie. En d'autres termes, il faut la levée de l'immunité parlementaire par le bureau de l'Assemblée national ou du Sénat en fonction du mandat parlementaire de la personne concernée. De plus, pendant l'exercice de son mandat, le président de la République ne peut pas faire l'objet de poursuites pénales, sauf dans le cadre de poursuites devant la Cour pénale internationale (art. 53-2 de la Constitution).

1.1. Le principe de la présomption d'innocence

En 1996, la Cour de cassation affirme que :

> *« L'atteinte à la présomption d'innocence contre laquelle l'article 9-1 instaure une protection, consiste à présenter publiquement une personne comme coupable, avant condamnation, une personne poursuivie pénalement »* (Cass., civ. 1re, 6 mars 1996, nº 93-20.478 P).

La présomption d'innocence est inscrite dans plusieurs socles textuels. La Déclaration des droits et du citoyen consacre son article 9 à la présomption d'innocence ; elle figure également à l'article 48 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi qu'à l'article 14 § 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Elle apparaît à l'article 6 § 2 de la Convention européenne. La Cour européenne en fait une double lecture : la présomption d'innocence constitue une garantie procédurale et une garantie visant à éviter que les autorités publiques ne considèrent une personne acquittée ou qui a fait l'objet d'un abandon des poursuites comme étant une personne coupable.

> → CEDH, 12 juillet 2013, *Allen c. Royaume-Uni*, nº 25424/09.

Plusieurs socles législatifs reconnaissent également la présomption d'innocence, tels que l'article préliminaire du Code de procédure pénale, ainsi que l'article 9-1 du Code civil.

Il découle de la présomption d'innocence que la charge de la preuve pèse sur l'accusation, il existe cependant des exceptions à ce principe de la charge de la preuve.

1.1.1. Les exceptions au principe de la présomption d'innocence

La présomption d'innocence est le principe, et la présomption de culpabilité constitue une exception déclarée constitutionnelle dès 1999, en subordonnant ces exceptions à plusieurs exigences :

> *« Ne revêtent pas de caractère irréfragable, qu'est assuré le respect des droits de la défense et que les faits induisent raisonnablement la vraisemblance de l'imputabilité »* (Cons. const., déc. nº 99-411 DC, 16 juin 1999, *Loi portant diverses mesures relatives à la sécurité routière et aux infractions sur les agents des exploitants de réseau de transport public de voyageurs*).

Le premier alinéa de l'article 392 du Code des douanes prévoit une présomption de culpabilité :

> *« Le détenteur de marchandises de fraude est réputé responsable de la fraude. »*

1.1.2. La présomption d'innocence et la détention provisoire

En 2002, le Conseil constitutionnel affirme que le placement en détention provisoire n'est pas incompatible avec l'article 9 de la Déclaration de 1789, à condition que ce placement soit nécessaire à la manifestation de la vérité et au maintien de la personne concernée à la disposition de la justice, dans le respect des droits de la défense.

> → Cons. const., déc. n° 2002-461 DC, 29 août 2002, *Loi d'orientation et de programmation pour la justice.*

1.2. Le droit de ne pas s'incriminer

Le Conseil constitutionnel a affirmé qu'une personne peut librement reconnaître sa culpabilité sans que cela soit contraire à des dispositions constitutionnelles.

> → Cons. const., déc. n° 2004-492 DC du 2 mars 2004, *Loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité.*

Toutefois, une personne accusée a le droit de garder le silence ; ce droit est explicitement indiqué à l'article 14 § 3 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et découle de l'article 6 § 1 de la Convention européenne.

L'exercice du droit de se taire ne saurait être interprété comme une marque de culpabilité !

Il est important de souligner que le droit de se taire implique le droit d'être informé de ce droit, et ce à toute étape de la procédure.

- Au moment de la garde à vue (art. 63-1 du Code de procédure pénale).
- Au moment d'une audition (art. 61-1 du Code de procédure pénale.
- Devant le juge d'instruction (art. 116 du Code de procédure pénale).

De plus, des déclarations obtenues au moyen de torture ou de traitements inhumains ou dégradants prive automatiquement d'équité la procédure selon les termes de la Cour européenne des droits de l'homme.

> → CEDH, 1er juin 2010, *Gäfgen c. Allemagne*, n° 22978/05.

1.3. Le droit à l'assistance d'un avocat

Une personne mise en examen a le droit à l'assistance d'un avocat durant toute la procédure : pendant l'instruction et pendant le jugement.

Il est reconnu explicitement à l'article 6 § 3 de la Convention européenne.

En 2011, à la suite de la condamnation de la France dans l'affaire Brusco, le Code de procédure pénale a été modifié afin que les personnes gardées à vue puissent demander à être assistées par un avocat dès le début de leur garde à vue.

> → Loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue.

De plus, la loi du 22 avril 2024 a supprimé le délai de carence de deux heures. Désormais, aucune audition ne peut commencer sans la présence de l'avocat. La loi a également étendu le droit d'accès au dossier pendant la garde à vue par l'avocat.

> → Loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole.

Le secret professionnel de l'avocat est un impératif pour le respect des droits de la défense qui comprend le droit de choisir son défenseur. L'article 6 § 3 de la Convention européenne prévoit également le droit de se défendre soi-même ce qui ne l'empêche pas, par ailleurs, d'être assisté.

L'article 4 du décret du 30 juin 2023 portant Code de déontologie des avocats prévoit que :

> *« L'avocat est le confident nécessaire de son client. Le secret professionnel de l'avocat est d'ordre public, absolu, général et illimité dans le temps. L'avocat ne peut en être relevé par son client ni par quelque autorité ou personne que ce soit, sauf dans les cas prévus par la loi. L'avocat ne commet, en toute matière, aucune divulgation contrevenant au secret professionnel, sous réserve des strictes exigences de sa propre défense devant toute juridiction et des cas de déclaration ou de révélation prévues ou autorisées par la loi. »*

Le Règlement Intérieur National de la profession d'avocats reprend ces dispositions en son article 2.

Néanmoins, le secret professionnel de l'avocat peut être levé pour assurer sa propre défense.

Enfin, il existe des situations pour lesquels l'assistance d'un avocat est obligatoire, c'est le cas devant la cour d'assises. En vertu de l'article 274 du Code pénal, devant la cour d'assises, l'accusé peut choisir un avocat, mais s'il n'en choisit pas, un avocat lui est désigné d'office. Tout mineur prévenu est assisté d'un avocat tout au long de la procédure en vertu de l'article L. 12-4 du Code de justice pénale des mineurs.

POUR ALLER PLUS LOIN

Le 29 avril 2025, le Conseil constitutionnel a censuré des dispositions du Code de procédure pénale qui ne prévoyaient pas le droit de visite des bâtonniers dans les geôles et dépôts des juridictions judiciaires, sur le fondement du principe d'égalité dans la mesure où les autres lieux de privation de liberté peuvent faire l'objet d'une visite, notamment par des parlementaires, y compris européens. Pour éviter que le droit de visite des autres lieux de privation de liberté ne soient supprimés, le Conseil constitutionnel a reporté les effets de sa décision au 30 avril 2026 afin de laisser le temps au législateur de tirer les conséquences de cette censure.

2. Le prononcé de la peine entouré par des garanties fondamentales

Le prononcé de la peine est également entouré d'un ensemble de règles qu'il convient d'observer afin de lutter contre l'arbitraire.

2.1 Le principe de légalité des peines

La légalité des délits et des peines signifie qu'une personne ne peut être poursuivie et condamnée que sur le fondement de peines qui sont expressément prévues par la loi. Le Conseil constitutionnel a affirmé sa valeur constitutionnelle à partir de 1981 au regard de l'article 8 de la Déclaration de 1789.

> → Cons. const., déc. n° 80-127 DC, 20 janvier 1981*, Loi renforçant la sécurité et protégeant la liberté des personnes.*

> → Art. 8 DDHC : *« La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée. »*

Le législateur détermine les délits et les crimes ainsi que les peines qui leur sont applicables en vertu de l'article 34 de la Constitution, ce qui est rappelé à l'article 111-2 du Code pénal.

La Convention européenne des droits de l'homme consacre l'article 7 à la légalité des peines et la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne consacre à l'article 48 les principes de légalité et de proportionnalité des délits et des peines.

La clarté de la loi est nécessaire pour être conforme au principe de légalité des délits et des peines afin d'éviter l'arbitraire.

> → Cons. const., déc. n° 20-127 DC, 20 janvier 1981, *Loi renforçant la sécurité et protégeant la liberté des personnes.*

Pour rappel, l'accessibilité et l'intelligibilité de la loi constitue un objectif de valeur constitutionnelle depuis 1999 rattaché aux articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration de 1789.

→ Cons. const., déc. n° 99-421 DC, 16 décembre 1999, *Loi portant habilitation du Gouvernement à procéder, par ordonnances, à l'adoption de partie législative de certains codes*.

Cette exigence de clarté de la loi a conduit le Conseil constitutionnel à prononcer l'inconstitutionnalité de dispositions législatives qui étaient en contrariété avec le principe de légalité des délits et des peines. Ces dispositions comportaient une définition de harcèlement sexuel insuffisamment claire, les éléments constitutifs n'étaient pas suffisamment définis.

→ Cons. const., déc. n° 2012-240 QPC, 4 mai 2012, *M. Gérard D. [Définition du délit de harcèlement sexuel].*

2.2. Le principe de nécessité des peines

La nécessité des peines signifie que les peines prononcées doivent être proportionnées à la gravité des infractions que la loi sanctionne, et émane aussi de l'article 8 de la Déclaration de 1789, ainsi que de son article 16.

Le législateur est compétent pour apprécier la nécessité des peines attachées aux infractions, le Conseil constitutionnel s'assure :

« De l'absence de disproportion manifeste entre l'infraction et la peine encourue » (Cons. const., déc. n° 2011-217 QPC, 3 février 2012, *M. Mohammed Akli B. à propos d'un délit d'entrée ou de séjour irrégulier en France).*

Pour autant, le Conseil constitutionnel a considéré qu'une sanction qui présenterait un caractère insuffisamment sévère ne constitue pas une méconnaissance du principe de proportionnalité des peines.

→ Cons. const., déc. n° 2019-795 DC, 20 décembre 2019, *Loi de financement de la Sécurité sociale pour 2020.*

Le Conseil constitutionnel a également affirmé que :

« Le législateur ne saurait, sans méconnaître le principe de nécessité des délits et des peines, réprimer la seule intention délictueuse ou criminelle » (Cons. const., déc. n° 2017-625 QPC, 7 avril 2017, *M. Amadou S.*).

2.2.1. La prise en compte du temps écoulé depuis l'infraction : une déclinaison du principe de légalité des délits et des peines

Du principe de nécessité des peines découle, sur le fondement des articles 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens :

« Un principe selon lequel, en matière pénale, il appartient au législateur, afin de tenir compte des conséquences attachées à l'écoulement du temps, de fixer des règles relatives à la prescription de l'action publique qui ne soient pas manifestement inadaptées à la nature ou à la gravité des infractions » (Cons. const., déc. n° 2019-785 QPC, 24 mai 2019, *M. Mario S*.).

L'article 8 du Code pénal prévoit des délais de prescription de l'action publique qui varient en fonction de la catégorie d'infractions. Les crimes contre l'humanité sont quant à eux imprescriptibles.

2.2.2. Le principe de non bis in idem *: une déclinaison du principe de légalité des délits et des peines*

Le droit à ne pas être jugé ou puni deux fois est inscrit à l'article 4 du protocole n° 7 à la Convention européenne. Au moment de la ratification du protocole n° 7, la France a posé une réserve d'interprétation visant à ce que ces dispositions ne s'appliquent qu'à la matière pénale, permettant ainsi le cumul des procédures pénales et administratives.

À l'échelle conventionnelle, ce droit est également inscrit à l'article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi qu'à l'article 14 § 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Ce principe n'est pas expressément prévu par la Constitution.

Le Conseil constitutionnel a affirmé qu'il découle du principe de nécessité des délits et des peines :

> *« Qu'une même personne ne peut faire l'objet de plusieurs poursuites tendant à réprimer de mêmes faits qualifiés de manière identique, par des sanctions de même nature, aux fins de protéger les mêmes intérêts sociaux. Si l'éventualité que deux procédures soient engagées peut conduire à un cumul de sanctions, le principe de proportionnalité implique qu'en tout état de cause le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues »* (Cons. const., déc. n° 2021-953 QPC, 3 décembre 2021, *Société Specitubes à propos du cumul des poursuites pour violation d'une mise en demeure prononcée par le préfet en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement*).

La Cour européenne a affirmé en 2009 que les dispositions de l'article 4 du protocole n° 7 s'opposent au cumul des poursuites administratives et pénales pour les mêmes faits si la poursuite administrative relève de la matière pénale.

→ CEDH, 10 février 2009, *Zolotoukhine c. Russie*, n° 14939/03.

Le fait, pour un fonctionnaire, d'avoir été condamné pénalement, n'empêche pas le prononcé d'une mesure disciplinaire en réaction à cette condamnation.

Pour une illustration récente : un gendarme a été condamné pénalement pour des faits de harcèlement à l'encontre de son épouse, puis il a été radié par décret du président de la République de ses fonctions. Le Conseil d'État a considéré que la mesure de radiation était proportionnelle et que la gravité des faits pour lesquels le gendarme a été condamné pénalement était incompatible avec le devoir d'exemplarité d'un officier supérieur de la gendarmerie.

→ CE, 5 juin 2024, *M. A. c. ministre des Armées*, n° 492310.

2.2.3. Le principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère : une conséquence du principe de légalité des peines

Le principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère est une conséquence du principe de légalité des peines, se rattachant à l'article 8 de la Déclaration de 1789.

Cependant, lorsque des faits n'ont pas fait l'objet d'un jugement et qu'une loi pénale plus douce est entrée en vigueur, c'est la loi pénale moins sévère qui s'applique : il s'agit de la rétroactivité *in mitius*. Ce principe est actuellement consacré à l'article 112-1 du Code pénal.

À l'échelle conventionnelle, la Cour européenne des droits de l'homme a fait découler de l'article 7 § 1 de la Convention le principe de rétroactivité de la loi pénale moins sévère.

→ CEDH, 17 septembre 2009, *Scoppola c. Italie (n° 2),* n° 10249/03.

De plus, la Cour de justice de l'Union européenne a affirmé que :

> *« Le principe d'application rétroactive de la peine plus légère fait partie des traditions constitutionnelles communes aux États membres »* (CJUE, 3 mai 2005, *Berlusconi et autres*, n° C-387/2).

L'appréciation du caractère moins sévère d'une loi pénale se fait à l'aune de la réduction du champ de l'infraction ou du *quantum* de peine qu'elle prévoit.

2.3. Le principe d'individualisation des peines

Rattaché à l'article 8 de la Déclaration de 1789, le principe d'individualisation des peines implique que le juge tienne compte des circonstances propres à chaque espèce pour le prononcé d'une peine. Selon les termes du Conseil constitutionnel, ce principe *« s'impose dans le silence de la loi »*.

→ Cons. const., déc. n° 2007-553 DC, 3 mars 2007, *Loi relative à la prévention de la délinquance.*

Dès lors, le principe de l'individualisation des peines entraîne l'impossibilité des peines automatiques qui ne permettent pas un pouvoir d'appréciation du juge.

Toutefois, ce principe ne suppose pas que le juge doive déterminer la peine exclusivement en fonction de la personnalité de l'auteur de l'infraction selon le Conseil constitutionnel.

→ Cons. const., déc. n° 2007-554 DC, 9 août 2007, *Loi renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs.*

2.4. L'obligation de motivation des peines

L'obligation de motivation des peines est une conséquence du principe d'individualisation des peines.

L'article 485 du Code de procédure pénale prévoit qu'un jugement doit contenir des motifs et un dispositif, et que ces « motifs constituent la base de la décision ».

Qui plus est, l'article 593 du même Code dispose que :

> *« Les arrêts de la chambre de l'instruction, ainsi que les arrêts et jugements en dernier ressort sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas des motifs ou si leurs motifs sont insuffisants et ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle et de reconnaître si la loi a été respectée dans le dispositif. »*

2.5. Le principe de responsabilité du fait propre de la personne

Le Code de procédure pénale prévoit en son article 121-1 que :

> *« Nul n'est responsable pénalement que de son propre fait. »*

Il s'agit d'un principe à valeur constitutionnelle résultant des articles 8 et 9 de la Déclaration de 1789.

→ Cons. const., déc. n° 99-411 DC, 16 juin 1999, *Loi portant diverses mesures relatives à la sécurité routière et aux infractions sur les agents exploitants de réseau de transport public de voyageurs.*

Si le principe de responsabilité personnelle existe, cela n'a pas pour objet d'exclure des peines aggravantes en cas de faits commis en réunion, qui constitue une circonstance aggravante n'impliquant pas l'instauration d'une responsabilité collective.

→ Cons. const., déc. n° 2010-604 DC, 25 février 2010, *Loi renforçant la lutte contre les violences de groupes et la protection des personnes chargées d'une mission de service public.*

Le Code pénal prévoit un régime de responsabilité pénale des personnes morales pour certaines infractions *« pour leur compte, par leurs organes ou représentants »*, à l'exclusion de l'État. Ce même article dispose d'un régime de responsabilité pénale spécifique pour les collectivités territoriales et leurs groupements.

3. Le principe d'irresponsabilité pénale en cas d'abolition du discernement

L'article 122-1 du Code pénal prévoit qu'une personne atteinte d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au moment de la commission des faits délictuels ou criminels n'est pas pénalement responsable.

Ce même article fait la distinction entre l'abolition du discernement et l'altération du discernement.

La responsabilité civile est maintenue lorsque l'altération ou l'abolition du discernement est retenue.

Une loi de 2022 a ajouté au Code pénal l'article 122-1-1 qui dispose que l'abolition temporaire du discernement ne peut être retenue en cas de consommation volontaire de substances psychoactives *« dans le dessein de commettre l'infraction ou une infraction de même nature ou d'en faciliter la commission ».*

POUR ALLER PLUS LOIN

La loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic a fait couler beaucoup d'encre. En effet, de nombreux avocats ont exprimé leurs inquiétudes quant aux conséquences de cette loi sur les garanties fondamentales en matière pénale, comme Maître Julie Couturier, présidente du Conseil national des barreaux, qui a exprimé le fait que la lutte contre le trafic de stupéfiants devait se faire dans le respect des droits de la défense et de l'État de droit.

Le 12 juin 2025, le Conseil constitutionnel a contrôlé la constitutionnalité de la loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic. 32 articles ont été déclarés conformes à la Constitution qui comportent, notamment, comme dispositions l'activation à distance d'appareils électroniques fixes et mobiles pour enregistrer l'image et le son afin de lutter contre la criminalité organisée, ainsi que la prolongation exceptionnelle de la garde à vue pour certaines infractions liées aux trafics de stupéfiants.

De plus, le Conseil constitutionnel a censuré totalement ou partiellement 6 articles dont l'article 40 relatif au « dossier coffre » que le Conseil a jugé contraire aux droits de la défense, ainsi que l'article 56 qui prévoyait le seul recours à la visioconférence pour la comparution des personnes qui sont en quartier de lutte contre la criminalité organisée notamment. Enfin, il a formulé plusieurs réserves d'interprétation.

POUR S'ENTRAÎNER

Argumentation juridique : Soutenez que la médiatisation des affaires judiciaires porte atteinte aux garanties fondamentales en matière pénale.

Le système judiciaire inique de l'Ancien régime était vivement critiqué par les Lumières, dont Beccaria représente une figure incontournable. La Révolution française marque un tournant important pour la reconnaissance des garanties fondamentales en matière pénale.

Plusieurs garanties fondamentales en matière pénale ont été inscrites dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; il faudra cependant attendre avant que ces principes soient effectifs en droit positif. Actuellement, le droit international et européen des droits humains, à travers un éventail de conventions, porte une considération particulière pour le respect des garanties fondamentales en droit pénal.

Le XXIe siècle est marqué par une accélération croissante de l'information au moyen de supports numériques supplantant les sources d'informations traditionnelles, les chaînes d'informations en continu et les réseaux sociaux ont fait évoluer la diffusion de l'information, dont celle des affaires judiciaires.

La médiatisation des affaires judiciaires et son encadrement juridique s'inscrivent en démocratie libérale dans un sensible équilibre entre le respect de la liberté d'expression et le respect des droits de la défense. Cette médiatisation inclut un enjeu crucial qui réside dans la libération de la parole des victimes, notamment dans des matières dont le traitement judiciaire est souvent insuffisant, tels que pour le traitement judiciaire des violences faites aux mineurs et des violences faites aux femmes (des traitements lacunaires récemment reconnus par plusieurs arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme).

Problématique et annonce de plan : La médiatisation des affaires judiciaires est juridiquement justifiée sous plusieurs aspects **(I)**, mais il est indispensable qu'elle préserve les garanties fondamentales en matière pénale, un bouclier de l'État de droit **(II)**.

I. Une médiatisation indispensable à une société démocratique

A. La liberté d'expression au fondement de la démocratie libérale

La liberté d'expression est consacrée dans plusieurs grands textes (article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, article 10 de la Convention européenne, article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques).

La médiatisation des affaires judiciaires contribue à la transparence de la justice, l'opacité totale des affaires judiciaires étant l'apanage des régimes illibéraux.

B. La liberté d'expression dans le cadre d'un débat d'intérêt général

Exemple de mise en balance de la présomption d'innocence avec une telle médiatisation : à propos de la diffusion du film « Grâce à dieu » qui traite d'accusations de violences sexuelles commises par un prêtre mis en examen : le 6 janvier 2021, la Cour de cassation opère un contrôle de proportionnalité en prenant en compte divers éléments (reprenant la méthode de la Cour européenne dans l'affaire *Bédat contre Suisse* rendu en 2016) et dit que la suspension du film avant jugement n'était pas nécessaire.

La médiatisation d'affaires judiciaires permet de contribuer à des débats juridiques sur le traitement pénal de certaines infractions (Exemple de l'affaire des viols de Mazan qui a eu un retentissement mondial, mettant en lumière l'ampleur des violences faites aux femmes).

II. Une médiatisation parfois délétère pour les droits de la défense

A. Une médiatisation source de remise en cause des garanties procédurales

La forte exposition médiatique d'affaires judiciaires mène souvent à des entorses au principe de la présomption d'innocence (art. 9 Déclaration de 1789), qui perd de plus en plus de sa substance.

Dans sa liste des critères de l'État de droit, la Commission de Venise inclut la présomption d'innocence comme *« élément essentiel du droit à un procès équitable »* et mentionne *« certains faiseurs d'opinions, comme les médias »*.

Certains juristes dénoncent l'existence d'un « tribunal médiatique » en dehors des prétoires.

L'article 35 *ter* de la loi de 1881 relative à la liberté d'expression prévoit qu'il est puni de *« soit de réaliser, de publier ou de commenter un sondage d'opinion, ou toute autre consultation, portant sur la culpabilité d'une personne mise en cause à l'occasion d'une procédure pénale ou sur la peine susceptible d'être prononcée à son encontre »* (rattacher avec la pratique du *« live-tweet »*).

Le même article punit la diffusion d'images d'une personne identifiée ou identifiable portant des menottes ou de sa détention provisoire sans son accord (dispositions insérées par la loi du 15 juin 2000).

Dans un arrêt du 20 février 2007, la chambre criminelle de la Cour de cassation affirme que la liberté d'expression peut être restreinte pour faire respecter le principe de la présomption d'innocence.

Les émotions que suscite la forte exposition médiatique d'affaires en matière pénale mène régulièrement à une remise en cause du rôle des avocats de la défense dans le débat public, compromettant ainsi un principe fondamental des droits de la défense.

Plusieurs affaires qui ont été surexposées médiatiquement ont mené à des catastrophes judiciaires (exemple de l'affaire d'Outreau ; une Commission d'enquête parlementaire a rendu un rapport en 2006 qui évoque la pression médiatique excessive à propos de cette affaire).

B. Une médiatisation source de remise en cause des garanties entourant la peine

La forte exposition médiatique de certaines affaires mène également à une remise en cause du principe de l'irresponsabilité pénale (exemple de l'affaire de Sarah Halimi et de la modification de l'article 122-1-1du Code pénal en 2022).

La médiatisation des affaires judiciaires donne souvent lieu à des discours visant à vouloir instaurer des peines automatiques, au détriment du principe d'individualisation des peines.

Enfin, la liberté d'expression justifie la médiatisation d'affaires judiciaires. Cependant, les carences de l'encadrement de cette médiatisation mènent à des remises en cause des garanties fondamentales en matière pénale et donne lieu à un « populisme pénal », peut perturber le travail des acteurs de la justice et donne lieu à beaucoup de désinformations des règles juridiques en matière pénale.

Fiche nº 33 - LE DROIT À LA VIE PRIVÉE

POINTS CLÉS

- Notion « attrape-tout ».
- Lecture souple et large.
- Jurisprudence européenne marquée par l'effectivité et l'évolution constante.
- Une constitutionnalisation tiraillée entre liberté individuelle et personnelle.
- Double portée, intime et sociale, du droit au respect de la vie privée.

PRINCIPALES RÉFÉRENCES

- Article 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
- Article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.
- Article 7 de la Charte des droits fondamentaux.
- CEDH, 22 octobre 1981, Dudgeon c. Royaume-Uni, nº 7525/76.
- CEDH, 29 avril 2002, *Pretty c. Royaume-Uni, nº 2346/02.*
- CEDH, 13 février 2003, *Odievre c. France*, nº 42326/98.
- *CEDH, 16 décembre 1992, Niemietz c. Allemagne, nº 13710/88.*
- CEDH, 19 janvier 2021, X te Y c. Roumanie, nº 2145/16.
- *CEDH, Kyrtatos c. Grèce, 22 mai 2003, nº 41666/98.*
- *Cons. const, décision nº 2004-492 DC du 2 mars 2004.*

1. L'affirmation générale du libre choix de la vie privée

Constitutionnalisé en droit français au terme d'un parcours semé d'embûches, le droit au respect de la vie privée trouve une consécration claire dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Convention européenne des droits de l'homme et la Charte des droits fondamentaux.

→ Cons const., déc. nº 99-416, 23 juillet 1999, *Loi portant création d'une couverture maladie universelle.*

→ Art. 17 PIDCP.

→ Art. 8 CESDH.

→ Art. 7 CDFUE.

En vertu de l'article 8 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, sous réserve des restrictions prévues par la loi et nécessaires, dans une société démocratique, à la protection des valeurs suivantes :

- Sécurité nationale.
- Sûreté publique.
- Défense de l'ordre.
- Protection des droits et des libertés d'autrui.
- Protection de la santé ou de la morale.
- Prévention des infractions pénales.
- Bien-être économique du pays.

En droit interne, le Conseil constitutionnel soumet les atteintes au droit au respect de la vie privée à des exigences de proportionnalité théoriquement rigoureuses. Toutefois, dans la pratique, le contrôle exercé par le juge se limite à vérifier l'absence d'une erreur manifeste.

Le respect de la vie privée est consacré par le Code civil et reconnu comme une liberté fondamentale au sens du référé-liberté.

→ Art. 9 du Code civil.

→ Art. L. 521-2 du Code de justice administrative.

→ CE, ord., 25 octobre 2007.

La capacité de déterminer librement sa vie personnelle manifeste l'existence d'une sphère privée échappant aux ingérences des pouvoirs publics. La Cour européenne des droits de l'homme a indiqué que la notion d'autonomie personnelle constitue un principe fondamental guidant l'interprétation des garanties de l'article 8, en reconnaissant le droit de chacun de faire des choix essentiels relatifs à la conduite de sa propre existence.

→ CEDH, 29 avril 2002, *Pretty c. Royaume-Uni.*

POUR ALLER PLUS LOIN

En France, le droit au respect de la vie privée s'est longtemps trouvé tiraillé entre la liberté individuelle et la liberté personnelle, suscitant selon les cas l'intervention, ou non, du juge judiciaire pour en assurer la protection. La doctrine, non sans hésitation, avait inféré son rattachement à la liberté individuelle à partir de la jurisprudence du Conseil constitutionnel des années 1970. Toutefois, cette construction fut bouleversée par les contradictions apparues dans les décisions du juge constitutionnel durant les années 1990. En 1999, le Conseil constitutionnel opère une clarification décisive, en rattachant le respect de la vie privée à la liberté proclamée par l'article 2 de la Déclaration de 1789, le distinguant ainsi de la notion de sûreté. Cette solution est désormais consacrée : le respect de la vie privée est pleinement détaché de l'article 66 de la Constitution. Il reste que plusieurs conceptions du droit au respect de la vie privée coexistent en droit français et en droit européen. Qualifiée de « folle du logis » conventionnelle, la protection de la vie privée est fréquemment mobilisée par la Cour de Strasbourg pour garantir, de manière large et indirecte, d'autres droits. À rebours de cette approche expansive consacrée par l'article 8 de la Convention, l'article 9 du Code civil se limite, quant à lui, à une protection centrée sur les seules atteintes à l'intimité de la vie privée.

1.1. La dimension personnelle du droit au respect de la vie privée

Dans la conception européenne libérale, plus les aspects de la vie privée touchent la sphère personnelle de l'individu, plus les ingérences de l'État doivent être rigoureusement limitées. En droit de la Convention, le droit au respect de la vie privée a connu une importante extension de son champ d'application dans la mesure où la Cour européenne a mobilisé l'article 8 pour assurer un droit au respect de l'identité aux multiples facettes.

1.1.1. Respect de l'identité

• Nom et prénom. Bien qu'ayant une dimension familiale, le nom de famille est rattaché à la vie privée en raison de son rôle dans l'identification et l'individualisation de la personne. Ainsi, l'attribution du nom relève du champ d'application de l'article 8 de la CEDH.

→ CEDH, 22 février 1994, *Burghartz c. Suisse.*

Une grande marge d'appréciation est néanmoins laissée aux États, qui sont les mieux placés pour apprécier la situation.

→ CEDH, 25 novembre 1994, *Stjerna c. Finlande.*

Il en est de même pour le prénom tant pour le choix que son utilisation.

→ CEDH, 24 octobre 1996, *Guillot c. France.*

• Intégrité physique et morale. La protection de la vie privée s'étend parfois à l'intégrité physique et morale de la personne, ainsi qu'au droit à la santé.

→ CEDH, 9 juin 1998, *McGinley et Egan c. Royaume-Uni.*

Un traitement ne présentant pas un degré de gravité suffisant pour relever de l'article peut néanmoins nuire à l'intégrité physique et morale de manière à enfreindre l'article 8.

→ CEDH, 6 février 2001, *Bensaid c. Royaume-Uni.*

La vaccination obligatoire constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie privée, mais elle satisfait les conditions de légitimité et n'est donc pas contraire à l'article 8.

→ CEDH, 8 avril 2021, *Vavricka c. République tchèque.*

Au nom du principe d'autonomie personnelle, un individu peut décider du moment et de la manière dont sa vie doit prendre fin. Cependant, cela n'implique pas que l'État soit tenu de garantir l'accès à des substances mortifères.

→ CEDH, 20 janvier 2011, *Haas c. Royaume-Uni.*

• Nationalité et ethnie. La notion de vie privée inclut le droit pour l'individu de voir respecté ce qui constitue son identité, comme l'a reconnu le juge administratif en ce qui concerne la nationalité. Ainsi, un décret portant déchéance de nationalité affecte un élément constitutif de l'identité et est susceptible de porter atteinte au droit au respect de sa vie privée, justifiant un contrôle entier de proportionnalité.

→ CE, 8 juin 2016, n° 393348.

L'identité ethnique est un élément important de la vie privée aux yeux de la Cour européenne des droits de l'homme.

→ CEDH, 27 avril 2010, *Ciubotaru c. Moldavie.*

POUR ALLER PLUS LOIN

Qu'en est-il des étrangers ? La Cour de Strasbourg a élargi la protection de certains droits garantis par la Convention à des domaines qui n'y sont pas expressément prévus. La jurisprudence relative à l'article 8 de la Convention illustre cette évolution, prenant en compte des préoccupations humanitaires. Bien que les étrangers ne bénéficient pas d'une protection générale et directe, l'idée d'une protection dite « par ricochet » s'impose désormais. Le droit au respect de la vie privée et, surtout familiale, est fréquemment invoqué par des étrangers faisant l'objet d'une mesure d'éloignement ou de refoulement. Cette dynamique est facilitée par une interprétation large de la notion de famille, bien que la jurisprudence européenne semble aujourd'hui plus restrictive. En effet, les juges précisent que la notion de vie familiale, dans le contexte des étrangers, se limite au noyau familial. Le lien familial invoqué doit être réel et effectif. De plus, la famille polygame est exclue, Dans un souci didactique, il importe de distinguer la protection de la vie privée et celle de la vie familiale, même si dans de nombreuses affaires les deux protections sont envisagées simultanément.

1.1.2. La reconnaissance de l'identité

Concernant le droit d'accès aux origines personnelles, la jurisprudence européenne a suscité certaines incertitudes et a évolué de manière intéressante, bien que cette évolution demeure inachevée.

→ CEDH, 7 juillet 1989, *Gaskin c. Royaume-Uni.*

La Cour de Strasbourg semble reconnaître le droit à la connaissance de ses origines, mais se réfugie derrière la marge d'appréciation des États, rappelant notamment le principe de l'anonymat du donneur de sperme dans le cadre de l'insémination artificielle.

→ CEDH, 22 avril 1997, *X, Y et Z c. Royaume-Uni.*

Sans affirmer catégoriquement que ce droit constitue un droit fondamental, la Cour précise néanmoins que chaque individu doit avoir la possibilité de recueillir des informations concernant son identité.

→ CEDH, 7 février 2002, *Mikulic c. Croatie.*

Une tendance vers la reconnaissance du droit à la connaissance de ses origines se dessine. La Cour de Strasbourg admet l'applicabilité de l'article 8 dans une situation où une personne, désireuse de connaître son histoire personnelle au nom de la vérité biologique, se trouve dans l'incapacité d'accéder à ses origines et aux informations les concernant.

→ CEDH, 13 février 2003, *Odièvre c. France.*

L'arrêt Odièvre soulève une certaine ambiguïté : bien que la Cour ait reconnu l'applicabilité de l'article 8, elle conclut qu'il n'y a pas de violation par le législateur qui empêche l'action en recherche de maternité lorsque la mère biologique a demandé le secret. La question est délicate, car elle implique deux droits antagonistes : le droit de l'enfant à connaître ses origines et le droit de la mère à préserver le secret de la naissance.

La jurisprudence s'est par la suite affinée puisque la Cour de Strasbourg a reconnu la violation de l'article 8 en raison de l'impossibilité pour une personne d'obtenir l'analyse ADN de la dépouille de son père biologique présumé.

→ CEDH, 13 juillet 2006, *Jaggi c. Suisse.*

Dans une affaire portant sur l'impossibilité pour une personne abandonnée par sa mère de connaître ses origines, la Cour a conclu à une violation de l'article 8. Elle a estimé qu'un juste équilibre n'avait pas été trouvé entre les intérêts en présence, la législation n'offrant ni la possibilité à l'enfant adopté de demander des informations non identifiantes, ni la réversibilité du secret de naissance avec l'accord de la mère biologique.

→ CEDH, 29 septembre 2012, *Godelli c. Italie.*

1.1.3. Reconnaissance de l'identité

a. Minorités ethniques, religieuses, linguistiques.

La Cour de Strasbourg n'a pas hésité à reconnaître que la vie en caravane fait partie intégrante de l'identité tsigane. Les mesures concernant le stationnement affectent la capacité de maintenir cette identité et de mener une vie privée conforme à cette tradition.

→ CEDH, 18 janvier 2001, *Chapman c. Royaume-Uni.*

Mais si l'interdiction de stationnement constitue une ingérence de l'État, la Cour juge que celle-ci était justifiée. Il reste que les États ont une obligation positive de permettre aux minorités de poursuivre leur mode de vie.

L'expulsion des gens du voyage des terrains où ils étaient établis depuis longtemps constitue ainsi une violation de leur droit au respect de la vie privée, et de leur domicile.

→ CEDH, 17 octobre 2013, *Wintestein c. France.*

b. Minorités sexuelles et de genre.

Au sujet de personnes transgenres dont les demandes de reconnaissance de l'identité sexuelle avaient été rejetées au motif qu'elles n'avaient pas subi d'intervention chirurgicale, la Cour européenne a estimé que l'État avait porté une atteinte injustifiée au droit au respect de la vie privée.

→ CEDH, 19 janvier 2021, *X et Y c. Roumanie.*

En effet, les autorités nationales avaient placé les requérants, qui ne souhaitaient pas une intervention chirurgicale de conversion sexuelle, face à un dilemme : subir malgré eux l'intervention ou renoncer à la reconnaissance de leur identité sexuelle qui relèvent du droit au respect de la vie privée.

1.2. L'intimité et la liberté sexuelle

Le droit à l'épanouissement personnel consacré par l'article 8 de la Convention implique le droit d'entretenir des rapports avec d'autres êtres humains, y compris en matière de relations sexuelles qui est l'un des aspects les plus intimes de la sphère privée.

→ CEDH, 17 février 1995, *KA et AD / Belgique.*

1.2.1. Respect de la vie et de l'orientation sexuelles

La vie et l'orientation sexuelle font partie de la vie privée au sens de l'article 8.

→ CEDH, 26 mars 1985, *X et Y c. Pays-Bas.*

Le principe de liberté de la vie sexuelle est affirmé même s'il existe des limites tenant par exemple à la publicité de certains comportements sexuels, l'exercice de la contrainte ou la réalité d'un danger pour les personnes

→ CEDH, 19 février 1997, *Laskey c. Royaume-Uni.*

Sous ces réserves, chacun a le droit de mener la vie sexuelle de son choix en conformité avec son identité profonde.

→ CEDH, 27 septembre 1999, *Smith c. Royaume-Uni.*

Les minorités sexuelles sont protégées : toute répression pénale contre des comportements homosexuels en privé entre adultes consentants est contraire à l'article 8 et il importe peu que cela puisse éventuellement choquer une partie de la population.

→ CEDH, 22 octobre 1981, *Dudgeon c. Royaume-Uni.*

1.2.2. Droit au mariage et égalité

Le mariage est protégé à la fois par la Convention dans son article 12 et par le Protocole n° 7 dans son article 5. Cette double protection, traduisant le souci de l'égalité des sexes, s'avère utile au regard de la Convention, dans la mesure où les droits des époux ne sont pas visés.

De fortes, et légitimes, revendications d'un droit au mariage au profit de personnes de même sexe se sont exprimées ces dernières décennies, faisant valoir le principe d'égalité.

a. Mariage entre personnes homosexuelles du même sexe.

En l'état de la jurisprudence, la Convention ne paraît pas pouvoir fonder la revendication d'un droit au mariage homosexuel, la marge d'appréciation reconnue aux États restant importante.

→ CEDH, 10 mai 2001, *Mata Estevez c. Espagne.*

Mais la Cour, en consacrant un droit à l'adoption plénière au profit des célibataires dans le cadre d'une adoption internationale, semble avoir ouvert la porte à la reconnaissance des mariages homosexuels contractés à l'étranger

→ CEDH, 28 juin 2007, *Wagner c. Luxembourg.*

Cependant, dans la mesure où aucun consensus ne se dégage parmi les États membres sur le mariage homosexuel, la Cour de Strasbourg reconnaît que les autorités nationales sont mieux placées pour apprécier les besoins sociaux en la matière, le mariage ayant des connotations culturelles profondément ancrées qui diffèrent d'une société à l'autre.

b. Mariage des personnes transsexuels.

La jurisprudence a évolué dans un sens libéral. La Cour européenne juge désormais que les États contractants ont l'obligation positive d'assurer l'exercice du droit au mariage aux transsexuels : si le texte vise le droit pour un homme et une femme de se marier, la Cour estime que, compte tenu de l'évolution de la société et des progrès de la médecine, il n'est plus possible de continuer à penser que ces termes impliquent que le sexe doive être déterminé selon des critères purement biologiques.

→ CEDH, 11 juillet 2002, *Goodwin c. Royaume-Uni.*

1.2.3. Le caractère évolutif et effectif du droit des libertés

Les relations homosexuelles durables relèvent de la vie privée et toute exclusion fondée sur l'orientation sexuelle constitue une violation de l'article 8 de la Convention.

→ CEDH, 27 septembre 1999, *Lustig-prean c. Royaume-Uni.*

La non-reconnaissance juridique des couples de même sexe porte ainsi atteinte à l'article 8 de la Convention : si les États ne sont pas tenus d'ouvrir le mariage aux personnes de même sexe, ils doivent néanmoins leur offrir un statut légal.

→ CEDH, 21 juillet 2015, *Oliari c. Italie.*

L'arrêt *Goodwin* rendu par la Grande chambre à l'unanimité en 2002 a marqué un changement notable dans sa jurisprudence relative au statut juridique des transsexuels : les États ont désormais l'obligation positive de reconnaître juridiquement la conversion sexuelle et leur marge d'appréciation est limitée aux moyens à mettre en œuvre pour assurer cette reconnaissance. Il s'agit d'une illustration significative du caractère évolutif et effectif de cet instrument vivant qu'est la Convention, laquelle prend en compte les évolutions de la société.

1.3. Droit à la réputation

Le droit à la réputation entre dans le champ d'application de la protection de la vie privée.

→ CEDH, 6 novembre 2019, *Del Campo c. Espagne.*

La Cour de Strasbourg protège le droit à la réputation sur la base de l'article 8, estimant que la réputation d'une personne constitue une partie de son identité personnelle et psychique.

→ CEDH, 15 décembre 2007, *Pfeifer c. Autriche.*

En France, la protection de la réputation est assurée en premier lieu par le droit pénal tandis que les règles de droit civil complètent l'interdiction de la diffamation et des infractions considérées comme contraires aux valeurs morales et sociales communément admises.

→ Art. 29 de la loi de 1881.

→ Art. R 621-1 du Code pénal.

Le droit à l'image fonde une protection lorsque la reproduction de l'image d'une personne porte atteinte à sa dignité ou jette le discrédit sur celle-ci, compromettant sa réputation.

→ Cass, civ. 1re, 16 juillet 1998.

Cette facette de la protection du droit à la vie privée risque de prendre une nouvelle dimension avec l'essor de l'intelligence artificielle et des *deepfakes* à caractère sexuel.

2. Le droit aux secrets

L'adage « ne rien avoir à cacher », ne signifie pas qu'on souhaite tout montrer pour autant. À l'ère du numérique et du capitalisme de surveillance, il est plus que jamais essentiel de préserver la possibilité de tenir certains propos et exprimer ses opinions à l'abri des regards intrusifs du public, du pouvoir… et des algorithmes.

2.1. Le secret des correspondances

Le pouvoir de surveiller secrètement les citoyens ne peut être admis qu'à la condition d'être strictement nécessaire à la sauvegarde des institutions démocratiques et encadré par des garanties adéquates.

→ CEDH, 6 septembre 1978, *Klass et a. c. Allemagne.*

Une vigilance accrue est requise, qu'il s'agisse de la correspondance écrite ou des communications par télécommunications. L'État ne doit pas se contenter de ne pas interférer avec le droit garanti par l'article 8 : il lui incombe également une obligation positive de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour prévenir toute atteinte à ce droit.

→ CEDH, 17 juillet 2003, *Craxi c. Italie.*

Toutes les formes de communication sont protégées, quelle que soit leur nature.

→ CEDH, 22 octobre 2002, *Taylor-Sabori c. Royaume-Uni.*

La correspondance des avocats bénéficie d'une protection particulière, en raison de leur rôle essentiel dans le fonctionnement de toute société démocratique.

→ CEDH, 12 février 2015, *Yuditskaya c. Russie.*

La saisie de documents et données informatiques dans un cabinet d'avocats ne viole pas l'article 8 de la Convention dès lors que des garanties procédurales adéquates permettent de prévenir les abus et de protéger le secret professionnel.

→ CEDH, 3 septembre 2015, *Sérvulo & Associados c. Portugal.*

La Cour de Strasbourg admet le principe des écoutes téléphoniques, à condition que l'ingérence soit nécessaire dans une société démocratique pour la sécurité nationale, la défense de l'ordre ou la prévention des infractions pénales.

→ CEDH, 6 septembre 1978, *Klass et a. c. Allemagne.*

Les modalités d'exercice de ces pouvoirs doivent être définies avec clarté et précision.

→ CEDH, 24 avril 1990, *Huvig c. France.*

Si les interceptions peuvent se justifier par la lutte contre le terrorisme, elles doivent impérativement être encadrées par des garanties solides afin d'éviter toute dérive arbitraire. L'enregistrement des conversations au parloir d'une prison est une ingérence contraire à l'article 8, lorsque la législation ne précise pas de manière suffisante la possibilité d'une telle ingérence ni les conditions de son exercice.

→ CEDH, 20 décembre 2005, *Wisse c. France.*

Les sonorisations, à l'instar des écoutes téléphoniques, sont une atteinte au droit au respect de la vie privée : elles ne sont admissibles que si elles reposent sur une base légale claire et détaillée, conforme aux exigences classiques encadrant l'ingérence étatique.

→ CEDH, 31 mai 2005, *Vetter c. France.*

Elles concernent tant la protection de la correspondance que celle du domicile. Ainsi, la condamnation fondée sur des preuves recueillies lors d'une surveillance secrète au domicile constitue une violation de l'article 8 de la Convention.

→ CEDH, 16 juillet 2002, *Armstrong c. Royaume-Uni.*

2.2. Le salarié

La Cour européenne adopte une conception large de la vie privée incluant sa dimension sociale. L'article 8 protège non seulement le droit à l'identité et au développement personnel, mais aussi la faculté pour chacun d'entretenir des relations avec le monde extérieur. Le lieu d'exercice des activités professionnelles s'inscrit dans cette dynamique, justifiant l'extension de l'article 8 de la Convention européenne à ces activités.

→ CEDH, 16 décembre 1992, *Niemietz c. Allemagne.*

Dès lors que des restrictions à la vie professionnelle affectent la manière dont une personne construit son identité sociale à travers ses relations interpersonnelles, le droit d'exercer une activité professionnelle entre dans le champ de la vie privée protégée par l'article 8.

→ CEDH, 28 mai 2009, *Bigaeva c. Grèce.*

Une ingérence dans la vie privée d'un salarié peut néanmoins être admise, en particulier s'il s'agit de répondre à un impératif de sécurité ou protéger les droits d'autrui au sein d'une entreprise, comme les tests de détection d'alcool ou de drogue.

→ CEDH, 7 novembre 2002, *Madsen c. Danemark.*

2.3. Le droit de s'opposer aux publications portant atteinte à l'intimité

La publication par la presse de photographies montrant une personne publique, seule ou accompagnée, dans le cadre de sa vie quotidienne, relève de sa vie privée.

→ CEDH, 24 juin 2004, *Von Hannover c. Allemagne.*

Tout en délimitant les contours du droit au respect de la vie privée face à un autre droit garanti par la Convention – la liberté d'expression –, la Cour rappelle que la protection de la vie privée s'étend même aux espaces publics.

→ CEDH, 11 janvier 2005, *Sciaccia c. Italie.*

Toute personne, y compris une personnalité publique, doit pouvoir bénéficier d'une « espérance légitime » de respect de sa vie privée. Mais malgré l'apparente continuité des critères jurisprudentiels, la Cour semble avoir opéré un certain repli dans la protection accordée à la vie privée ces dernières années.

→ CEDH, 7 février 2012, *Von Hannover II c. Allemagne.*

En toute hypothèse, les États demeurent investis d'obligations positives visant à garantir le respect de la vie privée. L'image d'une personne constitue un élément fondamental de son développement personnel et un attribut essentiel de sa personnalité.

La Cour a ainsi souligné que le droit à la protection de l'image implique, avant tout, que l'individu puisse en conserver la maîtrise.

→ CEDH, 15 janvier 2009, *Reklos et Davourlis c. Grèce.*

Le droit à l'image comprend donc la faculté de s'opposer non seulement à la diffusion, mais aussi à la captation, à la conservation et à la reproduction de son image.

→ CEDH, 13 octobre 2015, *Bremner c. Turquie.*

Actualité jurisprudentielle. - Le secret médical demeure protégé après le décès

Le secret médical constitue une garantie essentielle du respect de la vie privée et couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance des professionnels de santé, sauf dérogation expressément prévue par la loi.

La Cour de cassation a jugé en 2025 que le rapport d'autopsie d'un salarié décédé à la suite d'un accident du travail demeure couvert par le secret médical. Il ne peut donc être communiqué à l'employeur au seul motif que celui-ci souhaite contester la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident.

La protection du secret médical doit ainsi être conciliée avec le principe du contradictoire sans que celui-ci permette, à lui seul, d'obtenir communication d'informations médicales protégées.

⟶ Cass. 2e civ., 3 avril 2025, n° 22-22.634, publié au Bulletin.

À retenir. - Le décès ne fait pas disparaître le secret médical. L'accès aux informations relatives au défunt demeure limité aux personnes et aux hypothèses prévues par la loi.

3. Lieux spécifiques et respect du droit à la vie privée

La protection de la vie privée trouve à s'appliquer dans des lieux où l'individu exerce son autonomie et son intimité. Ces espaces, qu'ils soient physiques ou numériques, deviennent des zones de cristallisation des atteintes potentielles aux droits fondamentaux.

Le domicile, l'environnement et l'espace numérique forment ainsi trois sphères où le droit s'efforce d'assurer un équilibre entre libertés individuelles et impératifs collectifs.

3.1. Le domicile : l'inviolabilité

Le domicile occupe historiquement une place centrale dans la protection de la vie privée. Il est le refuge de l'intimité à l'abri des intrusions arbitraires. Affirmée par la jurisprudence constitutionnelle et encadrée par des

règles de procédure, son inviolabilité connaît toutefois des exceptions, justifiées par la gravité de certaines infractions et les nécessités d'enquête.

3.1.1. L'affirmation constitutionnelle du principe

Initialement rattachée à l'article 66 de la Constitution, la protection du domicile est fondée en droit français sur les articles 2 et 4 de la Déclaration de 1789.

→ Cons. const., déc. n° 83-164 DC, 29 décembre 1983, *Loi de finances pour 1984.*

→ Cons. const., déc. n° 2013-674 DC, 4 décembre 2013, *Loi relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière.*

Le principe selon lequel l'autorisation d'un magistrat du siège est requise pour toute intrusion dans un domicile a été réaffirmé.

→ Cons. const., déc. n° 2019-778 DC, 21 mars 2019, *Loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.*

L'inviolabilité est plus ou moins étendue selon la nature du lieu et la période de la journée : le droit commun interdit les perquisitions entre 21 heures et 6 heures, sauf exception légale.

→ Art. 59 du Code de procédure pénale

3.1.2. Régimes dérogatoires : perquisitions de nuit, infractions graves, et lieux non résidentiels

La possibilité de perquisitions de nuit a été étendue (avec autorisation du Juge des libertés et de la détention à la requête du parquet) dans les cas d'enquêtes de flagrance, mais aussi en enquête préliminaire, hors locaux d'habitation.

Ces dérogations ont été validées par le Conseil constitutionnel à condition de garanties strictes : décision écrite et motivée, contrôle judiciaire, nullité en cas de détournement.

→ Loi du 9 mars 2004.

→ Cons. const, déc. n° 2004-492 DC, 2 mars 2004, *Loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité.*

Le Conseil constitutionnel a aussi rappelé que le procureur ne peut autoriser une intrusion domiciliaire sans encadrement précis, même de jour. De jour, le consentement exprès est requis, sauf en cas de flagrance ou autorisation judiciaire.

→ Art. 76 du Code de procédure pénale.

→ Cons. const., déc. n° 2019-778 DC, 21 mars 2019, *Loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.*

3.1.3. Dispositifs spécifiques : professions protégées et technologies intrusives

Les perquisitions chez les avocats, médecins, notaires, huissiers sont strictement encadrées : elles doivent être effectuées par un magistrat, en présence du bâtonnier (ou équivalent), sur décision écrite précisant leur objet.

→ Loi du 7 avril 1997.

L'inviolabilité du domicile s'étend aux dispositifs de géolocalisation, lorsqu'ils nécessitent une intrusion dans un lieu d'habitation : une autorisation judiciaire est alors obligatoire.

→ Art. 230-34 et 230-35 du Code de procédure pénale.

→ Cons. const., déc. n° 2014-693 DC, 25 mars 2014, *Loi relative à la géolocalisation.*

La protection constitutionnelle du domicile s'est réduite aux lieux d'habitation, contrairement à l'approche plus large de la Cour européenne des droits de l'homme qui intègre aussi les lieux professionnels dans la notion de domicile.

→ CEDH, *Nimietz c. Allemagne*, 1992.

→ Cons. const, déc. n° 2016-552 QPC, 8 juillet 2016, *Société Brenntag [Droit de communication de documents des agents des services d'instruction de l'Autorité de la concurrence et des fonctionnaires habilités par le ministre chargé de l'économie].*

3.2. L'environnement : le droit de vivre dans un environnement sain

Si la Convention européenne ne consacre pas expressément un droit à l'environnement, la Cour a progressivement intégré les enjeux environnementaux dans sa jurisprudence.

→ CEDH, 22 mai 2003, *Kyrtatos c. Grèce.*

La dégradation de l'environnement peut compromettre l'exercice effectif de certains droits garantis par la Convention. Plusieurs dispositions peuvent être mobilisées à cette fin – notamment les articles 2 et 3 –, mais c'est l'article 8 qui joue un rôle central.

Garantissant le respect de la vie privée ainsi que du domicile, cet article permet d'appréhender les atteintes environnementales qui affectent directement et substantiellement la sphère personnelle des individus. Ainsi, des nuisances graves – comme le bruit ou la pollution – peuvent justifier une intervention sous l'angle de l'article 8.

→ CEDH, 10 février 2001, *Hatton c. Royaume-Uni.*

Encore faut-il que l'atteinte porte concrètement et gravement sur la vie privée du requérant.

→ CEDH, 16 novembre 2004, *Moreno Gómez c. Espagne.*

Il en découle pour les autorités nationales une obligation de mettre en œuvre les mesures nécessaires à la protection des droits garantis par cet article.

→ CEDH, 25 octobre 2016, *Otgon c. Moldavie.*

3.3. L'espace numérique : de nouvelles atteintes pour la vie privée

La mise en ligne d'un faux profil sur un réseau social constitue une atteinte au respect de la vie privée et au droit à l'image. Toute personne, quelle que soit sa notoriété, a droit, au respect de sa vie privée et est fondée à en obtenir la protection en fixant elle-même les limites de ce qui peut être divulgué à ce sujet.

→ Art. 9 du Code civil.

→ Art. 226-4-1 et 226-1 du Code pénal.

→ Tribunal de grande instance de Paris, 17e chambre civile, 24 novembre 2010.

La distinction entre sphère publique et sphère privée constitue un pilier des sociétés libérales. Pourtant, les projections dystopiques de Georges Orwell dans 1984 résonnent désormais comme des avertissements plausibles : les technologies de surveillance peuvent être mobilisées au sein même d'États démocratiques, remettant en cause l'intimité des citoyens.

Le numérique bouleverse profondément les frontières entre vie publique et vie privée, rendant poreuses les distinctions traditionnelles. Ce brouillage soulève de nouveaux défis pour l'interprétation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, lequel se trouve au cœur des réflexions sur la protection de la vie privée à l'ère numérique.

POUR S'ENTRAÎNER

Commentaire de texte : Communiqué CEDH, 4 septembre 2014, *Dzemyuk c. Ukraine*, n° 42488/02

« En fait – Le requérant vivait dans un village sans distribution centralisée d'eau et utilisait l'eau de puit alimenté par la nappe phréatique. En 2000, l'autorité locale décida de construire un cimetière sur un terrain voisin de la maison du requérant, à une quarantaine de mètres de celle-ci. Le requérant engagea alors une procédure en vue de l'annulation de cette décision et de la fermeture du cimetière. Finalement, en 2003, le tribunal saisi de l'affaire fit droit à la demande du requérant après avoir constaté que le cimetière avait été construit trop près d'une zone résidentielle et d'une source d'eau, en violation des règlements nationaux relatifs à la sécurité et à la santé environnementales. Il ordonna la fermeture du cimetière, mais sa décision ne fut pas exécutée. Dans l'intervalle, une analyse bactériologique de l'eau du puit du requérant effectuée en 2008 avait indiqué que le taux des bactéries Escherichia Coli était fortement supérieur au taux autorisé par la loi.

En droit – Article 8 a) Applicabilité – La Cour rappelle que, pour soulever une question sous l'angle de l'article 8, l'atteinte alléguée doit avoir des répercussions directes sur le droit au respect du domicile et de la vie privée et familiale du requérant et atteindre un niveau minimum de gravité. Le taux élevé de bactéries relevé dans l'eau du puit du requérant, associé à la violation flagrante des règlements nationaux relatifs à la sécurité et à la santé environnementales confirme l'existence de risques environnementaux, notamment une grave pollution de l'eau, qui ont des répercussions sur la « qualité de vie » du requérant et atteignent un degré suffisant de gravité pour mettre en jeu l'application de l'article 8. b) Observation – L'illégalité de l'emplacement du cimetière a été signalée à plusieurs reprises par les autorités environnementales et reconnue par des décisions des juridictions internes. De plus, les autorités locales ne se sont pas conformées à une décision judiciaire définitive ordonnant la fermeture du cimetière. L'ingérence dans l'exercice par le requérant de son droit au respect de son domicile et de sa vie privée et familiale n'était pas prévue par la loi. »

Introduction (faits et procédure). Le requérant conteste en justice la construction en 2000 d'un cimetière à 40 mètres de son domicile, invoquant un risque de pollution. En 2003, les tribunaux ordonnent sa fermeture pour non-respect des normes sanitaires, mais la décision n'est pas exécutée. En 2008, une analyse révèle une contamination de l'eau. Le requérant saisit alors la CEDH pour violation de l'article 8.

Problématique et annonce du plan : Dans quelle mesure l'inaction d'un État face à une atteinte environnementale illégale, ayant des effets sur le cadre de vie d'un individu, peut-elle constituer une violation du droit au respect de la vie privée et du domicile ? La Cour s'est saisie de cette affaire pour réaffirmer son approche indirecte, mais rigoureuse des atteintes à l'environnement **(I)**, et pointer le manquement grave des autorités nationales **(II)**.

I. Une protection indirecte, mais effective d'un droit à l'environnement par la Cour européenne des droits de l'homme

A. Une jurisprudence attentive aux préoccupations environnementales et sanitaires

Selon une jurisprudence constante, la Cour rappelle que même en l'absence d'une consécration d'un droit à l'environnement dans la Convention européenne des droits de l'homme, elle peut protéger les individus contre les atteintes graves à leur cadre de vie (CEDH, 22 mai 2003, *Kyrtatos c. Grèce*). Ici, la pollution bactériologique avérée affecte directement la qualité de vie du requérant et justifie l'applicabilité de l'article 8.

B. L'article 8 de la convention, vecteur principal de la protection en l'absence de consécration textuelle

L'article 8 sert de fondement pour sanctionner les atteintes environnementales ayant des effets concrets sur la vie privée ou le domicile. La Cour considère que la proximité du cimetière, son caractère illégal, et les risques sanitaires suffisent à caractériser une atteinte d'une gravité suffisante. La Cour avait déjà souligné, à l'occasion de l'affaire *Dubetska c. Ukraine* (CEDH, 10 février 2011), que des nuisances sonores ou environnementales

graves et directes subies par une personne peuvent relever du champ d'application de l'article 8 de la Convention.

II. Une situation factuelle révélatrice d'un manquement étatique aggravé

A. Une ingérence non prévue par la loi au sens de l'article 8 § 2 de la Convention européenne

L'ingérence dans les droits du requérant résulte d'une construction reconnue illégale par les tribunaux internes. L'État ne pouvait donc justifier cette atteinte, celle-ci étant dépourvue de base légale, condition essentielle à toute restriction au sens de l'article 8 § 2.

B. Une inaction prolongée malgré les alertes sanitaires et les décisions de justice

Malgré des rapports alarmants des autorités nationales et une décision judiciaire définitive, l'État n'a pris aucune mesure concrète pour remédier à la situation du requérant.

L'inexécution persistante du jugement renforce la violation de l'article 8, l'État n'ayant pas assumé ses obligations positives.

Fiche nº 34 - LE DROIT À LA VIE FAMILIALE

POINTS CLÉS

- La notion de vie familiale fait l'objet d'une définition autonome par la Cour européenne des droits de l'homme.
- La vie de famille peut être établie par des liens de parenté ou d'alliance, mais aussi par des relations *de facto.*
- La Convention EDH ne protège que la vie de famille préexistante et non le droit d'en créer une.

PRINCIPALES RÉFÉRENCES

- CEDH, 13 juin 1979, *Marckx c. Belgique*, nº 6833/74.
- Cons. const., déc. nº 93-325 DC, 13 août 1993, *Loi relative à la maîtrise de l'immigration et aux conditions d'entrée, d'accueil et de séjour des étrangers en France.*
- Cass. civ. 1re, 4 décembre 2013, nº 12-26.066.
- CEDH, 10 septembre 2019, *Strand Lobben et a. c. Norvège*, nº 37283/13.

1. Les contours de la vie familiale

Le droit au respect de la vie familiale est protégé internationalement par un grand nombre de textes internationaux et régionaux.

→ Art. 12 et 16 DUDH ; art. 17 et 23 PIDCP, art. 10 PIDESC.

→ Art. 8 CEDH ; art. 7 CDFUE.

L'interprétation de l'article 8 de la Convention EDH par la Cour a considérablement étendu cette stipulation. Selon la Cour européenne des droits de l'homme, la vie familiale fait effectivement l'objet d'une définition autonome qui se caractérise par l'existence de liens personnels étroits.

→ CEDH, AP., 13 juin 1979, *Marckx c. Belgique*, nº 6833/74.

Ce droit entretient en outre des liens étroits avec d'autres textes portant sur les droits des enfants ou le droit au mariage.

→ Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant (sur la mobilisation de la Convention par le juge strasbourgeois voir CEDH, GC., *Vavřička et a. c. République tchèque*, 8 avril 2021, nº 47621/13).

→ Le droit au mariage fait l'objet d'une consécration autonome de la part du droit international (art. 23 PIDCP ; art. 12 CESDH, art. 5 du protocole nº 7 ; art. 9 CDFUE).

Le droit à la vie familiale fait partie de l'état des personnes et était historiquement fortement imprégné de considérations politiques, culturelles et morales. Les États disposent donc généralement d'une large marge d'appréciation dans ces domaines, sauf si la question laisse transparaître un consensus européen.

La Convention EDH a néanmoins produit une influence importante sur les ordres juridiques nationaux.

En France, le droit à la vie familiale fait également l'objet d'une protection par le Conseil constitutionnel. Les Sages de la rue de Montpensier ont en effet qualifié le « droit à mener une vie familiale normale » de droit fondamental de valeur constitutionnelle sur le fondement de l'alinéa 10 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.

→ Cons. const., déc. nº 93-325 DC, 13 août 1993, *Loi relative à la maîtrise de l'immigration et aux conditions d'entrée, d'accueil et de séjour des étrangers en France*.

Le Conseil constitutionnel assure également la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant découlant des alinéas 10 et 11 du préambule de la Constitution de 1946.

> → À propos de la réalisation d'examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l'âge de l'individu : Cons. const., déc. n° 2018-768 QPC, 21 mars 2019, *M. Adama S*.

Les juges ordinaires œuvrent également à la protection de ce droit. Ce droit constitue ainsi selon le Conseil d'État une liberté fondamentale pouvant faire l'objet d'un référé-liberté au sens de l'article L. 512-2 du Code de la justice administrative.

> → CE, 30 octobre 2001, n° 238211.

Le Conseil d'État a ainsi admis en prenant en considération les particularités de la cause qu'il était possible d'autoriser le transfert de gamète à l'étranger en vue d'une utilisation post-mortem bien que la loi l'interdise, car son refus aurait porté une atteinte manifestement excessive à son droit au respect de la vie privée et familiale.

> → CE, Ass., 31 mai 2016, *Mme Gonzalez-Gomez*, n° 396848.

Le juge judiciaire protège le droit à la vie familiale grâce au contrôle de proportionnalité ou contrôle concret de conventionnalité dans le cadre de relations purement internes.

> → Cass. civ. 1re, 4 décembre 2013, n° 12-26.066.

Le juge judiciaire assure également la protection de ce droit dans le cadre de litiges présentant un lien d'extranéité en faisant obstacle à l'application d'une loi étrangère dont le résultat serait inconciliable avec l'ordre public international.

> → Une loi étrangère qui impose des délais stricts pour l'action en recherche de paternité doit être écartée si elle a pour effet de priver l'enfant mineur du droit d'établir sa filiation : Cass. civ. 1re, 30 avril 2025, n° 22-24.549.

Actualité jurisprudentielle. - L'égalité des parents relève de l'ordre public international français

Les décisions étrangères relatives à l'état et à la capacité des personnes produisent en principe leurs effets en France, sans qu'une procédure d'exequatur soit nécessaire. L'administration peut toutefois refuser d'en tirer les conséquences lorsqu'elles révèlent une fraude ou une situation contraire à la conception française de l'ordre public international.

Le Conseil d'État a précisé en avril 2025 que l'égalité des parents dans l'exercice de l'autorité parentale appartient à cette conception française de l'ordre public international.

Il a ainsi admis que soit écarté un jugement sénégalais ayant délégué l'autorité parentale sur un enfant à sa tante à la seule demande du père, faute d'établir que la mère avait effectivement consenti à cette délégation.

→ CE, 24 avril 2025, *Mme A c/ ministre de l'Intérieur*, n° 490561, publié au Recueil.

À retenir. - La reconnaissance en France d'une situation familiale constituée à l'étranger peut être subordonnée au respect de principes fondamentaux de l'ordre juridique français, parmi lesquels figure désormais expressément l'égalité des parents dans l'exercice de l'autorité parentale.

2. Le droit au mariage

2.1. La liberté de se marier

Le droit au mariage est consacré par l'article 12 de la Convention européenne des droits de l'homme, mais reste intimement lié au droit à la vie familiale. En effet, cette disposition consacre le droit de se marier et donc incidemment celui d'établir une vie de famille.

Il ne s'agit pas d'un droit absolu bien que l'article soit dépourvu de clause d'ordre public relative aux restrictions pouvant être adoptées par l'État comme cela est le cas pour les articles 8 et 11 de la Convention.

Le mariage emporte des conséquences juridiques, sociales et personnelles. L'État peut de ce fait limiter ce droit en exigeant des conditions de formes et de fond.

→ CEDH, 5 janvier 2010, *Frasik c. Pologne*, n° 22933/02.

L'État peut également interdire le mariage pour les couples de même sexe.

→ CEDH, 24 juin 2010, *Schalk et Kopf c. Autriche*, n° 30141/04.

→ CEDH, 15 mars 2012, *Gas et Dubois c. France*, n° 25951/07.

En l'absence d'accès au mariage des couples de même sexe, l'État a toutefois l'obligation de reconnaître officiellement l'union de ces couples et protéger leur droit de conclure au moins une forme d'union civile ou de partenariat enregistré.

→ CEDH, 21 juin 2015, *Oliari et a. c. Italie*, n°s18766/11 36030/11.

L'État ne saurait toutefois restreindre le droit de se marier au point de l'atteindre dans sa substance.

L'article 12 ne garantit pas le droit au divorce, mais lorsque l'État le consacre au sein de son droit interne, il ne doit pas adopter de mesures de nature à le restreindre de manière déraisonnable.

→ Ainsi, l'interdiction de remariage temporaire prononcée après plusieurs divorces constitue une violation de l'article 12 : CEDH, 18 décembre 1987, *F. c. Suisse*, n° 11329/85.

En France, si la liberté du mariage est absente du texte du bloc de constitutionnalité, elle a néanmoins été reconnue en 1993 par le juge constitutionnel.

Le Conseil constitutionnel a dans un premier temps protégé la liberté du mariage comme composante de la liberté individuelle (art. 66 de la Constitution).

→ Cons. const., déc. n° 93-325 DC, 13 août 1993, *Loi relative à la maîtrise de l'immigration et aux conditions d'entrée, d'accueil et de séjour des étrangers en France*.

Ce dernier l'a dans un second temps rattaché à la liberté personnelle découlant des articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

→ Cons. const., déc. n° 2003-484 DC, 20 novembre 2003, *Loi relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité.*

Le législateur peut apporter des limites à la liberté du mariage dès lors que celles-ci sont justifiées par l'intérêt général ou qu'elles sont liées à des exigences constitutionnelles.

→ Cons. const., déc. n° 2012-260 QPC, 29 juin 2012, *M. Roger D*.

Depuis la loi du 17 mai 2013, dite loi « Taubira », le mariage est désormais ouvert aux couples de même sexe (art. 143 du Code civil).

Le mariage repose sur la liberté du consentement (art. 146 du Code civil) dès lors que l'individu a atteint l'âge nubile (en général la majorité, mais la détermination de cet âge reste l'apanage des États dans certaines limites fixées par le droit international).

Les mariages de complaisance visant à faire bénéficier à l'un des époux un avantage conféré par la loi nationale de l'autre époux, ou mariages blancs, sont interdits en France. Les mariages gris le sont également puisque l'un des époux aura vu son consentement être vicié.

2.2. La dissolution du mariage

Selon la Cour européenne des droits de l'homme, le droit de divorcer ne saurait être déduit du droit au mariage consacré par l'article 12 de la Convention.

→ CEDH, 18 décembre 1986, *Johnston et a. c. Irlande*, n° 9697/82.

Les États doivent toutefois prévoir un mécanisme en droit interne permettant de consacrer juridiquement la séparation des époux.

→ CEDH, 9 octobre 1979, *Airey c. Irlande*, n° 6289/73.

Constitue ainsi une violation de l'article 12 combiné à l'article 14 de la Convention l'obligation faite aux femmes divorcées de respecter un délai de viduité de 300 jours à moins de prouver par un examen médical qu'elles ne sont pas enceintes.

→ CEDH, 27 juin 2023, *Nurcan Bayraktar c. Turquie*, n° 27094/20.

La liberté de mettre fin au mariage est *a contrario* reconnue par le Conseil constitutionnel sur le fondement des articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

→ Cons. const., déc. n° 2016-557 QPC, 29 juillet 2016, *Bruno B*.

Actualité jurisprudentielle.

1°) Le mariage ne peut emporter une obligation juridiquement sanctionnée d'avoir des relations sexuelles

La liberté sexuelle relève de l'autonomie personnelle protégée par l'article 8 de la CESDH. Elle implique non seulement la liberté de consentir à une relation sexuelle, mais également celle de la refuser.

La Cour européenne a ainsi condamné la France dans une affaire où un divorce avait été prononcé aux torts exclusifs d'une épouse, notamment parce qu'elle avait cessé d'avoir des relations sexuelles avec son conjoint. La Cour relève que le « devoir conjugal », tel qu'il était retenu par les juridictions françaises, ne prenait nullement en compte le consentement aux relations sexuelles.

Elle juge que l'affirmation d'une telle obligation matrimoniale, dont le non-respect peut constituer une faute justifiant le divorce et produire des conséquences patrimoniales, porte atteinte à la liberté sexuelle, à l'autonomie corporelle et au droit au respect de la vie privée.

→ CEDH, 23 janvier 2025, *H.W. c. France*, n° 13805/21.

À retenir. - Le consentement au mariage ne vaut jamais consentement anticipé aux relations sexuelles. Le refus ou le retrait du consentement ne peut être juridiquement sanctionné au titre des obligations matrimoniales.

3. Le droit au respect de la vie familiale

Le droit au respect de la vie familiale est protégé par l'article 8 de la Convention EDH. Ce droit implique le droit de vivre ensemble et doit permettre le développement normal des relations familiales.

L'applicabilité de ce droit requiert toutefois l'existence préalable d'une famille.

→ CEDH, 13 juin 1979, *Marckx c. Belgique*, n° 6833/74.

Ainsi, les désirs de fonder une famille ou d'adopter ne sont pas par principe protégés par le droit au respect de la vie familiale.

→ CEDH, 26 février 2002, *Fretté c. France*, n° 36515/97.

→ CEDH, 22 janvier 2008, *E.B. c. France*, n° 43546/02.

La Cour n'exige pas nécessairement de lien institutionnel tel que le mariage pour constater l'existence d'une vie familiale.

→ CEDH, 18 décembre 1986, *Johnston et a. c. Irlande*, n° 9697/82.

La vie familiale est en effet appréciée concrètement par la Cour afin de déterminer l'existence d'une vie familiale *de facto*.

→ CEDH, GC., 24 janvier 2017, *Paradiso et Campanelli c. Italie*, n° 25358/12.

Le constat d'une vie familiale est en ce sens conditionné par l'existence d'un lien personnel effectif.

→ CEDH, GC., 8 avril 2021, *Vavřička et a. c. République tchèque*, nos 47621/13 et a.

Cette notion d'effectivité s'apprécie concrètement en prenant notamment en compte la cohabitation, la durée de la relation ou si les individus ont eu des enfants ensemble.

→ CEDH, GC., 22 avril 1997, *X, Y, Z c. Royaume-Uni*, n° 21830/93.

→ CEDH, 28 juin 2007, *Wagner et J.M.W.L. c. Luxembourg*, n° 76240/01.

En France, le Conseil constitutionnel a également validé la disposition prévoyant une appréciation *in concreto* de l'effectivité des liens familiaux pour la délivrance de titres de séjours.

→ Voir par exemple : Cons. const., déc. n° 2006-539 DC, 20 juillet 2006, *Loi relative à l'immigration et à l'intégration.*

En matière de responsabilité civile extracontractuelle, la Cour de cassation a admis l'indemnisation du préjudice moral de l'enfant conçu, mais non né au moment du décès accidentel de son père en raison de l'absence définitive de ce dernier et ce, du seul fait de leur lien de parenté. En se fondant sur la théorie de l'*infans conceptus*, la Cour admet ainsi l'indemnisation de ce préjudice alors même qu'aucun lien affectif n'avait encore été noué entre eux lors de la survenance du dommage.

→ Cass. civ. 2e, 14 décembre 2017, no 16-26.687.

La Cour a retenu une position similaire face à un enfant simplement conçu, mais non né au moment du meurtre de son grand père. Ce faisant, la Cour retient une conception objective du préjudice moral, indépendante des liens effectivement entretenus entre la victime directe et la victime par ricochet.

→ Cass. civ. 2e, 11 février 2021, no 19-23.525.

4. L'établissement du lien de parenté

4.1. L'établissement par la filiation

L'État doit donc permettre l'établissement d'un lien de filiation entre un enfant et ses parents biologiques. Selon la Cour, la filiation maternelle peut découler de la déclaration de naissance.

→ CEDH, 13 juin 1979, *Marckx c. Belgique*, no 6833/74.

Selon la Cour européenne des droits de l'homme, l'État commet une ingérence dans le droit au respect de la vie familiale lorsqu'il impose des restrictions aux parents biologiques dans l'établissement de leur filiation avec leurs enfants ou lorsqu'ils sont exclus de la vie de ces derniers.

→ CEDH, 12 octobre 2023, *C.P. et M.N. c. France*, nos 56513/17 et 56515/17.

L'État commet ainsi une ingérence lorsqu'il impose des conditions de fond ou de forme pour l'établissement d'un lien de filiation.

→ Constitue une violation de l'article 8, l'impossibilité pour un père biologique de contester la déclaration de paternité faite par un tiers et d'établir la sienne à l'égard de son enfant biologique : CEDH, 7 juin 2024, *Vagdalt c. Hongrie*, no 9525/19.

4.2. L'établissement par l'adoption

Le droit au respect de la vie familiale ne garantit pas de droit à l'adoption.

→ CEDH, GC., 24 janvier 2017, *Paradiso et Campanelli c. Italie*, no 25358/12.

Toutefois, s'il est consacré en droit interne, l'État ne doit pas prendre de mesures discriminatoires dans la mise en œuvre de ce droit.

→ CEDH, GC., 22 janvier 2008, *E.B. c. France*, no 43546/02.

Il existe en France deux formes différentes d'adoption.

L'adoption plénière va avoir pour effet de remplacer le lien de filiation préexistant par celui de l'adoptant. L'adopté voit alors ses liens avec sa famille d'origine disparaître.

L'adoption simple quant à elle n'a pas pour effet de supprimer les liens familiaux avec la famille d'origine. Cette forme d'adoption vient donc ajouter un lien de filiation à celui de la famille d'origine (art. 364 du Code civil).

L'adoption a fait l'objet d'assouplissements successifs de ses conditions.

→ L'adoption, depuis la loi du 17 mai 2013 dite loi « Taubira », est ouverte aux couples de même sexe (art. 6-1 du Code civil). Elle a également facilité l'adoption intrafamiliale (art. 343 et suiv. du Code civil).

→ La loi du 21 février 2022 a permis l'adoption à toute personne de plus de 26 ans.

4.3. La gestation pour autrui

La pratique de la gestation pour autrui (GPA) est interdite en France en vertu de l'indisponibilité du corps humain (art. 16-7 du Code civil). Cette pratique n'est toutefois pas universellement proscrite.

La problématique autour de la GPA réside de ce fait dans la réalisation d'une GPA à l'étranger au sein d'un État où cette pratique est légale et de demander par la suite la transcription en France du registre de l'état civil étranger.

La France s'est dans un premier temps fermement opposée à la transcription de l'état civil mentionnant les parents biologiques d'un enfant né par GPA et ce, quand bien même celle-ci aurait été réalisée légalement à l'étranger.

→ Cass. civ. 1re, 6 avril 2011, no 09-17.130.

La Cour européenne des droits de l'homme a toutefois condamné la France à plusieurs reprises pour avoir refusé de retranscrire le lien de filiation des parents biologiques dans le cadre d'une GPA.

→ CEDH, 26 juin 2014, *Mennesson c. France*, no 65192/11.

La Cour de cassation a par la suite opéré un revirement de jurisprudence en affirmant que la seule réalisation d'une GPA à l'étranger ne pouvait faire obstacle à la transcription de l'acte d'état civil de l'enfant dès lors que cet acte est régulier, exempt de fraude et qu'il correspond à la réalité biologique.

→ Cass. ass. plén., 3 juillet 2015, no 14-21.323 et no 15-50.002.

Le juge judiciaire s'opposait cependant toujours à l'établissement d'un lien de filiation à l'égard du parent d'intention.

La Cour européenne des droits de l'homme n'exige pas que les États prévoient une transcription du lien de filiation établi par les registres d'état civil étrangers à l'égard du parent d'intention. L'État doit néanmoins prévoir un moyen d'établir un lien de filiation à l'égard de ce parent par le biais par exemple de l'adoption simple ou plénière ou par la possession d'état.

L'État dispose en la matière d'une large marge d'appréciation en raison de l'absence de consensus européen.

→ CEDH, GC., 10 avril 2019, Avis consultatif relatif à la reconnaissance en droit interne d'un lien de filiation entre un enfant né d'une gestation pour autrui pratiquée à l'étranger et la mère d'intention

Dans le cadre de l'affaire Mennesson, la Cour de cassation a finalement permis la transcription intégrale de l'acte d'état civil étranger désignant la mère d'intention en prenant appui sur l'avis de la Grande Chambre et en relevant la durée de la procédure en cause.

→ Cass. ass. plén., 4 octobre 2019, no 10-19.053.

Le législateur a par la suite adopté la loi du 2 août 2021 (no 2021-1017) relative à la bioéthique modifiant notamment l'article 47 du Code civil afin de faire obstacle à la transcription d'un acte d'état civil qui ne correspondrait pas à la réalité biologique.

Les parents peuvent également avoir recours à une autre procédure afin d'obtenir la reconnaissance de leur lien de filiation à l'égard d'un enfant issu d'une GPA réalisée à l'étranger lorsque ce lien a été reconnu par un jugement étranger. Il s'agit de la procédure d'exequatur.

L'établissement d'un lien de filiation entre la mère d'intention et l'enfant né d'une GPA à l'étranger ne constitue pas une violation de l'ordre public international ni ne constitue une fraude à la loi. La désignation du parent d'intention au sein de l'acte d'état civil ne fait donc pas obstacle à la reconnaissance du jugement étranger.

→ Cass. civ. 1re, 14 novembre 2024, no 23-50.016.

Le jugement étranger doit toutefois être suffisamment motivé pour que les juridictions françaises se prononcent favorablement à la demande d'exequatur.

→ Cass. civ. 1re, 2 octobre 2024, no 22-20.883.

Actualité jurisprudentielle. - GPA à l'étranger : l'interdiction française ne suffit plus à faire obstacle à la reconnaissance de la filiation

Actualité traitée sur le fond de la décision : Fiche 26, p. 257.

La gestation pour autrui demeure interdite en France par les articles 16-7 et 16-9 du Code civil. La Cour de cassation confirme que cette interdiction constitue un principe essentiel du droit français relevant de l'ordre public international.

Toutefois, l'ordre public international français comprend également les droits fondamentaux garantis par la Convention européenne des droits de l'homme, notamment le droit de l'enfant au respect de sa vie privée et de son identité. L'interdiction française de la GPA ne peut donc, à elle seule, justifier le refus de reconnaître une décision étrangère établissant légalement la filiation de l'enfant à l'égard de ses parents d'intention.

La reconnaissance demeure soumise à un contrôle juridictionnel effectif. Le juge doit notamment pouvoir identifier les personnes ayant participé au projet parental et vérifier que la mère porteuse a consenti à la convention de GPA, à ses modalités ainsi qu'à ses conséquences sur ses droits parentaux. Il doit également pouvoir écarter toute situation contraire à l'ordre public, notamment en présence d'une fraude ou d'un trafic d'enfants.

Lorsque la décision étrangère satisfait à ces exigences, la filiation qu'elle établit est reconnue en tant que telle en France : le juge ne peut la transformer artificiellement en adoption.

→ Cass., Ass. plén., 3 juillet 2026, nos 24-50.028 et 24-50.029.

À retenir. - La jurisprudence ne légalise pas la GPA en France. Elle distingue désormais nettement l'interdiction de la pratique sur le territoire français et la protection de l'identité et de la filiation de l'enfant déjà né à l'étranger.

4.4. La procréation médicalement assistée

Le droit au respect de la vie familiale comprend le droit de devenir parent au sens génétique du terme. La Cour a ainsi estimé que le choix de recourir à la procréation médicalement assistée constituait une expression de la vie familiale au sens de l'article 8 de la Convention.

> → CEDH, GC., 3 novembre 2011, *S.H. et a. c. Autriche*, n° 57813/00

La Cour reconnaît aux États une ample marge d'appréciation en matière de bioéthique. Ces derniers peuvent donc conditionner le recours à la PMA ou l'interdire lorsqu'elle conduirait à la réalisation d'une procréation post-mortem.

> → Concernant la conformité à la Convention de l'interdiction d'exporter des gamètes à l'étranger en vue de procéder à une procréation post-mortem (CEDH, 14 septembre 2023, *Baret et Caballero c. France*, nos 22296/20 et 37138/20).

Le Conseil d'État a considéré que l'interdiction de dons post-mortem prévue par les articles L. 2141-2 et L. 2141-9 du Code de la santé publique était conforme à la Convention européenne.

> → CE, 28 novembre 2024, n° 497323

Depuis la loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique, la PMA est ouverte aux couples hétérosexuels, aux couples de femmes, mais également aux femmes célibataires.

> → Selon le Conseil d'État, les homme trans ayant obtenu une modification de leur état civil ne peuvent donc prétendre à la procréation médicalement assistée (CE, 22 mars 2024, n° 459000).

Cette loi a également introduit un nouveau mode d'établissement du lien de filiation pour la mère d'intention au sein de l'article 342-11 du Code civil : la procédure de reconnaissance conjointe d'enfant.

> → Sur le refus de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité : Cass. civ. 1re, 10 mai 2024, n° 24-40.001.

En dehors du cadre de la procréation médicalement assistée, le prélèvement d'ovocytes en vue d'un don ne peut être réalisé que de manière anonyme.

→ La réception d'ovocyte par conjoint ou « ROPA » est donc interdite en France : CE, 19 juin 2024, n° 472649.

5. Le maintien du lien familial

Le droit au respect de la vie familiale impose aux États non seulement des obligations négatives, ne pas causer d'ingérence injustifiée, mais également des obligations positives matérielles et procédurales.

Les mesures de placement en foyers d'accueils d'enfant constituent des ingérences au droit au respect de la vie familiale, car *« pour un parent et son enfant être ensemble représente un élément fondamental de la vie familiale »*.

→ CEDH, 24 mars 1988, *Olsson c. Suède* (n° 1), n° 10465/83.

Les mesures d'assistances éducatives constituent donc des ingérences dans le droit au respect de la vie familiale qui doivent être prévues par la loi, justifiées et nécessaires au sein d'une société démocratique. L'État doit opérer une pesée des intérêts entre l'objectif de réunir les membres de la famille et la protection des enfants.

→ CEDH, 13 octobre2015, *SH. C. Italie*, n° 52557/14.

→ CEDH, GC., 10 septembre 2019, *Strand Lobben et a. c. Norvège*, n° 37283/13.

Ces mesures attentatoires au lien familial doivent par principe être temporaires. La déchéance de l'autorité parentale est ainsi une mesure grave en ce qu'elle entraîne une rupture de ce lien.

→ Commet ainsi une violation de l'article 8, l'État ayant déchu un parent de son autorité parentale sans avoir poursuivi l'objectif de réunification de la famille (CEDH, 15 avril 2025, *Van Slooten c. Pays-Bas*, n° 45644/18).

Les détenus conservent par ailleurs le droit au respect de leur vie familiale. L'État doit donc assurer le maintien des liens familiaux en permettant, par exemple, dans la mesure où cela s'avère possible, la visite des membres de leur famille.

→ CEDH, 28 juin 2001, *Selmani c. Suisse*, déc., n° 70258/01.

Actualité jurisprudentielle. - L'enfant capable de discernement doit personnellement être entendu en assistance éducative

La protection de la vie familiale comporte également une dimension procédurale. Dans toute procédure d'assistance éducative, le juge des enfants doit systématiquement procéder à un entretien individuel avec l'enfant capable de discernement.

La possibilité de dispenser l'enfant d'assister à l'audience ne permet pas de supprimer cet entretien. Lorsque celui-ci n'a pas été réalisé en première instance, la cour d'appel doit elle-même y procéder si elle ne constate pas que l'enfant est dépourvu de discernement.

⟶ Cass. 1ère civ., 12 juin 2025, n° 22-23.646, publié au Bulletin.

À retenir. - L'intérêt supérieur de l'enfant ne consiste pas seulement à décider pour lui : lorsqu'il est capable de discernement, il implique aussi de lui permettre de participer personnellement à la procédure qui détermine ses relations familiales.

6. L'égalité entre enfants

La notion de vie familiale s'applique aussi bien aux familles légitimes, qu'aux familles naturelles.

→ CEDH, 13 juin 1979, *Marckx c. Belgique*, n° 6833/74.

Le seul fait que les enfants aient été conçus hors mariage ne saurait donc justifier une différence de traitement avec les enfants légitimes dans le cadre de successions.

L'ancien article 760 du Code civil constituait ainsi une violation de la Convention, car il prévoyait une réduction de la part successorale de l'enfant naturel lorsqu'était également appelé à la succession un enfant légitime.

→ CEDH, 1er février 2000, *Mazurek c. France*, nº 34406/97.

Cette disposition discriminatoire selon les juges strasbourgeois a été abrogée le 3 décembre 2001 (loi nº 2001-1135 relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins et modernisant diverses dispositions de droit successoral). Le Code civil consacre désormais au sein de l'article 310-1 l'égalité successorale des enfants.

L'interprétation retenue par les juridictions andorranes d'un testament ayant pour effet d'exclure de la succession un enfant pour l'unique motif que celui-ci serait adopté constitue une violation des articles 8 et 14 de la Convention.

→ CEDH, 13 juillet 2004, *Pla et Puncernau c. Andorre*, nº 69498/01.

POUR S'ENTRAÎNER

Dissertation : Existe-t-il un droit à la parenté ?

L'accès à la parenté était historiquement intimement lié à la conception biologique dans le cadre de couples hétérosexuels.

La parenté peut toutefois se concrétiser de plusieurs manières, reflétant ou non la réalité biologique. La multiplication des schémas familiaux a parfois rendu difficile l'accès à la parenté pour certaines familles ne pouvant ni procréer naturellement, ni établir de lien de filiation avec un enfant notamment par le biais de l'adoption. Les progrès médicaux avec le développement de l'aide médicale à la procréation (don de gamètes, fécondation in vitro, conservation des gamètes) ont néanmoins permis à certaines de ces familles de caresser l'espoir d'un projet parental.

Le législateur est cependant intervenu à plusieurs reprises afin d'encadrer ces hypothèses d'accès à la parenté et de les concilier avec des principes d'ordre éthique et sociétaux.

Ce dernier a donc dû repenser les règles relatives à la concrétisation des projets parentaux afin de s'adapter aux évolutions sociétales au sein de plusieurs lois bioéthiques (en 1994, 2004, 2011 et 2021).

Problématique et annonce du plan : S'il n'existe pas de consécration explicite d'un droit à l'enfant **(I)**, la France et la Cour européenne des droits de l'homme semblent toutefois de plus en plus faciliter l'accès à la parenté **(II)** au point qu'il est aujourd'hui permis de se demander s'il n'a pas été implicitement consacré un droit à devenir parent.

I. L'inexistence d'un droit à l'enfant

A. L'absence de consécration d'un droit à la parenté biologique

La Cour ne protège la vie familiale que lorsqu'elle est existante. Elle ne garantit effectivement pas le droit de fonder une famille (CEDH, GC., 22 janvier 2008, *E.B. c. France*, n° 43546/02). Si la volonté d'être parent génétique peut relever de la vie familiale au sens de l'article 8 de la Convention (CEDH, GC., 3 novembre 2011, *SH c. Autriche*, n° 57813/00), l'État peut toutefois limiter, voire refuser, le recours à la procréation médicalement assistée puisqu'il dispose d'une large marge d'appréciation. Jusqu'en 2021, la procréation médicalement assistée n'était ainsi ouverte qu'aux couples hétérosexuels et sous condition d'infertilité ou afin d'éviter la transmission de maladies graves. La France interdit encore à ce jour la réception d'ovocytes de la partenaire ou « maternité partagée » pour les couples de femmes (CE, 19 juin 2024, n° 472649).

Le Conseil d'État a également validé l'interdiction des dons de gamètes post-mortem (CE, 28 novembre 2024, n° 497323).

Le recours à l'aide médicale à la procréation est donc conditionné par une reconnaissance de ce droit par l'État et peut tout à fait être soumis à des conditions.

B. L'interdiction du recours à la gestation pour autrui

La France a consacré au sein de l'article 16-7 du Code civil l'interdiction de la GPA. La Cour de cassation a ainsi pendant longtemps refusé de retranscrire l'acte de naissance étranger d'un enfant né d'une gestation pour autrui à l'étranger (Cass. civ. 1re, 6 avril 2011, n° 10-19.053) avant de modifier sa position à la suite d'une condamnation de la CEDH.

La Convention européenne des droits de l'homme ne consacre pas non plus de droit à la GPA.

La Cour européenne des droits de l'homme a toutefois estimé contraire à la Conv. EDH le fait de refuser la transcription du lien de filiation avec le parent biologique de l'enfant né d'une GPA. La Cour a par la suite

souligné que la reconnaissance d'un lien de filiation devait également être possible avec le parent d'intention (CEDH, GC., 10 avril 2019, Avis consultatif relatif à la reconnaissance en droit interne d'un lien de filiation entre un enfant né d'une gestation pour autrui pratiquée à l'étranger et la mère d'intention).

II. La facilitation progressive de l'accès à la parenté

A. La facilitation des procédures de filiation

L'adoption s'est progressivement ouverte aux différents schémas familiaux.

La loi du 17 mai 2013 dit loi Taubira a tout d'abord ouvert l'adoption aux couples de même sexe (article 6-1 et article 343 du Code civil). La loi du 21 février 2022 a ouvert les procédures d'adoption aux couples pacsés ou concubins et a abaissé l'âge minimum à 26 ans.

Des limites subsistent toutefois encore à l'accès à la parentalité.

L'application du principe *« mater certa semper est »* n'est, selon la Cour européenne des droits de l'homme, pas contraire à la Convention lorsqu'il empêche l'établissement de la filiation à l'égard de la mère d'intention à la suite d'une réception des ovocytes de la partenaire (CEDH 12 novembre 2024, *R.F. et a. c. Allemagne*, n° 46808/16).

La mesure de placement d'un enfant né d'une gestation pour autrui ne porte pas atteinte au droit à la vie familiale puisqu'aucun lien familial n'existait avec le couple ayant eu recours à la technique reproductive. La Cour affirmant par ailleurs qu'il n'existe aucun droit à adopter (CEDH, GC., 24 janvier 2017, *Paradiso et Campanelli c. Italie*, n° 25358/12).

B. L'ouverture progressive de la procréation médicalement assistée

Depuis la loi 2 août 2021, la procréation médicalement assistée est ouverte aux couples hétérosexuels, aux couples de femmes, mais également aux femmes seules. Cette loi a également supprimé les conditions relatives à l'infertilité et à la transmission de maladies graves (art. L. 2141-2 du Code de la santé publique).

La loi ne permet cependant pas aux personnes transsexuelles nées homme, mais ayant réalisé un changement de sexe à l'état civil d'avoir recours à la procréation médicalement assistée, car cela impliquerait d'avoir recours à une convention de mère porteuse contraire à l'article 16-7 du Code civil.

De même, l'aide à la procréation médicale est toujours encadrée : elle est ainsi soumise à des rendez-vous préparatoires ainsi qu'à des conditions d'âge (CE, 15 juillet 2024, n° 493840).

En conclusion, s'il n'existe toujours pas formellement de droit à la parenté en droit français, l'ouverture progressive des modalités d'établissement des liens de filiation tend néanmoins à favoriser l'émergence d'un tel droit.

Fiche nº 35 - LE DROIT À LA PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

POINTS CLÉS

- Personnes physiques identifiables.
- Consentement libre et éclairé.
- Principe de minimisation des données.
- Données personnelles et données « sensibles » : restriction d'accès.
- Surveillance de masse et risque systémique pour les libertés.
- Équilibre entre vie privée et droit à l'information.
- Données biométriques et systèmes d'IA à haut risque.
- Importance du contrôle juridictionnel de proportionnalité.
- Droit à l'oubli.

PRINCIPALES RÉFÉRENCES

- *Loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.*
- *Article* 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
- A*rticle 8 de la Convention européenne des droits de l'homme*.
- Règlement nº 2016/679 du 27 avril 2016 (RGPD).
- Règlement nº 2024/1689 du 13 juin 2024 (RIA).
- *CJUE, 13 mai 2014, Google Spain, C-131/12.*
- CJUE, 6 octobre 2020, *La Quadrature du Net, C-511/18.*
- CJUE, 8 avril 2014, *Digital Rights, C-293/12.*
- CJUE, 21 décembre 2016, *Tele2 Sverige, C-203/15.*
- CEDH, 4 décembre 2008, *S. et Marper c. Royaume-Uni, nº 30562/04.*

1. Un régime juridique complexe en constante évolution

Tandis que les technologies de captation et de stockage prolifèrent, le droit à la protection des données personnelles apparaît comme le théâtre d'un affrontement entre la liberté individuelle et l'efficacité sécuritaire. Face à la montée des dispositifs de surveillance et à la traçabilité généralisée des comportements, le droit se voit contraint d'évoluer pour préserver les garanties au fondement de la protection de la vie privée.

1.1. Origine du droit à la protection des données à caractère personnel

En droit français, la loi « Informatique et libertés » de 1978 constitue le texte fondateur, largement modifiée en 2018 par une loi et une ordonnance, afin de tenir compte des exigences du droit de l'Union européenne.

→ Loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

→ Loi nº 2018-493 du 20 juin et ordonnance nº 2018-1125 du 12 décembre 2018.

La Charte des droits fondamentaux consacre expressément le droit de toute personne à la protection des données à caractère personnel. Ce droit, indissociable de celui au respect de la vie privée garanti par la Convention européenne, s'inscrit dans un cadre juridique, national et européen, à la fois dense et évolutif.

→ Art. 8 CDFUE.

→ Art. 8 CESDH.

En droit de l'Union européenne, le droit fondamental à la protection des données à caractère personnel est essentiellement garanti par le Règlement général de protection des données (RGPD), auquel s'ajoutent la directive Police-Justice et la directive ePrivacy de 2002.

→ Règlement n° 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

→ Directive n° 2016/680 du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités à des fins de prévention et de détection des infractions pénales.

→ Directive n° 2002/58/CE du 12 juillet 2002 sur le traitement des données personnelles et la protection de la vie privée dans les communications électroniques.

La directive de 2002 devait être remplacée par un règlement ambitieux, le projet ePrivacy, en discussion depuis 2017. Pensé pour moderniser le cadre juridique applicable aux métadonnées et aux cookies, ce projet, faute de consensus entre États membres, a été abandonné par la Commission début 2025.

Le règlement général de protection des données, d'application directe, se distingue par son champ d'application étendu puisqu'il concerne tant les entités établies dans l'Union européenne que celles qui, sans y être implantées, y offrent des biens ou des services.

Le régime issu de l'ensemble de ces réglementations vise à concilier la protection effective des données personnelles avec d'autres impératifs d'intérêt général, tels que la sécurité publique ou la liberté d'entreprendre.

Actualité. - « Chat Control » : jusqu'où peut aller la détection des contenus illicites dans les communications privées ?

La lutte contre les abus sexuels commis sur les enfants soulève une difficulté majeure de conciliation entre la protection des mineurs et les droits au respect de la vie privée, à la confidentialité des communications et à la protection des données personnelles.

Depuis 2022, l'Union européenne négocie un règlement pérenne destiné à prévenir et combattre les abus sexuels sur mineurs en ligne, couramment désigné dans le débat public sous l'expression « Chat Control ». La proposition initiale prévoyait notamment des mécanismes permettant d'imposer à certains fournisseurs de services des obligations de détection de contenus pédopornographiques ou de sollicitations sexuelles d'enfants. Le Comité européen de la protection des données et le Contrôleur européen de la protection des données ont alerté sur le risque que des dispositifs insuffisamment ciblés conduisent à une analyse généralisée et indifférenciée des communications électroniques, incompatible avec les exigences de nécessité et de proportionnalité.

Le Parlement européen a défendu une approche plus restrictive : les ordres de détection doivent constituer une mesure de dernier recours, viser des utilisateurs ou groupes déterminés pour lesquels existent des motifs de suspicion et ne doivent pas s'appliquer aux communications protégées par un chiffrement de bout en bout.

Dans l'attente d'un accord sur le régime définitif, un nouveau règlement temporaire a été adopté le 24 juillet 2026. Le règlement (UE) 2026/1881 autorise, jusqu'au 3 avril 2028, certains fournisseurs de services de communications à détecter volontairement, sous conditions, les contenus relatifs aux abus sexuels sur mineurs. À la suite des modifications introduites par le Parlement européen, ce régime temporaire exclut expressément de son champ les communications auxquelles s'applique un chiffrement de bout en bout ainsi que l'analyse des communications audio.

⟶ Règlement (UE) 2026/1881 du Parlement européen et du Conseil du 24 juillet 2026.

Le dispositif permanent demeure, en août 2026, en cours de négociation entre le Parlement européen et le Conseil. Le Conseil a arrêté sa position en novembre 2025 et les négociations interinstitutionnelles se poursuivent.

1.2. Principales notions et définitions

Bien que le droit à la protection des données personnelles ne soit pas une création récente, l'essor d'Internet et des systèmes d'information a profondément transformé ses contours. Confronté à des enjeux d'automatisation et de dématérialisation, ce droit se complexifie à mesure que se croisent les logiques juridiques, technologiques et éthiques.

1.2.1. « Données personnelles » et « données sensibles »

Les données à caractère personnel sont des informations se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable. Est réputée identifiable une personne physique qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par un identifiant (nom, numéro d'identification, données de localisation, identifiant en ligne) ou des éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale.

→ Art. 4.1 RGPD.

Cette notion recouvre tout élément qui particularise la personne (image, voix, nom, immatriculation du véhicule, coordonnées professionnelles, adresse IP) et qui est de nature à permettre son identification.

→ CE, 30 décembre 2015, Association Juricom c. CNIL.

→ Cass. civ. 1re, 3 novembre 2016, no 15-22595.

Les données personnelles sont des données particulièrement sensibles qui, du point de vue des droits fondamentaux, méritent une protection spécifique, car le contexte dans lequel elles sont traitées engendre des risques pour les droits et libertés de la personne concernée.

Ainsi, est interdit le traitement des données personnelles révélant l'origine ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses, l'appartenance syndicale, ainsi que le traitement des données génétiques, biométriques, concernant la santé, la vie ou l'orientation sexuelle d'une personne.

En revanche, le traitement des photographies n'est pas systématiquement considéré comme un traitement de catégories particulières de données personnelles, celles-ci ne relevant de la définition de données biométriques que lorsqu'elles sont traitées selon *« un mode technique spécifique permettant l'identification ou l'authentification unique d'une personne »*.

→ Art. 9.1 RGPD.

En principe, le traitement de ces données dites sensibles est interdit. Mais des dérogations sont possibles (consentement de la personne, exercice des droits propres au responsable en matière de droit du travail ou de la protection sociale, sauvegarde des intérêts vitaux…).

Le Règlement général énumère une série de dérogations qui tendent à relativiser le principe de l'interdiction.

→ Art. 9.2 RGPD.

1.2.2. « Traitement de données » et « fichier »

La notion de traitement est appréhendée de manière souple par le RGPD. Il s'agit de *« toute opération ou tout ensemble d'opérations effectuées ou non à l'aide de procédés automatisés et appliquées à des données ou des ensembles de données à caractère personnel, telles que la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la structuration, la conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, la limitation, l'effacement ou la destruction »*.

→ Art. 4.2 RGPD.

La notion de « fichier », centrale en ce domaine, renvoie à un ensemble structuré de données personnelles accessibles selon des critères déterminés, qu'il soit centralisé, décentralisé ou réparti de manière fonctionnelle ou géographique.

→ Art. 4.6 RGPD.

1.2.3. Responsables du traitement

La notion de responsable de traitement est définie comme la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou un autre organisme qui détermine les finalités et les moyens du traitement.

→ Art. 4.7 RGPD.

La définition est volontairement large dans la mesure où cette disposition vise à garantir une protection efficace et complète des personnes.

Ainsi, la Cour de justice a considéré qu'un moteur de recherche tel que Google doit être qualifié de responsable de traitement au sens du droit de l'Union, dès lors que son activité – consistant à rechercher des informations publiées par des tiers sur internet, à les indexer automatiquement, à les stocker temporairement et à les rendre accessibles aux internautes selon un ordre de préférence – constitue un traitement de données à caractère personnel.

→ CJUE, 13 mai 2014, *Google Spain.*

De même, la Cour de justice a jugé qu'un administrateur de page fan sur un réseau social tel que Facebook partage la responsabilité du traitement des données personnelles des visiteurs de sa page avec la plateforme elle-même.

→ CJUE, 5 juin 2018, Aff C-210/16.

1.3. Les principes encadrant le traitement des données personnelles

En droit français, la loi Informatique et libertés, indique désormais que *« l'informatique doit être au service de chaque citoyen »* et qu'elle ne doit porter atteinte *« ni à l'identité humaine, ni aux droits de l'homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou publiques ».*

1.3.1. Licéité, loyauté et transparence

Les données personnelles doivent être traitées de manière *« licite, loyale et transparente au regard de la personne concernée »*, conformément aux exigences découlant tant du droit interne, que du droit supranational.

→ Art. 5 RGPD.

→ Art. 4 de la Loi du 6 janvier 1978.

→ CEDH, 4 déc. 2008, *S. et Marper c. Royaume-Uni.*

En outre, les conditions applicables à la collecte, au traitement et à la conservation des données personnelles imposent que celles-ci soient :

- Collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes (limitation des finalités).
- Adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire (minimisation des données).
- Exactes et, si nécessaire, tenues à jour (exactitude).
- Conservées sous une forme permettant l'identification des personnes pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités (limitation de la conservation).

→ Art. 5 RGPD.

1.3.2. Le consentement : pilier relatif de la licéité des traitements

L'exigence du consentement est essentielle. Le Règlement général indique ainsi que le consentement devrait être donné par un acte positif clair par lequel la personne manifeste *« de façon libre, spécifique, éclairée et univoque »* son accord au traitement de ses données personnelles, par exemple au moyen d'une déclaration écrite (y compris par voie électronique), ou orale.

Si le consentement est donné à la suite d'une demande introduite par voie électronique, cette demande doit être claire et concise et ne doit pas inutilement perturber l'utilisation du service pour lequel il est accordé.

Il reste que la mise en œuvre d'un traitement de données personnelles n'est pas exclusivement conditionnée au consentement des personnes concernées. Le droit français et le droit de l'Union prévoient cinq autres fondements juridiques permettant un tel traitement sans que ce consentement soit requis.

Ainsi, un traitement de données personnelles est licite dans les cas suivants :

- Nécessité du traitement pour l'exécution d'un contrat.
- Respect d'une obligation légale.
- Sauvegarde des intérêts vitaux d'une personne.
- Exécution d'une mission d'intérêt public.
- Poursuite d'un intérêt légitime du responsable du traitement ou d'un tiers.

→ Art. 6 RGPD.

→ Art. 5 de la Loi de 1978.

Même pour le traitement des données sensibles qui suppose en principe le consentement explicite de la personne, les dérogations à l'interdictions existent, et elles sont nombreuses :

- Respect des obligations en droit du travail ou sécurité sociale.
- Sauvegarde des intérêts vitaux d'une personne.
- Traitement réalisé par une organisation à but non lucratif.
- Données rendues publiques par la personne concernée.
- Nécessité pour l'exercice ou la défense d'un droit en justice.
- Traitement pour un intérêt public important.
- Médecine préventive, diagnostic, soins.
- Raisons d'intérêt public en matière de santé publique.
- Fins archivistiques, scientifiques, historiques ou statistiques.

Les modalités du consentement sont renforcées lorsqu'il constitue un préalable au traitement, notamment s'agissant des cookies. Ces traceurs, déposés sur les terminaux lors de la navigation, nécessitent un consentement explicite dès lors qu'ils ne sont pas indispensables au fonctionnement du site.

La Cour de justice de l'Union européenne a ainsi jugé illégal le recours à des cases pré-cochées, estimant qu'un tel procédé ne constitue pas un consentement valable.

→ CJUE, 1 octobre 2019, *Bundesverband der Verbraucherzentralen*.

À noter que la Commission nationale de l'informatique et des libertés a édicté en juillet 2019 des lignes directrices renforçant les exigences en matière de recueil du consentement.

→ CNIL, Délibération n° 2019-093, JO, 19 juillet 2019.

1.3.3. Protection des données au-delà du consentement

Le consentement n'étant pas toujours requis pour le traitement des données, un ensemble de droits visent à préserver la maîtrise de l'individu sur ses données.

a. Droit d'opposition

Le règlement général de protection des données permet à toute personne de s'opposer à tout moment, pour des raisons tenant à sa situation particulière, à un traitement fondé sur une mission d'intérêt public ou sur l'intérêt légitime du responsable. Celui-ci ne peut s'y soustraire qu'en démontrant des motifs légitimes et impérieux.

→ Art. 21 RGPD

Le Conseil d'État a néanmoins précisé que l'opposition doit être fondée sur des éléments personnels et non sur de simples craintes générales.

→ CE, 18 mars 2019, n° 406313

b. Droits à l'information et à l'accès

Le droit de l'Union impose au responsable du traitement de fournir à la personne concernée, lors de la collecte ou *a posteriori*, des informations claires sur la finalité, les destinataires, et la durée de conservation des données.

→ Art. 13 et 14 RGPD.

Le règlement confère, par ailleurs, un droit d'accès aux données et aux informations relatives à leur traitement. Ce droit inclut l'obtention d'une copie des données, sauf exceptions.

→ Art. 15 RGPD.

En matière de sûreté de l'État ou de défense, ce droit ne peut s'exercer que par l'intermédiaire de la CNIL.

→ Art. 118 de la loi du 6 janvier 1978.

c. Droit de rectification et à effacement (ou droit à l'oubli)

Le droit de l'Union reconnaît la possibilité de rectifier des données inexactes ou problématiques.

→ Art. 16 du RGPD.

En outre, un droit à l'effacement des données est également garanti, notamment lorsque :

- Les données ne sont plus nécessaires au traitement.
- La personne retire son consentement.
- La personne exerce son droit d'opposition sans que le responsable n'ait de justification

→ Art. 17 du RGPD.

Ce droit est limité lorsque le traitement est nécessaire à l'exercice de la liberté d'expression, à des fins scientifiques, historiques ou judiciaires.

→ Art. 17.3 du RGPD.

Le contentieux du déréférencement a cristallisé ces enjeux. Ainsi, une personne peut exiger le retrait d'un lien lorsqu'il porte atteinte à sa vie privée.

→ CJUE, 13 mai 2014, *Google Spain.*

Mais le droit au déréférencement peut être écarté en cas d'intérêt public supérieur, notamment pour les personnes jouant un rôle dans la vie publique.

→ CE, 6 décembre 2019, n° 395335.

Pour des données dites sensibles, le référencement n'est licite que s'il est strictement nécessaire à la liberté d'information.

→ CJUE, 24 sept. 2019, aff. C-136/17.

Actualité jurisprudentielle. - Un véritable droit à l'explication des décisions algorithmiques

Lorsqu'une décision est prise de manière automatisée, le droit d'accès ne se limite pas à la communication des données utilisées. La personne concernée doit pouvoir obtenir des informations lui permettant de comprendre concrètement la logique ayant conduit à la décision.

La Cour de justice l'a affirmé en 2025 à propos d'un système automatisé de scoring évaluant la solvabilité d'une cliente. Le responsable du traitement doit expliquer, sous une forme concise, intelligible et accessible, la procédure et les principes effectivement appliqués à ses données afin qu'elle puisse comprendre et contester le résultat obtenu. La simple communication d'une formule mathématique ou d'un algorithme ne suffit donc pas.

Le secret des affaires ne permet pas davantage d'écarter automatiquement ce droit : en cas de conflit, les informations litigieuses doivent pouvoir être communiquées à l'autorité de contrôle ou au juge afin qu'il procède à une mise en balance des intérêts en présence.

→ CJUE, 27 février 2025, *Dun & Bradstreet Austria*, C-203/22.

À retenir. - Le RGPD tend à consacrer un droit à l'intelligibilité de la décision automatisée : une personne doit être mise en mesure de comprendre pourquoi l'algorithme a produit un résultat déterminé à son égard et de le contester effectivement.

2. Les mécanismes de garantie administratifs et juridictionnels

La protection des données personnelles repose sur des mécanismes de contrôle articulant vigilance administrative et garantie juridictionnelle. Entre prévention, régulation et sanction, ces dispositifs assurent un équilibre entre l'innovation numérique et le respect des libertés.

Autorité administrative indépendante, la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) veille à ce que l'informatique soit au service de la personne humaine, tandis que les juridictions nationales et européennes assurent un relais essentiel dans l'affirmation du droit à la protection des données personnelles.

2.1. La Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL)

La loi française confie à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, en tant qu'autorité nationale de contrôle au sens du règlement général de protection des données, la mission de veiller au respect des principes fondamentaux de la protection des données.

À ce titre, elle dispose de pouvoirs d'investigation – y compris d'un droit d'accès aux locaux, avec l'autorisation du juge des libertés si nécessaire – et de sanction, notamment dans le traitement des réclamations et plaintes.

2.1.1. Un rôle central et unique dans la protection des personnes

Instituée par la loi Informatique et libertés à la fin des années 1970, la Commission occupe une place centrale dans le dispositif de protection des personnes, et de leur vie privée, face aux traitements de données à caractère personnel. Autorité administrative indépendante à caractère collégial, elle se compose de 18 membres nommés pour cinq ans.

2.1.2. Une diversité de missions et de pouvoirs

La diversité des missions et pouvoirs confiés à la Commission témoigne de l'originalité de cette autorité de régulation : information, sensibilisation, certification, conseil, régulation et sanction. Avec l'entrée en vigueur du règlement général de protection des données, ses prérogatives ont évolué : le régime de formalités préalables a été remplacé par une logique de responsabilisation des acteurs publics et privés du traitement des données.

La mission principale de la Commission est de s'assurer que les traitements de données personnelles sont conformes à la législation française et européenne. À cette fin, elle dispose de plusieurs leviers : elle émet des avis sur certains traitements étatiques et adopte des lignes directrices, recommandations et référentiels facilitant la mise en conformité des traitements.

La Commission est habilitée à établir des règlements types visant à garantir la sécurité des systèmes de traitement de données personnelles, ainsi qu'à encadrer les traitements de données sensibles telles que les données biométriques, génétiques ou de santé. Pour veiller au respect des obligations légales par les responsables de traitement, elle dispose d'un pouvoir de contrôle lui permettant de vérifier tout traitement de données et d'obtenir les documents nécessaires à l'exercice de sa mission.

En cas de manquement, elle peut, par l'intermédiaire de son président, adresser une mise en demeure, ou engager une procédure de sanction via sa formation restreinte : rappel à l'ordre, injonction, retrait de certification, ou amende administrative pouvant atteindre 4 % du chiffre d'affaires mondial de l'entreprise.

Ainsi, en 2019, elle a infligé une amende de 50 millions d'euros à Google pour violation du RGPD.

→ CNIL, Délibération du 21 janvier 2019.

La Commission est consultée sur les projets de lois et décrets relatifs aux données personnelles, et peut faire des propositions au gouvernement. Elle a ainsi émis des avis sur les dispositifs numériques déployés durant la crise sanitaire du Covid-19.

→ CNIL, Délibération n° 2020-051 du 8 mai 2020 portant avis sur un projet de décret sur les systèmes d'information du projet de loi prorogeant l'état d'urgence sanitaire.

→ CNIL, Délibération n° 2020-056 du 25 mai 2020 portant avis sur un projet de décret relatif à l'application « StopCovid ».

2.2. Les juridictions nationales et supranationales

Les juridictions françaises et européennes assurent la protection du droit aux données personnelles, mais la Cour de Luxembourg et celle de Strasbourg se distinguent par une approche plus rigoureuse que celle du Conseil constitutionnel, tout particulièrement en matière de contrôle de proportionnalité

2.2.1. Le Conseil constitutionnel

Le Conseil constitutionnel veille à encadrer les atteintes au droit au respect de la vie privée, en rappelant que *« la collecte, l'enregistrement, la conservation, la consultation et la communication de données à caractère personnel doivent être justifiés par un motif d'intérêt général et mis en œuvre de manière adéquate et proportionnée à cet objectif »*.

Il a ainsi censuré, au nom du principe de proportionnalité, l'absence de restrictions quant au cercle des agents habilités à accéder à un registre révélant les intentions patrimoniales de certaines personnes, jugeant l'atteinte à la vie privée disproportionnée.

→ Cons. const., déc. n° 2016-591 QPC, 21 octobre 2016, *Mme Helen S. [Registre public des trusts].*

La même exigence a guidé son contrôle du dispositif de traitement des données relatives aux personnes infectées par le coronavirus. Il a notamment pris en compte le caractère sensible des données, l'absence de consentement, la détermination précise des finalités, la limitation des données auxdites finalités et la durée de conservation, en particulier lorsque les personnes étaient identifiables.

→ Cons. const., déc. n° 2020-800 DC, 11 mai 2020, *Loi relative à la prorogation de l'état d'urgence sanitaire.*

2.2.2. La Cour de justice de l'Union européenne

Au nom du principe de proportionnalité, le juge de l'Union a jugé contraire aux droits fondamentaux l'obligation imposée aux opérateurs de conserver, de manière systématique et continue, l'ensemble des données de trafic et de localisation, en raison de la gravité de l'atteinte portée à la vie privée.

→ CJUE, 6 octobre 2020, *La Quadrature du Net.*

La Cour de justice applique avec rigueur ce principe aux dispositifs de conservation généralisée des données à des fins répressives, et censure toute obligation de stockage indifférencié des données de connexion.

→ CJUE, 8 avril 2014, *Digital Rights.*

Elle considère également que la conservation préventive et massive des données ne répond pas au critère de proportionnalité au regard des objectifs poursuivis, en soulignant les risques systémiques pour les libertés fondamentales.

→ CJUE, 21 décembre 2016, *Tele2 Sverige.*

Par ailleurs, la Cour de justice a reconnu que les moteurs de recherche effectuent un traitement de données à caractère personnel, imposant un équilibre entre le droit à l'information du public et les droits à la vie privée et à la protection des données. Cette jurisprudence consacre le droit au déréférencement (droit à l'oubli).

→ CJUE, 13 mai 2014, *Google Spain.*

2.2.3. La Cour européenne des droits de l'homme

La Cour européenne des droits de l'homme s'est également montrée vigilante face à l'attrait croissant des autorités nationales pour le stockage de données personnelles, notamment les empreintes digitales et les profils ADN. Elle a souligné que l'article 8 de la Convention serait affaibli si l'usage des technologies scientifiques modernes dans le système pénal n'était pas soumis à une mise en balance rigoureuse entre les bénéfices attendus et le respect de la vie privée.

La protection des données personnelles est ainsi indissociable de l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale. La législation nationale doit prévoir des garanties effectives contre tout usage contraire aux exigences de l'article 8, en particulier dans le cadre de traitements à finalité policière.

→ CEDH, 4 décembre 2008, *S. et Marper c. Royaume-Uni.*

La conservation de données personnelles par l'État constitue une ingérence dans la vie privée. Elle n'est admissible que si elle repose sur la loi, poursuit un but légitime et s'accompagne de garanties effectives (contrôle parlementaire ou indépendant).

→ CEDH, 26 mars 1987, *Leander c. Suède.*

Les données publiques fichées par l'administration relèvent de la protection de l'article 8.

→ CEDH, 5 mai 2000, *Rotaru c. Roumanie.*

La Cour insiste sur la nécessité de prévoir des garanties appropriées, en particulier lorsque les données sont traitées de manière automatisée à des fins comme la sécurité publique.

→ CEDH, 18 septembre 2014, *Brunet c. France.*

En matière de santé, la confidentialité est de principe.

→ CEDH, 29 juin 2006, *Panteleyenko c. Ukraine.*

La communication du dossier médical dans une procédure ne peut se faire qu'avec des garanties suffisantes et dans un but d'intérêt public, sous peine de violer l'article 8.

→ CEDH, 6 juin 2013, *Avilkina c. Russie.*

La Cour impose aux États une obligation positive de protéger ces données contre les accès non autorisés, renforçant ainsi l'effet horizontal du droit à la confidentialité.

→ CEDH, 17 juillet 2008, *I. c. Finlande.*

En dehors de l'article 8 de la Convention, d'autres instruments renforcent cette protection.

→ Convention 108 du Conseil de l'Europe, amendée par le Protocole STCE n° 223.

3. Protection juridique des données personnelles à l'ère du Big Data et de l'IA

À l'ère du numérique, la protection des données personnelles s'impose comme un défi majeur. La montée en puissance et le déploiement de systèmes algorithmiques capables de traiter des données sensibles à grande échelle mettent les cadres juridiques à rude épreuve. Dans ce contexte mouvant, marqué par l'entrée en vigueur du règlement européen sur l'intelligence artificielle, la protection des droits fondamentaux se heurte à des impératifs sécuritaires et aux logiques économiques propres au capitalisme de surveillance.

3.1. Le règlement européen sur l'IA (AI Act)

Afin de protéger les personnes physiques contre les systèmes d'IA à haut risque, le règlement sur l'IA contient des règles spécifiques sur le traitement des données à caractère personnel, notamment des restrictions portant sur l'utilisation de systèmes d'IA pour l'identification biométrique à distance (reconnaissance faciale), l'évaluation des risques liés à des personnes physiques ainsi que la catégorisation biométrique à des fins répressives.

Cependant, il ne modifie pas les règles existantes sur la protection des données personnelles ni les pouvoirs des autorités de contrôle, comme la CNIL. Des interactions complexes avec le RGPD subsistent.

Le respect de la vie privée et de la protection des données personnelles doit être assuré tout au long du cycle de vie des systèmes d'IA. Les principes de minimisation et de protection des données dès la conception s'appliquent lors du traitement des données personnelles.

Les fournisseurs peuvent adopter diverses mesures pour garantir ces principes, comme l'anonymisation, le cryptage, ou l'utilisation de technologies permettant de traiter les données sans les transférer ou copier, tout en respectant les exigences de gouvernance des données.

L'impact potentiel d'un système d'IA sur les droits fondamentaux, notamment la vie privée, est un critère clé pour déterminer s'il doit être classé à haut risque.

En raison de la nature particulière des données biométriques, le règlement sur l'IA classe comme étant à haut risque l'utilisation critique des systèmes biométriques.

> → Règlement (UE) 2024/1689 du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l'intelligence artificielle.

3.2. Reconnaissance faciale et systèmes prédictifs

L'IA a donné naissance à de nouvelles technologies dans le domaine policier, renouvelant les promesses sécuritaires : lecture automatisée des plaques d'immatriculation, surveillance algorithmique, reconnaissance faciale via caméras fixes ou drones autonomes, analyse des réseaux sociaux. Ces dispositifs visent à anticiper les comportements criminels avant leur commission, mais les échecs répétés de la police prédictive au cours de la décennie 2010, notamment aux États-Unis, n'ont pas freiné l'engouement pour ces technologies.

Malgré l'incapacité des algorithmes à saisir la complexité des phénomènes sociaux, ni les entreprises ni les forces de l'ordre n'ont renoncé à leur usage, et les législateurs dans le monde peinent à encadrer ces pratiques. Le recours à ces outils implique un accroissement de la surveillance et de la collecte de données : cette dynamique présente un risque croissant pour le droit fondamental à la protection des données personnelles, d'autant plus problématique qu'elle implique non pas des acteurs privés, mais des autorités publiques.

Le cadre juridique européen, plus protecteur que celui des États-Unis, a amorcé une régulation de l'utilisation des données personnelles à des fins prédictives, notamment en interdisant certaines formes de profilage automatisé. Toutefois, face à l'opacité des algorithmes, il est essentiel de doter les autorités de contrôle de moyens renforcés.

En France, l'outil PAVED développé par la Gendarmerie suscite des inquiétudes. Bien que son utilisation soit officiellement restreinte, ce logiciel repose sur des variables sociodémographiques fortement corrélées à la délinquance, telles que la nationalité, les données migratoires, les revenus, le niveau d'éducation, la composition des ménages…

Notion essentielle. - Le droit des données personnelles comme première protection contre les usages de l'intelligence artificielle

Bien avant l'adoption du règlement européen sur l'intelligence artificielle, le droit à la protection des données personnelles a constitué un instrument essentiel d'encadrement des systèmes algorithmiques. Le RGPD, la directive « Police-Justice » et la loi Informatique et libertés permettent notamment au juge de contrôler la licéité, la nécessité et la proportionnalité de traitements automatisés reposant sur l'analyse de données biométriques ou d'images de vidéosurveillance.

Le tribunal administratif de Marseille a ainsi annulé l'expérimentation d'un dispositif de reconnaissance faciale destiné à contrôler l'accès à deux lycées de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le traitement reposait sur des données biométriques particulièrement sensibles. Le tribunal relève notamment que le consentement des élèves ne pouvait être regardé comme libre en raison de la relation d'autorité existant avec l'établissement et que l'objectif de sécurisation des accès pouvait être atteint par des moyens moins attentatoires aux droits des personnes.

→ TA Marseille, 27 février 2020, *La Quadrature du Net et autres*, n° 1901249.

Dans ce prolongement, le juge des référés du tribunal administratif de Caen est allé plus loin en 2023 à propos de l'utilisation du logiciel BriefCam par une communauté de communes. Ce système de vidéosurveillance algorithmique permettait d'identifier et de suivre automatiquement des personnes à partir de différentes caractéristiques physiques ou comportementales. Le juge rappelle que le droit au respect de la vie privée, qui comprend le droit à la protection des données personnelles, constitue une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du Code de justice administrative.

En l'absence de cadre légal ou réglementaire autorisant le dispositif et alors qu'il n'était pas établi que l'objectif de sécurité ne pouvait être atteint par des moyens moins intrusifs, son utilisation constituait une atteinte grave et manifestement illégale au respect de la vie privée. Le juge a notamment ordonné l'effacement des données personnelles recueillies.

→ TA Caen, ord., 22 novembre 2023, *Ligue des droits de l'Homme et autres*, nos 2303004 et 2303012.

À retenir. - L'AI Act ne remplace pas le droit de la protection des données. Dès lors qu'un système d'intelligence artificielle traite des données personnelles, et particulièrement des données biométriques, il demeure soumis parallèlement au RGPD, à la directive Police-Justice et à la législation nationale. Ces normes peuvent donc conduire à interdire un dispositif d'IA indépendamment de sa qualification au regard de l'AI Act.

POUR ALLER PLUS LOIN

Surveillance de masse et capitalisme de surveillance : la généralisation des technologies informatiques, la prolifération des moyens de paiement dématérialisés et l'essor des dispositifs de captation, d'enregistrement et d'archivage des données transforment profondément le rapport entre sécurité et liberté. Il devient aujourd'hui aisé, pour qui en détient les moyens, de retracer dans les moindres détails les actes d'un individu, faisant de nos traces numériques une ressource précieuse, pour les enquêteurs et les magistrats, mais également une source inégalée de preuves à charge. La rapidité avec laquelle les autorités parviennent, à la suite d'un attentat, à reconstituer le parcours d'un auteur grâce à la vidéosurveillance ou aux données de téléphonie mobile témoigne de l'efficacité de ces outils, mais aussi de leur puissance intrusive. Si ces technologies n'empêchent pas la commission des crimes, elles nourrissent néanmoins un sentiment d'efficacité et de contrôle qui peut faire illusion. Les juristes doivent rester lucides face à une évolution où la collecte massive de données, la reconnaissance faciale, les drones ou encore le stockage délocalisé des informations personnelles sur des serveurs externes dessinent les contours d'un capitalisme de surveillance. Il leur appartient de veiller à ce que la quête de sécurité ne se traduise pas, insidieusement, par un abandon irréversible de la sphère privée et des droits fondamentaux.

POUR S'ENTRAÎNER

Dissertation : Systèmes biométriques et protection des droits humains

Les technologies biométriques utilisent des caractéristiques physiques uniques afin d'identifier des individus, selon des procédures standardisées pour créer des signatures numériques. Depuis leur apparition au début du XXe siècle, avec la collecte des empreintes digitales, elles se sont diversifiées grâce aux progrès des algorithmes et de l'intelligence artificielle (IA), permettant des applications telles que la reconnaissance faciale ou l'évaluation des émotions.

On distingue trois types de systèmes biométriques :

- L'authentification.
- L'identification.
- L'évaluation.

Les systèmes biométriques présentent un risque d'atteinte aux droits fondamentaux, tout particulièrement au respect de la vie privée et à la protection des données personnelles consacrés par la Convention européenne des droits de l'homme et la Charte des droits fondamentaux.

En effet, l'utilisation de ces technologies implique la collecte et l'enregistrement de données dites sensibles dans un système informatique. Elles constituent dès lors une ingérence dans l'exercice de ces droits qui peut être considéré comme une intrusion injustifiée dans la sphère privée des individus (*rapport du Défenseur des droits, Technologies biométriques : l'impératif respect des droits fondamentaux, 2021*).

Problématique et annonce du plan : Dans un contexte où les technologies biométriques se généralisent, permettant une identification rapide et précise des individus, comment concilier le recours croissant à ces systèmes avec la protection des droits fondamentaux ? Pour éviter que les systèmes biométriques ne compromettent les droits humains, à l'ère de l'intelligence artificielle, l'Europe a décidé d'en réglementer strictement l'utilisation. Il n'en reste pas moins que, malgré une volonté d'encadrement affirmée par l'Union européenne **(I)**, il est à craindre que les garanties juridiques soient insuffisantes face à la montée des techniques de surveillance **(II)**.

I. Une volonté d'encadrement juridique forte en Europe

A. La reconnaissance du caractère particulièrement sensible des données biométriques

Les données biométriques utilisées pour identifier une personne physique sont considérées comme des données personnelles « sensibles » au regard du RGPD, de la directive Police-Justice et du nouveau règlement sur l'intelligence artificielle. Cette qualification est également consacrée en droit français par la loi du 6 janvier 1978 en raison de la capacité des données biométriques à identifier un individu à partir de caractéristiques biologiques permanentes et inaltérables.

Les données biométriques sont issues de traitements techniques portant sur des caractéristiques physiques, physiologiques ou comportementales permettant d'identifier une personne de manière unique, mais peuvent aussi servir à l'authentification, la catégorisation et la reconnaissance des émotions. L'identification biométrique, automatisée et à distance, compare les données d'une personne à celles d'une base de référence, avec ou sans son consentement, tandis que la catégorisation permet de classer les individus selon des critères tels que le sexe, la langue ou l'orientation.

B. Un régime d'interdiction assorti de certaines dérogations

Interdiction de la collecte non ciblée de données biométriques (art. 5.1, point e du règlement sur l'IA) : interdiction du scraping ou de la collecte massive de données biométriques (visages, empreintes…) à partir de sources accessibles au public (réseaux sociaux, caméras…).

Interdiction de la reconnaissance des émotions dans le travail et l'éducation (art. 5.1, point f du règlement sur l'IA). Exceptions : applications médicales, aide au diagnostic. Mesures de sécurité spécifiques : infrastructures critiques, aviation…

Interdiction de la catégorisation biométrique à partir de caractéristiques sensibles portant notamment sur l'origine ethnique, la religion, l'orientation sexuelle, les opinions politiques (art. 5.1, point g du règlement sur l'IA).

Interdiction de l'identification biométrique à distance en temps réel dans les lieux publics, sauf dans des cas exceptionnels, comme les enquêtes pour des infractions graves (art. 5.1, point h du règlement sur l'IA).

II. La persistance d'un danger systémique pour les libertés individuelles et collectives

A. Une réglementation trop strictement focalisée sur les données personnelles

La réglementation concernant la reconnaissance faciale se concentre principalement sur la protection des données personnelles. Ces traitements ne peuvent être réalisés que dans des cas exceptionnels, tels que le consentement explicite des individus, la protection de leurs intérêts vitaux, ou un intérêt public majeur.

Selon la directive « Police-Justice », le traitement de ces données n'est autorisé que lorsqu'il est absolument nécessaire, sous réserve de garanties pour les droits et libertés des personnes concernées.

En droit interne, le régime d'autorisation préalable des données sensibles a été remplacé par un système de responsabilisation des acteurs, qui doivent réaliser une analyse d'impact en cas de risques élevés pour les droits et libertés des individus.

En raison de la sensibilité des données biométriques, toute utilisation de ces données par l'État, dans le cadre de ses prérogatives de puissance publique, doit être soumise à des formalités préalables. Ces traitements doivent être autorisés par décret en Conseil d'État, après avis de la CNIL, et l'analyse d'impact doit systématiquement être soumise à cette autorité.

Il reste que la réglementation se focalise plus sur la donnée que sur la personne, sans s'appesantir sur les usages et les impacts sociaux.

À certains égards, le droit reste trop accommodant. Les évolutions du cadre juridique ne prennent pas assez la mesure du changement de paradigme induit par les systèmes biométriques, c'est-à-dire une surveillance invisible, permanente et automatisée, largement incompatible avec les garanties classiques des libertés publiques.

B. Le risque latent d'une société de surveillance algorithmique généralisée

Si l'identification biométrique à distance en temps réel dans les lieux publics à des fins répressives est interdite par le règlement sur l'IA, il existe des exceptions :

- Retrouver des victimes (enlèvement, traite, exploitation sexuelle, disparus).
- Prévenir une menace imminente à la vie ou sécurité physique.
- Localiser un suspect d'infraction grave.

Bien que l'Union européenne encadre rigoureusement l'usage de la reconnaissance faciale par les forces de l'ordre, cette technologie ouvre la voie à une surveillance de masse aux implications préoccupantes pour la vie privée des citoyens.

La tentation d'y recourir, souvent justifiée par des impératifs sécuritaires tels que la lutte contre le terrorisme, demeure forte. Les débats autour de l'usage de ces dispositifs lors des Jeux Olympiques de 2024 en France en ont témoigné : si le Conseil constitutionnel en a validé l'utilisation, une partie de la classe politique y a vu une

dérive sécuritaire, susceptible de porter atteinte aux libertés fondamentales, notamment en permettant le traitement de données biométriques sans garanties suffisantes quant à l'encadrement des algorithmes.

Pour éviter les dérives, il est impératif que l'identification biométrique à distance en temps réel soit strictement encadrée par des autorités de contrôle indépendantes, soumise à une évaluation rigoureuse et continue, et limitée à des cas exceptionnels dûment justifiés (Conseil Constitutionnel, *Décision du 17 mai 2023*).

Fiche nº 36 - LA LIBERTÉ DE PENSER, DE CONSCIENCE ET DE RELIGION

POINTS CLÉS

- Protection juridique du for intérieur et extérieur.
- Liberté de croire ou de ne pas croire.
- Liberté de manifester sa foi et conciliation avec l'ordre public.
- Principe de laïcité.

PRINCIPALES RÉFÉRENCES

- Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État.
- Jean Baubérot, *Histoire de la laïcité en France*, PUF, « Que sais-je ? », 8e éd., 2021.
- Collectif, *État et religions*, Anthemis, 2018.
- Francis Mesner (dir.), *Dictionnaire du droit des religions*, CNRS, ed., 2022.
- Frédérique De La Morena, *Les frontières de la laïcité*, LGDJ, Systèmes, 2016.
- Gérard Gonzalez (dir.), Laïcité, liberté de religion et Convention européenne des droits de l'homme, Bruylant, Nemesis, 2006.
- Valentine Zuber, *La laïcité en débat – Au-delà des idées reçues*, Le Cavalier Bleu, Coll. Idées reçues, 2017.

1. La liberté de penser, de conscience et d'opinion

Les libertés de penser, de conscience et d'opinion sont fondatrices dans nos sociétés libérales. Ce sont les libertés sur lesquelles le pouvoir possède le moins d'emprise.

Elles précèdent et rendent possible de nombreuses autres libertés : liberté d'expression, de manifestation, de réunion, d'association, droit de vote…

1.1. La protection juridique du for intérieur

La liberté d'opinion est reconnue à l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen : *« Nul ne doit être inquiété pour ses opinions même religieuses pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi. »*

La liberté de conscience bénéficie de la même assise textuelle avec l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ainsi que de la loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation de l'Église et de l'État dont l'article 1er dispose *que « la République assure la liberté de conscience »* et *« garantit le libre exercice des cultes »*.

La liberté de conscience comprend la liberté d'opinion et la liberté religieuse. Elle a aussi été consacrée par le Conseil constitutionnel comme principe fondamental reconnu par les lois de la République.

> → Cons. const., déc. nº 77-87 DC, 23 novembre 1977, *Loi complémentaire à la loi nº 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée par la loi nº 71-400 du 1er juin 1971 et relative à la liberté de l'enseignement.*

Les deux notions, liberté de conscience et liberté d'opinion, sont très imbriquées au point qu'il est parfois difficile de les dissocier. En sciences juridiques, la liberté d'opinion concerne plutôt les opinions « laïques » comme les

opinions politiques, syndicales et scientifiques. La liberté de conscience concerne plutôt les croyances religieuses et philosophiques.

La Cour européenne des droits de l'homme rappelle que la liberté de pensée et de conscience protège toutes les convictions.

→ CEDH, 25 février 1982, *Campbell et Cosans c. Royaume-Uni*, n° 7511/76 ; 7743/76.

L'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme énonce :

> *« Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit. »*

Le Conseil constitutionnel a consacré la liberté de conscience comme principe fondamental reconnu par les lois de la République.

> → Cons. const., déc. n° 2001-446 DC, 27 juin 2001, *Loi relative à l'interruption volontaire de grossesse et à la contraception.*

1.2. Le droit de ne pas voir ses opinions prises en compte

Ce droit est essentiellement garanti par toutes les clauses contre la discrimination.

> *« La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances »* (art. 1er de la Constitution du 4 octobre 1958).

Le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 énonce que :

> *« Nul ne peut être lésé, dans son travail ou son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances. »*

Il est donc interdit de licencier ou de discriminer une personne en raison de ses convictions ou de ses engagements.

> → Art. L. 1132-1 et suiv. du Code du travail

Tous les traités internationaux prohibent aussi la discrimination fondée sur *« la religion, les opinions politiques ou les autres opinions »*.

> → Art. 14 CESDH.
>
> → Art. 26 du PIDCP.

Ou sur *« la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion »*.

> → Art. 21 CDFUE.

1.3. Le droit de voir ses opinions prises en compte

Il s'agit du droit d'agir en son âme et conscience et il s'incarne principalement avec l'objection de conscience et la clause de conscience.

1.3.1. L'objection de conscience

À l'époque du service militaire obligatoire, ce n'est qu'à partir du 21 décembre 1963 que les appelés au service militaire ont pu objecter. Ils devaient prouver leur opposition à l'usage des armes en toutes circonstances devant une commission juridictionnelle où siégeaient des militaires afin d'effectuer un service civil.

Le droit à l'objection de conscience est expressément reconnu à l'article 10 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

1.3.2. La clause de conscience

Il s'agit du droit reconnu à un professionnel de refuser d'accomplir certains actes contraires à ses convictions.

> → Art. L. 2212-8 du Code de la santé publique : nul n'est tenu de pratiquer ou de recourir à une interruption volontaire de grossesse.
>
> → Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : les avocats collaborateurs ou salariés peuvent être demander à être déchargés d'une mission qu'ils estiment contraire à leur conscience.
>
> → Art. L. 123-1 du Code de la santé publique : permet de s'opposer de son vivant à tout prélèvement post-mortem sur son corps.
>
> → Proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir votée par l'Assemblée nationale le 27 mai 2025 : prévoit une clause de conscience instituée pour les professionnels de santé qui refuseraient de participer à la procédure d'aide à mourir. Ils devront renvoyer la personne vers un confrère.

Il n'existe aucune clause de conscience au bénéfice des maires et des adjoints, en tant qu'officiers de l'état civil exerçant leurs attributions au nom de l'État, qui souhaiteraient refuser de célébrer un mariage de couple de même sexe.

> → Cons. const., n° 2013-353 QPC, 18 octobre 2013, *M. Franck M. et a.*

1.4. La protection juridique du for extérieur

La liberté d'opinion ne prend réellement effet que lorsqu'elle est assortie du droit de les exprimer. La liberté d'exprimer ses pensées et ses opinions est un principe juridique fondamental.

L'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen prévoit que :

> *« La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. »*

Partant, il existe un délit d'entrave à la liberté d'expression.

> → Art. 431-1 du Code pénal.

La France ne reconnaît pas le délit d'opinion ni le blasphème, cependant l'injure et la diffamation sont prohibées. La liberté de conscience et de communication doit être conciliées avec d'autres principes.

Les atteintes à la libre communication des idées sont acceptables quand le but recherché est légitime et que les atteintes sont proportionnées.

> → Cons. const., déc. n° 2017-695 QPC, 29 mars 2018, *M. Rouchdi B. et autre (Mesures administratives de lutte contre le terrorisme).*

Le pluralisme des courants d'expression socioculturels nécessaire à la construction libre des idées est un objectif à valeur constitutionnelle.

> → Cons. const., déc. n° 82-141 DC, 27 juillet 1982, *Loi sur la communication audiovisuelle.*

La Cour européenne des droits de l'homme déclare que la liberté d'expression doit être vue comme un des fondements des sociétés démocratiques.

> → CEDH, 7 décembre 1976, *Handyside c. Royaume-Uni*, n° 5493/72

POUR ALLER PLUS LOIN

Modalités spécifiques de l'expression des agents publics : devoir de neutralité, de réserve et de loyauté.

Article L. 121-2 du Code de la fonction publique : « Dans l'exercice de ses fonctions, l'agent public est tenu à l'obligation de neutralité.

Il exerce ses fonctions dans le respect du principe de laïcité. À ce titre, il s'abstient notamment de manifester ses opinions religieuses. Il est formé à ce principe.

L'agent public traite de façon égale toutes les personnes et respecte leur liberté de conscience et leur dignité. »

Le devoir de loyauté et de réserve concerne surtout les agents publics remplissant une fonction d'autorité comme les policiers, les militaires ou les gendarmes.

Actualité jurisprudentielle. - La neutralité du service public ne permet pas de discriminer en raison d'une pratique religieuse privée

Les agents publics sont tenus à une obligation de neutralité dans l'exercice de leurs fonctions. Cette exigence ne permet toutefois pas à l'administration de déduire de la seule apparence physique d'une personne qu'elle entend manifester ses convictions religieuses dans le service.

Le Conseil d'État s'est prononcé en juillet 2026 sur le refus d'agrément opposé à un candidat aux fonctions de policier adjoint. L'intéressé présentait sur le front une marque dermatologique résultant de sa pratique régulière de la prière. Si l'administration pouvait vérifier qu'il respecterait à l'avenir les obligations de neutralité propres à ses fonctions, la seule présence de cette marque, résultant d'un rite pratiqué dans sa vie privée, ne permettait pas de considérer qu'il entendrait manifester ses convictions religieuses dans le service.

→ CE, 27 juillet 2026, *M. A.B. c/ ministre de l'Intérieur*, n° 499886, publié au Recueil.

À retenir. - La neutralité s'impose au comportement de l'agent dans le service ; elle ne permet pas de transformer les manifestations physiques involontaires d'une pratique religieuse privée en présomption de non-respect de la laïcité.

2. La liberté de culte et de religion

La liberté de religion est complexe, elle se décline sous plusieurs formes et elle protège essentiellement la liberté de croire. Le droit français consacre la liberté de religion dès l'article 1er de la Constitution de 1958 et dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en son article 10.

La liberté de religion est aussi protégée par les textes relatifs à l'absence de discrimination fondées sur la religion : Déclaration des Nations unies de 1981 sur l'élimination de toutes les formes d'intolérance et de discrimination fondées sur la religion.

La liberté religieuse comporte une dimension individuelle : la liberté de croire ou non et une dimension collective, le droit pour les croyants de se réunir pour se livrer à un culte.

2.1. La liberté de croire, de ne pas croire et d'en changer

Le Conseil d'État a établi trois conditions cumulatives imposables aux associations qui souhaitent être reconnues comme des associations cultuelles :

- Leur objet social doit être exclusivement cultuel : en relation avec le religieux ;
- L'activité ne doit pas s'écarte de cet objet ;
- Et elles ne doivent pas troubler l'ordre public.

Cette liberté de religion, purement interne à chacun emporte des conséquences. Le juge européen en dégage le droit au respect de l'intimité des convictions religieuses. Le secret de ces convictions, leur caractère privé et intime doit être protégé.

→ CEDH, 12 décembre 2002, *Sofianopoulos et a. c. Grèce*, 1977/02.

Il s'agit de données sensibles dont le RGPD interdit la collecte sauf exceptions strictement définies.

L'État se voit donc imposer de fortes obligations négatives liées au respect du caractère absolu de la liberté de choisir sa religion ou de ne pas en avoir et il doit protéger les individus des préjugés dont ils pourraient être victimes du fait du caractère minoritaire de leur courant de pensée religieuse ou philosophique.

La liberté de religion comprend aussi la liberté de ne plus croire ou de changer de religion. Cette liberté figure dans plusieurs textes européens :

→ Art. 9 CESDH.

→ Art. 10 CDFUE.

2.2. La liberté de manifester sa foi

Il existe diverses manifestations de la liberté de conviction : le culte, les rites, l'enseignement et les pratiques.

Le culte désigne l'hommage religieux rendu à Dieu, ou à un saint personnage ou encore l'ensemble des pratiques réglées par une religion pour rendre cet hommage. Au pluriel, l'expression renvoie aux religions elles-mêmes comme dans l'article 1er de la loi de 1905 qui garantit « le libre exercice des cultes ».

Le culte est en général rendu à la divinité dans un lieu dédié sous la direction d'un ministre du culte.

Pour le Conseil d'État, il s'agit d'un principe fondamental reconnu par les lois de la République et une liberté fondamentale au titre de l'article L. 521-2 du Code de la justice administrative.

→ CE, 6 avril 2001, *Syndicat national des enseignants du second degré.*

→ CE, 16 février 2004, *Benaïssa.*

Les rites sont quant à eux associés à l'exercice du culte. Le pluralisme religieux a favorisé l'apparition de rites nouveaux dont la prise en compte peut être problématique comme l'abattage rituel ou encore les rites funéraires.

Un enseignement religieux peut être inscrit au programme des écoles publiques françaises, mais une dispense doit être automatiquement accordée aux élèves qui le souhaitent sans que cette demande soit motivée. Il en est de même pour les écoles privées sous contrat.

Enfin, s'agissant des pratiques, la Cour européenne des droits de l'homme a souvent rappelé que ce terme ne désignait pas n'importe quel acte motivé ou inspiré par une conviction lui permettant de refuser certaines prétentions comme le refus de vaccination, l'irrespect des horaires de travail pour motif religieux…

→ CEDH, 8 avril 2021, *Vavricka et a. c. République Tchèque*, n° 47621/13.

→ CEDH, 3 décembre 2006, *Kontinen c. Finlande*, n° 24949/94.

Le contentieux fait apparaître de nombreuses difficultés liées au port des signes religieux qui constitue la pratique la plus contestée ainsi que les tenues vestimentaires.

2.3. Les restrictions à la liberté de religion

Les différentes manifestations de la liberté de religion peuvent être soumises à des restrictions. Classiquement, l'État peut limiter la liberté de religion pour des motifs de maintien de l'ordre public ou de bon fonctionnement du service public. Il en est de même au sein des entreprises.

2.3.1. Les restrictions fondées sur l'ordre public

Le Préfet est compétent pour prononcer la fermeture d'un lieu de culte *« aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme »* dans lequel, *« les propos qui sont tenus, les idées ou théories qui sont diffusées ou les*

activités qui se déroulent provoquent à la violence, à la haine ou à la discrimination, provoquent à la commission d'actes de terrorisme ou font l'apologie de tels actes ».

→ Art. L. 227-1 du Code de la sécurité intérieure.

→ Cons. const., n° 2017-695 QPC, 29 mars 2018, *M. Rouchdi et autres.*

La fermeture prononcée ne peut pas excéder six mois, non renouvelables.

Le Conseil d'État a ajouté que la provocation à la violence, à la haine ou à la discrimination en lien avec le risque de commission d'actes de terrorisme, à la commission d'actes de terrorisme ou à l'apologie de tels actes peut résulter, outre des propos tenus au sein du lieu de culte :

- de propos exprimés, dans les médias ou sur les réseaux sociaux, par les responsables de l'association chargée de la gestion de ce lieu ou par les personnes en charge du culte qui y officient.
- de propos émanant de tiers diffusés dans les médias ou sur les réseaux sociaux relevant de la responsabilité de cette association ou de ces personnes en charge du culte.
- de la présence au sein du lieu de culte d'ouvrages ou de supports en faveur de ces idées ou théories.

→ CE, 26 avril 2022, n° 462685, *Association Rassemblement des musulmans de Pessac.*

Le Conseil d'État a notamment suspendu des arrêtés municipaux interdisant le port du burkini sur les plages, ces arrêtés portaient une atteinte illégale à la liberté de conscience en l'absence de risque avéré de trouble à l'ordre public.

→ CE, 26 août 2016, *Ligue des droits de l'homme*, n° 402742.

→ CE, 17 juillet 2023, *Ligue des droits de l'homme*, n° 457636.

Une telle interdiction a pu être justifiée en Corse à la suite de la commission d'actes violents.

→ CE, 14 février 2018, *Ligue des droits de l'homme*, n° 413982.

Concernant la dissimulation du visage dans l'espace public : les pouvoirs de police du maire et du préfet leur permettent d'interdire la dissimulation du visage dans certains lieux publics exposés à des risques avérés pour l'ordre public en fonction des circonstances locales. La loi du 11 octobre 2010, n° 2010-1192 interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public généralise ses possibilités et dispose que : *« Nul ne peut, dans l'espace public, porter une tenue destinée à dissimuler son visage, l'espace public est constitué des voies publiques ainsi que des lieux ouverts au public ou affectés à un service public. »*

Actualité jurisprudentielle. - La fermeture administrative d'un lieu de culte est soumise à un contrôle strict de proportionnalité

Outre le régime de l'article L. 227-1 du Code de la sécurité intérieure relatif à la prévention du terrorisme, l'article 36-3 de la loi du 9 décembre 1905 permet au préfet de fermer temporairement un lieu de culte lorsque les propos, idées, théories ou activités qui s'y développent provoquent ou encouragent la haine ou la violence.

Saisi de ce dispositif, le Conseil constitutionnel rappelle que la mesure porte atteinte à la liberté de conscience, au libre exercice des cultes et à la liberté d'association. Elle n'est admissible que si elle est nécessaire, adaptée et proportionnée à la prévention des atteintes à l'ordre public.

Le préfet peut tenir compte de propos ou comportements extérieurs au lieu de culte ou émanant de personnes qui n'y officient pas, à la condition qu'ils présentent un lien suffisant avec le lieu concerné. Il doit également tenir compte des conséquences de la fermeture sur les fidèles et de la possibilité pour eux de pratiquer leur culte dans un autre lieu.

→ Cons. const., déc. n° 2025-1180 QPC, 6 février 2026, *Association des Bleuets*.

À retenir. - Le principe de laïcité ne constitue pas seulement un fondement de restrictions : il impose également à la République de garantir le libre exercice des cultes.

2.3.2. Les restrictions fondées sur le fonctionnement du service public

La liberté des usagers d'exprimer leurs convictions religieuses au sein du service public peut être limitée si elles empêchent le bon fonctionnement du service.

En matière d'enseignement, le Conseil d'État a admis le principe d'encadrement de la liberté religieuse des élèves à condition que l'interdiction de porter tout signe religieux ne soit pas générale et absolue.

→ CE, 2 novembre 1992, *Kherouaa*, n° 130394.

La loi n° 2004-228 du 15 mars 2004, encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics a interdit le port de signes manifestant ostensiblement une appartenance religieuse dans les établissements scolaires.

Le Conseil d'État a ainsi jugé que le port d'un sous-turban sikh manifestait ostensiblement l'appartenance à la religion sikhe de celui qui le porte.

→ CE, 5 décembre 2012, *Singh*, n° 385394.

Idem pour le bandana couvrant la chevelure d'une élève, et qu'elle avait refusé d'ôter.

→ CE, 5 décembre 2012, *Ghazal*, n° 295671.

De plus, le principe de laïcité interdit de se prévaloir de ses croyances religieuses pour s'affranchir des règles communes régissant les relations entre les collectivités publiques et les particuliers.

→ Cons. const., déc. n° 2004-505 DC, 19 novembre 2004, *Traité instituant une Constitution pour l'Europe*.

Un individu ne peut donc pas être dispensé de figurer tête nue sur les photographies de sa carte d'identité compte-tenu de ses pratiques religieuses.

→ CE, 15 décembre 2006, *Association United Sikhs*, n° 289946.

Concernant les dispositions d'un règlement intérieur d'une piscine municipale autorisant le port du burkini, le Conseil d'État a considéré que cette dérogation, qui ne visait qu'à satisfaire une revendication religieuse, affectait le bon fonctionnement du service public et portait atteinte à l'égalité de traitement des usagers et, par suite, à la neutralité du service public.

→ CE, 21 juin 2022, *Commune de Grenoble,* n° 464648.

2.3.3. Les signes religieux en entreprise

Le droit de manifester sa religion au travail ne peut pas être interdit de façon générale et absolue. Toute sanction ou discrimination en raison de la religion est illégale.

Cependant, le règlement intérieur d'une entreprise peut contenir des dispositions inscrivant le principe de neutralité et restreignant la manifestation des convictions des salariés si ces restrictions sont justifiées par l'exercice d'autres libertés et droits fondamentaux ou par les nécessités du bon fonctionnement de l'entreprise et si elles sont proportionnées au but recherché.

→ Art. L. 1321-2-1 du Code du travail.

La Cour de cassation a ainsi jugé que l'employeur est en droit d'imposer des contraintes vestimentaires à un salarié si elles sont justifiées par la nature des tâches à accomplir et proportionnées au but recherché.

La religion ne peut pas être invoqué par un salarié pour refuser d'accomplir des tâches pour lesquelles il a été recruté ou se soustraire aux visites médicales obligatoires. De plus, le prosélytisme est strictement interdit dans l'entreprise.

→ Cass, soc., 12 novembre 2008, n° 07-42220.

→ Cass, ass. plén., 25 juin 2014, n° 13-28369, *Affaire dite de la crèche Baby Loup.*

La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 fournit un cadre aux entreprises de tendance et aux entreprises qui souhaitent instaurer une obligation de neutralité religieuse dans leur règlement intérieur.

Les entreprises de tendance sont autorisées à prendre en compte les convictions personnelles dans le recrutement de leurs personnels puis à les soumettre à des obligations particulières notamment en matière de religion.

Elles impliquent une doctrine que le salarié doit respecter au moins en comportement si ce n'est pas en conscience.

→ Cass. ass. plén., 19 mai 1978, *Dame Roy c. Association pour l'éducation populaire Sainte-Marthe.*

Actualité jurisprudentielle. - La participation à un service public ne suffit pas toujours à établir l'assujettissement d'un opérateur privé à la neutralité

Les principes de laïcité et de neutralité s'appliquent aux services publics, y compris lorsqu'ils sont assurés par des personnes privées. Il convient toutefois de déterminer si l'opérateur privé concerné est effectivement assujetti à ces obligations.

En novembre 2025, la Cour de cassation a été saisie d'une société de pompes funèbres utilisant le terme « catholique » dans son nom commercial. Le service extérieur des pompes funèbres constitue bien un service public industriel et commercial. Toutefois, l'entreprise concernée n'exerçait cette activité qu'en vertu d'une habilitation préfectorale, sans qu'une collectivité lui ait délégué le service.

Au regard de la rédaction de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, qui vise notamment les organismes auxquels la loi ou le règlement confie directement l'exécution d'un service public, son assujettissement aux obligations de neutralité n'était donc pas suffisamment certain pour que l'usage du terme « catholique » constitue, avec l'évidence requise en référé, un trouble manifestement illicite.

⟶ Cass. com., 13 novembre 2025, *Société Service catholique des funérailles*, n° 23-22.932, publié au Bulletin.

À retenir. - Il ne suffit pas qu'une personne privée participe matériellement à une activité de service public pour lui appliquer automatiquement l'ensemble des obligations de neutralité : il faut identifier précisément le fondement juridique de son intervention et les règles auxquelles elle est soumise.

3. Le principe de laïcité

Issue de la loi de 1905 de séparation des Églises et de l'État bien qu'elle n'y figure pas *expressis verbis*, la laïcité est un modèle destiné à assurer la neutralité de l'État à l'égard des cultes. Les religions sont préservées de l'État et réciproquement.

Le principe est aujourd'hui inscrit à l'article 1er de la Constitution en tant que principe républicain. Le Conseil constitutionnel en a précisé le contenu en dégageant quatre axes (Cons. const., déc. n° 2012-297 QPC, 21 février 2013, *Association pour la promotion et l'expansion de la laïcité*) :

- Le respect de toutes les croyances et l'égalité de tous les citoyens devant la loi sans distinction de religion ;
- La garantie du libre exercice des cultes ;
- La neutralité de l'État ;
- L'absence de culte officiel et de salariat du clergé.

3.1. Le principe de séparation de l'Église et de l'État

La loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation de l'Église et de l'État proclame la liberté de conscience dans son article 1er et oblige l'État à la neutralité en matière de religion. En effet, l'article 2 de la loi de 1905 interdit à l'État de subventionner les cultes.

« La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. »

Le juge administratif est venu encadrer les interventions des administrations concernant les dépenses d'édifices cultuels. Il a considéré qu'elles pouvaient financer les dépenses d'entretien et de conservation des édifices servant à l'exercice public d'un culte dont elles sont demeurées ou devenues propriétaires en 1905, et accorder des concours aux associations cultuelles pour des travaux de réparation d'édifices cultuels.

Les collectivités peuvent aussi participer au financement de projets en rapport avec un édifice cultuel en respectant le principe de neutralité et d'égalité comme la construction d'un ascenseur pour faciliter l'accès aux personnes à mobilité réduite.

→ CE, 19 juillet 2011, n° 308817, *Fédération de la libre pensée et de l'action sociale du Rhône*.

L'article 4 de la loi de 1905 institue un statut spécial pour les associations cultuelles.

Cependant, toutes les relations entre l'État et les cultes ne sont pas proscrites : l'État a l'obligation d'assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics comme les lycées, les collèges, les écoles, les hospices, les asiles et les prisons.

Le principe de laïcité implique une intervention de l'État afin de garantir à chacun la possibilité de pouvoir pratiquer son culte :

- Les aumôneries : chaque personne détenue peut exercer le culte de son choix, à titre individuel dans sa cellule ou collectivement dans les salles prévues à cet effet, en présence des intervenants d'aumônerie.

  → Art. R 351-1 du Code pénitentiaire.

- Les cimetières : exception à l'interdiction d'apposition des signes religieux au profit des cimetières, autorisation des signes et emblèmes religieux sur les sépultures et autorisation des cérémonies religieuses.

  → Art. 28 de la loi du 9 décembre 1905.

  → Art. L. 2223-11 et -12 du CGCT.

- Les autorisations d'absence pour les agents publics : l'administration peut accorder des autorisations d'absence à ses agents à l'occasion de la célébration de fêtes religieuses. Le chef de service, dans le silence des lois et règlements fixe les règles applicables aux agents concernés et apprécie si cette autorisation d'absence est compatible avec les nécessités du fonctionnement normal du service.

  → CE, 12 février 1997, *Demoiselle H,* n° 125893.

Enfin, le déféré-laïcité permet aux préfets de demander la suspension d'un acte d'une collectivité territoriale portant *« gravement atteinte aux principes de laïcité et de neutralité des services publics »*. Le juge administratif dispose de 48 heures pour statuer sur la demande de suspension.

→ Art. L. 2131-6, L. 3132-1 et L. 4142-1 CGCT.

Actualité jurisprudentielle. - La séparation protège l'autonomie interne des organisations religieuses

La neutralité de l'État implique également le respect de l'autonomie d'organisation des cultes. Le juge judiciaire ne peut ainsi apprécier la régularité ou le bien-fondé de la décision par laquelle une congrégation ou une association cultuelle légalement constituée nomme ou révoque un ministre du culte conformément à ses règles internes (en l'espèce, il s'agissait d'une procédure interne engagée contre l'Eglise catholique contre un diacre, accusé d'agressions sexuelles).

La Cour de cassation précise, en outre, que l'engagement religieux n'est pas, par lui-même, de nature à créer des obligations civiles. Les avantages matériels accordés au ministre du culte pour l'exercice de son ministère ne résultent donc pas nécessairement d'un contrat.

Lorsque la suppression de ces avantages est indissociable de la décision religieuse de révocation, le juge civil ne peut en contrôler indirectement le bien-fondé par l'intermédiaire d'une action indemnitaire.

⟶ Cass., Ass. plén., 4 avril 2025, n° 21-24.439, publié au Bulletin.

À retenir. - La liberté religieuse possède une dimension institutionnelle : les organisations religieuses disposent d'une autonomie dans leur organisation interne que la neutralité de l'État impose au juge de respecter.

3.2. Les exceptions au principe de laïcité

La laïcité ne s'applique pas sur tout le territoire français. Le concordat de 1801 reste en vigueur en Alsace et en Moselle qui n'était pas française en 1905.

Le Conseil constitutionnel a reconnu la constitutionnalité du droit local d'Alsace-Moselle qui est érigé en principe fondamental reconnu par les lois de la République.

→ Cons. const., déc.n° 2011-157 QPC, 5 août 2011, *Société SOMODIA (Interdiction du travail le dimanche en Alsace-Moselle).*

Les décrets-lois Mandel du 16 janvier 1939 et du 5 décembre 1939 permettent aussi à d'autres territoires ultramarins de déroger au principe de laïcité : Guyane, Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Mayotte, Wallis-et-Futuna, Saint-Pierre-et-Miquelon.

3.3. La laïcité « à la française »

Certains auteurs s'interrogent sur la notion de laïcité à la française et la place prépondérante de l'Église catholique en France. L'Église catholique a conservé de nombreux avantage et en a conquis après la loi de 1905 : fêtes légales, calendrier scolaire, jouissance des lieux de culte anciens, possibilité de sonner les cloches, diffusion des messes sur le service public, organisation de cérémonies officielles sur des bâtiments de la marine de guerre…

De manière générale, l'Église catholique a bénéficié d'un véritable assouplissement de la laïcité à telle enseigne que certains auteurs ont pu parler de « fausse laïcité à la française ».

La Cour européenne des droits de l'homme mentionne dans ses arrêts concernant la France l'existence du « modèle française de laïcité », sa spécificité et son importance dans l'histoire et le droit français.

→ CEDH, 26 novembre 2015, *Ebrahimian c. France*, n° 64846/11.

POUR S'ENTRAÎNER

Commentaire d'arrêt : CE, 8e et 3e chambres réunies, 18 mars 2024, n° 471061.

Selon le rapport de la commission de réflexion sur l'application du principe de laïcité paru en 2003, la laïcité est *« la pierre angulaire du pacte républicain »*. La loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État est venue ancrer cette notion de laïcité en France.

Avant de recevoir une traduction juridique au sein des constitutions de 1946 et de 1958 « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale », le principe de laïcité a fait l'objet de débats politiques et philosophiques mouvementés.

Ces débats sont toujours d'actualité comme en témoigne l'arrêt à commenter en l'espèce. Cet arrêt trouve sa source dans l'occupation à titre gratuit d'un théâtre municipal à une association de culte pour la célébration de l'Aïd.

Dans son arrêté du 13 juin 2018, le maire de Nice autorise l'association « Union des Musulmans des Alpes-Maritimes » à occuper à titre gratuit le théâtre municipal Lino Ventura le vendredi 15 juin 2018 de 7 heures à 11 heures.

Le 3 septembre 2018, le tribunal administratif rejette la demande de M.B.A et de l'Association niçoise pour la défense de la laïcité qui souhaitait faire annuler l'arrêté municipal. La Cour administrative d'appel de Marseille dans son arrêt du 7 janvier 2019 annule l'ordonnance du tribunal administratif et renvoie l'affaire devant le tribunal administratif de Nice. Dans son jugement du 16 février 2021, le tribunal administratif de Nice rejette la demande de l'association pour la défense de la laïcité. La Cour administrative d'appel de Marseille, dans son arrêt du 19 décembre 2022, annule le jugement du 16 février 2021 ainsi que l'arrêté municipal du maire de Nice.

La commune de Nice se pourvoit en cassation devant le Conseil d'État. Le Conseil d'État devait donc statuer sur la légalité de cet arrêté municipal et de sa conformité au principe de laïcité.

Problématique et annonce du plan : Pédagogue, le Conseil d'État rappellera dans un premier temps les fondements du principe de laïcité **(I)**, tout en contrôlant et validant les possibles exceptions à ce principe **(II)**.

I. Le rappel du principe de laïcité

A. La laïcité fondée sur la neutralité et l'égalité

Le Conseil d'État rappelle tout d'abord dans son considérant 2 les fondements de la laïcité en France et les termes de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État. *« La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes »* ; *« La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte »* ainsi les associations formées pour subvenir aux frais et à l'entretien et à l'exercice des cultes *« ne pourront, sous quelque forme que ce soit, recevoir des subventions… »*. C'est cette question de subvention « déguisée » qui est au cœur de cet arrêt du fait de la gratuité accordée qui contreviendrait aux principes de neutralité de l'État envers les cultes et au principe d'égalité requis dans l'établissement du montant de la contribution pour l'occupation d'un local communal par une association cultuelle.

B. La protection des associations cultuelles contre les discriminations

Dans son considérant 5, le Conseil d'État rappelle qu'une *« commune ne peut rejeter une demande d'utilisation d'un tel local au seul motif que cette demande lui est adressée par une association dans le but d'exercer un culte »*.

On retrouve ici un rappel classique de l'interdiction des discriminations fondées notamment sur la religion. Clauses contre la discrimination prévues à l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958, préambule du 27 octobre 1946 et des textes internationaux (article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques…)

II. L'encadrement des exceptions au principe de laïcité

A. L'autorisation d'un usage ponctuel des locaux communaux

Dans les considérants 4 et 5, le Conseil d'État reprend des conditions qu'il avait déjà énumérées dans des précédents arrêts (CE, ass, 19 juillet 2011, no 313518, Commune de Montpellier et CE, 8e et 3e chambres réunies, 7 mars 2019, no 417629).

Il est possible que soit ponctuellement exercé un culte par une association dans un local communal (au sens large, de l'article L. 2144-3 du CGCT) à la quadruple condition :

- L'occupation ne doit être ni exclusive ni pérenne.
- Le principe d'égalité de traitement doit être respecté.
- Prise en compte *« des nécessités de l'administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l'ordre public »*.
- Absence d'une quelconque aide financière ou libéralité.

B. L'ajout d'une gratuité envisageable

Le Conseil d'État vient préciser qu'il appartient au conseil municipal de déterminer la contribution due par l'association en raison de l'utilisation du local communal en vertu des dispositions de l'article L. 2144-3 du Code général des collectivités territoriales, qui dérogent à celles, générales, de l'article L. 2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques.

« Il lui appartient d'arrêter le montant de cette contribution, dans le respect du principe d'égalité, de telle façon qu'il ne soit pas constitutif d'une libéralité. »

De plus, cette libéralité ne saurait résulter du simple fait que le local est mis à disposition gratuitement. Elle est appréciée compte tenu de la durée et des conditions d'utilisation du local communal, de l'ampleur de

l'avantage éventuellement consenti et, le cas échéant, des motifs d'intérêt général justifiant la décision de la commune.

En conclusion, le Conseil d'État justifie ainsi la gratuité en fonction du contexte et de la durée en question de la mise à disposition du local communal et casse l'arrêt du 19 décembre 2022 pour erreur de droit (considérant 7).

Fiche nº 37 - LA LIBERTÉ D'EXPRESSION

POINTS CLÉS

- Pierre angulaire d'une société démocratique.
- Pluralisme.
- Liberté d'opinion et liberté de parole.
- Liberté de communiquer et de recevoir des informations.
- Droit de la presse.
- Absence de considération de frontières.
- Devoirs et responsabilités.
- Limitations et mise en balance.
- Abus de droit : discours de haine, antisémitisme, racisme, etc.

PRINCIPALES RÉFÉRENCES

- Art. 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
- Art. 10 de la Convention européenne des droits de l'homme.
- Art. 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
- Art. 11 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
- Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
- Cons. const., déc. nº 86-217 DC, 18 septembre 1986, *Loi relative à la liberté de communication.*
- Loi nº 2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte.
- Règlement (UE) nº 2022/2065 « Digital Service Act » du 19 octobre 2022.

1. Une liberté essentielle à la vie démocratique

1.1. Les fondements d'un droit essentiel

La liberté d'expression est consacrée dans de nombreux instruments normatifs internationaux et européens. Au niveau universel, l'article 19 de la Déclaration Universelle des droits de l'homme et l'article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques indiquent que *« toute personne a droit à la liberté d'expression ;* […] *».* Une formule similaire est retenue pour sa consécration au niveau européen à l'article 11 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi qu'à l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme qui dispose que :

> *« Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. »*

La liberté d'expression est reconnue comme étant une liberté essentielle au plus haut niveau de l'ordre normatif. Elle est à la fois un droit subjectif et un principe objectif et structurant dans tout régime démocratique.

Dès 1789, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en son article 11 reconnaît qu'il s'agit *« d'un des droits les plus précieux de l'homme »*. Elle constitue un principe à valeur constitutionnelle reconnu par le Conseil constitutionnel.

Sa préciosité est affirmée en ce que *« son exercice est l'une des garanties essentielles du respect des autres droits et libertés et de la souveraineté nationale »* :

→ Cons. const., déc. n° 84-181 DC, 11 octobre 1984, *Loi visant à limiter la concentration et à assurer la transparence financière et le pluralisme des entreprises de presse.*

→ Cons. const., déc. n° 93-345 DC, 29 juillet 1994, *Loi relative à l'emploi de la langue française*.

La liberté d'expression est néanmoins un droit susceptible de limitations et non absolu, elle n'en est pas moins essentielle dans ses multiples facettes, à la fois individuelle (permettant la libre expression de chacun), mais également collective (permettant le partage et le débat d'idées, la réception des informations par le public tout en favorisant l'exercice des autres libertés telles que la liberté d'association ou la liberté de conscience et de religion). En cela, elle est fondamentale à l'épanouissement de chacun et à l'exercice et au progrès de la démocratie par l'expression du pluralisme :

→ CEDH, 7 décembre 1976, *Handyside c. Royaume-Uni*, n° 5493/72.

→ CDH, 12 juillet 1996, *Adimo M. Aduayom et a. c. Togo* (déc.), n° 422 à 424/1990.

Le fait d'entraver l'exercice de la liberté d'expression est par ailleurs un délit sanctionné à l'article 431-1 du Code pénal.

1.2. La substance du droit à la liberté d'expression

1.2.1. Une liberté protéiforme

Le droit à la liberté d'expression ne protège pas seulement contre les potentielles ingérences de l'État, mais également les atteintes dans les relations interindividuelles et possède ainsi un « effet horizontal ». Elle implique ainsi une obligation positive pour l'État de garantir l'exercice de cette liberté et de mettre en place les garanties matérielles et procédurales adéquates contre les atteintes par des personnes privées.

→ CEDH, 20 octobre 2009, *Lombardi Vallauri c. Italie*, n° 39128/05.

a. La liberté d'opinion

Sous cet angle, la liberté d'expression protège l'expression de toutes les idées et opinions, même minoritaires, contribuent au pluralisme essentiel à une société démocratique. Une formule célèbre de la Cour européenne indique que cette liberté *« vaut non seulement pour les "informations" ou "idées" accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent l'État ou une fraction quelconque de la population. Ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l'esprit d'ouverture sans lesquels il n'est pas de "société démocratique" »*.

→ CEDH, 7 décembre 1976, *Handyside c. Royaume-Uni*, n° 5493/72.

Le législateur peut cependant édicter des règles concernant l'exercice du libre droit à la communication, de la liberté de parler, d'écrire et d'imprimer, tout en préservant le pluralisme des courants d'expression socioculturels (art. 4 et 34 de la Constitution) qui est un objectif de valeur constitutionnelle :

→ Cons. const., déc. n° 86-217 DC, 18 décembre 1986, *Loi relative à la liberté de communication.*

Elle s'exerce sans considération de supports :

→ Cass. crim, 26 février 2020, n° 19-81.827.

Elle vaut pour tous les contextes (académique, recherche, carcéral…) même si certaines restrictions peuvent frapper les fonctionnaires soumis du fait de leur statut à des « devoirs et responsabilités » spécifiques et une obligation de « neutralité » (art. L. 121-2 du Code général de la fonction publique).

→ CEDH, 2 septembre 1998, *Ahmed et a. c. Royaume-Uni*, n° 65/1997/849/1056.

b. La liberté d'information :

Elle vaut pour toute personne et ne distingue pas selon les objectifs recherchés. Elle implique la liberté de recevoir des informations et la liberté de « communiquer » des informations.

> *« La Cour considère toujours que "le droit à la liberté de recevoir des informations interdit essentiellement à un gouvernement d'empêcher quelqu'un de recevoir des informations que d'autres aspirent ou peuvent consentir à lui fournir". De plus, "le droit de recevoir des informations ne saurait se comprendre comme imposant à un État des obligations positives de collecte et de diffusion,* motu proprio*, des informations" »* (CEDH [GC], 8 novembre 2016, *Magyar Helsinki Bizottság c. Hongrie*, n° 18030/11).

Il n'existe pas un droit absolu d'accès aux informations détenues par une autorité publique, ni d'obligation de l'État à les lui communiquer, sauf si celle-ci a été imposée par une décision judiciaire devenue exécutoire ou lorsque l'accès à l'information est essentiel pour l'exercice de la liberté de recevoir et de communiquer des informations.

> Les critères pour considérer si une restriction à l'accès des informations par l'État doit être considérée comme une ingérence sont les suivants (CEDH [GC], 8 novembre 2016, *Magyar Helsinki Bizottság c. Hongrie*, n° 18030/11) :

- Le but de la demande d'information : la collecte d'information peut représenter une étape préparatoire à l'exercice de la liberté d'expression, il faut alors déterminer si les informations sont nécessaires à celle-ci.
- La nature des informations recherchées : un poids particulier est attaché à la liberté d'information si les informations sont d'intérêt public ou contribuent au débat politique.
- Le rôle de la personne recherchant ces informations : si celle-ci endosse le rôle de « chien de garde public » en facilitant la transmission de l'information au public, elle doit pouvoir bénéficier d'une protection importante de son droit d'accès à l'information.
- La disponibilité des informations : le fait que les informations demandées soient déjà disponibles constitue un critère important dans l'appréciation globale de la question de savoir si un refus de fournir ces informations peut être considéré comme une « ingérence ».

La notion d'information doit être comprise largement. Elle inclut, de manière non exhaustive, le discours politique ou commercial, l'art, les informations factuelles ou tout autre échange d'idées ou question d'intérêt général pouvant donner lieu à un débat d'intérêt général, recouvrant également la sphère numérique.

Le Comité des droits de l'homme définit lui aussi la liberté d'information comme couvrant l'expression et la réception de communications sur toute forme d'idée et d'opinion susceptible d'être transmise à autrui.

> → CDH, 29 juillet 2011, Observation générale n° 34 sur l'article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Cette liberté protège toutes les formes d'expression ainsi que les moyens de les diffuser, sans considération de frontières, afin de favoriser la libre circulation de l'information. Les autorités nationales doivent donc s'abstenir d'empêcher cette libre circulation, et mettre en œuvre des moyens pour la favoriser.

Ces obligations recouvrent désormais également l'accès à Internet :

> → CDH, 29 juillet 2011, Observation générale n° 34 sur l'article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
>
> → CEDH, 10 mars 2009, *Times Newspapers Ltd c. Royaume-Uni (n° 1 et 2)*, n° 3002/03 et 23676/03.

Cependant, toutes les informations ne bénéficient pas de la même protection. Le discours politique bénéficie par exemple d'une protection renforcée lorsqu'il est exercé par des acteurs de la vie politique, notamment des personnalités membres de l'opposition. Il participe directement à la vie démocratique et à la discussion des idées. Partant, la restriction de cette forme expression doit néanmoins être appréciée strictement et ne peut être justifiée que par un besoin social impérieux, à l'instar de l'apologie de la violence ou du discours de haine, notamment en ce qu'une société démocratique doit être fondée sur le respect et la dignité.

> → CEDH, 16 juillet 2009, *Féret c. Belgique*, n° 15615/07.

1.2.2. La particularité du droit de la presse

a. Un pilier de la démocratie

La presse tient un rôle essentiel pour la démocratie et l'État de droit puisqu'elle permet la diffusion des idées et des questions d'intérêt général et participe directement au pluralisme. Sa protection est considérée comme une « exigence impérative » :

→ CJCE, 26 juin 1997*, Vereinigte familiapress Zeitungsverlags- und Vertriebs GmbH*, C-368/95.

La loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse et la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication forment le cadre normatif de ce droit en France en consacrant la liberté de la presse et les responsabilités lui étant associées. Ce cadre a connu plusieurs évolutions législatives pour tenir compte des exigences constitutionnelles et internationales.

→ CE, SSR, 7 février 2003, *GISTI*, n° 243634.

La presse joue un rôle de « chien de garde public » de la société démocratique qui implique une marge d'appréciation étroite pour considérer comme nécessaire la restriction de ses activités par les autorités nationales dès qu'un débat d'intérêt général est en jeu, imposant une tolérance particulière à ses activités.

→ CEDH, 7 novembre 2006, *Mamère c. France*, n° 12697/03.

L'article 10 n'interdit pas une restriction ou interdiction préalable à la diffusion de l'information. En revanche, de telles restrictions sont dangereuses pour le libre accès du public à l'information, notamment si celle-ci est périssable, et ces restrictions doivent faire l'objet d'un examen rigoureux des juridictions.

Ces principes s'étendent à la publication d'ouvrages qui ne sont pas considérés comme faisant partie de la « presse » *stricto sensu*, mais qui traitent d'informations d'intérêt général.

→ CEDH, 26 novembre 1991, *Observer et Guardian c. Royaume-Uni*, n° 13585/88.

→ CEDH [GC], 10 novembre 2015, *Couderc et Hachette Filipacchi Associés c. France*, n° 40454/07.

La Cour européenne des droits de l'homme effectue un contrôle afin de vérifier si les juridictions ont correctement réalisé l'équilibre entre les différents intérêts en jeu selon la marge nationale d'appréciation de l'État et substituer son appréciation à celles des autorités internes si cela s'avère nécessaire à l'issue de son contrôle. En cas d'incitation à la violence ou à la haine, la restriction de la liberté de la presse est légitime pour des considérations d'ordre public, tout en tenant compte de l'impact potentiel de l'expression sur le public :

→ CEDH, 2 octobre 2008, *Leroy c. France,* n° 36109/03.

Le droit de la presse implique également une protection accrue des sources journalistiques en ce qu'une divulgation de ces sources *« ne saurait se concilier avec l'article 10 (art. 10) de la Convention que si elle se justifie par un impératif prépondérant d'intérêt public »*, notamment eu égard aux conséquences négatives qu'auraient ces divulgations dans une société démocratique en dissuadant la presse d'exercer son rôle.

→ CEDH, 27 mars 1996, *Goodwin c. Royaume-Uni*, 17488/90.

→ Art. 2 de la loi du 29 juillet 1881 tel que modifié par la loi du 4 janvier 2010, n° 2010-1.

Ces sources relèvent du secret professionnel et toute tentative des autorités publiques de révéler celles-ci constituent une ingérence. Cela vaut également pour les perquisitions, bien que l'ingérence puisse être justifiée si la mesure est proportionnée au but légitime et que les garanties procédurales sont respectées.

Le Conseil constitutionnel précise que les atteintes aux sources journalistiques sont justifiées *« uniquement aux fins de recueillir des renseignements intéressant la sécurité nationale, la sauvegarde des éléments essentiels du potentiel scientifique et économique de la France ou la prévention du terrorisme, de la criminalité et de la délinquance organisées et de la reconstitution ou du maintien de groupements dissous »* et bénéficient des garanties adéquates.

→ Cons. const., déc. 2015-478 QPC, 24 juillet 2015, *Association French Data Network et autres.*

b. … impliquant des devoirs et une déontologie

L'exercice de la recherche et de la transmission des informations fiables et précises par la presse implique des devoirs et des responsabilités, dont l'étendue dépend de la situation et du procédé utilisé, notamment au regard du respect des règles pénales de droit commun, mais également du respect de la déontologie journalistique :

→ CEDH, 10 décembre 2007, *Stoll c. Suisse*, n° 69698/01.

→ CDH, déc. 29 juillet 2004, *Kankanamge c. Sri-Lanka*, n° 909/2000.

La protection dévolue au droit de la presse ne peut s'exercer que dans le cadre d'un journalisme responsable, qui ne *« couvre pas uniquement le contenu des informations qui sont recueillies et/ou diffusées par des moyens journalistiques. Elle englobe aussi, entre autres, la licéité du comportement des journalistes, du point de vue notamment – ce qui est pertinent en l'espèce – de leurs rapports publics avec les autorités dans l'exercice de leurs fonctions journalistiques »*.

Néanmoins, le fait qu'un journaliste ait enfreint la loi doit être pris en compte, mais n'est pas déterminant pour établir s'il a agi de manière responsable :

→ CEDH [GC], 20 octobre 2015, *Pentikäinen c. Finlande*, n° 11882/10.

Actualité jurisprudentielle. - La protection des sources journalistiques s'applique quel que soit le lieu de la saisie

Le secret des sources constitue une garantie essentielle de la liberté de la presse. Sa protection ne saurait dès lors dépendre uniquement du lieu dans lequel les investigations sont réalisées.

Un journaliste avait été interpellé dans un restaurant alors qu'il rencontrait une source. Son carnet de notes, son téléphone et son ordinateur professionnels avaient été saisis. Or, l'article 56-2 du Code de procédure pénale organisait principalement les garanties applicables aux perquisitions dans les locaux professionnels, les véhicules professionnels ou le domicile du journaliste.

Afin de rendre ce texte compatible avec l'article 10 de la Convention européenne, la Cour de cassation juge que, lorsque les investigations sont liées à son activité professionnelle, le journaliste doit pouvoir s'opposer à la saisie d'un objet ou document en sa possession quel que soit le lieu où elle intervient, lorsqu'il fait état d'éléments laissant présumer que son exploitation porterait atteinte au secret de ses sources. Le bien doit alors être placé sous scellé fermé et la contestation soumise au juge des libertés et de la détention.

→ Cass. crim., 17 mars 2026, n° 25-81.815, publié au Bulletin.

À retenir. – La protection des sources est attachée à l'activité journalistique et aux informations détenues par le journaliste, et non au seul lieu dans lequel elles se trouvent.

2. Une liberté susceptible d'être limitée

2.1. Les clauses de limitation

Les dispositions encadrant la liberté d'expression peuvent s'accompagner de restrictions légitimes à son exercice, d'interprétation étroite.

L'article 19-3 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ainsi que l'article 10-2 de la Convention européenne des droits de l'homme énoncent une possibilité de restriction spéciale, et l'article 52-1 de la Charte des droits fondamentaux dispose une possibilité de restriction générale.

L'analyse d'une ingérence dans la liberté d'expression s'analyse selon le triptyque libéral bien connu : légalité, légitimité, nécessité ou proportionnalité.

La proportionnalité de l'ingérence au but légitime poursuivi s'apprécie relativement à l'ensemble des éléments de l'affaire. Une ingérence sera considérée comme proportionnée si elle répond aux critères suivants :

- L'existence d'un besoin social impérieux doit pouvoir justifier l'adoption d'une mesure de restriction, laissant une certaine marge nationale d'appréciation concernant l'interprétation de celui-ci (restreinte dans le cas du droit de la presse).
- Les sanctions infligées ne doivent pas être excessives ni avoir pour conséquence de dissuader l'exercice de la liberté d'expression (à l'instar de la censure). En cela, les autorités nationales doivent prendre les sanctions les moins attentatoires possibles et éviter les mesures trop générales.

Le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État et la Cour de cassation se sont alignés en la matière sur la jurisprudence de la Cour européenne dont ils reprennent mot pour mot les formules.

→ Cons. const., déc. n° 2012-647 DC, 28 février 2012, *Loi visant à réprimer la contestation de l'existence des génocides reconnus par la loi.*

→ Cass. civ., 23 avril 2003, n° 01-01851.

Le Conseil constitutionnel rappelle par ailleurs qu'il incombe au législateur d'assurer la conciliation entre, d'une part, la prévention des atteintes à l'ordre public et des infractions, nécessaire à la sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelle, et, d'autre part, l'exercice des droits et des libertés constitutionnellement garantis.

→ Cons. const., déc. 2015-478 QPC, 24 juillet 2015, *Association French Data Network et a*.

Dans le cas où la liberté d'expression entre en conflit avec l'exercice d'un autre droit humain d'égale valeur, la Cour européenne des droits de l'homme a développé la technique de la « mise en balance ». Celle-ci implique pour les autorités nationales l'obligation de ménager un juste équilibre entre les différents intérêts en présence.

→ CEDH [GC], 7 février 2012, *Axel Springer AG c. Allemagne*, n° 39954/08.

Une jurisprudence abondante est née de la confrontation de la liberté d'expression avec le droit au respect de la vie privée, et notamment la protection de la réputation, bien que cette mise en balance ne soit pas limitée à ce cas particulier. Quand la Cour européenne des droits de l'homme considère l'article 8 applicable à la protection de la réputation d'autrui, l'atteinte portée par la liberté d'expression et à la réputation doit atteindre un certain seuil de gravité, de manière à causer un préjudice à la jouissance des droits d'autrui.

→ CEDH [GC], 7 février 2012, *Von Hannover c. Allemagne (n° 2)*, n° 40660/08 et 60641/08.

L'existence d'un débat d'intérêt public a une importance fondamentale pour cette mise en balance des droits concurrents et fait sensiblement pencher la balance vers une appréciation large de la liberté d'expression. La jurisprudence européenne laisse toutefois une grande marge nationale d'appréciation pour désigner ce qui entre ou non dans ce type de débat en fonction des circonstances et parfois au préjudice des intérêts individuels.

La tolérance à la critique doit être élargie dans le cadre du débat public de même que pour les acteurs prenant part au débat politique (associations, syndicats, personnalités politiques…), en comparaison avec le degré admissible de critique à l'égard d'un particulier, nécessairement loin large :

→ CEDH, 1er juillet 1997, *Lingens c. Autriche*, n° 9815/82.

Dans ce cadre, le délit de critique d'un chef d'État, d'un monarque ou toute interdiction d'une critique envers une personne en fonction de son statut n'est pas compatible avec la liberté d'expression et a été abrogé par la loi du 9 mars 2004 (voir anciennement l'article 36 de la loi du 29 juillet 1881).

À noter : l'article 16 de la Convention européenne des droits de l'homme permet à l'État de restreindre les activités politiques des étrangers extraeuropéens constituant dès lors une justification légitime à la restriction de la liberté d'expression.

Actualité jurisprudentielle. - Le retrait d'un contenu en ligne suppose un abus manifeste de la liberté d'expression

En l'espèce, plusieurs personnes mises en cause dans six vidéos diffusées sur une chaîne YouTube avaient demandé à Google Ireland d'en obtenir le retrait. Les vidéos les accusaient notamment de corruption et de participation à un réseau ayant affecté le fonctionnement des institutions monégasques. Les intéressés estimaient ces accusations diffamatoires et demandaient également la communication des données permettant d'identifier l'auteur de la chaîne.

La Cour de cassation rappelle que le juge peut, sur le fondement de la LCEN (Loi pour la confiance dans l'économie numérique), ordonner le retrait d'un contenu ou le blocage d'un site afin de faire cesser un dommage. Toutefois, lorsque l'auteur des propos n'est pas partie à la procédure et ne peut donc présenter sa défense, une telle mesure porte directement atteinte à la liberté d'expression. Le juge doit alors caractériser le caractère manifestement illicite des propos litigieux.

La seule circonstance que les propos portent atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne ne suffit pas : une accusation apparemment diffamatoire peut encore échapper à la qualification de diffamation si son auteur établit la vérité des faits ou bénéficie de l'excuse de bonne foi.

Lorsque l'auteur ne peut être identifié malgré les obligations pesant sur le prestataire technique, le juge doit en outre rechercher si la suppression des propos constitue une mesure proportionnée à l'atteinte subie par les personnes visées.

→ Cass. 1ère civ., 26 février 2025, *Société Google Ireland Limited*, n°23-16.762, publié au Bulletin.

À retenir. - Le caractère potentiellement diffamatoire d'un contenu ne permet pas son retrait automatique. En l'absence de l'auteur des propos, le juge doit protéger le débat contradictoire et la liberté d'expression en vérifiant l'illicéité manifeste du contenu puis la proportionnalité de sa suppression.

2.2. Les clauses d'autorisation

Les systèmes européen et français permettent de soumettre la possibilité de diffusion sur les ondes à un système de licence et d'autorisation. L'État doit cependant permettre à différents acteurs et différentes représentations d'avoir accès à la diffusion afin de garantir un pluralisme effectif et l'indépendance des médias, tout en pouvant subir des limitations ou restrictions sur le contenu diffusé :

→ Cons. const., déc. n° 86-217 DC, 18 septembre 1986, *Loi relative à la liberté de communication.*

→ CJCE, 23 octobre 2003, *RTL Television GmbH c. Niedersächsische Landesmedienanstalt für privaten Rundfunk*, C-245/01.

La loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (dite loi Léotard) encadre ces autorisations et l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (anciennement Conseil Supérieur de l'Audiovisuel) contrôle l'exercice de la liberté de communication au public par voie électronique, dans les conditions définies par la loi. En cas de non-respect de ces dispositions, l'autorisation peut être retirée :

→ CE, sect. 19 février 2025, *Sociétés NRJ 12 et NRJ Group, Société C8*, n° 499823 et 500009.

2.3. Les interdictions

La loi du 29 juillet 1881 sanctionne l'injure et la diffamation. Les deux notions sont à différencier en ce que la diffamation, sanctionnée à l'article 29, concerne l'attribution ou l'allégation d'un fait précis et vérifiable portant atteinte à l'honneur, alors que l'injure porte sur une appréciation générale sans se référer à des faits en particulier.

L'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 limite cependant ces atteintes en considérant que *« ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux »*, de même que l'article 26 de la Constitution attribue une liberté d'expression élargie aux parlementaires.

Il n'existe pas de délit de blasphème en France, permettant dès lors une critique même véhémente des religions. En revanche, les propos tenus à l'encontre d'une personne ou d'un groupe de personnes de par leur religion doivent s'abstenir d'être à teneur injurieuse, ménageant un équilibre délicat entre la liberté d'expression et le discours injurieux.

L'article 17 de la Convention européenne des droits de l'homme, 20 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et l'article 54 de la Charte des droits fondamentaux concernant l'abus de droit interdisent d'utiliser les dispositions de ces instruments dans un but « visant à la destruction » des autres droits humains protégés et dès lors, contraire aux valeurs défendues par ces instruments. Concrètement, cela correspond à l'interdiction de l'utilisation de la liberté d'expression pour justifier les discours appelant à la haine, à la discrimination, à la violence ou l'hostilité ainsi que ceux faisant l'apologie du terrorisme (art. 421-2-5 du Code pénal).

Cette interdiction s'applique également en cas de connotations péjoratives incitant à la haine ou à la violence :

→ Cass. crim., 17 septembre 2019, n° 18-85299

La loi « Pleven » du 1er juillet 1972 relative à la lutte contre le racisme a tout d'abord permis l'incrimination de tout discours constituant une provocation à la discrimination raciale, à la haine ou à la violence à l'égards d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. La loi « Gayssot » du 13 juillet 1990 tendant à réprimer tout acte raciste, antisémite ou xénophobe complète cette liste et créé le délit de « négationnisme » (art. 24 et 24 *bis* de la loi du 29 juillet 1881).

→ Cass, Crim 16 octobre 2012, n° 11-82866.

→ CEDH, 20 octobre 2015, *Dieudonné Mbala Mbala c. France*, n° 25239/13.

→ CEDH, 24 juin 2003, *Garaudy c. France* (déc.), n° 65831/01.

Le Conseil constitutionnel a par ailleurs reconnu la constitutionnalité de ces interdictions en considérant qu'elles *« ont pour objet de réprimer un abus de l'exercice de la liberté d'expression et de communication qui porte atteinte à l'ordre public et aux droits des tiers »* :

→ Cons. const., 8 janvier 2016, déc. n° 2015-512 QPC, *M. Vincent R. [Délit de contestation de l'existence de certains crimes contre l'humanité].*

Cependant, le Conseil constitutionnel n'a pas reconnu comme nécessaire, adaptée et proportionnelle, l'élargissement de cette interdiction à *« la négation, la minoration ou la banalisation de façon outrancière d'un crime de génocide, d'un crime contre l'humanité, d'un crime de réduction en esclavage ou d'un crime de guerre »*.

→ Cons. const., 26 janvier 2017, déc. n° 2016-745 DC, *Loi relative à l'égalité et la citoyenneté.*

La Cour européenne des droits de l'homme possède également une jurisprudence relativement restreinte concernant le déclenchement de l'article 17 et si elle a pu connaître d'affaires concernant la négation de l'holocauste sous cet angle, la négation du génocide arménien est analysée sous l'angle de l'article 10-2, dès lors qu'en l'espèce, elle considère qu'il existait un lien trop ténu entre l'État en question et les événements du génocide :

→ CEDH, 15 octobre 2015, *Perinçek c. Suisse*, n° 27510/08.

Cependant, le négationnisme, le racisme et l'antisémitisme ne sont pas les seuls discours interdits, les lois du 30 décembre 2004 puis du 27 janvier 2017 introduisent également l'interdiction de la provocation à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe en raison du sexe, de l'orientation sexuelle ou identité de genre ou de leur handicap.

3. La digitalisation de la liberté d'expression

Le Conseil constitutionnel reconnaît l'importance du développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication pour la participation à la vie démocratique et l'expression des idées et des opinions, toute atteinte devant dès lors être nécessaire, adaptée et proportionnée à l'objectif poursuivi.

→ Cons. const., déc. n° 2018-773 DC, 20 décembre 2018, *Loi relative à la lutte contre la manipulation de l'information.*

→ Cons. const., déc. n° 2009-580 DC, 10 juin 2009, *Loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet.*

Le développement sans précédent des nouvelles technologies de télécommunication participe au pluralisme et à l'idéal démocratique, mais présentent en même temps des risques importants de dérives au regard de la protection des droits d'autrui, des discours de haine ou de la désinformation. Partant, plusieurs instruments juridiques sont venus réglementer les discours en ligne.

Les dispositions relatives à la liberté d'expression sont étendues au cadre numérique qui bénéficient de dispositions spécifiques notamment la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique qui responsabilise les hébergeurs et fournisseurs de service en ligne, les obligeant à retirer un contenu manifestement illégal après notification. De même, la loi du 24 juin 2020 visant à lutter contre les contenus haineux sur Internet (dite loi Avia) améliore les dispositifs de signalement sur les plateformes et renforce la coopération entre autorités et hébergeurs. Elle devait initialement obliger les plateformes à retirer dans les 24 heures un contenu manifestement illicite avant que la disposition ne soit censurée par le Conseil constitutionnel :

→ Cons. const., déc. n° 2020-801 DC, 18 juin 2020, *Loi visant à lutter contre les contenus haineux sur Internet.*

Au niveau de l'Union européenne, le Digital Service Act, en vigueur depuis le 17 février 2024, responsabilise les plateformes et tous les acteurs agissant dans le cadre européen en luttant contre la diffusion de discours ou productions illicites ou dommageables en facilitant le signalement de contenus illicites devant être retirés rapidement.

La Cour européenne des droits de l'homme considère également qu'une plateforme en ligne possède des devoirs et responsabilités et est responsable en cas de publication de contenus manifestement illicites en ce que son rôle de modérateur nécessite de retirer rapidement certains contenus problématiques.

→ CEDH [GC], 16 juin 2015, *Delfi AS c. Estonie*, n° 64569/09.

Le Comité des ministres du Conseil de l'Europe a adopté plusieurs recommandations sur le respect des droits humains sur Internet notamment la recommandation CM/Rec(2011)7 – du 21 septembre 2001 sur une nouvelle conception des médias ou le Guide des droits de l'homme pour les utilisateurs d'Internet (CM/Rec(2014)6) adopté le 16 avril 2014 par le Comité des ministres permettant de ménager un équilibre entre protection des droits d'autrui et liberté d'expression dans la sphère numérique.

POUR ALLER PLUS LOIN

La protection des lanceurs d'alerte est également couverte par la protection de la liberté d'expression (CEDH [GC], 12 février 2008, Guja c. Moldavie, n° 14277/04). En France, c'est la loi du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte qui en définit le cadre et transpose la directive européenne 2019/1937. La loi assouplit certains éléments de la loi « Sapin 2 » qui encadrait très strictement ce régime causant des difficultés pour la protection effective des lanceurs d'alerte. Le lanceur d'alerte est ainsi défini comme une personne physique qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l'intérêt général, une violation ou une tentative de dissimulation d'une violation d'un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d'un acte unilatéral d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement, du droit de l'Union européenne, de la loi ou du règlement. La loi supprime la condition de « désintéressement » de l'action et l'obligation d'avoir « personnellement » connaissance des informations dénoncées. Les signalements se font désormais par le biais d'une procédure interne à l'entité ou externe en se référant à une autorité compétente (Défenseur des droits, autorités judiciaires, etc.). La dénonciation publique est alors restreinte à des cas restreints de danger imminent (pour le public ou le lanceur d'alerte lui-même) ou d'absence de traitement de la plainte, toujours sous le sceau de l'irresponsabilité pénale.

Actualité jurisprudentielle. - Le retrait d'un contenu en ligne suppose un abus manifeste de la liberté d'expression

La lutte contre les contenus illicites en ligne doit être conciliée avec le risque de suppression excessive de contenus licites.

La Cour de cassation juge ainsi que le retrait d'un contenu ou le blocage d'un site ordonné sur le fondement de la Loi pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN), en l'absence de débat contradictoire avec l'auteur des propos, suppose que leur caractère manifestement illicite soit établi.

La seule circonstance que des propos portent atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne ne suffit pas à caractériser cette illicéité manifeste. Une accusation apparemment diffamatoire peut en effet bénéficier de l'exception de vérité ou de la bonne foi de son auteur.

Lorsque l'auteur des propos ne peut être identifié, le juge doit en outre rechercher si leur suppression constitue une mesure proportionnée à l'atteinte subie par la personne visée.

→ Cass. 1ère civ., 26 février 2025, n° 23-16.762, publié au Bulletin.

À retenir. - La régulation des contenus numériques ne doit pas conduire à une logique de retrait automatique. Lorsqu'il ordonne la suppression d'une expression en ligne, le juge doit préserver la liberté d'expression et vérifier concrètement la nécessité et la proportionnalité de son intervention.

POUR S'ENTRAÎNER

Commentaire d'arrêt : Cass, ass. plén., 25 octobre 2019, n° 17-86.605.

« […] *Faits et procédure*

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 septembre 2017), la chaîne de télévision France 2 a diffusé, le 7 janvier 2012, dans l'émission « On n'est pas couché », une séquence au cours de laquelle, à l'issue de l'interview de l'un des candidats à l'élection présidentielle, ont été montrées des affiches, publiées trois jours auparavant par le journal "Charlie Hebdo", concernant ces candidats.

2. L'une de ces affiches représentait un excrément fumant surmonté de la mention "C…, la candidate qui vous ressemble".

3. Mme C… a déposé plainte avec constitution de partie civile en soutenant que cette comparaison constituait, à son égard, l'infraction d'injure publique envers un particulier.

4. Renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef de complicité de cette infraction, M. I…, animateur de l'émission, a été relaxé. Seule la partie civile a interjeté appel.

Énoncé du moyen

5. Mme C… fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement ayant rejeté ses demandes, alors que : "1°/ toute injure au sens de l'article 29, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse constitue une atteinte à la dignité de la personne visée et qu'en l'espèce, la cour d'appel n'avait pas à rechercher si, au-delà du caractère injurieux de l'affiche incriminée qu'elle admettait comme établi, était également caractérisée une atteinte à la dignité de la partie civile,

2°/ en toute hypothèse, l'affiche incriminée porte atteinte à la dignité de la partie civile en l'associant à un excrément, même si cette affiche s'inscrit dans une forme d'humour satirique volontiers scatologique, n'utilise pas l'image de la partie civile et renvoie tant à celle-ci qu'à son électorat, et dépasse donc les limites admissibles de la liberté d'expression,

3°/ l'injure est présumée faite avec une intention coupable et que si cette présomption peut céder devant la preuve contraire, celle-ci ne saurait résulter en l'espèce de ce que M… I… s'est contenté d'exhiber, dans le cadre de la séquence d'une émission polémique, l'affiche litigieuse en précisant son origine et en donnant un avertissement sur son caractère satirique, ces éléments n'étant nullement de nature à démontrer qu'il n'avait pas conscience que cette affiche était injurieuse à l'égard de A… C…"

Réponse de la Cour

6. La liberté d'expression constitue l'un des fondements essentiels d'une société démocratique. 7. Elle ne peut être soumise à des ingérences que dans les cas où celles-ci constituent des mesures nécessaires au regard de l'article 10, § 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

8. La restriction qu'apportent à la liberté d'expression les articles 29, alinéa 2, et 33 de la loi du 29 juillet 1881, qui prévoient et répriment l'injure, peut donc être justifiée si elle poursuit l'un des buts énumérés à l'article 10, § 2, de cette Convention.

9. Parmi ces buts, figure la protection de la réputation ou des droits d'autrui.

10. Il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme que la réputation d'une personne, même lorsque celle-ci est critiquée au cours d'un débat public, fait partie de son identité personnelle et de son intégrité morale et, dès lors, relève de sa vie privée au sens de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, arrêt du 15 novembre 2007, Pfeifer c. Autriche, n° 12556/03).

11. Le droit au respect de la vie privée et le droit à la liberté d'expression ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de rechercher, en cas de conflit, un juste équilibre entre ces deux droits.

12. La dignité de la personne humaine ne figure pas, en tant que telle, au nombre des buts légitimes énumérés à l'article 10, § 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

13. Si elle est de l'essence de la Convention (CEDH, 22 novembre 1995, S.W. c. Royaume-Uni, n° 20166/92), elle ne saurait être érigée en fondement autonome des restrictions à la liberté d'expression.

14. Dès lors, pour déterminer si la publication litigieuse peut être incriminée, il suffit de rechercher si elle est constitutive d'un abus dans l'exercice du droit à la liberté d'expression.

15. La première branche du moyen est donc inopérante.

16. L'exigence de proportionnalité implique de rechercher si, au regard des circonstances particulières de l'affaire, la publication litigieuse dépasse les limites admissibles de la liberté d'expression.

17. En l'absence de dépassement de ces limites, et alors même que l'injure est caractérisée en tous ses éléments constitutifs, les faits objet de la poursuite ne peuvent donner lieu à des réparations civiles.

18. En l'espèce, l'arrêt retient que l'affiche, qui a été publiée dans un journal revendiquant le droit à l'humour et à la satire, comporte une appréciation du positionnement politique de Mme C… à l'occasion de l'élection présidentielle et a été montrée par M. I… avec d'autres affiches parodiant chacun des candidats à l'élection présidentielle, dans la séquence d'une émission polémique s'apparentant à une revue de presse, mention étant expressément faite que ces affiches émanent d'un journal satirique et présentent elles-mêmes un caractère polémique.

19. La cour d'appel, qui a exactement apprécié le sens et la portée de cette affiche à la lumière des éléments extrinsèques qu'elle a souverainement analysés, en a déduit, à bon droit, que la publication litigieuse ne dépassait pas les limites admissibles de la liberté d'expression.

20. La deuxième branche du moyen n'est donc pas fondée.

21. L'arrêt étant légalement justifié par la seule constatation de l'absence de dépassement des limites admissibles de la liberté d'expression, la troisième branche, qui critique des motifs surabondants, relatifs au renversement de la présomption d'intention coupable, est inopérante.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, siégeant en assemblée plénière, et prononcé le vingt-cinq octobre deux mille dix-neuf. »

L'arrêt se penche sur les limites de la liberté d'expression dans le cadre de la caractérisation d'une injure publique d'une candidate à l'élection présidentielle.

La requérante dénonce le caractère attentatoire à sa dignité humaine en ce que son nom est associé à un excrément dépassant selon elle les limites de la critique admissible, la cour d'appel ayant considéré de son côté que l'affiche ne constituait pas un abus de la liberté d'expression.

La Cour de cassation confirme le raisonnement de la cour d'appel en considérant que bien que l'injure soit caractérisée, celle-ci ne dépasse pas les limites de la critique admissible.

L'arrêt est notable en ce qu'il permet à la Cour d'appliquer les dispositions européennes tout en clarifiant le lien entre liberté d'expression et dignité humaine, toutes deux au cœur du développement des droits humains, dans un arrêt qui constitue un revirement de jurisprudence sur le sujet.

Problématique et annonce du plan : La Cour de cassation affirme le caractère essentiel de la liberté d'expression par un contrôle classique de proportionnalité **(I)** tout en opérant un revirement sur les fondements des limitations à la liberté d'expression précédemment admis **(II)**.

I. L'appréciation classique de la portée de la liberté d'expression

A. Le rappel de la liberté d'expression comme droit essentiel à la vie démocratique

La Cour rappelle le fondement essentiel de la liberté d'expression pour la société démocratique du fait de sa contribution au pluralisme, à la circulation des idées et au débat public qui correspondent aux éléments essentiels d'une société démocratique (CEDH, 7 décembre 1976, *Handyside c. Royaume-Uni*, n° 5493/72).

Sa protection est au cœur des instruments supranationaux (art. 19 DUDH et PIDCP, art. 10 CESDH).

Ce droit est par ailleurs consacré au plus haut niveau de l'ordre normatif interne (Cons. const., déc. n° 84-181 DC, 11 octobre 1984, *Loi visant à limiter la concentration et à assurer la transparence financière et le pluralisme des entreprises de presse*). Le pluralisme favorisé par la liberté d'expression est lui-même considéré comme un objectif à valeur constitutionnelle (Cons. const. déc. n° 86-217 DC, 18 décembre 1986, *Loi relative à la liberté de communication*).

Le Comité des droits de l'homme mentionne également son caractère essentiel dans une démocratie comme « pierre angulaire » (déc. 12 juillet 1996, *Adimo M. Aduayom et al. c. Togo*, n° 422 à 424/1990). La Cour de cassation rappelle ainsi tout d'abord cette place essentielle.

B. Un contrôle de proportionnalité étendu

La Cour de cassation confirme son contrôle étendu concernant la liberté d'expression de la presse, montrant ainsi l'importance accordée à la protection de cette liberté, et selon une jurisprudence constante en en faisant un contrôle minutieux (Cass. civ. 11e, mars 2020, n° B19-13.716).

Elle réalise un contrôle de proportionnalité au sens de l'article 10 § 2 de la Convention européenne et mentionné par le Conseil constitutionnel dans Cons. const., déc. n° 2012-647 DC, 28 février 2012, *Loi visant à réprimer la contestation de l'existence des génocides reconnus par la loi*, indiquant également que les restrictions à la liberté d'expression doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif poursuivi.

Elle recherche donc les limites admissibles de la liberté d'expression face à la protection de la réputation et des droits d'autrui par un contrôle de proportionnalité de ces deux droits de valeur égale. Dans ce cadre, des éléments traditionnels du contrôle sont mis en avant notamment le contexte « polémique » de l'émission et du journal, la référence au programme politique, le fait que les autres candidats à l'élection aient également fait l'objet de critiques du même ordre (CEDH [GC], 7 février 2012, *Von Hannover c. Allemagne (n° 2)*, n° 40660/08 et 60641/08 et CEDH [GC], 7 février 2012, *Axel Springer AG c. Allemagne*, n° 39954/08).

Les exigences de la jurisprudence européenne sont conciliées avec la loi du 29 juillet 1881 : le contrôle de proportionnalité permet de justifier ou non l'ingérence et l'article 29 de loi du 29 juillet 1881 et permet la réparation, mais cette réparation n'est plus une conséquence automatique de la caractérisation de l'injure, celle-ci devant outrepasser les limites de la critique admissible. Cela s'inscrit dans une série de modification ou réinterprétation de la loi du 29 juillet 1881.

II. Une protection paradoxale de la liberté d'expression

A. La remise en question de la dignité comme fondement de la limitation de la liberté d'expression

La Cour fait une interprétation stricte des buts légitimes.

Elle décline le moyen selon lequel la dignité humaine en ferait partie selon une interprétation stricte et formaliste des restrictions listées de manière exhaustive dans la Convention européenne des droits de l'homme.

Il s'agit ainsi d'un revirement de jurisprudence concernant l'utilisation de la dignité humaine (en l'espèce par l'injure) pour limiter la liberté d'expression.

La dignité avait pu être utilisée auparavant comme fondement de la limitation de la liberté d'expression dans Cass. civ., 20 décembre 2000, n° 98-13.875, mais également par le juge administratif dans CE, réf. 9 janvier 2014, *ministre de l'Intérieur c. Sté de Production La Plume*, n° 374508.

Le recours à la valeur de la dignité était cependant particulièrement malléable.

Cet arrêt fait émerger un paradoxe selon lequel la dignité est au cœur des droits humains et en constitue un principe matriciel, mais l'atteinte à ce principe fondamental ne peut plus servir de fondement « autonome » pour la restriction de la liberté d'expression.

Il s'agit ainsi d'une réaffirmation de l'importance de la liberté d'expression et de la jurisprudence CEDH, 7 décembre 1976, *Handyside c. Royaume-Uni*, n° 5493/72, mais qui questionne sur le refus général de l'utilisation de la dignité comme but légitime de limitation.

B. Une liberté d'expression particulièrement protégée dans le cadre des élections nationales

L'analyse de la Cour s'insère dans un contexte très particulier correspondant aux élections présidentielles :

L'arrêt fait le lien entre la liberté d'expression, le pluralisme et le droit à des élections libres, malgré le fait que la Cour de cassation ne mentionne pas l'intérêt public d'une telle expression, bien que cet élément soit déterminant pour le contrôle de proportionnalité.

La Cour européenne des droits de l'homme reconnaît une large marge nationale d'appréciation dans le cadre des élections et du discours à visée politique, peu importe le support.

L'art satyrique qui « vise naturellement à provoquer et à agiter » (CEDH, 17 septembre 2013, *Welsh et Silva Canha c. Portugal*, n° 16812/11) et de manière générale, tout discours politique, particulièrement dans ces circonstances, sont alors particulièrement protégés (CEDH, 24 mai 1988, *Müller et a. c. Suisse*, n° 10737/84 ; Cass. crim, 26 février 2020, n° 19-81.827), surtout dans le cadre particulièrement protecteur de la liberté de la presse (qu'elle soit sous forme de journal ou audiovisuelle).

En conclusion, par cet arrêt, la Cour réaffirme le caractère fondamental de la liberté d'expression particulièrement lorsqu'elle contribue au débat d'idées, mais réalise à cette fin une interprétation paradoxale du lien entre cette liberté et la dignité humaine.

Fiche nº 38 - LA LIBERTÉ DE RÉUNION ET DE MANIFESTATION PACIFIQUE

POINTS CLÉS

- Des libertés qui permettent l'expression publique d'idées et d'opinions.
- Des libertés disposant de conditions et de régimes différents en France.
- Une protection conditionnée par le caractère pacifique.
- Des libertés pouvant faire l'objet de restrictions.

PRINCIPALES RÉFÉRENCES

- Cons. const. 18 janvier 1995, nº 94-352 DC.
- CEDH, GC., 15 octobre 2015, *Kudrevičius et a. c. Lituanie*, nº 37553/05.
- CE, 19 mai 1933, *Benjamin*, nºs 17413, 17520.

La liberté de réunion et la liberté de manifestation sont intimement liées. Toutes deux s'expriment en effet de manière collective, disposent d'un caractère temporaire et permettent *« l'expression publique d'idées et d'opinions »*.

> → Cons. const., déc. nº 94-352 DC, 18 janvier 1995, *Loi d'orientation et de programmation relative à la sécurité.*

Ces libertés qui sont au fondement des démocraties libérales ne sont toutefois pas protégées de manière identique au sein des ordres juridiques nationaux et internationaux.

Elles relèvent également d'un régime libéral bien que les mesures restrictives et limitatives d'exercice de ces libertés se soient multipliées.

Malgré ces traits communs, ces libertés doivent faire l'objet d'une distinction.

Elles ne sont pas consacrées uniformément sur le plan international et national. Si la liberté de réunion fait l'objet d'une consécration internationale par les principaux textes protecteurs des droits de l'homme (art. 20 DUDH, art. 21 et 22 PIDCP, art. 11 CESDH, art. 12 CDFUE), la liberté de manifestation quant à elle n'est pas expressément mentionnée par ces textes.

Du point de vue du droit interne français, aucune disposition constitutionnelle ne consacre ni la liberté de réunion, ni la liberté de manifestation. Leur valeur constitutionnelle a néanmoins été reconnue par le Conseil constitutionnel.

Ces libertés ne disposent également pas de conditions d'application et de régime uniques en droit interne contrairement à leur protection sous l'égide de la Convention EDH. Cette dualité de régime en droit interne nécessite dès lors de les aborder séparément en droit interne.

1. La protection européenne de la liberté de réunion

1.1. La protection des réunions pacifiques

La Convention européenne des droits de l'homme ne vise formellement que la liberté de réunion au sein de son article 11. Elle ne distingue cependant pas les notions de réunion et de manifestation contrairement au droit français.

La Cour européenne a effectivement eu l'occasion de préciser le champ d'application de l'article 11 de la Convention par le biais de son interprétation constructive. La Cour la conçoit ainsi comme une notion autonome extrêmement large puisqu'elle vise tous les rassemblements momentanés de personnes dès lors qu'ils sont pacifiques.

→ CEDH, GC., 15 novembre 2018, *Navalny c. Russie*, n°s 29580/12 et a.

Peuvent ainsi entrer dans le champ d'application de l'article 11 des réunions publiques ou privées de personnes, des réunions statiques voire des défilés publics.

→ CEDH, GC., 15 octobre 2015, *Kudrevičius et a. c. Lituanie*, n° 37553/05.

Ces réunions de personnes au sens de l'article 11 doivent nonobstant poursuivre un objectif commun poursuivi par les participants.

→ CEDH, 3 octobre 2013, *Kasparov et a. c. Russie*, n° 21613/07.

Cette protection couvre ainsi tant les participants à ces réunions privées ou publiques que leurs organisateurs.

Cette notion est indépendante des qualifications données en droit interne au regroupement de personnes.

Ces droits (*lex specialis*) entretiennent selon la Cour des liens particuliers et étroits avec la liberté d'expression (*lex generalis*) consacrée à l'article 10 de la Convention, notamment lorsqu'ils permettent d'exprimer une opinion personnelle. La Cour peut ainsi être amenée à interpréter l'article 11 à la lumière de cette dernière disposition.

→ CEDH, 26 avril 1991, *Ezelin c. France*, n° 11800/85.

La protection offerte par l'article 11 de la Convention ne couvre que les réunions pacifiques. Ne sont donc pas protégées les réunions au sein desquelles les participants ou les organisateurs sont animés par des intentions violentes, ont incité ou commis des violences, ou renié les fondements de la société démocratique.

→ CEDH, GC., 15 octobre 2015, *Kudrevičius et a. c. Lituanie*, n° 37553/05.

Ce droit s'applique y compris lorsque des violences ont été commises lors de ces réunions, mais que les intentions et le comportement du requérant demeuraient pacifiques.

→ CEDH, 16 janvier 2025, *Bodson et a. c. Belgique*, n° 35834/22 et a.

L'absence de déclaration préalable d'une manifestation n'enlève donc pas à ce regroupement la qualité de manifestation pacifique. Il continue de ce fait de bénéficier de la protection de l'article 11 de la Convention.

Actualité jurisprudentielle. - L'organisateur d'une manifestation ne peut être tenu automatiquement responsable du comportement des participants

L'organisateur d'une manifestation bénéficie lui-même de la protection de l'article 11 de la Convention. Sa responsabilité ne peut être engagée du seul fait qu'il n'a pas été en mesure d'empêcher tous les comportements irréguliers de certains participants.

La Cour européenne l'a précisé à propos de l'organisatrice d'une manifestation organisée à Genève à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Elle avait été condamnée au motif que le service d'ordre qu'elle avait constitué n'avait pas empêché certaines perturbations, notamment une tentative de modification de l'itinéraire et des inscriptions sur des vitrines. La Cour relève toutefois que l'intéressée n'avait ni participé à ces agissements, ni incité les manifestants à les commettre, ni organisé ceux-ci. Elle avait au contraire cherché à faire respecter les consignes. Le simple fait que l'organisatrice ait été dépassée par certains comportements ne constitue pas, en lui-même, un acte répréhensible.

La condamnation, bien que limitée à une faible amende, présentait en outre un risque d'effet dissuasif sur l'organisation future de manifestations. La Cour conclut à une violation de l'article 11.

→ CEDH, 7 mai 2026, *Batou c. Suisse*, n° 30781/22.

À retenir. - L'organisateur doit prendre des mesures raisonnables pour favoriser le déroulement pacifique de la manifestation, mais il n'est pas le garant absolu du comportement de tous les participants. Lui imposer une telle responsabilité serait susceptible de décourager l'organisation même de rassemblements.

1.2. Les obligations négatives de l'État dans le cadre de la liberté de réunion

La Cour européenne des droits de l'homme impose aux États des obligations négatives de ne pas causer d'ingérences injustifiées aux droits garantis par l'article 11 § 1 de la Convention.

L'État commet une ingérence lorsqu'il adopte des mesures causant des restrictions à ce droit avant, pendant ou après le déroulement de la réunion.

> → CEDH, GC., 15 octobre 2015, *Kudrevičius et a. c. Lituanie*, n° 37553/05.

Les restrictions à l'article 11 mises en œuvre par les États peuvent concomitamment affecter d'autres droits conventionnels, comme la liberté de circulation au sens de l'article 2 du Protocole n° 4, et ainsi entraîner des atteintes à la liberté de réunion.

> → À propos d'une mesure d'encerclement réalisée par les forces policières afin d'empêcher la participation d'individus à une manifestation autorisée (CEDH, 8 février 2024, *Auray et a. c. France*, n° 1162/22).

Dans la même logique, l'usage abusif des forces de police peut également porter atteinte aux articles 2 concernant le droit à la vie et 3 relatif à l'interdiction de la torture et des traitements inhumains et dégradants.

> → CEDH, 27 juillet 1998, *Güleç c. Turquie*, n° 21593/93.

Des sanctions infligées après la participation à une réunion sont également considérées comme des restrictions à cette liberté.

> → CEDH, 24 octobre 2024, *Eckert c. France*, n° 56270/21 à propos d'une amende infligée après la participation d'un gilet jaune à une manifestation interdite.

Les atteintes à la liberté de réunion commises par l'État ne constituent toutefois pas nécessairement des violations de la Convention. L'article 11 ne consacrant pas un droit absolu, il peut donc faire l'objet de restrictions de la part de l'État sous réserve du respect du § 2 de cette disposition, c'est-à-dire être prévues par la loi, poursuivre un objectif légitime, et être nécessaires dans une société démocratique.

La Cour européenne des droits de l'homme réalise en effet un contrôle de proportionnalité de la restriction. Ce contrôle se réalise en tenant dûment compte des circonstances de l'espèce et de la marge d'appréciation à disposition de l'État selon le domaine concerné.

> → Constitue ainsi une violation de l'article 11 le fait d'avoir dispersé des manifestants pacifiques alors que des mesures plus douces existaient : CEDH, 3 avril 2025, *Bogay et a. c. Ukraine*, n° 38283/18.

Ainsi, s'agissant de restrictions imposées avant, pendant ou après le déroulement de la réunion, les États disposent d'une large marge d'appréciation. Inversement, celle-ci sera infime lorsque sera en cause une interdiction générale de manifester.

→ CEDH, *Ukraine c. Russie (Crimée)*, 25 juin 2024, n° 20958/14 et 38334/18.

En présence de manifestations pacifiques, les États doivent faire preuve de tolérance, y compris lorsque le rassemblement est illégal, car non déclaré. Ainsi, le fait que la manifestation soit illégale ne permet pas à lui seul de justifier l'ingérence à la liberté de réunion causée par l'évacuation de manifestants par des forces de police.

→ CEDH, 9 avril 2002, *Cissé c. France*, n° 51346/99.

Nonobstant, lorsque la manifestation dépasse la simple gêne occasionnée à autrui, par exemple en cas de blocage volontaire, complet et brutal d'axes routiers, la condamnation des participants peut être considérée comme étant nécessaire dans une société démocratique.

→ CEDH, 16 janvier 2025, *Bodson et a. c. Belgique*, n° 35834/22, et a.

1.3. Les obligations positives de l'État dans le cadre de la liberté de réunion

La Cour impose également à l'État des obligations positives d'assurer le respect de l'article 11 dans le cadre de relations interindividuelles.

L'État a donc l'obligation d'assurer le déroulement pacifique de ces réunions. Il s'agit toutefois d'une obligation de moyens (et non de résultat) d'adopter des mesures raisonnables et appropriées visant à assurer leur déroulement pacifique.

→ CEDH, GC., 15 octobre 2015, *Kudrevičius et a. c. Lituanie*, n° 37553/05.

L'État a en outre l'obligation d'assurer que des atteintes à la liberté de réunion ne soient pas commises par d'autres individus, notamment dans le cadre de contre-manifestations.

→ CEDH, 21 juin 1988, *Plattform "Ärzte für das Leben" c. Autriche*, n° 10126/82.

La Cour ménage toutefois aux États une large marge d'appréciation dans le choix des mesures à prendre afin de se conformer à cette obligation de moyens.

Commet ainsi une violation de ses obligations positives l'État n'ayant pas assuré le déroulement pacifique d'une manifestation licite en ne réglementant pas notamment l'usage de la force par des services de sécurité privés et en s'étant abstenu d'intervenir pour éviter les affrontements.

→ CEDH, 18 juin 2019, *Chernega et a. c. Ukraine*, n° 74768/10.

2. La protection interne de la liberté de réunion et de manifestation

En droit interne, ni la liberté de réunion ni la liberté de manifestation n'ont été consacrées explicitement au sein de la Constitution. L'une et l'autre constituent néanmoins des libertés fondamentales consacrées par la loi et protégées par le Conseil constitutionnel.

Si ces libertés n'ont pas été qualifiées par le Conseil constitutionnel de principes fondamentaux proclamés par les lois de la République, il les protège néanmoins par le biais d'une interprétation extensive de la liberté d'expression consacrée à l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

Ces libertés constituent en effet selon les Sages de la rue de Montpensier un *« droit d'expression collective des idées et opinions »*.

→ Cons. const., déc. n° 94-352 DC,18 janvier 1995, *Loi d'orientation et de programmation relative à la sécurité.*

→ Cons. const., déc. n° 2016-535 QPC, 19 février 2016, *Ligue des droits de l'homme.*

En droit français, ces deux libertés ne sont pas synonymes, contrairement à la conception européenne. Elles disposent donc de conditions et de régimes différents.

2.1. La liberté de réunion

La liberté de réunion a été consacrée par la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion et par celle du 28 mars 1907 sur les réunions publiques. Ces lois n'ont toutefois pas défini cette notion.

> → Le Commissaire du gouvernement dans le cadre de ses conclusions préalables à l'arrêt Benjamin avait pourtant tenté d'en donner une définition : CE, 19 mai 1933, *Benjamin*, n°s 17413, 17520.

Elle vise les rassemblements organisés et pacifiques ce qui permet de la distinguer des attroupements, définis à l'article 431-3 du Code pénal.

Cette notion implique également un caractère momentané permettant l'échange d'idées ou d'opinions ce qui la distingue de la notion d'association.

> → CE, 6 août 1915, *Delmotte et Senmartin*, n° 49987 et n° 54583.

Seules les réunions publiques sont saisies par la loi, les réunions privées n'étant soumises à aucun régime particulier sont donc libres par principe. Les secondes ne se tiennent pas sur la voie publique et les participants ont par principe été invités personnellement à y prendre part.

La liberté de réunion constitue selon le Conseil d'État une liberté fondamentale susceptible de faire l'objet d'un référé-liberté au sens de l'article L. 521-2 du Code de la justice administrative.

> → Sur la suspension d'un arrêté d'interdiction : CE, ord., réf., 19 août 2002, *Front national et Institut de formation des élus locaux*, n° 249666.

La liberté de réunion relève d'un régime libéral (ou répressif) depuis la loi du 30 juin 1881. Elle ne requiert effectivement ni autorisation préalable, ni déclaration préalable.

Cette liberté s'exerce donc par principe librement dans le cadre des règles applicables aux réunions. Les autorités judiciaires disposent néanmoins a posteriori d'un pouvoir de sanction si des infractions sont constatées dans le cadre de l'exercice de cette liberté.

En cas de risques de troubles à l'ordre public résultant de l'exercice de la liberté de réunion, les autorités dotées du pouvoir de police peuvent interdire la tenue d'une telle réunion.

> → Sur la liberté de réunion des supporters : CE, 22 novembre 2018, n° 425530.

Le juge administratif dispose par la suite d'un pouvoir de contrôle de la mesure d'interdiction. Ce dernier doit alors réaliser une mise en balance entre la liberté de réunion et la protection de l'ordre public.

Cette mesure sera considérée comme étant proportionnée si aucune autre mesure moins sévère ne pouvait remplir l'objectif de préservation de l'ordre public.

> → CE, 19 mai 1933, *Benjamin*, n°s 17413, 17520.

Cette liberté ne concerne toutefois que les réunions pacifiques et sans armes.

La liberté de réunion fait l'objet d'un certain nombre d'obligations légales. Un bureau responsable du maintien de l'ordre de 3 personnes minimum devra ainsi être désigné ou élu afin d'empêcher toute infraction.

Les réunions ne pourront en outre pas se tenir sur la voie publique après 23 heures sauf si les établissements recevant du public ferment plus tard (art. 6 de la loi du 30 juin 1881).

Cette liberté fait néanmoins l'objet de restrictions et de dérogations.

Certains types de réunions font par exemple l'objet d'une obligation de déclaration préalable tels que les rassemblements festifs à caractère musical (art. 53, Loi dite « Vaillant » n° 2001-1062 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne) ou ceux réunissant plus de 1 500 personnes.

Indépendamment du type de réunion, cette liberté peut être limitée en cas de circonstances exceptionnelles (art. 16 et 36 de la constitution et la loi du 3 avril 1955).

2.2. La liberté de manifestation

Aucun texte ne permet non plus de définir la liberté de manifestation. Elle peut toutefois se déduire par opposition à ses notions voisines.

La manifestation doit tout d'abord être distinguée de celle de l'attroupement. Cette dernière est définie à l'article 431-3 du Code pénal comme étant tout rassemblement de personnes sur la voie publique ou dans un lieu public susceptible de troubler l'ordre public.

La liberté de manifestation ne concerne donc que les regroupements organisés et pacifiques d'individus.

Les notions de manifestations et de réunions partagent également comme traits communs le caractère momentané de l'expression collective d'idées et d'opinions, leur caractère organisé et pacifique.

La notion de manifestation se distingue cependant de celle de réunion, car elle se déroule sur la voie publique et dispose d'un but revendicatif.

Le juge a ainsi défini la manifestation de la manière suivante *« tout rassemblement, statique ou mobile, sur la voie publique d'un groupe organisé de personnes aux fins d'exprimer collectivement et publiquement une opinion ou une volonté commune »*.

→ Cass. crim., 9 février 2016, n° 14-82.234.

La liberté de manifestation dispose toutefois d'un régime bien distinct et bien plus restrictif que celui applicable aux réunions. En effet, les manifestations sont soumises depuis le décret-loi du 23 octobre 1935 à une obligation de déclaration préalable en mairie.

Ce régime déclaratif vise à informer l'administration de la tenue prochaine d'une manifestation. Il ne s'agit donc pas d'une procédure d'autorisation préalable.

Cette déclaration doit mentionner des informations relatives notamment à l'identité des organisateurs, la date, le lieu et l'heure, et au tracé de la manifestation.

Une fois que la déclaration sera réalisée par les organisateurs, ceux-ci se verront délivrer un récépissé par les autorités de police.

POUR ALLER PLUS LOIN

La déclaration faite à la mairie ou aux mairies concernées par l'itinéraire de la manifestation doit être réalisée 3 jours francs au moins et 15 jours au plus avant la date de la manifestation (art. L. 211-2 du Code de la sécurité intérieure).

Cette déclaration n'assure cependant pas la tenue de cette manifestation. Les autorités peuvent effectivement s'y opposer en raison de risques de troubles à l'ordre public qu'elle pourrait créer (art. L. 211-4 Code de la sécurité intérieure).

Plusieurs hypothèses de regroupements publics illicites sont prévues par la loi.

La manifestation peut tout d'abord être illicite, car elle n'a pas fait l'objet d'une déclaration préalable.

Attention, cette procédure de déclaration préalable ne conditionne pas l'applicabilité du régime de la liberté de manifestation. L'absence de déclaration ne transforme pas automatiquement la manifestation en attroupement.

Cette dernière notion vise les regroupements spontanés de personnes sur la voie publique ou dans un lieu public, mobiles ou statiques susceptibles de troubler l'ordre public (art. 431-3 du Code pénal).

Dès lors qu'une manifestation non déclarée ne sera pas susceptible de créer des risques de troubles à l'ordre public celle-ci ne pourra dès lors pas être qualifiée d'attroupement. Seuls les organisateurs s'exposent en ce cas à des sanctions pénales (art. L. 211-1 du Code de la sécurité intérieure) et non les participants à cette manifestation non déclarée.

La manifestation peut également avoir été interdite par arrêté de l'autorité dotée des pouvoirs de police en raison des risques de troubles à l'ordre public (art. L. 211-4 du Code de la sécurité intérieure).

Cette décision est alors immédiatement notifiée aux organisateurs de la manifestation ayant signé la déclaration préalable et est susceptible de recours. Ces arrêtés doivent être publiés suffisamment tôt pour qu'un recours contre l'arrêté d'interdiction puisse être formé par les manifestants ou les organisateurs.

→ À propos de la publication tardive d'arrêtés d'interdiction de manifestation dans le cadre des manifestations contre la réforme des retraites laissant un délai ne permettant pas de saisir le juge des référés : TA Paris, 4 avril 2023, n° 2307385.

Les arrêtés d'interdictions peuvent faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir afin d'en obtenir l'annulation.

Le Conseil d'État lui reconnaît également sa valeur fondamentale puisqu'il s'agit selon lui d'une liberté invocable en référé-liberté sur le fondement de l'article L. 521-2 du Code de la justice administrative.

→ CE, ord., 5 janvier 2007, *ministre de l'Intérieur contre Solidarité des Français*, n° 300311.

→ CE, ord., 18 octobre 2023, *Association Comité Action Palestine*, n° 488860.

Lorsque le juge est saisi de tels recours, il opère alors un contrôle approfondi de la mesure afin de vérifier si la décision est nécessaire adaptée et proportionnée puisqu'il s'agit d'un contrôle maximum.

→ Un arrêté d'interdiction fondé sur des motifs autres que des risques de troubles à l'ordre public doit être annulé : CE, 12 novembre 1997, *Min. de l'Intérieur c. Assoc. communauté tibétaine de France et ses amis*, n° 169295.

Il apprécie dès lors la nécessité de la mesure et sa proportionnalité au regard des objectifs de préservation de l'ordre public et du respect de la liberté de manifestation.

→ CE, 19 mai 1933, *Benjamin*, n°s 17413, 17520.

→ S'agissant de l'annulation d'une interdiction de manifestation en période de crise sanitaire, car les gestes barrières pouvaient être respectés par les manifestants : CE, ord, réf., 13 juin 2020, *Ligue des droits de l'homme, CGT-Travail et a.*, n°s 440846, 440856, 441015.

→ À propos du refus d'interdire l'usage du lanceur de balles de défense dans le cadre de manifestations : CE, ord., réf., 1er février 2019, *Union départementale de Paris du syndicat de la Confédération générale du travail*, n° 427386 ; *Confédération générale du travail et a.*, n° 427390 ; *M. de Heer et a.*, n° 427418.

Si le juge contrôle l'effectivité de la liberté de manifestation face aux décisions de l'administration, le législateur est cependant intervenu à plusieurs reprises afin de restreindre cette liberté.

Plusieurs sortes de restrictions à la liberté de manifester ont ainsi été consacrées par la loi telles que des mesures visant à limiter la participation d'individus à des manifestations.

La loi n° 2019-290 du 10 avril 2019 dite « anticasseurs » avait notamment octroyé au préfet le pouvoir d'interdire à un individu susceptible de porter atteinte à l'ordre public de participer à une manifestation, mais également la possibilité pour le juge répressif de prononcer une peine d'interdiction de manifestation. Le Conseil constitutionnel a toutefois censuré cette première mesure, car elle avait pour effet de conférer à l'autorité administrative une latitude excessive dans l'appréciation des motifs justifiant l'interdiction.

→ Cons. const., déc. n° 2019-780 DC, 4 avril 2019, *Loi visant à garantir le maintien de l'ordre public lors des manifestations.*

Des mesures visant à accroître les pouvoirs de contrôle et de maintien de l'ordre dans le cadre de manifestations ont également été adoptées telle que l'interdiction du port et du transport sans motif légitime d'objets pouvant constituer une arme lors d'une manifestation après sa déclaration en mairie et jusqu'à 24 heures avant son déroulement et jusqu'à dispersion (art. 211-3 du Code de la sécurité intérieure).

→ Cons. const., déc. n° 94-352 DC, 18 janvier 1995, *Loi d'orientation et de programmation relative à la sécurité.*

L'interdiction de la dissimulation du visage aux abords d'une manifestation sur la voie publique d'abord mise en œuvre par un décret du 19 juin 2009 a finalement été consacrée à l'article 431-9-1 du Code pénal par la loi du 10 avril 2019.

POUR S'ENTRAÎNER

Commentaire : CEDH, 16 janvier 2025, *Bodson et a. c. Belgique*, n° 35834/22 et a.

La liberté de manifestation ne fait pas l'objet d'une consécration textuelle au sein de la Convention EDH. Ce texte protège toutefois cette liberté en son article 11 sur le fondement de la liberté de réunion. Cette notion fait effectivement l'objet d'une définition autonome de la part de la Cour européenne des droits de l'homme. Elle protège ainsi les réunions publiques, mais également les manifestations dès lors qu'elles s'expriment pacifiquement. L'arrêt du 16 janvier 2025 porte en l'espèce sur la condamnation pénale de leaders syndicaux qui avaient participé à une manifestation au cours de laquelle un axe autoroutier avait été bloqué. Les juridictions belges avaient effectivement condamné les requérants pour entrave méchante à la circulation routière avec mise en danger de la vie d'autrui.

Les requérants estiment avoir subi une atteinte injustifiée dans leur droit à la liberté de réunion garanti par l'article 11 de la Convention.

Un État commet-il une ingérence injustifiée lorsqu'il condamne pénalement des individus à une courte peine privative de liberté, car ces derniers avaient participé à une manifestation au cours de laquelle un blocage autoroutier avait été réalisé ?

La Cour européenne des droits de l'homme a estimé que l'article 11 était applicable en l'espèce, car la manifestation pouvait être qualifiée de pacifique en dépit des graves troubles à l'ordre public qu'elle avait engendré. Bien qu'étant une restriction à la liberté de réunion, la condamnation pénale prononcée à l'encontre des requérants ne constituait pas pour autant une ingérence injustifiée.

Annonce du plan : La Cour européenne des droits de l'homme admet l'applicabilité de l'article 11 de la Convention en constatant l'existence d'une réunion pacifique **(I)**. Elle ne procède toutefois pas à un constat de violation. La Cour estime en effet que les sanctions prononcées à l'encontre des manifestants à l'issue de la manifestation ne constituaient pas une ingérence injustifiée **(II)**.

I. L'applicabilité de la liberté de réunion en cas de manifestations troublant l'ordre public

A. L'appréciation extensive de la notion de manifestation pacifique

La Cour ne protège classiquement les réunions que dans la mesure où elles sont pacifiques. Ce caractère revêt donc une importance cruciale pour les requérants, car il conditionne l'applicabilité du régime protecteur de l'article 11. Cette notion est classiquement appréciée de manière large. La survenance de violences dans le cadre d'une manifestation n'a pas nécessairement pour effet d'ôter son caractère pacifique dès lors que le requérant n'a pas commis de violence (CEDH, 26 avril 1991, *Ezelin c. France*, n° 11800/85).

En l'espèce, aucune violence n'a véritablement été commise par les requérants et ce bien que leur comportement ait été susceptible de troubler gravement l'ordre public. La Cour a considéré en effet que l'article 11 était applicable puisqu'ils n'avaient pas eu d'intention violente et qu'ils n'avaient pas non plus été condamnés pour violence par les juridictions internes. Cette conception du caractère pacifique s'inscrit ainsi dans la droite ligne de sa jurisprudence antérieure qui avait déjà pris en considération les motifs ayant justifié en droit interne la condamnation de requérants (CEDH, GC., 15 octobre 2015, *Kudrevičius et a. c. Lituanie*, n° 37553/05).

B. Le constat prévisible d'une atteinte à la liberté de réunion

Selon la Cour, toute mesure de nature à restreindre la liberté de réunion peut s'analyser comme une ingérence. Il n'est pas nécessaire que la liberté de réunion soit totalement annihilée.

Ainsi, des sanctions pénales visant les manifestants après le déroulement de la manifestation constituent une atteinte à la liberté de réunion (CEDH, 24 octobre 2024, *Eckert c. France*, n° 56270/21).

Le constat de l'existence d'une ingérence dans la liberté de réunion en l'espèce était donc prévisible puisque les sanctions pénales, y compris lorsqu'elles sont prononcées à l'issue d'une manifestation, peuvent avoir un effet dissuasif pour les manifestants.

II. L'absence d'ingérence injustifiée dans la liberté de réunion

A. L'abaissement du seuil de contrôle de la mesure pour des motifs tenant aux requérants

Si la Cour a considéré que la manifestation pouvait être qualifiée de pacifique, cela ne signifie toutefois pas que le comportement des requérants a été sans effets sur leur liberté de réunion.

La Cour prend en effet en considération les potentiels troubles à l'ordre public causés par les manifestants, leur gravité ainsi que le lien entre celle-ci et leurs contestations afin d'apprécier la proportionnalité de l'ingérence de l'État. La Cour avait en effet par le passé estimé que les perturbations intentionnelles causées par une manifestation pouvaient être répréhensibles et donc justifier des sanctions de la part de l'État dès lors qu'elles dépassaient un certain seuil (CEDH, GC., 15 octobre 2015, *Kudrevičius et a. c. Lituanie*, n° 37553/05).

En l'espèce, le blocage routier n'avait aucun lien avec leurs contestations qui pouvaient être exprimées autrement. En prenant en considération le comportement des auteurs, la Cour abaisse en l'espèce le seuil des exigences pesant sur l'État au titre de l'article 11 de la Convention permettant de considérer que les mesures s'avéraient en l'espèce justifiées.

B. Le constat d'une ingérence nécessaire au sein d'une société démocratique

La Cour estime en l'espèce que l'ingérence commise par les autorités belges avait été nécessaire au sein d'une société démocratique.

Par le passé, la Cour avait admis la conventionnalité d'amendes d'un faible montant infligées après la tenue d'une manifestation à des participants et ce, car cette dernière avait été interdite et avait fait naître des risques de troubles à l'ordre public (CEDH, 24 octobre 2024, *Eckert c. France*, n° 56270/21).

Les sanctions prononcées en l'espèce étaient toutefois d'une certaine importance puisqu'elles étaient constitutives de peines privatives de liberté.

Les autorités semblent cependant avoir souhaité garantir l'exercice de la liberté de réunion des requérants malgré l'absence d'autorisation préalable de la manifestation et des graves troubles à l'ordre public causés. Les autorités belges ont ainsi privilégié les mesures les plus douces telles que la négociation et l'intervention en cas de heurts sans avoir recours à la force ou à la dispersion de la manifestation. Il n'en demeure pas moins que les peines de prison, même de courte durée, ont été prononcées à l'encontre des requérants alors qu'ils n'avaient pas commis de violences

En conclusion, il persiste des incohérences. En effet, la réunion est considérée comme étant pacifique tout en estimant que le comportement des requérants qui portait gravement atteinte à l'ordre public pouvait justifier des peines privatives de liberté.

Fiche n° 39 - LA LIBERTÉ D'ASSOCIATION

POINTS CLÉS

- Principe constitutionnellement garanti.
- Liberté de création d'une association.
- Régime juridique de l'association.
- Le libre fonctionnement de l'association.
- Les limites à la liberté d'association.

PRINCIPALES RÉFÉRENCES

- Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.
- Cons. const., n° 71-44 DC, 16 juillet 1971, Loi complétant les dispositions des articles 5 et 7 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.
- Code des associations et des fondations, 14e ed., Dalloz, 2022.
- Colloque, La liberté d'association et le droit, centenaire de la loi de 1901, Paris, Conseil constitutionnel, 29 et 30 juin 2001.
- Jean Duffar, « La liberté d'association dans la Convention européenne des droits de l'homme », *LPA*, 24 août 1996, p. 41.
- « Les associations et la loi de 1901, cent ans après », Conseil d'État, Rapport, La Documentation française, 2000.
- Michel Doucin, dir., *Guide de la liberté d'association dans le monde*, 2e éd., La Documentation française, 2007.

1. Les sources de la liberté d'association

1.1. Les sources nationales

1.1.1. Une valeur législative ancienne

La liberté d'association a été consacrée par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, son article 1 énonce que :

> *« L'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d'une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations. »*

L'association peut être définie comme *« un regroupement de deux ou plusieurs personnes qui mettent en commun leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que celui de partager des bénéfices »*.

1.1.2. La consécration constitutionnelle de 1971

La liberté d'association n'est pas explicitement reconnue par la Constitution de 1958 ni par celle de 1946. C'est le Conseil d'État qui va reconnaître le premier l'existence d'un principe fondamental reconnu par les lois de la République en 1956 donc incidemment sa dimension constitutionnelle.

→ CE, 11 juillet 1956, *Amicale des Annamites de Paris*, n° 26638.

Il faudra attendre 1971 pour que le Conseil constitutionnel consacre sa valeur constitutionnelle en tant que principe fondamental reconnu par les lois de la République.

> → Cons. const., déc. n° 71-44 DC, 16 juillet 1971, *Loi complétant les dispositions des articles 5 et 7 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.*

La liberté d'association est un principe fondamental de la démocratie qui revêt un aspect individuel et collectif.

- Sur le plan individuel, chacun est libre, sous réserve du respect des valeurs fondamentales du pays et de l'ordre public, de rejoindre une association et ses relations avec les autres membres de l'association seront alors encadrées.
- Sur le plan collectif, chaque association est libre vis-à-vis des tiers, mais également de l'État ou des collectivités publiques.

En France, les litiges relatifs à la liberté d'association concernent principalement les conditions de formation du contrat d'association, la capacité à agir en justice, le fonctionnement, la responsabilité et la disparition de l'association.

La liberté d'association bénéficie d'une protection, mais celle-ci n'est pas absolue et elle est encadrée par un régime juridique qui fixe le cadre de son exercice.

1.2. Les sources supranationales

1.2.1. Les sources internationales

Le droit international a contribué à garantir le droit des personnes à se regrouper sous un format associatif.

La Déclaration Universelle des droits de l'homme de 1948 reconnaît à toute personne le droit à la liberté de réunion et d'association pacifique et précise que nul ne peut être forcé de faire partie d'une association.

> → Art. 20 DUDH.

Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 prévoit aussi que toute personne a le droit de s'associer librement avec d'autres tout en prévoyant de possibles restrictions par la loi qui sont nécessaires dans une société démocratique dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique, de l'ordre public ou pour protéger la santé ou la moralité publique ou les droits et libertés d'autrui.

> → Art. 22 PIDCP.

1.2.2. Les sources européennes

La Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de 1950 consacre aussi la liberté d'association ainsi que la liberté de réunion pacifique. Cette liberté peut être restreinte par la loi dans le cadre de mesures nécessaires pour garantir la sécurité nationale, la sûreté publique, la défense de l'ordre et la prévention du crime, la protection de la santé ou de la morale ou la protection des libertés d'autrui.

> → Art. 11 CESDH.

La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne de 2000 énonce à son article 12 :

> *« Toute personne a le droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association à tous les niveaux, notamment dans les domaines politiques, syndical et civique, ce qui implique le droit de toute personne de fonder avec d'autres des syndicats, et de s'y affilier pour la défense de ses intérêts. »*

Ces dispositions peuvent être invoquées devant la Cour européenne des droits de l'homme, laquelle a rappelé à plusieurs reprises que la possibilité pour les citoyens de former une personne morale afin d'agir collectivement dans un domaine d'intérêt commun constitue l'un des aspects les plus importants du droit à la liberté d'association.

> → CEDH, 10 juillet 1998, *Sidiropoulos et a. c. Grèce*, n° 26695/95.

La préservation de la liberté d'association implique qu'aucun refus d'enregistrement ne puisse être opposé à la création d'un organisme sans but lucratif. Ce refus n'est pas envisageable dans une société démocratique.

→ CEDH, 6 octobre 2009, *Özbek et a. c. Turquie*, n° 35570/02.

La liberté d'association implique aussi une liberté d'adhésion.

La Cour européenne des droits de l'homme est aussi vigilante concernant le respect de la liberté d'association des partis politiques et ne laisse qu'une faible marge de manœuvres aux États concernant la possibilité de restrictions.

→ CEDH, 29 avril 1999, *Chassagnou c. France*, n° 29515/95.

→ CEDH, 30 janvier 1998, *PCU c. Turquie*, n° 19392/92.

→ CEDH, 13 février 2003, *Refah Pastisi c. Turquie*, n° 41340/98.

La Cour européenne des droits de l'homme a ainsi confirmé à plusieurs reprises le rôle primordial que jouent les partis politiques dans un régime démocratique en bénéficiant des droits reconnus à l'article 11 (liberté de réunion et d'association) et à l'article 10 de la CEDH (liberté d'expression).

La protection octroyée par la Cour européenne des droits de l'homme ne se limite pas aux partis politique, elle est beaucoup plus large et concerne toute sorte d'associations : protection du patrimoine culturel ou spirituel, poursuite de divers buts sociaux ou économiques, recherche d'une identité ethnique…

→ CEDH, 17 février 2004, *Gorzelik et a. c. Pologne*, n° 44158/98.

La Cour européenne des droits de l'homme a ainsi rappelé l'importance de la liberté d'association pour les personnes appartenant à une minorité. La promotion de cette minorité permettant de défendre ses droits face à d'éventuelles atteintes extérieures.

2. Les différentes catégories d'association

Il existe en France de nombreuses associations : environ 1,3 million d'associations qui agissent dans des domaines très divers tels que la culture, le sport, le jeu, l'éducation et la solidarité…

Ces associations se répartissent en trois catégories :

- Les associations non déclarées : celles qui n'ont pas fait l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux ; ce sont des associations qui n'ont pas de personnalité juridique.
- Les associations déclarées : celles qui ont reçu un agrément préfectoral. Ce dernier est délivré par la Préfecture après envoi des statuts de l'association. L'existence de l'association est publique et elle dispose d'une personnalité juridique.
- Les associations reconnues d'utilité publique : celles qui ont une pleine capacité juridique en contrepartie d'obligations envers les autorités publiques.

Depuis une loi de 1981, il n'existe plus de régime spécial concernant les associations étrangères.

Par ailleurs, les congrégations sont, elles, toujours soumises à un régime juridique particulier. La personnalité morale des congrégations est accordée par décret, sur avis conforme du Conseil d'État. Une congrégation peut être qualifiée d'association, mais elle se distingue en général par trois éléments :

- Les membres se soumettent à l'autorité religieuse et poursuivent un objectif ou la réalisation d'une vie de piété ;
- Leurs besoins matériels sont assurés par la congrégation ;
- La congrégation dispose d'une organisation hiérarchique particulièrement marquée.

Enfin, il existe les associations cultuelles, créées par la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Églises et de l'État.

3. Le régime juridique des associations

3.1. La liberté individuelle d'adhérer ou de ne pas adhérer

En vertu de l'article 11 de la Convention européenne, il est possible d'adhérer à une association, mais aussi de ne pas adhérer à une association.

> → CEDH, 29 avril 1999, *Chassagnou c. France*, n° 29515/95.

Il y a donc un volet positif dans la liberté d'association : la liberté d'adhérer, et un volet négatif : la liberté de ne pas adhérer ou de ne pas rester membre d'une association.

> → Cass., 9 février 2001, n° 99-17.642 : *« Hormis les cas où la loi en décide autrement, nul n'est tenu d'adhérer à une association régie par la loi du 1er juillet 1901 ou, y ayant adhéré, d'en demeurer membre. »*

3.1.1. L'adhésion à l'association

Une association repose sur un contrat d'association qui unit ses membres. L'association peut donc poser des conditions d'adhésion dans ses statuts et elle est libre de vérifier que ces conditions sont remplies.

L'association ne doit pas opérer de discrimination dans la sélection de ses adhérents sous peine de commettre un délit.

Il existe deux régimes spécifiques d'association :

- Pour les personnes malades : ces personnes peuvent constituer une association de personnes malades pour assurer la défense de leurs droits et prérogatives au sein de l'établissement de santé.

  > → Loi du 4 mars 2002, n° 2002-303, relative au droit des malades et à la qualité du système de santé.

- Pour les personnes mineures : les mineurs de 16 ans révolus peuvent constituer une association sous réserve de l'accord écrit préalable de leur représentant légal.

  > → Loi du 28 juillet 2011, n° 2011-893, pour le développement de l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels.

3.1.2. La non-adhésion et le retrait de l'association

La Cour de cassation a explicitement consacré le droit de ne pas adhérer à une association ou de pouvoir en sortir.

> → Cass., 9 février 2001, n° 99-17.642.

> → Art. 4 de la loi du 1er juillet 1901 : *« Tout membre d'une association peut s'en retirer en tout temps, après paiement des cotisations échues et de l'année courante, nonobstant toute clause contraire. »*

Il existe des rares cas dans lesquels il est obligatoire d'adhérer ou de rester dans une association pour des raisons d'intérêt général (obligation d'assurer son véhicule).

Le départ d'une association est en principe volontaire et libre : cela peut se faire par démission ou le non-renouvellement de l'adhésion ou le non-paiement des cotisations.

Actualité jurisprudentielle. - Le droit de quitter une association relève des garanties fondamentales de la liberté d'association

La liberté d'association comprend non seulement le droit d'adhérer à une association, mais également celui de pouvoir s'en retirer.

Un texte réglementaire imposait aux producteurs de lait membres de certaines organisations de producteurs ou associations d'organisations de producteurs une durée minimale d'adhésion de cinq ans renouvelables. Il leur interdisait donc, pendant cette période, de quitter librement l'association.

Le Conseil d'État a jugé qu'une telle restriction touche aux garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice de la liberté d'association. En application de l'article 34 de la Constitution, seul le législateur pouvait déroger au principe posé par l'article 4 de la loi du 1er juillet 1901 selon lequel tout membre d'une association peut s'en retirer à tout moment. Le pouvoir réglementaire était donc incompétent pour imposer une telle durée minimale d'adhésion.

→ CE, 24 juin 2025, *Sociétés Savencia Ressources Laitières et Savencia*, n° 494853

À retenir. - La liberté d'association possède un volet négatif particulièrement protecteur : l'adhésion ne peut, en principe, se transformer en appartenance forcée. Les garanties fondamentales relatives au droit de quitter une association relèvent du domaine de la loi.

3.2. Le principe de libre constitution de l'association

L'article 2 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association prévoit que *« les associations de personnes pourront se former librement sans autorisation ni déclaration préalable »*.

La capacité juridique de l'association s'obtient par la déclaration en préfecture.

Le Conseil constitutionnel a censuré la loi qui prévoyait un contrôle administratif préalable pour les associations dont l'administration pouvait estimer qu'elles pouvaient menacer l'ordre public.

> → Cons. const., déc. n° 71-44 DC, 16 juillet 1971, *Loi complétant les dispositions des articles 5 et 7 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.*

Le principe primordial concernant une association est qu'elle doit être un contrat unissant plusieurs fondateurs. Une association ne peut pas être constituée par une seule personne en droit français. L'hypothèse s'apparente à une association fictive.

Le contrôle des associations est effectué *a posteriori*, après leur déclaration et cela peut donner lieu à des actions devant les juridictions civiles, administratives ou pénales.

Actualité jurisprudentielle. - Le nom d'une association (politisée) ne suffit pas à justifier son refus d'enregistrement

La liberté d'association protège la possibilité pour des personnes de se regrouper autour d'une identité commune, y compris lorsqu'elles appartiennent à une minorité.

En l'espèce, sept ressortissantes grecques avaient souhaité faire enregistrer l'« Association culturelle des femmes turques de la préfecture de Xanthi ». Les juridictions grecques s'y étaient opposées au motif que l'emploi du terme « turques » risquait de créer une confusion entre la minorité musulmane reconnue par la Grèce et l'existence d'une minorité turque qu'elles ne reconnaissaient pas.

La Cour européenne rappelle que la libre identification constitue un élément essentiel de la protection des minorités. En l'absence d'éléments établissant que l'association présentait une menace réelle pour l'ordre public ou la société démocratique, son seul nom ne pouvait justifier le refus de l'enregistrer.

→ CEDH, 24 juin 2025, *Sagir et autres c. Grèce*, n° 34724/18.

À retenir. - Les opinions identitaires ou minoritaires, même contestées par l'État, ne suffisent pas à justifier une restriction à la liberté d'association : un risque concret pour l'ordre public doit être établi.

3.3. L'objet de l'association

L'association reposant sur un contrat d'association, le principe de la liberté contractuelle s'applique. Les fondateurs de l'association sont donc libres dans la rédaction des statuts de l'association pour prévoir son organisation, son fonctionnement et sa gestion. D'autant plus qu'il existe un principe de libre fonctionnement de l'association.

L'association ne peut pas avoir pour objet de retirer un quelconque bénéfice pour ses membres sous peine d'être requalifiée en société par le juge.

Certaines mentions sont obligatoires dans les statuts de l'association comme les mentions nécessaires pour l'acceptation de la déclaration en préfecture telles que le titre exact et complet de l'association, les objets ou les buts qu'elle se propose, l'adresse du siège social et éventuellement des autres établissements.

L'objet de l'association est important : il exprime le projet associatif lui-même. L'objet de l'association doit être mentionné dans les statuts. Souvent cet objet confond les objectifs et les buts de l'association ainsi que les moyens de réalisation de l'activité juridique, mais cela ne pose pas de problème juridique.

3.4. Le libre fonctionnement de l'association

Le droit français reconnaît le principe du libre fonctionnement de l'association. Ce sont les rédacteurs des statuts, puis les organes habilités à les modifier qui sont libres de prévoir les modalités de fonctionnement, d'organisation et de gestion de l'association.

La loi du 1er juillet 1901 n'envisage pas d'organes obligatoires ou systématiques au sein des associations ce qui engendre une grande diversité dans l'organisation des associations.

Chaque association peut donc avoir sa propre organisation avec un ou plusieurs organes de décision, de délibération ou établir dans ses statuts des relations avec d'autres associations.

Chaque association peut créer en son sein différents statuts qui peuvent donner accès à différentes prérogatives ou prestations. Par exemple, une distinction peut être faite entre membres de l'association et membres ayant le droit de vote au sein des organes décisionnaires.

Dans beaucoup d'associations, il existe ainsi une différence entre membres actifs au sein de l'association et les simples membres adhérents à l'association qui ne participent ni à l'assemblée générale ni aux organes de direction.

La liberté de fonctionnement des associations est assortie de certaines limites : il est interdit de distinguer les membres de l'association selon des critères discriminatoires et l'association est tenue de respecter les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations.

De plus, toute association jouit du principe d'autonomie patrimoniale.

4. Les limites de la liberté d'association

4.1. Les restrictions de la liberté d'association

L'article 3 de la loi de 1901 identifie l'objet qui peut être celui d'une association et les restrictions :

> *« Toute association fondée sur une cause ou en vue d'un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes mœurs, ou qui aurait pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire national et à la forme républicaine du gouvernent, est nulle et de nul effet. »*

C'est ainsi qu'a pu être déclarée nulle une association ayant pour objet de mettre en relation des personnes dans la perspective de conclure un accord de mère porteuse.

> → Cass, civ., 13 décembre 1989, *Association Alma Mater*, n° 88-15.655.

L'atteinte à l'intégrité du territoire national et à la forme républicaine du gouvernement a pu justifier l'annulation d'une association ayant pour objet le rétablissement de la monarchie par tous moyens, y compris par la force.

→ CE, 4 avril 1936, *Pujo, de Lassus et Réal Del arte*, n° 52.834, 52.835, 52.836.

Il en a été de même pour l'association Enbata qui voulait libérer le Pays basque français de la domination de l'État français.

Lorsque l'association est créée sur un objet illicite, sa dissolution peut être prononcée par voie judiciaire ou administrative.

4.2. La dissolution judiciaire

Lorsque l'association a été fondée sur une cause ou en vue d'un objet illicite, il appartient au juge judiciaire de prononcer sa dissolution à la demande du Procureur ou de toute personne intéressée.

Par exemple, la dissolution d'une association qui avait été fondée pour distribuer un produit présenté comme un médicament est illicite au regard de l'article L. 511 du Code de la santé publique qui prévoit que les médicaments ne peuvent pas être distribués par des non-pharmaciens.

→ Cass, civ., 19 janvier 1970, n° 68-12.910.

Ou encore la dissolution d'une association coupable de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme et de financement d'entreprise terroriste.

→ Cass, crim., 21 mai 2014, *Association CKK Ahmet Kaya*, n° 13-83.758.

4.3. La dissolution administrative

La dissolution administrative est possible depuis la loi du 10 janvier 1936 laquelle avait été adoptée afin de lutter contre les groupes de combat d'extrême droite et les milices privées.

La loi de 1936 a été révisée par la suite pour étendre la possibilité de dissolution administrative aux groupements incitant à la discrimination, à la haine ou à la violence.

→ Loi du 1er juillet 1972, n° 72-545, relative à la lutte contre le racisme.

Ainsi qu'aux groupements à l'origine d'actes de terrorisme.

→ Loi du 9 septembre 1986, n° 86-1020, relative à la lutte contre le terrorisme.

Les associations et groupements à l'origine de violence aux abords des stades peuvent aussi faire l'objet d'une dissolution administrative.

→ Loi du 5 juillet 2006, n° 2006-784, relative à la prévention des violences lors des manifestations sportives.

La possibilité de dissolution administrative des associations et des groupements va à l'encontre de la liberté d'association. Cependant, cette dissolution peut être justifiée par l'illicéité de l'objet associatif et la nécessité d'y mettre immédiatement un terme.

La dissolution administrative permet cette réponse immédiate tout en étant contrôlée par le juge administratif.

Le Conseil d'État est compétent en premier ressort pour statuer sur les recours dirigés contre les décrets portant dissolution d'une association. Le juge considère qu'eu égard à la gravité de l'atteinte portée par une mesure de dissolution à la liberté d'association, principe fondamental reconnu par les lois de la République, ces dispositions sont d'interprétation stricte et ne peuvent être mises en œuvre que pour prévenir de graves troubles à l'ordre public.

Le Conseil d'État a ainsi pu suspendre le décret portant dissolution du collectif « Les Soulèvements de la Terre ». Le juge a estimé qu'il ne pouvait pas être imputé à ce groupement des provocations explicites à la violence contre les personnes, et qu'il ne peut être regardé comme ayant revendiqué, valorisé ou justifié publiquement de tels agissements. La décision de dissolution ne présentait pas un caractère adapté, nécessaire et proportionné à la gravité des troubles susceptibles d'être portés à l'ordre public par ses agissements.

→ CE, sect., 9 novembre 2023, n° 436784.

À l'inverse, le Conseil d'État peut aussi rejeter les recours dirigés contre le décret de dissolution. On peut citer à titre d'exemples médiatiques :

→ CE, sect., 9 novembre 2023, n° 464412 : dissolution du groupement de fait « Groupe Antifascistes Lyon et environ » justifiant l'usage de la violence envers les représentants des forces de l'ordre, leurs locaux et leurs véhicules et se réjouissant de telles actions.

→ CE, sect., 9 novembre 2023, n° 459704 : dissolution de l'association « Coordination contre le racisme et l'islamophobie » dont les agissements étaient de nature à provoquer à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personne à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une nation, une prétendue race ou religion déterminée ou à propager des idées ou théories tendant à les justifier ou à les encourager.

→ CE, sect., 9 novembre 2023, n° 460457 : dissolution du groupement de fait « L'Alvarium » pour des agissements tendant à justifier ou à encourager la discrimination, la haine ou la violence envers les personnes d'origine non européennes, en particulier celles de confession musulmane.

Notion essentielle et actualités jurisprudentielles. - Dissolution administrative : un contrôle strict de l'imputabilité des agissements et de leur proportionnalité

Parce qu'elle met fin à l'existence même d'une association ou d'un groupement de fait, la dissolution administrative constitue une atteinte particulièrement grave à la liberté d'association. Le Conseil d'État rappelle donc que l'article L. 212-1 du CSI est d'interprétation stricte et ne peut être mis en œuvre que pour prévenir des troubles graves à l'ordre public. La dissolution doit en outre être adaptée, nécessaire et proportionnée (application du triple test de proportionnalité, donc).

La jurisprudence récente précise surtout les conditions dans lesquelles des comportements ou des publications peuvent être imputés au groupement :

- En janvier 2025, le Conseil d'État a ainsi annulé la dissolution du groupement rennais Défense Collective, créé pour apporter un soutien juridique aux personnes poursuivies à la suite d'actions militantes. Le Gouvernement lui avait notamment imputé de nombreuses publications du média « Rennes DTR » incitant à des violences contre les biens et les forces de l'ordre. Or, la proximité idéologique entre les deux structures, le fait qu'elles relaient certains contenus réciproquement et que l'un des responsables du groupement soit susceptible d'administrer une page du média ne suffisaient pas à établir que celui-ci constituait une simple émanation de Défense Collective. Les faits principalement retenus ne pouvant lui être imputés, le décret de dissolution a été annulé.

  → CE, 27 janvier 2025, *Défense Collective*, n° 494845.

- La solution a été différente concernant le Collectif Palestine Vaincra. Le CE relève que le groupement exprimait notamment sa sympathie pour le Front populaire de libération de la Palestine et critiquait l'inscription du Hamas sur la liste des organisations terroristes. Ces prises de position, aussi contestables soient-elles, ne constituaient pas en elles-mêmes des agissements visant à provoquer des actes terroristes. De même, son antisionisme militant et son discours prônant la disparition de l'État d'Israël n'excédaient pas, par eux-mêmes, les limites de la liberté d'expression. Toutefois, les publications du collectif provoquaient sur ses réseaux sociaux de nombreux commentaires agressifs, haineux et parfois explicitement antisémites. Le groupement n'ayant pas suffisamment utilisé les moyens de modération dont il disposait pour les prévenir ou les supprimer, ces provocations pouvaient lui être imputées sur le fondement de l'article L. 212-1-1 du CSI. Compte tenu de leur nature, de leur gravité et de leur récurrence, la dissolution a été jugée proportionnée.

→ CE, 20 février 2025, *Collectif Palestine Vaincra*, n° 462981.

Cette jurisprudence a été prolongée en 2026 à propos de La Jeune Garde antifasciste. Le groupement organisait notamment des opérations de « vigilance antifasciste » et de « quadrillage » de quartiers destinées à exclure de l'espace public les personnes considérées comme appartenant à l'extrême droite, ainsi que des formations d'« autodéfense » préparant ses membres à des affrontements. Certaines de ses branches suivaient également des comptes « Antifa Squads » diffusant des vidéos d'actions violentes

attribuées à La Jeune Garde et avaient approuvé certaines de leurs publications, sans que le groupement ne s'en désolidarise.

Le Conseil d'État a considéré que ces comportements caractérisaient une stratégie d'intimidation et une provocation à des agissements violents. Eu égard à leur répétition et à leur gravité, la dissolution était nécessaire et proportionnée.

→ CE, 30 avril 2026, *Jeune Garde antifasciste*, n° 506860.

À retenir. – En définitive, la proximité idéologique ou politique avec des auteurs de violences ne suffit pas à justifier une dissolution. En revanche, peuvent être pris en compte les actes des membres directement liés aux activités du groupement ainsi que, dans certaines circonstances, le soutien apporté à des contenus violents ou l'absence de réaction et de modération face à ceux-ci. Le juge contrôle à la fois l'imputabilité des faits, leur qualification et la proportionnalité de la dissolution. Il procède donc à un examen *in concreto* et de proportionnalité.

POUR ALLER PLUS LOIN

La liberté d'association est le corollaire de la liberté de réunion dans une société démocratique. Elle permet de créer des liens sociaux stables entre les citoyens et de les concrétiser juridiquement autour d'une ou de causes communes.

La liberté d'association a été consacrée tardivement avec la loi de 1884 Waldeck-Rousseau réhabilitant les syndicats professionnels puis la loi de 1901 relative au contrat d'association.

Cela s'explique par l'influence philosophique libérale révolutionnaire : les libertés sont celles des individus alors que les différents groupes – corporations, guildes et ordres divers – sont regardées avec suspicion, car limitative de l'initiative individuelle.

POUR S'ENTRAÎNER

Argumentation juridique : Soutenez que la liberté d'association est un droit fondamental.

En France, il existe plus d'1,3 million d'associations. La plupart sont des associations déclarées et reconnues œuvrant dans des domaines très divers : culture, sport, éducation, social…

La liberté d'association fait partie des droits fondamentaux piliers de nos démocraties modernes et ce droit est particulièrement scruté par la Cour européenne des droits de l'homme notamment pour le rôle primordial des partis politiques qui sont une forme d'association.

La Cour européenne des droits de l'homme a ainsi confirmé à plusieurs reprises le rôle primordial que jouent les partis dans un régime démocratique bénéficiant de la liberté de réunion et d'association ainsi que de la liberté d'expression.

Cette protection ne se limite pas aux partis politiques, mais à toutes les associations qui se répartissent en trois catégories :

- Les associations non déclarées : celles qui n'ont pas fait l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux ; ce sont des associations qui n'ont pas de personnalité juridique.
- Les associations déclarées : celles qui ont reçu un agrément préfectoral. Ce dernier est délivré par la Préfecture après envoi des statuts de l'association. L'existence de l'association est publique et elle dispose d'une personnalité juridique.
- Les associations reconnues d'utilité publique : celles qui ont une pleine capacité juridique en contrepartie d'obligations envers les autorités publiques.

Problématique et annonce du plan : Bien qu'absente dans le texte constitutionnel, la liberté d'association bénéficie d'une consécration jurisprudentielle **(I)**, tout en étant encadrée législativement **(II)**.

I. La consécration constitutionnelle de la liberté d'association

A. Le fruit d'une reconnaissance jurisprudentielle et conventionnelle.

La liberté d'association n'est pas explicitement reconnue dans le texte de la Constitution de 1958.

Le Conseil d'État l'a érigé en principe fondamental reconnu par les lois de la République en 1956 (CE, 11 juillet 1956, n° 26638, Amicale des Annamites de Paris).

Puis en 1971, le Conseil constitutionnel consacre sa valeur constitutionnelle en tant que principe fondamental reconnu par les lois de la République (Cons. const. déc. n° 71-44 DC, 16 juillet 1971, *Loi complétant les dispositions des articles 5 et 7 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association*).

La liberté d'association possède aussi une reconnaissance internationale et conventionnelle : article 20 de la Déclaration Universelle des droits de l'homme, article 22 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Art. 11 CESDH / art. 12 CDFUE.

Cette reconnaissance conventionnelle entraîne donc un contentieux devant la Cour européenne des droits de l'homme qui veille au respect de la liberté d'association et notamment des partis politiques (CEDH, 29 avril 1999, *Chassagnou c. France*, n° 29515/95, CEDH 30 janvier 1998, PCU c. Turquie, n° 19392/92).

Cette protection ne se limite pas aux partis politiques, elle concerne aussi toutes les associations (CEDH, 17 février 2004, *Gorzelik et a. c. Pologne*, n° 44158/98).

B. Le régime juridique de la liberté d'association

La liberté d'association repose sur un régime juridique très libre prévu par la loi.

Cette liberté s'incarne dans la liberté individuelle d'adhérer ou de ne pas adhérer à une association et le droit de pouvoir en sortir (art. 11 CEDH, CEDH, 29 avril 1999 *Chassagnou c. France*, n° 29515/95 ; Cass. 9 février 2001, n° 99-17.642).

Rares cas d'adhésion obligatoire à une association (assurances).

On retrouve aussi le principe de libre constitution d'une association : simple déclaration en préfecture, censure de la loi prévoyant un contrôle administratif préalable (Cons. const., déc. n° 71-44 DC, 16 juillet 1971, *Loi complétant les dispositions des articles 5 et 7 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association*).

Liberté contractuelle concernant l'objet de l'association et principe de libre fonctionnement de l'association. Chaque association peut avoir sa propre organisation et différents statuts.

Enfin, toute association jouit du principe d'autonomie patrimoniale.

II. L'encadrement de la liberté d'association

A. Les possibles restrictions à la liberté d'association

Art. 3 de la loi de 1901 énonce les restrictions prévues de la liberté d'association : *« Toute association fondée sur une cause ou en vue d'un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes mœurs, ou qui aurait pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire national et à la forme républicaine du gouvernement, est nulle et de nul effet. »*

Déclaration nulle et non avenue d'une association mettant en relation des personnes pour un accord de mère porteuse (Cass., civ., 13 décembre 1989, *Association Alma Mater*), ou encore une association ayant pour objet le rétablissement de la monarchie (CE, 4 avril 1936, *Pujo, de Lassus et Réal Del arte*).

Dissolution judiciaire : prononcée par la Cour de cassation à la demande du Procureur ou de toute personne intéressée quand l'association a été fondée sur une cause ou en vue d'un objet illicite.

Dissolution administrative : prévue par la loi du 10 janvier 1936 permettant de mettre un terme aux activités de groupes de combat et de milices privées.

Révision en 1972 pour pouvoir dissoudre les groupements incitant à la discrimination, à la haine ou à la violence, puis en 1986 pour les groupements à l'origine d'actes de terrorisme et en 2006 pour les associations et groupements à l'origine de violence aux abords des stades.

B. L'encadrement des restrictions par un contrôle du juge

La dissolution administrative est encadrée et contrôlée par le juge administratif afin d'éviter toute dissolution politique et d'assurer l'effectivité de cette liberté.

La dissolution doit être justifiée par l'illicéité de l'objet associatif et la nécessité d'y mettre immédiatement un terme.

Le Conseil d'État est compétent en premier ressort pour statuer sur les recours dirigés contre les décrets portant dissolution d'une association.

Lorsque la dissolution ne présente pas un caractère adapté le Conseil d'État peut suspendre le décret portant dissolution du collectif (CE, sect., 9 novembre 2023, n° 436784, « Les Soulèvements de la Terre).

Quand le décret de dissolution est justifié, le Conseil d'État rejette les recours dirigés contre le décret de dissolution (CE, sect., 9 novembre 2023, n° 464412, « Groupe Antifascistes Lyon et environ ; CE, sect., 9 novembre 2023, n° 459704, « Coordination contre le racisme et l'islamophobie » ; CE, sect., 9 novembre 2023, n° 460457 « L'Alvarium »).

En conclusion, la fondamentalité de la liberté d'association ne prête pas au doute. Forte de son assise conventionnelle, constitutionnelle et légale, elle permet aux personnes de se regrouper pour agir dans un but autre que celui de générer des bénéfices. Cette liberté vectrice de solidarité et de lien social dans certains domaines est donc protégée et encadrée pour assurer sa pleine effectivité.

Fiche nº 40 - LA LIBERTÉ D'ALLER ET VENIR

POINTS CLÉS

- Liberté d'aller et venir.
- Espace public.
- Droit fondamental des citoyens.
- Privation de liberté versus restriction.
- Régimes différenciés.
- Mesures d'exception.
- Espace Schengen : citoyens européens et ressortissant de pays tiers.
- Crise exceptionnelle et temporaire : état d'urgence (sanitaire).
- Enjeux contemporains : contrôle au faciès et dérives sécuritaires.

PRINCIPALES RÉFÉRENCES

- *Articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.*
- *Article 45 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.*
- *Protocole nº 4 de la Convention européenne des droits de l'homme.*
- *Article 12 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.*
- *Article L. 521-2 du Code de justice administrative.*
- *Article 78-2 du Code de procédure pénale.*
- *Cons. const., déc. nº 2010-13 QPC, 9 juillet 2010, Monsieur Orient et autre [Gens du voyage].*
- *Cons. const., déc. nº 2015-527 QPC, 22 décembre 2015, Monsieur Cédric D. [Assignation à résidence dans le cadre de l'état d'urgence].*
- *CEDH, 6 novembre 1980, Guzzardi c. Italie,* nº 7367*/76.*
- *Article 20 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.*

1. Le cadre général de la liberté d'aller et venir en France

Le régime juridique de la liberté d'aller et venir diffère en fonction de la nationalité, des restrictions pouvant être imposées aux ressortissants étrangers, en particulier concernant les conditions d'entrée sur le territoire.

En général, c'est la distinction entre ressortissants français – ou de l'Union européenne – et étrangers qui détermine les règles applicables à cette liberté.

1.1. Fondement de la liberté de circulation

La liberté d'aller et venir est considérée comme une composante de la liberté personnelle au regard de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen par les juridictions françaises.

→ Art. 2 et 4 DDHC.

→ Cons. const., déc. nº 2010-13 QPC, 9 juillet 2010, *Monsieur Orient et autre [Gens du voyage].*

→ CE, 11 avril 2018, nº 418027.

Elle est reconnue comme une liberté fondamentale, comme l'a affirmé le juge administratif.

→ Art. L. 521-2 CJA.

→ CE, ord., 9 janvier 2001, *Deperthes*, n° 228928.

Cette liberté bénéficie, par ailleurs, d'une protection en vertu du protocole n° 4 de la Convention européenne des droits de l'homme et du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

→ Art. 2 du Protocole n° 4 CESDH.

→ Art. 12 du PIDCP.

Le droit de l'Union européenne revêt une importance centrale pour les ressortissants des États membres. La charte des droits fondamentaux consacre pour tout citoyen de l'Union le droit de circuler et de séjourner sur le territoire des États membres.

→ Art. 45 CDFUE.

1.1.1. Privation de liberté et restriction à la liberté d'aller et venir

Bien qu'il soit manifeste que toute privation de liberté constitue une entrave à la liberté d'aller et venir, une distinction entre ces deux notions doit être faite. Tant le Conseil constitutionnel que la Cour européenne des droits de l'homme marquent une différence entre la privation de liberté et les limitations de la liberté d'aller et venir, en excluant la première du champ de la liberté d'aller et venir.

En droit français, la privation de liberté relève de la liberté individuelle, garantie par l'article 66 de la Constitution, qui désigne le juge judiciaire comme le protecteur de cette liberté. Par conséquent, les autres formes de restrictions à la liberté d'aller et venir échappent, en principe, à la compétence de ce même juge, notamment lorsque les mesures sont prises dans le cadre de la police administrative.

→ Cons const., déc. n° 2015-527, QPC, 22 décembre 2015, *Monsieur Cédric D. [Assignation à résidence dans le cadre de l'état d'urgence].*

La Cour européenne des droits de l'homme opère aussi une distinction entre la privation de liberté au sens de l'article 5 et les restrictions à la liberté d'aller et venir, qui relèvent de l'article 2 du Protocole n° 4.

→ CEDH, 6 novembre 1980, *Guzzardi c. Italie.*

1.1.2. Zones grises : l'état d'urgence

La distinction entre privation et restriction de liberté peut parfois prêter à confusion, étant donné qu'elle relève davantage d'une différence de degré que de nature. Cette question s'est posée en ce qui concerne les mesures d'assignation à résidence dans le cadre de l'état d'urgence.

Ainsi, l'assignation à résidence est, en principe, interprétée comme une simple entrave à la liberté d'aller et venir.

→ Art. 6 de la loi du 3 avril 1955.

Le juge constitutionnel précise que l'astreinte quotidienne à domicile, limitée à 12 heures, n'atteint pas le seuil de la privation de liberté et ne relève donc pas de l'article 66 de la Constitution.

→ Cons. const., déc. n° 2015-527 QPC, 22 décembre 2015, *Monsieur Cédric D. [Assignation à résidence dans le cadre de l'état d'urgence].*

Dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, le Conseil constitutionnel a jugé que, lorsqu'une interdiction totale de sortie est imposée, les mesures de quarantaine et d'isolement constituent une privation de liberté. Il en va de même pour l'obligation de rester à domicile pendant plus de douze heures par jour.

→ Cons. const. déc. n° 2020-800 DC, 11 mai 2020, *Loi prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions.*

Actualité jurisprudentielle. - La libre circulation n'interdit pas le rétablissement temporaire des frontières intérieures

La suppression des contrôles aux frontières intérieures constitue le principe dans l'espace Schengen. Toutefois, le Code « frontières Schengen » permet leur réintroduction temporaire, en dernier recours, lorsqu'une menace grave affecte l'ordre public ou la sécurité intérieure.

La France avait ainsi décidé de rétablir les contrôles à ses frontières intérieures du 1er novembre 2024 au 30 avril 2025, en invoquant notamment la persistance de la menace terroriste et l'activité de réseaux criminels de passeurs.

Appliquant pour la première fois le cadre issu du règlement (UE) 2024/1717, le Conseil d'État considère ces motifs susceptibles de justifier la réintroduction des contrôles. Compte tenu de la nature et de l'actualité des risques, il juge également la mesure proportionnée, aucune mesure moins restrictive, notamment des contrôles réalisés uniquement à proximité immédiate des frontières, ne permettant d'y répondre avec une efficacité équivalente.

→ CE, 7 mars 2025, *Association nationale d'assistance aux frontières pour les personnes étrangères et autres,* n° 499702.

À retenir. - L'absence de contrôle aux frontières intérieures demeure le principe de Schengen. Leur rétablissement constitue une mesure exceptionnelle et temporaire qui doit être justifiée par une menace grave et rester nécessaire et proportionnée.

1.2. Entrée et sortie en territoire français

L'entrée et la sortie du territoire ne suivent pas tout à fait la même logique puisque si quitter un pays est un droit, l'accès au territoire d'un État est soumis à une réglementation différenciée en fonction du statut de l'individu, national ou étranger.

1.2.1. L'entrée sur le territoire

Il convient d'opérer une distinction entre trois catégories de ressortissants, chacune soumise à un régime juridique spécifique : les nationaux, les ressortissants de l'Union européenne et ceux des pays tiers.

S'agissant des ressortissants français, les instruments internationaux consacrent un droit fondamental : nul ne peut être empêché d'entrer sur le territoire de l'État dont il possède la nationalité.

→ Art. 3 du protocole n° 4 CESDH.

→ Art. 12 PIDCP.

Concernant les étrangers, il faut différencier les ressortissants de l'Union européenne de ceux des États tiers.

En effet, le droit de l'Union reconnaît à tout citoyen européen un droit de libre circulation et de séjour sur le territoire des autres États membres, sous réserve de la seule présentation d'une carte d'identité.

→ Art. 5 de la directive n° 2004/38/CE du 29 avril 2004.

Aucune règle constitutionnelle ne garantit aux ressortissants de pays tiers, ne leur garantit un droit général et absolu d'accès ou de séjour sur le territoire national.

→ Cons. const., déc. n° 2003-484, 20 novembre 2003, *Loi relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité*.

Toutefois, la souveraineté de l'État trouve certaines limites, notamment lorsqu'il s'agit de garantir le droit au regroupement familial.

→ Cons. const., déc. n° 93-325 DC, 13 août 1993, *Loi relative à la maîtrise de l'immigration et aux conditions d'entrée, d'accueil et de séjour des étrangers en France.*

1.2.2. La sortie du territoire

La liberté d'aller et venir ne se limite pas au seul territoire national, puisqu'elle inclut également le droit de le quitter. Le principe selon lequel toute personne a le droit de quitter un pays, y compris le sien, est affirmé par les instruments internationaux et reconnu par les juridictions françaises.

→ Art. 2 du protocole n° 4 de la CESDH.

→ Art. 12 PIDCP.

→ Cons. const., déc. n° 93-325 DC, 13 août 1993, *Loi relative à la maîtrise de l'immigration et aux conditions d'entrée, d'accueil et de séjour des étrangers en France.*

→ Cass. civ. 1re, 28 novembre 1984.

1.3. Les entraves à la liberté de circulation

La liberté d'aller et venir suppose que la circulation des personnes sur le territoire français ne soit pas entravée au-delà des contraintes inhérentes à la poursuite de finalités d'intérêt général. En pratique, les entraves existent, comme l'illustrent les contrôles d'identité, c'est-à-dire la sommation de justifier de son identité par tout moyen.

1.3.1. Les contrôles de police judiciaire

Ces contrôles sont possibles lorsqu'il existe des raisons plausibles de soupçonner que la personne visée a commis une infraction ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par l'autorité judiciaire. Par ailleurs, sur réquisition du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d'infractions, l'identité de toute personne peut être contrôlée dans les lieux et pour une période déterminée par ce magistrat.

→ Art 78-2 alinéa 7 du Code de procédure pénale.

Le Conseil constitutionnel a émis des réserves d'interprétation pour en canaliser l'usage :

> *« Les réquisitions du procureur de la République ne peuvent viser que des lieux et des périodes déterminés. Ces dispositions ne sauraient, sans méconnaître la liberté d'aller et de venir, autoriser le procureur de la République à retenir des lieux et périodes sans lien avec la recherche des infractions visées dans ses réquisitions. Elles ne sauraient non plus autoriser* […] *la pratique de contrôles d'identité généralisés dans le temps ou dans l'espace »* (Cons. const., déc. n° 2016-606/607 QPC, 24 janvier 2017, *M. Ahmed M. et autre [Contrôles d'identité sur réquisitions du procureur de la République]*).

1.3.2. Les contrôles de police administrative

La possibilité de contrôle d'identité relevant de la police administrative est également prévue. Ainsi l'identité de toute personne peut être contrôlée, quel que soit son comportement, pour prévenir une atteinte à l'ordre public, la sécurité des personnes ou des biens.

→ Art. 78-2 al. 8 du Code de procédure pénale.

Mais là aussi le Conseil constitutionnel a formulé une réserve d'interprétation afin de prévenir le risque de contrôles généralisés.

> *« Considérant que la prévention d'atteintes à l'ordre public, notamment d'atteintes à la sécurité des personnes ou des biens, est nécessaire à la sauvegarde de principes et de droits ayant valeur constitutionnelle ; que toutefois la pratique de contrôles d'identité généralisés et discrétionnaires serait incompatible avec le respect de la liberté individuelle ; que s'il est loisible au législateur de prévoir que le contrôle d'identité d'une personne peut ne pas être lié à son comportement, il demeure que l'autorité concernée doit justifier, dans tous les cas, des circonstances particulières établissant le risque d'atteinte à l'ordre public qui a motivé le contrôle »* (Cons. const., déc. n° 93-323 DC du 5 août 1993, *Loi relative au contrôle et vérification d'identité*).

Actualité jurisprudentielle. - Les supporters peuvent être interdits de déplacement en présence de risques suffisamment caractérisés

Les interdictions de déplacement de supporters constituent des mesures de police administrative portant directement atteinte à la liberté d'aller et venir (art. L. 332-16-1, Code du sport). L'administration doit donc justifier précisément devant le juge tant la réalité des risques de troubles graves à l'ordre public que la proportionnalité de l'interdiction.

En l'espèce, en avril 2026, le ministre de l'Intérieur avait interdit le déplacement des supporters de l'AS Saint-Étienne à Nancy à l'occasion d'un match de Ligue 2. Le préfet avait parallèlement interdit leur circulation dans certains secteurs de l'agglomération et leur accès au stade.

Le Conseil d'État relève plusieurs incidents récents impliquant des supporters stéphanois : rixes ou affrontements à Reims, Troyes, Dunkerque et, quelques semaines seulement avant la rencontre, à Grenoble. La précédente rencontre entre Nancy et Saint-Étienne avait également été marquée par des provocations réciproques nécessitant l'intervention des forces de l'ordre. Enfin, celles-ci étaient déjà fortement mobilisées par d'autres événements sportifs, le contexte de menace terroriste et le week-end pascal.

Dans ces circonstances, des mesures moins restrictives n'apparaissaient pas suffisantes. L'interdiction de déplacement n'était donc pas manifestement disproportionnée.

→ CE, ord., 3 avril 2026, *Association nationale des supporters*, n° 514220.

À retenir. - Une interdiction de déplacement ne peut reposer sur la seule qualité de supporter. Elle suppose des éléments précis et circonstanciés établissant un risque de troubles graves, ainsi que la démonstration que des mesures moins restrictives ne permettraient pas d'assurer suffisamment l'ordre public. L'arrêt apporte aussi une précision intéressante : le risque peut être apprécié objectivement, indépendamment du comportement individuel de chaque supporter, lorsque leur seule présence est susceptible d'occasionner des troubles graves.

POUR ALLER PLUS LOIN

Nouvelles technologies et dérives sécuritaires. *Il importe de dénoncer le risque d'un usage dystopique de l'IA, où l'apparence servirait à prédire la criminalité, au mépris de la science et de l'éthique. Des chercheurs, notamment en Chine, développent des algorithmes de reconnaissance faciale pour identifier des criminels potentiels à partir de traits du visage. Leur étude, inspirée des théories aujourd'hui discréditées de Lombroso sur le « criminel né », prétend obtenir une précision de 90 %... sur un échantillon très limité. Les résultats sont contestés : manque de diversité dans l'échantillonnage, biais inhérent aux données d'entraînement, absence d'évaluation interdisciplinaire, etc. L'algorithme ne fait que reproduire les biais humains tout en apparaissant comme « objectif ». Ces nouvelles approches rappellent les doctrines pseudo-scientifiques du passé, tout en ignorant les avancées des sciences sociales. C'est dans ce contexte préoccupant qu'il convient de lire la note n° 43, de 2019, du CREOGN, qui évoque la possibilité d'un contrôle d'identité permanent et généralisé rendu possible par les outils numériques et la reconnaissance faciale. Présentée comme une évolution de l'anthropométrie judiciaire, cette technologie permettrait d'automatiser l'identification et la recherche d'individus. Si elle promet de lutter contre la discrimination du contrôle au faciès, et l'atteinte à la liberté de circuler, en rendant le contrôle invisible, permanent et général, elle glisse paradoxalement vers une surveillance de masse. Il convient de rappeler que le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 5 août 1993 (n° 93-323 DC), a jugé que les contrôles d'identité généralisés et discrétionnaires sont contraires au respect des libertés individuelles.*

2. L'articulation de la liberté de circulation avec la lutte contre le terrorisme

Dans un contexte de menace terroriste persistante, le législateur a instauré, depuis 2014, un arsenal de mesures restreignant la liberté de circulation. Ces dispositifs, allant de l'interdiction de sortie du territoire à l'assignation à résidence, visent à prévenir les départs vers les zones de conflit, à sécuriser l'espace public et à encadrer les individus suspectés de liens avec le terrorisme, tout en soulevant des enjeux majeurs de respect des libertés fondamentales.

2.1. Les restrictions spécifiques sur l'entrée et la sortie du territoire

Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, le législateur français a instauré en 2016 une procédure de contrôle administratif visant toute personne, y compris de nationalité française, ayant quitté le territoire national *« dont il existe des raisons sérieuses de penser que ce déplacement a pour but de rejoindre un théâtre d'opérations de groupements terroristes dans des conditions susceptibles de la conduire à porter atteinte à la sécurité publique* ». Le contrôle se fait *« dès son retour sur le territoire national »*.

→ Loi n° 2016-731 du 3 juin 2016.

→ Art. L. 225-1 du Code de la sécurité intérieure.

Le législateur a par ailleurs institué une mesure d'interdiction de sortie du territoire des français dont il existe des raisons de penser qu'ils projettent des déplacements à l'étranger ayant pour objet la participation à des activités terroristes.

→ Art. 1er de la loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014.

→ Art. L. 224-1 du Code de la sécurité intérieure.

La politique de lutte contre le terrorisme a également conduit à un renforcement des restrictions concernant la sortie du territoire des mineurs. En 2016, le législateur a ainsi réintroduit l'autorisation de sortie du territoire pour les mineurs voyageant sans l'accompagnement d'un détenteur de l'autorité parentale.

→ Art. 371-6 du Code civil.

Actualité jurisprudentielle. - La sécurité nationale peut justifier le refus de délivrer un passeport

Le refus de délivrer un passeport porte atteinte au droit de quitter son pays garanti par l'article 2 du Protocole n° 4 à la Convention EDH. Il peut néanmoins être justifié par des impératifs de sécurité nationale, sous réserve d'un contrôle de nécessité et de proportionnalité.

En l'espèce, la Cour EDH s'est prononcée en 2025 sur le cas d'un ressortissant belge précédemment condamné pour des faits liés au terrorisme. Les services de sécurité considéraient qu'il existait un risque qu'il retourne en Syrie et un drapeau de Daech avait notamment été découvert à son domicile. Les autorités avaient refusé de lui délivrer un passeport.

La Cour relève que la mesure n'équivalait pas à une interdiction totale de voyager : l'intéressé pouvait encore se déplacer dans les États où sa carte d'identité était suffisante, notamment au sein de l'espace Schengen. Le refus avait également été limité dans le temps et avait fait l'objet d'un contrôle effectif du Conseil d'État belge, qui avait accès à l'ensemble du dossier.

La restriction était donc proportionnée aux impératifs de sécurité poursuivis.

⟶ CEDH, 26 juin 2025, *Cimpaka Kapeta c. Belgique*, n° 55000/18.

À retenir. - Les impératifs de lutte contre le terrorisme peuvent justifier une restriction au droit de quitter le territoire, mais le juge tient compte de son intensité, de sa durée, de la réalité du risque invoqué et de l'existence d'un contrôle juridictionnel effectif.

2.2. Les périmètres de protection (pour tous)

Le préfet peut instaurer, pour un mois renouvelable, une zone de protection où l'accès et la circulation des personnes sont réglementés, afin de sécuriser un lieu ou un événement exposé à un risque d'attentat en raison de sa nature ou de son importante fréquentation. Dans ce périmètre de protection, il peut également autoriser les forces de l'ordre à effectuer des palpations de sécurité, ainsi que des inspections visuelles et des fouilles de sacs, avec le consentement des personnes concernées.

→ Art L. 226-1 Code de la sécurité intérieure.

Plusieurs garanties encadrent la définition des périmètres, veillant à ce que la mesure soit adaptée et proportionnée. Le Conseil constitutionnel a d'ailleurs reconnu la conformité de ce dispositif à la Constitution.

→ Cons const., déc. n° 2017-695 QPC, 29 mars 2018, *M. Rouchdi B. et autre [Mesures administratives de lutte contre le terrorisme].*

2.3. Les mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance (anciennement assignations à résidence - pour certaines personnes)

Le ministre de l'Intérieur peut prononcer pour 12 mois maximum une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance (MICAS) contre toute personne à l'égard de laquelle il existe des *« raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics qui soit entretient des contacts avec des personnes en relation avec des actes de terrorisme, soit diffuse ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie* ».

→ Art L. 228-1 du Code la sécurité intérieure.

Elle peut impliquer l'obligation de rester à domicile pendant 12 heures par jour et de se présenter à la police jusqu'à trois fois par jour.

→ Art. L. 228-2 du Code de la sécurité intérieure.

Le ministre de l'Intérieur peut recourir à des mesures de surveillance individuelles, moins contraignantes, telles que le placement sous surveillance électronique mobile avec l'accord de la personne concernée, l'interdiction de se rendre dans certains lieux ou d'entrer en contact, directement ou indirectement, avec certaines personnes.

Les obligations prévues par l'article L. 228-2 sont prononcées pour une durée maximale de trois mois et peuvent être renouvelées pour la même durée. Au-delà de six mois cumulés, chaque renouvellement doit être justifié par des éléments nouveaux ou complémentaires. Leur durée totale cumulée ne peut excéder 12 mois. Depuis la loi du 27 juillet 2026 *visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat*, le renouvellement fait en outre l'objet d'un contrôle juridictionnel accéléré : l'intéressé peut saisir le tribunal administratif dans les 48 heures et celui-ci est tenu de statuter dans les 72 heures.

Attention. - Il ne faut pas confondre cette limite de 12 mois, qui concerne la durée totale de la MICAS, avec le seuil de 12 heures par jour dégagé à propos des mesures d'assignation ou d'isolement. Lorsqu'une personne est obligée de demeurer dans un lieu déterminé plus de 12 heures par période de 24 heures, la mesure atteint le degré d'une privation de liberté : elle relève alors de la liberté individuelle garantie par l'article 66 de la Constitution et appelle l'intervention de l'autorité judiciaire.

Il faut donc distinguer clairement la mesure restrictive de liberté (compétence du juge administratif) de celle privative de liberté (relevant de la compétence du juge judiciaire).

3. La libre circulation des personnes dans l'Union européenne

L'instauration d'un espace en Europe prévoyant la libre circulation des personnes a été achevée par la conclusion des Accords de Schengen du 14 juin 1985

Avant le 1er janvier 2025, 27 pays participaient pleinement à l'espace Schengen : 23 États membres de l'Union européenne auxquels s'ajoutaientt la Norvège, l'Islande, la Suisse et le Liechtenstein (qui ont le statut d'États associés).

Depuis le 1er janvier 2025, la Bulgarie et la Roumanie sont pleinement intégrées à l'espace Schengen. Les contrôles aux frontières aériennes et maritimes avaient déjà été supprimés le 31 mars 2024 ; ceux aux frontières terrestres l'ont été à compter du 1er janvier 2025.

L'espace Schengen comprend désormais 29 États : 25 États membres de l'Union européenne et quatre États associés : Islande, Liechtenstein, Norvège et Suisse. Chypre participe à la coopération Schengen mais les contrôles à ses frontières intérieures n'ont pas encore été supprimés ; l'Irlande n'appartient pas à l'espace Schengen.

Les réalisations résultant des accords de Schengen comprennent :

- La suppression des contrôles aux frontières intérieures pour toutes les personnes.
- L'harmonisation de la surveillance des frontières extérieures : les citoyens européens peuvent entrer dans l'espace Schengen sur présentation de carte d'identité/passeport.
- Une politique commune des visas de court séjour.

Le Traité sur l'Union européenne, dans sa version issue de la révision de Lisbonne, précise désormais que l'Union offre à ses citoyens un espace *« au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes, en liaison avec des mesures appropriées en matière de contrôle des frontières extérieures, d'asile, d'immigration ainsi que de prévention de la criminalité et de lutte contre ce phénomène »*.

Cependant, au-delà de cet « espace de liberté, de sécurité et de justice », c'est bien le « marché unique » qui constitue le principal moteur des libertés de circulation, lesquelles, bien que qualifiées de « fondamentales » en droit de l'Union européenne, s'inscrivent essentiellement dans une logique économique.

3.1. Marchandises et personnes : une liberté fondamentale(ment) économique

La liberté de circulation des personnes s'inscrit historiquement dans un cadre strictement économique, dans le but de l'édification d'un marché intérieur, au même titre que les biens.

3.1.1. Le travailleur avant la personne

Dans le traité sur le fonctionnement de l'Union, la libre circulation des personnes demeure, encore aujourd'hui, mentionnée secondairement, après celle des marchandises. Elle est d'ailleurs regroupée avec la libre circulation des services et des capitaux. Cette liberté ne s'entend pas comme un droit subjectif inhérent à la personne humaine, mais comme un instrument au service de l'intégration économique.

→ Art. 45 TFUE (libre circulation des travailleurs).

→ Art. 56 TFUE (libre prestation des services).

→ Art. 63 TFUE (libre circulation des capitaux).

→ Art. 49 TFUE (liberté d'établissement).

L'article 45 du Traité ne parle pas de « personnes », mais bien de « travailleurs ». Il convient également de souligner que les « personnes morales » bénéficient, souvent davantage que les personnes physiques, des libertés fondamentales du marché.

À l'origine, la libre circulation des personnes se limitait aux travailleurs et entreprises, c'est-à-dire aux acteurs économiques que sont les salariés et les prestataires de services.

Si la notion a évolué depuis les premières dispositions du traité instituant la Communauté économique européenne en 1957, ces libertés restent avant tout instrumentales, dans la mesure où elles facilitent l'intégration des marchés nationaux.

3.1.2. Un citoyen de marché

Le traité de Maastricht a introduit en 1992 la notion de citoyenneté de l'Union dont peut se prévaloir tout citoyen ayant la nationalité d'un État membre. C'est désormais sur cette citoyenneté de l'Union que se fonde le droit des personnes de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres.

→ Art. 20.2 a) TFUE.

En dépit de la dynamique de fondamentalisation des droits des personnes, la citoyenneté de l'Union demeure une « citoyenneté de marché », dont l'identité constitutive repose sur la figure du travailleur migrant. Initialement circonscrite à la libre circulation des travailleurs et des prestataires de services, cette liberté s'est étendue à une catégorie plus large d'agents économiques mobiles – consommateurs, étudiants, retraités, chômeurs – tout en conservant une orientation intrinsèquement économique.

Le statut de travailleur reste en effet la clé d'accès aux droits sociaux les plus étendus.

→ CJUE, 20 septembre 2001, *Grzelczyk*, aff. C-184/99.

Sur le plan juridique, la citoyenneté européenne est façonnée dans le cadre du marché, où s'appliquent les principes de libre circulation, de non-discrimination, de reconnaissance mutuelle, ainsi que la logique de suppression des entraves

→ CJUE, 30 novembre 1995, *Gebhard*, aff. C 55/94.

Cette matrice économique gouverne également la citoyenneté sociale, laquelle s'est construite principalement par la jurisprudence de la Cour de justice qui a ouvert l'accès aux droits sociaux aux citoyens européens mobiles, même inactifs, sous condition d'un « lien réel » avec l'État d'accueil.

→ CJUE, 12 mai 1998, *María Martínez Sala c. Freistaat Bayern*, aff. C-85/96.

La jurisprudence récente de la Cour marque néanmoins un recentrage très net sur la condition économique des bénéficiaires.

→ CJUE, 11 novembre 2014, *Elisabeta Dano et Florin Dano c. Jobcenter Leipzig*, aff. C-333/13.

Le modèle soulève d'importantes questions politiques. La solidarité européenne repose sur un découplage entre droits et devoirs, imposant aux citoyens « sédentaires » – ceux qui ne font pas usage de leurs libertés de circulation en Europe – le financement des droits sociaux des citoyens mobiles – ceux qui exercent ces libertés – non-contributeurs.

Cette tension met en lumière l'absence d'harmonisation sociale et fiscale en Europe. Ainsi, la citoyenneté européenne continue de s'inscrire dans la dynamique du marché, où la mobilité économique prime sur les enjeux politiques et sociaux, révélant une dépendance structurelle aux origines économiques qui conditionne tant le contenu que la légitimité du statut juridique de citoyen de l'Union.

3.2. La cinquième liberté (numérique) : la libre circulation des données personnelles

À côté des quatre libertés de circulation traditionnelles (marchandises, personnes, services et capitaux) on peut s'interroger sur l'émergence d'une cinquième liberté de mouvement dans l'Union : la libre circulation des données à caractère personnel.

Le règlement général de protection des données (RGPD) n'a pas seulement pour objet de protéger les données personnelles, mais aussi d'assurer leur libre circulation, dans le but d'assurer le bon fonctionnement du marché.

> *« Pour que le marché intérieur fonctionne correctement, il est nécessaire que la libre circulation des données à caractère personnel au sein de l'Union ne soit ni limitée ni interdite pour des motifs liés à la protection des personnes physiq*ues *»* (cons. 13 RGPD).

La question se pose de l'équilibre entre la libre circulation de ces données, moteur de l'économie numérique européenne, et la protection effective des droits des individus. Leur traitement massif génère des risques comme le profilage ou la surveillance, que le règlement général s'efforce de réglementer via la transparence, la responsabilité des acteurs et le renforcement des droits et libertés des personnes.

Cependant, la complexité technique et les cybermenaces compliquent son application, et appelle à une vigilance constante.

POUR S'ENTRAÎNER

Commentaire de texte :

« Art. 2 du Protocole n° 4 CESDH – Liberté de circulation

1. *Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d'un État a le droit d'y circuler librement et d'y choisir librement sa résidence.*

2. *Toute personne est libre de quitter n'importe quel pays, y compris le sien.*

3. *L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l'ordre public, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.*

4. *Les droits reconnus au paragraphe 1 peuvent également, dans certaines zones déterminées, faire l'objet de restrictions qui, prévues par la loi, sont justifiées par l'intérêt public dans une société démocratique. »*

L'article 2 du Protocole n° 4 à la Convention européenne des droits de l'homme consacre le droit fondamental de toute personne, se trouvant régulièrement sur le territoire d'un État, à circuler librement, à choisir librement sa résidence et à quitter tout pays, y compris le sien. Ce droit est cependant susceptible de limitations, à condition que celles-ci soient prévues par la loi, qu'elles répondent à des objectifs légitimes, et qu'elles soient nécessaires dans une société démocratique.

L'article 2 introduit un droit non prévu dans le texte originel. En effet, contrairement aux traités communautaires qui ont fait de la libre circulation un principe fondateur (notamment dans le cadre du marché commun), la Convention, centrée à l'époque sur les libertés civiles et politiques, était sur ce point jusqu'à l'adoption de ce protocole en 1963.

Adopté dans le contexte de la guerre froide (1963) et destiné à garantir des libertés de déplacement parfois fortement limitées par les régimes autoritaires, cet article reste d'une grande actualité. Le contexte sécuritaire d'aujourd'hui marqué par la menace terroriste, les crises migratoires et les pandémies sanitaires (Covid-19), montre à quel point la liberté de circulation est susceptible d'être restreinte au nom d'intérêts collectifs, même dans les démocraties les plus avancées.

La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme en a précisé la portée, en veillant à maintenir un équilibre entre les droits individuels et les impératifs d'intérêt général.

Problématique et annonce du plan : Comment l'article 2 du Protocole n° 4 affirme-t-il la liberté de circulation tout en en encadrant strictement les limitations susceptibles d'y être apportées ? Le texte commenté consacre une liberté de circulation, et ses corollaires, aux personnes en séjour régulier **(I)**, tout en l'assortissant de restrictions possibles, mais rigoureusement encadrées par des exigences légales et démocratiques **(II)**.

I. Une liberté de circulation affirmée mais conditionnée

L'article 2 consacre la liberté de circulation, mais en limite le bénéfice aux personnes en séjour régulier, et garantit tant les déplacements internes que le droit de quitter le territoire.

A. Condition préalable : la régularité du séjour

Le premier paragraphe de l'article 2 précise que la liberté de circulation est garantie à toute personne se trouvant *« régulièrement sur le territoire d'un État »*. Cette condition est essentielle : la Cour européenne a rappelé qu'elle constitue une exigence préalable à l'application du droit à la libre circulation (CEDH, 8 février 2019, Balta c. France).

Il convient de souligner que ce droit ne concerne pas uniquement les étrangers. Il bénéficie également aux ressortissants empêchés de circuler sur leur propre territoire (CEDH, 13 décembre 2005, *Timishev c. Russie*), ainsi qu'aux personnes ayant une double nationalité (CEDH, 23 mai 2006, *Riener c. Bulgarie*).

Toutefois, la régularité du séjour est laissée à l'appréciation souveraine de l'État : il s'agit d'un domaine relevant de sa compétence exclusive, sur lequel le juge européen n'a pas vocation à interférer.

B. Des droits garantis à l'intérieur comme à l'extérieur des frontières

Le texte consacre une double liberté :

- Liberté de circuler et de choisir sa résidence à l'intérieur du territoire (§ 1).
- Liberté de quitter n'importe quel pays, y compris le sien (§ 2).

La liberté de quitter le territoire implique nécessairement la faculté de se rendre dans un autre État, sous réserve d'en obtenir l'autorisation d'entrée (CEDH, 20 février 1995, *Peltonen c. Finlande*).

Toute restriction imposée par l'État à l'une ou l'autre de ces libertés est soumise à un strict test de proportionnalité. Elle doit être nécessaire à la réalisation d'un objectif légitime dans une société démocratique (CEDH, 22 mai 2001, *Baumann c. France*).

Ainsi, le retrait du passeport d'un individu pendant dix ans dans le cadre d'une procédure pénale a été jugé disproportionné (CEDH, 31 octobre 2006, *Földes c. Hongrie*).

II. Une liberté susceptible de restrictions justifiées

Les paragraphes 3 et 4 prévoient une double limitation : si la première est habituelle **(A)**, la seconde est plus singulière **(B)**.

A. Des limitations classiques soumises à des exigences strictes

Le paragraphe 3 énumère les motifs légitimes usuels : sécurité nationale, sûreté publique, maintien de l'ordre public, prévention des infractions pénales, protection de la santé ou de la morale, protection des droits et libertés d'autrui.

Ces restrictions doivent être prévues par la loi, nécessaires et proportionnées. La Cour exerce à cet égard un contrôle exigeant, en particulier lorsque les limitations durent dans le temps ou qu'elles s'appliquent de manière automatique.

B. Une restriction spécifique : les « zones déterminées »

Le paragraphe 4 introduit une restriction particulière : l'État peut restreindre la liberté de circulation dans certaines zones, si cette restriction est prévue par la loi et justifiée par l'intérêt public.

Cette précision peut paraître redondante au regard du paragraphe précédent. En effet, les limitations énoncées au paragraphe précédent sont aussi subordonnées à une justification par l'intérêt général dans une société démocratique. On peut donc s'interroger sur la pertinence d'un ajout spécifique pour les zones géographiques déterminées : une mesure localisée peut parfaitement répondre à un intérêt général.

Il n'en demeure pas moins que la Cour a reconnu la validité de telles mesures. Ainsi, elle a jugé que l'instauration d'un régime d'autorisation préalable pour s'installer dans un quartier défavorisé ne viole pas l'article 2 du Protocole n° 4 (CEDH, 23 février 2016, *Garib c. Pays-Bas*). Cette décision illustre la marge d'appréciation laissée aux États dans la mise en œuvre de politiques sociales ou urbaines ciblées.

En conclusion, l'article 2 du Protocole n° 4 à la Convention européenne des droits de l'homme consacre un droit fondamental à la liberté de circulation, tout en l'inscrivant dans un cadre juridique rigoureux, garant d'un équilibre entre protection des droits individuels et impératifs d'intérêt général dans une société démocratique.

Fiche nº 41 - LA LIBERTÉ D'ENSEIGNEMENT

POINTS CLÉS

- Distinction entre liberté de l'enseignement et droit à l'enseignement.
- Principe fondamental reconnu par les lois de la République.
- Neutralité de l'enseignement.
- Libertés académiques.
- Liberté de créer des établissements d'enseignement privé.

PRINCIPALES RÉFÉRENCES

- Loi Guizot, 28 juin 1833 pour l'enseignement primaire.
- Loi Falloux, 15 mars 1850 pour l'enseignement secondaire.
- Loi Dupanloup, 12 juillet 1875, pour l'enseignement supérieur.
- Cons. const., déc., nº 84-184 DC, 29 décembre 1984, *Loi de finances pour 1985.*
- Tanneguy Larzul, « L'enseignement libre : liberté de l'enseignement – liberté d'enseigner », Titre VII [en ligne], nº 12, *L'enseignement*, avril 2024.
- Stéphanie Hennette Vauchez, « Un éléphant dans la pièce ? La liberté de l'enseignement comme régime d'accommodement de la religion », Titre VII [en ligne], nº 12, *L'enseignement*, avril 2024.

1. Les fondements de la liberté de l'enseignement

La liberté de l'enseignement ne doit pas être confondue avec le droit à l'enseignement ou le droit à l'instruction. La liberté de l'enseignement concerne les enseignants tandis que le droit à l'enseignement concerne les élèves et les étudiants.

1.1. Les sources législatives de la liberté de l'enseignement

La liberté de l'enseignement a tout d'abord été consacrée législativement :

- Loi Guizot du 28 juin 1833 pour l'enseignement primaire.
- Loi Falloux du 15 mars 1850 pour l'enseignement secondaire.
- Loi Dupanloup du 12 juillet 1875 pour l'enseignement supérieur.
- Loi du 18 mars 1880 relative à la liberté de l'enseignement supérieur.

1.2. La liberté de l'enseignement : un principe fondamental reconnu par les lois de la République

Le Conseil constitutionnel a reconnu la liberté de l'enseignement comme un principe fondamental reconnu par les lois de la République en se fondant sur la liberté d'opinion consacrée à l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et l'article 91 de la loi de finances du 31 mars 1931 qui énonce : *« la liberté d'enseignement, qui est un des principes fondamentaux de la République »*.

> → Cons. const., déc. nº 77-87 DC, 23 novembre 1977, *Loi complémentaire à la loi nº 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée par la loi nº 71-400 du 1er juin 1971 et relative à la liberté de l'enseignement.*
>
> → Cons. const., déc. nº 84-184 DC, 29 décembre 1984, *Loi de finances pour 1985.*

Reconnaissance de la liberté de l'enseignement au profit des établissements du supérieur.

> *« Considérant que le principe de liberté de l'enseignement constitue l'un des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, réaffirmés par le préambule de la Constitution de 1946 et auxquels la Constitution de 1958 a conféré valeur constitutionnelle ; qu'en ce qui concerne l'enseignement supérieur, il trouve son fondement dans les lois susvisées des 12 juillet 1875 et 18 mars 1880 »* (Cons. const., déc. n° 99-414 DC, 8 juillet 1999, *Loi d'orientation agricole*).

Cette consécration est le fruit d'une longue maturation. En effet, dès 1793, le décret *Bouquier* énonçait la liberté de l'enseignement. Tous les citoyens étaient libres d'enseigner à condition de produire un certificat de civisme et de bonnes mœurs.

La Constitution de 1848 réaffirme cette liberté dans son article 9 :

> *« L'enseignement est libre. La liberté d'enseignement s'exerce selon les conditions de capacité et de moralité déterminées par les lois, et sous la surveillance de l'État. Cette surveillance s'étend à tous les établissements d'éducation et d'enseignement, sans aucune exception. »*

Enfin, la loi *Debré* n° 59-1557 du 31 décembre 1959, sur les rapports entre l'État et les établissements d'enseignement privés, a sanctuarisé la coexistence des établissement publics et privés et réaffirmé la participation de ces derniers à la mission de service public d'éducation.

Actualité jurisprudentielle. - Le contrôle de l'État sur les établissements privés ne peut pas reposer sur des critères imprécis

La liberté de l'enseignement n'interdit pas à l'État de contrôler les établissements privés, notamment afin de protéger les élèves ; encore faut-il que les pouvoirs de l'administration soient suffisamment encadrés par la loi.

Dans cette affaire en Alsace-Moselle, des dispositions issues du droit local datant de 1873 subordonnaient le recrutement d'un enseignant dans une école privée à une autorisation préalable de l'administration. Le chef d'établissement devait notamment produire des éléments relatifs à l'âge, aux « bonne vie et mœurs » et à l'aptitude du candidat. L'administration pouvait également assortir son autorisation de conditions relatives aux matières enseignées et aux classes confiées.

Le Conseil constitutionnel admet qu'un contrôle du recrutement des enseignants puisse poursuivre la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant et la préservation de l'ordre public. Il censure toutefois ce dispositif : les critères relatifs à l'âge et aux « bonne vie et mœurs » étaient insuffisamment précis, la liste des motifs de refus n'était pas limitative et les conditions susceptibles d'être imposées par l'administration n'étaient pas définies.

Le dispositif privait ainsi de garanties légales la liberté de l'enseignement.

⟶ Cons. const., déc. n° 2025-1145 QPC, 2 juillet 2025, *École Mathias Grünewald et autre*.

L'abrogation avait été différée au 1er juillet 2026 afin d'éviter la disparition immédiate de tout contrôle administratif du recrutement dans les établissements concernés ; elle est donc désormais effective.

À retenir. - La liberté de l'enseignement n'exclut pas le contrôle de l'État, mais elle interdit que l'administration dispose d'un pouvoir discrétionnaire insuffisamment encadré sur le recrutement et le fonctionnement des établissements privés.

2. Contenu de la liberté de l'enseignement

2.1. La liberté de créer des établissements d'enseignement privé

La liberté de l'enseignement implique l'existence de l'enseignement privé et la possibilité de créer des écoles privées et la faculté pour le législateur de prévoir l'octroi d'une aide des collectivités publiques et de l'État à l'enseignement privé.

> → Loi n° 59-1557, 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'État et les établissements d'enseignement privés.

→ Loi n° 77-1285, 25 novembre 1977, renforce ce principe de subvention avec un contrôle strict de l'État.

→ Cons. const., déc. n° 93-329 DC, 13 janvier 1994, *Loi relative aux conditions de l'aide aux investissements des établissements d'enseignement privés par les collectivités territoriales.*

→ Cons. const., déc., n° 99-414 DC, 8 juillet 1999, *Loi d'orientation agricole.*

Cette possibilité de création d'établissement d'enseignement privé n'est pas nouvelle.

→ Art. 2 de la loi Goblet du 30 octobre 1886 : *« Les établissements d'enseignement primaire de tout ordre peuvent être publics, c'est-à-dire fondés et entretenus par l'État, les départements ou les communes, ou privés, c'est-à-dire fondés et entretenus par des particuliers ou des associations. »*

La liberté de créer des établissements d'enseignement privé est toutefois encadrée par la loi : déclaration préalable d'ouverture au recteur d'académie qui peut s'opposer, contrôle approfondi du contenu du dossier…

Une fois l'établissement ouvert, ce dernier est contrôlé par l'État : obligation de respecter la liberté de conscience des élèves et le caractère facultatif de l'enseignement religieux sous peine d'annulation du contrat avec l'État et perte des financements publics.

→ Art L. 613-1 du Code de l'éducation : obligation de se conformer et de suivre les programmes de l'enseignement public.

La liberté d'enseignement est soumise à un régime de police administrative afin de préserver l'ordre public et les exigences d'intérêt général propre à l'enseignement (capacité à enseigner ou à diriger un établissement).

POUR ALLER PLUS LOIN

Cons. const., déc., n° 2016-745, 26 janvier 2017, Loi relative à l'égalité et à la citoyenneté : « En habilitant le Gouvernement à remplacer les régimes déclaratifs par un régime d'autorisation d'ouverture d'un établissement privé d'enseignement scolaire, le législateur a précisément défini le domaine d'intervention des mesures qu'il autorise le Gouvernement à prendre par ordonnance. En revanche, eu égard à l'atteinte susceptible d'être portée à la liberté de l'enseignement par la mise en place d'un régime d'autorisation administrative, en confiant au Gouvernement, sans autre indication, le soin de préciser "les motifs pour lesquels les autorités compétentes peuvent refuser d'autoriser l'autorisation" de tels établissements, le législateur a insuffisamment précisé les finalités des mesures d'être susceptibles d'être prises par voie d'ordonnance. »

2.1. L'encadrement des établissements privés hors contrat

Création d'un régime de fermeture administrative pour les écoles non déclarées ou qui n'ont pas remédié aux défaillances constatées par l'administration.

→ Loi n° 2021-1109, 24 août 2021, confortant le respect des principes de la République.

La loi prévoit une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende pour un directeur d'établissement privé ou son représentant accueillant des classes hors contrat ou n'ayant pas pris de mesure pour remédier aux manquements relevés.

Une mesure de fermeture temporaire ou définitive peut être adoptée pour assurer la protection de la santé, de la sécurité, du droit à l'éducation des élèves et de prévenir les risques de troubles à l'ordre public.

Les parents reçoivent aussi une mise en demeure d'inscrire leurs enfants dans un autre établissement.

→ CE, 20 mars 2023, *Association École en couleurs*, n° 456984.

Un nouveau régime législatif a été mis en place pour encadrer le régime d'ouverture et de contrôle des établissements d'enseignement scolaire privés hors contrat avec de nombreuses conditions concernant la

personne qui ouvre l'école et son directeur. Cette loi a instauré la possibilité pour l'État de s'opposer à l'ouverture de l'établissement dans l'intérêt de l'ordre public ou de la protection de l'enfance et de la jeunesse.

> → Loi n° 2018-266, 13 avril 2018, visant à simplifier et mieux encadrer le régime d'ouverture et de contrôle des établissements privés hors contrat.

Les établissements privés doivent transmettre chaque année au recteur d'académie la liste de leurs enseignants. À défaut, une peine d'emprisonnement et une amende peuvent être prononcées.

Actualité jurisprudentielle. - La liberté pédagogique des établissements hors contrat ne fait pas obstacle au contrôle du droit à l'instruction

Les établissements privés hors contrat disposent, en vertu des articles L. 442-2 et L. 442-3 du Code de l'éducation, d'une liberté dans le choix de leurs méthodes et supports pédagogiques. L'administration ne peut donc leur imposer une pédagogie déterminée ni apprécier la pertinence de leur projet éducatif.

Cette liberté trouve cependant sa limite dans les obligations fondamentales auxquelles ces établissements demeurent soumis. Le contrôle de l'État peut notamment porter sur l'instruction obligatoire et l'acquisition progressive par les élèves du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, ainsi que sur le respect de l'ordre public, la protection de l'enfance et la prévention sanitaire et sociale.

Dans cette affaire, le préfet de l'Ardèche avait ordonné la fermeture d'une école privée hors contrat ouverte depuis 2017 et mettant en œuvre la pédagogie *Steiner-Waldorf*. Une première inspection réalisée en avril 2024 avait révélé des insuffisances dans l'enseignement dispensé. Après une mise en demeure adressée à l'établissement et plusieurs mesures correctrices mises en avant par celui-ci, une seconde inspection avait été réalisée en mars 2025. Les contrôles avaient notamment fait apparaître des insuffisances concernant plusieurs domaines du socle commun : maîtrise des langages, méthodes et outils pour apprendre, formation de la personne et du citoyen ainsi que systèmes naturels et techniques.

Le Conseil d'État vérifie concrètement si les mesures correctrices prises par l'établissement après la mise en demeure ont effectivement permis de faire disparaître les manquements relevés lors du premier contrôle. En l'espèce, malgré plusieurs adaptations pédagogiques, la seconde inspection avait encore mis en évidence des insuffisances dans plusieurs domaines du socle commun. Le juge en déduit que les manquements persistaient. Il valide donc la fermeture, en rappelant qu'une telle mesure de police ne peut intervenir qu'après une mise en demeure préalable et à la condition que l'établissement n'ait pas remédié, de manière suffisante, aux carences constatées.

→ CE, ord., 21 novembre 2025, *Établissement privé hors contrat L' Arrosoir et autres*, n° 509481

À retenir. - La liberté de l'enseignement protège le choix de la pédagogie, non le droit de s'affranchir des objectifs de l'instruction obligatoire. L'État ne contrôle donc pas les méthodes pédagogiques en elles-mêmes, mais peut vérifier qu'elles permettent effectivement l'acquisition progressive du socle commun. En cas de manquements persistants après mise en demeure, cette conciliation peut aller jusqu'à la fermeture administrative de l'établissement.

2.3. Le financement public des établissements privés

Le financement public de l'enseignement privé a pu alimenter de nombreux débats et polémiques. Cependant la suppression de l'aide publique prévue par la loi conduirait à la disparition des établissements privés et porterait atteinte à la liberté de l'enseignement.

- Lorsque les établissements privés ne participent pas à la politique nationale de l'éducation, ils peuvent bénéficier d'aides publiques uniquement à partir du secondaire et sans que cette subvention n'excède le dixième des dépenses annuelles de l'établissement.
- Lorsque l'établissement privé participe au service public en étant sous contrat, le législateur peut prévoir une participation des collectivités publiques pour financer cet établissement.

> → Cons. const., déc. n° 2009-591 DC, 22 octobre 2009, *Loi tendant à garantir la parité de financement entre les écoles élémentaires publiques et privées sous contrat d'association*

lorsqu'elles accueillent des élèves scolarisés hors de leur commune de résidence : *« Il résulte de la liberté de l'enseignement que le principe de laïcité ne fait pas obstacle à la possibilité pour le législateur de prévoir, sous réserve de fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels, la participation des collectivités publiques au financement du fonctionnement des établissements d'enseignement privés sous contrat d'association selon la nature et l'importance de leur contribution à l'accomplissement de missions d'enseignement. »*

Il existe deux types de contrats concernant les établissements privés :

- Le contrat simple : pour les établissements d'enseignement privé du premier degré. Les maîtres agréés sont rémunérés par l'État. Les collectivités territoriales peuvent participer au financement de ces établissements. L'enseignement des matières de base est organisé par référence aux programmes et aux règles générales relatives aux horaires de l'enseignement public.

- Le contrat d'association : les établissements d'enseignement privé du premier et second degré peuvent demander un contrat d'association sous certaines conditions. Pour accepter ce contrat, l'État vérifie l'existence d'un besoin scolaire reconnu. Les enseignants sont alors soit des enseignants fonctionnaires de l'État soit des enseignants qui deviennent agents publics par contrat avec l'État. Le contrat d'association permet ainsi une insertion dans le service public et un contrôle de l'État concernant les modalités de l'enseignement. Ce contrat d'association respecte le caractère propre de l'établissement (liberté de conscience des enseignants et des élèves) tout en pouvant le limiter.

  → Cons. const., déc. n° 84-185 DC, 18 janvier 1985, *Loi modifiant et complétant la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 et portant dispositions diverses relatives aux rapports entre l'État et les collectivités territoriales : « La reconnaissance du caractère propre des établissements d'enseignement privés n'est que la mise en œuvre du principe de la liberté d'enseignement, qui a valeur constitutionnelle. »*

  → CE, 8/3 SSR, 18 octobre 2000, *Association Promouvoir*, n° 213303 : l'obligation d'un cours d'éducation sexuelle ne porte pas atteinte au caractère propre des écoles d'enseignement catholique.

Actualité législative. - Face au développement rapide de l'enseignement supérieur privé, le législateur envisage un renforcement du contrôle des établissements et de la protection des étudiants Le projet de loi relatif à la *régulation de l'enseignement supérieur privé*, adopté par le Sénat en première lecture le 1er juin 2026, poursuit un double objectif : renforcer le contrôle des établissements et améliorer l'information et la protection contractuelle des étudiants.

Le texte prévoit notamment :

-la création d'un régime commun d'ouverture applicable aux établissements et cours privés d'enseignement supérieur ;

-la mise en place de deux régimes de reconnaissance par l'État, afin de mieux distinguer les établissements bénéficiant d'une reconnaissance publique des autres opérateurs ;

-un renforcement de l'information préalable de l'étudiant sur la nature de la formation, la valeur du diplôme ou du titre préparé et sa reconnaissance par l'État ;

-la création d'un véritable droit de résiliation du contrat d'inscription : l'étudiant ou son représentant légal pourrait résilier le contrat sans avoir à justifier d'un motif jusqu'à trente jours avant le début de la formation. Les sommes versées devraient alors être remboursées dans un délai maximal de trente jours, sous réserve d'un montant limité correspondant aux seuls actes de gestion nécessaires à l'inscription ;

-l'interdiction de certaines clauses imposant le versement de sommes pouvant s'apparenter à des frais de réservation ;

-un encadrement de la possibilité pour l'étudiant de résilier son inscription jusqu'à trois mois après le début de la formation, dans les conditions prévues par le texte.

→ Projet de loi relatif à la régulation de l'enseignement supérieur privé, texte adopté par le Sénat le 1er juin 2026, n° 126.

3. La liberté des enseignants

La liberté de l'enseignement implique la neutralité de l'enseignement. En effet, elle ne doit pas s'exprimer au détriment de la liberté de conscience des élèves ou de leurs parents.

→ Art. 2 du Protocole n° 1 CESDH.

De cette obligation de neutralité découle le fait que les enseignants doivent veiller à ce que leur enseignement soit délivré de manière objective, critique, pluraliste et tolérante sans bousculer la conviction des élèves.

→ T. confl., 2 juin 1908, *Girodet c/ Morizot*, J-1908-TC-634.

→ CEDH, 13 septembre 2011, *Dojan et a. c. Allemagne*, n° 319/08, 2455/08, 7908/10 et a.

Selon que l'enseignement soit privé ou public et selon le cycle, la liberté de l'enseignement possède différentes nuances.

3.1. La liberté de l'enseignement privé

Les enseignants des établissements privés sous contrat d'association sont tenus de respecter le caractère propre de l'établissement. Cette obligation leur impose un devoir de réserve qui ne porte pas atteinte à la liberté de conscience des maîtres, liberté à valeur constitutionnelle.

→ Art. 1er de la loi du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'État et les établissements privés.

→ Cons. const., déc. n° 84-185 DC, 18 janvier 1985, *Loi modifiant et complétant la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 et portant dispositions diverses relatives aux rapports entre l'État et les collectivités territoriales.*

Cependant, même si l'établissement conserve son caractère propre, il doit *« donner cet enseignement dans le respect total de la liberté de conscience »*. De plus, *« dans les classes faisant l'objet du contrat, l'enseignement est dispensé selon les règles et programmes de l'enseignement public »*.

→ Art. L. 442-1 du Code de l'éducation.

L'État rémunère donc les professeurs des établissements privés, mais ces derniers ont l'obligation de suivre les programmes de l'enseignement public en préservant le caractère propre de l'établissement.

L'instruction religieuse peut être enseignée dans les établissements privés, mais elle a un caractère facultatif et elle doit être donnée en dehors des heures de cours.

→ Art. L. 141-3 et R 141-5 du Code de l'éducation.

3.2. La liberté des enseignants du primaire et du secondaire

Au sein de l'école publique, la liberté de l'enseignement s'apparente à la liberté pédagogique, soit la manière dont l'enseignement est délivré. Cependant, cette liberté s'exerce dans le respect des programmes et des instructions émanant du ministère de l'éducation nationale.

→ Art L. 912-1-1 du Code de l'éducation.

La liberté d'expression des enseignants du primaire et du secondaire dans les établissements publics peut toutefois être limitée : ils ne doivent pas mettre en œuvre de propagande.

3.3. La liberté des enseignants du supérieur

L'indépendance des professeurs d'université publique est un principe à valeur constitutionnelle qui se déduit de l'article 11 de la Déclaration de 1789 et des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République.

→ Cons. const., déc. n° 83-165 DC, 20 janvier 1984, *Loi relative à l'enseignement supérieur.*

→ Cons. const., déc. n° 94-355 DC, 10 janvier 1995, *Loi organique modifiant l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 relative au statut de la magistrature.*

Cette indépendance des enseignants-chercheurs a été inscrite en toutes lettres dans le Code de l'éducation :

- Art. L. 123-9 : impose aux établissements d'enseignement supérieur de leur assurer les moyens d'exercer leur activité d'enseignement et de recherche dans les conditions d'indépendance et de sérénité indispensable à la réflexion et à la création intellectuelle.
- Art. L. 141-6 : garantit la possibilité d'un libre développement scientifique, créateur et critique.
- Art. L. 952-2 : indépendance limitée par la tolérance et l'objectivité : respecter les convictions d'autrui et adopter une démarche reposant sur des éléments vérifiables.

Les libertés académiques sont composées de trois branches :

- La liberté de recherche.
- La liberté d'enseignement.
- La liberté d'expression.

En droit européen, la liberté des universitaires est envisagée sous l'angle de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme.

→ CEDH, 27 mai 2014, *Mustafa Erdogan et a. c. Turquie*, n° 346/04 et 39779/04.

La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne la mentionne explicitement dans son article 13 :

« Les arts et la recherche scientifique sont libres. La liberté académique est respectée. »

POUR S'ENTRAÎNER

Argumentation juridique : Soutenez que la liberté d'enseignement est un droit fondamental.

Il convient tout d'abord de distinguer la liberté d'enseignement du droit à l'enseignement du droit à l'instruction. Ce dernier concerne les élèves et les étudiants tandis que le premier s'adresse aux enseignants pour leur garantir une liberté pédagogique dans leur manière de transmettre le savoir.

La liberté de l'enseignement recouvre aussi un autre droit qui est celui du libre choix pour les parents de recourir à tel ou tel mode de scolarisation pour leurs enfants, dans l'enseignement public ou privé sous contrat ou non avec l'État.

Cette possibilité d'un enseignement privé, en partie financé par les collectivités et l'État a pu cristalliser de nombreux débats au regard du principe de laïcité.

Problématique et annonce du plan : Cependant, la reconnaissance de la liberté d'enseignement en tant que droit fondamental **(I)** a permis d'encadrer ces différents types d'enseignements **(II)**.

I. La reconnaissance de la liberté d'enseignement

A. Le fruit d'une reconnaissance textuelle et jurisprudentielle

La liberté de l'enseignement a tout d'abord été consacrée par différents textes législatifs ancrés dans la tradition républicaine (loi Guizot du 28 juin 1833 pour l'enseignement primaire, loi Falloux du 15 mars 1850 pour l'enseignement secondaire et loi Dupanloup du 12 juillet 1875 pour l'enseignement supérieur).

Par la suite, le Conseil constitutionnel a érigé la liberté d'enseignement au rang de principe fondamental reconnu par les lois de la République en se fondant sur la liberté d'opinion de l'article 10 de la Déclaration de 1789 et l'article 91 de la loi de finances du 31 mars 1931 qui proclame : *« La liberté d'enseignement, qui est un des principes fondamentaux de la République. »* (Cons. const., déc. n° 77-87 DC, 23 novembre 1977, *Loi complémentaire à la loi* n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée par la loi n° 71-400 du 1er juin 1971 et relative à la liberté de l'enseignement, Cons. const., déc. n° 84-184 DC, 29 décembre 1984, *Loi de finances pour 1985*).

Cette liberté de l'enseignement a aussi été reconnue au profit des établissements du supérieur (Cons. const., déc. n° 99-414 DC, 8 juillet 1999, *Loi d'orientation agricole).*

B. La création et le financement d'établissements privés corollaires de la liberté d'enseignement

La liberté d'enseignement implique la possibilité de créer des établissements privés. Le législateur peut prévoir les modalités de leur financement (Loi n° 59-1557, 31 décembre 1959, *Debré*, accepte le principe d'une subvention de l'école privée ; Loi n° 77-1285, 25 novembre 1977, renforce ce principe de subvention avec un contrôle strict de l'État). Ce financement n'est pas sans contrepartie, car les établissements privés sont soumis à un strict contrôle de l'État.

Le financement public de l'enseignement privé a pu alimenter de nombreux débats et polémiques. Cependant la suppression de l'aide publique prévue par la loi conduirait à la disparition des établissements privés et porterait atteinte à la liberté de l'enseignement.

Deux types de contrats permettent d'encadrer les relations entre l'État et les établissements privés : le contrat simple et le contrat d'association qui emportent différentes conséquences.

II. Les différents degrés de la liberté d'enseignement

A. L'encadrement et le contrôle des niveaux primaires et secondaires

Que ce soit dans les établissements publics ou privés du primaire ou du secondaire, la règle est celle de la neutralité de l'enseignement.

Les enseignants des établissements privés sous contrat d'association sont tenus de respecter le caractère propre de l'établissement.

Tout comme les établissements publics, les enseignants des établissements privés doivent suivre les règle et programmes de l'enseignement public (art. L. 442-1 du Code de l'éducation).

L'instruction religieuse peut être enseignée dans les établissements privés, mais elle a un caractère facultatif et elle doit être donnée en dehors des heures de cours. (art. L. 141-3 et R. 141-5 du Code de l'éducation).

Au sein de l'école publique, la liberté de l'enseignement s'apparente à la liberté pédagogique, soit la manière dont l'enseignement est délivré. Cependant, cette liberté s'exerce dans le respect des programmes et instructions du ministère chargé de l'éducation nationale.

B. Une liberté d'enseignement universitaire totale

L'enseignement universitaire bénéficie d'une plus grande liberté par rapport au primaire et au secondaire. Les libertés académiques y sont plus vastes et composées de trois branches : liberté de recherche / liberté d'enseignement / liberté d'expression.

De plus, les professeurs des universités bénéficient d'une indépendance reconnue comme principe à valeur constitutionnelle (Cons. const., déc. n° 83-165 DC, 20 janvier 1984, *Loi relative à l'enseignement supérieur*, Cons. const., déc. n° 94-355 DC, 10 janvier 1995).

Cette indépendance des enseignants-chercheurs a été codifiée dans le Code de l'éducation (art. L. 123-9, L. 141-6 et L. 952-2).

En conclusion, la liberté de l'enseignement est bien un droit fondamental dont la primauté et le respect sont assurés par la possibilité de créer des établissement publics et privés. Selon le niveau d'enseignement, les enseignants comme les élèves ou les étudiants disposent d'une liberté croissante.

Fiche nº 42 - LE DROIT À DES ÉLECTIONS LIBRES

POINTS CLÉS

- Garde-fou des démocraties.
- Standard européen.
- Droit de vote et d'éligibilité.
- Conditions d'exercice du droit de vote.
- Suffrage universel, égal, libre et secret.

PRINCIPALES RÉFÉRENCES

- Code électoral.
- Art. 2 et 3 de la Constitution.
- Art. 3 du protocole nº 1 CESDH.
- Art. 21 DUDH.
- Art. 25 PIDCP.

1. Les sources du droit à des élections libres

Le droit à des élections libres trouve ses origines dans des sources supranationales et nationales. La plupart des sources relatives à ce droit sont formulées de manière ambivalente ou duale.

Les droits de participer à la vie démocratique de son pays sont à la fois des droits subjectifs et des principes objectifs essentiels à la démocratie. Ils sont la pierre angulaire de la relation entre gouvernants et gouvernés en démocratie.

1.1. Les sources supranationales

La première mention du droit à des élections libres en droit international se trouve à l'article 21 de la Déclaration universelle de 1948 :

> *« 1. Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis. 2. Toute personne a droit à accéder, dans des conditions d'égalité, aux fonctions publiques de son pays. 3. La volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics ; cette volonté doit s'exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage universel égal et au vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote. »*

Cet article sera repris et complété dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, article 25 :

> *« Tout citoyen a le droit et la possibilité, sans aucune des discriminations visées à l'article 2 et sans restriction déraisonnable : de prendre part à la direction des affaires publiques, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis ; de voter et d'être élu, au cours d'élections périodiques, honnêtes, au suffrage universel et égal et au scrutin secret, assurant l'expression libre de la volonté des électeurs ; d'accéder, dans des conditions générales d'égalité, aux fonctions publiques de son pays. »*

L'article 3 Protocole nº 1 à la Convention européenne des droits de l'homme consacre quant à lui le droit à des élections régulières, libres et justes :

« Les Hautes Parties contractantes s'engagent à organiser, à des intervalles raisonnables, des élections libres au scrutin secret, dans les conditions qui assurent la libre expression de l'opinion du peuple sur le choix du corps législatif. »

C'est une reconnaissance au rabais, car, dans cette version, le droit à des élections libres y est limité aux élections du corps législatif (et plus précisément à la chambre basse en cas de bicamérisme). Cela n'a pas empêché la Cour européenne des droits de l'homme d'y déceler le principe caractéristique d'un régime véritablement démocratique.

C'est la raison pour laquelle l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe conditionne l'adhésion d'un nouvel État à l'organisation au respect préalable du droit à des élections libres et à l'organisation d'élections tel qu'inscrit à l'article 3 du Protocole n° 1.

Du côté de l'Union européenne, la Charte des droits fondamentaux consacre le droit de vote et d'éligibilité aux élections du Parlement européen dans son article 30 et aux élections municipales à l'article 40.

1.2. Les sources nationales

Les premiers articles de la Constitution de 1958 font implicitement référence au droit à des élections libres en France :

→ Art. 2 alinéa 5 : *« Son principe est : gouvernement du peuple, par le peuple pour le peuple. »*

→ Art.3 : *« La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution. Il est toujours universel, égal et secret. Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux français majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques. »*

La Constitution renvoie ainsi au Code électoral qui encadre la tenue des différentes élections françaises, l'exercice du droit de vote, les caractères du suffrage ainsi que les conditions de jouissance et d'exercice du droit à des élections libres.

2. Les éléments du droit à des élections libres

2.1. Le volet passif du droit à des élections libres : le droit de vote

Le droit de vote permet aux citoyens d'exprimer leurs opinions au moment du scrutin pour élire des représentants ou répondre à un référendum.

En France, le vote est un droit, il n'est pas obligatoire contrairement à d'autres pays européens : Belgique, Grèce, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Suisse. Il joue un rôle essentiel dans une démocratie.

Comme énoncé dans la Constitution, la fixation des règles concernant les droits civiques relève du domaine de la loi (art. 34 de la Constitution).

Toutefois, le droit de vote n'est pas absolu et peut faire l'objet de restrictions.

La Cour européenne a ainsi jugé que ce dernier n'impose pas de garantir le droit de vote aux élections législatives pour les électeurs expatriés, ni pour les détenus, à condition d'avoir une raison légitime dans chaque situation.

→ CEDH, 18 janvier 2011, *Scoppola c. Italie (n° 3),* n° 126/05.

2.2. Le volet actif du droit à des élections libres : le droit d'éligibilité

Le droit à des élections libres garantit le droit de toute personne de pouvoir briguer un mandat électoral et la garantie de pouvoir exercer son mandat une fois élue. Il s'agit du « pouvoir souverain de l'électorat ».

→ CEDH, 11 juin 2002, *Selim Sadak c. Turquie*, n° 25144/94, 26149/95 à 26154/95, 27100/95 et 27101/95.

Il s'agit de la possibilité de présenter sa candidature devant le corps électoral et de pouvoir exercer le mandat une fois élu. La protection des mandats passe essentiellement par la mise en place d'immunités et de privilèges juridictionnels à l'instar de celui dont jouit le président de la République (art. 67 de la Constitution et loi organique du 24 novembre 2014).

L'éligibilité peut être également restreinte pour des motifs légitimes et non discriminatoires et une inéligibilité à vie est disproportionnée même si le motif qui la fonde est très sérieux.

→ CEDH, 6 janvier 2011, *Paksas c. Lituanie*, n° 34932/04.

En France, les inéligibilités ne peuvent découler que des dispositions expresses d'une loi. L'article L. 133 du Code électoral liste 19 catégories de personnes qui ne peuvent pas se présenter aux élections législatives pour éviter les conflits d'intérêt et la corruption (magistrats, recteurs, officiers des armées, inspecteurs d'académie…).

Actualité jurisprudentielle. - Le droit d'être élu protège également le maintien dans le mandat

L'article 3 du Protocole n° 1 de la CESDH ne protège pas seulement la possibilité de se présenter à une élection : il garantit également l'effectivité du choix exprimé par les électeurs et, par conséquent, l'exercice du mandat obtenu.

En l'espèce, en 2016 un député ukrainien avait quitté le groupe parlementaire constitué par le parti sur la liste duquel il avait été élu. Son parti avait alors obtenu la cessation anticipée de son mandat. La Cour européenne relève notamment qu'une telle conséquence était difficilement prévisible et que le mécanisme avait été appliqué de manière sélective : seuls deux des dix députés ayant quitté le groupe avaient perdu leur mandat.

La Cour conclut à une violation de l'article 3 du Protocole n° 1. Permettre au parti politique de mettre fin discrétionnairement au mandat d'un élu revient à faire prévaloir la volonté du parti sur celle exprimée par le corps électoral.

⟶ CEDH, 10 juillet 2025, *Tomenko c. Ukraine*, n° 79340/16.

À retenir. - Le mandat électif ne constitue pas seulement un droit individuel de l'élu. Sa protection garantit également le respect du choix des électeurs, qui ne peut être remis en cause arbitrairement après le scrutin.

2.3. La liberté des partis politiques

La liberté politique implique la libre constitution des partis politiques prévus à l'article 4 de la Constitution. Juridiquement, les partis politiques relèvent de la loi du 1er juillet 1901 concernant la liberté d'association : leur création et leurs activités sont donc libres.

Avec les partis politiques, la liberté d'association se trouve « sublimée » par une fonction constitutionnelle qui participe à la démocratie avec trois fonctions principales :

- Une fonction d'intermédiaire entre le peuple et le pouvoir ;
- Une fonction d'exercice du pouvoir politique ;
- Une fonction de sélection du personnel politique.

Le financement des partis est encadré afin d'éviter des partis instrumentalisés par les forces économiques et assurer l'égalité entre les candidats aux élections.

La France peut maintenir l'interdiction de financement d'un parti par une personne morale étrangère.

→ CEDH, 7 septembre 2007, *Parti national basque – Organisation régionale d'Ipparalde c. France*, n° 71251/01 : le parti indépendantiste basque espagnol ne peut pas financer sa branche française et ce afin de protéger la souveraineté française.

3. Les conditions de jouissance et d'exercice du droit à des élections libres

3.1. La nationalité

Le droit à des élections libres est assorti du droit de vote pour les nationaux. En France, le droit de vote fait partie des droits attachés à la qualité de français selon les articles 22 du Code civil et 80 du Code de la nationalité.

Depuis le Traité de Maastricht du 7 février 1992, les citoyens de l'Union européenne disposent d'un droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales.

→ Art. 88-3 de la Constitution de 1958.

3.2. La majorité électorale

La majorité électorale a été abaissée à 18 ans avec la loi du 5 juillet 1974, n° 74-631.

Toute personne jouissant de ses droits civiques peut s'inscrire sur des listes électorales.

Pour le droit de vote, la majorité doit être acquise le jour avant le scrutin et non pas le jour même. Pour l'éligibilité, la majorité s'apprécie au jour de l'élection et non du dépôt de la candidature. Depuis la loi du 10 novembre 1997, n° 97-1027, les majeurs sont automatiquement inscrits dans la commune où ils résident le jour de leur anniversaire.

3.3. La résidence

Pour pouvoir s'inscrire sur les listes électorales, une résidence effective d'au moins 6 mois est requise. La résidence est le lieu où la personne est juridiquement rattachée avec une présence effective et continue de cette dernière ce qui exclut les résidences secondaires.

Les expatriés peuvent voter pour les différentes élections françaises depuis l'étranger à condition d'être inscrits sur la liste électorale consulaire.

3.4. L'absence de déchéance des droits politiques

La radiation de la liste électorale découle bien souvent de la perte d'une des conditions de la qualité d'électeur (la résidence bien souvent) ou de la suite d'une décision de justice, soit à titre principal, soit comme conséquence d'une sanction pénale.

Depuis l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal en 1994, la déchéance des droits civiques n'est plus automatique. Elle est devenue une peine spécifique prononcée à titre accessoire par le juge pour un certain nombre de délits et de crimes :

- Article 222-45 du Code pénal : atteinte à la personne humaine.
- Article 312-13 du Code pénal : extorsion ou chantage.
- Article 434-44 du Code pénal : faux témoignage.
- Article 434-44 du Code pénal : non-dénonciation de mauvais traitements sur mineurs.
- Article 442-11 du Code pénal : fabrication de fausse monnaie…

L'article 7 du Code électoral prévoit également une liste d'infractions pour lesquelles la personne condamnée ne peut être inscrite sur une liste électorale pendant un délai de 5 ans.

3.5. L'inscription sur les listes électorales

En principe, l'inscription sur les listes électorales est obligatoire.

→ Art. 9 du Code électoral.

Cette inscription sur les listes électorales détermine la qualité d'électeur et permet de contrôler la régularité des listes électorales. Elle nécessite un lien avec la commune.

Les inscriptions multiples sont prohibées par les articles L. 10 et L. 86 du Code électoral.

La liste électorale est permanente et elle est révisée chaque année par une commission administrative composée du maire, d'un délégué du président du Tribunal judiciaire et d'un délégué du préfet.

3.6. Les conditions renforcées d'éligibilité

Dans certains cas, il existe des conditions renforcées d'éligibilité : il ne suffit pas d'être électeur pour pouvoir se présenter à certaines élections.

Pour se présenter à une élection municipale, il est nécessaire d'être résident de la commune. Pour les élections sénatoriales, les candidats aux élections doivent avoir au minimum 23 ans, tandis que cette limite d'âge n'existe pas pour les présidentielles ou législatives.

Il existe aussi des incompatibilités professionnelles ou statutaires prévues à l'article LO 133 du Code électoral pour les élections parlementaires et L. 231 du Code électoral pour les élections municipales. Ces incompatibilités sont justifiées par la nécessité de neutralité de l'État, l'égalité entre les candidats et la protection de l'électoral contre toute forme d'influence.

→ CEDH, 1er juillet 1997, *Gitonas c. Grèce*, no 8747/91, 19376/92, 19379/92 et al.

→ CEDH, 2 septembre 1998, *Ahmed et a. c. Royaume-Uni*, no 22954/93.

Actualité. - Le scrutin de liste paritaire est désormais généralisé à l'ensemble des communes

La loi du 21 mai 2025 a profondément modifié les élections municipales dans les communes de moins de 1 000 habitants. Depuis les élections municipales de mars 2026, leurs conseillers municipaux ne sont plus élus au scrutin majoritaire avec possibilité de candidatures individuelles et de panachage, mais selon un scrutin de liste à deux tours avec prime majoritaire, proche de celui applicable aux communes de 1 000 habitants et plus. Les listes doivent en outre être composées alternativement de candidats de chaque sexe. Concrètement, la parité devient également obligatoire pour les communes de moins de 1 000 habitants.

Le Conseil constitutionnel a validé cette réforme. Il rappelle que le droit d'éligibilité résulte de l'article 6 de la Déclaration de 1789, tandis que la liberté de l'électeur et le pluralisme doivent être conciliés avec l'objectif d'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux, prévu à l'article 1er de la Constitution.

La suppression des candidatures isolées et du panachage constitue ainsi une restriction à la liberté de choix des candidats et des électeurs. Elle n'est toutefois pas disproportionnée compte tenu de l'objectif de parité poursuivi et des adaptations prévues pour les petites communes, notamment la possibilité de présenter des listes comportant jusqu'à deux candidats de moins que l'effectif théorique du conseil municipal.

→ Cons. const., déc. n° 2025-883 DC, 15 mai 2025, *Loi visant à harmoniser le mode de scrutin aux élections municipales afin de garantir la vitalité démocratique, la cohésion municipale et la parité*.

À retenir. - Le droit d'éligibilité et la liberté de l'électeur ne font pas obstacle à l'instauration de mécanismes contraignants de parité. Le législateur doit toutefois assurer une conciliation qui ne soit pas manifestement déséquilibrée avec le pluralisme et la possibilité effective de présenter des candidatures.

4. Les caractères du suffrage

4.1. L'universalité du suffrage

L'universalité du suffrage n'a pas été acquise immédiatement. De 1789 à 1848, le suffrage était censitaire : il était réservé à ceux qui payaient un certain montant d'impôt que l'on appelait le « cens ». Selon la doctrine de la souveraineté nationale et la théorie de l'électorat droit, le suffrage censitaire était un gage de stabilité et de sécurité juridique.

À partir de 1848, le suffrage universel va s'affirmer et être proclamé pour les hommes.

→ Décret du 5 mars 1848, réaffirmé par la loi électorale du 15 mars 1849.

Les femmes, les militaires, les détenus, les membres du Clergé et les Algériens étaient exclus. Il faudra attendre l'ordonnance du 21 avril 1944 pour que les femmes puissent voter lors des élections de 1945. Les militaires obtiendront le droit de vote en 1945 et les Français d'Outre-mer en 1946.

4.2. L'égalité du suffrage

L'égalité du suffrage correspond à l'adage *« one man, one vote, one value »*.

> *« L'influence qu'un électeur exercer sur le résultat de l'élection droit être égale à celle qu'exerce chacun des autres électeurs ; chaque suffrage doit avoir un poids égal à celui de tous les autres »* (Hans Kelsen, *Théorie générale du droit et de l'État*, 1997, Bruylant-LGDJ, p. 342).

Pour les élections parlementaires, l'égalité du suffrage impose une répartition égale des sièges entre les différentes circonscriptions selon un critère précis : nombre d'habitants recensés, nombre de citoyens inscrits sur les listes électorales qui doivent être mises à jour périodiquement.

L'égalité du suffrage peut être compromise en cas de distorsions entre les circonscriptions électorales au moment du découpage électoral. Le mode du choix du scrutin exerce aussi une influence sur l'égalité de la représentation ou sur l'égalité entre les candidats de remporter l'élection.

4.3. La liberté et le secret du suffrage

Le caractère secret du vote lors du passage à l'isoloir permet d'en assurer la liberté. Ce caractère secret est rappelé à l'article 3 de la Constitution et à l'article L. 59 du Code électoral : *« Le vote est secret. »*

Il est question ici de soustraire l'électeur à des pressions, intimidations ou subordinations extérieures afin qu'il exerce son vote en toute conscience selon sa propre volonté.

Le secret du vote est donc une obligation à laquelle on ne peut déroger sous peine de nullité du scrutin. Il se concrétise par plusieurs éléments :

- Le passage dans l'isoloir.
- Prendre l'intégralité des bulletins de vote.
- Insérer le bulletin de vote dans une enveloppe.
- L'utilisation d'une urne électorale réglementaire.

Seuls les candidats et les personnalités politiques dont les opinions politiques sont connues de tous ne sont pas tenues au secret du vote.

La violation du secret du vote est sanctionnée par l'article L. 113 du Code électoral.

4.4. L'honnêteté et la sincérité du suffrage

L'honnêteté du suffrage est utilisée en droit international (art. 25 PIDCP), tandis que la sincérité du suffrage est visée par le Code électoral (art. L. 113).

La sincérité du suffrage est un critère essentiel de la vie démocratique, il s'agit de s'assurer que le vote des électeurs a bien été respecté et pris en compte.

C'est sur ce principe de sincérité du suffrage que le juge électoral va réprimer les différentes fraudes électorales et s'intéresser aux écarts de voix pour apprécier l'altération du scrutin. Lorsque l'écart de voix est très faible, le juge électoral est très vigilant et le risque d'annulation du scrutin est élevé.

L'imagination dans le domaine des fraudes susceptibles d'être sanctionnées par le juge électoral est sans borne. Voir à titre d'exemples : Fraude à la chaussette (CE, 23 avril 2009, n° 322243, Élections municipales de Perpignan), bourrage des urnes (CE, 14 septembre 1983, n° 51495, Élections municipales d'Antony), distribution de faux bulletins (CE, 29 novembre 1972, n° 84007, Élections municipales d'Aubusson), fausses domiciliations…

4.5. La périodicité du suffrage

Il s'agit de trouver le bon équilibre entre un intervalle trop court entre les élections et des mandats trop longs des représentants qui nuirait à leur légitimité démocratique.

Cette périodicité des suffrages n'est pas évoquée dans l'article 3 de la Constitution, c'est le Conseil constitutionnel qui lui a donné valeur constitutionnelle.

> → Cons. const., déc. n° 90-280 DC, 6 décembre 1990, *Loi organisant la concomitance des renouvellements des conseils généraux et des conseils régionaux.*

Il est toutefois possible de reporter une élection si les électeurs peuvent exercer leur droit de suffrage selon une périodicité raisonnable.

> → Cons. const., déc. n° 2013-667 DC, 16 mai 2013, *Loi relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral.*

L'article 3 du 1er protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme ne précise pas non plus cette notion d'intervalle raisonnable. Le Code de bonne conduite en matière électorale élaborée par la Commission de Venise du Conseil de l'Europe indique une durée maximale de 5 ans pour les législatives et de 7 ans pour les élections présidentielles.

4.6. Le caractère direct ou indirect du suffrage

L'article 3 de la Constitution énonce que le suffrage peut être direct ou indirect.

- Le suffrage est <u>direct</u> quand les électeurs désignent directement son ou ses représentants : élections présidentielles et élections des députés.

- Le suffrage est <u>indirect</u> quand les électeurs élisent un collège de grands électeurs qui vont par la suite élire le ou les représentants : élections des sénateurs. Ce mode favorise la stabilité, mais a comme inconvénient principal d'éloigner les électeurs des élus.

POUR S'ENTRAÎNER

Dissertation : Le droit à des élections libres

Le droit à des élections libre constitue le socle des démocraties contemporaines et assoit la légitimité démocratique de nos représentants.

Les droits de participer à la vie démocratique de son pays sont à la fois des droits subjectifs et des principes objectifs essentiels à la démocratie. Ils sont la pierre angulaire de la relation entre gouvernants et gouvernés en démocratie.

Le droit à des élections libres est proclamé par de nombreuses sources : la première mention de ce droit se trouve dans l'article 21 de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui a été repris dans l'article 25 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Par la suite, le Protocole n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme consacre le droit à des élections régulières, libres et justes pour le corps législatif.

Le caractère contraignant de la CEDH pour les États membres et l'effectivité de la protection de cette dernière font du droit à des élections libres un droit incontournable.

La Constitution de 1958 proclame aussi ce droit à l'article 2 alinéa 5 et à l'article 3 et renvoie au Code électoral qui encadre la tenue des différentes élections françaises, l'exercice du droit de vote, les caractères du suffrage ainsi que les conditions de jouissance et d'exercice du droit à des élections libres.

Problématique et annonce du plan : Afin que le droit à des élections libres soit effectif ce dernier est encadré pour assurer son effectivité. Ce droit peut être décomposé en deux volets complémentaires et interdépendants : le droit de vote et les caractères du suffrage **(I)** et le droit d'éligibilité **(II)**.

I. L'acquisition du droit de vote, pendant du droit à des élections libres

A. Le droit de vote assorti du suffrage universel

Le droit de vote est parfois qualifié de volet « passif » du droit à des élections libres.

En France, le vote est un droit, il n'est pas obligatoire contrairement à d'autres pays européens : Belgique, Grèce, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Suisse.

Le droit de vote joue un rôle essentiel dans une démocratie.

Le droit de vote peut faire l'objet de restrictions (CEDH, Gr. Ch., 18 janvier 2011, n° 126/05, *Scoppola c. Italie [n° 3]*).

Comme énoncé dans la Constitution, la fixation des règles concernant les droits civiques relève du domaine de la loi (art. 34 de la Constitution).

Le droit de vote permet aux citoyens d'exprimer leurs opinions au moment du scrutin pour élire des représentants ou répondre à un référendum.

Suffrage universel masculin : 1848 (Décret du 5 mars 1848, réaffirmé par la loi électorale du 15 mars 1849).

Ordonnance du 21 avril 1944 pour que les femmes puissent voter lors des élections de 1945. Les militaires obtiendront le droit de vote en 1945 et les Français d'Outre-mer en 1946.

B. Les caractères du suffrage garantissant le droit à des élections libres

Le droit de vote rend possible la tenue d'élections qui doivent répondre à certaines exigences.

L'égalité du suffrage : *« one man, one vote, one value »* qui implique un juste découpage des circonscriptions électorales, basé sur le nombre de citoyens inscrits sur les listes électorales.

La liberté et le secret du suffrage (art. 3 de la Constitution). Le passage à l'isoloir et les règles de vote permettent d'assurer cette liberté pour éviter toute pression extérieure lors du vote. Violation du secret sanctionnée / Honnêteté et sincérité du suffrage : prise en compte et respect du vote des électeurs. Le juge électoral reste très vigilant sur d'éventuelles fraudes électorales.

La périodicité du suffrage : trouver un équilibre entre intervalle trop court entre les élections et mandats trop longs diminuant la légitimité démocratique. Référence au Code de bonne conduite en matière électorale de la Commission de Venise (5 ans pour les législatives et 7 ans pour les élections présidentielles).

II. Le droit d'éligibilité, versant actif du droit à des élections libres

A. Le droit d'éligibilité

Le droit à des élections libres garantit le droit de toute personne de pouvoir briguer un mandat électoral et la garantie de pouvoir exercer son mandat une fois élue. Il s'agit du « pouvoir souverain de l'électorat ». (CEDH, 11 juin 2002, n° 25144/94, 26149/95 à 26154/95, 27100/95 et 27101/95, *Selim Sadak c. Turquie).* Possibilité pour une personne de briguer un mandat électoral et de pouvoir l'exercer une fois élu.

La protection des mandats passe essentiellement par la mise en place d'immunités (irresponsabilité et inviolabilité parlementaire) et de privilèges juridictionnels (privilège de juridiction pour le président de la République)

L'éligibilité peut être restreinte pour des motifs légitimes et non discriminatoires. En France, les inéligibilités ne peuvent découler que des dispositions expresses d'une loi. L'article LO 133 du Code électoral liste 19 catégories de personne qui ne peuvent pas se présenter aux élections législatives pour éviter les conflits d'intérêt et la corruption (magistrats, recteurs, officiers des armées, inspecteurs d'académie…).

B. Être électeur et éligible : jouissance complète du droit à des élections libres

Pour être électeur et éligible, il existe de nombreuses conditions : la condition de nationalité : le droit de vote est attaché à la qualité de français, les étrangers sont exclus du droit de vote sauf les citoyens européens pour les élections municipales depuis le traité de Maastricht.

Condition de la majorité électorale : 18 ans pour pouvoir voter / condition de résidence : résidence effective depuis 6 mois / absence de déchéance des droits politiques : prononcée dans une décision de justice soit à titre principal ou à titre accessoire pour certains crimes et délits (extorsion, chantage, faux témoignage…) / nécessité d'être inscrit sur les listes électorales.

Possibilité de conditions renforcées d'éligibilité pour certains mandats (résidence, âge, incompatibilités professionnelles ou statutaires).

En conclusion, le droit à des élections libres fait partie des fondements essentiels de nos démocraties modernes et de la République française.

Fiche nº 43 - LES PROTECTIONS FONDAMENTALES EN CAS D'ÉLOIGNEMENT, D'EXPULSION ET D'EXTRADITION

POINTS CLÉS

- Il existe en France plusieurs mesures d'éloignement, d'expulsion et d'extradition qui obéissent à des règles et à des objectifs bien différents en fonction de la situation des personnes.
- Pour autant, dans la mise en œuvre de ces mesures, les individus disposent de droits devant être garantis.
- Il existe une multitude de textes nationaux et internationaux préservant les droits de la personne.
- Parfois, la protection fondamentale en cas d'éloignement est mise en balance avec d'autres droits comme celui au mariage.

PRINCIPALES RÉFÉRENCES

- Cons. const., déc. nº 2011-631 DC, 9 juin 2011, *Loi relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité*.
- Cons. const., déc. nº 2003-484 DC, 20 novembre 2003, *Loi relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité*.
- CE, Ass., 21 janvier 1977, *ministre de l'Intérieur c/ Dridi,* nº 01333.

1. Le droit des étrangers et des citoyens de l'Union européenne

La qualité de citoyen national, d'étranger ou de citoyen de l'Union européenne emporte des différenciations entre les personnes en termes de droit. Selon qu'une personne appartienne ou non à l'une ou l'autre des catégories, elle ne disposera pas des mêmes droits.

À l'heure du développement des migrations liées à une multitude de phénomènes comme la guerre, le climat ou la famine, ces différences sont marquées en ce qui concerne les immigrés en situation régulière et ceux en situation irrégulière.

Le principe est que les États organisent comme ils le souhaitent l'entrée et le séjour des étrangers dans leur territoire. En France, pour le Conseil constitutionnel :

> *« Aucune règle de valeur constitutionnelle n'assure aux étrangers des droits de caractère général et absolu d'accès et de séjour sur le territoire national ; que les conditions de leur entrée et de leur séjour peuvent être restreintes par des mesures de police administrative conférant à l'autorité publique des pouvoirs étendus et reposant sur des règles spécifiques ; que l'objectif de lutte contre l'immigration irrégulière participe à la sauvegarde de l'ordre public qui est une exigence de valeur constitutionnelle »* (Cons. const., nº 2011-631 DC, 9 juin 2011, *Loi relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité*).

Néanmoins, l'absence de caractère général et absolu d'accès et de séjour sur le territoire national n'est pas synonyme de négation de tout statut juridique. Le Conseil constitutionnel a progressivement doté les étrangers d'un statut constitutionnel protecteur de leurs droits.

Par exemple, le Conseil constitutionnel a dégagé des exigences d'égalité de traitement, notamment en matière de droits humains, lorsque des étrangers résident de façon régulière sur le sol français. Il a retenu dans une décision de 1993 que :

> *« Considérant toutefois que si le législateur peut prendre à l'égard des étrangers des dispositions spécifiques, il lui appartient de respecter les libertés et droits fondamentaux de valeur constitutionnelle*

reconnus à tous ceux qui résident sur le territoire de la République » (Cons. const., 13 août 1993, n° 1993-325 DC, *Loi concernant les conditions d'entrée, d'accueil et de séjour des étrangers en France*).

Dans cette décision de 1993, le Conseil constitutionnel a dégagé un socle minimal de droits et libertés dont les personnes étrangères en situation régulière peuvent bénéficier, tels que la liberté individuelle et la sûreté, la liberté d'aller et venir, la liberté du mariage, le droit de mener une vie familiale normale. Qu'en outre, ils bénéficient du droit au recours pour assurer la garantie de ces droits et libertés.

Dans une décision de 2003, le Conseil constitutionnel a aussi rappelé que le respect de la liberté du mariage était une composante de la liberté personnelle protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et que cela s'opposait à ce que le caractère irrégulier du séjour fasse obstacle, en lui-même, au mariage.

→ Cons. const., déc. n° 2003-484 DC, 20 novembre 2003, *Loi relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité.*

POUR ALLER PLUS LOIN

Au mois de février 2025, le Sénat a adopté une proposition de loi destinée à interdire les mariages entre les français et les étrangers en situation irrégulière. Le texte sénatorial oblige tout ressortissant étranger voulant se marier à fournir la preuve du caractère régulier de sa situation.

Cette proposition de loi fait suite au refus du maire de Béziers de célébrer un mariage entre une française et une personne en situation irrégulière.

L'article unique de la loi interdisait totalement le mariage, mais en raison d'un risque d'inconstitutionnalité, le texte a été retravaillé et désormais la preuve du caractère régulier de la présence doit être fourni et rallonge le délai permettant au procureur de la République d'enquêter en cas de doute sur la véracité du consentement.

La protection en cas d'éloignement, d'extradition ou d'expulsion fait l'objet de plusieurs consécrations textuelles dans divers instruments.

Par exemple, l'article 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne prohibe les expulsions collectives et prohibe les expulsions, les extraditions ou les éloignements de personnes risquant la peine de mort, la torture ou tout autre traitement inhumain ou dégradant.

De même, l'article 1er du protocole n° 7 à la Convention prévoit des garanties procédurales en cas d'expulsion en prévoyant des cas particuliers dans lesquels cette dernière peut être mise en œuvre.

2. Les mesures d'éloignement du territoire

Pour contrôler son territoire, l'État peut utiliser des moyens pour contraindre les étrangers à le quitter en fonction de conditions qui se doivent d'être les plus objectives possibles.

Il dispose de plusieurs outils et procédures permettant de contraindre un étranger à quitter le territoire national. Cependant, il convient de noter que ces outils ne peuvent pas s'appliquer aux ressortissants dans la mesure où un État ne peut forcer ses ressortissants à quitter le territoire.

POUR ALLER PLUS LOIN

D'un point de vue étymologique, le terme ressortissant signifie qu'une personne est liée à un pays par le biais d'un lien de nationalité ou plus généralement par un lien juridique le lien à l'État en question.

Il faut distinguer par ailleurs l'immigré et l'émigré. L'immigré s'installe dans un autre pays que le sien tandis que l'émigré quitte son pays. La différence réside dans le fait de partir ou d'arriver.

2.1. L'obligation de quitter le territoire français (OQTF) et l'interdiction de retour sur le territoire français

Jusqu'en 2011, deux procédures existaient : celle de reconduite à la frontière et celle de l'obligation de quitter le territoire.

La reconduite à la frontière était caractérisée soit par une reconduite de nature pénale soit par une décision administrative de reconduite à la frontière. Dans le premier cas, c'était une juridiction répressive qui prononçait cette peine dans le second cas, c'était le préfet qui prenait une décision administrative.

La loi du 16 juin 2011 est venue modifier les procédures d'éloignement des étrangers en fusionnant les obligations de quitter le territoire français et les arrêtés de reconduite à la frontière. Elle crée en outre une interdiction de retour sur le territoire français.

Désormais, le Code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) précise les modalités selon lesquelles l'autorité administrative peut contraindre un étranger non ressortissant d'un État de l'Union européenne à quitter le territoire.

L'obligation de quitter le territoire français (OQTF) ne concerne que les étrangers en situation irrégulière. Seul ce critère peut servir à fonder une telle mesure. Dès lors que la personne revient sur le territoire et se met dans une situation régulière, elle n'est plus envisageable.

L'ensemble des conditions permettant à l'autorité administrative de prendre une décision administrative visant à obliger un étranger à quitter le territoire est prévu dans le CESEDA, mais il est possible de retenir ici que certaines personnes ne peuvent faire l'objet d'une telle obligation (étranger mineur, …).

Des garanties procédurales et des recours contentieux permettent de contrôler l'exercice du pouvoir discrétionnaire des préfets en la matière. Cependant, en l'espèce, le juge administratif n'exerce qu'un contrôle restreint, limité à l'erreur manifeste d'appréciation, en dehors de toute considération de la question de l'atteinte excessive au droit de l'étranger à une vie familiale normale par exemple.

2.2. L'expulsion

Comme pour l'obligation de quitter le territoire français, l'expulsion est une décision administrative. Cependant, elle concerne le cas particulier d'une mesure de police administrative prise si la présence sur le territoire français d'un étranger est constitutive d'une menace grave pour l'ordre public.

Contrairement à l'obligation de quitter le territoire français qui ne concerne qu'un étranger en situation irrégulière, l'expulsion est une mesure plus sévère. L'expulsé ne peut revenir que si l'arrêté d'expulsion est abrogé par l'administration ou annulé par le juge.

→ CE, sect., 4 novembre 1994, *Al Joujo,* n° 136240.

Il existe deux types de procédure d'expulsion : l'expulsion ordinaire et l'expulsion en urgence absolue.

L'expulsion ordinaire est décidée par un arrêté du préfet après mise en œuvre d'une procédure particulière destinée à préserver les droits de l'étranger concerné. Cette procédure fait appel notamment à une commission des expulsions dans laquelle siège des magistrats judiciaires et administratifs.

L'arrêté d'expulsion, une fois en vigueur, impose à l'étranger de quitter le territoire et l'empêche totalement de revenir sur le territoire national.

L'expulsion en urgence absolue est ordonnée par un arrêté du ministre de l'Intérieur et supprime la procédure préalable de la commission des expulsions. Pour éviter l'arbitraire du ministre, des conditions strictes sont posées, notamment pour les étrangers protégés.

Les arrêtés d'expulsion font l'objet d'un contrôle par le juge administratif qui veille, par le biais d'une jurisprudence foisonnante, au respect de la légalité de la procédure. Est ainsi vérifiée la réalité de l'examen individuel de chaque situation ou le respect des garanties procédurales comme la convocation devant la commission d'expulsion.

→ CE, Ass., 21 janvier 1977, *ministre de l'Intérieur c. Dridi,* n° 01333.

Le juge administratif examine aussi la réalité de la menace à l'ordre public ou celle de l'urgence absolue, notamment vis-à-vis des stipulations de la Convention européenne des droits de l'homme. Si le contrôle est limité à l'erreur manifeste d'appréciation, le contrôle du juge est plus important pour les étrangers protégés.

> *« Considérant que M. X…, ressortissant algérien, n'a aucune attache familiale avec le pays dont il possède la nationalité ; qu'il réside depuis sa naissance en 1958 en France où demeure sa famille composée de douze frères et sœurs dont il a, avec son frère aîné, assumé une partie de la charge à la suite du décès de son père en 1976 ; que si l'intéressé s'est rendu coupable de plusieurs vols en 1980 et 1982, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de son comportement, postérieurement aux condamnations prononcées à raison de ces faits, la mesure d'expulsion prise à l'encontre de M. X… a, eu égard à la gravité de l'atteinte portée à sa vie familiale, excédé ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public ; que, dans ces conditions, elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention précitée »* (CE, Ass., 19 av. 1991, *Belgacem et Babas*, n° 107470).

Actualité jurisprudentielle. - Certaines protections contre l'expulsion cèdent lorsque les faits sont commis contre les proches de l'étranger

Certains étrangers bénéficiant d'attaches particulièrement fortes avec la France disposent d'une protection renforcée contre l'expulsion. Ainsi, l'article L. 631-2 du CESEDA exige en principe, notamment pour l'étranger résidant régulièrement en France depuis plus de dix ans, que son expulsion constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'État ou la sécurité publique.

Depuis la loi du 26 janvier 2024 *pour contrôler l'immigration, amélioration l'intégration*, cette protection est toutefois écartée lorsque les faits à l'origine de l'expulsion ont été commis contre son conjoint, un ascendant, ses enfants ou un enfant sur lequel il exerce l'autorité parentale. L'expulsion relève alors du régime de droit commun de l'article L. 631-1, fondé sur l'existence d'une menace grave pour l'ordre public.

Le Conseil d'État a appliqué ce dispositif en 2026 à un ressortissant turc présent en France depuis 2006, condamné à un an d'emprisonnement ferme pour plusieurs années de violences intrafamiliales. Il avait également été interdit d'entrer en contact avec son ancienne épouse et ses six enfants et s'était vu retirer l'autorité parentale en raison du risque de récidive.

Le CE considère ici que son expulsion ne porte pas une atteinte disproportionnée à l'article 8 de la Convention. L'intéressé ne pouvait précisément plus invoquer une vie familiale effective avec ses enfants, compte tenu des interdictions judiciaires prononcées à son encontre et du retrait de son autorité parentale.

→ CE, 9 juin 2026, n° 504383.

À retenir. - La durée du séjour en France et les liens familiaux constituent des protections importantes contre l'expulsion, mais leur poids doit être apprécié concrètement. Un étranger ne peut utilement invoquer la préservation d'une vie familiale que ses propres violences et les décisions judiciaires qui en résultent l'empêchent désormais d'exercer. Cet arrêt fait, en outre, un lien très intéressant avec l'arrêt *Belgacem* : le contrôle de proportionnalité au regard de l'article 8 demeure, mais les éléments de la vie familiale sont appréciés dans leur réalité actuelle.

2.3. L'extradition

L'extradition permet à un État de remettre un étranger à la disposition de la justice d'un autre État qui lui en fait la demande. L'extradition est régie en France par les dispositions du Code de procédure pénale.

Les extraditions reposent sur des conventions internationales ou sur des accords d'extradition passés par la France avec des États étrangers.

De manière schématique, il existe en France deux procédures d'extradition : celle de droit commun et une procédure simplifiée d'extradition entre les États membres de l'Union européenne.

L'extradition de droit commun est prononcée par décret, après avis conforme de la chambre d'accusation de la cour d'appel. L'extradition n'est possible que si les faits reprochés par l'État qui en fait la demande sont passibles d'une peine correctionnelle ou criminelle.

L'extradition n'est pas possible quand le crime ou le délit a un caractère politique ou lorsqu'il résulte des circonstances que l'extradition est demandée dans un but politique.

En outre, plusieurs motifs empêchent l'extradition : lorsque l'individu est citoyen français, lorsque les crimes ou les délits ont été commis en France ou lorsque les crimes ou les délits ont été poursuivis et jugés définitivement.

Sous l'influence du Conseil d'État, l'acte d'extradition n'est plus un acte de gouvernement insusceptible de recours pour excès de pouvoir. En revenant sur sa jurisprudence de 1937, le Conseil d'État admet d'en contrôler la légalité au regard des conventions internationales et son contrôle est entier sur les motifs d'extradition depuis 1977.

→ CE, Ass., 28 mai 1937, *Decerf,* n° 54631.

→ CE, Ass., 24 juin 1977, *Astudio Calleja,* n° 01591.

Actualité jurisprudentielle. - L'extradition doit prendre en compte la vie familiale et l'intérêt supérieur des enfants

Une décision d'extradition est susceptible de porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Le Conseil d'État précise, en outre, qu'elle peut affecter suffisamment directement et certainement la situation des enfants mineurs dont la personne recherchée assume la charge effective et continue. Dans ce cas, l'autorité française doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant, conformément à l'article 3 § 1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant.

En l'espèce, un ressortissant turc devait être extradé vers la Turquie afin d'y exécuter deux peines d'emprisonnement, notamment pour trafic de stupéfiants et privation de liberté. Il invoquait son concubinage et la présence en France de son enfant mineur. Le Conseil d'État juge cependant que ces circonstances ne suffisaient pas à faire obstacle à l'extradition, compte tenu de l'intérêt d'ordre public attaché à l'exécution des décisions pénales étrangères.

→ CE, 10 mars 2025, M. B..A…,n° 497648.

À retenir. - L'intérêt supérieur de l'enfant constitue une considération primordiale dans la décision d'extrader son parent, mais il ne constitue pas une cause automatique de refus d'extradition. Le juge met en balance les conséquences familiales de la mesure et l'intérêt d'ordre public attaché à la coopération pénale internationale.

3. Les protections face aux mesures d'éloignement

3.1. Éloignement et protection de l'intégrité physique

En principe, l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques prohibent la torture et les traitements inhumains ou dégradants.

Dans le même sens, l'article 8 de la Convention européenne est interprété par la Cour comme assurant une protection de l'individu contre des atteintes à son intégrité physique lorsqu'elles n'ont pas atteint un seuil suffisant de gravité pour justifier l'applicabilité de l'article 3. Ainsi, l'article 8 de la CEDH est une protection subsidiaire en cas d'inapplicabilité de l'article 3.

Parfois, la mesure d'éloignement va entraîner un risque pour la personne d'être soumise à une atteinte à son intégrité physique. C'est pourquoi une mesure d'éloignement prise à l'égard d'un ressortissant étranger est incompatible avec l'article 3 de la CEDH si ce dernier risque d'être exposé à des traitements inhumains ou dégradants dans l'État d'accueil.

La Cour européenne a ainsi estimé dans un arrêt de 1989, à propos de l'extradition d'un individu allemand vers les États-Unis, que la responsabilité d'un État peut être engagée s'il décide d'éloigner une personne susceptible de subir de mauvais traitements dans le pays de destination. En l'espèce, la Cour avait conclu à la violation de l'article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des droits de l'homme en cas d'extradition vers les États-Unis puisque le requérant risquait d'être soumis à la peine de mort.

> *« En résumé, pareille décision peut soulever un problème au regard de l'article 3, donc engager la responsabilité d'un État contractant au titre de la Convention, lorsqu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on le livre à l'État requérant, y courra un risque réel d'être soumis à la torture, ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Pour établir une telle responsabilité, on ne peut éviter d'apprécier la situation dans le pays de destination à l'aune des exigences de l'article 3 »* (CEDH, 7 juillet 1989, *Soering c. Royaume-Uni*, n° 14038/88).

Dans la même logique, la Cour a jugé que l'expulsion vers l'Iran d'une femme menacée d'être lapidée pour adultère emporte la violation de l'article 3 de la Convention.

> → CEDH, 11 juillet 2000, *Jabari c. Turquie*, n° 40035/98.

La Cour a une appréciation très extensive de la notion de risque encouru. Il ne s'agit pas uniquement des cas dans lesquels il y a un risque à raison de l'action ou de l'intervention de l'État dans lequel la personne va être extradée. Il s'agit aussi de cas dans lesquels les traitements médicaux sont insuffisants et exposent la personne extradée à un risque pour sa vie ou sa santé.

Ainsi, la prohibition de l'éloignement peut s'appliquer selon la Cour dès lors qu'il existe :

> *« Des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie »* (CEDH, 13 décembre 2016, *Paposhvili c. Belgique*, n° 41738/10).

3.2. Éloignement et protection de l'intégrité morale

Le respect de la dignité de la personne humaine justifie d'interdire des actes ou des situations ayant pour effet de rabaisser ou d'humilier une personne.

À l'inverse de précédemment, il s'agit de cas dans lesquels ni la vie ni l'intégrité physique des individus ne sont menacées.

En ce sens, la Cour a interprété l'article 3 de la Convention comme prohibant les traitements dégradants et de nature à créer :

> *« Des sentiments de peur, d'angoisse et d'infériorité, propres à les humilier, à les avilir et à briser éventuellement leur résistance physique ou morale »* (CEDH, 18 janvier 1978, *Irlande c. Royaume-Uni,* n° 5310/71. Voir également CEDH, 28 juillet 1999, *Selmouni c. France,* n° 25803/94).

Concernant précisément l'éloignement du territoire, la solution dégagée dans l'arrêt *Soering* est évidemment applicable en l'espèce dès lors qu'en plus d'être confrontée à la peine de mort, la personne extradée va être exposée au « syndrome du couloir de la mort » (CEDH, 7 juillet 1989, *Soering c. Royaume-Uni,* n° 14038/88).

POUR ALLER PLUS LOIN

Le syndrome du couloir de la mort est lié à une longue période à passer dans le couloir de la mort, c'est-à-dire à un très long moment de détention avant d'être véritablement exécuté à la peine capitale. Ce syndrome est lié à des conditions extrêmes de détention accentuée par l'angoisse croissante de l'exécution

L'application de cette solution à la protection de l'intégrité morale perd de son intérêt dès lors que la Cour estime que l'éloignement d'une personne vers un État où elle encourt la peine de mort est contraire à l'article 3 de la Convention pour ce seul motif, peu importe les conséquences physiques ou morales que cela entraînerait supposément.

Cependant, la Cour a développé une jurisprudence abondante concernant la protection de l'intégrité morale dans l'exécution d'une mesure d'éloignement.

Elle estime que l'article 3 de la Convention prohibe l'extradition d'une personne vers un État dans lequel elle risquerait d'être condamnée à une peine de réclusion criminelle à perpétuité sans possibilité de réexamen.

> → CEDH, 4 septembre 2014, *Trabelsi c. Belgique,* n° 140/10.

Le Conseil d'État s'est livré à la même appréciation quelques années plus tard en retenant que :

> *« Dans ces conditions, le décret attaqué, en ce qu'il expose M. A…, en cas d'extradition pour l'exécution du mandat d'arrêt à raison de faits qualifiés de tentative d'homicide volontaire, à une peine de réclusion criminelle à perpétuité incompressible sans possibilité de réexamen, méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il suit de là que l'extradition ne pouvait être légalement accordée pour ces faits »* (CE, 18 novembre 2022, n° 461381).

3.3. Les garanties procédurales prévues par l'article 1er du protocole no 7 à la Convention européenne des droits de l'homme

Le Protocole no 7 à la Convention a été adopté le 22 novembre 1984. Il est entré en vigueur le 1er novembre 1988. Ce protocole reconnaît certains droits non encore garantis ni par la Convention européenne ni par ses Protocoles antérieurs et précisément le droit à des garanties procédurales en cas d'expulsion d'un étranger du territoire d'un État.

Il faut rappeler que la Convention ne garantit pas en tant que tel le droit pour un étranger d'entrer ou de résider dans un pays particulier.

→ CEDH, 13 décembre 2012, *De Souza Ribeiro c. France*, no 22689/07.

Cet article à une visée subsidiaire en ce qu'il permet d'assurer aux individus une protection dans les cas qui ne sont pas couverts par d'autres instruments internationaux et d'introduire cette protection dans le système de contrôle prévu par la Convention.

La Cour a souligné qu'en cas d'expulsion, les garanties spécifiques prévues par l'article 1er du Protocole no 7 dont bénéficient les étrangers s'ajoutent à la protection qui leur est offerte notamment par les articles 3 et 8 de la Convention.

→ CEDH, 8 septembre 2006, *Lupsa c. Roumanie,* no 10337/04.

L'article 1er du protocole no 7 à la Convention dispose de deux paragraphes qui correspondent à deux garanties.

La première garantie prévoit que l'étranger concerné ne peut être expulsé qu'*« en exécution d'une décision prise conformément à la loi »* et prévoit des garanties procédurales dont peut se prévaloir la personne étrangère résidant régulièrement sur le territoire.

Le second paragraphe prévoit une autre garantie en déterminant les circonstances dans lesquelles un étranger peut être expulsé avant l'exercice des droits reconnus par le paragraphe 1. On y retrouve notamment la protection de l'ordre public et des motifs de sécurité nationale.

Actualité jurisprudentielle. - Directive « retour » : une décision définitive n'épuise pas la protection des droits fondamentaux

La directive 2008/115/CE dite « retour » encadre les décisions et mesures d'éloignement des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Son article 5 impose aux États membres de tenir dûment compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, de la vie familiale et de l'état de santé de l'intéressé et de respecter le principe de non-refoulement. Son article 15 n'autorise la rétention aux fins d'éloignement que lorsqu'une mesure moins coercitive ne peut être efficacement mise en œuvre.

En 2025, un ressortissant algérien faisait l'objet aux Pays-Bas d'une décision de retour devenue définitive et avait été placé en rétention en vue de son éloignement vers l'Algérie. Il invoquait cependant un risque de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour et faisait valoir qu'il était père d'un enfant né en France.

La Cour de justice juge que le tribunal saisi du contrôle de la légalité de la rétention doit vérifier, au besoin d'office, si le principe de non-refoulement, l'intérêt supérieur de l'enfant ou la vie familiale font obstacle à l'éloignement. Cette obligation subsiste alors même que la décision de retour est devenue définitive.

→ CJUE, 4 septembre 2025, *Adrar*, C-313/25 PPU.

Cette solution résulte des articles 5 et 15 de la directive 2008/115, lus à la lumière des articles 6 (liberté), 7 (vie privée et familiale), 19 § 2 (non-refoulement), 24 § 2 (intérêt supérieur de l'enfant) et 47 (protection juridictionnelle effective) de la Charte.

À retenir. - Le caractère définitif d'une décision de retour ne rend pas son exécution automatique. Les droits fondamentaux doivent être respectés jusqu'au moment de l'éloignement et le juge de la rétention doit, si nécessaire, les examiner d'office.

Notion essentielle. - Les « hubs de retour » : l'externalisation du retour vers des États tiers

La Commission européenne a proposé en mars 2025 de remplacer la directive 2008/115/CE dite « retour » par un règlement établissant un système européen commun en matière de retour. Un accord politique est intervenu entre le Parlement européen et le Conseil en juin 2026 ; le Parlement a adopté sa position en première lecture le 17 juin 2026, mais la procédure législative n'est pas encore définitivement achevée au 25 août 2026.

Parmi les principales innovations figure la possibilité de créer des « hubs de retour » dans des pays tiers. L'objectif est de permettre à un État membre d'éloigner un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier faisant l'objet d'une décision de retour vers un État qui n'est pas nécessairement son État d'origine, de résidence habituelle ou de transit. Le pays tiers peut constituer soit la destination finale de l'intéressé, soit un centre de transfert à partir duquel son retour ultérieur vers son pays d'origine ou un autre État sera organisé.

Une telle externalisation suppose la conclusion d'un accord ou arrangement avec l'État tiers concerné. Celui-ci ne peut être conclu qu'avec un État respectant les standards internationaux de protection des droits fondamentaux et notamment le principe de non-refoulement. L'accord doit déterminer les conditions du transfert et du séjour dans l'État tiers, les responsabilités respectives des parties, les modalités d'un éventuel retour ultérieur ainsi que les conséquences d'une violation de l'accord ou d'une dégradation de la situation dans l'État concerné.

Il est à noter que les mineurs non accompagnés ainsi que les familles avec enfants mineurs sont expressément exclus du dispositif.

Cette faculté demeure soumise au respect de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en particulier de son article 19. Concrètement, l'éloignement ne peut conduire directement ou indirectement à exposer une personne à la peine de mort, à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants. Le principe de non-refoulement doit donc être apprécié concrètement avant l'éloignement vers le hub et, le cas échéant, au regard du risque de refoulement en chaîne vers un autre État.

À retenir. - Les hubs de retour consacrent une évolution importante du droit européen : le « retour » ne serait plus nécessairement dirigé vers le seul pays d'origine ou de transit de l'étranger. L'Union permettrait son transfert vers un État tiers partenaire, y compris comme étape intermédiaire avant un nouvel éloignement. Cette externalisation demeure néanmoins soumise aux droits fondamentaux, au principe de non-refoulement, à l'exclusion des mineurs non accompagnés et des familles avec mineurs et à un mécanisme indépendant de contrôle.

POUR S'ENTRAÎNER

Commentaire de texte : Proposition de loi n° 977 visant à ne pas autoriser le mariage d'un étrangers soumis à l'obligation de quitter le territoire français.

« Article unique - L'article 144 du Code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé : "Le mariage ne peut être célébré si l'une des deux personnes est soumise à une obligation de quitter le territoire français." »

Le droit au mariage est un droit fondamental consacré tant par le droit interne que par le droit international (Cons. const., décision n° 2003-484 DC du 20 novembre 2003, *Loi relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité*). En droit français, il est encadré par le Code civil, notamment aux articles 143 à 164, et son accès est reconnu à tous, y compris aux personnes étrangères. Toutefois, ce principe connaît certaines restrictions motivées par l'ordre public, comme la lutte contre les mariages de complaisance ou les fraudes au séjour, mais encadrées par des procédures visant à garantir les droits de la personne.

La proposition de loi n° 977, déposée à l'Assemblée nationale, qui vise à compléter l'article 144 du Code civil pour interdire la célébration d'un mariage si l'un des futurs époux est sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF), entend porter atteinte à ce droit au mariage puisque cette disposition vise à limiter les possibilités de régularisation du séjour par le biais du mariage.

Surtout, cette proposition vient modifier les droits et garanties d'une personne visée par une obligation de quitter le territoire français (OQTF). Elle fait suite au refus par le maire de Béziers de marier une personne ayant une OQTF.

Cette initiative législative soulève des enjeux sensibles, à la croisée des droits fondamentaux et de la politique migratoire. Elle conduit à s'interroger sur sa portée juridique, mais aussi sur sa conformité aux principes constitutionnels et conventionnels.

Il conviendra d'analyser d'une part les objectifs poursuivis par la proposition de loi au regard de la mesure d'éloignement **(I)**, puis d'autre part les risques d'inconstitutionnalité et de contrariété au droit européen qu'elle pourrait soulever **(II)**.

I. Une volonté de renforcer la cohérence entre droit des étrangers et droit du mariage

A. Une mesure fondée sur des préoccupations migratoires et de lutte contre la fraude

L'objectif affiché de cette proposition est clair : empêcher que le mariage soit utilisé comme une stratégie de régularisation du séjour par une personne faisant l'objet d'une OQTF.

En effet, en droit positif, un étranger faisant l'objet d'une décision administrative portant mesure d'éloignement peut tout de même contracter mariage. L'union peut alors entraîner, sous certaines conditions, l'annulation de la mesure d'éloignement ou ouvrir la voie à une régularisation.

L'ajout envisagé à l'article 144 introduit une condition préalable à la célébration du mariage, non pas liée à l'âge (comme le reste de l'article), mais à la situation administrative d'un des époux. Il s'agit ainsi d'éviter que le mariage serve d'obstacle à l'exécution des décisions préfectorales d'éloignement.

Cette mesure exerce donc une influence directe sur les droits de la personne faisant l'objet de la mesure d'éloignement.

B. La volonté de simplification de la gestion et d'anticipation des mariage en contexte migratoire

Au-delà de la lutte contre les fraudes, la proposition de loi s'inscrit dans une volonté de rationaliser l'action administrative. En interdisant la célébration du mariage en cas d'OQTF, on éviterait d'avoir à suspendre ou annuler une mesure d'éloignement en raison d'un mariage survenu postérieurement.

Il s'agit donc d'anticiper les effets juridiques du mariage, en empêchant qu'il interfère avec la procédure d'éloignement, ce qui est vu par les députés comme un moyen de préserver l'efficacité de la politique migratoire. Cette approche administrative se fonde sur une conception plus restrictive du droit au mariage, subordonnée aux impératifs d'ordre public migratoire.

II. Une proposition soulevant de sérieuses interrogations constitutionnelles et conventionnelles

A. L'atteinte sous-jacente au droit fondamental de se marier

Le droit au mariage est garanti par l'article 12 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) et les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Il a été reconnu comme une liberté fondamentale par le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État. Ce droit ne peut être limité que pour des raisons légitimes et de manière proportionnée.

Or, en interdisant *a priori* tout mariage à une personne sous OQTF, sans examen individualisé, la proposition de loi opère une restriction générale et absolue, susceptible d'être jugée disproportionnée. La Cour européenne des droits de l'homme a déjà rappelé que le droit au mariage ne peut être supprimé du seul fait de la situation administrative d'un étranger (CEDH, *O'Donoghue c. Royaume-Uni*, 2010).

B. Le risque d'inconstitutionnalité pour atteinte disproportionnée à une liberté individuelle

Le Conseil constitutionnel, dans plusieurs décisions (notamment DC n° 93-325 et DC n° 2003-484), a rappelé que le législateur peut encadrer l'exercice du droit au mariage, mais ne peut y porter atteinte de manière disproportionnée. La condition de régularité du séjour n'a jamais été reconnue comme préalable à la célébration du mariage.

Ainsi, une telle interdiction pourrait priver les individus de la possibilité de se marier en France même pour les personnes en situation irrégulière, tant que le mariage n'est pas frauduleux.

Enfin, la mesure risquerait de violer le principe d'égalité devant la loi, en instaurant une différence de traitement entre les couples selon la nationalité ou la situation administrative de l'un des époux, sans justification suffisante au regard de l'objectif poursuivi.

En conclusion, il existe de forts risques que cette loi soit déclarée inconstitutionnelle en ce qu'elle porte une atteinte démesurée au droit de se marier.

Fiche nº 44 - LE DROIT DES PEUPLES À DISPOSER D'EUX-MÊMES

POINTS CLÉS

- Décolonisation.
- Droit international coutumier.
- Principe de l'*uti posssidetis.*
- Charte africaine des droits de l'homme et des peuples.
- Valeur constitutionnelle de « peuple français ».
- Statut dérogatoire de la Nouvelle-Calédonie.
- Statut particulier de la Corse.

PRINCIPALES RÉFÉRENCES

- Charte des Nations unies.
- Pacte international sur les droits civils et politiques.
- Pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels.
- CIJ, *Burkina Faso c. République du Mali,* 22 décembre 1986.
- Cons. const., déc. nº 91-290, 9 mai 1991, *Loi portant statut de la collectivité territoriale de Corse.*
- CIJ, *Affaire relative au Timor oriental (Portugal contre Australie*), 30 juin 1995.
- Cons. const., déc. nº 75-59 DC, 30 décembre 1975, *Loi relative aux conséquences de l'autodétermination des îles des Comores.*
- Cons. const., déc. nº 99-412 DC, 15 juin 1999, *Charte européenne des langues régionales ou minoritaires.*
- Loi nº 99-209 organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.

Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes possède ses logiques propres (à commencer par la question du sujet) qui ont alimenté de nombreuses controverses sur sa fondamentalité même.

Son appréhension implique d'interroger l'existence, ou l'inexistence, de droits conférés à un groupe titulaire de droits, ce qui se distingue de l'existence de droits collectifs tels que le droit de réunion ou encore le droit de grève.

1. Les incertitudes autour de la définition juridique de « peuple »

Le droit international a essentiellement considéré la notion de « peuple » à l'aune de la domination par une puissance coloniale.

Dans un avis consultatif de 1971, la Cour internationale de justice a souligné, en évoquant les territoires non autonomes, le principe de l'autodétermination et les « territoires dont les populations ne s'administrent pas encore complètement elles-mêmes » : « Il est clair que ces termes visaient les territoires sous régime colonial. »

> → CIJ, avis consultatif, 21 juin 1971, *Conséquences juridiques de la présence de l'Afrique du Sud en Namibie.*

2. Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes en droit international

Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes constitue un principe cardinal du droit international. Il se trouve inscrit dans plusieurs textes conventionnels ainsi que dans des résolutions de l'Assemblée générale des Nations

unies. En outre, la Cour internationale de justice a mobilisé ce droit dans le cadre de sa compétence contentieuse ainsi que dans le cadre de sa compétence consultative.

2.1. La reconnaissance conventionnelle du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes

Selon les chiffres des Nations unies, en 1945, un tiers de la population mondiale vivait au sein de territoires colonisés. À l'issue de la Seconde Guerre mondiale, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes est introduit dans la Charte des Nations unies de 1945 dans ce contexte d'émergence de la décolonisation.

L'alinéa 2 de l'article premier reconnaît le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, qui apparaît également à l'article 55 de la Charte des Nations unies. En outre, le chapitre XI de la Charte des Nations unies est consacré aux territoires non autonomes, ce chapitre comporte les articles 73 et 74 ; le chapitre XII est relatif au régime international de tutelle. Un Conseil de tutelle est prévu à l'article 86, l'article 87 expose ses fonctions ; il a suspendu ses activités en 1994.

Bien qu'il n'ait pas été consacré de cette manière, il apparaissait en creux dans le Pacte de la Société des Nations de 1919, à son article 22 qui prévoyait que :

> *« Les principes suivants s'appliquent aux colonies et territoires qui, à la suite de la guerre, ont cessé d'être sous la souveraineté des États qui les gouvernaient précédemment et qui sont habités par des peuples non encore capables de se diriger eux-mêmes dans les conditions particulièrement difficiles du monde moderne. Le bien-être et le développement de ces peuples forment une mission sacrée de civilisation, et il convient d'incorporer dans le présent pacte des garanties pour l'accomplissement de cette mission. »*

En outre, ce droit apparaît en droit international des droits humains dans le Pacte international sur les droits civils et politiques ainsi que dans le Pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels de 1966.

L'article premier similaire des deux pactes est consacré à ce droit, indiquant que celui-ci implique de pouvoir déterminer librement le statut politique ainsi que d'assurer librement *« leur développement économique social et culturel »*. Leur dernier alinéa dispose que les États parties doivent faciliter la réalisation de ce droit ainsi que respecter ce droit.

Toutefois, au-delà de cette reconnaissance conventionnelle, il fait partie du droit international coutumier.

POUR ALLER PLUS LOIN

Dans son avis n° 2 du 11 janvier 1992, la Commission d'arbitrage pour la paix en Yougoslavie a affirmé que l'article 1er de ces deux pactes « établit que le droit à l'autodétermination est un principe protecteur des droits de l'homme. En vertu de ce droit, chaque être humain peut revendiquer son appartenance ethnique, religieuse ou linguistique de son choix ».

2.2. Les résolutions de l'Assemblée générale des Nations unies relatives au droit des peuples à disposer d'eux-mêmes

Plusieurs résolutions marquantes de l'Assemblée générale des Nations unies concernent le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes.

Parmi elles se trouve une résolution adoptée le 14 décembre 1960. Le droit de libre détermination des peuples, le droit à l'indépendance, ainsi que le droit à l'intégrité territoriale des peuples irriguent cette déclaration.

> → AGNU, Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, adoptée le 14 décembre 1960 par la résolution 1514 (XV).

Deux ans plus tard, le même organe a adopté une résolution au sein de laquelle il est indiqué que la souveraineté sur les richesses et les ressources naturelles constitue un *« élément fondamental du droit des peuples et des nations à disposer d'eux-mêmes »*.

> → AGNU, *Souveraineté permanente sur les ressources naturelles*, adoptée le 14 décembre 1962 par la résolution 1803 (XVII).

De plus, en 1970, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté une déclaration qui consacre des développements au droit des peuples à disposer d'eux-mêmes.

> → AGNU, Déclaration relative aux principes de droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations unies, adoptée le 24 octobre 1970 par la résolution 2625 (XXV).

En 2012, l'Assemblée générale affirme que *« le peuple palestinien a le droit de disposer de lui-même et d'exercer sa souveraineté sur son territoire »*.

> → AGNU, *Statut de la Palestine à l'Organisation des Nations unies*, adoptée le 29 novembre 2012 par la résolution 67/19

À la différence de certaines résolutions du Conseil de Sécurité, celles de l'Assemblée générale des Nations unies n'ont pas de valeur contraignante pour les États. Cette absence de valeur contraignante ne vide pas pour autant ces résolutions de tout intérêt.

Actualité politique. - La reconnaissance de l'État de Palestine par la France

La Palestine bénéficie depuis 2012 du statut d'État observateur non membre auprès des Nations unies. En 2024, l'Assemblée générale a considéré que l'État de Palestine remplissait les conditions d'admission prévues par l'article 4 de la Charte des Nations unies et a renforcé ses droits de participation aux travaux de l'Organisation. Son admission comme membre de plein droit demeure toutefois impossible en l'absence de recommandation du Conseil de sécurité, une telle recommandation ayant été empêchée en avril 2024 par le veto des États-Unis.

Une nouvelle étape a été franchie en septembre 2025. Le 12 septembre, l'Assemblée générale a adopté, par 142 voix contre 10 et 12 abstentions, la Déclaration de New York relative au règlement pacifique de la question palestinienne et à la mise en œuvre de la solution à deux États.

Le 22 septembre 2025, à l'occasion de la Conférence internationale de haut niveau organisée aux Nations unies, la France a officiellement reconnu l'État de Palestine. Cette reconnaissance s'inscrit notamment dans la reconnaissance du droit du peuple palestinien à l'autodétermination et dans la perspective d'une solution fondée sur l'existence de deux États. Plusieurs autres États ont procédé à une reconnaissance à la même période.

→ France, reconnaissance de l'État de Palestine, 22 septembre 2025.

→ AGNU, 12 septembre 2025, Déclaration de New York sur le règlement pacifique de la question de Palestine et la mise en œuvre de la solution à deux États, A/80/L.1/Rev.1.

À retenir. - La reconnaissance d'un État par d'autres États et son admission comme membre de l'ONU sont deux questions distinctes. La reconnaissance française du 22 septembre 2025 traduit la position de la France selon laquelle la Palestine possède la qualité d'État, mais elle ne modifie pas, à elle seule, son statut au sein des Nations unies. La Palestine demeure un État observateur non membre, l'admission à l'ONU supposant, conformément à l'article 4 de la Charte, une décision de l'Assemblée générale prise sur recommandation du Conseil de sécurité.

2.3. Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes dans la jurisprudence de la Cour internationale de justice

Le principe de l'*uti possidetis* (principe d'intangibilité des frontières) limite la libre détermination des frontières d'un État ayant accédé à l'indépendance.

Selon ce principe, un nouvel État doit conserver les frontières du territoire telles qu'elles étaient avant son indépendance. Dans un arrêt de 1986, la Cour internationale de justice a affirmé qu'il s'agit d'un principe général du droit international en matière de décolonisation afin d'éviter *« que l'indépendance et la stabilité des nouveaux États ne soient mises en danger par des luttes fratricides nées de la contestation des frontières à la suite du retrait de la puissance administrante ».*

> → CIJ, *Burkina Faso c. République du Mali*, 22 décembre 1986.

Dans un arrêt de 1995, la Cour internationale de justice a affirmé que le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes est un droit opposable *erga omnes,* en rappelant qu'il fait partie *« des principes essentiels du droit international contemporain »*.

→ CIJ, *Affaire relative au Timor oriental (Portugal contre Australie),* 30 juin 1995.

2.4. Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes dans les avis consultatifs de la Cour internationale de justice

Dans la lignée des avis de 1971 relatif aux *Conséquences juridiques de la présence de l'Afrique du Sud en Namibie*, ainsi que de celui de 1975 relatif au Sahara occidental, plusieurs avis consultatifs de la Cour internationale de justice abordent la question du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Malgré l'absence de valeur contraignante de ces avis, ils apportent tout de même des précisions importantes sur la portée du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, sur le droit à l'autodétermination.

En 2019, la Cour a énoncé que le droit à l'autodétermination est un droit humain fondamental. Par ce même avis consultatif, elle s'est prononcée sur le fait qu'au regard du droit international :

> *« Le processus de décolonisation de Maurice n'a pas été validement mené à bien lorsque ce pays a accédé à l'indépendance en 1968 à la suite de la séparation de l'archipel des Chagos. »*

Elle a ainsi affirmé que le Royaume-Uni était tenu de mettre fin à son administration de l'archipel Chagos.

> → CIJ, avis consultatif, 2019, *Conséquences juridiques de la séparation de l'archipel des Chagos de Maurice en 1965.*

En 2025, le Royaume-Uni a signé un accord de rétrocession de l'archipel à l'île Maurice.

S'agissant de la situation en Palestine, la Cour rappelle en 2004 le principe consacré par la résolution 2625 du droit des peuple à disposer d'eux-mêmes et le devoir qui en découle pour les États de s'abstenir de recourir à des mesures de coercition qui « priverait leur droit à l'autodétermination » ainsi que le droit international en la matière. Dans cet avis, elle a affirmé que *« l'existence d'un "peuple palestinien" ne saurait plus faire débat »*.

> → CIJ, avis consultatif, 9 juillet 2004, *Conséquences juridiques de l'édification d'un mur dans le territoire palestinien occupé.*

En 2024, la Cour était amenée à se prononcer sur la question de savoir si les politiques et pratiques d'Israël sur le territoire Palestinien occupé entravent le droit du peuple palestinien à l'autodétermination. La Cour a affirmé que la présence d'Israël dans le territoire palestinien occupé est illicite.

> → CIJ, avis consultatif, 19 juillet 2024, *Conséquences juridiques découlant des politiques et pratiques d'Israël dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est.*

Actualité jurisprudentielle. - Le droit à l'autodétermination implique le consentement du peuple concerné à l'application d'un accord international sur son territoire

La Cour de justice a précisé les conséquences du droit à l'autodétermination du peuple du Sahara occidental sur les accords conclus entre l'Union européenne et le Maroc.

Elle juge que le Sahara occidental constitue un territoire distinct du Maroc et que le peuple sahraoui est un tiers aux accords internationaux dont l'application est étendue à ce territoire. Son consentement constitue dès lors une condition de validité des décisions par lesquelles l'Union approuve de tels accords. Les accords commerciaux conclus en 2019 ont été jugés contraires aux principes d'autodétermination et d'effet relatif des traités, faute de consentement du peuple du Sahara occidental.

→ CJUE, GC., 4 octobre 2024, *Commission et Conseil c. Front Polisario*, aff. jointes C-778/21 P et C-798/21 P ; C-779/21 P et C-799/21 P.

À retenir. - Le droit à l'autodétermination ne constitue pas seulement un principe relatif à l'accession à l'indépendance. Il protège également le peuple concerné contre l'application à son territoire d'accords internationaux auxquels il n'a pas consenti.

POUR ALLER PLUS LOIN

Dans une observation générale du 13 mars 1984, le Comité des droits de l'homme a relevé que l'importance du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes tient au fait que sa « réalisation est une condition essentielle de la garantie et du respect effectif des droits individuels de l'homme ainsi que de la promotion et du renforcement de ces droits ».

3. Le droit des peuples dans les conventions régionales de protection des droits humains

La Convention européenne des droits de l'homme ne prévoit pas de droit spécifique accordé au peuple. La seule mention faite au peuple dans la Convention européenne réside à l'article 3 du Protocole n° 1 relatif au droit à des élections libres, mais il ne s'agit aucunement du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes.

Cependant, des textes régionaux de protection des droits humains accordent une place aux droits des peuples, y compris au droit des peuples à disposer d'eux-mêmes.

3.1. Une place centrale dans la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples

Comme son intitulé l'indique, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 1981 consacre une place importante à la notion de peuple. Le préambule de cette Charte mentionne à plusieurs reprises le colonialisme en Afrique.

L'article 19 de la Charte prévoit l'égalité de tous les peuples qui disposent de la même dignité et des mêmes droits. L'article suivant dispose du droit à l'existence des peuples, leur droit de se libérer.

L'article 21 insiste davantage sur la disposition des richesses et des ressources naturelles des peuples, l'article 22 sur le droit des peuples au développement économique, social et culturel, l'article 23 sur le droit des peuples à la paix et à la sécurité, notamment.

3.2. Les références aux peuples dans la Charte arabe des droits de l'homme

Dans une moindre proportion que la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, quelques développements sont consacrés au droit des peuples dans la Charte arabe des droits de l'homme de 2004.

Son article 2 est consacré au droit des peuples. Il prévoit explicitement le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes.

4. La notion de « peuple » en droit français

Le terme « peuple » apparaît à plusieurs reprises dans la Constitution du 4 octobre 1958. Le « peuple français » est mentionné dans son préambule, le « peuple » est indiqué à l'article 2 dans la célèbre phrase empruntée à Abraham Lincoln, le « gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple », à l'article 3 relatif à la souveraineté nationale, ainsi qu'à l'article 11.

De plus, l'article 72-3 de la Constitution prévoit que *« la République reconnaît, au sein du peuple français, les populations d'outre-mer, dans un idéal commun de liberté, d'égalité et de fraternité »*.

Dans une décision de 1975, le Conseil constitutionnel a affirmé la valeur constitutionnelle du principe de libre détermination des peuples d'outre-mer et de libre manifestation de leur volonté et a interprété l'application de dispositions de l'article 53 de la Constitution à l'aune du rattachement de Mayotte à la République française.

> → Cons. const., décision n° 75-59 DC, 30 décembre 1975, *Loi relative aux conséquences de l'autodétermination des îles des Comores.*

4.1. La valeur constitutionnelle du « peuple français »

En 1991, le Conseil constitutionnel a affirmé la valeur constitutionnelle du concept juridique de « peuple français ». Ainsi, il affirme que des dispositions législatives mentionnant le « peuple corse, composante du peuple français » sont contraires à la Constitution à l'aune de l'article 2 de la Constitution, qui prévoit que la République est indivisible, ce même article prévoyait (dans sa rédaction à la date de la décision) également l'égalité de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion.

> → Cons. const., décision n° 91-290 DC, 9 mai 1991, *Loi portant statut de la collectivité territoriale de Corse.*

La rédaction de plusieurs dispositions du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 apparaît alors en contradiction avec l'interprétation prétorienne de la notion de peuple. En effet, l'alinéa 16 évoque « les peuples d'outre-mer », l'alinéa 17 dispose que *« l'Union française est composée de nations et de peuples* […] *»*.

L'alinéa 18 de ce même texte prévoit que :

> *« Fidèle à sa mission traditionnelle, la France entend conduire les peuples dont elle a pris la charge à la liberté de s'administrer eux-mêmes et de gérer démocratiquement leurs propres affaires ; écartant tout système de colonisation fondé sur l'arbitraire, elle garantit à tous l'égal accès aux fonctions publiques et l'exercice individuel ou collectif des droits et libertés proclamés ou confirmés ci-dessus. »*

4.2. L'absence de ratification de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires

La Charte européenne des langues régionales ou minoritaires a été adoptée en 1992 sous l'égide du Conseil de l'Europe, elle est entrée en vigueur en 1998. Elle a vocation à promouvoir les langues régionales ou minoritaires dans la sphère privée ainsi que dans la sphère publique. 25 États ont signé et ratifié cette Charte, la France l'a signée en 1999, mais ne l'a jamais ratifiée.

Saisi par le président de la République, sur le fondement de l'article 54 de la Constitution, le Conseil constitutionnel a rendu une décision en 1999 relative à la conformité de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires à la Constitution. Le Conseil constitutionnel a considéré que plusieurs clauses de la Charte sont contraires à la Constitution en se fondant sur les articles 1er et 2 de la Constitution ainsi qu'à l'article 11 de la Déclaration de 1789.

Dans cette même décision, le Conseil constitutionnel affirme que le principe d'unicité du peuple français a une valeur constitutionnelle. Il a par ailleurs marqué le fait que les principes énoncés à l'article 1er de la Constitution :

> *« S'opposent à ce que soient reconnus des droits collectifs à quelque groupe que ce soit, défini par une communauté d'origine, de culture, de langue ou de croyance »* (Cons. const., déc. n° 99-412 DC, 15 juin 1999, *Charte européenne des langues régionales ou minoritaires*).

Le Conseil d'État, par un avis consultatif de 2015, n'a pas rendu un avis favorable à la ratification de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires.

> → CE, avis consultatif du 31 juillet 2015 relatif à la ratification de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires

POUR ALLER PLUS LOIN

Selon le Conseil de l'Europe, à l'aune des critères appréciés au regard de la Charte (langue, langue différente de la langue officielle, langue pratiquée traditionnellement, langue historique de l'Europe, langue encore parlée), elle trouverait à s'appliquer en France pour sept langues régionales. Le Conseil de l'Europe mentionne le basque, le breton, le catalan, le corse, le néerlandais (flamand occidental et néerlandais standard), l'allemand, et l'occitan.

Au regard de ce nombre de langues, le Conseil de l'Europe considère que les craintes tenant à l'application complexifiée de la Charte en France ne sont pas fondées.

Dans la continuité de sa jurisprudence, le Conseil constitutionnel a censuré plusieurs dispositions de la loi relative à la protection patrimoniale des langues régionales et à leur promotion en 2021. Il a notamment censuré les dispositions prévoyant la possibilité de dispenser un enseignement de langue régionale sous forme immersive en affirmant qu'elles entrent en contrariété avec l'article 2 de la Constitution.

> → Cons. const., décision n° 2021-818 DC, 21 mai 2021, *Loi relative à la protection patrimoniale des langues régionales et à leur promotion.*

4.3. Le statut dérogatoire de la Nouvelle-Calédonie

Le statut de la Nouvelle-Calédonie fait figure d'exception en droit constitutionnel et en droit des collectivités territoriales français.

Pour rappel, la France a pris possession de la Nouvelle-Calédonie en 1853. S'ensuit une histoire coloniale complexe au cours de laquelle les Kanaks ont fait l'objet d'un statut de l'indigénat, ce qui impliquait la privation de leurs droits civiques. Un processus de décolonisation s'est développé à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, processus au cours duquel ont émergé de façon croissante des revendications indépendantistes.

Actuellement, le Titre XIII de la Constitution est consacré à la Nouvelle-Calédonie, comportant deux articles, l'article 76 et l'article 77. L'article 76 mentionne les « populations de la Nouvelle-Calédonie ».

Cette spécificité constitutionnelle résulte de l'Accord de Nouméa de 1998, texte au sein duquel se trouve de multiples références explicites kanak, y compris au « peuple kanak » :

> *« La colonisation a porté atteinte à la dignité du peuple kanak qu'elle a privé de son identité. Des hommes et des femmes ont perdu dans cette confrontation leur vie ou leurs raisons de vivre. De grandes souffrances en sont résultées. Il convient de faire mémoire de ces moments difficiles, de reconnaître les fautes, de restituer au peuple kanak son identité confisquée, ce qui équivaut pour lui à une reconnaissance de sa souveraineté, préalable à la fondation d'une nouvelle souveraineté, partagée dans un destin commun. »*

Ce statut dérogatoire implique un transfert de compétences aux institutions de la Nouvelle-Calédonie, à travers les « Lois du pays ». Plusieurs référendums sur l'accès à l'indépendance ont eu lieu en 2018, 2020 et 2021 : le « non » l'a emporté à chaque fois. En 2021, le taux de participation au référendum était relativement faible.

De l'Accord de Nouméa résulte ce qui est appelé un « gel du corps électoral » pour les élections au Congrès et aux Assemblées de Provinces, ce gel implique des conditions restrictives pour être électeur, telle qu'une durée de domiciliation en Nouvelle-Calédonie depuis 1998, ou l'existence d'un lien de parenté avec une personne qui remplit les conditions pour être électeur au scrutin. Ces conditions sont inscrites dans une loi organique de 1999 (art. 188).

> → Loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.

En 2005, la Cour européenne des droits de l'homme a affirmé que ces restrictions du corps électoral ne portaient atteinte ni à l'article 3 du Protocole n° 1 relatif au droit à des élections libres, ni à l'article 56 relatif aux nécessités locales.

> → CEDH, 11 janvier 2005, *Py c. France*, n° 66289/01.

En 2024, il y a eu une volonté politique d'élargir ce corps électoral par une révision constitutionnelle afin de permettre à environ 25 000 personnes de pouvoir voter pour les élections en Nouvelle-Calédonie.

Ainsi, une loi organique d'avril 2024 visait à reporter les élections à décembre 2024 afin de dégeler ce corps électoral, ce qui a donné lieu à des émeutes en Nouvelle-Calédonie, l'état d'urgence a été déclaré du 15 au 28 mai 2024.

Finalement, il y a eu un nouveau report des élections pour fin 2025, et le Premier ministre a annoncé en octobre 2024 que le projet de loi constitutionnelle ne sera pas soumis au Congrès dans la perspective d'un dialogue sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie.

Actualité politique. - Un nouveau projet de statut pour la Nouvelle-Calédonie

À la suite de la crise de 2024 précitée, les négociations sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie ont conduit à la conclusion de l'accord de Bougival du 12 juillet 2025, complété par l'accord Élysée-Oudinot du 19 janvier 2026.

L'accord de Bougival s'inscrit expressément dans la continuité du processus de décolonisation et d'autodétermination ouvert par l'accord de Nouméa. Il prévoit notamment la création d'un « État de la Nouvelle-Calédonie » au sein de l'ensemble national, doté d'une capacité renforcée d'auto-organisation, ainsi que l'instauration d'une nationalité calédonienne cumulée avec la nationalité française.

→ Accord de Bougival, 12 juillet 2025, publié au JORF du 6 septembre 2025.

→ Accord complémentaire Élysée-Oudinot, 19 janvier 2026, publié au JORF du 24 janvier 2026.

Attention : Ces accords nécessitent une révision constitutionnelle et des textes organiques pour produire pleinement leurs effets. En l'état, le processus de révision constitutionnelle demeure en cours : les mécanismes projetés ne doivent donc pas être présentés comme constituant déjà le statut juridique en vigueur de la Nouvelle-Calédonie.

POUR ALLER PLUS LOIN

Les Nations unies ont dressé une « Liste des territoires non autonomes, classés par région » mise à jour le 9 mai 2024. Cette liste comporte 17 territoires au sein desquelles les populations sont considérées par les Nations unies comme ne s'administrant pas encore complètement elles-mêmes. Parmi ces territoires non autonomes se trouvent notamment le Sahara occidental ainsi que Gibraltar. Qui plus est, la Polynésie française ainsi que la Nouvelle-Calédonie figurent dans cette liste, dont la puissance administrante est la France.

4.4. Le statut particulier de la Corse

La Corse est un département français depuis 1790, dont le statut juridique a fait l'objet de récentes modifications. À grands traits, une loi du 13 mai 1991 confère à la Corse un statut particulier, cette dernière dispose d'une assemblée ainsi que d'un exécutif collégial.

→ Loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse.

De plus, une loi 2002 a été adoptée dans le but d'accorder une autonomie plus importante à la Corse par rapport aux autres régions. Jusqu'à devenir en 2018 une collectivité à statut particulier.

→ Loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse.

Il existe des mouvements de revendications autonomistes et indépendantistes en Corse, exacerbées depuis l'agression d'Yvan Colonna en 2022. Pour autant, les positions jurisprudentielles relatives à l'unité du peuple français ont récemment été réitérées.

Dans un arrêt de 2024, la justice administrative a annulé des règlements intérieurs de l'Assemblée de Corse au motif qu'ils prévoyaient l'usage dans les débats de la langue corse et de la langue française sur le fondement de l'article 2 de la Constitution, sans méconnaissance de l'article 75-1 de la Constitution.

→ CAA de Marseille, 4e chambre, 19 novembre 2024, 23MA01110.

Actualité politique. - Vers la reconnaissance constitutionnelle d'une autonomie de la Corse ?

Le statut de la Corse pourrait connaître une évolution substantielle. À la suite du « processus de Beauvau », un projet de loi constitutionnelle prévoit d'insérer dans la Constitution un nouvel article 72-5 reconnaissant à la Corse un « statut d'autonomie au sein de la République ». Le projet demeure cependant inscrit dans le titre XII relatif aux collectivités territoriales : la Corse resterait donc une collectivité territoriale à statut particulier relevant de l'article 72, et non une collectivité autonome d'outre-mer relevant de l'article 74 ou un territoire bénéficiant d'un statut constitutionnel comparable à celui de la Nouvelle-Calédonie. Le Conseil d'État a souligné le caractère inédit d'une telle autonomie accordée à une collectivité métropolitaine tout en maintenant son appartenance au régime constitutionnel de la décentralisation.

L'innovation principale réside dans la reconnaissance d'une autonomie normative. Dans les conditions déterminées par une loi organique, la Collectivité de Corse pourrait être habilitée non seulement à adapter certaines lois et certains règlements aux spécificités de son statut, mais également à fixer elle-même des normes dans les matières où s'exercent ses compétences. Il s'agirait ainsi de permettre à une collectivité territoriale métropolitaine d'intervenir, sur habilitation, dans des domaines relevant normalement du pouvoir législatif ou réglementaire national.

Cette autonomie demeurerait néanmoins fortement encadrée. Aucune habilitation ne pourrait porter notamment sur la nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés publiques, l'état des personnes, la justice, le droit pénal, la politique étrangère, la défense, la sécurité et l'ordre publics, la monnaie ou le droit électoral. Les normes adoptées par la Collectivité de Corse devraient en outre respecter le principe d'égalité et feraient l'objet d'un contrôle du Conseil d'État ou du Conseil constitutionnel, selon leur nature.

Le texte adopté par l'Assemblée nationale prévoit également qu'une loi organique puisse organiser un principe de non-régression par rapport aux normes nationales sociales et environnementales, ainsi qu'un mécanisme permettant au Gouvernement d'adapter par ordonnances certaines dispositions législatives aux spécificités corses. Enfin, les électeurs inscrits sur les listes électorales en Corse seraient consultés sur le projet de statut.

Cette évolution ne remet toutefois pas en cause, en l'état du projet, l'indivisibilité de la République, l'unicité du peuple français ou la primauté du français comme langue de la République. Le Conseil d'État a expressément analysé le projet comme instituant une autonomie normative dans le cadre de la République et de la décentralisation. La Corse demeurerait par ailleurs pleinement soumise au droit de l'Union européenne.

→ Projet de loi constitutionnelle pour *une Corse autonome au sein de la République*, déposé le 30 juillet 2025 ; texte adopté par l' Assemblée nationale en première lecture le 23 juin 2026, n° 318.

À retenir. - Le projet constitue une rupture importante avec le statut actuel : la Corse ne disposerait plus seulement de compétences administratives renforcées, mais pourrait être habilitée à exercer un véritable pouvoir normatif, y compris dans le domaine de la loi. Cette autonomie resterait néanmoins exercée au sein de la République, sous le contrôle des juridictions nationales et dans le respect des droits et libertés constitutionnels.

POUR S'ENTRAÎNER

Dissertation : Les implications du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes en France ?

Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes fait l'objet d'une reconnaissance multiple.

L'intérêt d'une telle analyse réside dans des revendications contemporaines d'indépendance hétérogènes en Nouvelle-Calédonie et en Corse, dont la réponse juridique apportée semble devoir se construire dans les années à venir.

Ces revendications s'inscrivent dans le cadre d'un État unitaire qu'est la France (art. premier la Constitution de 1958 « La France est une République indivisible ».)

Problématique et annonce de plan : L'exposé des contours du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes s'avère nécessaire **(I)** à la lecture de ses éventuelles applications à venir au sein de la République française **(II)**.

I. Les applications historiques du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes

A. Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes corolaire des processus de décolonisation

Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes a fait l'objet de plusieurs développements (relativement vagues) dans la Charte des Nations unies à l'issue de la Seconde Guerre mondiale. Plusieurs résolutions de l'Assemblée générale des Nations unies se sont saisies de ce droit dans la perspective de lui donner un contenu clair, un contenu plus éclairé par la Cour internationale de justice.

Dans le cadre de la décolonisation, il y a eu en France plusieurs référendums (comme à Mayotte et en Nouvelle-Calédonie) qui ont donné lieu à un rattachement à la France. Rappeler l'article 53 de la Constitution et son interprétation par le Conseil constitutionnel en 1975).

B. Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes en droit français

Si le droit français reconnaît un droit à l'autodétermination, le droit positif est clair sur la notion de « peuple français » (décision du Conseil constitutionnel de 1991 : *Loi portant statut de la collectivité territoriale de Corse* ; décision du Conseil constitutionnel de 1999 : *Charte européenne des langues régionales ou minoritaires*).

II. Des applications éventuelles à venir du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes en France

A. Une application incertaine à venir pour le cas de la Nouvelle-Calédonie

La Nouvelle-Calédonie dispose d'un statut dérogatoire. Plusieurs référendums sur l'accès à l'indépendance ont donné lieu au « non ».

Le projet de loi constitutionnelle relatif à la réforme du corps électoral a finalement été abandonné.

Le projet de réforme relatif au corps électoral mettait en présence deux points de vue : l'anomalie démocratique, car des milliers de personnes ne pouvaient pas voter / la conformité avec l'Accord de Nouméa qui prévoit une meilleure prise en compte de l'identité kanak.

Dans tous les cas, ce projet de réforme a donné lieu à un climat particulièrement sensible qui perdure en Nouvelle-Calédonie. Au regard des résultats des référendums ainsi qu'à l'instabilité actuelle en Nouvelle-Calédonie, l'application à venir du droit du peuple kanak à disposer de lui-même demeure incertaine.

B. L'actualité des débats juridiques sur l'avenir institutionnel de la Corse

Le statut de la Corse a évolué depuis 1982 (loi de 1982, loi de 1991, loi de 2002, loi de 2015).

Le 28 mai 2025, un rapport d'information (n° 1466) déposé par la commission des lois constitutionnelle, de la législation et de l'administration générale de la République traite de l'avenir institutionnel de la Corse. L'éventuelle issue de cette réforme serait la consécration d'un réel statut d'autonomie de la Corse.

La jurisprudence administrative récente sur l'usage de la langue Corse dans la sphère publique relance des débats sur la préservation de l'identité culturelle de l'île.

En conclusion, il semble délicat d'affirmer catégoriquement que le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes doive trouver à s'appliquer dans l'immédiat en France. Il existe une tension difficile à résoudre entre ce droit et l'intégrité territoriale de l'État (comparaison avec la Catalogne).

PARTIE VII. LES DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS

FICHE Nº 45

La liberté du commerce et de l'industrie

FICHE Nº 46

Le droit de propriété

FICHE Nº 47

Le droit à l'éducation et à la formation

FICHE Nº 48

Le droit à la santé et à la protection sociale

FICHE Nº 49

Le droit à un environnement sain

FICHE Nº 50

Le droit au travail

FICHE Nº 51

Le droit au logement

FICHE Nº 52

Le droit à la culture

Fiche nº 45 - LA LIBERTÉ DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE

POINTS CLÉS

- Une liberté protégée par le droit de l'Union européenne.
- Une liberté protéiforme.
- La valeur constitutionnelle asymétrique.

PRINCIPALES RÉFÉRENCES

- Articles 49 et 56 du TFUE.
- Cons. const., déc. nº 81-132 DC, 16 janvier 1982, *Loi de nationalisation.*
- CE 1er avril 2025, *La Quadrature du net et a.,* nos 494511, 494583 et 495174.
- CEDH, 13 juillet 2004, *Pla et Puncernau c. Andorre*, nº 69498/01.

1. La protection de la liberté d'entreprendre

1.1. La protection internationale de la liberté d'entreprendre

La liberté d'entreprendre n'a pas fait l'objet d'une vaste consécration par le droit international. Ni les deux pactes de 1966 ni la Convention européenne des droits de l'homme ne consacrent cette liberté.

Ce n'est ainsi que de manière ponctuelle que la Cour européenne des droits de l'homme analyse la conformité d'une restriction apportée à l'accès à une profession par rapport à la Convention.

> → La Cour européenne des droits de l'homme ne garantit donc pas en tant que tel le droit d'accès à une profession particulière : CEDH, 27 juillet 2004, *Sidabras et Džiautas c. Lituanie*, nos 55480/00 et 59330/00.

La consécration de cette liberté est toutefois intervenue au sein de l'ordre juridique de l'Union européenne.

Le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne consacre en effet plusieurs droits se rapportant à la liberté d'entreprendre.

> → Art. 34 et 45 TFUE sur la libre circulation des travailleurs, art. 49 sur la liberté d'établissement et d'accès aux activités non salariées, article 56 et 57 sur la libre circulation des prestations de service.

La Cour de justice a par ailleurs reconnu la liberté d'exercice du commerce, du travail et des activités professionnelles.

> → CJCE, 14 mai 1974, *Nold*, aff. nº 4-73.

Cette liberté a également été consacrée à l'article 16 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

1.2. La protection nationale de la liberté d'entreprendre

1.2.1. La reconnaissance constitutionnelle

La liberté de commerce et d'industrie tire son origine en France de l'article 7 de la loi des 2 et 17 mars 1791 dite « décret d'Allarde ». Cette loi vient en effet affirmer la liberté de chacun d'accès aux professions.

Cette dernière a été suivie par la loi des 14 et 17 juin 1791 dite « Le Chapelier » réaffirmant cette liberté professionnelle et interdisant les corporations professionnelles.

Ni le préambule de la Constitution de 1946 ni la Constitution du 4 octobre 1958 ne consacrent toutefois explicitement cette liberté.

Le Conseil constitutionnel a d'abord qualifié la liberté d'entreprendre de liberté publique avant de reconnaître qu'elle découle de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, lui conférant ainsi valeur constitutionnelle.

> → Cons. const., déc. n° 67-44 DC, 27 février 1967, *Nature juridique de diverses dispositions des titres I et II du Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme.*
>
> → Cons. const., déc. n° 81-132 DC, 16 janvier 1982, *Loi de nationalisation.*

La distinction entre cette liberté et la notion de liberté de commerce et d'industrie est toutefois peu perceptible. Le Conseil constitutionnel semble toutefois privilégier la mobilisation de la notion de liberté d'entreprendre.

Plusieurs autres libertés, essentielles à l'exercice d'activités économiques, sont également rattachées à la liberté de commerce et d'industrie. C'est le cas de la liberté d'établissement, de la liberté contractuelle et de la liberté de concurrence. Ces dernières n'ont toutefois pas fait l'objet d'une reconnaissance uniforme.

En tant que liberté fondamentale, la liberté d'entreprendre ne saurait toutefois être absolue. Selon les juges de la rue de Montpensier, il s'agirait en effet d'une liberté « ni générale, ni absolue ».

> → Cons. const., déc. n° 89-254 DC, 4 juillet 1989, *Loi relative aux modalités d'application des privatisations.*

Si le Conseil constitutionnel a désormais abandonné cette formule, la liberté d'entreprendre relève néanmoins toujours du régime des libertés et n'est donc pas absolue. Plusieurs types de limitations peuvent ainsi affecter cette liberté (autorisations préalables, exigences préalables à l'accès à une profession…)

> → Cons. const., déc. n° 2016-535 QPC, 19 février 2016, *Ligue des droits de l'homme.*

La valeur constitutionnelle de la liberté d'entreprendre ne la soustrait cependant pas aux limitations. Le législateur ne peut en effet adopter des limitations de nature à méconnaître manifestement cette liberté.

> → Cons. const., déc. n° 2017-756 DC, 21 décembre 2017, *Loi de financement de la Sécurité sociale pour 2018.*

La liberté d'entreprendre peut être conciliée avec d'autres droits ou objectifs constitutionnels.

> → Cons. const., déc. n° 2019-823 QPC, 31 janvier 2020, *Union des industries de la protection des plantes (protection de l'environnement).*

1.2.2. La jurisprudence administrative et judiciaire

Le Conseil d'État a très tôt reconnu la liberté de commerce et d'industrie, mais sa valeur a toutefois fait l'objet d'une évolution. Les juges du palais royal l'ont d'abord qualifié de principe général du droit.

> → CE, 20 décembre 1935, *Établissements Vezia*, n° 39234.

Avant de la qualifier de liberté publique au sens de l'article 34 de la Constitution.

> → CE, 28 octobre 1960, *de Laboulaye*, n° 48293.

Classiquement, le juge administratif considère que le législateur dispose du pouvoir de limiter cette liberté sans pour autant imposer d'autorisation préalable systématique.

> → CE, ass, 22 juin 1951, *Daudignac*, n° 00590 et 02551.

La liberté de commerce et d'industrie constitue également une liberté fondamentale susceptible de faire l'objet d'un référé-liberté sur le fondement de l'article L. 521-2 du Code de la justice administrative.

Le Conseil d'État n'a pas toujours recours à cette notion, il mobilise parfois la liberté de commerce et d'industrie de manière indépendante et parfois ne fera référence qu'à la liberté d'entreprendre.

> → CE, ord., 6 août 2021, n° 540228.

Le juge administratif semble néanmoins considérer de manière constante que la liberté de commerce et d'industrie constitue une composante de la liberté d'entreprendre, conçue comme un grand ensemble.

→ CE, ord., 12 novembre 2001, *Commune de Montreuil-Bellay*, n° 239840.

Cette liberté peut également être limitée en cas de circonstances exceptionnelles par les autorités administratives. Le Conseil d'État a toutefois exigé deux conditions cumulatives pour que le blocage intégral de l'accès à un service de communication soit conforme à la constitution :

- Cette mesure doit s'avérer indispensable pour répondre aux nécessités du moment.
- Le blocage doit être provisoire, il ne doit pas exister de mesure alternative moins attentatoire aux libertés et ce blocage ne doit pas excéder le temps nécessaire pour la recherche et la mise en œuvre de telles mesures alternatives moins attentatoires.

  → CE 1er avril 2025, *La Quadrature du net et a.*, n° 494511, 494583 et 495174 : annulation de l'interruption totale de l'accès au réseau social TikTok en Nouvelle-Calédonie.

Selon la Cour de cassation, la liberté de commerce et de l'industrie constitue une liberté fondamentale pouvant bénéficier de la procédure de la voie de fait. Les juges du Quai de l'Horloge ont ainsi estimé que le droit d'exercer une activité professionnelle constituait une liberté fondamentale.

→ Cass. civ. 1re, 16 avril 1991, n° 89-21.105.

Le juge judiciaire l'a également qualifié de principe général.

→ Cass. civ. 3e, 26 mars 1996, n° 93-19.059.

Il estime que la liberté du commerce et de l'industrie est directement invocable, notamment afin d'écarter des clauses contractuelles.

→ Cass. com. 26 mars 1996, n° 93-21250.

Cette liberté dispose d'un champ matériel élargi. Elle vise toutes les activités économiques (production, distribution achat, vente, prestations de services…). Partant, elle s'applique aux professions libérales (CE, 24 mai, 2017, n° 398801).

L'atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie peut résulter d'une réglementation des activités économiques soit de la prise en charge d'une activité économique par une personne publique

→ CE, 23 mai 2012, RATP, n° 348909.

Actualités jurisprudentielles

1/ La protection de la santé peut justifier l'interdiction d'une activité économique, mais non une interdiction générale disproportionnée

La liberté d'entreprendre, qui découle de l'article 4 de la Déclaration de 1789, peut être limitée pour assurer la protection de la santé. Encore faut-il que l'atteinte portée à cette liberté demeure proportionnée à l'objectif poursuivi.

En 2025, une « loi du pays » de Polynésie française avait interdit les sachets de nicotine et prévu, à compter de 2027, l'interdiction de la fabrication, de la distribution et de la vente de l'ensemble des produits du vapotage, y compris ceux ne contenant pas de nicotine.

Le Conseil d'État distingue les deux mesures. Il valide l'interdiction des sachets de nicotine au regard des risques sanitaires établis, de leur caractère fortement addictif et de leur promotion particulière auprès des jeunes. Une telle interdiction n'était pas manifestement inappropriée à l'objectif de protection de la santé.

En revanche, il censure l'interdiction de tous les produits du vapotage. La collectivité avait déjà prévu des mesures moins contraignantes, notamment l'interdiction de leur vente aux mineurs et l'encadrement de leur commercialisation. Interdire en plus, pour l'ensemble de la population, tout produit et composant de vapotage, y compris sans nicotine, constituait une interdiction générale et absolue portant une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre et à la liberté personnelle.

→ CE, 23 décembre 2025, *Sociétés Vape X et autres*, nos 508403, 508707 et 508794.

À retenir. - Un même objectif de santé publique peut justifier une interdiction ciblée sans autoriser pour autant la disparition complète d'une activité économique. Le contrôle de proportionnalité conduit le juge à rechercher si des mesures moins attentatoires permettent déjà d'atteindre l'objectif poursuivi.

2/ La protection de la santé peut justifier une suspension temporaire des importations

Dans un domaine harmonisé par le droit de l'Union, un État membre peut exceptionnellement adopter une mesure nationale de sauvegarde lorsqu'un risque sérieux pour la santé apparaît et que les institutions européennes n'ont pas elles-mêmes adopté les mesures nécessaires.

En janvier 2026, le Gouvernement français avait suspendu, par voie d'arrêté, l'importation et la commercialisation de nombreux fruits, légumes et céréales provenant de pays tiers lorsqu'ils contenaient des résidus quantifiables de cinq substances phytopharmaceutiques dont l'utilisation était interdite dans l'Union européenne. Ces produits demeuraient pourtant autorisés à l'importation lorsqu'ils respectaient les limites maximales de résidus fixées au niveau européen.

Le Conseil d'État valide la mesure. Il constate qu'elle reposait sur des données scientifiques fiables, récentes et suffisamment précises révélant un risque pour la santé humaine. Il vérifie également si des mesures moins contraignantes étaient envisageables. L'étiquetage spécifique ou la seule information des consommateurs n'offraient pas, en l'état des connaissances scientifiques, un niveau de protection équivalent. La suspension des importations était donc adaptée et proportionnée.

→ CE, 13 mai 2026, *Chambre syndicale des importateurs français de fruits et légumes,* n° 511530.

À retenir. - Une restriction importante à l'activité économique peut être admise pour protéger la santé, mais l'administration doit pouvoir démontrer la réalité scientifique du risque, l'efficacité de la mesure et l'insuffisance des solutions moins restrictives.

1.2.1. Les éléments de la liberté du commerce et de l'industrie

a. Le libre accès aux professions

Le législateur a pénalisé certains obstacles (art. 131-27 du Code pénal).

→ TA Versailles, ord., 28 mai 2020, n° 2003-065 et n° 2003-066.

b. Le libre exercice de la profession

Cela comprend la liberté d'exploitation et la liberté de gestion.

→ Cons. const., déc. n° 2012-285 QPC, 30 novembre 2012, *M. Christian S*.

→ CE, ord., 25 avril 2002, n° 245414.

→ CE, 26 août 2016, *SARL Rapid'apéro*, n° 402376.

→ Cons. const., n° 2021-824 DC, 5 août 2021, *Loi relative à la gestion de la crise sanitaire (obligation pour les salariés de présenter un pass sanitaire)*.

c. La liberté contractuelle

La liberté contractuelle est le corollaire de l'établissement des relations d'affaires en droit privé, laquelle comprend un aspect positif (la liberté de contracter) et un aspect négatif (la liberté de ne pas ou plus contracter).

→ Cons. const., déc. n° 2002-465 DC, 13 janvier 2003, *Loi relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi.*

→ La signature d'un contrat peut faire naître une espérance légitime chez un requérant au titre de l'article 1 du protocole n° 1 : CEDH, 24 novembre 2020*, Kurban c. Turquie*, n° 75414/10.

→ La Cour a consacré le droit de ne pas s'affilier à un syndicat : CEDH, GC., 11 janvier 2006, *Sørensen et Rasmussen c. Danemark*, n°s 52562/99 et 52620/99.

→ L'État peut ainsi commettre une violation s'il retient une interprétation en flagrante contradiction avec la Convention d'un contrat conclu entre particuliers : CEDH, 13 juillet 2004, *Pla et Puncernau c. Andorre*, n° 69498/01.

Elle concerne également la liberté de déterminer le contenu du contrat sous réserve de l'ordre public (art. 1102 al. 2 du Code civil).

d. La liberté de concurrence

Le Conseil constitutionnel persiste à ne pas reconnaître la valeur constitutionnelle de la liberté de concurrence. Toutefois, la loi sanctionne les actes de concurrence déloyale, les ententes ainsi que les abus de position dominante (voir par exemple les articles L. 420-1 et suiv. du Code de commerce).

Les cocontractants peuvent prévoir des limitations contractuelles à la liberté de commerce et d'industrie via des clauses de non-concurrence. La Cour de cassation opère toutefois un contrôle de proportionnalité de ces clauses notamment dans le cadre de litiges en matière de droit du travail. La clause doit ainsi être géographiquement et temporellement limitée, elle doit également permettre de protéger les intérêts légitimes de l'entreprise et tenir compte des spécificités de l'emploi du salarié. Elle doit en outre prévoir une contrepartie financière.

→ Cass. com., 11 mai 2017, n° 15-12.872.

POUR S'ENTRAÎNER

Dissertation : La soumission de la liberté d'entreprendre à des autorisations administratives.

Si la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 proclame la liberté comme principe, elle admet aussi que son exercice puisse être encadré pour garantir l'ordre public et l'intérêt général. La liberté d'entreprendre, fondement de l'économie de marché, n'échappe pas à cette logique.

Notions à aborder :

- Liberté d'entreprendre : principe à valeur constitutionnelle permettant à toute personne de créer, exercer et gérer librement une activité économique (Cons. const., décision n° 81-132 DC, 16 janvier 1982, *Loi de nationalisation*).
- Soumission à des autorisations administratives : procédure par laquelle l'exercice d'une activité économique est conditionné à l'obtention préalable d'une décision favorable d'une autorité administrative. Ces autorisations peuvent prendre la forme de licences, permis, agréments ou autorisations diverses.

Problématique : Dans quelle mesure la soumission de la liberté d'entreprendre à des autorisations administratives constitue-t-elle une conciliation légitime entre liberté économique et exigences d'ordre public, sans porter atteinte de manière disproportionnée à cette liberté fondamentale ?

I. L'articulation entre l'intérêt général et la liberté d'entreprendre

A. Une liberté constitutionnelle conciliable avec d'autres exigences constitutionnelles

Rattachement de la liberté d'entreprendre à l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme (liberté individuelle) et au Préambule de 1946 (alinéa 5 : droit d'obtenir un emploi et de choisir librement son activité professionnelle).

Exigences constitutionnelles avec lesquelles elle doit être conciliée : ordre public, santé publique, protection de l'environnement, dignité de la personne humaine (voir par exemple Cons. const., déc. n° 2013-346 QPC, 11 octobre 2013, qui met en exergue la nécessité de protéger les usagers).

B. Les régimes d'autorisation comme instruments classiques de police administrative économique

Diversité des régimes d'autorisation :

- Activités dangereuses ou sensibles (ex. : pharmacies, transports publics, professions juridiques).
- Réglementation économique spécifique (licences de taxis, licences de débit de boissons, marchés réglementés).

Tirer des exemples du Code de la santé publique, du Code des transports et du Code de commerce dans lesquelles l'autorisation vise la qualité du service rendu ou la préservation de l'équilibre économique (CE, SSR, 27 avril 1994, *Société Auchan*, n° 156860 : à propos des autorisations d'implantation commerciale).

II. Le contrôle des régimes d'autorisation

A. La proportionnalité des atteintes à la liberté d'entreprendre

Exigence de nécessité et d'adéquation des mesures restrictives (CEDH, 24 novembre 1986, *Gillow c. Royaume-Uni*, n° 9063/80 : la limitation d'une liberté fondamentale doit être justifiée, nécessaire et proportionnée). Le principe général posé par l'arrêt *Benjamin* est transposable à la police économique.

Le contrôle est renforcé dans les cas de restrictions lourdes ou discriminatoires (CE, 3 novembre 1997, *Société Million et Marais*, n° 169907 : contrôle de la compatibilité des décisions administratives avec les règles de concurrence. Voir également CJCE, 30 novembre 1995, *Reinhard Gebhard c. Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Milano*, aff. C-55/94 : les restrictions à la liberté d'établissement doivent être non discriminatoires, justifiées par des raisons impérieuses d'intérêt général, adaptées et nécessaires).

B. Les garanties juridictionnelles et procédurales

Possibilité de contestation des refus d'autorisation devant le juge administratif (CE, 17 février 1950, *ministre de l'Agriculture c. Dame Lamotte*, n° 86949).

Le juge administratif vérifie que la décision de refus d'autorisation est fondée sur des motifs légalement prévus, qu'elle poursuit un objectif d'intérêt général (protection de la santé publique, de la sécurité, de l'environnement…) et qu'elle respecte le principe de proportionnalité.

De plus, dans le cadre du contentieux de la responsabilité administrative, il est également possible d'obtenir réparation en cas de refus illégal d'autorisation ayant causé un préjudice économique, renforçant ainsi la protection effective de la liberté d'entreprendre.

En conclusion, si la soumission de la liberté d'entreprendre à des autorisations administratives constitue une restriction à un droit fondamental, elle apparaît globalement légitime et conforme aux exigences constitutionnelles et européennes dès lors qu'elle poursuit un objectif d'intérêt général et respecte les principes de nécessité, de proportionnalité. La multiplication des régimes d'autorisation soulève toutefois des interrogations sur la simplification administrative et la compétitivité économique, notamment à l'échelle de l'Union européenne où le principe de liberté d'établissement tend prévaloir.

Fiche n° 46 – LE DROIT DE PROPRIÉTÉ

POINTS CLÉS

- Un droit inviolable et sacré.
- Un droit relatif.
- Une définition autonome de la notion de « biens » par la Cour EDH.
- La protection contre l'expropriation illégale.

PRINCIPALES RÉFÉRENCES

- Art. 2 et 17 DDHC.
- Art. 1er du protocole n° 1 Conv. EDH.
- Art. 44 et suiv. du Code civil.
- Cons. const., déc. n° 89-256 DC, 25 juillet 1989.
- CE, 1er avril 2025, *La Quadrature du net et a.*, nos 494511, 494583 et 495174.
- CEDH, GC., 28 septembre 2004, *Kopecký c. Slovaquie*, n° 44912/98.
- CEDH, GC., 11 janvier 2006, *Sørensen et Rasmussen c. Danemark*, nos 52562/99 et 52620/99.

1. La protection du droit de propriété par la Convention européenne des droits de l'homme

Le droit de propriété fait l'objet d'une consécration disparate au sein du droit international. S'il a fait l'objet d'une consécration par la Déclaration universelle des droits de l'homme (art. 17), la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne demeure le seul texte contraignant l'ayant consacré (art. 17).

Ce droit ne figure pas au sein du texte initial de la Convention européenne des droits de l'homme. Il n'a été intégré à ce texte que dans second temps grâce à l'adoption du premier protocole additionnel en 1952.

L'article 1er du protocole n° 1 ne se limite toutefois pas au seul droit de propriété. Son champ d'application est en effet bien plus large puisqu'il assure un droit à la protection des biens.

> *« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »*

Cette notion de biens fait l'objet d'une définition autonome de la part de la Cour. Elle recouvre tout bien corporel ou incorporel (telle qu'une clientèle, des parts sociales). Mais également les prestations sociales et les créances constitutives d'une valeur patrimoniale.

> → CEDH, 26 juin 1986, *Van Marle et a. c. Pays-Bas*, nos 8543/79 8674/79.

Ces créances peuvent être qualifiées de bien, permettant ainsi l'application de cet article, qu'elles soient constituées ou seulement virtuelles lors de la saisine de la Cour dès lorsqu'il existe pour le requérant une espérance légitime à la voir se concrétiser.

> → CEDH, GC., *28 septembre 2004, Kopecký c. Slovaquie*, n° 44912/98.

Une espérance légitime d'obtenir une valeur patrimoniale doit être cependant suffisamment concrète. Elle doit en effet reposer sur une disposition législative interne ou un acte juridique telle qu'une jurisprudence.

→ CEDH, 26 janvier 2023, *Valverde Digon c. Espagne*, n° 22386/19.

La suppression de la jurisprudence *Perruche* par le biais de l'application immédiate de la loi du 4 mars 2002 aux instances en cours au jour de son adoption a fait l'objet de plusieurs requêtes auprès de la Cour européenne des droits de l'homme.

L'adoption d'une telle loi qui a eu pour effet de supprimer le droit des requérants à recevoir une indemnisation a ainsi été considérée comme une violation de la Convention. L'indemnisation constituait en effet selon la Cour européenne des droits de l'homme un bien pouvant être protégé au titre de l'article 1 du protocole n° 1, car les requérants pouvaient se prévaloir d'une espérance légitime à l'indemnisation de leur préjudice.

→ CEDH, GC., 6 octobre 2005, *Draon c. France*, n° 1513/03.

→ CEDH, GC., 6 octobre 2005, *Maurice c. France*, n° 11810/03.

La Cour a également estimé que l'application de la loi à des demandes en justice formulées auprès des juridictions internes postérieurement à l'adoption de la loi du 4 mars 2002, mais pour la réparation de préjudices survenus antérieurement à cette loi disposaient également d'une espérance légitime de voir leur créance se concrétiser.

→ CEDH, 3 février 2022, *N.M. et a. c. France*, n° 66328/14.

L'article 1 du protocole n° 1 a fait l'objet d'une profonde réécriture par la jurisprudence qui a permis d'élargir considérablement son champ d'application. La jurisprudence a en effet identifié trois normes (CEDH, 23 septembre 1982, *Sporrong et Lönnroth c. Suède*, n° 7151/75 et 7152/75).

- La première norme concerne la substance du droit de propriété. Elle s'applique quand les deux suivantes sont impossibles à activer.

  → CEDH, GC., 18 décembre 1996, *Loizidou c. Turquie*, n° 15318/89.

- La deuxième norme vise la privation de propriété.
- La troisième est issue du 2e alinéa de l'article concerne la réglementation par l'État de l'usage des biens.

  → CEDH, 2 décembre 2004, *Yaroslavtsev c. Russie*, n° 42138/02 : refus par les autorités de délivrer une carte d'immatriculation officielle pour un véhicule acheté par la victime.

2. La protection nationale du droit de propriété

Le droit de propriété est mentionné par deux fois au sein de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, aux articles 2 et 17.

> *« La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité. »*

Le Conseil constitutionnel a affirmé sa valeur constitutionnelle pour la première fois en 1982.

→ Cons. const., déc. n° 81-132 DC, 16 janvier 1982, *Loi de nationalisation.*

→ Cons. const., déc. n° 94-346 DC, 21 juillet 1994, *Loi complétant le Code du domaine de l'état et relative à la constitution de droits réels sur le domaine public (extension à la propriété de l'État et des personnes publiques).*

Le droit de propriété est également consacré au sein du Code civil à l'article 544. Il ne s'agit toutefois pas d'un droit absolu en dépit de la lettre de cet article puisque le législateur peut adopter des limitations à ce droit.

→ Cons. const., déc. n° 2011-169 QPC, 30 septembre 2011, *Consorts M. et a*.

Le Conseil constitutionnel retient une conception plus restreinte que celle de la Cour européenne des droits de l'homme. La protection qu'il accorde n'est en effet pas conditionnée à la notion de bien, mais à celle de propriété.

→ Cons. const., déc. n° 85-200 DC, 16 janvier 1986, *Loi relative à la limitation des possibilités de cumul entre pensions de retraite et revenus d'activité refus d'appliquer le droit de propriété à des prestations sociales.*

Le droit français protège néanmoins une diversité de biens pouvant faire l'objet d'une reconnaissance par la Cour. Le droit de propriété protège ainsi les biens immeubles ou meubles, mais aussi la propriété intellectuelle.

→ Cons. const., déc. n° 2020-841 QPC, 20 mai 2020, *La Quadrature du net.*

→ Cass. civ. 1re, 7 novembre 2000, n° 98-17.731 : admission de la patrimonialisation de la clientèle des professions libérales.

Actualités jurisprudentielles

1/ La vente d'un bien saisi au cours d'une enquête constitue une privation de propriété

Le régime constitutionnel applicable dépend de la nature de l'atteinte. Une simple limitation apportée à l'usage d'un bien relève de l'article 2 de la Déclaration de 1789. En revanche, lorsqu'une mesure entraîne la disparition du droit du propriétaire sur le bien, elle constitue une privation de propriété soumise aux exigences renforcées de l'article 17 : nécessité publique et juste et préalable indemnité.

En 2025, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la possibilité pour le juge des libertés et de la détention (JLD) d'autoriser l'AGRASC à vendre, avant même le jugement pénal, certains biens meubles saisis lorsque leur conservation risquerait d'en diminuer la valeur.

Le Conseil juge que la vente du bien entraîne bien une privation de propriété au sens de l'article 17, alors même qu'elle ne constitue pas encore une peine de confiscation. Il valide toutefois le dispositif. D'une part, la vente poursuit des objectifs de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice et de bon emploi des deniers publics, puisqu'elle permet d'éviter la dépréciation du bien et les frais liés à sa conservation. D'autre part, le produit de la vente est consigné et doit correspondre à la valeur du bien ; il est restitué au propriétaire si la procédure n'aboutit pas à sa confiscation.

Le Conseil précise enfin que l'exigence d'une indemnité « préalable » n'interdit pas que le produit de la vente demeure provisoirement indisponible afin de garantir notamment le paiement d'une éventuelle amende ou l'indemnisation des victimes.

→ Cons. const., déc. n° 2025-1156 QPC, 12 septembre 2025, *M. Eddir L. et autre*.

À retenir. - L'article 17 DDHC ne concerne pas uniquement l'expropriation immobilière. Toute mesure entraînant la disparition du droit du propriétaire sur un bien peut constituer une privation de propriété. Sa constitutionnalité suppose alors une nécessité publique ainsi qu'une juste et préalable indemnité.

2/ Réglementer l'usage d'un bien ne constitue pas nécessairement une privation de propriété

La loi du 19 novembre 2024 dite « Le Meur » permet, dans certaines copropriétés, de modifier le règlement de copropriété afin d'interdire la location de résidences secondaires en meublés de tourisme (de type AirBnB) à la majorité des deux tiers, alors qu'une telle modification nécessitait auparavant l'unanimité.

Le Conseil constitutionnel juge qu'une telle mesure ne prive pas le copropriétaire de son bien. Elle constitue seulement une limitation de ses conditions d'usage, relevant de l'article 2 de la Déclaration de 1789. Elle doit donc être justifiée par un motif d'intérêt général et proportionnée à l'objectif poursuivi.

Deux objectifs d'intérêt général sont retenus : la lutte contre les nuisances liées aux locations touristiques et contre la pénurie de logements destinés à la location de longue durée.

→ Cons. const., déc. n° 2025-1186 QPC, 19 mars 2026, *Société civile immobilière de la Barge rousse*.

À retenir. - Une restriction importante au pouvoir de jouissance du propriétaire n'est pas nécessairement une privation de propriété. Tant que le propriétaire conserve son bien et des possibilités substantielles de l'utiliser, la mesure peut relever de l'article 2 DDHC et du contrôle de proportionnalité, plutôt que de l'article 17.

POUR S'ENTRAÎNER

Commentaire de texte : Article 1er du protocole n° 1 :

« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »

Le droit de propriété était initialement absent du texte de la Convention européenne des droits de l'homme. Ce texte consacrait en effet lors de son adoption en 1950 uniquement des droits de nature civile et politique. Ce n'est donc qu'ultérieurement par le biais de l'adoption du premier protocole, en 1952, que le droit de propriété a intégré le système conventionnel. Ce texte est longtemps demeuré sous exploité. L'interprétation dynamique de la Cour européenne des droits de l'homme a toutefois permis une réécriture importante du régime de l'article 1er du protocole n° 1 et de ses conditions d'application.

Problématique et annonce du plan : Si l'article 1 du protocole 1 consacre le droit à la protection des biens contre les atteintes causées jusque dans les relations interindividuelles **(I)**, il ne consacre toutefois qu'un droit relatif à la protection des biens **(II)**.

I. La protection horizontale des biens contre les atteintes

A. Une protection contre les atteintes aux biens

La Cour a défini de manière autonome la notion de biens. Elle en adopte une conception large. Cette notion inclut ainsi les biens mobiliers ou immobiliers, corporels ou incorporels.

Les prestations sociales ainsi que les créances de sommes d'argent peuvent également être qualifiées en tant que tel (CEDH, GC., 28 septembre 2004*, Kopecký c. Slovaquie*, n° 44912/98).

Les créances constituées ou simplement virtuelles peuvent également être qualifiées de biens au sens de l'article 1 du protocole 1.

Les créances virtuelles doivent cependant être suffisamment concrètes pour être de nature à faire naître une espérance légitime chez la victime.

B. Une redéfinition jurisprudentielle des régimes juridiques des atteintes aux biens

La Cour européenne des droits de l'homme a redéfini le régime de l'article 1 du protocole 1 (CEDH, AP., 23 septembre 1982, *Sporrong et Lönnroth c. Suède*, n° 7151/75 et 7152/75).

La Cour a identifié trois régimes distincts, deux régimes spécifiques l'un fondé sur la privation du droit de propriété (2e phrase du 1er alinéa), l'autre concernant les réglementations par l'État de l'usage des biens (alinéa 2), et un principe général du respect de la propriété (1rephrase du 1er alinéa).

Cette réécriture a ainsi conféré une portée normative à la première phrase du premier alinéa.

Tandis que la deuxième norme vise le transfert ou la disparition de la propriété, l'atteinte visée par la troisième norme revêt un caractère davantage temporaire. La première norme quant à elle a permis d'étendre de manière conséquente le champ d'application de l'article, car elle recouvre les atteintes à la propriété ne pouvant rentrer dans le champ des deux autres normes.

II. La consécration d'un droit relatif à la protection des biens

A. La protection contre les atteintes illégitimes

La protection offerte par l'article 1 du premier protocole ne consacre pas un droit absolu. Il s'agit d'un droit relatif admettant que des atteintes justifiées soient commises par l'État.

Pour ce faire, les atteintes doivent être prévues par la loi, poursuivre un but légitime et s'avérer être nécessaires dans une société démocratique.

Afin d'apprécier ce dernier critère, la Cour analyse notamment la présence ou non d'indemnisation en contrepartie de l'atteinte à la propriété. Son absence est ainsi généralement constitutive d'une atteinte injustifiée lorsqu'est en cause la deuxième norme de l'article (CEDH, GC., 28 novembre 2002, *Ex-roi de Grèce et a. c. Grèce*, n° 25701/94).

B. La découverte d'obligations positives

L'article 1 du Protocole n° 1 s'applique que l'atteinte à la propriété soit causée par l'État ou par un particulier puisque l'article dispose d'un effet horizontal (CEDH, 29 janvier 2013, *Zolotas c. Grèce* (n° 2), n° 66610/09).

L'État doit ainsi assurer la protection du droit de propriété jusque dans le cadre des relations interindividuelles.

L'État doit permettre un accès aux recours permettant si nécessaire l'octroi d'une indemnisation.

S'assurer de l'exécution des décisions de justice au sein desquelles une somme pécuniaire est en cause (CEDH, 19 mars 1997, *Hornsby c. Grèce*, n° 18357/91).

En conclusion, loin d'avoir entraîné l'ajout d'un droit absolu à la Convention, l'entrée en vigueur du premier protocole en 1952 a consacré un droit relatif ayant fait l'objet d'une timide mobilisation par la Cour avant que cette dernière n'étende considérablement son champ d'application ainsi que les obligations découlant de son application.

Fiche n° 47 - LE DROIT À L'ÉDUCATION ET À LA FORMATION

POINTS CLÉS

- Principe de gratuité.
- Non-discrimination.
- Laïcité de l'enseignement.
- Liberté d'enseignement.
- Enseignement privé.
- Accès à la formation et à l'éducation.

PRINCIPALES RÉFÉRENCES

- Préambule de la Constitution de 1946.
- Art. 26 de la Déclaration universelle des droits de l'homme.
- Art. 2 du Protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme.
- Art. 24 de la Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement.
- Art. 13 du Pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels.
- Art. 28 et 29 de la Convention internationale des droits de l'enfant.
- Art. 1er et Point 10 de la Charte sociale européenne révisée.
- Art. 14 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
- Art. L. 6111-1 du Code du travail.
- Art. L. 111-1, L. 131-1 du Code de l'éducation.

Les termes d'« éducation » et de « formation » sont régulièrement évoqués ensemble dans les textes normatifs et témoignent de leur acception proche, souvent comprise comme se référant à la même idée du droit à l'instruction, pas uniquement à destination des enfants, mais qui concerne toute la vie en fonction des besoins.

L'instruction possède une double nature. C'est à la fois un droit fondamental comme l'attestent les multiples consécrations nationales et internationales (voir *infra*), mais dont l'exercice est obligatoire. Dans ce cadre, si le droit à l'instruction est valable tout au long de la vie, il nait dès l'âge de 3 ans puisque selon l'article L. 131-1 du Code de l'éducation, *« l'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans »*.

Cette place fondamentale de l'éducation se reflète par l'article L. 111-1 du Code de l'éducation mentionnant celle-ci comme la « première priorité nationale ».

1. Le cadre juridique du droit à l'éducation et à la formation

Le droit à l'éducation et à la formation englobe l'éducation au sens traditionnel du terme, renvoyant à la fois au parcours classique d'instruction des enfants jusqu'aux sphères académiques, ainsi qu'aux différents types de formations notamment professionnelles proposées aux adolescents et aux adultes tout au long de leur parcours individuel.

Ce droit dispose d'une base normative dans le bloc de constitutionnalité via le préambule de la Constitution de 1946 disposant dans son alinéa 13 *que « la Nation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction, à la formation professionnelle et à la culture. L'organisation de l'enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l'État »*.

Ce droit est garanti également par de nombreuses sources internationales et européennes parmi lesquelles l'article 26 de la Déclaration universelle des droits de l'homme énonçant les principes généraux liés au droit à l'éducation, ou l'article 13 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels qui dispose que l'éducation doit concourir à l'épanouissement de la personne humaine et renforcer le respect des droits de l'homme, contribuant également à favoriser la tolérance et la paix.

La Convention internationale des droits de l'enfant reconnaît également dans son article 28 le droit de l'enfant à l'éducation et son exercice « sur la base de l'égalité des chances », reprenant en substance les dispositions du Pacte. L'article 29 liste les objectifs que doit remplir l'éducation de l'enfant notamment concourir à son épanouissement et au développement de ses aptitudes mentales et physiques, *« inculquer à l'enfant le respect de ses parents, de son identité, de sa langue et de ses valeurs culturelles, ainsi que le respect des valeurs nationales du pays dans lequel il vit, du pays duquel il peut être originaire et des civilisations différentes de la sienne »*.

Le droit à l'éducation permet ainsi d'acquérir des compétences essentielles, mais forme également à la citoyenneté. Dans une société démocratique, le droit à l'instruction est ainsi indispensable à la réalisation des droits de l'homme et occupe une place fondamentale.

→ CEDH, 27 mai 2014, *Velyo Velev c. Bulgarie*, n° 16032/07.

Au niveau européen, la Convention européenne des droits de l'homme, dans l'article 2 du Protocole additionnel n° 1 prévoit que *« nul ne peut se voir refuser le droit à l'instruction. L'État, dans l'exercice des fonctions qu'il assumera dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement, respectera le droit des parents d'assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques »*.

Cette formulation négative souligne la marge d'appréciation dont disposent les États pour déterminer l'organisation et les types d'enseignement dispensés : le droit à l'instruction n'oblige pas les Parties contractantes *« à organiser à leurs frais, ou à subventionner, un enseignement d'une forme ou à un échelon déterminés »*.

→ CEDH, 23 juillet 1968, *Affaire « relative à certains aspects du régime linguistique de l'enseignement en Belgique » c. Belgique*, n° 1474/62, 1677/62 et suivants.

Actualité jurisprudentielle. - Le droit à l'éducation protège également contre l'endoctrinement scolaire

Lorsqu'il organise l'enseignement, l'État doit transmettre les connaissances de manière objective, critique et pluraliste et ne peut poursuivre un objectif d'endoctrinement contraire aux convictions des parents.

Dans cet arrêt dense, la Grande Chambre s'est notamment prononcée sur la politique éducative menée dans les territoires ukrainiens placés sous contrôle russe. Elle constate une suppression systématique de l'enseignement en langue ukrainienne ainsi que l'introduction dans les programmes scolaires d'un récit politique destiné à promouvoir la russification des élèves et à nier l'existence de l'Ukraine comme État souverain.

La Cour juge que cette politique poursuivait un objectif d'endoctrinement contraire aux convictions des parents et constituait une violation de l'article 2 du Protocole n° 1.

→ CEDH [GC], 9 juillet 2025, *Ukraine et Pays-Bas c. Russie*, requêtes nos 8019/16, 43800/14, 28525/20 et 11055/22.

À retenir. - Le droit à l'instruction ne garantit pas seulement l'accès matériel à une école. Il protège aussi la qualité démocratique de l'enseignement : l'État peut définir les programmes, mais il ne peut utiliser l'école comme instrument d'endoctrinement politique.

Nonobstant, cela n'implique pas que l'État n'est soumis à aucune obligation positives en matière de droit à l'éducation. Bien au contraire ! Il doit mettre en place les mesures adéquates pour en permettre l'exercice concret et effectif.

Au niveau législatif, deux sources principales sont à mentionner : le Code de l'éducation et le Code du travail, qui prévoit notamment dans son article L. 6111-1 la formation professionnelle tout au long de la vie.

2. Les principes structurant du droit à l'éducation

2.1. La gratuité de l'enseignement

C'est premièrement la loi du 16 juin 1881 qui établit la gratuité absolue de l'enseignement primaire dans les écoles publiques, mise en place par Jules Ferry.

Ce principe est par la suite abondamment rappelé au sein des conventions internationales, mais également par le Préambule de la Constitution 1946 qui lui confère une portée constitutionnelle.

Le Conseil constitutionnel a réaffirmé ce principe pour l'enseignement supérieur dans le domaine public en considérant que le principe de gratuité n'était pas violé dans le cas où l'établissement demandait des frais d'inscription « modiques » et adaptés aux capacités financières des étudiants (conformément également à l'article 14 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels). Il appartient alors *« aux ministres compétents de fixer, sous le contrôle du juge, les montants de ces droits dans le respect des exigences de gratuité de l'enseignement public et d'égal accès à l'instruction »*.

> → Cons. const., déc. n° 2019-809 QPC, 11 octobre 2019, *Union nationale des étudiants en droit, gestion, AES, sciences économiques, politiques et sociales et autres.*

2.2. Le caractère obligatoire de l'éducation

L'obligation scolaire, déjà prévue par les lois Ferry de 1881, est renforcée par la loi du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance modifiant l'article L. 131-1 du Code de l'éducation et disposant que *« l'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans »*, peu importe qu'elle soit *« donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés »* (art. L. 131-2).

La scolarité obligatoire doit garantir à chaque élève *« les moyens nécessaires à l'acquisition d'un socle commun de connaissances, de compétences et de culture »* (art. L. 122-1-1 du Code de l'éducation).

L'accès à la formation et le droit à l'éducation peuvent se rejoindre pour constituer une obligation légale jusqu'à la majorité selon l'article L. 114-1 du Code de l'éducation qui prévoit que *« la formation est obligatoire pour tout jeune jusqu'à l'âge de sa majorité. Le contrôle du respect de leur obligation de formation par les jeunes âgés de seize à dix-huit ans est assuré par les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes mentionnées à l'article L. 5314-1 du Code du travail, qui bénéficient à cet effet d'un dispositif de collecte et de transmission des données placé sous la responsabilité de l'État »*.

2. 3. La non-discrimination

Les dispositions internationales lient très étroitement le droit à l'éducation avec la non-discrimination en mentionnant une éducation pour « tous » et fondée sur « l'égalité des chances », faisant dès lors référence à une forme d'inclusion sociale. Elle implique une absence de discrimination qu'elle soit fondée sur le sexe, la religion, le milieu socio-économique…

L'article L. 112-2 du Code de l'éducation prévoit ainsi un droit à l'éducation, à la *« formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant »*, renforcé par l'article 15-1 de la Charte sociale européenne.

La Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement du 14 décembre 1960 en son article 24 de la Convention reconnaît un droit à l'éducation sans discrimination et inclusif, permettant l'accompagnement adéquat des personnes en situation de handicap. La Cour européenne a ainsi affirmé à plusieurs reprises qu'il y a lieu d'organiser des aménagements raisonnables pour corriger d'éventuelles inégalités nées d'une situation de handicap.

> → CEDH, 7 novembre 2024, *S. c. République Tchèque*, n° 37614/22.

L'égalité et la non-discrimination n'empêchent cependant pas la possibilité de soumettre les élèves à une sélection lors de certaines phases de leur enseignement.

> → CEDH, 9 juillet 2013, *Altinay c. Turquie*, n° 37222/04.

Celle-ci doit se faire selon des critères objectifs exempts de tout élément discriminant, à l'instar des opinions politiques des étudiants :

→ CE, ass., 28 mai 1954, *Sieur Barel*, n° 28238.

L'établissement peut en revanche utiliser des méthodes « dérogatoires » pour assurer la diversification de l'accès des élèves du second degré aux formations, et donc une meilleure mixité sociale :

→ Cons. const., déc. n° 2001-450 DC, 11 juillet 2001, *Loi portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel.*

Les critères d'admissibilité peuvent être connus *a posteriori* des candidats, comme l'a mentionné le Conseil constitutionnel à propos de l'application Parcoursup :

→ Cons. const., déc. n° 2020-834 QPC, 3 avril 2020, *Union nationale des étudiants de France.*

À noter : la digitalisation de l'enseignement, qu'il soit par l'utilisation d'un enseignement à distance ou par l'utilisation d'outils numériques, peut avoir pour conséquence d'accentuer les inégalités d'accès à Internet ou aux technologies du numérique. La fracture numérique peut dès lors être un frein concret à l'égalité des chances, les nouvelles technologies étant par ailleurs en forte expansion et constituant désormais un outil indispensable de l'enseignement et de la formation aux métiers d'avenir. Dans ce cadre, le Gouvernement porte une « Stratégie du numérique 2023-2027 » ayant conduit à la publication d'un document de synthèse le 28 mars 2025 incitant à la formation des professeurs des écoles dans ce domaine.

Le droit à l'éducation s'adresse également aux enfants migrants, qu'ils soient en situation régulière ou non. Dans son rapport sur le droit à l'éducation du 16 juillet 2021, le Secrétaire général des Nations unies rappelle que *« les articles 30 et 45 de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille protègent respectivement le droit des enfants des travailleurs migrants d'accéder aux établissements préscolaires ou scolaires publics, indépendamment de la régularité de leur séjour dans l'État, et le droit à l'éducation des membres de la famille des travailleurs migrants sur la base de l'égalité de traitement avec les nationaux de l'État concerné, tandis que l'article 3 de la Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement énonce explicitement la responsabilité des États parties d'accorder aux "ressortissants étrangers résidant sur leur territoire le même accès à l'enseignement qu'à leurs propres nationaux" »*.

Actualité jurisprudentielle. - L'égal accès à l'enseignement supérieur peut imposer l'aménagement des examens et concours pour des candidats en situation de handicap

L'égalité dans l'accès à l'éducation ne consiste pas nécessairement à soumettre tous les candidats aux mêmes conditions d'examen. L'article L. 112-4 du Code de l'éducation impose au contraire que les candidats présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant puissent bénéficier des aménagements rendus nécessaires par leur situation : temps supplémentaire, assistance, équipements ou dispositifs de communication adaptés.

En l'espèce, le CE précise que les conditions de déroulement d'un examen ou d'un concours ne constituent pas, par elles-mêmes, une liberté fondamentale. Toutefois, une carence caractérisée dans la mise en œuvre des aménagements auxquels un candidat handicapé a droit peut porter une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale et justifier l'intervention du juge du référé-liberté.

En l'espèce, un candidat atteint de dyslexie et de dysorthographie demandait, pour les concours d'entrée aux écoles de commerce, l'utilisation de logiciels spécifiques de correction ou, à défaut, que ses fautes d'orthographe ne soient pas prises en compte. Le Conseil d'État constate que plusieurs aménagements lui avaient déjà été accordés et estime qu'aucune carence grave et manifestement illégale n'était caractérisée.

→ CE, ord., 23 avril 2026, *Chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France*, n° 515053.

À retenir. - Le handicap ouvre un droit à des aménagements adaptés, mais non un droit à obtenir nécessairement l'aménagement précisément choisi par le candidat. L'administration doit rechercher une compensation effective et individualisée permettant de rétablir, autant que possible, l'égalité des chances. Une différence de traitement pour neutraliser un désavantage lié au handicap ne contrevient donc pas au principe d'égalité.

2.4. La protection de l'élève dans le milieu éducatif

L'accueil d'enfants dans des établissements scolaires implique également une attention particulière concernant leur protection.

La Cour européenne des droits de l'homme a reconnu une obligation positive de protection des élèves contre des mauvais traitements dans les écoles publiques et privées au titre de l'article 3, créant un écho tout particulier concernant les révélations relatives aux mauvais traitements dans les écoles privées catholiques en France ayant suscité débat et enquête parlementaires.

→ CEDH, 28 janvier 2014, *O'Keeffe c. Irlande*, n° 35810/09.

Dans cet objectif de protection, mais également d'inclusion, l'article L. 111-6 du Code de l'éducation interdit le harcèlement scolaire en renvoyant à l'article 222-33-2-3 du Code pénal permettant la mise en place des mesures visant à prévenir l'apparition de situations de harcèlement et à favoriser leur détection par la communauté éducative. Cet article, instauré par la loi du 2 mars 2022, s'inscrit dans le cadre d'une priorité nationale portée par le chef de l'État depuis 2017.

3. Le droit à la formation

Le droit à la formation constitue l'un des piliers du droit social.

Dès 1975, l'Organisation internationale du travail a développé la Convention n° 142 sur la mise en valeur des ressources humaines, afin d'inciter les États membres à *« développer des politiques et des programmes complets et concertés d'orientation et de formation professionnelles en établissant, en particulier grâce aux services publics de l'emploi, une relation étroite entre l'orientation et la formation professionnelles et l'emploi »* (art. 1).

Dans la Charte sociale européenne révisée de 1996, ce droit est inscrit comme un objectif pour tous les États parties, au point 10 de la 1re partie de la Charte : *« Toute personne a droit à des moyens appropriés de formation professionnelle »*. Un droit d'orientation professionnelle est également consacré dans la Charte en son article 9, et trouve une application concrète au niveau national par l'article L. 6111-6 du Code du travail disposant que *« toute personne peut bénéficier tout au long de sa vie professionnelle d'un conseil en évolution professionnelle, dont l'objectif est de favoriser l'évolution et la sécurisation de son parcours professionnel »*, par la création du Conseil en évolution professionnelle (CEP). Il est également réaffirmé par l'article 14 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

Au niveau national, ce sont le Code de l'éducation et le Code du travail qui régissent la matière.

Cet objectif est complété par l'article 1-4 sur le droit au travail, mentionnant que les États parties s'engagent *« à assurer ou à favoriser une orientation, une formation et une réadaptation professionnelles appropriées »*, ainsi qu'un article 10 sur le droit à la formation professionnelle encourageant à assurer et favoriser la formation professionnelle technique et professionnelle pour tous grâce à des mesures adéquates en permettant l'accessibilité.

Le droit à la formation professionnelle est également compris comme se fondant nécessairement sur l'égalité des chances et l'absence de discrimination (art. 20 de la Charte sociale européenne révisée), sans que cela fasse obstacle à l'intervention de certaines mesures « à titre transitoire », favorisant cette égalité et pouvant bénéficier à certaines catégories de la population comme les femmes (art. L. 6112-2 du Code du travail), ou les personnes en situation de handicap (art. L. 6112-3 du Code du travail).

La formation est également vue comme un outil de lutte contre la pauvreté (art. 30a de la Charte sociale européenne révisée), conditionnant le droit au travail et de nombreux droits économiques et sociaux.

Au sein des entreprises, l'employeur doit prévoir toutes les formations nécessaires et utiles à l'évolution de l'emploi et des fonctions pour minimiser les licenciements pour motifs économiques (art. L. 1233-4 du Code du travail). La loi du 5 septembre 2018 ouvre également le mécanisme de Compte personnel de formation (CPF) incitant à la formation professionnelle ainsi que rendant plus accessible les procédures et plus autonomes les individus cherchant à se former.

En revanche, concernant l'employé, le refus de se conformer à une formation imposée par l'employeur peut être constitutif d'un licenciement :

→ Cass. soc., 3 déc. 2008, n° 07-42.196.

POUR ALLER PLUS LOIN

Les détenus ont droit à l'enseignement de base, secondaire et supérieur (art. R 413-2 et suivants du Code pénitentiaire et défini par la circulaire n° 2020-057 du 9 mars 2020 du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche). Ils peuvent solliciter l'autorisation de suivre tout type d'enseignement, allant des cas d'analphabétisme, à la poursuite d'études supérieures. La demande doit être adressée au service pénitentiaire d'insertion et de probation, via le conseiller du détenu, et est accordée le cas échéant par le Juge d'application des peines, ce qui peut entraîner des permissions de sortie en fonction des enseignements suivis. Les formations professionnelles sont également possibles dans les conditions prévues par le Code pénitentiaire (cette possibilité est notamment prévue par les articles D113-60 et D113-63).

POUR S'ENTRAÎNER

Commentaire de texte : Cour des comptes et Chambre régionale et territoriale des comptes, L'enseignement primaire, Une organisation en décalage avec les besoins de l'élève, Rapport public thématique, mai 2025 [extraits].

« Le renforcement du capital humain est une des principales priorités de politique structurelle recommandée par l'OCDE. L'expérience montre que l'éducation des enfants joue un rôle fondamental pour le développement des compétences futures dans un monde en constante évolution. Un environnement et un accueil de qualité sont des composants indispensables pour favoriser la réussite scolaire de tous, en particulier ceux issus de milieux moins privilégiés. Or, pour améliorer ses performances, notre système scolaire doit réexaminer son organisation actuellement en décalage avec les besoins de l'enfant, renforcer l'attractivité de la fonction d'enseignant et adapter la gouvernance des écoles pour un management de qualité.

Un système éducatif en situation d'échec, des inégalités qui s'aggravent

L'échec scolaire constitue une des principales causes d'inefficacité pour les systèmes éducatifs. Le risque de quitter l'école prématurément, de ne pas pouvoir accéder aux filières qualifiantes ou d'y accéder dans de mauvaises conditions constitue un coût élevé, pour l'élève lui-même en obérant ses perspectives d'emploi, mais aussi pour la société qui a besoin d'une population active instruite pour stimuler l'innovation et la croissance économique à long terme. Or, en dépit d'une augmentation constante ces dix dernières années de la dépense consacrée à l'école primaire, le niveau des élèves a suivi une tendance inverse. Le déclin des performances scolaires des élèves, notamment vis-à-vis de nos voisins européens s'accompagne d'une incapacité de la politique éducative à résorber les fortes disparités de niveau, en particulier la proportion d'élèves qui sont en difficulté majeure. […]

Une organisation en décalage avec les besoins de l'enfant

L'ensemble des professionnels et des experts s'accorde à reconnaître le rôle majeur que l'éducation et l'accueil des jeunes enfants jouent dans le développement cognitif et émotionnel, l'apprentissage et le bien-être de la petite enfance. Les enfants qui bénéficient d'un enseignement structuré et de qualité, dès le plus jeune âge, sont les plus susceptibles d'avoir de bons résultats scolaires par la suite. Ce constat, scientifiquement établi, devrait par nature être universel. Il se vérifie moins, cependant, chez les enfants issus de milieux socio-économiques défavorisés, qui, trop souvent, ne bénéficient pas de toutes les possibilités de développement de leurs capacités dans le cadre strictement familial. **[…]** *»*

Le caractère fondamental du droit à l'éducation fait consensus au sein des instruments de protection des droits humains. C'est ce caractère essentiel à la fois pour l'enfant et la communauté qui est mis en avant dans le document présenté. Il s'agit d'un extrait de la synthèse du Rapport de la Cour des comptes sur l'éducation primaire, publié en mai 2025 et dressant un constat alarmant sur le système éducatif français. Celui-ci est déclaré être en « échec » puisqu'il n'atteint pas ses objectifs.

Ce texte, en plus de former une juste critique concernant la nécessité de la mise en place d'un système scolaire adéquate, inclusif et répondant aux besoins de l'enfant, conformément aux normes internationales et nationales, montre le délicat équilibre entre un droit individuel de l'enfant à l'éducation et les perspectives de la société vis-à-vis de ce droit. L'importance fondamentale du droit à l'éducation doit alors être soulignée en tant qu'exercice d'un droit humain particulier, mais également condition essentielle pour l'exercice de tous les autres. Néanmoins, selon ce rapport, l'école est vectrice d'inégalités et contribue même à les accentuer, en situation paradoxale avec le but du droit à l'éducation.

Problématique et annonce du plan : Le texte démontre d'une manière très juste que le système éducatif ne remplit pas correctement sa fonction sociale. En effet, il ne respecte pas les principes fondamentaux du droit à l'éducation **(I)**, cela emportant des conséquences néfastes pour la portée de ce droit, individuelle comme collective **(II)**.

I. Un système éducatif peinant à respecter ses principes fondamentaux

A. Une inégalité des chances structurelle

Le caractère égalitaire de l'école, particulièrement pour l'école primaire, a été soulevé très tôt, dès la Révolution française, pendant laquelle a été mise en avant la nécessité d'éduquer la population, notamment par Condorcet, Rousseau ou Diderot.

Or dans l'extrait, les obligations positives qui incombent à l'État pour la mise en œuvre du droit à l'éducation ne favorisent pas le développement des *« aptitudes mentales et physiques* [de l'enfant]*, dans toute la mesure de leurs potentialités »* (art. 29-1-a de la Convention internationale des droits de l'enfant).

L'inégalité est mentionnée comme touchant notamment les *« enfants issus de milieux socio-économiques défavorisés »*, mettant en avant le rôle supplétif essentiel de l'État dans l'éducation.

Cependant, si l'éducation doit en effet renforcer l'égalité et « développer le plein potentiel » des élèves, l'éducation ne permet plus une ascension sociale et reproduit les inégalités, ce qui constitue paradoxalement le but inverse du droit à l'éducation. La mixité sociale est pourtant un des buts des articles L. 111-1 et L 121-1du Code de l'éducation.

Ce rapport interroge également l'étendue des obligations incombant à l'État notamment concernant un droit personnel de chaque enfant à une qualité suffisante d'éducation, celui-ci dénonçant une inadéquation structurelle.

B. L'éducation, levier du droit à l'épanouissement

C'est un des éléments mis en avant dans le rapport, mais également central aux textes nationaux et internationaux : l'article 13 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels prévoit que *« l'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et du sens de sa dignité et renforcer le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales »*, faisant aussi écho à l'article 5 de la Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement de 1960, de même que l'article 29-1-a de la Convention internationale des droits de l'enfant, et à l'arrêt CEDH [GC], 19 octobre 2012, *Catan et a. c. Moldova et Russie*, n° 43370/04 et suivants.

La Cour européenne des droits de l'enfant indique par ailleurs elle-même que l'éducation est *« indispensable à la réalisation des droits de l'homme »* (CEDH, 23 février 2016, *Çam c. Turquie*, n° 51500/08).

L'épanouissement de l'enfant comme objectif pointé dans le rapport n'est donc pas uniquement un abus de langage, mais bien une obligation juridique (voir également l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant).

II. Les défaillances de la fonction sociale de l'éducation

A. L'éducation comme perspective professionnelle

Dans cet extrait, l'éducation constitue aussi et surtout un intérêt pour la société dans son ensemble par un renouvellement de la masse de travailleurs actifs, ce qui contraste avec le caractère utopiste de l'épanouissement individuel. Or, l'objectif défini par le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels en son article 13 est ici difficilement respecté.

L'éducation est un vecteur de développement socio-économique primordial : facteur de croissance, d'innovation et de cohésion sociale. L'échec scolaire représente donc un coût pour l'élève qui ne peut s'insérer correctement dans la société par l'accès « à des filières qualifiantes ». Le système éducatif et l'accession à des formations sont alors intrinsèquement liés, comme en témoigne la mention de l'OCDE.

Cette absence d'éducation adéquate vient dès lors remettre en question indirectement le droit à la formation, mais surtout les capacités d'y accéder. Le texte critique ainsi indirectement, mais avec pertinence le risque pour l'autonomie personnelle des élèves en tant que futurs travailleurs de pouvoir bénéficier d'un « droit au

travail » adapté effectif au sens de l'article 1 de la Charte sociale européenne révisée, ou de pouvoir à la fois utiliser leur formation pour lutter contre la pauvreté (art. 30a, Charte sociale européenne révisée). En effet, l'éducation doit permettre l'autonomie de l'enfant (Observation générale n° 1 Comité des droits de l'enfant, 2001) et lui permettre de répondre aux besoins liés à la mondialisation et aux changements majeurs des sociétés (*ibid*.), ce qui est questionnable dans cet extrait.

B. L'insuffisance et l'inconstance des mesures adoptées

La Convention des droits de l'enfant mentionne également un principe de non-régression (art. 28) dont le non-respect est vivement critiqué dans le rapport.

Malgré le caractère fondamental du droit à l'éducation pour l'élève et la société, les dernières mesures gouvernementales ne suffisent pas qu'elles portent sur le harcèlement : article L. 111-6 du Code de l'éducation ou sur les changements des temps de travail dans la semaine scolaire avec tout d'abord le décret du 24 janvier 2013, pris en application de la loi du 8 juillet 2013 imposant la semaine de 4,5 jours de travail, puis le décret du 27 juin 2017 offrant la possibilité de répartir de nouveau les enseignements sur quatre jours.

Le Gouvernement doit dès lors prendre des mesures beaucoup plus structurelles afin de remédier aux constats du rapport, mais aussi et surtout afin de respecter les principes fondamentaux du droit à l'éducation.

En conclusion, le rapport présenté montre les défaillances structurelles du système éducatif français au regard des normes fondamentales nationales et internationales et ses conséquences dévastatrices à l'échelle individuelle et collective pour l'épanouissement personnel.

Fiche nº 48 - LE DROIT À LA SANTÉ ET À LA PROTECTION SOCIALE

POINTS CLÉS

- Le droit à la santé se rattache aux dispositions du Préambule de 1946.
- Certains textes internationaux proclament un tel droit, mais leurs dispositions ne sont pas invocables directement dans l'ordre interne.
- Aux côtés du droit à la santé existe le droit à la protection sociale.
- Ce droit implique une action de l'État afin de mettre en œuvre des mécanismes et des organismes destinés à assurer la protection sociale des individus.
- Ce droit repose sur un principe d'égalité empêchant toute discrimination dans sa mise en œuvre.

PRINCIPALES RÉFÉRENCES

- Article 11 du Préambule de la Constitution de 1946.
- Article 22 de la Déclaration universelle des droits de l'homme.
- Cons. const., décision nº 2003-483 DC, 14 août 2003, *Loi portant réforme des retraites.*
- Cons. const., décision nº 89-269, 22 janvier 1990, *Loi portant diverses dispositions relatives à la Sécurité sociale et à la santé.*

1. Le droit à la protection de la santé

Le droit à la protection de la santé existe indépendamment du droit à la protection sociale. En effet, le droit à la protection sociale n'est qu'un mécanisme destiné à assurer une certaine protection du droit à la santé, mais ce n'est pas le seul.

L'article 12 § 1 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels évoque :

> *« Le droit à toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu'elle soit capable d'atteindre. »*

Ce texte n'évoque pas clairement un droit à la santé. La Charte sociale européenne va, quant à elle, s'y référer expressément.

Ce droit connaît des limites dans l'application des textes puisque d'une part, le Conseil d'État a retenu que ces deux textes n'étaient pas invocables dans l'ordre interne et qu'ils n'avaient donc pas d'effet direct.

→ CE, 7 juin 2006, *Association Aides,* nº 285576.

De même, la Convention européenne des droits de l'homme ne garantit pas, en tant que tel, le droit à la protection de la santé. Cependant, la Cour a tenté de dégager un tel droit de l'interprétation des articles 2, 3 et 8 de la Convention en prescrivant des obligations à la charge de l'État en matière de santé.

Cette obligation de l'État doit se manifester par la mise en place d'un cadre réglementaire propre à assurer un haut niveau de compétence chez les professionnels de santé. Cela se traduit aussi par une obligation pour l'État d'assurer aux détenus des conditions de détention propres à préserver leur État de santé.

→ CEDH, 26 octobre 2000, *Kudla c. Pologne,* nº 30210/96

En France, le Code de la santé publique se veut le relai de l'alinéa 11 du Préambule de 1946 qui garantit à tous une protection de la santé.

Par exemple, l'article liminaire du Code de la santé publique dispose que :

> *« Le droit fondamental à la protection de la santé doit être mis en œuvre par tous moyens disponibles au bénéfice de toute personne. »*

Cet article possède un fort caractère universel puisqu'il ne distingue pas entre les individus. En ce sens, l'article L. 1110-5 de ce Code prévoit que toute personne a, en raison de son état de santé et de l'urgence de l'intervention médicale, le droit de recevoir partout sur le territoire les traitements et soins adaptés et garantissant la meilleure sécurité sanitaire.

POUR ALLER PLUS LOIN

L'aide médicale d'État a été créée conformément à un objectif d'universalité de protection de la santé. Partant, il s'agit d'un dispositif qui doit permettre aux étrangers en situation irrégulière de bénéficier d'un accès aux soins. Elle permet d'être dispensé de l'avance des frais. Elle est attribuée sous conditions de résidence et de ressources.

1/ Actualité législative. - Le législateur renforce l'égal accès territorial aux soins palliatifs

La loi du 26 mai 2026 *visant à garantir l'égal accès de tous à l'accompagnement et aux soins palliatifs* renforce les obligations pesant sur les pouvoirs publics en matière de fin de vie.

L'accompagnement et les soins palliatifs doivent désormais garantir une prise en charge globale et de proximité, dans un délai compatible avec l'état de santé de la personne. La loi précise qu'ils doivent être accessibles sur l'ensemble du territoire national et que leur répartition doit garantir un accès équitable aux personnes malades.

Des organisations territoriales spécifiques, pilotées par les agences régionales de santé, doivent coordonner les professionnels et organismes intervenant localement. La loi instaure également une stratégie nationale pluriannuelle de l'accompagnement et des soins palliatifs et prévoit notamment le développement d'unités spécialisées, de maisons d'accompagnement et des prises en charge à domicile.

→ Loi n° 2026-404 du 26 mai 2026 visant à garantir l'égal accès de tous à l'accompagnement et aux soins palliatifs.

À retenir. - Le droit à la protection de la santé comporte une dimension territoriale : il ne suffit pas que des soins existent juridiquement, encore faut-il qu'ils soient effectivement accessibles. La loi de 2026 traduit cette exigence en matière de soins palliatifs par des obligations d'organisation, de planification et de répartition territoriale. Attention à ne pas la confondre avec la loi du 18 août 2026 relative au droit à l'aide à mourir.

2/ Actualité jurisprudentielle. - Le juge administratif ne peut déterminer lui-même la politique de lutte contre les déserts médicaux

L'accès effectif de la population aux soins constitue l'un des objectifs de la politique de santé, laquelle relève de la responsabilité de l'État. L'article L. 1411-1 du Code de la santé publique impose notamment de réduire les « *inégalités territoriales et de garantir l'accessibilité des parcours de santé* ».

L'UFC-Que Choisir demandait aux pouvoirs publics d'adopter plusieurs mesures contraignantes pour lutter contre les déserts médicaux : limitation de l'installation de médecins dans les zones suffisamment dotées, fermeture de l'accès au secteur 2 et suppression de certaines aides publiques.

Le Conseil d'État rappelle que le juge peut enjoindre à l'administration de prendre les mesures nécessaires lorsqu'elle méconnaît une obligation légale déterminée. Il ne peut, en revanche, se substituer aux pouvoirs publics pour définir ou modifier une politique publique. Or les mesures demandées impliquaient des choix portant notamment sur la liberté d'installation et les conditions tarifaires d'exercice des médecins.

→ CE, 1er octobre 2025, *Union fédérale des consommateurs - Que Choisir*, n° 489511.

À retenir. - Le droit à la protection de la santé n'implique pas que le juge puisse déterminer lui-même les moyens permettant d'assurer l'égalité territoriale d'accès aux soins. Il peut sanctionner la méconnaissance d'une obligation juridique, mais non substituer ses choix à ceux du législateur ou du Gouvernement en matière de politique sanitaire.

2. Les contours du droit à la protection sociale

La protection sociale est la combinaison de diverses techniques juridiques visant à prendre en charge des risques sociaux à un moment donné. Elle s'inscrit dans une démarche visant à répondre aux difficultés de l'existence ainsi qu'à la réduction des aléas socio-économiques.

À ce titre, l'individu doit être mis à même de vivre dignement et décemment et pour cela, la collectivité publique doit intervenir pour permettre à chacun de jouir de ce droit.

2.1. Les contours historiques du droit à la protection sociale

L'histoire du droit à la protection sociale se confond avec le développement des droits de solidarité au sens large.

Initialement, l'assistance aux nécessiteux était un devoir moral auquel la charité venait pourvoir dans un cadre religieux. Elle a longtemps été assurée en France par des institutions de l'Église catholique.

> ***POUR ALLER PLUS LOIN***
>
> *Ce n'est pas un hasard si encore au XXe siècle, de nombreuses associations d'aides aux plus démunis ont été créés par des religieux. On peut citer à titre d'exemples le Secours catholique en 1946 par l'Abbé Jean Rodhain ou encore Emmaüs en 1949 par le très problématique Abbé Pierre.*

À la veille de la Révolution française, la solidarité est sécularisée, mais n'est néanmoins pas érigée en obligation juridique de l'État.

Cette question de l'obligation juridique de l'État s'est véritablement concrétisée avec l'idée de « dette sacrée » consacrée par l'article 21 de la Constitution jacobine du 24 juin 1973 qui affirme que *« la Société doit la subsistance au citoyen malheureux »*.

Le XIXe siècle va marquer un tournant pour l'idée de protection sociale, notamment avec les revendications sociales et la montée en puissance des mouvements ouvriers dans une société en voie d'industrialisation.

La IIIe République permettra la naissance de grandes lois comme celle du 15 juillet 1893 sur l'assistance médicale gratuite ou encore la loi du 5 avril 1910 sur les retraites ouvrières et paysannes.

2.2. Les contours terminologiques du droit à la protection sociale

D'un point de vue terminologique, la protection sociale est souvent synonyme de sécurité sociale. Un tel sens est retenu dans l'article 22 de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui dispose que :

> *« Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale ; elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité, grâce à l'effort national et à la coopération internationale, compte tenu de l'organisation et des ressources de chaque pays. »*

À travers le prisme français, la sécurité sociale est bien plus restrictive que la protection sociale. En effet, la sécurité sociale est un instrument particulier de protection sociale passant notamment par l'instauration d'organismes et de mécanismes dédiés.

De même, l'idée de protection sociale est souvent confondue avec la notion de travail. On trouve l'expression « droit social » qui regroupe le droit du travail et celui de la protection sociale. La naissance de la protection sociale s'est faite dans le milieu salarié. Elle repose sur l'idée que ceux qui sont en âge et en condition de travailler doivent, par un mécanisme de solidarité, couvrir les besoins de ceux qui sont en difficulté.

Selon cette conception, on ne parle de protection sociale que dans les sociétés salariales.

Cette idée se retrouvait dans la volonté du Conseil national de la Résistance d'élaborer :

> *« Un plan complet de sécurité sociale visant à assurer à tous les citoyens des moyens d'existence dans tous les cas où ils seront incapables de se les procurer par le travail avec gestion appartenant aux représentants des intéressés et de l'État »* (CNR, Les jours heureux, 1944).

La protection sociale est, en France, dominée par la centralité de l'État. Il lui appartient de juguler l'insécurité en dressant un filet de protection sociale.

2.3. Les contours juridiques du droit à la protection sociale

Le droit à la protection sociale est un droit de solidarité. Il se caractérise par le fait qu'il implique l'intervention des collectivités publiques.

Dès lors, le droit à la protection sociale peut être défini comme un droit-créance destiné à protéger les individus contre les risques sociaux de la vie. Le droit à la protection sociale est un droit-créance en ce qu'il suppose l'intervention de l'État.

En effet, la réalisation d'un tel droit passe par l'octroi de prestations sociales. Il ne s'agit pas de protéger l'individu contre une immixtion de l'État dans sa sphère de liberté, mais plutôt de provoquer son intervention.

Pour autant, ce droit ne saurait avoir qu'une dimension active. Le droit à la protection sociale s'ordonne autour d'une trilogie dite *« obligation de respecter-obligation de protéger-obligation de mettre en œuvre ».*

2.4. Les contours pratiques du droit de la protection sociale

En France, il existe deux grands dispositifs qui assurent la protection sociale, à savoir la sécurité sociale et l'aide et l'action sociale.

La sécurité sociale est un dispositif contributif qui vise à protéger les personnes contre quatre types de risque dits sociaux à savoir la maladie, les accidents du travail, la vieillesse et la famille.

Le second dispositif repose quant à lui sur une logique non contributive d'assistance aux personnes en situation de vulnérabilité.

Le Conseil constitutionnel a jugé, à propos de la sécurité sociale, qu'il revenait au législateur d'organiser la solidarité entre personnes en activité, personnes sans emploi et retraités en même temps que de maintenir l'équilibre financier permettant à l'ensemble des institutions de sécurité sociale de remplir leur rôle. Il en a déduit que rien ne s'opposait à des transferts de ressources d'un régime vers l'autre, afin de financer des régimes d'assurances vieillesse déficitaires, particulièrement défavorisés en raison de la situation économique et sociale.

> → Cons. const., déc. n° 85-200 DC, 16 janvier 1986, *Loi relative à la limitation des possibilités de cumul entre pensions de retraite et revenus d'activité.*

3. La consécration dans les instruments internationaux de protection

L'article 25 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 stipule que :

> *« Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour tous les services sociaux nécessaires. »*

D'après cet article, les droits de solidarité impliquent donc au premier chef l'obligation pour les collectivités publiques de mettre les individus en situation de pourvoir à leurs besoins essentiels dans différents domaines.

Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels reconnaît le droit de toute personne à la sécurité sociale en son article 9, ainsi que le droit de chaque individu à un niveau de vie suffisant pour lui-même et sa famille et une amélioration constante de ses conditions d'existence en son article 9.

Enfin, la Charte sociale européenne évoque le droit à la sécurité sociale (art. 12) et le droit à l'assistance sociale et médicale (art. 13).

La difficulté de ces dispositions internationales réside dans le fait qu'elles ne sont pas directement invocables devant les juridictions ordinaires françaises.

Le Conseil d'État a jugé que, concernant les dispositions de l'article 11 du Pacte :

> *« Considérant qu'aux termes de l'article 11-1 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels :* […] *; que ces stipulations qui ne produisent pas d'effet direct à l'égard des particuliers, ne peuvent être utilement invoquées à l'appui de conclusions tendant à l'annulation d'une décision individuelle ou réglementaire »* (CE, 5 mai 2000, *Pinault,* n° 205043).

Il en est de même pour l'article 12 de la Charte sociale européenne.

> → CE, 15 mai 1995, *Rault,* n° 152417.

De son côté, la Cour européenne des droits de l'homme n'évoque pas un tel droit à la protection sociale même si les prestations sociales sont considérées comme des biens au sens de l'article 1er du protocole n° 1. Une telle analyse extensive permet de retenir que leur suppression s'analyse parfois comme une atteinte au droit au respect des biens.

> → CEDH, 12 octobre 2004, *Kjartan Asmundsson c. Irlande,* n° 60669/00.

4. La consécration du droit à la protection sociale en France

Du côté français, l'alinéa 11 du Préambule de 1946 garantit à tous la protection de la santé et de la sécurité matérielle et ajoute que :

> *« Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence. »*

A travers ces quelques dispositions, le Conseil constitutionnel a dégagé un certain nombre d'obligations pour l'État, destinées à protéger les individus à chaque stade de la vie. Par exemple, le Conseil constitutionnel a dégagé la nécessité de l'État de mettre en œuvre une politique de solidarité à destination :

- Des familles (Cons. const., déc. n° 37-393 DC, 18 décembre 1997, *Loi de financement de la Sécurité sociale pour 1998*).
- Des personnes handicapées (Cons. const., déc. n° 2018-772 DC, 15 novembre 2018, *Loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique*).

Le Conseil constitutionnel a fait application des principes de sécurité matérielle et de droit à des moyens convenables d'existence à de nombreuses reprises.

Dans sa décision n° 2003-483 DC du 14 août 2003, *Loi portant réforme des retraites*, le Conseil constitutionnel a déduit de l'article 11 du Préambule de 1946 une exigence constitutionnelle impliquant la mise en œuvre d'une politique de solidarité nationale à l'endroit des travailleurs retraités. Il s'ensuit que cette exigence donne un fondement constitutionnel aux prestations d'assurance-vieillesse.

> → Cons. const., déc. n° 2003-483 DC, 14 août 2003, *Loi portant réforme des retraites.*

POUR ALLER PLUS LOIN

Avant son entrée en vigueur, la très controversée réforme des retraites de 2023 a été déférée au Conseil constitutionnel. Dans une décision n° 2023-849 DC du 14 avril 2023, le Conseil constitutionnel a réitéré sa décision dégagée 20 ans plus tôt.

À ce titre, il a estimé que *« l'exigence constitutionnelle résultant des dispositions précitées implique la mise en œuvre d'une politique de solidarité nationale en faveur des travailleurs retraités. Il est cependant possible au législateur, pour satisfaire à cette exigence, de choisir les modalités concrètes qui lui paraissent appropriées. En particulier, il peut à tout moment, statuant dans le domaine qui lui est réservé par l'article 34 de la Constitution, modifier des textes antérieurs ou abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions. En outre, il peut adopter des modalités nouvelles dont il lui appartient d'apprécier l'opportunité afin de réaliser ou de concilier différents objectifs de nature constitutionnelle. Cependant, l'exercice de ce pouvoir ne saurait aboutir à priver de garanties légales des exigences de caractère constitutionnel »*.

Il retient que la réforme du système par répartition des retraites envisagée ne viole pas l'alinéa 11 du Préambule de 1946 puisqu'il viserait à en garantir la pérennité compte tenu de l'allongement de l'espérance de vie.

Néanmoins, le juge constitutionnel n'assure qu'un contrôle limité. Il reste loisible au législateur de rendre plus difficile l'accès à telle ou telle prestation. Il dispose d'un large pouvoir d'appréciation lui permettant de modifier dans un sens plus restrictif les conditions d'ouverture des droits à prestations en augmentant la durée de cotisation pour en bénéficier.

Il peut également prévoir que les assurés sociaux gardent à leur charge une partie des dépenses, à condition que celle-ci ne soit pas trop élevée, notamment par la mise en place une somme forfaitaire à la charge du bénéficiaire.

De son côté, le Conseil d'État a estimé que le principe de sécurité matérielle est, au moins pour l'enfant et sa mère, un principe général du droit permettant l'annulation d'un acte administratif qui lui serait contraire.

> → CE., 6 juin 1986, *Fédération des fonctionnaires, agents et ouvriers de la fonction publique et autres et sieur Goyeta*, n° 55751.

5. Le principe d'égalité dans le droit à la protection sociale

La question de l'égalité est au cœur de la protection sociale. C'est pourquoi, le droit à la protection sociale ne doit pas reposer sur des critères discriminatoires ou subjectifs.

En ce sens, dans sa décision n° 89-269 du 22 janvier 1990, le Conseil constitutionnel a affirmé le principe d'égalité entre les français et les étrangers dans l'attribution des prestations sociales. En l'espèce, il a déclaré contraire à la Constitution l'exclusion des étrangers du versement de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité.

> → Cons. const., déc. n° 89-269, 22 janvier 1990, *Loi portant diverses dispositions relatives à la Sécurité sociale et à la santé.*

La consécration de l'égalité dans le droit à la protection sociale ne signifie pas que tout le monde doit être traité de la même manière. En effet, le Conseil constitutionnel a introduit un tempérament à ce principe en retenant que le législateur peut réserver l'aide personnalisée au logement aux étrangers justifiant de la régularité de leur séjour.

> → Cons. const., déc. n° 93-325, 13 août 1993, *Maîtrise de l'immigration.*

La Cour européenne juge de manière régulière que des conditions d'octroi de prestations sociales fondées sur des critères discriminatoires sont susceptibles d'entraîner une violation de l'article 1er du premier protocole et de l'article 14 de la Convention.

→ CEDH, 16 septembre 1996, *Gayfusuz c/ Autriche,* n° 17371/90. Concernant la France, la Cour a estimé que la France ne pouvait refuser l'attribution de l'allocation adulte handicapé (AAH) au seul motif qu'il n'était pas de nationalité française. Partant, la Cour constate que l'allocation pouvait être accordée tant aux Français qu'aux ressortissants d'un pays ayant signé une convention de réciprocité avec la France à cette fin.

→ CEDH, 30 septembre 2003, *Koua Poirrez c/ France*, n° 40892/98 : le fait que le pays d'origine du requérant n'a pas signé une telle convention, alors même que le requérant s'était vu attribuer une carte d'invalidité, qu'il résidait en France, qu'il était fils adoptif d'un citoyen français résidant et travaillant en France et, enfin, qu'il avait préalablement bénéficié du RMI, ne saurait justifier, en soi, le refus de l'allocation litigieuse.

Si le principe d'égalité permet d'empêcher l'exclusion illégale de certaines personnes du bénéfice d'une prestation, il ne revêt toutefois pas une portée absolue. Il convient de préciser qu'en matière d'aide sociale, le Conseil constitutionnel a admis qu'une allocation répondant à une exigence de solidarité nationale soit cependant mise en œuvre par une collectivité territoriale.

→ Cons. const., n° 96-387 DC, 21 janvier 1997, *Prestation dépendance.*

Actualité jurisprudentielle. - L'accès aux soins ne peut dépendre de la situation administrative ou sociale du patient

L'article L. 1110-3 du Code de la santé publique interdit toute discrimination dans l'accès à la prévention ou aux soins. Cette interdiction protège notamment les bénéficiaires de l'aide médicale de l'État (AME).

En l'espèce, le Conseil d'État a sanctionné deux médecins ayant refusé de prendre en charge une enfant dont la mère bénéficiait de l'AME. Le premier avait conditionné la consultation à l'avance de frais dont la patiente était légalement dispensée ; le second avait refusé la consultation au motif qu'il ne disposait pas des documents administratifs nécessaires à sa prise en charge.

Le Conseil d'État juge que de telles circonstances ne peuvent justifier un refus de soins. Les difficultés rencontrées par le professionnel pour obtenir le remboursement des sommes dues par l'État sont également sans incidence. De même, orienter le patient vers un confrère ou constater l'absence d'urgence ne fait pas disparaître le caractère discriminatoire du refus.

→ CE, 27 février 2026, *Conseil départemental de Seine-Saint-Denis de l'ordre des médecins*, n° 501956.

À retenir. - Le principe d'égalité dans l'accès aux soins produit des obligations concrètes à la charge des professionnels de santé. Le bénéfice de l'AME ne peut justifier ni un refus de soins, ni l'exigence d'une avance de frais lorsqu'en vertu de la loi le patient en est dispensé.

POUR S'ENTRAÎNER

Commentaire de décision : CE, 8 septembre 2005, n° 284803

Placée au croisement du droit des libertés fondamentales et du droit pénitentiaire, la présente affaire met en cause les obligations de l'administration pénitentiaire à l'égard de la santé d'un détenu souffrant de pathologies cardiaques. M. X, incarcéré à la maison d'arrêt de Nantes depuis juillet 2002, subit un infarctus en juillet 2004. Bien que son état soit jugé compatible avec le maintien en détention, il demande ensuite à être placé dans une cellule non-fumeur, invoquant les risques du tabagisme passif sur sa santé. L'administration ne fait pas totalement droit à cette demande, notamment en raison de la volonté de l'intéressé de conserver son emploi aux cuisines. Le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, saisi par M. X sur le fondement de l'article L. 521-2 du Code de justice administrative, ordonne néanmoins au Garde des Sceaux de prendre des mesures visant à limiter l'exposition au tabagisme passif dans un délai d'un mois, notamment en le plaçant dans une autre cellule avec des détenus non-fumeurs.

À l'appui de sa demande, il soutient que lorsqu'il a saisi le juge des référés, il partageait sa cellule avec trois détenus fumeurs ; que, postérieurement à l'introduction de sa requête, deux non-fumeurs ont intégré sa cellule à la place de deux détenus fumeurs ; que le changement de cellule qui lui a été proposé le 23 août 2005 avec transfert a été refusé par lui au motif qu'il entraînait la perte de son emploi aux cuisines.

Problématique : dans quelles conditions l'exposition d'un détenu au tabagisme passif peut-elle constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, justifiant l'intervention du juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du CJA ? En d'autres termes, le droit à la santé est-il une liberté fondamentale invocable à l'occasion d'un référé ?

Pour y répondre, le Conseil d'État procède à une double analyse. Il écarte d'abord la qualification de liberté fondamentale pour le droit à la santé, tout en admettant certaines déclinaisons protectrices de la liberté personnelle (§1). Il apprécie ensuite de manière concrète les diligences de l'administration, concluant à l'absence d'atteinte grave et manifestement illégale (§2).

I. La reconnaissance encadrée des atteintes aux libertés fondamentales en milieu carcéral

A. L'exclusion du droit à la santé du champ de l'article L. 521-2 CJA

Dans un attendu de principe, le Conseil d'État rappelle que si la protection de la santé publique constitue un objectif de valeur constitutionnelle en vertu du Préambule de 1946, le droit à la santé ne saurait être considéré comme une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du Code de justice administrative.

Cette décision s'inscrit dans la lignée d'autres arrêts limitant la portée du droit à la santé. Par exemple, le Conseil d'État a retenu que le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels n'avait pas d'effet direct (CE, 7 juin 2006, *Association Aides,* n° 285576).

Le juge des référés de première instance avait quant à lui reconnu à la santé ce statut de liberté fondamentale, position ici censurée. Le Conseil d'État marque ainsi une limite claire entre les droits protégés par la Constitution et ceux qui, pour pouvoir justifier une intervention en référé-liberté, doivent présenter une dimension immédiate et fondamentale de la personne humaine, ce qui n'est pas toujours le cas du droit à la santé.

B. L'intégration de certaines composantes de la liberté personnelle

Malgré cette exclusion, le Conseil d'État n'écarte pas toute protection du détenu. Il souligne que certains droits dérivés du principe de liberté personnelle peuvent être protégés via l'article L. 521-2, notamment le droit de ne pas subir des contraintes qui excéderaient celles inhérentes à la détention.

Ainsi, le consentement éclairé aux soins ou le droit à un environnement respectueux de la dignité humaine, dans les limites de la contrainte carcérale, peuvent entrer dans le champ du référé-liberté. Ce raisonnement permet au juge de maintenir une exigence d'équilibre : il ne reconnaît pas un droit absolu à la santé, mais autorise un contrôle juridictionnel renforcé si les conditions de détention présentent un caractère manifestement excessif au regard des libertés fondamentales.

II. Le contrôle circonstancié des mesures administratives par le juge des référés

A. L'appréciation concrète des diligences administratives

La deuxième étape du raisonnement du Conseil d'État consiste à examiner de manière factuelle les efforts déployés par l'administration pour réduire l'exposition de M. X au tabagisme passif. Il relève notamment que des ajustements ont été faits à la suite des mesures de grâce présidentielle, permettant de placer M. X avec deux codétenus non-fumeurs et un troisième renonçant à fumer en sa présence par correction.

Par ailleurs, le Conseil d'État souligne que le maintien de M. X au service des cuisines, à sa demande, limite les possibilités de changement de cellule. Il en déduit que l'administration a pris des mesures adaptées aux contraintes pénitentiaires, sans pour autant nier la persistance d'un risque résiduel.

B. L'absence d'atteinte grave et manifeste excluant l'intervention du juge

En dernier lieu, et sans même examiner la condition d'urgence, le Conseil d'État juge qu'aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n'est caractérisée. Cette formulation, exigée par l'article L. 521-2 du CJA, constitue un seuil élevé, qui n'est franchi qu'en cas d'inaction manifeste ou de mépris volontaire des droits fondamentaux.

En l'espèce, l'administration a mis en œuvre une gestion pragmatique et réactive de la situation de M. X, ce qui suffit à exclure l'intervention du juge du référé-liberté. L'ordonnance du tribunal administratif est donc annulée, et les conclusions de M. X rejetées.

En conclusion, cet arrêt témoigne d'une ligne jurisprudentielle constante du Conseil d'État : le référé-liberté est un outil puissant, mais strictement encadré, même dans le cadre sensible de la détention. L'exclusion du droit à la santé en tant que liberté fondamentale ne signifie pas que les détenus soient privés de toute protection juridictionnelle, mais le juge exige que l'administration ait failli de manière manifeste.

Fiche nº 49 - LE DROIT À UN ENVIRONNEMENT SAIN

POINTS CLÉS

- Création jurisprudentielle du droit à un environnement sain par la CEDH.
- Création d'obligations positives.
- Distinction entre les contentieux environnementaux et les contentieux climatiques.
- Distinction entre le droit de l'environnement et le droit à un environnement.

PRINCIPALES RÉFÉRENCES

- Art. 8 Conv. EDH.
- Art. 1 Charte de l'environnement (2004).
- CEDH, 9 décembre 1994, *López Ostra c. Espagne*, nº 16798/90.
- CEDH, GC., 30 novembre 2004, *Öneryildiz c. Turquie*, nº 48939/99.
- CEDH, GC., 9 avril 2024, *Verein Klimaseniorinnen Schweiz et a. c. Suisse*, nº 53600/20.
- Cons. const., déc. nº 2011-116 QPC, 8 avril 2011, *Michel Z. et a.*
- CE, 1er juillet 2021, *Commune de Grande-Synthe*, nº 427301.

Droit de l'environnement et droit à l'environnement sont souvent amalgamés. C'est à tort même s'il existe des passerelles évidentes : le droit de l'environnement constitue l'instrument juridique permettant de réaliser concrètement le droit à l'environnement.

Nonobstant, le sujet diffère. Le droit de l'environnement regroupe l'ensemble des règles juridiques visant à protéger la nature, les ressources et les écosystèmes, notamment par des normes, des sanctions et des mécanismes de prévention. Le droit à l'environnement, quant à lui, désigne un droit subjectif reconnu aux individus ou aux peuples, leur garantissant de vivre dans un environnement sain, propre et durable.

1. La prise de conscience planétaire des enjeux environnementaux

L'apparition du droit de l'environnement au sein du droit international est intervenue au cours des années 1970. La Déclaration du 16 juin 1972 ou « Déclaration de Stockholm » adoptée à la suite de la Conférence des Nations unies sur l'environnement a ainsi été le premier texte international à consacrer le droit à un environnement sain même si la problématique principale de ce texte reste celle du droit de l'environnement.

Le droit international universel s'intéresse davantage au droit de l'environnement. Une multiplication des textes portant sur la protection environnement devenue indispensable et sur la nécessité de ralentir, voire enrayer, le changement climatique. Ainsi, en juin 1992 à l'occasion du 20e anniversaire de la conférence de Stockholm, la Conférence des Nations unies sur l'environnement et le développement (CNUED) ou « Sommet de la Planète Terre » s'est déroulé à Rio. Cette conférence a abouti à l'adoption de plusieurs textes dont la Déclaration de Rio et la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CNUCC).

Le Protocole de Kyoto adopté en décembre 1997 a permis de compléter cette dernière Convention en formulant les premiers objectifs chiffrés de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

En décembre 2015, la Conférence des Nations unies sur les changements climatiques s'est achevée avec l'adoption des Accords de Paris visant notamment à la réduction de l'émission des gaz à effet de serre dans le but de limiter à 2 °C le réchauffement climatique d'ici 2100.

Nonobstant, la plupart de ces textes ne font pas l'impasse sur le droit à un environnement sain. Au contraire, ils établissent avec force le lien entre les deux impératifs.

On discerne des problématiques liées au droit à une environnement dans des instruments relevant du droit international des droits humain comme le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (1966) qui protège le droit à la santé ou à un niveau de vie suffisant ou encore la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (2007) qui garantit les droits de ces derniers sur leurs terres et ressources naturelles avec un lien direct à la préservation de l'environnement.

Récemment, le Conseil des droits de l'homme des Nations unies a consacré le droit à un environnement propre et sain dans une résolution n° 48/13 du 8 octobre 2021.

2. La protection par ricochet opérée par la Cour européenne des droits de l'homme

Comme à l'échelle internationale, le Conseil de l'Europe s'est préoccupé des questions environnementales dès 1970 avec l'organisation à Strasbourg de la Conférence européenne sur la conservation de la nature.

Toutefois, la protection du droit à un environnement sain *stricto sensu* est beaucoup plus tardive et à mettre au crédit de la Cour européenne des droits de l'homme.

La Convention européenne des droits de l'homme ne garantissant pas explicitement ce droit, c'est grâce à l'interprétation dynamique de la Cour que ce droit a été protégé en tant que droit dérivé du droit à la vie privée (art. 8 Conv. EDH).

Depuis sa découverte prétorienne par la Cour, la question environnementale est devenue très présente au sein de sa jurisprudence puisque près de 300 affaires s'y rapportent.

La Cour n'a cependant pas pour mission de sanctionner les atteintes générales à l'environnement en tant que telles, ni d'assurer la préservation de la nature. Ces éléments ne sont en effet susceptibles de tomber sous la compétence de la Cour que lorsqu'elles affectent ou risquent d'affecter l'un des droits garantis par la Convention, il s'agit donc d'une protection par ricochet.

> → CEDH, 22 mai 2003, *Kyrtatos c. Grèce*, n° 41666/98.

La notion d'environnement au sens de la Convention est extrêmement vaste. Elle s'applique en effet aux atteintes à l'environnement telles que la pollution ou la dégradation d'un milieu naturel, mais également aux diverses nuisances pouvant affecter les individus (sonores, visuelles, olfactives…).

> → Exemple de nuisances sonores engendrées par un aéroport proche du domicile du requérant : CEDH, 21 février 1990, *Powell et Rayner c. Royaume-Uni*, n° 9310/81.

La Cour a initialement tiré le droit à un environnement sain de l'application de l'article 8 de la Convention, mais sa protection peut désormais être assurée par une multiplicité d'autres fondements conventionnels.

La Cour a élaboré des conditions exigeantes pour qu'une allégation d'atteinte puisse engendrer un constat de violation sur ces fondements.

2.1. La protection de l'environnement sain par l'application de l'article 2

La Cour a admis l'applicabilité de l'article 2 en cas d'atteintes graves à l'environnement causées par des activités industrielles dangereuses pouvant mettre en péril la vie d'individus.

> → En cas d'émissions de substances chimiques nocives par une usine : CEDH, GC., 19 février 1998, *Guerra et a. c. Italie*, n° 14967/89.
>
> → En cas d'exploitation de sites de stockage de déchets : CEDH, GC., 30 novembre 2004, *Öneryildiz c. Turquie*, n° 48939/99.

Il n'est alors pas nécessaire que l'activité en cause ait été menée par l'État puisqu'il dispose d'obligations positives au titre de l'article 2.

> → CEDH, GC., 30 novembre 2004, *Öneryildiz c. Turquie*, n° 48939/99.

Il n'est pas non plus nécessaire que la personne soit décédée, simplement qu'elle ait subi un risque réel et immédiat pour sa vie du fait de cette activité.

> → CEDH, 16 octobre 2003, *Fadeïeva c. Russie*, n° 55723/00.

Très récemment, la Cour a constaté dans le cadre d'une procédure d'arrêt pilote que l'Italie avait manqué à ses obligations positives découlant de l'article 2 en n'agissant pas pour mettre fin au problème de déversement, d'incinération et de l'enfouissement de déchets sur des terrains privés en Campanie.

→ CEDH, 30 janvier 2025, *Cannavacciuolo et a. c. Italie*, n°s 51567/14 39742/14 et 74208/14.

2.2. La protection de l'environnement sain par l'application de l'article 8

Un constat de violation de l'article 8 pourra être dressé par la Cour lorsque la pollution ou les nuisances auront eu pour effet d'affecter le bien-être de la victime ou de la priver de la jouissance de son domicile de manière à nuire au respect de la vie privée et familiale.

→ CEDH, 9 décembre 1994, *López Ostra c. Espagne*, n° 16798/90.

Les atteintes au droit à l'environnement sain sont principalement rattachées par la Cour au droit au respect du domicile sur le fondement de l'article 8.

→ CEDH, 16 novembre 2004, *Moreno Gómez c. Espagne*, n° 4143/02.

La victime doit avoir gravement souffert des nuisances ou des autres formes de pollution. Cela ne signifie cependant pas que la victime doit avoir subi une atteinte à sa santé.

→ CEDH, 27 janvier 2009, *Tătar c. Roumanie*, n° 67021/01.

La Cour a en outre estimé qu'un risque d'exposition à un danger environnemental pouvait constituer une violation de l'article 8 pour autant que celui-ci s'avérait suffisamment grave.

- → CEDH, GC., 9 avril 2024, *Verein KlimaSeniorinnen Schweiz et a. c. Suisse*, n° 53600/20.

La Cour exige sur le fondement de l'article 8 une double condition s'agissant des caractéristiques de l'atteinte à l'environnement : elle doit être suffisamment grave et directe.

- L'appréciation du seuil de gravité s'opère de manière concrète, en prenant notamment en considération des critères tels que l'intensité et la durée des nuisances ou leurs conséquences sur les requérants.

  → CEDH, 9 septembre 2014, *Chiş c. Roumanie*, (déc.), n° 55396/07.

  → CEDH, 8 juillet 2003, *Hatton et a. c. RU*, n° 36022/97.

- Il est également exigé que les requérants soient en mesure d'établir un lien de cause à effet direct entre ces nuisances et leurs droits issus de l'article 8 de la Convention (le droit au respect du domicile, de la vie privée, ou de la vie familiale).

  → CEDH, 4 février 2020, *Çiçek et a. c. Turquie*, (déc.), n° 44837/07.

  → CEDH, 19 février 1998, *Guerra et a. c. Italie*, n° 14967/89.

2.3. Les obligations découlant de la protection du droit à un environnement sain

L'État doit, au titre des articles 8 et 2, s'abstenir de commettre des ingérences injustifiées.

Il est également tenu à des obligations positives de s'assurer que des atteintes à l'environnement ou des nuisances causées par des personnes privées ne portent pas atteinte aux droits d'autres individus.

→ Sur le fondement de l'article 8 : CEDH, 9 décembre 1994, *López Ostra c. Espagne*, n° 16798/90.

→ Sur le fondement de l'article 2 : CEDH, GC., 30 novembre 2004, *Öneryildiz c. Turquie*, n° 48939/99.

Les obligations positives de l'État dans le cadre d'atteintes portées à l'environnement sont largement similaires, que la requête soit traitée sous l'angle de l'article 8 ou de l'article 2. Ses obligations se dédoublent en effet.

L'État doit tout d'abord respecter des obligations positives matérielles d'adopter des mesures nécessaires afin d'éviter la survenance de l'atteinte. Il peut également être obligé d'adopter un cadre administratif ou législatif

apte à prévenir, réparer les préjudices voire à punir les atteintes ou les risques d'atteinte découlant de nuisances ou de pollutions environnementales.

→ Sur le fondement de l'article 8 : CEDH, 27 janvier 2009, *Tătar c. Roumanie*, n° 67021/01.

→ Sur le fondement de l'article 2 : CEDH, GC., 30 novembre 2004, *Öneryildiz c. Turquie*, n° 48939/99.

En matière d'activités dangereuses, l'État peut en outre être tenu à une obligation de prévention et d'information.

→ CEDH, GC., 19 février 1998, *Guerra et a. c. Italie*, n° 14967/89.

Les risques d'atteintes à la vie doivent cependant être réels (c'est-à-dire suffisamment graves) et immédiats pour pouvoir entraîner un constat de violation.

→ CEDH, 24 juillet 2014, *Brincat et a. c. Malte*, n°s 60908/11 et a.

L'État est ensuite tenu par des obligations procédurales d'enquêter sur les activités privées ayant porté atteinte aux droits d'autrui, et, le cas échéant, de réparer le préjudice voire d'en sanctionner l'auteur.

→ Sur le fondement de l'article 8 : CEDH, 27 janvier 2009, *Tătar c. Roumanie*, n° 67021/01.

→ Sur le fondement de l'article 2 : CEDH, GC., 30 novembre 2004, *Öneryildiz c. Turquie*, n° 48939/99.

L'État dispose d'une marge nationale d'appréciation variable. Cette marge est plus large en matière d'environnement que lorsque les mesures litigieuses affectent des aspects intimes des individus.

→ CEDH, 8 juillet 2003, *Hatton et a. c. Royaume-Uni*, n° 36022/97.

2.4. Le contentieux climatique et protection de l'environnement sain par l'application de l'article 6 § 1

Récemment la Cour a eu à traiter de trois affaires ne portant pas exclusivement sur la question environnementale, mais en partie sur celle du changement climatique. Même si elle a précisé que la jurisprudence en matière environnementale n'était pas pleinement transposable aux litiges relatifs à la question climatique en raison des spécificités de cette dernière notamment en matière de qualité de victime ou de lien de causalité, elle a rendu un arrêt spectaculaire dans lequel elle condamne l'État défendeur pour son inaction climatique.

→ CEDH, GC., 9 avril 2024, *Verein Klimaseniorinnen Schweiz et a. c. Suisse*, n° 53600/20.

Dans cette affaire, elle retient la violation de l'article 6 § 1 en raison de l'absence de recours effectif permettant de mettre en œuvre les mesures internes relatives au changement climatique.

Si la marge nationale d'appréciation des États est étroite s'agissant de la prise en compte du changement climatique, elle demeure néanmoins large pour ce qui concerne le choix et la mise en œuvre effective des mesures.

3. La constitutionnalisation du droit à un environnement sain

Les premières apparitions du droit à un environnement sain se sont fait ressentir en France à partir des années 1970 consécutivement au premier Sommet pour la Terre qui s'est tenu à Stockholm en 1972.

Avant 2004, aucun droit fondamental à un environnement sain n'existait cependant. L'approche restait classiquement celle du droit de l'environnement.

→ CE, SSR, 15 mars 1968, *Commune de Cassis et Sieur Bodin et autres*, n°s 69312, 69315, 69326, 69327, 69328, 69329 et 69334.

→ La loi du 7 janvier 1983 dite « Loi Defferre » (n° 83-8) avait ainsi octroyé une compétence aux communes, départements, régions et l'État notamment pour ce qui concerne la protection de l'environnement et l'amélioration du cadre de vie.

Malgré l'adoption de quelques lois comme la loi n° 95-101 du 2 février 1995 dite « Loi Barnier », la protection du droit à l'environnement sain s'opérait essentiellement par le truchement de la notion d'ordre public à travers sa composante de la salubrité publique.

→ CE, 13 janvier 1988, *Syndicat national de la production autonome d'électricité*, n°s 35009 et 35063.

→ Pour des nuisances sonores : CE, 21 juin 1999, n° 179612, Commune de La Courneuve.

Ce droit est désormais consacré au sein du Code de l'environnement à l'article L. 110-2.

→ Pour une application récente voir CE, 25 mars 2025, n° 486318.

Puis dans un contexte mondial de multiplication des normes en matière environnementale, la France s'est dotée par mimétisme d'un texte constitutionnel, la Charte de l'environnement, directement intégrée dans le Préambule de la Constitution par la loi constitutionnelle du 1er mars 2005 n° 2005-205.

Ce texte élaboré sous la direction du paléontologue Yves Coppens comprend 10 articles consacrant des notions connues du droit international de l'environnement tel que le principe de prévention (art. 3), de précaution (art. 5) ou le droit à un environnement sain (art. 1er).

La Charte fait donc partie du bloc de constitutionnalité, au même titre que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ou que le préambule de la constitution du 27 octobre 1946.

→ CE, Ass., 3 octobre 2008, Commune d'Annecy, n° 297931

Toutes les dispositions de la Charte n'ont cependant pas de portée identique bien qu'elles aient toutes une valeur constitutionnelle. La Charte contient ainsi à la fois des droits et des devoirs, mais aussi des dispositions au sein de son préambule qui ne peuvent être qualifiées de droit ou de liberté.

Ce texte constitue néanmoins une norme de référence permettant au Conseil constitutionnel d'exercer son contrôle.

→ Cons. const., déc. n° 2008-564 DC, 19 juin 2008, *Loi relative aux organismes génétiquement modifiés.*

→ Cons. const., déc. n° 2014-394 QPC, 7 mai 2014, *Société Casuca (Plantations en limite de propriétés privées).*

Le juge constitutionnel a conféré à l'article 1er de la Charte un plein effet direct : il peut aussi bien être invoqué par les requérants dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité, que dans le cadre d'un litige interindividuel.

→ Cons. const., déc. n° 2011-116 QPC, 8 avril 2011, *Michel Z. et a.*

Le juge administratif a lui aussi admis l'invocabilité directe de l'article 1er de la Charte de l'environnement relatif au droit à l'environnement sain dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir.

→ CE, 26 février 2014, *Association Ban Asbestos France*, n° 351514.

Le Conseil d'État a également réaffirmé l'importance de ce droit en relevant que le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé présente les caractères d'une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du Code de la justice administrative. Ce droit est donc susceptible de faire l'objet d'un référé liberté.

→ CE, ch. Réunies, 20 septembre 2022, *M. B… et a.*, n° 451129 et 451129.

Le Conseil constitutionnel a également eu l'occasion de préciser la portée du droit à un environnement sain.

→ Celui-ci vaut aussi bien pour les générations présentes, mais aussi pour les générations futures : Cons. const., déc. n° 2023-1066 QPC, 27 octobre 2023, *Association Meuse nature environnement et autres.*

Ses modalités de mise en œuvre sont définies par le législateur et par les autorités administratives.

→ Cons. const., déc. n° 2024-868 DC, 17 mai 2024, *Loi relative à l'organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour répondre au défi de la relance de la filière nucléaire*.

Actualité jurisprudentielle. - L'acétamipride et le contrôle des atteintes au droit à un environnement équilibré

Le Conseil constitutionnel a précisé la portée du droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé à l'occasion du débat relatif à la réintroduction de certains néonicotinoïdes.

Pour rappel, en 2025, le législateur avait prévu la possibilité de déroger à l'interdiction d'utiliser des produits phytopharmaceutiques contenant des néonicotinoïdes ou des substances assimilées, dispositif destiné notamment à permettre le recours à l'acétamipride. Le Conseil constitutionnel reconnaît que la protection des capacités de production agricole et la lutte contre les distorsions de concurrence constituent un motif d'intérêt général. Il rappelle néanmoins que toute limitation au droit garanti par l'article 1er de la Charte doit être justifiée par une exigence constitutionnelle ou un motif d'intérêt général et demeurer proportionnée.

En août 2025, les Sages censurent le dispositif en raison de son encadrement insuffisant : la dérogation pouvait concerner toutes les filières agricoles, n'était pas limitée à une période déterminée et pouvait autoriser tous les modes d'utilisation, y compris la pulvérisation. Compte tenu des incidences de ces substances sur la biodiversité, l'eau, les sols et la santé humaine, le législateur avait ainsi privé de garanties légales le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. La censure est directement fondée sur l'article 1er de la Charte, sans que le Conseil ait eu besoin d'examiner les griefs tirés notamment des principes de prévention et de précaution.

→ Cons. const., déc. n° 2025-891 DC, 7 août 2025, *Loi visant à lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur*.

En 2026, le législateur a adopté un dispositif beaucoup plus strict, permettant notamment une dérogation à l'utilisation de l'acétamipride pour la seule culture de noisettes. Celle-ci est exceptionnelle, accordée pour un an et renouvelable deux fois, et subordonnée notamment à l'existence d'une menace grave pour la production, à l'absence d'alternative suffisante ainsi qu'à une évaluation des risques par l'ANSES. La dérogation ne peut être accordée si elle est susceptible d'engendrer des risques significatifs pour la santé humaine ou de porter une atteinte grave et irréversible à l'environnement.

Le Conseil constitutionnel valide cette fois le dispositif, sous deux réserves : l'ANSES doit pouvoir limiter géographiquement la dérogation en fonction de la réalité locale de la menace et, si elle n'a pu vérifier dans le délai légal que toutes les conditions sont réunies, son silence vaut refus. Compte tenu de ces garanties et du caractère temporaire du dispositif, la limitation apportée au droit garanti par l'article 1er de la Charte est jugée proportionnée au motif d'intérêt général poursuivi.

→ Cons. const., déc. n° 2026-914 DC, 14 août 2026, *Loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles*.

À retenir. - Ces deux décisions illustrent un véritable contrôle de proportionnalité fondé sur l'article 1er de la Charte de l'environnement. La Constitution n'interdit pas toute dérogation à une mesure de protection environnementale, mais exige un encadrement suffisamment précis, temporaire et proportionné. La décision de 2026 montre ainsi qu'une mesure censurée pour insuffisance de garanties peut devenir constitutionnelle lorsque le législateur resserre son champ et renforce les garanties scientifiques, temporelles et procédurales.

4. La montée en puissance du contentieux relatif au droit à un environnement sain

Les juridictions administratives ont récemment eu à traiter d'affaires importantes en matière climatique portant sur les taux d'émissions de gaz à effet de serre et sur le respect des engagements internationaux de la France en la matière.

Le Conseil d'État a ainsi enjoint le gouvernement à adopter des mesures avant le 31 mars 2022 afin de se conformer aux objectifs des Accords de Paris prévoyant une réduction de 40 % des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 par rapport à leur niveau de 1990.

→ CE, 1er juillet 2021, *Commune de Grande-Synthe*, n° 427301.

→ Le Conseil d'État a, dans un arrêt ultérieur, estimé que les mesures adoptées en réaction n'avaient pas permis d'exécuter sa précédente décision. Il adresse ainsi une nouvelle injonction au gouvernement (CE, 10 mai 2023, *Commune de Grande-Synthe et a.*, n° 467982).

Le juge judiciaire s'est également saisi de la question environnementale à travers le contentieux de la responsabilité civile. Il a en effet admis l'indemnisation des différents types de préjudices écologiques à l'occasion de l'affaire Erika.

→ Cass. crim, 25 septembre 2012, n° 10-82.938.

Depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1087 le 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, le Code civil comprend désormais, aux articles 1246 à 1252, des dispositions relatives aux préjudices écologiques, consacrant de la sorte la construction prétorienne.

→ Cass. crim., 26 mars 2024, n° 23-81.410.

Le préjudice écologique est désormais réparable lorsqu'il porte atteinte aux intérêts patrimoniaux ou extra-patrimoniaux d'un individu en tant que préjudice écologique subjectif. Le caractère indemnisable des préjudices écologiques s'étend également à ceux qui n'affectent que la nature de manière directe ou indirecte, il s'agit alors d'un préjudice objectif : un préjudice écologique pur (art. 1247 du Code civil).

Sa réparation s'effectue en priorité en nature sauf si celle-ci s'avère impossible ou insuffisante. Le responsable pourra alors être tenu de verser des dommages et intérêts affectés à la réparation de l'atteinte, attribués au demandeur ou à l'État.

→ Cass. crim, 4 octobre 2022, n° 21-85.290

L'État a été reconnu responsable sur le fondement de l'article 1246 du Code civil pour inaction climatique au sein de « l'affaire du siècle », car il ne s'était pas conformé à ses engagements dans le cadre de son premier budget carbone.

→ TA Paris, 3 février 2021, n°s1904967, 1904968, 1904972, 1904976/4-1.

→ Le Premier ministre ainsi que les ministres compétents ont ainsi été enjoints par le tribunal administratif à adopter des mesures visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre afin que la France se conforme à ses engagements. Le juge a également ordonné à ce que le préjudice causé par le dépassement de ces émissions au 31 décembre 2022 soit réparé : TA Paris, 14 octobre 2021, *« affaire du siècle »*, n°s 1904967, 1904968, 1904972, 1904976/4-1.

POUR S'ENTRAÎNER

Commentaire d'arrêt : CEDH, 30 janvier 2025, *Cannavacciuolo et a. c. Italie*, n°s 51567/14 39742/14 et 74208/14.

La gestion des déchets par l'Italie est une problématique récurrente qui a fait l'objet de nombreuses critiques depuis la fin des années 1990, particulièrement en raison du développement de l'écomafia dans la région de la Campanie. Cette gestion défaillante a d'ailleurs conduit l'Italie à être condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme en 2012 dans le cadre de l'affaire *Di Sarno*. L'affaire du 30 janvier 2025 portait une nouvelle fois sur la gestion des déchets au sein de la région désormais tristement surnommée « terra dei fuochi » ou terre de feu. Depuis les années 1990, la mafia procède de manière illégale, sur des terrains privés, à des déversements, des enfouissements, ainsi qu'à l'incinération de déchets toxiques. De nombreux requérants, 41 personnes et 5 organisations ont donc souhaité dénoncer l'incurie de l'État auprès de la Cour européenne des droits de l'homme. Ils alléguaient principalement que l'État n'avait pas respecté ses obligations positives au titre des articles 2 et 8 en ne prenant aucune mesure de nature à mettre fin à cette pratique privée.

La Cour européenne des droits de l'homme, après avoir accueilli favorablement la requête des requérants, personnes physiques, résidant encore au sein de cette région au jour de sa décision, a estimé que l'État n'avait pas respecté ses obligations positives au titre de l'article 2 de la Convention. En raison du grand nombre de requêtes potentiellement concernées par cette affaire, la Cour a mobilisé la procédure d'arrêt pilote.

Problématique et annonce du plan : La Cour va procéder de manière tout à fait prévisible à l'application de l'article 2 de la Convention dans le cadre d'une affaire environnementale **(I)**. Son approche demeure néanmoins innovante par le recours à la procédure d'arrêt pilote dans cette matière **(II)**.

I. Le constat prévisible de l'applicabilité de l'article 2 de la Convention dans le cadre d'une affaire environnementale

A. L'examen exigeant des conditions de recevabilité des requêtes

La jurisprudence étant hostile à l'*actio popularis* et contrairement à sa position en matière de litiges climatiques (CEDH, GC., 9 avril 2024, *Verein Klimaseniorinnen Schweiz et a. c. Suisse*, n° 53600/20), la Cour n'a pas admis en l'espèce la recevabilité des recours formés par les associations de victimes. Ces dernières ne pouvaient se prévaloir de la qualité de victime au titre des articles 8 et 2 sans qu'aucune circonstance spécifique ne puisse le justifier.

Les recours formés par les requérants ne vivant pas ou plus dans les communes affectées au jour de son jugement ont également été déclarés irrecevables.

La Cour a cependant apprécié avec davantage de tempérance l'absence de recours en indemnisation formulé par les requérants en droit interne.

B. L'applicabilité prévisible de l'article 2 de la Convention en cas de pollution environnementale

Le droit à l'environnement n'est pas protégé en tant que tel par la Convention, il ne dispose que d'une protection par ricochet.

L'applicabilité de l'article 2 à la cause en l'absence de décès n'est pas surprenante (CEDH, GC., 30 novembre 2004, *Öneryildiz c. Turquie*, n° 48939/99).

La Cour n'a pas exigé des requérants qu'ils démontrent l'existence d'un lien de causalité entre l'exposition à de telles pollutions et le développement de maladies.

La Cour admet en effet qu'en cas d'activités dangereuses commises par l'État ou des particuliers un risque réel et imminent pour la vie suffit pour appliquer l'article 2 (CEDH, 24 juillet 2014, *Brincat et a. c. Malte*, n°s 60908/11 et a.), critères qui ont été constatés en l'espèce.

II. Le recours innovant à la procédure des arrêts pilotes en matière environnementale

A. La violation des obligations positives de l'État au titre du droit à la vie

La Cour a rappelé que les obligations positives au titre de l'article 8 et de l'article 2 sont similaires lorsque sont en cause des activités dangereuses. L'État dispose ainsi d'obligations positives matérielles et procédurales (CEDH, GC., 19 février 1998, *Guerra et a. c. Italie*, n° 14967/89).

L'inaction prolongée de l'État ainsi que sa connaissance de la problématique depuis le début des années 1990 ont conduit la Cour à constater la violation des obligations positives de l'État au titre de l'article 2.

B. Le manquement systématique de l'État à ses obligations environnementales

La procédure d'arrêts pilotes a été développée initialement par la Cour en 2004 (CEDH, GC., 22 juin 2004, *Broniowski c. Pologne*, n° 31443/96) avant d'être codifiée au sein du règlement de la Cour (art. 61 du règlement). La Cour a relativement peu utilisé cette procédure qui lui permet de traiter au sein d'une seule affaire des violations systémiques ou structurelles. Cet arrêt est de ce fait d'une certaine importance, car il s'agit de la première application de ce type de procédure à la matière environnementale.

La Cour a formulé des recommandations de mesures générales à adopter par l'État défendeur telle que l'adoption d'une stratégie nationale permettant de lutter contre ces graves nuisances, la mise en place d'un mécanisme de suivi indépendant et d'une plateforme d'information du public.

En conclusion, la Cour procède à la condamnation prévisible de l'Italie pour non-respect de ses obligations environnementales dans le cadre de relations interindividuelles par le biais d'un arrêt pilote, les manquements de l'État en la matière ayant été systémiques.

Fiche nº 50 - LE DROIT AU TRAVAIL

POINTS CLÉS

- Il ne faut pas confondre le droit au travail et la liberté du travail.
- Le premier implique une dimension sociale. L'État devient débiteur d'un certain nombre d'obligations.
- Dans le cadre de la liberté de travailler, c'est le choix de l'individu qui devient un élément central.
- La liberté de travailler s'entend aussi de celle de ne pas travailler.
- Le droit au travail implique également des droits annexes comme le droit de grève ou la liberté syndicale.

PRINCIPALES RÉFÉRENCES

- Alinéa 5 du Préambule du 27 octobre 1946.
- Article 1er de la Convention nº 29 de l'Organisation Internationale du travail (OIT) du 28 juin 1930.
- CEDH, GC., 11 janvier 2006, *Sørensen et Rasmussen c. Danemark*, nos 52562/99 et 52620/99.
- Cons. const., déc. nº 2007-556 DC, 16 août 2007, *Loi sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs.*
- Article L. 1121-1 du Code du travail.
- Art. L. 4121-1 du Code du travail.
- Cass. soc., 2 octobre 2001, *Nikon*, nº 99-42.942.

1. Le droit d'obtenir un emploi

Il existe une confusion courante entre droit au travail et liberté du travail. Toutefois, alors que dans le premier cas, l'État est débiteur d'un certain nombre d'obligations, la liberté de travailler relève du choix de la personne de travailler (ou non).

Le droit au travail ou droit à l'emploi est d'un droit de solidarité qui s'appréhende sous un prisme socio-économique, comme une protection contre la pauvreté. Il n'est plus uniquement question d'une liberté à la discrétion de l'individu, mais plus globalement d'une nécessité sociale.

Ainsi, les revenus du travail sont traditionnellement conçus comme les premiers remparts contre la pauvreté. Le discours politique consiste à admettre que le seul moyen de protéger l'individu contre la pauvreté est de lui assurer un travail.

C'est dans ce cadre que la loi est venue garantir un salaire minimum, c'est-à-dire un socle de revenus minimal tiré du travail, traditionnellement appelé SMIC pour salaire minimum de croissance (art. L. 3231-2 du Code du travail).

Plusieurs critiques sont possibles à l'égard de ce dispositif. Tout d'abord, s'il contribue à assurer un salaire minimal, ce dernier ne concerne que les travailleurs et non les personnes exclues du travail pour diverses raisons. De même, ce salaire minimum est loin de garantir une rémunération suffisante pour vivre dignement.

1.1. Un droit constitutionnel

Aux termes de l'alinéa 5 du Préambule de 1946 : « *Chacun a le droit de travailler et le droit d'obtenir un emploi.* »

Enfin, d'un point de vue juridique, le Conseil constitutionnel ne prévoit pas une obligation de résultat pour le législateur en la matière, mais se borne à lui prescrire une obligation de moyen.

> *« Il incombe au législateur, compétent en vertu de l'article 34 de la Constitution pour déterminer les principes fondamentaux du droit du travail, de poser des règles propres à assurer, conformément au cinquième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, le droit pour chacun d'obtenir un emploi tout en permettant l'exercice de ce droit par le plus grand nombre et, le cas échéant, en s'efforçant de remédier à la précarité de l'emploi »* (Cons. const., décision n° 2006-535 du 30 mars 2006, *Loi pour l'égalité des chances*).

Avec cette décision, le Conseil laisse au législateur une grande marge de manœuvre pour atteindre les objectifs visés par le Préambule de la Constitution.

Toutefois, le caractère opératoire de cette disposition constitutionnelle est restreint. En effet, le Conseil d'État estime que l'article 5 du Préambule de 1946 ne constitue pas une liberté fondamentale dans le cadre du référé-liberté.

> → CE, sect., 28 février 2001, *Casanovas,* n° 229163.

De son côté, la Chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que le droit à l'emploi ne constitue pas une liberté fondamentale justifiant la poursuite du contrat de travail au-delà du terme de la mission de travail temporaire en cas de requalification du contrat de travail.

> → Cass. soc., 21 septembre 2017, n° 16-20270.

1.2. Les sources internationales du droit au travail

Le droit au travail figure à l'article 23 de la Déclaration universelle des droits de l'homme :

> *« Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage. »*

Il est également consacré à l'article 6 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels :

> *« Les États parties au présent Pacte reconnaissent le droit au travail, qui comprend le droit qu'à toute personne d'obtenir la possibilité de gagner sa vie par un travail librement choisi ou accepté, et prendront des mesures appropriées pour sauvegarder ce droit. »*

Mais c'est dans le cadre de l'Organisation internationale du travail qui a accouché des normes les plus avancées en la matière :

- Déclaration de Philadelphie (1944).
- Convention n° 122 (1964) sur la politique de l'emploi (promotion du plein emploi productif et librement choisi).
- Convention n° 111(1958) sur la non-discrimination en matière d'emploi et de profession.
- Convention n° 87 (1948) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical.
- Convention n° 98 (1949) sur le droit d'organisation et de négociation collective.
- Conventions n° 29 et 105 sur l'abolition du travail forcé.
- Conventions n° 138 et 182 sur l'abolition du travail des enfants.

À l'échelle européenne, l'article 1er de la Charte sociale européenne énonce que *« toute personne doit avoir la possibilité de gagner sa vie par un travail librement entrepris »*.

Cependant, ces articles sont totalement dépourvus d'effet direct en droit français, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas être directement invoqués par les justiciables à l'appui d'une demande.

En ce sens, le Conseil d'État a clairement estimé à propos du paragraphe 1er de l'article du Pacte de 1966 que :

> *« Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 6 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels publié par le décret du 29 janvier 1981 : "Les États parties au présent pacte reconnaissent le droit au travail, qui comprend le droit qu'à toute personne d'obtenir la possibilité de gagner sa vie par un travail librement choisi ou accepté, et prendront des mesures appropriées pour sauvegarder ce droit" ; qu'eu égard à leur contenu, ces stipulations ne produisent pas d'effet direct dans*

l'ordre juridique interne ; qu'ainsi, le requérant ne peut se prévaloir utilement de leur méconnaissance » ; CE, 26 janvier 2000, *Annad*, n° 170579.

1.3. Les implications du droit à l'emploi

La consécration d'un droit à l'emploi ne signifie pas que l'État est dans l'obligation de fournir à un emploi à tout individu.

Cependant, le Conseil constitutionnel estime qu'il incombe à l'État de mettre en œuvre une véritable politique de l'emploi. Il estime :

> *« Qu'il incombe au législateur* […] *de poser des règles propres à assurer, conformément au cinquième alinéa du Préambule de 1946, le droit pour chacun d'obtenir un emploi tout en permettant l'exercice de ce droit par le grand nombre »* (Cons. const., décision n° 2006-535 DC, 30 mars 2006, *Loi pour l'égalité des chances*).

À l'image des autres droits de solidarité, le Conseil constitutionnel laisse une grande marge de manœuvre au législateur en se bornant à un contrôle des finalités poursuivies par la loi. Il estime que :

> *« Il ne lui appartient pas de rechercher si l'objectif que s'est assigné le législateur pouvait être atteint par d'autres voies, dès lors que les modalités retenues par la loi déférée ne sont pas manifestement inappropriées à la finalité poursuivies »* (Cons. const., décision n° 2007-555 DC, 16 août 2007, *Loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat*).

2. Les garanties fondamentales en matière d'emploi et de conditions de travail

2.1. La protection par l'Organisation internationale du travail

La Déclaration de l'Organisation internationale du travail relative aux principes et droits fondamentaux au travail, adoptée en 1998 puis révisée en 2022, précise que les principes se rapportant aux droits faisant l'objet de ces conventions fondamentales s'imposent aux États du seul fait de leur qualité de membre, et donc indépendamment de la ratification desdites conventions.

Il s'agit des cinq principes suivants :

- La liberté d'association et la reconnaissance effective du droit de négociation collective.
- L'élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire.
- L'abolition effective du travail des enfants.
- L'élimination de la discrimination en matière d'emploi et de profession.
- Un milieu de travail sûr et salubre.

L'Organisation prévoit également un mécanisme de suivi annuel du respect des cinq principes fondamentaux pour les États qui n'ont pas encore ratifié toutes ses conventions fondamentales.

Il s'agit de normes contraignantes pour les États, car ils ont non seulement l'obligation de les respecter, mais sont également soumis à un système de contrôle du respect des normes de l'Organisation internationale du travail.

Il existe deux différents types de contrôles :

- Le système de contrôle régulier qui oblige, tous les trois ans (ou six ans selon le type de Convention), les États à fournir des rapports périodiques sur les mesures prises en vue de se conformer aux normes qu'ils ont ratifié.
- Des procédures particulières :
    - La procédure de réclamation qui permet aux organisations d'employeurs ou de salariés de présenter une réclamation concernant le non-respect par un État des conventions qu'il a ratifié.
    - La procédure de plainte interétatique.

Certaines stipulations de conventions adoptées par l'Organisation internationale du travail disposent d'un effet direct en droit interne français.

> → Art. 10 de la Convention n° 158 (Cass. soc., 11 mai 2022, n° 21-14.490).

→ Art. 4 de la Convention n° 158 (Cass. soc., 2 déc. 2020, n°s 19-11.986 à 19-11.994).

→ Art. 2 de la Convention n° 30 (Cass. soc., 3 avril 2019, n° 16-20.490).

2.2. La protection des libertés individuelles du salarié dans l'exécution du contrat de travail

Les relations de travail prennent leur source de la signature d'un contrat de travail. En vertu de la liberté contractuelle, les parties au contrat disposent donc d'une faculté de déterminer le contenu du contrat. Pour illustration, les parties peuvent prévoir, au profit du salarié, une prime d'arrivée indépendante de sa rémunération et conditionnée, sous peine de remboursement de la somme, à sa présence du salarié au sein de l'entreprise (Cass. soc., 11 mai 2023, n° 21-25.136).

Néanmoins, les contrats de travail disposent en France d'un régime spécifique disposant d'un certain nombre d'exigences du fait de la relation asymétrique dont disposent les employeurs sur leurs salariés. Le salarié dans le cadre de son emploi dispose de droits individuels en sa qualité d'être humain. Le Code du travail impose ainsi que l'atteinte causée aux droits des salariés soit proportionnée et qu'elle poursuive un but légitime (art. L. 1121-1 du Code du travail).

Cet article constitue l'un des piliers de la protection des droits du salarié. Il peut être mobilisé seul ou avec d'autres fondements issus notamment du Code du travail ou de textes internationaux.

Actualité jurisprudentielle. - La liberté d'expression du salarié : du contrôle de l'abus au contrôle de proportionnalité

La Cour de cassation a sensiblement fait évoluer sa jurisprudence relative à la liberté d'expression du salarié. Concrètement, elle modifie l'étendue de son contrôle en abandonnant la limite de « l'abus » (injure, propos excessifs, diffamation) au profit d'un contrôle de proportionnalité.

Dans une première affaire concernant une auxiliaire de vie employée dans un établissement accueillant des personnes âgées dépendantes, la salariée avait notamment exprimé son désaccord sur la prise en charge d'une résidente atteinte de la maladie d'Alzheimer, indiquant qu'elle ne pourrait pas s'occuper de personnes présentant de tels troubles. Son licenciement reposait également sur plusieurs comportements agressifs à l'égard de résidents et de collègues. La salariée soutenait que son licenciement portait atteinte à sa liberté d'expression.

La Cour de cassation rappelle que le salarié jouit de sa liberté d'expression dans l'entreprise comme en dehors de celle-ci, sur le fondement de l'article 11 de la Déclaration de 1789, de l'article 10 de la Convention européenne et de l'article L. 1121-1 du Code du travail. Elle abandonne surtout une approche uniquement centrée sur l'existence d'un abus pour imposer au juge une véritable mise en balance des droits et intérêts en présence. Celui-ci doit apprécier la teneur des propos, leur contexte, leur portée et leur impact dans l'entreprise ainsi que leurs conséquences pour l'employeur, afin de vérifier que la sanction est nécessaire, adaptée et proportionnée au but poursuivi. En l'espèce, compte tenu notamment du comportement agressif de la salariée et de son refus annoncé d'accomplir une tâche relevant de ses fonctions, le licenciement n'a pas été considéré comme disproportionné (Cass. soc., 14 janvier 2026, *Société les Sinoplies*, n° 24-13.778).

Cette évolution a été affirmée le même jour dans plusieurs arrêts. Dans une autre affaire, un salarié d'Airbus avait notamment réalisé des dessins critiquant les méthodes de management de l'entreprise. La Cour de cassation reproche aux juges du fond de ne pas avoir suffisamment recherché le contexte dans lequel ces dessins avaient été réalisés, leur portée et leur impact avant de considérer que la restriction apportée à sa liberté d'expression était justifiée (Cass. soc., 14 janvier 2026, *Société Airbus Atlantic*, n° 23-19.947).

À retenir. - La liberté d'expression du salarié n'est pas absolue, mais sa limitation suppose désormais une véritable conciliation entre cette liberté fondamentale et les intérêts légitimes de l'employeur. Le contrôle de proportionnalité de l'article L. 1121-1 devient ainsi le cœur du raisonnement du juge.

L'employeur est également soumis à une obligation de sécurité à l'égard de ses salariés (art. L. 4121-1 du Code du travail). Il s'agit d'une obligation de résultat entraînant un renversement de la charge de la preuve.

→ L'employeur peut toutefois s'exonérer de sa responsabilité en démontrant qu'il a pris toutes les mesures nécessaires afin d'assurer la sécurité de ses salariés : Cass. soc., 25 novembre 2015, *Air France*, n° 14-24.444.

Les atteintes à liberté de religion du salarié doivent être justifiées par la nature des missions de ce dernier et doivent être proportionnées : Cass. ass. plén., 25 juin 2014, *Baby-Loup*, n° 13-28.369. Sur ce terrain, le législateur a consacré au sein de l'article L. 1321-2-1 du Code du travail la possibilité pour l'employeur de prévoir au sein de son règlement intérieur une clause de neutralité. Cette clause doit cependant être proportionnée et justifiée par le respect des droits d'autrui ou par les nécessités du bon fonctionnement de l'entreprise (entreprise de conviction).

Le contrat de travail peut impacter de nombreuses libertés fondamentales comme le droit au respect de sa vie familiale des salariés. Ce droit peut par exemple être affecté par les obligations de mobilité prévues au sein du contrat de travail. Le juge contrôle la proportionnalité ainsi que la nécessité de telles clauses au regard des missions exercées.

→ Cass. soc., 22 mai 2019, n° 18-15.752.

Lorsque le contrat ne prévoit pas de clause de mobilité, la demande formulée par l'employeur de changement de lieu de travail sera appréciée par rapport à la notion jurisprudentielle de « secteur géographique ». Lorsque le changement de domicile demandé par l'employeur s'insère au sein de ce dernier, le salarié ne pourra refuser sans commettre de faute.

→ Cass. soc., 20 novembre 2013, n° 12-30.100.

Le droit du travail octroie également un statut protecteur pour les salariés au regard des règles entourant la terminaison de la relation contractuelle lorsqu'elles sont à l'initiative de l'employeur.

Si le salarié dispose d'une plus grande liberté lorsqu'il décide de mettre fin unilatéralement à la relation contractuelle par le biais de sa démission, le licenciement doit cependant respecter tant des conditions de forme (convocation, entretien, et information préalable du salarié) que de fond (le licenciement doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse).

→ Voir par exemple : Cass. soc., 27 mai 2025, n° 23-23.743.

2.3. La protection des libertés collectives des salariés

2.3.1. La liberté syndicale

Alors que la loi « Le Chapelier » des 14 et 17 juin 1791 avait prohibé tout groupement professionnel, la loi du 21 mars 1884 de Waldeck-Rousseau relative à la création des syndicats professionnels reconnaît expressément la liberté syndicale et affirme que les syndicats pourront librement se constituer sans autorisation préalable du Gouvernement.

La liberté syndicale a été pleinement consacrée par l'alinéa 6 du Préambule de la Constitution de 1946 qui énonce que *« tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale et adhère au syndicat de son choix »*.

Les salariés disposent tout d'abord du droit de créer des syndicats, mais aussi de s'affilier. Le Conseil constitutionnel lui a reconnu une valeur constitutionnelle sur le fondement de l'alinéa 6 du préambule de la Constitution de 1946.

> → Cons. const., déc. n° 2019-816 QPC, 29 novembre 2019, *Fédération nationale des syndicats du spectacle, du cinéma, de l'audiovisuel et de l'action culturelle CGT et a*.

La liberté syndicale est également proclamée par la Convention européenne des droits de l'homme dans son article 11 alinéa 1. C'est dans un arrêt *Syndicat national de la police belge c. Belgique* en date du 27 octobre 1975 que la Cour européenne a fixé les grandes lignes de la protection des droits en matière syndicale.

Selon la Cour, l'article 11 garantit :

> *« Le droit de fonder un syndicat et d'adhérer à un syndicat de son choix, le droit d'être entendu* […] *la liberté de défendre les intérêts professionnels des adhérents d'un syndicat par l'action collective de celui-ci, action dont les États contractants doivent à la fois autoriser et rendre possibles la conduite et le développement »* (CEDH, 27 octobre 1975, n° 4464/70).

La Cour européenne a également eu l'occasion de se prononcer sur l'impossibilité pour les militaires français d'appartenir à un syndicat. Il s'agissait alors de vérifier la conformité du dispositif français vis-à-vis de l'article 11 de la Convention.

La Cour a jugé contraire à la convention le régime français en estimant que le caractère particulier des fonctions des forces armées impliquait une modulation de l'activité syndicale. Ainsi, les États parties sont libres d'apporter des restrictions importantes à l'organisation, au fonctionnement et à l'expression publique de syndicats dans les forces armées.

En revanche, la Cour a estimé qu'il ne fallait pas

> *« Priver les militaires et leurs syndicats du droit général d'association pour la défense de leurs intérêts professionnels et moraux*. […] *L'interdiction pure et simple pour les militaires de constituer un syndicat ou d'y adhérer porte à l'essence même de leur liberté d'association une atteinte prohibée par la Convention »* (CEDH, 2 octobre 2014, *Matelly c. France*, n° 0609/10).

Comme toutes les libertés et les droits fondamentaux, la liberté syndicale n'est pas absolue. Le Conseil constitutionnel estime que le législateur peut limiter la liberté syndicale si l'objectif qu'il poursuit est légitime, par exemple pour un motif d'intérêt général.

Il faut aussi que l'atteinte soit adaptée et proportionnée pour réaliser le but recherché.

> → Cons. const., déc. n° 2019-816 QPC, 29 novembre 2019, *Fédération nationale des syndicats du spectacle, du cinéma, de l'audiovisuel et de l'action culturelle CGT et a*.

De son côté, l'article 11 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme autorise à imposer des restrictions légitimes à l'exercice de la liberté de réunion et d'association. Il dispose en effet que :

> *« L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le présent article n'interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l'exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l'administration de l'État. »*

Par exemple, la Cour européenne a conclu à l'unanimité que l'interdiction des syndicats au sein de l'armée française méconnaît l'article 11 de la Convention EDH.

> → CEDH, 2 octobre 2014, *Matelly c. France et Adefdromil c. France*, n° 10609/10 et n° 32191/09.

2.3.2. Le droit de grève

Le droit de grève est consacré au septième alinéa du Préambule de 1946, selon lequel « *le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent »*.

Très souvent, cette notion est abordée de façon conjointe avec la liberté syndicale par le Conseil constitutionnel.

Le droit de grève est reconnu par les organes de contrôle de l'OIT comme le corollaire indissociable du droit d'association syndicale protégé par la Convention n° 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical de 1948.

La grève est protégée par l'article 11 de la Convention EDH et représente pour la CEDH un des moyens les plus importants au travers desquels l'État peut assurer la liberté pour un syndicat de protéger les intérêts professionnels de ses membres.

> → CEDH, 6 février 1976, *Schmidt et Dahlström c. Suède*, n° 5614/72.

En premier lieu, le droit de grève n'est pas absolu. La grève elle-même peut être jugée abusive ou illicite. La grève est notamment considérée comme illicite si elle ne porte aucune revendication professionnelle, et en particulier si elle porte exclusivement des revendications politiques.

En deuxième lieu, le Conseil d'État a rapidement suppléé à la carence du législateur. En l'absence de la réglementation du droit de grève annoncée par le Préambule de la Constitution de 1946, il appartient au gouvernement, responsable du bon fonctionnement des services publics, de fixer lui-même, sous le contrôle du juge, en ce qui concerne ces services, la nature et l'étendue desdites limitations.

→ CE, ass.,7 juillet 1950, *Dehaene*, n° 01645.

Surtout, l'exercice du droit de grève est limité sinon interdit pour certains agents de l'État français. Ainsi, les personnels de police, des compagnies républicaines de sécurité (CRS) et des administrations pénitentiaires (gardiens de prison et agents du service pénitentiaire d'insertion et de probation), ceux des transmissions du ministère de l'Intérieur, les soldats et gendarmes et les magistrats judiciaires sont privés du droit de faire grève en raison des statuts spéciaux auxquels ils sont soumis

2.3.3. Le droit à la participation à la gestion de l'entreprise

Ce droit découle quant à lui de l'alinéa 8 du préambule de la Constitution de 1946.

→ Cons. const., déc. n° 2019-816 QPC, 29 novembre 2019, *Fédération nationale des syndicats du spectacle, du cinéma, de l'audiovisuel et de l'action culturelle CGT et a*.

Actualité jurisprudentielle. - Le salarié dispose-t-il d'un droit de se taire lors de l'entretien préalable ?

Plusieurs salariées ont contesté en 2025 les dispositions du Code du travail imposant à l'employeur de recueillir les explications du salarié lors de l'entretien préalable à une sanction ou à un licenciement. Elles soutenaient que, puisque leurs déclarations pouvaient être utilisées contre elles, elles auraient dû être préalablement informées de leur droit de se taire, garanti par l'article 9 de la Déclaration de 1789.

Le Conseil constitutionnel rejette cette argumentation. Le licenciement et les sanctions prononcées par un employeur privé interviennent dans le cadre de la relation de travail et ne constituent pas des sanctions ayant le caractère d'une punition. Les garanties constitutionnelles attachées au droit de ne pas s'auto-incriminer ne sont donc pas applicables à l'entretien préalable et l'employeur n'est pas tenu d'informer le salarié d'un droit de se taire (Cons. const., déc. n° 2025-1160/1161/1162 QPC, 19 septembre 2025, *Mme Nezha B. et autres*).

À retenir. - La diffusion des droits fondamentaux dans l'entreprise connaît des limites : les garanties propres à la matière répressive ne sont pas automatiquement transposées au pouvoir disciplinaire exercé par un employeur privé.

POUR S'ENTRAÎNER

Argumentation juridique : Soutenez que travailler n'est pas simplement un droit, mais aussi un devoir.

Dans les sociétés démocratiques contemporaines, le travail est généralement perçu comme un droit fondamental, au même titre que l'éducation ou la santé. Cette reconnaissance découle d'une longue évolution historique, marquée notamment par les luttes ouvrières, l'essor de l'État social et la consécration du travail dans les textes fondateurs.

Ainsi, le Préambule de la Constitution de 1946, toujours en vigueur par son intégration au bloc de constitutionnalité, énonce que *« chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi »* en son paragraphe 5. Cette formulation – souvent citée, mais rarement interrogée dans sa globalité – met sur un pied d'égalité deux idées que l'on oppose volontiers : le droit au travail et le devoir de travailler. On retrouve une telle consécration dans d'autres textes internationaux comme la Déclaration universelle des droits de l'homme.

Or, si l'on évoque volontiers le droit au travail dans les débats publics et politiques – notamment à travers la lutte contre le chômage ou la précarité –, la notion de devoir de travailler semble plus discrète, voire dérangeante, tant elle peut évoquer la contrainte ou l'atteinte à la liberté individuelle. Pourtant, elle s'enracine dans une certaine philosophie républicaine du travail, qui considère que participer à l'activité économique ne relève pas seulement de l'intérêt personnel, mais aussi d'un engagement au service du bien commun.

Problématique et annonce du plan. Dès lors, il convient de s'interroger sur la portée réelle de cette idée : le travail est-il simplement un droit dont on peut se prévaloir, ou n'engage-t-il pas également une responsabilité vis-à-vis de la collectivité ? Plus encore, en quoi peut-on soutenir que travailler est non seulement un droit, mais aussi un devoir ? Pour y répondre, il faut d'abord montrer que le travail constitue un droit essentiel, garantissant la dignité de chacun et sa place dans la société **(I)**, avant de démontrer qu'il revêt également une dimension de devoir civique et social, en tant qu'il assure la solidarité et la pérennité du modèle républicain **(II)**.

I. Travailler est un droit : une garantie individuelle et sociale

A. Le droit au travail comme droit fondamental

Le droit au travail est affirmé par des textes de valeur constitutionnelle (Préambule de 1946, al. 5).

Il est également consacré par des normes internationales (Déclaration universelle des droits de l'homme, Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, Charte sociale européenne…).

Il garantit la possibilité pour chacun de subvenir à ses besoins, de construire son autonomie et sa dignité.

Sa reconnaissance comme un droit ne fait donc aucun doute.

B. Les implications du droit au travail dans l'ordre juridique positif

L'État doit mettre en œuvre des politiques pour assurer un accès effectif à l'emploi (cf. obligations de moyens) // mise en place du SMIC.

Le droit du travail encadre la relation entre employeurs et salariés afin d'assurer un équilibre (conditions de travail, salaires, durée du travail, protection contre le licenciement abusif…).

Le Conseil constitutionnel a reconnu une valeur constitutionnelle au droit d'obtenir un emploi (décision 86-207 DC du 2 juillet 1986, *Loi autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures d'ordre économique et social* : une loi d'habilitation ne saurait avoir ni pour objet, ni pour effet de dispenser le Gouvernement dans

l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés en application de l'article 38 de la Constitution, du respect des règles et principes de valeur constitutionnelle, au nombre desquels figure le droit au travail.

Transition : Mais reconnaître un droit implique souvent une responsabilité corrélative. Et dans le cas du travail, cette responsabilité prend une tournure particulière : travailler, ce n'est pas seulement un droit que l'on peut revendiquer, c'est aussi une contribution attendue au pacte social.

II. Travailler peut être un devoir : une exigence civique et une contribution à l'intérêt général

A. Le travail comme devoir individuel inscrit dans la tradition républicaine

Le préambule de 1946 lui-même évoque expressément le « devoir de travailler » : cela inscrit le travail dans une logique de responsabilité.

Le devoir de travailler est également présent dans des contextes spécifiques : obligation de recherche active d'emploi pour les demandeurs d'emploi, devoir de formation ou de reconversion.

Le travail est un vecteur d'inclusion sociale, de cohésion et de dignité. Il permet de contribuer au financement de la solidarité nationale (impôts, cotisations sociales).

Ne pas travailler, lorsqu'on en a la capacité, peut peser sur la collectivité et fragiliser le lien social.

Le devoir de travailler se traduit parfois dans le droit positif : par exemple, les obligations de certaines personnes sous le RSA, ou les débats sur la « contrepartie » à l'aide sociale.

B. Un devoir de travailler remis en question

Cette conception est remise en question par certains philosophes ou hommes politiques.

Il est remis en question par l'idée de droit à la paresse.

Cela signifie que bien qu'il existe un droit de ne pas travailler, pris au prisme notamment de la prohibition du travail forcé. Les individus sont libres d'eux-mêmes, de refuser de travailler.

En conclusion, le devoir de travailler ne doit pas être compris comme une obligation absolue : il suppose que des conditions dignes et accessibles soient offertes. Il ne saurait justifier une stigmatisation des inactifs ou des exclus du marché du travail. Le droit à l'oisiveté ou au retrait temporaire du monde professionnel peut aussi faire partie d'un parcours de vie librement choisi.

Fiche nº 51 - LE DROIT AU LOGEMENT

POINTS CLÉS

- Fondement législatif du droit au logement.
- Droit au logement reconnu comme un objectif à valeur constitutionnelle.
- Absence d'uniformité des conceptions du droit au logement.
- Droit au logement dépendant des politiques sociales.

PRINCIPALES RÉFÉRENCES

- Loi nº 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi nº 86-1290 du 23 décembre 1986.
- Loi nº 90-449 du 31 mars 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement.
- Loi nº 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale.
- Cons. const., déc. nº 90-274 DC, 29 mai 1990, Loi visant à la mise en œuvre du droit au logement.
- Cons. const., 19 janvier 1995, déc. nº 359 DC
- CE, Droit au logement, Droit du logement, Rapport public 2009, La Documentation française, coll. « Rapports officiels », 2009.

1. Les sources du droit au logement

Le droit au logement puise son fondement dans des sources externes et internes puis sera reconnu comme objectif à valeur constitutionnelle par le Conseil constitutionnel.

1.1. Les sources externes du droit au logement

On retrouve quelques rares mentions du droit au logement dans les textes internationaux :

L'article 25-1 de la Déclaration universelle des droits de l'homme énonce que :

> *« Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment* […] *pour le logement. »*

L'article 11 du Pacte des Nations unies : amène les États à reconnaître le droit de toute personne à un logement suffisant comme corollaire de ce même droit à un niveau de vie convenable.

On constate une absence de proclamation expresse en droit européen. L'article 34 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne fait une simple mention à l'aide au logement tandis que l'article 31 de la Charte sociale européenne oblige les États à prendre les mesures destinées : à favoriser l'accès au logement d'un niveau suffisant, à prévenir et à réduire l'état de sans-abris en vue de son élimination progressive en vue d'assurer l'exercice effectif du droit au logement.

1.2. Les sources internes du droit du logement

Le droit au logement repose sur un fondement législatif et la reconnaissance en tant qu'objectif à valeur constitutionnelle.

1.2.1. Le fondement législatif du droit au logement

Toute une série de lois fait directement référence au droit au logement :

- Loi n° 82-526 du 22 juin 1982 relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs : évoque un droit à l'habitat.
- Loi n° 89-412 du 22 juin 1989 modifiant et complétant certaines dispositions du livre deuxième du code rural ainsi que certains articles du Code de la santé publique : proclame le droit à l'habitat comme un droit fondamental.
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et Loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement : proclament le droit au logement.
- Loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale : création du droit au logement opposable.
- Loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion (art. 89 : définition de l'habitat indigne et nécessité d'un *« programme national de requalification des quartiers anciens dégradés »* venant compléter la définition de ce droit fondamental).
- Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite.

1.2.2. L'affirmation du droit au logement comme objectif à valeur constitutionnelle

Le droit au logement a été défini par le Conseil constitutionnel comme un objectif à valeur constitutionnelle dans plusieurs décisions, de fait, ce droit est dépendant de la volonté des politiques.

> → Cons. const., déc. n° 90-274 DC, 29 mai 1990 : à propos de la loi du 6 juillet 1989 qui proclame le droit au logement, le Conseil constitutionnel estime que *« la promotion du logement des personnes défavorisées répond à une exigence d'intérêt national »*.
>
> → Cons. const., déc. n° 95-359 DC, 19 janvier 1995 : le Conseil constitutionnel reconnaît le droit au logement comme un objectif à valeur constitutionnelle fondé sur la dignité de la personne humaine.
>
> → Cons. const., déc. n° 98-403 DC, 29 juillet 1998 : dans la mise en œuvre de cet objectif à valeur constitutionnel, le législateur peut apporter des limitations qu'il estime nécessaires au droit de propriété. Cet objectif permet au législateur de fonder des limites au droit de propriété comme la mise en place d'une taxe annuelle sur les logements vacants avec la loi du 29 juillet 1998.

Cependant cet objectif à valeur constitutionnel n'est pas opposable à l'administration dans le cadre d'un référé-liberté et ne peut servir de base pour un recours contre le refus de réquisition de logements inoccupés.

> → CE, ord. réf., 3 mai 2002, *Association de réinsertion sociale du Limousin et autres* n° 245697. Le Conseil constitutionnel a *« qualifié d'objectif à valeur constitutionnelle la possibilité pour toute personne de disposer d'un logement décent ; il n'a pas consacré l'existence d'un droit au logement ayant rang de principe constitutionnel »*.
>
> → CE, ord. réf., 13 novembre 2009, *ministre de l'Immigration,* n° 325884. Le droit au logement même s'il constitue un objectif à valeur constitutionnel n'est pas une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du Code de justice administrative.

Le législateur peut mettre en place une procédure de réquisition des logements appartenant à des personnes morales et vacants depuis plus de 18 mois dans des communes où il existe un déséquilibre entre l'offre et la demande au détriment des personnes à revenus modestes et de personnes défavorisées ainsi qu'un régime fiscal moins favorable.

> → CC, 18 mars 2009, déc. n° 2009-578 DC, *Loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion* : l'objectif à valeur constitutionnel de logement décent pour chacun permet au législateur de porter atteinte aux contrats en cours, mais aussi de pouvoir instaurer un régime d'autorisation de « mise en location » dans des zones d'habitat dégradé en vue d'éviter la location de logements insalubres.

Selon le Conseil constitutionnel, cette atteinte au droit de propriété *« est une mise en œuvre l'objectif de valeur constitutionnelle que constitue la possibilité pour toute personne de disposer d'un logement décent, le législateur n'a pas porté aux conditions d'exercice du droit de propriété une atteinte disproportionnée au regard du but*

recherché ni méconnu les exigences constitutionnelles découlant de l'article 4 de la Déclaration de 1789 dont résulte la liberté contractuelle ».

→ Cons. const., déc. n° 2014-691 DC, 20 mars 2014, *Loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové*.

POUR ALLER PLUS LOIN

L'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains consacre le droit d'un locataire de logement loué à titre de résidence principale d'obtenir un logement décent, qui ne laisse pas apparaître « de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé », et qui soit doté d'éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets a fait évoluer les critères de décence du logement selon la classe énergétique de ce dernier avec la mise en place d'un « critère de performance énergétique minimal ». La contrainte imposée aux propriétaires liée au coût de mise en conformité du logement a été jugée non disproportionnée au droit de propriété et justifiée par le Conseil d'État au nom de la poursuite d'un droit à un logement décent, en tant qu'objectif à valeur constitutionnelle, pour améliorer le confort thermique des logements loués et réduire les dépenses énergétiques des locataires (CE, 5e – 6e chambres réunies, 21 décembre 2023, n° 488900).

2. La subjectivisation atténuée du droit au logement

Cette qualification floue du droit au logement d'objectif à valeur constitutionnelle n'a pas pour objet de conférer de prérogatives individuelles susceptibles d'être invoquées par les particuliers. Il s'agit seulement d'une terminologie spécifique du Conseil constitutionnel qui assigne une finalité au législateur.

Au nom des exigences liées à cet objectif à valeur constitutionnelle, le législateur doit contribuer à ce que toute personne ait un logement décent. Il s'agit donc d'un simple objectif à valeur constitutionnelle assigné aux pouvoirs publics et non une consécration d'un droit fondamental au logement.

2.1. La dimension horizontale du droit au logement

Il existe des éléments de concrétisation du droit au logement dans l'encadrement des relations entre bailleurs et preneurs et dans les règles du droit de la famille.

Les relations individuelles entre le bailleur et le preneur formalisé par le contrat de bail.

→ Art. 1er alinéa 3, loi n° 86-1290, 23 décembre 1986 : *« Les droits et obligations réciproques des bailleurs et des locataires doivent être équilibrés dans leurs relations individuelles comme dans leurs relations collectives. »*

Un contrat de bail ne peut pas être refusé pour des motifs discriminatoires.

→ Art. 158 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale insère deux alinéas à l'article 1er de la loi du 6 juillet 1989 : *« Aucune personne ne peut se voir refuser la location d'un logement pour un motif discriminatoire défini à l'article 225-1 du Code pénal »* conformément aux termes de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové.

Il existe aussi une protection pécuniaire du locataire par l'encadrement des prix des loyers notamment dans les zones « tendues » d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où il existe un déséquilibre entre l'offre et la demande. Il est désormais possible de fixer un loyer de référence par arrêté préfectoral ou, depuis la loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové du 24 mars 2014, par un décret de blocage des prix.

Une protection supplémentaire a été instaurée pour le locataire avec le droit à la conservation du logement afin de limiter les mises en œuvre de procédures d'expulsion en cas de non-paiement des loyers en saisissant a priori à titre préventif les services sociaux.

→ Art. L. 412-6 alinéa du Code des procédures civiles d'exécution : expulsion qui est exclue entre le 1er novembre et le 31 mars (trêve hivernale) sauf si le relogement peut être assuré *« dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille »*.

Depuis 2023, une meilleure protection des propriétaires d'un bien immobilier en cas de défaillance du locataire a été mise en place. Tout contrat de location contient désormais une clause résolutoire prévoyant la résiliation du loyer de plein droit du contrat de location en cas de défaut de paiement.

→ Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite.

2.2. La dimension verticale du droit au logement

Il s'agit des politiques du logement qui se doublent d'un mécanisme d'exigibilité en urgence d'un logement à l'égard de l'État. Afin d'assurer l'effectivité du droit au logement, les pouvoirs publics s'en saisissent via une politique sociale.

En conclusion, l'affirmation de soutenir l'existence d'un réel droit au logement, car rien n'oblige l'État ou un particulier à assurer un logement à tout individu qui le demanderait.

POUR ALLER PLUS LOIN

Le droit au logement des gens du voyage est méconnu par la législation française qui exclut les caravanes de la notion de domicile (Comité européen des droits sociaux, 19 octobre 2009. Centre européen des droits des Roms c. France).

3. L'influence des politiques sociales sur l'effectivité du droit au logement

3.1. L'accession au logement social

Dans les années 1990, on assiste à une priorisation de l'accession au logement social.

→ Art. 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement : « *Garantir le droit au logement constitue un devoir de solidarité pour l'ensemble de la Nation. Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, a droit à une aide de la collectivité, dans les conditions fixées par la présente loi, pour accéder à un logement décent et indépendant et s'y maintenir. »*

→ Art. 7 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement : instauration d'un fonds de solidarité pour le logement pour accorder des aides financières aux personne et familles défavorisées.

3.2. Le droit au logement opposable

Une réelle politique sociale concernant le droit au logement a été mise en place avec la loi du 5 mars 2007 et l'instauration du droit au logement opposable.

→ Art. 1er de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale (dite loi « DALO ») : le droit au logement *« est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir »*.

La loi du 5 mars 2007 relative droit au logement opposable instaure un mécanisme d'attribution prioritaire des logements en urgence par une commission de médiation sous la responsabilité des préfets. La régularité du séjour est une des conditions d'accès au droit au logement opposable. Le mécanisme a été ouvert pour tous depuis 2012 et dès 2008 pour les plus défavorisés.

POUR ALLER PLUS LOIN

Les publics susceptibles de bénéficier du droit au logement opposable doivent remplir au moins un des sept critères suivants :

- *Être sans domicile.*
- *Être menacé d'expulsion sans relogement.*
- *Être hébergé dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale (RHVS) de façon continue depuis plus de 6 mois ou logé temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de 18 mois.*
- *Être logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux.*
- *Être logé dans un logement ne présentant pas d'éléments d'équipement et de confort exigés (absence de chauffage, eau potable...) ; à condition d'avoir à charge au moins un enfant mineur ou une personne handicapée ou de présenter soi-même un handicap.*
- *Être logé dans un logement dont la surface habitable n'est pas supérieure ou égale à 16 m^2 pour un ménage sans enfant ou 2 personnes, augmentée de 9 m^2 par personne en plus dans la limite de 70 m^2 pour 8 personnes et plus, à condition d'avoir à charge au moins un enfant mineur ou une personne handicapée ou de présenter soi-même un handicap.*
- *Être demandeur d'un logement social depuis un délai supérieur au délai anormalement long (délai qui varie d'un département à un autre) sans avoir reçu de proposition adaptée aux besoins.*
- *Être, ou une personne à sa charge, logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens de l'article L 114 du Code de l'action sociale et des familles.*

Toutefois, le droit au logement apparaît comme un droit fondamental de second rang. Il s'agit davantage de la possibilité de faire respecter une procédure administrative et non un nouveau droit subjectif. En effet, la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové apporte des précisions pour la mise en œuvre de ce droit.

De plus, les applications effectives de ce droit restent limitées et insuffisantes. Une fois que la situation de la personne est reconnue comme prioritaire par une commission dite « DALO », le demandeur doit faire valoir sa situation auprès des différents bailleurs sociaux. Le préfet peut aussi enjoindre à un bailleur social de loger dans son parc la personne concernée sur un quota qui lui est réservé.

Ce n'est que passé un délai fixé et révisé par voie réglementaire que le demandeur reconnu prioritaire pourra saisir le juge administratif d'un recours contre l'État et engager la responsabilité de ce dernier pour absence de relogement.

→ CAA Paris, 20 septembre 2012, *Bel Hyad.*

→ CEDH, 9 avril 2015, *T. H. c. France*, n° 65829/12 : violation du droit au procès équitable d'une famille qui avait obtenu d'un juge l'attribution d'un logement, mais qui n'avait pas été relogée trois ans après.

POUR ALLER PLUS LOIN

Il ne faut pas confondre droit au logement et droit à l'hébergement

Le droit à l'hébergement se définit par son caractère urgent et provisoire afin de ne pas laisser des familles ou des personnes sans toit après une expulsion ou la destruction de leur logement.

> *→ Comité européen des droits sociaux du Conseil de l'Europe, arrêts des 8 septembre 2004, FIDH c. France et 20 octobre 2009, Défense des enfants international c. Pays Bas : exigence d'un abri pour les enfants même ceux en situation irrégulière.*
>
> *→ Art. 345-2-2 du Code de l'action sociale et des familles : fonde sur la dignité de la personne humaine le droit d'accès à un hébergement pour « toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale ».*
>
> *→ CE, ord. réf., 10 février 2012, M. F. c. Préfet de la région Île-de-France, n° 356456 : « Il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence. »*

Pour déposer un recours au titre du droit à l'hébergement opposable, il faut avoir sollicité l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et n'avoir reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Le requérant doit pouvoir justifier avoir effectué des démarches préalables, mais la loi ne fixe pas leur nature : ancienneté de la demande, répétition des demandes, etc. La saisine du Service Intégré d'Accompagnement et d'Orientation (SIAO) est une démarche préalable suffisante, mais pas obligatoire.

Le recours Dalo s'inspire du principe de l'accès inconditionnel à un hébergement (L. 345-2-2 du Code de l'action sociale et des familles). À ce titre, il est ouvert à toute personne, qu'elle que soit sa situation administrative. Cependant, les personnes ne disposant pas de titre de séjour ne pourront se voir proposer qu'un hébergement, et non un logement-foyer ou un logement de transition.

Les critères d'éligibilité sont beaucoup moins précis que pour le recours logement. Les personnes concernées peuvent être : des sans domicile fixe ou des sans abri, y compris les personnes hébergées chez des tiers qui sont privées de domicile personnel ou des personnes mises à l'abri dans des structures spécifiques de type centre hospitalier universitaire ou hôtel : ces structures ne constituant qu'une mise à l'abri, elles ne permettent pas d'assurer la continuité de la prise en charge, l'évaluation de la situation de la personne ainsi que son accompagnement et son orientation.

Actualité jurisprudentielle. - La perte de la régularité du séjour d'un membre du foyer ne met pas fin à la responsabilité de l'État

Lorsqu'une personne a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence au titre du DALO, la carence de l'État à lui proposer un logement dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans ses conditions d'existence.

Le Conseil d'État a précisé en 2025 que cette responsabilité ne prend pas fin du seul fait qu'une personne majeure composant le foyer cesse ultérieurement d'être en situation régulière sur le territoire. La décision de la commission de médiation continue donc de produire ses effets à l'égard du demandeur reconnu prioritaire.

La perte de la régularité du séjour produit toutefois un effet sur l'indemnisation : à compter de cette date, la personne majeure concernée ne peut plus être prise en compte dans le nombre de personnes composant le foyer pour calculer le préjudice subi.

→ CE, 6 novembre 2025, *Commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis*, n° 491346.

À retenir. - La responsabilité de l'État née de sa carence dans l'exécution d'une décision DALO ne disparaît pas automatiquement en raison d'une évolution ultérieure de la composition juridique du foyer. Cette évolution peut néanmoins influer sur l'évaluation du préjudice indemnisable.

POUR S'ENTRAÎNER

Dissertation : Le droit au logement est-il un droit fondamental ?

Le droit au logement ne peut pas être considéré comme un droit subjectif. En effet, ce dernier ne constitue pas un droit autonome opposable à l'État, il n'est pas directement invocable par les justiciables. En effet, la médiation par l'État et les collectivités de ce droit au logement est fluctuante. Les résultats de ces politiques publiques restent incertains. Il n'est donc pas possible pour l'individu de s'en prévaloir de manière automatique.

Ce n'est que par la volonté du législateur d'assurer une égalité des chances voire une égalité de fait que le droit opposable au logement devient justiciable.

Cette justiciabilité du droit au logement est cependant réservée et restreinte à des situations particulières concernant le droit au logement opposable mis en place en 2007 tandis que la relation bailleur/preneur est encadrée classiquement par les textes législatifs.

Problématique et annonce du plan : Cette absence de subjectivisation du droit au logement s'explique par une faible base textuelle **(I)** tout en étant dépendant des politiques publiques **(II).**

I. La faible consécration textuelle du droit au logement

A. Des sources disparates mentionnant le droit au logement

Rares mentions en droit international (art. 25-1 DUDH et art. 11 PIDCP).

Absence de proclamation expresse en droit européen (art. 34 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, « droit à l'aide au logement », et art. 31 de la Charte sociale européenne « favoriser l'accès au logement »).

En France, les seules références sont législatives (Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et Loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement : proclament le droit au logement / Loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale : création du droit au logement opposable.

Le constat en droit interne est donc celui d'une absence de proclamation d'un droit au logement dans les textes constitutionnels.

B. La simple reconnaissance du droit au logement comme objectif à valeur constitutionnelle

Droit au logement érigé par le Conseil constitutionnel comme un objectif à valeur constitutionnelle et non un droit ou principe fondamental (Cons. const., déc. n° 95-359 DC, 19 janvier 1995, *Loi relative à la diversité de l'habitat* : le Conseil constitutionnel reconnaît le droit au logement comme un objectif à valeur constitutionnelle fondé sur la dignité de la personne humaine. Voir également Cons. const., déc. n° 2009-578 DC, 18 mars 2009, *Loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion* : objectif à valeur constitutionnel d'un logement décent).

Or, les objectifs sont au mieux des droits fondamentaux de second rang (expression de Louis Favoreu) et plus certainement des instruments de sauvetage de la constitutionnalité des lois déférées devant le juge constitutionnel.

En outre, cet objectif à valeur constitutionnel n'est pas opposable à l'administration dans le cadre d'un référé-liberté et il ne peut servir de base pour un recours contre le refus de réquisition de logements inoccupés (CE,

ord. réf., 3 mai 2002, *Association de réinsertion sociale du Limousin et autres*, n° 245697 ; CE, ord. réf., 13 novembre 2009, *ministre de l'Immigration*, n° 325884).

II. Un droit au logement dépendant des politiques publiques

A. Un socle commun encadrant la relation bailleur/preneur

Préservation classique du droit au logement par l'encadrement des relations individuelles entre les bailleurs et les preneurs (art. 1er alinéa 3, loi n° 86-1290, 23 décembre 1986). Un contrat de bail ne peut pas être refusé pour des motifs discriminatoires (art. 158 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale).

Protection pécuniaire du locataire par l'encadrement des prix des loyers

Une protection supplémentaire a été instaurée pour le locataire avec le droit à la conservation du logement afin de limiter les mises en œuvre de procédures d'expulsion en cas de non-paiement des loyers en saisissant a priori à titre préventif les services sociaux.

Cependant cette législation concerne une partie de la population qui est en capacité d'avoir et qui possède déjà un logement.

B. La dimension sociale du droit au logement

Réelle mise en œuvre du droit au logement avec les politiques sociales qui s'adressent à une partie spécifique de la population.

Dans les années 1990, on assiste à une priorisation de l'accession au logement social et la mise en place d'un fonds de solidarité pour le logement (art. 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement et art. 7 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement).

Instauration du droit au logement opposable (loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 avec un mécanisme d'attribution prioritaire des logements en urgence par une commission de médiation sous la responsabilité des préfets. Le mécanisme du droit au logement opposable a été ouvert pour tous depuis 2012 et dès 2008 pour les plus défavorisés.

En conclusion, le droit au logement n'est pas un droit subjectif et il peut difficilement être considéré comme un réel droit fondamental. C'est dans la mise en œuvre des politiques sociales et le droit au logement opposable qu'il est le plus garanti par l'État même si les résultats de cette politique sont insuffisants.

Fiche nº 52 - LE DROIT À LA CULTURE

POINTS CLÉS

- Droit de la culture / droit à la culture.
- Reconnaissance symbolique.
- Faible portée juridique.
- Conflits entre droit à la culture et autres droits.
- Tensions : propriété intellectuelle, droit de l'Union européenne.
- Vers une fondamentalisation des droits culturels.
- Reconnaissance internationale des droits culturels.
- Approche anthropologique et dynamique.
- Patrimoine immatériel et essor du numérique.

PRINCIPALES RÉFÉRENCES

- *Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.*
- Cons. const., déc. nº 2011-207 QPC, 16 déc. 2011, *Société GRANDE BRASSERIE PATRIE SCHUTZENBERGEN [Inscription au titre des monuments historiques].*
- Cons. const., déc. nº 2013-370 QPC du 28 février 2014, *Marc S. et autre [Exploitation numérique des livres indisponibles].*
- Cons. const., déc. nº 2017-655 QPC du 15 septembre 2017, *M. François G. [Accès aux archives publiques émanant du président de la République, du Premier ministre et des autres membres du Gouvernement].*
- *Convention de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture 2003 sur la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel.*
- *Convention de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture de 2005 sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles.*
- *Cour européenne des droits de l'homme, 17 février 2015, Guseva c. Bulgarie, req. nº 6987/07.*
- *CEDH, 11 octobre 2011, Helly et a. c. France, nº 28216/09.*
- *CJUE, 16 novembre 2016, aff. C-301/15.*
- *Directive 2001/29 du 22 mai 2001 sur l'harmonisation du droit d'auteur.*

Le droit à la culture ne doit pas être confondu avec le droit de la culture, lequel s'inscrit dans le cadre de l'action publique et la poursuite de politiques culturelles.

Dans certains contextes contentieux, révélés par la jurisprudence du Conseil constitutionnel, le droit à la culture se heurte purement et simplement au droit de la culture.

> → Cons. const., déc. nº 2017-649 QPC, 4 août 2017, *Société civile des producteurs phonographiques et autre [Extension de la licence légale aux services de radio par internet]* : à propos des licences pour les radios web. (Des sociétés de producteurs contestaient l'extension de la licence légale aux radios web, qui leur enlève le droit d'autoriser la diffusion de leurs phonogrammes. Le Conseil constitutionnel a jugé que la restriction est limitée [radios non-interactives uniquement], que les ayants droit perçoivent une rémunération équitable, et que l'extension poursuit un objectif d'intérêt général : faciliter l'accès du public à une offre culturelle diversifiée.)

→ CJUE, 16 novembre 2016, aff.C-301-15. (Les requérants contestaient la numérisation automatique de leurs œuvres sans autorisation, prévue par la loi de 2012. Le Conseil constitutionnel a validé le dispositif en s'appuyant sur la conservation du patrimoine culturel et l'accès du public à la culture, reconnu comme objectif d'intérêt général. Cependant, la Cour de justice de l'Union a invalidé l'argument culturel, jugeant que le droit de l'Union n'autorisait pas de dérogations supplémentaires au droit d'auteur non prévues dans le droit dérivé, même au nom de la culture.)

Le droit à la culture a acquis une première portée juridique à partir de son inscription dans le préambule de la Constitution de 1946. Il implique toutefois une intervention active de l'État pour en assurer l'effectivité.

> *« La Nation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction, à la formation professionnelle et à la culture »* (alinéa 13).

Force est toutefois de constater que les contours du droit à la culture sont peu explorés : ses bénéficiaires, ses garanties ou ses prérogatives demeurent mal définis.

1. Un droit en tension avec d'autres droits constitutionnels

La protection des monuments historiques ou la gratuité des services culturels illustrent les tensions pouvant exister entre le droit à la culture et d'autres droits constitutionnels, conférant au juge un rôle essentiel dans leur mise en balance.

→ Cons. const., déc. n° 2011-207 QPC, 16 déc. 2011, *Société Grande Brasserie.*

La protection du patrimoine est conçue en principe comme une mission de l'État exercée dans l'intérêt collectif, non comme un droit dont les citoyens peuvent se prévaloir individuellement et directement.

Les revendications culturelles peinent à s'imposer parmi les droits consacrés par la Constitution, d'autant que certains d'entre eux, comme le droit de propriété, peuvent entrer en conflit avec le droit à la culture. Des tensions analogues apparaissent en matière d'accès aux archives publiques : bien que le Conseil constitutionnel reconnaisse ce droit, il admet sans réserve la possibilité de restrictions législatives.

→ Cons. const., déc. n° 2017-655 QPC, 15 septembre 2017, *M. François G. [Accès aux archives publiques émanant du président de la République, du Premier ministre et des autres membres du Gouvernement].*

2. La faible normativité du droit à la culture

L'absence de reconnaissance explicite d'un véritable droit fondamental à la culture fragilise les revendications en la matière, d'autant que l'alinéa 13 du Préambule de 1946 demeure largement inexploré par la jurisprudence. Relégué au second plan et absorbé dans le droit de la culture, le droit à la culture n'en constitue pas moins un fondement implicite des politiques publiques en matière de musées, d'archives ou de patrimoine.

Faute d'une normativité véritablement contraignante, le droit à la culture reste à la fois indéterminé et relatif, souvent réduit au rang d'argument purement rhétorique. Pourtant, l'évolution du droit tend à faire émerger plus clairement ce droit, en posant la question de sa portée et de sa capacité à fonder des obligations juridiques pour les pouvoirs publics.

3. Vers un droit subjectif à la culture

Le droit de la culture, à l'instar d'autres branches juridiques, semble connaître une fondamentalisation progressive.

Cette évolution marque un changement de paradigme : du droit public sectoriel – organisé autour de polices administratives (monuments, spectacles, musées) – vers un droit des personnes, fondé sur l'appartenance et la revendication culturelle.

Les conventions de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) sur la diversité des expressions culturelles illustrent ce glissement.

→ Convention de 2003 sur la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel.

→ Convention de 2005 sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles.

Non contente de ratifier ces conventions, la France en a intégré certains principes en droit positif. La définition du patrimoine dans le Code du patrimoine a ainsi été enrichie pour inclure explicitement la conception retenue par la Convention de 2003 :

> *« L'ensemble des biens, immobiliers ou mobiliers, relevant de la propriété publique ou privée, qui présentent un intérêt historique, artistique, archéologique, esthétique, scientifique ou technique. Il s'entend également des éléments du patrimoine culturel immatériel »* (art. L. 1 du Code du patrimoine).

Par ailleurs, le législateur a imposé à l'État comme aux collectivités territoriales, dans l'exercice de leurs compétences respectives, de tenir compte des droits culturels, conformément à la Convention sur la diversité des expressions culturelles.

→ Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant sur la nouvelle organisation territoriale de la République.

Si la portée juridique concrète de ces droits reste encore incertaine, leur mobilisation contentieuse, notamment via une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), pourrait renforcer leur valeur normative à l'avenir.

4. Les enjeux de l'accès à la culture : démocratisation de la culture

L'accès à la culture constitue un enjeu central des politiques publiques, bien qu'il ne soit pas défini en droit français. Le ministère de la Culture a pour mission de rendre *« accessibles au plus grand nombre les œuvres capitales de l'humanité et d'abord de la France »*.

→ Art. 1er du décret n° 2017-1077 du 24 mai 2017 relatif aux attributions du ministre de la Culture.

Faute de définition nationale, il faut se référer au droit international, notamment à la Recommandation de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture de 1976, qui définit l'accès à la culture comme la possibilité effective pour tous, grâce à des conditions socio-économiques adéquates, de *« librement s'informer, se former, connaître, comprendre et jouir des valeurs et des biens culturels »*.

> → Recommandation concernant la participation et la contribution des masses populaires à la vie culturelle du 26 novembre 1976.

L'accès à la culture est intimement lié à la démocratisation de la culture puisque la mise en œuvre du droit d'accès à la culture exige que les politiques publiques tiennent compte des obstacles susceptibles d'exclure certains publics, tels que les personnes en situation de handicap, les personnes isolées, âgées ou en difficulté financière.

Il s'agit ainsi de garantir une véritable égalité des chances dans l'accès à la vie culturelle. Cet objectif est affirmé par le législateur qui reconnaît l'égal accès de tous, tout au long de la vie, à la culture, aux loisirs, aux vacances et à la pratique sportive comme un objectif national essentiel à l'exercice de la citoyenneté.

→ Art. 140 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions.

Sous cet angle, l'accès à la culture englobe celui au patrimoine, aux biens et aux services culturels. Bien que rarement énoncé de manière explicite, le droit d'accès au patrimoine culturel est affirmé dans certains instruments internationaux.

> → Art. 12 de la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones (2007) relatif à l'accès des peuples autochtones à leurs sites religieux et culturels, aux objets de cultes et aux restes humains.

Le plus souvent, le droit d'accès au patrimoine est déduit du droit, plus largement reconnu, de participer à la vie culturelle.

> → Conseil des droits de l'homme, rapport de l'expert indépendante dans le domaine des droits culturels, F. Shaheed, 17e session, 21 mars 2011.

Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels précise que ce droit suppose d'avoir accès à son propre patrimoine culturel et linguistique ainsi qu'aux patrimoines culturels et linguistiques d'autres cultures. De plus, les États doivent respecter le libre accès des minorités à leur culture, leur patrimoine et autres formes d'expression qui leur sont propres.

→ CDESC, Observation générale n° 21 : Droit de chacun de participer à la vie culturelle.

L'accès des individus aux institutions de gestion du patrimoine culturel (musées, bibliothèques, archives) relève également du droit d'accès au patrimoine culturel. Ce dernier peut être assuré notamment par le « recours aux technologies modernes de l'information », telles que la numérisation.

→ Conseil des droits de l'homme, Rapport de l'expert indépendante dans le domaine des droits culturels

Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels souligne enfin que les États ont l'obligation d'adopter *« des politiques culturelles pour la protection et la promotion de la diversité culturelle, et de faciliter l'accès à un ensemble riche et diversifié d'expressions culturelles »*.

→ CDESC, Observation générale n° 21 : Droit de chacun de participer à la vie culturelle.

3. La fondamentalisation des droits culturels sur la scène internationale

En droit international, l'évolution se traduit par l'émergence d'un corpus normatif en expansion, allant de la protection des œuvres à la reconnaissance des pratiques, savoirs et modes de vie. Les instruments du droit international, qu'ils soient universels ou régionaux, consacrent une conception de plus en plus anthropologique, dynamique et relationnelle de la culture, ouvrant la voie à une nouvelle génération de droits collectifs et individuels.

Toutefois, la question de l'effectivité et de la portée réelle de ces droits demeure, dans la mesure où leur reconnaissance repose majoritairement sur des instruments de soft law, dont la valeur contraignante reste limitée.

3.1. L'émergence des droits fondamentaux culturels ?

Le droit de la culture n'échappe pas tout à fait au mouvement d'expansion du champ des droits fondamentaux. Ce processus est notamment encouragé par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, dont les décisions renforcent progressivement la reconnaissance des droits culturels.

En particulier, le droit du public à accéder à des informations d'intérêt général, tel que consacré par la Cour de Strasbourg, peut être invoqué devant les juridictions nationales pour faire valoir des revendications culturelles.

→ CEDH, 17 février 2015, *Guseva c. Bulgarie*, req. n° 6987/07.

La culture tend à être reconnue comme un droit fondamental sur la scène internationale, tant dans sa dimension matérielle que symbolique. Face à la complexité de la notion de culture, les instruments juridiques internationaux l'appréhendent selon deux grands axes :

- Comme ressource de sens incarnée dans des œuvres, biens ou pratiques.
- Comme identité culturelle, englobant modes de vie, traditions et expression des groupes.

La Cour européenne des droits de l'homme mobilise ainsi la notion d'intérêt général dans le cadre de sa quête d'un « juste équilibre » entre les exigences de l'intérêt public et le respect du droit de propriété. À ce titre, la sauvegarde du patrimoine historique et culturel est considérée comme un « objectif légitime d'utilité publique », susceptible de justifier des mesures d'expropriation.

→ CEDH, 11 octobre 2011, *Helly et a. c. France*, n° 28216/09.

La Cour de Strasbourg peut également retenir des formes plus singulières de l'intérêt général culturel. Il en va ainsi de l'intérêt général rattaché à la « culture universelle », légitimant le maintien sur le territoire national d'œuvres créées par des artistes étrangers.

→ CEDH, *Beyeler c. Italie*, n° 33202/96.

En ce qui concerne l'Union européenne, on peut s'étonner que la Charte des droits fondamentaux mette en correspondance le droit de participer à la vie culturelle directement avec les droits des personnes âgées.

> *« L'Union reconnaît et respecte le droit des personnes âgées à mener une vie digne et indépendante et à participer à la vie sociale et culturelle »* (art. 25 CDFUE).

Il est sans doute regrettable que la Cour de justice demeure silencieuse en matière de droits culturels. Pire encore, les évolutions jurisprudentielles en matière de droits d'auteur semblent compromettre toute consécration véritable d'un droit d'accès à la culture dans l'Union.

→ CJUE, 16 juin 2016, *Vereniging Openbare Bibliotheken*, C-174/15.

→ CJUE, 8 septembre 2016*, ITV Broadcasting Limited*, C-275/15.

→ CJUE, 14 juin 2017, *Stichting Brein v Ziggo BV*, C-610/15.

À l'instar de ce qui a été observé pour les droits sociaux, les impératifs économiques tendent à prévaloir sur la reconnaissance et la protection des droits culturels dans l'ordre juridique de l'Union.

3.2. La culture comme identité et mode de vie

Des instruments comme la Déclaration universelle des droits de l'homme ou le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels consacrent un droit pour tous à participer à la vie culturelle.

→ Art. 27 DUDH.

→ Art. 15 PIDESC.

Dans le prolongement d'une fondamentalisation du droit à la culture, une approche extensive se développe dans les textes internationaux, au-delà des seules productions artistiques.

L'interprétation qu'en donne le Comité des droits économiques, sociaux et culturels embrasse une définition anthropologique : la culture est comprise comme un ensemble de pratiques, de croyances, de langues, de modes de vie et de rapports au monde par lesquels les individus et communautés expriment leur humanité.

→ CDESC, Observation générale n° 21 : Droit de participer à la vie culturelle.

Cette vision est partagée par la Déclaration de Fribourg qui met l'accent sur l'individu, ou le groupe, exprimant les significations qu'il donne à son existence et à son développement.

→ Art. 2 de la Déclaration de Fribourg sur les droits culturels, 7 mai 2007.

Cette approche qui met l'accent sur l'identité culturelle s'éloigne des définitions plus traditionnelles de la culture, privilégiées par les conventions de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture.

La divergence entre deux conceptions du droit à la culture – l'une centrée sur le patrimoine culturel et les œuvres, l'autre sur l'identité vécue – soulève des tensions et des interrogations quant à l'opérationnalité de ces droits, tant leurs contours restent imprécis et parfois discordants.

La Cour interaméricaine des droits de l'homme a reconnu, au niveau régional, le droit des groupes à participer à la vie culturelle. Elle affirme le droit collectif des peuples autochtones à la propriété de leurs terres, soulignant que leur relation à la terre dépasse la simple possession matérielle pour inclure un lien spirituel essentiel à la préservation et à la transmission de leur héritage culturel.

→ CIDH, 31 août 2001, *Mayagna (Sumo) Awas Tingni c. Nicaragua.*

Cette tendance marque une rupture avec le paradigme centré sur l'exceptionnalité artistique ou monumentale. La culture est conçue de plus en plus comme un droit relationnel, défini par les liens que des communautés entretiennent avec leurs pratiques, leurs savoirs, leurs expressions.

Actualité législative. - La restitution des biens culturels comme instrument de réappropriation du patrimoine

La loi du 9 mai 2026 *relative à la restitution de biens culturels ayant fait l'objet d'une appropriation illicite* marque une évolution importante de la politique française de restitution. Jusqu'alors, le principe d'inaliénabilité des collections publiques imposait, hors régimes particuliers, l'adoption de lois d'espèce pour permettre la restitution de certains biens culturels à des États étrangers. La loi de 2026 instaure désormais un cadre général de restitution, par dérogation au principe d'inaliénabilité du domaine public.

La restitution peut être demandée par un État, le cas échéant au nom d'un groupe humain qui demeure présent sur son territoire, lorsqu'elle vise la « *réappropriation par son peuple d'éléments fondamentaux de son patrimoine* ». Cette formulation consacre une conception du patrimoine qui ne se limite plus à la propriété matérielle de l'objet mais prend également en compte son lien avec l'identité, l'histoire et la culture d'une communauté.

Le mécanisme reste strictement encadré. Le bien doit notamment provenir du territoire actuel de l'État demandeur et avoir fait l'objet, entre le 20 novembre 1815 et le 23 avril 1972, d'un vol, d'un pillage, d'une cession ou d'une libéralité obtenue par contrainte ou violence, ou consentie par une personne qui ne pouvait en disposer. Des règles particulières sont prévues pour les biens archéologiques et ceux saisis par les forces armées.

La demande fait l'objet d'un examen par un comité scientifique paritaire, puis d'un avis public et motivé de la commission nationale de restitution de biens culturels. La sortie du domaine public est finalement prononcée par décret en Conseil d'État.

⟶ Loi n° 2026-351 du 9 mai 2026 relative à la restitution de biens culturels ayant fait l'objet d'une appropriation illicite.

À retenir. - Le droit de la culture évolue d'une logique exclusivement centrée sur la conservation des collections nationales vers une prise en compte du lien culturel unissant certaines communautés à leur patrimoine. Concrètement, la restitution devient ainsi un instrument de réappropriation culturelle, sans remettre en cause de manière générale le principe d'inaliénabilité des collections publiques.

3.3. Patrimoine immatériel et essor du numérique

La notion de patrimoine des personnes publiques a longtemps été limitée, en France aux biens matériels – bâtiments, monuments – laissant de côté les propriétés immatérielles, culturelles et artistiques. Le droit français, centré sur un patrimoine tangible, peine à intégrer les enjeux liés aux créations numériques, aux logiciels, aux droits d'auteur ou aux données.

La révolution du numérique est venue néanmoins bouleverser cette approche traditionnelle. L'essor massif des productions et diffusions numériques a révélé l'impérieuse nécessité de préserver cette nouvelle forme de patrimoine.

Les initiatives internationales, notamment celles menées sous l'égide de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture, soulignent l'importance cruciale de garantir l'accès au patrimoine numérique, tant pour les générations actuelles que futures.

→ Charte sur la conservation du patrimoine numérique, 15 octobre 2003.

1/ Actualité jurisprudentielle. - La numérisation d'une œuvre culturelle n'en fait pas un document administratif librement communicable

Le développement de la numérisation des collections publiques facilite l'accès aux œuvres, mais il ne transforme pas pour autant les biens culturels en documents administratifs soumis au droit commun de la communication.

À propos de reproductions numériques en trois dimensions d'œuvres d'Auguste Rodin, le Conseil d'État juge que les œuvres appartenant aux collections d'un musée, pas davantage que leurs reproductions, même numériques, ne constituent des documents administratifs au sens de l'article L. 300-2 du Code des relations entre le public et l'administration. Elles ne peuvent donc être obtenues sur le seul fondement de la liberté d'accès aux documents administratifs.

→ CE, 23 décembre 2025, *M. B. c/ Musée Rodin*, n° 487950.

À retenir : La numérisation favorise matériellement l'accès au patrimoine, mais elle ne fait pas naître, par elle-même, un droit subjectif général à obtenir la reproduction numérique des œuvres détenues par les institutions culturelles.

2/ Actualité législative. - L'intelligence artificielle renouvelle le conflit entre accès aux contenus et protection des créateurs

L'entraînement des modèles d'IA générative repose sur l'utilisation massive de contenus numériques, dont une partie est protégée par le droit d'auteur ou les droits voisins. Le droit de l'Union autorise, sous certaines conditions, la fouille de textes et de données, tout en permettant aux titulaires de droits de réserver l'utilisation de leurs œuvres. Le règlement européen sur l'intelligence artificielle précité impose également aux fournisseurs de modèles d'IA à usage général des obligations de transparence concernant notamment les contenus utilisés pour leur entraînement.

Face à la difficulté pour les auteurs de démontrer que leurs œuvres ont effectivement été utilisées, une proposition de loi adoptée par le Sénat le 8 avril 2026 prévoit une présomption simple d'utilisation : lorsqu'un indice relatif au développement ou au déploiement d'un système d'IA ou au résultat qu'il génère rend vraisemblable l'utilisation d'une œuvre protégée, il appartiendrait au fournisseur de démontrer qu'il ne l'a pas utilisée.

Le Conseil d'État a estimé que ce mécanisme probatoire est compatible avec le droit de l'Union et les exigences constitutionnelles dès lors qu'il demeure réfragable et ne constitue pas une présomption de contrefaçon : il facilite seulement la preuve de l'utilisation de l'œuvre.

→ Proposition de loi relative à l'instauration d'une présomption d'utilisation des contenus culturels par les fournisseurs d'intelligence artificielle, adoptée par le Sénat le 8 avril 2026 (le texte est désormais en examen à l'Assemblée nationale).

POUR ALLER PLUS LOIN

Pour un droit à la culture numérique*. Le monde numérique se doit d'être plus inclusif. L'évolution constante des usages et enjeux des nouvelles technologies de l'information redéfinit les compétences requises pour maîtriser ces outils. Si le numérique facilite l'apprentissage, il crée aussi une nouvelle forme d'illettrisme, l'illectronisme, lié à l'absence des compétences de base nécessaires à l'autonomie quotidienne. La maîtrise du numérique dépasse l'aspect technique pour inclure la compréhension des médias et l'information, formant une véritable culture numérique.*

Le numérique comme matrice de liberté. *La culture numérique ne saurait être pleinement inclusive sans une réinvention des cadres juridiques. Le « copyleft » constitue à cet égard une alternative au droit d'auteur classique, tout en s'appuyant sur ce dernier pour garantir la libre utilisation, modification et diffusion des œuvres, à condition de préserver ces mêmes libertés pour les utilisateurs suivants. Né dans le sillage du mouvement du logiciel libre initié par Stallman avec la création de la licence GPL en 1985, le copyleft vise à empêcher qu'un travail partagé devienne propriétaire. Il s'oppose à la logique exclusive du copyright en promouvant l'accès ouvert à la culture numérique et la collaboration des créateurs. Les licences copyleft – GPL, licences Creative Commons – imposent que toute œuvre dérivée reste elle-même sous copyleft. Malgré certaines limites (incompatibilités, complexité juridique), le copyleft a contribué à l'émergence d'une culture numérique fondée sur le partage et l'innovation, illustrée par des projets emblématiques comme GNU/Linux, Wikipedia ou les outils de Creative Commons. Dans le contexte du droit à la culture numérique, le copyleft apparaît comme un outil pertinent pour repenser l'accès au savoir et promouvoir un modèle plus démocratique de création.*

POUR S'ENTRAÎNER

Dissertation : Quelles sont les interactions entre droit à la culture et droit de la culture ?

Le concept de culture occupe une place croissante dans le champ juridique, tant sur le plan national qu'international. Pourtant, la distinction entre le droit à la culture, qui relève des droits fondamentaux des individus et des communautés, et le droit de la culture, qui regroupe l'ensemble des règles juridiques encadrant la production, la diffusion et la préservation des biens et activités culturels, reste floue dans de nombreux discours. Or, ces deux dimensions sont intimement liées : le droit à la culture ne peut pleinement s'exercer sans un cadre juridique protecteur et structuré, tandis que le droit de la culture doit rester au service de l'accès effectif à la culture pour tous.

En effet, des instruments internationaux comme le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (article 15) reconnaissent le droit de toute personne de participer à la vie culturelle, tandis que des textes tels que la Convention de l'UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles (2005) établissent des règles visant à préserver la diversité culturelle.

Problématique et annonce du plan. Il apparaît que ces deux notions, loin de s'opposer, se complètent et s'enrichissent mutuellement. Le droit à la culture fonde et légitime le droit de la culture **(I)**, tandis que le droit de la culture garantit les conditions d'effectivité du droit à la culture **(II)**.

I. Le droit à la culture comme fondement et finalité du droit de la culture

A. Le droit à la culture : un droit fondamental reconnu et protégé

Reconnaissance internationale (art. PIDESC : droit de participer à la vie culturelle ; art. 27 DUDH).

Reconnaissance nationale (Préambule de 1946, alinéa 13 ; Cons. const., déc. n° 2001-450 DC sur la loi relative à la liberté de communication).

B. Le droit de la culture : un ensemble normatif au service des droits culturels

Réglementation de la production et de la diffusion culturelles : droit de la propriété intellectuelle (Code de la propriété intellectuelle), régulation des industries culturelles (ex : quotas audiovisuels), politiques publiques de soutien à la culture, interventions de l'État et des collectivités territoriales, protection du patrimoine culturel (UNESCO, Code du patrimoine) …

II. Le droit de la culture comme condition d'effectivité du droit à la culture

A. Les instruments juridiques garantissant l'accès effectif à la culture

Politiques de démocratisation culturelle : tarification sociale, accès à l'éducation artistique, dispositifs spécifiques pour les publics défavorisés, protection de la diversité culturelle (Convention de l'UNESCO de 2005 sur la diversité des expressions culturelles), soutien aux langues régionales et minoritaires (Charte européenne, même si non ratifiée par la France) …

B. Les tensions et limites dans l'articulation des deux dimensions

Tensions entre propriété intellectuelle et accès à la culture : exceptions au droit d'auteur (bibliothèques, enseignement…), débat sur les biens communs culturels, risques d'instrumentalisation politique ou commerciale du droit de la culture (marchandisation de la culture, politiques culturelles excluantes ou discriminatoires…).

En conclusion, le droit à la culture et le droit de la culture, bien que distincts par leur nature, s'inscrivent dans une relation d'interdépendance : le premier constitue la finalité essentielle du second, tandis que le second fournit les outils juridiques indispensables à la pleine effectivité du premier, soulignant ainsi que la protection juridique de la culture ne saurait être dissociée de la garantie de son accès au plus grand nombre.

Fiche nº 53 - LE DROIT D'ASILE

POINTS CLÉS

- Asile conventionnel.
- Asile constitutionnel.
- Protection subsidiaire.
- Distinction demandeur d'asile / réfugié.
- Les différentes procédures de demande d'asile.
- Les différentes garanties liées au statut de demandeur d'asile ou de réfugié.

PRINCIPALES RÉFÉRENCES

- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Cons. const., déc. nº 93-325, 13 août 1993, Loi relative à la maîtrise de l'immigration et aux conditions d'entrée, d'accueil et de séjour des étrangers en France.
- Loi nº 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile.
- Loi nº 2018-778 du 18 septembre 2018, Loi pour une immigration maitrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie et portant diverses dispositions relatives au séjour et à l'intégration des étrangers.
- Loi nº 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration.
- Jean-Michel. Belorgey, *Le droit d'asile*, 2e ed., LGDJ, Systèmes, 2016.
- Vincent Tchen, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 17ème ed., LexisNexis/Litec, 2022

1. Définition du droit d'asile

Il existe différentes formes de protection que la France peut accorder à un demandeur d'asile. Un demandeur d'asile est une personne qui a fui son pays et qui sollicite le statut de réfugié.

En France, c'est l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui est compétent pour accorder ou non ce statut. En cas de refus, un recours peut être formé devant la Cour national du droit d'asile.

Le droit d'asile est un droit reconnu à l'article 14 de la Déclaration Universelle des droits de l'homme de 1948 :

> *« 1. Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l'asile en d'autres pays. 2. Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuite réellement fondées sur un crime de droit commun ou sur des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies. »*

1.1. L'asile conventionnel

La Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés impose aux États qui ont ratifié la Convention à apporter leur protection aux personnes qui doivent fuir leur pays en raison de situations mettant leur vie en danger et dans lesquelles leur intégrité physique, mentale et émotionnelle est menacée.

> → Convention de Genève, article 1, A, 2 : *« Toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays. »*

Plusieurs conditions sont donc nécessaires pour prétendre à cette protection :

- Avoir subi ou craindre de subir des persécutions et d'apporter la preuve que leur vie est en danger.
- Les persécutions doivent avoir été commises pour des motifs précis et limitatifs à savoir : du fait de la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un certain groupe social ou du fait des opinions politiques.
- Il faut avoir quitté le pays, car ce pays est incapable de protéger son ressortissant ou est à l'origine des persécutions.

Dans le cas de l'asile conventionnel, peu importe que la persécution redoutée émane de l'État. Il suffit que l'État d'origine soit dans l'incapacité de protéger contre la persécution (mariage forcé, crime d'honneur…).

1.2. La protection subsidiaire

La mise en place de la protection subsidiaire fait suite à la directive 2003/9/CE du Conseil de l'Union européenne du 27 janvier 2003 (révisée par la directive 2011/95 UE du Parlement et du Conseil du 13 décembre 2011).

Elle a été transposée en droit français à l'article L. 512-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui accorde une protection subsidiaire à toutes personnes dont la situation ne correspond pas à l'asile conventionnel, mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire :

- Qu'elles courent dans leur pays un risque réel de subir la peine de mort ou une exécution (PS1).
- Qu'elles seraient exposées à de la torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants (PS2).
- Qu'il existe une menace grave et individuelle contre elles en raison d'une violence aveugle résultant d'une situation de conflit armé intense ou international (PS3).

Actualité jurisprudentielle. - Une protection effectivement garantie dans un autre État membre fait obstacle à une nouvelle demande en France

Lorsqu'une personne bénéficie déjà d'une protection internationale dans un autre État membre, l'OFPRA peut déclarer sa demande d'asile irrecevable aussi longtemps que cette protection lui est maintenue et effectivement garantie.

En l'espèce, le CE précise que l'absence, dans l'État ayant accordé la protection subsidiaire, d'un droit au regroupement familial équivalent à celui dont le demandeur pourrait bénéficier en France ne suffit pas, à elle seule, à établir que la protection accordée ne serait pas effective.

→ CE, 30 janvier 2026, *M. A…B…C…*, n° 496221.

À retenir. - L'asile européen n'ouvre pas un droit à choisir l'État membre offrant le régime social ou familial le plus favorable. Une nouvelle protection ne peut normalement être revendiquée en France lorsqu'une protection internationale demeure effectivement garantie dans un autre État membre.

POUR ALLER PLUS LOIN

La Cour de Justice de l'Union européenne a précisé la notion de violence aveugle, notamment en cas d'intensité exceptionnelle. Dans ce cas, l'individualisation des craintes n'est plus nécessaire et la protection subsidiaire est accordée automatiquement au demandeur d'asile.

À l'inverse, si la violence est de faible intensité, le demandeur d'asile doit à nouveau démontrer qu'il risque d'être exposé à des atteintes graves et individuelles.

→ CJUE, aff. C-465/7, 17 février 2009, Meki Elgafaji.

→ CNDA, 19 novembre 2020, M. M., n° 18054661 : liste pour évaluer le niveau de violence aveugle : méthode de guerre, nombre de victimes civiles, violation des droits humains, déplacements des populations.

1.3. L'asile constitutionnel

En France, le droit d'asile a une valeur constitutionnelle, consacrée par une décision du Conseil constitutionnel du 13 août 1993 :

> *« Considérant que le respect du droit d'asile, principe de valeur constitutionnelle, implique d'une manière générale que l'étranger qui se réclame de ce droit soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande »* (Cons. const., déc. n° 93-325, 13 août 1993, *Loi relative à la maîtrise de l'immigration et aux conditions d'entrée, d'accueil et de séjour des étrangers en France*).

L'asile constitutionnel est mentionné à l'article 4 du préambule de la Constitution de 1946 : *« Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d'asile sur le territoire de la République. »*

Un réfugié qui bénéficie de l'asile constitutionnel bénéficie de la même protection que celle accordée sous l'empire de l'asile conventionnel.

Cependant, ce statut est accordé pour des motifs différents :

- Pour obtenir le statut de réfugié sur la base de la Constitution française, il est impératif d'avoir subi des persécutions.
- Le préambule de la Constitution ne prévoit qu'un seul motif de persécution : « l'action en faveur de la liberté ». Il n'existe pas de définition exacte de cette dernière. La Commission des recours des réfugiés (devenue la Cour nationale du droit d'asile) retient, par exemple, qu'a constitué une action en faveur de la liberté le militantisme d'une Afghane en faveur des droits des femmes dans son pays ou l'engagement public d'un Colombien dans la mise en place de programmes sociaux et la lutte contre les stupéfiants dans son pays.
- Enfin, il est nécessaire que le demandeur ait participé à un combat : le préambule de la Constitution de 1946 exige qu'il y ait eu une action de sa part.

2. Les différentes procédures de demande d'asile

2.1. La procédure classique

2.1.1. La demande devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides

Le demandeur d'asile s'enregistre au guichet unique et introduit sa demande auprès de l'Office en déposant son dossier. Une attestation de demande d'asile valant autorisation de séjour pendant un mois sur le territoire français est délivrée par la préfecture.

Le demandeur d'asile dispose alors de 21 jours pour transmettre sa demande.

Lorsque le dépôt du dossier a été effectué dans le délai, l'Office envoie une lettre d'enregistrement de la demande lui permettant de faire renouveler son attestation de demande d'asile pour 9 mois jusqu'à la décision définitive sur sa demande d'asile.

Le demandeur d'asile est ensuite convoqué à un entretien avec l'Office.

En moyenne, l'Office rend sa décision dans un délai de six mois à compter de l'introduction de la demande.

2.1.2. Le recours devant la Cour nationale du droit d'asile

En cas de rejet de la demande d'asile, le demandeur dispose d'un délai d'un mois pour saisir la Cour Nationale du Droit d'Asile : il peut demander l'octroi d'une protection en cas de décision de rejet de l'Office ou demander la reconnaissance de la qualité de réfugié en cas d'octroi de la protection subsidiaire.

La Cour délivre un accusé de réception d'un recours permettant de renouveler l'attestation de demande d'asile et que le demandeur puisse rester en France jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande.

Il est possible pour le demandeur de se faire assister par un avocat et un interprète lors de l'audience devant la Cour.

2.2. La procédure « accélérée »

L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure dite « accélérée » notamment quand la demande émane d'une personne originaire d'un pays dit « sûr » où il possède sa résidence. La durée du traitement est alors réduite à 15 jours ou 96 heures si la personne est en rétention.

La liste des pays d'origine sûrs est fixée par le conseil d'administration de l'Office sous le contrôle du Conseil d'État. Cette liste a été actualisée à la suite de la décision du Conseil d'État du 2 juillet 2021.

Cette liste comprend 13 États : la République d'Albanie, la République d'Arménie, la Bosnie-Herzégovine, la République du Cap-Vert, la Géorgie, la République de l'Inde, la Macédoine du Nord, la République de Maurice, la République de Moldavie, la République de Mongolie, la République du Monténégro, la République de Serbie, la République du Kosovo.

La notion de pays d'origine sûr a été introduite dans la loi n° 2003-1176 du 10 décembre 2003. Elle tend à présumer du caractère infondé de certaines demandes d'asile formulées par des ressortissants originaires de pays où il n'y aurait pas de risques sérieux de persécutions.

Un pays est considéré comme « sûr » lorsqu'il peut être démontré qu'il n'a jamais recouru à la persécution, à la torture, à des peines ou traitements inhumains ou dégradants et qu'il n'y a pas de menace en raison d'une violence qui pourrait s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle dans des situations de conflit armé international ou interne.

→ Loi n° 2003-1176 du 10 décembre 2003 modifiant la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile.

→ Art. L. 722-1 CESEDA.

POUR ALLER PLUS LOIN

Le 16 avril 2025 la Commission européenne à publier une liste de sept pays « sûrs » : le Kosovo, le Maroc, la Tunisie, l'Égypte, l'Inde, le Bangladesh et la Colombie.

Elle souhaite établir une liste commune à tous les États membres relative aux « pays d'origine sûrs » en incluant les pays candidats à l'adhésion à l'Union européenne, car il n'existe pas de liste commune et harmonisée à l'échelle européenne.

Cette liste pourrait être élargie ou restreinte en fonction de l'évolution de la situation des droits de l'Homme dans les pays qui y figurent, mais il n'y a pas de consensus européen à l'heure actuelle.

Actualité européenne. - Une liste commune des pays d'origine sûrs est désormais fixée au niveau de l'Union

Le règlement (UE) 2026/464 du 24 février 2026 instaure pour la première fois une liste commune de pays d'origine sûrs à l'échelle de l'Union européenne. Sont désignés comme tels : le Bangladesh, la Colombie, l'Égypte, l'Inde, le Kosovo, le Maroc et la Tunisie. Les États candidats à l'adhésion à l'Union sont également, en principe, considérés comme sûrs, sous réserve des exceptions prévues par le règlement.

Cette qualification permet notamment de soumettre la demande à une procédure accélérée. Elle n'instaure cependant pas une présomption irréfragable : le demandeur doit toujours pouvoir établir, dans le cadre d'un examen individuel, que son pays ne peut être considéré comme sûr au regard de sa situation personnelle. Une désignation peut également comporter des exceptions concernant certaines parties du territoire ou certaines catégories identifiables de personnes.

Les États membres conservent la possibilité d'établir des listes nationales comportant d'autres pays satisfaisant aux critères européens.

→ Règl. (UE) 2026/464 du 24 février 2026.

À retenir. - La qualification de « pays d'origine sûr » permet d'accélérer l'examen d'une demande, mais elle ne dispense jamais d'un examen individuel permettant au demandeur de renverser la présomption de sûreté.

La procédure accélérée est aussi mise en œuvre dans divers cas : la personne sollicite un réexamen de sa demande d'asile, sur le constat du préfet, quand la personne dépose une demande pour faire obstacle à une mesure d'éloignement, quand la personne refuse le relevé de ses empreintes sur le fichier Eurodac, quand la personne présente à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides des déclarations manifestement incohérentes et contradictoires…

Le placement en procédure accélérée est déterminé soit par la loi, soit à l'initiative des préfectures, soit à l'initiative de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

L'Office peut déclasser une procédure accélérée vers la procédure normale s'il juge que des éléments du dossier nécessitent une instruction approfondie. Cette décision peut intervenir à tout moment à partir de l'introduction de la demande à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

POUR ALLER PLUS LOIN

Le 10 avril 2024, le Parlement européen a adopté un règlement relatif à la gestion de l'asile et de la migration au sein de l'Union européenne. Ce nouveau pacte met en place :

- *Des règles uniformes pour identifier les ressortissants de pays tiers à leur arrivée (« filtrage » des migrants) ;*
- *Une base commune de données avec des données plus fiables et plus complètes pour détecter les mouvements irréguliers avec le relevé de données biométriques (règlement Eurodac) ;*
- *De nouvelles procédures d'asile, de retour et « aux frontières » ; la mise en place d'un mécanisme de solidarité entre les États membres pour l'accueil des migrants et des règles plus claires concernant la prise en charge des demandeurs d'asile (pour remplacer le règlement Dublin III) ;*
- *La gestion des situations de crise par la coopération des États membres ;*
- *L'établissement de normes d'accueil des personnes demandant une protection internationale.*

Un nouveau Pacte attend actuellement d'être approuvé par le Conseil de l'Union européenne pour entrer en vigueur.

2.3. La procédure « Dublin »

Les règlements « Dublin » I, II et III reposent sur le principe de confier le traitement des demandes d'asile des personnes ressortissantes des États tiers en fonction du pays par lequel elles sont rentrées sur le territoire de l'Union européenne.

Il s'agit ici d'éviter un « marché du droit d'asile » en évitant que les demandeurs d'asile déposent une demande d'asile dans plusieurs États membres à la fois.

L'État membre désigné comme responsable de la demande d'asile doit prendre en charge cette demande et la traiter. Si un État membre est saisi d'une nouvelle demande d'asile, et qu'il considère qu'un autre État membre est compétent, il peut demander à ce dernier de reprendre en charge la personne et sa demande d'asile.

Depuis la troisième version du dispositif, l'État saisi d'une nouvelle demande peut aussi décider de conserver la maîtrise de la procédure.

La loi transpose le règlement Dublin III dans le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.. Lorsque l'examen de la demande d'asile relève d'un autre État membre, les demandeurs placés sous procédure Dublin ne peuvent saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, car un autre pays de l'Union européenne est potentiellement responsable de leur demande.

En effet, selon le règlement Dublin III, un seul état est responsable de l'examen d'une demande d'asile dans l'Union européenne :

- Soit le pays par lequel le demandeur d'asile est entré et dans lequel il a été contrôlé ;
- Soit l'État qui a accordé un visa ou un titre de séjour au demandeur d'asile.

En France, c'est la préfecture qui détermine l'État responsable de la demande d'asile. Lors du premier rendez-vous, la préfecture relève les empreintes du demandeur d'asile pour faire des recherches sur deux fichiers :

- Eurodac : fichier dans lequel les empreintes relevées dans tous les États membres de l'Union européenne sont enregistrées.
- Visabio : permet de vérifier si un visa a été obtenu dans un autre pays de l'Union européenne.

2.4. Le réexamen de la demande

Une demande de réexamen après un rejet définitif de la demande d'asile peut être présentée si le demandeur invoque des faits nouveaux, soit postérieurs à la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, soit antérieurs s'il n'en avait pas connaissance, ou encore s'il dispose de nouvelles preuves.

Ces éléments doivent permettre d'établir de manière crédible la crainte du demandeur d'asile de retourner dans son pays d'origine.

L'Office français de protection des réfugiés et apatrides enregistre la demande et examine sa recevabilité dans un délai de 8 jours.

- Si la demande de réexamen ne repose sur aucun élément nouveau ou que les éléments nouveaux ne sont pas pertinents, l'Office prend une décision d'irrecevabilité.
- Si les faits ou éléments nouveaux sont pertinents, le demandeur est convoqué à un entretien pour examiner et statuer sur la demande.

En cas de décision de rejet, un recours est à nouveau possible devant la Cour nationale du droit d'asile.

3. Les garanties offertes aux demandeurs d'asile et aux réfugiés

3.1. Les garanties liées au statut de demandeur d'asile

Les demandeurs d'asile sont dispensés de présenter un passeport ou un document justificatif d'identité, visas, attestations d'hébergement et justificatifs de ressources qui sont exigés normalement en vertu du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Ils doivent immédiatement déclarer qu'ils demandent l'asile : délai de 90 jours en France et 60 jours en Guyane pour déposer leur demande.

Le Préfet délivre alors une autorisation provisoire de séjour au demandeur qui lui permet de se déplacer librement sur le territoire.

→ Art. L. 741-1 CESEDA

Dans l'attente du traitement de leur demande, ils bénéficient d'une allocation temporaire d'attente ou d'un hébergement en centre d'accueil. En pratique, les demandeurs sont souvent réorientés vers une région en particulier dans laquelle ils sont tenus de résider le temps de l'examen de leur demande.

Les recours contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sont suspensifs.

→ CE, 2 septembre 1985, *France terre d'asile*, n° 44484 44485.

Bien souvent, la situation est très précaire dans les camps de regroupement des demandeurs d'asile : absence d'eau potable, d'hygiène, de soins élémentaires, d'électricité, violence… Exemple de la « jungle de Calais » qui en est l'illustration la plus dramatique. Le Conseil d'État a jugé que la carence de l'État à répondre aux besoins élémentaires des migrants s'assimile à un traitement inhumain et dégradant.

→ CE, 31 juillet 2017, n° 412125 et 412171.

3.2. Les garanties liées au statut de réfugié

La reconnaissance du statut de réfugié accorde un droit de séjour en France ainsi qu'à certains membres de sa famille.

Le réfugié bénéficie ainsi d'une carte de résident valable 10 ans.

→ Art. L. 314-11 CESEDA.

Les bénéficiaires de la protection subsidiaire se voient délivrer une carte de séjour pluriannuelle pour une durée maximale de 4 ans.

→ Art. L. 424-9 CESEDA.

Un titre d'identité et de voyage est aussi délivré aux réfugiés, il est valable pour tous les pays sauf pour leur pays d'origine qu'ils ont fui. Ils peuvent aussi obtenir l'échange de leur permis de conduire.

Pendant la durée de leur séjour, ils bénéficient des mêmes droits que les nationaux.

POUR S'ENTRAÎNER

Commentaire d'arrêt : Cons. const., n° 93-325 DC, 13 août 1993, *Loi relative à la maîtrise de l'immigration et aux conditions d'entrée, d'accueil et de séjour des étrangers en France*.

Cette décision du Conseil constitutionnel illustre la manière dont notre Constitution aborde les droits fondamentaux des étrangers et protège les droits de tous. Les étrangers qui peuvent être en situation irrégulière possèdent des droits fondamentaux qui sont particulièrement vulnérables et peuvent faire l'objet d'un traitement différencié.

Avec la décision Cons. const., n° 2018-717/718 QPC, 6 juillet 2018, le Conseil constitutionnel estime qu'il découle du principe de fraternité *« la liberté d'aider autrui, dans un but humanitaire, sans considération de la régularité de son séjour sur le territoire national »* permettant ainsi de censurer le délit d'aide. Cependant le principe de fraternité doit se concilier avec l'objectif de lutte contre l'immigration irrégulière qui participe de la sauvegarde de l'ordre public.

La loi de 1993 s'inscrit dans un ensemble législatif qui marque une politique de fermeté à l'égard de l'immigration (loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France « loi Pasqua » et loi n° 97-396 du 24 avril 1997 portant diverses dispositions relatives à l'immigration « loi Debré »). Ces lois déterminent un régime de police propre aux étrangers.

Problématique et annonce du plan : Cette décision pose le cadre des droits et libertés des étrangers en France en conciliant les droits des étrangers et le principe d'égalité **(I)** et en reconnaissant des droits fondamentaux aux étrangers **(II)**.

I. Droit des personnes migrantes et principe d'égalité

A. Les critères de l'altérité : la distinction entre étranger et national

Dans une décision antérieure, Cons. const., n° 89-269 DC, 22 janvier 1990, le Conseil constitutionnel avait initié une différenciation entre les droits des étrangers et ceux des nationaux. Aucun principe ni aucune règle de valeur constitutionnelle n'assure aux étrangers des droits de caractère général et absolu d'accès et de séjour sur le territoire national. Le second considérant de la décision permet au législateur de prendre des dispositions restrictives des libertés vis-à-vis des demandeurs d'asile.

B. La tolérance de la différence de traitement

Dans cette décision, le Conseil constitutionnel évalue certaines différences de traitement pouvant exister entre étrangers notamment pour l'obtention des droits découlant de l'obtention d'une carte de résident.

Certaines catégories d'étrangers sont assimilables aux nationaux notamment dans le cas d'étrangers ayant étudié en France pendant une dizaine d'année (cons. 26).

L'attitude de l'étranger, son respect de la législation ou *a contrario* la violation de la législation peut déterminer l'accès à certaines procédures (abrogation d'un arrêté d'expulsion ou relèvement d'une interdiction de territoire).

La loi peut aussi établir différentes procédures d'examen des demandes d'asile en fonction de la nationalité du demandeur : procédure prioritaire « Dublin » III mise en œuvre pour les ressortissants des pays dits « sûrs » ou mise en œuvre de l'asile constitutionnel ou conventionnel, ou encore la protection subsidiaire.

II. Les droits fondamentaux des personnes migrantes

A. La liberté d'aller et de venir des étrangers : un enjeu de souveraineté

Droit d'asile prévu par l'alinéa 4 du préambule de la Constitution de 1946 : *« Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d'asile sur le territoire de la République. »*

Le considérant 84 de la décision fournit les garanties de ce droit avec l'autorisation temporaire pour rester sur le territoire le temps que la demande soit examinée et les droits de la défense respectés. Le Conseil constitutionnel impose l'accueil de l'étranger et ses droits de la défense. La France doit procéder à l'examen de la situation des demandeurs d'asile qui seraient persécutés pour leurs actions en faveur de la liberté, avec admission provisoire de séjour le temps de statuer sur leur demande.

Conciliation entre la liberté d'aller et de venir et la protection de la sécurité nationale. La question du droit d'entrée et de séjour des étrangers demeure une question de souveraineté et les conditions de délivrance des titres de séjours peuvent évoluer sans que la garantie des droits fondamentaux ne s'y opposent.

Possible décision judiciaire ou administrative de rétention des étrangers.

B. Les droits fondamentaux des étrangers : un enjeu d'humanité

Les droits des étrangers peuvent subir des restrictions particulières, notamment pour que ces droits ne deviennent pas un moyen de contourner les règles relatives à l'entrée et au séjour sur le territoire.

Liberté du mariage : son respect s'oppose à ce que le caractère irrégulier du séjour d'un étranger fasse obstacle, par lui-même, au mariage de l'intéressé.

Droit à une vie familiale normale et regroupement familial : considérant 70 *« les étrangers dont la résidence en France est stable et régulière ont, comme les nationaux, le droit de mener une vie familiale normale ; que ce droit comporte en particulier la faculté pour ces étrangers de leurs conjoints et leurs enfants mineurs sous réserve de restrictions tenant à la sauvegarde de l'ordre public et à la protection de la santé publique* […] *»*. Le caractère « normal » de la vie familiale s'apprécie selon les conditions qui « prévalent en France, pays d'accueil », ce qui exclut la polygamie.

Le législateur peut déterminer les conditions d'appréciation de la stabilité du séjour nécessaire au regroupement familial.

Les étrangers bénéficient des mêmes droits sociaux que les nationaux : accès aux soins, prestations sociales et familiales, droit au respect de la vie privée et des données personnelles… S'agissant des demandeurs d'asile, la France encadre les différentes procédures. L'accession au statut de réfugié permet à ce dernier d'acquérir des droits équivalents à ceux des nationaux.

En conclusion, le Conseil constitutionnel vérifie et encadre la différence de traitements des migrants tout en étant garant de leurs droits fondamentaux.

PARTIE VIII. L'ÉGALITÉ ET LA NON-DISCRIMINATION

FICHE Nº 54

L'interdiction de la discrimination

FICHE Nº 55

La prise en compte des vulnérabilités

FICHE Nº 56

Les mesures d'inégalité compensatoire

Fiche nº 54 - L'INTERDICTION DE LA DISCRIMINATION

POINTS CLÉS

- *Principe d'égalité : même loi pour tous.*
- *Interdiction des traitements différenciés fondés sur des critères prohibés.*
- *Critères prohibés : sexe, origine, orientation sexuelle, handicap…*
- *Liste non limitative des critères prohibés.*
- *Égalité formelle versus égalité réelle : évolution du droit français.*
- *Influence anglo-américaine et du droit européen.*
- *Discriminations ou actions positives.*
- *Discriminations positives.*

PRINCIPALES RÉFÉRENCES

- Art 1er et 6 DDHC.
- Art. 1er de la Constitution (1958).
- Art. 14 CESDH et 1P12.
- Art. 21 CDFUE.
- CJCE, 12 février 1974, *Sotgiu*, aff.152/73.
- CEDH, 16 mars 2010, *Carson c. Royaume-Uni*, 42184/05.
- Cons. const., déc. nº 91-290 DC du 9 mai 1991, *Loi portant statut de la collectivité territoriale de Corse.*

.

1. Le principe de non-discrimination, prolongement du principe d'égalité

La problématique de l'articulation entre égalité et non-discrimination a fait couler beaucoup d'encre et passablement animé la doctrine juridique. Du fait de son caractère général et abstrait, le principe d'égalité qui interdit toute différenciation de traitement, quel qu'en soit le motif, peine à appréhender certaines formes subtiles, mais bien concrètes de discriminations.

Le principe de non-discrimination vient compléter ce cadre en interdisant explicitement les distinctions fondées sur une liste déterminée de critères édictés par les textes. Ainsi, la lutte contre les discriminations s'appuie sur cette identification précise des motifs prohibés.

Sous l'influence des traditions juridiques anglo-américaines et européennes, le droit français a ainsi évolué, passant d'une vision abstraite de l'homme-citoyen à une reconnaissance de la personne humaine dans sa singularité. Toutefois, l'évolution du droit positif s'inscrit dans le cadre républicain, qui refuse toute remise en cause de l'unité indivisible du peuple français.

Il reste que le droit à l'égalité et le droit à la non-discrimination, loin d'être antagonistes, se complètent pour garantir une exigence commune : traiter sans distinction les êtres humains tout en tenant compte de leurs différences réelles.

1.1. Une modernisation du principe d'égalité de 1789

Aux XVIIIe et XIXe siècles, la passion française pour l'égalité, selon Tocqueville, trouva sa traduction juridique dans l'égalisation des droits civils et politiques et dans l'affirmation de l'unité du peuple français.

Ce principe s'énonce, dans sa formule la plus ramassée, dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, tant à travers l'affirmation de l'égalité des droits des citoyens que de l'égalité devant la loi.

→ Art. 1er et 6 DDHC.

L'approche républicaine du principe d'égalité n'a pas empêché la persistance d'importantes inégalités, y compris devant la loi : en témoignent le statut juridique des femmes résultant du Code civil de 1804 (autorité maritale, incapacité…) et les restrictions au droit de vote (suffrage censitaire, masculin).

Si l'article 1er de la Constitution actuelle affirme solennellement que la République *« assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de race ou de religion »*, il est fréquent de relever le caractère mythologique de l'égalité républicaine qui, du fait de son caractère formel tend à masquer, encore de nos jours, la réalité des discriminations à l'égard des femmes ou des personnes issues des minorités.

Le droit à la non-discrimination vise, plus concrètement, à donner des solutions opératoires auxquelles l'égalité seule ne pourrait parvenir. L'interdiction des discriminations autorise ainsi une approche plus pragmatique de l'exigence d'égalité qui apparaît plus en phase avec la complexité contemporaine du social.

1.2. L'influence internationale sur le droit positif français : une conception plus « anglo-saxonne » de l'égalité

L'intégrisme républicain s'est révélé être une impasse. Le droit français, sous influence du droit européen et des exemples étrangers notamment américain, a évolué de manière à reconnaître effectivement des droits réellement égaux. On est passé de l'abstraction de l'homme et du citoyen à un homme situé et incarné dans sa singularité.

Ainsi, pour les différents instruments internationaux, la prohibition des discriminations est toujours associée à une liste de critères de différenciation prohibés.

Il en est ainsi dans la Convention européenne des droits de l'homme ou la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qui affirment toutes deux explicitement le principe de « l'interdiction des discriminations » suivi d'une liste de critères (sexe, race, couleur, origines ethniques ou sociales, caractéristiques génétiques, langue, religion, convictions, opinions politiques, appartenance à une minorité nationale, fortune, naissance, handicap, âge, orientation sexuelle).

→ Art. 21 CDFUE : s'agissant du droit de l'Union, la spécificité du cadre intégratif européen accorde une importance particulière à l'interdiction des discriminations fondées sur la nationalité.

Dans le cadre du droit de la Convention, l'interdiction des discriminations est également consacrée par le Protocole additionnel no 12 afin de conférer une portée plus large au principe d'interdiction des discriminations de la Convention.

La législation française, en conformité avec le droit de l'Union, assure désormais la protection du principe de non-discrimination et n'hésite pas à énumérer les motifs prohibés (origine, sexe, mœurs, orientation sexuelle, identité de genre, âge, situation de famille, grossesse, caractéristiques génétiques…)

→ Art. 1er de la loi du 27 mai 2008.

→ Art. L. 1132-1 du Code de travail.

→ Art. 225-1 du Code pénal.

Il faut encore souligner que les listes des critères établies par les textes européens ne sont pas fermées puisqu'elles sont introduites, tant dans la Convention que la Charte ; par l'adverbe « notamment ». La Cour européenne des droits de l'homme a confirmé que les différences de traitement fondées sur d'autres critères que ceux expressément énumérés sont donc susceptibles d'être saisies aussi.

→ CEDH, 16 mars 2010, *Carson c Royaume-Uni.*

Le processus de segmentation sociale ne saurait toutefois remettre en cause l'indivisibilité de la République, par une approche de différentiation des composantes du peuple français.

Le Conseil constitutionnel a ainsi pu censurer la mention du « peuple corse composante du peuple français » en soulignant que la Constitution ne connaît que le peuple français « sans distinction d'origine, de race ou de religion ».

→ Cons. const., déc. n° 91-290 DC du 9 mai 1991, *Loi portant statut de la collectivité territoriale de la Corse.*

1.3. Droit à l'égalité et droit à la non-discrimination : deux faces d'une même exigence diversement déclinée

Le droit à l'égalité et à la non-discrimination reposent tous deux sur l'interdiction des différences de traitement fondées sur différents critères de plus en plus nombreux dont la plupart font écho à des droits et libertés fondamentaux : état de santé, orientation sexuelle, opinions politiques, religion, activité syndicale…

Le droit à l'égalité et à la non-discrimination prolongent les garanties assurées sur le fondement de ces différents droits et libertés. Égalité formelle et égalité réelle apparaissent donc comme deux logiques complémentaires.

1.3.1. L'égalité formelle

L'égalité formelle implique que la loi soit la même pour tous, et que nul ne soit moins bien traité à raison de telle ou telle de ses caractéristiques propres. C'est l'approche traditionnelle du principe d'égalité en droit français qui justifie, par exemple, l'annulation d'une décision privant des militants politiques de la possibilité de se présenter au concours de l'ENA (désormais INSP) ou le dédommagement d'un salarié n'ayant pas bénéficié du même avancement que ses collègues à raison de ses activités syndicales.

→ CE, ass., 28 mai 1954, *Barel*, n° 28238 28493 28524 30237 30256.

→ Cass. soc., 15 février 2006, n° 04-45.738.

L'égalité formelle n'impose pas, contrairement à ce qui est parfois avancé, une stricte égalité de traitement. Le Conseil constitutionnel a ainsi estimé que le principe d'égalité *« ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que la différence de traitement soit en rapport direct avec l'objet de la loi »*.

→ Cons. const., déc. n° 2003-487 DC, 18 décembre 2002, *Loi portant décentralisation en matière de RMI.*

1.3.2. L'égalité réelle

L'égalité réelle, apparue sous l'influence du juge européen, se veut plus opératoire puisqu'elle permet d'appréhender des mesures qui, quoique neutres en apparence, sont susceptibles d'entraîner un désavantage particulier pour une catégorie de personnes définie sur la base d'un des critères de différenciation prohibés (race, sexe, orientation sexuelle…). C'est le principe de l'interdiction des discriminations dites « indirectes ».

Initialement consacrée par la Cour de justice de l'Union dès les années 1970, l'interdiction des « discriminations indirectes » a été reprise dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme.

→ CJCE, 12 février 1974, Sotgiu.

→ CEDH, 4 mai 2001, *Hugh Jordan c. Royaume-Uni.*

L'interdiction des discriminations, même indirectes, a pénétré le droit interne via l'obligation pour la France de transposer dans sa législation le droit de l'Union européenne.

→ Loi n° 2008-496 du 27 mai 2008.

L'interdiction des discriminations indirectes, désormais appliquée par le juge judiciaire et administratif, permet ainsi d'appréhender des mesures ayant pour effet d'entraîner un désavantage particulier pour les femmes.

→ Cass. civ. 2e, 9 novembre 2017, n° 16-20404.

L'interdiction des discriminations prend parfois une tournure particulière en droit européen. Ainsi, selon la Cour de justice, le principe d'égalité oblige à « traiter différemment » les personnes qui sont dans des « situations différentes ».

→ CJUE, 17 juillet 1963, *Italie c. Commission.*

La Cour de Strasbourg suit le même raisonnement en exigeant que l'interdiction des discriminations est transgressée lorsque les États n'appliquent pas un traitement différent à des personnes dont les situations sont sensiblement différentes.

→ CEDH, 6 avril 2000, *Thlimmenos / Grèce.*

Sans être toujours sur la même ligne que les Cours européennes, le juge judiciaire applique parfois un raisonnement similaire en estimant que le principe d'égalité s'oppose à ce que des situations comparables soient traitées de manière différente et que des situations différentes soient traitées de manière identique.

→ Cass. civ. 1re, 22 septembre 2016, *Syndicat des médecins d'Aix et régions aux dépens,* no 15-23.664.

Pour ce qui est du juge constitutionnel et du juge administratif, le principe d'égalité n'implique pas que des personnes se trouvant dans des situations différentes soient soumises à des régimes différents.

→ Cons. const., déc. no 2006-541 DC, 28 septembre 2006, *Accord sur l'application de l'article 65 de la Convention sur la délivrance de brevets européens.*

→ CE, ass. 28 mars 1997, *Baxter*, no 179049 179050 179054.

Actualités jurisprudentielles :

1/ La discrimination peut résulter du lien entretenu avec une personne présentant une caractéristique protégée

La protection contre les discriminations ne bénéficie pas seulement à la personne qui présente elle-même la caractéristique protégée. Une personne peut également subir une discrimination par association, lorsqu'elle est défavorisée en raison du handicap, de l'origine ou d'une autre caractéristique d'une personne avec laquelle elle entretient un lien.

En l'espèce, une salariée avait demandé à bénéficier durablement d'horaires fixes afin de pouvoir s'occuper de son enfant atteint d'un handicap grave. La Cour de justice juge que l'interdiction des discriminations indirectes fondées sur le handicap prévue par la directive 2000/78 s'étend au travailleur qui, sans être lui-même handicapé, subit un désavantage en raison de l'assistance qu'il apporte à son enfant handicapé.

La Cour va encore plus loin en considérant que l'employeur peut être tenu de prévoir des aménagements raisonnables des conditions de travail de ce salarié, dès lors qu'ils sont nécessaires pour lui permettre d'assurer cette assistance et qu'ils n'imposent pas à l'employeur une charge disproportionnée.

→ CJUE, 11 septembre 2025, *Bervidi*, C-38/24.

À retenir. - Le critère discriminatoire n'a pas nécessairement à caractériser directement la victime. Le droit de l'Union protège également celui qui subit un traitement défavorable en raison de son association avec une personne protégée. Cette protection peut même entraîner une obligation d'aménagement raisonnable.

2/ Un critère apparemment distinct de l'origine ethnique peut révéler une discrimination

En l'espèce, une réglementation danoise (dite « loi ghetto ») imposait de réduire le nombre de logements sociaux dans certains quartiers qualifiés de « zones en transformation ». Cette qualification dépendait notamment de la présence, pendant plusieurs années, de plus de 50 % d'« *immigrés originaires de pays non occidentaux et de leurs descendants* », et pouvait conduire à la résiliation de baux de logements sociaux.

La CJUE rappelle que l'origine ethnique constitue une notion autonome reposant sur un ensemble de facteurs, notamment l'origine géographique, la langue, la religion, les traditions ou le milieu culturel. La nationalité ou le pays de naissance ne se confondent donc pas nécessairement avec l'origine ethnique.

Il appartient néanmoins au juge national de rechercher si, derrière le critère des personnes originaires de pays « *non occidentaux* », la réglementation conduit en réalité à traiter moins favorablement une population identifiée selon son origine ethnique. À défaut de discrimination directe, il doit encore rechercher l'existence d'une discrimination indirecte et, le cas échéant, contrôler strictement sa justification et sa proportionnalité, notamment au regard du droit au respect du domicile.

→ CJUE [GC], 18 décembre 2025, *Slagelse Almennyttige Boligselskab, Afdeling Schackenborgvænge*, C-417/23.

À retenir. - Le juge ne s'arrête pas à la qualification formelle du critère utilisé. Un critère de nationalité, d'origine géographique ou de résidence peut fonctionner comme un substitut à l'origine ethnique et révéler une discrimination directe ou indirecte.

1.3.3. L'opposition entre les modèles français et anglo-américain

L'opposition frontale entre le modèle français, souvent critiqué pour son abstraction et son ignorance des inégalités réelles, et le modèle anglo-américain, jugé plus empirique et effectif, doit être nuancée. Si elle n'est pas dénuée de pertinence, la critique a surtout une saveur historique, car elle néglige l'évolution qu'a connu le droit français, notamment sous l'influence du droit de l'Union européenne.

Cette controverse nourrit l'opposition entre le droit à l'égalité et le droit à la non-discrimination. Toutefois, les indices d'une équivalence entre ces deux droits sont nombreux.

La jurisprudence de la Cour de justice à propos de la directive relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité social montre qu'en matière de « discriminations contraires au droit communautaire », tant que des « mesures rétablissant l'égalité de traitement » n'ont pas été adoptées, le respect du « principe d'égalité » ne peut être assuré que par l'octroi aux personnes défavorisées des mêmes avantages que ceux dont bénéficient les personnes de la catégorie privilégiée.

→ Directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978.

→ CJUE, 12 décembre 2002, *Caballero c. Fogasa.*

En France, les critiques adressées à l'approche formelle de l'égalité ont contribué à faire comprendre le besoin de traiter différemment des situations différentes. La non-discrimination a offert une technique de qualification des ruptures d'égalité, opérant un renouveau dans l'approche de l'égalité qui s'est traduit dans la Constitution par l'apparition d'une nouvelle catégorie, celle de la « parité » consacrée par les révisions constitutionnelles de 1999 et 2008.

→ Loi constitutionnelle du 8 juillet 1999.

→ Loi constitutionnelle du 23 juillet 2008.

La Constitution a ainsi été modifiée de manière à préciser que *« la loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales »*.

→ Art. 1er alinéa 2 de la Constitution.

POUR ALLER PLUS LOIN

Faut-il dissocier l « égalité » de la « non-discrimination » dans la mise en œuvre de l'interdiction des discriminations ? *La dissociation conceptuelle et juridique de l'égalité et de la non-discrimination est prônée par une partie de la doctrine, tantôt pour tenter de redonner à l'égalité sa cohérence supposément perdue, tantôt pour éviter la marginalisation des traitements différencitalistes en mettant fin à la logique dérogatoire qu'ils supposent au regard du principe d'égalité. Les tenants du principe de non-discrimination critiquent l'invocation du principe juridique d'égalité afin d'expliquer la mise en œuvre de l'interdiction des discriminations et dénoncent une tradition française si imprégnée par le principe d'égalité qu elle peinerait à admettre que ce principe ne puisse tout résoudre. Cette construction n est toutefois pas indispensable. D une part, on peut relever que si la notion de non-discrimination sert, en France, à mieux justifier le recours aux actions dites positives, dans d autres systèmes juridiques, ce n est pas le cas puisque cette notion renvoie à son versant négatif (l interdiction stricte des discriminations), et c est l'égalité qui permet de justifier le recours aux mesures positives (discriminations dites positives). D autre part, en droit positif, le principe d'égalité n exclut ni la prise en compte des situations concrètes de discrimination, ni l usage d outils de prévention, de correction ou de compensation de leurs effets. Le principe d'égalité ne s oppose donc pas à ce que le législateur adopte des mesures propres à venir en aide à des catégories de personnes défavorisées » (Cons. const., déc. n° 86-207 DC, 26 juin 1986) ou « rencontrant des difficultés particulières » (Cons. const., déc. n° 2005-521 DC, 22 juillet 2005). Avec l'évolution du droit positif, le principe d'égalité n exclut donc plus le recours aux différenciations légitimes.*

2. La mise en œuvre de l'interdiction des discriminations en France

Le droit français s'est progressivement doté d'un ensemble cohérent et évolutif de normes pour interdire les discriminations. Cette mise en œuvre repose sur une articulation entre textes constitutionnels, conventions internationales, législations internes, droit européen et instruments non contraignants, accompagnée de garanties procédurales et institutionnelles.

2.1. Législations et dispositions constitutionnelles et conventionnelles

La prohibition des discriminations s'ancre dans des textes fondamentaux de droit interne et international. Ces sources, issues de l'après-guerre, ont posé les bases du droit à la non-discrimination et ont été renforcées par des législations plus précises, sectorielles et européennes visant une égalité réelle et effective.

2.1.1. Les sources en droit interne et international dans le contexte de l'après-guerre

Au-delà de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et de l'article 1er de la Constitution, on peut citer en droit français l'importance du Préambule de la constitution de 1946 qui consacre l'égalité entre hommes et femmes, la non-discrimination dans le travail et l'emploi, ou encore l'égal accès à l'instruction.

→ Alinéas 3, 5, 13 du Préambule de la constitution de 1946.

L'interdiction des discriminations s'est longtemps opérée sur la base de « principes généraux du droit » qui ont été dégagés après la Seconde Guerre mondiale. Le Conseil d'État a ainsi consacré le principe d'égalité des usagers tant dans le service public, que dans le domaine public, ou encore l'égal accès aux emplois publics.

→ CE, ass, 25 juin 1948, *Journal L'Aurore*, n° 94511.

→ CE, 2 novembre 1956, *Biberon*, n° 95857.

Les grandes conventions internationales ne sont pas en reste. Surtout le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui se distingue de la Convention européenne, laquelle se borne à affirmer le principe de non-discrimination dans la jouissance des droits garantis (art. 14), par la profusion des articles qui consacrent l'égalité :

ainsi le Pacte évoque la non-discrimination dans le domaine de la justice, du mariage, entre les mineurs, dans le suffrage et l'accès aux fonctions publiques.

→ Art. 2,14, 23, 24, 25 et 26 PIDCP.

Par ailleurs, le droit international comprend plusieurs conventions qui s'intéressent spécifiquement à certains aspects de la discrimination.

→ Convention sur l'élimination de la discrimination raciale de 1965.

→ Convention sur l'élimination des discriminations contre les femmes, 1979.

2.1.2. Un cadre législatif d'une grande densité

Les nombreuses dispositions constitutionnelles et conventionnelles proclamant l'égalité et la non-discrimination sont relayées par un cadre législatif très dense.

Autant l'exigence de l'égalité formelle pouvait se satisfaire de quelques principes jurisprudentiels, autant l'égalité dite réelle suppose l'élaboration d'un arsenal juridique plus exigeant et solide.

La législation nationale repose à la fois sur des textes généraux et des textes sectoriels, à laquelle il faut ajouter les « principes non écrits » qui déclinent le principe d'égalité en droit administratif et en droit du travail.

Les textes généraux sont, d'une part, la loi de 2008 qui a un champ très large (travail, éducation, biens et services…) et qui recense plus d'une vingtaine de critères de discrimination, et, d'autre part, le Code pénal qui incrimine toute distinction opérée entre les personnes en reprenant la liste très large des critères prohibés, mais en excluant les discriminations indirectes.

→ Loi du 27 mai 2008.

→ Art. 225-1 du Code pénal.

Les dispositions sectorielles concernent essentiellement le travail, la fonction publique, les assurances ou encore la santé.

→ Art. L. 1132-1 du Code du travail.

→ Art. 6 de la loi du 6 juillet 1989.

→ Art. L. 111-7 du Code des assurance.

→ Art. L. 1110-3 du Code de la santé publique.

2.1.3. L'importance du droit dérivé de l'Union européenne

Le droit de l'Union n'est pas étranger à cette grande complexité législative dans la mesure où la lutte contre les discriminations est une compétence de l'Union. Au-delà du droit primaire (traités) et de la Charte des droits fondamentaux qui consacrent l'interdiction des discriminations, il faut souligner les nombreuses directives visant à mettre en œuvre l'égalité de traitement, notamment en matière de discriminations contre les femmes ou sur la base de l'origine ethnique.

→ Directive du 29 juin 2000 (interdiction de la discrimination fondée sur la race).

→ Directive du 13 décembre 2004 (interdiction de la discrimination fondée sur le sexe).

Ces directives, transposées dans la législation interne, interdisent les discriminations directes et indirectes et autorisent des différences de traitement pour autant que soit démontrée la légitimité du but et sa nécessité.

2.2. Le recours à la soft law pour sensibiliser sur les discriminations

L'interdiction des discriminations passe aussi par la nécessité de renforcer la représentation des personnes sous-représentées dans l'accès à une ressource. Les actions prises en ce sens reposent le plus souvent sur la soft law afin de sensibiliser les acteurs concernés dans un contexte national de forte réticence à l'égard des mécanismes plus contraignants de discriminations dites « positives ».

→ Charte de la diversité en entreprise, 2007.

→ CSA, délibération du 10 novembre 2009 tendant à favoriser la représentation de la diversité de la société française dans les programmes des chaînes nationales hertziennes gratuites et de Canal +.

2.3. Garanties administratives et juridictionnelles

L'interdiction des discriminations s'appuie sur un ensemble de dispositifs destinés à protéger les victimes et sanctionner les pratiques illégales. Ces garanties s'articulent autour d'institutions dédiées, de mécanismes procéduraux, ainsi que de l'accès au juge qui, notamment à travers la QPC, veille au respect du principe d'égalité.

2.3.1. Le défenseur des droits

Le Défenseur des droits a pour mission de lutter contre les discriminations, directes ou indirectes, prohibées par la loi ou les traités. Il peut être saisi par la victime ou par une association conjointement avec la victime.

Une fois la discrimination identifiée, le Défenseur des droits dispose d'une palette de pouvoirs dont l'usage dépend de la gravité des faits : elle ne s'épuise pas dans la répression puisqu'il doit aussi favoriser la pédagogie dans un domaine où les préjugés jouent un rôle important.

Outre la résolution amiable, il dispose du pouvoir d'émettre des recommandations pour remédier à la pratique discriminatoire ou en prévenir le renouvellement. Dans les cas les plus graves, il a la possibilité de transmettre le dossier au parquet aux fins de poursuites pénales.

2.3.2. Actions de groupe et preuves du traitement discriminatoire

La volonté de renforcer la lutte contre les discriminations a conduit à ériger des règles spécifiques comme les actions de groupe.

→ Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016.

En matière de preuve, sous l'influence du droit de l'Union, un aménagement légal des règles de preuve permet désormais à un requérant se disant victime de discriminations de présenter devant le juge les éléments qui permettent d'en présumer l'existence, tant pour la discrimination directe qu'indirecte.

→ Art. L. 1134-1 du Code du travail.

En outre, le testing (test de discrimination) a été reconnu comme un mode de preuve valide par le législateur français, en droit pénal et en dehors.

→ Loi du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances.

→ Art. 225-3-1 du Code pénal.

→ Art. 4 de loi du 27 mai 2008.

Actualité législative. - La réforme de l'action de groupe renforce la lutte collective contre les discriminations

La loi du 30 avril 2025 a institué un régime unifié de l'action de groupe. Celle-ci permet à plusieurs personnes placées dans une situation similaire et victimes d'un même manquement, ou de manquements de même nature, d'obtenir en justice la cessation du manquement, la réparation de leurs préjudices ou les deux. Le mécanisme peut notamment être utilisé en matière de discriminations.

L'action peut être exercée par certaines associations agréées. En matière de discrimination, les organisations syndicales représentatives disposent également de cette faculté. Lorsqu'elle tend seulement à faire cesser le manquement, le demandeur n'a à démontrer ni un préjudice individuel pour chacun des membres du groupe, ni une intention ou une négligence de l'auteur. Le juge peut ordonner toutes les mesures utiles pour faire cesser la pratique discriminatoire.

→ Art. 16 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes.

À retenir. - La lutte contre les discriminations ne repose plus seulement sur des actions individuelles. L'action de groupe permet d'appréhender des discriminations collectives ou structurelles et d'obtenir non seulement une réparation, mais également la cessation de la pratique à l'origine de la discrimination.

2.3.3. La jurisprudence du Conseil constitutionnel

L'examen de sa jurisprudence révèle que le principe d'égalité n'est pas appliqué de manière uniforme, mais varie selon les domaines concernés. Ainsi, le Conseil fait preuve d'une rigueur particulière lorsqu'il s'agit de l'égalité devant la justice, et de plus de souplesse en matière fiscale.

Le développement du contentieux constitutionnel par le biais de la QPC a contribué à renforcer l'application du principe d'égalité.

La première question prioritaire de constitutionnalité a censuré une disposition discriminatoire fondée sur la nationalité, relative à la cristallisation des pensions des anciens combattants étrangers. Le Conseil y a rappelé que si le lieu de résidence peut justifier une différence de traitement, la nationalité, elle, ne saurait fonder une inégalité.

→ Cons. const., déc. n° 2010-1 QPC, 28 mai 2010, *Consorts L.*

Dans le domaine fiscal, souvent mobilisé dans les questions prioritaires de constitutionnalité, le Conseil continue d'admettre des différenciations si elles reposent sur des critères objectifs et en lien avec l'objectif poursuivi par la loi.

→ Cons. const., déc. n° 2011-121 QPC, 29 avril 2011, *Société UNILEVEE France [Taux de TVA sur la margarine],* relative aux taux de TVA.

S'agissant du fichage, le Conseil a rappelé que la Constitution interdit les distinctions basées sur l'origine et a annulé la disposition prévoyant la possibilité de constituer des fichiers sur « les origines raciales ou ethniques ».

→ Cons. const., déc. n° 2007-557 DC, 15 novembre 2007, *Loi relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile.*

Toutefois, l'expérience québécoise montre que, encadrées de manière éthique, les statistiques ethniques peuvent s'avérer un outil précieux pour combattre les discriminations structurelles fondées sur la race ou l'ethnie.

3. Les biais algorithmiques : de nouvelles formes de discriminations

Les biais algorithmiques constituent une forme moderne et complexe de discrimination, dite discrimination par « proxy », où un élément utilisé par un système d'intelligence artificielle sert de substitut à des critères prohibés (genre, origine…), sans être explicitement fondé sur ces critères. Par exemple, un Code postal peut agir comme proxy indirect de l'origine ethnique ou du statut socio-économique, conduisant à des décisions biaisées.

Cette discrimination est insidieuse, car le proxy peut être n'importe quel critère technique, rendant son identification difficile. La discrimination est bien souvent invisible, multifactorielle et difficilement prévisible en ce qu'elle combine des proxys multiples qui peuvent se croiser et créer de nouvelles minorités, dont les membres ignorent parfois qu'ils sont discriminés.

Il est à craindre que la législation anti-discrimination – même fondée sur les discriminations indirectes – ne suffise pas à appréhender les mécanismes opaques des systèmes d'IA dont les décisions peuvent aggraver des inégalités sociales. Le cadre juridique de l'Union européenne tente d'intégrer cette réalité en insistant sur la transparence des systèmes d'IA, mais des zones d'ombres demeurent, aggravées par l'abandon en février 2025 de la directive sur la responsabilité de l'IA.

→ Règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l'intelligence artificielle.

Il importe de promouvoir des politiques combinant prévention, information des utilisateurs et responsabilité des concepteurs d'IA. Enfin, malgré les réticences du droit français, le recours encadré à des formes de discrimination positive pourrait constituer une voie complémentaire pour corriger certains déséquilibres structurels reproduits par les algorithmes.

POUR S'ENTRAÎNER

Commentaire d'arrêt : D.H. et a. c. République tchèque du 13 novembre 2007.

« En fait. *Les requérants sont 18 ressortissants tchèques d'origine rom. L'affaire concerne leur scolarisation dans des écoles spéciales, en raison, selon eux, de leur origine rom.*

En droit (fond) *– La chambre avait conclu, par six voix contre une, à la non-violation de l'article 14 combiné avec l'article 2 du Protocole n° 1.* […].

Sur l'existence d'une présomption de discrimination indirecte […] *La Grande Chambre admet que, faute d'information nationale officielle sur l'origine ethnique des élèves, les statistiques présentées par les requérants peuvent ne pas être entièrement fiables. À ses yeux, ces chiffres révèlent néanmoins la tendance prédominante, confirmée tant par l'État défendeur que par des organes de contrôle indépendants.* […] *Même si le pourcentage exact des enfants roms placés à l'époque des faits dans des écoles spéciales reste difficile à établir, leur nombre était démesurément élevé et ces écoles spéciales comptaient majoritairement des enfants roms. En dépit de sa neutralité, la loi en cause a donc, de facto, eu des répercussions beaucoup plus importantes sur les enfants roms que sur les enfants non-roms. Dans ces conditions, les éléments de preuve présentés par les requérants peuvent être considérés comme suffisamment fiables et révélateurs pour faire naître une forte présomption de discrimination indirecte, laquelle dans ce domaine notamment n'exige pas de prouver une intention des autorités de discriminer. Il appartient donc au Gouvernement de démontrer que cette différence d'effet de la législation était le résultat de facteurs objectifs qui n'étaient pas liés à l'origine ethnique.*

Sur l'existence d'une justification objective et raisonnable : […] *Plusieurs organismes indépendants du Conseil de l'Europe ont exprimé des doutes sur le caractère adéquat desdits tests. La Cour estime qu'il existe un risque que les tests soient entachés de préjugés et que leurs résultats ne soient pas lus à la lumière des particularités et des caractéristiques spécifiques des enfants roms qui les subissent. Dans ces conditions, les résultats des tests ne sauraient servir de justification à la différence de traitement litigieuse.* […]

Dès lors qu'il a été établi que l'application de la législation tchèque pertinente avait à l'époque des faits des effets préjudiciables disproportionnés sur la communauté rom, les requérants en tant que membres de cette communauté ont nécessairement subi le même traitement discriminatoire. Conclusion : violation (treize voix contre quatre). »

Une première décision de la chambre avait conclu à la non-violation de l'article 14 combiné à l'article 2 du Protocole n° 1. Les requérants ont obtenu le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre, qui, dans sa décision du 13 novembre 2007, a cette fois conclu à la violation.

La Cour européenne des droits de l'homme reconnaît dans cet arrêt une discrimination fondée sur l'origine ethnique dans l'accès au droit à l'instruction, à l'encontre d'enfants roms placés dans des écoles spéciales.

Il s'agit d'un arrêt de principe dans lequel la Cour pose les bases du contrôle des discriminations indirectes.

Problématique et annonce du plan. La recherche de l'égalité réelle impose-t-elle de sanctionner des dispositifs apparemment neutres, mais produisant des effets discriminatoires sur des groupes protégés, sans preuve d'une intention discriminatoire ? En consacrant la prohibition des discriminations dites indirectes, la Cour combine un contrôle des effets objectifs des normes prétendument neutres, mais discriminatoires en pratique **(I)** avec une reconnaissance, encore prudente, d'un droit collectif à la non-discrimination **(II)**.

I. La sanction des discriminations indirectes : la recherche de l'égalité substantielle

A. Des critères *a priori* neutres, mais défavorables à certains groupes protégés

Critères visant abstraitement des individus, mais désavantageant, en pratique, un groupe, lequel est identifié à partir d'un critère prohibé (en l'espèce, l'origine ethnique : les roms). En l'espèce, le placement reposait sur des tests psychométriques non adaptés aux spécificités culturelles et linguistiques des enfants roms.

Jurisprudence antérieure dans le sens d'un contrôle des discriminations indirectes : mais la Cour européenne des droits de l'homme n'était pas aussi claire : *Abdulaziz c. Royaume-Uni, 28 mai 1985*, *Thlimmenos c. Grèce* du 6 avril 2000, *Hoogendijk c. Pays-Bas* du 6 janvier 2005.

Rappeler que la Cour européenne des droits de l'homme était incitée, car la Cour de justice de l'Union procédait à ce contrôle depuis les années 1970 (CJCE, 12 février 1974, Sotgiu)

B. La charge de la preuve : présomption et statistique

Une fois l'effet défavorable établi, la Cour entend faire peser la charge de la preuve sur le défendeur, c'est-à-dire l'État.

Pas d'intention : s'agissant de la *preuve* de la discrimination, une des conséquences de la reconnaissance des discriminations indirectes est un détachement du caractère intentionnel de la discrimination.

Charge de la preuve (statistique et présomption) : dans un arrêt antérieur, la Cour avait reconnu la production d'une preuve statistique pour constater une discrimination (sexe) : CEDH, *Adami c. Malte,* 20 juin 2006. Standard de preuve moins strict quand les circonstances autorisent un renversement de la charge de la preuve. En principe, la charge de la preuve pèse sur celui qui affirme l'existence d'un fait, mais quand l'accès à la preuve est difficile (comme c'est souvent le cas des discriminations indirectes), la Cour facilite la tâche du requérant et applique un régime moins draconien.

Jurisprudence ultérieure (Roms) : la Cour apporte des précisions. Forte présomption de discrimination en cas d'incidents racistes dans l'école. La charge de la preuve pèse sur l'État qui doit démontrer que la différence de traitement se fonde sur des facteurs objectifs non liés à l'origine ethnique des élèves (CEDH, *Sampanis c. Grèce,* 5 juin 2008).

La notion de « discrimination indirecte » se révèle pertinente pour appréhender, à l'heure actuelle (et dans un futur proche) les biais et discriminations algorithmiques (non intentionnels par définition) + importance des statistiques pour prouver ces biais.

II. La non-discrimination au service des groupes et de la diversité

A. La dimension collective et structurelle du droit à la non-discrimination

Pour la première fois aussi expressément, le juge de Strasbourg sanctionne une discrimination à l'encontre d'un groupe. La dimension *collective* du droit à la non-discrimination prend en l'espèce une ampleur particulière même si la jurisprudence antérieure montrait déjà des signes (*CEDH, Abdulaziz, c. Royaume-Uni, 28 mai 1985*).

Les groupes victimes de discriminations et de préjugés constituent une réalité que la Cour européenne des droits de l'homme ne peut ignorer même si elle se montre encore prudente.

B. Les prémisses d'une consécration d'un droit des groupes en droit de la Convention

Pour l'heure, la Cour n'a pas développé un véritable « droit des groupes ». Une évolution jurisprudentielle n'est pas à exclure. Beaucoup de commentateurs, attachés à la conception universaliste (formelle, abstraite ?) des droits humains sont réticents à voir dans le droit à la non-discrimination un instrument de protection des groupes (lecture dite « communautariste » ou différentialiste des droits).

Rappeler qu'en France, le droit constitutionnel ne consacre ni un droit à la différence ni un droit des groupes (minorités ethniques).

Fiche nº 55- LA PRISE EN COMPTE DES VULNÉRABILITÉS

POINTS CLÉS

- Égalité et non-discrimination.
- Mesures de protection positives et justice sociale.
- Dignité humaine.
- Inclusion sociale.
- Minorités.
- Protection contre les violences.
- Vulnérabilités socio-économiques.
- Droit à la santé.

PRINCIPALES RÉFÉRENCES

- Préambule de la Constitution de 1946.
- Art. 3 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.
- Art. 11 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.
- Art. 30 et 31 de la Charte sociale européenne révisée.
- Art. 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
- Art. 222-4 du Code pénal.
- Art. 1146 du Code civil.
- Art. L. 114-1 du Code de l'action sociale et des familles.
- Art. L. 522-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La vulnérabilité est une notion juridique difficilement saisissable et pourtant de plus en plus présente dans le droit. Le terme provient du latin *vulnero* (blesser) et *vulneratio* (l'atteinte). À l'origine notion non juridique, et découlant de l'éthique du *care*, elle connaît une multitude de définitions, mais peut s'analyser comme une personne ou un état favorisant les violations des droits humains et nécessitant dès lors une protection adéquate.

Le droit pénal français en donne des exemples en considérant qu'une personne doit être considérée comme vulnérable eu égard *« à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur »* et en renvoyant à une situation de faiblesse (art. 222-4 du Code pénal, voir également entre autres l'article 434-3). La vulnérabilité ne touche cependant pas uniquement à ces catégories bien qu'elles constituent une première indication.

La notion de vulnérabilité est donc une notion diffuse qui ne bénéficie pas de texte juridique de référence, mais se trouve infusée dans de nombreux instruments, à l'instar de conventions traitant de sujets spécifiques. Ainsi la Convention internationale relative aux droits de l'enfant n'y fait pas explicitement référence, mais cite la Déclaration des droits de l'enfant dans son préambule, considérant qu'*« en raison de son manque de maturité physique et intellectuelle, a besoin d'une protection spéciale et de soins spéciaux, notamment d'une protection juridique appropriée, avant comme après la naissance »*.

En revanche, elle a souvent trait à une conception sociale de la dignité humaine. La vulnérabilité implique pour l'État de prendre des mesures pour redresser ou compenser les fragilités naissant de cet état de vulnérabilité, généralement par le biais de politiques sociales. La Cour interaméricaine indique ainsi que *« toute personne en situation de vulnérabilité a droit à une protection spéciale, en raison des devoirs spéciaux dont l'accomplissement par l'État est nécessaire pour satisfaire aux obligations générales de respect et de garantie des droits de l'homme »* :

→ CIDH, 4 juillet 2006, *Ximenes Lopes c. Brésil,* Série C Nº 149.

1. Vulnérabilité et notion d'égalité

La vulnérabilité place les individus dans des situations d'inégalité réelle et nécessite donc la mise en place de mesures positives de justice sociale pour pallier celles-ci (résultant de la doctrine de l'*Affirmative action* américaine). Le Préambule de la Constitution de 1946 fait par ailleurs référence à de nombreuses garanties visant la protection de la santé, des enfants, des personnes âgées ou des personnes persécutées.

Le Conseil d'État a ainsi reconnu la possibilité de régler *« de façon différente des situations différentes »* et de déroger *« à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier »* :

→ CE, ass., 11 avril 2012, *GISTI*, n° 322326.

Au sein de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, la vulnérabilité est interprétée comme nécessitant une diligence particulière de la part de l'État et peut dès lors trouver à s'appliquer dans le raisonnement de la Cour sous différents articles (à l'instar de l'article 8 concernant le respect de la vie privée) :

→ CEDH, 18 janvier 2001, *Chapman c. Royaume-Uni*, n° 27238/95.

Si le droit à la non-discrimination est protégé par les articles 14 de la Convention et 1 du Protocole additionnel n° 12, la Cour ne considère pas comme une violation toute mesure positive permettant de corriger une inégalité factuelle pour en atténuer les effets. L'absence de traitement différencié pour redresser cette inégalité peut en revanche ENTRAÎNER une violation de la Convention.

→ CEDH, 22 décembre 2009, *Sejdić et Finci c. Bosnie-Herzégovine*, n° 27996/06 et a.

À noter cependant, il ne faut pas confondre les motifs de discrimination énoncés dans l'article 14 et les catégories de personnes vulnérables, même si celles-ci peuvent se rejoindre dans certains cas.

2. Les cas spécifiques de vulnérabilité saisie par le droit

2.1. Vulnérabilité et capacité

Le droit reconnaît plusieurs incapacités résultant de situations de vulnérabilité. Cette incapacité juridique permet alors de protéger la personne vulnérable contre ses propres actions, mais également contre les actions des tiers (art. 1146 du Code civil).

2.1.1. Les enfants

Les mineurs sont les personnes vulnérables par excellence.

Ils sont reconnus par le droit comme étant des individus particulièrement vulnérables et incapables juridiquement, nécessitant alors une protection accrue dont on retrouve les mesures générales au sein de la Convention internationale des droits de l'enfant.

La situation de vulnérabilité de l'enfant a par ailleurs poussé au développement d'instruments concernant des cas d'extrême vulnérabilité de l'enfant, à l'instar du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés et le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants du 25 mai 2000.

Des mesures de protection reconnaissant son incapacité sont également énoncées dans le Code civil. Son incapacité civile est avant tout une mesure de protection, qui, sauf circonstances contraires, cesse au moment de sa majorité.

En matière pénale, le statut de mineur de la victime constitue une circonstance aggravante de l'infraction (à l'instar de l'article 221-4 du Code pénal). À l'inverse, le statut de mineur de l'auteur lui fait bénéficier d'une responsabilité atténuée, voire d'une mesure éducative s'il a moins de 13 ans, puisqu'il est alors présumé ne pas être capable de discernement (art. L. 11-1 du Code de la justice pénale des mineurs). Un système judiciaire adéquat est par ailleurs mis en place pour s'adapter à la situation spécifique du mineur.

Une protection particulière doit également exister lorsque les mineurs se trouvent en situation de danger. Des mesures administratives peuvent être organisées par l'Aide sociale à l'enfance avec l'accord des parents ou sur décision de justice, pouvant impliquer un retrait de l'enfant de son milieu naturel familial (art. 375 du Code civil).

→ Cass. civ. 1re, 12 juin 2025, no 24-18.562.

La Cour européenne des droits de l'homme a par ailleurs condamné la France pour ne pas avoir appliqué effectivement un système pénal apte à réprimer les actes sexuels non consentis par des mineures particulièrement vulnérables :

→ CEDH, 24 avril 2025, *L. et a. c. France*, no 46949/21.

Ou de manière générale, le défaut de protection des enfants d'actes de maltraitance et de violence de la part de leurs parents :

→ CEDH, 4 juin 2020*, Association Innocence en Danger et Association Enfance et Partage c. France*, no 15343/15.

2.1.2. Les majeurs protégés

La Commission nationale consultative des droits de l'homme rendant un avis sur le consentement des personnes vulnérables le 16 avril 2015, indique que *« les personnes vulnérables ne sont pas des personnes dont la volonté ou le discernement sont altérés ; mais leur état de vieillissement, leur pathologie, le contexte social, sanitaire et économique dans lequel elles vivent, les placent dans une situation de vulnérabilité particulière et contraignent leur choix »* montrant ainsi que la vulnérabilité influe indubitablement sur le consentement.

Ainsi, le Code civil prévoit que *« les personnes majeures reçoivent la protection de leur personne et de leurs biens que leur état ou leur situation rend nécessaire selon les modalités prévues au présent titre »* (art. 415). L'individu majeur dans l'incapacité de pourvoir à ses propres intérêts se voit alors accorder une protection particulière concernant sa personne ainsi que ses intérêts patrimoniaux (art. 425 et suivant du Code civil).

Différents régimes de protection sont ouverts, prenant graduellement en compte la vulnérabilité de l'individu et ses besoins spécifiques par l'établissement de différents types de protection à l'instar d'une sauvegarde de justice, d'une curatelle ou d'une tutelle (art. 440 et suivant du Code civil). Les actes et contrats formés dans ce cadre encourent ainsi la nullité, permettant dès lors de protéger la personne vulnérable.

Dans ce cadre, sont punis les actes conclus dans l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse pour conduire cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables, selon l'article 223-15-2 du Code pénal (cette disposition est également applicable à l'égard des mineurs), plus connu sous le terme d'abus de faiblesse et particulièrement utilisé dans le cas des dérives sectaires. La Cour de cassation a par ailleurs considéré que cette disposition était applicable dans des cas d'emprise, par l'utilisation de menaces, ayant *« provoqué un état d'enfermement physique et psychique »* :

→ Cass. crim, 26 octobre 2016, no 15-85.956.

En revanche, selon le Conseil constitutionnel, l'interdiction absolue de recevoir des dons pour les personnes aidant les majeurs particulièrement vulnérables est anticonstitutionnelle, malgré le but d'intérêt général qui était celui recherché par le législateur. L'interdiction *« s'applique même dans le cas où pourrait être apportée la preuve de l'absence de vulnérabilité ou de dépendance du donateur à l'égard de la personne qui l'assiste »* et est dès lors considérée comme trop étendue. L'encadrement de ces dons est donc possible, mais ne peut pas faire l'objet d'une interdiction absolue, celle-ci doit dépendre de la situation de vulnérabilité de la personne :

→ Cons. const., déc. no 2020-888 QPC, 12 mars 2021, *Mme Fouzia L. [Interdiction de recevoir des libéralités pour les personnes assistant certaines personnes vulnérables]*.

Le Comité des ministres des États membres du Conseil de l'Europe a par ailleurs adopté la Recommandation Rec(2004)10 relative à la protection des droits de l'homme et de la dignité des personnes atteintes de troubles mentaux (adoptée par le Comité des ministres le 22 septembre 2004, lors de la 896e réunion des Délégués des ministres) prévoyant une série de recommandations pour favoriser les droits des personnes atteintes de troubles mentaux.

2.2. Vulnérabilité et handicap

La vulnérabilité consécutive aux situations de handicap augmente le risque de violations des droits humains et laisse ces personnes particulièrement sujettes à la discrimination, à la pauvreté et aux violences. Cette situation est compensée par une série de mesures positives permettant de favoriser la pleine jouissance de leurs droits, leur autonomie, leur participation active à la société et surtout le respect de leur dignité.

La Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées du 12 décembre 2006 énonce ainsi une série de droits spécifiques nécessitant des mesures favorisant l'égalité (art. 5), l'accessibilité (art. 9), la protection contre les maltraitances (art. 16), …

La loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, modifie substantiellement le Code de l'action sociale et des familles en ajoutant et modifiant des dispositions en faveur de l'intégration des personnes en situation de handicap. L'article L. 114-1 du Code de l'action sociale et des familles se lit ainsi :

> *« Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l'ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l'accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté. »*

L'État est garant de l'égalité de traitement des personnes handicapées sur l'ensemble du territoire et définit des objectifs pluriannuels d'actions.

La notion de vulnérabilité n'est pas formellement mentionnée dans ces différentes dispositions eu égard à la portée potentiellement stigmatisante du terme.

Pour la Cour européenne des droits de l'homme, la protection spécifique due aux personnes en situation de handicap lui permet d'analyser si l'État a pris toutes les mesures nécessaires pour protéger les personnes handicapées de violations de leurs droits, reconnaissant leur vulnérabilité.

> → CEDH, 24 juillet 2012, *Đorđević c. Croatie*, n° 41526/10.

Elle accorde également une attention particulière à des facteurs de vulnérabilité, tels que l'âge, le sexe ou le handicap, qui pourraient empêcher certaines victimes de soumettre leur requête à la Cour, afin de juger recevable la requête formulée par un tiers pour le compte d'une victime, en tenant également compte des liens unissant la victime et l'auteur :

> → CEDH GC, 17 juillet 2014, *Centre de ressources juridiques au nom de Valentin Câmpeanu c. Roumanie*, n° 47848/08.

Cette même idée se retrouve au sein de l'article 2-8 du Code de procédure pénale, favorisant l'accès à la justice.

La Cour européenne reconnaît aussi le caractère vulnérable des personnes séropositives, dû aux préjugés et à la stigmatisation qu'ils subissent. En conséquence, les États possèdent une marge d'appréciation étroite pour la mise en balance de leurs droits :

> → CEDH, 3 octobre 2013, *I.B. c. Grèce*, n° 552/1.

2.3. Vulnérabilité des groupes minoritaires

L'État français ne reconnaît pas l'existence de minorités sur son territoire, considérant selon le Conseil constitutionnel que l'article 1er de la Constitution française s'oppose *« à ce que soient reconnus des droits collectifs à quelque groupe que ce soit, défini par une communauté d'origine, de culture, de langue ou de croyance »* :

> → Cons. const., déc. n° 99-412 DC, 15 juin 1999, *Charte européenne des langues régionales ou minoritaires.*

Néanmoins, certains groupes sont effectivement reconnus au niveau supranational comme minoritaires et donc vulnérables. La Cour européenne reconnaît ainsi à plusieurs reprises la vulnérabilité d'individus appartenant à différents groupes ethniques, dans le cas d'une stérilisation forcée subie par une femme Rom :

> → CEDH, 12 juin 2012, *N.B. c. Slovaquie*, n° 29518/10.

En outre, concernant la communauté Rom, la Cour a rappelé à maintes reprises que *« du fait de leurs vicissitudes et de leur perpétuel déracinement, les Roms constituent une minorité défavorisée et vulnérable, qui a un caractère particulier »* et ce qui implique des mesures de protection et une attention spéciale à leurs besoins et à leur mode de vie.

→ CEDH [GC], 13 novembre 2007, *D.H. et a. c. République tchèque*, n° 57325/00.

L'appréciation de la vulnérabilité d'un groupe est cependant évolutive et dépend des circonstances générales et spéciales :

→ CEDH, 29 avril 2022, *Khasanovembre et Rakhmanovembre c. Russie*, n° 28492/15.

Actualité jurisprudentielle. - Le cumul des facteurs de vulnérabilité renforce les obligations positives de l'État

La vulnérabilité peut résulter de plusieurs facteurs qui se cumulent et doivent être appréciés concrètement par les autorités.

En l'espèce, la CEDH s'est prononcée sur la mort d'un homme rom au cours d'une intervention de police. L'intéressé, fortement alcoolisé et blessé, avait été immobilisé au sol, menotté dans le dos et maintenu en position ventrale pendant plusieurs minutes, notamment sous le poids d'un policier. Les agents connaissaient son état de santé et savaient qu'il se trouvait dans une situation de vulnérabilité particulière.

La Cour juge que l'État a méconnu l'article 2 en ne garantissant pas une formation suffisante des policiers aux risques liés à cette technique d'immobilisation et en ne veillant pas suffisamment à l'état de santé de l'intéressé. Elle constate également une violation de l'article 3 en raison du caractère disproportionné de la force employée.

Enfin, compte tenu notamment de l'appartenance de la victime à la minorité rom, de la violence de l'intervention et du contexte documenté de discriminations à l'égard des Roms, les autorités avaient l'obligation de rechercher sérieusement si un mobile raciste avait contribué au comportement des policiers. Leur défaut de diligence entraîne également une violation de l'article 14 combiné aux articles 2 et 3.

→ CEDH, 16 juillet 2026, *S.T. c. République tchèque*, n° 28273/23.

À retenir. - Plusieurs facteurs de vulnérabilité peuvent se cumuler : état de santé, dépendance vis-à-vis des agents publics, origine ethnique ou appartenance à une minorité. Leur combinaison peut renforcer les obligations de prévention, de protection et d'enquête pesant sur l'État.

2.4. Les étrangers et apatrides

Le droit des étrangers est également traversé par des considérations relatives à leur vulnérabilité du fait de leur situation.

→ CEDH, 23 février 2012, *Hirsi Jamaa et a. c. Italie*, n° 27765/09.

Cette appréciation de la Cour européenne a par la suite été réduite à certains réfugiés présentant des vulnérabilités particulières (à l'instar des enfants, d'adultes malades, de demandeurs d'asile LGBT ou de mères allaitantes) :

→ CEDH, 5 juillet 2017, *O.M. c. Hongrie*, n° 9912/15.

→ CEDH, 22 juillet 2021*, M.D. et A.D. c. France*, n° 57035/18.

La Cour a par ailleurs refusé d'établir des critères précis concernant l'attribution de cette caractéristique aux demandeurs d'asile, considérant qu'elle *« doit examiner les éléments de preuve à sa disposition pour établir si, comme les intéressés le disent, ils pouvaient être considérés comme étant particulièrement vulnérables et, dans l'affirmative, si leurs conditions de vie pendant leur séjour en septembre et octobre 2015 dans la zone de transit de Röszke étaient incompatibles avec leur état de vulnérabilité au point d'être constitutives en ce qui les concerne d'un traitement inhumain et dégradant ».*

→ CEDH [GC], 21 novembre 2019, *Ilias et Ahmed c. Hongrie*, n° 47287/15.

En droit interne, la vulnérabilité du demandeur d'asile est l'objet d'une « évaluation » qui détermine ses besoins en termes d'accueil et qui permet d'adapter la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile pendant toute

la période d'instruction de leur demande, en tenant compte de leur situation spécifique (art. L. 522-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile).

L'article L. 522-3 énonce par ailleurs que *« l'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines »*, reprenant les termes de la Directive 2013/33/UE, et ciblant certaines vulnérabilités, celles-ci étant reconnues seulement sur la base de cette liste exhaustive.

À noter concernant les droits des étrangers, la Convention relative au statut des apatrides, reconnaît dans son préambule la situation de vulnérabilité de l'apatride qui ne bénéficie pas de la protection étatique et prévoit des dispositions minimales de protection. En droit interne, son statut est également régi par le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux articles L. 582-1 et suivants.

Actualités européennes :

1/ La vulnérabilité du demandeur d'asile impose une évaluation individualisée et évolutive de ses besoins

Depuis juin 2026, la directive (UE) 2024/1346 *relative aux conditions d'accueil des demandeurs de protection internationale* remplace la directive 2013/33/UE et renforce la prise en compte des vulnérabilités. Elle impose aux États d'identifier les demandeurs présentant des besoins particuliers en matière d'accueil et d'adapter leur prise en charge à leur situation. La France a adapté le CESEDA à ce nouveau cadre par plusieurs textes réglementaires adoptés en juin 2026.

Concrètement, l'article 24 de la directive vise notamment les mineurs, mineurs non accompagnés, personnes handicapées ou âgées, femmes enceintes, parents isolés, victimes de traite, personnes atteintes de maladies graves ou de troubles mentaux, mais également désormais expressément les personnes LGBTI, les personnes souffrant d'un stress post-traumatique et les victimes de violences fondées sur le genre, de mariages forcés ou de violences motivées par des considérations sexuelles, sexistes, racistes ou religieuses.

L'évaluation doit être individuelle, intervenir le plus tôt possible et, en principe, être achevée dans les 30 jours suivant la demande. Surtout, elle n'est pas figée : lorsqu'une vulnérabilité apparaît ultérieurement, les autorités doivent l'évaluer et adapter la prise en charge pendant toute la procédure.

À retenir. - La vulnérabilité n'est pas un statut définitivement attribué à certaines catégories de personnes. Elle appelle une évaluation concrète, individualisée et évolutive, susceptible de faire naître des obligations particulières d'accueil et d'accompagnement.

2/ La vulnérabilité d'un mineur non accompagné impose une prise en charge adaptée à son âge

La vulnérabilité particulière des mineurs étrangers non accompagnés renforce les obligations positives pesant sur les autorités publiques.

En l'espèce, un mineur burkinabé avait été maintenu pendant plus de cinq mois dans un centre de rétention italien destiné principalement à l'accueil d'adultes. Bien qu'il ait été installé dans une partie séparée du centre, il n'avait pas bénéficié des services et de l'accompagnement adaptés à son âge et à sa situation.

La Cour européenne conclut à une violation de l'article 3 de la Convention. Elle tient compte de la minorité et de la vulnérabilité de l'intéressé pour apprécier la gravité de ses conditions d'accueil : placer matériellement un mineur à l'écart des adultes ne suffit pas si la prise en charge ne répond pas effectivement à ses besoins spécifiques. La Cour constate également plusieurs violations de l'article 5 relatives à sa privation de liberté.

→ CEDH, 9 avril 2026, H.D. c. Italie, n° 41645/23.

À retenir. - La vulnérabilité exerce un effet concret sur le niveau de protection exigé de l'État : une mesure qui pourrait être admissible pour un adulte peut devenir contraire à la Convention lorsqu'elle est appliquée à un mineur sans adaptation suffisante.

2.5. Les minorités sexuelles

La Cour européenne reconnaît la vulnérabilité de la communauté LGBT dans certaines circonstances, notamment dans un contexte hostile. Ce contexte oblige l'État à assurer une protection spéciale renforcée, particulièrement contre les discours de haine et discriminants ayant un effet stigmatisant, en tenant compte de leur marginalisation et victimisation historique dans la société :

→ CEDH, 4 février 2025, *Bazhenovembre et a. c. Russie*, n° 8825/22 et 19130/22.

De même, la Cour a considéré qu'empêcher une femme transgenre incarcérée de poursuivre son traitement hormonal avait porté atteinte au droit à l'autodétermination de la requérante (reconnue sous l'article 8) et compte tenu de sa vulnérabilité particulière, les autorités n'avaient pas réalisé correctement la mise en balance des intérêts :

→ CEDH, 11 juillet 2024, *W.W. c. Pologne*, n° 31842/20.

La législation française et les normes européennes ne mentionnent pas directement la vulnérabilité des minorités sexuelles, mais disposent de règles spécifiques tenant à lutter contre les discriminations (art. 21 de la Charte des

droits fondamentaux de l'Union européenne) et la marginalisation de ces groupes auxquelles ils sont particulièrement vulnérables. Le 9 janvier 2025, la Cour de justice de l'Union européenne a ainsi répondu à une question préjudicielle posée par le Conseil d'État, considérant que l'obligation d'indiquer sur les titres de transport la qualité « Mme » ou « M. » n'est pas nécessaire aux fins des intérêts légitimes poursuivis, à savoir la personnalisation commerciale, en raison d'un risque de discrimination fondée sur l'identité de genre, ouvrant la voie à une meilleure prise en compte du sexe neutre :

→ CJUE, 9 janvier 2025, *Mousse*, C-394/23.

En France, de nombreuses mesures ont permis une évolution progressive vers la reconnaissance des droits LGBT+. Dans son avis de 2014 sur les Violences et discriminations commises à raison de l'orientation sexuelle et de l'identité de genre, la Commission nationale consultative pour les droits de l'homme reconnaît que les personnes transidentitaires sont particulièrement vulnérables aux violences, reconnaissant ensuite, de manière générale dans son rapport du 30 novembre 2023 sur l'Évaluation du plan national d'actions pour l'égalité des droits, contre la haine et les discriminations anti-LGBT+, une vulnérabilité étendue à toute cette communauté (point 28).

La loi du 31 janvier 2022 a renforcé la protection des minorités sexuelles en interdisant les pratiques, les comportements ou les propos répétés visant à modifier ou à réprimer l'orientation sexuelle ou l'identité de genre, vraie ou supposée, d'une personne et ayant pour effet une altération de sa santé physique ou mentale (art. 225-4-13 du Code pénal), ainsi que les consultations ou le fait de prescrire des traitements en prétendant pouvoir modifier ou réprimer l'orientation sexuelle ou l'identité de genre, vraie ou supposée, reconnaissant comme circonstance aggravante leur commission sur des mineurs ou des personnes vulnérables (voir l'article L. 4163-11 du Code de la santé publique).

2.6. Les femmes

Les femmes ne sont pas considérées comme *ipso facto* une catégorie de personnes vulnérables. Nonobstant, plusieurs situations exposent les femmes à cette catégorie.

C'est notamment le cas de l'état de grossesse, qui permet aux femmes de bénéficier d'une protection supplémentaire et constitue également une circonstance aggravante dans le cadre pénal (voir *supra*).

De même, dans le cadre des violences sexuelles, les femmes victimes peuvent être considérées comme relevant de la catégorie des « personnes vulnérables » ayant droit à une protection spéciale de l'État. Dans ce cadre, la Cour européenne des droits de l'homme utilise un faisceau d'indice pour déterminer celle-ci : *« A cet égard, elle prend acte des violences que l'intéressée a subies par le passé, des menaces que H.O. a proférées contre elle à sa sortie de prison, de la peur que lui inspire la perspective de subir de nouveaux sévices et de la vulnérabilité des femmes dans le milieu social qui est le sien, celui du sud-est de la Turquie »* :

→ CEDH, 9 juin 2009, *Opuz c. Turquie*, n° 33401/02.

La vulnérabilité peut également s'interpréter d'un état de dépendance, de soumission ou d'infériorité, se référant à des violences psychologiques (et non exclusivement réservé aux femmes).

Dans le cas des violences faites aux femmes, des mesures spécifiques de protection peuvent être mises en place à la fois judiciaire (par le biais d'ordonnance de protection rendue par le juge aux affaires familiales, par exemple) et grâce aux soutiens d'associations.

2.7. La vulnérabilité socio-économique

La vulnérabilité peut également résulter de situations de pauvreté ou de précarité, se traduisant dans les domaines de la santé, du travail et des conditions de vie dignes.

Dans le domaine de la santé, la vulnérabilité correspond à un défaut d'accès effectif aux soins, à l'éducation et à l'information sur la santé, le droit à la santé étant pourtant un objectif à valeur constitutionnelle selon le Préambule de la Constitution de 1946 et réaffirmé au travers des articles 11 à 13 de la Charte sociale européenne révisée.

De nombreux instruments permettent de redresser ces lacunes, à l'instar de l'existence de mécanismes spécifiques comme les Permanences d'accès aux soins de santé mis en place pour les personnes en situation de

précarité, le déploiement des missions Accompagnement santé, mais également la mise en place d'un régime de Sécurité sociale depuis 1945.

La vulnérabilité économique et sociale se reflète particulièrement dans le droit à des conditions de vie dignes, mettant en évidence des situations de précarité économique (voir à ce titre les articles 30 et 31 de la Charte sociale révisée de 1996 et l'article 11 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques). Près de 15 % de la population française vivait sous le seuil de pauvreté en 2022 selon l'INSEE.

Cet état rend alors particulièrement difficile le respect des droits humains économiques et sociaux à savoir le droit au logement, le droit au travail voire même le droit à l'alimentation. L'existence de mesures spécifiques comme les crédits nationaux soutenant financièrement les structures de distribution de l'aide alimentaire et les crédits européen provenant du Fond social européen afin de lutter contre la précarité alimentaire, ou le Pacte des solidarités entré en vigueur au 1er janvier 2024 et proposant quatre axes de lutte contre la précarité (prévenir la pauvreté et lutter contre les inégalités dès l'enfance, Amplifier la politique d'accès à l'emploi pour tous, Lutter contre la grande exclusion grâce à l'accès aux droits, Construire une transition écologique et solidaire) ne sont pas toujours suffisantes pour atténuer cette vulnérabilité.

L'article L. 266-2 du Code de l'action sociale et des familles propose également une aide alimentaire et un accompagnement des personnes en situation de vulnérabilité économique ou sociale.

Au niveau européen, la Cour européenne, ne protégeant que les droits de première génération, connaît quelques réticences à l'élargissement de son interprétation au volet économique et social des droits de la Convention européenne. Néanmoins, dans une affaire relative à la criminalisation de la mendicité, la Cour a jugé que l'emprisonnement d'une femme issue d'une minorité Rom et dans une situation de particulière vulnérabilité, était une mesure disproportionnée et portait atteinte à l'article 8 de la Convention :

→ CEDH, 19 janvier 2021, *Lacatus c. Suisse*, n° 14065/15.

En France, il existe régulièrement des contentieux au regard de l'interdiction de la mendicité et du vagabondage. Dans ce cadre, le Conseil d'État a jugé proportionné au but légitime de protection de la salubrité et de l'ordre public, la mesure prise par un maire d'interdiction de fouille des poubelles :

→ CE, 15 novembre 2017, n° 403275.

Dans le cadre du travail, la Cour européenne prend en compte la situation de vulnérabilité de la victime dans les cas d'exploitation par le travail (voir à ce titre la Fiche 29) :

→ CEDH, 30 mars 2017, *Chowdury et a. c. Grèce*, n° 21884/15.

3. Des conceptions étendues de la vulnérabilité

La Cour interaméricaine des droits de l'homme utilise abondamment la notion de vulnérabilité dans une conception plus extensive et sociale qu'elle applique par exemple aux enfants, aux victimes des conflits armés, aux communautés autochtones, aux déplacés forcés :

→ CIDH, 15 juin 2005, *Communauté Moiwana c. Suriname*, Série C n° 124.

La notion de vulnérabilité est également de plus en plus appliquée en dehors des cas réservés à l'être humain, et notamment aux écosystèmes et à l'environnement, à l'instar des « zones vulnérables » comme particulièrement exposées à la pollution, mentionnées à l'article R 211-77 du Code de l'environnement.

POUR ALLER PLUS LOIN

*Dans de nombreux cas, relevant des instances nationales ou internationales, les facteurs de vulnérabilité se cumulent en créant une situation « d'extrême vulnérabilité » ou de particulière vulnérabilité. Cela peut être le cas d'enfants en situation de handicap, (CEDH, 30 janvier 2018, Enver Şahin c. Turquie, n° 23065/12), de mineurs isolés (CEDH, 28 février 2019, Khan c. France, n° 12267/16) ou de femmes autochtones victimes de persécutions (CIDH, 19 novembre 2004, Massacre de Plan de Sanchez c. Guatemala, Série C n° 116), etc. Dans ces cas-là, la charge de protection incombant à l'État est d'autant plus importante***.**

POUR S'ENTRAÎNER

Argumentation juridique : Soutenez qu'il existe un droit à la mendicité.

La mendicité, comme état d'une personne qui mendie pour survivre, est une expression de la pauvreté. La mendicité n'est pas un délit, depuis sa suppression du Code pénal en 1994, sauf si elle est réalisée en réunion et de manière agressive, ou sous la menace d'un animal dangereux (art. 312-12-1 du Code pénal). Elle fait cependant régulièrement l'objet d'interdiction par des maires de communes souhaitant dissimuler cette précarité.

Néanmoins, elle occupe une position paradoxale, entre pratique permettant la réalisation des autres droits humains, et pratique qui résulte de la liberté individuelle. Il s'agit généralement d'une solution de dernier recours permettant à des personnes vulnérables de survivre et de compenser les inactions sociales de l'État. Dès lors, la mendicité peut être nécessaire pour survivre et devient donc un droit légitime, particulièrement pour les personnes vulnérables, bien que cette situation puisse accentuer leur vulnérabilité, par la stigmatisation, la marginalisation ou en tant que victime d'exploitation.

Problématique et annonce du plan : La mendicité est un droit, interdépendant avec d'autres droits humains. Elle peut être appréhendée comme résultant de la jouissance de droits fondamentaux des personnes en situation de vulnérabilité **(A)**. Elle est néanmoins contrôlée en tant qu'enjeu de société **(B)**.

I. La mendicité comme expression des droits fondamentaux protégés

A. Un droit à l'existence digne

Le droit à la mendicité est l'émanation de plusieurs dispositions du droit international des droits de l'homme, de première, deuxième et troisième génération. La mendicité est à la fois une nécessité pour la réalisation plusieurs droits. C'est le cas du droit à la vie (art. 2 de la CESDH, art. 6 du PIDCP, art. 2 CDFUE, art. 6 de la Convention des droits des enfants) et du droit à des conditions de vie dignes ou de ses corolaires (art. 11 de la Charte sociale européenne, 34 CDFUE, art. 11 PIDESC).

C'est un choix relevant de l'autonomie personnelle et du droit au respect de la vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Il s'agit d'un droit recoupant de nombreux autres droits et démontrant par là même l'interdépendance des droits humains.

B. Un droit à destination des plus vulnérables

La mendicité est une pratique utilisée par les personnes dans des situations de vulnérabilité socio-économique extrême et est un signe de pauvreté, qui peut elle-même créer un obstacle à l'accès à des moyens de subsistance essentiels comme la nourriture (Conseil économique et social, 1999, Observation générale n° 19 relative au droit à une nourriture suffisante, E/C.12/1999/5).

La Cour européenne reconnaît la vulnérabilité des personnes recourant à la mendicité pour survivre : CEDH, 19 janvier 2021, *Lacatus c. Suisse*, n° 14065/15. Son interdiction est ainsi une atteinte aux droits humains.

L'exploitation de la mendicité, comme forme d'exploitation par le travail, est un délit prévu à l'article 225-12-5 du Code pénal, et cette exploitation en bande organisée est par ailleurs une circonstance aggravante, de même que lorsqu'elle est commise à l'égard de personnes vulnérables. Il existe à ce titre un lien très étroit entre exploitation de la mendicité et traite des êtres humains, et constitue, dans ce cadre, une atteinte à la dignité de la personne.

Dans son rapport concernant la Suisse publié en 2019, le Groupe d'experts sur la lutte contre la traite des êtres humains considère que la pénalisation de la mendicité met les victimes dans des situations d'extrême précarité.

II. Un droit nécessaire dans une société démocratique

A. Un droit devant tenir compte de l'équilibre entre ordre public et droit individuel

Mendier n'est pas un droit absolu. Il ne peut faire l'objet d'une interdiction absolue qui serait disproportionnée (CEDH, 19 janvier 2021, *Lacatus c. Suisse*, n° 14065/15).

De nombreux maires ont édicté des arrêtés anti-mendicités qui ont été annulés par les juges administratifs : le juge doit alors opérer une conciliation *in concreto* en censurant les mesures trop générales ou absolues considérées comme disproportionnées, selon un raisonnement classique des droits humains (TA d'Amiens, réf., 16 mai 2024, *Ligue des droits de l'homme et autres*, n° 2401685).

Il peut néanmoins être réglementé en cas de risque d'atteinte à l'ordre public (sûreté, sécurité, salubrité publique) (par la fouille de poubelles par exemple) : CE, CHR, 15 novembre 2017, n° 403275. Les individus la pratiquant ont cependant un droit d'occupation de l'espace public.

B. Un palliatif aux carences de la protection sociale étatique

Si le droit international garantit le droit à l'alimentation, l'habillement, le logement ainsi que le droit au travail, les droits dits « créances » sont souvent difficilement mis en œuvre, rendant la mendicité nécessaire pour pallier les carences de la protection de l'État.

Le droit à l'alimentation n'est pas reconnu textuellement en droit interne. Néanmoins, il existe certaines mesures ou systèmes comme les crédits nationaux et le Fond social européen, le Conseil national de l'alimentation. L'article L. 266-2 du Code de l'action sociale et des familles qui prévoit une aide alimentaire qui reste cependant très insuffisante et parfois difficilement accessible.

Les droits-créances sont dépendants des politiques budgétaires de l'État, particulièrement dans une politique d'austérité. On note en outre une augmentation constante du nombre de personnes vivant sous le seuil de pauvreté. La mendicité permet ainsi aux individus de passer outre les carences de l'État pour survivre.

En conclusion, il existe un droit à la mendicité dans un cadre d'interdépendance des droits humains, non absolu, mais permettant de pallier les carences de l'État pour les personnes vulnérables.

Fiche nº 56 - LES MESURES D'INÉGALITÉ COMPENSATOIRE

POINTS CLÉS

- Discrimination positive / discrimination négative.
- Droit de la non-discrimination / droit de l'égalisation.
- Différentialisme compensatoire / correcteur.
- Mesures préférentielles / actions positives.
- Traitement différencié justifié par l'intérêt général.
- Critères objectifs et différences de situation.
- Quotas et objectifs chiffrés.
- Principe d'égalité à géométrie variable.
- Inégalité juridique temporaire pour égalité de fait.

PRINCIPALES RÉFÉRENCES

- *Art. 23 CDFUE.*
- Révision constitutionnelle du 8 juillet 1999.
- Révision constitutionnelle du 3 juillet 2008.
- *Convention relative aux droits des personnes handicapées (2000).*
- *CEDH, 23 février 2016, Cam c. Turquie, nº 51500/08.*
- *Art. L. 1225-9 du Code du travail.*
- *Cons. const., déc. nº 2003-489 DC, 29 décembre 2003, Loi de finances pour 2004.*
- *Directive 2023/970 du 10 mai 2023.*
- *Loi nº 2011-103 du 27 janvier 2011.*

1. L'« égalité réelle » par la rupture de l'« égalité formelle »

L'égalité ne passe pas toujours par un traitement identique pour tous. Parfois, c'est en acceptant des inégalités de traitement – dites compensatoires – que le droit cherche à corriger des déséquilibres réels. Les logiques d'égalisation, les discriminations dites positives, et les actions ciblées assument de rompre l'égalité formelle afin de tendre vers une égalité plus concrète.

1.1. Droit de la non-discrimination et « droit de l'égalisation »

Il faut distinguer « droit de la non-discrimination » et « droit de l'égalisation » qui correspondent à des usages distincts de l'égalité. Le premier repose sur le contrôle des distinctions et traitements défavorables qui requiert une attention aux motifs des décisions, pour limiter l'arbitraire, et justifie l'intervention d'une juridiction.

Le droit de l'égalisation s'articule, en revanche, autour des normes qui visent à s'assurer de l'effectivité de l'égalité par le biais d'une « politique de l'égalisation ». Celle-ci peut prendre corps dans des programmes de lutte contre les inégalités sociales ou des mécanismes de redistribution (fiscalité, protection sociale…).

Le droit de l'égalisation se rapporte à l'ensemble des dispositions visant la réduction des inégalités par une politique interventionniste, compensatoire ou correctrice. Ce dernier cible des groupes défavorisés afin de répondre aux inégalités de conditions et de jouissance des droits par l'instauration de mesures préférentielles et des actions positives.

1.2. Discrimination négative et discrimination positive

Bien que les discriminations positives et négatives constituent toutes deux une entorse au principe d'égalité formelle, leur rapport à celui-ci est fondamentalement opposé. Il existe donc une distinction essentielle entre ces deux notions.

Les discriminations positives visent à promouvoir l'égalité réelle en introduisant, de manière volontaire, une inégalité juridique temporaire destinée à corriger les déséquilibres constatés dans les faits. Leur logique repose sur une volonté de rétablir un équilibre en faveur des personnes défavorisées, en avançant vers une égalité de fait. Elles s'inscrivent ainsi dans une logique de justice sociale.

Adopter une mesure de discrimination positive constitue dès lors un choix politique, affirmant la primauté de l'égalité réelle sur l'égalité formelle.

1.2.1. Mesures préférentielles et actions positives

Les notions de « mesures préférentielles » et d'« actions positives » doivent être distinguées.

Les mesures préférentielles consistent à traiter différemment (plus favorablement) des catégories d'individus, en raison d'un état contingent (grossesse, maternité) pour compenser des difficultés particulières liées aux conditions matérielles d'existence. Elles relèvent d'un « différentialisme compensatoire ».

→ L. 1225-9 du Code du travail.

Les actions positives consistent à traiter différemment (plus favorablement) des catégories d'individus, non en raison d'une caractéristique permanente ou durable (sexe, origine), pour corriger des inégalités de fait par la détermination d'objectifs chiffrés (la proportion des administrateurs de chaque sexe ne peut être inférieure à 40 % dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé). Elles relèvent d'un « différentialisme correcteur ».

→ Art. 1 de la loi n° 2011-103 du 27 janvier 2011.

Actualité législative. - Les quotas sont étendus aux fonctions dirigeantes

Depuis le 1er mars 2026, dans les entreprises employant au moins 1 000 salariés pour le troisième exercice consécutif, la proportion de personnes de chaque sexe ne peut être inférieure à 30 % parmi les cadres dirigeants, d'une part, et les membres des instances dirigeantes, d'autre part. Ce seuil sera porté à 40 % à compter du 1er mars 2029.

→ Art. L. 1142-11 du Code du travail ; loi n° 2021-1774 du 24 décembre 2021 visant à accélérer l'égalité économique et professionnelle.

À retenir. - Le droit français recourt de manière croissante à des objectifs chiffrés contraignants pour corriger la sous-représentation des femmes dans les fonctions de responsabilité aussi bien dans la fonction que dans le secteur privé.

1.2.2. Un équilibre fragile entre égalité et différenciation

La non-discrimination peut être mobilisée pour établir une égalité réelle en instaurant, au bénéfice de groupes défavorisés, des traitements différenciés, ou justifier l'application de règles spécifiques à certains groupes, en raison de leur identité particulière. La doctrine française n'y voit pas d'objection lorsque le principe de non-discrimination permet d'assurer pleinement le principe d'égalité républicain.

En revanche, elle est très partagée sur les dispositifs compensatoires destinés à instaurer activement une égalité des chances. Bien que les « fissures différentialistes » soient rares, certains redoutent que la multiplication des traitements justifiés par des différences de situations conduise à une forme généralisée d'égalité différentielle aux effets pervers, pouvant institutionnaliser des égalités intra-catégorielles doublées d'inégalités inter-catégorielles.

Au-delà de la critique politique du prétendu « communautarisme » de l'inégalité compensatoire ou de la dénaturation supposée du principe d'égalité, les débats doctrinaux soulignent la complexité d'interpréter un principe dont la portée et la signification varient selon les contextes et les jugements.

1.2.3. La discrimination positive à la française

Si la conception classique de l'égalité en droit français reposait sur une égalité devant la loi, des revendications ont émergé en faveur d'une égalité par le droit. Il s'agissait d'appeler le législateur à corriger activement les inégalités de fait.

Le début des années 2000 a été marqué en France par le débat autour des discriminations positives, destinées à soutenir certains groupes dont les chances sont compromises par des inégalités socio-économiques, ou des pratiques sexistes ou sexistes. À deux reprises, la Constitution a été modifiée pour permettre à la loi de favoriser l'égal accès des femmes et des hommes, d'abord aux « mandats électoraux et fonctions électives » puis à l'ensemble des « responsabilités professionnelles et sociales ».

→ Révision constitutionnelle du 8 juillet 1999.

→ Révision constitutionnelle du 3 juillet 2008.

En revanche, le droit constitutionnel ne reconnaît ni un droit à la différence, ni un droit des groupes (qu'ils soient ethniques, culturels ou religieux).

→ Cons. const., déc. n° 2003-489 DC, 29 décembre 2003, *Loi de finance pour 2024.*

Il reste que si sous la pression des droits européens et par l'influence américaine, une forme spécifique de discrimination positive à la française a vu le jour, aucun consensus ne se dégage quant à sa définition. On peut néanmoins s'accorder à la considérer comme une différenciation juridique de traitement, temporaire, visant à favoriser une catégorie déterminée de personnes au détriment d'une autre, afin de compenser une inégalité de fait préexistante.

1.3. L'exemple de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne

La Charte des droits fondamentaux de l'Union pose le principe de la non-discrimination, et de l'égalité entre femmes et hommes en ouvrant la possibilité de discriminations positives.

→ Art. 21 CDFUE.

→ Art. 23 CDFUE : *« L'égalité entre les hommes et les femmes doit être assurée dans tous les domaines, y compris en matière d'emploi, de travail et de rémunération. Le principe de l'égalité n'empêche pas le maintien ou l'adoption de mesures prévoyant des avantages spécifiques en faveur du sexe sous-représenté. »*

L'article 23 qui autorise les actions positives en faveur des femmes permet désormais aux institutions de l'Union de déroger à l'égalité (formelle) pour promouvoir une égalité réelle. Ainsi, la directive de 2023 sur l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes s'appuie tant sur l'article 21 qui interdit les discriminations fondées sur le sexe que sur l'article 23 de la Charte.

→ Directive 2023/970 du 10 mai 2023 visant à renforcer l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les femmes et les hommes

POUR ALLER PLUS LOIN

Personnes en situation de handicap et actions positives. *Les personnes en situation de handicap font l'objet de mesures de discrimination positive de manière particulièrement marquée. Les États, dont la France, ont l'obligation de mettre en œuvre toutes les mesures appropriées afin de garantir l'égalité. L article 5 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées (2000) impose ainsi aux États de « faire en sorte que des aménagements raisonnables soient apportés ». Dans le même esprit, la Cour européenne des droits de l'homme a reconnu une obligation similaire découlant de l article 14 de la Convention, en matière de scolarisation des enfants handicapés (CEDH, 23 février 2016, Car c. Turquie). Les actions positives peuvent prendre deux formes principales : viser à renforcer l'égalité des chances, en améliorant la position d un groupe défavorisé dans la compétition pour l accès à une ressource ou à un droit ; chercher à garantir une véritable égalité des résultats, en assurant concrètement l accès à cette ressource à un nombre déterminé de personnes issues d un groupe désavantagé. Dans ce cas, les mesures peuvent prendre la forme de quotas, comme la règle des 6 % imposée aux employeurs pour l emploi de personnes handicapées*.

2. La correction juridictionnelle des inégalités structurelles

Les juges, qu'ils soient administratifs, constitutionnels ou européens, ont progressivement reconnu la légitimité de traitements différenciés, ou discriminations positives, lorsqu'ils visent à corriger des inégalités factuelles ou poursuivent un objectif d'intérêt général.

2.1. Le Conseil constitutionnel

Le Conseil constitutionnel, de son coté, affirme que *« le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit »*.

→ Cons. const., déc. n° 87-232 DC, 7 janvier 1988, *Loi relative à la mutualisation de la Caisse nationale de crédit agricole.*

Le Conseil a ainsi jugé qu'au regard de l'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction, la loi pouvait prévoir une voie particulière d'accès à l'Institut d'études politiques en proposant des conventions à des lycées situés dans des zones d'éducation prioritaire.

→ Cons. const., déc. n° 2001-450, 11 juillet 2001, *Loi portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel.*

Selon une jurisprudence constante, deux motifs peuvent justifier une atteinte au principe d'égalité :

- La <u>différence de situations</u>, sous réserve de compatibilité avec la finalité de la loi et à condition que le traitement différencié repose sur des critères objectifs.

  → Cons. const., déc. n° 81-132 DC, 16 janvier 1982, *Loi de nationalisation.*

  → Cons. const., déc. n° 79-107 DC, 12 juillet 1979, *Loi relative à certains ouvrages reliant les voies nationales ou départementales.*

  → Cons. const., déc. n° 2003-489 DC, 29 décembre 2003, *Loi de finance pour 2004.*

- La <u>poursuite d'un objectif d'intérêt général</u>, à condition que ce dernier soit en lien direct avec l'objet de la loi.

→ Cons. const., déc. n° 96-375 DC, 9 avril 1996, *Loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.*

Partant des mesures compensatoires peuvent être adoptées en faveur de certaines catégories, comme les jeunes, les personnes âgées ou les femmes, en raison d'inégalités factuelles constatées. Le Conseil souligne cependant que de telles mesures doivent viser à réduire les inégalités et non à reconnaître des droits collectifs à un groupe déterminé.

→ Cons. const., déc. n° 2006-535 DC, 30 mars 2006, *Loi pour l'égalité des chances.*

→ Cons. const., déc. n° 89-257 DC, 25 juillet 1989, *Loi modifiant le code du travail et relative à la prévention du licenciement économique et au droit à la conversion.*

→ Cons. const., déc. n° 2003-483 DC, 14 août 2003, *Loi portant réforme des retraites.*

Certaines formes de traitements différenciés demeurent néanmoins interdites. Le Conseil constitutionnel a ainsi censuré plusieurs dispositions législatives, en particulier celles fondées sur l'origine, sur le fondement de l'article 1er de la Constitution de 1958. Des différenciations fondées sur ce critère ont été jugées inconstitutionnelles dans plusieurs décisions.

→ Cons. const., déc. n° 84-177 DC, 30 août 1984, *Loi relative au statut du territoire de la Polynésie française, et notamment son article 10.*

→ Cons. const., déc. n° 84-178 DC, 6 septembre 1984, *Loi portant statut du territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, et notamment ses articles 12, 131 et 137.*

→ Cons. const., déc. n° 85-196 DC, 8 août 1985, *Loi sur l'évolution de la Nouvelle-Calédonie.*

→ Cons. const., déc. n° 91-290 DC, 9 mai 1991, *Loi portant statut de la collectivité territoriale de Corse.*

Plus récemment, le Conseil a annulé une disposition législative qui autorisait la constitution de fichiers mentionnant directement ou indirectement les origines raciales ou ethniques. Si des études peuvent reposer sur des données objectives, elles ne doivent pas se fonder sur la race ou l'origine ethnique, sous peine de méconnaître le principe d'égalité garanti par la Constitution.

→ Cons. const., déc. n° 2007-557 DC, 15 novembre 2007, *Loi relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile.*

Le cadre juridique peut néanmoins évoluer. Des révisions constitutionnelles ont permis des discriminations positives dans certains territoires (Nouvelle-Calédonie, Polynésie), à l'instar de ce qui s'est passé en 1999 et 2008, pour favoriser l'accès des femmes aux mandats électoraux et fonctions professionnelles.

2.2. Le Conseil d'État

Les évolutions récentes de la jurisprudence administrative sont significatives. Le Conseil d'État admet désormais des différences de traitement à condition qu'elles reposent sur des critères objectifs, qu'elles soient justifiées par des différences de situation ou qu'elles répondent à un motif d'intérêt général.

→ CE, 29 décembre 1997, *Commune de Gennevilliers*, n° 157425.

Revenant sur sa jurisprudence sur la tarification des services publics, le juge administratif a ainsi indiqué que l'intérêt général qui s'attache à ce que les enfants puissent fréquenter une école de musique permettait au conseil municipal de moduler les droits d'inscription au conservatoire de la commune en fonction des revenus des parents.

Le Conseil d'État considère que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit, dans l'un comme l'autre cas, en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier.

→ CE, Sect., 18 décembre 2002, *Mme Duvignères*, n° 233618.

Le juge administratif rappelle néanmoins que seule la loi peut mettre en œuvre les mesures autorisées par la Constitution.

→ CE, 7 mai 2013, *Fédération CFTC de l'agriculture et autres*, n° 362280.

2.3. La Cour européenne des droits de l'homme

La Cour exerce un contrôle particulièrement strict, affirmant qu'*« aucune différence de traitement fondée exclusivement ou de manière déterminante sur l'origine ethnique d'un individu ne peut passer pour objectivement justifiée dans une société démocratique contemporaine »*. Toute discrimination sur ce fondement est « odieuse ».

→ CEDH, 13 décembre 2005, *Timichev c. Russie.*

Cette affirmation met en exergue l'extrême rigueur du contrôle opéré par la Cour lorsqu'un tel critère est en jeu. Toutefois, plutôt qu'une interdiction absolue de toute distinction, elle préfère rester juge du caractère justifié d'un tel critère au regard du contexte spécifique.

En réalité, sa jurisprudence est traversée par deux logiques parfois contradictoires.

- D'un côté, un refus ferme de toute distinction fondée sur l'origine ethnique, perçue comme inacceptable en soi ;
- De l'autre, une reconnaissance possible de ce critère pour compenser des désavantages structurels subis par des groupes minoritaires (logique de traitement différencié ou d'actions positives).

Ce balancement se reflète dans des formules plus nuancées. Ainsi la Cour a pu préciser que *« la notion de justification objective et raisonnable doit être interprétée de manière aussi stricte que possible »* lorsqu'une différence de traitement est fondée sur la race, la couleur ou l'origine ethnique.

→ CEDH, 13 novembre 2007, *D.H. et a. c. République tchèque.*

→ CEDH, 5 juin 2008, *Sampanis et a. c. Grèce.*

De même, elle souligne que seules des considérations très fortes peuvent l'amener *« à estimer compatible avec la Convention une différence de traitement exclusivement fondée sur l'origine ethnique »*.

→ CEDH, 16 mars 2010, *Oršuš et a. c. Croatie.*

2.4. Cour de justice de l'Union européenne

Depuis les années 2000, la Cour de justice adopte une position sévère à l'égard des avantages familiaux de retraite réservés aux femmes qu'elle juge contraires au principe d'égalité de rémunération entre les sexes.

Dans une logique d'égalité formelle, la Cour a écarté les justifications tirées des rôles parentaux différenciés et condamné la bonification d'un an par enfant réservée aux mères dans la fonction publique, jugeant que cet avantage était fondé non sur la maternité, mais sur la charge d'éducation des enfants, laquelle peut aussi être assumée par des hommes.

→ CJCE, 29 novembre 2001, *Griesmar*, aff. C-366/99.

Cette logique contestée a été poursuivie dans la jurisprudence ultérieure. La Cour a examiné un dispositif accessible aux hommes comme aux femmes, à condition d'avoir interrompu leur activité au moins deux mois pour s'occuper de leur enfant. Bien que formellement neutre, cette exigence entraînait, selon le juge de l'Union, une discrimination indirecte, car rarement remplie par les hommes, pour qui le congé parental est optionnel et peu attractif.

→ CJUE, 17 juillet 2014, *Leone,* aff. C-173/13.

Ces décisions illustrent une approche qui, sous couvert d'égalité formelle, repose sur une logique marchande, où la retraite est perçue comme rémunération, et non comme mesure de justice sociale. La Cour entend ainsi éliminer les stéréotypes de genre, même au détriment de dispositifs censés corriger les inégalités concrètes.

→ CJUE, 30 sept. 2010, *Roca Alvarez*, aff. C-104/09.

POUR ALLER PLUS LOIN

Le système français de Sécurité sociale repose historiquement sur un modèle familialiste fondé sur une répartition genrée des rôles : l'homme actif ouvrait des droits sociaux propres, tandis que la femme au foyer bénéficiait d'un statut d'ayant droit non rémunéré, reconnaissant implicitement son travail domestique. Avec la montée du salariat féminin, les femmes ont progressivement acquis des droits propres, mais souvent dans des conditions désavantageuses. En effet, leur retraite est en moyenne inférieure de 40 % à celle des hommes, en raison d'un taux d'activité plus faible, du recours massif au temps partiel lié aux charges familiales, et de salaires moindres. Ce déséquilibre soulève un dilemme : ne pas compenser le poids des tâches familiales appauvrit les femmes à la retraite, mais les compenser revient à entériner une division sexuée du travail. Ce paradoxe structure le débat juridique entre une conception européenne, axée sur l'égalité formelle, et une approche française qui revendique, de manière paradoxale, une forme d'égalité matérielle, à rebours de la conception républicaine de l'égalité formelle qu'elle a pourtant inaugurée.

3. Critiques et perspectives

Le sujet des discriminations positives n'est pas politiquement neutre ; il suscite de vifs débats au sein d'une doctrine clivée, notamment dans ses expressions les plus engagées. Deux courants de pensée s'affrontent aujourd'hui.

Toutefois, à l'ère des systèmes d'Intelligence artificielle et des nouvelles formes de discrimination, plus diffuses et insidieuses, le discours des partisans de l'égalité réelle et des actions correctrices gagne en pertinence. Il reste qu'il ne faut pas perdre de vue que les métriques de débiaisement – ces outils mathématiques conçus pour identifier et corriger les biais algorithmiques – ne sauraient faire abstraction des questions liées à notre conception, variable et subjective, de ce qui est juste.

3.1. Pour ou contre la discrimination positive : des juristes partagés

L'attachement à l'idéal républicain d'égalité rend la notion de discrimination positive taboue en France, au point que l'expression elle-même est souvent rejetée. Pour certains juristes, ces actions positives bafouent à la fois le principe d'égalité et celui de liberté.

Ces critiques, de nature politique, dénoncent des revendications identitaires et des ressentiments collectifs en rappelant que la Constitution française ne consacre ni le multiculturalisme ni le marxisme.

Sur la question de la parité femmes-hommes, une partie de la doctrine avait, de même, reproché aux juridictions françaises leur attitude de résistance, et dénoncé une course d'obstacles jurisprudentiels. Le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel ont été accusé de neutraliser la dynamique paritaire, au nom d'une conception désuète de l'égalité réduite à sa dimension formelle, voire formaliste, insensible à la réalité de son application.

D'autres auteurs y ont vu un procès en misogynie juridictionnelle et salué la prudence des juges, défendant l'idée que la parité constitue une dérogation au principe d'égalité, non son prolongement.

Ces tensions se retrouvent aujourd'hui dans d'autres domaines, notamment dans les critiques formulées à l'encontre du Conseil constitutionnel, qui interdit à la recherche l'usage de données statistiques – même lorsqu'il s'agit de mesurer les discriminations subies par les populations dites « racisées ».

3.2. Le renouvellement discrimination positive consécutive au développement de l'IA : les métriques de débiaisement

Les métriques de débiaisement, conçues pour mesurer les écarts de traitement entre différents groupes sociaux, soulèvent des enjeux éthiques et politiques majeurs. Car derrière leur apparente neutralité mathématique, elles renvoient à des choix de société : faut-il viser une égalité des chances ou des résultats ? Quels critères utiliser

pour définir un traitement équitable ? À quel moment une différenciation de traitement devient-elle une forme de discrimination légitime – ou illégitime ?

Dans la mesure où l'intelligence artificielle tend à systématiser et amplifier des biais déjà enracinés dans les données et les structures sociales, une approche fondée sur l'égalité réelle semble plus adaptée pour en révéler les mécanismes et y remédier efficacement.

Il reste que ces interrogations traduisent une tension persistante entre l'objectivité technique des algorithmes et la subjectivité des valeurs que l'on prétend y inscrire. Si les systèmes automatisés peuvent, en théorie, contribuer à une application plus rigoureuse des principes d'égalité, ils ne sauraient trancher, par eux-mêmes, les débats philosophiques ou juridiques qui fondent notre conception du juste. L'enjeu n'est pas seulement technique ou juridique, mais fondamentalement démocratique.

POUR S'ENTRAÎNER

Commentaire de texte : article 1er DDHC

« Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. »

Introduction : L'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 pose les fondements de l'ordre juridique républicain en affirmant que *« les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits »* et que *« les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune »*. Si cette double formule consacre un idéal d'égalité, elle révèle aussi des tensions entre universalité proclamée et exclusions permises.

Problématique : Comment cette affirmation fondatrice peut-elle à la fois poser l'égalité comme principe absolu et admettre des distinctions qui en limitent la portée ?

Annonce de plan : Nous analyserons les limites d'une égalité formelle, historiquement marquée par l'exclusion de certains groupes **(I)**, avant d'étudier les dérogations admises au nom de l'utilité commune, justifiées par l'intérêt général, mais peu mobilisées, en pratique, pour tendre vers l'égalité réelle **(II)**.

I- Les lacunes d'une conception formelle de l'égalité

Il s'agit de commenter la première phrase en insistant sur les limites de la formule : *« Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits »* tant sur la forme (terminologie) que sur le fond (les conséquences juridiques pour certains groupes, à commencer par les femmes).

A. L'universalisme excluant : le biais patriarcal

Les hommes ne visent pas les êtres humains puisque les femmes sont, à l'époque de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, largement exclues (la terminologie n'est pas neutre du fait de l'héritage sexiste) et, plus généralement, tous ceux qui ne sont pas reconnus comme citoyens : enfants, étrangers.

Cette exclusion est manifeste au XVIIIe siècle et persiste, sous diverses formes, jusqu'au XXe siècle (ex. : droit de vote en 1944).

B- De l'égalité proclamée à l'interdiction explicite des discriminations

Au fil du temps, sous l'influence conjuguée des normes internationales, des modèles étrangers (notamment américain) et d'une relecture plus substantielle de l'égalité, le droit français a intégré des exigences antidiscriminatoires.

Le droit positif s'est enrichi depuis le XVIIIe siècle (art. 1er de la Constitution).

Droit de ne pas être discriminé (sexe, origine…).

Parité (discriminations positives en faveur des femmes : révisions constitutionnelles).

II. De possibles dérogations à l'égalité formelle : l'utilité commune

Il s'agit de relever le potentiel de la seconde phrase, exploitable par les juridictions nationales, sous l'angle de la réalisation de l'égalité réelle, en distinguant le traitement de situations jugées équivalentes et le traitement de situations non équivalentes.

A. La justification des ruptures à l'égalité formelle en recourant à l'intérêt général

« L'utilité commune », c'est-à-dire l'intérêt général (et lui seul) peut justifier un traitement différent de situations jugées équivalentes, c'est-à-dire qu'il peut justifier une rupture de l'égalité formelle et réelle.

L'intérêt général justifie ainsi des distinctions entre catégories de personnes. Le droit des étrangers en est une illustration. Selon le Conseil constitutionnel, *« aucune règle de valeur constitutionnelle n'assure aux étrangers des droits de caractère général et absolu d'accès et de séjour sur le territoire national ; qu'eu égard à l'objectif d'intérêt général qu'il s'est assigné, tendant à instituer un statut de résident de longue durée, le législateur a pu exiger que l'obtention de la carte de résident* […] *soit soumise à la double condition d'une durée de résidence ininterrompue de deux ou cinq ans sur le territoire français et d'une intégration »* (20 novembre 2003, 2203-484 DC).

On peut s'étonner que de telles « dérogations » à l'égalité formelle (et réelle) soit si peu critiquées par ceux qui se scandalisent devant les discriminations positives, qui, si elles sont aussi des dérogations à l'égalité formelle, visent quant à elles, une égalité bien réelle. Il est paradoxal de se montrer aussi attaché au principe d'égalité au point de lui préférer la lettre à sa réalisation effective.

B. La réalisation de l'égalité réelle par l'intérêt général : un manque de volontarisme du juge ?

Se pose donc, toujours sous l'angle de l'utilité commune/intérêt général de cet article, la possible dérogation fondée sur des actions positives (traitement différent de situations non équivalentes) : si elle contrevient à l'égalité formelle, la discrimination positive s'accorde avec l'égalité réelle. En effet, traiter de manière distincte des situations différentes est en adéquation avec l'égalité réelle. Il s'agit donc d'une dérogation différente de la première, fondée sur l'intérêt général, bien que toutes deux constituent une rupture de l'égalité formelle.

Malgré la mobilisation de l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen par le juge constitutionnel, le potentiel de sa deuxième phrase n'est pas exploité pour la justification des distinctions sociales au nom des mesures préférentielles et de lutte contre les inégalités. Cela exigerait un certain volontarisme de la part du Conseil constitutionnel qui, au contraire, s'est plutôt engagé lors des vingt dernières années dans une certaine réserve.

Il reste que les dérogations fondées sur les discriminations positives reposent sur une logique différente des premières, Le critère d'ajustement est interne à l'égalité, là où l'intérêt général est le critère de modulation extérieure à l'égalité.

L'intérêt général et les discriminations positives rompent tous deux l'égalité formelle dans sa conception républicaine (telle que proclamée dans la première phrase de l'article). Mais là où les actions positives s'attachent, précisément grâce à cette rupture, à tendre vers une égalité réelle, l'intérêt général permet de justifier l'existence d'une discrimination à la fois formelle et matérielle.

En conclusion, l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen contient en germe à la fois les fondements de l'égalité et les outils pour y déroger au nom de l'intérêt général. Si, concernant ce dernier point, le juge a accepté que des « discriminations négatives » soient justifiées par l'intérêt général, il s'est montré plus réservé s'agissant des « discriminations positives ». Le texte est ce qu'il est, ses failles et ses virtualités demeurent. Ses limites et lacunes ont été progressivement, et partiellement, comblées par d'autres instruments, y compris législatifs, mais il appartient aux juridictions, à commencer par le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État de s'en saisir pour assurer une égalité toujours plus effective.

TABLES DES MATIÈRES

PARTIE I – ÉLÉMENTS INTRODUCTIFS 4

FICHE N°1 - LES NOTIONS 5

1. Prolégomènes historiques 5

1.1. Les notions de liberté et de dignité au fondement des droits de la personne humaine : la subjectivisation des rapports juridiques 6

1.2. L'École moderne du droit naturel et les doctrines du contrat social à l'origine de la conception moderne des droits de l'homme 7

1.2.1. Le Jusnaturalisme 7

1.2.2. Le Contrat social 8

1.3. Les enjeux juridiques de l'invisibilisation linguistique des femmes 8

2. La fondamentalisation des droits et libertés : l'importance croissante des sources supra-législatives 8

2.2. Les sources constitutionnelles 9

2.1. La fascination de la doctrine française pour le modèle allemand 10

2.1.1. La construction incertaine du droit positif français 10

2.1.2. Les droits fondamentaux sous l'angle de l'Union européenne 10

2.3. Les sources conventionnelles 11

3. Les débats contemporains autour de la notion de droits humains 12

3.1. Glissements terminologiques et évolution sémantique : vers une universalité inclusive 12

3.2. Les libertés de la personne humaine à l'ère du numérique : vers des neurodroits humains 13

3.3. L'élargissement potentiel du cercle des bénéficiaires : la prise en compte juridique des « non-humains » 13

Fiche n° 2 - LES ORIGINES PHILOSOPHIQUES ET RELIGIEUSES 17

1. La difficile recherche des origines antiques 17

1.1. Le Code d'Hammourabi 17

1.2. Le cylindre de Cyrus 18

2. La philosophie grecque classique des libertés publiques 18

2.1. La pensée grecque classique : liberté et citoyenneté 18

2.2. La pensée stoïcienne : l'émancipation de l'individu de la Cité 18

3. La philosophie chrétienne : une nouvelle conception de l'humain 19

3.1. Les apports du christianisme : le renforcement de l'individualisme 19

3.1.1. L'égalité dans la pensée chrétienne 20

3.1.2. La séparation du spirituel et du temporel 20

3.2. Les obstacles du christianisme au développement des libertés publiques 20

4. La limitation du pouvoir de l'État (XVIe et XVIIe siècles) 20

4.1. Le droit naturel : un droit intrinsèque à l'individu 21

4.2. Les théories du contrat social 21
5. La philosophie des Lumières, l'essor des libertés (XVIIIe siècle) 22
5.1. La pensée des Lumières, prémices de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen 22
5.2. La philosophie révolutionnaire et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen 23
6. Le renouveau philosophique des libertés (XIXe et XXe siècle) 23
6.1. La critique marxiste des droits révolutionnaires 23
6.2. La pensée socialiste et l'intervention de l'État 23
7. L'émergence de nouvelles philosophies des libertés (XXe siècle). 24
7.1. Les théories féministes et la critique féministe 24
7.2. La protection du vivant face aux technologies 24
Fiche nº 3 - LES ORIGINES TEXTUELLES 28
1. Les premiers textes anglais 28
1.1. La Grande Charte (1215) 28
1.2. La Pétition des droits (1628) 29
1.3. L'Habeas Corpus Act (1679) 29
1.4. Le Bill of rights (1689) 29
2. Les textes américains 29
2.1. La Constitution de l'État de Virginie (12 juin 1776) 30
2.2. La Déclaration d'Indépendance des États-Unis d'Amérique (4 juillet 1776) 30
2.3. La Constitution américaine du 17 septembre 1787 31
3. La Déclaration des droits de l'homme et du Citoyen de 1789 32
3.1. Le contexte de la Déclaration de 1789 32
3.2. Le contenu de la Déclaration de 1789 32
Actualité. - Vers l'abrogation formelle du « Code noir » 33
Si l'esclavage a été définitivement aboli en France par le décret du 27 avril 1848, le « Code noir » n'avait jamais fait l'objet d'une abrogation expresse. Il était généralement regardé comme ayant perdu toute portée juridique du fait de l'abolition de l'esclavage, autrement dit comme ayant été tacitement abrogé, mais cette absence d'abrogation formelle conservait une forte portée symbolique et mémorielle. 33
Une proposition de loi déposée en septembre 2025 entend précisément mettre fin à cette situation. Le 28 mai 2026, l'Assemblée nationale a adopté à l'unanimité, en première lecture, un texte prévoyant l'abrogation expresse de l'ordonnance de mars 1685 dite « Code noir », ainsi que de l'ensemble des dispositions prises pour son application, son adaptation ou son extension dans les différentes colonies françaises. Le texte vise notamment les législations de 1723 et 1724 qui avaient étendu ce régime à d'autres territoires. 33
La proposition comporte également une dimension mémorielle : elle rattache expressément ces textes au crime contre l'humanité constitué par la traite et l'esclavage, déjà reconnu par la loi du 21 mai 2001 dite « loi Taubira ». Elle prévoit en outre un recensement des dispositions issues du droit colonial qui demeureraient encore en vigueur dans les territoires ultramarins. 33
3.3. Les caractères de la Déclaration de 1789 33
3.4. Les critiques à l'encontre de la Déclaration de 1789 34
3.4.1. La critique contre-révolutionnaire 34

3.4.2. La critique féministe 34
3.4.3. La critique socialiste et marxiste 34
Fiche nº 4 - LES CLASSIFICATIONS 37
1. Les classifications doctrinales 37
1.1. La classification chronologique ou diachronique : les générations de droit 37
1.1.1. Les droits de première génération (XVIIIe siècle) 37
1.1.2. Les droits de deuxième génération (XIXe siècle) 38
1.1.3. Les droits de troisième génération 38
1.1.4. Les droits de quatrième génération 39
1.1.5. Une classification soumise à critique 39
1.2. Les classifications en fonction de l'objet 40
1.2.1. La distinction entre droit substantiel/droit procédural 40
1.2.2. La distinction entre liberté physique, intellectuelle et relationnelle 40
1.3. La classification fondée sur le rôle de l'État 41
1.3.1. La distinction opérée par G. Jellinek 41
1.3.2. La distinction opérée par K. Marx 41
1.4. La distinction fondée sur le régime d'exercice 41
1.4.1. Le régime répressif 41
1.4.2. Le régime de la déclaration préalable 42
1.4.3. Le régime préventif 42
2. Les classifications prétoriennes 43
2.1. La classification retenue par le Conseil d'État : libertés individuelles/libertés collectives 43
2.2. La classification retenue par le Conseil constitutionnel : libertés fondamentales/libertés publiques 43
Fiche nº 5 - LES PRINCIPES DIRECTEURS 46
1. L'inaliénabilité des droits humains 46
1.1. Les fondements textuels de l'inaliénabilité 46
1.2. La question de la renonciation volontaire 47
1.2.1. L'inaliénabilité et la fin de vie 47
1.2.2. L'inaliénabilité et le droit de se faire mal 48
2. L'universalité des droits humains 48
2.1. La limite terminologique de l'universalité : droits de l'homme ou droits humains ? 49
2.2. La limite géographique de l'universalité : protection régionale ou universelle ? 49
2.2.1. La difficile universalité au niveau mondial 49
2.2.2. La difficile universalité au niveau régional et étatique 50
3. L'unité ou l'indivisibilité des droits humains 51
4. Le principe matriciel : la dignité humaine 52

4.1. La définition de la dignité de la personne humaine 52
4.2. Les consécrations de la dignité de la personne humaine 52
4.3. La portée du principe de dignité 53
4.4. Les droits couverts par le principe de dignité 53
Fiche n° 6 - LES RÉGIMES 56
1. Une nécessité de conciliation des libertés avec d'autres impératifs 56
1.1. Les principes généraux 56
1.2. La notion d'ordre public 57
2. Les types de régimes 58
2.1. Le régime répressif 58
2.2. Le régime préventif 58
2.3. Le régime déclaratif 59
Fiche n° 7 - LIMITATIONS ET ÉTATS D'EXCEPTION 63
1. Les régimes d'exception prévus par la Constitution 63
1.1 Les pouvoirs exceptionnels du chef de l'État prévus à l'article 16 de la Constitution 63
1.1.1. Les conditions de sa mise en œuvre 63
1.1.2. Les pouvoirs exceptionnels du chef de l'État 64
1.1.3. Le contrôle des décisions prises sur le fondement de l'article 16 64
1.1.4. La modification de l'article 16 par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 64
1.1.5. L'unique application de l'article 16 64
1.2. L'état de siège prévu à l'article 36 de la Constitution 65
1.2.1. Les conditions de mise en œuvre de l'article 36 65
1.2.2. L'accroissement des compétences de l'autorité militaire 65
1.2.3. Les limitations aux droits humains sous l'état de siège 65
2. L'état d'urgence prévu par le législateur 65
2.1. La loi du 3 avril 1955 classiquement appliquée sous la Ve République 65
2.1.1. Les conditions de la mise en œuvre et de la prolongation 65
2.1.2. Le contrôle juridictionnel de la mise en œuvre et de la prolongation 66
2.1.3. Les limitations aux droits humains prévues par la loi du 3 avril 1955 66
2.1.4. Le contrôle des mesures prises sur le fondement de la loi du 3 avril 1955 66
2.1.5. Les applications de la loi du 3 avril 1955 sous la Ve République 66
2.2. L'épidémie de Covid-19 et la loi du 23 mars 2020 67
3. La création prétorienne de la théorie des circonstances exceptionnelles 69
4. La reconnaissance conventionnelle de la dérogation aux droits humains 70
4.1. L'article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques 70
4.2. L'article 15 de la Convention européenne et son interprétation prétorienne 70

4.3. Les droits indérogeables en période d'exception 71
4.3.1. Les droits indérogeables selon le Pacte international relatif aux droits civils et politiques . 71
4.3.2. Les droits indérogeables selon la Convention européenne des droits de l'homme 71
Fiche nº 8 - LA CRISE DES DROITS HUMAINS ET L'ÉTAT DE DROIT 74
1. La définition de l'État de droit 74
1.1. L'absence de définition normative univoque 74
1.2. L'État de droit dans des textes constitutionnels et conventionnels 75
1.3. La définition de l'État de droit selon la Commission de Venise 75
2. La remise en cause protéiforme de l'État de droit 76
2.1. La contestation de la légitimité des juges 76
2.2. La contestation du droit supranational 77
2.3. La crise des droits humains 77
2.3.1 La fragilisation des droits de l'opposition 77
2.3.2. La liberté académique en crise 78
2.3.3. La remise en cause des droits des femmes 78
2.3.4. La réticence à l'égard des droits des personnes migrantes 78
PARTIE II. LES SOURCES INTERNES 82
Fiche nº 9 - LES SOURCES CONSTITUTIONNELLES 83
1. Le bloc de constitutionnalité 83
1.1. Avant la Constitution de 1958 83
1.2. Après la Constitution de 1958 84
2. Le contenu du bloc de constitutionnalité 84
2.1. La Constitution de 1958 et son préambule 84
2.2. Le préambule de la Constitution de 1946 85
2.2.1. Les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République 85
2.2.2. Les principes particulièrement nécessaires à notre temps 87
2.3. La Déclaration de 1789 87
2.4. La Charte de l'environnement 88
2.5. Les principes à valeur constitutionnelle 88
2.6. Les objectifs à valeur constitutionnelle 89
3. La supériorité du bloc de constitutionnalité 91
Fiche nº 10 - LE BLOC DE LÉGALITÉ 94
1. Les origines de la consécration législative des libertés 94
2. La définition du bloc de légalité 95
2.1. Le bloc de légalité « traditionnel » : la norme législative 95
2.1.1. La définition formelle : la hiérarchie des normes 95

2.1.2. La définition matérielle : le contenu du bloc de légalité 95

Actualité jurisprudentielle. - Le Conseil d'État précise à nouveau le statut des ordonnances non ratifiées. 97

Le Conseil d'État a rappelé en 2025 qu'une ordonnance prise sur le fondement de l'article 38 de la Constitution conserve, aussi longtemps qu'elle n'a pas été expressément ratifiée par le Parlement, le caractère d'un acte administratif. Une particularité existe toutefois après l'expiration du délai d'habilitation. Les dispositions de l'ordonnance qui relèvent du domaine de la loi ne peuvent alors plus être modifiées ou abrogées par le pouvoir réglementaire. Seul le législateur, ou le Gouvernement bénéficiant d'une nouvelle habilitation, peut intervenir. Cette règle s'applique même lorsque les dispositions concernées seraient entachées d'illégalité. 97

→ CE, 20 mars 2025, Association pour la défense du droit au recours, n° 494158. 97

À retenir. - Une ordonnance non ratifiée demeure un acte administratif, y compris après l'expiration du délai d'habilitation. Toutefois, les dispositions relevant du domaine législatif acquièrent alors un régime particulier : leur conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution relève de la QPC (art. 61-1 C.) et elles ne peuvent plus être modifiées ou abrogées par le simple pouvoir réglementaire. 97

2.2. Le bloc de légalité « élargi » : l'intégration des principes généraux du droit 97

2.2.1. La notion de principe général du droit 97

2.2.2. L'incertitude de la valeur des principes généraux du droit 97

3. Une protection législative des droits et libertés 98

3.1. Une protection législative prévue par la Constitution 98

3.2. Une intervention du législateur indispensable en pratique 99

3.3. Un outil de conciliation entre les droits 99

4. Les limites de la loi : la protection des droits contre la loi 100

4.1. Le contrôle juridictionnel de la loi 100

4.2. La critique de la loi 100

4.3. La désobéissance à la loi 101

Fiche n° 11- LE RÈGLEMENT ET LES LIBERTÉS 104

1. La définition du pouvoir règlementaire 104

1.1. Les autorités chargées du pouvoir règlementaire 104

1.2. La classification des normes règlementaires 106

2. La détermination des droits et des libertés par le pouvoir règlementaire 106

2.1. Le pouvoir règlementaire pour suppléer la loi 106

Actualité jurisprudentielle. - Un ministre peut préciser l'exercice d'une liberté sans se substituer au législateur 107

Si les ministres ne disposent pas, en principe, d'un pouvoir réglementaire général, la loi ou le règlement peuvent leur attribuer une compétence réglementaire dans un domaine déterminé. Le Conseil d'État en a donné une illustration en 2025 à propos du programme d'éducation à la vie affective, relationnelle et à la sexualité. 107

Le Code de l'éducation confie à l'État la fixation des programmes nationaux et prévoit que le contenu des formations est déterminé par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Celui-ci était donc compétent pour fixer le contenu du programme d'éducation à la sexualité applicable à compter de l'année scolaire 2025-2026. Le Conseil d'État vérifie ensuite que l'exercice de cette compétence respecte les droits et libertés en cause, notamment l'autorité parentale, la vie privée des élèves, leur droit à l'éducation ainsi que le principe

de neutralité du service public. Il relève notamment que les notions enseignées doivent être présentées de manière neutre et objective, en fonction de l'âge des élèves et sans les inciter à adopter un comportement déterminé. 107

→ CE, 27 juin 2025, Association Juristes pour l'enfance et autres, nos 501820 et 503152. 107

À retenir. - Les ministres ne disposent pas d'un pouvoir réglementaire général comparable à celui du Premier ministre. Ils peuvent toutefois exercer un pouvoir réglementaire spécial lorsqu'un texte leur attribue expressément cette compétence. 107

2.2. Le pouvoir règlementaire et les situations de crise 107

2.3. Le pouvoir règlementaire et la police administrative 109

2.4. Le pouvoir règlementaire contraventionnel du Premier ministre 110

2.5. Le contrôle du juge sur l'exercice du pouvoir règlementaire 111

PARTIE III. LES SOURCES EXTERNES 115

Fiche n° 12 - L'INTERNATIONALISATION DU DROIT DES LIBERTÉS 116

1. Le contexte général de l'internationalisation du droit des libertés en France 116

1.1. Les conflits du XXe siècle, traumatisme fondateur de l'internationalisation des droits humains 116

1.2. Un vecteur d'universalisation en phase avec l'idéal des Lumières 117

1.2.1. Une filiation avec l'universalisme de 1789 au-delà de l'État 117

1.2.2. La Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 : les droits d'un être humain situé 117

1.2.3. Les mécanismes de plaintes au cœur de la protection internationale des droits humains 118

1.3. Reconfiguration juridique de l'ordre interne : hiérarchie des normes 118

2. Une internationalisation à géographie variable 119

2.1. L'européanisation du droit des libertés 119

2.1.1. Le Conseil de l'Europe 119

2.1.2. L'Union européenne 120

2.1.3. L'européanisation à l'épreuve de la souveraineté démocratique 120

2.2. La situation des autres régions dans le monde 121

2.2.1. L'Amérique 121

2.2.2. L'Afrique 121

2.2.3. L'Asie 121

2.2.4. Le monde arabo-musulman 122

3. L'internationalisation des droits humains face au relativisme culturel 122

3.1. L'hégémonisme politique et culturel de l'Occident 122

3.2. La cohabitation des droits humains avec des systèmes de pensée valorisant la collectivité 122

Fiche n° 13 - LE DROIT ONUSIEN 125

1. La Charte internationale des droits de l'homme 126

1.1. La Déclaration universelle des droits de l'homme 126

1.2. Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques 127
1.3. Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels 128
2. Les traités spécialisés 129
Fiche n° 14 - LE CONSEIL DE L'EUROPE ET LA CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME 133
1. Le Conseil de l'Europe 133
1.1. Les organes politiques du Conseil de l'Europe 134
1.2. La diversité des normes adoptées au sein du Conseil de l'Europe 134
1.2.1. L'activité normative du Comité des ministres 134
1.2.2. Les principaux traités autres que la Convention européenne des droits de l'homme 135
2. La Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 136
2.1. Un mécanisme subsidiaire de protection des droits de l'Homme doté d'un plein effet direct 137
2.1.1. La primauté de la Convention sur le droit interne 137
2.1.2. Une Convention dotée d'un plein effet direct en droit interne 137
2.1.3. Un mécanisme de protection des droits humains reposant sur le principe de subsidiarité 138
2.1.4. Une Convention vivante garantissant des droits non pas théoriques et illusoires, mais concrets et effectifs 138
2.2. La dénonciation des traités du Conseil de l'Europe 141
Fiche n° 15 - LE DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE 144
1. Les sources des droits fondamentaux dans l'Union européenne 144
1.1. L'influence historique et persistance de la jurisprudence 144
1.1.1. La résistance des Cours constitutionnelles nationales face aux lacunes des premiers traités 144
1.1.2. La consécration prétorienne des principes généraux du droit 145
1.2. Le droit primaire : une incomplétude dépassée au fil des traités 145
1.2.1. Le tournant Maastricht : couverture conventionnelle et citoyenneté de l'Union 145
1.2.2. L'apport de Lisbonne : Charte des droits fondamentaux et adhésion à la Convention européenne des droits de l'homme 146
1.3. Le droit dérivé : une importance secondaire 146
2. La protection des droits fondamentaux : enjeu de fédéralisation pour l'Union 146
2.1. La spécificité des droits fondamentaux en droit de l'Union 147
2.2. Constitutionnalisation, fédéralisation ou instrumentalisation ? 147
2.3. Droits fondamentaux des individus et « droits fondamentaux » des États 148
3. Les rapports ambivalents entre droit de l'Union et droit de la Convention 148
3.1. Une recherche de cohérence entre les deux ordres juridiques européens 149
3.2. Adhésion de l'Union à la Convention : enjeux juridiques et politiques 149
3.3. Des obstacles persistants 149

PARTIE IV. LES MÉCANISMES INTERNES DE PROTECTION 153
Fiche nº 16 - LA PROTECTION PAR LE JUGE CONSTITUTIONNEL 154
1. L'instauration du Conseil constitutionnel 154
1.1. Les timides débuts du Conseil constitutionnel 154
1.2. L'affirmation du rôle de garant des droits et libertés fondamentaux du Conseil 155
1.3. Les compétences du Conseil constitutionnel 155
1.3.1. Les compétences consultatives 155
1.3.2. Les compétences juridictionnelles 156
2. Le contrôle de constitutionnalité des lois 156
2.1. Le contrôle a priori de constitutionnalité des lois 156
2.2. Le contrôle a posteriori de constitutionnalité des lois 156
3. Les techniques de contrôle du Conseil constitutionnel 158
3.1. L'économie et la stratégie du contrôle 158
3.2. Les réserves d'interprétation 158
3.3. Les décisions de non-conformité et de conformité partielle 159
3.4. L'effet cliquet 159
3.5. Les moyens et conclusions soulevés d'office 160
Fiche nº 17 – LA PROTECTION PAR LE JUGE JUDICIAIRE 164
1. Le juge judiciaire, garant de la protection des droits humains sur le plan interne 164
1.1. La protection des libertés individuelles et du droit de propriété face à l'administration 164
1.1.1. La protection de la liberté individuelle 165
1.1.2. La protection en cas de voie de fait 166
1.1.3. La protection contre les atteintes au droit de propriété portées par l'administration 167
1.2. La protection des droits humains par le juge judiciaire dans le cadre de litiges interindividuels 167
1.2.1. La protection des droits humains par l'application des normes afférant 167
1.2.2. La transposition du contrôle de proportionnalité 168
2. L'internationalisation des fondements de la protection des droits humains utilisés par le juge judiciaire. 170
2.1. La primauté du droit international des droits humains 170
2.1.1. Le contrôle de conventionnalité des lois et des dispositions internes 170
2.1.2. Le plein effet direct des normes de droit international en droit interne 170
2.2. La prise en compte de normes issues du droit international 171
3. Le rôle de filtre dans la transmission de questions en rapport avec les droits humains auprès d'organes juridictionnels tiers 171
3.1. La transmission de questions prioritaires de constitutionnalité au Conseil constitutionnel 171
3.2. La procédure d'avis consultatif auprès de la Cour européenne des droits de l'homme 172
Fiche nº 18 – LA PROTECTION PAR LE JUGE ADMINISTRATIF 177
1. L'intérêt de la dualité juridictionnelle pour la protection des libertés 178

À partir de la décision du 29 juillet 1998 (*Loi d'orientation et de programmation relative à la sécurité*), le Conseil constitutionnel est revenu sur cette conception en renouant avec l'esprit du Constituant : il a retenu une conception restrictive de la liberté individuelle, entendue comme le seul droit de ne pas être arbitrairement détenu. En conséquence, de nombreux droits qui avaient été rattachés auparavant à la liberté individuelle — comme le respect de la vie privée ou l'inviolabilité du domicile — en ont été détachés, ce qui a ouvert la voie à une compétence accrue du juge administratif. 179

2. Les instruments du juge administratif pour protéger les libertés 179

2.1. Le recours pour excès de pouvoir 179

2.1.1. Un recours objectif : la protection de la légalité 180

2.1.2. Un recours devenu subjectif : l'intégration des droits 180

2.2. Les référés 181

2.2.1. Le référé-liberté 181

2.3. Le contrôle de conventionnalité 184

3. L'évolution de la protection : la meilleure justiciabilité des actes 184

3.1. Les mesures d'ordre intérieur 184

3.2. Les actes de droit souple 185

Fiche nº 19 - LES DÉROGATIONS AU PRINCIPE DE SÉPARATION DES AUTORITÉS 188

1. Les fondements du dualisme juridictionnel 188

2. Le rôle du Tribunal des conflits en cas de situations conflictuelles de compétences 189

3. L'autorité judiciaire gardienne de la propriété privée immobilière et de la liberté individuelle 190

3.1. Les compétences juridictionnelles dans le cadre du contentieux de l'expropriation pour cause d'utilité publique 192

3.2. La compétence juridictionnelle en cas de voie de fait 192

3.3. L'emprise irrégulière 193

3.4. Le contentieux de la reconduite des étrangers à la frontière 193

4. Le juge judiciaire et les actes administratifs 194

Fiche nº 20 - LA PROTECTION ADMINISTRATIVE 197

1. L'effectivité des droits sans le juge ? 197

2. La protection au sein des administrations elles-mêmes 198

2.1. Les voies de recours consacrées : le recours administratif préalable 198

2.2. Un agent de l'administration protecteur : l'inspecteur du travail 199

3. La Commission nationale consultative des droits de l'homme (CNCDH) 199

4. La protection par des autorités administratives indépendantes 200

4.1. L'ébauche d'une définition générale de la protection administrative 200

4.2. Le Défenseur des droits, autorité constitutionnelle et générale 200

4.2.1. L'ancêtre du Défenseur des droits, le Médiateur pour la République 200

4.2.2. La consécration constitutionnelle d'une autorité indépendante 201

4.3. La protection par des autorités administratives indépendantes sectorielles 203

4.3.1. Le Contrôleur général des lieux de privation de libertés 203
4.3.2. La Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) 203
4.3.3. L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) 203
PARTIE V. LES MÉCANISMES INTERNATIONAUX ET EUROPÉENS DE PROTECTION 208
Fiche nº 21 - LES COMITÉS ONUSIENS 209
1. La multiplication des comités 210
1.1. Fondements normatifs 210
1.2. La composition des comités 211
2. L'hétérogénéité fonctionnelle des comités 211
2.1. Les rapports périodiques 211
2.2. Les communications interétatiques 212
2.3. Les communications individuelles 212
2.4. Les Observations générales 213
2.5. Les autres fonctions 213
2.5.1. Les procédures d'enquête 213
2.5.2. Le Sous-comité de prévention 214
3. Les controverses sur la valeur juridique des décisions des comités ? 214
Fiche nº 22 – LA COUR EUROPÉNNE DES DROITS DE L'HOMME 217
1. Le fonctionnement institutionnel de la Cour 217
1.1. La hiérarchisation des formations de jugement 217
1.2. Les différents types de recours 217
1.3. Les différentes étapes de la procédure contentieuse 218
2. L'interprétation de la Convention 218
2.1. L'activité juridictionnelle de la Cour 218
2.1.1. L'enrichissement de la Convention par l'interprétation dynamique de la Cour 218
2.1.2. La découverte de concepts modérateurs de la Convention 222
2.2. La procédure d'avis de la Cour 222
3. La portée des arrêts de la Cour 223
3.1. L'absence de force exécutoire automatique en droit interne 223
3.2. La force obligatoire des arrêts de condamnation à l'égard des États condamnés 223
3.2.1. La force obligatoire des arrêts de la Cour 223
3.2.2. La procédure des arrêts pilotes 223
3.3. L'existence d'une autorité de la chose interprétée à l'égard des autres États du Conseil de l'Europe . 224
Fiche nº 23 - LA COUR DE JUSTICE DE L'UNION EUROPÉENNE 227
1. L'institution, ses missions et son fonctionnement 227
1.1.1. Le recours en annulation devant le Tribunal 228

1.1.2. La question préjudicielle posée à la Cour de justice 228
1.2. L'accès limité des particuliers à la Cour de justice 229
1.2.1. Les conditions strictes de la jurisprudence Plaumann 229
1.2.2. Le droit à un recours effectif consacré par la Charte 229
1.3. Les recours en manquement en cas de violation des droits fondamentaux par un État 230
2. Protection des droits fondamentaux sous l'angle de la subsidiarité juridictionnelle 230
2.1. La compétence première des juridictions nationales 230
2.2. La complémentarité des voies de droit de l'Union et des États membres 231
3. La Cour de justice et les autres juridictions protectrices des libertés : concurrence ou synergie ? 232
3.1. Les rapports de la Cour de justice avec les juridictions des États membres 232
3.1.1. Le renvoi préjudiciel en interprétation : une coopération indispensable des juges 232
3.1.2. Protection juridictionnelle effective : protection du justiciable ou de la norme européenne 233
3.2. Les rapports de la Cour de justice avec la Cour européenne des droits de l'homme 233
Fiche n° 24 - LES AUTRES JURIDICTIONS RÉGIONALES 237
1. La Cour interaméricaine des droits de l'homme 237
1.1. L'entrée en vigueur de la Cour interaméricaine et la reconnaissance de sa compétence 237
1.2. Les compétences de la Commission et de la Cour 237
1.3. Exemples de rapports adoptés par la Commission interaméricaine 238
1.4. Exemples de décisions rendues par la Cour interaméricaine 238
2. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples 239
2.1. Entrée en vigueur et ratifications 239
2.2. Composition de la Cour africaine 239
2.3. Les compétences de la Cour africaine 239
2.3.1. La compétence contentieuse de la Cour africaine 239
2.3.2. La compétence consultative de la Cour africaine 240
2.3.3. Le partage de compétence avec la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples 240
3. La Cour arabe des droits de l'homme 240
3.1. L'adoption du Statut portant création de la Cour arabe 240
3.2. La composition de la Cour arabe 240
3.3. Les compétences de la Cour arabe 240
3.4. La portée limitée de la Cour arabe 241
4. Tableau comparatif des différentes juridictions régionales : 242
Fiche n° 25 - LA PROTECTION POLITIQUE ET ADMINISTRATIVE INTERNATIONALE 245
1. La protection administrative et politique par les organes des Nations unies 245
1.1. Le Conseil des droits de l'homme 246

1.1.1 La création du Conseil des droits de l'homme 246
1.1.2. La composition du Conseil des droits de l'homme 246
1.1.3. Les missions du Conseil des droits de l'homme 246
1.1.4. Les récents retraits d'États du Conseil des droits de l'homme 246
1.2. Le Haut-Commissariat aux droits de l'homme 246
1.2.1. La composition du Haut-Commissariat aux droits de l'homme 247
1.2.3. Le rôle du Haut-Commissariat aux droits de l'homme 247
2. La protection politique et administrative par des organes du Conseil de l'Europe 247
2.1. Le Commissaire aux droits de l'homme 247
2.1.1. La création du Commissaire aux droits de l'homme 247
2.1.2. Les compétences du Commissaire aux droits de l'homme 247
2.2. La Commission pour la démocratie par le droit 248
2.2.1. La création de la Commission de Venise 248
2.2.1. La composition de la Commission de Venise 248
2.2.2. Les compétences de la Commission de Venise 248
3. La protection politique et administrative par des organes de l'Union européenne 249
3.1. Le médiateur européen 249
3.1.1. L'élection du médiateur européen 249
3.1.2. Les compétences d'enquête du médiateur européen 249
3.1.3. La portée de l'action du médiateur européen 249
3.2. L'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne 250
3.2.1. La création de l'Agence des droits fondamentaux 250
3.2.2. Les compétences de l'Agence des droits fondamentaux 250
3.2.3. La portée limitée de l'action de l'Agence des droits fondamentaux 250
3.3. Le contrôleur européen de la protection des données 250
3.3.1. La création du contrôleur européen de la protection des données 250
3.3.2. La nomination du contrôleur européen de la protection des données 251
3.3.3. Les compétences protéiformes du contrôleur européen des données 251
PARTIE VI. LES DROITS CIVILS ET POLITIQUES 254
Fiche n° 26 - LE DROIT À LA VIE 256
1. Principes fondamentaux relatifs à la vie 256
1.1. Le point de départ de la protection 257
1.2. L'interdiction d'infliger la mort 258
1.2.1. La peine de mort 258
1.2.2. Les atteintes résultant des opérations de la puissance publique 259
1.2.3. L'état de guerre : le privilège du combattant 260

2. La protection étendue du droit à la vie 262
2.1. Les garanties procédurales 262
2.2. Les actions positives spécifiques 262
2.2.1. L'effet « horizontal » 262
2.2.2. La protection contre les aléas 263
Fiche n° 27 – LE DROIT À L'INTÉGRITÉ DE LA PERSONNE 267
1. Le droit à l'intégrité physique de la personne humaine 268
1.1. Le droit de la personne à disposer librement de son corps 268
1.2. La non-patrimonialité et l'indisponibilité du corps humain 270
1.3. Le droit à la protection de la santé 271
1.4. L'inviolabilité du corps humain 272
1.4.1. La protection de la personne contre les atteintes à la santé 272
1.4.2. Les exceptions à l'exigence de consentement aux soins médicaux 273
1.4.3. La fin de vie 273
2. Le droit à l'intégrité morale de la personne humaine 275
2.1. La protection internationale de l'intégrité morale 275
2.2. La protection nationale de l'intégrité morale 276
Fiche n° 28 - L'INTERDICTION DE LA TORTURE ET DES PEINES OU TRAITEMENTS INHUMAINS OU DÉGRADANTS 279
1. L'interdiction vigoureuse par le droit international et européen des droits humains 279
2. L'existence d'instruments conventionnels spécifiques 280
Actualité. - Violences en détention et recommandations d'urgence du CGLPL En juin 2026, la Contrôleure générale des lieux de privation de liberté a adressé des recommandations en urgence au ministre de la Justice concernant le centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe. À la suite d'une visite du quartier de lutte contre la criminalité organisée, elle a constaté des violences commises sur des détenus par certains personnels, ainsi que des fouilles humiliantes ou brutales et des usages disproportionnés de la force. Le CGLPL rappelle à cette occasion que l'administration pénitentiaire est tenue de garantir la sécurité et l'intégrité physique des personnes placées sous sa garde. Ces recommandations ont été publiées au Journal officiel le 9 juillet 2026. 281
→ CGLPL, recommandations en urgence du 9 juin 2026 relatives au centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe. 281
3. Les contours de la torture 281
3.1. La définition de la torture 281
3.2. La torture en droit interne 281
3. La distinction entre les traitements et peines « inhumains » et « dégradants » 282
3.1. Le caractère « inhumain » 282
3.2. Le caractère « dégradant » 282
3.3. Le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants en droit français 283
4. L'autonomie normative de l'interdiction de l'esclavage et du travail forcé 284

5. Les obligations négatives et positives de l'État 284
Fiche nº 29 – L'INTERDICTION DE L'ESCLAVAGE, DE LA TRAITE, DE LA SERVITUDE ET DU TRAVAIL FORCÉ 288
1. Principes généraux 288
1.1. L'interdiction de l'esclavage 289
1.2. Les formes d'exploitations analogues à l'esclavage 290
1.2.1 La servitude 290
1.2.2 L'interdiction du travail forcé ou obligatoire 290
1.2.3. La traite des êtres humains 291
2. Un terrain privilégié des obligations positives 292
2.1. L'obligation de prévention 292
2.2. Les mesures opérationnelles 293
2.3. L'obligation d'enquêter 293
2.4. L'obligation de réparer 293
Fiche nº 30 - LE DROIT À LA LIBERTÉ ET À LA SÛRETÉ 298
1. Le droit à la liberté individuelle et à la sûreté : le droit de ne pas être enfermé arbitrairement 298
1.1. La reconnaissance constitutionnelle 299
1.2. La reconnaissance conventionnelle 299
2. Le contrôle de la légalité de l'enfermement 299
3. La garde à vue 300
4. La détention provisoire 300
5. La rétention de sûreté 301
6. La rétention douanière 302
7. Le maintien en zone d'attente 302
8. Le placement en centre de rétention administrative 303
9. L'hospitalisation psychiatrique sans consentement 304
10. Le placement en cellule de dégrisement 304
Fiche nº 31 - LE DROIT À UN PROCÈS ÉQUITABLE ET LE DROIT À UN RECOURS EFFECTIF 308
1. Le droit à un recours effectif 309
2. Le droit à un procès équitable 310
2.1. Le volet civil du droit à un procès équitable 310
2.2. Le volet pénal du droit à un procès équitable 310
2.3. Les particularités du contentieux administratif 311
2.4. Les particularités du contentieux constitutionnel 311
3. Les garanties du droit à un procès équitable 312
3.1. Le droit à un tribunal 312
3.2. Les exigences procédurales liées au droit à un procès équitable 313

3.2.1. Les droits de la défense 313
3.2.2. Le contradictoire 314
3.2.3. Les exigences tenant au jugement 314
3.3. Les exigences institutionnelles 315
3.3.1. L'indépendance du juge 315
3.3.2. L'impartialité du juge 316
4. Les restrictions au droit à un procès équitable 317
4.1. Un droit non absolu 317
4.2. Le cas des immunités de juridiction 317
Fiche nº 32 - LES GARANTIES FONDAMENTALES EN DROIT PÉNAL 321
1. La procédure pénale entourée par des garanties fondamentales 321
1.1. Le principe de la présomption d'innocence 322
1.1.1. Les exceptions au principe de la présomption d'innocence 322
1.1.2. La présomption d'innocence et la détention provisoire 323
1.2. Le droit de ne pas s'incriminer 323
1.3. Le droit à l'assistance d'un avocat 323
2. Le prononcé de la peine entouré par des garanties fondamentales 324
2.1 Le principe de légalité des peines 324
2.2. Le principe de nécessité des peines 325
2.2.1. La prise en compte du temps écoulé depuis l'infraction : une déclinaison du principe de légalité des délits et des peines 325
2.2.2. Le principe de non bis in idem : une déclinaison du principe de légalité des délits et des peines 325
2.2.3. Le principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère : une conséquence du principe de légalité des peines 326
2.3. Le principe d'individualisation des peines 326
2.4. L'obligation de motivation des peines 327
2.5. Le principe de responsabilité du fait propre de la personne 327
3. Le principe d'irresponsabilité pénale en cas d'abolition du discernement 327
Fiche nº 33 - LE DROIT À LA VIE PRIVÉE 331
1. L'affirmation générale du libre choix de la vie privée 331
1.1. La dimension personnelle du droit au respect de la vie privée 332
1.1.1. Respect de l'identité 332
1.1.2. La reconnaissance de l'identité 333
1.1.3. Reconnaissance de l'identité 334
1.2. L'intimité et la liberté sexuelle 334
1.2.1. Respect de la vie et de l'orientation sexuelles 335

1.2.2. Droit au mariage et égalité 335
1.2.3. Le caractère évolutif et effectif du droit des libertés 336
1.3. Droit à la réputation 336
2. Le droit aux secrets 336
2.1. Le secret des correspondances 336
2.2. Le salarié 337
2.3. Le droit de s'opposer aux publications portant atteinte à l'intimité 338
3. Lieux spécifiques et respect du droit à la vie privée 338
3.1. Le domicile : l'inviolabilité 338
3.1.1. L'affirmation constitutionnelle du principe 339
3.1.2. Régimes dérogatoires : perquisitions de nuit, infractions graves, et lieux non résidentiels 339
3.1.3. Dispositifs spécifiques : professions protégées et technologies intrusives 339
3.2. L'environnement : le droit de vivre dans un environnement sain 340
3.3. L'espace numérique : de nouvelles atteintes pour la vie privée 340
Fiche n° 34 - LE DROIT À LA VIE FAMILIALE 343
1. Les contours de la vie familiale 343
2. Le droit au mariage 344
2.1. La liberté de se marier 344
2.2. La dissolution du mariage 345
3. Le droit au respect de la vie familiale 347
4. L'établissement du lien de parenté 348
4.1. L'établissement par la filiation 348
4.2. L'établissement par l'adoption 348
4.3. La gestation pour autrui 349
4.4. La procréation médicalement assistée 350
5. Le maintien du lien familial 351
6. L'égalité entre enfants 351
Fiche n° 35 - LE DROIT À LA PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL 355
1. Un régime juridique complexe en constante évolution 355
1.1. Origine du droit à la protection des données à caractère personnel 355
1.2. Principales notions et définitions 357
1.2.1. « Données personnelles » et « données sensibles » 357
1.2.2. « Traitement de données » et « fichier » 357
1.2.3. Responsables du traitement 358
1.3. Les principes encadrant le traitement des données personnelles 358
1.3.1. Licéité, loyauté et transparence 358

1.3.2. Le consentement : pilier relatif de la licéité des traitements 358
1.3.3. Protection des données au-delà du consentement 359
2. Les mécanismes de garantie administratifs et juridictionnels 361
2.1. La Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) 361
2.1.1. Un rôle central et unique dans la protection des personnes 361
2.1.2. Une diversité de missions et de pouvoirs 361
2.2. Les juridictions nationales et supranationales 362
2.2.1. Le Conseil constitutionnel 362
2.2.2. La Cour de justice de l'Union européenne 362
2.2.3. La Cour européenne des droits de l'homme 363
3. Protection juridique des données personnelles à l'ère du Big Data et de l'IA 363
3.1. Le règlement européen sur l'IA (AI Act) 363
3.2. Reconnaissance faciale et systèmes prédictifs 364
Fiche nº 36 - LA LIBERTÉ DE PENSER, DE CONSCIENCE ET DE RELIGION 369
1. La liberté de penser, de conscience et d'opinion 369
1.1. La protection juridique du for intérieur 369
1.2. Le droit de ne pas voir ses opinions prises en compte 370
1.3. Le droit de voir ses opinions prises en compte 370
1.3.1. L'objection de conscience 370
1.3.2. La clause de conscience 371
1.4. La protection juridique du for extérieur 371
2. La liberté de culte et de religion 372
2.1. La liberté de croire, de ne pas croire et d'en changer 372
2.2. La liberté de manifester sa foi 373
2.3. Les restrictions à la liberté de religion 373
2.3.1. Les restrictions fondées sur l'ordre public 373
2.3.2. Les restrictions fondées sur le fonctionnement du service public 374
2.3.3. Les signes religieux en entreprise 375
3. Le principe de laïcité 376
3.1. Le principe de séparation de l'Église et de l'État 376
3.2. Les exceptions au principe de laïcité 377
3.3. La laïcité « à la française » 378
Fiche nº 37 - LA LIBERTÉ D'EXPRESSION 381
1. Une liberté essentielle à la vie démocratique 381
1.1. Les fondements d'un droit essentiel 381
1.2. La substance du droit à la liberté d'expression 382

1.2.1. Une liberté protéiforme 382
1.2.2. La particularité du droit de la presse 384
2. Une liberté susceptible d'être limitée 385
2.1. Les clauses de limitation 385
2.2. Les clauses d'autorisation 387
2.3. Les interdictions 387
3. La digitalisation de la liberté d'expression 388
Fiche nº 38 - LA LIBERTÉ DE RÉUNION ET DE MANIFESTATION PACIFIQUE 395
1. La protection européenne de la liberté de réunion 396
1.1. La protection des réunions pacifiques 396
1.2. Les obligations négatives de l'État dans le cadre de la liberté de réunion 397
1.3. Les obligations positives de l'État dans le cadre de la liberté de réunion 398
2. La protection interne de la liberté de réunion et de manifestation 398
2.1. La liberté de réunion 399
2.2. La liberté de manifestation 399
Fiche nº 39 - LA LIBERTÉ D'ASSOCIATION 404
1. Les sources de la liberté d'association 404
1.1. Les sources nationales 404
1.1.1. Une valeur législative ancienne 404
1.1.2. La consécration constitutionnelle de 1971 404
1.2. Les sources supranationales 405
1.2.1. Les sources internationales 405
1.2.2. Les sources européennes 405
2. Les différentes catégories d'association 406
3. Le régime juridique des associations 407
3.1. La liberté individuelle d'adhérer ou de ne pas adhérer 407
3.1.1. L'adhésion à l'association 407
3.1.2. La non-adhésion et le retrait de l'association 407
3.2. Le principe de libre constitution de l'association 408
3.3. L'objet de l'association 409
3.4. Le libre fonctionnement de l'association 409
4. Les limites de la liberté d'association 409
4.1. Les restrictions de la liberté d'association 409
4.2. La dissolution judiciaire 410
4.3. La dissolution administrative 410
Fiche nº 40 - LA LIBERTÉ D'ALLER ET VENIR 416

1. Le cadre général de la liberté d'aller et venir en France 416
1.1. Fondement de la liberté de circulation 416
1.1.1. Privation de liberté et restriction à la liberté d'aller et venir 417
1.1.2. Zones grises : l'état d'urgence 417
1.2. Entrée et sortie en territoire français 418
1.2.1. L'entrée sur le territoire 418
1.2.2. La sortie du territoire 419
1.3. Les entraves à la liberté de circulation 419
1.3.1. Les contrôles de police judiciaire 419
1.3.2. Les contrôles de police administrative 419
2. L'articulation de la liberté de circulation avec la lutte contre le terrorisme 421
2.1. Les restrictions spécifiques sur l'entrée et la sortie du territoire 421
2.2. Les périmètres de protection (pour tous) 422
2.3. Les mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance (anciennement assignations à résidence - pour certaines personnes) 422
3. La libre circulation des personnes dans l'Union européenne 422
3.1. Marchandises et personnes : une liberté fondamentale(ment) économique 423
3.1.1. Le travailleur avant la personne 423
3.1.2. Un citoyen de marché 424
3.2. La cinquième liberté (numérique) : la libre circulation des données personnelles 424
Fiche n° 41 - LA LIBERTÉ D'ENSEIGNEMENT 428
1. Les fondements de la liberté de l'enseignement 428
1.1. Les sources législatives de la liberté de l'enseignement 428
1.2. La liberté de l'enseignement : un principe fondamental reconnu par les lois de la République 428
2. Contenu de la liberté de l'enseignement 429
2.1. La liberté de créer des établissements d'enseignement privé 429
2.1. L'encadrement des établissements privés hors contrat 430
2.3. Le financement public des établissements privés 431
3.1. La liberté de l'enseignement privé 433
3.2. La liberté des enseignants du primaire et du secondaire 433
3.3. La liberté des enseignants du supérieur 433
Fiche n° 42 - LE DROIT À DES ÉLECTIONS LIBRES 436
1. Les sources du droit à des élections libres 436
1.1. Les sources supranationales 436
1.2. Les sources nationales 437
2. Les éléments du droit à des élections libres 437
2.1. Le volet passif du droit à des élections libres : le droit de vote 437

2.2. Le volet actif du droit à des élections libres : le droit d'éligibilité 437
2.3. La liberté des partis politiques 438
3. Les conditions de jouissance et d'exercice du droit à des élections libres 439
3.1. La nationalité 439
3.2. La majorité électorale 439
3.3. La résidence 439
3.4. L'absence de déchéance des droits politiques 439
3.5. L'inscription sur les listes électorales 439
3.6. Les conditions renforcées d'éligibilité 440
4. Les caractères du suffrage 440
4.1. L'universalité du suffrage 440
4.2. L'égalité du suffrage 441
4.3. La liberté et le secret du suffrage 441
4.4. L'honnêteté et la sincérité du suffrage 441
4.5. La périodicité du suffrage 442
4.6. Le caractère direct ou indirect du suffrage 442
Fiche n° 43 - LES PROTECTIONS FONDAMENTALES EN CAS D'ÉLOIGNEMENT, D'EXPULSION ET D'EXTRADITION 445
1. Le droit des étrangers et des citoyens de l'Union européenne 445
2. Les mesures d'éloignement du territoire 446
2.1. L'obligation de quitter le territoire français (OQTF) et l'interdiction de retour sur le territoire français 447
2.2. L'expulsion 447
2.3. L'extradition 448
3. Les protections face aux mesures d'éloignement 450
3.1. Éloignement et protection de l'intégrité physique 450
3.2. Éloignement et protection de l'intégrité morale 451
3.3. Les garanties procédurales prévues par l'article 1er du protocole n° 7 à la Convention européenne des droits de l'homme 452
Fiche n° 44 - LE DROIT DES PEUPLES À DISPOSER D'EUX-MÊMES 456
1. Les incertitudes autour de la définition juridique de « peuple » 456
2. Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes en droit international 456
2.1. La reconnaissance conventionnelle du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes 457
2.2. Les résolutions de l'Assemblée générale des Nations unies relatives au droit des peuples à disposer d'eux-mêmes 457
2.3. Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes dans la jurisprudence de la Cour internationale de justice 458

2.4. Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes dans les avis consultatifs de la Cour internationale de justice 459
3. Le droit des peuples dans les conventions régionales de protection des droits humains 460
3.1. Une place centrale dans la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples 460
3.2. Les références aux peuples dans la Charte arabe des droits de l'homme 460
4. La notion de « peuple » en droit français 460
4.1. La valeur constitutionnelle du « peuple français » 461
4.2. L'absence de ratification de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires 461
4.3. Le statut dérogatoire de la Nouvelle-Calédonie 462
4.4. Le statut particulier de la Corse 463
PARTIE VII. LES DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS 467
Fiche n° 45 - LA LIBERTÉ DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE 468
1. La protection de la liberté d'entreprendre 468
1.1. La protection internationale de la liberté d'entreprendre 468
1.2. La protection nationale de la liberté d'entreprendre 468
1.2.1. La reconnaissance constitutionnelle 468
1.2.2. La jurisprudence administrative et judiciaire 469
1.2.1. Les éléments de la liberté du commerce et de l'industrie 471
Fiche n° 46 – LE DROIT DE PROPRIÉTÉ 475
1. La protection du droit de propriété par la Convention européenne des droits de l'homme 475
2. La protection nationale du droit de propriété 476
Fiche n° 47 - LE DROIT À L'ÉDUCATION ET À LA FORMATION 481
1. Le cadre juridique du droit à l'éducation et à la formation 481
2. Les principes structurant du droit à l'éducation 483
2.1. La gratuité de l'enseignement 483
2.2. Le caractère obligatoire de l'éducation 483
2. 3. La non-discrimination 483
2.4. La protection de l'élève dans le milieu éducatif 485
3. Le droit à la formation 485
Fiche n° 48 - LE DROIT À LA SANTÉ ET À LA PROTECTION SOCIALE 490
1. Le droit à la protection de la santé 490
2. Les contours du droit à la protection sociale 492
2.1. Les contours historiques du droit à la protection sociale 492
2.2. Les contours terminologiques du droit à la protection sociale 492
2.3. Les contours juridiques du droit à la protection sociale 493
2.4. Les contours pratiques du droit de la protection sociale 493
3. La consécration dans les instruments internationaux de protection 493

4. La consécration du droit à la protection sociale en France 494
5. Le principe d'égalité dans le droit à la protection sociale 495
Fiche n° 49 - LE DROIT À UN ENVIRONNEMENT SAIN 500
1. La prise de conscience planétaire des enjeux environnementaux 500
2. La protection par ricochet opérée par la Cour européenne des droits de l'homme 501
2.1. La protection de l'environnement sain par l'application de l'article 2 501
2.2. La protection de l'environnement sain par l'application de l'article 8 502
2.3. Les obligations découlant de la protection du droit à un environnement sain 502
2.4. Le contentieux climatique et protection de l'environnement sain par l'application de l'article 6 § 1 .. 503
3. La constitutionnalisation du droit à un environnement sain 503
4. La montée en puissance du contentieux relatif au droit à un environnement sain 505
Fiche n° 50 - LE DROIT AU TRAVAIL 509
1. Le droit d'obtenir un emploi 509
1.1. Un droit constitutionnel 509
1.2. Les sources internationales du droit au travail 510
1.3. Les implications du droit à l'emploi 511
2. Les garanties fondamentales en matière d'emploi et de conditions de travail 511
2.1. La protection par l'Organisation internationale du travail 511
2.2. La protection des libertés individuelles du salarié dans l'exécution du contrat de travail 512
2.3. La protection des libertés collectives des salariés 513
2.3.1. La liberté syndicale 513
2.3.2. Le droit de grève 514
2.3.3. Le droit à la participation à la gestion de l'entreprise 515
Fiche n° 51 - LE DROIT AU LOGEMENT 518
1. Les sources du droit au logement 518
1.1. Les sources externes du droit au logement 518
1.2. Les sources internes du droit du logement 518
1.2.1. Le fondement législatif du droit au logement 519
1.2.2. L'affirmation du droit au logement comme objectif à valeur constitutionnelle 519
2. La subjectivisation atténuée du droit au logement 520
2.1. La dimension horizontale du droit au logement 520
2.2. La dimension verticale du droit au logement 521
3. L'influence des politiques sociales sur l'effectivité du droit au logement 521
3.1. L'accession au logement social 521
3.2. Le droit au logement opposable 521
Fiche n° 52 - LE DROIT À LA CULTURE 526

1. Un droit en tension avec d'autres droits constitutionnels 527
2. La faible normativité du droit à la culture 527
3. Vers un droit subjectif à la culture 527
4. Les enjeux de l'accès à la culture : démocratisation de la culture 528
3. La fondamentalisation des droits culturels sur la scène internationale 529
3.1. L'émergence des droits fondamentaux culturels ? 529
3.2. La culture comme identité et mode de vie 530
3.3. Patrimoine immatériel et essor du numérique 531
Fiche n° 53 - LE DROIT D'ASILE 536
1. Définition du droit d'asile 536
1.1. L'asile conventionnel 536
1.2. La protection subsidiaire 537
1.3. L'asile constitutionnel 538
2. Les différentes procédures de demande d'asile 538
2.1. La procédure classique 538
2.1.1. La demande devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides 538
2.1.2. Le recours devant la Cour nationale du droit d'asile 539
2.2. La procédure « accélérée » 539
2.3. La procédure « Dublin » 541
2.4. Le réexamen de la demande 542
3. Les garanties offertes aux demandeurs d'asile et aux réfugiés 542
3.1. Les garanties liées au statut de demandeur d'asile 542
3.2. Les garanties liées au statut de réfugié 542
PARTIE VIII. L'ÉGALITÉ ET LA NON-DISCRIMINATION 546
Fiche n° 54 - L'INTERDICTION DE LA DISCRIMINATION 547
1. Le principe de non-discrimination, prolongement du principe d'égalité 547
1.1. Une modernisation du principe d'égalité de 1789 547
1.2. L'influence internationale sur le droit positif français : une conception plus « anglo-saxonne » de l'égalité 548
1.3. Droit à l'égalité et droit à la non-discrimination : deux faces d'une même exigence diversement déclinée 549
1.3.1. L'égalité formelle 549
1.3.2. L'égalité réelle 549
1.3.3. L'opposition entre les modèles français et anglo-américain 551
2. La mise en œuvre de l'interdiction des discriminations en France 552
2.1. Législations et dispositions constitutionnelles et conventionnelles 552
2.1.1. Les sources en droit interne et international dans le contexte de l'après-guerre 552

2.1.2. Un cadre législatif d'une grande densité 553
2.1.3. L'importance du droit dérivé de l'Union européenne 553
2.2. Le recours à la soft law pour sensibiliser sur les discriminations 553
2.3. Garanties administratives et juridictionnelles 554
2.3.1. Le défenseur des droits 554
2.3.2. Actions de groupe et preuves du traitement discriminatoire 554
2.3.3. La jurisprudence du Conseil constitutionnel 555
3. Les biais algorithmiques : de nouvelles formes de discriminations 555
Fiche nº 55- LA PRISE EN COMPTE DES VULNÉRABILITÉS 559
1. Vulnérabilité et notion d'égalité 560
2. Les cas spécifiques de vulnérabilité saisie par le droit 560
2.1. Vulnérabilité et capacité 560
2.1.1. Les enfants 560
2.1.2. Les majeurs protégés 561
2.2. Vulnérabilité et handicap 562
2.3. Vulnérabilité des groupes minoritaires 562
2.4. Les étrangers et apatrides 563
2.5. Les minorités sexuelles 565
2.6. Les femmes 566
2.7. La vulnérabilité socio-économique 566
3. Des conceptions étendues de la vulnérabilité 567
Fiche nº 56 - LES MESURES D'INÉGALITÉ COMPENSATOIRE 571
1. L'« égalité réelle » par la rupture de l'« égalité formelle » 571
1.1. Droit de la non-discrimination et « droit de l'égalisation » 571
1.2. Discrimination négative et discrimination positive 572
1.2.1. Mesures préférentielles et actions positives 572
1.2.2. Un équilibre fragile entre égalité et différenciation 572
1.2.3. La discrimination positive à la française 573
1.3. L'exemple de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne 573
2. La correction juridictionnelle des inégalités structurelles 574
2.1. Le Conseil constitutionnel 574
2.2. Le Conseil d'État 575
2.3. La Cour européenne des droits de l'homme 576
2.4. Cour de justice de l'Union européenne 576
3. Critiques et perspectives 577
3.1. Pour ou contre la discrimination positive : des juristes partagés 577

3.2. Le renouvellement discrimination positive consécutive au développement de l'IA : les métriques de débiaisement 577

TABLES DES MATIÈRES 581